

De Iustitia et Iure, Vol. 4

Luis de Molina

Collegij Societatis Iesv Monacij. 12 Septēb. 1609.

R. P.

LODOVICI
MOLINAE,
PRIMARII QVONDAM
IN EBORENSI ACADEMIA
SAC. THEOLOGIÆ PROFESSORIS,
E SOCIETATE IESV,
DE IVSTITIA ET IVRE
TOMI TERTII

Pars posterior.

De delictis & quasi delictis.



ANTVERPIÆ,
Sumptibus Martini Nutii
& Ioannis Hetfroy.

Cum gratia & privilegio,
M. DC. IX.

De Iustitia et Iure, Vol. 4

Luis de Molina
Antverpiae 1609
(Martinus Nutius Ioannis Hetsroy)

The School of Salamanca
A Digital Collection of Sources and a
Dictionary of its Juridical-Political Language
<https://www.salamanca.school>

Volume unpublished

Directors:
Duve, Thomas
Lutz-Bachmann, Matthias

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Goethe-Universität Frankfurt/Main

Electronic publication,
Online:

Editors:

Birr, Christiane
Rico Carmona, Cindy
Glück, David
Caesar, Ingo
Egío García, José Luis
Thönes, Martin
da Silva Santos, Pedro
Wagner, Andreas

PDF Production:

Kupreyev, Maxim N.

Digitized original(s):

Bayerische Staatsbibliothek
<https://mdz-nbn-resolving.de/details:bsb10497096>

Österreichische Nationalbibliothek
<http://data.onb.ac.at/rep/1039D4E8>

Proposed citation:

_X_X_, in: The School of Salamanca. A Digital Collection of Sources

[i] R. P. LODOVICI MOLINAE,
PRIMARII QVONDAM IN
EBORENSI ACADEMIA SAC.
THEOLOGIÆ PROFESSORIS,
E SOCIETATE IESV, DE
IVSTITIA ET IVRE TOMI
TERTII Pars posterior.
De delictis & quasi delictis.

ANTVERPIÆ, Sumptibus Martini Nutii & Ioannis
Hetsroy. *Cum gratia & priuilegio, M. DC. IX.*

[[iii]] [[iii]] INDEX DISPUTATIONVM, QVAE HAC TOMI
TERTII PARTE POSTERIORE CONTINENTVR.

680 . *V*aria genera eiusmodi delictorum distinguuntur: praecipue furtum, rapina, & damnum datum. pag. 1113.

681 . *Furtum pressè quid.* 1115.

682 . *De vi publica ac priuata, quas iura appellant.* 1123.

683 . *Rapina quid.* 1138.

684 . *De variis furti generibus, & consequenter etiã rapinae.* 1141.

685 . *Furtum an ex genere suo sit culpa lethalis. Et de quantitate requisita, vt culpa lethalis sit.* 1151.

686 . *De furtis domesticorum. Et num ob illa actio furti competat aduersus domesticos. Et quid de eumentibus, aut alio titulo accipientibus eas res à domesticis. Et quæ quantitas sufficiat, vt eiusmodi furta culpæ sint lethales. Et num excommunicatio à patre familias obtenta, pro rebus sibi furto ablati, comprehendat eiusmodi furta.* 1158.

687 . *De furtis religiosorum.* 1166.

688 . *Quando propter notabilem quantitatem, quam quis ab aliquo furatur minimis furtis, quarum singula ad culpam lethalem non sufficiunt, interueniat culpa lethalis ita furantis.* 1172.

689 . *Quando ob notabilem quantitatem, quam quis, per minima à singulis, furetur à diuersis; aut diuersi, per minima singuli, furentur ab eodem; culpa interueniat lethalis.* 1175.

690 . *Vtrum in occulta acceptione rei propriae, quam alius habet, cernatur furtum.* 1178.

691 . *Vtrum absque furto licitumque aliquando sit, propria autoritate compensare occultè, quod alius debet, tantundem de bonis illius accipiendo.* 1180.

692 . *Vtrum lata excommunicatione à praelato, vt, qui rem aliquam accepit, illam intra certum tempus restituat, & qui id scit, rem intra idem tempus manifestet, ea excommunicatio comprehendat eum, qui in compensationem licitam rem accepit, eumque qui ita acceptam fuisse nouit.* 1184.

693 . *Vtrum captiui inter Turcas, ac Saracenos, & alios, cum quibus ex parte nostra bellum est iustum, & ex parte ipsorum iniustum, verum furtum aut rapinam committant, accipiendo eorum bona, ipsis inuitis.* 1187.

694 . *De penis spiritualibus pro furto, in quo sacrilegium interuenit, pro furto seu rapina piratarum, & pro furto ex naufragio, statutis.* 1190.

695 . *De penis temporalibus pro furto, & vtrum licitè homines pro furto interdum occidantur.* 1197.

696 . *Quibus & aduersus quos actio furti competat.* 1239.

- 697 . *De damno iniustè indebitè dato.* 1254.
- 698 . *Vtrùm, qui culpa solùm leui, aut leuissima, dānum dedit, teneatur in foro conscientie ante latam sententiam illud restituere; an verò solùm in interiori foro teneatur illud restituere, ac proinde expectare possit in conscientie foro, vt feratur sententia.* 1285.
- 699 . *De damno in arboribus, aut quod ex arboribus prouenit.* 1292.
- 700 . *De crimine falsi, quatenus ex illo damnum in rebus proximi externis resultat. Et in primis de eo, qui sibi, aut alteri, qui in potestate ipsius sit, aut in cuius potestate ipse sit, scribit legatum, aut hæreditatem, in alterius testamento, & de eo qui rem eandem duobus vendit.* 1299.
- 701 . *De aliis criminibus falsi, nempe de supponente partum alienum, de immiscente indebitè res aliquas, & de vtente falsis mensuris & ponderibus.* 1309.
- 702 . *De crimine falsæ monetæ.* 1315.
- 703 . *De damno infecto, quod iura vocant, hoc est, quod nondum est factum, sed pendet in futurum.* 1321.
- 704 . *De damno proueniente ex aqua, ratione operis facti in vicino prædio: cuius operis ac dāni comparatione competit ciuili iure actio aquæ pluuiæ arcendæ.* 1355.
- 705 . *De aquæductis, & aqua quotidiana & æstiuæ.* 1375.
- 706 . *De noui operis nuntiatione, & simul de interdicto quod vi aut clam.* 1404.
- 707 . *De ædificiis, operibusque, ac immissionibus, in loco sacro aut publico, & peculiariter in viis publicis, & quæ illæ sint.* 1444.
- 708 . *De it inere, actu, viaque priuatis.* 1463.
- 709 . *Quousque cuique liceat ædificare in suo solo proprio, aut non liceat, quia id cedit in alterius, aut in boni communis, damnum seu præiudicium.* 1472.
- 710 . *De quasi delictis circa res externas, iudicis videlicet, qui, sine dolo, culpabiliter sententiam iniustam tulit; patris familias, qui tenetur ad damna ex iis, quæ ejiciuntur de sua domo, absque sua culpa secuta; nautarum, cauponum, & stabulariorum, qui similiter tenentur de damnis à suis datis.* 1479.
- 711 . *Ad damnum à mancipio absque domini culpa datum quousque dominus teneatur.* 1485.
- 712 . *Ad damna, quæ anim alia bruta absque domini culpa dant, quousque eorum dominus teneatur.* 1489.
- 713 . *Vtrùm in foro conscientie, nulla expectata actione, teneatur caput domus soluere damna absque vlla sua culpa à suis domesticis data, projiciendo, effundendo, vel appendendo aliquid indebitè de domo. Idem de nautis, cauponibus, & stabulariis, comparatione damnorum suorum famulorum. Et de domino mancipii aut animalis, comparatione damnorum, quæ mancipium aut animal, similiter dederint.* 1493.
- 714 . *Quid sit restitutio, & cuius virtutis sit actus.* 1499.
- 715 . *Discrimen inter restitutionem & satisfactionem, & num pro iniuria & offensa, sumptis præcisè à damno dato, restitutio debeatur.* 1503.

- 716 . *Vtrùm restitutio neceßaria sit ad salutem.* 1512.
- 717 . *De radicibus vnde restituendi obligatio oritur.* 1522.
- 718 . *Quousque obligatio consurgat restituendi ex parte rei acceptæ, ad alterúmve attinentis.* 1523.
- 719 . *Quousque bonæ fidei possessor rei alienæ, ad alterumve attinentis, fructus illius restituere teneatur. Et num tali bonæ fidei possessori solui debeant impensæ & melioramenta in tali re facta?* 1526.
- 720 . *Ex regula disp. 718 tradita, nonnulla deducuntur, quibus magis elucidatur.* 1529.
- 721 . *Nonnulla alia circa eum, qui rem alienam cæpit bona fide possidere. Et num, si titulo emptionis, aut alio oneroso, cæpit illam possidere, & postea bona fide illam vendat aut permutet, teneatur restituere domino illius, quod in commutationem pro illa accepit, comperto alienam fuisse.* 1532.
- 722 . *Vtrùm, qui bona fide rem emit, aut permutatione comparauit ex latrone, si, dum eam possidet, sciat ad alium pertinere, possit, vt se indemnem seruat, reddere eam latroni, & recuperare, quod pro ea dedit; an teneatur illam reddere domino.* 1539.
- 723 . *De malæ fidei possessore rei alienæ, titulo emptionis, aut quouis alio, quousque ad restitutionem teneatur.* 1544.
- 724 . *Obligationis restituendi, quando formalis iniustitia antecessit, tres partes distinguuntur. Et quousque sit restituendum in prima. Nempe, quando neque obligatio restituendi oritur ex eo, quòd res aliena iniustè sit læsa aut destructa, neque ex re, cuius dominium ad alium attinet.* 1550.
- 725 . *Quousque sit restituendum, quando restituendi obligatio consurgit ex re iniustè usurpata, aut iniustè retenta, quæ ad alterum quo ad dominium spectat. Et num deducendæ sint expensæ cum ea factæ. Ac num aliquando pereat domino illius, & non iniuste detentori.* 1552.
- 726 . *Quousque sit restituendum, quando obligatio consurgit ex damno iniustè rebus aliorum externis dato.* 1562.
- 727 . *Num, qui impedit aliquem ad assecutionem boni alicuius, teneatur id illi restituere.* 1568.
- 728 . *De restitutione damnorum in bonis externis, quæ ex adulterio sequuntur, vbi disputandum. Et num dans operam rei illicitæ, restituere teneatur damna, quæ absque alia sua culpa sequuntur.* 1575.
- 729 . *Qui ad restituendum teneantur. Et de iubente, seu mandante, ratúmve habente damnum nomine ipsius iniustè esse datum.* 1577.
- 730 . *De consulente.* 1580.
- 731 . *Discrimen inser mandantem & consulentem, quando post reuocatum mandatum ac consilium, damnum iniustè infertur.* 1582.
- 732 . *De consentiente. Et num consentiens aut suffragium ferens ad damnum iniustum, quando sine tali censu aut suffragio similiter id damnum daretur, ad restitutionem illi teneantur.* 1584.

- 733 . *De adulatore & receptatore.* 1587.
- 734 . *De participantibus. Et quousque singuli, in variis euentibus, restituere teneantur.* 1589.
- 735 . *De muto, non obstante, & non manifestante. Et num, qui solùm ex caritate ad hæc tenetur, restituere teneatur, si illa omittat. Ac utrùm, qui aliquid accipit, ut ea omittat, restituere id teneatur.* 1593.
- 736 . *Vtrùm, ut aliquis restituere teneatur damnum iniuste datum, satis sit esse concausam iniustam illius; an verò necesse sit esse causam, sine qua id damnum non esset datum.* 1598.
- 737 . *Quousque & quo ordine, nouem concausæ explicatæ, exequutorque ipse, restituere teneantur.* 1605.
- 738 . *Si is, cui facienda est restitutio, remittat vni concausarum damni iniuste dati obligationem restituendi, num reliquæ concausæ eiusdem damni maneant nihilominus obligatæ in solidum.* 1609.
- 739 . *Custodes diuersarum rerum, & alii ministri publici, qui ex officio ad aliqua tenentur, quousq; periuri sint, contra iustitiam peccent, atque ad restitutionem teneantur.* 1612.
- 740 . *Vtrùm custodibus, similibusque aliis ministris publicis, fas sit conuentionem facere circa pænas. Et utrùm restituere teneantur, si quid ita accipiant, antequam ipsis lata sententia adiudicetur.* 1621.
- 741 . *Cui facienda est restitutio. Et num fieri debeat domino, prætermisso non solùm iniusto illius rei detentore, sed etiam iusto.* 1626.
- 742 . *Restitutio quousque hæredibus illius, cui res erat debita, sit facienda.* 1631.
- 743 . *Vtrùm soluens creditori sui creditoris, liberetur ab onere restituendi suo creditori.* 1633.
- 744 . *Bona incerta quæ, & quæ diligentia adhibenda, ut iis, ad quos spectant, restituantur.* 1634.
- 745 . *De restitutione ita incertorum, ut scilicet incertum sit, cui aut quibus in particulari debeantur, certum tamen est, alicui aut aliquibus, ex certis quibusdam, id deberi.* 1637.
- 746 . *De restitutione omnino incertorum. Et num inuenta, quando, facta diligentia, nescitur, cuius sint, restitutioni sint obnoxia.* 1639.
- 747 . *Quibus pauperibus restitutio bonorum incertorum fieri debeat. Et num ad illa distribuenda necesse sit interueniat Episcopi autoritas.* 1642.
- 748 . *Vtrùm qui circa bona incerta summi Pontificis autoritate compositionem faciunt, tuti sint in conscientia.* 1646.
- 749 . *Lusitanæ leges circa animalia inuenta expenduntur, num iustæ sint.* 1651.
- 750 . *Leges huius Castellæ regni circa inuenta.* 1656.
- 751 . *Quid sit restituendum. Quod si pereat, aut dum mittitur, non perueniat ad eum, cui facienda est restitutio, cui pereat.* 1657.
- 752 . *Vbi & cuius expensis restitutio sit facienda.* 1660.

753 . *Quando restitutio sit facienda. Et num continuè peccet, qui non restituit: & quando peccata non restituendo numero multiplicentur.* 1663.

754 . *De causis excusantibus à restitutione statim facienda. Et præsertim de impotentia.* 1668.

[[v]] 755 . *Vtrùm ad vitandum damnum cuiusdam tertii, vel commune, aut etiam eius, cui restitutio est facienda, fas aliquando sit restitutionem differre.* 1674.

756 . *Num quando restitutio fieri debet statim, confessarius concedere pœnitenti inducias possit ad restitutionem differendam. Et quousque negare absolutionem debeat non restituenti statim.* 1677.

757 . *Num condonatio creditoris liberet debitorem à restituendi onere.* 1680.

758 . *Vtrùm debitor per ingressum religionis liber à restituendi onere maneat.* 1681.

759 . *Num creditorem esse excommunicatum, sufficiens causa sit differendi restitutionem eius, quod illi debetur.* 1686.

760 . *Restitutio quo ordine sit facienda, quive creditores præponendi sint aliis in solutione eorum, quæ illis debentur.* 1688.

[[vi]] INDEX LOCORVM S. SCRIPTVRAE, QVAE IN HOC TOMO DE DELICTIS CONTINENTVR.

Disp. 681.

ET reddidit iustis mercedem laborum suorum. Sap. 10.

Ideo iusti tulerunt spolia impiorum, & decant auerunt, Domine, nomen sanctum tuum, & victricem manum tuam laudauerunt pariter. Ibid.

Disp. 683.

Non rapinam arbitratus est, esse se æqualem Deo. Phil. 3.

Quæ non rapui, tunc exsoluebam. Psal. 68.

Disp. 684.

Qui furatus fuerit hominem, & vendiderit eum, conuictus noxæ, morte moriatûr. Exodi 21.

Disp. 685.

Neque fures, neque rapaces, regnum Dei possidebunt. 1 Corinth. 6.

Si vis ad vitam ingredi, serua mandata. Matth. 19.

Disp. 695.

Pro mensura enim peccati erit & plagarum modus. Deuter. 25.

Disp. 698.

Si egressus ignis inuenerit spicas, & comprehenderit aceruos frugum, siue stant es segetes in agris, reddet damnum, qui ignem succenderit. Exod. 22.

Disp. 715.

Mibi vindictam, & ego retribuam, dicit Dominus. Hebr. 10.

Si offers munus tuum ad altare, & ibi recordatus fueris, quia frater tuus habet aliquid aduersum te, relinque ibi munus tuum, ante altare, & vade prius reconciliari fratri tuo, & tunc veniens offeres munus tuum. Matth. 5.

Si quis furatus fuerit bouem aut ouem, & occiderit vel vendiderit, quinque boues pro vno boue restituet, & quatuor oues pro vna oue. Exod. 22.

Disp. 716.

Verumt amen, quod superest, date eleemo synam, & ecce omnia munda sunt vobis. Lucæ 11.

Reddite omnibus debita, cui tributum tributum. Nemini quidquam debeatis. Rom. 13.

Reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari. Matth. 22. Videte, ne fortè furtiuus sit. Reddite cum dominis suis: quia non licet nobis aut edere ex furto aliquid, aut contingere. Tob. 2.

Si dixero impio, morte morieris. Et ille egerit pœnitentiam à peccato suo, feceritque iudicium & iustitiam, & pignus restituerit, rapinamq; reddiderit, in mandatis vitæ ambulauerit, nec fecerit quicquam iniustum, vita viuet, & non morietur. Eze. 33.

Phariseus autem cepit intra se reputans dicere, quare non baptizatus esset ante prandium, dixit illi Christus: Nunc vos Pharisei, quod deforis est calicis & catini mundatis; quod autem intus est, vestrum, plenum est rapina & iniquitate. Stulti, nōne qui fecit quod deforis est, etiam id quod intus est, fecit. Lucæ 11.

Væ vobis, Scribæ & Pharisei, qui mundatis, quod deforis est calicis & paropsidis, intus autem pleni estis rapina & immunditia. Pharisee cæce, munda prius quod intus est calicis & paropsidis, ut fiat id, quod deforis est, mundum. Matth. 23.

Miserere animæ tuæ placens Deo. Eccli. 30.

Ecce, Domine, dimidium bonorum meorum do pauperibus, & si quid aliquem defraudaui, reddo quadruplum. Lucæ 19.

Quia hodie salus huic domui facta est. Ibid.

Sine fide impossibile est placere Deo. Heb. 10.

Nisi pœnitentiam egeritis, omnes peribitis. Lucæ 13.

Si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, & si tradidero corpus meum ita ut ardeam, caritatem autem non habuero, nihil mihi prodest. 1 Corinth. 1.

Si dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittet vobis Pater vester cælestis delicta vestra. Matth. 6.

[[vii]] *Sed vae vobis Phariseis, qui decimatis mentam, & rutam, & omne olus, & prætendis iudicium & caritatem Dei. Hæc oportuit facere, & illa non omittere.* Luc. 11.

Consilium meum placeat tibi, Rex, & peccata tua eleemosynis redime: forsitan ignoscet tibi Deus delictis tuis. Daniel. 4.

Beatus vir, qui intelligit super egenum & pauperem, in die mala liberabit eum Dominus. Psal. 40.

Per misericordiam & fidem purgantur peccata. Prouerb. 15.

Misericordia & veritate redimitur iniquitas. Prouerb. 16.

Eleemosyna ab omni peccato & à morte liberat, & non patietur animam ire in tenebras. Tobiaë 4.

Eleemosyna purgat peccata, & facit inuenire misericordiam & vitam aternam. Ibid. 12.

Et ego dico vobis, facite vobis amicos de mammonæ iniquitatis, ut cum defeceritis, recipiant vos in æterna tabernacula. Luc. 16.

Ecce Adam quasi vnus ex nobis factus est, sciens bonum & malum. Genes. 3.

Disp. 732.

Si iustum est in conspectu Dei, vos potius audire quàm Deum, iudicate. Actor. 4.

[[viii]] APPROBATIO.

Opus hoc de delictis & quasi delictis, Iustitiæ Commutatiuæ circa bona externa contrariis, Clariss. Doctoris & Professoris Ludouici Molinæ Societate Iesu, pari laudis præconio, quo altera huius tomi pars pridem in lucem edita, dignum est. Præsertim cum restitutionis campus in eo maiori diligentia & labore, quàm ab aliis, videatur excultus. Vnde non S. Theologiæ modò, sed & iuris prudentiæ studiosis, magno vsui futurum est: quodque in omnium manibus summa cum vtilitate versetur, dignissimum. Antuerp. In Seminario Episcopali, 14 Ianuar. 1608.

Laurentius Beyerlinck, Antuerp. S. Theol. Licent. Eccles. Antuerp. Canonicus, & librorum censor.

[[1]] DE DELICTIS, ET QVASI DELICTIS, IVSTITIAE COMMVTATIVÆ CIRCA BONA EXTERNA CONTRARIIS.

Varia genera eiusmodi delictorum distinguuntur: præcipuè furtum, rapina, & damnum datum. Disput. 680.

SVMMARIVM.

1 *Iniustitiæ, iustitiæ commutatiuæ circa bona externa contrariæ, varii modi.*

2 *Furtum latè, & peccatum ferti latè, quid.*

3 *Furtum præssè, quid.*

Dicendum est consequenter [sect. 1] de vitiis iustitiæ commutatiuæ circa bona externa contrariis: & simul de quasi delictis circa eadem bona. Multis autem modis euenit iniustitia circa bona externa, iustitiæ commutatiuæ contraria. In primis in contractibus: idque dupliciter. Vno modo, celebrando iniustū contractū cum aliquo, aliquídve iniustè eo contractu ab illo exigendo, aut accipiendo. Atque in tali iniustitia interuenire solet consensus, inuoluntarius tamen mixtè, ex parte eius, qui eam iniustitiam patitur; siue consentiat ex ignorantia, quia videlicet ignorat iniustitiam, quam patitur; siue sciēs & prudens, pressus tamen necessitate aliqua, aut ratione alia, ad id adductus. Hoc modo committitur vsura, & vitium circumuētionis, & supergressionis fratrum, de quo *Paulus 1. ad Thessalon. 4.* vt quando aliquid venditur, aut locatur, vltra iustum pretium, vel emitur, aut conducitur, infra pretium iustum, vel venditur res vitiosa, non detecto vitio, quod vendens detegere tenebatur, variisque aliis modis: qui ferè patent ex hactenus dictis, præsertim in materia de contractibus. Altero modo interuenit iniustitia ex contractu, non implendo id, ad quod quis ex contractu tenetur. Vt si emptor, aut conductor, non soluat pretium, vel venditor, aut locator, non tradat rem venditam, aut locatam, vel commodatarius non tradat rem commodatam congruo tempore, aut quouis alio modo aliquis sua culpa id non impleat, quod ex contractu iusto, aut ex quasi contractu, implere tenetur, vt si hæres non soluat debita aut legata defuncti. Atque cum hoc iniustitiæ genere cōiungere possumus, quando quis non implet id, quod lege iusta, aut ex alio capite, implere ex iustitia tenetur, vt quādo non soluit tributa iusta, aut voluntatem testatoris non implet iuxta onera sibi iniuncta. Quia verò hi omnes iniustitiæ modi circa res externas, iustitiæ commutatiuæ circa easdem res contrarii, facilè patent ex iis, quæ toto hoc secundo tractatu dicta sunt, & quæ in progressu huius secundæ secundę subjiuntur, non est cur plura hoc loco circa eiusmodi vitia dicamus.

Deinde euenit iniustitia circa bona externa, iustitiæ commutatiuæ contraria, usurpando extra contractum res aliorum externas, aut damnū illis iniustè inferendo. Atque hoc modo committuntur furtum, rapina, & datio iniusta damni: quæ sunt tria vitia, cum quasi delictis eis annexis, de quibus hoc loco disputare intendimus.

Est verò obseruandum, furtum sumi interdum [sect. 2] latissimè: quo pacto omnem iniustitiam circa res externas, exequutioni mandatam, suo ambitu cōprehendit. Dixi, exequutioni mandatā: quoniā vt habetur. *l. 1. §. 1. ff. de furtis*, sola cogitatio furti faciendi, id est, actus internus, etiamsi aliquam attentationem externam habeat adiunctam, quæ non perueniat ad effectum contrectationis rei alienæ, quemadmodum non est furtum, ita non facit furem. In hac significatione vsurpatur furtum septimo illo præcepto decalogi: *Non furtum facies*. Omnis enim iniustitia circa res externas, exequutioni mandata (nomine exequutionis etiam omissionē exequutionis comprehendēdo, non soluendo, quod quis ex iustitia soluere tenetur) prohibetur eo præcepto. Decimo verò illo alio præcepto; *Non concupisces rem proximi tui*, actus internus circa omnem eam iniustitiam, nōdū exequutioni mandatus, prohibetur. Quo fit, vt peccatum furti latissimè sumptum, omnia prohibita vtroque præcepto comprehendat. Licet enim furtum significet solū externum actum à peccato interno emanātē, illūdve coniunctum habens atque includens; quoniam, nisi à vero peccato interno furti emanaret, illudque coniūctum haberet ac comprehenderet, non esset furtum formaliter, sed materialiter; peccatum tamē furti etiam actum merè internum, decimo præcepto decalogi, ad maiorem rei explicationem, prohibitum, & attentationem actu externo sine effectu, comprehendit. Furtum hoc modo sumptum non distinguitur contra rapinam, sed eam suo ambitu amplectitur. *Vnde Augu. q. 71. in Exod. & refertur. c. panale 14. q. 5. Furti, inquit, nomine bene intelligitur omnis illicita usurpatio rei alienæ: non enim rapinam permisit, qui furtum prohibuit: sed utique furti nomine, in lege veteris testamenti, & rapinam intelligi voluit: à parte enim totum significauit, quicquid illicitè rerum proximi aufertur.* id est, à furto, quod pars est subiecta iniustæ acceptionis rerum proximi, ipsam iniustam acceptionē in toto suo ambitu significauit: nomine, iniustæ acceptionis, eam etiam comprehendendo, quæ in contractibus interuenit, duobus modis suprā explicatis. Quin & sub furto ita latè sumpto, comprehenditur omnis iniusta damni datio circa res externas, vt qua iniustè exuruntur, aut demoliūtur, segetes proximi, aut aliud damnum rebus externis illius iniustè infertur. Imò verò nomine, iniustæ acceptionis, damni datio iniusta comprehenditur in materia de restitutione, quando dicimus, obligationem restituendi interdum oriri ex parte iniustæ acceptionis, & interdum ex parte rei acceptæ. Quæ omnia furti nomine in septimo præcepto decalogi intelliguntur.

Alio modo sumitur furtum præcisè, non solū [sect. 3] vt distinguitur contra iniustitias circa res exter-[[2]]nas proximorum, quæ eueniunt in contractus, aut ex contractibus, modis suprā explicatis, sed etiam vt distinguitur contra rapinam, hoc est, violentā vsurpationē iniustam rerum externarū proximorum, & contra damnum circa easdem res iniustè datum, hoc est, eas non accipiendo, sed destruendo, aut deteriores eorum dominis, ac tentoribus, reddendo. Atque de furto in hac significatione est nobis hoc loco sermo.

Furtum præse quid. Disp. 681.

SVMMARIVM.

1. *Furtum præse unde dictum.*

2. *Furti præse definitio.*

3. *Furtum formaliter, & furtum materialiter, quid. Pro solo autem furto formali ac materiali simul, datur actio furti in foro exteriori, aut pro eo, quod præsimitur tale.*

4. *Furtum committitur, si inuentum retineatur ab inuenienti, & quando id præsimitur.*

5. *Furti non punitur, qui inuentum sibi retinet, quādo dominus eius rei eam habebat pro derelicto, esto inueniens id ignoraret.*

6. *Circa inuenta quid iure Lusitano statutum.*

7. *Circa inuenta quid iure Castellæ sancitum, & cui applicentur factis certis diligentis.*

8. *Furtum quando committant commodatarius, depositarius, conductor, aut habens in pignus, si rebus, quas ita habent, utantur ultra id, ad quod eas habent, inuitis dominis, & quale furtum id sit. Et qui alii furtum committant.*

9. *Expilatæ hereditatis crimen distinctum est à furto. Quæ actio aduersus expilatorem competat, & quibus puniatur pænis.*

10. *Furtum non est, sed aliud delictum, si vnus coniux, altero defuncto, aliquid subtrahat, aut deneget de hereditate defuncti aut de communibus bonis, & quæ actio aduersus eum eompetat.*

11. *Expilatæ hereditatis actio competit priuigno aduersus vitricum, aut nouercam, si ex hereditate aui, priuigni, aut alterius, qui non sit coniux vitrici, aut nouercæ, aliquid subtrahant.*

12. *Furtum committitur, non tamen datur actio furti, sed rerum amotarum, si vnus coniux, constante matrimonio, aliquid de bonis alterius surripiat.*

13. *Furtum committit tutor, si rem pupilli eo inuito usurpet, actioque furti aduersus illum datur, si de eo animo constet: si verò non constet, sed præsumat is animus, competit pænalis actio de rationibus distrahendis: si autem non præsumat, competit solùm actio tutelæ.*

14. *Rei nomine in definitione furti quid intelligatur.*

15. *Furti definitio à D. Th. tradita.*

16. *Furti alia definitio.*

Vt habetur. l. 1. in prin. ff. de furtis, & §. fur [sect. 1] tum inst. de oblig. quæ ex delicto,

consentitque Isidorus lib. 5. Etymolog. cap. 26. furtum, vt Labeo ait, cui consentit Varro lib. 14. rerum diuinarum, dicitur à furuo, id est nigro, quòd clām & obscurè fiat, & plerumque nocte. Vel, vt Sabinus ait, dicitur à fraude, aut, vt aliis placet, dicitur à ferendo, id est, auferendo: quia fur aufert ab alio, & sibi affert, quod fit contrectando rē, eamque ferendo de loco in locum. Vel vocabulum fur à sermone græco originem traxit, quo fur Phor appellatur: id quod, referente Calepino, Gellio magis placuit.

Definitur verò furtum, l. 1. cita. §. ult. & inst. §. [sect. 2] citato, contrectatio fraudulosa lucrificandi causa, vel rei, vel vsus illius, vel possessionis. Posita autem est in hac definitione vox, contrectatio, potiùs quàm usurpatio, vt vsum rei alienæ inuito domino comprehendat. Porrò, contrectatio fraudulosa duo includit. Vnum est, vt non sit aperta, vidente & resistente domino, atque adeò vt non sit pervim: tunc enim esset rapina, & non furtum pressè sumptum, de quo loquimur. Vnde per particulam, fraudulosa, eo modo intellectam, rejicitur rapina à ratione furti. Alterum verò, quod includit, aut supponit, est, quòd sit rei alienæ, ea ex

parte, qua committitur furtum; contrectatio enim rei propriæ, furtum non est, itemque, quòd fiat inuito domino. Quando enim constat, contrectationem esse iuxta domini voluntatem, neque fraus, aut occultatio, est necessaria, neque in ea contrectatione, aut vsurpatione, cernitur furtum.

Et quidem, quod ad conscientiæ forum attinet, si contrectans credat dominum rei fore inuitum, nec tamen sit, committit furtum formaliter, ac peccat; non tamen committit furtum materialiter. Si verò credat, meritoque sibi persuadeat, dominum non fore inuitum, & dominus inuitus sit, committit furtum materialiter, non verò formaliter, ac proinde nec peccat, nec ad restitutionē tenetur ex parte acceptionis, sed solūm ex parte rei acceptæ, quod ex illa extat, aut quantum ex ea fuerit factus locupletior. Quod verò ad forū externum attinet, semper cōtrectās rē alienam, præsumitur inuito domino eam contrectare, ac proinde vt fur punitur, nisi sufficientes adsint coniecturæ, vnde contrarium præsumatur. Neque, vt præsumatur non contrectasse inuito domino, erit satis, si rei dominus dicat postea, contrectationem non fuisse factam ipso inuito: quoniam, nisi sint verisimiles aliæ coniecturæ, quæ id persuadeant, contrarium præsumitur ad id delictum in commune bonum puniendum. Ita *Glos. l. inter omnes. §. rectè verb.* verumtamen. *ff. de furtis*, & concinit. *l. qui vas. §. vetare. ff. eodem titu.* atque cum *Bart. & Panor.* & cum communi doctorum sententia, quam refert, affirmat *Ant. Gom. 3. Tom. var. res. c. 5. n. 1. & 2.* apud quem lege circumstantias aliquas, quæ in foro exteriori persuadent, contrectationem non fuisse factā inuito domino. Quòd si contrectatio facta fuisset concurrentibus circūstantiis, quæ suaderent, dominum non futurum inuitum, atque cōtrectās, id sibi persuadens, rē alienam contrectaret, tunc, esto postea comperiretur, dominum fuisse inuitum, talis cōtrectans non diceretur furtum commisisse, nec proinde aduersus eum daretur furti actio. Ita habetur. *l. inter omnes. §. rectè, & l. qui re ff. de furtis, & inst. de oblig. quæ ex delict. §. placuit*, vbi hæc elegans ratio redditur; *quia furtum sine affectu furandi non committitur.* Quando autem quis crederet se contrectare rem alienam inuito domino, si postea comperiretur dominum [[3]] re ipsa non fuisse inuitum, quamuis peccauerit furti peccato, aduersus eum tamen non conceditur actio furti in exteriori foro: quia iniuriam re ipsa non intulit domino rei, licet se eam inferre crediderit. Ita *Vlpianus aduersus Pōponiū*, qui contrarium affirmavit. *§. rectè citato*, consentit. *l. falsus. §. qui alienum. ff. eod. titu. vt subiungam.*

Quando aliquid inuenitur, si accipiatur lucri [sect. 4] faciendi causa, hoc est, animo id sibi retinendi, committitur furtum, non solūm in conscientiæ, sed etiam in exteriori foro, & vt tale punitur, etiam si inuentor nesciat cuius sit, ita habetur *l. falsus. §. qui alienum. ff. de furtis, & l. ultim. §. omnes. C. vnde vi.* Et quando aliunde non sunt sufficientes coniecturæ, quòd id non acceperit animo sibi retinendi, præsumitur accepisse vt id sibi retineret, quando dominum non quæsiuit edicto publico, aut præconis voce, concinit *§. qui alienum citatus vers. plerique*, & cum aliis affirmat *Ant. Gom. vbi suprā n. 2. Lege falsus. §. qui alienum citato*, habetur, quando domi [sect. 5] nus rei inuentæ illam habuit pro derelicto, tunc, esto, qui illam inuenerit, id ignorauerit, eamque animo sibi retinendi acceperit, non esse puniendum vt furem: eo quòd re ipsa nulli furtum fecerit. Noluit enim ius punire furtum formale, nisi quando coniunctum esset cum furto materiali, vt suprā dictum est.

Quinto lib. *Lusita. ord. titu. 41.* statuitur, vt, si inuentor rei alicuius, sciat cuius ea sit, teneatur [sect. 6] eam illi tradere, esto ab eo non petatur: si verò ea¹ vtatur sine domini voluntate, puniatur ac si eam furto accepisset. Si verò ignoret, cuius ea sit, teneatur illam intra triginta dies præconizare in locis publicis ad id consuetis: quòd si id intra eos dies

non fecerit, & ea vtatur, punitur vt fur. Insuper statuitur, si res inuenta fuerit seruus, teneatur intra quindecim dies eum manifestare, vel proprio domino, vel iudici *da cabeça do almoxari fado da comarca emque for achado*, alioquin punitur vt fur. Ibidem subiungitur præmium propositum inuentoribus auium alienarum ad aucupium attinentium, vt accipitrum, atque item inuentoribus Mancipiorum, *de qua re Disput. 83. §. obiicies, dictum est.* Item de expensis factis cum re inuenta soluendis inuentori, subiungitur ibi sermo, *dictumq; est Disput. 83. citata.* Cum quibus computa iustum pretium laboris & industrię appositæ, etiam in extrahenda re aliena à periculo, vt ex ore lupi; *de qua re Dis. 41. dictum est.*

Lege 6. & 7. titu. 13. lib. 6. nouę collect. statuitur, vt quęcunque inuenta statim tradantur iudici [sect. 7] loci, in quo fuerint inuenta. *Et cū lege 6. citata,*² transacto anno, in quo non compareret dominus, res inuenta applicaretur fisco; *lege tamen. 7. statuitur*, vt iudex illam deponat, *en poder de persona, opersonas, idonea, que la tenga de manifesto por vn año y dos meses: yel que asi la ballare, o aquel à quien perteneciere por priuilegio, uso, y costumbre, lo mostrenco; hagalo en este interim pregonar por publicoy conocido pregonero del lugar, do la cosa fuere ballada, cada mes en dia de mercado. Y mandamos que el mismo dia, que fuere ballada, la notisique el q̃lla ballare ante el escribano del concejo del dicho lugar. Y si hasta el termino de vn año y dosmeses el señor dela cosę ballada viniere, libremente lesea restituida, pagãdo las costas que fueren hechas en laguardar. Y si aquel, o à quien pertenece lo mostrenco, no hiziere las diligencias desuso contenidas, piorda el derecho, quele compete à el mostrenco, y la cosa ballado la restituyga como por hurto.* Atque hæc est lex, cuius *Ant Gom. n. 2. citato meminit*, & quod in hoc Castellę Regno ait esse sancitum. Vbi vides, neque inuentori, neque cuicunque alteri, cui ex priuilegio & vsu res inuenta concedatur, aliter eam concedi, & appropriari, quàm si prædicta obseruet: quin potius, si aliquid prætermittat, & rem vsurpet, puniri vt furem: quando autem ea omnia ritè seruarentur, meritò publica autoritate adiudicatur res inuentori, si dominus non compareat intra annum & duos menses, aut alteri, cui ex priuilegio sit ita concessa. Cū verò nullibi videamus id seruari, nullus in hoc Regno consequitur dominium eiusmodi rerum ea ratione. Atque adeò, quando illa non seruantur, vt minimū tenetur inuentor facere moralem competentem diligētiam, vt dominus illius comperiatur, illique tradatur: si autem, illa facta, dominus non comparuerit, aut spes iam non sit, quòd dominus compareat, quia congruo tempore facta non fuit cōpetens diligentia, insumenda est ea res in eleemosynis, aut in aliis operibus piis, pro anima eius, cuius fuerit. Vtrū autem obligatio sit eam tradendi fratribus Mercenariis, aut Trinitariis, qui affirmant, se habere priuilegium, vt ipsis in captiuorum redemptionē tradatur, inferius in materia de restitutione eiusmodi inuentorum dicitur. Certè cū videamus, eos non seruare præscripta ea lege 7. vt dominus inuenire eam possit, ac cōsequi; inuētor, qui illa seruare vellet ad vnguē, non teneretur eam illis tradere in præiudicium dominorū; sed facta ea competenti diligentia, dominoque non comparente, meritò iuxta eam legem, compareret dominium talis rei.

Per particulam, fraudulosa, quatenus supponit esse inuito domino, excluditur præterea à ratione furti acceptio rei alienę per vsuram, aut per aliū contractum iniustè: id quippe fit consentiente domino, tametsi inuoluntariè mixtè.

Additur in definitione, lucri faciendi causa: quoniam, si quis rem accipiat, non vt eam sibi reseruit, aut alteri, ad quem sciat eam non pertinere, sed vt eam illi reseruet, ad quem pertinet, aut vt cautiorem eum reddat, non committit furtum.

Additur deinde, vel rei, vel vsus illius, vel possessionis: quoniam non solum cōmittitur furtum, si res omnino alterius (quod nomine rei in ea definitione intelligitur) integre

lucrificandi gratia vsurpetur; sed etiam si accipiat quoad solum vsum, aut si quoad possessionem, aut tentionē, quæ ad alterum spectat, accipiat eo inuito: nomine enim possessionis, tentio etiam, saltem legitima, in ea definitione cōprehenditur. Vnde, si quis rem [sect. 8] aliquam cōmodatā habeat ad certum vsum, & ea vtatur ad alium, aut per lōgi⁹ tempus, vel spatium, inuito domino, cōmittit furtum in ea cōtrectatione. *l. qui iumēta. ff. de furtis. §. furtum autē inst. de oblig. quæ ex delicto, & Disp. 195. dictum est, vbi ex Couar. adieciimus*, quando certum non esset eum vsum futurum contra domni volūtatē, eum cōmodatariū cēsēdū non esse cōmisisse furtū: idque habetur §. placuit inst. eod. titu. *Quin*, esto intelligeretur dominum futurum inuitum, eū cōmodatariū non cēsēdū esse infamē, neque dānādū tota pæna furibus statuta. Idem dicēdū est de eo, qui rem habet conductam ad certum vsum, vt habetur §. furtum autem citato. Eodem etiam modo, si creditor vtatur pignore, aut depositarius re deposita, inuito domino, committit **[[4]]** furtum, vt habetur. §. furtum autem citato, & aliis iuribus, quæ citauimus *disp. 524. & disp. 535.* quibus in locis hac de re dictum est. Simili modo, si quis rem contrectet quoad solam possessionem, priuando alterum possessione, in qua erat, eo inuito, committit furtum aduersus eum, esto non esset dominus rei: aut si rem contrectet, priuādo aliquem, ipso inuito, tenentia, qua eam rem iure ac legitimè tenebat, vt si pignus accipiat de potestate creditoris, qui illud tenebat, aut rem locatā de potestate eius, qui illam habebat conductam, aut rem depositam de potestate depositarii, vel custodis, committit furtum aduersus eos, vt habetur. §. furtum autem citato. *l. in actione. §. qui rē. l. si is qui. ff. de furtis. §. aliquando. §. furti autem inst. de oblig. quæ ex delicto. l. 9. tit. 14. part. 7. & aliis iuribus.* Quando tamen dominus rei, qui illam commodauerat, illam aufert à commodatario, non competit commodatario actio furti aduersus commodantem, nisi retinere eam posset ratione expensarum, aut alterius debiti, quo ei commodans tenebatur, vt habetur *l. creditoris. §. dominus, & l. si is qui. ff. de furt.* Si tamen nondum finitum fuerat tempus, pro quo res fuerat commodata, agere poterit actione commodati; vt ei restituatur, imò & ad damna. *Quin* abserua, furtum non dici committi, nisi aduersus eum, qui possidet, saltem per alterum, vel rem legitimè tenet. *Quare*, esto dominium ad vnum pertineat, si tamen ille, neque per se, neque per alium, sit in possessione illius rei, non dicitur furtum committi aduersus eum, sed aduersus possessorem, vel legitimum tentorem rei illius. De his tamen omnibus dicitur copiosius *Disput. 696.*

Hinc, si quis ex hæreditate, quæ ad ipsum non [sect. 9] pertinet, aliquid indebitè vsurpet, siue hæreditas adhuc iaceat, quia à legitimo hærede nōdum est adita, siue ab eo sit adita, eaque aditione comparauerit dominium, sed nondum possessionem illius obtinuerit: iuxta ea quæ *disp. 3.* & aliās sæpe, dicta sunt, is non dicitur fur pressè, neque in pænas furi à iure statutas incidit; sed incidit in crimen aliud distinctum, quod appellatur expilatæ hæreditatis, vt *constat. l. 2. & per totum titulū. ff. de crimine expilatæ hæred. l. vlt. & per totum. C. eodem titu. & l. 21. titu. 14. part. 7.* Cessat verò idcrimen eo ipsi, quòd obtenta est hæreditatis possessio per vnum ex heredibus, etiam si alii possessionem non comparauerint, isque aliquid amoueāt in præiudicium cæterorum, vt habetur. *l. 1. C. eod. titu.* Qui verò rem modo explicato ex hæreditate vsurpat, hæreditatē mve expilat, cogitur reddere eam rem legitimo hæredi, vnā cum fructibus ex illa perceptis, agiturque reiuendicatione. *l. 21. citata, & consentiunt lex. 2. & sequentes. ff. de crimine expil. hære.* *Quin* & fructus, qui percipi ex ea potuerunt, & sua negligentia non sunt percepti, cogetur soluere: atque ad fructus existētes competit reiuendicatio, ad non existentes verò condictio, vt *constat. l. malæ fidei. de cōdict. ex lege, & l. aduersus. C. de crim. expil. hære.* Insuper, qui in id crimen incidit, si nobilis sit, in exilium ad

tēpus, arbitrio iudicis constituendum, mittitur, aut alia pæna arbitraria pro qualitate criminis, spectatis circumstantiis omnibus concurrentibus, damnatur. Si verò non sit nobilis, damnatur in metella tempore iudicis arbitrio statuendo, vt habetur. *l. 1. §. expilatores. ff. de effractorib. & l. 21. citata.* Hodie verò in hoc Regno, cū vsus non sit damnandi ad metella, ea pæna commutatur in pænam remigandi in triremibus. *Lege. 3. titu. 13. lib. 4. nouę collect. in pænam statuitur ei, qui occupauerit possessionem hēreditatis defuncti, qui legitimos alios hāredes habuerit, vt, vltra illam, eis restituat insuper ęstimationem integram illius.*

Si vnus coniugum ex hāreditate alterius con [sect. 10] iugis defuncti, aut in hoc Regno ex bonis communib⁹, aliquid iniustè amoueat, illūdve ad partitionem non afferat, non competit hāredibus alterius coniugis defuncti aduersus eum actio ex furto, aut expilatæ hāreditatis; quia neutrum crimen censetur committere; sed mitior quædā alia ad rem, & aduersus eum, in matrimonii honorem, conciditur. Atque circa ea ex his, quæ adhuc extiterint, competit reiuendicatio, circa reliqua verò condictio. *Ita habetur. l. aduersus: C. de crimi. expil. hære. & l. malæ fidei. C. de condict. ex lege, & l. vxor. ff. de crim. expil. hære.*

Aduersus vitricum autem, si aliquid iniustè v [sect. 11] surpet, non quidem ex hāreditate ex sua vxore defuncta delata priuigno, sed ex auis priuigni, aut aliunde, competit priuigno actio expilatæ hāreditatis: & idem dicendum est de nouerca comparatione priuigni, si de hāreditate ad suum priuignum ex alio, quàm ex suo cōiuge defuncto, delata, aliquid iniustè vsurpet. *Ita habetur l. 2. & 3. C. de crimi. expil. hære.*

Quando vnus coniugum aliquid, constante ad [sect. 12] huc matrimonio, iniustè accipit debonis alterius, licèt verè furtum committat, vt habetur. *l. 1. & penul. ff. rerum amotarum:* in honorem tamen matrimonii, vt ibidem *l. 2. habetur*, noluit ius aduersus id ita accipientem concedere actionem ex furto, sed mitiorem multo aliam rerum amotarum, ad vendicandum, quod extiterit rerum ita amotarum, & fructuum inde perceptorum, & ad condicendum, quod fuerit consumptum, damnaque omnia ex tali amotione subsequuta. *Ita habetur ff. & C. rerum amotarum per totum.*

Vtrū autem aduersus tutorē agi possit actione [sect. 13] furtiua, si rem pupilli eo inuito sibi vsurpet, quasi verè furtum aduersus pupillum committat? *Lex. 5. titu. 14. part. 7. negare videtur*, sed solū ait, agi aduersus eum posse actione de rationibus distrahendis quam iura vocant, quę, finita tutela, datur aduersus tutorem, quando dolo aliquid aduersus pupillum fecit, condemnaturque in duplum æstimationis eius rei, soluendum pupillo, aut hāredibus illius: estque proinde ea actio pænalis, quoad id, quod soluere iubetur vltra æstimationem eius rei, non verò quoad æstimationem in illo duplo inclusam, ac proinde, si actio non sit intētata aduersus tutorem dum ille viueret, eo defuncto, non competit quoad id incrementum aduersus hēredes illius: secus autem quoad ęstimationē in illo duplo inclusam, & quoad dāna, si quæ inde pupillo sint etiam sequuta: nam quoad hęc actio non est pænalis, sed prosequutiua veri debiti, quæ proinde transit aduersus hāredes talis tutoris: vt hęc omnia habentur *l. 1. à. §. de rationibus, & l. 2. ff. de tutel. & rationibus distrah.*

Cæterū rectè Greg. Lopez. *l. illa. 5. distinguit.* Quod aut verè constat, tutorem, animo id furandi, aliquid pupilli vsurpasse, ac proinde interuenisse verum dolum in ea vsurpatione: atque tunc dicendum esse, commisisse verum furtum, darique actionem de furto aduersus illum, qua intentata, cessat circa id delictum actio de rationibus distrahendis, vt hęc omnia perspicuè habentur duobus iuribus citatis. *affirmantq; ibi [[5]] glos. Bart. & alii.* aut non constat de tali animo, sed præsimitur, & tunc locum non habere actionē de furto, sed solū de rationibus distrahendis ad duplum æstimationis eius rei. Atque hoc tantū voluisse legem.

5. citatam, & haberi duobus iuribus citatis. Aut denique dolus non interuenit tutoris, saltem sufficienter pręsumptus, & tūc solūm competit aduersus tutorem, & aduersus hęredes illius, actio tutelę, ad eam rem, aut ad ęstimationem illius, recuperandā. Iuxta hęc ergo dicendum est, tutorem, si rem pupilli sibi illo inuito vsurpet, committere furtum verum. Quādo verò de eo animo plenè non constat, non concidi actionem de furto aduersus illum.

Illud obserua, nomine rei, in definitione fur [sect. 14] ti, intelligi rem externam, de earum numero, de quibus in hoc secundo tractatu de iustitia nobis est sermo, *vt D. Tho. 2. 2. q. 66. ar. 3. rectè ait*: Vnde vsus alienę vxoris, seu potiùs abusus ad adulterium, inuito viro, cuius est vxor, non est furtum, neque rapina, si per vim fiat; quia non est rei alienę: quoad dominium, inuito domino; eo quòd vir non sit dominus vxoris, neque vxor sit res illius externa, de qua loquimur, sed sit persona illi coniuncta: quare disputatio de his, & de aliis similibus eriminibus, non ad hunc secundum de iustitia tractatum, sed ad tertium sequentem spectat. Hac eadem ratione, vsurpatio filiorum alienorum, aut hominum omnino sui iuris, vt alibi vendantur, & in seruitutem redigantur, non est furtum: quoniam parentes in filios non habent ius tanquam in res externas ipsorum: neque homines ipsi, quibus ea iniuria fit immediatè, habent ius in se ipsos tanquam in res ipsorum externas: quare ea iniuria est in personas proprias, quę, si aliis sint coniunctę, redundat etiā in personas coniunctas, estque proinde iniuria etiam earum, vt tractatu sequenti dicitur: neutrorum tamen comparatione est furtum, aut rapina, de qua in hoc tractatu loquimur. Si tamen mancipium vsurpetur alienum, domino inuito, vel mancipium ipsum se subtrahat à domino suo, verum furtum committitur: quoniam mancipium res est externa, cuius dominus verum habet dominium.

Iuris periti, iuxta. §. quod autem, vers. abolita, inst. de vsucapionibus, negant esse furtum, nisi rei mobilis, & idem affirmat. *l. 1. tit. 14. part. 7. & glos. verb. rei. §. 1. inst. de oblig. quę ex delicto*: vnde particule, rei, positę in definitione furti, addunt, mobilis: per quam excludunt à ratione furti, occupationem, inuito domino, tum rei immobilis, vt fundi, tum etiam rei incorporalis, vt seruitutum, & similium incorporalium rerum. Theologis placet, etiam eiusmodi rerum posse esse furtum, vt si quis rupta scriptura, qua res immobilis ad alterum pertinebat, aut conficta aliqua scriptura, occupet rē alterius, aut, mutatis limitibus, signisve, quibus agri diuiduntur, occupet partem agri alterius. Atque hęc etiam fuit sententia antiquorum iuris consultorum, vt refertur versiculo citato, vbi dicitur, abolitam iam esse eam sententiam. Et *l. 1. citata, cū dictum esset; Otro si de Zimos, que no puede ome furtar cosa, que no sea mueble*; additur; *como quier que los almogauares entran y furtanà las vagadas castillos o villas: pero no es propriamente furto*. Et simile quid subiungitur. *l. vlt. eiusdem tituli. Caiet. 2. 2. q. 66. ar. 3. & Sotus. 5. de iust. q. 3. art. 1.* carpunt definitionem iurisconsulti, hactenus explicatam, quę & longa est, & non nullis calūniis subiacere videtur. Cæterum ad rem iuris peritorum, eo pręsertim modo, quo à nobis explanata est, toleranda est, dicendisque in sequentibus non parum inseruiet.

D. Tho. art. 3. citato, in hunc modum furtum [sect. 15] definit: Est occulta acceptio rei alienę. Nomine rei alienę intelligit, quę sit alterius quasi possessio aliquo modo, saltem per legitimam illius tentionem, atque adeò, quę sit bonum externum aliquo modo illius: per quam particulam rejicit à ratione furti acceptiones iniustas, quę sunt iniurię in personam, saltem coniunctam, ad quam res illa aliquo modo pertinet, non tamen tanquam possessio illius, vt sunt vsurpatio vxoris alienę, aut filiorum alienorū. Nomine item rei alienę intelligit, quę ad alium pertineat aliquo modo, saltem quoad possessionem, aut quoad legitimam tentionem: vnde necesse non est exprimere, quod acceptio, seu contrectatio, sit rei, vel vsus,

vel possessionis illius. Nomine verò acceptionis, veram acceptionem intelligit: vnde per eam particulam rejicit à ratione furti iniustam damni dationem rerum externarum aliorum, eas non accipiendo, sed destruendo, aut deteriores reddendo. Particulam verò, occulta, eo modo intelligit, quo nos exposuimus particulam, fraudulosa, definitionis iurisconsulti. Vnde in ea intelligit, quòd acceptio non fiat vidente ac renitente eo, cuius ea res est, quoad id, in quo furtū aduersus eum committitur: quo fit, vt per eam particulam rapina à furti ratione rejiciatur. Intelligit præterea, quòd fiat non consentiente eo, etiam tacitè aut præsumptè, ad quem ea res quoad id pertinet, atque adeò quòd ea acceptio iniusta sit.

Fortasse melius possumus ita definire furtum: [sect. 16] Est acceptio iniusta boni externi, absque vi, & absque vllo consensu eius, cuius est, saltem quoad legitimam tentionem. Per particulam acceptio rejicitur à ratione furti iniusta damni datio, in qua nulla interuenit acceptio. Rejicitur etiam iniusta retentio rei alteri debitæ, quæ, vt non est acceptio, sed mora iniusta reddendi, quod ad alterum spectat, ita non est furtum. Per particulam iniusta, rejicitur à ratione furti, acceptio boni ad alterum attinentis, etiam illo inuito, in qua nulla cernitur iniustitia. Talis fuit expoliatio, qua filii Israël Ægyptios spoliauerunt bonis illorum externis, ipsis inuitis. Iniusta enim non fuit: eo quòd facta fuerit præcipiente Domino, vt habetur *Exod. 11. & 12.* qui vniuersalis ac supremus est Dominus rerum omnium, à quo cætera dominia sunt deriuata ac pendent, fueritque facta in recompensationem iustam pro obsequiis Ægyptiis præstitis, & oppressione iniusta, qua ab eis fuerant passi, *iuxta illud Sap. 10. Et reddidit iustis mercedem laborum suorum.* Et infra: *Ideo iusti tulerunt spolia impiorum, & decantauert, Domine, nomen sanctū tuum, & victricem manum tuam laudauerunt par iter.* id est, postquam se viderunt omnino liberatos ab Ægyptiis, illis demersis in mari rubro, & cum spoliis, quæ Domino præcipiente ab illis abstulerant, ac securè iam possidebant, laudauerunt nomen sanctū Domini, gratias agētes Deo, tum pro spoliis, tum etiam pariter pro victrice manu Domini. Talis etiam est acceptio, qua bonum alterius in extrema necessitate accipitur, quantum præcisè est necesse, ad eam necessitatem euadendam: licita enim est eiusmodi acceptio, vt in materia de [[6]] eleēmosyna dictum est. Quousque autem id obnoxium postea sit restitutioni, aut non, ibidem explanatum est.

Per particulam, boni externi, excluditur à ratione furti acceptio iniusta vxoris alienæ ad ea aburendum, & acceptio, tam illius, quàm filiorum alienorum, ad alibi eos vendendum, aut redigendum in seruitutem: neque enim hæc sunt furta, vt dictum est. Acceptio verò iniusta mancipii alieni, vt alteri seruiat, verum est furtum.

Per particulam, absque vi, excluditur rapina à furto pressè, de quo loquimur. Commodiùs verò ea particula apponitur in ea definitione, quam particula, occulta: quoniam furtum esse potest non occultè, si fiat à longè, vidente domino, ita tamē vt illud impedire non possit, nullaque vi, & absq; animo eam inferendi. Aut si fiat, vidente ac tacēte domino, vt confulat honori furis, ac famæ, aut alia de causa, absque vlla vi domino illata. Denique per particulam, & absque vllo consensu eius, cuius est, rejiciuntur à ratione furti acceptiones iniustæ vsurariæ, & aliæ ex contractu iniusto, quæ furta non sunt, de quibus loquimur, vt disputatione præcedente dictum est.

Quòd si, consentiente omnino eo, cuius id est, saltem tacitè, aut meritò præsumptè, acceptio fieret, tunc non esset iniusta: quoniam volenti ac consentienti omnino, sine inuoluntario mixtè, nulla fit iniuria, ac proinde talis acceptio longè diuersa esset à furto. Meliùs autem in eadem particula dicitur, eius cuius est, quàm domini: quoniam furtum non solùm committitur aduersus dominum rei, sed etiam aduersus solum possessorem, aut legitimum

tantum illius detentorem: hi autem domini non sunt illius; est tamen res eorum quoad eam possessionem, aut legitimam tentionem.

De vi publica & priuata, quas iura appellant. Disp. 682.

SVMMARIVM.

1. *RApina sola vi à furto differt.*
2. *Vis latius patet, quam violentia, & quid utrumque sit.*
3. *Vis publica & priuata quid, & in quo differant. Et quot modis vis publica fiat.*
4. *Vim in aliquibus euentibus in Lusitania inferens, quibus pænis afficiatur.*
5. *Furtum faciens de domo, quæ incendium patitur, in crimen ac pænam incidit de vi publica, nisi furetur ligna.*
6. *Iudex, qui appellantem percutit, comprehendit, aut inhonorat, esto sine armis id efficiat, crimen ac pænam vis publicæ incurrit.*
7. *Vis publicæ crimen incurrit, qui curam habens recipiendi redditus regios, per se vel per alium, plus aut noua tributa exigit, esto sine armis id efficiat.*
8. *Vis publicæ crimen incurrit, qui terrendo testes, aut iudicem, vel aliter perturbando nimis iudicium, sententiam obtinet, esto sine armis id efficiat.*
9. *Vis publicæ crimen ac pænam incurrit, qui per vim coierit cum puero, aut femina, esto sine armis id efficiat.*
10. *Vis publicæ crimen incurrit, & in quas pænas incidat, qui feminam rapuerit, esto sine armis id efficiat.*
11. *Vis publicæ crimen incurrens resarcire tenetur omnia damna data, & quas pænas incurrat.*
12. *Pæna inter dictionis aquæ & ignis aboleuit, & eius loco succedit deportatio.*
13. *Pæna deportationis annexam habebat de iure communi pænam confiscationis omnium bonorum, nisi deportatus haberet descendentes, aut ascendentes, vel etiam collaterales vsque ad tertium gradum. Hodie, ut deportatio non est in usu, ita neque confiscatio bonorum in consequentiam deportationis. Et pænæ criminis de vi publica, regulariter est hodie arbitraria.*
14. *Vim priuatam inferens resarcire tenetur omnia damna, & quas pænas incurrat. Et regulariter hodie punitur pæna arbitraria.*
15. *Vim publicam aut priuatam, si mancipium inferat, quibus pænis subiaceat, tam ipse, quam dominus eius, si dominus sciens, aut ratum postea habens, mancipium vim intulit.*
16. *Vi autoritate propria occupans possessionem rei, in quo alius erat, illam restituit cum fructibus & damnis, & quas pænas insuper incurrat.*
17. *Aduersus vi ita occupantem possessionem, licet simul possit agi de vi publica aut priuata, & ad rem fructus, atque ad damna sequuta, non tamen ad alias pænas legis si quis in tantam: sed vna actio pænalis aliam impedit.*

18 . Vi ita ejiciens à possessione, etiam si miles, rusticus, vel prodigus sit, in eas pœnas incurrit. Secus carens usu rationis. Impubes eas non incurrit: minor verò pubes eas incurrit, sed ex quacūq; causa restituitur. Neque parens intrans res filii, neque patronus intrans res liberti, eas incurrit. Tutor verò, aut curator, occupantes ita possessionem nomine minorum, eas pœnas incurrunt, soluendos de suo, nec restituntur.

19 . Possessione, aut officio, nullus publica autoritate, etiam rescripto principis, ejicitur, nisi prius audiatur. Eiectus verò restituitur.

20 . Vi si commodans rem commodatam accipiat à commodatario, locans à conductore, aut deponens à depositario, non incidunt in pœnam legis si quis in tantam, sed puniuntur pœna arbitraria, & coguntur reddere rem, & resarcire damna, si finitus non erat contractus.

21 . Vi si miſſus in possessionem ex primo decreto, dejiciatur ex ea, dejiciens non incidit in pœnam si quis in tantam, sed punitur pœna arbitraria, & cogitur reddere rem cum fructibus ac resarcire damna. Idem de ventre misso in possessionem.

22 . Commodatarius, conductor, & depositarius, qui finito contractu rem petitam non restitunt, sed expectant definitivam sententiam, in pœnam incidunt instar legis si quis in tantam.

23 . Debitor si vi eripiat pignus de manu creditoris, dominium illius amittit in pœnam creditori, instar pœnæ legis si quis in tantam.

24 . Visi creditor aliquid usurpet à debitore, tanquam sibi debitum, aut in securitatem vel [[7]] recompensationem sui debiti, quas pœnas iuxta legem si quis in tantam incurrat, & quantum in hoc regno extendantur. Potest etiam agere criminaliter de vi publica aut priuata, sed locum tunc non habebit actio ad pœnam ex lege, si quis in tantam.

25 . Repræsalia propter damna illata ex alia re publica, quousque locum habeant autoritate rei publicæ, quæ damnum est passa.

26 . Comprehendens alium pro debito autoritate propria, quas pœnas incurrat.

27 . Vi si proprietarius, aut alius tertius, ejiciat usufructuarium, emphyteutam, aut vassallum, à re usufructuaria, aut feudali, in quas pœnas incurrat.

28 . Vi expellens aliquem à iurisdictione, quas pœnas incurrat.

29 . Vi si administratores ecclesiæ aliquid usurpent nomine ecclesiæ, ecclesia in nullam prædictarum pœnarum incidit, sed administratores ipsi de suo illas soluere tenentur, etiam de redditibus ad ipsos attinentibus, alioqui luunt in corpore.

30 . Vi si communitas secularis aliquid usurpet nomine ciuitatis, aut alterius communitatis, vel mandet id fieri, vel ratum illud habeat, in pœnas incidit ipsa communitas de bonis communitatis soluendas. Secus si vnus illorum autoritate propria, communitatis nomine id vi usurpet.

31 . Siquis in iudicio conqueratur se ejectum ex aliqua re, cognosci ante omnia de vi debet, eaque comperta, restituendus ante omnia est in possessionem, esto ejiciens, aut quidam tertius, in continenti probare velint, rem ad se pertinere.

Anteqvam ad varias furti species [sect. 1] descendamus, & ad pœnas pro illis statutas, dicendum est de rapina: quæ, vt ex duabus præcedentibus disputationibus liquet, à furto

pressè sumpto in eo differt; quòd in furto vis non interueniat, interueniat verò in rapina. Vnde cùm, interuenire vim, culpam ac delictum agrauet, sanè rapina, cæteris paribus, grauius delictum est, quàm furtum, eaque, quæ de furto sunt dicenda, ferè omnia in rapina locum habent: eo quòd, interueniente vi, quod alioquin furtum pressè erat futurum, transeat in rapinam, ac proinde locum in rapina habeant, tum furti omnes ferè species, tum etiam pœnæ pro illis statutæ, nisi quatenus, ratione vis, aliquid in iure auctum, aut variatum, circa rapinam fuerit repertum. Priùs verò, in maiorem lucè, dicendum hac Disputatione erit de vi publica & priuata, quas iura appellant.

Illud verò est obseruandum, cum Greg. Lope Z. [sect. 2] l. 1. tit. 10. part. 7. verbo, *fecha à otro*, & verb. *comete*. consentancè ad Bart. & ad Paulum Castrensem, quos citat, & consentit Ant. Gom. 3. tom. var. res. cap. 4. in princ. Violentiam pressè sumptam, quam iuris periti appellant, tum absolutam, tum etiam præcisam, requirere impetum in eum factum, qui violentiam patitur: vim verò etiam sine impetu inferri: vnde latius patet vis, quàm violentia, pressè sumpta: quotiescumque enim aliquid violenter fit, fit vi: non tamen quicquid fit vi, fit violenter. Si enim aliquis efficiat aliquid, inductus ad id metu incusso, cadente in constantem virum, neque tamen ipse contingatur, impetúsve in eum non fiat, quo id facere efficiatur, aut quo aliquid ab eo eripiat, dicitur pati vim, víve id effecisse, concinitque l. 1. *iunctis sequentib.* ff. de eo quod met. causa, non tamen dicitur passus violentiam pressè, sed latè, pro vt violentia comprehendit etiam eam, quam iurisperiti conditionatam vocant, qua quis metu cogitur facere aliquid, aut consentire in aliquo, in quo, secluso metu, non consentiret, quæ proinde conditionalis dicitur, causatque inuoluntarium mixtè. De vtraque violentia diximus. l. 2. q. 6. art. 5. & 6. iuxta c. maiores causæ, §. vlt. de baptis. & eius effectus, & iuxta alia iura, cum D. Th. in 4. & cum communi doctorum sententia.

Quando itaque aliquis, impetu in eum facto, aliquid eo impetu efficere cogitur, aut ab eo eripitur, dicitur propriè pressè pati violentiam; siue, qui eam violentiam infert, præualeat, siue nō. Effectus autem, qui ex violentia sequitur, dicitur actus seu effectus violentus: qui verò sequitur ex sola vi sine violentia, dicitur actus vi effectus, non tamen violentus propriè & pressè: vterque tamen dicitur proprie vi factus.

Hoc ita constituto, si vis latè sumpta, vt sub se [sect. 3] violentiam comprehendit, alicui iustè inferatur, tunc, si armis inferatur, dicitur vis publica, vt habetur. l. 1. & sequentibus. ff. ad leg. Iuliam de vi publ. §. item lex Iulia inst. de publ. iud. & l. 1. titu. 10. part. 7. Siverò inferatur sine armis, dicitur vis priuata. l. si quis aliquem, & per totum ff. ad legem Iuliam de vi priuata. §. item lex Iulia. inst. de publ. iud. & l. 1. citata. Nomine autem, armorum, in re proposita, intelligitur, quicquid nocere ferirève possit, siue sit ensis, telum, fustis, lapis, siue quoduis aliud. Ita habetur. l. 1. & sequentib. l. armatos. l. penult. §. telorum. ff. ad leg. Iuliam, de vi publi. & l. 1. titu. 10. part. 7. Qui ita armatus aliquem in castro, aut domo, includit, aut oppugnat, vel comprehendit, aut efficit ad aliquid se obligare, & longè maiori cum ratione, si efficiat eum aliquid elargiri, censetur vim publicam ei intulisse. lib. 1. titu. 10. part. 7. iuxta. l. qui cetu. & l. qui dolo. §. 1. ff. ad leg. Iul. de vi public. Idem statuere videtur l. 1. citata de eo, qui cum hominibus armatis aggreditur exurere, aut diripere, domos, in quibus aliqui habitant, aut in quibus aliquid asseruatur, vel nauem, esto opere id non compleat, & longè magis, si id opere compleat, consentaneè ad leg. 3. & ad l. hi qui ædes. ff. ad leg. Iul. de vi publica, eam legas, & Gregorium Lopez leg. 1. citata, idemque affirmat Anton. Gom. vbi suprà.

Qui cetum hominum armatorum congregauerit (Castellanè *assonada*, Lusitanè verò *assuada*, nuncupatur) ad vim aliquam faciendam, esto neque illam efficiat, neque eam efficere attentet, incidit in pœnam legis Iuliæ de vi publica sola cōgregatione ipsa hominum ad id facinus. *Ita habetur. l. 3. & l. qui cetu. ff. ad leg. Iul. de vi publ. iuncta. l. ult. C. eod. titu. & l. 2. titu. 10. part. 7.* Vbi cum Baldo Greg. Lopez ad eiusmodi cetum necessarios esse affirmat cū minimum decem homines, si pedites sint; aut quatuor, si sint equites. Quo loco obserua, *legem 1. & sequentes. ff. ad leg. Iul. de vi publ.* vt aliquis incidat in crimen de vi publica, & in pœnam pro eo crimine statutam, videri asserere satis esse, si arma congreget, de quibus præ-[[8]]sumptio sit, ad aliquid tale congregari. Non tamen tantus rigor videtur esse vsu receptus. Illud etiam obserua, cū vnique licitum sit se defendere, vim vi repellendo, vtique, qui homines armatos congregat, vt se defendat à vi ac damno, quod ipsi paratur, & qui ea de causa cum ipso cōgregantur, non incidere in crimen legis Iuliæ de vi publica, vt est satis perspicuum, & *habetur. l. 7. titu. 10. part. 7.* consentiunt lex quoniam multa. *C. ad leg. Iul. de vi publ. & alia iura, quæ Greg. Lopez ibi citat, tradiditque Azo. à Greg. Lopez ibidem relatus.* Lege etiam circa eiusmodi congregationes hominum armatorum, vt priuati inuicē pugnent, & damna inferant, *Legem. 16. & 17. titu. 26. part. 2.* & pœnas, quæ statuuntur. *l. 1. & sequentibus, titu. 15. lib. 8. nouæ collect.* Inter alia autem, qui ex eiusmodi cetibus aliquid occupauerit, iubetur illud duplum restituere ei, à quo ablatum est, & insuper quadruplum fisco Regis.

Lib. 5. Lusitanar. ord. titu. 15. qui congregatis ali [sect. 4] quibus vltra suos domesticos, ingreditur domum³ alienam, vt domino domus, aut alicui alteri, qui in ea sit, nocumentum inferat, aut eum percutiat, afficitur pœna mortis. Intellico tamen, si percusserit, vt ex iis, quæ mox ibi subiunguntur, cōstat. Quòd si non percusserit, si, qui ita cum hominibus armatis domum alienam intrauerit, fuerit plebeius, flagellatur publicè *com baraço è preguam*, & exulat decem annis in insulam diui Thomæ. Si verò fuerit homo maioris notæ, exulat decem annis ad loca Africæ *com preguam na audiencia*. Qui modo prædicto congregauerit homines ad nocumentum alicui inferendum, esto neque domum alienam cum eis intret, neque alicui noceat, si sit *fidalgo*, mittitur in carcerem, & exulat quatuor annis in locis Africæ, ac soluit centum aureos, dimidium accusanti, & dimidium fisco Regis. Si verò sit *escudeiro ou caualeiro*, mittitur similiter in carcerem, & exulat tribus annis in locis Africæ, ac soluit quinquaginta aureos eodem modo diuidendos. Quòd si plebeius sit, flagellatur publicè *com baraço è preguam*, ac soluit viginti quinque aureos similiter diuidendos. Si autem eos non habeat, exulat duobus annis in locis Africæ. In pœnas omnes explicatas incidunt singuli, qui ad id conuenerint, hoc solū excepto, quòd in primo euentu, in quo dictum est, eum, qui congregat ita homines, & ingreditur domū alienam, ac percutit, puniri pœna mortis naturalis, qui illum comitati sunt, solū puniuntur morte ciuili. Si homines modo prædicto congregentur ad damnum alicui inferendum, esto non exeant, ad id efficiendum, incurruntur solæ pœnæ pecuniariæ explicatæ, non verò cæteræ pœnæ: Iudex verò loci, in quo quoduis horum acciderit, præcipitur facere inquisitionem circa quoduis horum delictorum ex suo officio, esto à nemine ad id requiratur, & procedere ad punitionem delinquentium. Item, qui vi domum aliquam ingreditur confringendo fores, aut ex cardine illas extrahendo, ad percutiendum, aut occidendum, aliquem, aut ad rapiendum, vel furandum, vel ad opprimendam feminam, aut ad illam inde extrahendam, vel ad iniuriam aliam inferendam alicui, qui intra eam domum sit, esto intentum opere non compleat, exulat in perpetuum

in insulam diui Thomæ, & insuper soluit iniuriam ei, cui illā intulerit, atque etiam damna, si quæ intulit,

Propter criminis inhumanitatem sancitum [sect. 5] est, vt qui de domo, quæ incendium patitur, aliquid furatur, esto sine armis id efficiat, modò, quod furatur, non sint ligna, quæ fomentum incendio præstare possunt, incidat in crimen vis publicæ, atque in pœnam pro eo crimine statutam. *Ita habetur. l. 3. §. item tenetur. ff. ad leg. Iul. de vi publ. & l. 3. titu. 10. part. 7.* In illo autem §. item tenetur, solùm subijcitur huic crimini, ac pœnæ, qui ex incendio rapuerit: rapere autem, amouere cum vi importat, atque adeò veram rapinam, *vt habetur, l. 3. vers. non solùm. ff. de incendio.* Tametsi interdum latiùs etiam sumatur, vt est idem, quòd furari, siue cum vi, siue sine vi. Lex verò. 3. titul. 10. part. 7. etiam eum huic crimini ac pœnæ subijcit, qui clàm aliquid de incendio tulerit, nisi sint ligna. Quando autem aliquis auferret aliquid de incendio, vt illud asseruaret domino, tunc non incurreret hoc crimen ac pœnam, *vt habetur. l. 3. titul. 10. part. 7. & concinit. lib. 3. §. non tantùm. ff. de incend.* In idem crimen ac pœnam incidit, qui cum armis de incendio rapit, aut prohibet dominum res suas de incendio eripere. *Ita habetur lib. 3. versic. sed & quiff. ad leg. Iul. de vi public. Lex verò. 3. titul. 10. part. 7.* sic habet: *Otro tal hierro decimos que faria. el que se parase con armas, y defendiese à los que viniesen à matar el fuego, que lo no matasen, o que no aiudasen à sacar las cosas del Señor de la casa que ardiesen, diciendo maliciosamente, que las dexasen arder.* Vbi vides, multum explicare, quomodo paragrapho, *sed & qui*, intelligatur, prohibere dominum res suas de incendio eripere: intelligitur enim etiam prohibendo alios, ne adiumento sint, vt eripiantur.

Iudex, qui appellantem ad superius tribunal, [sect. 6] ea de causa percuteret, comprehenderet, aut necaret, vel in honoraret, incurreret crimen de vi publica, & pœnam ob illud statutam, perinde ac si armis vim intulisset. *Ita habet. lib. 4. titul. 10. part. 7, consentaneè ad lib. lege Iulia. 1. & 2. ff. ad leg. Iul. de vi public.* Greg. tamen Lopez ibidem arbitratur, non satis esse inhonorare verbo ea de causa ita appellantem, sed necesse esse facto illum inhonorare. Id autem verum videtur stando in iure communi: lex tamen illa apertè contrarium videtur statuere.

Qui curam habent recipiendi redditus re [sect. 7] gios, si per se, vel per alium, plus exigant & accipiant, quàm sit debitum, vel ipsi, aut alii, noua tributa exigant, incidunt in crimen ac pœnam legis Iuliæ de vi publica, etiamsi armis ad id non cogant. *lib. vlt. ff. ad leg. Iul. de vi publ. & lib. 5. titul. 10. part. 7.* Vide etiam legem penult. & vltim. titul. 7. part. 5. vbi etiam pœna dupli puniuntur, si exigatur à parte læsa intra annum.

Qui terrendo est in causa, vt iudices non iu [sect. 8] stè iudicent, vel vt iudicium non rectè procedat, terrendo testes, ne verum dicant, aut aliter iudicium minis perturbando, & ita obtinent sententiam aduersus aliquem, incidunt in crimen de vi publica, & in pœnam illius, perinde ac si, quod ita obtinent, armis vi eriperent. *Ita habetur. l. qui dolo, in princ. & §. item qui cum telo. ff. ad leg. Iul. de vi public. & lib. 6. titul. 10. part. 7.* Lex verò. 6. exigit, vt cum armis accedant, & minentur iudici, aut testibus, vel aliis, à quibus iudicium pendet, & idem exigere videtur. §. qui cum telo.

Item qui puerum, vel feminam, vel quem [sect. 9] cumque per vim stuprauerit, esto sine armis id efficiat, incidit in hoc crimen, & in pœnam illi [[9]] statutam. *Ita habetur. l. 3. §. præterea. ff. ad leg. Iul. de vi pub.* Vbi stuprare latè videtur sumi, pro coicu cum virgine, vidua, coniugata, aut cum puero, vel cum quocunque alio, iuxta legem inter stuprum. ff. de verb.

signif. vt satis innuunt verba. §. præterea citati: modò enim per vim is coitus fiat, inciditur in hoc crimen, & concinit. *l. mariti. §. vlt. ff. ad leg. Iul. de adult.*

Qui rapuerit vacantem (glossa exponit, viduā: [sect. 10] sed meliùs dic, non nuptam, siue vidua sit, siue virgo, siue quæuis alia) vel nuptam, incidit in crimen de vi publica, esto sine armis id efficiat, & capite plectitur. Si autem pater non accuset, accusare potest quicumque alius, etiam elapso quinquennio. *Ita habetur. l. qui cetu. §. vlt. ff. ad leg. Iul. de vi publ.* Eadem pœna statuitur. §. *itē lex Iulia de vi publica, vers. sin autem, inst. de publ. iud.* vbi sermo est de quacunque muliere, siue vidua, siue virgo, siue coniugata, aut quæuis alia: pœnaque extenditur etiam ad opem ferentes ad id flagitium, dum committitur. Idem fusiùs habetur. *l. 1. C. de raptu virg.* Et hoc crimen in hoc Regno, si fiat *en yermos y despoblados, o en qual quiera lugares poblados*. Si raptores cum eiusmodi feminis egressi fuerint in agrum, pertinet cognitio ad iudices, *de la hermandad. l. 2. tit. 13. libr. 8. nouæ collect.*

Qui vim publicam infert, siue cum armis, [sect. 11] sine sine illis, in euentibus explicatis, præterquam quòd resarcire tenetur omnia damna inde subsequuta, etiam fructuum, qui percipi poterant, & non fuerunt ea de causa percepti, *vt habetur. l. 1. §. ex die. ff. vnde vi. l. si de possessione. C. eod. tit. c. grauis de rest. spoliat. l. 10. tit. 10. part. 7. & aliis iuribus*, si mancipium non sit, incidit in pœnam perpetuæ deportationis, vt habetur. §. *item lex Iulia de vi public. inst. de public. iud.* Licet enim [sect. 12] *l. qui dolo. §. vlt. ff. ad leg. Iul. de vi publ.* pœna interdictionis aquæ & ignis pro hoc crimine imponatur, loco tamen illius successit postea deportatio, vt glossa ibi affirmat, & habetur *l. 3. ff. ad leg. ful. peculatus*. vnde interdictio aqua & igni locum iam non habet. Is autem, qui depor [sect. 13] tabatur, eo ipso omnia bona sua amittebat fisco, *vt habetur. l. 3. citata. ff. ad leg. Iul. pecul. l. eius qui. §. si cui. ff. de test. & aliis iuribus*. Postea verò de iure authenticorum sancitum fuit, vt si is ascendentes, vel descendentes, haberet vsque tertium gradum, proximiores in gradu ea bona obtinerent, nec confiscarentur. Ita habetur in authentico, vt nulli iudicum. §. vlt. & in authentica bona damnatorum. C. de bonis præscriptorum: in qua id extenditur ad collaterales vsque ad tertium gradum ita damnati. Hinc iam intelliges *l. 8. titu. 10. part. 7.* quæ, consentaneè ad ius commune, incidenti in crimen de vi publica in euentibus explicatis, si mancipium non sit, imponit pœnam deportationis, & confiscationis omnium bonorum, si descendentes, & ascendentes, vsque ad tertium gradum non habeat. Conditores enim eius legis, cum aliquibus, quos ibi Grego. Lopez refert, eam literam authenticorum sequuti sunt, quæ non meminit collateralium vsque ad tertium gradum. Greg. verò Lopez ad eandem legem. 8. ait, hodie pœnam deportationis non esse in vsu, & consequenter locum etiam non habere confiscationem omnium bonorum, quæ de iure communi in consequentiam deportationis habebat locum: eaq; de causa pœnam pro vi publica esse hodie arbitrariam. *Et Iul. clarus l. 5. sent. q. 83. n. 4. ait*, cōmittens vim publicam, seu priuatam, hodie ex generali consuetudine punitur arbitrio iudicis, citatque autores, qui id affirmant. Esse tamen prædictas pœnas statutas de iure communi, multum iudicem adiuuabit, vt videat quam pœnam arbitrari atque imponere debeat. Quando armati homines congregantur ad vim inferendam, non solùm, qui illos congregauit, incidit in prædictas pœnas, sed etiam singuli, qui ad id scienter congregati sunt. *Ita habetur. l. 8. citata, consentaneè ad. l. 3. §. vlt. & ad l. 4. ff. ad leg. Iul. de vi pub. & ad §. item lex Iulia de vi pub. inst. de publ. iud.* Quòd si, quam do quis cum hominibus armatis vim infert, aliquis interficiatur, vel ex parte aggressi, vel etiam ex parte aggressoris, tunc quia aggressor, qui eos homines congregauit, in culpa fuit eius homicidii, is punitur pœna mortis. *Ita habetur. l. quoniam multa. C. ad leg. Iul. de vi. pub. & l. 8. citata.*

Qui vim priuatam aduersus aliquem commit [sect. 14] tit (excipe euentus, de quibus infrà erit sermo, in quibus aliæ pænæ statuuntur, siue ea vis cum armis siuesine armis fiat) præterquam, quòd tenetur ad damna inde subsequuta, eo modo, quo circa vim publicam dictum cōprobatumque est, punitur amissione tertiæ partis suorum bonorum, *vt habetur, l. 1. ff. ad leg. Iul. de vi priuata. §. item lex Iulia de vi publica inst. de pub. iud. & l. 8. tit. 10. part. 7.* Item relegatur ad tempus iudicis arbitrio, vt habetur eadē. *l. 8. & affirmant glossa. l. Quoniam multa verb. relegatione. C. de vi pub. & Azo. Non tamē video ius commune, quod id sufficiēter probet: nā l. 2. ff. de termino moto, quam Greg. Lopez. l. 8. citat. solūm loquitur de crimine terminimoti. Item, qui vim priuatam infert, (& lōgè magis, qui infert vim publicam) punitur pæna infamis, ad effectū vt amittat officium publicum, si quod habeat, & publicum officium non possit deinceps obtinere, nisi prius à principe in pristinum statum restituatur. Ita habetur *l. 1. & ult. ff. ad l. Iul. de vi priuata. l. seruos C. ad leg. Iul. de vi pub. & l. 8. citata.* Vt tamen suprà dictum est, Iulius Clarus, cum aliis, ait, hodie, etiam vim priuatam, puniri pæna arbitraria.*

Quando mancipium vim infert, distinguen [sect. 15] dum est. Quoniam, si inscio, aut domino prohibere non valente, vim efficiat, punitur mancipiū pæna mortis. Si verò domino iubente (intellige, aut etiam ratum id postea habente) vim intulit, mancipiū solum damnatur in perpetuum ad metella, & dominus manet infamis modo paulo antè explicato. Quòd si dominus vilis persona sit, aut nobilis, qui bis, aut pluries, vim intulerit per se, aut per seruum, punitur ac si ipse vim intulisset. Quod ita intellige, si mancipium vim publicam intulerit, puniatur dominus ac si eam vim publicam ipse intulisset, vltra pænam mācipii admetalla, quæ in dominū, qui mancipium eo ipso amittit, redundat. Si verò mācipiū vim priuatam intulerit; punitur dominus ac si illam ipse intulisset. Ita habetur *l. seruos C. ad leg. Iul. de vi pub. & l. 8. citata.* Non nulla tamē obserua. Primum est, legem octauam citatam solūm loqui, conditoresque illius intellexisse legē seruos citatam, iuxta quam ea lex octaua lata fuit, quando mancipium vim publicam infert; non verò quando infert vim priuatam. Cū tamen quidam legem seruos intelligant, quando mancipium infert solūm vim priuatam: alii verò rectiūs, quando mancipium infert, siue vim publicam, siue priuatam: de vtraque enim vi est sermo [[10]] in illo titulo Codicis. Vtraque autem lex solūm irrogat domino, si vi lis non sit, etsi antea simile delictum non fecit, pænam infamiæ, quando ipse mancipio delictum mandauit, quoniam simul etiam eum punit amissione mancipii ad metalla: alioquin enim mandans pænam ordinariam, pro delicto statutam, subire debet. Secundum est, si mancipium, vim inferendo de mandato domini, quenquam interficiat, præsertim si limites mandati non excessit, tunc non solūm mancipium esse occidendum; sed etiam dominum esse puniendum tanquam occisorem: iura enim citata solūm sunt intelligenda, quādo in vi illata non interuenit homicidium. Tertiū est, si vi illa, facta à mancipio de mandato domini, damnum aliud inferatur, dominum teneri insuper ad integrum damnum compensandum. Quartum est, legem seruos, quando de vilibus personis, aut quæ aliās simile aliud flagitium cōmiserant, loquitur, non perspicuè loqui, quādo suo mancipio vim inferre præceperunt: legem verò 8. citatam, cum glossa eadem *l. seruos*, verb. infames, ita illam intellexisse, & de eis dominus fuisse loquutam, solumque eis addidisse in pænam, vt exularent, ac si ipsi id flagitium per se ipsos commisissent. Lex tamen seruos totam pænam meritò eos tunc subire præcipit, impositam inferentibus per se ipsos eam vim. Quintum est, legem seruos, iudici, qui id crimen probatum, distulerit eis pænis punire, aut qui absoluerit talem reum, vel pæna mitiori eum puniuerit, imponere pænam infamiæ in sensu suprà explicato. Sextum verò est,

peculiare in ea lege esse, vt mancipium mitiùs puniatur, quādo de mandato alterius flagitium facit, & quando sine mandato id exequitur: id quod glossa ibi obseruat.

Quando quis vi, propria auctoritate, occupat rem, in cuius possessione est alius, siue illa im [sect. 16] mobilis sit, siue mobilis, restituere eam cogitur cum fructibus, & damnis omnibus subsequutis, & insuper incidit in pœnam, vt, si erat vi illam occupantis, amittat eam ei, à quo illam occupauit: si autem non erat vi illam occupantis, cogitur insuper restituere æstimationē illius ei, à quo eam occupauit, etiam si hic iniustè eam possideret. *Ita habetur l. si quis in tantam C. vnde vi l. 10. tit. 10. part. 7. l. 1. tit. 13. lib. 4. nouæ collect. & allis iuribus*, quæ Disput. 16. dum sermo nobis esset de interdicto vnde vi, citauimus: quo in loco adiecimus aduersus multos, rem ita vi occupantem, non teneri ad hanc pœnamante latam sententiam: quoniam pœna non debetur ante latam sententiam, esto ipso iure esset statuta. Lege, quæ ibi copiosè dicta sunt: ea enim de causa non plura hoc loco hac de re dicimus.

Dubitabis, num aduersus ita vi ejicientem alterum de possessione agi possit ad pœnam legis Iuliæ de vi publica, si cum armis eum deiecit, vel de vi priuata, si sine armis eum deiecit. Lex si de possessione, iūcta glossa ibi. C. vnde vi, perspieuè docet, ita vi eiectum, non solū posse agere interdicto vnde vi ad recuperandam rem cum fructibus, & cum damnis subsequutis, sed etiam agere posse ad pœnam legis Iuliæ de vi priuata aut publica. Atque id est indubitatum, & habetur expressè ea lege, & l. vnica. C. quando ciuilis actio criminali præiudicet: quoniam vna actio solū est merè ciuilis ad rē, & ad fructus ex illa atque ad damna subsequuta, nihil miscens de pœna, & altera est ad pœnam; quæ duæ actiones non se impediunt, sed habita condemnatione ex vna actione, potest intentari alia, vt habetur l. vnica citata, & nos dicimus Disput. 695. Cæterū dicendum est, non posse agere simul ad pœnam legis si quis in tantam, & ad pœnā legis de vi publica, aut de vi priuata: sed solū posse agere ad pœnam, quam maluerit, vel legis si quis in tantam, vel legis Iuliæ de vi publica, aut de vi priuata: quoniam distinctæ actiones ad pœnas diuersas ex legibus diuersis pro eodem delicto se mutuò impediunt, intentataque vna non relinquitur locus alteri; vt copiosè ostendemus Disp. 695. citata.

Incidit verò in pœnam legis si quis in tantam, [sect. 18] etiam miles, aut rusticus, qui vi rem ab alio possessam occupat, vt Greg. Lopez cum glossa vlt. l. si quis in tantam, ait, atque etiam prodigus, vt idem Greg. Lopez ibidem contra eam glossam affirmat. Quoniam id est delictum, de quo nullus horum prætereundum potest ignorantiam: cū ad id iudices sint constituti, vt unicuique ius dicant, nullusque exequatur aduersus alterum, qui est in possessione alicuius rei, quod iustum ipse iudicauerit, aut quod sibi placuerit. Minor, si impubes sit, etiam si pubertati sit proximus, non incidit in hanc pœnam, vt affirmat lex. 10. citata, & cum ea Greg. Lopez aduersus glossam. l. si quis in tantam, quæ asseruit proximum pubertati in eam pœnam incidere. Minor verò, qui pubes sit, licet in eam incidat, restituitur tamen in integrum aduersus eam pœnam, ex quacunque causa, etiam leui, putauerit id sibi licere, vt Greg. Lopez, cum glos. c. 1. verb. rigot de dolo & contum. Bart. & aliis, quos citat, asseuerat. Qui carens iudicio rationis rem alienam vi occuparet, non incideret in hanc pœnam, vt est notissimum: neque pater si ita intraret possessionem rei filii: neque patronus, si intraret possessionem eius, quem ipse libertati donasset: sed solū hi omnes tenerentur restituere rem cum fructibus, quin & damna subsequuta, si priuati iudicio rationis ea non intulerint. *Ita habetur l. 10 citata, eonsentaneè ad glossam, l. si quis in tantam*. Si tamen tutor, aut curator, minoris, prodigi, aut carentis vsu rationis, dejiceret vi alterū de possessione nomine eius, cuius haberet curam, tunc talis tutor, aut curator, in eam pœnam incideret,

nec restitueretur in integrum: soluere tamen de suis propriis bonis teneretur eam pœnam: *Ita habetur. l. 10. citata, consentaneè ad. l. meminere. §. ult. C. unde vi, & ad alia iurâ. Lege [sect. 19] 2. & 7. tit. 13. lib. 4. nouæ collect. præcipitur, vt nullus, nisi prius audiatur, publica autoritate, etiam rescripto Regis, ejiciatur à possessione, vel officio, & vt, si eiectus sit, restituatur in pristinam possessionem. ¶ Quia neque commodatarius pos [sect. 20] sidet rem commodatam, sed is, qui eam commodauit; neque conductor, sed is, qui eam locauit; neque depositarius, quando rei depositæ dominium in eum non est translatum, sed possidet, qui rem deposuit, vt Disp. 21. §. secundum, Disp. 13. §. sextus, Disput. 194. & alibi dictum est; inde efficitur, quòd si is, qui commodauit, aut alius de mandato illius, vi auferat rem à commodatario, locator à conductore, aut deponens à depositario, non incidant in pœnam legis si quis [[11]] in tantam, sed commodatario, aut conductori, restitui debeat res ita ablata, quousque tempus illorum contractuum finiatur, atque restitui etiã eis debeant damna ex talis rei ante id tempus ablatione eis subsequuta, iuxta l. 1. §. ex die, & §. ex interdicto. ff. de vi & vi armata, & insuper ex suo officio arbitrio iudicis puniri is possit, qui ita rē vi abstulit, pro delicti quantitate. Ita habetur. l. [sect. 21] 11. titu. 10. part. 7 cum glossa. l. si quis in tantam citata. ¶ Eadem ratione, quia is, qui ex primo decreto iudicis in possessionem missus est propter contumaciam rei possidentis, non comparat veram possessionem eius rei, sed solam tenentiam: neque item venter in possessionem missus, hoc est, vxor manens prægnans per mortem mariti, missa in possessionem, vt bona mariti teneat loco prolis, quæ in ventre ipsius latet, comparat veram possessionem eorum bonorum, sed solam tenentiam, vt vtrumque habetur. l. 3. §. ult. ff. de acquir. posseß. & l. 11. citata, atque. l. si finita §. Iulianus. ff. de damno infecto; inde etiam efficitur, quòd, si ea bona vi eripiantur ex illis, dejicianturque ex ea tenentia, eripiens non incidat in pœnam legis si quis in tantam, sed solùm restitui eiecti debeant in tenentiam eorum bonorum, restituique eis debeant fructus, & damna inde subsequuta, & vt insuper puniri dejiciens possit ex officio iudicis pœna arbitraria, prout iudex dignum fuerit arbitratus. Ita, iuxta glossam. l. si quis in tantam, habetur. l. 11. cita.*

Qui commodatarius rem commodatam peti [sect. 22] tam à commodante, finito tempore contractus, ei non restituit, sed expectat vsque ad definitiuā sententiam; qui item conductor rem conductā petitam à locatore, finito iam tempore contract⁹, ei non restituit, sed expectat definitiuam sententiam; & idem est de depositario, & de quocunque alio, qui non possidet, sed rem tenet nomine alterius, neque illam, finito contractu, ei petenti restituit, sed expectat vsque ad definitiuam sententiam, punitur instar pœnæ legis si quis in tantam, vt, vltra illam, & fructus, restituat æstimationem illius. Ita habetur. l. non abs re. C. unde vi. l. 12. titu. 10. part. 7. & copiosè dictum est, tum alibi, tum præcipuè Disp. 498.

Cùm, quando creditori traditum est pignus [sect. 23] in securitatem debiti, creditor verè comparet possessionem illius quoad aliquos effectus, licèt quoad alios possessio maneat penes debitorem, qui ciuilitè per seipsum possidet, & naturaliter per creditorem, vt vtrumque explicat glossa l. sciendum. §. creditor. ff. qui satisd. cog. dictumque atque ostensum à nobis est Disput. 534. inde efficitur, quòd si debitor vi eripiat pignus à creditore, eumque ab ea possessione vi ejiciat, debitor, in pœnam eius criminis, amittat dominium eius pignoris, iusque totum, quod ad illud habebat, creditori, argumento l. si quis in tantam. C. unde vi, vt ibi affirmant glossa, Bart. & alii, & sancitum est l. 13. titu. 10. part. 7.

Quando creditor vi aliquid autoritate pro [sect. 24] pria extrahit à debitore, distinguendum est. Quoniam, si illud extrahit tanquam sibi in particulari debitum, vt quia illud emerat à debitore, aut alia simili ratione, tunc in pœnam amittit illud debitori, ita quòd cogitur id

reddere: Si verò illud postea petat titulo emptionis, aut alio alioquin legitimo, excluditur exceptione, quòd illud amiserit debitori, ob eam violentam usurpationem. Si vero illud non erat ei debitum, sed in recompensationem, aut in pignus, pro suo debito, id accepit, cogitur similiter illud reddere, & in pœnam, amittit debitum, ita quòd debitor non tenetur deinceps id debitum illi soluere. *Ita glossa, & alii l. Siquis in tantam. C. unde vi, sancitumque est. l. 14. titu. 10. part. 7. & habetur l. penult. ff. ad leg. Iulian. de vi priuata, & l. extat. ff. de eo quòd metus causa.* Obserua autem, cum *Greg. Lopez l. 14. cita. glossa 1. & cum Angelo*, quem refert, si creditor pro suo debito vi usurpet à debitore aliquid in pignus, distinguendum esse. Quoniam, si ius habebat, vt ea res sibi in pignus traderetur, quia promissa in pignus sibi erat, aut alia ratione tradi sibi in pignus debebat, tunc, ob eam violentam usurpationem amittit solùm ius, quod habebat, vt sibi in pignus traderetur, non verò amittit debitum principale. Si verò non erat sibi debita tradi in pignus, tunc ob eam violentam illius usurpationem amittit debitum principale, & cogitur restituere rem, quam ita extraxit. *Greg. Lopez. l. 14. cita. glossa ult. rectè obseruat*, si agatur ciuilitè, agi posse modo explicato. Cæterùm agi etiam posse criminaliter ad pœnam statutam inferenti vim priuatam, *vt habetur l. ult. ff. de vi priuata.* Adde, si cum armis res vi sit extracta de potestate debitoris, agi posse similiter ad pœnam legis Iuliæ de vi publica. Veruntamen, qui egerit ad pœnam de vi publica aut priuata, agere non potest ad pœnam, de qua, iuxta illa alia iura, in hoc §. dictum est, sed ad alterutram solùm agere potest. Insuper obserua *l. 1. titu. 17. lib. 5. nouæ collect.* sancitum esse, vt, qui pignus absque iudicis autoritate occupat, puniatur tanquam qui vim intulit. *Et l. 10. sequenti subiungitur*, vt ipso facto amittat debitum, & insuper amittat fisco Regis dimidium suorum bonorum, & incurrat pœnam *de robador publico. Vide item legem 5. & 6. titu. 13. lib. 4. nouæ collect. Lex. 14. titu. 10. part. 7.* pœnam eius legis extendit, vt intelligatur, etiam quando sine vi pignus, aut aliquid in recompensationem debiti, acceptum est propria autoritate, non præcedente pacto, inter ipsum & debitorem, vt id autoritate propria possit usurpare; nam in hoc euentu pœnam non incurrent, *iuxta l. 3. C. de pig. & in vtroque euentu consentire videntur quædam ex iuribus citatis.* Quanuis represaliæ licitæ sint, quando aliquis, aut aliqui, de aliena republica usurpauerunt aliquid alicuius de nostra republica, vel damnum ei intulerunt, alienaque republica in culpa est, non efficiens illud resarciri, ita scilicet, quòd fas est usurpare pignora aliorum de illa republica, pro eo debito, quin ex illis compensare id debitum & damnum, vt *Disput. 121.* ostensum est, seruatis tamen, quæ seruanda esse ibidem est explanatum; nihilominus quando homines sunt de eadem republica, eidemve principi subiecti, qui aduersus debitorem ius creditori dicere potest, nefas est pro debito vnus debitoris, etiamsi ad aliud oppidum, aut ciuitatem, pertineat, pignora accipere ab alio, qui pro illo non se obligauit, & multo minùs eum comprehendere, quia id cum iure naturali pugnat. Vnde, qui id efficit, punitur amissione debiti, & **[[12]]** insuper, vt rem, quam accepit, & triplum aliud, ei restituat, à quo eam accepit. *Ita habetur in authentica, sed omnino. C. ne vxor pro marito, iuncta glossa ibi, & in authentico vt non fiant impignorationes, vnde illa fuit desumpta, ac. l. 15. titu. 10. part. 7.* Lege etiam, quæ circa hoc disponuntur. *l. 3. & 10. titul. 17. lib. 5. nouæ collect.*

Quòd si comprehendat propria autoritate, vel debitorem ipsum, vel alium pro debito sui debitoris, tunc amittit similiter debitum, & insuper soluit ita comprehensor tantundem, atque est ipsummet debitum, & insuper punitur in corpore à iudice pœna arbitraria. *Ita habetur in authentico vt nulli iudicum. §. quia verò, in authentica imò à debito. C. de act. & oblig. & l. 15. citata, Lege etiam quæ statuuntur. l. 5. & 6. titul. 13. lib. 4. nouæ collect.* Agi etiam

aduersus eiusmodi delinquentem potest ad pœnam instituentis carcerem priuatum: sed non credo posse agi ad vtramque pœnam simul, sed ad alterutram dumtaxat, arbitrio eius, cui vtrauis actio competit.

Lex 16. titul. 10. part. 7. statuit, vt si is, qui le [sect. 27] gitimè erat vsufructuarius, emphyteuta, aut vassallus, quoad aliquod prædium, vi ejiciatur ab vsufructu, aut dominio vtile, quod possidebat, à proprietario ipso, proprietarius rem ita ablatam illi restituat, cum fructibus ex ea perceptis, & qui percipi poterant, & non sunt percepti, & insuper amittat tali vsufructuario, emphyteutæ, aut vassallo, proprietatem, & vis accipiendi ab illo pensionem, aut seruitium. Et quòd si tertius vi eosdem expellat, restituat similiter eis rem & fructus, & insuper, in pœnam, æqualem vsumfructum, aut æquale dominium vtile, in aliquo alio prædio, aut prædiis, eis tribuat, consentaneè ad legem si quis in tantam, & ad glossam ibid. C. vnde vi. Si tamen eos ejiceret quoad totam eam rem, intendendo scilicet, non solùm occupare vtile dominium, sed etiam directum, tunc æquale aliud prædium restituit integre in pœnam, tam quoad vtile, quàm quoad directum dominium, *Vt rectè ibi Greg. Lopez glossa ultim. subiungit.* Credo tamen tunc id prædium, quod in pœnam soluitur, pertinere ad proprietarium quoad Dominium directum, & quoad totum ius, quod in illo alio prædio habet: quandoquidem hæc omnia possidebat proprietarius in illo alio prædio, per seipsum quidem ciuilitè, & per vsufructuarius, emphyteutam, aut vassallum, naturaliter, ipseque, quoad ea omnia, censeatur vi eiectus à sua illa possessione in tali prædio, & vsufructuarius, emphyteuta, aut vassallus, solùm quoad vsumfructum, aut dominium vtile, quæ naturaliter & ciuilitè possidebant, vt Disput. 12. §. secundum, ostensum est, possessiones illas, modo explicato, attinere ad proprietarium, vsufructuarius, emphyteutam, aut vassallum. *Cynus, & alii, quos Greg. Lopez. l. 16. citata glossa 2. refert, aliter glossam. l. si quis in tantam intelligunt,* quoad eiectum ab vsufructu à proprietario. Nempe vt, si eiectus verè habebat vsumfructum, aut dominium vtile, proprietarius ei soluat in pœnam æstimationem illius, proprietariusque retineat dominium directum, & alia sua iura, vt antea ea habebat. Si verò ei ectus non habebat verè vsumfructum, aut dominium directum, illud in pœnam proprietarius in ea re ei concedat. Quando è contrario fructuarius, emphyteuta, aut vassallus, ejiciunt proprietarium à possessione rei, in qua vsumfructum, emphyteusim, aut feudum, prætendunt, tunc, si id ius eis non competeat, restituant rem, & æstimationem iuris illius, proprietario: Si verò id ius eis competeat, illud amittunt, *vt iuxta. l. si quis in tantam, & glossam ibi,* ac doctores, quos citat Gregor. Lopez glossa citata affirmat. Si verò nullum ius habens, intendat vsurpare rem quoad dominium vtile & directum, eaque de causa proprietarium à possessione illius ejiciat, restituit rem integram cum fructibus & damnis, & insuper in pœnam soluit valorem illius quoad vtile & directum dominium simul. Quòd si dominium vtile, aut vsusfructus, ei competat, & illam vsurpet, censetur, nisi contrarium probetur, eam vsurpare quoad solum ius sibi cōpetens, vt illud conseruet, & tunc illud solum amittit. Si verò probetur, etiam quoad proprietatem intendisse illam vsurpare, tunc amittit ius, quod sibi competeat, & insuper cogitur soluere æstimationem proprietatis. Ita Greg. Lopez ibi cum aliis, quos citat, consentaneè ad prædictam legem ac glossam. Hæc eadem similiter in [sect. 28] telligenda esse subiungit Greg. Lopez cum Cyno, Iacobo de Arena, & Saly. in prætendente iurisdictionem, eaque de causa ejiciente alium à possessione iurisdictionis.

Circa pœnas hactenus explicatas ob vim illa [sect. 29] tam, vt scilicet res occupata vi, amittatur ei, de cuius potestate eripitur, si ad occupantem pertinebat; si verò non pertinebat, soluat æstimationem; dubium est. Si occupetur vi à prælato, aut ab alio bonorum Ecclesiæ

administratore, perse, vel per alium, de ipsius mandato, aut ratum id postea habeat, factum nomine ipsius, aut Ecclesiæ, an Ecclesia incidat in eam pœnam, illudque amittat. *Glossa. l. siquis in tantam, quam sequi videtur. l. 17. titu. 10. part. 7.* & communior doctoum sententia, præsertim interpretum iuris ciuilis, affirmanter respondet, si id fiat communicato consilio cum capitulo. Contrarium verò affirmant *glossa. 16. q. 6. in summa, & c. placuit, verb. detrimentum, & glos. sa c. 1. de dolo & contum. verb. rigor. Panor. ibi. a nu. 9. & multi alii, quos Greg. Lopez. l. 17. cita. glos. 2. refert.* Nempe delictum ea in parte administrantium bona Ecclesiæ, nocere quidem ipsis, quia tenentur ad eas pœnas de suis bonis, & de bonis Ecclesiæ quoad commoditatem ex illis, quantum ad ipsos commoditas illa attinuerit dum vixerint. Quòd si ex his capitibus non possint integre pœnam soluere, luent in corpore, hoc est, cōpetens alia pœna personis eorum est imponenda, in complementum integræ pœnæ pro eo delicto. Ecclesia verò indemnis, quoad sua bona, seruari debet, nihil impediēte tali delicto ea administrantium. Quemadmodum, si tutor, aut curator, simile delictum committeret circa bona minoris, quæ administrat, non concurrente minore ad delictum, solus tutor, aut curator, teneretur soluerere pœnam de suis bonis; bona verò minoris manerent illæsa. Ratio autem cur delictum administrantium bona Ecclesiæ, etiamsi simul cōcurrant prælatus & capitulum, Ecclesiæ non noceat, est. Tum quia delictum administrantium redundare non debet in Ecclesiam, *vt habetur. c. si Episcopus. 16. q. 6. maxime*, vt Ecclesia soluat **[[13]]** pœnam pro eorum delicto, tum etiam quoniam, prælato & capitulo, non est concessa alienatio bonorum Ecclesiæ, nisi seruata certa forma, interuenienteq; legitima causa, aliterque facta est nulla: non est autem legitima causa delictum illud, vt alienentur. Tum denique quoniam Ecclesia nunquam admisit pœnam legis si quis in tantam circa ipsius bona, imò contrarium habere voluit locum in bonis Ecclesiasticis, vt constat. C. 1. de dolo & contum. leges verò ciuiles, quæ præiudicium afferre possunt bonis Ecclesiasticis, non habent locum in bonis Ecclesiasticis, nisi quatenus ab Ecclesia fuerint receptæ. Quòd si objicias: Si minor committat tale delictum, punitur in suis bonis, ergo idem est in Ecclesia. Dicendum est, bona illa verè esse minoris, eaque de causa delictum minoris non immeritò puniri in eis bonis: concedi tamen illi restitutionem in integrum, si aliqua probabilis ratio, verisimilitu. dôve, appareat, quòd id fecerit, putans sibi licere, vt suprâ dictum est. Administratores verò bonorum Ecclesiæ non esse illorum dominos, sed totum Ecclesiæ corpus, quod non deliquit, quodque non pro suo libito disponere validè potest de eis bonis, vt disponere potest respublica secularis de suis bonis pro libito, saltem vt factum teneat, vt hæc omnia Disp. 142. & Disput. 300. explanata sunt. Si autem communitas secularis in simile delictum incideret, quoad bona ipsius communitatis, etiam si sola communitas rectorum id committeret, aut alius de mandato illius; vel illa ratum id postea haberet, pœna redundaret in ipsam communitatem quoad ipsius bona, quæ ad illam tenerentur. *Ita habetur. l. metum. 3. §. animaduertendum, & affirmat glossa vlt. ibi. ff. quod metus causa, consentit. l. sicut. ff. quod cuiusque vniuersitatis, & habetur expressè. l. 17. titu. 10. part. 7. atque affirmant Bart. Panor. & communis doctorum sententia, quam Greg. Lopez ibi refert ac sequitur.* Atque hinc videtur permoti, qui idem dixerunt locum haberi in Ecclesia: cū tamen nos Disp. 142. citata latum tradiderimus discrimen, cur non similiter hoc habeat locum in corpore Ecclesiæ: id verò discrimen ibi legas. Quando autem communitas ipsa oppidi, modo explicato, non committeret crimen, neque illud ratum haberet factum nomine ipsius, sed aliquis alius de communitate, loco & nomine communitatis, id committeret, tunc id delictum non redundaret, quoad pœnam, in communitatem, sed in

solùm delinquentem, vt habetur. l. 17. citata, & omnes conueniunt, tam circa communitates seculares, quàm circa Ecclesiasticas, id verum habere.

Quando aliquis in iudicio ait, se vi fuisse eie [sect. 31] ctum à possessione rei alicuius, & petit restitui, esto is, à quo vi dicitur eiectus, dicat rem ad se pertinere, velitque id in continenti probare, & esto alius tertius dicat, rem ad se attinere, velleq; id probare, eaque de causa petat, ne vi eiectus mittatur in possessionem rei illius, ante omnia examinari debet, an vi fuerit eiectus, eoque sufficienter probato, debet ei res restitui, maximè post dispositionem legis si quis in tantam. *C. vnde vi, iuxta quam*, esto res pertineret ad spoliante, eo ipso illam amittit spoliato, debetque spoliato tradi: postea verò decidi debent aliæ causæ. *Ita habetur. l. ult. tit. 10. part. 7. consentiunt. l. si quis ad se fundum. C. ad leg. Iul. de vi pub. l. momentariæ. C. vnde vi. l. qui cetu. §. qui de vi. ff. ad l. Iul. de vi publ. &c. in literis, de rest. Spol.*

Rapina quid. Disp. 683.

SVMMARIVM.

1. *Rapina quot modis vsurpetur.*
2. *Rapinæ præssè definitio.*
- 3 *Rapinæ pæna, vive bonorum raptorum, in quibus bonis locum non habeat, sed solùm pæna de vi publica, aut priuata, aut legis si quis in tantam.*
4. *Rapina quando interueniat cum consensu inuoluntario mixtè eius, qui illam patitur.*
5. *Rapina non censetur in foro exteriori ob metum, nisi cadens sit in constantem virum, neque ita acceptum restitui iubetur, neque accipiens pæna raptoris punitur. In conscientia verò restituendum est, si inuoluntariè mixtè ex quocunque metu sit datum.*
6. *Rapina non est, sed furtum, si vis illata sit parietibus, aut foribus, sine vi illata personæ, ac sine animo eam personæ inferendi.*
7. *Rapina specie distinguitur à furto, tanquam includens rationem furti, & superaddens nouam speciem iniustitiæ, & quando vtraque lethalis culpa. In ratione tamen furti, specie non distinguuntur.*
8. *Rapina aduersus quos committatur. Qui item pænam raptorum incurrant.*

Rapina vno modo sumitur latissimè, pro v [sect. 1] surpatione eius, quod sibi non debetur, aut retentione eius, quod alteri quodammodo debetur. Sic sumitur in illo ad Phil. 3. *Non rapinam arbitratus est, esse se æqualem Deo.* & Aug. de primis parentibus: *Voluerunt, inquit, rapere diuinitatem, & perdiderunt felicitatem.* De qua rapina sermo est ex persona Christi in illo Psal. 68. *quæ non rapui, tunc exoluebam, in cruce scilicet ac passione mea.* Et Hiero. ac refertur Dist. 42. in prin. *Aliena rapere conuincitur, qui, ultra neceßaria, sibi retinere probatur.* Alio modo sumitur, vt comprehendit furtum, ac quamcumque iniustam acceptionem. Sic sumitur ab Ambros. de bono mortis, & refertur. 14. q. 4. c. si quis, dum ait: *Si quis usuram accipit, rapinam facit.* Eodem modo sumitur ab Aug. & refertur. 14. q. 5. c. si quid, dum ait: *Si quid inuenisti, & non reddidisti, rapuisti.* Tertio modo sumitur rapina pressè & propriè,

vt distinguitur contra furtum, & contra alios iniustitiæ modos. Atque eo modo sumitur in proposito.

Possumus verò eam, hoc tertio modo sump [sect. 2] tam, sic definire: Est iniusta acceptio boni externi per vim, eius, cuius est. Intellige per vim, siue publicam, siue priuatam, disputatione præcedente explicatam, *vt habetur. l. 2. §. 1. & sequentibus. ff. de vi bonor. raptor. inst. eodem titu. & titu. 13. in prinpart. 7. ac l. 1. eiusdem tituli, & utrobique Greg. Lopez.* Et consentiunt cæteri doctores. In eo, quod dicitur, iniusta acceptio, rejicitur à ratione rapinæ acceptio per vim bonorum alienorum externorum bello iusto, aut in extrema eorum necessitate, vel ritè à potestate publica: quoniam in eiusmodi acceptionibus per vim iniustitia non cernitur. Rejicitur etiam iniusta damni datio per vim in bonis aliorum externis, ea destruendo, aut deteriora reddendo: id enim propriè non est acceptio bonorum alienorum externorum, sed de-[[14]]structio aut deterioratio illorum.

Per particulam, boni externi, rejicitur à ratione rapinæ, de qua loquimur, rapina filiæ, aut vxoris, aut cuiusuis alterius mulieris, ad rem cum illa habendum, quæ non est iniustitia circa bona externa, sed circa propriam personam, comparatione mulieris ita raptæ, aut circa personam coniunctam, comparatione patris, mariti, aut alterius personæ, in cuius custodia aut domo sit. Eadem ratione rejicitur rapina alicuius personæ, vt in seruitutem redigatur, aut vt iniuria alia in sua propria persona afficiatur. Tales enim rapinæ non sunt de numero carum, de quibus loquimur, neque disputatio de illis, ad hunc secundum tractatum de iustitia spectat, sed ad tertium sequentem.

Iura in explicatione rapinæ, particulæ, [sect. 3] boni externi, addunt, particulam, mobilis, latè sumpti, vt comprehendit etiam, se monentis, *vt constat. l. 1. C. de vi bon. rapt. §. penult. inst. eodem titu. & l. 1. titu. 13. part. 7.* Sicut etiam similem particulam addunt definitioni furti: quoniam sicut admittere non volunt surtum pressè extra res mobiles, vt Disp. 681. dictum est: ita neque admittere volunt rapinam pressè extra res mobiles, licèt vim circa illas admittant, vt Disputatione præcedente visum est. Vnde pænæ pro rapina, vite bonorum raptorum, iure statutæ, locum non habent in rapina latè sumpta, vt sumitur à Theologis, pro vt se extendit ad bona immobilia: sed, quoad immobilia bona, solùm habent locum pænæ legis Iuliæ de vi publica, aut de vi priuata, si criminaliter agatur; aut legis si quis in tantam, & sequentium, de quibus Disputatione præcedente dictum est, si agatur ciuilitè, *vt habetur inst. de vi bon. rapt. §. penult.* Simili modo, quia iura, sicut furtum non admittunt circa vsurpationem sine vi rei propriæ illam vsurpantis, quando is, ex quo vsurpatur, nullum ius habet in eam rem: ita neque admittere volunt rapinam, *vt habetur. l. 2. §. doli mali. vers. hac actione 15. ff. de vi. bon. rapt. & inst. eod. titu. §. penult.* non habent in hoc euentu locum pænæ de vi bonorum raptorum, seu de rapina, sed legis si quis in tantam, & cæterarum, quæ præcedente Disputatione explicatæ sunt, vt habetur. §. penult. citato. Imò verò, quando quis rapit rem, quæ verè aliena est, putans esse suam, sibi què id licere; non incidit in pænas raptoris, sed solùm in pænas legis si quis in tantam, & in alias explicatas, *vt habetur inst. §. penult. citato.*

Non apposui verò in definitione rapinæ [sect. 4] particulam, absque vllo consensu eius, cuius ca res est, quam in definitione surti pressè sumpti, vt à rapina distinguitur, apposui. Quoniam licèt interueniat consensus eius inuoluntarius mixtè, si tamen exortus sit per vim, seu metum cadentem in constantem virum ad id iniustè incussum, propriè erit rapina. Quando enim grassator, iniusto metu mortis, aut alio graui, cogit aliquem consentire vt sibi aliquid exhibeat, verè committit rapinam in ea acceptione: est què id furtum manifestum,

adhibita vi, quæ illud transire facit in rapinam. Eadem ratione exactiones tributorum iniustè. licèt fiant consentientibus, qui illa soluunt, quia aliud non audent, rapinæ quædam sunt, furtaque manifesta. Idem dic de eo, quod potentes, aut ministri publici, similiter accipiunt, non audentibus, qui id dare consentiunt, aliud efficere, timore maioris mali. Idem dicerem, si quis metu cogeretur consentire in aliquem iniustum contractum: quod enim, vi talis consensus metu extorti, extraheretur, atque acciperetur, rapina esset, furtumve manifestum cum vi.

Illud hoc loco est observandum. Quamvis [sect. 5] in exteriori foro requiratur metus in virum constantem (attenta qualitate personæ & circumstantiarum concurrentium) cadens, ad hoc vt, quod extrahitur & accipitur per metum, rapina censatur, & per consequens vt repetitio illius concedatur, & insuper vt accipiens pæna raptoribus statuta puniatur; nihilominus in conscientia foro, quicquid per metum extortum est, ita vt constat inuoluntariè mixtè esse datum, siue metus illi grauis sit, cadensque in constantem virum, siue levis, in virumque constantem non cadens, obnoxium esse restitutioni. *Ita, inter alios, Nauarr. in Manu. c. 17. n. 15. Syluest. verb. restitutio. 2. §. 7. Adria. q. 2. de rest. §. ex quibus omnibus, & Couar. reg. peccatum, part. 2. §. 3. nu. 7.*

Dubium est, vtrum, quando alicui, in illius [sect. 6] absentia, & in absentia cuiusuis alterius, qui nomine illius rem custodiat, aut resistat, infringuntur fores domus, aut perforantur parietes, vel tectum, vt, quod intus est, iniustè accipitur, ea in iusta acceptio habeat tantum rationem furti; an verò etiam rapinæ. *Sotus. 5. de iust. q. 3. art. 2. rapinam esse affirmat. Victoria verò. 2. 2. q. 66. art. 4. id negat.* Nobis verò hæc Victorie sententia probatur. Quoniam licèt in iure pæna ita furantibus meritò augeatur, vt infra, quando de furium pænis fuerit fermo, dicetur; nihilominus ad rationem rapinæ vis illata personæ, animusve eam inferendi, requiritur, neque sufficit vis illata parietibus, aut foribus, vel tecto. Dixi, ad rapinam, saltem animum vim personæ inferendi requiri: quoniam, si quis domum alienam ingrediatur animo per vim vsurpandi iniustè quod ibi fuerit repertum, illudque vsurpet, etiam si nullum intus reperiat, qui resistere possit, rapinam committit, & vt raptor est puniendus, *vt habetur. l. si quis ex dome. ff. de furtis*, quam eo modo existimo esse intelligendam.

Dubium deinde est, vtrum rapina & furtum [sect. 7] specie distinguantur in genere moris. *D, Th. 2. 2. q. 66. art. 4. Caiet. ibi. Sotus. 5. de iust. q. 3. art. 2. Couar. reg. peccatum, part. 2. §. 1. n. 2. & doctores communiter, affirmanter respondent.* Quoniam, cum ad rationem iniustitiæ requiratur inuoluntarium ex parte eius, qui iniuriam patitur; eo quod nullus patiatur iniustitiam volens: diuersa autem ratio inuoluntaril inueniatur in eo, qui iniustitiam per vim patitur, & in eo, qui illam patitur sine vi, *vt Arist. 3. ethi. c. 1. explicat*: consequens est, vt ex parte obiecti proximi, hoc est, alieni per vim. aut sine vi, acceptio iniusta rapinæ, specie distinguatur ab acceptione iniusta furti. *Gab. verò [[15]] in 4. dist. 15. q. 3. art. 1. ad finem notabilis 5. propèdere videtur, eas differentias esse accidentarias, ac proinde rapinam specie non distingui à furto.* Dicendum arbitrò, animum vim inferendi personæ, eamve vim re ipsa inferre, quod de intrinseca ratione est rapinæ, per quod à furto pressè sumpto distinguitur, distinctam esse speciem iniustitiæ à furto: furtum quippe est iniustitia aduersus proximum circa bona illius externa: ea verò vis est iniustitia aduersus eundem proximū circa ipsius personam ac honorem: vnde rapina & includit iniustitiam furti, & etiam hanc aliam distinctam speciem iniustitiæ aduersus personam & honorem proximi: quo fit, vt distinguatur specie à furto, tanquam addens nouam distinctam speciem supra furtum; sicut furtum rei sacræ, & est furtum contra iustitiam, & addit distinctam speciem contra

virtutem religionis: & sicut adulterium, & est fornicatio, contra virtutem temperantiæ, & contra bonum prolis, & addit distinctā speciem contra iustitiam aduersus alterum coniugem. Vnde rapina, in ratione furti, specie non distinguitur à furto pressè sumpto, sed differt ab illo solùm accidentario in ratione furti; & nihilominus supra surtum addit nouam speciem iniustitiæ. Est ergo rapina specie distincta à furto, tanquam addens nouam rationem, atque speciem iniustitiæ, supra furtum. Quare, pro qualitate vis, quæ infertur, aut quæ inferri intenditur, periculúmve est, ne inferatur, iudicandum est, utrùm ea vis sit noua culpa lethalis, & quanta, aut qualis, & utrùm sit duplex lethalis culpa, vna contra personam, vt si mors, vulnus, aut aliud simile, intendatur, periculúmve sit, vt inferatur: & altera cōtra honorem, eum notabiliter lædendo.

Quemadmodum Disp. 681. dictum est, & in [sect. 8] sequentibus amplius explicabitur, furtum committi aduersus tenentem rem aliquam legitimè, quando ab ea tentione dejicitur: ita committitur aduersus eundem rapina, si vi ea legitima tentione spoliatur. *Ita habetur l. 2. §. in hac actione. ff. de vi. bon. rapt. §. ult. inst. eod. tit. & l. 2. tit. 13. part. 7.*

Illud etiam obserua, ad rapinam pertinere, saltem vt accipiens rem mobilem puniatur pæna raptoris, quando quis aliquid sine vi accipit, pro quo tamen iure humano est statutum, vt incurrat crimen legis Iuliæ de vi publica, aut de vi priuata, iuxta ea quæ disputatione præcedente explanata sunt: quoniam, iuris dispositione censetur id vi auferre. Sic, qui de incendio aliquid furatur, quod ligna non sit, censetur rapinam committere, pænaque raptoris punitur, *vt habetur. l. 1. in sine titul. 13. part. 7.*

De variis furti generibus, & consequenter etiam rapinæ. Disp. 684.

SVMMARIVM.

1. *F* Vr quis nocturnus, & quis diurnus. Nocturnus impunè occiditur, non diurnus, nisi tele se defendat.
2. *Furtum quod manifestum, & quod occultum.*
3. *Furtum quot modis saorilegii rationem sortiatur, specie distinctam à furto in ratione furti, & vtraque ratio ex genere suo est lethalis.*
4. *Pecula tus furtum quando committatur.*
5. *Crimen legis Iuliæ de residuis quando cōmittatur.*
6. *Abigeatus furtum quod, & quibus panis punitur. Quibus item pænis receptator abigeorum puniatur.*
7. *Plagii crimen quod, & quibus punitur pænis.*
8. *Varia circa mancipia cōnexa cum crimine plagii.*
9. *Mancipium fugitiuum, etiam si ad suos transeat, numquam præscribit libertate aduersus suum dominū.*
10. *Seruus corrumpens consilio, aut alia ratione, ad quid teneatur, & quam pæn. im incurrat.*

11 . *Filium, aut famulum, corrūpens ad quid teneatur.*

S**V**bjicienda sunt varia furtorum genera, seu mo [sect. 1] di, de quibus mentio peculiaris fit

in iure. Atque in primis fur ipse, ratione temporis, in quo furtum committit, diuiditur in nocturnum & diurnum. Diurnus est, qui orto iam sole, aut (vt bene Panor. c. perfodiens, de homicidio ait) tanta existēre illius luce, vt agnosci possit, aliquid furatur. Qui verò alio tempore furatur, dicitur fur nocturnus. Fur nocturnus impunè occiditur. Diurnus verò non, nisi telo, hoc est, quibuscunque armis, se defendat. Licèt enim teli nomine id propriè intelligatur, quod iaci potest, eminusque ferire, siue id sit lapis, siue ferrum, aut quoduis aliud, autore tamen Calepino verb. telum, interdum sumitur latè, pro quocunque offensiuorum atmorū genere: eoque modo sumitur in proposito: qui enim ense aut lancea se defenderet, vtique occidi impunè posset, non minus, quàm si lapide, aut alio iaculo, se defenderet. Quòd autem nocturnus fur occidi impunè possit, diurnus verò non possit, nisi telo se defendat, *habetur. l. itaq̃. §. lex duodecim tabularum. ff. ad. l. Aquil. l. furem. ff. ad leg. Corn. de sicariis, & c. si perfodiens, iuncto c. antecedente, de homicidio.* Quomodo autem id sit intelligendum, commodiùs explicabitur tractatu. 3. de iustitia sequenti, dum sermo fuerit an pro defensione bonorum externorum, licitum sit occidere aggressorem.

Deinde furtum diuiditur in manifestum, & [sect. 2] non manifestum. Furtum manifestum appellatur in iure, non solùm quando fur deprchenditur in ipso actu furandi, sed etiam quando, vel à domino rei, vel ab aliquo alio, deprehenditur cum re furtiua, aut conspicitur antequam illam detulerit ac apposuerit in loco, in quo illam reponere destinabat: in reliquis verò euentibus, furtum dicitur non manifestum, siue fur deprehendatur cū re furtiua, postquam illam posuit in loco, quo eā ponere destinabat, siue aliter de furto cōstet. Sūt verò diuersæ pænæ statutæ pro furto manifesto, & pro non manifesto, vt videbimus. Distinctio hæc, atque explicatio, furti manifesti, & non manifesti, *habetur. l. 2. & sex legibus sequentibus. ff. de furtis. §. furtorum inst. de obligationib. quæ ex delicto, & l. 2. titu. 14. part. 7.* Obserua tamen, quòd quamuis vt furtum dicatur manifestum, satis sit furē videri à domino, vel ab aliquo alio, quando rem furatur, vel quando illam defert, antequam illam reponat in loco, quò eam deferre destinabat, *vt habetur expresse. §. furtorum citato;* nihilominus non esse satis nudam visionē, sed insuper requiri currere ad furem comprehēdendū, vel illi ac clamare, quòd rem furatam deferat, vel vt rem furto ablatam relinquat: quouis autem horum facto, dicitur furtū manifestum, esto fur rem abjiciat, ac relinquat: alioquin, fi nihil eorum fiat, esto videatur à proprio domino, aut à multis aliis, non dicitur furtum manifestū, sed occultū. Quin, si à domino videatur, & taceat, distinguendum est. Quoniam si coniecturæ sint, eum intendisse consentire in eo furto, actio [[16]] furti ei denegabitur, si postea intentare eam velit. Si verò non sint tales coniecturæ, sed præsūmēdum sit ex timore tacuisse, ne interficeretur, aut ne a liud detrimentum subiret, vel ob verecundiam, aut vt consuleret honori ac famæ furis, vt si patronus furabatur à liberto, conspiciente id liberto, tunc conceditur ei actio furti, non tamē manifesti, sed occulti. *Ita habetur. l. 7. citata, iuncta l. penult. ff. de furtis, & consentit cum Baldo, & aliis, Greg. Lopez. l. 2. citata, gloss. vlt.* Illud etiam obserua, quando dicitur furtum esse manifestum, si fur deprehēdatur cum re furtiua antequam eam reponat in loco, in quo eam ponere destinabat, intelligendum esse, si cum ea deprehendatur eo ipso die, quo illam furatus est: si enim deprehendatur elapso iam eo die, esto nondum cum illa deuenerit ad locum, quò illam deferre intendebat, nō censetur furtum manifestum,

sed occultum. *Ita habetur. l. 4. ff. de furtis, & affirmat glossa. l. siue, verb. occidisse. ff. de cōdict. furt. & Greg. Lopez glossa vlt. cita. cum aliis, quos refert.*

Furtum ex parte rei furto ablatae, aut etiam lo [sect. 3] ci, in quo fit, in multa diuiditur membra. Quoddam enim est sacrilegium, vt quando quis furatur sacrum de loco sacro, aut sacrum de loco non sacro, vel non sacrum de loco sacro. *c. quisquis 17. q. 4. glossa. c. sacrilegium eadem quæstione, & doctores communiter.* Quid autem sit res sacra, & quis locus sacer, inferiùs explicabitur, quando trademus pœnas pro hoc sacrilegio statutas. Furtum, quod rationem sacrilegii sortitur, in ratione furti atque iniustitiæ, ab aliis furtis, meo iudicio, specie non differt: addit tamen furto distinctam speciem vitii sacrilegii, virtuti religionis contrariam: vnde formaliter ad duplicem speciem peccati spectat, & vtraque est necessariò confitenda, quando ad culpam peruenit lethalem. Est verò vtraq; ex suo genere culpa lethalis, nisi, ex leuitate materiæ, venialis reddatur.

Aliud est furtum, quod peculatus nuncupatur, [sect. 4] peculiariterq; punitur, quando videlicet furto accipitur res publica, ad fiscum Regis, aut ad bona illius, attinens, vel ad ciuitatem Romanam: nam si aliquid furto accipiatur de bonis aliarum ciuitatum priuatarum, aut cæterorum oppidorum, non censetur peculatus, sed furtum simplex, licet grauius, *vt habetur. l. ob pecuniam. ff. de furtis, eoq; modo intelligitur. l. 4. §. vlt. ff. ad leg. Iul. peculat. vt glossa ibi. notat, & doctores communiter.* Hac ratione, si quis, dum Regis monetam cudit, vnde ei prouenit emolumentum, cudat aliam sibi æquè bonam ex sua propria materia, absque Regis facultate, in crimen incidit peculatus, dum principi id emolumentum furatur, còve illum priuat. Multo verò magis in crimen peculatus incidit, qui, dum à principe accipit aurum, aut argentum, ad monetam cudendam, illi immiscet deterius aliud metallum, quo ipse aliquod lucrum inde percipiat. Vtrumque habetur. *l. sacrilegii. §. penult. & vlt. ff. ad leg. Iul. peculat. & l. 15. titu. 14. part. 7.* Qui item furatur rem sacram, aut religiosam, sub qua comprehendere ornamenta non benedicta, & reliqua ad cultum diuinum attinentia, incidit in crimē peculatus: bona quippe sacra ac religiosa bona sunt publica: vnde intelliges, furti sacrilegium cum crimine peculatus sæpe esse coniunctum. Prædicta omnia ad crimen peculatus attinere, constat *ex §. item lex Iulia peculatus inst. de publ. iud. ex. l. 1. & sequentibus. ff. ad. l. Iul. pecul. & ex. c. quid ergo. 23. q. 4.* quod est Augustini.

Cum crimine peculatus est coniunctum cri [sect. 5] men legis Iuliæ de residuis. Nempe, quando aliquis pecuniam aliquam publicam apud se habet, neque illam in eo expendit, ad quod est destinata, vt insumatur, sed eam conuertit in suum vsum ac commodum; non quidem animo nunquam eam soluendi; nam tunc esset furtum ac peculatus; sed defraudando principem, aut communitatem, cuius est, aut alios, quibus ex præscripto principis, aut communitatis, est tradenda, vsu illius ac emolumento. *Ità habetur. l. 2. & 4. §. lege Iulia. ff. ad leg. Iul. pecul. §. sunt præterea inst. de publ. iud. & l. 14. titu. 14. part. 7.* Quæ hoc crimen dicit habere etiam locum in ministro habente pecunias cuiusq; ciuitatis, aut oppidi, defraudantemq; similiter eam communitatem, aut alios, quibus est tribuenda, vsu & emolumento illius: itemq; locum habere in his omnibus ministris, qui, cùm teneantur tribuere pecuniam aliquibus, ex principis, aut cōmunitatis, præscripto, illis inuoluntariè mixtè tribuunt merces, aut aliquid aliud, loco illius. Sunt verò eiusmodi crimina satis frequentia in ministris principum, & communitatum, quibus incumbit soluere debita principum, aut cōmunitatum, vel aliter distribuere, aut insumere, eiusmodi bona; de pœnis verò horum delictorum inferiùs dicitur.

Aliud furtum abigeatus dicitur, & peculiari [sect. 6] ter punitur. Vt verò in authentico de nuptiis. §. mitiores, vers. si igitur, habetur, *abigei appellantur, quibus est cura alienis insidiari animalibus, aut iumentis, & ea transponere alibi*. Ab abigendo enim aliena animalia, furti gratia, dictum est hoc crimen abigeatus, & qui illud committunt, abigei sunt nuncupati. Quia verò expediens fuit, secu ritatem esse in animalibus, maximè in eis, quæ pascuntur, circa quæ non possumus habere tantam custodiam, quantam circa res alias nostras mobiles adhibere solemus, tanquam peculiare furti crimen fuit distinctum, apposis ei peculiaribus grauioribus pænis. Neque tamen quodcumque furtum alienorum animalium est sufficiens, vt quis in abigeatus crimen incidisse censeatur, & vt incurrat pænas peculiare pro hoc crimine in iure statutas. Sed necesse est, vt furetur decem, aut plures, oues, (idem intellige de arietibus, capris, quin & de agnis, & hædis) aut quinque porcos, vel saltem quatuor, vel equum vnum, aut bouem (idem intellige de mulo, asino, aut camelo.) Item, qui sæpius (hoc est, ter, vt minimum, vt rectè cum aliis affirmat ac probat *Greg. Lopez. l. 19. titu. 14. part. 7.*) ouem vnam, aut porcum vnum, vel aliud simile animal, quod non sit de maioribus, furatus fuerit, censetur abigeus, & in pænas pro hoc crimine statutas incidit: quoniam censetur quasi ex arte, & consuetudine, insidiandi eiusmodi alienis animalibus, id efficere. Qui euim vnum equum, aut vnum aliud animal ex magnis, vel semel, furatur, censetur abigeus, vt dictum est. Hęc omnia habentur. *l. 1. & vlt. ac per totum titulum. ff. de abigeis, & glossa. l. 1. l. 1. C. eod. tit.* atque ea cum communi doctorum sententia, quam refert, affirmat *Ant. Gom. 3. tom. var. res. c. 5. n. 13.* Quando autem aliquis ouem aberrantem, aut equos in solitudine, extra gregem, aut extra armēta, repertos, abegerit, etiam si dolo id effecerit, censebitur fur, non verò abigeus. *Ita habetur l. 1. citata. §. cæterum. [[17]]* Quoniam ad crimen abigeatus necesse est, vt furtum sit de grege, aut de armento, nisi sit equus, aut aliud simile animal mansuetum; nam tunc satis est furtum illius de stabulo, vt in hoc crimen incidatur, *vt habetur. l. vlt. ff. de abigeis.* Qui pecora abegit, prætendendo sua esse, eaque de re quæstionem mouēdo, non punitur vt abigeus: nisi manifestum sit, eo quæsito colore intendisse excusare crimen abigeatus. *Ita habetur. l. 1. citata. §. vlt.* Abigeatus crimen de iure communi pæna mortis punitur; in locis tamen vbi frequens est id crimen: alioquin ad metalla, ad aliāve opera publica, de eodem iure communi abigeus ad tempus damnatur. *Ita habetur. l. 1. citata.* Quòd si ferro id crimen committatur, armis animalia auferendo, ac defendendo, abigeus bestiis de iure communi objicitur, *vt habetur eadē. l. 1. & 2. ff. de ab igeis.* Quando autem abigeus erat honesto loco natus, & alioquin, vel ad metalla, vel ad opera publica, erat damnandus, aut etiam interficiendus, tunc relegabatur de iure communi, aut à sua dignitate in pænam deponebatur, vt habetur. *l. 1. citata. §. quanquam.* Receptatores verò abigeorum pæna exilii decem annis à toto Regno de iure communi puniuntur, *vt habetur. l. vlt. ff. de abigeis, & l. 19. titu. 14. part. 7.* Crimen tamen abigeatus non computatur inter crimina, quæ iura appellant publica, *vt habetur. l. 2. ff. de abigeis.* Et qui de eo crimine accusat, necesse non habet seipsum subscribere, vt scilicet, si à probatione deficiat, pænam talionis subeat, *vt habetur l. vnic. C. eod. titu.*

Lex. 19. titu. 14. part. 7. licèt in multis cum hactenus dictis consentiat; in aliquibus tamen dis⁴crepat. In primis pænam mortis statuit abigeo, qui quasi ex arte & consuetudine, modo explicato, etiam ouem vnam furatur. Item ei, qui furatus fuerit decem oues simul: & idem intelligit de furante simul decem alia similia animalia. Item ei, qui simul furatus fuerit quinque porcos, aut quatuor equos, vel quatuor alia similia maiora animalia: quoniam hæc reputantur greges. In aliis autem euentibus, in quibus de iure communi dictum est, incurri

crimen abigeatus, solùm ab igeo statuit pœnam damnationis ad opera publica ad tempus iudicis arbitrio statuendum. Atque ad prædictam formam reduxisse temperasseque videntur conditores huius legis dispositiones iuris communis circa hoc crimen. Lege Greg. Lopez ad eam legem. Opus autem fuit hoc loco de pœna huius criminis dicere, antequam de pœna cæterorum furtorum dicamus, propter discrimen hoc quod est inter hanc legem huius Regni, & inter ius commune.

Aliud crimen peculiariter distinguitur, quod [sect. 7] plagium nuncupatur. Ceterùm hoc crimen, neque omne furtum comprehendit, sed solùm Mancipiorum, quibus priuantur eorum proprii domini: neque comprehendit solum id furtum, sed etiam delictum, quo parentes spoliuntur propriis filiis, qui in ipsorum sunt potestate, vt in seruitutem iniquè redigantur; aut etiam, quo alii liberi homines iniquè in seruitutem similiter rediguntur. Dictum verò est hoc delictum plagium à plaga & dolore, quo eo delicto afficiuntur parentes, aut domini, talium filiorum, aut Mancipiorum, vel etiam homines ipsi liberi, qui peruersè eo delicto in seruitutem rediguntur. Incidunt verò in hoc delictum, non solùm qui, scientes aliquem esse hominem liberum, aut esse alienum Mancipium, illum vendunt, dono dant, aut aliter alienant, vel in seruitute retinent; sed etiam qui, cum eadem scientia, eum emunt, aut alio titulo accipiunt: secus autem, qui, id ignorantes, eum alienant, vel accipiunt. *l. 1. 3. 4. & 6. ff. ad leg. Fabiam de plagiis, & l. comparantem. l. plagii. 2. & l. penult. C. eod. titul.* Porrò, qui hoc flagitium, quouis ex modis explicatis, committunt, si nobiles sint, in metalla in perpetuum mittuntur: si verò non sint nobiles, & sint Mancipia, aut liberti, bestiis obijciuntur: quòd si ingenui sint, nec nobilitate fulgeant, gladio interficiuntur, cuius pœnæ loco hodie furca necabuntur. *Ita habetur. l. 1. & ult. ff. ad leg. Fabiam de plagiis, eadem pœna habetur expressiùs l. ult. C. eodem titul.* Quamvis autem de solo crimine loquitur, quo parentes prædicto modo filiis, quos in potestate habent, orbantur: *lex tamen quoniam. C. eod. titul.* pœnam capitis extendit ad plagiarios quorumcunque hominum liberorum, ac Mancipiorum, & *l. 22. titul. 14. part. 7.* quæ de omnibus delictis explicatis loquitur, eandem pœnam pro singulis irrogat, accommodatè ad ius commune. Neque vt hoc crimen incurratur, & vt delinquens puniri debeat pœna explanata, necesse est, vt ex consuetudine aliquid eorum, quæ explicata sunt, efficiat, vt voluit glossa. *l. si abducta, verb. plagio. C. de furtis, quæ, vt Greg. Lopez. l. 22. citata glossa. 1. ait,* communiter reprobatur. Haud dissimilis erat lex illa iudicialis veteris testamenti *Exod. 21.* quæ ita habebat: *Qui furatus fuerit hominem, & vendiderit eum, conuictus noxæ, morte moriatur.*

Qui Mancipium suum, dum in fuga erat, absolute vendebat, in hoc idem crimen incidebat: secus verò, si illud vendebat in tempusquo esset recuperatum, aut comprehensum, atque adeò sub conditione, si comprehenderetur, aut recuperaretur. *Ita habetur. l. 2. ff. ad leg. Fabiam de plagiis, & l. in fuga. C. eod. titul.* Credo tamen eam dispositionem, quoad priorem partem, sancitam esse, eo quòd, iuxta dispositionem Cæsarei iuris eius tempestatis, id Mancipium, si fines egrederetur ea fuga prouinciæ, in qua erat Mancipium, & ad fines suorum perueniret, continuò consequebatur libertatem, vt Disp. 37. explanatum est. Cùm autem eadem disputatione ostensum à nobis sit, contrarium habere rei veritatem, arbitror eam dispositionem vim non habere: sed solùm posse agi ad rescindendam venditionem, aut etiam ad damna subsequuta, ob id vitium talis Mancipii nonmanifestatum. *Glossa. l. in fuga citata. verb. pœnam,* ait, multos hodie arbitrari, pro eo crimine imponi non posse, nisi pœnam pecuniariam, & consentit. *§. est & inter inst. de public. iud.*

Qui mancipium fugituum suscipit ac celat, esto postea contendat suum esse, ad suum proprium crimen excusandum, incidit in crimen plagii. *Ita habetur. l. 5. ff. ad leg. Fabiam de plagiuncta. l. 2. C. eod. titu.* Idem est de quocunque alio celante mancipium alienum, vt habetur. l. [[18]] eum qui. C. eod. titu. Non verò in id crimen incideret, qui mancipium alienum conduceret ad operas aliquas, illudque interim pasceret, *vt habetur. l. 6. ff. ad leg. Fab. de plagiis.* Interim enim, dum fraudare non intenderet mancipii dominum suo mancipio, quamuis sciens & prudens illo ad tempus vteretur, contra domini voluntatem, possetque aduersus eum ea de causa agi ex furto talis mancipii quoad eum vsum; non tamen censeretur incurrere crimen plagii. Atque hoc est, quod tradere ac intendere videtur. lex. 6. citata in priori sui parte.

Vniuersim verò, qui quouis modo in crimen plagii incideret circa mancipium alienum, si contenderet suum esse, examinanda ante omnia esset ea causa, compertoque esse suum, non censetur incidisse in crimen plagii: pronunciato verò alienum esse, tunc locum habet condemnatio de crimine plagii, *iuxta l. præses. C. eod. titu.* nisi iusta ratione persuasus crediderit esse suum: nam tunc in crimen plagii non incidit, & multo minùs, si compertum fuerit esse suum, *vt habetur. l. plagii. 2. C. eod. titu.*

Qui hominem liberum, etiam libertum, inuitum celauerit, ac vinctum habuerit, crimen plagii incurrit. Poteritque tunc etiam frater vincti agere aduersus detinentem ita hominem liberum, *vt habetur. l. si fratrem. C. ad leg. Fab. de plagiis.* Itemque, qui mancipio suaserit, vt fugam arripiat, (intellige, fuga inde subsequuta) & qui mancipium alienum inuito domino vinctum habuerit, in idē crimen incidit. Itemque incidunt in idem crimen, qui ad quoduis ex criminibus explicatis fuerint cooperati, intellige, subsequutis eis criminibus. *Hæc habentur. l. 6. cita. §. ult. & l. 1. & sequētib. C. eod. titu.* ¶ Crimen plagii ad publica iudicia spectat, vt patet. l. plagii. 1. C. ad leg. Fab. de plagiis, & §. est & inter inst. de publ. iud. Atque in accusatione de eo crimine interuenire debet inscriptio accusantis, *vt habetur. l. vt legis. C. ad leg. Fab. de plagiis.*

Quando mancipium sugit dominum suum, [sect. 8] dominus adire potest iudicem, qui tradere ei tenetur mandatum in scriptis, vt inuestigetur, & ministrum, aut ministros, qui id exequutioni mandent, illud inuestigando in domibus, aut prædiis, in quibus dominus mancipii, aut qui partes illius egetit, suspicatus fuerit, illud latere. Quòd si, vel iudex mandatum & ministros non det, vel dominus domus, aut prædii, in quo suspicio est illud latere, non permiserit quæri in eo, singuli, hoc est, tam iudex, qui mandatum & ministros non dederit, quàm dominus domus aut prædii, qui inuestigari non permiserit, incidunt in pœnam centum solidorum fisco Regis; & nihilominus inuestigari mancipium debet in ea domo, aut prædio, & in quocunque alio suspicio fuerit, illud latere. *Ita habetur. l. 1. & l. alienus. ff. de seruis fugit. l. requirendi. C. eod. titu. & l. 24. titu. 14. part. 7.* Quo in loco glossa. 2. *legito apud Gregor. Lopez,* num similiter inuestigari in domibus alienis possint reliquæ res, etiā si indicia non sint in eis esse.

Qui, sciens seruum fugituum esse, consultò eum receperit, aut celauerit in suo prædio, incidit in pœnam soluendi fisco Regis centum solidos, *vt habetur. l. 1. iunctaglossa ibi verb. statuit. ff. de seruis fugit. & l. 24. citata,* & insuper incidit in pœnā soluendi domino mancipii, vltra mancipium quod celauit, aliud æquè bonum, vel viginti solidos, *vt habetur. l. quicunque. C. de seruis fugit. & l. 24. citata,* tametsi lex 24. statuatur, vt optio non sit penes celatorem mancipii, vt soluat vel mancipium æquè bonum, vel viginti solidos, vt maluerit; cuius tamen cōtrarium apertè innuit. l. quicunque citata, & affirmant glossa ibi, & doctores communiter,

dicendumque est stando in iure communi: sed ut solū soluat viginti solidos in euentu, quod non habeat aliud mancipium æquè bonum, quod reddat: atque hoc erit seruandum in hoc Regno. Lege ibidem Greg. Lopez. glossa vlt. Hæautem pœnæ statuuntur recipienti aut celanti mancipium alienum fugitium, quoniam eo ipso censetur committere furtum illius, *ut habetur. l. 1. in prin. ff. de seru. fugit. & l. Neratius. §. vlt. ff. de seruo corrupto.* Illud obserua, legem quicumque citatam, innuere videri, quod qui secundò celat mancipium, vltra celatum, soluat duo alia, aut viginti solidos pro vnoquoque eorum; & quod, qui tertio celat, soluat tria, & ita intelligit eam legem glossa ibi, verb. vel tertio. Additio tamen in margine ex Salyceto contrariū affirmat, quod scilicet, si bis celet, soluat duo, vnū pro prima vice, & alium pro secunda: si verò ter celet, soluat similiter tria. Quod si is, qui in has pœnas incidit, non habet vnde soluat, luit in corpore, *ut habetur. l. quicumque citata. §. 2. & l. 25. titu. 14. part. 7.* Quod si is, qui recepit, aut celauit, mancipium, illud manifestet intra viginti dies, vel domino mācipii, vel iudici, aut ministris publicis ad illud quærendum deputatis, euadit pœnam soluēdi fisco centum solidos: non verò euadit pœnam soluendi domino mancipii, aliud æquè bonum, vel viginti solidos. *Ita habetur. l. 1. §. 1. iuncta. l. in publicum. in prin. ff. de ser. fug. & l. 24. citata.* Dictum autem est; qui, sciens seruum fugitium esse, consultò eum receperit, aut celauerit in prædio suo: quoniam, ad incurrendas eas pœnas, dolus requiritur in recipiente aut celante mancipium alienum, *ut habetur. l. doli. ff. de seru. corrup. & l. 24. citata.* Quare, non solū si quis ignorans aliquem esse seruum, sed etiam si sciens seruum esse fugitium, illum recipiat in prædio suo, si tamen id efficiat humanitatis gratia, aut ut illum restituat domino suo, non verò ut inde detrimentum domino talis serui sequatur, non incidit in pœnas explicatas, *ut habetur. l. doli. citata. l. quicumque. §. quod si seruus. C. de seru. fugit. & l. 26. titu. 14. part. 7.* quoniam, neque crimen in dominum talis serui commisisse censetur.

Si in prædio minoris recipiatur, aut celetur, mancipium alienum, non incidit minor in prædictas pœnas, esto ipse id sciuerit. Tutor autem, aut curator, si id sciuit ac permisit, aut fecit recipi vel celari, prædictas pœnas incurrit. *Ita habetur. l. quicumque. §. 1. C. de seru. fugit. & l. 25. tit. 14. part. 7.* Credo tamen, si minor pubes, absque curatoris autoritate ac scientia, mancipium in proprio prædio celauit, puniendum esse, vel eis pœnis, vel alia iudicis arbitrio pro quantitate ætatis ac culpæ. Imò, esto curator fuerit simul in culpa, minor pubes puniendus erit pœna arbitraria, pro culpæ ipsius quantitate. Neque refragatur. l. quicumque si rectè expendatur: quæ tutorem aut curatorem puniendum affirmat, & nihil de minore non puniendo loquitur: tametsi. l. 25. citata, de orphano dicat, puniendum non esse.

Quando dominus proprio mancipio persuasit, ut fugeret ac se absconderet in prædio alicuius, ut in eo quæsitum ac inuentum, dominus prædii cogeretur soluere pœnas supra explicatas, **[[19]]** tunc, non solū ille, in cuius prædio fuerit repertum, non cogitur soluere eas pœnas, etiam si consenserit ut tale mācipium in eo suo prædio se absconderet, sed etiam dominus mancipii illud in pœnam talis delicti amittit fisco. *Ita habetur. l. quicūque. C. de seru. fugit. & l. 26. tit. 14. part. 7.* Atque si indicia sint, dominum mancipii id præcepisse, & dominus prædii requirat, ut torqueatur mancipium, ut manifestet veritatem, torqueri debet, atque, si mancipium tormentis manifestet dominum suum id ei suasisse, statur confessioni talis mancipii, absoluiturque dominus prædii, & dominus mancipii in pœnam priuatur eo mancipio fisco. *Ita habetur. l. quicumque citata. §. penult. & vlt. iunctis tribus glossis vltimis ibi, & l. 26. citata.* Si tamen dominus prædii à principio inuitauit mancipium alienum, ut ad se fugeret, & in suo prædio se absconderet, tunc, esto dominus mancipii, id sciens, diceret

mancipio, vt id opere impleret, animo quærendi postea illud in eo prædio, & exigendi pœnam à domino prædii, cogeretur dominus prædii eam soluere, tum domino mancipii, tum etiam fisco, iuxta. *l. si quis seruo. C. de seru. fugit.* & affirmat glossa vlt. *l. quicunquecita. & habetur. l. 26. titu. 14. part. 7.*

Qui dolosè recipit aut occultat, modo suprà explicato, mancipium Regis patrimoniale, hoc est, ad fiscum, coronámve Regni, minimè spectans, vltra illud, cogitur soluere in pœnam libram auri. *Ita habetur. l. 2. C. de fugitiuis colonis. lib. 11. l. 2. in prin. titu. 14. part. 7.* quæ de eiusmodi Regis mancipiis intelligi debet, & affirmat glossa vlt. *l. quicunque. C. de seruis fugit.* Qui verò similiter recipit, aut occultat, mancipium ad fiscum, coronámve Regni, spectans, vltra illud, cogitur soluere duodecim libras argenti. *Ita habetur. l. penul. C. de seru. fugitiu.* & affirmat glossa vlt. citata, atque de eiusmodi mancipio est intelligenda. *l. 28. citata in secunda sui parte, quæ idem statuit, vt affirmat ibidem Gregor. Lopez glossa. 2.* Qui autem similiter receperit aut occultauerit mancipium ciuitatis, aut alterius oppidi, vltra illud, soluit ei communitati aliud æquè bonum, & insuper duodecim solidos. *Ita habetur. l. mancipia. C. de seruis fugit. & l. 28. cita.* quæ, vt Greg. Lopez ibi. glossa. vlt. rectè obseruat, est corrupta, loco enim duodecim solidorum, corruptè habet *doze libras de oro.*

Circa hactenus dicta est obseruandum. Crimen explicatum recipiendi, aut occultandi, mancipium alienum, simul esse crimen plagii, vt ex supradictis facilè constat. Ei autem, cui actio competit, ad pœnam exigendam, vindicandumque eiusmodi crimen, integrum est, vel agere criminaliter ad pœnam plagii, vel agere ciuilitè ad pœnas recipientibus, aut occultantibus, seruos alienos titulis de seruis fugitiuis statutas. Ad vtrasque verò simul agere non poterit: neque ad ciuiles post criminales, aut è contrario: Tametsi, vltra pœnam criminalem, exigere possit damnum, si quod ex tali crimine accepit.

Illud obserua, cùm seruus fugitiuus in hoc sen [sect. 9] su furtum sui domino efficiat, quòd libertatem non consequatur, etiamsi ad suos transeat, vt Disp. 37. copiose ostendimus, dominiumque illius dominus, à quo aufugit, retineat, teneaturque seruus se illi in conscientia, & in exteriori foro, restituere, ac proinde semper sit in mala fide, quòd liber non sit, sed ad suum dominum pertineat, vtique ipse, neque tribus, neque decem, neque viginti annis præscribere libertatem potest aduersus suum legitimum dominum. Atque hoc est, quod intendunt ac tradunt. *l. 1. C. de seru. fugit. l. 23. titu. 14. part. 7. & l. 23. titu. 29. part. 3.* Hæ tamen duæ leges huius Regni statuunt, tempore triginta annorum præscribere libertatem cum ea mala fide; id quod asseruit glossa. *l. 1. C. de præscrip. longi temp. quæ pro libert.* Contrarium tamen non dubito esse verum, tum in conscientia, tum etiam in exteriori foro: eo quòd cum mala fide inualida sit præscriptio, præsertim post iuris canonici dispositionem: id quod notat Grego. Lopez. *l. 23. titu. 39. citata. glossa penult.* Atque hæc adiunge iis, quæ diximus in calce Disp. 71.

Cum hactenus dictis coniunctum est, vt ali [sect. 10] quid dicamus de corruptione seruorum, qua ab aliis corrumpuntur, consilio, aut alia ratione, ita vt moribus mali aut deteriores fiant, vel etiam prorsus inutiles. Et quidem, qui dolo malo, in sensu in præcentibus explicato, ita in causa est, vt seruus malus aut deterior fiat, esto seruus promptus & aptus ex se esset, vt id efficeret, si tamen consilio, aut alia ratione, ad id adiutus atque inductus fuit, corruptor serui tenetur domino serui ad duplum damni. Ita videlicet, quòd, si eo consilio, inductione, vel adiutorio quauis alia ratione, seruus furatus est, aut aliud damnum dedit, siue domino, siue cuicunque alteri, tenetur corruptor ad duplum eius damni, quod proximè ex ea inductione, aut adiutorio, sequitur: non verò tenetur ad damna, quæ postea fuerit patrat, esto remotè

ex illa inductione sequuta sint, vt quia mansit prauè ad id efficiendum affectus, audaxve ad simile quid iterandum, *vt habetur. l. Neratius. ff. de seruo corrup.* Insuper, si seruus ipse mansit in se deterior aut inutilis, quia minus æstimabitur, & minus valet, vel prorsus nihil, postquam ita corruptus est, tenetur domino ad duplum minoris illius æstimationis, ac damni serui in se. Neque, quòd dominus priùs egerit, vel actione furti, vel alia, ad duplum furti, vel alterius damni à seruo ea inductione dati, tollitur, aut minuitur, hæc alia distincta actio, vt eadem. l. Neratius, subiungitur. Neque quòd is, qui ita corrumpit seruum alienum, arbitratus fuerit esse liberum, impedit quo minùs dominus serui agere possit ad duplum damni ex ea corruptione sequuti. Ratio autem est, quoniam ex illa iniqua corruptione, facta per inductorem, id totum damnum sequutum est. *Ita habetur. l. doli. §. si quis. ff. de seruo corrup.* Atque, quòd actio dupli competat domino serui corrupti ad totum damnum explicatum, ita scilicet vt simplum, quod in eo duplo includitur, debeatur tanquam damnum iniustè datum, atque adeò debeatur, non solùm in exteriori, sed etiam in conscientiae foro, nulla expectata sententia: aliud verò æquale insuper debeatur solùm in pœnam, ac proinde dependenter ex eo, quòd feratur sententia, *habetur. l. 1. & sequentib. ff. de seruo corrup. & l. 29. titu. 14. part. 7.* quibus in locis res hæc multis adhibitis exemplis explicatur.

Hæc eadem actio competit parentibus aduer [sect. 11] sus eos, qui ipsorum corruperint filios, nepotes, & alios liberos ipsorum familias, vt scilicet agant ad duplum damni ex ea corruptione sequuti. *Ita habetur. l. vt tantum. §. 1. ff. de seruo. corrup. & l. [[20]] 29. citata.* Quin lex 29 etiam extendit eam actionem, vt competat domino aduersus eum, qui illi corrupetit famulum, aut famulam, sibi mercede aut gratis seruientem.

Furtum an ex genere suo sit culpa lethalis. Et de quantitate requisita, vt culpa let halis sit. Disp. 685.

SVMMARIVM.

1. *Furtum, rapina, & damnum datum, peccata sunt ex suo genere lethalia. Et licèt furtum ex suo genere leuius peccatum sit cæteris, quæ sunt contra præcepta decalogi, ex circumstantiis esse potest grauius.*
2. *Furti quæ quantitas sufficiens ad culpam lethalem, comparatione eorum, qui non pingues habent facultates.*
3. *Furti actio an detur pro vna gallina, & similibus rebus, & qualis concedatur.*
4. *Furtum vt sit culpa lethalis, maior quantitas requiritur comparatione opulenti, quàm comparatione habentis tenues facultates.*
5. *Furtum de quacunque re leui, si verè sit furtum, culpa est venialis. Et quousque obligatio sit illud restituendi sub veniali culpa.*
6. *Furtum rei modicæ, quando ob damnum vltius sequutum est culpa lethalis, cum onere restituendi etiam damnum. Comparatione tamen damni locum non habet pœna furti, sed legis acquilie: neque item excommunicatio lata profurte, non facta mentione de damno.*

7. *Qui leue quid furatus est, cum animo furandi quantitatem, quæ ad culpam lethalem sufficeret, lethaliter peccauit. In foro verò exteriori solùm datur actio furti pro eo, quod est furatus.*

8. *Furtum rei minimæ, ob tristitiam inde ac culpam eius, qui id furtum est passus, quando culpa lethalis.*

FVrtum, damnum iniustè datum, (de quo [sect. 1] infra erit sermo) & multo magis rapinam,

ex suo genere culpas esse lethales, affirmat D. Th. 2. 2. q. 66. art. 6. nullusque est, qui dubitet. Sunt enim contra proximi caritatem, iustitiam violant, pacemque Reipublicæ, illiusque tranquillitatem, perturbant. Id quod inde etiam confirmatur, quòd septimo decalogi præcepto prohibentur: decalogi autem præcepta, ea continent, quæ ad vitam æternam consequendam sunt necessaria, iuxta illud Matth. 19. *Si vis ad vitam ingredi, serua mandata*: vita verò æterna non, nisi per lethalem culpam, amittitur. Vnde Paul, 1. ad Corin. 7. *Neque fures, neque rapaces, Regnum Dei possidebunt*. Est nihilominus furtum leuius peccatum ex obiecto, non solùm quàm peccata, quæ sunt contra præcepta primæ tabulæ, sed etiam quæ sunt contra reliqua præcepta secundæ tabulæ, etiam quàm simplex fornicatio. Ratio autem est, quoniam reliqua peccata, quæ præceptis secundæ tabulæ aduersantur, vel sunt directè contra proximi personam, aut contra personas eis coniunctas, (etiam fornicatio simplex est contra bonum prolis generandæ) vel sunt contra bonum honoris ac famæ; quæ omnia præstantiora bona sunt, quàm bona externa, in quibus per furtum læditur. Ex magnitudine tamen obiecti, & ex aliis circumstantiis concurrentibus, esse aliquando potest furtum grauius peccatum, etiam quàm homicidium.

Quia tamen, quamuis peccatum aliquod [sect. 2] ex suo genere culpa sit lethalis, ex paruitate ac leuitate materiæ reddi potest venialis, vt 1. 2. q. 72. art. 5. *ostendimus*; dubium est, quæ valoris quantitas necessaria sit, vt furtum culpa sit lethalis: idem suo modo intellige de rapina, & damno iniustè dato. Vt autem art. 5. citato dicebamus, res hæc non potest in hac vita certò indiuisibiliter definiri: quoniam neque id certò potest in hac vita cognosci. Cognoscunt quidem in hac vita sapientes, furari obolum, aut vnum racemum vuarum, de se non esse culpam lethalem: quia nec est tanta læsio, nec tanta proximi iniuria, vt ea de causa, qui ita delinquit, exhæredandus sit vita æterna, æternisque cruciatibus sit mancipandus. Cognoscunt item, furari viginti aureos, esse lethale peccatum: quia est notabilis læsio ac iniuria proximi. Cæterùm meritò dubitant, num furari duos regales argenteos sit lethale peccatum, neque possunt certò id definire. Et multo minùs possunt certò definire in indiuisibili, quæ summa valoris sufficiat ad culpam lethalem, ita vt quæcunq;, infra illam, ad culpam lethalem non sufficiat. Quare in re, de qua disputamus, semper est abstinendum, tamquam à culpa lethali, à furto, de cuius quantitate meritò aliquo modo dubitatur, an sit sufficiens ad culpam lethalem. Atque ad cautelam, est necessariò aperiendum tale furtum in confessione, si quis in illud incidat, vt art. 5. dicebamus.

Quidam Dominico à Soto. 5. de iust. q. 3. art. 3. ad. 3. *tribuunt*, existimasse, quantitatem, quæ secundùm se, & comparatione quorumcunque, qui damnum in ea iniustè paterentur, sufficeret ad culpam lethalem, esse duos, aut tres, ducatos, atque adeò furtum duorum aut trium ducatorum esse culpam lethalem, etiam si quis eos à Rege potentissimo furetur. Quantitatem verò, quæ in furto sufficit ad culpam lethalem, non secundùm se & comparatione quorumcumque, sed solùm si quis eam furetur à miseris personis, esse vnum regalem argenteum, aut duos. Et quamuis Nauar. locis citandis, & alii, arbitrentur, Sotum

id non intendisse, sed solum exempli gratia id protulisse: certè mihi verisimile omnino est, eum in ea fuisse sententia. Tum quia eam videtur mutuatus à Syluestro verb. *furtum. n. 5.* qui apertè in ea fuit sententia. Tum etiam quoniam à viris doctis in similibus materiis, & eo modo, quo loquutus est Sotus, non solent apponi exempla, nisi iuxta id, quod verisimiliter credunt. Præterea Sotus apertè fuit ibi in ea sententia vt crederet, maiorem quantitatem esse necessariam ad culpam lethalem furando à diuitibus, quàm furando à pauperibus; ac proinde eam, quæ sufficeret ad culpam lethalem, furando ab illis, qui tenues habent facultates, non sufficere ad culpam lethalem, furando à Regibus: in eademque sententia fuerunt. *Syluester vbi supra, & Ioan. Medi. de rest. q. 10. §. antepenult.* Tametsi Med. ausus non fuerit definire quantitatem ad culpam lethalem necessariam, sed illam reliquerit arbitrio prudentis definiendam. Est verò satis rationabilis ac vera ea sententia, quæ affirmat, maiorem quantitatem requiri ad culpam lethalem in furto facto diuiti, quàm in furto facto pauperi. Itaque Sotus affirmavit, quandam esse quantitatem, quæ comparatione omnium hominum, etiam Regum potentissimorum, sufficeret ad culpam furti lethalem: eamque, cum Syluestro, explicauit, dicens, vt verbi gratia, si sit duorum aut trium ducatorum. Et quandam aliam esse, quæ, non comparatione quorumcunque, sed quorundam duntaxat, ad id sufficeret. Atque explicans vltimam, quæ (seclusa quacunque alia circumstantia alterius iacturæ ac damni iniusti) sufficeret comparatione tenuium ac miserabilium personarum, non verò comparatione aliorum, dixit, vt si sit quantitas vnus regalis argentei, aut duorum. Quare voluit, proportionem quadam esse iudicandum de intermediis quantitibus inter hanc vltimam, & illam aliam, quæ sufficit comparatione omnium, vt pro quantitate diuitiarum hominum, qui sunt inter tenues ac miserabiles ex vna parte, & inter Reges potentissimos ac ditissimos ex alia, arbitraremur, spectatis diuitiis cuiusque, & aliis circumstantiis concurrentibus, vt qualitas status cuiusque, ac multitudo, vel paucitas, liberorum, & aliis similibus, quæ quantitas intermedia sufficeret, aut non sufficeret, ad culpam lethalem comparatione cuiusque eorum. *Nauar. in Manu. c. 17. n. 3. & in Cõment. c. vlt. 14. q. 6.* arbitratur, ad culpam lethalem furti sufficere comparatione quorumcunque valorem duorum regaliū argenteorum. Imò, ad effectum, vt reputari, aut timeri, debeat, culpa lethalis, atque vt aperiri in confessione debeat, iufficere valorem vnus argentei, atque etiam dimidii. De quarta autem parte vnus argentei ait, non sufficere ad culpam lethalem. De quantitibus verò intermediis inter quartam partem regalis argentei, & dimidium regalem, ait, se non condemnaturum eum, qui affirmaret, eas non sufficere ad culpam lethalem. Est verò nimis arcta & scrupulosa hæc Nauarri opinio. Vt ad confessionum praxim dicam, quod sese mihi offert, & quod facere consueui. In primis arbitror, rem hanc definiendam non esse quantitate pecuniæ. Vt enim Disp. 406. ostensum est, minimè variata pecunia, quoad valorem vnicuique earum à Republica constituto, accrescit, & decrescit, valor illius multitudo aut paucitas illius: plusque valet ad reliquas res emendas, vbi minus est pecuniæ, quàm vbi est maior illius abundantia: eaque de causa minus valet hodie in Hispaniis, propter maximam illius copiam asportatam ex Nouo orbe, quàm valuerit quadraginta antea annis, & longè adhuc minus, quàm valuerit octoginta antea annis. Quæ enim octoginta antea annis emebantur, aut conducebantur, vno, non emuntur, neque conducuntur, hodie quinque, aut etiam sex. Hodie item, vbi est maior copia pecuniæ, minus valet, quàm vbi est minor illius copia. Vt minus valet in Nouo orbe, maximè in Peru, quàm in Hispaniis. Et minus valet Hispali, quò appellunt naues ex Nouo orbe, & vbi est maxima illius abundantia, quàm in reliquo Hispaniarum. Et minus valet Olyssipone, quàm in regione, quæ est inter Durium & Minium, aut in Bera, quam in Lusitania vocant: eo

quòd his in locis minor sit copia pecuniæ, viliusque eâ res emantur, aut conducantur, quàm Olyssipone. Eodem etiam modo, non est idem valor pecuniæ in reliquis Hispaniarum locis: sed quo regiones, ciuitates, & oppida, minùs abundant pecunia, eo plus valet, viliusque res illa emuntur, & conducuntur: & quo plus ea abundat, eo minus valet, cariusque res ea emuntur, ac conducuntur. Quo fit, vt ad definiendam summam, quæ satis sit, vt furtum sit culpa lethalis comparatione omnium locorum ac temporum, non sit apta ac certa regula dicere, esse certam pecuniæ quancitatem, vt duos, tres, vel quatuor, regales argenteos. Quoniam vbi minus valent, ob maximam pecuniæ abundantiam, minor læsio minorque iniuria proximo fit in furto valoris summæ eius pecuniæ, quàm vbi plus valent: & vbi plus valent, ob pecuniæ magnam penuriam, maior læsio maiorque iniuria proximo fit in furto eius valoris summæ pecuniæ, quàm vbi minus valent. Et in Hispaniis longè maior læsio atque iniuria proximo fiebat in furto quatuor regalium argenteorum ante octoginta annos, quàm nunc fiat: eo quòd, quæ tunc emebantur, aut conducebantur, quatuor regalibus argenteis; non emantur, neque conducantur hodie, si cæteræ circumstantiæ sint pares, sedecim, imò neque viginti argenteis. Quare, sicut in furto tritici inepta esset regula quoad omnia loca, & tempora, dicere, quòd, qui furatur tantam quantitatem, putà quartam fanecæ partem, peccat lethaliter, qui verò minorem quantitatem furatur, non peccat lethaliter, eo quòd quarta fanecæ pars in vno loco valeat duplo, triplo, aut quadruplo, quàm in alio: & in vno eodemque loco, vno tempore valeat duplo, triplo, aut quadruplo, quàm in alio: propter maiorem tritici, aut minorem, abundantiam in diuersis locis, aut in vno & eodem loco diuersis temporibus: ita non est apta regula comparatione omnium locorum ac temporum, ad definiendum, quando furtum ex parte materiæ culpa sit lethalis, aut non, constituere certum valorem pecuniæ lege taxatum: quoniam hic, comparatione diuersorum locorum, ac temporum, multum accrescit, ac decrescit, ad cæteras res emendas, ac conducendas, perseuerantibus eisdem circumstantiis, hacque vna duntaxat variata, quod sit maior, aut minor, pecuniæ abundantia, vt dictum explanatumque est.

Dicerem ergo, tantam pecuniæ quantitatem, illiusve valorém, quæ in vnoquoque loco sufficit ad conducendas operas vnus diei fossoris terræ tempore, quo non est magna penuria, neque abundantia, eorum; qui se ad id locent, & quo pre-[[22]]tium, pro qualitate regionis, solet esse moderatum, videri quantitatem notabilem ad constituendum peccatum lethale comparatione eorum, qui non pingues habent facultates. Hoc autem aliquibus in regionibus, vel locis, aut oppidis, erunt quatuor regales argentei, alicubi tres, alicubi duo, & alicubi vnus cum dimidio, & alicubi plus, aut etiam minus: & in vno atque eodem loco, vno tempore erit plus, & alio minus, pro abundantia, aut penuria, pecuniæ in eo loco temporum successu. Cæterùm, quoniam non potest in hac vita attingi certò punctum indiuisibile, ad quod si summa valoris perueniat, furtum erit culpa lethalis, & infra quod non erit culpa lethalis, sanè quemadmodum non iudico improbabile, quòd fortè in oculis Dei maior valoris summa requiritur, vt furtum sit culpa lethalis: ita improbabile non iudico, quòd fortè minor valoris summa sufficiet. Hac de causa, in confessionibus, quando vnum solum, aut alterum, furtum examinandum occucrit, interrogo quantitatem valoris illius. Quando verò multa occurrunt examinanda, interrogo quantitatem valoris omnium simul, plus minus: postea verò interrogo, quoties furando valorem regalis cum dimidio, aut duorum regalium (aut aliquid plus, vel minus, pro regionis, aut loci, qualitate) ad eam summam totam peruenerit, Atque ita facilè verisimiliter conjicio, tum numerum lethalium peccatorum, tum etiam latitudinem culpæ omnium simul ex parte circumstantiarum, quæ illam possunt augere ratione quantitatis

obiecti. Interrogatoq; insuper vno, aut altero, alio verbo, si quid aliud hac in parte (iuxta ea quæ dicenda sunt) occurrat examinandum, breuiter, ac sine confitentium molestia, examino simul multitudinem quamcumque peccatorum in hac materia.

Possumus confirmare, hanc nostram sententiam consonantem esse rectè rationi ac veritati. Primò, quoniam, ex omnium sententia, tunc furtum est lethale peccatum, quando quantitas est notabilis: quantitas autem à nobis explicata non leuis, sed notabilis, censetur: eo quòd sit, quod hominibus communibus sufficit ad sustentationem ac sumptus ordinarios vnus diei. Secundò, quoniam, vt Nauarrus vbi suprà, & alii, referunt, Synodalibus constitutionibus aliquorum episcopatum sancitum est, vt nullus excommunicetur pro minori summa furto ablata, quàm duorum regalium argenteorum, & alicubi, vt non excommunicetur pro minori summa, quàm centum maravedinorum: cum ergo ratio earum constitutionum sit, quia excommunicatio pro furto restituendo ferri non possit, nisi culpa sit lethalis illud abstulisse, & non velle illud restituere; consequens est, vt, qui eas constitutiones statuerunt, arbitrati sint, minorem summam, quàm illam, quæ eo tempore pro operibus vnus diei tradi fossori consueuerat, non sufficere ad culpam lethalem, eam verò sufficere. Atque fortasse id eo tempore erat paulo plus, quàm quod eo stipendio tradi tunc consueuerat: quoniam expediebat, rem securè statuere. Hodie verò, cùm à quadraginta annis valde in Hispaniis decreuerit valor pecuniæ, longè maior summa statuatur, statuique consuevit: quoniam expedit, vt pæna illa non statuatur in eo euentu, nisi pro aperta culpa lethali. Tertiò, à quibusdam confirmatur ex. §. *gallarum inst. de rerum diuis.* vbi pro vna gallina, furto ablata, furti actio conceditur: vt communis sententia affirmat, quam, inter alios, refert ac sequitur *Iulius Clarus lib. 5. sent. §. furtum. n. 23.* quare, cùm actio non concedatur, nisi pro culpa lethali; & gallinæ valor in vnoquoque loco, ac tempore, esse soleat tantus, aut ferè, quantum in eodem loco tradi fossori consuevit pro operibus vnus diei; consequens est, vt rectè à nobis taxata sit quantitas, quæ in furto sufficit ad culpam lethalem. Vnde *Couar. 1. var. resp. c. 3. nu. 12.* affirmans, furti actionem non concedi pro quantitate, quæ minima sit, nec sufficiat ad culpam lethalem, subiungit, gallinæ valorem minimum non esse iudicandum, & quod ad lethalem culpam non sufficiat. Neque refert, quòd actio de dolo non concedatur pro duobus aureis, vt habetur. *l. si oleum. §. ult. tunctis tribus legib. sequentib. ff. de delo,* hoc est, pro duobus solidis, seu *Castellanos*, vt ibi exponit glossa. Quoniam sicut aduersus vendentem vltra, aut ementem infra, iustum pretium, non datur in foro exteriori actio, si non sit vltra, aut infra, dimidium iusti pretii, ne lites multiplicentur: ita neque datur actio de dolo vsque ad illam summam, ad dolosum puniendum: tametsi detur actio in factum, vt restituat, quod dolosè accepit, aut nocuit, vt habetur iuribus citatis: longèque maior ratio erat, vt pro minori summa concederetur actio furti, quàm de dolo, in quo non interueniret furtum, aut grauius aliud delictum.

Illud tamen admonuerim, ex. §. *gallarum*, [sect. 3] non colligi pro vna sola gallina dari actionem furti. Tum quia textus ille loquitur de gallinis in plurali. Tum etiam quoniam ibi non asseritur dari actionem furti, sed committi furtum, si quis inueniens gallinas alicuius dispersas, eas accipiat animo sibi illas retinendi: eo quòd dispersio earum non priuet dominum earum antiquum dominio illarum: id quod verissimum est. Solumque in eo. §. constituitur discrimen inter anseres domesticos, & gallinas domesticas, ex vna parte, & inter anseres, & gallinas, sylvestris ex alia parte: quòd hæc animalia in nullius sint dominio, sed fiant primò occupantis: illa verò sint in dominio possessoris, etiam si dispergantur, ac proinde verum furtum fiat in earum occupatione animo sibi illas occupandi. Arbitror verò

pro vna tantum gallina non ita concedi actionem furti, vt, damnatus, maneat infamis, aut vt publicè flagellari debeat pro eo crimine: sed solum vt eam restituat, aut etiam soluat duplum, vel quadruplum, prout crimen occultum fuerit, aut manifestum, vel certè in publico loco constituetur cum illa appensa collo, vt ipsi id sit in pœnam, & aliis in exemplum. vt vidi aliquando ea pœna affici duos homines, qui de nocte furtum vuarum fecerant in vineis, & à ministro publico, quem *alguazil* vocant, fuerant cum furto deprehensi: non tamen hi manent infames propter tale furtum ac pœnam.

[[23]] Illud est addendum, mihi satis probabilem [sect. 4] ac veram videri opinionem Soti, Medinae, & Syluestri vbi suprâ, quæ fuit etiam *Victoriae*. 2. 2. q. 66. art. 6. nempe summam, quæ sufficit ad culpam lethalem in furto facto habenti tenues facultates, non sufficere ad culpam lethalem in furto facto Regi, aut alii opulento, sed pro quantitate diuitiarum eius, cui fit furtum, spectatis aliis circumstantiis, modo explicato suprâ expendendo Soti opinionem, arbitrandam esse maiorem, aut minorem, summam, quæ ad culpam lethalem sufficiat. Quia verò non solum punctum indiuisibile attingi non potest in hac materia, sed neque quicquam omnino certum potest statui, non auderem in praxi confessionum, quenquam absolvere, qui vnum ducatum fuisset à Rege furatus, & non haberet verum animum eum ei cum effectum restituendi, imò neque eum, qui dimidium esset ab eo furatus.

Illud insuper admonuerim, furtum de qua [sect. 5] cumq; re leui, esse culpam venialẽ, si verè sit furtum, quia videlicet rei dominus est rationabiliter inuitus. Essequè proinde id sub culpa veniali restituendum, si dominus rei præsumatur, etiam post id veniale furtum commissum, velle vt restituatur, & non sit causa legitima, quæ excuset: quia videlicet, qui id commisit, longè distat, neque sine sumptu, aut graui molestia, potest id efficere: tunc verò restitui id debet pauperibus, aut insumi debet in re alia pia, pro anima domini, si præsumptio sit, dominum id ita velle.

Obseruandum verò est, quamuis furtum de [sect. 6] re modici valoris non sit lethalis culpa, si tamen coniunctum habeat damnum notabile, etiam lucri cessantis, erit lethalis culpa, cum onere restituendisub lethali culpa, latitudinem totius valoris. Vt si quis furetur à sartore acum, à sutore subulam, à scriba calamum, eoque furto in causa sit, vt perdant operas eius diei, aut plurium dierum, quia non habent aliud instrumentum, quo operentur, vtique si ad id damnum attendit, aut attendere debuit, lethaliter peccauit, restituereque tenetur id totum damnum, tanquam causa iniusta illius. Si verò probabiliter id damnum ignorauit, tunc, cum non fuerit causa iniusta illius, neque comparatione talis damni locum habeat teneri ex parte rei acceptæ, sanè ad restitutionem illius non tenebitur, sed solum ad restitutionem rei modici valoris acceptæ, si ita is velit, ex quo fuit furto ablata. In foro verò exteriori, licèt ratione rei furto ablata, locum haberet pœna furis, dupli, si furtum esset occultum, & quadrupli, si esset manifestum, resque esset tanti valoris, vt illius habenda esset ratio, iuxta ea quæ suprâ dicta sunt; comparatione tamen damni iniustè vterius dati, non habet locum pœna furis, sed legis Aquiliæ, damni que dati, de quo infrâ erit sermo, & Nauar. in Manu. c. 17. n. 2. obseruat. Non tamen voluerunt contrarium Sylvester & Sotus, vt Nauar. illis tribuit. Illud etiam cum eodem Nauar. obserua, si ad petitionem eius, à quo id esset furto ablatum, lata esset excommunicatio aduersus eos, qui res illius furto abstulerunt, nec restituunt, cum non comprehendere illos, qui rem modicam furto abstulissent, sicèt ex eodem furto subsequutum esset domino damnum notabile; quia damnum non est furtum: secus autem si excommunicatio esset lata, etiam aduersus illos, qui damnum notabile iniustè dedissent, nec illud restituerent.

Quando aliquis solùm esset furatus paruam [sect. 7] aliquam quantitatem, quæ, iuxta hactenus dicta, ad lethalem culpam non sufficeret, si accessit cum animo furandi maiorem, si illam reperisset, aut si eam furari potuisset, ut ique lethaliter peccat, ut ex se est notissimum, doctoresque communiter affirmant: atque id est, quod voluit *Hiero. 14. q. 6. c. ult.* Quare in confessionibus, quando aliquis reperitur in peccata furti incidisse, examinandus est, quoties accesserit animo furandi quantitatem notabilem: quia toties lethaliter peccauit. In foro tamen exteriori, solùm datur actio furti circa id, quod furatus est, non verò circa id, quod furari intendit, ut patet. *l. vulgaris in prin. & §. 1. ff. de furtis.*

Nauar. n. 2. citato, & quidam alii, affirmant, [sect. 8] si dominus rei minimæ, quæ ad culpam lethalem non sufficiat, ægre ferat furtum illius, quia scilicet multum eam diligit, posse ex eo capite interuenire culpam lethalem. Cæterum, si non erat unde fur id præsumere deberet, non est cur condemnari ex eo capite debeat culpæ lethalis, quicquid postea sequatur. Quòd si erat verisimile, dominum rei illius, occasione talis furti, vel ira, vel passione alia, in lethalem culpam ruiturum, tunc lethaliter peccabit contra proximi caritatem, qui, id sciens, tale furtum commiserit, quatenus, ab eo furto abstinendo, impedire potuit, ac debuit, id lethale peccatum. Propter solam tamen molestiam domini rei furto ablata non facilè condemnare lethalis culpæ eum, qui rem minimam esset furatus, maximè cum dominus eius rei inordinate, & sua culpa, usque adeò tristetur. Tanta nihilominus timeri posset tristitia domini rei ante furtum patratum, ut timeri etiam posset, culpam lethalem in eo furto interuenire.

De furtis dome sticorum. Et num ob illa actio furti competat aduersus domesticos. Et quid de ementibus, aut alio titulo accipi#tibus, eas res à domesticis. Et quæ quantitas sufficiat, ut eiusmodi furta culpæ sint lethales. Et num excommunicatio à patre familias obtenta, pro rebus sibi furto ablati, comprehendat eiusmodi furta. D p. 686.

SVMMARIVM.

- 1 . *FVrta domestica quæ. Sunt verè furta, neque vsucapi res ita furtiue aduersus verum dominum possunt, nisi triginta annis.*
- 2 . *Furtum domesticum quando vxor aduersus maritum committat. Tunc autem competit aduersus illam actio, ut id reddat, cum damnis inde sequutis, non verò furti actio ad vllam pœnam: licèt maritus punire moderatè illam possit.*
- 3 . *Furtum domesticum quando filius familias committat, & quando restituere illud in conscientie foro teneatur. Pro illo puniri a patre [[24]] moderatè potest. Et cogi à iudice illud reddere si extet. Actio in factum conuenit aduersus eum, ut illud & damna soluat, si habeat castrensia, aut quasi castrensia bona. Idem de furto facto à filio emancipato, & de furto facto à patre filio suo. Locum tamen non habet in his euentibus actio ad vllam pœnam.*
- 4 . *Furtum domesticum si mancipium committat, moderatè puniri potest à domino. Et quando criminaliter posset facere illud puniri a Iudice. Si mancipium bona propria haberet, actio etiam ad pœnam furti pecuniariam aduersus illud competeret.*

- 5 . *Furta domestica famulorum, aut aliorum mercede conductorum, liberti, aut patroni, si modica sint, moderatè ea punit paterfamilias domus, & datur actio in factum ad rem, & ad damna sequuta, non verò furti ad ullam pœnam. Si autem sint magna, iudex procedit ex officio ad illa punienda pœna ordinaria, & competit actio furti. Et quæ magna censenda.*
6. *Furtum domesticum uxoris, liberorum, aut mancipii, etiam si magnæ quantitatis sit, locum nõ habet pro eo actio furti ad pœnam.*
- 7 . *Furto domestico remablatam, si quis sciens alienam esse, illam emat, aut alio titulo comparet, tenetur illam restituere domino. Si autem bona fide illam accepit, quousque restituere teneatur. Et quousq; in eis euentibus venditor teneatur emptori de euictione.*
- 8 . *Emere, quæ præsumuntur furtiua, præsertim furto domestico, sub quibus pœnis prohibitum.*
9. *Ad furtum domesticum si aliquis non domesticus cooperetur, competit aduersus illum actio furti.*
- 10 . *Furtum quando domestici non committant, & quando non lethale. Et quando domestici restituere teneantur, aut non teneantur, quod accipiunt inuito domino.*
- 11 . *Furtum domesticum vt ad culpam pertingat lethalem, maior quantitas est necessaria, quàm in aliis furtis. Neque in omnibus domesticis sufficit eadem quantitas.*
- 12 . *Ob furtum quando lata est excommunicatio nisi intra tantum tempus restituatur, & domesticus, aut aliter coniunctus, furatus est, quando ea excommunicatio censenda sit, aut non sit, eum li gare.*
- 13 . *Furtum domesticum qui commisit, nisi sibi omnino persuadeat, dominum contentum fore, vt non restituat, restituere tenetur, aut obtinere ab eo remissionem.*

DE furtis domesticorum, qualia sunt, quæ ab [sect. 1] vxore committuntur de bonis mariti, à filiis de bonis parentum, à mancipiis de bonis dominorum, & à famulis mercede conductis de bonis eorum, quibus seruiunt, quin & à libertis de bonis patronorum, dubium est num sint peccata lethalia, & num in eis maior requiratur quantitas, vt ad culpam pertingant lethalem. Atque in primis statuendum est, esse verè furta, quando fiunt inuitis iis, quorum sunt ca bona, esseque eiusdem speciei cum aliis furtis, vt tracta. 1. disp. 7. dictum est. Quare, sicut cæteræ res furto ablata, etiamsi venditione, aut alio titulo, transeant in bonæ fidei possessorem, aut possessores, præscribi ab eis nequeunt minori tempore, quàm triginta annorum, in quo toto bona fide fuerint possessæ, vt Disp. 79. ostendimus: ita eiusmodi res furto ab vxore, à filiis, aut ab aliis domesticis ablata, & in alios venditione, aut alio titulo, translate, præscribi non possunt, nisi completis triginta annis à puncto, quo bona fide possideri cæperunt. Hæc omnia habentur. §. *hi qui. inst. de obligat. quæ ex delict.* cuius verba sunt: *Hi qui in parentum, vel dominorum, potestate sunt, si rem eis surripiant, furtum quidem faciunt, & res in furtiuam causam cadit: neque ob id (quia scilicet est furtiua) ab ullo vsucapi potest, antequam in domini potestatem reuertatur.* Intellige de præscriptione longi temporis, triennii, decennii, aut viginti annorum: secus autem de præscriptione longissimi temporis triginta, aut plurium annorum, vt cum quadam glossa, & communi doctorum sententia Disp. 79. citata dictum est. Præterea, quòd dicitur, *antequam in domini potestatem reuertatur*; quod de rebus omnibus furto à quocunque ablati est accipiendum, vt constat ex dictis Disputatione citata, & ex iuribus mox citandis, intelligendum est, de verò domino

rei: quare, esto res furto fuerit ablata ex creditore, cui in pignus erat data, aut ex alio, qui illam retinebat, & qui agere poterat actione furti aduersus furem, non satis est, vt vsucapi possit minori tempore, quàm triginta annorum, quod ad illos reuertatur, sed necesse est, vt ad verum dominum reuertatur. *Ita habetur. l. sequitur. §. quod autem. ff. de vsucap.* Si tamen dominus rei, intentata lite, æstimationem rei furtiuæ accepit, aut illam vendidit furi, tunc vsucapi potest tempore ordinario. *Ita habetur l. quamuis. ff. de furtis, consentit. l. si fur. ff. de usu cap.* Atque hæc adiunge dictis Disp. 79. citata.

Quod ad vxorem attinet. Si non excedat ea, [sect. 2] quæ Disp. 274. ei licere diximus, furtum non committit, etiam in bonis sibi cum marito communibus in his Castellæ & Lusitaniæ Regnis. Iura autem Cæsarea potissimum loquuntur, stando in solo iure communi, iuxta ea quæ disputatione citata explanata sunt, quando videlicet, præter omnia bona viri, & quæ lucrabatur tempore toto constantis matrimonii, fructus dotis ad eum solum spectabant toto eo tempore, quin & dos ipsa quousq; matrimonium dissolueretur, & nihil horum ad vxorem attinebat. Quamuis autem, si vxor aliquid de bonis mariti, ipso inuito, accipiat, furtum committat, *vt habetur. l. 1. ff. rerum amot.* teneaturque id viro reddere, non solum in conscientiæ, sed etiam in exteriori foro, si ita vir velit; nihilominus iura noluerunt concedere viro actionem furti aduersus vxorem, ad pœnam dupli, quadrupli, aut ad aliam aliquam, si furtum committat interim dum inter eos constat matrimonium, per diuortium non separatum, sed solum vt repetere posset ab ea ablatum, & quodcunque damnum ab ea ei iniuste datum. *Ita habetur. l. qui seruo. §. item placuit. l. si quis vxori in prin. ff. de furtis. l. 1. ff. rerum amotar. l. ult. §. ult. & l. 4. titul. 14. part. 7.* Cuius rei rationem reddit. *l. 2. ff. rer. amot. dicens: Nam in honorem matrimonii, turpis actio aduersus vxorem negatur.* Concinit. *l. 2. C. eod. titu.* vbi ita scriptum legitur: *Constante etenim matrimonio neutri eorum* (neque viro scilicet aduersus vxorem, neque vxori aduersus virum) *neq; pœnalis, neque famosa, actio conceditur, sed de damno in factum datur actio;* hoc est, vt solum reddat simplum damnum, [[25]] quod furto, aut aliquo alio delicto, vxor marito dedit, velmaritus vxori: id quod de vxore habetur etiam *l. ult. ff. de seruo corrupto.* Eadēq; actio cōpetit vxori aduersus virum, si, constāte matrimonio, damnum iniuste inferat bonis vxoris, vt ex verbis ex *l. 2. C. rerum amotarum* relatis cōstat. Obserua verò, quòd cū vxor sub viri sit potestate constante matrimonio, etiam vt corporaliter punire eam possit moderatē proquātitate delicti, & qualitate vxoris, spectatis cæteris circumstantiis concurrentibus, vtique, pro quātitate, & qualitate furti, punire eam poterit moderatē, *vt habetur l. 4. titu. 14. part. 7.* non tamen eam mutilando, & multo minùs interficiendo.

Quod verò ad filiosfamilias, & ad mancipia, [sect. 3] attinet. Inprimis ex dictis Disp. 234. 242. & 277. liquet, quousq; filius familias licitè insumat, aut non insumat, sua, vel patris, bona, ac proinde facilè inde intelligetur, quousque filius familias furtum committat, aut non committat, aduersus patrem, atque adeò, quousque restituere teneatur, aut non teneatur, patri, aut fratribus post mortem patris, ablata, & malè consumpta, de bonis patris, aut quæ ad patrem, saltem quoad vsumfructum, attinebant. Quauis autem, tam filiifamilias, quàm mancipia, furtum committant aduersus patrem, aut dominum, si aliquid irrationabiliter subtrahant, aut vsurpent, de bonis illius, ipso inuito; actio tamenfurti non conceditur patri, aut domino, aduersus eos, ad pœnam dupli, quadrupli, aut ad aliam pro furto statutam: sed pater ipse familias, aut dominus, sub cuius potestate sunt, punire eos poterit moderatē pro quantitate delicti, procedendo, etiam ad verbera, & ad alias similes pœnas, ita tamen, vt eos nec mutilet, nec occidat: quoniam hæc pœna extra limites familiæ administratoris

est, ad solumque iudicem spectat eam, pro criminis qualitate, iurisque dispositione, aut consuetudine, recepta, infligere. Quòd verò furti actio non competat patri aduersus suum filium familias, neque domino aduersus suum mancipium, *habetur §. bi qui, inst. de oblig. quæ ex delict. l. serui & filii. l. qui seruo. §. item placuit, & l. si quis uxori. ff. de furt. l. 1. §. habet itaque, iuncta glossa ibi, verb. seruus potest coërceri. ff. si quis testam. liber esse iussus, & l. 4. titu. 14. part. 7.* Quòd autem ad patrem familias, aut ad dominum, spectet punire pro his criminibus moderatè, modo explicato, constat ex *l. respiciendum. §. furta. ff. de pænis l. si filius, & l. congruentius. C. de patr. potest. & l. 4. titu. 14. part. 7.* Si tamen filius familias, aut mancipium, reddere non vellent rem furto ablatam, cùm possent, tunc implorare paterfamilias, aut dominus, officium iudicis posset, qui, seueriùs coërcendo, ea reddere efficeret, iuxta *l. si filius, & l. congruentius*, citatas, & affirmat *Greg. Lopez. l. 4. citata verb. en buena manera.* Quādo filiusfamilias haberet bona Castrensia, aut quasi castrensia, vnde furtum de bonis patris consumptum, aut aliud damnum in temporalibus patri iniustè datum, solueret, vtique, quando à solo patre moderatè coactus, illud non solueret, patri coram iudice competeret aduersus eum actio furti, non quidem ad pænam, sed in factum, vt damnum patri iuiustè datum resarciret. Quemadmodum, si paterfamilias aliquid de bonis castrensibus, aut quasi castrensibus, filii indebitè, ipso inuito, vsurparet, concederetur actio de furto filio aduersus patrem, non quidem ad pænam, aut ad infamiam, sed solùm in factum, vt illud, aut tantundem, si, quod abstulit, non extaret, ei solueret, vt vtrumque habetur expressè. *l. si quis uxori. §. si filius meus, iuncta glossa ibi, verb. furti. ff. de furt.* Simili etiam ratione, si filius iam sui iuris, & extra patriam potestatem existens, aliquid surriperet de bonis patris, aut pater de bonis filii, daretur vtriusque, qui id damnum iniustè esset passus, actio de furto aduersus alterum, non quidem ad pænam, sed in factum, præcisè vt resarciret damnum, argumento. *§. si filius meus citati.*

Quando mancipium graue furtum com [sect. 4] mitteret aduersus dominum, nec dominus posset ab illo id recuperare, aut esto iam id recuperasset, integrum, meo iudicio, esset domino, accusare coram iudice tale mancipium de eo crimine, & postulare, vt afficeretur pæna corporali ordinaria pro eo crimine statuta, *argumento l. respiciendum. §. furta domestica. ff. de pænis.* Pænam verò pecuniariam dupli, aut quadrupli, exigere non posset: eo quòd quicquid mancipium habet, ad dominum spectet. Si tamen, conuentione facta inter dominum, & mancipium, id mancipium bona aliqua sua propria haberet, tunc ex illis, & exigere posset rem furto ablatam, & insuper pænam pecuniariam, ex præscripto iuris ei applicandam, aduersus quem furtum esset commissum.

Quod verò attinet ad famulos mercede con [sect. 5] ductos, aut etiam nulla statuta mercede seruiantes, atque ad mercenarios, certo statuto pretio pro vnoquoque die, aut pro vnoquoque opere, (ita tamen, vt in domo eos conducentis habitent, vt cum Cepola exponit *Greg. Lopez. l. 17. citanda, verb. por jornal cierto*) qui omnes domestici nuncupantur, atque etiam libertus, si in domo patroni habitet, quin eodem priuilegio gaudet, etiam si in domo patroni non habitet, sicut & è contra patronus comparatione liberti: quod, inquam, ad hos omnes attinet, si eorum furta modica sint, pro eis non conceditur actio furti patrifamilias domus ad pænam aliquam pæcuniariam, aut ad aliquam aliam; tametsi repetitio eius, quod furto oblatum est, aut valoris illius, ei in exteriori foro concedatur, quando aliter illud recuperare plenè non valet. Conceditur præterea tali patrifamilias domus, moderata punitio pro eo furto, habita ratione conditionis & ætatis talis domestici, quantitatis ac qualitatis furti, & reliquarum circumstantiarum concurrentium. Si verò eiusmodi furta modica non sint, tunc patri familias

domus conceditur actio furti, tum ad repetitionem rei ablatae, ac damni inde subsequuti, tum etiam ad pœnam pecuniariam, aut ad aliam lege statutam, vel consuetudine receptam, perinde atque ei concederetur, si furtum ab aliquo externo esset commissum, atque iudex ex officio procedere potest ad furta in commune bonum punienda, [[26]] sicut ad alia. *Hæc habentur. l. respiciendum. §. furta. ff. de pœnis, & l. 17. titu. 14. part. 7.* Quod verò ad libertum & patronum attinet, habetur. *l. prætor edixit. §. præterea. ff. de iniur. & l. si libertus. ff. de furt.* Quæ autem furta domestica modica sint censenda, & quæ non item, ad effectum, vt actio furti concedatur, aut non concedatur, iudicis prudentis arbitrio est relinquendum, vt notant Bart. §. furta citato, & doctores communiter, atque habetur l. 17. citata: quæ meritò cum glossa. §. furta citato, statuit, ad iudicandum, quæ furta domestica censenda sint modica, quæ non item, attendendum esse ad quantitatem & qualitatem rei furto ablatae, & ad qualitatem personæ, quæ illam abstulit, & à qua ablata est: quod enim in vno, spectatis his circumstantiis, erit furtum magnum, in alio non erit tale. *Iulius Clar. lib. 5. sent. §. furtum. n. 22. testatur,* communi praxi esse receptum, quando furtum domesticorum non est modicum, domesticum furem puniri vt alios fures, refortque multos euentus particulares, in quibus variis in locis ita iudicatum fuit. Attendendum etiam est ad multiplicationem furtorum domesticorum, quæ ab eodem domestico fure sint commissæ, ad iudicandum, vtrum quantitas censenda sit magna, vt ibidem Iulius Clarus subiungit, & cum *Bald. affirmat Greg. Lopez. l. 17. citata verb. pœna de furto.* Arbitror tamen, non eam quantitatem, quæ in vnico furto sufficiens iudicaretur, vt censeretur magna, sufficere in multis simul sumptis, vt magna reputetur. Imò, quo furta fuerint plura, & quo decursu longioris temporis sint patrata, eo maior quantitas omnium simul sumptorum esse necessariam, vt magna, seu non modica, reputetur.

Dubium est, vtrum; si furtum ab vxore commissum de bonis viri, à filio, aut nepote, de bonis patris aut aui, vel à mancipio de bonis domini sui, locum habeat, vt, si magnæ sit quantitatis, concedatur actio furti aduersus hos, sicut conceditur aduersus famulos mercede conductos, & aduersus alios domesticos. Bart. §. furta, citato, & multi alii, quos refert ac sequitur *Ant. Gom. 3. tom. var. res. c. 5. n. 3.* & quos refert ac sequi videtur *Greg. Lopez. l. 17. citata glossa penul. affirmanter respondent.* Contrarium tamen habetur. *l. 4. iuncta. l. 17. titu. 14. part. 7.* sequendumque omnino est in hoc Castellæ Regno, & innuere apertè videntur iura communia hactenus citata, quæ apertè denegant actionem furti viro comparatione vxoris, patri comparatione filii & nepotis, atque domino comparatione mancipii, absque vlla distinctione, vtrum furtum magnum sit, an paruum: eam verò distinctionem solùm adhibet. *l. respiciendum. §. furta. ff. de pœnis,* in famulis, & aliis domesticis, minimè tanto vinculo coniunctis, quantum est inter virum & vxorem, & inter patrem ac filios, neque ita sub potestate patris familias domus constitutis, ac est mancipium domino suo. Atque hanc sententiam veram esse iudico, Lex verò si filius, & *l. congruentius. C. de patria potestate, & l. propter. C. de his qui accusare non possunt,* quæ permittunt, parentes adire iudices, vt filii ab eis coërceantur ac puniantur, loquuntur, quando filii alias iniurias parentibus irrogant, & quando expedit, vt pœna aliqua acerbiori puniantur, quàm possit, aut valeat, pater ei infligere: neque tunc iudex punire acrius eos poterit, quàm pater voluerit, iusteque postulauerit. De mancipio verò iam suprà diximus, si dominus velit, vt corporaliter puniatur, pro quantitate & qualitate furti, posse id exigere, iudicemque id exequutioni mandari teneri.

Quamuis aduersus vxorem, filium, aut [sect. 7] mancipium, non detur actio furti, vt dictum est, neque etiam aduersus alium domesticum, si furtum sit modicum: nihilominus, si quis res ita ab eis furto ablatas, ex eis emat, aut alio titulo accipiat, comperto fuisse furto ablatas,

restituere eas tenetur dominis, si extent; neque dominus tenetur reddere pretiū, quo emptæ fuerunt, etiam si bona fide fuerint emptæ, ignorando furtiuas esse: sed in eo euentu, qui illas vendidit, tenetur emptori de euictione. Quòd si non extent, & bona fide sint acceptæ, tenetur accipiens restituere domino rei, solū quantum ex eis fuerit factus locupletior. *Ita habetur. l. inciuilem. C. de furtis, & l. 4. titu. 14. part. 7.* & cum Couar. reg. peccatum, affirmat *Iul. Clar. §. furtum citato. n. 26.* resque satis est perspicua, neque probatione indiget. Quando autem quis rem emit, sciens furtiuam, aut alienam esse, tunc venditor non tenetur illi de euictione, ac proinde neque ad pretium, atque hoc est, quod affirmat. *l. 4. titu. 14. part. 7. iuxta. l. si fundum C. de euict.* Excipe, nisi expressè conuentio fuisset facta, vt venditor de euictione teneretur: nam tunc agere poterit aduersus venditorem ad solum pretium, iuxta. *l. si fundum citata, vt Disp. 380. §. sextus, dictum est.* De iure verò Lusitano is emptor, neque ad pretium agere potest, vt. §. citato dictum est. Ad quem autem pretium tunc pertineat, ibidem explanatum est.

De iure huius Regni. *lib. 6. nouæ collect. [sect. 8] titu. 20. l. 5.* quousque prohibitum sit, emere aliquid, *de criado o criada que sirue à otro.* & quòd talis emptor puniatur, *como encubridor de furto*, dictum est *Disput. 340, & repetetur Disput. 695.* Quousque etiam prohibitum sit emere ex mancipiis *l. 15. titu. 11. lib. 5. nouæ collect. eadem Disputat. 695* dicitur. Quousque item de iure Lusitano *libr. 5. ordi. titu. 37. §. 5. & 6.* prohibitum sit, & sub quibus pænis, emere aliqua, vel à domesticis, vel ab aliis, de quibus præsumptio est esse furtiua, eadem *Disputat. 695* dicitur. Item quamuis aduersus vxorem, filium, mancipium, aut familiarem domus, non competat actio furti eo modo, quo hactenus explanatum est: si tamen ope, aut consilio alicuius, tale furtum sit factum, competit actio furti aduersus eiusmodi cooperatorem ad id furtum. *Ita habetur. §. hi qui inst. de oblig. quæ ex delict. l. qui seruo. §. item placuit iunctis antecedentibus & sequentibus, l. si quis vxori. ff. de furtis, & l. 4. titu. 14. part. 7.* Hæc quod attinet ad forum exterius.

[[27]] Quòd verò ad forum conscientie attinet, si [sect. 10] domestici, aut quicumque alii, aliquid accipiant ex præsumpta voluntate domini, quia scilicet rationabiliter sibi persuadent, dominum non fore inuitum, nullum committunt furtum: quoniam absque domini inuoluntatio esse nequit ratio furti. Si verò rem acciperent domino quidem inuito, non tamen quoad rem, sed quoad modum: quia vult, vt eam petant, & non vult, vt occultè, autoritatè propria, eam accipiant: tunc solū est veniale peccatum, esto quantitas sit notabilis. *Ita Caie. in summa verb. furtum, Nauar. in Manu. c. 17. n. 138. & alii.* Atque hinc excusari à culpa lethali possunt multæ occultæ acceptiones, quibus domestici, amici, aut aliter domino coniuncti, res illius accipiunt.

Quòd si eiusmodi homines aliquid accipiant domino inuito quoad rem, adhuc id esse poterit vno è duobus modis. Quoniam dominus esse potest inuitus, vel ratione rei in se, vel ratione finis, ad quem accipitur. Sæpe enim pater non est inuitus, quòd filius aliquid accipiat ad honestam ac rationabilem oblectationem; cū tamen valde inuitus sit, quòd id accipiat ad ludum, ad meretrices, aut ad aliud simile: non quidem propter rem in se, sed propter filii detrimentum ac periculum. Atque tunc quantitas peccati, & num ad culpam perueniat lethalem, aut non, ex patris inuoluntario sunt conjicienda, atque ex obiecti quantitate seu valore. Regulariter verò in eo euentu nulla consurgit obligatio restituendi: quoniam, vt supponimus, pater non est inuitus propter rem in se.

Quòd si rei dominus inuitus sit propter [sect. 11] rem in se, tunc, quia minùs solet esse inuitus, quòd à domesticis, & coniunctis, id accipiat, quàm quòd accipiat ab aliis; ratioque peccati

furti eo plus, cæteris paribus, extenuatur, quo dominus rei furto ablata minus est inuitus; consequens profectò est, vt regulariter maior quantitas requiratur ad culpam lethalem in furto domesticorum, ac coniunctorum amicitia, aut alio vinculo, domino rei, quàm in furto aliorum. Atque hinc fit, vt quantitas, quæ in extraneo ad culpam sufficeret lethalem, in domestico, aut in aliter coniuncto, regulariter ad lethalem culpam non sufficiat. Et vt, quo dominus rei, inter domesticos, aut aliter coniunctos, minus est inuitus, quòd res ab vno accipiat, quàm ab alio, eo maior quantitas requiratur ad culpam lethalem in furto vnus eorum, quàm in furto alterius. Quare statui hac de re non potest certa regula generalis, qua discernatur, quando furtum domesticorum aut aliter coniunctorum domino rei, sit lethale, aut non, ex parte quantitatis seu valoris rei furto ablata: præsertim cùm inter patres familias domus, dominosque suarum rerum, vnus possit esse magis inuitus, quòd æqualis quantitas accipiat à suis filiis, vxore, à famulis, aut ab aliter ipsi coniunctis, quàm alii: eo quòd quidam suo ingenio sint liberaliores, quàm alii, aut sint ditiores, aut magis affecti ad reliquos, quàm alii, & propter alias circumstantias concurrentes. Quo sit, vt prudentia confessarii hæc omnia sint iudicanda ac conjicienda, attentis circumstantiis omnibus concurrentibus: & quàm sæpissime doctissimo ac prudentissimo cuique erit valde incertum, num eiusmodi furta ad culpam perueniant lethalem, an non.

Sotus. 5. de iusti. q. 3. art. 1. & alii, rectè [sect. 12] obseruant, quando ad petitionem alicuius, cuius bona furto ablata sunt, fertur sententia excommunicationis in eos, qui res furto abstulerunt, nisi illas intra certum terminum restituant, tunc, cùm intentio quasi habitualis ferentis excommunicationem sit, vt non plus liget, nec plures comprehendat, quàm similiter is, ad cuius petitionem fertur, quasi habitualiter intendat comprehendere; vtique, si vxor, aut filii, sint, qui id furati sunt, arbitrio prudentis iudicandum est, iuxta ea quæ proximè dicta sunt, num talis vxor, aut filii, eam excommunicationem incurrant, esto non restituant intra eum terminum: quia vel pater, aut maritus, non vult eos restituere, vel non intra id tempus, & cum tanto onere. Idem dicendum est de aliis familiaribus, aut amicitia, vel alio vinculo, coniunctis cum eo, cuius res furto ablata sunt. In dubio autem, cùm de excommunicatione lata constet, censendum est, eos excommunicationem incurrere, si intra præfixum terminum, cùm possint, non restituant.

Quod ad restitutionem furtorum domesti [sect. 13] corum attinet. Quando is, qui tale furtum commisit, non sibi omnino persuadet, rei dominum contentum fore, vt non restituat, vtique iniungendum illi est, vt restituat, vel obtineat remissionem ab eo, cui facienda esset restitutio, esto, qui furatus esset, vxor esset, aut filius. *Ita Sotus vbi suprà, Syluest. verb. furtum. q. 11.*

De furtis Religiosorum, Disp. 687.

SVMMARIVM.

1. *Contra votum paupertatis religiosorum quæ sint, tum in aliis religionibus, tum in nostra, quo ad eos, qui emissis tribus votis post duos probationis annos, nec professi, nec quo adiutores formati sunt.*
2. *Quantitas sufficiens, vt religiosus culpam lethalam committat contra votum paupertatis, quæ.*

3. Religiosi nostræ Societatis si aliquid accipiant pro missis, aut aliis ministeriis, contra votum peccant paupertatis.

POSITIS his, quæ Disp. 139. & duabus sequentibus, & Disp. 276. dicta sunt, observandum

est. Contra votum paupertatis religiosi esse, appropriare aliquid sibi, tanquam suum illud habendo, vel quoad dominium directum & vtile, vel quoad vtrumvis, etiam quoad vsumfructū; eo quòd, etiam veri vsusfructus, incapax per paupertatis votum sit; propterea quòd vsusfructus [[28]] vera pars sit dominis integri rei, vtileque dominium nuncupetur ac verè sit, atque ex illo ius reale ei competat cuius est, vt Disp. 3. cum Bart. & aliis ostendimus: religiosus autem per votum paupertatis incapax sit, etiam partis domini rerum quarumcunque externarum, quippe per id votum rebus externis omnino renunciaret, quoad dominium, & quoad quodcunque aliud ius, quod ipsi possit competere, tam ad præsens, quàm in futurum, vt ad ipsum non spectet, sed ad monasterium nomine & loco ipsius, si, iuxta constitutiones eius religionis, ad monasterium deuenire possit. Excipe in nostra Societate, quo ad eos, qui neque professi neque coadiutores sunt, & tamen tria vota paupertatis, obedientiæ, & castitatis, emiserunt: nam in his paupertatis votum non excludit dominium vtile & directum, tam rerum, quarum tempore emissi voti erant domini, quàm rerum aliarum, quæ ad ipsos hæreditario iure, aut alio simili titulo, deuenierint, tametsi excludat vsum, administrationem, ac dispositionem, earundem rerum, nisi ex præscripto & consensu superiorum, vt Disput. 139 vtrunque explanatum est. Votum enim paupertatis horum, quando emittitur, eo modo intelligitur, neque ad plus sese extendit, ex præscripto nostrarum constitutionum, & approbatione sedis Apostolicæ, ad meliorem statum ac gubernationem nostræ Societatis: vota autem, cùm voluntariæ ac liberales oblationes sint vouentium, non plus sese extendunt aut obligant, quàm vouentes intenderint offerre Deo, ac veluti condonare. Dixi; vsum fructum verum pugnare cum voto paupertatis religiosorum: quoniam licet cum eo voto paupertatis non pugnet administratio, ac dispositio, reddituum alicuius census, aut tencæ, quam vocant, vel fructuum, seu prouentuum, alicuius rei immobilis, quæ legitimus superior concedat alicui religioso, parato cessare ab ea administratione, ac dispositione, quando legitimo superiori ea in parte libuerit; id tamen non est vsusfructus eorum bonorum immobilium, seu quæ cum immobilibus computantur; (licet à quibusdam improprie vsusfructus nuncupetur) sed est solùm cōmoditas, atque perceptio, & vsus eorum reddituū, ex præscripto & facultate legitimi ea in parte superioris, atque interim dum ea fuerit eius voluntas, dependenterque proinde ex eo, quòd talis superior id non reuocet: verus autem vsusfructus, sicut & directum dominium eorundem bonorum immobilium, quin & fructuum, interim dum non consumuntur, aut alienantur, ad monasterium, & non ad eum religiosum, spectat.

Contra votum item est paupertatis quoruncunque religiosorum, etiam eorum, qui in nostra Societate emiserunt tria vota, nec tamen adhuc sunt professi, vel coadiutores spirituales aut temporalis vsus, & multo magis consumptio, aut alienatio, quarumcunque rerum, non ex voluntate, saltem præsumpta, suorum superiorum, siue tales res quoad dominium adhuc ad eum religiosum spectent, vt de nostris, qui nec professi nec coadiutores sunt, dictum est dominium suarum rerum retinere; siue ad ipsos quoad dominium nullo modo attineant, sed sint summi Pontificis, vel dantium, interim dum non consumuntur, vt de bonis fratribus Minoribus ad vsum & consumptionem concessis Disp. 6 dictum est; siue quoad dominium pertineant ad conuentum, in quo sunt religiosi, vt regulariter pertinere

solent; & siue ab aliquo concessæ absolutè sint tali religioso; quæ tamen eo ipso efficiuntur quoad dominium conuentus, nisi conuentus si fratrum Minorum; siue non absolutè sint ei concessæ, quasi concedens non abdicet à se dominium earum interim dum non consumuntur, sed duntaxat sint ei concessæ quoad vsum, consumptionem, aut alienationem, facta solùm tali religioso potestate eis vtendi, & ea consumendi, aut alienandi, oneroso contractu, vel lucratiuo: Vsum, inquam, consumptio, & alienatio, harum rerum, absque facultate, saltem præsumpta, legitimi ea in parte sui superioris, est contra votum paupertatis: quoniam per illud religiosus à se abdicat vsum quaruncunque rerum externarum, nisi quatenus sua regula legitimæ superioris sui facultate sit ei concessus ac permissus. Quin potius, qui contra regulam, atque absque legitima facultate sui superioris, aliquid vsurpat ad suum vsum, & consumptionem, seu alienationem, siue illud sit de bonis antea iam effectis conuentus, siue de bonis sibi ab aliquo ad id collatis, censeatur eo ipso proprietarius: non quidem quasi proprietatem, seu dominium, illius acquisierit; cùm omnino sit illius incapax, sed quòd retinere vtique illo velit, tanquam suo, esto fciat suum non esse; eo pacto, quo is, qui similiter vsurparet aliena, esset fur, censereturque ea sibi appropriare, esto intelligeret, non comparare eorum dominium. Ex dictis intelligitur facilè, quòd si religiosus ex facultate superioris aliquid velit habere quoad administrationem, consumptionem, ac vsum, independenter ex eo, quòd pro libito superioris possit ab eo, quandocunque superior voluerit, omnino auferri, sit proprietarius, atque in statu damnationis, si quantitas ad culpam lethalem sufficiat, siue id sit res immobilis, aut quæ cum immobili computatur, siue pars eius rei, vt vsus fructus illius, siue sit aliquid mobile. Et quia hoc pugnat cum statu religiosi, paupertatisque voto, ait *Inno. 3. c. cùm ad monasterium, in fine, de statu monach. Neque æstimet Abbas, quòd super habenda proprietate possit cum aliquo monacho dispensare: quia abdicatio proprietatis, sicut & custodia castitatis, adeò est annexa regulæ monachali, vt contra eam, neque etiam summus Pontifex, possit licentiam indulgere.* Videant ergo religiosi, qui peculia retinent, an cum animo ea retineant, quòd omnino parati sint ea relinquere monasterio, quandocunque superior iusserit: ne proprietarii in suo affectu sint, atque in culpa lethali. Et quoniam abusus re vera est, quòd religiosi eiusmodi peculia possideant quoad administrationem & eorum dispositionem, etiam ad non illicita, maximè si pro libito, inconsulto superiore quoad dispositiones particulares, de eis disponant, Concilium Trid. *Seß. 25. c. 2. de regularib. quæ sequuntur statuit: Nemini igitur regularium, tam virorum, quàm mulierum, liceat bona immobilia, vel mobilia, cuiuscunque qualitatis fuerint, etiam quouis modo ab eis acquisita, tanquam propria, aut etiam nomine conuentus, (nota præcedens verbum) possidere vel tenere, sed statim [[29]] ea superiori tradantur, conuentuique incorporentur. Neque deinceps liceat superioribus bona stabilia alicui regulari concedere, etiam ad vsum fructu (improprie) vel vsum, administrationem, aut commendam. Administratio autem bonorum monasteriorum, seu conuentuum, ad solos officiales eorundem, ad nutum superiorum amobiles, pertineat. Mobilium verò vsum ita superiores permittant, vt eorum suppellex statui paupertatis, quam professi sunt, conueniat, nihilque superflui in ea sit, nihil etiam, quod sit necessarium, eis denegent. Quòd si quis aliter quidquam tenere deprehensus, aut conuictus, fuerit, is biennio actiua & passiuæ voce priuatus sit, atque etiam iuxta suæ regulæ & ordinis constitutiones puniatur.* Quid de hoc decreto sentiam, ex parte dixi Disp. 276. Et quoties illud lego, scrupulus non leuis meum animum pungit, circa tenæas seu annuos redditus, quos moniales multæ, & religiosi aliqui, tenent. Interim verò, dum communitates eiusmodi religiosorum non ita instituuntur, vt de communitatibus ipsis singulis religiosi sobriè necessaria subministrentur, vt idem decretum præscribit, redactis communitatibus ad

minorem religiosorum numerum, si ad id efficiendum ita opus sit, vt alibi in eodem Concilio statuitur, sed singuli coguntur necessaria aliunde sibi conquirere, ad libros, supellectilem, partem vestitus, ad medicinas, & alia necessaria morborum tempore, atque ad similia alia, non video quomodo huic, & aliis abusibus, congruè sufficienterque possit subueniri.

Ex dictis etiam intelligitur facilè, similiter esse censendum proprietarium, esseque in statu damnationis æternæ (si quantitas ad lethalem culpam sufficiat) religiosum, qui clàm, aut apertè, contra regulam, absque legitimi superioris facultate aliquid vsurpat, aut retinet, quo ad vsũ aut dispositionem, siue de bonis conuentus, siue de bonis aliunde conquisitis. Atque de vtroque proprietario sermo est c. monachi ex concilio Lateranensi, c. super quodam, quod est Clementis 3. & c. cum ad monasterium, de statu monach. Et de proprietario posteriori hoc modo iuribus citatis habetur, vt, si cum aliquo eiusmodi peculio tempore mortis fuerit repertus, quod absque legitima superioris facultate possederit, in sterquilinio sepeliatur, careatque Ecclesiastica sepultura, tanquam qui in culpa lethali eo ipso discesserit. Quæ autem quantitas sufficiat, vt religiosus [sect. 2] censeatur in culpam incidisse lethalem contra votum paupertatis, aliquid prædicto modo sine superioris facultate sibi appropriando ac vsurpando, cùm ea de re consultus sæpe fuisset Reuerendus Pater noster Generalis, approbantibus patribus congregationis generalis, habitæ anno 1594. sic, quod ad nostros religiosos attinet, respondit: *Curauimus ea de re inter nostros doctores diligenter inquiri ac disceptari. Omnium verò sententia hæc fuit: eam quantitatem, quæ, furto sublata, satis esset ad constituendum peccatum mortale contra septimum præceptum, eandem sufficere, vt peccasse iudicaretur aduersus votum paupertatis: si quis è nostris eam, vt propriam, vel vsurpet, vel alienet, sine superioris facultate. Quam opinionem volumus, vt nostri sequantur, præscribimusque patri prouinciali, vt eam nostris omnibus patefaciat, quo huius voti exacta perfectio quam studiosissimè obseruetur.* Obserua autem, quòd sicut, quando quis, inuito domino, vsurparet rem quoad solum vsum, quo non consumeretur, animo eam reddendi domino post eum vsum, ad iudicandum lethale peccatũ furti contra septimum decalogi præceptum, attēdi debet, non ad valorem rei, sed ad valorem talis vsus: ita in re proposita, quando religiosus absque superioris facultate vteretur re aliqua, quam non consumeret, neque alienaret, animo vtendi solũ eo modo re illa, ad iudicandum an culpa talis sacrilegii contra votum paupertatis lethalis sit, attendi debet, non ad valorem rei illius in se, sed ad valorem talis vsus, ac damni, quod ex tali vsu prouenit.

Dubium est, vtrũ in nostra Societate, reli [sect. 3] giosus, qui ob missarum sacrificia, vel prædicationes, vel lectiones, vel vllius Sacramenti administrationem, vel ob quoduis aliud pium officium ex iis, quæ, iuxta suum statutum, Societas potest exercere, stipendium vllum, vel eleemosynam, quæ ad compensationem huiusmodi ministeriorum dari solent, acciperet, peccaret lethaliter sacrilegii peccato contra votum paupertatis, modò quantitas esset tanta, quæ ad lethalem culpam, iuxta proximè dicta, sufficeret. Mihi semper fuit omnino persuasum, atque hodie est, quòd quamuis regulę, & constitutiones nostræ, nos non obligent, neque ad lethalem, neque ad venialem culpam, nisi quando id, vel ex natura rei, vel quia est contra vorum, vel quia in virtute sanctæ obedientiæ, vel sub excommunicationis pæna, in aliquo particulari euentu à superiori præciperetur, vt constat apertè ex. 6. part. consti. c. 5. quod sic habet: *Cum exoptet Societas, vniuersas suas constitutiones, declarationes, ac viuendi ordinem, omnino, iuxta nostrum institutum, nihil vlla in re declinando, obseruari: optet etiam nihilominus suos omnes securos esse, vel certè adiuuari, ne in laqueum vllius peccati, quod ex vi constitutionum huiusmodi, aut ordinationum, proueniat: visũ est nobis in Domino, vt, excepto expresso voto, quo*

Societas summo Pontifici pro tempore existenti tenetur, ac tribus aliis essentialibus Paupertatis, Castitatis, & Obedientiæ, nullas constitutiones, declarationes, vel ordinem ullum viuendi, posse obligationem ad peccatum mortale, vel veniale, inducere: nisi superior ea in nomine Domini nostri Iesu Christi, vel in virtute obedientiæ, iuberet: quod in rebus, vel personis illis, in quibus iudicabitur, quod ad particulare vniuscuiusque, vel vniuersale bonum, multū conueniet, fieri poterit: & loco timoris offensæ, succedat amor & desiderium omnis perfectionis: & ut maior gloria & laus Christi, creatoris ac Domini, sequatur. Mihi, inquam, semper persuasum fuit, & est, nihil impediēte, quòd hæc ita sint, lethaliter peccare sacrilegii peccato contra votum paupertatis, qui ob missas, aut ob aliud eorum quæ cōmemorata sunt, stipendium, aut recompensationem, acceperit quantitatis quæ ad lethalem culpam in furto sufficeret. Ducor, quoniam id non accipere, ad votum nostræ paupertatis spectat, ad idque eodem voto nos astringimus, dum illud emittimus, & non extra voti substantiam, solū peculiari regula, aut constitutione, id nobis iniungitur. Sic enim habetur. c. 1. examinis, §. 3. Ad hunc finem melius consequendum, tria vota in ea, Obedientiæ, Paupertatis, & Castitatis emittuntur: sic paupertatem accipiendo, ut nec velit, nec possit, re-[[30]]ditus vllos ad suam sustentationem, nec ad quoduis aliud habere. Quod non tantū in particulari de vnoquoque, sed etiam de Ecclesiis, & domibus, Societatis professæ, est intelligendum. Neque etiam (quamuis aliis sit licitum) pro missarum sacrificiis, vel prædicationibus, vel lectionibus, vel vllius sacramenti administratione, vel quouis alio pio officio ex iis, quæ, iuxta suum institutum, Societas potest exercere, st ipendium ullum, vel eleemosynam, quæ ad cōpensationem eiusmodi ministeriorum dari solent ab alio, quam à Deo (ob cuius obsequium omnia purè facere debent) possunt admittere. Hactenus ibi. Ex quibus constat, sicut in nostra Societate de substantia voti paupertatis est, in eoque includitur, ut non solū priuati bona immobilia, & quæ cū immobilibus computantur, sed etiam domus professæ, & earum Ecclesiæ, eadem immobilia bona non habent, peccarētq; lethaliter, sacrilegii peccato contra votum paupertatis, professi, qui illa admitterent, factūq; non teneret, neque tales domus, aut Ecclesiæ, ullum ius ad ea cōpararēt: ita de substātia voti paupertatis esse, in eoque singulos religiosos nostræ Societatis, dum illud emittunt, includere, nihil accipere in recōpensationē pro rebus enumeratis: quoniam ita à fundatore Societatis, Societateque ipsa tota tunc, quæ constitutiones approbavit & admisit, & à sancta sede Apostolica, quæ non solū facultatem concessit ad illas ita cōdēdas, sed etiam easdem conditas approbavit; ita expositum ac declaratum est votum nostræ paupertatis: singuli autem, qui finitis duobus probationis annis, tria vota Obedientiæ, Paupertatis, & Castitatis, emittunt, continuò addunt, omnia intelligendo iuxta ipsius Societatis cōstitutiones, ut habetur. 5. part. const. c. 4. §. 4. Neque opus est eos, aut quoscūq; alios, id addere: quoniā, qui in aliqua religione professionē faciunt, aut aliter vota emittunt, iuxta institutum, constitutiones, aut regulam, eius religionis, censentur ea emittere, ad eaque se obligare. Ac certè illa verba §. 3. capitis 1. examinis; sic paupertatē accipiēdo; apertè significnt interpretationem substantiæ atque obligationis voti: non verò, quid conduceret, ut perfectiūs obseruatum censeretur. Præsertim cū multa alia attineant ad perfectiorē & exactio rē illius, & duorum aliorum votorum, obseruationem, de quibus nulla mentio ibi est facta, dum de tribus illis votis substantialibus habitus est sermo; sed in constitutionibus & regulis de illis in particulari instruamur, nobisque ad maiorem perfectionem iniungantur, sine vlla ad culpam obligatione, ut dictum est. Potissimum sexta parte constitutionum à cap. 1. instruimur de iis, quæ ad perfectiorem trium votorum attinent, eaque nobis iniunguntur.

Quod dictum est, potest confirmari *ex. 6. part. cōst. c. 2. §. 7.* vbi, dum ad hanc rem est deuentum, sic dicitur: *Omnes, qui sub obedientia sunt Societatis, meminerint, se gratis daredebere, quæ gratis acceperūt, nec postulando, nec admittendo, stipendium, vel eleemosynas ullas, quibus missæ, vel confessiones, &c. cōpensari videātur. Meminerint, dixit: quoniā ex paupertatis voto ad id tenentur. Neque id iniūxit, aut docuit, tanquam regulam substātiæ voti, ad perfectiorē illius obseruationem, superadditam, vt iniungere ac docere consuevit, quæ ad maiorem perfectionem spectant.*

Illud admonuerim, quamuis gratis daremus, rē de qua disputamus, non esse de substātia voti Paupertatis, atque in eo contentam, (quod tamen falsum est) nostro tamen iudicio, lethaliter peccare cōtra idem Paupertatis votum, qui quātitatē, quæ ad lethale peccatum furti sufficeret, acciperet sibi, vel alteri, pro eiusmodi rebus. Ratio autem est, quoniam, vt in priori parte huius disputationis ostēsū est, religiosus, qui absque facultate, saltem præsumpta, legitimi sui superioris, vsurpat, aut alienat, notabilem quantitatem, siue cam accipiat de bonis conuentus, siue aliunde sibi traditam, aut concessam, lethaliter peccat, tanquam proprietarius, contra votum paupertatis: constat autem, quod ita religiosus nostræ Societatis pro eiusmodi rebus acciperet, absque expressa, & præsumpta, suorum superiorum voluntate, imò contra expressam regulā ac superiorum prohibitionem, id accipere, ac proinde lethaliter peccare contra paupertatis votum.

Quando propter notabilem quantitatem, quā quis ab aliquo furatur minimis furtis, quarum singula ad culpam lethalem non sufficiunt, interueniat culpa lethalis ita furantis. Disp. 688.

SVMMARIVM.

1. FVrtum notabile per minima quot modis contingat.

2. Furtum per minima ab eodem homine quande culpa lethalis cum restituendi onere sub culpa lethali. Minor autem quantitas ad id requiritur, quo longiori tempore ea summa aufertur, præsertim in famulis.

3. Furto si ablata sit aut retineatur quantitas, quæ ita ad culpam lethalem sufficiat, vt quæcunque minor adeānon sufficiat, si restituatur quæcunq̃pars illius, reliquum retinetur sine culpa lethali, cum solæ veniali.

FVrtis minimis auferri notabilem quātitatē, [sect. 1] ita vt dubium sit, an cum furtis rerum minimarum coniuncta sit culpa lethalis, obligatioque restituendi sub lethali culpa, vno è tribus modis potest euenire. Primò, si vnus atque idem homo tot multiplicet furta ex bonis vnus & eiusdē hominis, vt, licet quantitas nullius eorum sufficiat ad culpam lethalem, quantitas tamen omnium simul adæquat, aut superat, eam, quæ ad culpam lethalem sit satis. Secundò, si quis à diuersis furetur minima quæque, quæ nulli eorum efficiant damnum, ac iniuriam notabilem; summa tamen tota æquet, aut superet, quantitatem, quæ ad culpam sufficiat lethalem. Tertiò, si multi alicui inferant damnum magnum, nullus tamen eorum accipiat quantitatem notabilem, vt si, transeunte exercitu per aliquem locum, multi ex

militibus accipiant racemum ex aliqua vinea, sicque consumant maximam fructuum partem, aut fructus omnes eius vineæ. Hæc eadem locum similiter habent in damnum inferentibus, destruendo similiter sata, aut aliquid aliud eiusdem hominis, vel diuersorum. In hac autem disputatione dicemus de primo ex tribus modis commemoratis: & in sequenti de duobus reliquis.

Conueniunt omnes, eum, qui ita furando per [sect. 2] minima ab eodem homine, peruenit ad quantitatem, quæ ad culpam lethalem sufficit, teneri ad illius restitutionem sub reatu culpæ lethalis. *Nauar. tamen in Manu. c. 17. n. 139. negat vltimum furtum, per quod illa quantitas completur, esse [[31]] lethale peccatum. Contrarium verò asseuerant Sotus. 5. de iust. q. 3. art. 3. in resp. ad. 3. Ioan. Med. de rest. q. 10. prope finem, Maior in 4. dist. 15. q. 25. cum quibus consentire videtur Vega lib. 4. in concil. trid. c. 11. & consentiunt alii. Atque hæc sententia, in sensu statim explicando, nobis probatur. Ratio autem est, quoniam vltimum furtum in virtute, præcedentium, hoc est, posito damno per præcedentia furta dato, in causa est damni notabilis iniustè proximo dati: actus autem, quo notabile damnum proximo iniustè datur, aut quo id damnum consummatur, culpa sanè est lethalis. Item, quatenus fur tunc accipit animo nihil restituendi, attendens, aut attendere debens, se iam multa alia ab eodem iniustè accepisse, quæ simul sumpta efficiunt damnum notabile iniustè datum, vtique eo actu, quo complere vult quantitatem eius damni, quæ ad culpam sufficit lethalem, virtute vult retinere iniustè eam totam quantitatem: id verò, ex sententia eiusdem Nauarri, culpa est lethalis, Atque ex hoc solo capite admitterem, post completam quātitatem ad culpam sufficientem lethalem, furta alia leuia, quæ adduntur, non esse peccata lethalia: quandoquidem non dant notabile damnum, sed iam est datum, illudque leuiter augent.*

Sunt tamen circa hæc nonnulla obseruanda. Primum est. Si, dum quis furtum leue committit, quod complet quantitatem ad lethalem culpam sufficientem, aut, post illam completam, addit leuia alia furta, habeat animum restituendi, vt sæpe habere solent famuli, qui intendunt in fine, quando ab heris discesserint, ab eis petere, vt vel ea furta remittant, vel illa ex mercede ipsis debita compensent, tunc non facilè condēnari debet peccati lethalis. Tametsi, quia facilè potest id impediri, vel obliuione talis famuli, vel verecundia, vel cupiditate integræ mercedis, tempore, quo est soluenda, aut etiam morte repentina, qua id non possit hero significare, arcendus omnino sit ab eiusmodi furtis, timendaque aliquando sit culpa lethalis.

Secundum est. Sæpe inaduertentia præcedentium furtorum, & obligationis restituendi sub lethali peccato quantitatem notabilem ita per minima ablatam, videri excusare à culpa lethali eiusmodi furta. Præsertim quando, qui illa cōmittebat, existimabat se non incidere in culpam lethalem, eratque persona rudis ac idiota, quæ non penetrabat subtilitates has.

Tertium est. Tantam intercapedinem esse posse inter vnum ex his furtis leuibibus, & aliud, vt bene vbi suprà notat Nauar. & tam longo tempore posse perueniri ad summam aliquam valoris, vt, esto lethaliter peccaret, qui illam simul, aut breuiori tempore, esset furatus, non tamen peccaret lethaliter, neque teneretur illam sub culpa lethali restituere, qui tam longo tempore, & per tot internalla, aut per quantitates adeò paruas, eandem quantitatem valoris vsurpasset. Ratio autem est, quoniam non solent homines adeò esse inuiti, quòd longo tempore, & per minima, ita res de bonis ipsorum accipiantur, ac si simul acciperentur, aut breuiori alio tempore. Vt non solet herus ita esse inuitus, vt famulus, qui ipsi inseruit, accipiat de bonis ipsius per minima intra decem annos valorem sex, aut octo, regalium argenteorum, vel etiam ducati, ac si eam quantitatem simul acciperet, aut intra breue tempus, neque solet ita obligare ad restitutionem. Quo fit, vt quantitas, quæ ad culpam lethalem sufficit, si simul

accipiatur, aut intra breue tempus, non sufficiat, si successu temporis accipiatur. Præsertim in furtis domesticis famulorum, attento quòd heri non solent esse adeò inuiti, quòd à domesticis, quàm quòd ab externis, fiant: & quòd heri ipsi intelligunt, difficilè transigi hanc fragilem vitam, quin famuli interdum modicum aliquid accipiant: quare longè maior valoris summa decursu longi temporis accepta requiritur, vt famuli damnandi sint culpæ lethalis, atque vt sub eadem culpa cogendi sint illam restituere, quàm requiratur in aliis, aut si ipsi simul, aut breuiori tempore, illam acciperent.

Attendendum item est, ad eam summam taxandam, ad qualitatem & diuitias dominorum, & ad tenacitatem ac liberalitatem eorum, & ad qualitatem rerum, quæ furto ablatae sunt, & num ad cibum & potum attineant, vel non, atque ad reliquas circumstantias concurrentes. Ac sanè, nisi summa esset magna, attenta dominorum qualitate, & furta essent frequentia, iniungenda non esset restitutio, nisi heri essent miseri. Quoniam quamuis alioquin videantur tenaces pecuniæ, ac vellent, quòd ea furta non fierent, præsumendum est, non velle obligare ad eorum restitutionem, postquam eo modo sunt facta, eo magis, quo ditiores sunt, & splendidiorum habent familiam, ac generosiores animo sunt. Et quando ad sobriam sustentationem aliquid à famulis sumeretur, etiam ad vestitum, qualem eis heri præbere tenentur, non solùm non esset obligatio restituendi, quod ita sumeretur, sed neque esset peccatum illud clàm accipere, quando, si peteretur, denegaretur, aut non sine iurgio, & verecundia petentis, esset obtinendum, iuxta ea quæ disp. 506 dicta sunt. Tametsi confessarii, antequam hæc fiant, vrgere debeant, vt non fiant, nisi petendo illa à dominis: nisi fortè, qui confitentur, certi essent, dominos, si scirent, non fore inuitos, vt interdum certos se esse affirmant, aut nisi id sumeretur iuxta ea quæ Disp. 506. citata dicta sunt.

Dubium est, dato, verbi gratia, quòd, qui fura [sect. 3] tus est tres regales argenteos, siue simul, siue successiuè, teneatur restituere sub lethali, & quancumque minorem summam furto ablatam, non teneatur restituere sub lethali culpa, sed solùm sub veniali, vtrùm, qui furto retinet quantitatem trium regalium, excusetur à culpa lethali restituendi reliquum in posterum, si restituat octo, quatuor, aut duos, maravedinos, reliquumque sibi retineat. *Ioan. Med. q. 10. citata, §. penul.* innuere videtur, non excusari, sed sub lethali culpa teneri restituere reliquum. Mihi verò longè probabilius videtur contrarium. Non enim video, cur retentio summæ, quæ, si de nouo acciperetur, nō induceret obligationem restituendi sub culpa lethali, eam inducat, si retineatur ex alia maiori summa. Confirmari autem potest, quoniam si is, qui debebat centum aureos, retineat sibi infra tres regales argenteos, non peccat lethaliter, facta hypothesi initio huius dubii proposita; eo quòd summa ita sibi iniuste reseruata non pertingat ad eam, quæ requiritur ad culpam lethalem: ergo neque si eandem summam retineat ex tribus regalibus argenteis, peccabit lethaliter. Confirmatur rursus, quoniam ridiculum esset dicere, eum, qui ex tribus regalibus argenteis sibi retineret duos maravedinos, peccare lethaliter: neque eius rei alia est ratio, nisi quia summa illa adeò parua non sufficit ad culpam lethalem: cū ergo neque summa alia maior infra tres regales argenteos sufficiat ad culpam lethalem, vt supponimus; consequens profectò est, vt neque, si illa retineatur, obligatio sit eam restituendi sub culpa lethali. Ad id verò, vnde Med. ducitur, vt eam sibi persuadeat opinionem, nempe, quòd, qui sibi retinet tres regales argenteos, tenetur sub culpa lethali eos restituere, dicendum est. In eo sensu teneri eos restituere sub culpa lethali, quòd integros eos, & singulas eorum partes, tenetur restituere, & quamdiu eos integros retinet, cum animo nihil restituendi, peccat lethaliter, propter notabile detrimentum, quod iniuste infert proximo suo ea retentione: non verò quasi, si restituat partem, & retineat

reliquum, non cesset à lethali culpa, quatenus cessat ab inferendo notabile damnum proximo, eo ipso, quòd partem eius integri damni iam ei non infert.

Quando ob notabilem quantitatem, quam quis, per minima à singulis, furetur à diuersis; aut diuersi, per minima singuli, furentur ab eodem; culpa interueniat lethalis. Disp. 689.

SVMMARIVM.

1 . FVrtum, per minima à diuersis, maiorem summā requirit, vt pertingat ad culpam lethalem, quam si fieret ab eodem, & maiorem si decursu temporis, & sine animo inde ditandi, quam si fieret breuiori tempore, & cum animo ea via ditandi.

2 . Furtum notabile per minima à diuersis si factum sit vni & eidem, quando singuli sub lethali culpa restituere teneantur, vel totum, vel vnusquisque suum minimum, quando non item. Atque si excommunicatio lata sit non restituentibus id furtum ac damnum, quando singuli ea innodentur.

QVod ad primum attinet, dicendum est: In [sect. 1] primis maiorem requiri quantitatem ad

culpam lethalem, & ad obligationem restituendi sub culpa lethali, quando aliquis furatur à multis, à nullo tamen aliquid notabile, quàm quando furatur ab vno solo. Ratio est, quoniam, cum nulli eorum multorum damnum inferat notabile, omnes sunt minùs inuiti, quàm esset vnus, cui totum id damnum inferret. Quo fit, vt, cæteris paribus, dupla, aut plus quàm dupla, quantitas requiratur ad lethalem culpam in eiusmodi furtis multis, factis per minima ex singulis, quàm in furto facto in bonis vnus & eiusdem.

Dicendum deinde est: Minorem quantitatem sufficere ad culpam lethalem, quando aliquis simul furatur à multis, aut intra breue tempus, atque animo augendi opes de bonis aliorum, quàm quando longi temporis decursu furatur à multis, non animo congregandi bona ex facultatibus aliorum. Vt, verbi gratia, si aliquis de cumulo cōmuni multorum furetur quantitatem aliquam, quæ sit quidem in se notabilis, ceterum quæ nulli dominorum talis acerui notabile damnum inferat; vel si quis, intendens congregare sibi quantitatem notabilem de bonis aliorum, nulli eorum notabile damnum inferendo, discurrat per vineas, aut segetes, aliorum, & ab vnoquoque modicum quid accipiat, atque ita congreget quantitatem notabilem; vel si quis, vendendo vinum, aut aliquid aliud, misceat aquam, aut defraudet modicum quid de mensura, aut pondere, ita vt nulli eorum inferat notabile damnum, multos tamen emētes, simul sumptos, defraudet quātitate notabili: vel si quis de pecuniis aureis, vel argenteis, modicum quid præscindat, quod nulli, accipientium eas pecunias, notabile damnum inferat, omnibus tamen magnum inferat damnum; vti que in his omnibus euentibus, minor quantitas sufficit ad lethalem culpam, atque ad restituēdi obligationem sub culpa lethali, quàm in eo, qui longo tempore à diuersis modicum quid acciperet, non eo animo, sed fragilitate quadam, nunc ex vna vinea racemos aliquos colligendo ad manducandum, nunc ex alia, aut fructus alios simili modo furando, aut rem aliam modici valoris, ita quod longo tempore similibus furtis accipiat notabilem quantitatem. Ratio autem est, quoniam domini plus offenduntur, magisque sunt inuiti, illis prioribus modis furandi, quàm his

posterioribus, plusque volunt, vt illi priores restituant, quam vt restituant hi posteriores: quòd autem domini minùs sint inuiti, minusque velint restitutionem, in causa est, vt longè maior quantitas requiratur ad culpam lethalem, vt hac & præcedente disputatione est dictum. Adde, eum, qui ita temporis decursu furatur per modica notabilem quantitatem sine animo augendi sua bona, sed occasione data, non habere animum furandi magnam quantitatem, sed quasi per accidens, ac præter intentionem, ad eam quantitatem deuenire: qui verò simul accipit quantitatem notabilem ex aceruo multorum, aut paulatim animo augendi sua bona, aut comparandi vnde viuatur, & suppleat quotidianam necessitatem, intendere deuenire ad eam totam quantitatem notabilem: qui animus multum auget culpam.

Iuxta hactenus dicta, non facillè condemnarem culpæ lethalis eum, qui absque animo congregandi bona, & perueniendi ad notabilè quãtitatē, per minima, intra longum tempus furatus esset à diuersis valorem sex, aut octo, regalium argenteorum. Et quanuis semper pœnitētes, qui eiusmodi furta ita cōmissa confitentur, præcipiēdi sint restituere, vel propriis dominis, vel pauperibus pro animabus eorum, quorum sunt ea bona, si commodè non possit fieri dominis rei adeò modicæ restitutio: nisi, qui ea furta cōmiserūt, adeò pauperes sint, vt pręsumēdū sit, dominos nō velle, vt teneantur tam modicam quantitātē singulis restituui, sed potiùs, vt ipsis à confessario cōdonetur in eleemosynam pro animabus eorum dominorum; non tamen sum eius opinionis, vt, ac si posteriora essent peccata lethalia in virtute priorum ob notabilē quantitātē, quæ ex omnibus simul sumptis resultat, arbitror interrogādū esse in confessionibus numerum eorum furtorum: neque eiusmodi confitentes inducerem in conscientiam peccati lethalis, si non restituerent quantitātē totā. Hęc deprimò eorum, quę proposita sūt.

Quod verò ad secundum attinet, distinguēdū [sect. 2] est. Quoniam, si illi simul conueniant ad damnum notabile proximi tāquā concausē, ita quòd se in-[[33]]uicem inuitant, aut animo se inuicem defendēdi, accedunt simul ad id damnum inferendum, tunc vnusquisque eorum lethaliter peccat, teneturque sub culpa lethali restituere totum damnum, in euentu, quòd alii contribuere non velint, aut non possint, ad partes damni illius, quas ipsi dederunt: si tamen loco illorum restituat, singuli tenentur ei soluere, quod ipsorum loco restituit. Ratio huius asserti est, quoniam vnusquisq; eorum, esto modicum quid accipiat, causa est dāni totius ab omnibus dati, totalis quidem vtalitate effectus, sed partialis partialitate causæ, vt inferiùs, dum de restitutione sermo fuerit, fusiùs explanabitur. Si verò simul concurrerunt, nullus tamen fuit causa damni aliorum, sed sui dumtaxat, esto fortè fuerit occasio, quia primus cœpit furari, & alii, moti eius exemplo, illum sequuti sunt, tunc dicendum est: Si damnum ab omnibus datum sit notabile, & vnusquisque sciat de dāno dato, aut inferendo, ab aliis, omnes peccare lethaliter, tenerique sub culpa lethali eorum vnumquemque restituere eam solam partem dāni, quam dedit: eaque de causa, si feratur ex cōmunicatio, qua restitui præcipiatur id damnum, neque addatur, vt soli illi eam incurrant, qui tātum, vel tantum, sint furati, neque singuli suas partes restituant, vtique omnes, qui non restituerint, ea excommunicatione ligabuntur; quoniam licèt ea excommunicatio non incurratur, nisi ab iis, qui in culpa fuerint lethali non restituendo; omnes tamen sub reatu lethali tenentur in eo euentu restituere partes, quas furati sunt. Ratio verò huius asserti hæc est: Quoniam licèt damnum, à singulis datum, non sit notabile, damnum tamen ab omnibus datum est notabile; eaque de causa vnusquisque ipsorum, simul cum aliis, concausat damnum proximi notabile, ac proinde, nisi ignorantia probabilis excuset, qua vnusquisque eorum nesciat alios, vnà cum ipso, esse concausas talis damni notabilis, lethaliter peccant: eo quòd concausare damnum proximi notabile culpa sit

lethalis. Eadem ratione quādo alicui constat, post damnum notabile iniuste datum, ipsum, vnā cum aliis, illud dedisse, tenentur singuli sub culpa lethali illud ei resarcire, atque adeo tenetur ille sub lethali culpa restituere partem damni, quam ipse dedit; interim dum non est verum dicere, proximum illum iam non esse in damno notabili.

Nonnulla tamen admonuerim. Primum est; Maius damnum requiri ad lethalem culpam multorum, quorum quilibet accepit modicum quid, neque fuit causa damni aliorum, quā requiratur ad lethalem culpam vnus solū, qui dedisset totam latitudinem damni. Ratio autem est, quoniam longē minor culpa vnus cuiusque est, causam esse iniustam damni notabilis proximi, vnā cum aliis, modicum quid accipiendo de bonis illius, quā sit vnus eorum, dare iniuste id totū damnum; eaquē de causa longē maior quantitas damni requiritur, vt accipere modicum quid imputetur alicui ad culpam lethalem, quando alii dant similiter damnum, quā quando aliquis solus dat totum damnum.

Secundum est, non videri culpam lethalem, quando, post datum totum notabile aliquod dānum, vt post transitum exercitus per vineam alicuius, aliquis racemum de eadem vinea acciperet. Quoniam per eam acceptionem non concausat notabile damnum, sed inuenit illud iam datum, & ipse modicum damnum dat. Teneretur tamen id restituere sub culpa lethali: quemadmodum tenerentur, qui à principio modicum damnum dedissent, nescientes alios postea augmentaturos notabiliter damnum, esto id tunc accipiendo, non peccauerint lethaliter.

Tertium est. Quando modica aut nulla est spes reliquos restitutos, non videri culpam lethalem, eum, qui modicum quid accepisset, siue à principio, siue dum simul damnum notabile dabatur, siue post illud datum, id non restituere. Ratio autem est, quoniam id tunc insufficiens est ad eruendum proximum, etiam partialiter à damno notabili, & per se solum non est tanta quantitas, quā inducat obligationem restituendi sub culpa lethali, nihil impediēte, quod is, de cuius bonis iniuste est ablatum, sit aliorum culpa in damno notabili. Quando autem spes aliqua esset, quod multi ex aliis restituerent, tunc vnusquisque esset cogendus sub lethali culpa modicū id restituere, neque aliter esset absoluendus. Rarō tamen in praxi occurret casus, in quo modicū iniuste acceptum sub lethali culpa sit restituendum: quia rarō spes erit, quod alii modicas partes, quas acceperunt, restituent.

Quartum denique est. Moraliter hæc omnia esse intelligenda, ne in baratrum scrupulorum incidant confessarii & pœnitentes. Neque in alio euentu esse injiciendum scrupulum lethalis culpæ modicum quid accipientibus, aut cogendos esse illud restituere sub reatu culpæ lethalis, nisi quando constat alios dedisse simul damnum notabile, nihil impediēte, quod probabile sit multis, de quorum bonis modicum quid accipitur, decursu longi temporis, simul, aut successiuē, datum ab aliis esse notabile damnum. Longē quippe antea datum esse ab aliis damnum notabile non efficit culpam lethalem in me, quod circa aliquam rem damnum leue illi dem, neque inducit obligationem restituendi sub culpa lethali.

Vtrum in occulta acceptione rei propriæ, quam alius habet, cernatur furtum. Disp. 690.

SVMMARIVM.

1 . *FVrtum non committit, qui rem suam clàm ab eo accipit, qui illam iniustè retinebat.*

Peccat tamen, nisi concurrant conditiones requisitæ ad licitam compensationem, & quæ curare teneatur.

2 . *Furtum, saltem aliquo modo, committit, qui rem, suam clam ab eo accipit, qui iustè illam retinebat, teneturq; illi restituere valorem vsus, quo eum iniustè priuauit, & damna subsequuta, etiam lucri cessantis, & impedire ne alia sequantur, atque hæc omnia ex iustitia. Et quando actio furti concedatur, quando non item.*

QVod propositum est, erit consequenter disputandum. Rem, cuius dominium est apud alterum, potest aliquis apud se habere vno è duobus modis. Primo, titulo iusto, vt si illam accepit commodatam, conductam, in depositum, in pignus, aut titulo alio iusto. Secundo, iniustè, vt si illam furatus est, aut vsuariè accepit, vel finito tempore, pro quo erat commodata, conducta, [[34]] aut titulo alio iusto detenta, non vult eam reddere, vel alia ratione iniustè eam retineat.

Hoc ita constituto. Prima conclusio est. Quã⁵do aliquis rem suam clam accipit ab eo, qui illã [sect. 1] iniustè detinebat, non committit furtum. Et quãuis aliquando possit id licitè fieri, si concurrant ea, quæ ad compensationem licitam disputatione sequenti explicabimus; quando tamen illa nõ concurrunt, peccatum est ius sibi dicere, propria autoritate illam accipiendo. Præterea, qui rem clàm eo modo accipit, curare tenetur, ne ab eo, qui rem detinebat, neque ab hæredibus illius, iterum restituatur. Item curare tenetur eruere illum à conscientia, qua credit, se adhuc teneri eã restituere; ne in peccato perseueret. In hac conclusione conueniunt doctores communiter, Ioan. Med. de rest. q. 11. Sotus. 5. de iust. q. 3. art. 1. ad. 3. Syluest. verb. furtum. q. 12. Gab. in. 4. d. 15. q. 3. art. 3. dub. 3. & alii, patebitq; magis ex dicendis circa compensationem disputatione sequenti. Prima verò pars huius conclusionis colligitur apertè ex l. si is qui rem. 1. ff. de furtis. D. Th. 2. 2. q. 66. art. 3. ad. 3. licèt in re circa eandem primam partem conclusionis consentire videatur, obscurè tamen loquitur, & Caiet. ibidem laborat in eo explicando ac defendendo.

Secunda conclusio. Quando aliquis rem suã⁶ clàm accipit ab eo, qui iusto titulo eam detinebat, neque adhuc tenebatur eam reddere, committit [sect. 2] furtum aliquo modo, quatenus scilicet iniustè priuat legitimum detentorem iure, quod ad illã retinendam habebat, teneturq; restituere ei commodatam, quam iure poterat ex ea percipere. Vt si erat commodata vsque ad certum tēpus, aut locata, tenetur restituere ei vsum rei illius, quo iniustè eum priuauit, aut valorem illius, si vsus restitui non possit. Insuper tenetur ei restituere totum lucrum ex eo ei cessans, aut damnum ex eo ei emergens, quòd iniustè eam rem acceperit. Præterea tenetur curare, ne is detentor, aut hæres illius, iterum illam restituant, arbitantes periisse, aut disparuisse, culpa detentoris. In hac conueniunt D. Th. & Med. locis citatis, & doctores communiter. Neque in ea potest esse dubium, tum in conscientia, tum etiam in exteriori foro, quoad ea, ad quæ eum teneri, sunt commemorata:

eo quòd ea iniusta talis rei acceptione, causa fuerit iniusta eorum omnium damnorum ei, qui iustè illam retinebat: atque in exteriori foro, saltem actione ex eo titulo iusto, ex quo iustè illam detinebat, vt actione cōmodati, vel locati, aut alia simili, iniustus talis rei ante tempus occupator cogetur ad ea omnia, quæ commemorata sunt. Dubium verò est, vtrùm in exteriori foro aduersus dominum rei, ita iniustè elàm eam occupantis, competat actio furti ad pœnam pro furto statutam. Et quidem, quando detentor iustam causam habebat rem retinendi, vt quia in pignus adhuc perseuerabat ei obligata, aut quia in re commodata fecerat commodatarius expensas, quas commodans tenebatur soluere, & ratione quarum, interim dum non soluebantur, tanquam pignus poterat eam retinere, aut si detentor vsumfructum in ea re adhuc habebat, & idem credo, si illam habebat conductam, necdumque finitus erat contractus, quandoquidem ex mercede conductionis competeat oneroso contractu iusta detentio, sanè in his omnibus, & in similibus euentibus, conceditur actio furti aduersus dominum rei ita iniustè eam clàm occupantem, vt expressè habetur *l. creditoris. §. vlt. l. in actione. §. qui rem, & l. si quis rem. 1. ff. de furtis*. Quando autem contractu commodati lucratiuo commodatarius rem iustè detinebat, & ante finitum contractum commodans rem clàm usurpauit, non videntur iura concedere commodatario aduersus commodantem actionem furti, sed solùm actionem ex commodato contrariū (ei scilicet actioni, quæ commodanti competit aduersus commodatarium, quæ in iure appellatur actio directa ex commodato) ad ea omnia, quæ commemorata sunt, vt satis innuere videntur. *l. creditoris. §. vlt. iuncta glossa ibi*, verb. placuisse, & *l. si quis rem. 1. ff. de furtis*.

Discrimen verò est inter acceptionem proprię rei in euentu huius, & in euentu præcedentis cōclusionis. Quòd, cùm in euentu huius conclusionis ea acceptio sit contra iustitiam, tenetur accipiens ex iustitia ad damna omnia ex tali acceptione subsequuta. Ad ea verò, ad quæ diximus in prima conclusione teneri, qui rem suam clàm accipit, solùm tenetur ex caritate, quoad commodè id efficere potuerit; eo quòd acceptio non fuerit contra iustitiam; atque inde est, quòd, quicquid sequatur, non teneatur id resarcire, nisi aliquid proximi inde ad ipsum peruenerit.

Vtrùm absque furto licitumque aliquando sit, propria autoritate compensare occultè, quod alius debet, tantundem de bonis illius accipiendo. Disp. 691.

SVMMARIVM.

1. *C*ompensatio in foro conscientię, quibus conditionibus interuenientibus sit licita.
2. *L*egitimè si in foro conscientię sit facta compensatio, & propter illam, qui legitimè eam fecit, condemnetur in foro exteriori, non tenetur stare sententię, si sine scandalo possit, quę in sola præsumptione fundatur.
3. *C*ompensantem legitimè in foro conscientię, dominium comparat rerum, quas in compensationem accipit.

4 . Compensatio quousque licita, aut illicita, famulis, & iis, qui res aliorum agunt. Quam panane incurrant sartores, & alii, qui a mercatoribus aliquid accipiunt, & mercatores, qui id eis dant, vt emptores ab ipsis potius, quàm ab aliis emant.

Disputatio hæc cum præcedente est coniun [sect. 1] cta. In quibus autem rebus, & quando,

locum habeat compensatio in foro exteriori, & in quibus rebus, & quando, locum non habeat, Disp. 297 & 560. dictum est. Nunc verò de compensatione in conscientiæ foro est disserendum. Et quidem communis doctorum sententia affirmat, licitam in foro conscientiæ esse occultam compensatio nem autoritate propria, atque adeò furtum in ea minimè interuenire; modò tamen sequentes conditiones interueniant.

Prima, vt debitum, quod quis ita compensat, sit liquidum ac certum omnino. In dubio enim, etiam probabili, an aliquid alicui debeatur, nefas est ei, occultam accipere compensationem. Quòd si aliquid in compensationem talis debet [[35]] accipiat, contra iustitiam peccat, atque ad restitutionē illius tenetur, & damnorum, quæ inde ei fuerint subsequuta, à quo fuerit acceptum. Ratio verò est, quo niam in dubio melior est conditio possidentis: eaque de causa, sicut, qui id possidet, non tenetur dare, nec totum, nec partem eius, quod ita possidet: sic contra iustitiam peccat, qui id clā ab eo inuito accipit. Cum hac prima conditione id etiam est coniunctum vt non plus accipiat, quàm sit liquidò debitum.

Secunda, vt, qui id vult ita compensare, non speret, petendo à debitore, aut iudicis autoritate, quodsibi debetur, posse id cōmodè recuperare: vt, si desint ei probationes, aut debitor sit potēs, quē iudices solent timere, periculumque sit quòd ea, aut alia ratione, iudex flectetur, aut ex ignorantia iniustam feret sententiam, vel si necessarii sint magni sumptus, aut labores, aut molestiæ, ad eam rem via iudicis obtinendam, aut timetur periculum alicuius damni ac iacturæ honoris, amissionis amicitiae cum debitore, vel alterius similis: modò tamen hæc alicuius sint momenti, habita ratione rei, de qua agitur. Ac sanè, quando adsunt cæteræ conditiones requisitæ, facilè hæc interuenire poterit, nisi debitor cordatus sit ac bonæ conscientiae, qui facilè, sine lite, debitum soluet, si admoneatur, sufficientesque sint probationes. Illud verò admonuerim, qui, quando debitum est liquidum, commodeque posset illud via iudicis obtinere, faceret occultam compensationem, quamuis peccaret, & interdum lethaliter, ius sibi dicendo, propriæ autoritate rem sibi debitam vsurpando, contra id, quod. l. vnica. C. nequis in sua causa, sancitum est; nihilominus, quia res erat sibi debita, neque ita occultè eā vsurpando, peccauit contra iustitiam, sed solùm transgressus est ordinem à iure statutum, vtique ad nullam teneretur illius restitutionem; sed solùm teneretur subire pænam, si quam iudex postea ea de causa ei imposuerit, detecta iam acceptione propria autoritate, & lata à iudice ea de re sententia.

Tertia, vt ex tali compensatione non sequatur scandalum aliorum, aut detrimentum alterius, cui imputari possit, eum furto id accepisse, aut aliud simile, neque item sequatur periculum infamiæ propriæ, aut dāni ipsius corporalis, quatenus, si constet postea ipsum id accepisse domino inuito, præsumetur in exteriori foro, fuisse id furatum, punieturque vt fur. Ad hanc tamen cōditionem seruandam, solùm teneretur lege caritatis propriæ, ac proximorum, non verò iustitiæ lege. *Gab. in 4. d. 15. q. 3. art. 3. quem sequitur Nauar. in Manu. c. 17. n. 113. ait*, quando ex tali compensatione sequeretur damnum spirituale, aut corporale, alterius, teneri ita compensantem ad restitutionem illius. Cæterum, si solùm sequeretur per accidens, quia videlicet per accidens est, quòd præsumatur alium id furto abstulisse, aut alia simili

ratione, non video efficientem ita cōpensationem, peccare contra iustitiam, sed solū contra caritatem, & ob id non credo teneri eum ad restitutionem.

Quarta, vt consulat spirituali eius saluti, à quo id in compensationem accipit, illi significando, non teneri eum iam ad id debitum, quando est verisimile eum existimare, se adhuc ad illud teneri, cum conscientia peccati non restituendo, quod re ipsa restituere non tenetur. Item vt provideat, ne debitor, aut hæredes illius, idem debitum restituant iterum, si notitiam habeant de debito, arbitrenturque se ad illius restitutionem adhuc teneri. Ad hæc tamen duo solū tenetur lege caritatis, quantum patiuntur circumstantiæ concurrentes, attendendo, ne ex tali significatione, aut ex alio remedio, quod in debitoris bonum sit adhibendum, immineat ei, qui compēsationem fecit, notabile aliquod damnum, si debitor compensationem suspicetur. Quia ergo compensans ad hæc non tenetur lege iustitiæ, neque etiam ad secundum, quando sine suo notabili detrimento non potest impedire restitutionem minimè iam debitam, vtique quicquid postea sequatur, ad nullam tenetur restitutionem ex parte iniustè acceptionis, damnive iniustè dati; sed solū ex parte rei acceptæ tenetur reddere, quod fuerit restitutum, cū iam minimè deberetur, aut teneretur illud non accipere, si commodè possit.

Quinta, vt id, quod in compensationem accipitur, sit debitoris, & non alicuius alterius. Si enim acciperet rem apud debitorem deposita, aut ei commodatam, vel in pignus traditam, aut quam furto, vel vsurariè, acceperat, vel cuius alia ratione non comparasset dominium, tum restituere illam teneretur ei, cuius esset, seruareque eum teneretur indemnem.

Sexta, vt compensatio, quoad fieri possit, in re fiat vsu consumptibili, eiusdemque speciei cū ea, quæ debebatur. Vt si debebatur pecunia, fiat in pecunia; si triticum, aut oleum, fiat in tritico aut oleo. In aliis quippe rebus non facilè seruatur æqualitas, faciliusque euenit, grauari debitorem, esseque rationabiliter inuitum: qua de causa, vt disputationibus citatis dictum est, in foro exteriori non admittitur compensatio, nisi in rebus vsu consumptibilibus, eiusdemque speciei, cum rebus debitis. Quando autem non sunt bona eiusmodi, in quibus compensatio fiat, fieri in foro conscientiæ potest in quibuscumque aliis rebus: seruanda tamen est æqualitas quoad valorem, semperque fieri debet cum quàm minima debitoris iactura possibili.

Aliqui septimam addunt, quòd, qui ita compensat debitum, non sit in erronea conscientia, quòd compēsando eo modo, quod sibi debetur, peccet. Et quòd paratus non sit committere lethale peccatum periurii, negando compensationem, si de ea sub iureiurando interrogetur, aut aliud lethale peccatum. Cæterum id, quod dicitur de conscientia erronea, in omnibus actibus licitis similiter locum habet. Id verò, quod de periurio illo additur, facilè vitari posset, respondendo, cam non fecisse, intelligendo, quam confiteri teneatur. Qui sensus verus est, legitimusque ac rectus iudex, si is sensus exprimeretur, diceret, se non in alio interrogare, vt alibi copiosius de similibus iudicum interrogationibus dicitur.

In his conditionibus, tametsi non ita copiosè explanatis, consentiunt. *D. Th. 2. 2. q. 66. art. 5. ad 3. Caiet. ibi. Sotus 5. de iust. q. 3. art. 3. Med. de rest. q. 11. Gab. in. 4. d. 15. q. 3. art. 3. dub. 3. Syluest. verb. furtiū. qu. 13. Nauar. in Manu. ca. 17. nu. 112. & sequentibus, Palud. in. 4. d. 15. q. 2. art. 2. concl. 5. & alii.* Ratio verò cur, seruatis his conditionibus, fas sit occulta compensatio, hæc est: Quoniam non est præsumentum, ius humanum intendisse, concurrentibus his conditionibus, nullaque occurrente via [[36]] tuta, qua is, cui aliquid in dubitatè debetur, comparare id possit via iudicis, prohibere compensationem occultam, neque, si id intendisset, iustum esset tale præceptum: quo fit, vt, concurrentibus his conditionibus, non faciat contra ordinem, sed præter ordinem iuris,

qui talem fecerit compensationem. Neque is dicit sibi ius, sed exequitur suum ius perspicuum ac manifestum, in defectum publicæ potestatis, quæ id velit, aut possit exequi: in quo sanè nullum interuenit peccatum.

Dubium est, vtrùm, qui modo explicato acci [sect. 2] pit aliquid in compensationem, comparet dominium illius, & alter, de cuius bonis id accipit, illud amittat. Et vtrùm, si postea de compensatione facta constet, eaque de causa compensans condemnetur ad aliquam pœnam, teneatur in conscientiæ foro stare sententiæ. Hæc duo dubia excitat *Ioan. Med. q. 11. citata*. Atque, quod ad primum attinet, propendere videtur, compensantem non comparare dominium. Quod verò attinet ad secundum, ait, non teneri in foro conscientiæ stare sententiæ. Quoniam, quando non interuenit culpa, non debetur pœna. Et quoniam ea sententia fundatur in præsumptione, quòd culpa interuenerit in ea acceptione rei alienæ: quemadmodum autem, qui ante Cōciliū Tridētinum duxerat aliquam clandestinè, & postea duxit aliam ante faciem Ecclesiæ, non tenebatur parère iudici præcipienti, habitare maritaliter cum secunda; eo quòd ea iudicis sententia fundaretur in præsumptione, quòd secunda esset legitima vxor illius, & non prima; eaque de causa, esto ei imponeretur excommunicationis pœna, excommunicatus non esset coram Deo, non parendo tali sententiæ; ita res haberet in proposito, quòd condemnatus ad pœnam ob legitimā compensationem, non teneretur in foro conscientiæ subire eam pœnam, ex falsa præsumptione ei impositam.

Mihi probatur hæc responsio Medinæ ad secundum dubium. Quoniam ea compensatio iustè ac licitè esset facta: eaque de causa, si ei, de cuius bonis esset facta, id constaret, peccaret cōtra iustitiam accusando eum, qui illam fecisset, aliquidque in pœnam eius compensationis ab eo accipiendo, tenereturque illi in conscientiæ foro ad omnia damna inde ei subsequuta. Et similiter, si in iudicio id apertè constaret, peccaret iudex contra iustitiam ferendo talem sententiam, tenereturque similiter ei in conscientiæ foro ad omnia dāna ex ea sententia illi subsequuta. Quia, vt dictum est, ius humanum nunquam intendit, prohibere in eo euentu compensationem in se æquam, & neque parti, neque iustitiæ publicæ in eo euentu iniuriosam. Quando autem in iudicio non constat, interuenisse in ea omnes conditiones requisitas ad licitam in foro consciētiae compensationem, præsumptio est iuris & deiure, interuenisse aliquam culpam, maiorem, vel minorem, prout fuerint conditiones, quas interuenisse non constat; eaque de causa potest iudex licitè eum condemnare ad maiorem, vel ad minorem, pœnam prout fuerint conditiones, quas interuenisse non constet: ita tamen condemnatus, stare non tenetur in foro conscientiæ tali sententiæ, quæ in falsa præsumptione fundatur.

Quod verò ad primum dubium attinet, in cō [sect. 3] trarium potius inclino responsioni Medinæ. Nempe ita compensantem, comparare dominiū rerum, quas ita accipit in compensationem iustā ac licitam. Cū enim ea compensatio iusta ac licita sit, iureque naturali permissa, sanè eandem vim videtur in se, & in conscientiæ foro, habere, ac si publica autoritate esset facta: maximè cū dicere possimus, interuenire auctoritatem diuinam mediante naturali iure, quod illam permittit, ac licere docet. Confirmatur compensantem dominium earum rerum comparare, quoniam si dominium earum perseueraret cum eo, cuius erant ante compensationem, sequeretur, quòd si, facta compensatione, res illæ perirent sine culpa eius, qui illas accepisset in suas, non perirent cōpensanti, sed ei, cuius antea erant; eo quòd, quando aliud iure non est statutum, res pereat illi, cuius est. Vnde vltiūs sequeretur, posse eum, qui res illas in compensationem iustam accepit, facere iterum aliam compensationem, exigereq; de nouo suum debitum: quod nullus admittet, vtpote omnino absurdum.

Ad id verò, vnde Medina ducitur, vt eam sibi persuadeat opinionem. Nempe, quòd antiquus dominus potest extrahere postea eiusmodi res de potestate cuiuscunque, apud quem fuerint repertæ, ei que adiudicabuntur vt suæ; dicendū est. Falsum id esse, si constet, compensationem factam esse cum conditionibus requisitis, vt sit licita. Quando autem id non constaret, præsumeretur facta illicitè & iniustè, eaque de causa tales res, ex præsumptione, quòd iniustè essent usurpatæ, adiudicarentur antiquo domino; aut in pēnam, quòd non via ordinaria esset facta, eidem adiudicarentur.

Quousque autem famulis, & aliis, quibus a [sect. 4] liquid faciendum committitur, concedi possit, aut non possit, compensatio occulta, Disp. 363. 506. & Disp. 548. dictum est. Illud circa dicta disp. 363. obserua. l. 11. titu. 12. lib. 5. nouæ collect. sic esse dispositum. *Mandamos, que ningun mercader, trapero, nitratante, no de à los sastres, ni tundidores, ni jubeteros, ni calceteros, hoques ni marauedis algunos, porque vayan à sus tiendas con los que van à sacar dellas paños, ni sedas, ni otras mercadurias so pena delo pagar con el quatro tanto para nuestra Camara. rotro si mandamos à los dichos sastres, y tundidores, y jubeteros, y calceteros, y otras personas, à quien tocæ y atañe lo suso dicho, que no pidan ni demanden los dichos hoques, so pena de lo pagar con el quatro tanto para nuestra Camara.*

Vtrūm lata excommunicatione à prælato, vt, qui rem aliquam accepit, illam intra certū tempus restituat, & qui id seit, rem intra idem tempus manifestet, ea excōmunicatio comprehendat eum, qui in compensationem licit am rem accepit, eumque, qui ita acceptam fuisse nouit. Disp. 692.

SVMMARIVM.

1. *EX*communicatio vt furtum intra tantum tēpus restituatur, aut aliud simile fiat, ad quod occultus peccator tenetur, & vt qui id scit, illud intra id tempus detegat, ortum habet à correctione media inter fraternam, seu paternam, ac iudicialem, & quid præcedere ante eam denunciationem debeat.

[[37]] 2. *Ex*communicatio si feratur, vt aliquid intra tantum tempus restituatur, non ligat præceptum ac *ex*communicatio eum, qui illud in recompensationem licitam occultè accepit. Et quando idem erit dicendum, etiam si compensatio facta sit cum peccato.

3. *Sciens, aut omnino sibi persuadens, aliquid acceptum esse in compensationem licitam, aut retineri licitè in compensationem, non tenetur id denunciare, etiam si sub excommunicatione præceptum sit, vt denunciatur. In dubio verò, an licitè retineatur, detegere illud tenetur.*

VT tractatu. 5. copiosius dicitur, eiusmodi [sect. 1] *ex*communicationes ortum habent ex correctione media inter fraternam, seu paternam, de qua mentio est in Euangelio, & inter iudicialem; de qua quidem correctione media sermo est. c. nouit, de iudiciis, vt doctores ibi, & alibi, fusè tradunt. Quatenus enim præcipuè ea correctione intenditur eruere à peccato lethali eum, qui rem alienam iniustè detinet, correctio illa est Euangelica. Quatenus verò simul intenditur per accidens, & ex consequenti, vt resarciatur damnum iniustè datum

denunciante, atque ad petitionem illius id præceptum, eaque excommunicatio, sub qua id præcipitur, fertur, eadem correctio participat de iudiciali: eaque de causa media est inter fraternam, seu paternam, & iudicialem; tametsi magis de fraterna seu paterna Euangelii participet, quàm de iudiciali. Hinc est, quòd, præsertim dum occultus est delinquens, præcedere debeat admonitio, ordoque in Euangelio præscriptus, si spes sit, quòd ea via resipiscet, ac restituet, vt tenetur, fierique debeat ea correctio cum quanta minima iactura famæ illius fuerit possibile, atque statim ac cessauerit à peccato, & à damno iniusto proximi, cessare debet ea correctio: nihilque impediante præcepto prælati, quo sub excommunicationis latæ sententiæ pæna præcipit, vt, qui nouerit, quis id habeat, eum denunciaret ac detegat, non prius detegi possit ac denunciari, quàm si, admonitus, non velit resipiscere, cessareque à peccato, vel nisi spes non sit, quòd admonitus, seruatoque ordine in Euangelio præscripto, non resipiscet.

His ita constitutis, prima conclusio hac de⁷ re est. Quando aliquid in compensationem licitam, modo præcedente disputatione explica [sect. 2] to, fuit acceptum, certè, nihil impediante prælati præcepto sub excommunicationis latæ sententiæ pæna, non tenetur, qui id accepit, illud restituere, neque excommunicationem incurrit, esto prælatus expressè præcipiat, vt, quamuis in recompensationem sit acceptum, restituatur. Probatur, quoniam, qui id accepit, non tenetur id reddere, quasi debitum parti; eo quòd iustè id acceperit ac retineat; neque in pænam propter delictum; eo quòd nullum cõmiserit delictum, id ita accipiendo; neque prælatus præcipere potest eam restitutionem, nisi ex hypothesi quòd, qui id acceperit, sit in peccato id retinendo, ac non reddendo illi, cui reddi præcipit, vel in alia culpa, ob quam prælatus id præcipere posset in pænam: ergo in euentu, de quo nostra conclusio loquitur, nihil impediante prælati præcepto, ac excommunicationis pœna, qui id in compensationem iustam ac licitam accepit, non tenetur illud reddere. Quòd si prælatus aliud intenderet, (quod tamen nullo modo est præsumendum) vtique eius præceptum esset iniustum, contineretque errorem intolerabilem, ac proinde excommunicatio esset nulla omnino, de qua proinde non esset curandum. Ita *Ioan. Med. de rest. q. 11. Nauar. in Manu. c. 17. num. 114.* & sequentibus, & doctores communiter.

Secunda conclusio. Quando debitum erat⁸ certum, & quod in compensationem est acceptum, non excedebat debiti quantitatem, eratque ipsius debitoris, atque ex compensatione nullum sequebatur detrimentum, quod compensans sub reatu lethalis culpæ post factam cõpensationem vitare teneretur, quodque prælatus suo præcepto sub ea pæna intenderet, vt compensans vitaret, tunc, esto compensatio esset facta cum lethali compensantis peccato, propterea quòd seruata non esset aliqua alia ex conditionibus præcedente disputatione explicatis, vt compensatio sit licita, vtique, quamuis prælatus sub pæna excommunicationis præciperet, vt id restitueretur, & quamuis adderet, vt restitueretur nihil impediante, quòd id acceptum esset in compensationem, accipiens non teneretur id restituere, neque incideret in eam excommunicationem. Hanc conclusionem mihi persuadeo, quoniam accipiens non teneretur tunc in hoc euentu ex ipsa rei natura rem ita acceptam restituere; eo quòd non peccauerit contra iustitiam eam ita accipiendo, quin potiùs per eam acceptionem redacta ad æqualitatem sit inæqualitas, quæ antea erat inter ipsum & debitorem: vnde communiter doctores consentiunt, nisi prælatus in præcepto addat, vt restituatur nihil impediante, quòd in compensationem sit accepta, compensantem non teneri in hoc euentu eam restituere, vt *Med. & Nauar. locis citatis*, & alii affirmant; cuius rei hæc est ratio: quoniam præceptum illud, si id non addatur, intelligitur, quando accipiens ex ipsa rei natura

restituere eam rem tenetur; si ergo in euentu nostræ conclusionis, addente prælato, quòd, esto accepta in recompensationem sit, restituatur, insurgeret obligatio eam restituendi sub pœna excommunicationis, vtique id ex eo esset quòd prælatus id statuere potuerit in pœnam delicti, vt Med. vbi suprà affirmat.

Cæterùm, si res hæc rectè expendatur, comperietur, non attinere ad prælatum punire eiusmodi occultum peccatum, quod in futurum nō pendet, sed finitum, consummatumque iam est, præsertim pœna temporali, cogendo compensantem restituere, quod ex natura rei licitè iam retinet, & præcipiendo, vt seipsum efficiat exequutorem eius pœnæ.

Pœna quippe excommunicationis non imponitur ei propter peccatum præteritum, sed nisi velit obedire præcepto prælati, exequendo aduersus seipsum pœnam temporalem, quam ei prælatus ob præteritum delictum imponit. Vnde arbitror, prælati potestatem ad id non se extendere; eaque de causa, si illa esset illius mens in eo præcepto, contineret errorem intolerabilem, neque in conscientia obligaret. Quando ergo prælatus sub excommunicationis sentētia præcipit rem ablatam restitui, nihilque vlte-⁹[[38]]rius addit, intelligitur, quando ex natura ipsa rei cōpēsans ad id tenetur, secluso eo suo præcepto. Quando verò addit, nihil impediēte, quòd res accepta sit in compensationem, intelligit, tum quando debitum non erat certum, tum etiam quando plus fuit acceptum, (in hoc tamen euentu solūm intelligit quoad incrementum) tum denique quando ex compensatione sequutum est damnum, quod compensans teneatur vitare restituendo, quod in compensationem accepit. Quòd si de prælati mente aliud constaret, vel ex verbis præcepti, vel aliunde, certè præceptum tunc errorem contineret intolerabilem, neque in conscientia obligaret.

Tertia conclusio. Qui scit, aut sibi omnino⁹ persuadet, rem acceptam esse in compensatio [sect. 3] nem in euentibus, in quibus duabus præcedentibus conclusionibus dictum est, accipientem non teneri rem restituere nihil impediēte prælati præcepto, & pœna excommunicationis apposita, sanè is neque tenetur, neque potest, denunciare prælato, quis rem acceperit, aut possideat: quin potiùs, si prælatus obligare in his euentibus intenderet scientes, vt id denunciarent, præceptum contineret errorem intolerabilem, ac proinde non obligaret, neque transgredientes id præceptum incurrerent excommunicationem. In dubio tamen, an res in talem recompensationem esset accepta, tenerentur scientes sub excommunicationis pœna id de nūciare. Neque esset satis, si, qui id accepit, diceret, se in compensationem iustam id accepisse, vt, qui in eo esset dubio, denunciare id non deberet: nisi, qui id sic affirmaret, esset talis, cui meritò esset omnino credendum, vt Nauar. vbi suprà probè obseruat. Conclusio hæc communis est doctorum. Quoniam sciens solūm tenetur manifestare eum, qui rem accepit, quando accipiens tenetur eam restituere: eo quòd in eo solo euentu potest ad id prælatus obligare. Obseruat verò optimè Nauarrus vbi suprà, si in euentu, in quo quis non tenetur rem restituere, sub iure iurando interrogetur, an ipse eam acceperit, posse neganter respondere, intelligendo in euentu, in quo teneatur id manifestare. Ratio autem est, quoniam in eo solo sensu debet iudex interrogare, si legitimè ac iuridicè interroget: in euentu autem, in quo quis non legitimè interrogatur, non tenetur respondere ad mentem interrogantis, sed satis est, quòd respōdeat in aliquo sensu vero, præsertim in eo, in quo iudex interrogare deberet, si legitimè ac iuridicè interrogaret. Idem dic, si quis sub iureiurando interrogetur, an sciat quis rem acceperit, aut retineat, in euentu, in quo ipse non tenetur id manifestare: potest enim respondere similiter neganter, intelligendo in euentu, in quo ipse teneatur id manifestare.

Vtrum captiui inter Turcas, ac Saracenos, & alios, cum quibus ex parte nostra bellum est iustum, & ex parte ipsorum iniustum, verum furtum, aut rapinam, cōmittant, accipi#do eorum bona, ipsis inuitis. Disp.693.

SVMMARIVM.

1. *Furtum committeret captiuus Christianus, si aliquid clām acciperet ab infideli, à quo bello iusto ex parte infidelium esset captus.*
2. *Captiui Christiani inuitè ab infidelibus capti, licitè fugiunt, & licitè accipiunt competentem suorum obsequiorum compensationem ab iis, à quibus detinentur, aut qui causa eius captiuitatis ac damnorum ipsis fuerunt, etiam tempore treguæ aut pacis.*
3. *Furtum non committunt, quicunque de republica Christianorum, quæ bellum iustum habet cum infidelibus, aliquid ex eis infidelibus belli tempore diripiunt, sed licitè id efficiunt. Excipe, si diripiatur ab eis, qui ex pacto inter nos conuersarentur, aut si qui nostri ex pacto inter illos versarentur.*

Disputatio hæc ad rem licitæ compensationis etiam spectat. Et quamuis in principio Disp.

37. aliquid hac de re dictum sit, copiosius tamen est hoc loco examinanda.

Quando Christianus aliquis bello iusto ex [sect. 1] parte infidelium legitimè esset captus, dubium non est, quin verum furtum, aut rapinam, committeret, sivi, aut clām, aliquid acciperet ab eo, à quo legitimè possideretur, aut à republica, ex cuius parte bellum esset iustum: non secus ac de captiuis, qui apud nos sunt, est dicendum, quando bellum à parte nostra est iustum, legitimeque illi à nobis possidentur: & ideo rem hanc arctauimus, vt in titulo est proposita.

Prima ergo de hac re est conclusio. Captiui,¹⁰ de quibus hoc loco controuertimus, non solùm licitè possunt fugere atque euadere captiui [sect. 2] tatem, sed etiam accipere possunt de bonis eorum, à quibus captiui detinentur, quive causa fuerunt damni ipsorum, competentem recompensationem pro seruitiis, & pro iniuriis, quas passi sunt. Hanc affirmat *Caiet. 2. 2. q. 66. art. 8.* Probari autem potest, quoniam eiusmodi compensatio iusta est ex natura rei: si verò ex aliquo capite esset illicita, solùm esset, quia fit propria autoritate: Cæterum, licèt eiusmodi captiui sint inter illos, sunt tamen de aliena republica, vereque sunt hostes illorum, qui non sperant ius suum obtinere per potestates reipublicæ, in qua detinentur ac vexantur iniustè: ergo licitè possunt ius suum exequi aduersus illos, tanquam partes alterius reipublicæ, quæ iustum habet bellum aduersus illos, quæque potest sumere de illis competentem satisfactionem ac vindictam: præsertim cùm principes reipublicæ talium captiuorum præsumendi non sint ea in parte inuiti, neque sit æquum, vt sint inuiti. Quo fit, vt non solùm occultè, sed etiam apertè, ac vi, possint mandare id exequutioni, si spes sit, quòd absque graui incommodo assequuntur, quod intendunt. Quin & quicunque alii licitè eos possunt ad id adiuuare: eo quòd non aliud id sit, quàm ad rem iustam cum eis cooperari. Secunda conclusio. Etiam tempore treguæ¹¹ inter vtramque rempublicam fas est eiusmodi captiuis fugere, accipereque competentem cōpēsationē pro seruitiis, ac iniuriis ab iis acceptis, à quibus eas sunt passi. Probatur, quoniam in tregua, aut pace, solùm intelligitur,

quòd nullus de numero eorum, qui sunt in vnaquaque earum rerumpublicarum, inuadat rempublicam alteram, damnúmve aliquod illi [[39]] inferat: non verò quòd, qui iniustè detinentur in vna, non possint transfugere ad aliam, asportando secum iustam mercedem suorum laborum, iustamque compensationem iniuriarum, quas in illa alia sunt passi.

Tertia Conclusio. Tempore belli, hoc est, quā¹²do neque pax neque tregua est, fas est, non solùm [sect. 3] eiusmodi captiuis, sed etiam quibuscunque de nostra republica, accipere à Turcis & à Saracenis, contra quos bellum iustum habemus, quæcunque, tanquam à veris hostibus, idque non solùm clam sed etiam vi. Excipe, quando ex pacto conuersamur inter illos, aut illi inter nos: nam tunc tregua est inter illos & nos, quoad eos præcisè, qui ita ex pacto conuersantur, & de hoc euentu sermo erit conclusione sequenti. Probatur conclusio proposita. Quoniam verè sunt hostes nostri: neque est præsumptio, quòd principes nostri sint quoad illa inuiti, quin potius id approbabunt, æquumque est, vt id ratum habeant: quare cùm iustè fiat, fiatque autoritate, saltem præsumpta, nostrorum principum consequens est, vt licitè fiat: præsertim cùm, supposita veritate sanctissimæ fidei nostræ, & quòd belli iustitia à nostra parte pugnet, nullum sit rationabile scandalum ea in re.

Quarta conclusio. Quando nostri inter illos¹³ ex pacto commorantur, vt quando peregrinantes Hierosolymam, de illorum consensu, transeunt per terras, quas illi occupatas habent, aut aliquis nostrorum, ex eorum facultate, versatur inter illos, vt redemptioni captiuorum, aut alteri negotiationi intendat, vel illi, de facultate nostrorum principum, inter nos commorantur, nefas est, non solùm vi, sed etiam clàm, quicquam illorum eripere, nisi eorum aliquis in particulari aliquid iniustè retineret eius, qui id acciperet, aut aliquam aliam iniuriam ei fecisset, in cuius recompensationem iustè, clàm, absque vllò scandalo, id acciperet. Probatur conclusio, quia tales infideles domini re vera sunt rerum suarum mobilium, licèt respublicæ eorum iniustè possideant terras, quas à Christianis occuparunt; suppositoque illo pacto, nefas est bellum aduersus quenquam eorum mouere, illúmve bonis suis spoliare; eo quòd ibi locum habeat regula illa *Aug. & communis. c. noli. 23. q. 1. Fides quando promittitur, etiam hosti, seruanda est:* ergo iniustitia, cum onere restituendi, fieret tali infideli, si aliquid ab eo vi, aut clàm, eriperetur. Si autem is, à quo aliquid tunc eriperetur, retineret iniustè aliquid eius, qui id acciperet, vt tributum, quod Turca iniustè præcipit eos soluere, qui Hierosolymam petunt, vel pretium, quod Christianus ei dedisset in suam redemptionem ob captiuitatem iniustam, aut aliud simile, vel aliam ab eo accepisset iniuriam, tunc fas vtique esset, clam, & absque scandalo, tantundem ab eo eripere in compensationem iustam. Quoniam tunc, neque iniustitia interueniret, neque peccatum contra caritatem, sed solùm violatio fortè fidei datæ, quam in eo euentu non plus teneretur seruare, quàm ille, qui sine iuramento soluere promisisset vsuras, aut dare aureos centum grassatori, ne ipsum iniustè interficeret. Cùm scandalo verò, & existente notitia eiusmodi infidelitatis, simile quid ab eo eripere, peccatum esset, non quidem iniustitiæ, sed scandali, denigratæque existimationis, quàm par est infideles de nobis habere. Præterea, qui id acciperet, ius tunc sibi diceret priuata sua autoritate, & contra præsumptam voluntatem principis; quod est illicitum.

De pœnis spiritualibus pro furto, in quo sacrilegium interuenit, pro furto, seu rapina piratarum, & pro furto ex naufragio, statutis. Disp. 694.

SVMMARIVM.

- 1 . *Furtum sacrilegum si sit cum effractione loci sacri, incurritur pro illo excommunicatio.*
- 2 . *Incendiarii non sunt ipso iure excommunicati, sed sub excommunicatione ferendæ sententiæ inhibutum est id crimen. Et num id intelligatur de solis incendiariis loci sacri.*
- 3 . *Piratæ rapinam committunt, interficiendo, paratîve interficere ac percutere resistentes, excommunicatiq̃ue sunt de cœna Domini, ipsi & receptatores eorum, aut auxilium seienter vel fauorem eis præbentes. Et qui hi omnes sint.*
- 4 . *Receptatores piratarum necessitate, ad euadendum grauiâ mala, non peccant, neque excommunicationem incurrunt.*
- 5 . *Recipientes Turcas, aut alios infideles piratas, an excommunicationem incurrant.*
- 6 . *Furtum regulariter committitur circa res naufragii, si occupentur animo sibi eas retinendi, excommunicatiq̃ue ob illud de cœna Domini incurritur.*
- 7 . *Accipiens sibi de naufragio, quæ nisi ipse eriperet, statim erant peritura, an excommunicationem incurrat.*
- 8 . *Eam excommunicationem non incurreret simplex, qui licere arbitraretur aliquid sibi de naufragio usurpare.*

Dicendum deinde est de pœnis pro furto, & rapina, statutis: ordiendumq̃ue est à pœnis spiritualibus excommunicationis ab Ecclesia statutis.

Quod ad primum eorum, quæ proposita sunt, [sect. 1] attinet, Disp. 684. est explanatum, quando in furto, aut rapina, sacrilegium interueniat, vel ex parte rei furto ablata, vel ex parte loci, vei etiam ex parte vtriusque. Quando autem furtum, aut rapina, fit in loco sacro, effringendo fores, parietes, seras, tectum, aut aliquid aliud, tunc, qui ita furatur, est ipso facto excommunicatus, vt supponit. *c. conquesti de sent. excommun.* ex eoq̃ue textu constat. Videtur verò id supponi ex. *c. omnes Ecclesiæ. 17. q. 4. inncto. c. canonica. 11. q. 3.* Quod si talis effractor simul ac raptor denunciatur excommunicatus, tunc absolui non potest ab alio, quàm à Summo Pontifice, vt habetur. *c. conquesti citato.* Effractio tamen loci sacri, nisi sequatur furtum, non sufficit, vt effractor sit ipso facto excommunicatus. In his consentiunt. *Panor. c. conquesti, citato, & c. ultim. de furtis, Caiet. verb. excommunicatio. c. 21. & Nauar. in Manu. c. 27. n. 94.* Nomine verò loci sacri, quoad sacrilegium, & quoad hanc pœnam, intelligitur quælibet Ecclesia, monasterium, hospitale, *ermita*, quam vocant, modò edificata sit de facultate Summi Pontificis, aut Episcopi, & cæmeterium à summo Pontifice, aut ab Episcopo, benedictum, vt Nauar. vbi suprâ, & alii, quos citat, consentancè ad varia iura, affirmant. Quando autem sacrilegii furtum non fit cum effractione loci sacri, tunc, qui illud committit, non est ipso facto excommunicatus, sed excommunicandus quousque satisfaciât, si, admonitus, satisfacere noluerit, vt apertè constat ex. *c. conquestus de foro*

competenti, & affirmant Panor. vbi suprà, & doctores communiter: iuxta quod caput intelligenda accipiendaque sunt antiquiora iura ea de relata.

Panor. c. tua nos de sent. excōmun. vult, incen [sect. 2] diarios loci sacri esse ipso facto excōmunicatos, &, antequam denunciarentur excommunicati, absolutionē non esse reseruata summo Pontifici: post denunciationem verò esse summo Pontifici reseruata, vt apertè disponitur hoc vltimum. c. tua nos citato. Verior tamen est sententia *Cai. verb. excommunicatio. c. 22.* quem sequitur *Nauar. n. 94.* citato, incendiarios non esse excommunicatos ipso iure, sed excommunicandos, si in id incidant crimen; quasi sub pœna excommunicationis, non latæ sententiæ, sed ferendæ, sit id crimen prohibitum, *vt habetur. c. pessimam 24. q. 8.* neque est alius textus vnde colligatur, eos esse excommunicatos ipso facto. Capite verò tua nos, citato, statuitur, quòd si excommunicentur, denunciarenturque excommunicati, eo ipso absolutio talis excommunicationis sit reseruata summo Pontifici. *Cai. c. 22.* citato intelligit caput illud tua nos, de quibuscunque incēdiariis, siue loci sacri, siue alterius loci, quibus omnibus incendiariis statuta est pœna excommunicationis, non latæ sententiæ, sed ferendæ. c. pessimam citato. Alii verò solùm intelligunt. c. tua nos de incendiariis loci sacri: eo quòd titulus de sententia excommunicationis, loquatur de excommunicationibus pro sacrilegiis impositis. Hæc de primo eorum, quæ proposita sunt.

Quod verò ad secundum attinet. Constat pi [sect. 3] ratas, maritimósve latrones, raptores esse: eo quòd cum violentia furentur. Constat item, non solùm peccare eos grauissimo lethali peccato furti, cum circumstantia vis illatæ, interdum interficiendo, aut mutilando, damnaque alia inferendo, aut eorum periculo se exponendo, quin & aggrediendo, paratos ea omnia efficere, si illi, quos ita aggrediuntur, ac mari perpetuò quærunt, eis resistent; sed etiam teneri restituere damna omnia, quæ ita iniustè inferunt: neque est, quòd his de rebus hoc loco controuertamus. Solùm verò sunt explicandæ censuræ, quas ob id crimen incurrunt.

In primis. c. excommunicationi de raptorib. præcipitur, vt excommunicationi subijciantur, qui capere, aut spoliare, præsumpserint Christianos pro negotiatione, vel aliis honestis causis, nauigantes. Canon tamen hic non est latæ sententiæ, sed ferendæ.

Hodie verò clausula. 3. bullæ cenæ Domini sic habet: *Anathematizamus omnes piratas, cursarios, ac latrunculos maritimos, & illos præcipuè, qui mare nostrum à monte Argentario vsque ad terracinam discurrere, & nauigantes in illo deprædari, mutilare, interficere, ac rebus & bonis suis spoliare, præsumunt, ac omnes receptatores corundem, & eis auxilium scienter dantes vel fauorem.* In hac clausula ipso facto excommunicantur piratæ, seu latrones maritimi, modò aliquam ex his actionibus exequutioni mandent, atque ad effectum perducant, nempe prædari nauigantes, aut eos mutilare, vel interficere, vel rebus suis spoliare. Quòd si nullam harum actionum ad effectum perducant, peccabunt quidem lethaliter eo animo discurrendo per mare, aut etiam aliquos aggrediendo, non tamen erunt excommunicati. Quòd si nauigantes deferant res alienas, eisque, aut earum aliqua pirata quemquam eorum spoliet, erit vtique excommunicatus ea excommunicatione: eo quòd verè deprædetur ita nauigantem, esto eum non spoliet re sua, sed aliena. Præsertim, cùm satis sit eam esse nauigantis quoad custodiam, vt sua, in re proposita, dicatur.

Nomine piratarum, cursariorum, ac latronum maritimorum (quos Hispanè *cosarios* vocamus) intelliguntur omnes, qui ex instituto discurrunt per mare animo prædandi, siue simul intendant exercere mercaturam, aut aliquid aliud, siue non, & siue parui piratæ sint, siue magni. Parui quippe piratæ dicuntur latrunculi maritimi in ea clausula, vt intelligatur, sermonem esse de quibuscunque piratis, tam paruis, quàm magnis, vt

Caie. verb. excommunication. cap. 18. obseruat. Illi tamen, qui iniustum bellum contra aliquam rempublicam gerunt, & tanquam hostes, in belli consequentiam, deprædantur homines talis reipublicæ, quamuis lethaliter peccent, atque ad restitutionem damnorum ita illatorum teneantur: non tamen dicuntur piratæ, eaque de causa non incurrunt hanc excommunicationem, vt Ang. verb. excommunication. 5. casu. 18. Syluest. verb. excommunication. 7. casu. 20. Nauar. in Man. cap. 27. n. 59. & alii, rectè affirmant. Præterea, qui discurrunt per mare, non intuitu, & quasi ex instituto prædandi, casuque aliquando, vel necessitate, vel cupiditate, prædantur, non censentur piratæ, eaque de causa non incurrunt hanc excommunicationem, vt Syluest. & Nauar. locis citatis aduersus Ang. asseuerant. Satis tamen est, vt quis pirata dicatur, incurratque proinde hanc excommunicationem, si intuitu deprædandi homines vnus nationis dumtaxat, discurrat per mare, vt si Galli discurrant animo prædandi solos Lusitanos. Ita Nauar. vbi suprà.

Qui nunquam egredierentur flumen aliquod, in quo deprædarentur, non incurrerent hanc excommunicationem, iuxta Ang. verb. pirata, & doctores communiter. Quoniam non essent latrones maritimi, de quibus solis in hac clausula est sermo.

Qui verò, discurrentes per mare, ingrederentur portum, aut flumen, & deprædarentur nauigia, quæ ex nauigatione ibi se receperunt, hanc utique incurrerent excommunicationem: quia verè essent piratæ, & deprædarentur nauigantes. Illi verò, qui discurrentes per mare, applicarent ad aliquem locum, ac deprædarentur in terra, non inciderent in hanc excommunicationem: eo quòd non deprædarentur nauigantes. Toties verò piratæ incurrunt excommunicatio-[[41]]nem hanc, quoties deprædantur, interficiunt, aut mutilant, nauigantes.

In eadem clausula excommunicantur receptatores piratarum, & auxilium scienter eis dantes vel fauorem. Quod intelligendum est de receptatoribus, quatenus piratæ inde iuuamen accipiunt ad prædandum, aut ne ob id crimen puniantur, vel ne de potestate eorum eripiantur, quæ deprædati sunt, aut ne competens accipiat ex eis satisfactio. Vt si ex eo, quòd recipiantur in aliquo portu, aut ibi necessaria eis vendantur, sequatur eos plures prædas exercere, aut impediatur, ne capiantur ac puniantur ab eis, qui iustè eos capere ac punire propter id crimen possint, aut ne de potestate eorum eripiantur, quæ deprædati sunt, vel ne competens satisfactio ex eis accipiat. Eodem modo intelligendi illi sunt dare cis auxilium vel fauorem, qui ad ea, quæ commemorata sunt, eis fauent, aut auxilium dant. Et quia is, qui consilium dat, eo ipso fauere dicitur ad id, ad quod consilium præstat, sanè, qui ad prædicta consilium daret, aut nuncium de præda, quam exercere possent, ad eos mitteret, incideret in hanc excommunicationem. Qui verò eos aliter reciperent, aut in aliis auxilium, vel fauorem, illis darent, esto id esset ad aliquod aliud malum patrandum, non incurrerent hanc excommunicationem. Quia non essent receptatores, auxiliatores, vel fautores, piratarum, quæ tales, sed ad aliud, vt in simili explicauimus in materia de fide, quæstione 11. artic. 4. dum sermo nobis erat de receptatoribus, & fautoribus, hæreticorum.

Dubium est. Quid si piratæ accedant, vt re [sect. 4] cipiantur in aliquo portu, & habitatores illius iustè timeant graue aliquod malum ipsis ab eis inferendum, nisi illos recipiant, tribuantque eis necessaria, incidèntne in hanc excommunicationem, si eos recipiant, eisque necessaria tribuant, quando inde maiores vires sument ad prædandum.

Respondendum est neganter. Quoniam lex humana non intendit cum tãto detrimento obligare, neque iustè cum eo obligare potest.

Dubium deinde est. Si Christiani aliqui conce [sect. 5] dant Turcis portum, vbi se reficiant, scientes eos accedere ad prædas exercendas inter Christianos, atque intelligentes, eos inde

maiores vires ad id assumere, vtrùm in hanc excommunicationem incident? Partem negantem suadere videtur, inprimis, quòd Turcæ non incident in hanc excommunicationem; eo quòd sint extra Ecclesiam; eaque de causa non sint de numero piratarum, quos in hac clausula Summus Pontifex excommunicat. Postquam autem dixit, *anathematizamus piratas, subiunxit: Et omnes receptatores eorundem, &c.* hoc est, piratarum, quos excommunicamus. Deinde, quòd cùm Turcæ, & Saraceni, bellum, licèt iniustum, gerant aduersum nos, non propriè videntur piratæ, dum accedunt ad nos capiendum, diripiendum, ac occidendum, sed sunt hostes nostri, qui, in belli consequentiam, nos diripiunt: quo fit, vt receptatores, & fautores, eorum, non videantur in hac clausula comprehendi. Hæc satis probabilem reddunt partem, quæ negat. Pars tamen affirmans non caret sua probabilitate. Eo quòd potiùs ad legissatoris mentem, quàm ad legis verba, sit attendendum: mens autem legissatoris fuisse videtur, excommunicare omnes piratas, quantum sua iurisdictio se extendit, & receptatores quoruncunque piratarum ac latronum maritimorum, nihil impediens, quòd piratæ ipsi incapaces essent eius excommunicationis. Adde, inter nos, Turcas, & Saracenos, qui nos inuadunt, piratas, & cursarios, atque latrones maritimos, nuncupari. Et quòd, si mens Summi Pontificis interrogaretur, num vellet etiam comprehendere receptatores horum, responsurus videtur affirmanter, esto nihil hac de re cogitauerit, quando legem tulit. Quare, quanuis probabilius videatur, hos receptatores eam excommunicationem non incurrere; res tamen non caret aliqua dubii effigie. Hæc de secundo eorum quæ proposita sunt.

Quod verò ad tertium attinet, nempe [sect. 6] de furto ex naufragio, saris patet ex iis, quæ circa definitionem furti Disputat. 681. à nobis dicta sunt, obnoxia ea esse restitutioni propriis dominis, furtumque circa ea committi, si animo ea retinendi accipiantur: nisi quando domini earum rerum ea haberent pro derelictis: quod tamen regulariter non est præsumendum, vt Disputat. 55. comprobatum est, vbi subiecimus, quando aliquid tale habendum sit pro delicto, & simul ostendimus, iniquas esse leges, quæ statuunt, vt eiusmodi bona, tanquam oberrantia, ipso facto pertineant ad fiscum domini prouinciæ, quò deueniunt.

De iure Canonico. c. excommunicationi, de raptorib. excommunicantur ipso facto, qui Christianos, patientes naufragium, spoliant rebus suis, nisi ablata reddiderint, hoc est, eo ipso quòd in mora sint restituendi. Quare ad incurrendam excommunicationem illam, non satis erat eripere de naufragio, sed vlteriùs requirebatur, eos esse in mora restituendi. Vnde interim, dum non erant in mora restituendi, quia non se offerebant, quibus possent restituere, non incurrabant excommunicationem illam, esto, animo non restituendi, aliquid accepissent. Non tamen necessaria erat admonitio, vt incurrerent excommunicationem illam, vt aduersus Ioan. Andr. notant Panor. & doctores communiter.

Hodie verò de cæna Domini sunt excommunicati, qui de naufragio aliquid accipiunt: sic enim habet quarta clausula eius Bullæ: *Excommunicamus, & anathematizamus, omnes, & singulos, qui Christianorum quorunque nauibus, tempestate, seu in transuersum (vt dici solet) iactatis, vel quocunque modo naufragium passis, siue in ipsis nauibus, siue ex eisdem eiecta in mari, vel in littore inuenta, cuiuscunque generis bona, tam in nostri Tyrreni, & Adriatici, quam in cæteris cuiuscunque maris regionibus, & littoribus, surripuerint, ita vt neque ob quodcunque priuilegium, consuetudinem, aut longissimi, etiam immemoriabilis, temporis possessionem, seu alium quemcunque pretextum, excusari possint.*

Obserua primò, aliter habuisse quondam hanc clausulam, quàm hodie in Bulla Clementis octauì habeat: & iuxta verba antiqua non incurrabant hanc excommunicationem, qui aliquid accipiebant, eiectum ob tempestatem ex [[42]] naui antequam illa naufragium faceret; eo

quòd non esset verbum vllum in hac clausula, quod eos comprehenderet: hodie verò, etiam hi, hanc incurrunt excommunicationem: quia verè accipiunt eiecta de nauibus tempestate iactatis, quos comprehendunt verba huius clausulæ, vt constat illam expendenti. In hac verò clausula nomine, nauis, quodcunque nauigium intelligitur, etiam si sit triremis. Tum quia nomen nauis tam latè interdum vsurpatur. Tum etiam, quia ea est mens legislatoris, ad quam potiùs, quàm ad verba, quibus est expressa, est attendendum.

Obserua secundò, eos, qui de naufragio, aut ex eiectis de nauì tempestate iactata, aliqua accipiunt, quæ eorum domini habent pro derelictis, cùm non peccent ita ea accipiendo, neque incurrere hanc excommunicationem, quæ non est imposita nisi pro lethali culpa furti similium rerum. Idem dic de eis, qui easdem res accipiunt, quas domini earum non habent pro derelictis, attamen eas accipiunt, non quidem animo sibi illas retinendi, sed seruandi eas propriis ipsarum dominis: quandiu enim non mutauerint propositum, nec in mora fuerint eas restituendi, ita vt lethaliter peccent, non incurrunt hanc excommunicationem, quæ, vt dictum est, pro lethali culpa furti eiusmodi rerum est imposita.

Obserua tertio, ad incurrendam hanc excommunicationem, satis esse accipere de eiusmodi rebus animo eas sibi retinendi, esto, qui accipit, non sit in mora eas restituendi, quia non comparet is, cui restitutio est facienda: eo enim ipso, quòd eo animo eas accipit, illas furatur: verbum autem surripuerint, in ea clausula appositum, idem pollet ac significat, quod furati fuerint: comprehendit quippe inuenta in littore absque defensore, si qui ea accipiunt, illa sibi vsurpent atque accipiant. Quare, esto postea mutent animum, easque tempore congruo restituant, hanc incurrunt excommunicationem. Item, si quis bona fide accipiat aliquid, ignorans id esse de numero eiusmodi rerum, eo ipso, quòd iniustè vult illud retinere, committit aduersus proprium dominum furtum eiusmodi rerum, ac proinde incidit in hanc excommunicationem: id quod expressum erat quondam verbis in hac clausula apposis. Fortè illa expuncta sunt, ad non innodandum hac excommunicatione eos, qui titulo oneroso, aut gratuito, bona fide accepissent eiusmodi res ab aliis, esto postea intelligerent, eas à principio vsurpatas esse ex naufragio. Non tamen est mihi hæc res certa.

Quando, quod ex eiusmodi rebus esset acceptum, vel in littore, vel in mari, aut in nauì, animo id sibi vsurpandi contra domini voluntatem, tam modicum esset, quòd non sufficeret ad culpam lethalem, iuxta ea quæ superiùs explanata sunt, tunc non incurreretur hæc excommunicatio. Non defuit verò, qui arbitraretur, ad incurrendam hanc excommunicationem, non sufficere quantitatem, quæ satis sit ad lethalem culpam furti, sed requiri longè maiorem. Ducebatur. Quoniam pæna esse debet proportionata culpæ: incidere autem in lethale peccatum ob quantitatem, quæ non sit admodum notabilis, non est culpa digna excommunicatione, quæ tam arctè Sedi Apostolicæ reseruetur, & ad cuius absolutionem obtinendam, necessarii sæpe sint sumptus non modici, ob distantiam loci à Sede Apostolica. Non est tamen certa hæc opinio, neque redderem tutum in conscientia, qui iuxta eam absolueretur, & qui eum absolueret, quasi in eo euentu excommunicatus non esset, aut reseruata talis excommunicatio non esset summo Pontifici. Tum quia, licèt vnus furando quantitatem non ita magnam, cæterùm quæ sufficeret ad culpam lethalem, non inferret damnum admodum notabile; multi tamen, qui simili modo furarentur, illud inferre possent. Tum etiam quoniam propter genus delicti, quod expedit, vt de medio tollatur, apponi potest insolita pæna. Tum præterea, quoniam excommunicationes maiores omnes in se sunt æquales: reseruatio autem, quæ per accidens habet adiunctos sumptus & molestiam, est pro potestate Summi Pontificis: sicut & reseruatio absolutionis à quibusdam peccatis. Tum

denique quoniam, cū lex Summi Pontificis hac de re sit vniuersalis, temeritas minimeque securum est, quenquam excipere eorum, quos generalitas illius comprehendit, absque Summi Pontificis declaratione. Maximè cū perdifficile esset, absque summi Pontificis declaratione taxare, quæ quantitas, ad peccatum lethale sufficiens, satis esset ad eam excommunicationem incurrendam, quæ non item.

Dubium est. Vtrū incurrant hanc excom¹⁴municationem illi, qui de rebus, de quibus in [sect. 7] hac clausula est sermo, accipiunt ea, quæ, nisi ipsi ea acciperent, statim erant peritura, vt saccharum, farinam, papyrum, & eiusmodi. Conueniunt omnes, quando eripi possunt sine probabili mortis periculo, teneri eripientem ea restituere, accepta mercede sui laboris ac industriæ: si verò ea accipiat animo sibi illa retinendi, incidere iu hanc excommunicationem. Quando verò eripiuntur cum probabili mortis periculo, &, nisi ita eriperentur, certò erant peritura, nec dominus volebat se exponere ei periculo, nec habebat alium, qui mercede, aut gratis, se vellet exponere tali periculo in gratiam illius, affirmant multi, eripientem non teneri ea restituere domino: eaque de causa non incurrere hanc excommunicationem, si ea sibi retineat. Ita Sylluest. verb. naufragium, Nauar. in Manu. cap. 17. n. 98. eandemque sententiam innuit Caie. 2. 2. q. 66. artic. 5. versic. nota tertio, ac sequuntur alii. Eam sibi persuadent, quoniam in eo euentu eripiens eiusmodi bona, neque ex caritate tenetur ea eripere domino illorum: & cū peritura sint omnino absque aliqua spe; nullam facit iniuriam illorum domino, si se exponere velit ei periculo, vt ea sibi ipsi eripiat: quin potius illorum dominus, irrationabiliter erit inuitus, si id prohibeat: quo fit, vt ita ea eripiens, non peccet, & vt ea apprehensione comparet sibi eorum dominium, ac proinde non incurrat hanc excommunicationem.

Contraria nihilominus sententia videtur pro¹⁵babilior. Primò, quoniam durum videtur, quòd quis sine suo consensu amittat dominium rerum suarum, illudque alius acquirat, hoc solo, quòd eas eripiat de periculo, quo erant perituræ, cō-[[43]]trariumque videtur definitum. l. Pomponius, iuncta glossa ibi. ff. de acq. rer. domi. quare, si prior manet dominus, nihil impediens quòd hic alius cum periculo suæ vitæ eas de interitu eripiat, certè ad antiquum dominum pertinent, neque eripienti cum periculo propriæ vitæ debetur, nisi competens pretium sui laboris ac periculi, eaque de causa, si eripiens, animo sibi eas retinendi, altero inuito, eas accipiat, incidet in excommunicationem hanc, nisi excusetur ignorantia, qua arbitretur, id in eo euentu sibi licere, vt autores contrariæ sententiæ sunt arbitrati. Secundò, quoniam licet eripiens non teneatur se exponere periculo pro eis bonis liberandis, potest tamen dominus eorum bonorum, non velle ea illi concedere, nisi sibi det partem eorum: quòd si eripiens non velit ea lege ea liberare, posset eorum dominus velle, vt potius pereant, quando quidem eripiens non vult esse ei utilis in illorum parte aliqua: quo fit, vt is, cuius illa erant, non amittat eorum dominium, nisi ea eripienti concedat. Tertio, quoniam, offerentibus se duobus ad ea eripiendum cum periculo propriæ vitæ, quorum neuter velit ea eripere domino, sed sibi, posset dominus cōcedere vni eorum ius ea sibi eripiendi cum pacto, vt partem aliquam eorum domino relinqueret: ergo ex eo, quòd similia bona sint in eo periculo, dominus illorum non amittit illorum dominium, atque adeò, si sine ipsius consensu formali, aut præsumpto, illa liberentur, non fiunt accipientis. Quartò, quoniam si quis amittat rem suam, quæ, nisi quæatur, est peritura, nullus tenetur eam quærere, si dominus possit illam quærere; & tamen, si quis eam quærat & inueniat, tenetur eam restituere domino, accepta iusta mercede sui laboris ac industriæ: ergo idem erit, quādo idem cum periculo propriæ

vitæ eam eripit ab interitu, quam dominus vel non vult cum tanto suo periculo eripere, vel non potest.

Obseruant Sylvester & Nauarrus locis cita [sect. 8] tis, simplicem, qui lege regionis iniusta, aut aliqua alia ratione, crederet, licere vsurpare sibi rē aliquam de naufragio, non incurrere hanc excommunicationem, eam sibi vsurpando.

De pænis temporalibus pro furto, & utrū licitè homines pro furto interdum occidantur. Disp. 695.

SVMMARIVM.

1. *FVrem interficere cum quinta decalogi præcepto non pugnat, licitūq; publica autoritate esse potest, maximè præcedente lege, quæ id statuatur.*
2. *Fur ad quid cogetur in exteriori foro, non in pænam, sed quia ad id tenetur ex natura rei, in foroque conscientie, nulla expectata sententia.*
3. *Furtum tum manifestum, tum etiam non manifestum, quibus pænis ciuilibus seu pecuniariis iure communi puniantur.*
4. *Actio furti ad pænam ciuilem, & actio ad rēfurto ablatam, & ad damna subsequuta, quantam diuersitatem habeant. Possunt seorsim intentari, aut etiam simul incidenter vna ex alia eodem libello.*
5. *Agi etiam potest ob furtum criminaliter ad pænam corporalem, sed tunc locum non habet actio ad pænam ciuilem. Et pro furto imponi non poterat iure communi pæna mortis nec mutilationis.*
6. *Agere ciuiliter vno modo sumitur pressè, pro agere ad interese distinctum à pæna: alio modo latè, pro agere etiam ad pænam pecuniariam. Agere item criminaliter vno modo sumitur latè pro agere ad pænam siue corporalē, siue pecuniariam: alio verò modo pressè, pro agere ad pænam corporalem. Actio primo modo ciuiliter, non impedit actionem criminaliter primo neque secundo modo. Agere verò ciuiliter ad pænam pecuniariam, impedit agere simul criminaliter ad pænam corporalem, & è contra.*
7. *De iure communi nefas erat interficere, aut mutilare, simplicem furem, etiam pro tertio furto, aut pro quarto furto: damnandæ tamen non sunt leges, aut consuetudo, quæ pro tertio furto interficiunt, aut quæ pro furto certæ quantitatis, aut qualitatis, mut ilant, vel interficiunt. Et qualia esse debeant ea furta. Neque fur iugulari debet, sed furca suspendi.*
8. *Fur, grassator, & latro, in quo differant de iure communi, & quæ pænæ de eodem iure sint illis impositæ.*
9. *Pro unico furto magnæ quantitatis, quod tribus æquipolleat, agrauari debet pæna, sed non debet fur suspendi, ubi lex, aut consuetudo, non fuerint in contrarium, vt in hoc regno non sunt.*
10. *Furtum de iure communi circa immobilia licet non committatur, quæ pæna statuta sit mouenti terminos agrorum, aut limitum oppidorum.*

11 . Furtum quando quis agreßus est committere, neq̃ est furatus, quæ actio aduersus illum competat, & qua pæna sit puniendus.

12 . Furibus variæ pænæ in hoc regno statutæ. Hodie regulariter, nisi propter nobilitatem, commutanda pæna sit in exilium, flagellantur pro primo furto, (tametsi aliquibus in locis, si soluendo sint, damnentur pæna dupli soluenda offenso, & septupli soluenda fisco) pro secundo flagellantur & abscinduntur eis aures, & pro tertio furca necantur.

13 . Furibus si aures in pænam abscindantur, non est ea pæna mutilationis membri, neque iudices ob eam pænam irregularitatem incurrunt.

14 . Furta in castris commessa qualiter puniantnr.

15 . Furem reperiri abscissis auribus, licet sufficiens sit vt interrogetur de causa abscissionis, &, nisi aliã probet, vt subijciatur tormentis, vt confiteatur duo priorafurta, ac suspendatur pro eo tertio; nō tamen est sufficiens coniectura, vt probatum censeatur, furtum commißum post illas abscissas esse tertium.

16 . Furibus hodie pro primo furto imponitur pæna remigandi in triremibus, & pro secundo pæna flagellorum ac remigandi in triremibus.

17 . Furtum ex naufragio vt hodie puniatur in hoc regno, restituique totum iubetur dominis. Idem de bestiis eadentibus e ponte, aut aliter periclitantibus, aut pereuntibus.

18 . Furtum, rapina, aut vis, in curia regia, aut in regio rastro, morte plectitur, & vt mitigata sit ea lex.

19 . Furtum, aut vis, circa animalia, aut alia ad culturam attinentia, vt puniatur.

20 . Furti pæna punitur, & insuper reddere dominis tenetur res, aut æstimationes earum, ac damna, quicunq̃ oneroso aut gratuito titulo, vel in custodiam, acceperit aliquid a mancipiis.

21 . Furtorum quorum cognitio ad iudices de la her-[[44]]mandad spectet, & quibus pænis ea furta puniantur.

22 . Furibus, eorum receptatoribus, ac comparticipibus, & aliis, quousque pæna commutetur in pænam remigandi in triremibus.

23 . Furem interficiens, quando à pæna mortis eximatur.

24 . Furibus pænæ Lusitano iure statutæ.

25 . Furto rem verisimiliter ablatam, qui eo in regno emit, punitur pæna furis, esto ostendat à quo eam emit. Lege alia ad pænas furium, aut ementium a furibus, attinentia.

26 . Furetur si ecclesiasticus, quibus pænis iure Canonico puniatur.

27 . Furtum cum effractione, sed sine vi illata personæ, quibus pænis iure communi puniatur.

28 . Furtum idem, & perforatio ad faciendum quodcunq; aliud maleficium, quibus pænis iure buius regni puniantur.

29 . Furtum idem quibus pænis iure Lusitano puniatur.

30 . Raptores bonorum externorum, quales etiam sunt graßatores & piratæ, quibus pænis iure communi plectantur, & quæ actiones aduersus eos competebant. In his computantur, qui iuris priuilegio raptores censentur.

- 31 . *Raptores iidem, quibus pænis iure huius regni puniantur.*
- 32 . *Raptoris pænas in hoc regno incurrunt campsores, seu bancarii, & eorum fautores, qui cum pecuniis apud ipsos deposit is fugiunt, & mercatores, eorumq̃ fautores, qui merces credito acceperunt, & similiter fugiunt, aut qui cum quibuscunque aliis rebus scaſcan, & qui hos omnes recipiunt.*
- 33 . *Raptoribus quæ pænæ iure Lusitano statutæ.*
- 34 . *Raptores, si personæ sint ecclesiasticæ, quibus pænis Canonico iure puniantur.*
- 35 . *Furtum, in quo sacrilegium interuenit, quibus pænis iure communi Cæsareo puniatur.*
- 36 . *Furtum idem quibus pænis iure huius regni puniatur.*
- 37 . *Furtum idē quibus pænis iure Lusitano puniatur.*
- 38 . *Furtum, quod peculatus dicitur, quibus pænis puniatur.*
- 39 . *Peculatus, præsertim quoad monetas cudendas, circuncidendas, destruendas, aut extrahendas de regno, quibus pænis de iure huius regni puniantur.*
- 40 . *Peculatus crimen quibus pænis iure Lusitano puniatur.*
- 41 . *Criminis legis Iuliæ de residuis pæna.*
- 42 . *Criminum abigeatus ac plagii pænæ.*
- 43 . *Furti aduersus concausas ad rem furto ablatam, vel ad illius æstimationem, ad fructus & ad dāna inde sequuta, etiam lucri cessantis, condictio furtiua competit, & quatenus singulæ teneantur.*
- 44 . *Furti aduersus concausas actio ad pœnam pecuniariam parti læsæ applicandam, competit vt vna tantum illi ab omnibus soluatur, quam præcipuè soluere tenetur causa furti principalis, nisi furtū comparatione illius sit domesticum. Ad pœnam verò pecuniariam fisco applicandam, aut ad pœnā corporalem, competit actio, vt singulæ concausæ puniuntur integra pœna. Et quando non interueniat furtum propriè ex parte concausæ, solumque teneatur ad intereſse & damnum, & quando ad nihil.*
- 45 . *Rapinæ, concausa, aut furti, in quo sacrilegium, aut alia circumstantia aggrauans, interueniat, vt puniatur.*
- 46 . *Furti concausa quando mitiùs puniatur, quàm causa principalis.*
- 47 . *Furtum consulens, si id consilium ad furtum fuit cooperatum, saltem quia fur eo cosilio fuit confirmatus, competit actio furti aduersus ita consulentem. Esto autem ad furtum id consilium nihil fuerit cooperatum, consulens puniri debet pœna arbitraria.*
- 48 . *Furium receptatores pænis furium puniuntur, quando fures cum rebus furtiuis, aut furtiuis res, scienter recipiunt. Et quid quando fures sine rebus furtiuis recipiunt, aut occultant.*

M Vltà circa furtum, & circa damnum iniustè datum (de quo, post materiam hanc de furto, erit nobis sermo) de industria relinquendo examinanda in materia de restitutione, rem hâc de furto concludamus hac & sequenti Disputatione, in qua examinabimus, quibus, & aduersus quos, actio furti competat.

Atque ordiendo ab eo, quod secundo loco est propositum, sermonemque de primo permiscendo *Scot in. 4. d. 15. q. 3.* asseruit, simplicem furem, hoc est, eum, qui ex circumstantia alia non sit dignus morte, puniri non posse pœna mortis, esto furtum sit notabilis cuiuscunque quantitatis, &¹⁶ esto multoties iteretur. Ducitur, quoniam, inquit, præceptum illud quintum decalogi, non occides, est de iure diuino, estque vniuersale: unde, cum solus Deus possit in suis legibus dispensare, nefas est quenquam pro delicto aliquo occidi, nisi quatenus ex scripturis constet, Deum id concessisse: quanuis autem, inquit, Deus *Exod. 22.* permittat occidere furem nocturnum, quatenus præsumitur paratus ad interficiendum eum, qui sibi restiterit, qua ratione iuste etiam occidi posset grassator, nihilominus eo in loco non vult Deus occidi posse furem diurnum: neque, ait Scotus, audiuius de bulla super hoc descendente de cælo, qua Deus hac in re dispenset.

Est tamēhęc Scoti ratio indigna prorsus suo au [sect. 1] tore: meritoque hæc sua opinio ex eo fundamēto deducta, communiter improbat. Etenim præceptum illud quintum decalogi non eum habet sensum, quasi omnis vniuersim hominis occisio sit in eo prohibita, & qua si ad interficiendum malefactores, quibus mors iuste à publicis potestatibus infligitur, necessaria sit dispensatio diuina: quin potiùs. *1. 2. q. 100. art. 8.* copiosè ostendimus, præceptum illud, neque diuina potentia, posse dispensari, si de propria dispensatione sit sermo. Sensus itaque illius præcepti est, neminē esse occidendum iniuste: secus autem iuste, atque quando lumen naturæ, rectaque ratio, id fieri posse præscribit.

Quo fit, vt ex naturali ipso lumine, rationibusque naturalibus, sit inuestigandum, an liceat furem, aut quencunque alium malefactorē, interficere: de qua re copiosius tractatu. 3. sequēti, dum de homicidio erit nobis sermo, est disputandum. Cum autem constet, naturali iure esse in principe potestatem puniendi delicta suorum subditorum, prout viderit esse dignum, efflagitareque commune reipublicæ bonum; sanē inde pendet iudicium, num sit licitum punire furē mortis pœna, si prudentium arbitrio id delictum tanta pœna sit dignum, saltem quia valde expedit communi bono id delictum non committi.

Quo loco obserua, in principe non solū esse [[45]] potestatem ad punienda delicta, quantum postulat natura ipsa delictorum, secluso iure humano, sed etiam ex iure ipso humano, prohibitionēque humana, augeri culpam, & posse augeri pœnā, eo plus, quo arctius aliquid humano iure prohibetur, quia ita postulat commune bonum. Sicut autem principes multa prohibent, aut præcipiunt, & interdum sub pœna mortis, prout cōmuni bono iudicauerint expedire, quorum contraria non essent mala secluso eo iure positio: ita etiam, quæ iure naturali sunt mala, possunt arctius interdum prohibere, augendo pœnam, qua, seclusa ea prohibitionē humana, essent digna in republica temporali, prout expedire iudicauerint bono communi, finique, ad quem ea prohibent: & tunc præcedente talis legis promulgatione, iuste puniunt transgressores maiori ea pœna tali lege statuta: cum tamen, si non antecessisset ea lex, tantam pœnam meritò constituens, nefas esset tam graui pœna quenquam pro eo delicto puniri. Sic videmus, duces belli interdum sub mortis pœna aliqua præcipere, aut prohibere, eaque pœna continuò punire transgressores talis præcepti, quia ita expedit regimini exercitus, fini belli, ac bono communi; cum tamen transgressionē illæ, secluso eo præcepto, vel nulla, vel perexigua, pœna essent dignæ, iniustumque omnino esset eas puniri, non solū mortis pœna, sed etiam inferiori alia graui, nisi præcessisset id præceptum. Sic etiam videmus, multa alia in rebus publicis prohiberi sub pœna mortis, quæ, seclusa tali lege humana, nec ea pœna, neque alia graui, aut etiam leui, possent iuste puniri. Vt in hoc Regno prohibetur sub pœna mortis extrahi pecunias ex hoc Regno, &

deferri equos in Galliam, & similia alia. Et in Lusitania prohibitum sub pœna mortis erat transferre boues ex eo Regno in hoc. Sicut enim Deus imposuit Adamo præceptum illud de iure positio, non edendi de ligno vetito, sub pœna mortis corporalis & spiritualis ipsius, totiusque generis humani, quod in lumbis illius tunc erat, & multa alia de iure positio præcepit in lege veteri, & in noua quædam etiam præcepit circa sacramenta: ita principibus temporalibus, qui ab eo potestatem deriuatam habent in sibi subditos, potestatem dedit condendi leges, in commune reipublicæ bonum, etiam sub pœna mortis, quæ vim haberent ex imperio ac præcepto ipsorum. Hinc dico. Quauis, nisi antecessisset lex, aut consuetudo, quæ vim legis haberet, nefas fortasse esset, pro furto aliquo certæ quantitatis, aut aliquot vicibus commisso, imponere pœnam mortis; præcedente tamen lege humana, quæ id prius statuatur, quia ita princeps iudicat expedire suæ reipublicæ, non esse, cur eiusmodi leges vel iniustitiæ condemnentur, vel improbentur, vt ex iacto à nobis fundamento facillè liquet; ad quod tamen multi non attendunt.

Alexand. Alens. 3. part. q. 47. memb. 4. art. 3. asseruit iniustam esse legem, quæ pœnam mortis statueret pro furto. Eadem sententia tribuitur à *Couar. 2. var. res. c. 9. n. 7. Syluestro verb. furtum. q. 3. pronunciato ult.* Sed immeritò, si Sylvester expendatur, & verba illius pronunciati cum antecedentibus conferantur: tametsi non defuerit, qui perperam ita exponere fuerit conatus Syluestrum, vt censerit, quod Couar. ei tribuit.

Ratio, cui opinio Alexandri Alens. nititur, est. Quoniam pœna, vt sit iusta, proportionari¹⁷ debet culpæ: *pro mensura enim peccati erit & plagarum modus*, vt habetur *Deuter. 25.* Cùm ergo res externæ infimæ sint inter omnia bona nostra; vita verò sit omnium temporalium bonorū præstantissimum, cæterorum que fundamentum, & mors, præsertim violenta, sit terribilium omnium terribilissimum, maximeque hortendum: consequens est, vt improporcionata, longeque excedens, sit mors corporalis pro furto, in quo damnum infertur proximo in solis bonis illius externis, atque adeò iniusta erit lex, quæ mortis pœnam statuerit pro furto simplici. *Vnde in authentica sed nouo iure. C. de seruis fugit. & in autentico vt nulli iudicum. §. ult. quibus consentit. l. 18. titu. 14. part. 7,* præcipitur, vt pro furto simplici nullus interficiatur. Antequam dicam quid de hac re sentiam, referam varias pœnas, quæ de iure Cæsareo, de iure huius Castellæ Regni, de iure Lusitano, & de iure Canonico, comperiuntur statutæ pro variis furti, ac rapinæ, generibus. Atque in primis fur, [sect. 2] non in pœnam, sed quia id in conscientie foro restituere tenetur, nulla expectata sententia, & esto res non esset deducta ad forum externum, cogetur in exteriori foro reddere, quod furatus est, ei, à quo illud est furatus, si existat: si verò nō existat, cogetur reddere æstimationem illius: si autem sit deterius redditum, cogetur soluere, vel æstimationem, vel rem, & quod minus valet ratione deteriorationis, optione eius, à quo illud accepit, & nsuper cogetur ei soluere, si quod lucrum cessauit, aut damnum ei emersit ex tali furto. Atque hæc omnia tenetur fur restituere in foro conscientie, esto tale furtum pœna corporali, etiam mortis, afficiatur, nisi dominus rei ea remittat. In foro verò exteriori, si de furto constet, & non de quantitate illius ac valore, conceditur ei, à quo res furto ablata est, iurare in litem, quantum id fuerit, accedenteque arbitrio iudicis quoad æstimationem, cogitur fur id totum soluere. Ita communis doctorum sententia, quam *Iul. Clarus. 5. lib. sent. §. furtum. n. 18.* refert ac sequitur. Et idem credo esse, quoad lucrum cessans, aut damnum emergens.

De iure communi Cæsareo simplex fur, si fur [sect. 3] tum non fuit manifestum, punitur pœna, vt vltra rem furto ablatam, restituat ei, à quo illam furatus est, duplum aliud æstimationis: si verò fuit manifestum, restituat ei quadruplum, vltra rem furto ablatam. *Ita habetur. §.*

conceptum vers. vlt. in sine, iuncto. §. vlt. eiusdem tituli, inst. de oblig. quæ ex delict. §. ex maleficiis, inst. de actionib. l. in furti actione. ff. de furtis. l. 18. titu. 14. part. 7. & assirnant. Greg. Lopez ibi glossa. 1. Ant. Gom. 3. tom. var. res. c. 5. n. 4 & doctores communiter. Lex verò in furti actione docet, lucrum cessans, aut damnum ex furto emergens, non duplicari, aut quadruplicari, sed solam æstimationē rei furto ablata. Quòd si res decrescat in valore postquam furto ablata est, duplicari, aut quadruplicari, quoad æstimationem, quam habebat, quando furto fuit ablata: si verò accrescat in valore, duplicari, aut quadruplicari, iuxta valorem, quem habuerit: quando furti actio intentatur: quoniam is valor furto est retentus. Lege autem vnica. C. de grege dominico lib. 12. qui equum furatur de grege Regis, punitur pæna vnus libræ auri, & videba- [[46]]tur esse duodecim vnciarum: qui verò furabatur ex alio grege, punitur pæna sex vnciarum, dimidiæve libræ auri. Si tamen sua sponte equum offerat ac restituat, immunis est ab ea pæna. Quod autem furtum sit manifestum, & quod non manifestum, Disp. 684. explicatum est.

Quimuis actio furti ad duplum, aut ad qua [sect. 4] druplum, & actio ad recuperandam rem furto ablatam, aut æstimationem illius, distinctæ sint, vt patet. §. ex maleficiis, inst. de actionib. & §. vlt. inst. de oblig. quæ ex delict. seorsimque possint intentari: actio enim ad pænam solùm competit aduersus furem, & non aduersus hæredes illius, quasi post mortem furis possit aduersus eos intentari, nec debetur, nisi post latam sententiam: ad rem verò furto ablatam, si illa existat, agi potest rei vendicatione, etiam aduersus quēcunq; illius possessorem, ad quem transierit: & siue existat, siue non, agi potest conductione furtiua ad illius æstimationem, & ad interesse lucri cessantis, aut damni emergentis, tam aduersus furem, quàm aduersus illius hæredes, agereque possunt, etiam hæredes eius, à quo furto est ablata, eo quòd petatur verum debitum, quod fur, hæredesque ipsius de bonis illius, tenentur soluere in foro conscientiæ, nulla expectata sententia, vt hæc omnia constant ex duobus. §§. citatis: quāuis, inquam, hæc ita sint. Greg. Lopez. l. 9. verb. la puede demandar, & l. 18. glosa 2. consentaneè ad eam legem, titu. 14. part. 7. ait, vtranque actionem intentari posse eodem libello, aut certè posse rem, aut æstimationem illius, & interesse, peti incidenter in eodem libello, in quo intentatur actio furti ad pænam, iuxta Bart. l. interdum. §. qui furem. ff. de furtis, consentaneè ad eandem legem, quæ habet, simul condemnari posse furem, vt restituat rem furto ablatam, & vt subeat aliquam pænam ob furti delictum, vbi innuitur, incidenter posse peti pænam, & ad eam condemnari, intentando recuperationem rei furto ablata: & eadem ratione, agendo ad pænam furti, potest simul incidenter peti restitutio rei furto ablata.

*De iure item communi Cæsareo, si is, à quo ali [sect. 5] quid furto est ablatum, velit agere criminaliter, ad pænam corporalem, punitur fur pæna corporali, iudicis arbitrio, pro criminis qualitate, & quantitate, & pro qualitate personæ, imponenda, attentisq; circumstantiis omnibus concurrentibus: aitque Vlpianus. l. vlt. ff. de furtis, suo tempore plerunq; consueuisse agi aduersus fures criminaliter; id tamen non impedire quominus, qui velit, possit aduersus furem ciuilitè agere, ad pænam scilicet dupli, aut quadrupli. Et quando agitur criminaliter, accusantem teneri se subscribere, ad talionis pænam se obligando, non quasi crimen furti sit publicum, cuius accusatio ad quencunque de populo spectet, sed vt temeritas, ita sine causa accusantium, ea extraordinaria pæna coërceatur. Verba illius legis hæc sunt: *Meminisse oportet, nunc furti plerumque criminaliter agi: & eum, qui agit, in crimine subscribere: non quasi publicum sit iudicium, sed quia visum est temeritatem agentium, etiam extraordinaria animaduersione, coërcendam. Non ideo tamen minùs is, qui velit, poterit ciuilitè agere. Concinit. l. interdum. §. qui furem. ff. de furtis, vbi de pæna corporali furis est sermo. Idem vsus**

apertè constat ex autentica sed nouo iure. C. de seruis fugit. & ex autètico vt nulli iudicum. §. penult. vbi prohibetur pro furto simplici occidi, aut mutilari, furem, sed posse aliter castigari. Vbi pæna corporalis arbitraria iudicis pro furto prohibetur extendi ad mortem aut mutilationem, statuiturque debere esse infra has. Verba eius authentici hæc sunt: *Pro furto autem nolumus omnino quodlibet membrum abscindi, aut mori, sed aliter eum castigari. Fures autem vocamus, qui occultè & sine armis huiusmodi delinquant. Eos verò, qui violenter aggrediuntur, aut cum armis, aut sine armis in domos, aut itineribus, aut in mare, pænis eos legalibus subijci iubemus.* Idem constat ex. l. 18. titu. 14. part. 7. cuius verba sunt: *Los furtadores pueden ser escarmentados de dos maneras: La vna es, con pena de pecho. E la otra es con escarmiento, que les fazen en los cuerpos por elfurto, o pòr el malque fazen.* Et statuta pæna ciuili, seu pecuniaria, dupli, aut quadrupli, vltra rem furto ablatam, prout furtum fuerit manifestum, aut non manifestum, additur: *Otro si deuẽ los juzgadores, quando les fuere demandado en juicio, escarmentar los furtadores publicamente con feridas de açotes, o de otraguisa, de manera que sufran pena, è verguença, Mas por razon de furto no deue matar, ni cortar miembro ninguno.* Vbi vides simul disposuisse, quoad furtum simplex, quæ de pæna ciuili dupli, aut quadrupli, habentur iuribus suprà citatis: & quæ de pæna criminali habentur. l. vlt. ff. de furtis, & duobus authenticis citatis.

Ant. Gom. n. 4. cltato vult, eum, à quo simplici furto aliquid est ablatum, posse simul agere, licèt non in eodem libello, sed in diuersis, ad pænam ciuilem dupli, aut quadrupli, sibi applicandam vltra rem furto ablatam, & ad criminalem; pænamq; vtramque esse simul à iudice furi imponēdam; eumque arbitratur esse sensum legis vltimæ, ff. de furtis, suprà relatæ, eamque affirmat esse communem doctorum sententiam, inter quos citat. Bart. in authentica, sed nouo iure. C. de seruis fugit. Vbi tamen nihil tale Bart. dicit. In eadem sententia fuit Syluest. verb. furtum. q. 3, pronunciato. 4. quam confirmant ex. l. vnica. C. quādo ciuilis actio criminali præiudicet. vbi ita habetur: Quoties de re familiari, & ciuilis & criminalis, competit actio, vtraque licere experiri: siue priùs criminalis siue ciuilis actio moneatur: nec si ciuilitè fuerit actum, criminalē posse cōsumi: & similiter è cōtrario. Atque inter alia exempla, quæ in ea lege subijciuntur, dicitur. Quo in genere habetur furti actio.

Arbitror verò eam sententiam inhuma [sect. 6] nam ac falfam esse, contrariamque esse amplectendam cum Ludouico Romano, & aliis. Atque in primis non dubito id non intendissem Vlpianum. l. vlt. ff. de furtis, vt eam legem expendenti erit satis manifestum, legitimumque illius sensum esse; cum vtrouis modo possit furti actione agi, frequentius tempore Vlpiani fuisse solitū agi criminaliter, eo quòd indecorum esset agere ad pænam pecuniariam accusanti applicandam; id tamen non tollere, quin quiuis, si maluerit, agere possit ciuilitè, & non criminaliter. Eundēq; sensum apertè sonat dispositio legis. 18. relatæ, quæ, quoad hoc, desumpta fuit ex lege vlt. ff. de furtis. Quod verò attinet ad legem vnicam. C. quando ciuil. act. crimin. præiudicet, dicendum est, ibi nomine, actionis ciuilis, intelligi illam, qua res familiaris, seu externa, repetitur, vel rei vendicatione, vel quoad æstimationem, vel damnum [[47]] in rebus temporalibus, etiam lucri cessantis, iniustè illatum, quæ in foro conscientiæ, nulla expectata sententia, restitui debent, aut tanquam ita debita, & non in pænam, in foro exteriori petuntur: hæc enim ad rem familiarem pertinet eius, qui illa petit, & non ad iniuriam præcisam à damno dato, actioque, qua in foro exteriori petuntur, verè ciuilis est, & non criminalis: atque hæc actio propriè dicitur de re familiari. Nomine verò actionis criminalis, de re familiari, seu ob iniustitiam commissam circa rem familiarem, quæ est secunda actio, de qua est sermo in ea lege, est actio ad pænam propter talem iniustitiam

commissam: id enim omne, quod in pœnam ob crimen petitur, actio criminalis potest non immeritò appellari, hoc est, ad pœnam ob crimen commissum: quo pacto iudices, qui de criminibus cognoscunt ad pœnam, siue pecuniariam parti applicandam, ad quam agi ciuilitè in alia significatione dicitur, siue ad pœnam corporalem exilii, verberum, & similium, vel etiam ad pecuniariam fisco applicandam, ad quas omnes pœnas agi criminaliter dicitur, appellantur iudices criminis, ad differentiam eorum iudicum, qui non de criminibus, sed de causis merè ciuilibus cognoscunt. De his ergo duabus actionibus de re familiari habetur in ea lege, vnam non impedire alteram, vt patet in exemplis eadē lege propositis, vt quando recuperata est possessio vi ablata interdicto vnde vi, agi potest ad pœnam, & quando aduersus libertum, qui se dixit ingenuum, est actum ciuilitè ad æstimationem operum, quas patrono ita denegauit, agi potest ad pœnam: porrò actio ad recuperandam possessionem interdicto vnde vi, & actio ad æstimationem operarum liberti, non sunt pœnales, sed merè ciuiles. De eisdem actionibus ciuili & criminali, in vsurpationibus explicatis, diximus suprā cū Greg. Lop. & Bart. vtranque posse intentari simul eodem libello, vnam incidenter cum alia. Quādo autem variæ pœnæ statutæ sunt seorsim pro aliquo delicto, ita quòd non per modum vnus sunt statutæ, vna in augmentum alterius, nec peti possunt vnica actione, & vnico libello, sed seorsim, quo pacto pro iniuria agi potest, vel ciuilitè ad pœnam pecuniariam, vel criminaliter ad pœnā corporalem, iuxta. §. in summa inst. de iniuriis, & iuxta alia iura, & pro furto agi potest ciuilitè ad pœnam dupli, aut quadrupli, & criminaliter ad pœnam corporalem, tunc vna impedit aliam, quia, imposita vna pœna, non est locus alteri, vt constat in actione iniuriarum, tunc ex ipsamet lege vnica. C. quando, ciuil. act. criminal. præiud. quæ solūm ait vnam actio nem non impedire alteram, quando sunt de re familiari, modo explicato, tum etiam ex aliis iuribus mox citandis, cōsentitque communis doctorum sententia: eadē verò est ratio in furto, quod vltra actionem de re familiari ad recuperandam rem furto ablatam, aut æstimationem illius, & insuper si quod damnum in familiari sequutum est, quod attinet ad duas alias actiones ad pœnam pro furto, quæ vltèrius seorsim ac indifferenter competunt, nēpe quod attinet ad actionem ciuilem ad pœnam dupli, aut quadrupli, parti applicandam, & ad criminalem ad pœnam corporalem, vna extinguat & impediatur simili modo aliam: id quod satis probat l. senatus. ff. de accusationib. cuiusverba sunt, *Senatus censuit, nequis ob idem orimen pluribus legibus reus fieret*, id est, ne quis puniretur pro eodem crimine pœnis diuersis, seorsim statutis diuersis legibus, sed actio intentata ad pœnā vnus legis, impediret ac extingueret actionē ad aliam pœnam. Ecce, lex vniuersim loquitur, eademque profectò est ratio de eiusmodi omnibus pœnis. Idem adhuc apertiùs *robat. t. prætor edixit. §. si dicatur, iūcto. §. at quin, & §. quid ergo. ff. de iniuriis*, vbi exponitur regula, quæ ex antiquioribus iuribus traditur. l. vnica. C. quando ciuil. act. criminal. præiud. vt notat glossa. §. at quin citato. verb. & hoc est verum, & ex ipso textu liquet. In illis enim tribus §.§.§. habetur, quòd licet pro illata iniuria non possit agi ciuilitè, & criminaliter, ad distinctas pœnas, sed vna actio intentata impediatur atque extinguat aliam; si tamen in iniuria interuenit damnum iniuste datum ea iniuria, aut ex illa sequutum, vt quia percussus impeditus fuit à lucro suo labore, aut negotiatione, comparādo, vel quia insumpsit in medicinis, & cum chirurgis, tunc agi posse ciuilitè, priuatōve iudicio, vt ibi dicitur, ad resarcionem damni in re familiari iniusti dati, & publico iudicio, hoc est, ad pœnam pro iniuria illata, siue pecuniariam, siue corporalem, neque ex duabus his actionibus, ad resarciendum scilicet damnum in re familiari, & ad pœnam, vnam impedire aliam, eoque modo intelligi regulam legis vnicae. C. quand. ciuil. act. criminal. præiud. Quando ergo lege vnica citata, exemplum in actione furti adhibendo,

dicitur; *Quo in genere habetur furti actio*; vt scilicet ciuilis actio criminalem non impediatur, neque è contrario criminalis ciuilem, non ita id intelligitur, quasi ciuilis actio, de qua in ea lege est sermo, sit propriè actio furti; quia non est nisi cōdictio furtiua vendicādo rē furto ablatam ex quocunq; eam possidente, aut petēdo æstimationē illius, & insuper dāna omnia ex tali furto subsequuta; sed quo ad criminalē, pecuniariam, aut corporalē, ob furtum, quæ proprie & vere est actio furti, dicitur eo loco, *Quo in genere habetur actio furti*, quia scilicet no impeditur per ciuilē cōdicēdo furtū&dāna subsequuta, sicut nec ciuilis impeditur per furti actionem ad pēnam, siue pecuniariam, siue corporalē. Prædictis non aduersatur discriminē, quod inter actionem iniuriarum, & actionem furti ad pēnam dupli, aut quadrupli, constituitur. *l. 2. §. emancipatus filius. ff. de collat. bonor. iuncta. l. 2. §. vlt. ff. de acquir. hæred.* quòd ex eo, quòd filius agat actione mere iniuriarum, quæ ipsi verè infertur, esto occasione rei hæreditariæ, neque censetur eo ipso adire hæreditatem, quoniam suum negotium agit, & non hæreditatis, neque tenetur id cōferre: si verò agat actione furti ad duplum, aut quadruplū, ratione rei, quæ ad hæreditatem spectat, cēsetur adire hæreditatem, eaque pēna in augmentum hæreditatis cedere; si item filius emancipatus ea dē actione agat ratione rei furto ablatæ, quam conferre teneatur, eam pēnam pecuniariam esse etiam cōferendā. Non, inquam, hoc prædictis aduersatur: quoniam, quando res furto eripitur, delictum redūdat in eos omnes, ad quos ea res attinet, aut attinere debet, ac pro inde pēna pecuniaria ob rē furto ablatam cedit in incrementum, cōferriq; aut diuidi inter aliquos debet. *Iul. Clar. 5. lib. sent. §. furtū. n. 16.* cum Cæpola ait, pēnam dupli, aut quadrupli, pro furto, non esse hodie in vsu, sed solam pēnam corporalē. *Idem in calce. n. 4. citati ait Ant. Gom.* esse hodie ferè in hoc toto Regno, & quòd **[[48]]** vbi seruatur *lex. 6. tit. 5. & l. 2. titu. 13. lib. 4. fori.* quæ statuūt, vt pro primo furto restituatur res, & insuper duplum parti, & septuplum fisco, sola ea pēna imponitur pro eo furto, & non pēna corporalis.

Iuxta ea, quæ suprā ex duobus authenticis, & [sect. 7] *ex. l. 18. titu. 14. part. 7.* sunt relata, constat, de iure communi Cæsareo pro furto simplici non imponi mortis, aut mutilationis, pēnā. Et quāuis. *c. 1. §. si quis quinque solidos de pace tenenda in vsibus feudorū, sancitum fuerit, vt si quis furaretur valorem quinq; solidorum, aut plus, laqueo suspēderetur: in primis illud non fuit statutum pro solo simplici furto, sed pro crimine violationis pacis simul interueniēte inter milites, vt constat ex rubrica & titulo, in quo paragraphus ille est collocatus, vt cum Baldo, & aliis, affirmant doctores mox citandi, cōsentaneè ad legem vlti. §. vlt. ff. de re militari, cuius verba sunt: Miles turbator pacis, capite punitur.* Alii, cū Bart. dicunt §. illum postea correctum fuisse per. *c. 1. §. iniuria de pace iuram firm. ibi: Iniuria, seu furtū, legitimè puniatur.* hoc est, iuxta ciuiles Cæsareas leges, vt aliqui exponunt. Denique omnes conueniunt §. illum, ob sui nimium rigorem, de communi consuetudine non seruari, vt referūt ac sequuntur *Iul. Clar. 5. l. sent. §. furtum. n. 7. 3. tom. Ant. Gom. var. res. c. 5. n. 9. & Gre. Lop. 18. citata. verb. matar ni cortar miembro.* in prin.

Dispositionem de iure Cæsareo authenticorū relatā, quòd scilicet fur nec mutiletur, nec interficiatur, pro furto simplici, intelligit glossa penult. in authentica sed nouo iure. C. de seruis fugit. & cum ea intelligunt multi, quos Greg. Lop. *l. 18. glossa citata meliùs, quam alii, refert; modò is fur semel tantum sit furatus: si enim furatus sit pluries, censetur publicus, seu famosus, latro, qui furca suspendi debet, iuxta. l. capitaliū. §. grassatores. ff. de pēnis,* cuius verba sunt: *Grassatores, qui prædæ gratia id faciunt, proximilatronibus habentur: & si cum ferro aggredi & spoliare instituerunt, capite puniuntur: vtique si sæpius atque in itineribus hoc admiserunt: ceteri ad metallum damnantur, vel in insulas relegantur.* Quidam, quos Greg.

Lopez vbi suprà meliùs, quàm alii, refert, asserunt, satis esse furem bis esse furatum, vt latro seu fur publicus ac famosus dicatur, ac proinde, vt furca debeat plecti: communis verò sententia affirmat, necesse esse, vt ter sit furatus. Atque legibus quorundam Regnorum est sancitum, vt pro secundo furto suspēdatur: frequētiùs verò est constitutum, & communi consuetudine Regnorum multorum, absque lege ea de re lata, est receptum, vt pro tertio furto suspēdatur: eaque consuetudo originem traxit ex opinione glosse citatæ, & doctorum, qui illam amplexati sunt: vigetque hodie in hoc Castellæ Regno. Quod autem consuetudine multorum Regnorum sit id receptum, atque exequutioni mandetur, affirmat communis doctorum sententia, quam referunt ac sequuntur *Couar. 2. var. res. c. 9. n. 7. Iul. Clar. §. furtum citat. n. 8. Greg. Lopez glossa citata, & Ant. Gom. c. 5. citato n. 5.* Id verò corroborant, quoniam cum fur simplex possit pro vno furto puniri pœna corporali arbitraria, vt flagellorum, vel alia, infra mortem ac mutilationē, & ex iteratione eiusdē criminis pœna arbitrio eiusdē iudicis augeri debeat, iuxta. *l. 3. iuncta glossa vlt. ibi. C. de Epis. audiēt. l. capitaliū. §. solēt, & §. grassatores. ff. de pœnis. l. 3. §. si plures. ff. de re militari. l. seruos. §. 1. C. ad leg. Iul. de vi, & iuxta alia iura, consequens est, vt, si simplicia furta multiplicētur, ita vt ad tertium perueniant, in corrigibilisq; comperiatur fur, possit iudex illi imponere pœnam mortis, nihil refragāte dispositione illa authenticorum relata.*

In primis arbitror dicendum esse cum Bart. in authentica sed nouo iure. C. de seruis fugit. & cū aliis, quos Greg. Lopez & Iul. Clar. vbi suprà referunt, & quorum sententiam Iul. Clar. amplectitur, opinionem glossæ in authētica sed nouo iure, & eorum, qui illam sequuntur, neccolligi, nec probari, ex lege capitaliū. §. grassatores. ff. de pœnis. Ibi enim non est sermo defuribus, qui, vt suprà ex authētica sed nouo iure & ex authentico vt nulli iudiciū. §. penul. relatum est, vocantur illi soli, qui occultē, & sine armis, hoc est, sine animo vim inferendi, furantur: grassatores autem sunt, qui inuadēdo, cum violentia spoliant ac diripiūt: grassari enim est cum impetu & concitatione ad aliquid incedere; & quamuis interdum sumatur etiam inobnam partem, frequētiùs sumitur in malam, vt est aggredi cum impetu ac vio lentia ad malum aliquod, quod *saltear* Hispanè dicitur: & sic sumitur. §. grassatores, dum sic habet; *grassatores, qui prædæ gratia id efficiunt, proximi latronibus habetur*, hoc est, iis, qui occidēdo grassantur ad prædam: de quibus in eadē lege. §. famosos, sic habetur; *famosos latrones in his locis, vbi grassati sunt, furca figēdos compluribus* [sect. 8] *placuit, &c.* Iuxta hæc ergo tres gradus diripiētīū, quod ad rē propositam attinet, distinguuntur. Primus, diripiētīū occultē ac sine vi, qui fures appellātur. Secūdus, aggrediētīū ad prædam cūvi, sed non interficiēdo, & hi grassatores dicuntur, non verò latrones. Et tertius, aggredientium ad prædādū interficiēdo, atque hi soli latrones nūcupātur. Vnde meritò. §. grassatores citato, de diripiētibus secūdi gradus dicitur, *haberi proximos latronibus*. Atque de eisde cōtinuò subiūgitur: *Et, si cum ferro ag gredi & spoliare instituerint, capite puniūtur; utique si sæpius atque in itineribus hoc admiserūt: cæteri in metallum dānantur, vel in insulas relegātur*. Hinc iam facilè liquet, fures, qui sæpius occultē furantur, & ob id crimen sæpius dānantur, neque dici, iuxta dispositiones iurium, quæ relatæ sunt, grassatores, neque latrones famosos, aut publicos, sed famosos latrones appellari, qui grassando ad prædam aliquem, vt deprēdentur, interficiunt, atque hos pro primo furto cum homicidio comisso capite plecti, debereq; suspēdi in eodem loco, in quo crimen cōmiserūt, si commodè id fieri possit, vt exemplo sint alii, & sit id solatium consanguineis eius, qui ab eis directus ac interfectus fuit, vt habetur. §. famosos citato: eos verò, qui occultē furati sunt, esto sæpius furati sint, & de eo furto sæpius sint dānati, posse quidem dici publicos ac famosos, incorrigibilesq; fures, non verò famosos

latrones, vt notat additio in margine ad glossam penul. in authentica sed nouo iure. Liquet deinde, tantum abesse, vt ex dispositione eorūdem iurium colligatur, furē simplicem posse pro tertio furto capite plecti, vt cōtrariū manifestē colligatur ex duobus authēticis citatis, iuncto. §. grassatores citato. Si enim, vt habetur duobus authēticis citatis (cum quibus cōsētit. *l. 18. tit. 14. part. 7.* fures, qui occultē sine vifurātur. neq; mutilandi neque interficiendi sunt; ij verò, qui violēter furantur in domibus, itineribus, aut in mari, iuxta dispositionem legum sunt puniendi; &. §. grassatores citato, erat sancitum, vt grassatores ad prædam, si cum ferro aggredi & spoliare instituerint, tunc solū capite puniantur, quando sæpius, & in itineribus, id fecerūt; liquidò constat, fures occultē, esto sæpius sint furati, non esse ex dispositione authenticorum capite plectendos; alioquin [[49]] æquarentur in pæna grassatoribus, qui vi publica & in itineribus grassantur, contra apertam dispositionem authenticorū: imò verò acrius punirentur, quàm qui grassarentur sæpius in itineribus vi priuata, hoc est, sine armis, & quàm qui sæpius extra itinera grassarentur vi publica, hoc est, cum armis: nam hi omnes. §. grassatores, præcipiuntur non puniti mortis pæna, sed vel metallorum, vel relegationis in insulam aliquam. Quo fit, vt proculdubio sit dicendum, de iure Cæsareo authēticorum, nefas fuisse interficere, etiam pro tertio, aut quarto, furto furem simplicem, qui sine vi esset furatus, vt *Iul. Clar. n. 8. citato*, & alii, rectē affirmant, tametsi non ita, vt nos, id deducant ex ipsa iurium dispositione.

Quamuis autem id ita dispositum fuerit de iure Cæsareo nouissimo authēticorum, neque contrarium comperiamus sancitum de iure Codicis, aut digestorum, sed fortē ad comprimendum iudices, ne pænam criminalē pro furto simplici arbitrariam extenderent usque ad mortem, aut mutilationem, esto furtum simplex esset cuiuscunq; quantitaris, aut esto sæpius esset commissum, ea dispositio lata videatur, relinquendo illis, vt, infra mortem ac mutilationem, augere possent pænas pro quātitate furti, & pro iteratione illius, accumulando exilio flagella, vel multiplicando flagella, vel illis augendo auxilium, vsque ad deportationem aut damnationem ad metalla: quamuis, inquam, id ita de iure authenticorum sit dispositum, consonetque legi veteri, quæ pro furto simplici solū imponebat pænam dupli, quadrupli, aut quintupli, vt patet *Exod. 22.* nihilominus damnandæ non sunt leges, quæ pro furto secūdo, aut tertio, aut pro furto certæ quantitatis, aut cum talibus, vel talibus, circumstantiis cōmisso, pænam mutilationis statuunt, aut mortis, vt, referente *Couar. n. 7. citato*, Carolus quintus legem in Germania tulit, vt fur pro tertio furto suspenderetur, & lex erat Longobardo rum, quam refert glossa. *c. 1. §. iniuria, verb. seu furtum, de pace iurament. firm.* quòd pro primo simplici furto erueretur oculus furi, pro secūdo abscinderetur ei nasus, & pro tertio fur suspenderetur, & aliæ sunt latæ in aliis Regnis. Neque item inde est dānanda consuetudo recepta, quæ vim habet, legis, vt pro secundo, aut tertio, furto suspendatur fur, vt in hoc Regno, & in aliis est recepta: id quod ex dictis in principio huius disputationis aduersus Scotum liquet. Vnaquæq; enim respublica, etiam mortis pænam, statuere potest pro furto, si ita expedire iudicauerit bono suo communi, eam prius comminando ac promulgando subditis lege, aut consuetudine recepta, quæ vim legis habeat, vt aduersus eundem Scotum dictum ostensumque est.

In Regno, in quo lex lata est, vt fur pro tertio furto suspendatur, aut id consuetudine est receptum, intelligendum est id de furtis, quæ non sint paruæ quantitatis, vt vnus gallinæ, aut duarum, vel similium rerum, vt cum Cæpola & aliis rectē affirmat Grego. Lopez glossa citata: subiungitq; eiusmodi furta puniri, vel pæna pecuniaria, vel detinendo furem aliquibus diebus, vel mensibus, in carcere, vel exponendo illum ad aliquot homs in loco publico cum re

furto ablata. Qui tamen tria furta commisit notabilis quantitatis, esto duo priora commiserit in alio territorio, potest pro tertio suspendi; & potest iudex huius alterius territorii cognoscere de duobus prioribus furtis incidenter, tãquam de circũstantiis aggrauantibus tertium, vt pro tertio pœnam legibus, aut consuetudine, statutam imponat. Ratio verò præcipui asserti est, quoniam duo priora aggrauant tertium, & fur, qui ad tertium peruenit furtum, censetur consuetudinem habere furandi, & famosus fur. Ita communis doctorum sententia, quam referunt ac sequuntur *Ant. Gom. 3. tom. var. res. c. 5. n. 8. Iulius Clar. 5. lib. sent. §. furtum. n. 10. Grego. Lopez. l. 18. titu. 14. part. 7. verb. matar ni cortar miembro, & Couar. 2. var. res. c. 9. n. 7.* Neque necesse est, quòd sit damnatus de duobus prioribus furtis, vt probant iura & affirmat communis sententia, quam *Ant. Gom. vbi supra. n. 9. & Couar. n. 7. cita.* referunt ac sequuntur: quoniam adhuc duo priora furta aggrauant tertium, & tertio cõmisso, fur censetur habere consuetudinẽ furandi. Neque item refert, quòd duo priora furta sint iam præscripta, ita quòd non competat iam actio furti ex eis aduersus furẽ: quoniam adhuc sunt circunståtiæ aggrauantes tertium, & de eis cognoscit iudex tertii furti incidenter, tanquam de circunstantiis illud aggrauantibus, vt cum Baldo, Salyceto, & Iasone rectè ait *Ant. Gom. in calce. n. 8. citati.* Neque refert præterea, si iam fuerit punitus pro primo, & secũdo, aut quòd per gratiam principis fuerint ei remissa: quoniam similiter adhuc sunt circunstantiæ aggrauantes tertium furtum. Ita *Iul. Clar. vbi supra. n. 12. & 13.* cum aliis, quos citat, & consentit *Couar. n. 7. citato.* Debent verò furta esse tria distincta, non solũ re, sed etiam tempore, vt bene cum aliis notat *Iul. Clar. ibidem. n. 14. qui. n. 15.* cum aliis subiungit, pœnam furis esse furcam, nec debere iugulari, atque ita consuetudine est receptum. Quando autem iudex cognosceret de solo primo furto, aut secundo, tunc esto constaret de tertio posteriori furto, aut de secundo & tertio posterioribus, siue de tertio esset iam is fur punitus, siue non, non posset pro tali primo, aut secundo, furto, suspendi: quoniam posteriora delicta non aggrauant priora, sed è contrario priora aggrauant tertium, vt pro illo imponi possit pœna mortis. Ita, cum *Angel. & aliis, Ant. Gom. n. 9. citato, & Grego. Lopez vbi supra.*

Vtrũ autem pro primo furto, quod sit magnæ [sect. 9] quantitatis, ita vt æquipolleat tribus, pro quorum tertio posset fur suspendi, aut ea excedat, posset fur suspẽdi. Baldus in authẽtica sed nouo iure. C. de seru. fugit. & alibi, *Angel. & alii, quos Couar. n. 7. citato* refert, & in quorum sententiam propendet, affirmanter responderunt, atque aliqui affirmant iuxta eam sententiam fuisse iudicatum frequenter in Hispaniis. Communis tamen sentẽtia contrarium affirmat, quam referunt ac sequũtur *Iul. Clar. §. furtum citato. n. 9. Grego. Lopez vbi supra in calce eius glossæ, & l. 1. titu. 17. part. 2. verb. el hurto, & Ant. Gom. c. 5. citato. n. 7.* Atque hæc sententia nobis probatur, vbi contraria non fuerit lege sancita, aut consuetudine, quæ vim legis habeat, recepta, vt non est adhuc ita recepta in hoc Castellæ Regno: quandoquidem à tet viris doctis Hispanis reprobatur. Ducor, quoniam, vt ostensum est, de iure communi, neque pro tribus simplicibus furtis, neque pro vno cuiuscunq; sit quantitatis, potest imponi pœna mortis, aut mutilationis, sed pro furtis simplicibus, ratione quantitatis, iterationum, & cæterarum circunståtiarũ, quæ ea non extrahunt à ratione furtorum simplicium, aggruari possunt pœnæ infra mortem ac [[50]] mutilationem: quate, nisi sit noua lex, quæ contrarium statuatur, aut consuetudo, quæ vim legis habeat, nefas est pro simplici furto, cuiuscunque quantitatis, quenquam interficere aut mutilare. Neque rationes *Couar.* aliud probant, quàm posse statui legem, quæ talem pœnam licitè constituat. Prædictis non obstant. *l. 2. ff. arbor. furt. cæsar. & l. ult. titul. 15. part. 7.* quæ habent, si damnum datum fuerit in arboribus, maximè in vitibus, posse dominum, si velit, agere de furto aduersus eum, qui illud dedit,

ac, si damnum sit magnum & exorbitans, debere puniri eum, qui illud dedit, pœna mortis. Non, inquam, obstant prædictę leges. Tum quia id statuitur, non pro vero furto, sed pro damno dato. Tum præcipuè, quoniam id solùm statuitur in eo tantùm particulari damno dato, vt infrà cum de damno dato fuerit sermo dicetur: eaque proinde dispositio extendi non debet ad alia.

Quamuis de iure Cæsareo furtum non com [sect. 10] mittatur circa res immobiles, sed solùm circa res mobiles, vt Disp. 68;. dictum est, nihilominus, si quis limitem, diuidentem agrum suum ab agro vicini, propria auctoritate amoueat animo occupandi partem agri illius, incidit in pœnam quinquaginta aueorum (qui solidi videntur esse) pro vnoquoq; termino, quem amouerit, soluendos fisco Regis, *vt habetur. l. agraria. ff. de termino amoto, c. l. 30. titu. 14. part. 7.* Atque lex 30. addit, vt insuper amittat ei, qui in possessione erat agri, cuius partem ea termini amotione occupare intendit, ius omne, si quod habebat, in partem, quam ita occupauerit: si verò nullum ius in eam habebat, soluat ei de suo tantundem, quantum ex agro alieno occupauit: id quod etiam disponit. *l. si constiterit. C. finium regundorum:* quæ licèt solùm loquatur, quando, post litem contestatam, ante sententiam latam, eam partem occupauit; eadem tamen est ratio, quando, nulla mota lite, id propria auctoritate fecit. Consentit. *l. extat. ff. quod metus causa,* quæ licèt de amissione sola iuris loquatur; in ea tamen est sermo, etiam si lis non fuerit contestata; loquiturque vniuersim de occupante propria auctoritate, quod sibi deberi arbitrabatur. Lex. 30. citata addit: *Elo que diximos en esta ley del mudamiento de los mojones, ha lugar otrosi en el hierro, que ome faze en los mojones, que departen los terminos entre las ciudades, è las villas, y entre los castillos, y los otros lugares.* Atque in euentu proposito ad finemque propositum intelligo. *l. agraria. §. alia quoque. ff. de term. mot.* quæ statuit, si seruus, aut serua, domino, aut domina, insciis, amoueatur ad eundem finem limites agrorum, morte moriatur, nisi dominus, aut domina, soluere voluerit fisco loco serui, aut seruæ, pœnam quinquaginta aureorum.

Circa rem hanc lege opiniones, quas, stando in iure communi Cæsareo, refert Grego. Lopez. *l. 30. cita. verb. cinquenta maravedis de oro.* Et mihi, extra casum de quo dictum est, & de quo solo loquitur. *l. 30. citata,* dicendum videtur. Quòd si quis terminos amouit animo seminandi Zizania & discordias inter possessores agrorum, non puniatur pœna quinquaginta aureorum, sed pœna extraordinaria, pro qualitate facti, personarum, ac circumstantiarum concurrentium, iuxta. *l. 1. c. l. agraria. ff. de termino moto, ac. l. 1. C. de accusationib.* vt cum Salyceto affirmat Greg. Lopez glossa citata. Si verò illos auoueatur, animo illos furandi, vt si euellat ac vsurpet sibi lapides fixos in signum terminorum, tunc distinguendum est. Quoniam vel sciebat illos esse terminos agrorum, vel non. In priori euentu, si sit nobilis, relegatur ad longius, vel breuius, tempus, prout patietur ætas, & postulauerint aliæ circumstantiæ: iuuenis enim, cæteris paribus, ad longius, & senis ad breuius, tempus, debet relegari: si verò fuerit ignobilis, flagellatur, & insuper damnari biennio debet ad opus publicum. In posteriori verò euentu satis est ignobilem flagellari. Lexque intelligendum consequenter relinquit, in eadem proportionem minui debere pœnam nobili in hoc posteriori euentu, licèt id non exprimat. Ita habetur satis perspicuè. *l. 2. ff. de term. moto.* Et quoniam hæc pœnæ maxima ex parte sunt arbitrariæ, atque extraordinariæ, vtique in his etiam euentibus suo modo locum habent. *l. 1. ff. de termino moto, c. l. 1. C. de accusationib.* Atque hæc nostra decisio consonantior comperietur iuribus citatis, quàm decisiones Angeli, & Salyceti, quas Greg. Lopez vbi suprà refert, & quàm Gregorii Lopez decisio.

De iure communi, qui intentasse furtum cōperi [sect. 11] tur, illud verò non perfecit, vt si in domo aliena reperiatur ad furandum absconditus, aut, dum apertire aut præscindere marsupium alienum est aggressus, sentitus ac deprehensus fuit, non censetur furtum cōmisisse, ac proinde neque actio furti aduersus eum datur. *l. vulgari. §. qui furti. ff. de furtis.* Et cū nihil sit furatus, constat non competere aduersus eum actionem furti ad pœnam pecuniariam dupli, quadrupli, aut ad aliam similem. Potest vero agi aduersus eum actione iniuriarum: cū iniuria sit ingredi domum alienam domino inuito, vt habetur. *l. is qui domum. ff. de iniuriis,* & maximè animo furandi, vt habetur. *l. vulgari. §. qui furti. ff. de furt. & l. sacularii. vers. 1. ff. extraord. criminib.* vniuersimque intentare furariem alienam crimen atque iniuria sit, aduersus eum, cuius est illa res, vt constat ex duobus iuribus citatis. Vnde. *l. sacularii,* habetur, vt qui repertus fuerit in domo aliena animo furandi, puniatur plusquam fur, & pro qualitate personæ, ac furti, quod fuerit aggressus, & aliarum circumstantiarum concurrentium, vel damnetur ad seruiēdū ad tempus in publicis operibus, vel flagelletur, vel relegetur ad tempus iudicis arbitrio constituendum. Et idem dicendum est de aliis, qui alia furta aggrediuntur committere. Lege *Ant. Gom. 3. tom. var. res. c. 5. n. 15.*

De iure huius *Castellæ Regni. l. 6. titul. 5. libri¹⁸ quarti fori,* iuncta. *l. 2. titul. 13. eiusdem libri,* fur [sect. 12] pro primo furto quadraginta marauedinosaurum, & infra, vltra rem furto ablatam, cogebatur soluere in pœnam æstimationem illius, duplam quidem ei, à quo furto illam acceperat, & septuplam fisco Regis, & ita pœna illa appellabatur, *pechar las nouenas.* Quòd si fur non esset soluendo, amittebat quicquid in bonis illius reperiabatur, & insuper amputabantur ei aures. Si verò primum furtum excedebat quadraginta marauedinos, incidebat in eandem pœnam pecuniariam, sed si soluendo non erat, occupabatur similiter quicquid in bonis illius reperiabatur, & amputabantur illi aures, *yelpuño,* hoc est, & altera manus. Pro secundo verò furto suspendebatur. Circa hanc pœnam in primis nota, conditores legio illius sequutos fuisse opinionem illorum, qui, stando [[51]] in iure communi, exist mauerunt, furem pro secundo furto esse suspendedum. Deinde nota, tēpore, quo lex illa fuit condita, quadraginta marauedinos plus valuisse, quàm valeant hodie ducenti, quin & trecenti, aut plures, vt ex iis, quæ in materia de cambiis à nobis dicta sunt, habita ratione antiquitatis earum legum, facilè intelligetur. Nefas autem esset hodie, pro primo furto quadraginta marauedinosaurum, abscindere aures, esto quis non esset soluendo pœnam illam pecuniariam pro illo; aut pro furto centum marauedinosaurum abscindere aures & manum, neque id esset consonum illi legi, quæ id statuit, attento valore tunc monetæ, ad illa comparandas res cæteras. Quare iudices, ne iniusti sint, verba legis, potiùs quàm intentum, in exequutione earum, in pœnisque iuxta eas imponendis, sequendo, attendere debent ad rerum circumstantias, num variatæ sint, ac proinde num, iuxta eam variationem, de rigore legis sit remittendum. Et quidem lex illa iam hodie vsu non seruatur quoad eam abscissionem aurium & manus pro primo furto, esto longè multo maioris quantitatis sit, quàm mille marauedinosaurum, nedum quàm quadraginta marauedinosaurum. Vtrū autem in vsu sit, quo ad pœnam illam pecuniariam dupli, applicādam parti, aduersus quam furtum fuit commissum, & septupli fisco Regis, Greg. Lopez l. 18. titu. 14. part. 7. verb. *matar ni cortar miembro,* affirmat esse in vsu, suffragaturq;. *l. 12. titu. 26. lib. 8. nouæ collect.* quæ à Ferdinand do & Elisabetha anno 1499 lata fuit, & qua iudicibus Regni Granatensis sic præcipitur: *Cada y quando que ouieredes de hazer condenacion de setenas contra qualesquier personas por qualesquier hurtos, en que segun las leyes de nuestros reinos deuan ser condenados en setenas, las juz guedes yappliquedes para la nuestra camara y fisco, &c.* Ant. verò Gom. 3. to. var. res. c. 5. in calce.

n. 4. loquens de eadem. l. 6. *fori* sic ait: Vnde in locis, vbi viget illa lex vel consuetudo, non punitur fur criminaliter: quia pœna applicatur fisco: sed in aliis locis & partibus, vbi non viget nec seruatur illa consuetudo, standum esset iuri communi. Sed certè communiter in maiori parte Regni de consuetudine non imponitur pœna pecuniaria applicanda fisco, sed solùm corporalis, vel alia iudicis arbitrio, secundùm qualitatem furti & personæ. Hæc ille. Standum tamen potiùs est sententiæ Grego. Lopez, quam, præter legem citatam, confirmat. l. 9. titu. 11. lib. 8. *nouæ collect.* quæ lata fuit anno. 1566. eamque inferiùs referemus, & inter alia sic habet: *Y como quiera que, conforme à el uso yestilo, que los juezes tienen en estos reinos, en el dicho caso del primer hurto condenan en setenas, y en su defecto en la dicha pena de açotes, ordenamos, y queremos, que la dicha pena de condenacion sea precisa, y no en defecto de setenas.* Vbi vides, ante eam legem semper viguisse consuetudinem, vt pro primo furto condemnaretur fur ad pœnam dupli parti læsæ, & insuper septupli fisco Regis, & in defectum, puniretur regulariter pœna flagellorum: & quia ferè nunquam habebant fures, vnde, vltra furtum, & damna subsequuta, soluerent æstimationem illius nouies, vt plurimum, ac ordinariè, puniebantur pœna flagellorum. Nunc prosequamur reliqua: quæ hodie magna ex parte innouata sunt, vt videbimus lege 9. citata.

Conueniunt Ant. Gom. Grego. Lopez vbi suprâ, & alii, consuetudinem esse huius Regni, (iuxta Baldi opinionem, vt fur non suspendatur, nisi pro tertio furto) quòd fur pro secundo flagelletur, & abscindantur illi aures, & pro tertio suspendatur. Pro primo verò, vbi fuerit consuetudo, vt pœna pecuniaria, dupli parti, & septupli fisco, puniatur, eam solam pœnam esse illi imponendam: si verò non sit soluendo, puniendum esse pœna flagellorum, aut relegationis, pro qualitate personæ, & quantitate furti, vel alia corporali arbitraria. In loco verò, vbi non est consuetudo, vt puniatur pecuniaria pœna, puniendum esse pœna flagellorum, nisi, propter nobilitatem, commutari debeat in pœnam exilii, vel aliam arbitrariam, consonatq̃ue ius commune in authentica sed nouo iure. C. de seru. fugit. Obserua tamen, pro furto quadraginta, sexaginta, octoginta, quin & centum, marauedinatorum, nefas esse hodie quenquam punire pœna flagellorum, imò neque relegationis, præsertim si sit primum furtum, idq̃ue propter modicum valorem hodie talis summæ marauedinatorum ad reliquas res ea summa comparandas, vt dictum est: cùm neque par calceorum communium, centum quinquaginta marauedinis hodie, ematur. Quare eiusmodi leuia furta hodie vel pœna pecuniaria, dupli parti applicandæ & septupli fisco, erunt punienda, vel, si reus non sit soluendo, punienda erunt detentione illius in carcere aliquibus diebus, aut mensibus, vel collocazione illius in loco publico ad certas horas, appenso furto ad collum, pro qualitate personæ, vt suprâ cum Greg. Lopez est dictum.

Illud obiter obserua, falsum esse, quod Greg. [sect. 13] Lopez in calce glossæ citatæ affirmat, nempe pœnam abscissionem aurium pro simplici furto, esse pœnam abscissionis membri contra autheticam sed nouo iure citatam. Neque enim cartilago tota aurium est membrum, nedum pars illa sola, quæ furibus abscinditur, vt sit illis in ignominiam, atque in signum, quòd iam bis furati sunt, vt si iterum furentur, suspendantur, vt tractatu. 3. sequenti ostendetur: quare iudices, qui eam pœnam infligunt, irregulares propter illam non sunt, vt ibidem ostendetur.

Dubium est. Vtrùm, si is, qui de furto aliquo¹⁹ in hoc Regno conuincitur, reperiatur abscissis auribus eo modo, quo furibus consueuerunt abscindi pro secundo furto, id satis sit, vt illud furtum censeatur tertium, & vt possit suspendi pro illo absque alia probatione. Pars, quæ affirmat,²⁰ suaderi potest. Quoniam. l. 6. titu. 28. part. 2. cùm referatur, quondam pro primo

furto, facto in ex [sect. 14] exercitu ab ignobili, constitutum fuisse, ut solueret illud duplum, abscinderenturque ei aures, ac manus, qua id esset furatus, & pro secundo interficeretur: Si verò furtum fuisset annonæ; pro prima vice interficeretur, modo ibi explicato. Atque pænæ adeò acerbæ statuerentur, quoniam in exercitu non habent homines domus, neque arcas, in quibus res suas custodiant, cum tamen expediat valde res militum in exercitu, & præcipue dum sunt inter hostes, tutas illis esse, ut habeant unde viuant, eaque ratione opus fuit, ut timore pænæ acerbæ, tutæ illis essent. Cum hæc, inquam, ibi referantur, mitigando eam pænam, statuitur, ut ignobilis pro primo furto soluat illud duplum, & insuper signetur ferro candenti in facie, & pro secundo interficiatur. Et dum sermo est de eo signo, sic in ea lege habetur: *Porque quando otra vagada lo fiziese, fuese conocido por el, è el segundo furto y esta señal fuese en testimonio para escarmentarlo dandole muerte.* Et, loquendo de antiqua pœna, sic in eadem lege dicitur: *Que lo pechase doblado, y lo señalasen cortandole las orejas, è la mano, con que lo furtase. E esto fizieron, por dar escarmiento à los otros, porque se guardasen de fazer otro tal, è porque, si aquel furtasse otra vagada, que el furto y la señal le fuesen testimonio para darle muerte.* Pari ergo ratione furtum plenè comprobatum, & abscissio aurium, sufficere debent, ut pro eo furto, tanquam pro tertio, imponatur hodie pœna mortis. Ut verò hîc obiter nos expediamus à furtis factis in castris, in eadem lege subiungitur, si ignobilis furetur annonam, soluat illam quadruplam, & ei amputentur aures pro prima vice, nisi, fame pressus, id fecerit, neque plus annonæ sit suratus, quàm quod statim consumeret. Nobiles, qui furantur in exercitu, si furtum non sit annonæ, pro prima vice soluunt illud quadruplum, & amittunt portionem, quæ eos contingere debebat ex præda. Pro secunda verò in eadem pænam incidunt, & exulant à loco habitationis suæ tempore arbitrio Regis taxando. Si verò furtum sit annonæ, pro prima vice soluunt illud octuplum, & pro secunda incidunt in eandem pænam, & insuper exulant modo explicato. Nunquā autem audiui, quenquam in exercitu punitum fuisse pro primo furto illo signo ferri candentis in facie, aut pro primo furto annonæ abscissas illi fuisse aures. Quare contraria consuetudine videtur cessasse illæ pænæ, videnturque in exercitu huiusmodi furta pænis arbitrariis puniri, acerbioribus, quàm puniantur furta extra exercitum commissa. Id tamen ex usu & consuetudine erit ad descendendum ex iis, qui in exercitu sunt versati. Ad²¹ rem verò nostram redeundo, dicendum est cum *Ant. Gom. 3. tom. var. res. c. 5. n. 14.* re periri aurículas abscissas eo modo, quo furibus abscindi consueuerunt, esse sufficiens indicium, sufficientemque præsumptionem, ut interrogari possit de furtis præteritis, & nisi sufficienter probet alia de causa abscissas illi fuisse, ut subjiciatur tormentis, quibus confiteri cogatur furta alia commissa, causamque veram abscissionis aurium: antequam autem duo anteriora furta confiteatur, aut illi probentur, mittendo literas requisitorias ad loca ubi illa commisit, & ubi propter illa abscissæ sunt ei aures, non potest puniri pœna mortis: quoniam abscissio illa aurium aliunde potuit euenire: & quoniam licet sit præsumptio vehemens, ob duo anteriora furta fuisse ei abscissas; pœna tamen ordinaria pro crimine non potest imponi, nisi integre ac plenè de crimine constet, ut habetur, l. vlt. C. de probationibus,²² & aliis iuribus, præscribitque recta ratio. *Ad. l. 6. titu. 28. par. 2.* respondet *Ant. Gom.* id præcisè esse intelligendum in eo euentu, & in terminis eius legis, neque esse extendendum ad alia. Dicerem, neque in eo euentu esse id integrum & plenum testimonium, sed solum valde vrgens ac violentum, multumque coadiuuans ad plenam probationem, ac sufficiens, ut interrogari possit de priori furto, & de causa talis signi, atque ut, nisi aliam causam reddat, ac sufficienter probet, subjici possit tormentis, ut confiteatur furtum antecedens & causam legitimam eius signi, quando aliunde non integre ex testibus constat.

Hodie verò, quæ hactenus dicta sunt, de pæ [sect. 16] na pro primo & secundo furto, locum non habent, quando furta sunt alicuius momenti, propter. l. 9. iunctis duabus antecedentibus, titul. 11. lib. 8. nouæ collect. infrà referendæ, quæ statuunt, vt pro primo furto, si fur non sit minor decem & septem annis, neque imponatur pæna pecuniaria septupli fisco Regis, neque pæna flagellorum, sed remigandi in triremibus, & vt pro secundo imponatur pæna flagellorum, loco verò abscissionis aurium, imponatur pæna remigandi in triremibus.

Lex. 9. titul. 10. lib. 7. nouæ collect. sic habet: Si [sect. 17] naue, o galera, o otro nauio qualquier, en la mar peligrare, o se quebrare, mandamos, que el nauio, y todas las cosas, que del ballaren, sean dadas à aquellos, cuyas eran antes, que el nauio quebrase, o peligrase, y ninguno sea osado de tomar cosa alguna dellas sin licencia de sus dueños, saluo si las tomare para guardarlas. Y antes que las tome, llame à el alcalde del lugar, si lo pudiere auer, o à otros hombres buenos, y escriba todas las dichas cosas, y guardelas por escrito, y por cuento, y de otra guisa no sean osados de lo tomar, y quien de otra guisa lo tomare, pechelo como de hurto. Y esto mismo sea de las cosas, que fueren echadas del nauio, por lo aleuiar, o se cayeren y perdieren en qualquier manera. Et l. 11. subiungitur: Ordenamos y mandamos, que de aqui adelante en los puertos de los mares de todos nuestros reinos, no se puedan ni lleuen por nos, ni por otras personas algunas, precio ninguno de los nauios, que quebraren, o se anegaren, en las nuestras mares, y queremos, que los tales nauios, y todo lo que en ellos viniere, queden y finquen para sus dueños, y no les sea tomado, ni ocupado, por personæ alguna, so color del dicho precio, so pena que qualquier que lo contrario hiziere, por la primera torne à su dueño todo lo que tomare con mas las costas y daños, y pague el quatro tanto dello para la nuestra camara. Y por la segunda vez, torne à su dueño todo lo que tomare, con mas las costas y daños, y que aya perdido el puerto de la mar, por razon del qual pide el dicho precio, y el lugar mas cercano del, que tuuiere por suyo, y que sea applicado y confiscado por el mismo hecho para la nuestra camara y fisco. Y esso mismo mandamos y defendemos, que quando alguna bestia cayere de puente, o hiriere otra bestia, o persona, o se despeñare carreta, o se cayere cosa, que no tomen por esso las justicias, ni los señores de los lugares, las bestias, ni las carretas, ni las cosas, como dicen que se acostumbra en algunos de los lugares: pues es injusta esta extorsion y corruptela: ni de las cosas suso dichas, ni de otras semejantes, se lleuen derechos de sangre ni homezillo, y que esto se guarde y cumpla, no embargante qualquier uso y costumbre, por donde lo tal se diga ser introduzido, el qual usu y costumbre nos por la presente reuocamos.

Lege. 1. titu. 23. lib. 8. nouæ collect. sic habetur: [sect. 18] Eßo mismo dezimos, que muera por justicia aquel, que fuere conuencido de hurto, o robo, o fuerça, en la dicha nuestra corte, o en el nuestro rastro, y aquel que fuere tomado con el hurto, o robo, en la dicha [[53]] corte orastro. Hæc tamen pæna hodie mitigata est, vt paulo inferiùs subijciemus ex. l. 7. 8. c. 9. tit. 11. lib. 8. nonæ collect.

Lege. 5. titu. 17. lib. 5. nouæ collect. habetur: Quien [sect. 19] burtare, o forçare, bueyes, obestias, de arar, o los aparejos, que son para arar y labrar, y coger pan, y los frutos de la tierra, que la torne a aquel, a quien la tomo, con onze doblado, la mitad destapena para el quereloso, y la otra mitad paranuestra camara.

Lex. 16. titu. 11. lib. 5. nouæ collect. sic habet: Man [sect. 20] damos, que ninguna, ni algunas personas de nuestros reinos, de qualquier estado y condicion que scan, no sean osadas de comprar de ningun esclauo, ni esclaua, ningunas joyas, ni paños, ni lienços, ni oro, ni plata, ni otros bienes algunos, de grande ni de pequeño valor, ni los troquen ni cambien con ellos, ni los reciban de gracia, ni por via de donacion, ni encomienda, ni en guarda, ni en peño, ni para los dar, ni llevar, a otras personas, ni por otra via, ni manera alguna, agora sean los dichos esclauos negros, o loros,

o blancos, nacidos en estos nuestros reinos, o fuera dellos, agora sean Christianos, agora Moros, so pena que qualquier, que lo contrario hiziere, o fuere o passare cotra lo con enido en esta nuestra carta, por esse mismo hecho sea tenuto y obligado à la restitucion de los tales bienes y dineros, oro, y plata, o otras qualesquier cosas, que recibiere, sabiendo que aquel, o aquellos, de quien los vbieron, eran esclauos o siendo auidos y tenidos por tales, y sean mas obligados a pagar la pena de los hurtos, assi como si ellos vuieran hurtado o subtrahido las dichas cosas, y que esto aya lugar y se cumpla, aunque no sean hallados los tales bienes en poder de las tales personas, que assi los vbieron de los dichos esclauos prouandose legitimamente que vinieron a su poder en qualquier maneras de las suso dichas. Saluo si los tales esclauos, o esclauas, de consentimiento de sus dueños vuieren sido, o fueren, tratantes y negociadores, o si fueren auidos y tenidos comunmente y reputados por tales, ca en los tales casos mandamos, que no aya lugar lo contenido en esta nuestra carta, mai que se guarde cerca dello, lo que las leyes de nuestros reinos mandan.

Ministri de la hermandad, non solùm cognos [sect. 21] cunt de rapinis, vt infrà dicetur, sed etiam de furtis rerum mobilium, aut se mouentium; modò tamen eiusmodi furta fiant in yermos, o en despoblados, o en qualesquier lugares poblados, si los malbechores salieren a el Campo con los tales bienes, que vbieren hurtado. Y es yermo, para este y otros tasos de hermandad, lugar descercado de treinta vezinos a baxo. Ita habetur. l. 2. titul. 13. lib. 8. nouæ collect. Si eiusmodi furtum non excesserit valorem centum quinquaginta marauedinatorum, fur reddit, quod furatus est, & insuper duplum aliud parti læsæ, & quadruplum in sumptus de la hermandad, & flagellatur, ac exulat. Si autem furtum excedat valorem centum quinquaginta marauedinatorum, nec excedat valorem quingentorum marauedinatorum, subit pœnam centum flagellorum, & amputantur ei aures. Quòd si furtum excedat valorem quingentorum marauedinatorum, ita tamen vt non excedat valorem quinque milie marauedinatorum, amputatur illi pes, & insuper imponitur ei pœna, vt nunquam equitet, neque mulam ascēdat, sub pœna mortis, sagittis ei inferendæ. Si verò furtum excesserit valorem quinque mille marauedinatorum, eripitur ei vita iactis in eū sagittis. Ita habetur. l. 3. tit. 13. citato. Et quamuis. l. 7. sequenti præscriberetur modus, quo sagittis esset interficiendus; postea tamen. l. 46. sancitum fuit, vt nullus sagittis interficeretur, sed priùs extranguletur, & postea mittantur in eum sagittæ. Qualiter autem in hoc, & in aliis delictis, in quibus punire possunt iudices de la hermandad, procedere possint iudices alii ordinarii, & quousq; sit locus præuentioni iudicum de la hermandad, vide ibidem lege. 10. Haud tamen scio, num eiusmodi pœnæ tanto cum rigore exequutioni mandentur, præsertim imminuto adeò his nostris temporibus valore pecuniæ, vt supra dictum est.

Lex. 7. titu. 11. lib. 8. nouæ collect. sic habet: Mandamos a todas las justicias de nuestros reinos, que los ladrones, que coforme a las leys de nuestros reinos deuen ser condenados en pena de açotes, de aqui adelãte la penasea, que los traygam ala verguença,²³ y que siruã quatro años en nuestras galeras por la primera vez, siendo el tal ladron mayor de veinte años: y por la segunda le den cien açotes, y sirua perpetuaneente en las²⁴ dichas galeras. Y si fuere el hurto en nuestra corte, por la primera vezle seam dados a ciẽ açotes, y sirua ocho años en las dichas nuestras galeras, siedo mayor de la dicha edad, y por la segunda vezle sean dados do zientos açotes, y sirua perpetuamente en las dichas galeras. b Y en los hurtos qualificados, y robos, y salteamientos en cam nos, o en campos, y fuerças, y otros delictos semejantes, o mayores, los delinquentes sean castigados conforme a las leyes de nuestros reinos. c Y mandamos que los ladrones y vagamundos y holgazanes, menores de la dicha edad de veinte años, y las mugeres vagamundas, y ladronas, y los esclauos, de qualquier qualidad que sean los suso dichos, siendo presos por lo suso dicho, no sean echados a las galeras, sino

que sean penados y castigados conforme a las leyes de nuestros reinos. Postea autem extensa fuit lex præcedens, etiam ad rapinas in eremo, & itineribus, & ad alia delicta lege 7. sequenti, in hunc modum: *Mandamos que assi en los hurtos qualificados, y robos y salteamientos, en caminos, o en campo, y fuerças, y otros delictos semejantes, o mayores, como en otros qualesquier delictos de otra qualquier qualidad, no siendo los delictos tan qualificados y graues, que conuenga à la republica no diferer la execucion de la justicia, y en que buenamente pueda auer lugar con mutacion sin auer en ello perjuizio a las partes querellosas, las penas ordinarias los sean commutadas en mandarlos ir à servir en las nuestras galeras por el tiempo que pareciere a las nuestras justicias, segun la qualidad de los delictos.* Postea lege. 9. eiusdem tituli sic sancitum est: *Por quanto en la pragmatica a 25 de Nouiembre del año pasado de 1552, de que en algunas leyes deste titulo se haze mencion, se ordena y manda, que los ladrones, que conforme a las leyes destos reinos auian de ser condenados en pena de açotes por la primera vez, fuessen condenados en quatro años de galeras y verguença publica, siendo el hurto hecho fuera de la corte, y siendo en corte, ocho; mandamos, que los quatro años sean y se entiendan seis, y los dichos ocho diez. Lo qual se entienda y execute, no embargante que los dichos ladrones no ayan la edad de los veinte años, como en la dicha pragmatica se dize, siendo de tal disposicion y qualidad, que puedan servir en las dichas galeras, y auiendo à lo menos diez y siete años. Y como quiera que, conforme a el vsu y estilo que los juezes tienen en estos reinos, en el dicho caso del primer hurto condenan en setenas, y en su defecto en la dicha pena de açotes, ordenamos y queremos, que la dicha condenacion de galeras sea precisa, y no en [[54]] defecto de setenas. Y que otrosi en le dispuesto por la dicha pragmatica, acerca de los dichos ladrones, y lo que en esta se añade y declara, se entienda y estienda a los encubridores y receptores y participes en los hurtos, para que en estos aya lugar la misma pena, y en la misma forma que de suso esta declarado en los ladrones. Vide etiam. l. 4. 6. &. 10. titu. 24. eiusdem lib. 8. quæ de eadem re loquuntur.*

Lege. 4. titu. 23. lib. 8. nouæ collect. eximi [sect. 23] tur à pæna mortis, qui interfecerit a el ladron, que ballare de noche en su casa hurtando, o fora dandola, o si lo ballare con el hurto huiendo, y no se quisiere dar a prision, o si lo ballare hurtando lo suyo, y no lo quisiere dexar.

De iure Lusiano, qui furatur valorem selibræ²⁵ argenti marco de plata nostri appellant) punitur pæna mortis, etiam si furtum sit primum. Ita ha [sect. 24] betur. 5. lib. Lusit. ord. titu. 37. in prin. Vt aumin materia de cambiis dictum est, tempore, quo ea lex condita fuit, ex selibra argenti solùm conficiebantur in eo Regno sex cruciati: hodie verò eucto regali argenteo ad quadraginta reais in eo Regno, plures conficiuntur. Cùm autem valor, quem furtum habere debet, vt puniatur pæna mortis, expressus ea lege sit selibra argenti, non verò sex cruciatis, quos tunc valebat, vtique hodie necesse est quòd furtum ad valorem pertingat, quem selibra argenti nunc habet, vt puniri pæna mortis possit. Præsertim cum valor pecuniæ, ad res alias ea emendas, multum decreuerit. Et cùm pænæ, maximè adeò acerbæ, sint restringendæ. Idem intellige, quotiescunque in ordinationibus Lusitanis mëtio fit selibræ argenti, valorisve illius, aut partis illius, ad pænam infligendam, & quotiescunque pæna nomine selibræ argenti, aut partis illius, exprimitur. Qui infra valorem selibræ argenti, furatur in eo Regno valorem quadringentorum reais, aut vltra, punitur pæna flagellorum con baraco è preguam, & abscissionis aurium. Qui verò infra eum valorem furatur, punitur pæna flagellorum con baraco è preguam, aut alia minori corporali, arbitrio iudicum, attenta quantitate & qualitate furti, & qualitate eius, qui furatus est. Mancipium verò, siue Christianum, siue infidele, quod id fuerit furatum, modò furtum pertingat ad valorem centum reais, punitur pæna flagellorum con baraco è preguam, & abscissionis aurium.

Quando autem furtum mancipii non pertingit ad valorem centum *reis*, punitur sola pœna flagellorum. Quicumque in eo Regno commiserit tria furta, modò singula vt minimum sint valoris quadringentorum *reis*, punitur pœna mortis, esto pro primo, & secundo, furto punitus iam antea fuerit aliis pœnis. *Ita habetur titu. 37. citato. §. 2. & 3.* Nescio tamen, an pœnæ adeò acerbæ, præsertim hodie, quando adeò decreuit in eo Regno valor pecuniæ ad res alias ea comparandas, tanto cum rigore mandentur exequutioni. Eiusque ego essem sententiæ, vt mutarentur, multumque de tanto rigore mitigaretur.

Qui emit in eo Regno rē, quæ verisimiliter, [sect. 25] attenta eius qualitate, ac personæ vendentis, videtur furto ablata, aut non esse eius, qui illam vendit, si postea comperiatur, eam rem furto fuisse ablatam, punitur emptor ac si eam furto abstulisset, neque ei prodest, quòd dicat, à quo illam emerit. *Ita habetur ibidem. §. 4.*

Qui in curia, aut in ciuirate Olyssiponensi, emit aliquid valoris vltra quinquaginta *reis* ab alio, quàm *dos pregoeyros è a de las*, qui ad res vendendas sunt deputati, aut ab artificibus, qui tales res conficiunt, si cõperiat postea id furto fuisse ablatum, soluit rem ita emptam domino, & insuper quadruplum, quòd si quadruplum non pertingat ad duo mille *reis*, soluit duo mille *reis*, dimidium totius pœnæ accusanti, & dimidium pietati, & detinetur in vinculis quindecim dies: neque eum excusat à tota hac pœna, quòd dicat, à quo eam rem emerit. Quòd si secundò in idem crimen inciderit, exulat insuper vno anno in aliquo *dos cautos do reyno*. *Ita habetur ibidem. §. 5.*

Is, cui offertur emenda res furto ablata, potest comprehendere talem venditorem, eūque offerre ministris publicis cum tali re furtiua. Cõpertoque postea, furto fuisse ablatam, soluitur tali, qui ita venditorem cõprehendit, de bonis eius venditoris, quantum ea res æstimabitur. Si verò is soluēdo non sit, soluitur ei de arca pietatis, modò non plus de ea arca ei soluatur, quàm quinque cruciati. *Ita habetur ibidem. §. 6.*

Quando res deuenit ad aliquem legitimo titulo, vt commodati, depositi, tanquam receptori, opifici ad aliquid inde efficiēdum, aut alio legitimo titulo, si is id furetur, aut cum eo fugiat, vel illud vendat, punitur iudicis arbitrio, etiam pœna mortis, si crimen tanta pœna iudicabitur dignū. Præcipitur verò, vt quando tale furtum pertigerit ad valorem decem selibrarum argenti, imponatur pœna mortis, & vt nunquam pœna mortis, pro eo crimine imposita, mandetur exequutioni, quin priùs ea de re factus Rex ipse sit certior. *Ita habetur ibidem. §. 7.* Qui deprehenditur scindens, aut aperiēs marsupium alterius, esto nihil in eo marsupio reperiatur, damnatur pœna flagellorum ac abscissionis aurium. *Ita habetur. l. 1. titu. 3. part. 4. leg. extrauag.*

Quicumque fuerit repertus habere *gazuas*, punitur pœna flagellorum, & exilii duobus annis in insulam diui Thomæ. Si verò fuerit eius qualitatē, qui flagellorum pœna non debeat puniri, exulat tribus annis in eadem insula. In easdem pœnis incidit faber ferrarius, aut quicumque alius, cui probatum fuerit, fecisse ea instrumenta. *Ita habetur ibidem. §. 8.* In easdem pœnas incidunt, qui, post datum signum, vt omnes de nocte se recipiant, repertus fuerit cum instrumentis, de quibus constet, esse ad aperiendas, aut confringendas, arcas, vel portas, aut ad eas extrahendas de cardine. *Ita habetur titu. 37. citato. §. 9.* Ibidem §. 10. subiungitur, vt fures signarentur signo quodam in facie. Ea tamen lex abrogata est. *l. vlt. titu. 1. part. 4. leg. extrauag.*

Qui de nocte à parte exteriori claudit portas aliorum, ipsis non consentientibus, si sit plebeius, punitur pœna flagellorum *con baraco è preguam*: si verò sit maioris notæ, exulat duobus annis

in aliquo ex locis transmarinis. Quòd si simul aliud delictum committant, insuper puniūtur pæna eius delicti. *Ita habetur ibidem. §. ultimo.*

De iure canonico, si clericus furetur, deponē [sect. 26] dus est: modò furtum non sit leue, vt quia modicæ quantitatis, aut quia domesticum, vt bene notat *Panor. c. tuæ de pænis*: nam tunc pæna solūm [[55]] arbitraria puniri debet. Quòd si depositus fuerit incorrigibilis, admonitus, erit excommunicandus & anathematizandus. Atque, vt hæc fiant, comprehendi debet, & in vinculis detineri, dum de causa cognoscitur ac profertur sentētia. Si verò nec sic destiterit, relaxari verbaliter debet seculari potestati, atque ex tunc non gaudet priuilegio fori Ecclesiastici; sed puniri debet per secularē potestatem pænis aliorum furium; attempta tamen qualitate personæ, sicut & in puniendis furibus secularibus qualitas personæ attēditur. *Ita habetur. c. cū non ab homine de iudiciis, ibique, & c. tuæ.* citato, notat *Panor.* vide etiam *Syluestrum* verb. degradatio. De clerico verò rapinam committente mox dicitur.

De iure Cæsareo communi, quando furtum, sine [sect. 27] vi quidem illata personis, cæterum cum effractione fiebat, seræ, portarum, parietis, tecti, aut alterius rei, non imponebatur pæna mortis, aut muti lationis, sed si talis fur cum effractione erat nocturnus, flagellatus, mittebatur in metallum: si verò erat diurnus, flagellatus similiter, damnabatur vt seruiret in opere publico in perpetuum, aut ad tempus, pro criminis, & circumstantiarum, qualitate, vel nobilis relegabatur, vt constat ex. *l. ult. ff. de effractoribus, iuncto. §. ult. legis antecedentis*, & ita affirmant *Greg. Lopez. l. 18. titu. 14. part. 7.* verb. *matar nin cortar miembro, Ant. Gom. 3. tom. var. resol. c. 5. n. 12.* & alii, quos citant. Neque refragatur. *l. 18.* citata: quoniam non statuit pænam mortis effractoribus, seu furantibus ex domibus cum effractione sine violentia illata personis, sed diripientibus ex domibus cum violentia personis illata, siue cum armis, siue sine armis: de qua re statim dicitur.

De iure huius Regni lex. 6. titu. 26. lib. 8. no²⁶uæ collect. Sic habet: *Todo aquel, que fora da casa, [sect. 28] o fiziere lugar por donde hombre entre a hazer maleficio, cae en caso de aleue, y pierde la mitad de sus bienes para la nuestra camara, y el cuerpo à la mi merced.* Item lex. 6. titu. 5. lib. 4. fori sic habet: *Todo ome, que foradare casa, o quebrantare Iglesia, por furtar, muera por ello.* Et hæc lex est, quæ seruatur in praxi quoad hoc in hoc Regno, vt hoc seruari in praxi affirmat *Ant. Gom. n. 12.* citato, etiam si furtum sit paruæ quantitatis, & *Greg. Lopez* glossa citata, relata eadem lege fori, ait se credere seruari eam in praxi: non verò est *lex. 18. titu. 14. par. 7.* quicquid *Ant. Gom. n. 12.* citato in contrarium dicat, cū lex illa. 18. nihil tale statuatur. *Greg. Lopez* glossa citata, & *Montalius in legem. 5. fori*, referunt. *l. 74. styli*, quæ, declarando prædictam legem. 5. fori, eam extendit ad ascendentem per parietem, vel intrantem per fenestram, vel per tectum domus, vel si aperuerit ostium clauē, vel seram arcæ fregerit. Subiungit verò *Greg. Lopez*, se non affirmare, seruari in praxi eam legem styli, remittitque vt ea de re consulantur practici in puniendis delictis. Quòd verò non seruetur in praxi, non leue mihi est argumentum, me non inuenisse eam legem styli in noua legum collectione, etiamsi diligenter eam quæsierim. Et *Ant. Gom. n. 12.* citato in postrema editione, facta solūm mentione *de. l. 18. & de lege. 5. fori*, citatis, non verò de hac lege styli, ait, se defendisse quendam, qui furatus fuerat plus, quàm quinquaginta ducatos, fracta arca, & obtinuisse, ne interficeretur, eo quòd prædicta lex loquatur de fractura domus, eaque de causa non sufficiat fractura arcæ.

De iure verò Lusitano, si quis aperuerit aliquā [sect. 29] portam, aut intrauerit domum, quæ erat clausa, per portam, fenestram, aut tectum, vel aliquo alio modo, & furatus fuerit valorem dimidii selibræ argenti, aut amplius, punitur mortis pæna. Et quamuis nihil furetur

ex tali domo, si tamen aperuerit portam illius, aut intrauerit domum modo explicato, furandi animo, punitur flagellorum pœna *con baraco è preguam*, amputanturque ei aures, & exulat in perpetuum in insulam diui Thomæ, *Ita habetur. 5. lib. ord. titu. 27. §. 1.* De eo verò, qui deprehenditur cum instrumentis ad hæc patrandum, dictum est paulo superiùs, dum de pœnis furibus iure Lusitano statutis est dictum.

Quod ad rapinam, raptosque, attinet, ex rela [sect. 30] tis hac eadem disputatione *ex. l. capitalium. §. grassatores, & §. famosos. ff. de pœnis*, iunctis authentica sed nouo iure. *C. de seruis fugit. & authentico vt nulli iudicum. §. penult. liquet*, de iure communi, si, vt rapiant, aliquem interficiant, puniendos esse pœna mortis, ibique esse suspendendos, si commodè fieri possit, vbi homicidium ob rapinam patrarunt, vt ex. §. famosos relato, cõstat. Debere etiam eos puniri pœna mortis, patet etiã ex dictis Disp. 682. vbi ostensum est, quando vis iniusta infertur, & aliquis interficitur, etiam ex parte eius, qui eam vim intulit, autorem talis vis puniri pœna mortis: multo verò magis id locum habebit, quando aliquis interficit alterum, vt illum bonis suis iniustè spoliaret, qui solus latro illis iuribus nuncupatur, vt suprà expendimus. Ex. §. grassatores, etiam est perspicuum, de iure communi tunc solùm grassatorem ad prædam, qui neminem interficit, esse morte plectendum, quando cum ferro prædari aggreditur, non semel, sed sepius, hoc est, saltem bis, & in itineribus. Si enim, vel sine armis prædetur semel tantùm, aut pluries cum armis prædetur, cæterùm non in itineribus, sed vel in domo, aut villa aliqua, vel deprehensos aliquos in deserto, non punitur pœna mortis, sed vel mittitur in metallum, vel relegatur in insulam aliquam, vt habetur. §. citato. Atque hæc similiter habent locum in grassatoribus mari, qui piratæ, aut cursarii, dicuntur, quod si interficiant, puniuntur morte, si verò non interficiant, sed aggrediantur pluries, vt bis, interficiuntur similiter, quia aggrediuntur agentes iter mari, vbi non sunt alia itinera, neque aliæ semitæ. Si verò semel tantùm aggrediantur, non interficiuntur de iure communi, consentiunt duo authentica citata, & doctores, quos referunt ac sequuntur *Ant. Gom. 3. tom. var. res. c. 5. n. 10. & Greg. Lopez. l. 18. titu. 14. part. 7. verb. tuuiesse caminos*, & verb. *en la mar*. Itaque de iure cõmuni raptor bonorum alienorum, extra duos euētus cõmemoratos, non puniebatur pœna mortis: sed vno è duobus modis agi poterat aduersus eum, quem potiùs eligere vellet offensus. In primis agere poterat ciuilitè, exigendo, vltra rē raptam, aut æstimationem illius, & fructus ex ea perceptos, & qui percipi potuerunt, ac damna omnia subsequuta, ad quæ omnia tenetur raptor ex iustitia, etiam in foro conscientiæ, nulla expectata sententia: exigendo, inquam, vltra hæc omnia, triplū eius, quod valebat res rapta, idque in pœnam delicti sibi applicandam, aut exigendo quadruplum, includendo in eo rem ipsam raptam, ita [[56]] vt solum triplum haberet rationem pœnæ. Porro hæc actio ciuilis solùm competeat læso, vno integro anno à puncto commissi delicti; vt tamen, hoc est, non computando in partes illius dies, in quibus non potuit agere, vel quia impeditus, vel aliqua alia ratione, vt quia non erant dies audientiæ, addendoque totidem alios dies vtiles usque ad complementum integri anni. Extra eum verò annum vtilem, folū poterat agere ad simplum, hoc est, ad rem ipsam raptam, aut ad æstimationem illius, & ad fructus ac damna subsequuta: quoniam sola pœna præscribatur eo anno integro elapso. Quando autem rapina fuit facta in absentia eorum, qui possent resistere, vt quia aggressus est aliquis rapere animo vim inferendi, si quem reperisset, qui posset resistere, tunc, si læsus egisset ad duplum actione furti occulti, posset iterum agere ad incrementum solum actione bonorum raptorum, vt integra pœna tripli malefactori imponeretur. *Hæc habentur. l. 1. & 2. ff. de vi bonor. rapt. inst. eod. titu. in prin. l. 2. & tribus sequent. C. eod. titu. & l. 3. titu. 13. part. 7.* Deinde læsus

poterat agere criminaliter, *vt habetur. l. 3. citata*, & aliis iuribus, ad pœnam legis Iuliæ de vi publica, aut de vi priuata, prout fuerit vis, quæ in rapina interuenerit, publica videlicet, aut priuata: quæ autem sint pœnæ, ad quas agitur hac actione, Disp. 682 est copiosè explicatum: & in illis, quando vis est publica, hoc est, cum armis, includuntur pœnæ deputationis ad metalla, aut deportationis, vt Disp. 682 citata dictum est, de quibus est sermo §. grassatores citato, quãdo grassatores ferro aggrediuntur, neque illis est imponenda pœna mortis. Vt verò obseruat Greg. Lopez. *l. 18. citata. verb. en la mar*, cum aliis, quos citat. hodie non est in vsu pœna ad metalla, aut deportationis, eaque de causa imponenda est loco illius pœna arbitraria, refertque, quendam dixisse, esse imponendam pœnam abscissionis manuum propter delicti immanitatem. Porro hæc actio criminalis, ad pœnam legis Iuliæ de vi publica, aut priuata, non impedit, quòd merè ciuilitèr agatur etiam ad rem raptam, aut ad æstimationem illius, & ad fructus ex ea perceptos, & qui percipi poterant, atque ad reliqua damna, si quæ inde sint sequuta, vt Disp. 682 citata dictum est: neque enim ex his duabus actionibus vna impedit aliam, vt suprâ in hac Disputatione est ostensum. Quo loco obserua, etiam in criminibus, in quibus vera vis non interuenit, sed priuilegium habent, vt in eis agatur etiam de vi publica, aut priuata, vt sunt furtum ex incendio, & alia Disput. 682. commemorata, posse agi cisdem modis: eo quòd sint rapinæ iuris priuilegio, vt Disp. 683 est dictum.

Quod ad hoc Castellæ Regnum attinet. In²⁷ primis. lex. 18. citata sic habet: *Por razon de furto [sect. 31] no deue de matar ni cortar miembro ninguno. Fueras ende. si fuesse ladron conocido, que manifestamente tuuiesse caminos, o que robasse otros en la mar con nauios armados, a quien dizen cursarios, o si fuessen ladrones que ouiessen entrado por fuerça en las casas, o en los lugares, de otros para robar con armas, o sin armas.* Vbi vides, in his euentibus statui pœnam mortis. Greg. Lopez ibidem in duobus prioribus euentibus intelligit hac legem consentancè ad ius commune, vt scilicet nō sufficiat vna rapina in itineribus, aut in mari, quando non interuenit mors, vt grassator terra, aut mari, interficiatur, sed necessarium sit pluries, saltem bis, id fecisse, aggressumve fuisse iē facere: id quod satis significant verba illa, *si fuesse ladron conocido, que manifestamente tuuiesse caminos*: qui enim semel tantum in itinere rapinam commisisset, non diceretur *ser ladron conocido, que manifestamente tuuiesse caminos*. Idem significant verba illa; *que robasse a otros en la mar con nauios armados, a quien dizen cursarios*: qui enim semel tantum prædam fecisset in mari, non diceretur *cursario, ni robar a otros con nauios armados*, præsertim cū repetendum videatur verbum *manifestamente*. Greg. Lopez idem censet dicendum in tertio euentu, *de los ladrones que entran por fuerça en las casas, o en los lugares, de otros para robar con armas, o sin ellas*, nempe non sufficere semel tantum, id fecisse, aut attentasse, si mors non interueniat, sed necessarium esse pluries, saltem bis, id fecisse, vt mortis pœna puniantur. Ducitur, quoniam hoc crimen non est grauius, sed leuius, quā grassatorum in itineribus, aut in mari; præsertim cū in domibus soleat esse maior defensio à vicinis, quā in itineribus, aut in mari: neque sit verisimile, quòd in vno & eodem contextu grauior pœna imponatur pro minùs graui, & minùs pernicioso delicto, quā pro grauiori, magisq; pernicioso. Ant. verò. Gom. 3. tom. var. res. c. 5. n. 10. de solis duobus prioribus euentibus loquens, licet non improbabilem arbitretur opinionem, quam Greg. Lopez amplectitur, ait tamen, in consulendo, & iudicando, dicendum esse, iuxta eam legem, satis esse vnum actum grassatoris terra aut mari, vt, esto mors non interueniat, grassator morte plectatur. Ego verò ex sola ea lege id non existimo verum: quoniam lex ipsa in illis duobus prioribus euentibus satis innuit opinionem, quam Greg. Lopez amplectitur, quæ consentanea est iuri cōmuni, eaque ratione amplectenda: præsertim

cùm leges partitarum recedere non soleant à dispositionibus iuris communis, correctioque iuris communis, quantum fieri possit, sit vitanda. Quoad posteriorem verò euētum, cùm de iure communi, neque pro vno neque pro pluribus actibus, sit statuta pœna mortis, sed solùm pœna legis Iuliæ de vi publica, aut de vi priuata, prout fuerit vis, quæ in eo euentu interuenerit, neque authentica citata statuatur, vt in eo euentu alia pœna imponatur, quam pœna antiquioribus legibus iuris communis statuta, lexque ea partitarum apertè in eo euentu à iure communi discedat, statuens in eo euentu pœnam mortis, neque innuat necessarios ad id esse plures actus, sed potiùs apertè sonet, sufficere vnum, sanè non auderem dicere, in eo euentu necessarios esse plures actus, vt tales raptores pœna mortis afficiantur, neque credo id habere consuetudinem.

Lex 1. tit. 12. lib. 8. nouæ collect. sic habet: Defendemos, que persona alguna no sea osado de hazer en los caminos fuerças, ni robos, y qualquiera que las hiziere, aliende de las penas que deue proceder por derecho, cayga y ineurra en pena de seis mil marauedis para la nuestra camara. Pœnæ autem potentibus, qui cum suis roban o toman, statutæ habentur ibidem. l. 2. & sequentibus. Lex verò 6. titu. 23. eiusdem lib. 8. sic habet: Elque matare, o hiriere, à otro rabandole en el camino, allende de la pena corporal, que deue padescer, que pierda la mitad de sus bienes para la nuestra camara. Y si robar en el camino de cien [[57]] marauedis arriba, aunque no mate, ni hiera, pierda la mitad de los bienes, y la mitad dellos sea para el robado, y la otra mitad para la camara.

Quæ suprà. §. ministri de la hermandad, dicta sunt de furtis factis in eremo, & quando censeatur facta in eremo, & quibus pœnis sint punienda, & quando pœna mortis, & quali, & quousque cognitio de illis, & punitio, spectet ad iudices de la hermandad, similiter, & præcipuè, habent locū in rapinis similiter factis, de quibus præcipuè leges ibi citatæ loquuntur, ideoque necesse non erit illas circa rapinas repetere. Item circa rapinas locum etiam habent, quæ ibi subiuncta sunt de cōmutatione in pœnam remigandi in triremibus, nisi delictum sit tale, vt expediatur continuò pœna legibus statuta, minimeque in aliam commutata, ea puniri, vt ibidem subiunctum est.

Lex 1. titu. 19. lib. 5. nouæ collect. Sic habet: Por [sect. 32] que algunos cambiadores, y mercaderes, reciben mercadurias fiadas para pagar à cierto termino, y los cambiadores reciben moneda de otros para la tener en su cambio, y despues se ausentan con caudales agenos, y van à lugares de señorio y à fortalezas, ofuera de nuestros reinos, lo qual es cosafea y dañosa, por ende ordenamos y mandamos, que el cambiador, o mercader, que tal cosa hiziere, sea tenido dende en adelante por robador publico, è incurra por ello en las penas, en que caen è incurren los robadores publicos, y se haga processo criminal en su ausencia, como contra publico robador Y defendemos, que ningun alcalde, ni otro que tenga fortaleza, ni otra persona alguna, ni las nuestras justicias, no sean osados à receptar à el cambiador, o mercader, y que lo entreguen à la justicia, que en este caso deuiere conocer, cada y quando que fuere requerido, so pena que el tal receptor, o el que lo denegare de entregar, sea tenido y obligado à la tal pena, que el dicho cambiador o mercader, que buyo con lo ageno, pagara, si fuese entregado, y sea tenido de pagar lo que el tal cambiador, o mercader, deue. Y tenemos por bien, que en esta misma pena incurra el, que de aqui adelante fuere requerido con esta nuestra ley, el que receptare, o defendiere, y no entregare, à el questa alçado con lo ageno, desde antes questa ley se hiziese. Hinc patet, crimen, de quo in hac lege est sermo, priuilegio eiusdem legis sortiri rationem rapinæ.

Et lex. 2. sequens sic habet: *Ningun mercader, ni cambiador, ni sus factores, se alcen con mercadurias, ni dineros, ni otra hazienda alguna agena, so læs penas contenidas en la ley por nos*

hecha en las cortes de Toledo (hoc est, lege præcedente) y en las otras leyes de nuestros reinos, que acerca desto disponen. Y nos por la presente declaramos, los que ansi se alçaren, ser publicos ladrones y verdaderos robadores. Y queremos que en caso, que las penas criminales en ellos no sean executadas, que el mercader, o cambiador, o su fator, que assi se alçare, dende en adelante no pueda tener, ni usar, ni tenga, ni use, officio de mercader, ni de cambiador, ni de fator, ca nos por la presente por el mismo hecho, sin otra sentencia ni declaracion alguna, los inhabilitamos de los dichos officios para toda su vida, y les mandamos que no usen dellos, so las penas, en que caen è incurren las personas priuadas, que usan de officios publicos sin tener poder ni facultad para ello, y so pena de perdimiento de todos sus bienes, que tuuieren, para la nuestra samara y fisce. Y otrosi mandamos, que qualquier iguala, y conueniencia, o transaction, o remission, que sea hecha despues de assi alçados, con los dichos sus acreedores, o con otra qualquier persona en perjuizio de los dichos sus acreedores, con qualesquier clausulas y vinculos y cautelas, de qualquier manera que sean, que no valgan, y sin embargo de todo ello, sea hecho cumplimiento de justicia à las partes conforme à lo en esta nuestra pragmatica contenido. Y las nuestras justicias, cada y quando que se alçaren qualesquier cambiadores, o mercaderes, o sus fatores, con alguna hazienda agena, bagan processo contra ellos, y contra cada vno dellos, y contra sus bienes, conforme à las dichas leyes y à lo de suso contenido, y executen en ellos, y en sus bienes, las penas en ellas contenidas. Y si algunos bienes suyos hallaren, que estan receptados en algunas yglesias, o monasterios, o hospitales, o fortalezas, o en otras qualesquier partes y lugares, los saquen dellas, para que de alli se paguen los acreedores, de lo que les fuere deuido. Y mandamos à qualesquier personas, en cuyo poder estuuieren qualesquier deudas, o mercaduria, o mercadurias, o otros qualesquier bienes de los que assi se alçaren, o supieren quien los tiene, no paguen las dichas deudas à las personas, que assi se viueren alçado como dicho es, ni les acudan con los dichos bienes, ni con parte de ellos, y dentro de treinta dias, despues que en qualquier manera viniere à su noticia, que el tal mercader, o cambiador, o fator, sea alçado, venga à manifestar lo que tiene suyo, y les deue, ante las nuestras justicias, para que dellos puedan pagar, y paguen, los dichos acreedores conforme à derecho, so pena, que lo que les pagare, se aya por no pagado, y lo torne à pagar otra vez, y pierda otra tanto de sus bienes, como encubriere, o no descubriere, sabiendo quien lo tiene, para la nuestra camara y fisco, y otro tanto para pagar los acreedores del que assi estuuire alçado.

Et l. 3. sequenti subiungitur: Mandamos, que las leyes, que hablan contra los que se alçan, ayan lugar y se executen en las personas de aquellos, que alçaren sus bienes, aunque sus personas no se ausenten, prouando sus acreedores que las tales personas alçaron, y escondieron los bienes, que tenían.

Et l. 4 sequenti additur: Mandamos que de aqui adelante ningun mercader, que se alçare, no pueda gozar, ni goze, del priuilegio de la hidalguia, para excusarse de la pena del dicho delito, ni para otro caso, ni cosa alguna. Y lo mismo mandamos, que se guarde y cumpla contra los recaudadores y mayordomos de concejos, y de qualesquier personas, que se alçaren.

Et l. 5. additur: Otrosi por quanto algunos de los mercaderes, y cambiadores, puesto que no alcen sus personas y bienes, pero dicen que quiebran en sus contrataciones y negocios, de lo qual, siendo por su culpa y dolo o malicia, resulta daño à la república, mandamos, que en quanto à los que assi quiebran y no cumplen por falta de bienes, que se haga justicia conforme à derecho y à leyes destos reynos, y la qualidad de los negocios.

De iure Lusitano, lib. 5. ord. titu. 38. erat san²⁸ citum, vt qui vi, ac contra alterius voluntatem, [sect. 33] auferret aliquid ab eo, penes quem erat, si res ita vi accepta esset valoris mille reais, aut vltra, accipiens interficeretur. Si verò non attingeret valorem mille reais, subiret pœnas,

quæ suprâ rela-[[58]]tæ sunt, statutas in eo Regno esse furantibus eam quantitatem. Quæ autem dicta sunt, locum habent, etiam si is, qui rem ita vi accepit, dicat, se obtulisse pretium rei ita acceptæ ei, penes quem ea res erat, & à quo vi illam accepit, aut illi reliquisse pretium illius. Si tamen res vi acceptæ ad victum attinebant, & qui illas accepit erat *caualeiro*, aut altioris notæ, tunc pro prima vice soluebat illud in triplo, pro secunda in sexcuplo, & pro tertia nouies, indeque soluebatur ei, qui eam rapinam erat passus, pretium rei, totumque lucrum cessans, ac damnum emergens, & reliquum erat in redemptionem captiuorum. *Ita habetur titu. 38. citato, iuncto titu. 36. lib. 2.* Quo in loco lege pænas statutas, tum dominis temporalibus, qui à sibi subditis inuitis, tum etiam quibus scunq; aliis, qui à quocunque inuito, sine auctoritate iudicis, accipiunt cibos, iumenta, aut plaustra, nihil impediens, quod pretium iustum offerant. *Postea verò lege. 2. titu. 3. part. 4. leg. extrauag.* statuit Emmanuel Rex, ut quicumque in via, vel in agro, aut in loco deserto, raperet quicquam ab alio, si res rapta excederet valorem centum *reais*, morte puniretur. Si verò non excederet eum valorem, flagellaretur, ac mitteretur in perpetuum exilium in insulam diui Thomæ.

De iure canonico, si clericus latrocinium (hoc [sect. 34] est, furtum cum violentia, ut bene exponit Panor. c. tuæ de pænis) committat, ut si sit grassator, simul est deponendus, seu (quod idem est) degradandus verbaliter, & detrudendus in monasterium ad perpetuam in eo penitentiam agendam. Quando autem esset incorrigibilis, relinquendus esset brachio seculari, atque ex tunc non gauderet privilegio fori, sed puniri per secularem potestatem posset ac si esset laicus. Hæc constant ex c. tuæ de pænis, iuncto. c. cum non ab homine de iudiciis. *Lege Panor. utrobique, & Syluest. verb. degradatio.* Hæc de pænis rapinæ statutas.

Quod attinet ad pænas pro furto, in quo sa [sect. 35] sacrilegium interuenit, in principio disputationis præcedentis, agendo de spiritali pæna pro eo delicto, explanauimus, quis dicatur locus sacer, ut furtum in eo commissum sacrilegium censeatur. In foro seculari de iure Cæsareo communi, qui furatur rem sacram de loco sacro, punitur pæna mortis, *ut constat ex. l. sacrilegii. & ex. l. sacrilegi. ff. ad leg. Iul. peculat.* Aliquando tamen, attenta qualitate personæ, quoad ætatem, & alias circumstantias, & attenta quantitate & qualitate furti, mitior pæna iniungebatur, ut deportationis, exilii, aut alia iudicis arbitrio, ut patet lege sacrilegii citata.

Lex tamen sacrilegii citata, pæna mortis punire videtur furtum, etiam rei non sacræ Deo donatæ, si de nocte fiat cum templi effractione: secus verò si de die aliquid tale ex templo furto sit ablatum.

In hoc verò Regno *lex. 18. titu. 14. part. 7.* indistinctè statuit pænam mortis furanti rem sacram de loco sacro. Commemorando enim fures, qui mortis pæna puniuntur, ait, *o ladron que furtasse de la Iglesia, o de otro lugar religioso, alguna cosa sancta o sagrada.* Et *Ant. Gom. 3. tom. var. res c. 5. n. 11.* ait, ita indistinctè eam legem in hoc Regno practicari. Greg. tamen Lopez ibidem verb. *alguna cosa sancta o sagrada*, censet ex circumstantiis minui eam pænam, iuxta dispositionem iuris communis. Ac certè id videtur consentaneum rationi ac æquitati. Ea enim verba exceptio sunt ab illa regula, quod pro furto imponi non debeat pæna mortis aut mutilationis, excipitque ea lex illis verbis sacrilegium rei sacræ de loco sacro, prout etiam de iure communi est exceptum: relinquit verò id moderandum iuxta moderationem ac dispositionem iuris communis: durum quippe videtur, ut pro furto mapparum sacrarum, quæ corporales dicuntur, si modici valoris sint quoad materiam, & furtum non sit ad rem profanam, sed ut inseruiant in alia Ecclesia, aut sacello, imponatur pæna mortis, maximè si, qui ad eum vsum eas mappas est furatus, puer, simplex, aut nobilis sit. Nomine autem

rei sacræ hoc loco intelligitur absque controuersia, quæ est cōsecrata, aut benedicta, vt sunt calices, ara, mappæ quas *corporales* vocamus, vestes quibus fit sacrum, & similia. Vasa autem, quibus vinum, & aqua, in calicem infunditur, ornamenta serica altaris, quæ *frontales* dicuntur, linteus pannus, quo tegitur & ornatur altare, & his similia, quæ benedicta non sunt, non dicuntur res sacræ, licèt ministerio altaris deseruiant, & licèt furtum earum rerum grauius sit puniendum, quàm furtum rerum merè profanarum. Imò est verum crimen peculatus furtum rerum Ecclesiæ, etiam si cultui diuino non inseruiant, neque sint ad id deputatæ, neque tale furtum in loco sacro committatur, furesque talium rerum pænis criminis peculatus puniuntur, vt Disp. 684 dictum est, dum de crimine peculatus erat nobis sermo. De eiusmodi verò pænis statim erit sermo. De cruce, quæ Christum in ea affixum repræsentat, & de reliquis imaginibus, quæ ea, quorum sunt typi, repræsentant, eaque ratione verè res sanctæ dicuntur, & comprehendi videntur illis verbis legis. 18. relatis, quæ disiunctiua sunt, *alguna cosa sancta o sagrada*, est maius dubium, num, saltem quando materia est magni valoris, vt si sit crux argentea non exigui valoris, suspendi fur propter furtum illius debeat. Ant. Gomez vbi suprà ait, cùm Salmanticæ eiusmodi furtum fuisset factum, furque esset comprehensus, multum ea de re fuisse dubitatum, & tandem iudicatum fuisse, id furtum non esse rei sacræ, nec furem damnandum esse pæna mortis. Certè propenderem, etiam eiusmodi res in ea lege comprehendi: legem tamen intelligendam esse, vt pro furto de re sacra, aut sancta, imponatur pæna mortis, attento valore, & attento modo rei sacræ, attentisque reliquis circumstantiis concurrentibus: vnde pro furto crucis magni valoris de loco sacro satis probabile existimo, imponi in hoc Regno posse mortis pænam.

De sure verò Lusitano *lib. 5. ord. titu. 33. in prin. [sect. 37]* non solùm, qui furatur rem sacram de loco sacro, sed etiam, qui furatur rē sacram de loco non sacro, punitur pæna mortis. Quin etiam, qui furatur partē aliquam *de pedra dara*, aut ma parum, quas *corporales* appellamus, punitur mortis pæna; quod crimen comittere solent mulieres ad veneficia conficienda. In his tamen euentibus præcipitur, vt mortis pæna non priùs exequutioni mandetur, quàm Rex certior ea de re fiat, vt videat, num ex circumstantiis mitior pæna sit imponenda. Item de eodem Lusitano iure *li. 5. ord. tit. 37. §. 4.* qui furatur argentum, aut aurum, Ecclesiæ, vel mona-[[59]]sterii, si furtum id committat in Ecclesia, aut in monasterio, vel in domo aliqua, quæ sit intra cæmeterium Ecclesiæ, aut intrà monasterium, punitur mortis pæna. Eademque pæna afficitur, qui furatur scripturam aliquam de cartorio Ecclesiæ, aut monasterii. Attamen in his etiam euentibus præcipitur, vt pæna mortis non priùs exequutioni mandetur, quàm Rex certior ea de re fiat.

Quando autem furtum fieret in Ecclesia cum effractione, apertione serarum, aut extractione valuarum de cardine, aut alia simili ratione, etiā si res inde furto ablata nec sacra, nec sancta, modis explicatis, esset, ex dictis suprà circa furtum cum effractione, aut perforatione, videndum est, vtrùm in hoc & in Lusitanię Regnis pæna mortis incurratur.

De furto, quod peculatus dicitur, & de crimi [sect. 38] ne illi affini, legis videlicet Iulię de residuis. Disp. 684. est dictum. Quòd verò ad pænas attinet. Si iudex, perseuerante officio suo, incideret in crimen peculatus, vsurpando sibi pecuniam, aut alia bona principis, communitatis, aut Ecclesiarum, punitur pæna mortis. *Ita habetur expresse. §. item lex Iulia peculatus inst. de publ. iudic. l. vnica. C. de crimine pecul. §. l. 18. titu. 14. part. 7.* Vnde meritò rejicitur glossa. l. vnica citata, quæ, textum destruendo, exponit, *capitali animaduersioni subijci iubemus*, id est, deportationi. Etenim. §. item lex Iulia peculatus, apertè ponit discrimen inter iudicis peculatum, & alios peculatus, quòd iudicis peculatus capitali animaduersione

puniatur, alii verò puniantur deportationis pœna. Lex. 18. citata eandem pœnam mortis extendit ad ministros Regis, quorum curæ sunt bona Regis, & aliquid inde surripiunt, aut Regi denegant: sic enim lex illa habet: *O official del Rey que tuuiesse del algun thesoro en guarda, o que ouiesse de recadar sus pechos, o sus derechos, è le furtare, o le encubriere dellos à sabiendas, o el juzgador que furtasse los marauedis del Rey, o de algun concejo, mientras estuuire en el officio. Qualquier destos sobredichos, à quien fuere probado, quæ fizo furto en alguna destas maneras, deue morir por ende el, y quantos dieren aiuda.*

Illi, quos thesoreros, aut almoxarises, vel receptores, in hoc Regno & in Lusitania vocant, cùm ea, quæ Regis recipiunt, suo periculo accipiant, illorumq; dominium comparent, nec teneantur eadē numero soluere Regi, aut aliis de Regis mandato, sed solūm equalē valorem, sanè ex eo, quòd illis negotientur, & illa insumant, dum modò nō intendant aliquid celare, sibiue vsurpare, neque ita insumant, vt reddantur impotentes ad soluendū Regi, nullum crimen, ac pœnam, incurrunt. Imò, cùm Regi fide iussores optimos tribuant, qui, in talium ministrorum defectum, Regi totum soluant, quòd ei debetur, vtique, esto prodigè insumant, ac reddantur impotentes ad soluendum, non cēsantur incurrere crimen peculatus, aut legis Iuliæ de residuis; nisi aliquid celent ac sibi vsurpent; in quo euentu crimen peculatus, & pœnam pro illo ipsis statutam, incurrunt, vt dictum est; vel nisi, occupando pecuniam Regis in suis propriis negotiationibus, aut in suos sumptus, tempore congruo, ac iuxta præscriptum Regis, eam non soluant, aut non insumant in rebus, in quibus erat insumenda; in quo euentu incurrunt crimen legis Iuliæ de residuis, vt Disp. 684. dictum est, & in pœnam pro eo crimine statutam, de qua statim erit sermo. Quo fit, vt in eiusmodi ministris locum non habeant. l. 1. §. 2. C. de iis qui ex publicis rationib. lib. 10. quæ solūm loquuntur in sequenti euentu. Quando verò eiusmodi ministri, pressè sunt depositarii bonorum Regis, quæ recipiunt & apud se habent, ita quòd dominium eorum bonorum permanet Regis, neque in ipsos transit, vnde si absque ipsorum culpa, de qua iuxta contractum cum Rege teneantur, pereant, non ipsis pereunt, sed Regi, sanè, si quis ex illis acciperet ex ea pecunia mutuo absque Regis facultate, esto fideiussores optimos cautionemq; optimam præstaret, incideret in pœnam amissionis omnium suorum bonorum ac deportationis, iuxta. l. 2. C. de his qui ex publ. ration. lib. 10. cùm tamen antea, iuxta. l. 1. eusdem tituli, solūm incideret in pœnam quadrupli. Nisi dicas, legem secundam loqui, quando mutuo acciperetur pecunia aurea; & primam legem loqui, quando mutuo acciperetur quæcunq; alia pecunia: quod non videtur verum, sed potiùs vi detur secunda lege auctam illo modo fuisse pœnam, antiquatamq; fuisse pœnam legis primæ. Qui verò pecuniam illam mutuo daret absque Regis facultate, mortis pœnam incurreret iuxta eandem. l. 2. Atque iuxta hanc nostram doctrinam accipienda collimandaq; sunt, quæ Greg. Lop. cum aliis, quos citat, tradit. l. 18. citata verb. *mientras estuuire en el officio*. Nescio tamen an rigor earum legum sit hodie in vsu.

Crimen peculatus præscribitur quinquennio à commisso delicto, ita vt deinceps non admittatur actio de eo delicto. l. peculatus. ff. ad leg. Iul. pecul. Lex tamē. 18. citata id in criminibus peculatus explicatis, pro quibus mortis pœna imponitur, restringit, vt, elapso quinquēnio, imponi nō possit mortis pœna, agi tamen possit aduersus eosdem ministros publicos ad pœnam quadrupli eius quantitatis, quam eo crimine furati sunt. Non tamen video id locum habere stando in solo iure cūmuni.

Accusatio item de crimine peculatus, & de crimine legis Iuliæ de residuis, intentari primò potest aduersus hæredes delinquentis, illo iam defuncto. Ita habetur. l. ult. ff. ad leg. Iul. pecul.

Intellige, quoad rem furto ablatam, ac damna subsequuta, & quoad pœnas pecuniarias, quæ omnia solui possunt ex bonis delinquentis, non verò quoad pœnas corporales.

In reliquis eūctibus crimen peculatus de iure communi non punitur mortis pœna, sed deportationis, cum qua coniunctum quondam erat, vt amitteret omnia sua bona fisco, aut, si nobilis erat, puniebatur pœna exilii perpetui in aliquam insulam, *vt habetur. l. peculatus pœna, iuncta. l. sacrilegii. §. si quis ex metallis, & l. hac lege. ff. ad leg. Iul. pecul. §. item lex Iulia pecul. inst. de publ. iud.* Lex sacrilegii citata in fine ait, eum, qui ex metallis Regis furatur aurum, aut argentum, immiscendo aliud vilius, quando cuditur moneta, loco eius, quod furatur, condemnandum esse pœna quadrupli. Et eandem pœnam quadrupli imponit. *l. penul. ff. eod. titu.* ei, qui ex præda capta à militibus ex hostibus, quæ ad Regem, vel tota, vel quoad partem, pertinet, aliquid furatur. Atque in his duobus euentibus non video, de illo iure communi, locum simul habere pœnam deportationis: nam qui tunc deportabatur, **[[60]]** omnia sua bona fisco amittebat, vt habetur. *l. peculatus pœna, citata.*

Lex verò. 15. titu. 14. part. 7. statuit, vt, qui mo²⁹do explicato metallum Regis furatur, quando cuditur moneta, vel eum defraudat emolumentum [sect. 39] to, quod ex moneta, quæ cuditur ipsius, ei prouenit, cudendo simul aliam similem, atque æquè bonam, monetam, ex suo proprio metallo, aut ex metallo alterius, cui proueniat id lucrum, & non Regi, puniri simus pœna quadrupli eius, quod ita furatur, aut quo ita defraudat Regem, & simul pœna deportationis, si sit minister cudendæ monetæ, aut perpetui exilii in aliquam insulam, si sit aliquis alius: redditque lex rationem, quia, cum furto, falsarii crimen incurrit. Hodie verò in hoc Regno cuicumque est permissum cudere monetam in domibus publicis ad id deputatis, soluendo Regi suum tributum, quod post leges citandas est impositum, vt in materia de cambiis dictum est. Ad æreā verò monetam cudendam necessaria est hodie facultas Regis. Qui autem monetam cudit extra domus publicas ad id deputatas, esto moneta legitima sit, pœna mortis punitur, & amittit dimidiū omnium suorum bonorum, diuidendum in tres partes, quarum vna pertinet ad accusantem, altera ad iudicem, & tertia ad fiscum. *Ita habetur. l. 11. titu. 21. lib. 5. nouæ collect.* Qualiter autem metallum sit tradendum, vt in monetas in domibus monetarum redigatur, neque aliud possit admisceri, etiam legitimum, quod cudatur, habetur ibidem. *l. 13. sub pœna mortis thesaurario eius domus, & cuicumque alteri, qui illud cudendum dederit, & insuper sub pœna amissionis totius metalli, quod ita cudendum dederit, diuidendum similiter in tres partes, inter accusantem, iudicem, ac fiscum.* Item opifices, seu ministri, cudendarum monetarum, qui comperti fuerint aliud cudere, aut aliud habere metallum ad cudendas monetas, puniuntur mortis pœna, ibidem. *l. 17.* Item iidē ministri cudere non possunt monetam, nisi ab ortu solis vsque ad occasum, quòd si antea, vel post, aliquid cuderint, morte plectuntur, ibidem. *l. 18.* Lege alia, quæ iidem ministri similiter ad eandem cautelam ibidem præcipiuntur seruare sub pœna mortis, & aliqua insuper sub pœna pecuniaria amissionis partis, aut omnium, bonorum. *l. 19. 20. 21. 23. 24. 26. 28. 32. & 35.* Videas etiam legem 60. & cæteras eius tituli, atque leges additionis ad eundem titulum. Lege 67 pœna mortis, & amissionis omnium suorum bonorum, statuitur iis, qui monetas cussas circuncidunt, aut destruunt, redigendo illas in metallum, aut eas extrahunt è Regno. De iure Lusitano *lib. 2. ord. titu. 28.* crimen pe³⁰culatus ministrorum Regis, qui aliquid de bonis illius furantur, sequenti modo punitur: *Qual [sect. 40] quer noſſo official, ou outra pessoa, que algua cousa por nos ouuer de receber, guardar, ou despender, ou noſſas rendas arrendar, ou por qualquer outra maneira administrar, se algua das ditas cousas furtar ou maliciosamente leuar, ou leixar furtar, ou leuar a outrem, perca o dito officio, e outra qualquer cousa, que denos*

teuer, & paguenos o preço, ou valia, da quello que aſſi for furtado, ou leuado, anoueado, & aalem deſto, auera pena de ladram, ſegundo a qualidade da couſa for, & por noſſas ordenações he ordenada. Las ditas penas aueram iſſo meſmo lugar em quaesquer officiaes noſſos de qualquer officio que ſeja, que derem aiuda, ou concelho, ou fauor, a os officiaes contheudos nesta ordenaçam, pera cada hun das ditas couſas fazer.

Qui inciderunt in crimen legis Iuliæ de resi [sect. 41] duis, ſolùm puniuntur pænna ſolutionis fiſco Regis tertix partis valoris pecuniæ, aut aliarum rerum, in quibus ita deliquerunt. Soluunt tamen ſimul, non in pænna, ſed tanquam rem ex natura rei, atque in conſcientiæ foro debitam, res, in quibus deliquerunt, Regi, aut iis, quibus ex præſcripto Regis erant ſoluendæ, & inſuper omnia damna ex tali delicto eis ſubſequuta. *Ita habetur. l. 4. §. ſed & qui pecuniam. ff. ad leg. Iul. pecul. & l. 14 titu. 14. part. 7.*

Furtum, quod abigeatus dicitur, quid ſit, & quæ [sect. 42] pænæ de iure communi, & de iure huius Regni, ſint pro eo ſtatutæ, Diſp. 684. eſt dictum, & qua occaſione fuerit de pænis pro hoc crimine diſſerendū.

Ibidem etiam dictum eſt de crimine plagii. Et quia non ſolùm comprehēdit furtum mancipiorum, ſed etiam flagitia alia, quæ furta non ſunt: ideo de pænis pro hoc crimine dictum ibi eſt, & de aliis, quæ cum hoc crimine erant coniuncta.

Quòd ad eos attinet, qui furti concauſæ ſunt, [sect. 43] dicendum eſt. Aduerſus illos agi poſſe de furto. In primis conſtatione furtiua ad omnia damna, tam furti in ſe, quàm ad cætera ſubſequuta; eo quòd cauſæ, ſeu concauſæ, eorum omnium damnorum fuerunt. Principali tamen integre ea perſolvente, cæteri ad illa non tenentur: eo quòd, quoad eiſmodi omnia damna, plenè ſatisfactum ſit parti læſæ. Idem propter eandem rationem eſt, ſi aliquis cæterorum, qui fuerunt concauſæ, integre ſatisfaciat. Atque principalis potiùs, quàm cæteri, cogi in foro exteriori debet ea ſatisfacere: in illius tamen defectum, aduerſus cæteros competit actio, vt illa ſoluant. Qui, ſi ſint multi, & ſinguli ſint ſoluendo, & præſentes, vt ſoluere ſtatim poſſint, ſinguli contribuere eſſent cogendi, æqualiter, aut plus, vel minus, prout æqualiter, vel plus, aut minus, fuiſſent concauſæ eorum damnorum. Si verò aliqui cogi non poſſent aliqua de cauſa contribuere ſtatim, tunc illi ſoli ſunt cogendi contribuere ad integram omnium damnorum ſolutionem, qui ſtatim ſoluere poſſunt. Remanet verò eis actio aduerſus principalem, vt ipsis ſoluat, quod loco illius ſoluerunt, quaſi negotii ea in parte illius geſti: atque in defectum principalis remanet eis actio aduerſus alios, qui ſimul fuerunt concauſæ eorum damnorum, nec ſoluere ſunt coacti, eo quòd aliqua de cauſa contribuere non potuerint ſtatim. Porrò, in re proposita, principalis dicitur mandans, aut ratum habens id nomine atque intuitu ipſius factum, ſi talis aliquis ſit datus: niſi res furto ablata ſit penes exequutorem: quoniam tunc, quoad eam rem, ipſe tenetur præcipuè. Poſt mandatorem, aut ratum id habentem nomine ipſius factum, tenetur exequutor, qui principalis cauſa, poſt illos, cenſetur: aut ipſe ſolus cenſetur cauſa principalis, ſi nullus fuit mandator, aut ratum id habens nomine ipſius factum. Quod ſi multi ſint partiales exequutores, aut mandatores, eiſdem furti, vt quia ſunt ſocii ad ſurandum, habentes commune maſſupium, aut prædam inter ſe diuidentes, ita quòd nomine omnium furta committuntur, aut damna dantur, tunc ſinguli tenentur tanquam principales, aut æqualiter, aut iuxta partem, quæ vnumquemque contingit, & ſin-[[61]]guli tenentur minùs principaliter in totum, in aliorum defectu. Semper tamen, ſi res furto ablata ſit apud aliquem, tenetur iſ illam reddere, poſteſtque ex ipſo vendicari, etiam ſi contractu lucratiuo, vel oneroſo, illam à fure, aut ab aliquo alio, obtinuiſſet; cui, prout fuerit titulus, quo eam obtinuit, competere poterit actio de euictione

aduersus eum, qui illam ei tradidit. Atque hæc eadem similiter habent locum in foro conscientia: eo quòd in eo foro similiter debeantur, nulla expectata sententia, eo ordine, qui explicatus est, à quibusdam deberi principaliter, & ab aliis, in aliorum defectu, cum recursum aduersus eos, vt ipsis persoluant, quod loco eorum soluerunt, vt hæc omnia fusiùs in materia de restitutione explanabuntur, vbi modos omnes explicabimus, quibus aliquis censeatur concausa furti, aut cuiusuis alterius damni iniustè dati. Illud verò est obseruandum, quando furtum esset factum ab aliquo domesticorum, aduersus quem non datur actio furti, tametsi detur repetitio eius, quod furto ablatum est, si extet, iuxta ea quæ disp. 686. fusè sunt dicta, tunc cooperantes ad id furtum cogi in foro exteriori possunt restituere valorem rei furto ablata, patrifamilias, & insuper damna omnia, si quæ inde vlteriùs sint ei subsequuta, esto res ad eiusmodi cooperatores non deuenerit. Si tamen res extet, ita vt facilè recuperari à patrefamilias possit, illam vindicare debeat, & reliquum persoluent cooperatores: qui, quoad hæc, recursum habebunt aduersus furem domesticum, si ille soluendo sit, & non possit se tueri beneficio restitutionis in integrum, vt ipsis soluat, quod eorum loco soluerunt; alioquin illud amittent. Atque hoc est, quod, inter alia, intenditur ac docetur. l. 4. titu. 14. part. 7. circa cooperantes ad furta domesticorum.

Quod attinet ad pœnam pecuniariam lege [sect. 44] statutam, vt parti læsæ applicetur, dicendum est. Si furtum sit commissum ab aliquo domestico, aduersus quem non competit ea actio furti, iuxta ea quæ Disp. 686. dicta sunt, tunc competit ea actio aduersus cooperantem ad id furtum, vt ibidem est comprobatum. Quia tamen cooperās nunquam tenetur de furto manifesto, etiamsi exequutor cum furto deprehendatur, sed solùm de furto non manifesto, vt habetur. l. is qui. ff. de furt. & notat glos. 1. §. interdum inst. de obligat. quæ ex delicto, nunquam cooperans tenetur parti læsæ ad pœnam quadrupli, sed solùm ad pœnam dupli. Arbitror tamen, si multi sint cooperatores, posse agere patrem familias aduersus quem eorum voluerit, vel aduersus omnes simul, ad eam pœnā: non tamen illi esse soluendas tot integras pœnas dupli, quot fuerunt cooperatores, sed vnam tantùm in recompensationem iniuriæ ipsi illatæ, argumento textus in. l. 2. §. hac actione. ff. de vi bon. raptor. Ratio autem est, quoniam illa legibus, comparatione illius, statuta est æqualis pœna pro iniuria eius furti ei illata. Quare, quādo multi sunt cooperatores, omnes contribuere debent ad eam pœnam in proportionem, in qua dictum est suprā, cooperatores contribuere debere ad surta, & ad dāna vlteriùs data: quòd si vnus solus eam soluat, credo eum agere posse aduersus reliquos, vt partes suas ei soluant, quas loco illorum soluit, vt de cooperatore soluente furtum, & damna vlteriùs illata, suprā est dictum. In re tamen proposita locum non habet recursus ad exequutorem furti, tanquam ad causam principalem, vt eam pœnam soluat: quoniam aduersus eum non competit actio furti. Quando autem pœna esset vel pecuniaria applicanda fisco, (quæ inter pœnas criminales computatur) vel corporalis exilii, flagellorum, remigandi in triremibus, aut quæuis alia criminalis, vt in hoc Regno erat pœna septupli, & iam hodie præcipitur, vt in criminibus furti, quæ pœna remigandi in triremibus, saltem attenta qualitate personæ, sint digna, illa pecuniaria locum non habeat, sed solùm habeat locum pœna remigandi in triremibus, commutata pecuniaria in hanc, vt suprā est dictum: quando, inquam, eiusmodi pœnæ sunt statutæ, credo cooperatores singulos teneri ad integras has pœnas, etiamsi principalis fur domesticus ad eas non teneatur, vt ex dicendis erit perspicuum.

Quando autem furtum est commissum ab eo, aduersus quem actio furti ad pœnam competit, dicendum est. Si agatur ad solam pœnam dupli, aut quadrupli, parti applicandam, vt quondam de iure communi agebatur, tunc solus exequutor furti tenetur eam integram soluere, aut

mandans, vel ratum id habens nomine ipsius factum, si talis causa magis principalis eius furti detur, tenetur pœnam dupli integram soluere, & in defectum horum, agi potest aduersus cooperatores, vt contribuant ad illam integram dupli pœnam soluendam, vt suprâ explicatum est, contribuere eos debere ad furtum, & ad damna subsequuta; non tamen plus, quàm vna integra eiusmodi pœna, solui & applicari debet parti læsæ. Arbitror tamen, singulos cooperatores puniendos esse æquali integra pœna, non quidem applicanda parti læsæ: sed fisco, propter idem delictum in commune bonum puniendum: nisi princeps statuatur, aut permittat, vt applicetur ad aliquos sumptus, vel ad aliquod opus pium. Iura enim mox referenda statuunt, vt cooperatores ad furtum æquali pœna puniantur cum fure principali: constat verò ex eo, quòd exequutor furti cooperatores habeat, non excusari ab integra pœna ordinaria, aut arbitraria, pro furto statuta: quare, cùm cooperatores, ex præscripto legum, æquali pœna cum exequutore furti sint puniendi, neque parti læsæ sit applicanda, nisi vna sola pœna dupli, aut quadrupli, consequens esse arbitror, vt æquali pœna singuli cooperatorum sint puniendi, sed illa applicari debeat vel fisco, vel alteri operi pio, vltra integram pœnam quadrupli, aut dupli, modo explicato parti læsæ solutam. Atq; in furtis domesticis, in quibus non datur actio furti aduersus furẽ domesticum, credo singulos cooperatores de iure communi esse damnandos ad integram pœnam dupli; sed postquam vnica talis pœna persoluta fuerit parti læsæ, reliquum applicari debere fisco. In hoc autem Regno, quando locus erat pœnæ pecuniariæ dupli, soluendi parti læsæ, & septuli, soluendi insupet fisco, credo satis fuisse in furtis non domesticis, atque etiam in domesticis, postquam domino rei fuisset soluta vna pœna dupli, tum principalem furem, tum etiam cooperatores, puniri singulos pœna septupli fisco applicanda. Hodie verò, quoniam non habet locum ea pœna pecuniaria, singuli damnandi sunt pœna triremium, in quam illa est commutata, vt satis expressè *habetur lege. 9. titul. 11. lib. 8. nouæ collect.* suprâ re-[[62]]lata, in cuius calce dicitur: *Y que otro si en lo dispuesto por la dicha pragmática cerca de los dichos ladrones, y lo que en esta se añade y declara, se entienda y estienda à los encubridores y receptadores y participes en los hurtos, para que en estos aya lugar la misma pena, y en la misma forma, que desuso esta declarada en los ladrones.* Aliæ quoque pœnæ corporales pro furto imponendæ, exilii, flagellorum, abscissionis aurium, remigandi in triremibus, mortis, & similes, iuxta præscriptum legum, aut consuetudinem receptam diuersorum Regnorum, similiter locum habent in cooperantibus ad furtum. Hæc constant ex. §. interdum inst. de oblig. quæ ex delicto, ex. l. in furti. §. ope. & l. si pignore. §. qui serramenta. ff. de furt. l. 4. & l. 18. titu. 14. part. 7. Quibus in iuribus habetur, qui aliquid facit quasi præambulum ad furtum, animo vt alius furetur, aut sciens, vel præsumens, id inseruiturum ad furtum, etiam si consilium ad furtum non det, neque id efficiat, vt de furto participet, teneri actione furti: vt, si pecunias de manu alterius excutiat, vt alius illas arripiat ac furetur; vel si detineat dominum rei, vt alius interim illam arripiat; vel si fuget panno rubeo, aut alia arte, animalia alterius, vt alius ea animalia dispersa furetur; vel si aperiat ostium, aut aliquid aliud, vel perfodiat parietem, vt alter furetur; vel scalam apponat; aut illam mutuo det, sciens, aut præsumens, ad furtum peti, vel clauis consiciat, aut alia ferramenta, vel illa mutuo det, aut vendat, sciens, aut præsumens, ad furtum peti, tenetur in his, & in aliis similibus euentibus, actione furti pœnis, quibus fures ipsi puniuntur. Qui tamen aliquid faceret, ignorans inde furtum sequendum, attamen, quod omnino imprudenter ac cum periculo damni sequendi efficeret, tunc, si furtum sequeretur, non competeret aduersus eum actio furti, nec proinde pœnis furibus statutis posset puniri; competeret tamen aduersus eum actio in factum ad damna omnia inde subsequuta. *Ita habetur. §. interdum inst. de oblig.*

quæ ex delicto, & l. in furti. §. ult. ff. de furtis. Exempla sunt, vt si quis ioco, vel ira percitus, excuteret pecunias, quas alius in manu habebat, & inde sequeretur, quòd alius aliquas earum, aut omnes, furaretur, aut quòd non inuenirentur; aut si ioco, vel vt molestiam alteri daret, fugaret, aut dispergeret, oues, vel armenta, illius, atque inde sequeretur, præter suam intentionem, quòd alius aliqua ex eis animalibus furaretur; aut sequeretur, quòd perirent dilacerata à feris, aut alia ratione, vel vt omnino disparerent; tunc aduersus id ita, cum periculo detrimenti alterius, efficientem, cæterum sine furti intentione, competeret actio in factum ad damna subsequuta, non tamen competeret actio furti, vt iuribus citatis habetur. Quando verò aliquis faceret aliquid, vnde furtum, aut damnum aliud, sequeretur, cæterum sine vlla sua culpa, probabiliterque ignorans id damnum sequendum, tunc ad nihil tenebitur, quicquid inde sequatur. Vt si faber ferrarius conficiat clauem ei, de quo suspicio non erat, velle eam ad furandum; vel si quis mutuo det alteri scalam, aut ferramenta, de quo non erat præsumendum, velle illa ad furandum, vel ad aliud damnum inferendum, ad nihil tenetur, quicquid inde vltèriùs sequatur.

Sicut qui cooperatur cum simplici fure [sect. 45] ad furtum, tenetur actione furti, subiactèque pænis furibus statutis: ita, qui cooperatur cum raptore ad rapinam, tenetur pæna raptoris; &, qui cum sacrilego ad sacrilegii furtum, tenetur pæna eius furti; &, qui cum fure ad peculatum, subiactet pœnis pro eo crimine statutis, vt quoad hæc omnia crimina, *habetur, l. 18. titu. 14. partic. 7.* & quoad crimen peculatus habetur. §. *item lex Iulia peculatus instit. de publ. iud. & l. vnica. C. de crimin. peculat.*

Quando autem mitiùs puniatur cooperans [sect. 46] ad furtum, aut aliud crimen, quàm exequutor surti, aut alterius criminis, intelligitur facilè ex dictis Disp. 550. circa mandatum ad crimen aliquod patrandum.

Inst. §. interdum, vers. certè, de obligatio [sect. 47] nib. quæ ex delicto, habetur; Eum, qui opem non tulit ad furtum, esto consuluerit furtum, ad illudque furem adhortatus fuerit, non teneri de furto. Quod glossa ibi exponit, quando fur similiter idem furtum erat factururus: quoniam tunc consulens verè non concausat furtum. Atque id ita sancitum est. *l. 4. titu. 14. part. 7.* eoque modo conciliatur paragraphus citatus *cum. l. in furti. §. ope, vers. consilium, & cum. l. si quis uxori. §. neque. ff. de furtis*, consentireque videtur lex sæpe. §. *item, in fine. ff. de verb. signif.* Ait verò Greg. Lop. l. 4. citata verb. *o con consejo*, cum Dino, & Bal. quando datum est consilium ad furtum, furtumque est subsequutum, præsumendum esse, furem alioquin id non fuisse facturum, ac proinde consulentem teneri tunc ad pœnam furti, atque etiam ad damna, quando fur ea non resarcit. Addit præterea, consulentem, de quo constat, furem similiter fuisse facturum idem furtum, esto datum ei non fuisset id consilium, esse nihilominus à iudice puniendum ex suo officio pæna, non quidem furti, sed alia arbitraria: quia rem fecit mali exempli, sequutumque fuit, quod consuluit. Eo vero erit grauiùs tunc puniendus, quo plus fuerint coniecturæ, confirmasse furem in suo malo proposito. Legas verò varias opiniones, quas idem *Greg. Lopez ibi, & l. 18.* sequenti, circa consulentem furtum, refert.

Quod ad furis receptatorem attinet, quan [sect. 48] do furem recepit cum rebus furtiuis, sciens furto fuisse ablatas, aut res solas furto ablatas recepit, sciens furtiuas esse, tunc verè est concausa furti illius; eo quòd interim, dum non restituuntur, perseuerat furtum ac damnum id proximi, quod ipse, cum fure, continuat ac causat retinendo apud se eas res. Atque in hoc euentu intelliguntur ac loquuntur. l. eos. C. de furtis, cuius verba sunt: *Eos, qui à seruo furtim ablata, scientes, susceperint, non tantum de susceptis conuenere, sed etiam pœnali furti actione*

potes: & l. si quis seruum. C. ad leg. Fabiam de plagiar. cuius verba sunt: Si quis seruum fugitiuum, sciens, cum rebus furtiuis suscepit, cum horum nomine furti actione teneatur, hæc tibi rector prouinciæ cum solita pæna restitui faciet; ac l. penult. C. ad leg. Iul. de vi public. [[63]] quæ sic habet; crimen non dissimile est rapere, & ei, qui rapuit, raptam rem, scientem delictum, seruare; & §. item lex Iul. peculatus inst. de pub. iud. ac lex vnica. C. de crimine pcculatus sic habent; vel qui subtractas ab his (iudicibus scilicet incurrentibus crimen peculatus) scientes suscepint, eadem pæna percellendis: & l. 3. §. non tantum ff. de incend. ruin. in qua sic scriptum legimus; non tantum autem qui rapuit, verum is quoque, qui recepit ex causis supra dictis, tenetur: quia receptatores non minus delinquant, quam aggressores; ac denique l. 18. titu. 14. part. 7. quæ receptatoribus furium, cuiuscunque generis furti ex commemoratis, eandem pænam statuit, quæ decreta est furibus ipsis, qui eodem genere furti furantur, atque ita affirmat communis doctorum sententia, quam Ant. Gom. 3. tom. var. res. c. 5. num. 16. refert ac sequitur, quicquid in contrarium dixerit Hipolitus ab Ant. Gom. ibidem relatus, quasi receptatores scienter furium, rerumque furto ablatarum, tunc solum puniendi sint pænis furibus statutis, quando furtum est domesticum: ductus, quod duobus iuribus primo loco citatis sermo sit de receptatoribus furium domesticorum, cum rebus domesticis furto ablatis: cum tamen posteriora iura vniuersim, atque etiam de aliis speciebus furti à furto simplici distinctis, loquantur: & cum sit eadem ratio de recipientibus scienter fures non domesticos, cum rebus furtiuis, & de recipientibus fures domesticos, nec minus, sed plus, illi peccent, quam hi. Adde. l. 3. §. non tantum. ff. de incend. apertè docere, vniuersim receptatores quorumcunque furium eadem pæna, qua fures ipsi, esse puniendos. Excipe, nisi aliud peculiariter reperiatur in iure sancitum, vt de receptatoribus abigeorum disp. 684. est dictum aliud in iure esse sancitum. Quando aliquis reciperet scienter solum furem, non verò rem furtiuam, distinguerem. Quoniam si illum reciperet, dum furatur ac continuat furta, ita quod receptio & occultatio quasi adiutorium sit, vt ille commodius furetur, aut rapiat, vel vt perseueret in delictis, dicerem eiusmodi teneri pænis furium: atque hoc modo intelligerem. l. 18. titu. 14. part. 7. quæ statuit, vt puniatur pænis furibus statutis. Si verò ita illum reciperet, vt receptio in ea domo nullas vires, nullumque adiutorium, illi præberet ad delictum, quia similiter hospitari posset apud quoscunque alios, qui furta illius ignorarent, tunc longè minus puniri deberet, quam ipse fur, & meo iudicio, nulla pæna deberet puniri, si iam cessauerat à furtis. Quod si simul illum occultaret postquam à furtis cessauit, teneretur, non pœna furis, sed occultatoris delicti ac delinquentis, nisi pæna eius delicti imposita ac promulgata esset à iudice ei, qui occultaret ac non manifestaret talem delinquentem. Si item illum denegaret ministris iustitiæ eum quærentibus in ea domo, & multo magis, si illis resisteret, incideret in pænas. l. 1. & 2. C. de his qui latrones occultant. Atque iuxta hæc acciperem, quæ de hac re tradunt Ant. Gom. num. 16. citato, & Greg. Lopez. l. 18. citata glos. antepenul. iuncta glossa antecedente. Et, quando occultans esset consanguineus occultati, mitius esset puniendus in eiusmodi delictis, quæ non sunt in perniciem publicam, vt prædicti autores tradunt. Memento autem in hoc Regno, vt suprà ex. l. 16. titul. 11. lib. 5. nouæ collect. relatum est, euentes, aut quomodo accipientes à mancipiis, res quascunque, tanquam fures reputari, ac pænis furium puniri.

Superest respondeamus ad argumentum³¹ paulo post initium longissimæ huius disputationis pro opinione Alexandri Alensis propositum. Atque concessa maiori, nempe pænam proportionari debere culpæ, vt sit iusta, hoc est non debere illam excedere; itemque concessa maiori, res videlicet externas infimas esse inter omnia bona nostra, vitamque

esse omnium bonorum temporalium præstantissimum, fundamentumque esse cæterorum; ac mortem, præsertim violentam, esse terribilium omnium terribilissimum, maximeque hortendum; neganda est consequentia, qua infertur, improporcionatam pœnam, longeque excedentem, esse mortem corporalem pro furto, in quo damnum infertur proximo in bonis illius temporalibus, ac proinde iniustam esse legem, quæ eam statuit. Ratio autem, cur hæc consequentia nulla sit, hæc est: Quoniam ad iudicandum, an pœna pro delicto sit iusta, minimeque culpam excedens, non est attendendum ad materiam culpæ, quasi materia pœnæ, seu bonum, quo pœna priuat, non debeat excedere materiam culpæ, seu bonum, quo delinquens priuat proximo suo culpa, seu delicto, quod ea pœna punitur: sic enim iniusta esset pro furto pœna dupli, quadrupli, aut alia maior, neque pœna imponi posset, nisi pro delicto, in quo proximus læderetur, saltem pecuniaria, aut corporalis, quod constat esse falsum, ac manifestum absurdum. Ad iudicandum ergo, an pœna pro delicto sit iusta, hoc est, minimè culpam excedens, attendi debet ad ipsam culpam, ad legisque transgressionem ac inobedientiam, & ad vim maiorem, vel minorem, qua à legitimo legissatore aliquid prohibetur, aut præcipitur, atque ad commune bonum, cuius intuitu id prohibetur, aut præcipitur, ad maioremque, vel minorem, transgressionem ex parte obiecti, & ad reliquas circumstantias concurrentes: cùm autem in furto, pro quo pœna mortis imponitur, culpa interueniat lethalis, stando in solo iure naturali, seclusaque vi iuris humani acrius adhuc illud inhibentis ad pacem ac securitatem ciuium conseruandam, atque ad vitandas cædes, & alia mala, sanè in eo est sufficiens culpa, vt corporali morte iustè à potestatibus publicis puniri possit, quandoquidem à Deo pœna interitus æterni iustè infra condignum damnatur, maximè id ita postulante bono communi temporalis reipublicæ, accedenteque inhibitione eius criminis sub tanta temporali pœna, pro potestare sibi à Deo concessa ad præcipiendum, & inhibendum, loco ac nomine ipsius, quæ iudicauerint ad bonum reipublicæ expedire, atque sub pœnis, quæ similiter eidem bono expedire iudicauerint. Quare meritò communis doctorum sententia aduersus Alexandrum Alensem asseuerat, iustè pro furto imponi posse mortem corporalem, vt communis praxis Christianarum rerumpublicarum obseruiat: de numero verò eorum doctorum sunt. Ioa. [[64]] Medina de rest. q. 4. Maior in 4. dist. 15. q. 27. Driedo. 1. de libert. Christ. c. 10. Castrus. 1. de leg. pœnali. c. 2. Couar. 2. var. res. c. 4. num. 7. Caiet. 2. 2. q. 64. art. 2. & Sotus. 5. de iust. q. 3. artic. 3. ad 4. Fateor verò Lusitanas leges, suprâ relatas, rigidas esse in plectendis morte furibus, etiam prima vice, pro modico valore, non tamen sunt temere damnandæ, neque credo illas tanto cum rigore in eo Regno exequutioni mandari.

Quibus, & aduersus quos, actio furti competat. Disp. 696.

SVMMARIVM.

1. *Furti ratione actio ad rem, fructus, & interesse, etiam lucri cessantis, quæ condictio furtiua dicitur, aduersus surem hæredesque illius competit, quin vendicatio rei furto ablatæ competit aduersus quencunque illius possessorem, & competit domino rei, hæredibusque seu successoribus in bonis illius.*

2. *Furti actio ad pœnam, in omnibus furti speciebus, non transit aduersus hæreses furis, nisi pœna sit pecuniaria, & lis contestata fuisset cum fure ante ipsius mortem. Excipiuntur crimina peculatus, & de residuis, in quibus actio ad pecuniariâ pœnam transit aduersus*

hæredes delinquentis, esto lis cum delinquente non esset contestata. Non verò transit actio furti aduersus furem, & ad hæredes eius, in quem commissum est furtum, nisi is litem cum fure esset contestatus. Et num sufficiat parasse actionem. Et num querela detur aduersus furem.

3 . Fur an conueniri possit in loco, in quo delictum commisit, & in quo repertus fuerit cum re furto ablata, & in quo ipse fuerit repertus, aut res furto ablata.

4 . Furti actio ut competat, necesse est patratum fuisse furtum formaliter, & materialiter simul. Quando autem aliquis mancipium, aut filium alienum, induceret, ut hero, aut patri, furaretur, ad séque furtum afferret, sequuto furto ex consensu heri, aut patris, ut iniquus ille consulens puniretur, actio furti competeret aduersus eum hero aut patri.

5 . Furtiactio quousque competat aduersus commodatarium, conductorem, creditorem, ac depositarium, vtentes re commodata, conducta, pignore, aut deposito, aliter, quàm eis liceat.

6 . Furti actio quousque competat, aut non competat, aduersus dominum rei eam accipientem a commodatario, aut conductore, & quæ alia actio aduersus eos competat. Et quid si vi illam ab eis eripiat. Et quid quando dominus rei illam vi occupat ex legitimo detentore, qui illam non possidet.

7 . Actio furti competit aduersus rei dominum clā propria autoritate ejicientem à possessione eum, qui in illa erat. Et quas pœnas incurrat, si vi illum ejiciat.

8 . Furti actio competit aduersus debitorem, qui pignus suum accipit clam à creditore, & ad quid se extendat. Et quid si vi illud accipiat.

9 . Furto si pignus ex creditore, nondum finita pignoris obligatione, sit à quodam tertio ablatum, furti actio ac certi condictio aduersus furem ei competunt, & quid debitori inde reddere teneatur. Et quando debitori competit actio aduersus furem, & quando competit creditori. Eadem in rapina pignoris facta à quodam tertio.

10 . Furto si res alienæ sint ablatae ex eo, qui so locauerat aliquid circa illas, aut qui conductas eas res mobiles habebat, quando & quæ actiones competant ei, etiam in suum commodum, & quando & quæ actiones competant domino earum rerum, & quando dominus agere aduersus illos poterit.

11 . Furto si res à quodam tertio auferatur ex commodatario, ita ut commodatarius ad nihil commodanti teneatur, agere conductione furtiua, & actione furti, ad solum commodantem spectat, nisi absenssit, aut aliter impeditus: ad commodatarium verò solum agere spectat ob emolumentum usus, quo iniuste fuit priuatus. Quando autem commodatarius tenetur commodanti de re commodata, quo usque actio ad commodatarium & quousque ad commodantem spectet. Et quousque actio commodanti aduersus commodatarium competat.

12 . Furto quando res est ablata à quodam tertio ex depositario, actio regulariter aduersus furem non ad depositarium, sed ad eum, qui deposuit, pertinet. Et quando ad depositarium spectet.

13 . Furto quando res est ablata ex œconomo, tutore, aut curatore, actio aduersus furem ad hos quidem spectat, sed non nomine proprio, neque in suum commodum, sed eius, cuius bona administrant. Quando autem dominus rei eam ex ipsis exigeret, quia culpa ipsorum amissa, tunc soluere eam non tenerentur, nisi cedente domino ipsis actiones aduersus furem, atque ex tunc agerent ipsi aduersus furem in suum commodum.

14 . Furto sires mobilis auferatur ex usufructuario, agit usufructuarius aduersus furem quo ad valorem præcisè ususfructus, & propriarius quo ad valorem præcisè proprietatis. Idem si usufructuarius furetur eam rem quoad proprietatem, aut propriarius quoad vsumfructum. Fructus si auferantur furto à re immobili, cuius ususfructus ad aliquem spectat, actio aduersus furem soli usufructuario conuenit.

15 . Furto si auferantur fructus ex agro locato colono pro certa pensione, quam colonus soluat, ad solùm colonum pertinet actio aduersus furem. Si pro quota fructuum, quam soluat domino agri, illum colat, actio pertinet ad vtrumque pro rata. Si colonus solùm accipiat quotam in mercedem, actio competit soli domino agri: sed colonus cogere eum potest vt illam intentet, vt ipse accipiat suam partem fructuum, & partem pænæ, deductis expensis.

16 . Furto si res vendita, nec tradita, ablata esset, itæ vt periculum ad emptorem spectaret, teneretur venditor agere aduersus furem condictione furtiua, & actione furtiua, totumq; emolumentum tradere emptori, deductis expensis, aut cedere emptori actiones aduersus furem. Si autem culpa venditoris res fuisset furto ablata, nec recuperaretur, teneretur emptori ad damna. Quando verò res venditori periret, ageret venditor in suum cōmodum aduersus furem.

17 . Furto si res alteri promissa ab alique esset ab-[[65]]lata ex potestate promissoris, ad promissorem spectaret agere aduersus furem condictione furtiua, & furti actione, traderéque ei, cui illam promiserat, debet rem promissam, aut illius æstimationem, non vero pœnam furti, etiam si per promissorem stetisset, quo minus eam tempore congruo tradidisset.

18 . Furto si res, in singulari legata, sit ablata post mortem testatoris, legatario competit aduersus furem conditio furtiua, & furti actio. Si verò ante mortem testatoris sit ablata, legatario solùm competit reiuendicatio illius, aut actio ad æstimationem: hæredibus verò conditio furtiua.

19 . Raptorum bonorum actio non solùm conceditur, vi interueniente, quando, illa seclusa, concederetur actio furti, sed etiam quando non tantum sua interesset eius, ex quo res aufertur, vt se clusa vi, concedenda esset actio furti.

20 . Rapina rei de potestate eius, qui illam tenet, si cum iniuria personali eam tenentis sit facta, tunc actio iniuriarum ipsi competit, esto res illa nihil sua referat.

VT Disputatione præcedente dictum est, a [sect. 1] ctio aduersus furem, quocunque furti genere, ad rem surto ablatam, ad fructus illius, etiā qui percipi potuerunt, & non sunt percepti, aut ad æstimationem cuiuscunque horum, si non existant, aut deteriora sint reddita, itemque ad damna omnia, etiam lucri cessantis, ex furto subsequuta, competit, tum ei, à quo res furto est ablata, tum etiam hæredibus illius, & competit, tum aduersus furem, tum etiam aduersus hæredes illius de bonis, quæ ex fure ad ipsos deuenerunt: atque actio ad hæc omnia conditio furtiua nuncupatur, quæ in odium furti comprehendit etiam vendicationem rei furto ablatæ, ac proinde conditio furtiua realem, & personalem, actionem comprehendit, vt constat ex. l. si pro fure. §. 1. ff. de condict. furt. Ratio autem cur actio ad hæc omnia transeat ad hæredes eius, qui id damnum iniustè à fure est passus, & aduersus hæredes furis, hæc est: Quoniā fur horum omnium est debitor, non in pœnam, sed in conscientiæ foro, nulla expectata sententia, ratione iniustæ acceptionis, damniq; iniuste dati, ac proinde rationem sortiuntur verorum debitorum furis, comparatione eius, à quo furatus est, & cui damnum id iniustè dedit: vera autē debita & transeunt ad hæredes eius, cui debetur, & aduersus

hæredes eius, qui illa debebat: neque, qui illa debebat, plus in bonis reliquisse censetur, quàm quæ superfuerint, deductis omnibus debitis, totòve ære alieno. Quòd autem ad hæc omnia competat actio, ex se est notissimum, & constat ex. l. 3. & ex. l. in re furtiua, ac ex legib. sequentib. ff. de condict. furt. Quòd verò competat etiam hæredibus eius, qui furtum est passus, & aduersus hæredes furis, ex se etiam est satis perspicuum, atque præter iura disputatione præcedente, & disputat. 682. citata, habetur. l. 2. 3. 5. l. si pro fure. §. condictio. l. in conductione. l. sed neque, & l. si serutis. ff. de condict. furt. §. ult. inst. de actionib. quæ ex delict. l. 2. §. ult. iuncto antepenult. ff. de vi bonor. rapt. iuncta. l. sine. §. ei quoque ff. de condict. furt. & l. 2. ac 3. titul. 13. part. 7. Atque hæc posteriora iura in rapina loquuntur.

Actio verò furti ad pœnam, in omnibus fur [sect. 2] ti speciebus, solùm competit aduersus furem; nō verò aduersus illius hæredes, nisi pœna sit pecuniaria, & actio litis contestatione fuerit aduersus furem ante illius mortem intentata: nam tunc hæredes illius tenentur de bonis furis ad pœnam pecuniariam, in qua fur condemnatus fuerit. Ita habetur inst. de perpetuis actionib. §. non autem. l. ex iudiciorum. ff. de accusationib. & l. 2. titu. 13. part. 7. atque ex dicendis tractatu sequenti magis notum fiet. Excipe crimen peculatus, & de residuis, in quibus ex peculiari priuilegio agi potest ad pœnam aduersus hæredes, etiam si lis contestata ante mortem aduersus delinquentem non fuerit, vt habetur. l. ult. ff. ad leg. Iul. peculatus, & disputatione præcedente est dictum. Ad hæredes autem eius, qui furtum est passus non transit actio ad pœnam aduersus furem, nisi, qui furtum est passus, eam ante suam mortem intentasset, contestatusque esset aduersus furem. Ita habetur. §. non autem in fine inst. de perpet. act. & l. 2. titul. 13. part. 7. Glossa verò Accursii. §. non autem citato, verb. contestatæ, ait, satis esse actionem fuisse præparatam à defuncto, etiam si contestata non fuerit, vt hæredi concedatur ea actio aduersus furem: quin, subiungit, hodie concedi ei querelam, etiam si defunctus actionem non præparauerit.

Lex. 2. in fine titu. 13. & lex. 4. in princ. titul. [sect. 3] 14. part. 7. atque. l. 32. titul. 2. part. 3. apertè statuunt, potissimum lex. 2. citata, agi aduersus furem posse, tum in loco, in quo furtum commisit, tum etiam in quocunque alio, in quo repertus fuerit cum re furto ablata, tum denique vbi vel ipse, vel res furto ablata, fuerint reperti. Atque l. 32. citata statuit, si in aliquo loco repertus fuerit aliquis cum re, quæ furto fuit ablata, & ab eo petatur, tam quam quæ furto fuerit ablata, si is suspectus sit de furto eius rei, deberi statim comprehendi: si verò non sit suspectus, atque satisfactionem det, quòd circa illam respondebit in loco, in quo dicitur fuisse ablata, aut vbi ipse alioquin poterat, tanquam coram suo competenti iudice, conueniri, dimitti cum ea re debere, data ea satisfactione. Greg. Lopez, præsertim. l. 4. citata, arbitratur, in his iuribus definiri sententiam Bartoli, quòd possit ad pœnam furti agi aduersus furem, non solùm in loco delicti, sed etiam extra illum, si cum re furto ablata fuerit repertus, & extendi eam opinionem, vt agi aduersus eum possit, siue ipse ibi fuerit repertus, siue res sola furtiua: cùm tamen circa Bartoli opinionem non omnes consentiant, sed multi refragentur. Ego existimo, iura illa solùm loqui quando sola res furtiua est reperta, posse agi vbicunque illa fuerit reperta, rei vindicatione aduersus eam tenentem, probando dominium illius ad eum, qui illam petit, spectare: nisi eam tenens alibi habeat suum competentem iudicem, & satisdet, quòd coram illo respondebit, aut in loco vbi furtum dicitur patratum, vt petens maluerit, neque, qui rem tenet, suspectus sit de furto. Quando verò aliquis conuenitur de furto ad pœnam, extra locum vbi crimen dicitur patratum, & vbi ille, tanquam reus, habet suum competentem iudicem, tunc, si conuentio sit in eodem Regno, & ille de furto sit suspectus, comprehendi debet, sed [[66]] vt remittatur ad iudicem loci delicti, aut ad

aliū suum competentem iudicem, prout elegerit agens de furto, si reus iudicium recuset in loco, in quo fuit repertus. Nisi dicas, quòd cūm continuet furti delictum, non restituendo rem furto ablata cōueniri possit, vbi cum re furto ablata reperitur. Tunc tamen, si pro furto diuersæ pænæ statutæ sint in loco delicti, puniendus est pœna loci, in quo delictum commisit, maximè si illa mitior sit.

Disputat. 681. & sequentibus, dictum est, vt [sect. 4] competat actio furti, non satis esse interuenire furtum formaliter, sed necessarium etiam esse, vt interueniat furtum materialiter, hoc est, rei verè alienæ, quatenus furto accipitur, ac verè inuito eo, cuius est, alioquin actionem non dari. Quando tamen quis induxisset alienum mancipium, vt furaretur proprio domino, furtumque illud ad se afferret, aut similiter induceret, vt furaretur à patre, atque ad se furtum adduceret, tunc si, sciente id domino, aut patre, consentirent vt id efficeret, gratia puniendi pœna furti, qui id ita consuleret, competeret aduersus eum, qui id ita consuleret, actio furti domino ac patri. *Ita habetur l. si quis seruo. C. de furt. & l. 8, tit. 14. part. 7.* quæ etiam de filio idem disponit, cum glo. vlt. l. si quis seruo citata. Vtrūm autem idem sit in fratre, & in aliis, vide Greg. Lop. ibi.

Dictum præterea ibidem iset, quousque fur [sect. 5] tum interueniat, actioque furti detur domino rei, aduersus illum, qui eam habebat commodatam, conductam, in pignus, aut in depositum, eaque vtitur inuito domino ad aliud, aut aliter, quam ei concessa erat. Atque Disput. 535 est explanatum, ad pœnam pro furto tunc imponendam, non attendi ad valorem rei, sed ad vsum illius inuito domino, qui solus vsurpatur. Et Disputat. 682. est dictum, in quam pœnam hi incurrant, si domino rei, illam, finito contractu, petenti, non restituant, sed expectent quousque definitiua sententia feratur.

Disputatione itam 681. & Disp. 690 conclu. [sect. 6] 2. est dictum, si dominus rei eam accipiat à commodatario, aut à conductore, eis inuitis, antequam finiatur tempus contractus, quousque commodatario, aut conductori, concedatur, aut non concedatur, actio furti aduersus eius rei dominum; tametsi semper eis concedatur actio contraria ex commodato, & actio ex cōducto. Itemque Disput. 682. est explicatum, esto dominus vi illam ab eis tunc auferat, non tamen puniri pœna legis Iuliæ de vi publica, aut de vi priuata, sed alia ibi explicata; eo quòd illi verè non possideant eam rem, sed per eos illam possidet dominus, qui vi eam ab ipsis aufert: eademque ratione est dicendum, eum neque in pœnam incidere raptoris, nisi in euentu, in quo aduersus illum scio furti concederetur, si vis non interuenisset, sed sola occulta talis rei vsurpatio inuito commodatario aut conductore. Eodem verò modo dicendum est, aduersus rei dominum, neque actionem furti, neque de vi publica aut priuata, neque actionem vi bonorū raptorum, concedi, quando illam occupat, etiā cum vi à quocunque alio legitimo illius tentore, qui eam non possidet, sed iuberi eam restituere cum fructibus, & damnis subsequitis, quousque finiatur tempus legitimæ illius tentionis, & insuper puniri pœna arbitraria, vt hæc omnia Disp. 682. sunt comprobata.

Disputat. 681. est dictum, si quis autoritate [sect. 7] propria dejiciat aliquem à vera possessione rei, in qua est, eam ab illo clām auferendo, etiam si is, qui in ea est possessione, dominus non sit rei illius, rem ita clām auferentem committere furtum, competereque furti actionem ei, qui in ea erat possessione, aduersus rem illam auferentem. Et Disput. 682 est ostensum, si vi quis ejiciatur à possessione rei mobilis, aut immobilis, in qua erat, esto is possidens, dominus rei illius non esset, ejicientem cum vi à tali possessione incidere in pœnas legis si quis in tantam. C. vnde vi, & quæ sind pænæ illæ.

Eadem Disput. 681. & Disput. 690. conl. 2. di [sect. 8] ctum est, si rei dominus vsurpet clàm rem à creditore, cui in pignus erat tradita, antequam ratio pignoris cesset, competere creditori furti actionem aduersus dominum eam rem ita iniustè tunc vsurpantem. Obserua tamen tunc, si pæna furti sit duplum, vt est de iure communi, quando furtum non est manifestum, non agere aduersus dominum ad duplum valoris pignoris, sed tantùm ad duplum eius, quod sibi debetur, si pignus plus valeat, quàm quod sibi debetur, hoc est, aget, vt sibi in pænam restituat duplum, ac erat id, quod isbi debebat, & simul contrario pignoratitia actione aget, vt vel sibi restituat pignus in securitatem debiti, aut aliud æqualis valoris, si nondem tempus solutionis debiti aduenit, vel vt sibi debitum soluat. It affirmat *glossa. 1. l. si pignore. ff. de pignorat. act.* & cum ea doctores communiter. Atque, vt eadem lege habetur, ea tota pæna pertinet præcipuè ad creditorem, neque eam tenetur computare in id, quod sibi debetur; eo quòd culpa fuerit ipsiusmet debitoris. Disputatione autem 682. est dictum, quòd cùm creditor verè sit in possessione pignoris ad aliquos effectus, etiam si simul debitor sit in possessione eiusdem pignoris simpliciter & quoad alios effectus, si debitor vi extrahat pignus de potestate creditoris, dum adhuc pignoris ratio perseuerat, incidit in pænam amissionis illius creditori, argumento legis si quis in tantam, C. vnde vi. Obserua verò, posse etiam agere ad pænam legis Iuliæ de vi publica, aut priuata, prout fuerit vis, quæ ei fuerit illata: non tamen poterit agere ad vtramque pænam, sed ad alterutram duntaxat, quam eligere maluerit. Eodem in loco dictum etiam est, in quas pænas incidat creditor, qui autoritate propria vi accipit pignus, aut aliquid aliud, à debitore pro suo debito.

Diximus paragrapho proximè præcedente, [sect. 9] quando dominus rei accipit suum pignus à creditore. Quando verò aliquis extraneus illud furatur ab eodem creditore: interim dum debitum non est ei solutum, pignorisque rationem id adhuc retinet, dicendum est: Creditorem posse in primis agere aduersus furem, non quidem conditione furtiua, quæ solùm competit domino rei furto ablata, sed conditione, quam iura vocant incerti conditio, *vt habetur l. & ideo. §. ult. ff. de condict. furt.* & competit eis, qui, cùm domini non sint rei furto ablata, interest tamen eis de ipsorum potestate non esse furto ablatam, quia ius aliquod circa illam habent: [[67]] atque ad ea omnia competit, quæ furtiua actione peti possunt, nempe vt restituatur res ablata cū fructibus, etiam qui ex illa percipi potuerunt, aut æstimatio eorum omnium, si non extent, aut si quid deterius sit redditum, & insuper vt soluatur damna omnia, etiam lucri cessantis, ei subsuquuta, à quo furto fuit ablata. Deinde creditor agere potest actione furti ad pænam pro furto statutam, (neque vna actio impedit aliam, imò verò post vnam intentatam poest alia intetari, quin, vt *Greg. Lopez. l.9. tit.14. part.7.* cum Bart. affirmat. vtraque potest simul intentari eodem libello) atque si creditor agat ad pænam dupli pecuniariam, aut ad aliam maiorem, non solùm poterit petere à fure duplum sui debiti, sed etiam duplum integri valoris pignoris furto ablati, aut pænam in maiori proportionem, si in maiori fuerit statuta, vt habetur expressè. l. creditoris in prin. ff. de furt. Cæterum, sui furtum factum sit interueniente culpa creditoris, ex qua debitori teneatur, siue absque vlla sua culpa, totum, quod à fure acceperit, siue conditione incerti, sui in pænam furti, tenetur tradere debitori, sibi duntaxat retinendo integrum suum debitum, & si quid expendit in eis omnibus obtinendis, (in quibus computa, si quod damnum, etiam lucri cessantis, fuerit inde ipsi subsequutum) incrementumque totum, vltra eas expensas ac debitum, tenetur reddere debitori, poteritque illud debito exigere à creditore pignoratitia actione. *Ita habetur l. si pignore. ff. de pignorat. act. l. creditoris. ff. de furt. & l. 9. tit. 14. part. 7.* Lex inter omnes §. hæc actio. ff. de furt. manifestè docet, si in pignore alius, à debitore, habeat vsumfructum, vel

partem, vt si pignus sit mancipium commune debitori cum altero, aut in quo alter habeat vsumfructum, tunc creditorem posse agere de furto, & debitorem, & tertium illum, qui in eo pignore partem habet, aut vsumfructum, atque vnūquenq; eorum agere posse, quatenus sibi nocuit furtum; si autem vnus eorum transactionē faciat cum fure, id accipiendum esse solūm quoad id, quod ad ipsum spectat, integramque manere actionem reliquis, quatenus ad ipsos agere spectat. Contrarium verò innuere videtur apertè lex 9. citata. quæ habet, solūm creditorem agere posse aduersus furem, non verò debitorem, cuius est pignus, Gregoriusque Lopez ibi anxie laborat in ea lege exponenda ac defendenda. Intelligenda verò est, quando creditori agit ad totum, quod ad debitorem spectat: tunc enim præponendus est creditor in agendo, à quo res furto fuit ablata, neque circa idem omnino duæ simul actiones sunt admittendæ. Quando verò creditor segnis esset in actione intentanda, posset agere debitor, cuius est pignus, & qui, per creditorem, suam rem etiam possidebat naturaliter. Item, si creditor non agat ad totum, ad quod agere potest debitor, vt si non condicat damna debitori sequuta, aut si in minori quantitatē petat dupli pœnam, quam pignus valeat, potest debitor agere ad incrementum: & similiter vsufructuarius, aut qui dominii partem in eo pignore habet, poterit condicere id, quod in eo pignore habet, & dēna ipsi ex tali furto subsequuta, atque agere simul poterit ad pœnam dupli æstimationis eius, quod in eo pignore ipse habebat: neque transactio, aut conuentio vnus horum triū cum fure, impediet, quin cæteri agere possint ad suum interesse proprium, vt aperte disponit. §. hæc actio, citatus. Quando in pignore, quod adhuc erat penes creditorum, ratio ignoris cessauerat, quia integrum suum debitum acceperat, vel à debitore, vel actione aduersus alterum priorem furem, qui idem pignus furatus antea fuerat, distinguendum est. Quoniam vel furto accipitur culpa ipsius, ex qua debitori teneatur, vel absque tali ipsius culpa. In hoc secundo euentu, ipse non potest agere aduersus furem, quia iam nullum ius in ea habet: sed agere aduersus furem spectat ad dominum rei. In primo verò euentu, quoniam ipse ob culpam tenetur creditori de re furto ablata, agere potest aduersus furem, totū tamen reddere tenetur domino rei, deductis expensis, & damnis ipsi creditori ex tali furto sequutis. Ita habetur l. eum qui. §. idem scribit. ff. de furt.

Lex 9. titu. 14. part. 7. non solūm in furto pignoris totam pœnam pecuniariam parti læsæ, cōsentaneè ad iura communia relata, applicandam, domino applicat, cuius ea res erat, & nihil illius creditori, de cuius potestate pignus furto est ablatum, etiam si interueniente iuridica culpa ipsius, furtum esset commissum, ipseque proinde teneretur de ea re domino illius, si recuperati nō posset ex fure; sed etiam in rapina totam pœnam applicat domino pignoris, & nihil creditori, esto creditor passus sit violentiam rapinæ, & non pignoris dominus. Ratio autem est, quoniam pœnan illa pecuniaria non applicatur parti, isi ratione rei, quæ per rapinam, aut furtum, est ablata, quæ proinde debetur domino rei: vnde videmus, pro rapina, quæ rationem furci manifesti sortitur, non maiorem statui pœnam pecuniariam, quàm statuatur pro eo furto manifesto, in quo vis, rapinæque ratio, non interuenit: quo sit, vt lex illa consentanea sit dispositioni iuris communis.

Quod ad locatorem attinet, qui se ad aliquid [sect. 10] circa materiam alienam faciendum locauit, vt ad aurificem, qui se locauit ad arte factum ex alieno auro, aut argento, conficiendum; ad sartorē, qui vestes ex panno alieno conficiendas suscepit; ad fullonem, qui res alienas abluendas accepit; ad molendinarium, qui triticum alienum molendum suscepit, & ad alios similes, qui alienas res suscipiunt, vt aliquid circa eas pro mercede aliqua exerceant: itemque quod attinet ad conductorem alienæ rei mobilis ad aliquem vsum, vt equi ad iter

conficiendum, si res, ita ab eis susceptæ, furto ex ipsis accipiantur, est distinguendum: Quoniam, vel ita sunt furto ablatæ, vt ipsi ex iuridica culpa, aut ex pacto, teneantur ad earum solutionem propriis dominis, vel ita vt non teneantur. Et rursus, vel adeò pauperes sunt, vt soluendo integre non sint propriis dominis, vel ita vt sint eis integre soluendo. Item, vel proprii domini præsentis sunt, ita vt exigere eas possint à fure, vel sunt absentes, aut aliter omnino impediti, ita vt exigere per se, aut per tertiam personam, eas non possint. Quando ita ex eiusmodi hominibus sunt furto ablatæ, vt ipsi teneantur eas soluere propriis dominis, tunc, quia ipsorum interest, non esse furto ablatas, eo quòd teneantur eas soluere propriis dominis, atque illas susceperunt, vt circa eas aliquid in suum commodum, saltem quoad mercedem recipiendam, exercere possent, ipsis competit actio furti, [[68]] vt sibi pecuniariam pœnam vsurpent, neque teneantur quicquam de ea reddere propriis illarum rerum dominis. Excipitur, nisi soluendo integre non sint earum æstimationem propriis dominis: nam tunc, sicut damnum, aut pars damni, imminet ex eo furto propriis carum rerum dominis, ita actio furti ad pœnam integram sibi vsurpandam, competit eisdem rerum earundem dominis. Vtrumque habetur expressè. *l. itaque fullo*, in prin. iunctis duabus legib. anteceditib. *ff. de furt. §. item si fullo inst. de obligationib. quæ ex delicto. l. ult. in prin. C. de furtis, §. l. 10. titu. 14. part. 7.* Quando autem ita ex eis hominibus essent furto ablatæ, vt ipsi ad nihil tenerentur earum dominis, tunc actio furti ipsis non competit, sed earum dominis, quorum interest non esse furto ablatas, si præsentis sint, atque agere possint, vt ex eisdem iuribus apertè colligitur, & affirmant Faber. §. item si fullo, citato, & cum eo *Greg. Lopez. l. 10. citata glos. 1.* Quando homines, ex quibus furto sunt ablatæ, non essent integre soluendo propriis earum dominis, tunc, si requisiti, vt furti actionem aduersus furem intentarent, easque conditione furtiua repererent, facere id nollent, aut, si præsentis non essent, vt id præstare possent, vtique illi, à quibus furto sunt ablatæ, intentare possunt furti actionem, atque, reddendo earum dominis res ipsas, aut illarum æstimationem, ad ipsos pertinet tota pœna pecuniaria furti. Vtrumque habetur. *l. 10 citata.* Illud verò hoc loco obserua, quando is, ex quo res furto sunt ablatæ, tenetur illas soluere earundem domino, integrum esse domino, siue is ex quo furto sunt ablatæ, siteas integre soluendo, siue non, vel petere illas à fureconditione furtiua, vel exigere eas ab eo, ex quo furto sunt ablatæ, actione ex locato, vt maluerit is, cuius res illæ erant: nisi expedientius iudicetur, vt priùs illas condicat à fure; nam tunc: si illas exigat ab eo, ex quo furto sunt ablatæ, poterit is ei excipere, seu opponere, vt priùs illas condicat à fure, sumptibus ipsius id excipientis, & vt, quando cas faciliè obtinere non poterit conditione furtiua, tunc illas ei soluet; iudexque debet id illi præcipere, si æquum iudicauerit ac expediens, vt ita fiat: semperque, quando æstimationem earum rerum obtinuerit ab eo, ex quo furto fuerunt ablatæ, tenetur cedere illi actiones suas; atque is, cui ita fuerint cessæ, poterit deinceps, loco ac nomine eius, cuius antea erant, agere aduersus furem conditione furtiua, vindicareq; res illas furto ablatas, ex quocunque, apud quem illas repererit, vt hæc omnia expresse habentur. *l. cum in plures. §. vestimenta. ff. locati, & consentiunt. l. 10. citata in fine, atque. l. ult. C. de furt, quæ addit, si semel dominus rerum eligat agere aduersus vnum, non posse mutare propositum, & agere potiùs aduersus alterum, si, sciens furtum, id faciat. Si verò, ignorans furtum, agat aduersus eum, ex quo res erant furto ablatæ, & postea sciat furtum, ad ipsumque spectet agere etiam ad pœnam furti, poterit tunc desistere agere contra eum, ex quo res fuerunt furto ablatæ, & intentare, etià actionem furti, aduersus furem ad pœnam, nisi iam accepisset ab illo alio integrum valorem suarum rerum: nam tunc ille alius solus agere posset ad pœnam furti sibi applicandam, vt habetur. *l. ult. C. de furtis.* Iuxta*

hæc, quando is, ex quo res furto sunt ablata, tenetur eas soluere illorum domino, habetque vnde integre eas illi soluat, integrum est domino agere aduersus furem cōdictione furtiua, & simul integrum est ei, ex quo furto sunt ablata, agere aduersus eundem furē actione furti ad integram pœnam ipsi soluendā: quin & simul agere poterit aduersus eum ad omnia damna, etiam lucri cessantis, quæ ipsi ex eo furto fuerint subsequuta, idque actione in factū, aut officio iudicis, vt, argumento. *l. si coloni. C. de agricol. & cēs. lib. 10. affirmat glossa vlt. l. & ideo. §. vlt. ff. de condict. furtiua*, quam Bart. Bald. & doctores communiter sequuntur. Quòd si dominus earum rerum non intentet aduersus surem conductionem furtiuam, tunc is, ex quo furto fuerunt ablata, agere simul poterit aduersus eū actione furti, atque actione in factum, vel iudicis officio, ad rem recuperandam cum fructibus, vel ad horum æstimationem, atque ad damna omnia, etiam lucri cessantis, ex eo furto subsequuta, iuxta glossam citatam, & doctores communiter. Neque video, cur non etiam agere possit conductione incerti ad ea omnia, vt de creditore, ex quo pignus est furto ablatum ab aliquo extraneo, dictum supra est agere posse eadē conductione, & *habetur expressè. l. & ideo. §. vlt. ff. de condict. furt.* Tametsi Accursius & alii nolint eam actionem illi concedere, imò neque officium iudicis, sed solam actionem in factum. Quando verò dominus earūdem rerum, actione locati ageret aduersus eum, ex quo res furto sunt ablata, vt eas, earūmve æstimationem, ipsi solueret, tunc videndum erit, num iuxta dicta ex. §. vestimenta, locum habeat exceptio, quòd eas, sumptibus excipientis, prius condicat furtiua actione: quòd si ea exceptio locum non habeat, sed earum æstimationem illi soluat, petere ab illo poterit, eumque cogere, vt sibi cedat actiones, quas ad easdem res condicendas habebat; atque, postquam illas ei cesserit, poterit agere vtili conductione furtiua, loco ac nomine domini, easque vindicare sibi, ex quocunque ac apud quem fuerint repertæ. Hæc eadem similiter locum habent, quando is, ex quo furto sunt ablata, tenetur eas soluere proprio earundem rerum domino, neque integre habet vnde eas illi soluat, dominusque agere non vult contra furem. Quando dominus eiusmodi rerum non est præsens, vt agere aduersus furem possit, tunc, siue ille, ex quo furto sunt ablata, teneatur domino rerum locati actione, siue non teneatur, potest, ac debet, agere aduersus furē, tum actione in factum, iudicisve officio, ad rem & damna, tum etiam actione furti, atque tunc tota pœna furti ad ipsum spectabit, & nihil illius ad dominum earum rerum, *vt habetur. l. 10. citata, & l. vlt. §. sed cum in secunda. C. de furt. & affirmat Greg. Lop. eadē. l. 10. verb. en el lugar, & verb. è la deue.* Ratio autem cur tunc agere possit, ac debeat, aduersus furem, est: quoniam alioquin sua negligentia perire posset res domino, aut ex mora transire posset in deteriore statum, ac proinde teneretur domino rei ad illius æstimationem locati actione. Ratio verò, cur tunc pœna ad ipsum pertineat, si furti actione simul agat, est: quoniā suo periculo eam intentat, ac proinde commodum ad ipsum solum pertinere debet, vt habetur. §. sed cum in secunda citato. Duo obserua. Primum est, in hoc Regno regulariter non habere hodie locum pœnam furti pecuniariam, vt **[[69]]** disputatione præcedente est dictum. Secundum verò, etiam quando is, ex cuius potestate res sunt furto ablata, non tenetur earum domino actione commodati, præsensque est ipsarum dominus, agere posse aduersus furem actione in factum ad damna lucri cessantis ipsi ex eo furto subsequuta, si quæ ex illo subsequuta ei sint, & dominus aget simul conductione furtiua, ac furti actione. Quod ad commodatarium attinet, de cuius [sect. 11] potestate res cōmodata furto fuit erepta, in primis est dicendū. Si absque vlla sua culpa furto fuit ex illo erepta, atque ita vt de re cōmodata non teneatur cōmodanti, tunc ad solum commodantem attinere agere conductione furtiua, itemque furti actione ad pœnam sibi applicandam, aduersus furem, non verò ad

commodatarium: nisi quando commodans esset absens, neque agere posset aduersus furem: nam tunc ad commodatarium attineret actione in factum repetere rem & dāna; quatenus, vi commodati, teneretur curare, ne res illa commodanti periret, aut in deteriore statum transiret, interim dum ei non esset reddita. Credo etiam agere posse actione furti, aut illam relinquere commodanti, vt postea eam intentet, quando de furto fuerit conscius, possitq; eam intentare: neque video, cur in hoc euentu pæna applicari debeat commodatario, qui non partes suas, sed commodantis agit. Deducere tamē commodans poterit expensas, in quibus cōputa industriam & laborem in agendo, in cōmodātis commodum. Item, si commodatarius iacturam aliquam ex eo furto est passus: saltem lucri cessātis, quia scilicet ob id furti ūpriuatus fuit vsu rei sibi commodatę, emolumētoq; ex eo vsu, quod, perseuerante contractu, erat percepturus, tunc ad id etiam poterit agere, Id quod locum etiam habet in euentibus mox explicandis. Hęc omnia ex se sunt satis perspicua, & ex proximè dictis circa conductorem, atque circa locatorem sui ad aliquid circa alienam materiam efficiendum.

Dicendum est deinde, quando cōmodatarius tenetur commodanti de re furto ablata, vel quia culpa commodatarii fuit ablata à fure, vel quia ex pacto appposito tenetur illam soluere commodanti, tunc integrum esse cōmodanti, vel agere aduersus commodatarium actione commodati, vel aduersus furem conditione furtiua & actione furti, & quodcunque elegerit, sciens rem furto esse ablatam, non potest postea pēnitere, relictaque vna actione, intentare alteram. Si tamen, ignorans, aut dubitans, rem esse furto ablatam, egerit aduersus commodatarium actione commodati, tunc, si postea comperiat rem furto esse ablatam, necdūq; estimationem rei commodatę acceperit à commodatario, desistere poterit ab actione cōmodati, quam aduersus cōmodatariū intētare cæperat, poteritque intentare cōditionē furtiuam, actionēque furti, aduersus furē, totaq; pæna furti ad ipsum tunc attinebit. Secus autem, si iam à commodatario acceperat estimationem rei commodatę: quoniam tunc non poterit intentare actionem aduersus furem, sed ad solū commodatarium spectabit, repetere rē furto ablatam, aut estimationē illius, & damna omnia, etiam lucri cessantis, subsequuta, atque agere actione furti ad integram pænam sibi accipiendam. Quando cōmodās eligere differt, num agere velit aduersus commodatarium actione cōmodati, vel potius aduersus furem, cōmodās petere à iudice potest, vt commodatario certum tempus præscribat, intra quod eligat, alioquin amittet ius agēdi aduersus furem, & spectabit ad commodatariū. Eo autem ipso, quod cōmodans eligit agere aduersus furem, manet omnino liber commodatarius, ita vt, esto commodans nihil à fure obtineat, commodatarius ad nihil cōmodanti teneatur. Si verò eligit agere actione commodati aduersus commodatarium, tunc cōmodatarius solus agere potest aduersus furem, tum ad rē & dāna, tum etiam actione furti ad pænam integram cōmodatario applicandā: cogereque poterit commodatē, vt cedat ipsi actiones, quas habet aduersus furem, eo ipso, quod ei soluerit estimationem rei commodatę. Hęc omnia habētur. *l. ult. C. de furt. §. quæ de fullone inst. de oblig. quæ ex delict. c. l. 11. tit. 14. part. 7.* Ratio autem, cur cōmodanti detur optio, vt, esto commodatarius sit integre soluēdo, possit agere aduersus furem actione furti; cū tamen nondetur domino rei locatę, aut domino rei, circa quam conduit operas alicuius, vt suprà est dictum; hęc est. Quoniam commodatarius rem accipit commodatam gratis: conductor verò, aut qui ad aliquid circa eam exercendū se locat, accipit illam pro certa mercede.

Quod ad depositarium attinet, dicendum est, [sect. 12] regulariter non competere illi actionem furti ob rem depositam furto ex ipso ablatam, quasi agere possit ad commodum pēnē ipsi applicandum, sed eam actionem competere domino talis rei. Ratio autem est, quoniam

regulariter ad ipsum non spectat periculum, sed ad dominum rei illius, si dolus depositarii non interueniat: quando autem dolus interuenit, non debet ex illo reportare commodum, vt ad pœnam sibi applicandam agere possit. Potest tamen agere ad rem recuperandam, vbicunque illam repererit: intellige actione in factum, & interim dum dominus non agit condictione furtiua. Vtrunque habetur. *l. 12. titu. 14. part. 7.* & est quasi expositio iurium communium, quę actionem furti denegant depositario, de quorum numero sunt. *l. eum qui. §. is autem ff. de furt. §. sed is. inst. de actionib. quę ex delict. l. 2. §. & generaliter. ff. de vi bon. rapt.* Quia tamen depositarius tenetur delata culpa, vt a dolo pressè sum pto distinguitur, affirmant Bart. & alii, quos Greg. Lop. *l. 12.* citata refert ac sequitur, tunc competere illi actionem de furto, intellige, si soluendo integre sit deponenti, aut si, quando integre non sit soluendo, deponens eligat agere potiùs actione depositi aduersus eum, quàm aduersus furem, condictione furtiua, furrique actione, & quando deponens non est præsens vt agere possit. Cùm autem, quando adest lata culpa, dolus præsumat in iure, fortasse iura, neque interueniente vero dolo, neque præsumpto, concedere voluerunt depositario actionem furti: atque sanè id sonant iura. Quando autem ex circumstantiis constaret, interuenisse latam culpam, sine vlla doli præsumptione, locum haberet Bart. opinio & aliorum. Vniuersim enim, quando dolus non interuenit ex parte depositarii, & sua interest, rem ex ipso non esse furto ablatam, quia retinere eam potest pro expensis, vt Greg. Lop. vbi suprà rectè ait, vel quia ex lata culpa, vt ab omni dolo distinguitur, tenetur deponenti, vel quia tenetur ex alia minori, vt quia ad id se obligauit, competit ei actio furti, *vt ha-[[70]]betur. l. eum qui. §. ult. ff. de furtis. l. 2. §. & generaliter. ff. de vi. bon. rapt. ac. l. 12. citata.* & consentit cōmunis doctorum sententia. Intelligo autem ei competere eam actionem in euentibus omnibus, in quibus illi competeret, si res ipsi esset locata, iuxta ea quę supra dicta sunt, quando actio furti competat conductori, eíve, qui circa rem alienam operam suam locauit: cùm enim depositum non sit in depositarii commodum, sicut commodatum in commodatarii est commodum, neque depositarius vsum rei depositę habeat, vt commodatarius vsum habet rei sibi commodatę, vtique, quando dolus ex parte ipsius noninteruenit, suaque interest rē non fuisse furto ablatam, quia tenetur de ea deponenti, eaque de causa furti actio quoad pœnā commodum ei conceditur, potiùs censendum est esse ei concessam iuxta regulas præsriptas ea in parte circa conductorem, quàm iuxta regulas præsriptas circa commodatarium, quando aliud non reperitur expressum in iure.

Quando ex œconomo aliquid domini esset [sect. 13] furto ablatum, aut ex tutore, vel curatore, aliquid minoris, tunc ait. *l. 12. citata,* competere his actionem furti: at meritò intelligit Greg. Lopez, non nomine proprio, sed domini, aut minoris, neque in commodum proprium, sed domini, aut minoris: quoniam. *l. qui iniurię. §. qui in alienis, & l. is cuius. ff. de furt.* eiusmodi hominibus, etiam si ex ipsis res eorum, quorum negotia gerunt, culpa ipsorum furto sint ablata, non conceditur actio furti nomine proprio: bene tamen eis conceditur furti actio nomine eorum, quorum sunt tales res, *vt habetur. l. interdum. §. qui tutelam. ff. de furt.* Quando tamen dominus rei exigeret rem suam à tutore, curatore, aut negotiorum gestore, cuius culpa esset furto ablata, non priùs teneretur eam ei soluere, quàm ipsi cederet actiones suas aduersus furem, atque ex eo puncto agere tutor, curator, aut negotiorum gestor, posset actione vtili furtiua aduersus furem, atque item furti actione in suum commodum proprium, *vt habetur. l. qui iniuria. §. qui alienis. ff. de furtis.*

Quod ad vsufructuarium in re mobili atti [sect. 14] net, si ea furto auferatur, diuiditur actio furti inter vsufructuarium, & proprietarium, vt vsufructuarius agere possit ad duplum, aut

ad aliā maiorem pœnam, si furtum sit manifestum, comparatione valoris vsusfructus ipsius, & proprietarius comparatione valoris rei, præcisè spectatæ à valore vsusfructus, seu deducto valore talis vsusfructus. *Ita habetur. l. inter omnes. §. si seruus, & sequentib. ff. de furt. & l. 12. citata.* Et pari ratione agere poterit proprietarius aduersus fructuarium furti actione præcisè quoad valorem rei, deducto valore talis vsusfructus, si vsufructuarius furetur proprietatem: & eodem modo agere potest vsufructuarius furti actione aduersus proprietarium, comparatione præcisè valoris vsusfructus, si proprietarius rem quoad vsumfructum ex vsufructuario furetur, *vt habetur. l. inter omnes. §. hæc actio. in fine.* Quando aliquis vsufructuarius est circa rem immobilem, cùm furtum locum non habeat circa eam rem in se, si quis fructus ex illa furetur, quia illi ad solum vsufructuarium attinebant, soli vsufructuario competit actio furti aduersus talem furem, *vt habetur. l. 12. citata*, resque ex se est satis perspicua.

Quando aliquis colit agrum alienum, eum se [sect. 15] minando, est distinguendum. Quoniam, si mercede certa soluenda, vel in pecunia, vel in tritico, vel in alia simili re, eum colat, ita quòd fructus omnes collecti ad eum pertineant, solumque mercedem certam soluere teneatur domino agri, tunc, licet dominium fructuum ad ipsum non pertineat interim dum non sunt percepti, sed, vnà cum agro, tanquam partes illius, ad agri dominum attineant, qui tamen statim ac percipiuntur, à soloque separantur, ad colonum spectant quoad dominium, vtique, si quis eos furetur ex agro, actio furti pertinet ad solum colonum, non verò ad dominum agri, vt de vsufructuario agri, propter eandem rationem, paulo antea est dictū, idque perspicuè habetur. *l. eum qui. §. præterea. & l. apes. §. vlt. ff. de furtis.* Si verò sit aliquis colonus particiarius, ita quòd agrum colat, & semen apponat, atque industriam, & certa quota fructuum, qui percipientur, ad dominum agri spectet; tunc, quia est vera societas inter illos, & statim ac fructus ex agro separantur, pro indiuiso pertinent ad vtrunque quoad dominium, interim dum inter ipsos facta non est eorum diuisio; sanè, si quis aliquid ex illis furetur, tam ad dominum agri, quàm ad eiusmodi colonum, pertinet actio furti aduersus talem furem, vnicuique eorum pro parte fructuum, quæ ad ipsum spectat, vt expressè habetur. *l. fullo. §. frugibus. ff. de furt.* Quando autem dominus sibi coleret agrum, & apponeret sementem, colono aliquo apponente industriam, pro qua acciperet quotam certam fructuum, qui perciperentur, vt sæpe fieri solet, quod est, conductum habere colonum pro ea mercede; tunc, si quis furetur fructus, antequam diuidantur inter dominum agri, & talem colonum, quia simpliciter quoad dominium pertinent ad dominum agri, tametsi colonus ius habeat ad partem pro indiuiso eorum fructuum, meritò statuerunt iura, vt in hoc euentu ad dominum agri, & non ad colonum, pertineret conditio furtiua aduersus furē, & vt colonus posset cogere dominum, vt ex fure condiceret eos fructus, & ipsi tribueret partem suam, & fortasse etiam partem pœnæ furti, deductis expensis. Atque hoc solum est, quod habetur. *l. cùm in plures. §. mēsem. ff. locati*, in hocq; solo euentu intelligo. *l. 12. titu. 14. part. 7.* quæ idē statuit, & ita consentiunt inter se iura omnia citata, quæ ad inuicem pugnare videbantur.

Quando res erat vendita, & nondum tradita [sect. 16] emptori, si furto auferatur absque culpa venditoris, tenetur venditor, vel agere conditione furtiua aduersus furem, furtique actione, vt emptori restituat rem & damna, & insuper emolumentum pœnæ furti, quod fuerit consequutus à fure, vel cedere emptori actiones ad hæc omnia, vt venditor maluerit. *Ita habetur. l. eum qui, in prin. l. si vendidero. ff. de furtis. l. quod sæpe. §. si res, ff. de contr. empt. l. si ea res in prin. ff. de act. emp. l. 13. titu. 14. part. 7.* & aliis iuribus. Atque, si actiones ei cedat, eo ipsi competit emptori utilis conditio furtiua, non verò dominium rei emptæ, quia hoc sine traditione ei non competit. Tenetur verò venditor ad alterum illorū duorum,

quoniam, cū emptor per eam emptionem non comparauerit dominium, sed adhuc [[71]] perseueret penes venditorem, neque de potestate ipsius res sit furto ablata, sed de potestate venditoris, solus venditor agere tunc potest aduersus furem, nisi actiones emptori cedat: cū tamen, si res sine culpa venditoris tunc pereat, emptori pereat, & non venditori, iuxta ea quæ Disputat. 366. dicta sunt: quare interesse totum, etiam pænæ furti, attinere debet ad emptorem, sicut & furti periculum totum ad eundem emptorem in eo euentu pertinet, idq; vel agente venditore (qui expēsas extrahere debebit, cū in commodum solius emptoris tunc agat) ad ea omnia, vel cedente emptori actiones, vt ad ea omnia agere possit. Quando autem res culpa venditoris furto fuisset ablata, tunc venditor teneretur emptori de omnibus damnis, etiā lucri cessantis, ex eo furto ei subsequutis, quæ ex fure non recuperaret: neque satis esset actiones ei cedere, vt constat ex. l. si ea res in prin. iunctis tribus glossis à verb. non solūm. ff. de actionib. empt. Totam autem hanc doctrinam intelligo, quando ita erat venditio consummata, vt periculum rei venditæ ad emptorem spectaret, iuxta ea quæ Disp. 366. dicta sunt: quando autem non ita esset consummata, sed periculum ad venditorem attineret, iuxta ea quæ eisdem disputationibus explanata sunt, ad venditorem pertineret agere aduersus furem, ad eumque spectaret emolumentum pænæ, sicut ad ipsum solum pertineret tunc damnum totum ex eo furto.

Quando solūm res aliqua esset alicui promissa, [sect. 17] etiam si promissio esset stipulatione vallata, & antea quā ei traderetur, furto esset ablata ex potestate promissoris, tunc ad promissorem spectaret agere aduersus furem conditione furtiua, & actione furti: satisfacereque ei, cui illam promiserat, tradendo illi rem promissam, aut æstimationem illius; non tamen teneretur tradere ei aliquid de pæna surti, etiam si per promissorem stetisset, quo minùs eam illi traderet tempore congruo. *Ita habetur. l. is cui ex stipulatu, & l. is cuius interest. vers. vlt. ff. de furt. & l. 13. ci tata.*

Quando res alicui est legata, & post mortem [sect. 18] testatoris est furto ablata, omnes consentiunt, competere legatario actionem furti aduersus furem ad commodum pænæ, quando furtum post mortem testatoris commissum fuit: nam eo ipso, quòd legatarius legatum rei determinatæ in singulari sibi relictum acceptat, sensetur comparasse dominium illius à puncto mortis testatoris, ac proinde tale furtum commissum est aduersus ipsum, quando iam dominium eius rei comparauerat: atque, quòd tunc actio furti ad ipsum spectet, habetur expressè. *l. si. dominium. ff. de furtis. & l. 13. citata.* Vtrū autem ei tunc conditio furtiua competat, an verò solūm rei vindicatio, tanquam domino iam tunc eius rei, &, in rei defectum, actio ad æstimationem illius, disputatur. l. sed nec, iuncto. §. vlt. legis antecedentis. ff. de condict. furtiua, atque plerique affirmant, solūm competere ei rei vindicationem, non verò conditionem furtiuam, ducti. l. sed nec citata. Ego verò contrarium existimo esse verum, nempe competere ei, etiam conditionem furtiuam ad interesse, & ad damna omnia, vt postulat natura ipsa rei, eo quòd furtum commissum sit post comparatum ab eo legatario dominium eius rei; & consentire videtur. l. 13. citata. vt ibi Greg. Lop. expendit: neque refragatur. l. sed nec, citata, iuncto. §. vlt. legis antecedentis. Ibi enim solūm est sermo de furto rei testato ris, commissio ante ipsius mortem, definiturque, conditionem furtiuam aduersus furem circa eam rem competere testatori, & hæredibus illius, post eius mortem, si res ad ipsos spectet; eo quòd repræsentent personam defuncti, actionesque actiuæ, & passiuæ, defuncti ad eos pertranseant: non verò competere illis, ad quos transiuit dominium illius rei facto testatoris, etiam si institutione legati transeat ad legatarium, sed his tantūm competere rei vindicationem. Atque tunc arbitror, quamuis legatario solūm competat vëdicatio eius rei

furto ablatae, si tamen testatori aliquod damnum fuit sequutum ex eo furto, putà fructuum, aut aliud, si illud expressè aut tacitè non remisit furi, posse hæredes, tanquam successores defuncto in omnibus actionibus, quæ ei competeabant, agere aduersus furē, ad eos omnes fructus ac damna, ad ipsos loco defuncti attinentia. Non verò est in ea lege sermo de furto commisso postquam dominium illius rei, facto ipsius defuncti, transiuit in legatarium, aut in quemcunque alium, vt intuiti eam legem est perspicuum, neque recta ratio, naturaquæ ipsa rei, patiebantur, vt id ita statueretur.

Illud est obseruandum circa hactenus dicta [sect. 19] tota hac disputatione, quamuis actio bonorum raptorum regulariter solùm concedatur iis, quibus furti actio concederetur, si in ea iniusta vsurpatione vis non interueniret, *vt habetur. l. 2. §. & generaliter. ff. de vi bonor. rapt. & §. ult. inst. eod. titu.* nihilominus facilius esse concedendam vim passis, actionem bonorum raptorum, quando aliquo modo sua refert rem ex ipsis non esse ereptam, quàm concedatur actio furti, ita vt minus interesse eorum sufficiat ad actionem bonorum raptorum eis concedendam, quàm requiratur ad concedendam actionem furti pressè sumpti, vt à rapina distinguitur, vt duobus iuribus citatis subiungitur ac innuitur.

Illud addo, quando in rapina rei, de [sect. 20] potestate eius, qui illam tenet, iniuria aliqua personalis interuenit, tunc, esto nihil referat res illa eam tenenti, ad ipsum tamen spectare actionem iniuriarum aduersus raptores, & non ad dominum rei: ad quem solùm spectabit suorum bonorum raptorum actio.

De damno iniustè indebitè dato. Disputa. 697.

SVMMARIVM.

1. *Damnum in rebus externis indebitè, hoc est, culpa saltem iuridica datum, ex qua illud dans teneatur, quid.*
2. *Oritur interdum a damno dato in corpore, honore, aut fama.*
3. *Licèt distinctum quid sit à furto, & rapina, ex eis interdum oritur, & cum eis est coniunctum.*
4. *Damna quæ absque iuridica culpa, quorum proinde ratione non competit actio legis Aquiliæ.*
5. *Damnum datum in domo vicina ei, quæ exurit, ne incendium illam & alias destruat, [[72]] resarcire, contribuerè ad illud soluendum, non tenentur illi, in quorum commodum id cedit.*
6. *Damnum, quod vi tempestatis, aut alia ratione, vnum nauigium dat in alio, aut in quacunque alia re, sine culpa moderatorum, resarciendum non est: secus si culpa eorum interuenit.*
7. *Damnum, quod carens usu rationis dat, quin & puer infantie proximus, resarciendum non est. Quando tamen puer post septennium damnum daret culpa theologica, lethali præsertim, licèt non competeret actio legis Aquiliæ ad pœnam, resarcire tamen illud tenetur in conscientie foro.*

- 8 . *Damnum etiam si culpa leuissima detur, competit pro eo actio legis Aquiliæ. Et quando maior culpa, quam leuissima, requiratur.*
- 9 . *Damnum ex eo, quòd culpabili omissione detur, non indiget maiori culpa, vt pro illo competat actio legis Aquiliæ, quam si facto culpabili daretur. Tametsi iura actionem ob omissionem culpabilem appellent vtilem legis Aquiliæ, & non directam, & cur ita eam appellent.*
- 10 . *Damnum, quod dat inuasus sine sua culpa inuasori, aut alicui tertio, non tenetur resarcire. Iniustus tamen ag gressor tenetur de illo lege Aquilia tertio illi. Si interuenit leuis culpa inuasi in eo dando inuasori, non tenetur illi resarcire illud. Si vero interueniat in eo dando cuidam tertio, nec inuasor illud restituat, tenetur ipse id illi resarcire.*
- 11 . *Damnum datum ex militum exercitio valde periculoso in loco, ad id deputato, resarcire non tenetur miles, nisi de alia eius culpa constet: secus si alibi illud det. Et quando damnum cursu equorum datum lege Aquilia sit resarciendum, quando non item.*
- 12 . *Damnum, quod ex ludo, aut ex impulsione, prouenit, quando & a quo lege Aquilia resarciendum, quando non item.*
- 13 . *Damnum datum immoderata ac irrationabili castigatione disciplinæ gratia, lege Aquilia est resarciendum.*
- 14 . *Damnum dans scindendo arbores, aut aliud diruendo, vel ejiciendo, quando lege Aquilia teneatur illud resarcire, quando non.*
- 15 . *Damnum datum ex domibus aque deiectione sine sufficienti præmonitione, aut alterius rei, quæ nocere possit in vestibus, corpore, aut in alia re, soluitur duplum, & in defectum eius, qui illud dedit, soluit id caput eius domus.*
- 16 . *Damnum sequutum ex foueis, & instrumentis paratis ad capiendas feras, quando lege Aquiliæ resarciendum, quando non item.*
- 17 . *Damnum datum à bestiis feris, quæ incautè ducuntur per vias, aut ligatæ tenentur, quo usque resarciendum, ac puniendum, & quando pænæ dupli soluendum.*
- 18 . *Damna sequuta ex eo, quòd quis misericordiæ motus, soluat seruum, quem dominus ligatum tenebat, resarcit lege Aquilia. Si verò ex odio domini, aut alia sinistra intentione, illum soluerit, tenetur exfurto.*
- 19 . *Damna sequuta iudicum, collectorum tributorum, & aliorum ministrorum publicorum culpa circa pignora & alia, resarcire illa tenentur lege Aquilia.*
- 20 . *Damna data in aliorum prædiis pecudibus, aut armentis, de industria, diuersimodè puniuntur iure communi, Castellæ, ac Lusitano.*
- 21 . *Damna eadem si de industria custodis absquo domini culpa sint data, totum damnum & pœnam tenetur soluere custos. In defectum verò illius, dominus animalium solum tenetur soluere damnum, vel tradere pro illo animalia noxæ. Ad idem tenetur, si culpa leui custodis sit datum. Si verò leuissima aut nulla pastoris culpa sit datum, custos ad nihil tenetur, dominus verò ad alterum duorum, quæ dicta sunt, tenetur.*
- 22 . *Damnum datum animali reperto damnum dando in alieno prædio a domino prædii, restituendum est quoad excessum, quod tale animal dedisset. Si autem missum de industria*

fuiſſet, vt id dānum daret, compensari in hoc regno poſſet etiam duplum damni ab eo animali dati. Licitum autē eſſet ſtatutum, quo domino prædii concederetur id animal occidere.

23 . Damna ſequuta animali reperto in prædio alieno, ex eo quòd id animal excludatur, quo uſquæ ſoluenda, & quatenus prohibitum ſit tale animal includere.

24 . Damna mercibus, aut nauì, ex eo ſequuta, quòd quis ſua culpa nauem perforaſſet, lege Aquilia reſarcienda ſunt.

25 . Damna ſequuta ex aduſtione, permixtione vino, tritico, etiam ſeminato, aut alteri rei, lege Aquilia reſarciuntur.

26 . Damnum in mancìpio ex eo ſequutum, quòd quis illi ſuaſit, vt ſe exponeret alicui periculo, vel quòd illud impulerit, vel aliter fuerit illi cauſæ, aut occaſio damni, lege Aquilia reſarcitur.

27 . Damnum ex eo ſequutum, quòd quis canem cõcitet in aliquem, aut ferocem canem ſoluit vt noceat, vel illum deſerat, non valendo illum comprimere, ſimiliter eſt reſarciendum. Et quando idem ſit dicendum de cane feroci inſeruiente ad cuſtodiam, quando non item. Idem de damno ſequuto ex concitatione, ſeu irritatione alterius beſtiæ, quæ nocere ſoleat.

28 . Damnum ſi idcirco ex animalibus ſequatur, quòd quis imperitus ſit illa regere, aut non valeat impetũ eorum continere, ſimiliter eſt reſarciendum.

29 . Damna ex eo ſequuta, quod quis animalia aliena fugauit, aut ita vrſit, vel minatus eſt, vt præcipitarentur, diſparerent, aborſum facerent, aue aliud detrimentum acciperent, vel ipſa inferrent, ſimiliter eſt reſarciendum.

30 . Damnum occiſionis mancìpii alieni culpa ſaltem leuiſſima, aut pecudis alienæ, reſarcitur lege Aquilia ſolutione ſupremi valoris, quem ea res habuit intra annum retro, uſque ad punctum occiſionis. Et quid pecudis nomine quoad hoc intelligatur.

31 . Damnum quodcunque aliud datum eidem mancìpio, aut pecudì, & vniuerſim quodcunque aliud damnum quibuſcunque aliis rebus culpa datum, reſareſtur lege Aquilia in maiori valore, quem ea res habuit triginta diebus uſque ad punctum talis damni dati.

32 . Damnum ſi ſufficienter probetur fuiſſe culpabiliter ab aliquo datum, ſtatur, quo ad æſtimationem illius, iuramento eius, cui datum eſt, accedente iudicis arbitrio ac moderatione.

33 . Lex Aquilia, quoad exceſſum vltræ damnum culpa datum, pænalis eſt, neque quo ad illum obligat, niſi quando poſt latam ſententiam exigitur. Neque transit aduerſus hæredes, niſi liſ fuerit conteſtata cum eo, qui damnum dedit: neque competit hæredibus eius, qui damnum eſt paſſus, niſi fuerit conteſtatus litem, aut illam præparauerit.

[[73]] 34 Lex Aquilia, quo ad damnum culpa Theologica datum, pænalis non eſt, transitque aduerſus hæredes eius, qui damnum ita dedit, & ad hæredes eius, qui damnum eſt paſſus.

35 Damnum culpa datum eſt reſarciendum lege Aquilia & in foro conſcientiæ, etiam quod inde vltèriùs euenit. Vt ſi interfecit ſeruum tibicinem, & inde ſequitur, quòd alii ſerui tibicines ſine illo minùs valeant.

36 Damnum datum ſi quis coram iudice neget, & conuincatur poſtea teſtibus, cogitur & damnum & pœnam legis Aquiliæ ſoluere duplum: ſecus ſi ſua confeſſione, etiam iuramento ei adhibito, conſtet. Minor in integrum reſtituitur, vt non ſoluat duplum. Maritus verò ſi

de damno dato in bonis uxoris, aut vxor in bonis mariti, convincatur, solùm soluunt simplex damnum, sine vlla prorsus pœna.

37 Damnum dedisse si quis sit confessus, & postea probet, nullum tale damnum fuisse datum, absoluitur. Si verò id damnum fuerit datum, esto probet se illud non dedisse, non absoluitur, nisi probet quis illud dederit.

38 Damnum si datum sit concurrentibus multis, occidentibusq; seruum alienum, aut animal aliud alienum, nec constet ex cuius vulnere interierit, qualiter ciuiler competat actio legis Aquiliæ aduersus omnes aut singulos.

39 Furtum eiusdem numero rei si tres simul committant, quæ condictio furtiua aduersus omnes ac singulos competat, & quæ actio furti ad pœnam ciuilem ac criminalem.

40 Irregulares sunt censendi omnes, qui concurrerunt ad idem homicidium, quando dubium est, quis illorum interfecerit.

41 Damnum datum mancipo ex vulnere lethali vnus, superueniente postea vulnere alterius, quo mortuum fuit, sic lege Aquilia resarciendum est: Quòd prior tenetur de seruo vulnerato, quantum seruus plus valuit intra triginta dies usque ad vulnus inflictum, æstimatum quanto minus valet cum eo vulnere, totamque eam æstimationem soluere tenetur, & insuper expensas & damna usque ad posterius vulnus. Posterior verò soluere tenetur, si quid plus valuit intra annum usque ad mortem, & quod valebat accepto eo vulnere tempore, quo interfecit. Idem de priori est dicendum, si mancipium post vulnus acceptum, ruina, aut alio infortunio intereat. Tenetur verò de mancipo mortuo, si legatum fuit, aut si fuit manumissum, post vulnus inflictum.

42 Irregularitatem vterque incurrit, si vnus lethaliter priùs percussit, & postea alius interfecit. Erit autem in vtroque ea irregularitas ex homicidio voluntario, si vterque formaliter aut virtute intersicere intendit.

43 Damnum si datum sit vulnere in mancipo, quando vulnus non erat lethale, & mancipium ex mala curatione aut aliunde interiit, non tenetur, qui vulnus inflixit, de mancipo occiso, sed solùm de vulnerato.

44 Damni dati ratione actio, quæ competit domino, & hæredibus illius quo ad damnum, & quoad pœnam, si lis à domino fuerat contestata, quatenus competat etiam usufructuario, vsuario, possessori rei bonafide, depositario, conductori, & commodatario.

45 Damnum pignori si sit datum, lege Aquilia agit debitor, cuius est. Et quando creditor agat.

46 Damnum si datum sic in seruo legato in singulari (idem de quacunque alia legata in singulari) post delatam hæreditatem, & ante eam aditam, vel post illam aditam, ad quem actio legis Aquiliæ ratione eius damni attineat.

Dicendum deinde est de damno, vt à furto & [sect. 1] rapina distinguitur, iniustè, indebitè, hoc est culpa saltem iuridica dantis, ex qua teneatur, dato. Atque sic possumus illud describere; *Est iactura data in rebus externis alicuius, absque earum usurpatione, culpa saltem iuridica eam dantis, ex qua legum præscripto teneatur.* Nomine autem iacturæ comprehenditur destructio rei in totum, aut ex parte, & quæcunque alia deterioratio, vndecunque proueniat, siue ex permixtione, siue ex quacunque alia causa, atque etiam lucrum cessans.

Per particulam, in rebus externis alicuius, [sect. 2] rejiciuntur à ratione damni dati, de quo nunc loquimur, iacturæ, & læsiones, indebite datæ, in propria proximi persona, aut in honore, vel in illius fama, de quibus agere ad duos sequentes tractatus pertinet. Si tamen ex his læsionibus, iacturis, ac damnis, sequatur iactura in rebus externis, vt quia ex vulnere necesse fuit insumere in medicinis, chirurgis, ac medicis, cessare à labore ac lucro, vel quia ex vulnere, qui illud est passus, ineptior manet ad deinceps laborandum ac lucrandum, tunc hæ, & similes aliæ iacturæ in rebus externis, inde profectæ, ad iacturam & damnum, de quo nunc loquimur, spectant, atque in definitione tradita comprehenduntur. Vtrūque iniuriæ ac læsionis genus explicatur. *l. sed & §. iniuriam. ff. ad leg. Aquil.* & quòd solùm secundum genus ad præsens attineat institutum, atque quòd secundum genus coniunctum esse possit cum primo, & ab illo deriuari. Quòd autem damnum interdum sumatur pro solo secundo iacturæ genere, vt de eo nunc loquimur, constat ex. l. 3. ff. de damno infecto, vbi *Paulus iuris consultus* sic ait: *Damnum ab ademptione* (vbi glossa ait, melius dixisset à perditione) *& quasi diminutione patrimonii dictum est.*

Per particulam, absque earum vsurpatione, [sect. 3] rejiciuntur à ratione damni dati, de quo loquimur, furta & rapinæ, quæ sunt damna in vsurpatione iniusta rerum externarum aliorum consistentia. Si tamen cum ea vsurpatione iniusta coniuncta sit iactura alia in rebus externis proximi, culpa id vsurpantis, quæ non in vsurpatione consistat, vel ex tali vsurpatione sequatur, tunc illa, etiam si sit lucri cessantis, ad iacturam & damnum, de quo nunc loquimur, attinebit.

Per particulas denique, culpa saltem iuridi [sect. 4] ea eam dantis, ex qua legum præscripto teneatur; rejicitur iactura omnis in rebus proximi data absque tali culpa. Eiusmodi in primis est iactura in rebus proximi data bello iusto: quia enim in ea danda nulla interuenit culpa, ad dānum datum, de quo loquimur, non spectat. Atque cum hac est coniuncta, quam quis dat aduersario, se, aut sua, tuendi gratia, cum moderamine inculpatæ tutelæ: neque enim in ea vlla est culpa, eo quòd sit quasi bellum iustum se eo modo defendentis; eaque ratione, cū actio legis Aquiliæ competat pro damno dato à nobis definito, pro eiusmodi iactura, seu damno, non cōceditur, *vt habetur. l. scientiam. §. qui cū aliter. ff. [[74]] ad leg. Aquil.* redditurque ibi hæc ratio; *Vim enim vi defendere, omnes leges omniaque iura permittunt;* idemque statuitur. *l. 3. titu. 15. part. 7.* cum eadem est etiam coniuncta iactura, quam iudex dari præcipit in exequutione iustæ suæ sententiæ, aut mandati sui iusti, quando aliqui resistunt, atque, vt exequutio sortiatur effectum, id iudicatur necessarium, aut expediens: est enim similiter quasi bellum iustum ex parte iudicis, suorumque ministrorum, quin & in pœnam iustam ita resistentium, id absque culpa præcipi potest. *Ita habetur. l. quemadmodum. §. penul. ff. ad leg. Aquil. & l. 4. titu. 15. part. 7.* Quando item ignis peruenit ad domum aliquam, ita vt, si non destruatur, etiam in parte, ad quam nondum ignis deuenit, periculum est, quòd domus proxima, aut fortè etiam aliæ exurentur; tunc, siue præcepto iudicis ea domus ob talem causam destruatur, siue à domino vicinæ domus, aliis ad id cooperantibus, vtique iactura ita data in domo proximi, quæ iam ardebat, atque ab igne consumebatur, non spectat ad damnum, de quo agimus: quoniam datur absque culpa, ex iusta causa, atque in commune bonūviciniæ ac oppidi, eaque ratione, neq; competit aduersus destruentes actio legis Aquiliæ ad pœnam, neque etiam ad interesse, *vt habetur. l. si quis fumo. §. ult. ff. ad l. Aquil. l. si alius. §. est & alia exceptio. ff. de præsci. ver. & l. 12. ti. 15. pa. 7.*

Vtrū autem tunc contribuere teneatur vi [sect. 5] cinia, ac oppidum, ad compensandum damnum ita absque culpa datum domino destructæ domus, pro vtilitate, ac æstimatione,

vationis periculi cuiusq; vicini? quemadmodum, quando merces projiciuntur in mari, ad nauem & cæteras merces, quæ in ea deferuntur, conseruandas, illi, quorum bona ea ratione conseruâtur, contribuere tenentur, vt Disp. 365 dictum est? Neganter, meo iudicio, est respondendum: quando non esset statutum in aliqua ciuitate, aut prouincia, in contrarium: quoniam id apertè sonant iura citata: & quoniam iam domus illa exurebatur ac consumebatur igne: ac quoniam id iustè statui potest in bonum commune, eaque lex communis est & æqualis omnibus ciuibus; cùm sicut domus vnius exuri possit, ita & cæterorum, omnesque proinde, antequam quicquam eueniat, æquè gaudent commodo, & damno, illius legis: & denique, quoniam difficilè admodum posset definiri, qui, & quantum, singuli ad id damnum contribuere deberent; quod non cernitur in naui, & in asportantibus merces in ea, quando quædam merces projiciuntur in mare, ad nauem & ad cæteras merces conseruandas. Atque nobiscum hac in re conuenire videtur communior doctorum sententia, quam Greg. Lop. l. 12. citata refert, & in quam propendêre videtur.

Præterea, quando nauigium, quod anchoris [sect. 6] tenebatur, aut quo nauigabatur, absque culpa domini, aut moderatorum illius, vi tempestatis, aut aliqua alia ratione, impegit in aliud nauigium, illudq; submersit, aut aliud damnum ei, retibus, in portu, aut in mari expansis, aut cuiuis alteri rei, dedit, tunc, sicut ei damno non competit definitio tradita, ita neque est damnum, de quo modò loquimur, neque pro eo conceditur actio legis Aquiliæ ad pænam, neque ad illud compensandum: idemque est de quocunque alio simili damno, quod absque culpa obuenit, datûmve est. *Ita habetur. l. quemadmodum. §. si nauis tua, & sequentibus. ff. ad leg. Aquil. l. 14. titu. 15. part. 7.* Secus autem esset, si culpa eorum aliquid tale obueniret: nam tunc tenerentur id damnum resarcire, vt ex eisdem iuribus, argumento à contrario sensu, constat, & ex se est satis perspicuum.

Eadem ratio ne damnum, quod furiosus, aut [sect. 7] quicunque alius vsum rationis non habens, dat, cùm culpa careat, non comprehenditur sub eo, de quo nunc loquimur, neque pro eo vlla competit actio. Idemque est dicendum, non solùm de damno, quod infans dat, sed etiam de eo, quod dat puer infantie proximus, hoc est qui decimū annum cum dimidio non excedebat. Hæc omnia habentur. *l. 5. §. igitur iniuriam. ff. ad leg. Aquil. & l. 3. titu. 15. part. 7.* Quamuis autem pro damno, quod puer à septimo suæ ætatis anno vsque ad decimum cum dimidio dat, non concedatur actio legis Aquiliæ; credo tamen, si cum culpa Theologica, lethali maximè, illud det, teneri in conscientie foro illud integre restituere: quoniam iure naturali ad id tenetur ratione culpæ Theologicæ, iniustæve acceptionis.

Ad damnum de quo nobis hoc loco est ser [sect. 8] mo, pro quo competit actio legis Aquiliæ, satis est, si datum sit culpa iuridica, etiam si non interueniat culpa Theologica, sufficitque culpa leuissima, *vt habetur. l. in lege Aquilia. 2. ff. ad leg. Aquil. & §. iniuria inst. de leg. Aquil. consentitq; c. vlt. de iniuriis & damno dato.*

Obseruat verò optimè Couar. in. 4. decretal. part. 2. c. 6. §. 8. n. 14. cum Carolo Molinæo, tunc aliquem lege Aquilia ex culpa leuissima teneri, quando natura actionis, seu facti, quo damnum datur, pro quo competit actio legis Aquiliæ, id exposcit, seu patitur, & non aliàs. Hoc sequentibus exemplis elucido. Quando quis locauit suas operas ad aliquid, in commodum ipsius locantie ac conducentis, vtique, cùm ex eo contractu non teneatur de culpa leuissima, sed solùm de leui, proculdubio, si tali actu damnum det in re, circa quam se locauit, tunc, sicut non tenetur locati actione de culpa leuissima, sed solùm de leui, ita neque actione legis Aquiliæ tenetur de culpa leuissima, sed de sola leui. Hinc, qui pretio curat, aut patrocinator in aliqua causa, aut pannos tingendos, abluendos, aut aliquid aliud

circa illos, aut circa aliam materiam, pretio exercendum, accepit, si aliquod damnum inferat eis actibus, aut aliqua omissione, circa eas res, vel inde vltteriùs conductoribus damnum sequatur, non teneri lege Aquilia de culpa leuissima eius damni, sed solùm de culpa leui: secus autem, si aliquo alio actu, qui ad eum contractum non spectet, damnum det: nam tunc non est melioris conditionis ea in parte, quàm sint cæteri. Ad eum verò contractum spectat cura custodiendi aliquam rem; eaque de causa, neque circa custodiam tenetur nisi de culpa leui. Item, quia quando aliquid fit in commodum tantùm alterius, tunc, qui illud exercet, solùm tenetur de dolo ac lata culpa, non verò de leui, aut leuissima, nisi aliud deductum sit in pactum, aut lege est sancitum, vtique, quādo aliud in pactum non est deductum, neque lege aliud est sancitum, si exercendo eum actum, aut omissione aliqua, damnum sequatur ei, in cuius commodum fit, culpa leui, aut leuissima, id exercentis, non tenetur lege Aquilia de tali damno. Hinc, si medicus gratis curet, aut aduocatus gratis patrocinetur, vel aliquis alius gratis exer-[[75]]ceat aliquid in bonum alterius, atque eo facto, aut omissione aliqua, damnum ei inferatur, in cuius commodum fit, non tenetur inferens lege Aquilia, nisi dolo, aut lata culpa, datum sit. Hac eadem ratione, qui ex sola caritate confessiones audit, si aliquod damnum omissione aliqua, aut errore deceptus, det confessiones audiendo, neque præcipiendo id restitui, quod restituendum erat, non tenetur de leuissima, aut leui, culpa, sed solùm de dolo, aut de culpa lata.

Iuxta hæc intelligenda sunt, quæ traduntur. *l. qua actione. §. vlt. & l. sequenti in prin. ff. ad legem Aquil. §. præterea inst. eod. titu. & l. 9. titu. 15. part. 7.* nempe, si medicus, chirurgus, veterinarius (nostri *alueitar* vocant) per imperitiam artis, aut temeritate, aliquid circa homines, aut iumēta, quæ curanda accipiunt, efficiant, vel omittant ob negligentiam, aut aliqua alia ratione, vel si deserant curationem cæptam, absque iusta causa, suæque proinde culpa moriatur mancipium, quod curandum accepit, vel iumentum, quod veterinarius curandum suscepit; aut damnum ac detrimentum ea de causa eueniat, teneri ad ea damna, tum actione legis Aquiliæ, tum etiam ex locato, vt habetur. *l. qua actione. §. vlt. citato, & aliis iuribus*, vt agere maluerit eligere, qui id damnum est passus: idemque est de damnis, quæ simili modo obuenerint hominibus, liberis, quos medicus, aut chirurgus, curandos susceperint: & qua pæna teneantur, si culpa ipsorum intereant, tanquam eorum homicidæ, dicetur tractatu sequenti. Hæc, inquam, intelligenda sunt, iuxta doctrinam traditam. Sicut enim actione locati solùm tenentur ad ea damna, si ex culpa leui, non verò ex leuissima, obueniunt, & quando gratis quis operam suam adhibebat, consentiente eo, cui impendebatur, solùm tenetur de dolo & lata culpa: ita si legis Aquiliæ in eisdem euentibus ob damna subsequuta actio intentetur, non tenebitur quis de minori culpa, consentitque ex parte glossa. *l. idem iuris in prin. ff. ad leg. Aquil.* Idem intellige de obstetricibus, quæ potiones dant ad concipiendum, & ad alia, & de aliis imperitis, qui vnctiones & medicamenta adhibent: tametsi in his plus præsumenda sit culpa leuis, aut maior, damni inde sequuti, proptet temeritatem maiorem in illis applicadis, eo quòd imperiti sint artis medicinæ, consentit. *l. item si obstetrix. ff. ad leg. Aquil.*

Conar. in. 4. decret. part. 2. c. 6. §. 8. n. 13. Maranta [sect. 9] de ord. ind. part. 4. dict. 1. n. 71. & alii quos referunt, tradunt etiam aliam limitationem dispositioni legis in lege Aquilia. 2. ff. ad leg. Aquil. quæ actionem tribuit legis Aquiliæ etiam pro damnis culpa leuissima ea dantis subsequutis, vt ea dispositio intelligatur, quando culpa leuissima consistit in facto, quo ea damna inferuntur, quid scilicet culpa, saltem leuissima, est effectum: secus autem quando culpa leuissima consistit in omissione facti alicuius, quòd si omissum non esset, ea damna

non essent sequuta. *Maranta. n. 71.* citato id confirmat ex. *l. si cuius. §. denique consultus. ff. de vsufructu*, vbi dicit esse textum expressum. In eo verò textu, reddendo rationem, cur, nihil impediens, quòd fructuarius teneatur proprietario lege Aquilia de damnis, quæ proprietati sua culpa dederit, sit nihilominus expediens, quòd caueat, fideiussorésve det, quòd resarciat damna, quæ in proprietate culpa ipsius fuerint reperta, manifestè docetur, cautionem fideiussoriam se extendere ad omnia vniuersim damna culpa fructuarii reperta, siue illa ex facto aliquo fructuarii prouenerint, siue ex omissione: legem verò Aquiliam solùm se extendere ad culpabilia damna, quæ fructuarii facto obuenerint, non verò ad ea, quæ ob meram omissionem culpabilem prouenerint: sic enim textus ille habet: *Quia sunt casus, quibus cessat Aquiliæ actio. Nam, qui agros non proscindit, qui vites non subserit, qui aquarum ductus corrumpi patitur, lege Aquilia non tenetur.* Sanè ex hoc textu non video, vnde potius colligatur, legem Aquiliam locum non habere, quando damnum prouenit ex leuissima culpa, quæ consistit in omissione, quàm in leui, aut lata, quæ similiter in omissione consistat. Etenim exempla illa, non ad leuissimam culpam, sed ad leuem, quin & ad latam, spectare vidètur. Neque enim leuissima, sed potius lata, culpa est, proprietatem deteriore ex co reddi, quòd terra, in qua sunt plantæ, non fodiatur, & quòd loco vitium demortuarum, aliæ non subserantur, & quòd aquæ ductus corrumpi ac destrui permittatur. Vnde glossa ibi, duplicè, expositionè, ac responsionè, tradit: neque primam intendit satisfacere, nisi simul secunda ei adiungatur. Prima est, quòd textus hic intelligatur, quando culpa, siue leuissima, siue leuis, aut lata, consistit in mera omissione, sine vllò prorsus actu antecedente fructuarii, per se, aut per interpositam ab eo personam, vnde damni periculum immineat, nisi ei occurratur, sed res per seipsam sine vllò prorsus actu deterior redditur, aut facto alicuius alterius, cui non occurritur, reddatur deterior. Quàdo verò actus præcedit, ex quo imminere potest periculum, nisi vigiletur ac damno occurratur, tunc, esto culpa ac negligentia in vigilando ac occurrendo periculo ac damno, non sit posita in vltiori actu, sed in illius omissione, locum habet actio legis Aquiliæ, vt glossa dilucidè probat ex. *l. si seruus seruum. §. si ex plaustro. ff. ad leg. Aquil.* Cuius verba sunt: *Si ex plaustro, cum duceretur, lapis ceciderit, & quid ruperit, vel fregerit, Aquiliæ actione plastruarium teneri placet, si male composuit lapides, & ideo lapsi sunt.* Ecce, quia præcessit lapidum positio in plaustro, eorumque compositio, ad illos vehendos, si illos non cōposuit & continuit, vt decidere non possent, nec vigilauit, quando ictibus postea plaustri discom ponebantur, & periculum erat ne deciderent, vt occurreret ei periculo, & eos contineret ac componeret, actio legis Aquiliæ aduersus eum competit propter omissionem subsequutā. Eodem modo, si quis ignem accendat, sine probabili periculo damni eorum, quæ in forno tali igne cōquoquantur, vel alibi aptantur, aut fiunt, & sine probabili periculo incendii domus, aut aliarum rerum, modo ipse inuigilet, sanè si per negligentiam, absque nouo actu, inuigilare omittat, ac damnum ex eo igne sequatur, actio legis Aquiliæ pro eo damno competit. Secunda responsio ac expositio glossæ est, quòd, quando damnum prouenit ex culpa, quæ in omissione mera, modo explicato, consistit, non competat pro eo damno actio directa legis Aquiliæ aduersus sic culpabiliter omittentē impedire ea damna: com petat tamen aduersus eum actio vtilis legis Aquiliæ: id quod expressè habetur. *l. si seruus seruum citata. §. si Fornacarius, qui sic habet; Si Fornacarius seruus co-*[[76]]*loni ad foruacem obdormisset, & villa fuerit succēsa, Neratius scribit, ex locato conuentum, præstare debere, si negligens in eligendis ministris fuit. Cæterùm, si alius ignem subiecerit fornaci, alius negligēter custodierit, an tenebitur, qui subiecerit? Nam, qui custodit, nihil fecit: qui rectè ignē subiecit, non peccauit. Quid ergo? puto, utilem competere actionem, tam in eum, qui ad fornacem obdormiuit, quam*

in eum, qui negligenter custodiuit. Neque quisquam dixerit, in eo, qui obdormiuit, rem eum humanam & naturalem passum: cùm deberet vel ignem extinguere, vel ita munire, ne euagaretur. Ecce, Vlpianus, cuius est hic textus, exponit, quod Iulianus dixit in §. denique consultus, citato. Nempe, quòd, quando damnū prouenit ex mera omissione culpabili, vt prouenit in illo, qui ignem non succendit, sed ad illum custodiendum est relictus, & vel obdormiuit, vel alia ratione negligēter custodiuit, competit aduersus eum, ob damnum ex eo igne sequutum, utilis actio legis Aquiliæ, esto directa non competat, de qua sola intelligendus est Iulianus. §. denique consultus, citato: atque ita iura iuribus consonant. Quid autem intersit inter actionem legis Aquiliæ directam, & inter vtilem, atque inter actionem subsidiariam in factum, iuxta iuris ciuilis subtilitates, (quæ vtinam ex iure abscinderētur) habetur *inst. de leg. Aquil. §. ult.* Ac sanè. §. si fornacarius citato, sermo videtur esse de culpa leui, aut lata, non verò de leuissima. Quoniam sermo est de colono, qui custodiam fornacis cōmisit seruo, qui obdormiuit, ex eaque culpa villa conducta est succēsa. Colonus enim conductor solūm tenetur de leui aut lata culpa, ex conducto, si ea culpa ipsius interuenit in eo seruo deputādo tali custodiæ: si verò in ea deputatione non interuenit tanta culpa, ipse ad nihil tenetur. Custos verò, si erat mercede conductus, aut mancipium illius, tenetur domino villæ, loco coloni, actione utili legis Aquiliæ de damno dato, vt in. §. si fornacarius, definitur, ac proinde, si is custos mancipium erat talis coloni, cenetur colonus, vel soluere damnum loco mancipii, vel tradere mancipium domino villæ pro eo damno, esto nulla interuenerit culpa talis coloni, iuxta ea quæ in sequentibus dicemus de quasi delicto, actionibúsve noxalibus; atque cum hac tota doctrina consentit apertè. §. Proculus in eadem lege si seruus seruum, subiunctus. Quare ex iuribus citatis non colligitur, soli culpæ leui competere, quòd si in omissione consistat, locum non habeat actio legis Aquiliæ pro damno ex ea sequuto, si verò sit in aliquo actu, competat actio legis Aquiliæ pro damno ex ea sequuto.

Couar. idem confirmat ex glossa. l. si mora verb. ne facto. ff. soluto matri. & ex glossa. 2. l. in lege Cornelia. ff. ad senatus consult. sillanianum. Hęc tamen nihil vrgent. Cū enim lege, si mora, citata habeatur, si maritus vxori dotem, soluto matrimonio, debeat, eamque illi offerat, atque vxor in mora sit eam statim accipiendi, non teneri illi deinceps maritum, quoad dotales fundos, de culpa, sed solūm de dolo malo, si non colantur, fructusque non percipiantur, red datque rationem textus, *ne facto mulieris*, hoc est, ne mora in accipienda dote oblata, maritus *in perpetuum agrum eius colere cogatur*; cū, inquam, hæc ita in ea lege habeantur, glossa Accursii verb. *ne facto*, sic quærit: *Sed quid si maritus in faciendo commisit culpam leuem, aut leuissimam? Respondeo. Tenetur, vt suprà ad leg. Aquil. l. in lege.* Et hic in non dando loquitur, vel negligendo. Hęc, inquam, nihil vrgent pro opinione Couar. & Marantæ. In ea enim glossa æqualiter, eodemque modo, est sermo de culpa leuissima & leui, quòd scilicet, si consistat in omissione, de ea non teneatur maritus lege Aquilia, secus verò si consistat in facto: quare, si sententiæ eius glossæ esset standum, idem dicendum esset de leui culpa & leuissima, cuius contrarium affirmant doctores eius sententiæ. Quòd verò ad rem ipsam, & ad sententiā eius glossæ, attinet, obserua. Eo ipso, quòd maritus dotem vxori obtulit, illaque in mora est eam accipiendi, perinde maritum manere deob ligatum à curandis rebus immobilibus dotalibus eius vxoris, atque quicumque alius; si tamen fructus aliquos recipiat ex eis rebus, teneri eos reddere illi vxori, vt in eo textu subiungitur. Hinc dico, si omnino negatiuè se habeat maritus circa ea bona immobilia, de nulla omnino tenetur culpa, de qua teneretur, si non obtulisset eam dotem, siue ea leuissima sit, siue leuis, siue etiam lata: quia non magis tenetur ad curanda ea bona, & ad impedienda damna circa illa,

quàm teneatur quivis alius extraneus, cui nulla omnino negligentia circa ea bona imputatur ad culpam. Quare, si de culpa hoc modo sumpta, quæ in mera omissione circa ea bona consistat, loquatur, falsum affirmat glossa in eadem lege verb. culpam, dum ait, teneri de culpa lata, quæ dolo æqui paratur: in re enim proposita, non æquiparatur dolo malo: sed solùm quando quis tenetur aliquo modo ad custodiam rei alicuius, vt tenetur depositarius. Si verò maritus aliquem actum exerceat circa ea bona, cùm ad eum non teneatur, tunc, vel actus respicit administrationem, ac agere negotium vxoris, vel non. Si ad administrationem & ad negotium vxoris attineat, tunc, si gratis illam exerceat, neque impediatur alium, qui eadem negotia & administrationem susciperet, solùm tenebitur de dolo, & de lata culpa, non verò de leui, aut leuissima; perinde atque quivis extraneus teneretur, si eadem negotia & administrationem simili modo susciperet, iuxta ea quæ suprà in materia de negotiis gestis dicta à nobis sunt: atque, si in hoc euētu loquatur glossa verb. culpam, citato, verum affirmat. Si autem actus, quem exercet maritus circa ea bona, non spectat ad administrationem eorum bonorum, & ad negotium vxoris, tunc, si ex illo sequatur damnum in eis bonis, tenebitur maritus lege Aquilia ad id damnum, etiam si culpa eius leui, aut leuissima, obuenisset, perinde ac teneretur quivis extraneus, qui ex eadem culpa id damnum dedisset. Quare doctrina eius glossæ nihil omnino vrget ad id, quod Couar. Maranta, & alii doctores eius opinionis intendunt. Glossa verò in lege Cornelia solùm ait, plus culpæ esse in facto, quo serui aliqui dominum suum interfecerunt, quàm sit in omissione defensionis eiusdem domini, quando videbant interfici ab aliis: inde verò non video, quod vrgens argumentum erui possit ad opinionem Couar. ac Marantæ confirmandam.

A Couar. & Maranta citatur. l. qui ædes. ff. de incend. reu. nauif. non quidem, vt inde suam sententiam confirmet, sed vt eum textum iuxta suam exponant sententiam. Cæterùm in ea lege solùm habetur, quòd cùm acrius puniri debeat, [[77]] qui sciens & pragens incendit ædificium, atque adeò voluntariè eo modo, quo appellamus homicidium voluntarium, vt distinguitur contra casuale: si tamen casu, id est negligentia, (vt exponit ipse textus) ædificium incendat, debere soluere damnum, aut, si non habeat unde soluat, debere leuius castigari, quàm scilicet si sciens & prudens id fecisset, pro quantitate videlicet negligentiae ac culpæ. Ea autem lex potius confirmat contrariam sententiam: nomine enim negligentiae, omnis iuridica culpa intelligitur in eo textu, quæ non est cum scientia, aut intento, eius damni: & ex quacunque tali negligentia asseritur, teneri incendiarium ad resarciendum totum damnum: si verò non habeat unde illud resarciat, debere luere in corpore pro negligentiae & culpæ quantitate, spectata simul latitudine damni illati. Consentit. *l. capitalium. §. qui ob inimicitias. ff. de pænis*, vbi, cùm ob incendium scienter factum grauior multo pæna statuatur, additur: *Nam fortuita incendia*, hoc est quæ sunt præter intentionem, *si, eum euitari possent, per negligentiam eorum, apud quos orta sunt, damno vicinis suerint, ciuilitè exercentur, vt qui iactura affectus est damni, disceptet*, hoc est, lege Aquilia agat ad illius solutionem, vt glossa ibi exponit, *vel modicè vindicetur*, pro qualitate videlicet culpæ, & damni quantitate, si, qui illud dedit, non habeat unde soluat. Vbi vides, negligentiam omnem culpabilem in euitando damno ex incendio puniri lege Aquilia ad damni solutionem, aut si, qui illud dedit, soluendo non sit, agi criminaliter ad pænam corporalem, pro culpæ, & damni, quantitate.

Hinc certè non probo opinionem Couar. vbi suprà, & quorundam aliorum, qui, ducti de bilibus fundamentis, à no bis hactenus euersis, asserunt, si culpa leuissima eius, qui ignem incendit, sequatur exustio & damnum bonorum proximi, non teneri incendiarium lege Aquilia illa soluere, si negligentia ac culpa leuissima fuit in omissione aliqua ne ignis incensus

noceret: secus autem, si suit in ipso actu incensionis ignis. Eo enim ipso, quòd ignis est incensus, prospicere ac vigilare tenetur, qui illum incendit, ne res alterius incendat ac perdat, quando periculum aliquod est, vt id sequatur, & saltem per diligentissimum prouideri potuit, ne sequeretur: nec minor culpa est, eum ignem incendere, attendere debendo ex eo posse sequi damnum aliorum, nec vigilando, & occurrendo, vt non sequatur, quàm quando est incensus, & superuenit circumstantia, ex qua attendere debuit imminere periculum, ad id negligenter non attendere, ex negligentiaque non accurrere ad damnum ex eo igne vitandum. Quo fit, vt, quando ex igne succenso damnum est sequutum in bonis alterius, attendi debeat, an vlla negligentia culpabilis fuerit ex parte eius, qui illum incendit, aut qui in custodiam illius est relictus, qua potuerit ac debuerit vitari id damnum; quòd si, prudentis arbitrio, aliqua reperiatur, vel in igne in cendendo, vel in illo custodiendo, ne noceret, quam diligentissimus adhibuisset, adhibereque teneretur, quia cum eo onere incendere quiuisset ignem debet, aut facere quoduis aliud, vnde euenire potest, ac solet, damnum proximi, tunc tenetur lege Aquilia resarcire id totum damnum, aut luet in corpore modo explicato, si non habeat vnde soluat; si verò nulla talis interuenit, ad nihil tenetur. Atque iuxta hæc accipienda & intelligenda sunt, quæ habentur. *l. si seruus seruum. §. si quis insulam. §. si fornacarius, & §. Proculus. l. qui occiderit. §. in hac quoque. ff. ad leg. Aquil. l. 10. & 11. titu. 15. part. 7. c. si egressus, iuncto. c. ult. de iniur. & damn. dat.* quæ iura hanc nostram sententiam confirmant. Memento tamen, quòd quando is, qui damnum intulit, mercede erat conductus comparisone eius, qui damnum accepit, atque tunc exercebat actum tanquam ad id conductus, & in aliis similibus euentibus, non teneri de culpa leuissima comparisone illius, vt supra dictum est.

Est verò res hæc tota de damno culpa dato, [sect. 10] aliquibus veluti exemplis ex iure depromptis, iurisque definitionibus, amplius explananda, vt plenius intelligatur, quando & quousque legis Aquiliæ actio locum habeat. Atque supra dictum est, si quis damnum det aduersario, se suaque defendendo cum moderamine inculpatæ tutelæ, locum non esse actioni ex lege Aquilia: quia id licitè fit, iureque permittente, quasi bello desensiuo iusto, iuxta. *l. scientiam. §. qui cum aliter ff. ad leg. Aquil. & l. 3. titu. 15. part. 7.* Est tamen obseruandum, damnum inferre aggressori in ipso flagranti delicto ad iniuriam propulsandam, & se defendendum, non esse mathematicè sumendum, vt, si modicum quid excedatur id, quod præcisè sufficeret ad defensionem, locum habeat actio legis Aquiliæ pro tali damno aduersario illato: quia enim aduersarius est in culpa ac lacessit, difficileque admodum est tenere modum, vt nihil omnino excedatur, quod præcise sufficit ad defensionem, sanè, si non multum ac patenter excedatur, locum non habebit concedi aggressori actionem legis Aquiliæ ad eum excessum: maximè quia tunc locum habere videtur quasi compensatio pro intentata iniuria ab aduersario. Vnde. *l. qui occiderit in prin. ff. ad leg. Aquil. habetur*, si quis deprehendat seruum alienum adulterantem cum sua propria vxore, cumque interficiat, non concedi domino talis mancipii actionem legis Aquiliæ aduersus interfectorem ob id damnum ei illatum: quia lacessitum esse ab eo mancipio tanta iniuria ac contumelia, excusat interfectorem à solutione eius damni, facta veluti compensatione, legis autoritate, eius damni cum contumelia & iniuria accepta. Hinc iam intelliges, quod subiungitur. *§. qui cum aliter, citato, & habetur. l. 6. titu. 15. part. 7.* Nempe, si duo rixentur, & vnus mittat lapidem in alterum, aut aliter intendendo illi damnum inferre, præter suam intentionem, percutiat transeuntem, aut quemuis alium tertium, etiam si in sui defensionem ab aggressore id efficiat, teneri illi tertio percusso actione legis Aquiliæ de damno ei dato. Intelligendum est enim id,

quando aliqua sua culpa id fecit, quia potuit id euitare: si enim nulla sua culpa id fecit, quia præcisè fecit, quod omnino necessarium ei occurrebat ad sui defensionem, neque attendere debuit damnum imminere alteri, tunc, cùm nulla sua culpa id fecerit, etiam comparatione eius tertii, non tenebitur ipse lege Aquilia compensare id damnum, vt satis innuit lex. 6. citata, dum hanc reddit rationem, cur tenetur; *porque como quier que el non fizo à sabiendas el daño al otro, pero* [[78]] *ac aecio por su culpa*; quasi quando nulla omnino interuenerit ipsius culpa, ad nihil ipse teneatur. Atque ita affirmat ibi Greg. Lopez, asserens eam legem explanare ea in parte. §. qui cum aliter citatum, atque Azonem eodem modo intellexisse cum. §. Aggressor tamen tenebitur tunc lege Aquilia ad id damnum, tan quam qui sua iniuria occasio, & veluti causa, illius fuerit. Si autem aggressus in sui defensionem, ad vitandum maius suum malum, leuius intulit proximo in bonis externis, attendens, aut attendere debens, posse id sequi, tunc tenebitur, in defectum aggressoris, illud ei resarcire: quoniam ea lege, ac conditione, debuit se exponere peticulo illud inferendi in suam defensionem ac commodum, vt illud ipse resarciret, quando ab aduersario non resarciretur. Et fortè duo iura citata, attendendo, quòd, percutere intendens aduersarium, regulariter sua culpa percuteret tertium, aut quòd sub ea conditione se exponere deberet periculo cum percutiendi, quòd, saltem in defectum aduersarii, ipse damnum resarciret, absolute statuerunt, teneri lege Aquilia id damnum resarcire.

Quando ludus esset valde periculosus, quia [sect. 11] facile nocumentum inferre posset transeuntibus, & solis militibus in certo loco ad id deputato propter id periculum concessus, vt iacula emittere exercitationis atque instructionis ad bellum gratia; tunc, si miles in loco ad id deputato eum exerceret, & fortè interficeret mancipium illà transiens, non teneretur lege Aquilia domino talis mancipii ad damnum, nisi constaret, videntem mancipium, iacula misisse, illudque percussisse. Ratio est, quoniam tunc nulla præsumitur culpa in tali milite, sed potiùs in mancipio, quod, sciens, aut scire debens, eum locum esse militibus ad id deputatum, illà ita transiuit, vt percuti posset. Si verò non miles ibi id efficeret, maximè quando non simul cum militibus se ibi exerceret, aut miles extra cum locum, idem efficeret, ac mancipium, aut aliud animal, interficeret, teneretur de damno lege Aquilia: quia culpa ipsius id damnum cueniret, exercendo rem adeò periculosam extra locum ad id, propter rei periculum, solis militibus peculiariter deputatum. Atque de eiusmodi solo ludo, qui iam hodie nullibi, quod sciam, est in vsu, intelligo. *l. item si obstetrix. §. penult. & ult. ff. ad leg. Aquil. & §. iniuria inst. eod. titu.* eo quòd hæc iura de eo solo perspicuè loquantur: neque credo id trahendum esse ad alia exercitia, vt ad hastiludium, ad ludum iaculationum arundinum, ad cursus alios equorum, & ad similia aliqua, in quibus licèt non nullum sit periculum, quòd aliqui incauti, & qui pericula fugere nesciunt, sed potiùs illis videntur se exponere, equorum pedibus damnum notabile accipiant, aut etiam interficiantur, non tamen eminus grauiter ferire solent. De eiusmodi verò aliis cursibus equorum. *l. 6. titu. 15. part. 7. iuncta. l. 5. titu. 8. part. 7.* habetur, quòd si fiant in loco ad id consueto, (adde tu, & quando homines non sunt incauti ac ignari, quòd curri equo tunc ibi velit) sanè, si aliquis transuersim se objiciat cursibus equorum, neque eques continere, aut remouere, possit equum, ne illum conculcet, non teneri ad damnum subsequutum: quoniam eques tunc in nulla fuit culpa, sed potiùs is, qui se incautè cursui equi obiecit. Si verò equi cursus fiat in loco ad id non consueto, aut in consueto quidem, quando tamen homines incauti sunt, quòd curri velit; tunc, nisi vocibus priùs sufficienter præmoneat, vt omnes cursui equi cedant, aliquemque conculcet, tenetur de damno dato: quoniam culpa sua id damnum est sequutum: secus autem, si sufficienter vocibus præmonuit, vt omnes cederent locum cursui.

Quando aliqui pila, verbi gratia, luderent, & [sect. 12] casu euenerit, vt pila percuterent tonsoris manum, qui noua cula rade bat gulam, atque ita, qui radebatur, sit percussus, aut interiit, tunc, si in culpa fuit tonsor, qui, videns alios ibi ita ludere, se exposuit ad barbam in eo loco radendam, non tenenter ad damnum, qui luderent, nisi inciperent ludum, inscio tonsore, neque ab eis præmonito; quoniam non essent in culpa, quando in loco luderent, in quo non tenerentur desistere à ludo; sed tonsor, qui locum tutum non elegit, teneretur ad damnum: nisi, qui radebatur, sciens & prudens elegerit ibi radi: nam tunc sibi debet imputare id damnum. Quando autem aliquis aliter impelleret tonsorem, atque ita, qui radebatur, nouacula, aut alio instrumento, feriretur, prudentis arbitrio est attendendum, an impellens fuerit in culpa, vel tonsor, qui eo in loco elegit radere, vel qui sciens & prudens elegit eo in loco radi, atque ei imputandum est damnum tanquam causæ, qui, prudentis arbitrio, causa, aut occasio illius fuerit iudicatus. Hæc habentur. *l. item Mela in prin. ff. ad leg. Aquil.* atque idem intendit. *l. 27. titu. 15. part. 7.*

Quando ludus, in quo aliquid est periculi inter colludentes inter se, quia vnus superare, impedire, aut dejicere, conatur alterum, est permissus, (si enim esset prohibitus, damnum, quod inde alteri sequeretur, imputaretur illud inferenti, iuxta. *l. nam ludus. ff. ad leg. Aquil.*) tunc, si vnus colludentium, non transgrediendo moderationē ac limites, qui in eo ludo esse debent, nocumentum aliquod alteri inferret, vt in lucta, hastiludo, torneamento, iaculatione arundinum, & in similibus aliis, non teneretur lege Aquilia illud resarcire: quia non censeretur datum culpa inferentis, qui suo iure in eo ludo est vsus, sed potiùs censeretur casu, & absque culpa in eo ludo, euenisse. Ita habetur. *l. qua actione. §. si quis in colluctatione, & l. si ex plagis. §. vlt. ff. ad leg. Aquil.*

Si cui traditus sit aliquis ad eum docendum [sect. 13] opificium aliquod, vel rem aliam, eumque disciplinæ gratia immoderatè ac inordinatè castiget, eaque castigatione damnum illi inferat, tenetur lege Aquilia ad damna omnia subsequuta, vt ad expensas omnes in eo curando, ad æstimationem operarum, si quibus ea de causa priuatus impeditusque est, & ad reliqua. Quòd si ita est percussus, vt oculum amiserit, aut mancus manserit, vel alia ratione minùs aptus ad in posterum operandum, tenetur ad æstimationem totius eius damni in futurum. Docenti enim sola moderata, ac rationabilis, castigatio permittitur, pro ratione culpæ, & pro cæteris circumstantiis concurrentibus, non verò irrationabilis & immoderata. Hæc habentur. *l. sed etsi, & duabus sequentibus. ff. ad leg. Aquil.* Quod [[79]] autem dictum est, teneri ad æstimationem operarum, ad quas manet impeditus in futurum, similiter intellige in reliquis damnis, ex quibus manet eodem modo impeditus, & ad quæ tenetur lege Aquilia, aut quauis alia actione, vt, præter iura citata, habetur. *l. ex qua. ff. si quadrup. paup. fecis. dic. l. vlt. ff. de his qui deiecer. & c. 1. de iniur. & damn. dat.*

Quando aliquis cædit arborem, aut tegulas, [sect. 14] vel aliquid aliud ejicit ex ædificio, vel ex machina, quæ destruit, aut reficit, aut ex alia simili re, si quidem in locum publicum id dejiciat, vt in viam publicam, aut in alium, vbi homines esse vel transire solent, nisi priùs sufficienter ac tempestiuè proclamet, vt transeuntes, aut infrà existentes, sufficienter euitare possint id periculum, adeò vt, si illud non effugiant, culpa sit ipsorum, & non cædentium, aut ejicientium, vtique, si aliquod damnum det, tenetur lege Aquilia illud resarcire. Secus si proclam auit priùs tempestiuè ac sufficienter, vt illud possent vitare, aut si arborem scindat in deserto, aut in loco, vbi nullus esse solet: quia tunc, nisi, sciens ibi aliquem esse, id ejecerit, non tenetur ad damna subsequuta: quia diuinare non debuit, ibi esse aliquem, vt priùs eum admoneret. Ita habetur. *l. si putator. ff. ad leg. Aquil. §. item putator inst. eod.*

titu. l. vlt. iunctis antecedentibus. ff. de his qui deiecer. c. l. 6. titu. 15. iuncta. l. 5. titu. 8. part. 7. Obserua. l. si putator citata, haberi, si quis excidat arborem, non in loco publico, sed in priuato, in quo tamen est aliqualis semita, aut iter, quo solent homines transire, licet non ita frequenter, tunc etiam teneri excidentem, aut dejicientem, de damno dato, nisi prius sufficienter ac tempestiue proclamauerit. In hoc tamen euentu in ea lege, quia non tantum est periculi, quantum in via publica, solum docet ea lex, dejicientem teneri de culpa leui, hoc est, si non adhibuit diligentiam, quam homines diligentes adhibuissent. Quod glossa. l. in lege Aquilia. 2. ff. ad. l. Aquil. affirmat, esse exceptionem ab ea lege, in qua statuitur, vt quis lege Aquilia de damno dato teneatur, sufficere leuissimam culpam. Fortasse tamen in eo euentu nihil differt leuis culpa à leuissima: quia sufficit proclamatio tempestiua, vt homines sibi prospiciant, quam eodem modo adhibere solent homines diligentes, ac diligentissimi, eaque de causa lex illa eo modo est loquuta, nullam intendens facere exceptionem.

Peculiariter est in iure statutum, quando ex [sect. 15] domibus effunditur aqua, aut mittitur aliquid aliud, quod nocere possit transeuntibus, in vestibus, aut in corpore, vel in aliqua alia re, sine pramonitione sufficienti, vt cauere id damnum possit, si damnum sequatur, soluendum esse duplum quoad æstimationem ei, qui illud est passus; & quoniam difficile erat inuenire quis de domo illud dederit, vt is solus cogeretur illud soluere, sancitum est, vt, qui habitant domum, illud soluant, eaque ratione, quod ita soluitur, solui dicitur ex quasi delicto, quia fieri potest, vt soluat, aut contribuat, qui sine culpa est omnino: atque in bonum commune statutum est, vt cum eo onere domus habitentur, vt infra, dum sermo fuerit de quasi delictis, dicitur: quando autem comperitur, quis in particulari id damnum dederit, is tenetur lege Aquilia ad id duplum, vel ei, qui id damnum est passus, vel aliis, qui illud soluerunt. Hæc omnia constant ex. l. 1. c. sequentib. ff. de his qui eiecer. ex. §. 1. c. 2. inst. de quasi delict. c. ex. l. 25. titu. 15. part. 7.

Qui foueas, aut instrumenta, quæ læsionem [sect. 16] animalibus in eis captis inferunt, (*trampas y texuelas* hispanè dicimus) ad feras capiendas efficiunt, si in desertis, quò homines & animalia mansueta accedere non solent, eas efficiant, casuque vel homo, vel bos, aut aliud mansuetum animal, in eis decidat, ac lædatur, non tenetur, qui illas fecit, damnum soluere: quia absque culpa, in locis ad id consuetis, eas fecit, neque sine emolumento reipublicæ, ad necandas feras nociuas, aut ad venandos ceruos, & similia alia fera, esui vtilia. Si verò ea efficiat in locis, in quibus decidere possunt homines, aut animalia alia mansueta, neque admoneat sufficienter homines, ne ipsi, aut ipsorum animalia, eò accedant, ita vt singuli in particulari ea admonitione vitare sufficienter possint id damnum, tunc tenebitur lege Aquilia ad damna inde subsequuta. Secus verò si sufficienter eos admoneat. Ita habetur. l. qui foueas. ff. ad leg. Aquil. c. l. 7. titu. 15. part. 7.

Bestiæ, quæ nocere possunt, vt leones, pan [sect. 17] teræ, vrsi, tauri, & similes, si asportentur per vias publicas, ita vt nocere possint, aut teneantur (etiam ligatæ) in loco vbi nocere possint, damnumque sequatur, punitur pæna dupli. Ita habetur. l. hi enim, & duabus sequentibus. ff. de edil. edict. §. vlt. inst. si quadrupes pau. fecis. dicat. c. l. 7. titu. 15. part. 7. quæ de pæna dupli non meminit, sed solum præcipit, resarciri damnum ab eo, qui in ea culpa fuit, vel id ita efficiendo cum periculo aliorum, vel id fieri præcipiendo, lex tamen. 23. eiusdem tituli idem, quod alia iura citata, statuit. Et cum iuribus citatis subiungit, quòd si eiusmodi bestiæ hominem liberum damno afficiant in corpore, neque illum interficiant, teneatur dominus bestiæ ad impensas omnes in eo curando, & ad æstimationem operarum, quibus ea de causa priuatus est; non tamen ad hæc damna teneatur in duplum. Et quòd si mancus, aut claudus,

vel alio membro orbatus, maneat, arbitrio iudicis puniatur, quantum damnum hoc quoad tempus futurum æstimabitur. Si verò homo à tali bestia interficiatur, dominus soluat ducentos solidos. Et cùm iura communia non explicant, cui sint applicandi, lex 23. citata exprimit, dimidium pertinere ad fiscum Regis, & alterum dimidium ad hæredes defuncti, & idem dixit additio in margine glossæ verb. & nocitum. §. vlt. inst. si quadrup. pau. fecis. dicat. quæ citat glossam. l. qua vulgo. ff. de ædil. edict. in qua tamen id non reperitur.

Si quis seruum suum vinculis constrictum [sect. 18] teneat, & alius, misericordia motus, illum soluat, tenetur domino ad damna inde ei subsequuta, atque ad æstimationem serui, si fugiat, nec recuperetur, idque actione in factum subsidiaria legi Aquiliæ, vt hæc omnia expressè habentur. §. vlt. instit. de leg. Aquil. l. & eleganter. §. item Labeo. ff. de dolo, & l. 8. titul. 15. [[80]] part. 7. Si verò eum soluat ex odio domini, aut ex alia sinistra intentione, tunc, si seruus fugiat ac se furto à domino subtrahat, is, qui eum soluit, tenetur domino de furto, vt habetur. §. item habeo, citato. Lex verò. 8. citata, licèt dicat teneri domino tunc ad damna, non tamen exprimit, teneri illi de furto.

Iudex, aut quicumque alius minister publicus, [sect. 19] si damnum alicui det, aut dari præcipiat, absque rationabili & iusta causa, aut aliter culpa illius sequatur, ad illud tenetur. Quin, si iustè pignora accipiat, suaque culpa ea deteriora reddat, tenetur damnum soluere. Eadem etiam ratione, si hi (inter quos eos computa, qui curam habent colligendi tributa) in pignus pecudes, aut armenta, accipiant, eaque ita inclusa habeant, vt non sinant ea pascere, vel aliter cibum sumere, aut bibere, eaque de causa detrimentum illis proueniat, tenentur id soluere, quia culpa ipsorum prouenit. Hæc habentur. l. quemadmodum §. magistratus. ff. ad leg. Aquil. & l. 4. titu. 15. part. 7.

Si aliena animalia damnum dent in vinea, [sect. 20] horto, satis, prato, aut in alia re aliena, tunc, si missa ad id sint à domino eorum animalium, aut à custode illorum, etiam domino inscio, neque id volente, soluendum est damnum, de iure quidem communi simplum, vt notat Greg. Lopez. l. 24. titu. 15. part. 7. verb. *doblado*, quia non reperitur textus, qui aliud statuatur, vt constat ex. l. qui seruandarum. §. vlt. ff. de præscrip. verb. ex. l. Iulianus. §. glans. ff. ad exhib. & ex. l. vlt. C. ad leg. Aquil. de iure verò huius Regni duplum in eo³² euentu, vt habetur. l. 24. citata. De iure Lusitano lib. 5. ordinationum titu. 85. sic sancitum est: *Ordenamos, que qualquer pessoa, que acintemente meter, ou mandar meter, gaados, ou bestas, em pam, vinbas, oliuaes, ou pomares, no tempo em que sam coimeros po las posturas das camaras, sendo lhe prouado dentro de seis meses, po la primeira vez seja degradado tres meses fora da villa e termo, e po la segunda vez que lhe for prouado, seis meses pera huum couto do reino, e pola terceira, huum anno para cada huum dos lugares dalem, e mais de cada vez paguaraa o daño que fezer, e coimas, segundo as postur as das camaras. E sendo achado o gaado, ou bestas, nos ditos pães, vinhas, oliuaes, ou pomares, nos ditos tempos defesos tres vezes em huum mes, em tas caso seram degradadas as ditas bestas ou gaado, seis meses fora do termo da cidade, villa, ou lugar, onde ho dono do gaado, ou bestas, morar, è assi do termo onde assi foram achadas as tres vezes.*

Vtrùm autem, quando, sine culpa domini, [sect. 21] custos eorum animalium ea immisit, teneatur dominus ad pœnam dupli? Quidam, quos Greg. Lopez vbi suprà refert, licèt non loquantur de pœna dupli, sed de solo integro simplo damno, in eo duplo incluso, (quod solùm de iure communi est soluendum) affirmanter respondent; quia præsumitur, inquirunt, culpa domini in custode infideli ac negligenti eligendo: atque in eandem sententiam propendet ibi Greg. Lopez quoad pœnam dupli in hoc Regno, ita vt, licèt nulla interuenerit culpa domini in eo damno, non liberetur ab eo de iure communi integro soluendo, neque

de iure huius Regni à pœna dupli tradendo noxæ, hoc est relinquendo ei, qui id damnum est passus, animal, aut animalia, quæ damnum dederunt. Ego verò contrarium existimo omnino verum, saltem de pœna dupli. Ducor, quoniam illa non statuitur pro eiusmodi damno vtcunque culpabili, sed pro culpabili immittendo de industria animalia ad id pascendum: negligentia autem domini in eligendo fidei ac diligenti pastore, non peruenit ad tantam culpam, vt censeatur ipsum de industria misisse sua animalia ad id pascendum, quando id nec præcepit, nec suasit custodi suorum animalium. Neque contrarium huius nostræ sententiæ habetur. l. 24. citata, quæ solùm statuit, soluendum esse tunc duplum damnum datum, non tamen statuit soluendum esse ab alio, quàm ab eo, qui id damnum de industria ita dedit. Quando verò datum id damnum est culpabili quidem negligentia custodis, cæterùm non de industria, locum in hoc Regno non habet pœna dupli, sed tam in hoc Regno, (tametsi id non exprimat lex. 24. citata) quàm de iure communi, soluendum est integrum damnum datum ab eo, cuius culpa obuinit. Cæterùm, vtrùm tunc solus custos, cuius negligentia est datum, teneatur illud soluere, an verò, in defectum illius, etiam dominus teneatur illud soluere, vel dominus liberetur ab eo soluendo dedendo noxæ animal, aut animalia, quæ illud dederunt. Satis probabile existimo, cum aliis, quos idem Greg. Lopez ibidem refert, dominum, tam in hoc euentu, quàm in præcedente, quando custos, absque domini voluntate, misit animalia ad dandum id damnum, ad nihil aliud teneri, quàm vel ad resarciendum integrum damnum, vel ad relinquendum animalia, quæ illud dederunt, ei, qui illud est passus. Quoniam quando animalia absque vlla domini culpa damnum dant, ad nihil aliud tenetur dominus, vt statim, & multo copiosius, inferius ostendemus. In quocunque verò euentu, in quo animalia, pastoris culpa, saltem leui, damnum dant, absque domini iussu ac voluntate, tenetur custos illud soluere, &, si quid dominus loco illius soluat, tenetur custos id soluere domino, si dominus integro iuris rigore aduersus custodem agere velit. Dixi, pastoris culpa saltem leui: quoniam, cùm mercede conductus seruiat, contractusque proinde fuerit in commodum ipsius, ac domini, non tenetur illi de culpa leuissima. Quia verò ei, qui damnum est passus, tenetur de culpa leuissima actione legis Aquiliæ, aut actione in factum legi Aquiliæ subsidiaria, vt hactenus dictum est, tunc credo, dominum animalium teneri ad id totum damnum illi, qui illud fuerit passus, neque satisfacere dedendo animalia noxæ; neque tunc pastorem teneri domino, qui ipsum ad custodiam eorum animalium conduxit, ad id, quod dominus soluerit ob leuissimam pastoris culpam: quoniam pastor solùm tenetur domino de leui, non verò de leuissima culpa: neque mirum est, quòd, qui sua pecora per famulum mercede conductum pasci, ac custodiri, eligit, ei oneri maneat ob sua animalia subiectus. Quando verò, nulla omnino interueniente culpa pastoris ac domini, animalia dilabuntur ac damnum inferunt, tunc pastor ad nihil tenetur, vt est notissimum: dominus verò tenetur, vel [[81]] integrum damnum soluere, vel animalia noxæ dare, ea relinquendo ei, qui damnum est passus, vt do minus eligere maluerit, vt. l. 24. habetur, atque ex dicendis erit magis manifestum. Quãdo, in euentibus omnibus explicatis, damnum integrum est soluendum, aut duplum illius, estimari debet damnum per arbitratore ad id deputatos; nisi is, qui illud est passus, & qui soluere illud debet, conueniant in illius pretio ac valore. Æstimari verò debent sata, & similia alia, quorum fructus sunt adhuc in spe, iuxta statum præsentem, quantum emerentur & venderentur, si quis spontaneè vellet ea vendere; nihil impediante, quòd dominus nollet ea vendere: quia mallet expectare rei euentum, & apponere reliquum expensarum, industriæ, ac laboris.

Nefas est reperienti alienum animal in præ [sect. 22] dio suo, illud interficere, aut aliquid circa illud efficere, unde domino damnum sequatur, ut aborsus talis animalis, vel aliud, sed tractare & expellere illud debet sine damno, ac si esset suum: quandoquidem actionem aduersus dominum habet ad damnum recuperandum. Quod si inordinate cum eo animali se gerat, illudque interficiat, aut aliud damnum ei in ferat, tenebitur compensare damnum ita datum cum accepto ex tali animali: si verò, quod ipse dat, superet acceptum, soluere tenetur domino animalis incrementum. *Im habetur. l. Quintus, & l. quamuis. ff. ad leg. Aquil. l. penult. C. eod. titu. & l. 24. citata.* Vbi verb. *que lo mate*, refert Greg. Lopez Salycetum, Decium, & Cæpolam, asserentes, si quis suæ, aut aliud animal, reperiat in suo fundo, ac fugiat, posse illud occidere: atque, dum Greg. Lopez id solum refert, nec impugnat, annuere videtur. Ego contrarium non dubito esse verum, quando plus valet animal, quam damnum acceptum, tenerique proinde restituere domino incrementum damni, quod illi ita infert supra id, quod ex tali animali accepit. Atque hoc reputo verum, esto nesciret, cuius esset id animal, aut ex fuga non posset domino probare, tale animal id damnum sibi dedisse, ut dominus animalis solueret, quando non est maius, quam valeat tale animal. Ducor, quoniam iura citata id aperte so nant ac statuunt. Et quoniam æquitas non patitur, quod accipiens damnum sua auctoritate puniat dominum animalis ob damnum, quod ex eo animali accepit, maius illi damnum inferendo, quam acceperit, non solum, quando dominus animalis in nulla fuit culpa eius damni, sed etiam quando fuit in culpa: maxime stando in solo iure communi, iuxta quod pro culpa dāni, etiam quando ex industria immissis animalibus datur, solum iubetur resarciri simplum ei, qui illud est passus. In hoc autem Regno, quamuis non bene faceret, qui animal interficeret, quod à domino fuit de industria immissum, ut id damnum daret, si tamen animal non excederet valorem dupli talis damni, in exteriori foro se posset defendere exceptione, quod dominus animalis soluat ei duplum damni ex tali animali accepti, & quod ipse soluat ei valorem eius animalis: atque in foro conscientie se etiam tueri posset, volens, si damnum animali illatum exigatur, excipere, ut ipsi prius solvatur duplum damni, de industria ita dati. Quando verò de industria non esset datum, tunc esto culpa aliqua interuenisset domini animalis, utique, qui animal interficeret, in conscientie, & in exteriori, foro teneretur soluere domino animalis incrementum damni dati in animali, supra damnum ex animali acceptum. Vtrum autem validum esset ac licitum statutum, quo permetteretur, ut, qui animal alienum in suo prædio inueniret, posset illud impunè & absque vlla culpa interficere? Salycetus, à Greg. Lopez vbi suprà relatus, affirmanter respondet, annuereque videtur Greg. Lopez, & cum Angelo idem affirmat *Nauar. in Minu. c. 17. n. 120.* Neque ego id statutum damnarem, aut aliud, quo statueretur, ut tunc dominus animalis soluere teneretur certam pecunie quantitatem: non quidem hæc statuendo vniuersim in pænam; quoniam quando absque vlla domini culpa animal elaberetur, ac reperiretur in eo prædio, nefas esset in pænam id accipere, quæ nulla ratione habere potest locum, vbi nulla est culpa: sed quod, ut homines cautiores ac diligentiores essent in suis animalibus custodiendis, ac continendis ab inferendo aliis damnum, ea lex vniuersalis, omnibusque æqualis ac communis, statueretur, qua singuli cum eo onere & grauamine sua animalia possiderent; maxime quia postea difficile potest discerni, an culpa domini, aut sine vlla prorsus eius culpa, animal eò peruenerit. Lege quamuis, & l. 24. citatis, habetur, quod, [sect. 23] qui animal in suo prædio inuenit, illud non includat. *Quod Greg. Lopez eadem. l. 24. verb. encierre*, cum aliis, quos refert, limitat, nisi ignoretur, cuius sit id animal: nam tunc licitum est illud includere, ut dominus sciatur, ac soluat damnum. Item nisi sit statutum aut consuetudo in contrarium, ut esse solet.

Glossa verò. l. quamvis citata, verb. includit, exponit, animo celandi atque usurpandi animal, quasi bono fine liceat id animal ad tempus includere & asseruare. Semper tamen ita fieri debet, vt animal ex fame, aut siti, detrimentum non patiatur: alioquin includens teneretur ad damnum inde animali, dominóve animalis, sequutum. Admonendus ergo est dominus, si non accurrat ad liberandum suum animal, ad illique prouidendum de cibo & potu, animal detineri inclusum quousque damnum, aut pœnam, soluat, & vt de illo curet. Quòd si neque ipse, neque alius de sua familia, reperiatur, qui admoneri sufficienter possit, vt tali animali succurratur, tunc expensis domini eius animalis prouideri illi debet de cibo, vel pastu, ac potu necessario, alioquin includens tenebitur domino animalis de damno sequuto, iuxta. §. vlt. instit. de leg. Aquil. & alia iura citata, tum circa rem, de qua loquimur, tum etiam circa ministros publicos, qui animalia aliqua in pignus accipiunt.

Si quis nauem sua culpa perforasset, idque in [sect. 24] causa esset, vt merces, aut alia in ea existentia, damnum reciperent, aut vt nauis submergeretur, teneretur lege Aquilia resarcire totum damnum, vt ex se est notissimum, & habetur, l. si seruus seruum. §. si nauem. ff. ad leg. Aquil. & l. 13. titu. 15. part. 7.

Qui adussit, miscuit aliquid vino, aut alteri rei, [sect. 25] vnde id in se redderetur deterius, quia acuit, aut malum contraxit saporem, vel aliud detrimentum est [[82]] passum, aut illud effudit, frangendo, aut perforando vas, in quo continebatur, aut quauis alia ratione, tenetur lege Aquilia soluere id totum damnum. Si verò tritico seminato, superseminauit lolium, aut aliquid aliud, quo infestum sit triticum, non corrumpendo, aut deterius reddendo triticum in se, sed admixtione alterius rei, quę difficilè separatur, tunc resarciendum est id dānum actione in factum subsidiaria legi Aquilię: & idem est, si similis permixtio rei deterioris fiat tritico iam collecto, aut cuius alteri rei, vnde in ea damnum sequatur. Hęc habentur. l. si seruus seruum. §. inquit lex. ff. ad leg. Aquil. §. capite tertio inst. eod. titu. & l. 13. titu. 15. part. 7. suntque ex se perspicua.

Si quis seruo alieno persuasit, vt se alicui ex [sect. 26] poneret periculo, conscendendo arborem sublimem, aut in alium periculosum locum, vel descendendo in puteum, aut quauis alia ratione, & inde sequatur mors, aut aliud illius damnum, vel illum impulit, etiam ioco, aut concitauit equum, quem seruus ille ascenderat, vel aliqua alia ratione occasio, aut causa, illi fuit mortis, aut dāni, tenetur id resarcire domino mācipii, vel actione legis Aquilię, vel actione in factum legi Aquilię subsidiaria. Ita habetur. §. vlt. inst. de leg. Aquil. l. qua actione. §. si quis de ponte, iunctis antecedentibus. l. item si quis obstetrix. §. si seruum meum. ff. ad leg. A suil. & l. 20. titu. 15. part. 7.

Qui canem concitat aduersus aliquem, aut [sect. 27] ferocem canem soluit, animo vt alicui noceat, vel illum defert per aliquem locum non habēs vires sufficientes ad illum tenendum, ac comprimendum, ne noceat, damnumque canis det, tenetur is homo lege Aquilia, aut actione in factum subsidiaria legi Aquilię ad id damnum resarciendum. Idem dicerem, quando canis est ferus, qui nocere soleat, nec tenetur ligatus, & cū debita cautela, ne cui noceat: si enim damnum det, tenetur dominus, aut qui illum soluit, resarcire similiter id damnum. Excipe, nisi de nocte soluator ad custodiendum locum septum, aut interdium ad illum custodiendum, damnumque inferat ingredienti eum locum ad malum patrandū, aut ingredienti irrationabiliter & inordinatè: nam tunc, qui eum soluit, suo vititur iure, ad sua custodienda; & qui ingreditur, non vt oportet, sibi imputet damnum, quod inde ei sequitur. Idem, quod de cane lacesito est dictum, est dicendum, si quis stimulet equum, mulam, aut quancunq; aliam bestiam, aut aliter illam irriter ac prouocet ad calces mittendos, aut ad aliter

nocendum: si enim inde damnum aliquod vel domino bestiæ, vel cuicunque alteri, sequatur, tenetur similiter illud ei resarcire, quo de cane lacesito dictum est. Hæc habentur. *l. 1. §. sed & si. ff. si quadr. pau. feciss. dic. l. item Mela. §. item & cum eo. ff. ad leg. Aquil. & l. 21. & 22. titu. 15. part. 7.*

Item quando aliquis imperitus est ad regendū [sect. 28] equum, iumenta, aut alia animalia, aut ad impetum eorum continendum, tunc, si ea de causa talia animalia damnum dent, tenetur ipse id resarcire: quoniam in culpa est eius damni, cum aliorum periculo, id efficiendo, ad quod peritiam sufficientem, aut sufficientes vires, non habet. *Ita habetur. l. idem iuris est. §. 1. ff. ad leg. Aquil. & §. impetu quoque inst. eod. titu.*

Præterea, qui animalia aliena, sua culpa, fuga [sect. 29] uit, aut ita vrsit, vel minatus est, vt præcipitarentur, disparerent, aborsum facerent, aut aliud detrimentum acciperent, vel aliis darent, tenetur compensare id totum damnum. *Ita habetur. §. vlt. inst. de lege Aquil. & l. 21. titu. 15. part. 7.*

Qui sua culpa, saltem leuissima, occiderit [sect. 30] Mancipium alienum, aut pecudem alienam, tenetur lege Aquilia soluere domino, quantum plus id valuit intra annum retro computandum vsq; ad punctum occisionis, ita quòd dominus eligere potest valorem, quem res habebat tempore occisionis, vel quem habebat in quocunque die, aut puncto totius anni antecedentis finiti in puncto occisionis talis rei, quem maluerit. Atque hoc de interfectione Mancipii, aut pecudis, appellatur primum caput legis Aquiliæ. In eo verò, pecudum, nomine non comprehenduntur feræ, quæ non consueuerunt pasci gregatim, sed solum quadrupedia non fera, quæ gregatim pasci consueuerunt, vt sunt equi, muli, oues, houes, & sues, & similia animalia. Computantur etiam cum eiusmodi animalibus cameli & elephantes. Hæc omnia habentur. *l. 2. & l. ait lex. ff. ad leg. Aquil. inst. eod. titu. in prin. & l. 18. titu. 15. part. 7.* Atque quamuis tale Mancipium, aut pecus, tempore occisionis esset manchum, cæcum, aut debile, ac proinde exigui valoris, si tamen in aliquo momento totius anni retro, vsque ad occisionis tēpus, erat sanum ac robustum, longeq̃ue proinde maioris valoris, solui debet in eo maiori valore, quem tunc habebat, vt expressè habetur. *§. his autem inst. eod. titu. l. inde Neratius. §. idem Iulianus. ff. eod. titu. & l. 19. titu. 15. part. 7.* Quod similiter intellige in triginta diebus euentus sequentis. Si tamen ab aliquo alio, intra eum annum, aut intra eos triginta dies, fuit illatum damnum, quo ea res fuit reddita deterior; tunc, qui illud intulit, tenetur lege Aquilia de eo damno, neque est spectandus maior valor, quem ea res ante eam læsionem intra eum annum aut intra eos triginta dies habuit, vt posterior, qui damnum intulit, eum soluat. *Ita Greg. Lopez. l. 19. citata glos. 2. iuxta. l. item Mela. §. Celsus. ff. ad leg. Aquil.*

Qui verò non interficit Mancipium, aut pe [sect. 31] cudem, sed solùm sua culpa vulnerat, aut aliud damnum ei infert, vel cuius alteri rei alienæ, siue animatæ, siue inanimatæ, quodcunque damnum infert, etiam mortis, aut omnimodæ destructionis, soluit lege Aquilia, quantum res illa valet tempore damni accepti, aut triginta diebus antea, vt maluerit dominus, qui id damnum est passus. Atque hoc appellatur tertium caput legis Aquiliæ. Secundum verò in dissuetudinem abiit, & cum tertio computatur. Hæc habentur. *l. si seruus seruum. §. tertio autem capite. ff. ad leg. Aquil. §. tertio capite inst. eod. titu. & l. 18. titu. 15. part. 7.*

Quo indo autem damnum fuisse sibi datum probatū [sect. 32] fuit suffici enter ab eo qui illud est passus, statur iuramento illius, quantum illud estimetur, accedēte iudicis arbitrio ac moderatione, vt hab. *l. 18. cit.*

Quia lex Aquilia non solum præcipit restitui [sect. 33] damnum datum, sed etiam, quod plus valuit res, vel intra annum antea, vel intra triginta dies modo explicato, instit. de leg. Aquil. §. his autem, hæc verba subiunguntur: *Quaratione creditum est, pœnalem esse huius legis actionem: quia non solum tanti quisque obligatur, quantum damnum dede-[[83]]rit, sed aliquando longè pluris. Ideoque constat, in hæredem eam actionem non transire; quæ transitura fuisset, si, ultra damnum, nunquam lis æstimaretur.* Hinc vnum est satis perspicuum; alterum verò maximè dubium, scituque dignum, atque ea ratione accuratè examinandum. Quod est perspicuum, hoc sanè est. Legem hanc pœnalem esse quoad excessum ultra damnum culpa datum: idemque dicendum est de legibus suprà relatis, quæ duplum damni dati in aliquibus euētibus solui præcipiunt. Atque quemadmodum hæc omnes leges pœnales sunt quoad excessum ultra damnum culpa datum, sic etiam neque obligant ad illius solutionem ante latam sententiam, & antequam, post latam sententiam, exigatur in eius sententiæ exequutionem, vt suprà in hoc tractatu sæpe est dictū: neque item actio ad eum excessum transit aduersus hæredes delinquentis, vt ex. §. his autem, verbis paulo antea relatis, ex. l. inde Neratius. §. hanc actionem. ff. ad leg. Aquil. & ex. l. 3. titu. 15. part. 7. constat. Excipe, nisi lis contestata fuisset aduersus eum, qui damnum dedit, antequam ille è vita discederet; nam tunc hæredes illius tenerentur, non solum ad damnum, sed etiam ad pœnam, vt habetur. l. 3. citata, satisque perspicuum est ex dictis in principio disputationis præcedentis. Vtrum autem actio, quoad eiusmodi excessum, competat hæredibus eius, qui damnum est passus, quamuis. l. inde Neratius. §. hanc actionem. ff. ad leg. Aquil. & l. 2. in prin. titu. 15. part. 7. affirmant actionem legis Aquiliæ competere hæredibus eius, qui damnum est passus; quod tamen attinet ad excessum, de quo loquimur, quo ad quem ea actio pœnalis est, dic, non transire, nisi is, cui succedunt, dum viueret, actionem intentasset, aut eam præparasset; competere tamen eis querelam, vt de actione ad pœnam furti in principio disputationis præcedētis vtrumque est dictum; est quippe vtroque eadem ratio.

Alterum verò, quod ex eisdem verbis para [sect. 34] graphi, his autem, suprà relatis, est maximè dudium, ac scitu dignum, hoc profectò est. Num lex Aquilia, actioque ex illa concessa, sit pœnalis, etiam quoad damnum culpa datum, ac proinde ea actio, etiam quoad id damnum præcisè sumptum ab excessu, qui in pœnam statuitur, non competat aduersus hæredes eius, qui illud dedit, quando lis contestata non fuit aduersus dantē, dum ille ad huc viueret. Ac sane iura sentire statuereque videntur, etiam quoad id damnum, legem Aquiliam, actionemque ex illa esse pœnalem, nec competere aduersus hæredes eius, qui illud dedit, quando lis contestata non fuit aduersus eum antequam moreretur. Id quod satis apertè innuunt verba relata ex. §. his autem, & videtur haberi apertè. l. inde Neratius. §. hanc actionem. ff. ad leg. Aquil. dum ibi sic dicitur; *actionem hanc hæredi, cæterisque successoribus, dari constat; sed in hæredem, vel cæteros (successores scilicet) hæc actio non dabitur; cùm sit pœnalis: nisi fortè ex damno locupletior hæres sit factus.* Vbi vides Vlpianum, cuius est hic textus, affirmare, actionem ex lege Aquilia concedi hæredibus eius, qui damnum est passus, aduersus eum, qui illud dedit: in quo consentit. l. 2. in prin. titu. 15. part. 7. Et negare, concedi, etiam ei, qui damnum est passus, actionem aduersus hæredes eius, qui illud dedit; nisi ex damno facti sint locupletiores: atque idem affirmat. l. 3. titu. 15. part. 7. Arbitror tamen dicendum esse. Si damnum proficiscatur ex ea culpa, ob quam, seclusa omni lege humana, qui illud dedit, teneretur in foro conscientiæ illud restituere ex parte iniustæ acceptionis, damnive iniustè dati, tunc hæredes illius teneri restituere illud integrum de bonis defuncti sub reatu culpæ lethalis, esto, neque qui illud dedit, neque hæredes illius, facti sint ex eo damno locupletiores. Probatur,

quoniam restitutio illa est verum debitum defuncti non minus, quàm si furatus fuisset id damnum, seu detrimentum, quod dedit; ac proinde, quod ea de causa est restituendum, computatur inter æs alienum talis defuncti: defunctus verò non plus relinquere censetur in bonis, neque plus ad ipsius hæredes, ac legatarios, de bonis illius spectat, quàm quod remanserit deducto ære toto alieno eius defuncti: quare tenentur id totum restituere in foro conscientiæ, neque, quo ad id, lex Aquilia censetur, aut censi potest, lex pœnalis. Idem arbitror esse dicendum quo ad hoc damnum in foro exteriori, ac proinde concedendam esse in foro exteriori actionem prosequutiua aduersus hæredes quoad hoc damnum, quicquid Vlpianus senserit in illo. §. hanc actionem, vnde cætera posteriora iura originem habuerunt. Mirumque esset, quòd, si quis cum lethali culpa exussisset segetes alienas, isque mortuus fuisset, antequam earum dominus agnouisset damnum sibi datum, concedenda non est in foro exteriori illarum domino actio aduersus hæredes talis malefactoris, vt de bonis illius resarcirent damnum ita iniustè ab illo datum. Neque valet hæc consequentia; lex Aquilia est pœnalis, quia, aut quatenus, præcipit reddere aliquid vltra dānum iniustè datum, ergo est pœnalis, ac proinde ex ea non conceditur actio aduersus hæredes illius, qui tale damnum dedit, etiam quoad solum damnum iniustè ab eo datum; quæ consequentia fefellisse videtur Vlpianum, & post eum, atque cum eo, Theophilum. §. his autem, inst. de lege Aquilia in verbis illis, quæ ex illo suprà retulimus, si vterque in ea fuit sententia, quòd neque quoad damnum iniustè datum, præcisèque consideratum, detur actio aduersus hæredes illius, qui illud dedit: quare neque in exteriori foro erit standum tali sententiæ. Theophilus verò ipse confitetur, actionem ex lege Aquilia transituram fuisse aduersus hæredes eius, qui damnum dedit, si lege Aquilia præciperetur, vt solùm resarciretur damnum datum.

Qui sua culpa damnum dat, non solùm tene [sect. 35] tur restituere damnum, seu valorem, rei in se, quam destruxit, aut deteriore reddidit; sed etiam, si inde resultat damnum, diminutiõne valoris, in aliis rebus, aut quoduis aliud damnum ac detrimentum, id etiam tenetur restituere actione ex lege Aquilia, atque etiam in foro conscientiæ, nulla expectata sententia: quoniam sua culpa eorum omnium est causa. Vt si quis ex pluribus mulis, qui inseruiebant ad aliquod ministerium, ita vt sine vno eorum exerceri non posset, aut ex pluribus equis inseruientibus ad vehendum plastrum, aut rhedam, vel ex seruis tibicinibus, aut cantoribus, vnum interficiat, tenetur soluere, non solùm quantum ille in se valebat, sed etiam quantum minus valent reliqui sine illo. Item si man-[[84]]cipium institutum erat hæres ab aliquo, & antequam delata ad illud esset hæreditas, fuit interfectum, tenetur occidens restituere domino, etiam commodum, quod ex ea hæreditate sperabat, & ita de quocunque alio detrimento, quod ei ex tali occisione, aut priori damno, obueneret. *Ita habetur. §. illud inst. de leg. Aquil. l. ait lex. l. proinde. l. inde Neratius in prin. & §. sed & si seruus. ff. eod. titu. & l. 19. titu. 15. part. 7.*

Si aliquis coram iudice conueniatur de dam [sect. 36] no dato, negetque se illud dedisse, ac postea testibus sufficienter probetur illud dedisse, cogitur soluere duplum. *Ita habetur. l. 2. & l. inde Neratius. §. hæc actio. ff. ad leg. Aquil. l. contra negantem, & l. sequenti* (quæ intelligenda est cum glossa ibi, & cum communi doctorum sententia, quando negauit damnum id de disse) *C. eod. titu. & l. 16. titu. 15. part. 7.* Atque duplicatur in pœnam non solùm damnum datum, sed etiam quicquid lege Aquilia cogendus erat soluere, si non negasset se dedisse id damnum, vt affirmant glossæ tribus iuribus priori loco citatis, Azo, & alii, quos *Gre. Lopez. l. 16. citata glossa. 1.* refert ac sequitur. Licet autem quidam dicant, iudicem ex officio suo posse ac debere in eo euentu condemnare ad pœnam dupli, esto non petatur; Greg. tamen

Lopez ibidem ait, tutius esse, si in libello petatur, vt condemnetur in duplum, si damnum negauerit. Porrò tunc solùm cogitur soluere duplum, quando, postquam damnum in iudicio negauit, ei sufficienter per testes, aut aliunde, probatur damnum id dedisse. Secus autem quando id postea constat ex sua confessione, siue adhibitum fuerit ei iuramētum, siue non. Ita affirmant tres glossæ citatæ ac doctores communiter, habeturque. *l. 16. cita.* & consentit. *l. eum qui, in prin. ff. de iure iur.* Si minor neget se dedisse damnum, restituitur in integrum, vt non cogatur soluere duplum, sed solùm simplum, ac si delictum fuisset consessus. *Ita habetur. l. si ex causa. §. nunc in minoribus. ff. de minor. l. electio. §. neque. ff. de noxal. act. & l. 16. citata.* Item, si vxor aduersus virum, vel vir aduersus vxorem, agat de damno dato, etiam si, qui damnum dedit, neget se id dedisse, ac cōuincatur, non damnatur nisi ad simplex damnum resarciendum, non verò ad pœnam vllam. *Ita habetur. l. 16. citata,* & constat ex dictis suprâ de furtis domesticis.

Si agatur aduersus aliquem ciuilitè lege A [sect. 37] quilia, quòd interfecerit, aut vulnerauerit, seruum alienum, aut quòd aliud damnum intulerit: isque confiteatur, se id damnum intulisse: si postea probet, id damnum non esse illatum, quia probat eum seruum viuere, aut ex morbo, & nō ex interfectione, fuisse mortuum; vel quia probat seruum, quem vulnerasse fuerat confessus, nunquam vulnus accepisse; aut quia probat id, cui aliud damnum intulisse fuerat confessus, nunquam tale damnum fuisse passum; tunc non tenetur lege Aquilia resarcire id damnum: secus autem, si probetur, aut constet, id damnum esse datum: nam tunc condemnatur lege Aquilia, nihil impediēte, quòd probare postea velit, se illud non dedisse, nisi probet, quis illud dederit, seque nulla ratione id fecisse. *Ita habetur. l. inde Neratius. §. ult. & tribus legibus sequentibus. ff. ad leg. Aquil. & l. 17. titu. 15. part. 7.*

Quando multi vulnerarunt eundem seruum [sect. 38] alienum, & mortuus est, adeò discordare videntur. *Vlpianus. l. it em Mela. §. sed si seruum, & l. huic scripturæ. §. si seruus, & Iulianus. l. ita vulneratus. ff. ad leg. Aquil.* vt difficilè ad concordiam adduct posse videantur; tametsi glossæ satagant ad concordiam eos reuocare. Dicam verò, vt theologus, ac moralis Philosophus, quid consonantius naturæ rei, posita iuris ciuilis dispositione circa legem Aquiliam, videatur mihi: id quod consonum erit legi. 15. titu. 15. part. 7. tametsi ea lex non omnes euentus circa rem hanc definierit.

Quando multi eum seruum vulnerarunt, (idē suo modo dic, si pecudem alienam similiter occiderunt) nec constat ex cuius vulnere is interierit, quia vel omnia vulnera erant æquè lethalia, vel quia licet constet vnum tantum esse lethale, ignoratur quis eorum illud inflixerit, vel denique quia ignoratur, num ex posteriori vulnere, licet leuiori, adiuncto antecedenti, mortuus fuerit, si ciuilitè agitur ad damnum, & ad pœnam, vt tantum soluatur, quantum ille plus valuit intra annum computatum retro à puncto vulneris lethalis inflictī, modo suprâ explicato, tunc aduersus singulos, de quibus est dubium, an illum interfecerint, agi potest, arbitrio eius, cui id damnum est resarciendum, & aduersus omnes simul, vt contribuant; non tamen agi potest aduersus omnes, vt singuli id totum tribuāt. Quòd si agatur aduersus vnum solum, & ille non integre soluat, vel quia disparuit, neque inueniuntur bona illius, vnde soluatur, vel quia non est soluendo id totum damnum, agi potest aduersus quencunque alium, vel aduersus quoscunque alios ex reliquis, vt integre id totum soluant. Vno tamen ex omnibus persolvente integre id totum, quod lege Aquilia statutum est vt soluatur, is, cui ea actio competeat, agere non potest aduersus reliquos. Qui tamen soluit, poterit agere aduersus reliquos actione negotiorum gestorum, vt contribuant, quod loco illorum soluit: quandoquidem actio tunc æquè aduersus omnes competeat, omnesque erant debitores

interesse illius. Quin, si is, cui soluendum id erat, & cui ea actio competebat, cedat ei, qui totum soluit, actionem, quæ ei aduersus reliquos competebat, agere tūc is poterit lege Aquilia, vt singuli contribuant. Imò, si vnus non sit soluendo, agere poterit, vt reliqui secum totum persoluant.

Primum eorum, quæ dicta sunt, nempe agi tunc posse aduersus singulos, de quibus est dubium, quis illum interfecit, quando constat omnes eum vulnerasse, & ignoratur, ex cuius vulnere interierit, idque pro arbitrio eius, cui id dānum est resarciendum, habetur. *l. item Mela. §. sed si seruum, & §. sed si plures, & l. ita vulneratus. §. rursus vers. idque est consequens. ff. ad leg. Aquil. & multo expressius. l. 15. titu. 15. part. 7.*

Secundum verò, quòd scilicet agi possit simul aduersus omnes, saltem vt contribuant id totum, quod lege Aquilia est soluendum, satis perspicuum est: quoniam ex iuribus citatis, actio aduersus omnes competit ei, cui tale damnum est soluendum: quare agere poterit aduersus omnes simul, saltem vt omnes illud totum soluant, contribuendo inter se, atque contribuendo etiam pro iis, qui re ipsa non statim soluerint: eo modo, quo de duobus reis debendi, & de fideiussoribus, qui in integrum tenentur, suprà suo loco est dictum.

[[85]] Tertium verò, videlicet, quòd agi non possit aduersus omnes, vt singuli id totum tribuant, probatur. Quoniam lege Aquilia solum est statutum, vt pro seruo iniuste occiso soluatur, non solum damnum ei datum, sed simul etiam in pœnam, si quid plus valuit intra annum retro à puncto vulneris lethalis inflicti: si autem quatuor eum percussissent, ac nesciretur, ex cuius vulnere interierit, sequeretur, soluendum ei tunc esse quadruplum damni accepti, & insuper quadruplum incrementi æstimationis, si quod fortè habuit in aliquo puncto anni antedētis; quod esset omnino irrationabile, & præter intentum legis Aquiliæ: præsertim quando constaret, vno solo vulnere interiisse, sed ignoraretur, quis illorum quatuor illud dedisset: nam tunc vnus solus dedisset id damnum, & vnus solus ad illud re ipsa teneretur, sed ignorantia faceret, vt omnes pro in diuiso tenerentur, interim dum non constaret, quis illud dederit. Imò, si aliquis alius prius eum seruum vulnerasset, sed non lethaliter, teneretur de seruo vulnerato, quanto plus æstimaretur, quam cum eo vulnere, intra dies triginta antea, vt habetur. *l. 15. citata, iuxta. l. item Mela. §. Celsus, & l. hæc scriptura. §. si seruus. ff. ad leg. Aquil. & occisor solum teneretur de seruo illo, detracto eo valore ex vulnere prius accepto, quem soluere teneretur is, qui id vulnus prius inflixit, iuxta eadem iura proximè citata. Vnde meritò. l. 15. citata statuit, vt quando multi percusserunt, & non cōstat ex cuius vulnere interierit, soluente vno integre damnum iuxta maiorem valorem, quem intra annum retro seruus occisus habuit, non maneat actio legis Aquiliæ ei, qui damnum est passus, aduersus reliquos. Neque refragatur. l. item Mela. §. si plures. ff. ad leg. Aquil. quæ sic habet: *Si plures trabem dejecerint, & hominem oppresserint, æquè veteribus placet, omnes lege Aquilia teneri.* Sensus enim est, quòd omnes æquè teneantur ad æstimationē damni, & ad maiorem valorem, si quem seruus occisus habuit intra totum annum antecedentē, & quòd singuli pro indiuiso teneantur in solidū ad id totum damnum, eo quòd singuli id totum dederunt totalitate effectus ac damni dati: non tamen est sensus, quòd singuli ita teneantur soluere integrum damnum ei, qui illud est passus, quasi tot æstimationes integras totius damni accipere debeat, quot fuerunt, qui illud dederunt totaliter, effectus totalitate, accipiendo singulas integras à singulis; id enim esset prorsus irrationabile: sed quia nihilominus singuli partialiter tantū illud dederunt, causæ partialitate; & omnes simul totaliter, totalitate causæ, omnes quidem pro indiuiso tenentur ei soluere integrum dānum vnica solutione, qua sufficienter illud ciuilitate ei resarciunt iuxta legis Aquiliæ dispositionem;*

singuli tamen solùm tenentur contribuere æqualiter: eaque de causa, si vnus eorum totum soluat, vel quia is, qui illud est passus, ab eo solo illud exegerit, eo quòd, modo explicato, integrum illud debeat, vel aliqua alia ratione, reliqui contribuere ei tenentur, quod loco ipsorum soluit: non secus atque hæc omnia similiter habent locum in multis reis debendi in solidum id ēdebitū, vt suo loco suprà explanatum est.

Exemplum verò, quod *Iulianus. l. ita vulne* [sect. 39] *ratus. §. vlt. ff. ad leg. Aquil.* affert in confirmationem suæ sententiæ, de qua statim erit sermo, nempe, si tres furentur eandem trabem, quam vnus solus furari, amoueré à loco, in quo erat, non poterat, omnes teneri de furto, sanè potiùs confirmat, quàm infirmet, nostram sententiam. Etenim, si aduersus illos agatur ciuilitè conductione furtiua, ridiculum est affirmare, deberi condemnari, vt restituant tres trabes domino trabis furto ablatae, singuli singulas, & vt insuper resarciant si quæ damna fuerint eidem domino ex eo furto subsequuta, singuli ea integra, ac proinde omnes simul in triplum; & si vltèriùs agatur furti etiam actione ad pænam dupli, ridiculum similiter est, condemnandos esse, vt singuli soluant insuper duplum æstimationis trabis, ita vt dominus accipiat sextuplum ex omnibus. Quod ergo eo. §. *Iulianus* voluit, est, omnes, ac singulos, teneri in coeuentu de furto, & licèt singuli teneantur ad totum furtum, & ad integra damna inde subsequuta, eo quòd singuli causa fuerunt totius furti, teneri tamen singulos pro indiuiso in solidum; cæterùm, quia partiales causæ fuerunt eius furti, causæ partialitate, teneri singulos contribuere partem, & ita omnes simul teneri soluere totum; vnoque soluente integrum furtum ac damna, dominum trabis nihil aliud posse petere à reliquis: eum tamen, qui integrum furtum damnaque integra soluit loco omnium, petere actione negotiorum gestorum posse, vt reliqui ipsi restituant partes, quas eorum loco soluit. Si autem ageretur criminaliter ad pænam corporalem, singuli profectò essent damnandi, ac si solam tertiam partem trabis vnusquisque esset furatus; & insuper, si fuit etiam causa furti alicuius cæterorum, id ei consulendo, aut ad id eum aliter mouendo, puniendus est etiam criminaliter, tanquam causa furti partis aliæ eiusdem trabis.

Quartum denique, & reliqua, quæ subjunguntur, satis perspicua sunt ex probationibus trium præcedentium, atque ex dictis in materia de cōtractibus, dum nobis erat sermo de duobus reis debendi, atque de fideiussoribus in solidum pro debito aliquo. Neque dubito, dominum Mancipii, si accipiat ab vno solo totum, quod lege Aquilia ipsi est soluendum pro damno interfectionis Mancipii, teneri ei cedere actiones suas legis Aquiliæ aduersus reliquos, vt, qui partes aliorum soluit, eas ex illis actione legis Aquiliæ recuperare etiam possit; vt de creditore accipiente integrum suum debitum ex vno reo debendi, aut ex vno fidei iussore, in solidum, cedere ei actiones suas teneri, vt, quod loco aliorum soluit, recuperare ex eis possit, prædicto loco est dictum.

Quod ad irregularitatem pro homicidio at [sect. 40] tinet, dicendum est, singulos, de quibus est dubium, an ex eorum vulnere tale Mancipium, aut quiuis alius, interierit, censendos esse irregulares interim, dum aliud non constat. Ratio autem est, quoniam, licèt quando est dubium, an pro aliquo actu sit imposita irregularitas in iure, censendum sit impositam non esse, ac proinde censendum sit exercentem eum actum irregularem non esse; quando tamen constat pro actu aliquo impositam esse irregularitatem in iure, vt constat impositam esse pro homicidio, tunc in dubio, an aliquis occiderit, reputandus est irregularis, vt tractatu sequenti, dum de irregularitate pro homicidio, & mutilatione, ser- [[86]]mo fuerit, dicetur, & constat in re proposita ex. c. significasti. 2. de homicidio, & cum glossa ibi affirmat *Greg. Lopez. l. 15. citata glossa. 1.* Si verò agatur pro eiusmodi homicidio criminaliter, quanta

pæna imponi debeat singulis, de quibus est dubium, an ex ipsorum vulnere aliquis interierit, dicetur tractatu sequenti.

Quando verò vnus percussit lethaliter seruū [sect. 41] alienum, & alius postea ex intervallo illum iterum percussit ac interfecit, discordes videntur *Iulianus. l. ita vulneratus. ff. ad leg. Aquil. §. Vlpianus. l. item Mela. §. Celsus. §. l. huic scripturæ. §. si seruus. ff. ad leg. Aquil.* Iulianus enim affirmavit, vtrumque teneri de seruo occiso lege Aquilia, annumque, quoad primum, computandum esse retro à pūcto, quo vulnus lethale inflixit: quoad secundum verò à puncto, quo postea percussit ac interfecit: atque innuere videtur, vtrumque teneri ad integram satisfactionem ex lege Aquilia, ita vt duplex integra satis factio fieri debeat domino serui alieni. Vlpianus verò postea cum Celso & Marcello asseruit, primum teneri solūm de seruo vulne rato, quod ad dispositionem legis Aquiliæ attinet: secundum verò teneri de seruo occiso, atque hoc ipsum statuit. l. 15. titu. 15. part. 7. huicque definitioni, vt posteriori, ac correctoriæ dispositionis Iuliani, est standum, quam etiam asseruisse Celsum, & probabiliorem existimasse Marcellum, resert Vlpianus. §. Celsus citato. Scio glossam. l. ita vulneratus, ad concordiam adducere voluisse vtrāque sententiam, quòd Vlpianus sit loquutus, quando vulnus erat lethale, sed non certum omnino, quòd percussus moriturus esset ex illo: & Iulianus quando certum omnino esset, moriturum fuisse ex illo. Cæterū vterque iurisconsultus simpliciter vniuersimque loquitur: neque vnquam est dicendum, soluendam domino serui esse duplam æstimationem illius, sed simplam tantūm. Atque iuxta Vlpiani sententiam, primus, qui primò lethaliter percussit, restituere debet domino serui, quantum minus valet cum eo vulnere, æstimando seruum, quantum plus valebat intra dies triginta retro computatos à puncto vulneris inflictī: & insuper soluere debet expensas vsque ad vulnus postea illi ab alio datum, & omnia alia damna vsque ad id instans subsequuta. Is verò, qui postea interfecit, soluere solūm tenetur, quantum seruus plus valuit intra annum retro computatum à puncto posterioris vulneris, detracto, quod minus valuit propter prius vulnus ab alio inflictum: nam cam æstimationem soluere tenetur, qui prius vulnus inflixit, vt dictum est. Atque hæc Vlpiani decisio satis consona est rectæ rationi, & amplectenda, quod attinet ad ciuilem actionem ex lege Aquilia, de qua sola ipse loquitur.

Quod verò attinet ad irregularitatem, vter [sect. 42] que procul dubio irregularitatem incurrit: eo quòd vterque causa fuerit mortis illius, & consentit. c. consuluisti. 2. de homicidio. Erit verò vterque irregularis ex homicidio voluntario, si vterque eo modo percutere intendit. De pæna verò criminali vtriusque, tractatu sequenti erit sermo. Si tamen secundus casu acceleraret mortem, ignorans vulneratum eum esse, aut præter intentionem id efficiens, vnde sequuta esset mors, tunc irregularis non esset ex homicidio voluntario, neque ipse, sed primus, teneretur de mancipio mortuo, quando non effecit, quod ad mortem sufficeret, si non præcessisset illud aliud lethale vulnus. Quando vnus lethale vulnus inflixit: euenit verò postea, vt ex ruina, aut ex alio infortunio, seruus ita percussus interierit, tunc, qui ita eum percussit, non tenetur lege Aquilia de seruo mortuo, sed de seruo vulnerato. Quando verò post vulnus acceptum, legatus alteri fuit, aut manumissus, si moriatur ex eo vulnere, lege Aquilia tenetur de seruo mortuo. Vtrumque habetur. l. huic scripturæ. §. si seruus. ff. ad l. Aquil.

Quando alienus seruus vulneratus fuit non [sect. 43] mortiferè, si negligentia, aut culpa sua, vel domini, aut alterius, interiit, percussor non tenetur de seruo occiso, sed de seruo vulnerato. Ita habetur. l. qui occiderit. §. ult. ff. ad leg. Aquil. Idem quando criminaliter agitur

de seruo, aut de homine libero, ita non mortiferè vulnerato, qui culpa sua, Chirurghi, aut alterius, interiit.

Actio de damno dato competit domino [sect. 44] rei, & hæredibus illius post eius mortem, præcisè quoad damnum, atque etiam quoad pœnam, si lis fuerat à defuncto contestata, aut præparata, vt suprà dictum est. Competit etiam vsufructuario, atque vsuario, sed præcisè quoad damnum in vsufructu, aut in vsu, suscepto. *Ita habetur. l. item Mela. §. ultim. & l. sequenti. ff. ad leg. Aquil. & l. 2. titu. 15. part. 7.* Item possessori rei bona fide, in qua damnum est datum, competit hæc actio, ita vt repelli non possit exceptione, quòd ad ipsum non attineat. *Ita habetur. l. item Mela. §. sed si seruus bona fide. ff. ad leg. Aquil. & l. 2. citata.* Quod glossa. §. sed si seruus citato, ex Azone intelligit, modò cum titulo possideat, & consentit Greg. Lopez vbi suprà. Depositarius item agit loco domini, si sit absens, vt habetur. l. 2. citata ex doctrina Azonis. Et idem videtur esse de commodatario, & de quocunque alio legitimo rei detentore, quando dominus rei est absens, vt ibi Greg. Lopez affirmat. Lex tamen item Mela. §. eum. ff. ad leg. Aquil. commodatario denegat hanc actionem. Quod intelligendum est, nomine proprio, & quando dominus est præsens. Item intelligenda est, quoad damnum domini, & quoad id, quod pœnale est in hac actione de iure humano introductum: secus autem quoad particulare damnum, præcisè sumptum, quod sequitur commodatario, conductori, aut cuicunque alteri eius rei legitimo detentori: quoniam id actione in factum exigere optimè potest ab eo, qui illud ei dedit.

Si pignori damnum sit datum, dominus pig [sect. 45] noris agit lege Aquilia, & non creditor: nisi quando debitor non est soluendo, aut creditori periculum immineret: nam tunc agit creditor, & retinet vsque ad debiti quantitatem: reliquum verò restituit debitori, deductis expensis. *Ita habetur. l. qui occiderit. §. 1. ff. ad leg. Aquil. & l. 2. citata, quæ dilucidius hoc definit.*

Si seruus in particulari erat alicui legatus, & [sect. 46] post delatam hæreditatem, & ante eam aditam, fuit occisus, ait *Vlpianus. l. huic scripturæ, in prin. ff. ad leg. Aquil.* competere hæredi, ratione hæreditatis, actionem legis Aquiliæ, & non legatario: innuereque videtur, ad nihil teneri [[87]] hæredem legatario, sed quòd ea actione fuerit hæres consequutus, ad ipsum, & nihil ad legatarium, pertinere. Quod certè videtur valde durum. Etenim, statim delata hæreditate, comparauit legatarius ius integrum ac perfectum ad eū seruū, licèt non comparet dominium, nisi à puncto aditæ hæreditatis, si tunc seruus in rerū natura existat: quare æquitas postularet, vt actio legis Aquiliæ cederetur in eo euentu, aut certè sine cessione competeret legatario. Atque in hoc Regno, in quo, *iuxta. l. 1. titu. 4. lib. 5. nonæ collect.* legata valida sunt, esto hæres institutus hæreditatem non adeat, arbitror esse omnino dicendum, competere hanc actionem legatario eo ipso, quòd seruus post aditam hæreditatem est mortuus, siue post eam delatam, & ante eam aditam, siue post eam aditam, fuerit occisus. Quando seruus legatus in singulari, vulneratus fuit post delatam hæreditatem, & ante eam aditam, viuebatque post eam aditam, tunc hæres post aditam hæreditatem tenetur cedere actionem legis Aquiliæ legatario, *vt habetur. l. huic scripturæ citata, & l. 2. titu. 15. part. 7.* Quòd si legatarius sit absens, agit hæres, aut quicunque alius eius rei tentor, actione legis Aquiliæ ad id damnum loco legatarii, vt, quod obtinuerit, ei restituat, deductis expensis, vt habetur eadem l. 2. citata.

Quòd si seruus sit vulneratus, aut interfectus, post aditam hæreditatem, tunc, cū à puncto hæreditatis aditæ, dominium serui illius transiisse censeatur in legatarium à tempore mortis testatoris, hæreditatisve delatæ, vtique actio legis Aquiliæ pro eo damno competit

soli legatario, si præsens sit, vt habetur. l. liber homo. §. si seruus legatus. ff. ad leg. Aquil. Hæc, quæ de seruo legato dicta sunt, similiter intellige de quocunque alio animali legato, & de quacunque alia re legata, vt habetur. l. 2. citata, atque ex se liquet, cùm sit eadem ratio.

Vtrum, qui culpa solùm leui, aut leuissima, damnum de dit, teneatur in foro conscientiae ante latam sententiam illud restituere; an verò solùm in exteriori foro teneatur illud restituere, ac proinde expectare possit in conscientiae foro, vt feratur sententia. Disput. 698.

SVMMARIVM.

*Q*ui asserant solum dantem damnum dolo, aut lata culpa, teneri illud restituere in conscientiae foro ante latam sententiam: non verò dantem illud culpa sola leui, aut leuissima.

2 . Qui asserant dantem damnum culpa solùm leui, aut leuissima, teneri illud restituere in foro conscientiae, nulla expectata sententia.

3 . Damnum ita datum, quòd, nisi id dans. firmum haberet propositum illud restituendi in euentu, quòd eueniret, peccaret contra iustitiam, restituere illud tenetur in conscientiae foro nulla expectata sententia, si eueniat: transitque ea obligatio ad ipsius hæredes.

4 . Damnum dari potest culpa theologica lethali, interueniente sola culpa leui, aut leuissima, iuridica. Fieri item potest, vt interueniat culpa iuridica lata cum proximi notabili detrimento, absque culpa theologica lethali.

5 . Damnum datum culpa iuridica absque culpa theologica, idque quod lex Aquilia insuper solui statuit, non in pœnam est statutum, neque statui potuit, sed in commune reipublicæ bonum, pro principum ad id potestate.

6 . Damnum datum culpa iuridica absque culpa theologica, non solùm quoad incrementum lege Aquilia statutum, sed etiam quo ad damnum ipsum, non est obligatio restituendi in foro conscientiae ante latam sententiam in exteriori foro.

7 . Damnum iniuste datum culpa theologica veniali, restituendum est in foro conscientiae, nulla expectata sententia.

8 . Damnum, ex quo quis tenetur contractu, iurisve dispositione, vt ex commodato, locatione, &c. esto nulla interueniat culpa theologica, restituendum est in foro conscientiae, nulla expectata sententia.

Innoentius. c. sicut dignum de homic. quem se³³ quiti sunt Panor. c. cum causam de iestib. n.

7. [sect. 1] c. dilecti de arbit. n. 12. &c. c. quoniam contra de probat. n. 18. Syluest. verb. culpa. n. 5. &c. 6. &c. verb. aduocatus. §. ult. ac verb. restitutio. 2. pronuntiato. 12. Decius, Fel. & alii, quos Couar. in. 4. decret. part. 2. c. 6. §. 8. n. 12. refert, in ea fuit sententia, vt diceret. Eum quidem, qui damnum de dit dolo, aut lata culpa, restituere teneri damnum in foro conscientiae nulla expectata sententia. Eum tamen, qui leui, aut leuissima, culpa damnum

dedit, non priùs teneri illud restituere, quàm in exteriori foro sententia feratur. Atque hanc affirmant Sylvester, & alii; esse communioem doctorum sententiam.

Ducuntur hi autores. Quoniam re vera, ex³⁴ ipsa rei natura, seclusa lege positiva, qui culpa iuridica leui, aut leuissima, damnum dat, non tenetur restituere id damnum; eo quòd neque ex parte rei acceptæ, neque ex parte iniustæ acceptionis, ad id teneatur; quandoquidem culpa iuridica leuis, aut leuissima, interuenire potest absque culpa theologicè sumpta, hoc est, absque peccato, vt Disp. 293. fuit explanatum. Quòd si aliquando cum culpa leui peccatum interueniat, illud erit veniale, quod non inducit obligationem restituendi totum damnum datum, sed partem tantum, pro culpæ quantitate. Quo fit, vt, quod lex Aquilia hac de re statuit, & disputatione præcedente explicatum est, solùm sit in pænā: id quod iura quædam ibi citata apertè docent, eaque ratione statuunt, actionem ex lege Aquilia, non trāsire in hæredes eius qui damnum dedit, nisi lis cū illo fuisset ante illius mortem contestata: cum ergo pænā, lege statuta, non debeatur ante latam sententiam; consequens est, vt, qui sola culpa leui, aut leuissima, damnum dedit, ad restitutionem illius in foro conscientiæ ante latam sententiam non teneatur, sed solùm post sententiam in foro exteriori latam. Argumentum hoc non ita proponunt autores huius sententiæ, sed solum dicunt, restitutionem damni lege Aquilia, statutam tantùm esse in pœnam, eaque de causa dantem damnum ex sola culpa leui, aut leuissima, non teneri illud restituere ante latam sententiam.

In contraria sententia, nempe damnum dantē³⁵ culpa leui aut leuissima, teneri in conscientiæ foro illud integrum restituere ante latam sententiam, [sect. 2] [[88]] sunt Adrianus de rest. q. vtrum in foro animæ, &c. Angel. verb. culpa in fine, Panor. qui, scribens postea in. 5. decretalium, sententiam mutauit. Nam. c. si egressus de iniur. & damn. dat. adducens dictum Innocentii, quod toties antea cōmendauerat, incipit de veritate illius dubitare, & postea. c. vlt. eiusdem tituli, contrariam sententiam apertè amplectitur. In eadem sententia est Barbat. à Couar. vbi suprā relatus, videturque esse Ioan. Med. de rest. q. 9. atque eandem amplectitur Couar. n. 12, citato, tametsi firmiùs, quando damnum est datum culpa leurssima, quàm quando datum est culpa leui.

Ratio, cui hæc sententia nititur, hæc est. Quo³⁶ niam dispositio iuris ciuilis hac de re, quamuis quoad excessum valoris, quem aliquando restituere iubet supra id, quod res valebat tempore, quo damnum ei fuit illatum, pœnalis sit, vt habetur. §. his autem inst. de leg. Aquil. & l. inde Neratius. §. hanc actionem. ff. eod. titu. nihilominus quoad compensationem damni ad æqualitatem, pœnalis non est, sed summa cum æquitate constituta, vt homines, timore obligationis iniunctæ restituendi, si quod damnum quacunque sua culpa dederint, cautiore sint ad illud suis proximis non inferendum. Quod sanè potestas publica statuere optimè potuit in bonum commune, reque ipsa statuit, Aquilio regulo, plebis tribuno, id postulante, atque inde lex, qua id ita sancitum fuit, Aquilia fuit nuncupata, per quam leges omnes, quæ de damno dato antea fuerant stututæ, abrogatæ sunt, vt habetur. l. 1. ff. ad leg. Aquil. Quarè, cū lex ciuilis, rationabilis ac iusta, ea ex parte qua pœnalis non est, vim in conscientiæ foro habeat ante latam sententiam, cōsequens profectò esse videtur, legem Aquiliam, quatenus iubet resarcire ad æqualitatem damnum quacunque culpa datum, vim in foro conscientiæ habere ante latam sententiam.

Id quod confirmatur ex Greg. 9. c. vlt. de in³⁷iur. & damn. dat. vbi, interrogatus à quodam, an restituere teneretur damnum, quod fua ignorantia dedit, respondet, si quacunque sua culpa iuridica illud dedit, restituere teneri. Neque ibi videtur explicare forum externum, sed

conscientiæ forum: quandoquidem non iudici, sed delinquenti, respondit, solumque præceperit restituere damnum, non verò aliquid in pœnam ultra damni valorem.

Adde, si dispositio illa (quoad damnum præ³⁸cisè) non solùm iuris ciuilis, sed etiam canonici, esset propriè pœnalis, esset vtique apertè iniusta; eo quòd nescias sit, statuere pœnam propriè, & multo magis cam exigere, nisi pro vera culpa theologica, hoc est, pro peccato: sæpe autem damnum datur culpa iuridica absque aliqua theologica culpa.

Adde etiam, similem legem latam fuisse à Deo³⁹ *Exod. 22.* quoad compensationem ad æqualitatem damni dati, quando aliquis ignem succēdebat, atque ignis exurebat segetes alienas: sic enim habet sacer ille textus: *Si egressus ignis inuenerit spicas, & comprehenderit acervos frugum, siue stantes segetes in agris, reddet damnum, qui ignem succenderit.* Vt autem Adrianus. q. citata bene notat, eadem lex hodie vim habet, non quatenus erat lex iudicialis veteris Testamenti, quæ Christi morte cessauit, sed quatenus iure canonico est innouato. c. si egressus de iniur. & damn. dat. Ea autem lex, iuxta glossam ibi, & doctores communiter, solùm habet locum, quando interuenit culpa aliqua iuridica, quæ semper præsumitur in foro exteriori, nisi cōtrarium sufficienter probetur.

Vt verò, sub aliorum iuridicio, dicam in re [sect. 3] difficili, quod mihi sese offert, atque magis certa à minùs certis separem. In primis dico. Quando damnum ita datum est, quòd illud dans peccaret contra iustitiam aduersus proximum id dando, nisi firmum haberet propositum, quòd in euentu, quod sequeretur, illud integre restitueret; tunc, si sequatur, datùmve sit, tenetur in foro conscientiæ, qui illud dedit, integrum id restituere, nulla expectata sententia, transitque proinde ea obligatio ad ipsius hæredes, etiamsi lis aduersus eum, dum viueret, contestata non fuerit. Proposui autem hoc nostrum assertum sub hac forma. Quoniam euenire potest, vt quis rem aggrediatur, ex qua periculum imminet rebus alienis, quique peccaret contra iustitiam, si illam aggrederetur minimè paratus satisfacere damnum, si quod inde aliis proueniret; paratus verò illud integre satisfacere, vel omnino non peccaret, si alii nullo modo essent inuiti, quòd sub ea lege & conditione id aggrederetur, aut si non essent rationabiliter inuiti, vel certè aliquādo solùm peccaret venia liter, esto illi rationa biliter essent inuiti, animo illo integre, & cum effectū, satisfaciendi damnum, si quod eueniret, valde extenuante ac minuente culpam, quæ alioquin esset, si sine eo animo id aggrederetur. Quando verò cum prædicto animo rem periculosam aggrederetur, indeque damnum aliis proueniret, consurgeret quidem obligatio restituendi in conscientiæ & in exteriori foro id damnum, non quidem ratione culpæ theologicæ, sed ratione pacti, seu quasi pacti, sub quo id damnum sine culpa theologica datum esset; cū tamen vera theologica culpa contra iustitiam, eaque lethalis, alioquin interuenisset, si quātitas damni esset tanta, quæ in materia furti ad culpam lethalem sufficeret. Idem etiam euenire potest in damno dato de industria cum eo animo integre cum effectū illud resarciendi. Quòd autem in omnibus euentibus, nostro hoc asserto cōprehensio, obligatio sit in foro conscientiæ integrè restituendi damnum datum, nulla expectata sententia, idque sub lethali culpa, si damnum tantum sit, quod in materia furti ad culpam sufficiat lethalem, nulli potest esse dubium, neque de hac re video esse vllam controuersiam; tametsi nullus, quod recorder, sub hac nostra forma fuerit loquutus. Quare non est cur in eo amplius immoremur.

Illud verò admonuerim, culpam posse aliquā [sect. 4] do interuenire theologicam lethalem, coniunctam cum sola culpa iuridica leui, aut etiam leuissima, aggrediendo rem valde periculosam, & quæ multum potest nocere, sine animo integre resarciendi cum effectū, moraliter certo, damnum totum, si quod fuerit sequutum, ac proinde non esse regulam

certam, etiam stando in fundamento autorum prioris sententiæ, quòd vniuersim, si damnum culpa iuridica leui, aut leuissima, proueniat, non consurgat obligatio in foro conscientiae resarciendi id damnum ante latam sententiam. Quo enim res magis est periculosa, quia facilè valde potest ex ea prouenire damnum, [[89]] & quo damnum, quod euenire potest, est maius, eo maior est culpa theologica, eam aggredi, & quacunque negligentia in cauendo, & obuiando, ne noceat, vt in nauium incendiis liquet, quæ facilè, & cum ingenti damno hominum, ac mernum, ipsiusque nauis, solent ex leuissima ignis occasione euenire. Item, stando in eodem fundamento autorum eius sententiæ, non esset vniuersim verum aliud eorum assertum, quo dicunt; si damnum lata culpa iuridica sit datum, consurgere obligationem in foro conscientiae illud integre restituendi nulla expectata sententia. Vt enim Disput. 293. explanatum fuit, esse potest aliquando lata culpa, ex qua quis teneatur, iuxta leges contractus, iurisque dispositionem, quæ tamen coniunctam non habeat culpam theologicam lethalem. Dico deinde, quando cum culpa iuridica con [sect. 5] iuncta non est culpa theologica, dispositionem legis Aquiliæ, quòd soluatur damnum datum, quantum res plus valuit intra triginta dies, aut intra annum, retro à puncto damni dati, non esse propriè ac verè pænalem, non solùm quoad latitudinem valoris damni dati, sed etiam quoad excessum illum vltra valorem damni re ipsa dati: neque esset iusta, aut seruanda, ea lex, si in veram pœnam aliquid eorum esset sancitum. Probatur, quia vbi non est culpa theologica, verùmve peccatum, locum non habet pœna, quæ solum potest iustè infligi pro vera culpa, hoc est, pro peccato in genere moris. Cùm ergo, quod lege Aquilia in eo euentu solui resarcirique præcipitur, neque in veram pœnam præcipiatur; quia, vt dictum est, vbi non est theologica culpa, locum nō habet pœna; neque item quasi ex natura ipsa rei, seclusa lege humana, restitui sit debitū; eo quòd neque ratione rei acceptæ, neque ratione iniustæ acceptionis, damnive iniustè dati obligatio sit id restituendi; quia esse nequit iniustitia sine vera culpa theologica; consequens profectò est, vt non ex alio capite censendum sit, id iustè solui præcipi, quàm quia lex ipsa Aquilia, quæ mera est dispositio iuris humani in commune bonum pro Principum reipublicæve ipsius potestate, statuit, vt quicumque damnum culpa sua iuridica, saltem leuissima, daret, id, modo lege ipsa Aquilia præscripto, resarcire teneretur, vt ea ratione homines cautiores essent, magisque abstinerent, a damno aliis inferendo, & ad tollenda ea ratione dubia, num vera theologica culpa datum esset, præcipiendumque esset resarciri, an non. Cùm autem ea lex æqualis sit omnibus de republica, atque in commune bonum statuta, (sicut & illa alia, de qua inferiùs suo loco erit sermo, qua sancitum est, vt, qui mancipium, aut aliud animal, habuerit, cùm eo onere ea possideat, vt, si damnum aliquod dederint absque vlla domini culpa, teneatur dominus vel resarcire id damnum, vel tradere noxæ tale mancipium, aut aliud animal, quod id damnum dederit, in damni recompensationem, prout dominus ipse talis animalis eligere potius velit) dubitandum non est, eam legem vim habere obligandi in foro conscientiae, quantum intendit, vt etiam in eo foro obligaret; aut saltem quantum vtentium vsu est recepta, vt in eo foro obliget: eo quòd leges, quoad id, quod de solo iure humano continent, non plus obligent, quàm vsu fuerint receptæ, atque exequutioni mandatæ. Hinc tertiò dico. Quando in damno dando, [sect. 6] culpa solùm iuridica, sine culpa theologica, interuenit, num obligatio sit id damnum resarciendi in foro conscientiae, nulla expectata sententia; an verò solùm in foro exteriori, in conscientiae verò foro non, nisi post latam in exteriori foro sententiam; pendere, tum ex intento eorum, qui legem Aquiliam condiderunt: tum etiam ex eo, num in vsu & praxi sit receptum, vt id damnum, quod culpa iuridica, sine vlla culpa theologica, illatum est, restituatur in foro conscientiae nulla expectata

sententia; an non, sed solùm postquam in exteriori foro lata sit sentētia condemnatoria: si enim ea lex vsu ac praxi non sit recepta, vt in conscientiæ foro resarciatur id damnum nulla expectata sententia, sanè, licèt aliud fuerit intentum condentium eam legem, nulla est obligatio illud restituendi ante latam sententiam; eo quòd, vt dictum est, humanę leges non plus in conscientia obligent, quàm vsu sint receptæ. Hinc, saluo meliori iudicio, dico, legem Aquiliam in euentu, de quo Disputamus, non obligare in foro conscientiæ ante latam sententiam. In primis, quoniam iura ipsa ciuilia sufficienter exprimunt, legem Aquiliam, quo ad id, quod ex natura rei, seclusa ea lege, non est debitum, eaque lege solui præcipitur, esse instar legis pænalis ex legumlatorum intento, eamque proinde obligationem non transire aduersus hæredes eius, qui damnum dedit, quando cum dante damnum non fuit lis contestata dum viueret, vt constat ex. l. inde Neratius. §. hanc actionem. ff. ad leg. Aquil. ex. §. his autem instit. eod. titu. & ex. l. 3. titu. 15. part. 7. Eadem verò est ratio, quòd in foro conscientiæ non debeatur ante latam sententiam: si enim ex iuris intento ante latam sententiam deberetur, vtique id debitum, iam omnino ac perfectè cōtractum, transiret ad hæredes talis debitoris: atque hæc duo mutuò sunt connexa, obligationē non transire aduersus hæredes eius, qui ex iuris dispositione ad id tenebatur, & id non debere ante latam sententiam aduersus eum, vt in legibus pænalibus liquet. Deinde illud idem dico, Quoniam non videtur vsu receptum, vt damnum sine vlla prorsus theologica culpa datum, ante latam sententiam resarciatur: quare, esto contrarium fuisset intentum conditorum legis Aquiliæ, (quod tamen est falsum) nulla esset obligatio id restituendi in foro conscientiæ ante latam sententiam. Adde; in dubio meliorem esse conditionem id possidentis, vt illi restitutionem non iniungamus, neque grauemus iugum sacramenti pænitentia.

Quartò dico, mihi videri obligationem esse [sect. 7] restituendi in foro conscientiæ, nulla expectata sententia, damnum culpa theologica iniusteque datum, esto iniustitia ad culpam lethalem non pertingat. Id verò intelligendum est de damno, si non toto, quando culpa ad lethalem non pertingit, saltem quoad partem proportionalem pro damni & culpa infra lethalem quantitate. Quoniam satis est, vera tua culpa id damnum mihi prouenisse, vt ex natura rei, atque adèò in conscientiæ foro, tenearis illud mihi restituere, pro culpæ saltem quantitate: neque enim æquitas patitur, vt ex vera tua culpa ego maneam in detrimento ac iactura meorum bonorum. Quo loco obserua, nos non dicere, obligatio-[[90]]nem illam, id integrum damnum restituendi, esse in pænam talis culpæ venialis: tunc enim id non deberetur ante latam sententiam, dubiumque præterea esset, quando damnum esset maximi valoris, an tanta pæna iusta esset, pro tam modica culpa: sed quod dicimus est, eam obligationem consurgere ex natura rei ex eo, quòd id damnum iniuste sit datum.

Illud etiam addo, quando ex contractu, vt ex [sect. 8] commodato, vel ex locatione, aut ex alio, mihi tenereris curare conseruationem rerum mearum, tunc damnum, quod in eis meis rebus mihi proueniret ex tua culpa iuridica, qua mihi ex eo contractu iurisque dispositione tenereris, etiam si adiunctam non haberet culpam theologicam, resarcire mihi tenereris in foro conscientiæ nulla expectata sententia, idque vi talis contractus initi inter me & te, vt Disput. 295 dictum est.

Superest respondeamus ad argumenta proposita pro vtraque sententia ante nostram relata, quatenus cum tertia nostra sententia pugnare videbuntur. Ad argumentum ergo prioris⁴⁰ sententiæ negandum in primis est, vniuersim, qui culpa leui, aut leuissima, damnum dat, non teneri ex natura rei illud restituere: si enim cum ea culpa leui, aut leuissima, coniuncta sit culpa theologica, saltem venialis, vt, coniunctam esse posse, non solùm venialem, sed

etiam lethalem, dictum ostensumque est, obligatio est ex natura rei id damnum restituere, saltem quoad partem proportionalem, si culpa sit venialis, ut explanatum est. Admittendum verò est, culpam venialem, iniuste ex illa damnum inferendo, non sufficere, ut ex natura rei, atque in foro cōscientiæ, obligatio consurgat restituendi totum damnum ex ea iniuste datum: tametsi sufficiat, ut obligatio ex natura rei sit restituendi partem damni pro culpæ quantitate. Negandum præterea est, id totum, quod lex Aquilia resarciendum soluendumque præcipit, iniunctum esse in pœnam: multa enim eorum, non in pœnam, sed ex natura rei debentur: quædam verò alia partim debentur in pœnam propriè, partim verò instar pœnæ, non autem in pœnam propriè, ut hac & præcedente disputatione explanatum comprobaturque est. Quare, cùm argumentum his multis falsis innitatur, constat vim contra nostram sententiam non habere.

Ad argumentum verò posterioris sententiæ,⁴¹ in primis negandum est, semper latitudinem valoris, quem, ultra damnum datum, lex Aquilia soluere præcipit, esse in pœnam propriè dictam: contrarium quippe apertè est explanatum ac comprobatum. Deinde dicendum est, quamvis dispositio eius legis obliget in foro conscientiæ; non tamen plus in eo foro obligare, quàm fuerit intentum legumlatorum, & quàm ea dispositio usu sit recepta, ut in conscientiæ foro obliget: ostensum autem est, neque legislatores intendisse, ut obliget in foro conscientiæ ante latam sententiam ultra damnum culpa theologica datum: neque usu esse receptam, ut plus in conscientiæ foro obliget.

Ad primam confirmationem dicendum est,⁴² Greg. nonum declarare ibi forum conscientiæ post latam sententiam: quasi intenderit explanare, legem Aquiliam iniustam non esse, sed iustam ac æquam, obligareque proinde in conscientia iuxta legumlatorum intentum: satis verò in iure civili est expressum intentum legumlatorum non fuisse, ut quoad id, quod iuxta eam est soluendum, ultra damnum culpa theologica datum, obliget in foro conscientiæ ante latam sententiam, ut explanatum est.

Ad secundam dicendum est, iam explicatum⁴³ esse, quousque ea lex pœnalis non sit, & quousque sit pœnalis propriè, itemque quousque instar sit legis pœnalis: atque quousque in foro cōscientiæ ante latam sententiam obliget, aut non obliget.

Ad tertiam dicendum est, similiter eam le⁴⁴gem esse intelligendam, atque explanata est lex Aquilia, neque aliter obligare, quàm in illo eodem euentu lex Aquilia obliget.

De damno in arboribus, aut quod ex arboribus prouenit. Disp. 699.

SVMMARIVM.

1 . *A Rborum nomine quid, ut aduersus eum, qui damnum eis infert, actio peculiaris competat arborum cæsarum.*

2 . *Damnum in arboribus si datum sit sine dolo, scientiæve quòd detur, competit solùm actio legis Aquiliæ: si verò cum ea scientia, & sine vi, atque adeò clam, competit etiam interdictum quod vi aut clam, & peculiaris actio arborum cæsarum ad duplum eius damni: & quatenus ea actio competat hæredibus damnum passi, & transeat aduersus hæredes eius, qui damnum intulit.*

- 3 . Ob eiusmodi damnum licet competant tres predictae actiones, intentataque una possit rursus intentari alia, solum tamen potest intentari quoad incrementum pæne.
- 4 . Damnum ob idem licet actio arborum cæsarum pænalis sit quo ad incrementum supra id damnum; & actiones pænales solum concedantur intra annū vtilem; hæc tamen perpetua est.
- 5 . Damnum idem si datum sit animo lucri faciendi ligna, aut arborem, competit etiam actio furti, & actio ad exhibendum ligna aut arborem.
- 6 . Damnum idem si vi datum sit, competit similiter actio vi bonorum raptorum, aut de vi publica, aut priuata, qualis fuerit vis illata.
- 7 . Damnum ob idem, etiam si clam sit datum, agi potest, vel ciuilitur ad pænam pecuniariam, vel criminaliter ad pænam corporalem. Et quando mortis pæna imponatur.
- 8 . Damnum idem imperans, pænis subiacet, ac si ipse illud esset exequutus. Et quid de aliis cooperantibus ad id damnum. Mancipium si inscio domino id det, dominus vel soluit damnum ac pænam, vel mancipium noxæ dat.
- 9 . Damnum idem si colonus det in prædio, quod conductum habet, agitur aduersus illum ad id damnum ex conducto, aut actione arborum cæsarum; sed una actione intentata, altera locum non habet.
- 10 . Damnum idem si à pluribus datum est in ea-[[91]]dem arbore, aduersus omnes, & singulos, competit actio ad duplum; sed uno solvente, cæteri ei contribuere tenentur. Quando damnum datum est arbori multis communi, omnibus competit actio ad duplum, diuidendum inter omnes.
- 11 . Arbor una censetur, si duo germina coniungantur in eodem stipite, aut in eadem radice, & coniunctio appareat super terram: duæ verò si coniunctio non appareat super terram.
- 12 . Damnum ob idem actio competit emphyteutæ perpetuo in duplum, quoad æstimationem dominii utilis in eis arboribus, & domino directo quoad æstimationem dominii directi. Vsusfructuario etiam competit similis actio utilis. Et quatenus competat, aut non competat, aliis legitimis tentoribus.
- 13 . Damnum idem si, antequam prædium alienaretur, datum fuit in arboribus, & postea alienatum fuit, actio ad duplum, duplūque ipsum, pertinet ad eum, qui prædium alienauit.
- 14 . Damnum si ex arbore, pendente super domum alienam, ei domui proueniat, saltem quia frondes decedentes impediunt decursum aquæ pluuiæ per tegulas, denunciatione domino arboris factaper iudicem, succiditur, & euellitur radicitus: quod si arboris dominus id non efficiat, succiditur a domino domus, & ligna ad ipsum pertinent. Eadem actio competit vsusfructuario eius domus; ac si multi sint domini eius domus, singulis competit.
- 15 . Damnum si radices arboris alterius inferant fundamentis, aut parietibus alterius domus, similiter succiduntur, euellunturve radicitus, ne deincepsnoceant.
- 16 . Arbor unius si pendeat in prædium alterius, & in altitudine quindecim pedes excedat à terra, admonetur à iudice, ut excessum præcidat, alioquin præciditur à domino alterius prædii, & ligna ad ipsum spectant.
- 17 . Arbor si ita pendeat in viam publicam, ut commodum transitum impediat, impunè quoad id præscinditur, quod eum transitum impedit.

Peculiariter est dicendum de damno dato [sect. 1] in arboribus: quoniam peculiariter id crimen punitur in iure, vt constat. ff. arborum furtim cæsarum, per totum, & l. 18. titul. 15. partic. 7. Vt autem habetur. l. 3. ff. arborum furt. cæsar. nomine arboris, vites etiam comprehenduntur, quin & harundines, & hæderæ. Salices etiam arbores dicuntur. Quando autem salicum virgæ defixæ sunt, vt radices agant, salicesque inde fiant, si præcidantur, aut euellantur, antequam radices agant, non dicuntur præcidi, aut euelli, arbores; quia ramus, etiamsi adhuc viuat, ex eoque arbor fieri possit, interim tamen dum radices non habet, non est arbor simpliciter, sed arboris pars; ac proinde, qui eum præcidit, aut euellit, non dicitur incidere in pænam, de qua erit sermo, sed solùm tenetur lege Aquilia de damno dato. Idem dic de eo, qui euellit aut præcidit palmitem, aliudve ei damnum infert, plantato quidem, vt ex eo vitis fiat, sed antequam radices agat, vitisque proinde simpliciter sit; & de aliis similibus partibus quarundam aliarum arborum, quæ infiguntur, vt radices agant, & in arbores euadant. Excipi videntur in fine legis 3. citatæ partes oliuarum de fixæ, vt radices agant, & in perfectam euadant oliuam: nam antequam radices agant, ex priuilegio censentur arbores, vt, si quis eas præcidat, aut euellat, vel aliter destruat, incidat in pænam, de qua erit sermo. Nisi dicas, cum glossa vltima ibi, sermonem esse de oliuis transplantatis cum radicibus dum terræ omnino non adhæserunt. Quando arbor transplantata est, & viuit, si quis illam præcidat, aut aliter destruat; dicitur præcidere, aut destruere, arborem, vt in pænam incidat, de qua erit sermo, esto nondum terræ omnino adhæserit, vt radices in illam egisse dicatur. Et idem est, si similem arborem euulsam cum radicibus, vt transplantetur, antequam transplantata sit, præcidat, aut destruat: quoniam, cum adhuc viuat, & radices habeat, arbor est simpliciter, vt habetur. l. 3. citata. Quando autem ex semine arbor est producta, si tenera adhuc sit, ita vt herbæ rationem videatur habere, non censetur arbor, vt qui illam euulserit, aut aliter destruxerit, in pænam incidat, de qua erit sermo. Ita subiungitur ibidem. l. 4. Quando aliquis arborem alienam euellit, [sect. 2] præcidit, aut alia ratione destruit, vel notabile detrimentum illi infert, (*vt lex cedere, & l. furtim. ff. arbor. fur. cæs. explicant*) agi aduersus eum potest lege Aquilia eo modo, quo agitur ad cætera damna data, *vt habetur. l. 1. ff. eod. titu.* Si autem ex intentione id efficiat, cum scientiæ, quòd id damnum detur, (*vt recte explicat. l. 18. titul. 15. part. 7.* eaque de causa dolus requiritur ad hanc aliam sequentem actionem) idque clàm, nullave vi illata domino arborum, tunc non solùm potest agi aduersus eum lege Aquilia, qui illud dedit, atque interdicto quod vi aut clàm ad id, quod plus tenetur ex hoc interdicto, quàm ex l. Aquilia, *vt habetur. l. penul. ff. arb. fur. cæs.* sed etiam agi potest peculiari actione ex lege duodecim tabularum, vt eadem lege. 1. citata habetur, quæ actio arborum cæsarum dicitur, atque hæc est actio ad duplum valoris damni dati, *vt habetur. l. furtim. ff. eod. titu.* ita vt æstimetur damnum, deducendo si quid adhuc valent ligna præcisa domino arborum, & valor damni, qui remanserit, soluatur domino arborum duplus, *vt habetur. l. facienda. ff. eod. titu.* simplum quidem, in eo duplo inclusum, ratione valoris damni, qui valor ex natura ipsa rei debetur, & non in pænam, ac proinde debetur nulla expectata sententia; aliud verò tantundem, quod id duplum complet, est solùm in pænam; vt rectè ait glossa. l. facienda citata verb. æstimationem, & per consequens non debetur ante latam sententiam.

Quando ergo lege furtim citata in fine dicitur, hanc actionem, quia pænalis est, non transire aduersus hæredes delinquentis: (intellige, nisi cum delinquente lis fuerit contestata dum viueret) nam tunc transit, *vt habetur. §. penult. inst. de perpet. & tempor. actionib.*) & concedi aduersus delinquentem, etiam hæredi eius, qui damnum est passus, intelligenda

hæc sunt, quoad id præcisè, quod complet duplum, vnà cum valore damni: quoniam quoad id solùm ea lex est pænalis: non verò sunt intelligenda quoad æstimationem [[92]] damni præcisam: nam quoad hoc, ea actio pœnalis non est, sed prosequutiua eius, quod ex natura rei debetur, vt recte ait glossa citata: quemadmodum enim hoc debetur ex natura rei, atque in foro conscientiæ, nulla expectata sententia, ita actio ad hoc recuperandum competit etiam aduersus hæredes delinquentis, eo quòd prosequutiua sit eius, quod defunctus ex natura rei, in foroq̃ue conscientiæ, atque in exteriori, debebat, vt vtrunque circa similem dispositionem legis Aquiliæ Disp. 697. ostensum etiam fuit.

Quamuis actio legis Aquiliæ, & actio arborum [sect. 3] cæsarum, competant aduersus eum, qui arbori, aut arboribus, damnum modo explicato dedit; iudex tamen condemnare non potest eum, qui damnum dedit, vtraque pœna fimul, sed deducere debet ex posteriori actione, quæ intenta fuerit, quod iam solutum fuerit ex priori actione intentata, *vt habetur. l. 1. ff. eod. titu.* Vnde si priùs fuit actum lege Aquilia, &, qui damnū dedit, soluit quantum damnum fuit æstimatum, iuxta valorem plantarum intra triginta retro dies, posteaq̃; agatur actione arborum cæsarum, solum condēnari debet is, qui damnum dedit, vt addat vsque ad valorem dupli æstimationis damni dati. Si autem priùs intenta sit actio arborum cæsarum, locum non habebit actio legis Aquiliæ: quoniam nunquam, quod ex illa debetur, excedit duplum damni iam solutum actione arborum cæsarum. Eodem modo, si actum sit lege Aquilia, agi adhuc potest interdicto quod vi aut clàm, præcisè ad incrementum pænæ statutæ interdicto quod vi aut clàm, deducendo, quod acceptum fuerit ex lege Aquilia, & adhuc poterit postea agi actione arborum cæsarum præcisè ad incrementum pænæ, quod supra interdictum quod vi aut clàm, statutum est vt soluatur hac alia actione. *Ita habetur. l. penult. ff. arb. furt. cæs.*

Quamuis autem actio arborum cæsarum pæ [sect. 4] nalis sit quoad incrementum supra damnum datum, vt dictum est; actionesq̃ue pœnales regulariter non sint perpetuæ, sed solùm concedantur intra annum vtilem, *vt habetur inst. de perpet. & temp. act. in prin.* hæc tamen actio perpetua est, *vt habetur. l. furtim in fine. ff. arb. furt. cæsar.* quæ proinde non minori tempore præscribetur, quam præscribantur personales actiones debitorum prosequutiua, iuxta ea quæ in materia de præscriptione dicta sunt.

Quando autem aliquis clàm alienas arbores [sect. 5] cædit, aut euellit, lucrisaciendi causa, hoc est, gratia vsurpandi, furandive ligna, tunc non solum competit actio legis Aquiliæ, & actio arborum cæsarum, comparatione damni dati in arboribus, vt dictum est; sed etiam simul competit actio furti comparatione lignorum, atque actio ad ligna exhibenda. *Ita habetur. l. facienda. ff. arb. furt. cæs. & l. verum est. 1. §. eorum. ff. de furt.*

Quòd si, vi illata domino arborum, dam [sect. 6] num in eis illatum sit, competit aduersus id damnum vi inferentem actio vi bonorum raptorum, *vt habetur. l. facienda citata, & l. 2. de vi bonor. rapt.* quæ lex vniuersim statuit, pro damno quocunque dato cum vi competere actionem bonorum raptorum. Agere etiam poterit, si id potiùs maluerit, actione de vi publica, aut priuata, prout fuerit vis illata, ad pœnam eis legibus statutam, vt suprà, dum de rapina nobis erat sermo, dictum est.

Est etiam peculiariter sancitum circa crimen arborum cæsarum, vt quamuis damnum [sect. 7] sit datum clàm ac sine vi, integrum sit ei, qui illud est passus, vel agere ciuilitè ad pœnam dupli modo explicato, vel agere criminaliter ad pœnam corporalem, vt maluerit: atque, si damnum sit notabile admodum, maximè in vitibus, delinquens puniatur pœna mortis. Si verò non sit tantum, puniatur corporaliter pœna flagellorum, exilii, aut alia simili, iudicis arbitrio, ita videlicet, vt crimen eo modo delinquentium, instar latronum seu grassatorum puniatur.

Ita habetur. l. 2. ff. arb. furt. cæs. c. l. 28. titul. 15. part. 7. quam legem exponere conatur Greg. Lopez ibi, vt mitior non sit, quàm dispositio hactenus ex iure communi explicata, neque ab ea discordet.

Qui imperat damnum inferri arboribus, [sect. 8] siue libero homini, siue suo mancipio, id imperet, tenetur de damno ab eis dato, ac si ipse illud dedisset, vt est perspicuum, *c. habetur. l. furtim. ff. arb. furt. cæs.* Et idem dic de quocunque cooperante ad id damnum, comparatione huius pænæ, quod suprâ suo loco de cooperantibus ad furtum, aut ad damnum datum, comparatione pænarum pro eis criminibus statutarum, dictum est. Quando autem mancipium, inscio domino, damnum in arboribus daret, nisi solueret dominus damnum & pœnam pro mancipio, teneretur tradere mancipium ei, qui damnum esset passus, pro eo damno ac pœna, quod est tradere mancipium noxæ. Ita habetur. l. furtim citata.

Si colonus damnum det in arboribus prædii, [sect. 9] quod conductum habet, agi aduersus eum potest ad id damnum, vel ex conducto, vel actione arborum cæsarum: intentata tamen vna actione, locum in eo non habet alia. *Ita habetur. l. si colonus. ff. eod. titu.*

Quando multi eandem arborem sciderunt, [sect. 10] damnumve vlli intulerunt, aduersus singulos agi potest in solidum ad totam pœnam: quia singuli totum id damnum dederunt totalitate effectus, licet non totalitate causæ. *Ita habetur. l. si plures. ff. eod. titu.* Non tamen intelligas, eum, qui damnum est passus, toties in duplum accipere debere æstimationem totius damni, quot fuerunt illi, qui illud dederunt: id quippe irrationabile atque ridiculum esset: sed, vno integre soluente damnum in duplo, cæteri liberi manent, vt nihil aliud ei soluant: tenentur tamen contribuere ei, qui loco ipsorum totum damnum in duplum soluit, partes suas, vt de damno similiter in aliis rebus dato Disputat. 697. dictum explanatumque est. Quando autem vnus damnum dat in arbore multis communi, solum tenetur soluere omnibus simul vnicam integram pœnam, hoc est, duplum damni dati: omnibusque illis simul solum competit vnica actio aduersus eum. Ita habetur. l. si plures citata.

Quando duo germina coniunguntur in eodē [sect. 11] [[93]] stipite, aut in eadem integra radice, si ita coniungantur, vt coniunctio eorum appareat super terra, censentur vna arbor, & non duæ: quando verò coniunctio eorum non apparet super terram, censentur duæ arbores. *Ita habetur. l. si germina. ff. arb. furt. cæs.* Id verò scire inseruit, vt ibi notat glossa Accursii, vt intelligatur, si pro vnaquaque arbore cæsa, aut euulsa, certa pœna lege aliqua sit sancita, quando debeatur vnica pœna, & quando duplex.

Actio arborum cæsarum competit domino [sect. 12] earum aduersus eum, qui damnum dedit. Et competit etiam emphyteutæ, qui dominium vtile habet perpetuum: sed pro æstimatione damni, quod respondet præcisè dominio vtili, vt illi adiudicetur duplum damni illius: quoad reliquum verò æstimationis damni proprietatis, competit domino directo actio, vt ipsi duplum æstimationis etiam adiudicetur. Atque hoc est, quod intenditur. l. cedere. ff. arb. furt. cæs. Ea verò lex denegat hanc actionem vsufructuario. Id tamen glossa ibi intelligit de actione arborum cæsarum directa: secus verò de vtili, in sensu Disput. 697. circa actionem legis Aquiliæ explicato: nam sicut actio legis Aquiliæ conceditur vsufructuario, *vt habetur. l. item Mela. §. vlt. ff. ad legem Aquil.* & in calce Disput. 697. dictum est, intelligique id debet de vtili actione; sic etiam concedi ei debet actio arborum cæsarum; cum sit par ratio. Quoad legitimos verò alios tētores prædii, cuius arboribus damnum est datum, quousque eis competat actio loco ac nomine domini arborum, vt pœna domino acquiratur: & nihilominus posse ipsos agere ad damnum præcisè, si quod eis inde etiam resultauit, die vt in calce disputationis. 697. dictum est circa reliqua damna data.

Qui agrum, in quo arbores erant, vendidit, [sect. 13] aut quouis alio titulo in alium transtulit, si, antequam eum alienaret, damnum datum illi fuit in arboribus, poterit, post illud alienatum, agere aduersus eum, qui damnum dedit, actione arborum cæsarum, ad ipsumque pertinet duplum eius damni, & non ad nouum agri dominum. *Ita habetur. l. vlt. ff. arb. furt. cæs.* Hæc de damno arboribus illato.

Quod verò attinet ad damnum, quod ex arboribus [sect. 14] prouenit. Quando arbor vnus pendet super domum alterius, vnde euenire potest, vt ex frondibus, floribus, aut fructibus, qui ex ramis decidunt, aut ex ramis ipsis, impediatur decursus aquæ pluuiæ per tegulas, aut aliud damnum sequatur; tunc, esto arbor à principio ritè fuerit plantata, domino domus conceditur adire iudicem, qui domino arboris denunciaret, vt, nō solū, quod supereminet, præcidat, sed etiam vt eam radicitus succidat, aut euellat, ita vt ex illa nullo tempore possit id damnum imminere; iudexque, comperto eam arborem supra domum alterius pendere, tenetur id illi denunciare. Si verò dominus arboris, facta ei denunciatione, in mora sit, eam succidendi, tunc dominus domus potest illam excidere, accipereque sibi ligna omnia eius arboris; neque dominus arboris potest id impedire aut prohibere, *Ita habetur. l. 1. ff. de arborib. cædendis. c. l. 28. titu. 15. part. 7.* Quæ (satis consentaneè ad rectam rationem, ad naturamque ipsam rei, & ad ius commune) exprimit, iudicem esse prius adeundum, denunciationemque iudicis autoritate esse faciendā. Vnde probanda non est opinio Bart. l. 1. citata, quòd scilicet satis sit, dominum domus denunciare domino arboris, vt eam succidat, vt postea, si dominus arboris in mora sit, dominus domus possit eam succidere, sibi que vsurpare ligna. Ius verò id petendi ac faciendi non solū competit domino domus, sed etiam vsufructuario illius: quoniam sua etiam interest, eam arborem non pendere supra talem domum. Quòd si multi sint domini domus, supra quam pendet arbor aliena, singuli eorum habent etiam ius in solidum, idem petendi ac faciendi: sicut singuli etiam vindicare possunt seruitutem ei domui competentem. Vtrum que habetur. l. 1. citata.

Quando radices arboris alienæ præiudicium [sect. 15] afferre incipiunt fundamentis, parietibusve, alicuius domus, tunc idem ius est domino domus, vt succidatur, aut euellatur, ita vt omnino nec noceat, nec nocere deinceps possit, ac quando arbor pendet supra domum. *Ita habetur. l. 1. C. de interdict.* Quæ ait, quamuis hic euentus non comprehendatur in edicto prætoris, qui habetur. l. 1. ff. de arb. cæd. si ad sola illius edicti verba attendas, si tamen ad paritatem rationis, intentumque illius legis, aduertas, esse similiter subueniendum à iudice in vtroque euentu. Vnde glossa. l. 1. C. de interdictis, & doctores ibi, dubitant, vtrum, etiam in hoc posteriori euentu, subueniendum sit domino domus actione directa ex illo prætorio edicto; an verò solū vtili; quasi directa solū competat in euentu, quem sonat & statuit edictum; vtilis verò, quando fit extensio edicti per interpretationem ex æquitate ac paritate rationis; an autem solū competat actio in factum subsidiaria officio iudicis. Iuxta quam doctrinam actio legis Aquiliæ distinguitur etiam, in directam ex lege Aquilia, quando verba legis, vt primò lata fuit, euentus comprehendit; & in vtilem, atque etiam in actionem in factum subsidiariam legi Aquiliæ, *vt habetur instit. de leg. Aquil. §. penult. c. disput. 697.* dictum est. Accursius arbitratur, in euentu, de qua loquimur, competere directam, quasi hic euentus verè comprehendatur in edicto illo prætorio, attendendo non tam ad verba illius, quàm ad intentum illud ferentis, iuxta quod loqui videtur. l. 1. C. de interdictis: alii verò aliter loquuntur. Vtinam verò hæc omnes subtilitates auferentur à iure, quæ ad nihil aliud inseruiunt, quàm ad obscurum illud reddendum, & ad litium ambages, ac multiplicationem. Vnde meritò ius huius Regni, dum titu. 15. part. 7. sermo illi est de

damno dato, & dispositione legis Aquiliæ, eas non curat: dicereque possumus, ex legibus eius tituli, semper in hoc Regno dari actionem directam in omni euentu, in quo de iure communi datur actio directa ex lege Aquilia, vtilis, vel subsidiaria in factū

Quando arbor vnus pendet in agrum alterius, [sect. 16] tunc, si arbor in altitudine excedat quindecim pedes à terra, dominus agri, in quem arbor aliena pēdet, potest similiter, adito iudice, illum admoneri facere, vt præcidat solum excessum vltra quindecim pedes. Quòd si, admonitus, in mora fuerit, eū præscindendi, tunc dominus agri, in quem rami pēdēt, poterit illos præscindere, & accipere sibi ligna, quæ ita præsciderit: neque alter potest id impe- [[94]]dire aut prohibere. *Ita habetur. l. 1. §. deinde ait prætor. ff. de arb. cæden.*

Greg. Lopez. l. 28. titu. 15. part. 7. verb. otro si dezimos, cum Luca de pæna, ait, quando aliqui diuiserunt inter se agrum, ita quòd in confinio partis, quæ vnum eorum contigit, erat arbor, cuius rami, vltra quindecim pedes à terra, pēdebāt iam supra aliam partem agri, quæ alterum contingit, aut vnus vendidit vnā partem sui agri alteri, in quam, aut ex qua, pendebant similiter in alteram rami vltra quindecim pedes à terra, tunc locum non habere eam dispositionem legis. Quoniam quasi cum ea lege est facta diuisio, aut venditio, vt arbor ita maneret, alterque id, quasi seruitutem, sustineret, argumento. l. quod principis in prin. ff. de aqua plu. arc. Quando autem tempore diuisionis, aut venditionis, arbor, quæ manebat in confinio, non excedebat quindecim pedes à terra, tunc, si accrescat vltra quindecim pedes, optimè quoad excessum habebit locum edictum illud prætoris.

Vtrum autem dominus arboris, cuius rami, vltrāquindecim pedes à terra, pendent in agrum alterius, possit se aduersus hunc alterum tueri præscriptione, quòd sic pependerunt triginta aut quadraginta annis? Respondet ibidem Greg. Lopez, cum eodem Luca de pæna. Quoad id, quod arbor creuit, aut produxit, infra triginta annos, & pendet, non esse locum præscriptioni. Obserua, *legem. 28. titu. 15. part. 7. cū in reliquis, quæ de arbore pendente in agrum alterius dicta sunt, cum iure communi cōueniat, in hoc tamen discordare; quòd non præcipiat attendēdum esse, an rami pendeant quindecim pedes à terra, vel non: sed vt, si nocuerint, & quoad id, quoad quod nocuerint, præscindantur; si verò nō nocuerint, & quoad id, in quo non nocuerint, non præscindantur, vt ibi Greg. Lopez notat.* Fortasse tamen ea lex iuxta dispositionem iuris communis est intelligenda, vt scilicet tunc nocere sint censendi ob nimiam vmbram, vt habet dispositio iuris communis, quando eleuati à terra sunt vltra quindecim pedes: non verò quando non adeò sunt eleuati.

Quando arbor ita pendet in viam publicam, [sect. 17] vt commodum transitum quoquomodo per eā impediatur, impunè præciduntur ii rami ex illa, qui transitum commodum aliqua ex parte impediūt. *Ita habetur. l. 28. in fine titu. 15. part. 7. & consentit. l. 2. (aliàs. 1.) §. deinde ait, vers. si ex fundo tuo. ff. nequid in loco pub.*

De crimine falsi, quatenus ex illo damnum in rebus proximi externis resultat. Et in primis de eo, qui sibi, aut alteri, qui in potestate ipsius sit, aut in cuius potestate ipse sit, scribit legatum, aut hæreditatem,

**in alterius testamento, & de eo qui rem eandem duobus vendit.
Disp. 700.**

SVMMARIVM.

- 1 Falsi crimen quot modis committatur. Et quæ pœna pro illastatuta, quando grauior alia, aut mitior, non comperitur statuta. Et deportationis pœna, quamuis in usu non sit, cur in Lusitania sit in usu.*
- 2. Falsi crimen publicum est, de quo proinde quiuis de populo accusare potest, excepto crimine partus suppositi. De crimine autem falsi quiuis accusat intra viginti annos ab eo commisso.*
- 3. Falsi crimen vt incurratur, requiritur dolus, nec sufficit lata culpa, quæ in criminibus dolo non æquiparatur. Requiritur etiam, vt nocum entum momēti alicuius ex ea falsitate sequatur, alioquin non punitur pœna ordinaria.*
- 4. Damnum ex crimine falsi iniustè datum, in exteriori & in conscientiæ foro est restituendum. Testis tamen, qui iussus testificari, veritatem subticuit, crimen falsi incurrit, non tamen tenetur restituere ei, quem non adiuuauit, detrimentum, quod vitasset: quia solùm peccauit contra caritatem & obedientiam, non verò contra iustitiam.*
- 5. Falsi crimen incurrit, qui se, aut eum, qui sub ipsius potestate est, aut in cuius potestate ipse est, scribit hæredem, aut legatarium, in alterius testamento, irritumque est, quod ita in suum commodum scribit. Et quando id locum etiam habeat in testamento nuncupatiuo. In foro autem conscientiæ validum est, si nulla re ipsa interuenit falsitas.*
- 6. Falsi crimen non incurrit, qui ei, qui in ipsius est potestate, hæreditatem scribit, aut legatum, quando totum ad eum spectat, cui scribitur.*
- 7. Falsi crimen incurrit pater, qui filio in ipsius potestate constituto, scribit hæreditatem, aut legatum, esto solùm commodum ususfructus, & administrationis, ad ipsum pertineat, dum ille sub ipsius fuerit potestate.*
- 8. Falsi crimen non incurrit, dispositioque est inualida, quando aliquis alterum scribit hæredem, aut legatarium, & se substitutum illi fidei commissarium.*
- 9. Falsi crimen incurrit, & dispositio est nulla, quando è duobus, qui sub potestate sunt testatoris, vnus alteri scribit legatum, aut hæreditatem, quando per mortem testatoris vnus eorum recasurus est in potestatem alterius.*
- 10. Falsi crimen non incurritur in euentibus explicatis, & dispositio est valida, si testator propria manu subscribat, se id illi relinquere in particularis Idem si in generali subscribat, confirmo, quæ tali relinquo, si is in potestate erat testatoris. Si verò non erat in potestate illius, crimen falsi non incurrit, & inualida est dispositio. Item quando constat testatorem præcepisse illi scribere testamentum illud, aut codicillum, & is sub potestate testatoris erat, non incidit in crimen falsi, & dispositio est nulla. Si verò sub potestate illius non erat, crimen etiam falsi incurrit.*

11 . Falsi crimen non incurrit filius emancipatus, validaq̃ est dispositio, si in testamento patris, aut matris, in id totum solūm se scribat heredem, in quo ab intestato erat is succeſsurus. Si verò in plus se scriberet, crimen falsi incurreret, & dispositio eſet nulla.

12 . Falsi crimen incurreret, & dispositio esset nulla, si patronus, aut consanguineus patroni, in idso scriberent hæredes, in quo ab intestato fuiſſent ſucceſſuri. Vxor si in testamento mariti scriberet, vt dos ei statim mortuo marito solueretur, aut creditor in testamento debitoris scriberet, vt ante diē, in quo erat soluendum, debitum ei solueretur, sua debita non amitterent; ob id tamen testamentum anticipanda eis non eſet solutio.

[[95]] *13 . Falsi criminis pænæ venia quibus condonetur ob præſumptam ignorantiam, aut minorem ætatem, & alias causas, quibus non item, & dispositio nihilominus est nulla.*

14 . Falsi criminis pæna locum habet in euentibus explicatis, si testamentum, aut codicillus, integre & cum debita ſolemnitate ſint facta, esto ex præteritione, aut exhæredatione, vel ex alia causa reddantur nulla.

15 . Falsi si non incurrat pænam, qui in testamento se filio testatoris impuberitorem scripsit, quid inde incurrat.

16 . Falsi crimen, etiam quia confector falsi instrumenti, incurrit, qui falsò se heredem, aut legatarium, scripsit, restituereque in conſcientiæ foro tenetur damna omnia aliis inde ſubſequuta.

17 . Falsi crimen an incurrat, qui prohibet alium testari.

18 . Falsi crimen incurrit, qui eandem rem vendit duobus. Et num neceſſe ſit accepiſſe pretium ab utroque.

AGere de crimine falsi, non ad hunc, sed ad [sect. 1] consequentes tractatus, maximè

ad quintū spectat. Hoc verò loco, hac, & duabus ſequentibus diſputationibus, ſolum de illo est dicēdū, quatenus cōiunctum habet damnum iniuſtum in rebus proximi externis, ex illòve iniuſtè resultat. Falsitas verò, ex qua hoc crimen incurritur, & à qua, qui illud committit, falsus, falsariūſve, nuncupatur, non ſolūm verbis, cōmittitur, vt si quis dolosè falſum teſtificetur de aliquo, aut etiam ſcripto, vt si tabellio vnum pro alio dolosè ſcribat, sed etiam facto, dolosè aliquid efficiēdo, quo pernicioſè aliqui rebus ipsis decipiantur, vt ſupponendo partū alienum, meſuras, aut pondera, deprauādo, monetas adulterando, & ſimilia alia efficiendo, quibus homines rebus ipsis, in ipſorum, aut in cōmunis boni, detrimentum, decipiantur. Atque hoc crimen in caſibus expreſſis à iure incurritur: qui varii ſunt, neque eandem habent à iure ſtatutam pænā. Tametsi pæna ordinaria pro hoc crimine ſit, in hominibus liberis, deportatio, in perpetuum, cum conſſicatione omnium bonorum, niſi habeant aſcendentes, aut deſcendentes, vel etiam collaterales vſque ad tertium gradum; nam tunc hi ſuccedunt in eis bonis poſt diſpoſitionē authenticæ, vt nulli iudicum. §. vlt. & non pertinent ad fiſcum; in mācipio verò pæna est vltimum ſupplicium, hoc est, mors naturalis. Ita habetur. l. 1. §. vlt. ff. ad leg. Cornel. de falſ. & §. item lex Cornelia de falſis inſt. de publ. iud. & l. 6. titu. 7. part. 7. atque ea pæna est intelligenda incurri pro eo crimine, quando alia grauior, aut mitior, non exprimitur, ac comperitur impoſita. Cum verò deportatio non ſit hodie in vſu, alia arbitraria imponitur, vt Greg. Lopez. l. 7. citata, & Iul. Clar. lib. 5. ſent. §. falſum. n. 40. & §. vlt. q. 67. n. 8. cum aliis, quos referunt, affirmant. In Luſitania verò, quia ſunt inſulæ, & loca, ad quæ incolenda expedit mitti malefactores, hæc pæna videtur eſſe in

vsu, dum homines frequenter damnantur in exilium in Insulam diui Thomæ, in Brasilicam regionem, & in similia alia loca. Bart. posuit pœnam ordinariam pro hoc crimine. §. vlt. citato, in homine libero plebeio esse damnationem in metalla, & nobilium deportationē, iuxta. *l. si quis aliquid. §. qui. viui. ff. de pœnis.*

Cōputatur verò hoc crimen inter delicta pu [sect. 2] blica, vt constat *inst. de publ. iud. §. item lex Cornelia de falsis, & l. 1. ff. cod. titu. & l. 5. titu. 7. part. 7.* affirmantque Greg. Lopez ibi, *Ant. Gom. 3. tom. var. res. c. 1. n. 4. Iul. Clar. 5. lib. sent. §. blasphemia. n. 4. & §. falsum. n. 1.* Quando autem iudicium est publicum, quilibet de populo potest de illo accusare, etiāsi sua nihil intersit, *vt habetur inst. de pub. §. 1. & l. 5. citata*, affirmanque doctores citati vbi suprā, *Ant. Gom. & Iul. Clar. n. 1.* Tametsi aliqua in particulari, interdum excipiantur, circa quæ non quibus de populo potest accusare, vt in crimine falsi excipitur partus suppositus, de quo non quibus accusat, vt videbimus. Porrò integrum est cuilibet accusare de crimine falsi intra viginti annos à commisso delicto. *Ita habetur. l. querela. C. ad leg. Cornel. de falsis, & l. 5. citata.*

Ad crimen falsi necessarius est dolus, neque est [sect. 3] satis esse factum per errorem, etiam ex lata culpa, *vt constat ex. l. nec exemplum. C. ad legem Cornel. de falsis*, & affirmat communis doctorum sentētia, quam referunt ac sequuntur Syluester verb. *falsarius. n. 1. Ant. Gom. l. 83. tauri. n. 1. & Iul. Clar. 5. lib. sent. §. falsum. n. 42.* Licet enim in contractibus, vt aliquid alicui pereat, soluerēve id teneatur, lata culpa dolo æquiparetur; ad incurrēdū tamen crimen, pro quo pœna corporalis est statuta, atque vt ea quis puniri valeat, lata culpa non æquiparatur dolo, *vt cum glossa. l. in actionibus. §. sed in his, verb. non etiam ob culpam. ff. de in litem iurand.* affirmat communis doctorum sententia, quam *Iul. Clar. 5. lib. sent. §. vlt. q. 84. n. 1. refert* ac sequitur. Item, vt crimen falsi incurratur, necesse est vt falsitas fiat circa id, quod præiudiciū aliquod proximo afferre possit: Vnde, si quis deprauet scripturam, ex cuius deprauatione nullum, aut leue admodum, præiudicium obuēire potest, vt quia illa in se erat inualida, aut aliqua alia ratione; vel si, testificando in iudicio, falsum dicat circa circumstantiam, quæ nullius, aut perexigui, sit momenti, aut circa aliud simile, non incurritur crimen falsi, saltem vt ordinaria pœna debeat puniri. *Ita, consentaneè ad glossam. l. damus verb. priuatas. C. ad leg. Cor. de falsis*, communis doctorum sententia, quam referunt ac sequuntur Couar. c. *quamuis pactum part. 1. §. 7. n. 6. Nauar. de datis & promissis pro iust. vel gratia. n. 14. Syluester. num. 1. citato, & Iul. Clar. §. falsus citato. num. 44. iuncto. num. 14.* antecedente: qui addit, puniri nihilominus debere pœna extraordinaria stellionatus iudicis arbitrio imponenda, de qua in calce Disp. 532. dictum est.

Illud vniuersim est dicendum, quod attinet [sect. 4] ad damnum in rebus externis ex crimine falsi proximo subsequutum, & quod ad præsens nostrum institutum attinet. Tam in exteriori, quàm etiam in conscientię foro, resarciendum esse damnum ab eo, qui id crimen falsi commisit, quando falsitas, crimēve falsi, in causa fuit, vt sequeretur tale damnum, vt regulariter esse solet. *Iul. Clar. §. falsum citato. n. 19. de teste*, qui in crimen falsi testificando incidit, sic ait: Item testis falsus tenetur versus partem de omni damno contingente propter falsum testimonium, secundum regulam, quam tradit glossa in. c. presbyterum in glossa finali de homicid. Hoc tamen intellige, vt procedat in foro contentioso: secus autem in foro conscientię. Nam in hoc foro non tenetur, nisi de falso testimonio, non autem ex damno ex illo subsequente. Ita sin-[[96]]gulariter dixit *vinc. in. c. 1. de custod. Euchar.* quem sequuntur communiter doctores, vt dicit *Corsetus in suis sing. in verb. testi, vers. si aliquis.* Quod nota, quia de facili quis responderet contrarium. Hactenus Iul. Clar. Quòd si id intelligat de

teste: qui contrarium dixit, ac res ipsa habebat, eaque ratione in causa fuit, vt in contrarium ferretur sententia, ac erat ferenda, certè tunc contra iustitiam peccauit aduersus eum, qui eo falso testimonio damnatus est, suumve ius non obtinuit, ac proinde restituere ei tenetur in foro conscientiae, nulla expectata alia sententia, totum damnum inde ei subsequutum, tanquam vera causa, aut concausa, iniusta totius illius dāni, neque est cur id in controuersiam vllam vocetur. Idem dic, quando solùm subticuisset veritatem, quam sciebat, accedendoque ita ad testificandum in causa fuit, vt is, à cuius parte iustitia stabat, non adhiberet alios testes, vt Disp. 83. vtrumque dictum à nobis est. Eadem disputatione diximus, quando solùm testificari tenebatur ex caritate & ex obedientia, quia à potestate publica iussus fuit ea de re testificari, veritatemque, quam sciebat, solùm subticuit, noluitque eam manifestare, tunc quàm plurimos doctores affirmare, peccasse etiam contra iustitiam, tenerique proinde restituere proximo damna omnia subsequuta ex eo, quòd suo testimonio non aperuerit veritatem, qua is proximus suum ius consequeretur, nobis verò diximus contrarium videri verum, nempe peccasse solùm contra caritatem, & contra obedientiam publicæ potestati tunc debitam, non verò peccasse contra iustitiam, ac proinde non teneri in foro conscientiae restituere dāna ex eo, quòd veritatem suo testimonio non aperuerit, ei proximo subsequuta: de qua re diximus eo loco, copiosius nos esse dicturos tractatu quinto: atque in eadem nunc sumus sententia. Quare, si in hoc solo euētu Iul. Clar. esset loquutus, sanè ei non repugnaremus. Quoniam, qui ita contra caritatem ac obedientiam veritatem occultat, verè incidit in crimen falsi, vt affirmat communis doctorum sententia, quā *Couar. c. quamuis pactum part. 1. §. 7. n. 5.* refert ac sequitur: est enim eo ipso reus contra Deum, & contra publicam potestatem, ac contra proximū suū, vt *Augustinus ait. c. 1. de crim. falsi, & c. quisquis. 11. q. 3.* quod satis est, vt crimen falsi testis incurrisset dicatur: consentitque. *l. 1. tit. 7. part. 7.* illis verbis; *o negare la verdad sabiendola*: ea verò de causa in exteriori foro inter alias pœnas, ea etiam puniatur, vt resarciat ei, in cuius detrimētū mentitus in iudicio est, veritatem non manifestando, damna omnia inde illi subsequuta. Iulius verò Clarus non de hoc solo euentu, sed vniuersim videtur loquutus: quare falsum existimamus, & contra omnium communem sententiam, quod ille affirmauit.

Propter periculum, ne ex cupiditate falsum scri [sect. 5] bat, qui se scribit hæredem, aut legatarium, in testamento alterius, irritum est id ac nullum, quod ita in suum commodum scribit: & præterea incidit in crimen falsi, nihil impediēte, quòd fortè ita dictauerit ei ac disposuerit testator. Et cū pro hoc crimine nulla pœna peculiaris, vel mitior, vel grauior, quàm ordinaria, statuta comperitur in iure, incidit in pœnam ordinariam in principio huius Disputationis explicatam, vt communis doctorum sententia affirmat. Idem est, si aliquis in testamento alterius scribat hæredem, aut legatarium, eum, sub cuius potestate sit, qui id scribit; vt si filius familias scribat patrem suum, aut si mancipium scribat suum dominum: quia enim imperium eorum, sub quorum sunt potestate, atque studium eis placendi, multū eos permouere potest, vt id falsò scribant, irritū id est redditum ac nullum, & is, qui id ita scribit, incidit similiter in crimen & in pœnam falsi. Atque idem similiter est, si quis in testamento alterius eum scribat hæredem, aut legatarium, qui sub ipsius est potestate; vt pater suum filium familias, aut dominus suum mancipium: quia enim per has personas sibi acquirit, ac proinde ea hæreditas, aut legatum, in suum redundaret commodum, redditum est nullum etiam id, &, qui id ita scribit, in pœnam ac crimen incidit falsi. *Ita habetur. l. 1. §. ad testamenta. l. filius, & l. diuus Claudius. ff. ad leg. Corn. de fal. ac. l. 1. & sequentibus. C. de his qui sibi ascrib.* Quòd autem talis institutio hæredis, aut legatarii, sit nulla, in calce

disputationis 125. ex parte est etiam dictum. Vbi explicuimus, non solùm id habere locum in testamento in scriptis, seu clauso, sed etiam posse aliquando habere locum in testamento nuncupatio, & consentit *Iulius Clarus. §. falsum citato. n. 34.* cum aliis, quos citat. In eadem Disp. 125 diximus, quando verè testator aliquem ita instituit hæredem, aut legatarium, posse in conscientie foro retinere hæreditatem, aut legatum, quousque feratur sententia, qua adimatur ac pronunciatur nullum. Ratio autem est, quoniam, præterquam quòd eiusmodi leges multum in præsumptione falsitatis fundantur, sunt etiam leges pænales, quæ locum non habent ante latam sententiam, non solùm quoad pœnam criminis falsi, sed etiam quoad amissionem hæreditatis aut legati.

Iuxta hæc, iuribus citatis, & aliis citandis, filius familias, qui est in potestate testatoris, aut eius, cui scribit hæreditatem, vel legatum, aut qui ipsi scribit hæreditatem, vel legatum, itemque seruus comparatione eorundem, distinguuntur à cæteris, cæteri que in re proposita appellantur extranei, etiam filius emancipatus cõparatione patris, & quicumque filius comparatione matris. Hinc efficitur, quòd si filius in testamento cuiuscunque, etiam patris, aut fratris, scribat matri legatum, neque incidit in pœnam legis Corneliæ de falsis, neque legatum est nullum, sed illud consequitur mater. *Ita habetur. l. si pater filio, in fine. ff. ad leg. Corn. de fals.* Inde etiam efficitur, quòd, esto maritus scribat hæredem, aut legatariam suam propriam vxorem, in testamento alterius, valida sit institutio, aut legatum, neque talis maritus incidat in pœnam legis Corneliæ de falsis. *Ita habetur. l. vxori. ff. ad leg. Corn. de falsis.* E contra verò, si maritus se scribat hæredem aut legatarium, in testamento suæ vxoris, inualida est ea institutio, aut legatum, inciditque in pœnam legis Corneliæ de falsis. *Ita habetur. l. quæ in testamento. ff. de his qui sibi adscrib.*

Quoniam, quando pater scribit in testamēto ali [sect. 6] cuius legatum filio, quem habet in sua potestate, idcirco legatum est nullum, & pater incidit in pœnam falsi, quia ex tali legato cõmodū in patrem redūdat, eo quòd si pater per filium suum familias sibi acquirat; inde efficitur, quòd si pater, habens filium in sua potestate, illi scribat legatum, in testamento eius, qui tali filio aliquid relinquit [[97]] tanquam commilitoni, occasioneve militiæ, in quo euentu tale legatum est bonum castrēse cõparatione talis filii, vt Disp. 130. explanatum fuit, neque acquiritur patri, sed est proprium bonū filii quoad dominium, administrationem, ac dispositionem; efficitur, inquam, quòd, si pater tale legatum scribat ei filio, neque legatum sit nullum, neque pater incidat in pœnam falsi; quia cessat ratio legis, ob quam sub ea pœna erat prohibitum, patrem filio, qui sub ipsius erat potestate, scribere legatum in alterius testamēto. *Ita habetur expresse eade. l. si pater filio. ff. ad leg. Corn. de fal.* Hinc colligo, quandocunque ita legatum, aut hæreditas, relinqueretur filio, vt neque vsusfructus illius attinere deberet ad patrem, tunc, esto id legatum, aut eam hæreditatem, pater scriberet filio, qui sub ipsius est potestate, in testamento alterius, neque hæreditas, neque legatum, esset nullum, neque is pater incideret in pœnam falsi, propter eandem rationem. Sicut neque quando pater filio suo emancipato, & filius matri, vel mater filio, scribit hæreditatem, aut legatum, in testamento alterius, iuribus non est dispositum, vt sint nulla, & vt incurratur pœna falsi.

Vtrū autem solum cõmodum vsusfructus,⁴⁵ quod, post iura Codicis & authenticorum, cõ [sect. 7] parat pater in bonis aduentitiis filii sui familias, cū tamen quondam de iure Digestorum, quādo lata hac de re fuit lex Cornelia de falsis, etiam compararet proprietatem, & omnino quicquid talis filius acquirebat, attinebat ad patrem, non secus ac quicquid mancipium acquirit, pertinet ad dominum suū; vtrū, inquam, id solum commodū sit hodie satis, vt, si pater legatum, aut hæreditatem, scribat filio suo familias in testamento

alterius, irrita sint ac nulla, & pater falsi pēnam incurrat? Partē negantem possumus suadere. Quoniam, si⁴⁶ filius matri scribat legatum, aut hēreditatē, intestamento alterius, vel filius emancipatus, scribat similiter patri legatum, aut hēreditatē, in testamēto alterius, valida hęc sunt, vt suprā dictum est *ex. l. si pater filio, ff. ad leg. Cor. de fal.* nihil impediēte, quòd iure hēreditario, aut alia ratione, tali filio obuēnire possit cōmodum ex eo legato aut hēreditate: quare idem dicendum videtur de patre cōparatione filii sui familias, nihil impediēte, quòd, interim dum pater vixerit, & filius non fuerit emancipatus, pater sit habiturus vum fructum, & administrationem, talis legati aut hēreditatis. Res sanè est dubia. Propendo tamen magis inua⁴⁷lidū id esse, & patrē incurrere pēnam falsi. Tum quia id ita statuunt iura de patre, quando ex tali legato, aut hēreditate, eo ipso patri acquiritur cōmodū: administratio verò, & vsus fructus, talis legati, aut hēreditatis, verè est cōmodū, quod eo ipso acquiritur patri. Tum etiam, quoniam, *vt habetur. l. filius. ff. ad leg. Cor. de fal.* si filius emancipatus in testamento patris scribat legatum mācipio, eidem filio & Titio communi, is filius incidit in pēnā falsi, & legatum est nullum, non solūm quoad partem, quam per id mācipiū, sibi commune cum Titio, erat consequuturus, sed etiam quoad totum, atque adeò etiam quoad partem, quam Titius acquisiturus erat per idem mācipiū: ergo eodem modo, in re proposita, pater incidet in pēnam falsi, & legatum erit nullum, non solum quoad partem illius, hoc est, quoad administrationē & vsumfructum illius, quæ per eum filium erat eo ipso acquisiturus, sed etiā omnino, atque adeò quoad id, quod filio ex eo legato erat obuēnturum. Neque est eadem ratio de⁴⁸ filio, qui legatum in testamento alterius scripsit matri: quoniam mater sola consequitur immediatè id totum commodum ac legatum, & filius nihil ex illo consequitur eo ipso per matrem: quòd autē remotè postea ex interuallo iure hēreditario, aut alia ratione, prouenire possit filio commodum aliquod ex eo legato, neque reddit illud nullum, neque efficit eum filium incurrere pēnam falsi. *Vnde. l. diuus Claudius in fine. ff. ad leg. Cor. de fals. [sect. 8] habetur,* si quis in testamento alterius duos hēredes scribat, apposita clausula, quòd si illi sine liberis decedant, hēreditas obuēniat ei, qui testamentum scripsit, hunc non incidere in pēnā falsi ex eo, quòd se ita fidei cōmissarium hēreditatis illius scripserit, & possit consequi hēreditatem, si illi postea sine liberis decedant. Ratio autem est, quia nihil consequitur eo ipso morte testatoris, sed hēreditatem totam consequuntur alii: quòd verò ipse in euentu, quòd illi sine liberis decedant, id fidei commissum consequatur ex testatoris præsripto, neque efficit eum reum falsi ex eo, quòd eam clausulam scripserit, neque fidei commissum illud nullum reddit.

Lege de eo. ff. ad leg. Cor. de fal. habetur, si quis in [sect. 9] testamento eius, in cuius potestate est, scribat legatum ei, qui in eiusdē testatoris est potestate, incidere in crimen falsi, & legatum esse nullum. Glossa ibi exemplum adhibet, vt si vnus filius familias in testamento patris, fratri suo, filio etiam familias eiusdem patris, scripsisset legatum. Hoc tamen falsum esse reputo: quoniam neque cum hactenus dictis, neque cum ratione, quam textus ille reddit, consentit. Etenim ex legato alterius fratris non magis fratri scribēti testamētū prouenit commodum, quàm si vterque esset emācipat⁹, aut aliter essent extranei cōparatione testatoris, atq; inter se: quando autem neque is, qui legatum scribit, est in potestate eius, cui relinquitur, neque ex eo legato commodum reportat, vtique legatum non redditur nullum, neque illud scribens, pēnā incurrit falsi, vt ex dictis, atque ex iuribus citatis, liquet. Eam verò legem intelligo, quando ita vterq; est sub potestate testatoris, vt is, cui legatū scribitur, aut qui legatum scribit, per mortem testatoris recasurus sit in potestatem scribētis id legatum, aut eius, cui scribitur, vt si filius familias habens filium, nepotem testatoris, in testamēto

sui patris scribat filio suo, nepoti testatoris, legatū: de iure enim communi vterque erat sub potestate talis testatoris, vt in materia de patria potestate dictum à nobis est, & cū nepos, de eodē iure communi recasurus esset in potestatem sui patris, pater cōparaturus erat id legatum morte talis testatoris, de iure quidem Digestorum omnino, & de iure Codicis, & authenticorum, quoad vsumfructum, & administrationē, vt dictum est. Aliud verò exemplum est, si filius familias in testamēto patris scribat legatum mancipio, quod in potestate testatoris sit, attamen quod morte testatoris recasurus sit in potestatem talis filii, quia videlicet per mortem patris consequuturus est id mancipiū. Atque cum his exemplis, non verò cum glossæ exemplo, consentit apertè ratio, quē in eo textu hisce verbis redditur; *quia huius rei* (hoc est legati) *emolumentū ad patre* (filium videlicet testatoris) *dominūmve pertinet, ad quem pertineret, si filius, seruūve, sibi scripsissent.* Quasi dicat, non minùs in his euentibus pater nepotis testatoris, & [[98]] dominus, qui acquirit mancipium illud morte testatoris, consequitur testatoris morte emolumentum talis legati, quàm si idem nepos & mācipium idem legatum sibimetipsis scripsissent in testamento eius testatoris: quare sicut in hoc euentu legatum esset nullum, & hi incurrerent pēnam falsi: ita in illo alio euētu legatum erit nullum, & filius familias talis testatoris, pēnam incurreret falsi.

Circa euentus omnes hactenus explicatos, in quibus dictum est, scribentem legatum, aut hæ [sect. 10] reditatem, sibi, aut alteri, in testamēto alterius, incidere in pēnam falsi, legatūq;, ac institutionē hæredis, esse nulla, est adhibenda sequens limitatio seu exceptio. Quòd si testator subscripsit specialiter, se relinquere in tali testamento, aut in tali codicillo, talem hæredem, aut tali in particulari relinquere tale, aut tantum, legatum, tunc, qui id scripserat in testamento, aut in codicillo, in nullam incidit pēnam, & valida sunt talis institutio hæredis, aut legatū: quia cessat omnis præsumptio falsitatis ex tali subscriptione in particulari testatoris. Si verò id subscripsit solū in generali; dicendo omnia, quæ tali relinquo, aut quod tali relinquo, confirmo, etiam si non exprimat in particulari, quòd tali personæ relinquat, *vt ait glossa. l. 1. §. ad testamenta, verb. subscriptio. ad leg. Cor. de fal.* tunc, si is, qui eam vltimam voluntatem scripsit, erat sub potestate testatoris, quia videlicet, vel erat illius filius familias, vel illius mancipium, vtique talis scribens non incidit in pēnam falsi, & valida sunt talis hæredis institutio, aut legatū: si verò scribens erat extraneus comparatione testatoris, hoc est, neque filius familias testatoris, neque eius mancipium, non incidit quidem in pēnam falsi, attamen ea institutio hæredis, aut legatum, nulla sunt. *Ita habetur. l. 1. §. ad testamenta, vers. inter filium. l. filius, & l. diuus Claudius. ff. ad leg. Cor. de fals. & l. 2. C. de his qui sibi adscribunt:* iunctis glossis in his omnibus iuribus. Item, quando constat, testatorem præcepisse ei, qui testamentum tale, aut talem codicillum, scripsit, ea scribere, tunc, si is, qui id scripsit, erat sub potestate testatoris, quia scilicet erat filius familias aut mancipium illius, non incidit in pēnam falsi, etiā si generalis subscriptio testatoris non fuerit addita, excusante eiusmodi scriptorē à tali pēna, testatoris præceptio, cuius obedientiam cōmodè declinare non potuit; nihilominus tamen ea institutio hæredis, aut legatum, vel etiam scriptio libertatis propria manu mancipii, sunt inualida: si verò is, qui scripsit, erat aliquis alius, institutio hæredis, aut legatum, sunt inualida, & scriptor incurrit pēnam falsi. *Hæc habētur. l. ult. C. de his qui sibi adscrip. l. filius, jūctis glossis verb. licet iussu, & sequentibus, & l. diuus Claudius, vers. & quatenus. ff. ad leg. Cor. de fals.*

Quando filius emancipatus in testamento pa [sect. 11] tris (idem dicerem in testamēto matris, cum hodie eodem modo cōpetat ei successio matri, ac patri, eodemq; modo sit ei debita legitima in vtriusq; bonis) scripsit se hæredem, tunc, si in totum id, in quod se scripsit

hæredem, successurus ab intestato erat eidem patri, de æquitate non incidit in pænā falsi, validaque est talis institutio. *Ita habetur. l. 1. C. de his qui sibi adscrib.* A contrario autem sensu, si is pater alium, aut alios, habebat filios, atque vnus eorū cmācipatus, propria manu sibi scripsit plus, quā ex eodem patre obtenturus erat ab intestato, sanè relictum esset nullum, & ille incideret in penam falsi.

Quòd si patronus in testamento liberti, aut a [sect. 12] lius consanguineus testatoris, qui non esset filius illius, sibi in testamento eius scripsisset, quantū obtenturus ex illo esset, si ille ab intestato discederet, tunc incurreret in pœnam falsi, & quod ita scripsisset, esset nullum, vt affirmat glossa *vt. l. 1. C. de his qui sibi adscrib. & habetur. l. si quis legatū. §. vt. ff. ad leg. Cor. de fals.* Ratio autem est, quoniam non ita arcte debita est reliquis portio in bonis testatoris, sicut filiis debetur in bonis suorum parentum. Quòd si vxor in testamento mariti scriberet, vt ipsi dos, sibi debita, solueretur statim mortuo testatore, aut creditor in testamento sui debitoris scriberet, vt debitum suum ipsi solueretur ante diem, qua alioquin solui erat debitum, tunc ea de causa debitum suum non amitterent, soluendum tamen eis esset tempore alioquin eis debito. *Ita habetur. §. vt. citato.*

Quando mancipium matris, iussus, in testamē [sect. 13] to filii, scripsit matri legatum, aur filia sibi in testamento matris per ignorantiam scripsit legatū, venia eis conceditur, ne puniantur pœna falsi. *Ita habetur. l. diuus Claudius. §. penul. ff. ad leg. Cor. de falsis.* Et vniuersim, quando persona, quæ id scripsit, est, talis, vt præsumentum sit ex ignorantia id fecisse, vt quia mulier erat, aut rusticus, vel miles, facilè ei conceditur venia pœnæ legis Corneliæ de falsis, à principe, aut supremo senatu, modò profiteatur, se velle abstinere ab eo legato. *Ita habetur. l. senatus, & l. penult. C. de his qui sib. adscrib.* Quando autem non sunt tales, vt præsūmēda sit in eis ita ignorantia, non excusantur à pœna legis Corneliæ de falsis ex eo, quòd dicant, se ignorasse, id iure adeò seuerè esse prohibitum, *vt habetur. l. diuus Claudius citata. Lege senatus. ff. ad leg. Cor. de fal. habetur*, quòd, cūm filius patris testamentum iussu eiusdem patris scripsisset, in quo ipse hæres erat institutus, & grauabatur soluere multa legata, & postea scripsisset codicillos, quibus legata reuocabantur; quod virtute erat, ea sibi scribere; obtinuisse eum veniam pœnæ legis Corneliæ à senatu, tum quòd iussu patris id fecisset, tum etiam quòd integros viginti quinque annos non implesset, obtinuisseque hæreditatē. Arbitror tamen (quamuis ibi id non exprimatur) reuocationem illam legatorum in codicillis iudicatam fuisse nullam, illūq; ab illis abstinuisse, iuxta alia iura citata.

Si testamentum sit perfectum, ita vt integre sit [sect. 14] confectum, & cum debita solēnitate, esto in eo aliquis indebitè sit præteritus, aut exheredatus, & esto ex quacunque causa nullum reddatur, locum habet pœna legis Corneliæ de falsis imposita scribentibus in testamento alterius legatum, aut institutionē hæredis in euentibus explicatis, idq; etiam si legatum testamētū sit nullum, vel quia de re sacra, vel aliqua alia ratione: secus autem si testamētū esset nullum, quia non factum perfectè & cōsūmatèac cūrequisita solēnitate. Idem intellige de codicillo. *Ita habetur. l. si quis legatū. ff. ad leg. Cor. de fal.*

Qui se filio testatoris impuberi tutorem in [sect. 15] testamento patris scripserit, non consequitur tutelam ex tali testamento, (intellige, nisi pater in subscriptione testamenti id expresserit) & nihilominus, si idoneus, nec suspectus, ad id iudicetur, poterit à iudice designari ei tutor. Designato verò, non admittitur recusatio eius muneris, esto alioquin haberet legitimam excusationem: quoniam, cūm in [[99]] testamento patris consenserit, non est cur excusatio ei admittatur. *Ita habetur. l. vxori. ff. ad leg. Cor. de fal.* Limitarem tamen

id, consentaneè ad eam ipsam rationem, quam textus reddit, nisi legitima causa excusationis, post scriptum id testamentum, ei aduenisset.

Quando is, qui alienum testamentum, aut co [sect. 16] dicillos, scripsit, falsò se, aut alium, scripsisset hæredem, aut legatarium, vel in maiori quantitate, quam testator dixisset: tunc dubium non est, non solùm ita scribentem incurrere in crimen falsi, etiam quia falsum instrumentum scripsisset, de qua re alibi est dicendum, sed etiam teneri restituere omnia vniuersim damna inde quibuscunq; aliis subsequuta, quibus plus alioquin obuensisset, vel ex testamēto, vel ab intestato, ex bonis talis defuncti, aut quibus quacunque alia ratione nocuisset. Hæc omnia adiunge iis, quæ Disp. 125. diximus, quibus magis illa explanantur; atque iuxta hæc illa intellige.

Quando aliquis censendus sit prohibere ali [sect. 17] quem testari, & quòd teneatur restituere omnia damna inde subsequuta, & in quas pœnas alias incidat, dictum est Disput. 135. §. ex eadem doctrina, & §. qui impedimento, & Disput. 176. §. nona, & rursus infra eadem Disputat. §. quarta, & Disputat. 178. §. quartus, *Iulius Clar. lib. 5. sent. §. falsum. n. 36.* affirmat, incurrere etiam pœnam falsi, & puniendum esse extraordinariè iudicis arbitrio, citat ad id legem Paulus (aliàs incipit, instrumētorum). ff. ad leg. Cor. de fals. & multos doctores. Ea tamen lex, neque alia in eo titulo, aut. C. eod. titu. ea de re non loquitur, neque hactenus video vnde id probetur.

Disputat. 369. dictum est de eo, qui rem vendit [sect. 18] duobus, & quòd incidat in pœnam falsi, *Iuxta. l. qui duobus. ff. ad leg. Cor. de fal. & l. 7. titu. 7. part. 7.* Et, cùm iura non expriment peculiarem pœnam pro hoc delicto, erit pœna deportationis. Lex. 7. citata exprimit, quòd sit, non in perpetuum, sed ad aliquod determinatum tempus iudicis arbitrio in aliquam insulam. Item exigit, vt vendens præmium acceperit ab utroque emptore, vt hæc pœna incuratur. Alioquin solùm incurreretur pœna stellionatus, vt ibidem Greg. Lopez ait: quæ pœna incurritur ex contractu alio quocunque alienationis eiusdem rei duobus, vt glossa lege qui duobus citata. *Iulius Clar. vbi suprà. n. 37.* & doctores communiter affirmant. Iulius Clarus ibidem subiungit, per contrariam consuetudinem pœnam falsi non habere hodie locum, etiam in contractu venditionis rei eiusdem duobus.

De aliis criminibus falsi, nempe de supponente partum alienum, de immiscente indebitè res aliquas, & de vtente falsis mensuris & ponderibus. Disp. 701.

SVMMARIVM.

1. *Falsi crimen committit, qui partum supponit, aut ad id, vel ad quodcunque aliud crimen falsi, cooperatur.*

2. *Falsi de crimine accusare possunt criminaliter uxorem, quæ partum supposuit, vir, & qui successuri sunt, excluso eo partu supposito, modò filii non sint talis mulieris: nam hi solùm possunt agere ciuilitè, vt is partus excludatur, aduersus matrem: aduersus alios verò cooperantes ad id crimen agere possunt criminaliter. Alii verò de populo de eo crimine agere non possunt.*

- 3 . *Falsi criminis actio aduersus matrem ob partum suppositum non suspenditur ob detrimentum status filii impuberis: & quatenus, eo nihil impediante, causa filii differatur.*
- 4 . *Falsi criminis actio ob partum suppositum, cooperationemq; ad illum supponendum, nullo tempore præscribitur.*
- 5 . *Falsi crimen qui incurrunt partum supponendo, aut ad id cooperando, restituere tenentur in conscientie foro damna omnia subsequuta, & quã ante quos.*
- 6 . *Falsi crimen incurrunt aurifices, qui auro, aut argento, ex quibus arte facta conficiunt, metallum impurius miscent.*
- 7 . *Falsi crimen incurrunt pharmacopolæ, qui vnum pro alio pharmacis miscent, & ad quantum restitutionem teneantur.*
- 8 . *Falsi crimen incurrunt qui pulueri sulphureo, quæ non oportet, miscent, inutilioremque ad bellum reddunt. Et quàm acriter puniendi, & ad quam magnam restitutionem teneantur, si ad bellum illum vendant, aut conficiant.*
- 9 . *Falsi crimen quousque incurrant, qui arte facta ex cera, non vt oportet conficiunt, aliqua illis miscendo. Et hoc ac præcedentia crimina qualiter hodie puniantur.*
- 10 . *Falsi crimen incurrunt, qui scienter falsis mensuris aut ponderibus vtuntur. Et multa quæ circa mensuras ac pondera statuta sunt in hoc regno, ac circa metiendi modum, & ad quam restitutionem hi omnes teneantur.*
- 11 . *Falsi criminis pœnam non incurrunt, & qualiter sint puniendi, & quousque ad damna inde sequuta teneantur, & num hæredes eorum teneantur, actioq; aduersus illos transire debeat, mensor agrorum, ædificii, tritici, aut alterius rei, ponderator, & qui rationes supputat ac perficit nomine aliorum, si dolo, aut scienter falsum referat & ex quanta culpa teneantur.*

Committitur præterea crimen falsi, si partus [sect. 1] alienus supponatur, fingendo aliquem

esse filium alicuius, cùm non sit, siue ab ea fiat, quæ fingit esse suum filium, cùm non sit, siue ab aliquo, qui ad id cooperetur consilio, aut aliqua alia ratione. Cooperantes enim ad crimen quodcũq; falsi, in crimen falsi, & in pœnam pro eo statutam, incidunt, vt colligitur ex. l. falsi, iuncta. l. qui testamentum. ff. ad leg. Cor. de fals. & habetur in calce. l. 3. titu. 7. part. 7. resque ex se est perspicua. Cùm verò pro hoc crimine nulla peculiaris pœna statuta sit in iure, incurreretur pœna ordinaria, de qua initio Disputationis præcedentis habitus est sermo. Ita Ant. Gom. l. 83. tauri. n. 12. Neque refert, quòd. l. 1. C. ad leg. Cor. de fals. dicatur, eam, quæ de crimine partus suppositi accusatur, subire capitis periculum: quoniam deportatio, cum bonorum confiscatione, inter capitales pœnas computatur.

Mulier, quæ partum supponit viro suo, dicēs [sect. 2] ex illo esse conceptum, accusari criminaliter potest ad pœnam legis Corneliæ de crimine falsi à viro suo, atque ab hæredibus viri, qui non sint filii talis vxoris, & successuri fuissent ei viro in bonis illius, excluso eo, de quo contendunt esse partum suppositum: reliqui verò accusare non [[100]] possunt eam mulierem de crimine falsi: vnde hoc falsi crimen excipitur à reliquis, vt non quiuus de populo possit de illo accusare. Ita habetur. l. lege Cornelia. 2. §. de partu. ff. ad leg. Cor. de fals. l. cū suppositi. C. eod. titu. & l. 3. titu. 7. part. 7. Filii verò, si sint eiusdem matris, poterunt quidem agere ciuilitè, vt partus suppositus ab hæreditate patris, ac matris, excludatur: non verò criminaliter, vt mater pœna legis Corneliæ de falsis puniatur, idque propter reuerentiam,

quam filii parentibus suis debent; aduersus alios tamen cooperatores ad id crimen agere possunt criminaliter. *Ita habetur. l. hi tamen. ff. de accus. l. falsi. C. ad leg. Cor. de fals. c. l. 3. titu. 7. part. 7.*

Vtrùm autem, si partus, qui suppositus con [sect. 3] tenditur, impubes sit, debeat causa differri vsque ad tempus pubertatis illius, quatenus de statu illius agitur, & de impedienda missione illius in possessionem bonorum patris, cui is partus suppositus contenditur. Lege, quæ copiosè ea de re Disput. 637. à nobis sunt dicta. *Lex. 1. C. ad leg. Cor. de fals.* satis perspicuè definit, causam criminalem aduersus matrem, differendam non esse vsque ad pubertatem filii, eo intuitu, quòd sententia aduersus eam præiudicare possit filio impuberi, quoad bona patris, cui suppositus fuisse contenditur. Et reddit rationem textus ille: quoniam, cùm agatur de pæna capitali imponenda matri, si probetur aduersus eam, supposuisse eum partum, credendum est, quòd diligenter causam defendent, & quòd non permittet præiudicium tali partui circa bona patris, cum tanto suo detrimento. Dicendum verò est, consentaneè ad glossam ibi, & ad ea, quæ Disputatione citata dicta sunt. Propter statum quidem atque emolumentum filii, differendam non esse causam criminalem aduersus matrem, quatenus præcisè agitur de matre punienda, deq; matris incōmodo: nihilominus, nisi luce clariùs ex probationibus aduersus matrem constet, partum verè fuisse suppositum, (quando enim id apertè constaret, locum non haberet Carbonianum edictum, de differenda causa status, & de ventre, aut sobole iam nata, mittenda in possessionem bonorum patris defuncti, vt disputatione citata dictum est) causam peragi aduersus matrem, non impedire, quominus causa status filii differatur usque ad talis filii pubertatem, & quòd, modo disputatione citata explicato, in possessionem bonorum patris mittatur.

Hoc loco est obseruandum. Actionem crimi [sect. 4] nalem ad puniendum crimen partus suppositi ex lege Cornelia de falsis, nullo tempore præscribi, sed semper intentari posse aduersus delinquentes superstites, *vt constat ex. l. qui falsam. §. accusatio. ff. ad leg. Cor. de falsis.* Vnde, si post mulierem defunctam, quæ partum supposuit, & quæ principalis fuit in eo delicto, tempore quocūq; superstites sint aliqui ex iis, qui cooperati essent ad idem delictum, aduersus illos agi posset criminaliter eo modo, quo paragrapho præcedēte dictum est, agi posse aduersus eam, quæ eum partum, tãquam suum, marito supposuit, neque id est differendum propter statum impuberis suppositi, *vt habetur. l. licèt. ff. de Carb. edict.*

Qui partum supponit, aut, vt id fiat, coopera [sect. 5] tur, dubium non est, restituere teneri dāna omnia inde subsequuta, legitimis alioquin hæredibus, vel quibuscunq; aliis, idque in foro conscientiae ante vllam latam sententiam. Cooperans verò tenetur solùm in defectum causæ principalis supponendi ita partum. Mandans verò tenetur primo loco ad eam restitutionem ante omnes alios, eoque restituente, cessat obligatio cæterorum. Ex dicendis verò tractatu. 3. dum sermo erit, quousque, & quantum, restituere te neatur vxor, quæ concepit ac peperit ex adulterio, facillè intelligetur, si quid in particulari addendū hoc loco erat, circa quantitatem, & modum, restituendi ob partum ita suppositum, quando de eo delicto in foro exteriori non constat.

In crimen item falsi incidunt aurifices, qui [sect. 6] auro, ex quo arte facta conficiunt, immiscent aliud. minoris valoris metallum. Et idem est, si argento immisceant metallum inferioris valoris. *Ita habetur. l. lege Cornelia, 1. in prin. ff. ad leg. Cor. de fal. c. l. 4. titu. 7. part. 7.* Quot autem caractorum esse debeat in hoc Regno aurum arte factorum, quæ vendenda conficiuntur, vt, qui plus alteri⁹ metalli eis arte factis miscuerit, in hoc crimen incidat, dictum est in materia de cambiis. Vbi etiam explicatum est, quale esse debeat

argentum arte factorum, & explanatæ sunt pænæ in hoc Regno statutæ iis artificibus, qui ex auro, aut ex argento, magis impuro arte facta conficiunt. Quando autem aliquis in hoc Regno traderet aurifici aurum magis purum, quàm sit, ex quo ipsi tenentur arte facta conficere, vt arte factum ex auro puriori ipsi conficeret, atque aurifex detraheret de puritate illius, sibi vsurpando partem eius auri, & reliquo immiscendo tantundem ponderis ex alio metallo, quantum sibi ex auro vsurparet, tunc furtum committeret, & in crimen falsi incideret, esto arte factum non haberet impurius aurum, quàm lege sit præscriptum, vt habeant arte facta ex auro, quæ in hoc Regno vendenda exponuntur.

Lex. 4. citata, etiam in crimen falsi inci [sect. 7] dere statuit eos pharmacopolas, qui medicinas, & res alias, quæ ad ipsorum ministerium spectant, conficiunt, permiscendo in illis res quasdam minùs vtilis, loco earum, ex quibus constare, iuxta ipsorum artem, ac medicorum præscriptum, debebant. Atque in exemplum adhibet, vt si, vbi sacharum apponere debebant, mel apponât: lōgè autem magis incident in idem crimen, aciusque puniri debent, si permisceant res alias minùs proficuas ad sanitatem consequendam, & quæ plus nocere possunt; tenebunturque in conscientiæ foro ad restitutionem, non solùm eius, quod minus valent, quàm sit pretium, quod pro eis acceperunt, imò & totum pretium, si res illæ inutiles sunt ad finem, ad quem petuntur, ac emuntur; sed etiam dāna omnia inde subsequuta, prolongationis ea de causa morbi, expēsarum, atque aliorum damnorum, inde subsequutorum, tum in rebus externis, tum etiam in corpore ac salute. Atq; hæc attēdere debent confessarii, dum farmacopolarū confessiones audiunt, eaque diligenter examinare debent, pharmacopolasque admonere debent, quantum periculi ac culpæ in eiusmodi criminibus sit, & quāta ex eis restituendi obligatio cōsurgat.

In idem crimen incidunt, qui puluerē sulphu [sect. 8] reū conficiunt ac vendunt, & quo plus lucentur, illi non immiscent, quę necessaria sunt, vt sit acris & vtilis ad bellū. Atque si ad bellum eum ita conficiant ac vendant, non solum incidunt in crimen falsi, **[[101]]** tenenturque ad restitutionem grauissimorum damnorum, quæ inde reipublicæ ac militibus sequuntur, sed etiam, tanquam hostes ea in parte reipublicæ, essent puniendi.

In idem crimen incidere dicuntur, qui arte facta ex [sect. 9] cera conficiunt, ceræque permiscent, vel multum resinæ vel ceram intus pessimam, & quæ defluxit ex aliis arte factis, quæ arserunt, consumptis tenuioribus & pinguioribus partibus igne antiquo, & relictis crassioribus, ac veluti cineribus, ceræ antiquæ. Si tamen eiufmodi artefacta ex cera impura intus confecta ita vendenda exponantur, vt emptores intelligant quali cera constent, rectè Greg. Lopez. l. 4. citata ait, non incurrere pœnam falsi, neque ea de causa esse puniendos: eo quòd nullum crimen committant, idque satis apertè innuit vniuersim lex ipsa. 4. citata, quandocunque res aliqua ei venditur, qui scit qualiter sit confecta, quibusque materialibus cōstet. Quamuis autem commemorati toto hoc. §. quin & §. præcedente, & alii similes, crimen falsi suo modo commi: tant, dignique pœna sint; credo tamen non esse in more positum, vt pœna ordinaria, pro crimine falsi statuta, puniantur, sed pœna arbitraria, prout iudex expedire iudicauerit, attenta qualitate delicti, attentisque aliis circumstantiis concurrentibus, puniuntur, vel pœna legibus priuatis Regnorum statuta, si quæ talis statuta alicubi comperiatur. Qui tamen inutilem puluerem sulphureum ad bellum conficeret ac traderet, & qui militum cibariis aliquid saluti eorum nociuum admisceret, etiam si id efficeret, nō animo nocendi, sed lucrandi, sanè vltimo supplicio esset plectendus, nedum pœna deportationis, aut, loco illius, triremium; quandoquidem grauissimū damnum eo suo delicto toti reipublicæ infert.

Qui vtitur falsis ponderibus, aut mensuris, e [sect. 10] mendo, aut vendendo, (intellige, vel permutando) si sciens id efficiat, in crimen incidit falsi, atque de iure communi punitur dupli pæna eius præcisè damni, quod ita dederit, & insuper relegatur in aliquam insulam tempore principis arbitrio statuendo. *Ita habetur. l. penul. ff. ad leg. Cor. de fals. l. annonam. §. ult. ff. de extraord. crim. iuncta lege in Dardanarios. ff. de penis, & l. 7. tit. 7. part. 7.* Item frangi debent tales mensuræ falsæ, vt colligitur ex. *l. item quæritur. §. si quis mensuras. ff. locati. & habetur. l. 7. citata*, quæ addit vt fractio fiat ante ianuam eius, qui illis fuerit vsus. Quibus autē mensuris, & ponderibus, in hoc Regno sit vtendum, disponitur titu. 13. lib. 5. nouæ collect. abrogatis mensuris, & ponderibus, antiquioribus. Atque l. 2. inter alia, sic habetur: *Y qualquiera, que con otra medida midiere, saluo por las dichas medidas, que por la primera vez, que le fuere probado, cayga è incurra en pena de mil marauedis, y que le quiebren publicamente la tal medida, y se ponga en la picota. Y por la segunda, cayga è incurra en pena de tres mil marauedis, y estè diez dias en la cadena. Y por la tercera vez le sea dado pena de falso. Y en esta misma pena cayga e incurra qualquier carpintero, o calderero, o otro official, que de otra guisa hiziere las medidas de pan y vino.* Lege autem. 4. eiusdem tituli, & l. 19. titu. 5. lib. 3. sancitur, vt correctores, & alii iudices, cùm primùm munera sua acceperint. iubeant publico præconio, vt intra certum tēpus omnes afferant mēsuras, quibus vtuntur, vt videatur, an certæ ac iustæ sint, & vt, eo termino elapso, & non antea, pænas exequutioni mandent. Credo tamen, si quis comperiatur fuisse vsum falsis mensuris, aut ponderibus, de industria ad id confectis, animo decipiendi ac defraudandi alios, statim puniri posse, ac debere, pæna falsi. Iura quippe huius Regni citata intelligi debent, quando non constat mensuras de industria esse falsas, sed diminutas esse, eo quòd tempore sint attritæ ac imminutæ. Lege etiam, quæ de ponderibus statuuntur, lib. 5. nouæ collect. titu. 22. l. 1. & sequentibus. Qualiter autem metiri in hoc Regno debeant panni, & quas pænas incurrant, qui id sint transgressi, habetur eodem lib. 5. nouæ collect. titu. 12. Et. l. 6. falsariorum pæna statuuntur plectendi mercatores, *que venden sedas y brocados, si à las pieças quitan o mudan los sellos, por los quales se pueden conocer de donde son, hasta ser vendida del todo la pieça que los tiene.*

In euentibus omnibus explicatis satis perspicuum est, qui damnum aliquod dat, teneri in conscientiæ foro illud totum ei restituere, nulla expectata sententia, cui est datum, si constet quis is sit, alioquin pauperibus pro anima illius, aut illud insumendo in aliis operibus piis, vt de dāno dato vtendo falsis mēsuris, aut ponderibus, inter alios, affirmat *Nauar. in Manu. c. 17. n. 169.*

Quando mensor adhibetur agrorum, ædificii, [sect. 11] tritici, aut alterius rei, vel ponderator, vel qui rationes aliquas supputet, & perficiat nomine aliquorum, si is falsum referat, idque dolo seu sciēter, præterquam quòd tenetur de damno subsequuto, modo statim explicando, puniri deber ob eam falsitatem, non quidem pæna legis Corneliæ de falsis, cùm nullibi in iure id sancitum reperiatur, neque hoc crimen inter crimina, ob quæ lex Cornelia de falsis lata est, computatum inueniatur, sed iudicis arbitrio pro qualitate criminis, circumstantiarumque concurrentium, puniri debet tanquam de crimine stellionatus, iuxta. l. 3. ff. de crimine stellion. & ea, quæ in calce disputationis 532. dicta sunt, idque est, quod intendit ac statuit lex. 8. titu. 7. part. 7. consentitque Greg. Lopez ibi. Præterea, siue dolo id fecerit, siue lata culpa, quamuis agi non possit aduersus eum ex locato, esto pretium aliquod, in remunerationem industriæ ac laboris suscepti, ei solutum sit, eo quòd id, non tanquam merces, sed tanquam honorarium præmium ei solutum sit, vt habetur. l. 1. ff. si mensor falsum modum dixerit; peculiari tamen actione ex edicto eius tituli agi potest aduersus eum ad

damnum ei sequutum, in cuius præiudicium id falsum retulit, per se, vel per literas, vel per interpositam personam, vel per alium, cui dimensionē, ponderationē, aut supputationem, loco sui, commisit: solū tamē conceditur aduersus eum hæc actio, quando is in cuius cōmodū id cessit, quīve inde factus est locupletior, non fuerit soluendo, vel aliqua alia ratione obtineri ab illo in foro exteriori non poterit: si enim obtineri condicīve ex illo in exteriori foro possit, quia ad illum id cōmodū peruenit, cessat ea actio aduersus mēsorē, ponderatorē, aut supputatorem, & solum competit aduersus eum, qui commodum illud retinet, aut ex illo est factus locupletior, quatenus illud ita retinet; solūq; dimēsor, ponderator, aut supputator, tenebitur ad incrementū, si plus damni datum sit, quā ille alius soluere ratione rei acceptæ teneatur. *Ita habetur. l. 1. & sequentib.* maximè tribus vltimis. *ff. si mens. fal. mod. dix. & l. 8. titul. 7. part. 9.* [[102]] Atque leg. 1. citata satis apertè innuitur, quanuis mensori merces aliqua soluatur, non teneri de maiori culpa, quā de lata: eo quòd prætor, sciens mercedem honorariam sæpe ei solui, non de maiori culpa, quā de lata; edicto, quod ea de re tulit, illum teneri voluit. Vt verò criminalem pænam stellionatus incurrat, non sufficit lata culpa, sed verus dolus est necessarius.

Lex. 3. §. vlt. ff. si mens. fal. mod. dix. ait, actionem ex eo edicto competere aduersus mēsorē ei, qui damnum est passus, eiusque hæredibus; non verò aduersus hæredes mensoris. In foro tamen conscientiæ non dubito, hæredes mensoris teneri resarcire damnum ita à mensore datum, de illius bonis, nulla expectata sententia, in defectum tamen eius, qui ex parte rei acceptæ resarcire illud tenetur, idque non solū quando dolo mensoris datum est damnum, sed etiam quando culpa lata, coniūcta cum theologica culpa eiusdem mensoris, fuit datum: neque video, cur in his euentibus denegari etiam debeat actio aduersus hæredes mensoris, vt glossa ibidem, citatis aliis iuribus, propendēre videtur, quando dānum dolo fuit datum; etenim ea actio in his euētib; non est pænalis, quæ transire non debeat ad hæredes mēsoris, sed prosecutiua eius, quod mensor ex ipsa rei natura, nulla expectata sentētia, solucre in conscientiæ foro tenetur.

Illud hoc loco obserua, quæ de mensore dicta sunt, tam quoad pænam criminalem stellionatus, quā quoad actionem ciuilem damni dati, in defectum illius, qui ad illud ratione commodi inde percepti, reiveacceptæ, tenetur; similiter habere locum in iis, qui ex consensu partium, vel à iudice ad id deputati, intendunt partitioni bonorum defunctorum, eamque inter hæredes perficiunt, & in similibus aliis, qui, licet præmium ea de causa sæpe accipiant, illudque petant, etiam in iudicio, non tamen propriè dicuntur se ad id locare pro eo præmio & commo do, sed illud accipiunt ac petunt tanquam præmium, honorariamque mercedem, sui laboris ac industriæ: quarehi solū tenentur de dolo & lata culpa ex suo ministerio aliis sequuto, idque in defectum eius, in cuius commodum id cessit, & qui ratione rei acceptæ tenetur, vt de mensore dictum est. Si quis tamen propriè se locaret, tenetur etiam de leui culpa.

De crimine falsæ monetæ. Disp. 702.

SVMMARIVM.

1. *Falsam monetam eudere dicitur, qui sine principis facultate eam cudit, licet legitimam alioquin eam cudat. Et qui non legitimi ponderis, aut non legitimi metalli eam cudit. Bona*

illius confiscantur, & extrangulatus crematur. Appellatio ei non admittitur. Neque extrahenti illum de carcere, qui mortis pœnam incurrit.

2 . Moneta falsa vt cudatur, qui scienter cooperantur, aut domum, in qua cudatur, ad ministrant, eis de omnibus subiacent pœnis. Excipitur impubes, qui pubertati non est proximus: is quippe nullam pœnam incurrit.

3 . Falsa moneta si in domo aliqua cudatur, amittit eam dominus fisco, etiam si id ignorauerit. Et quando illam non amittat.

4 . Falsam monetam qui cudit in prouincia, in qua non expenditur, vt eam in aliam, in qua expenditur, transferat, deprehensus in prouincia, in qua illam cudit, solùm punitur pœna arbitraria: deprehensus verò in prouincia, in quam illam transportat, punitur ordinaria pœna.

5 . Falsam monetam cudens in loco recognoscentis superiorem, qui tamen ius habet monetam cudendi, quam pœnam incurrat.

6 . Falsam cudere monetam aggressus si ante cuneum adhibitum pœnitentia ductus cessauit, non punitur. Et qua pœna puniatur, si non destitit pœnitentia ductus.

7 . Falsæ monetæ de crimine accusans, præmio afficitur, si id probetur. Et esto id non probet, de calumnia non tenetur.

8 . Falsificans monetas eas tondendo, radendo, aut tingendo, quas pœnas de iure communi & huius regni incurrat.

9 . Falsam monetam scienter expendens, quibus subiaceat pœnis iure communi & huius regni.

10 . Falsam monetam cudens, etiam iusti ponderis ac materiæ, lethaliter peccat, principique restituere tenetur emolumentum, quo illum iniuste priuauit, & priuatis, si quod damnum inde etiam eis prouenit.

11 . Falsam monetam cudens detrahendo de pondere, aut depuritate metalli, vel illam tondens, radens, aut tingens, lethaliter peccat, & ad quam ac qualem restitutionem teneatur.

12 . Falsam monetam qui ignoranter aut scienter expendit, quousque & quo modo restituere teneatur.

SVperest dicam is de crimine falsæ monetæ. [sect. 1] Crimen falsi circa monetam multis

modis euenire potest. Atque in primis, cùm ad solùm Imperatorem, Principemve, aut rempublicam, non recognoscentem superiorem, spectet cudere monetam, tanquam ius regale, sibi que proprium, vt constat ex. c. 1. quæ sint reg. feud. & affirmat communis doctorum sententia, quam referunt ac sequuntur. *Couar. de collatione veterum numismatum. c. ult. & Ant. Gom. l. 83. tauri. n. 3.* vtique, qui non ex supremi principis facultate monetam cudit, si ex tempore, de cuius initio non extat memoria, præscriptum non habeat ius eam sua auctoritate cudendi, censetur falsam cudere monetam, ob defectum formæ illius, quam furatur, esto iusti ponderis, atque ex materia alioquin debita, eam cudat, & consentit *Augus. c. quod quidam. 1. q. 1.* idque apertè cedit in supremi principis, ac in reipublicæ, detrimentum. Multo autem magis censetur falsam eam cudere, si simul detrahat de pondere, aut permisceat plus alterius metalli, quàm sit consuetum, & quàm habeant monetæ iussu supremi principis cussæ. Qui verò falsam monetam aliquo ex his modis cudit, in crimen incidit falsi, & quanuis ante iura Codicis non tanta seueritate plecterentur, post iura tamen Codicis, omnia illorum

bona confiscantur, & ipsi extrangulati exuruntur, *vt constat. l. 2. C. de falsa moneta, & l. 9. titu. 7. part. 7.* & affirmat communis doctorum sententia, quam referunt ac sequuntur *Couar. c. ult. citato. n. 4. §. qui verò, & §. is verò, Ant. Gom. n. 3. citato, & Iul. Clar. lib. 5. sent. §. falsum. n. 46.* Qui refert, eos in Gallia in feruenti aqua suffocari. *Couar. vbi suprà. §. ego verò, arbitratur, pœnam illam [[103]] extraordinariam legis. 2. C. de falsa moneta, non habere locum in falsificante quoscunque nummos, etiam argenteos, & æneos, sed solùm in falsi ficante nummos aureos, ductus quibusdam legibus ex Codice Theodosiano, quas refert, atque vnde desumptam ait eam legem secundam: fatetur tamen communem sententiam esse in contrarium. Ac certè, si fundamentum *Couar. vllius esset momēti, dicendum esset, neque in omnibus monetis aureis habere locum, sed in solidis tantùm, de quibus solis fit mentio in iuribus, quæ ex Codice Theodosiano refert. Dicendum verò est, Codici Iustiniani esse hodie standum: lege autem. 2. citata sermonem esse de nummis falsis in gene. Præterea hodie in hoc Regno stādum est communi sententiæ: quoniam iuxta eā lata est lex. 9. titu. 7. part. 7, quæ de nummis argenteis, & æreis, loquitur, eamque pœnam statuit. De eo, qui Regis autoritate cudit monetam, sed minoris ponderis eam cudit, quàm à Rege sit præscriptum, vel miscet plus de inferiori metallo, quàm à Rege sit præscriptum, vt incrementum puritatis, aut ponderis, sibi vsurpet, credo in eandem pœnam incidere: quia verè falsam, adulterinamque, cudit monetam, eam contra præscriptum principis ita cudens. Quare, non solùm puniri hodie potest pœna antiquiori legis Iuliæ de residuis, de qua in materia de furto est dictum, sed etiam pœna posterius statuta. l. 2. C. de falsa moneta. Vtraque tamen simul puniri non potest.**

Lex. 5. titu. 17. lib. 8. nouæ collect. sic habet: Qualquier, que fabricare falsamoneda, o la mandao acõseja fazer, porque es aleue pierda la mitad de sus bienes para nuestra camara. Credo tamen ob hanc legem, qui in crimen explicatum inciderit, non euadet integram pœnam legis. 2. de fals. mon. Præsertim cùm hodie. l. 67. titu. 21. lib. 5. nouæ collect. pœna mortis, & confiscationis omnium bonorum, statuta sit ei, qui monetas sine Regis autoritate cusserit. Crimen explicatum inter crimina læsæ magestatis computatur. *lege. 2. Cod. de falsa mone. & l. 1. titu. 2. part. 7. & affirmant Couar. n. 4. citato. §. qui verò, & Ant. Gom. n. 7. citato, dictumque est Disput. 657. §. quartum-decimum. In hoc crimine, & in crimine eius, qui comprehensum ob hoc crimen de carcere extraxit, (qui mortis pœnam eo ipso incurrit) appellatio non admittitur. Ita habetur. l. 1. C. de fals. mone. juncta. l. 2. ibi. ilico, & affirmat. Ant. Gom. l. 83. citata. n. 14.*

In idem crimen, in eandemque pœnam con [sect. 2] fiscationis bonorum, & vt exurantur, incurrunt socii cudentium falsam monetam, auxilium, cõfilium, aut fauorem, scienter eis dantes, aut sciēter eis concedentes domum, aut prædium, in quo illam cudant. *Ita habetur expressè. l. 9. titu. 7. part. 7. & affirmat. Ant. Gom. n. 3. citato. consentitque ius commune. l. 1. iuncta. l. 2. C. de fals. monet.* Lege onim prima eadem pœna puniendi decernuntur, qui prædictis modis socii sunt cudētium falsam monetam, qua falsam monetam cudentes puniuntur: vnde, cùm postea. l. 2. sancitum sit, vt cudentibus falsam monetam confiscentur omnia bona, & insuper exurantur: sanè eadem pœna statuta censetur cooperantibus, vt falsa moneta cudatur.

Dominus domus, in qua falsa moneta cuditur, [sect. 3] etiam si ignoret in ea cudi, amittit domum fisco; quia punitur negligentia id sciendi ac detegēdi. Excipitur, nisi tam longè fuerit absens, vt scire id non potuerit, aut nisi continuò, ac id sciuerit, illud detexerit, antequam ab alio sit denunciātū: in his enim duobus euentibus non amittit domum fisco. Item excipitur, nisi domus sit alicuius viduæ, aut pupilli: vidua quippe, si ignorauit in sua

domo eam monetam cudi, esto absens ab eo loco non fuerit, domum suam non amittit fisco: secus verò si id sciuit, neque detexit antequam ab alio id denunciaretur. Pupillus item, etiam si sciat in ea cudi falsam monetam, non amittit suam domum fisco. Tator verò illius, nisi sit longè absens loco ubi est ea domus, esto rem ignoret, punitur ut soluat fisco, quantum ea domus aestimabitur. Si tamen continuò, ac rem sciuerit, id detexerit, antequam ibi alio crimen denunciatur, euadit eam pœnam. Impubes, esto cooperetur ad id crimen, si tamen proximus non sit pubertati, quia non excedit decem annos cum dimidio, nullam incurrit pœnam. *Hæc habentur. l. 1. C. de fals. monet. & l. ult. titu. 7. part. 7.* atque, cum communi doctorum sententia, affirmat. *Greg. Lopez. ibi, Ant. Gom. n. 3. citato, & Couar. C. ult. citato. n. 3.*

Quò eam falsam monetam cum dicit, quæ non ex [sect. 4] penditur in prouincia principis, in qua cuditur, quia ibi in commerciis non admittitur, ut si in Gallia Hispaniarum cuneis monetam æream cudat, quæ ibi non valet, ut eam transportet in Hispanias, deprehensus in eo scelere in Gallia, non punietur pœna ordinaria cudentium falsam monetam, sed extraordinaria: secus autem in Hispaniis, si in eis comprehendatur eam asportando ac insumendo. *Ita Couar. n. 4. citato cum aliis, quos refert.*

Quando aliquis falsam monetam cudit in loco [sect. 5] eo recognoscente superiorem, in quo tamen præscriptione immemorabili, aut principis supremi priuilegio, ius est cudendi monetam auctoritate domini eius loci, aut eius communis, tunc communis doctorum sententia, quam refert Couar. n. 4. citato, affirmat, ita cudentem falsam monetam in eo loco, incurrere quidem pœnam capitalem ob id crimen in eo loco patratum, eam tamen esse ordinariam deportationis pro crimine falsi, quæ inter capitales pœnas connumeratur. Atque de ea pœna intelligunt legem. *l. 1. C. de fals. monet.* Rectè verò Couar. ibi subiungit, in lege illa non esse sermonem de crimine patrato in tali loco, sed de crimine patrato aduersus principem, aut rempublicam, non recognoscentem superiorem. Quòd si in loco recognoscente superiorem sit tase ius cudendi monetam propria auctoritate domini, aut communis, eius loci, dicerem, si in eo sit statutum, decernens pœnam cudenti falsam monetam in eo loco, tali statuto esse standum, aut consuetudini eius loci puniendi tale delictum.

Qui falsam monetam cudere est aggressus, si, [sect. 6] pœnitentia ductus, destiterit antequam eam formauerit, cuneumve ei adhibuerit, ab soluitur, hoc est, deprehensus non punitur. *l. qui falsam. ff. ad leg. Cor. de falsis, & affirmat Couar. in Clem. si furios. part. 2. in initio. n. 6.* Secus autem, si deprehendatur id facto aggrediens, aut aggressus, neque constet illum pœnitentia destitisse: tunc enim punietur. Vtrum autem puniendus sit tunc tota ordinaria pœna, si nullas pecunias adhuc perfectè formauerat. Fortasse pars affirmans est vera, & saltem puniendus est pœna extraordinaria iudicis arbitrio imponenda. *Lege Couar. n. 6. citato.*

Accusans aliquem de crimine falsæ monetæ, [sect. 7] esto id non probet, non tenetur de calūnia. *Ita habetur. l. 1. C. de fals. monet.* iuncta glossa ibi, & affirmant *Pan. c. quando de iurerur. n. 4. & alii.* Item, qui detegit cudentem falsam monetam, premio debet per iudicem affici. *Ita habetur. l. 2. C. eod. tit.*

Qui monetam tondit, (*cercenar* nostri dicunt) [sect. 8] radit, (*limar* à nostris appellatur, & sub nomine de *cercenar* comprehenditur, est enim *cercenar* detrahere de pondere iusto, quacunque ratione, postquam monetæ auctoritate publica factæ sunt) aut tingit, auro scilicet, ut aurea appareat, cum sit inferioris metalli: qui, inquam, aliquid horum efficit, si homo liber sit, de iure communi bestiis subicitur, si verò sit mancipium, ultimo supplicio afficitur. *Ita habetur. l. quicunque. ff. ad leg. Cor. de fals. & affirmat communis doctorum sententia, quam referunt ac sequuntur Panor. n. 4. citato, Ant. Gom. l. 83. tauri. n. 4. Couar. c. ult. citato. n.*

5. *Greg. Lopez. l. 9. citata verbo cercenaren, & verb. tingeren, & Iul. Clar. §. falsum citato. n. 47.* Quo loco obserua, qui ita fundunt monetas aureas, vt interiùs habeant vel argentum, aut impurius aurum, & in exteriori parte habeant purissimum aurum, vt aliquando audiui deprehensum fuisse in Lusitania in confictis quibusdam ducatis *de à diez*, quos ibi *portugueses* vocant, hos, cùm falsas cudant monetas, in cidere in pœnam legis. 2. C. de fals. mon. Obseruat tamen Couar. pœnam legis quicunque relatæ, solùm habere locum in tondente, aut radente, monetas aureas, vel tingente auro monetas metalli inferioris, vt appareant aureæ: quoniam de his tantum monetis sermo est. l. quicunque, vt patet legem illam intuēti: qui verò tondent, aut radunt, monetas alias, vel illas aliter tingunt, puniuntur de iure communi, vel pœna falsi ordinaria, vel arbitrio iudicis pro qualitate delicti. *Lex huius Regni. 9. titu. 7. part. 7. de tondente*, vel radente, aut etiam tingente quouis modo, quascunque monetas, loquitur, & statuit, eum puniendum pœna Regis arbitrio imponenda, vt patet eam legem intuenti, affirmâtque *Greg. Lopez ibi, & Couar. vbi suprâ. Hodie verò. l. 67. titu. 21. lib. 5. nouæ collect. pœna mortis, & confiscationis omnium bonorum, statuta est ei, que cercenare las monedas deste Reyno, & cōsentiūt. Greg. Lop. l. 9. citata, & Ant Go. n. 4. citato.*

Qui, sciens, falsam expendit monetam, si illa [sect. 9] plumbea sit, aut stannea, incidit in pœnam ordinariam legis Corneliæ de falsis, quæ habetur. l. 1. §. vlt. eius tituli, vt habetur apertè. l. lege Cornelia. 1. ff. eod. titu. Si autem sit alterius metalli, punitur mitiori pœna extraordinaria iudicis arbitrio imponenda, vt ex eodem textu, argumento à contrario sensu, colligit, ac affirmat ibi Bart. & affirmant plerique alii, quos referunt ac sequuntur *Panor. c. quanto de iureiur, n. 5. Couar. n. 4. citato. §. sed si quis, Ant. Gom. vbi suprâ. n. 5. & Iul. Clar. §. falsum citato. n. vlt.* Referunt tamen Salycetum & Hippol. affirmare, pœna ordinaria vniuersim puniri, qui quancunque monetam falsam scienter expendunt, esseque id receptum in praxi. Notant verò Couar. & Ant. Gō. si is, qui falsam expendit monetam, indicauerit, à quo illam acceperit, præsumi ignoranter eam expendisse, argumento. l. maiorem. C. ad leg. Cor. de falsis, excusarique proinde à pœna, nisi aliunde constet, scientem eam esse falsam, illam expendisse: fi verò non indicauerit, à quo illam acceperit, præsumi scienter illam expendisse, ac proinde puniri ea pœna. Hodie verò in hoc Regno. l. 64. titu. 21. lib. 5. nouæ collect. sic de hac re sancitum est: *Porque es de creer, q̃ no auria falsadores de moneda, si no hallaßen personas q̃ gelas recibiesen, y distribuiesen engañosamente entre las personas, quo no la conocian, porende ordenamos y mandamos, que ningun cambiador, ni otra persona, no reciba ni tenga en su casa, ni en su cambio, ni en su tienda, ni en su trato, moneda de plata, ni de oro, ni de vellon, con los cuños de suso nõbrados, que no sea labrada en qualquier de las dichas nuestras siete casas, donde agora mãdamoslabrar, o de la que hasta aqui sea labrada en ellas, ni monedas est rangeras de falsa ley, ni la dē en pago, ni en cãbio, ni en otra manera alguna, so pena, que qualquier q̃ lo contrario hiziere, sea desterrado de nuestros reynos por quatro años, y de mas pierda la mitad de sus bienes. Ysea la mit ad para la nuestra camara, y de la otra mitad sea la mitad para el acusador, y la otra mitad para el juez rexecutor que lo sentēciare y executare. Y mandamos à todos y à qualesquier cãbiadores, que cada y quando que qualquier persona les diere alguna moneda falsa, quier sea de los nuestros reynos, o de fuera dellos, que luego antes que salga de su poder la corte por medio, y la entregue à las justicias, donde esto acaeciēre, para que luego la quemēpublicamēte. Pero, si antes que fuere tomado con la tal moneda, este q; la trae, o la tiene, descubriere à lajusticia y regimiēto donde le fuere dada, y nombrare la persona que gela dio, y fuere la tal persona de q̃ verdaderamente se puede presumir que no conoce la dicha moneda, que en qualquier de estos casos sea quito de la pena de suso contenida: cō tâto, que luego en cōtinēte*

que lo supiere, entregue la tal moneda falsa à las justicias y oficiales del lugar donde fuere ballada, paraque la quemen luego publicamente, y dende en adelante no la traten.

Qui falsam monetam cudit, lethaliter peccat, [sect. 10] etiam si iusti ponderis ac materiæ eam cudat. Quoniã in re graui iuri principis supremi præiudicat. Et quoniam, si princeps inde aliquod emolumentum iustum erat percepturus, in rei publicæ subsidiũ, atque ad sumptus publicos, in iustè eum illo defraudat. Vnde tenetur id illi in cõsciẽtię foro restituere: eo quòd iniustè eũ illo priuauerit. Quòd si inde etiam priuatis detrimentum obueniatur, vt quia pecunia illa, tanquam verè falsa, quia talis ex parte formæ est, interdicitur, atque vel minoris valoris ea de causa constituitur, vel solũ retinet valorem metalli, quo constat, vtique id etiam detrimentum tenetur priuatis restituere in conscientiæ & in exteriori foro.

Quando autem moneta non constat puritate [sect. 11] metalli, quo constare debet, aut non est tanti põderis, quanti esse debet, vel quia à principio ita fuit cussa, vel quia postea de pondere est detractum tonsione, aut abrasione, tunc restituendum insuper est cõmunitati reipublicæ, quoad particulares, qui id damnum sunt passi, totum detrimentum inde eis sequutum: si constare potest, qui in particulari id dānum sint passi, eis est restituendum, singulis quantum vnusquisque eorum in particulari est passus. Si verò constare nō potest, insumendum est tantundem in re quæ credatur utilis eisdem particularibus futura, eosque contentos fore, vt, quando res singulis in particulari restitui non potest, pro quantitate dāni, quod vnusquisque accepit, eo modo resti- [[105]] tuatur. Quòd si nihil tale occurrat, restituẽdum erit id totum pauperibus, aut insumendum erit in aliquo opere pio pro animabus eorum, quibus id debetur. Quod attinet ad eos, qui eiusmodi monetas [sect. 12] defectuosas expenderunt, postquam eis traditæ ab illis sunt, qui id crimen circa illas cõmiserũt, distinguendum est. Quoniam, si bona fide illas acceperunt, & bona fide easdem etiam expenderunt, neque ipsis constat, qui damnum inde sint passi, neque, facta morali diligentia, id ipsis potest constare, quia pro valore, in quo eas acceperunt, easdem distraxerunt, vel soluendo debita, vel aliquid inde emendo, vel aliqua alia ratione, tunc credo ad nullam restitutionem eos teneri: quia in nullo sunt ex eis facti locupletiores, & si quid contractibus lucrati sunt, id fructus est suæ industriæ ac negotiationis, non verò talis pecuniæ, nec tenentur ratione iniustę acceptionis, aut alienationis talium monetarum, excusante eos bona fide, probabiliq̃ue sua ignorantia. Si verò eis constat, aut constare possit, quis inde damnum acceperit, in hoc sensu tenentur id illis resarcire, quòd, qui proximè eas pecunias illis tradidit, tenetur illis restituere, quantum minus illæ valebant, eis verò tenetur proximior immediatus, & ita consequenter, donec ad ipsum deueniatur, ipsi verò tenetur, qui ei immediatè illas dedit. Si verò mala fide eas consumpsit, tenetur omnino restituere, quod minus valebant, ei quidem, qui vltimus reperitur in damno, si constat quis ille sit, alioquin pauperibus, pro anima illius: eo quòd ipse, ita scienter illas alienando, causa, aut concausa, iniusta fuit talis dāni: ipsi verò tenebitur restituere, qui proximè eas pecunias ipsi tradidit, si in eo toto valore eas ipsi tradidit, Lege quoad hæc *Nauar. in Manu. c. 17. an. 167. & Syluest. verb. falsarius à. q. 6.*

De damno infecto, quod iura vocant, hoc est, quod nondum est factum, sed pendet in futurum. Disp. 703.

SVMMARIVM.

1 . Damnum infectum quid.

2 . Damnum si sequatur ex ruina domus, aut alterius rei, neque, qui id est passus in re sua, caueri sibi de eo petierat, dominus domus, quæ corruit, ad nihil ei tenetur, si illi relinquat rudera, quæ corruerunt ac damnum id de derunt, neque tenetur ea extrahere. Quòd si extrahere illa velit, tenetur omnia omnino extrahere, & soluere damnum datum, & cauere de dando ex illorum extractione.

3 . Damnum qui ita est passus, si negligens non fuit in petendo, vt sibi caueretur, sed legitimo impedimēto absentia rei publicæ causa id non petiit, aut petiuit, & antequam intimaretur parti, domus corruit, tunc tenetur dominus domus, quæ corruit, vel extrahere rudera omnia, & soluere damnum datum, vel relinquere solum domus, quæ corruit, & partes illius, quæ non corruerunt, ei, qui id damnum est passus.

4 . Damnum ex ruina quando alicui homini obuenire potest, iudex ex officio tenetur præcipere dirui id, vnde id damnum imminet, aut ita fulciri, vt id periculum cefset.

5 . Fluminis vi si delata fuerit planta in prædium alienum, & ibi coaluerit, aut delatum fuerit crustū terræ, cedit domino prædii, nec extrahi potest. Solui tamen debet valor plantæ, quem habebat ibi delata antequam coaluisset, nisi suo ingressu tantundēdāni dedisset. Reliqua delat a extrahi possūt, & quod interdictum ad id competat; modò soluatur damnum eis datum suo ingressu, & extractione; alioquin relinqui debeat domino prædii.

6 . Damnum infectum vt sit soluendum, si sequatur, peti debet coram iudice pro tribunali sedenti vt de eo caueatur, nec sufficit peti extra iudicium. Si tamen dominus rei, vnde timetur, caueat extra iudicium stipulatione, aut in hoc regno nuda promissione, soluendum est. Et obligatio tunc est in foro conscientie, esto stipulatio aut promissio probari non possint.

7 . Damni infecti qui sibi caueri petit, toties de calūnia iurare debet, quoties id petit. Et quid de procuratore, quando per procuratorem id petit.

8 . Damni infecti si procurator alicuius, ei, cuius est procurator, caueri petat, cauendum ei est, modò procurator de rato caueat. Et quid protestari is debeat, qui ita cauet. Quod si procuratori tunc non caueatur, mitti debet in possessionem rei, vnde damnum timetur, sicut mitti deberet is, cuius est procurator.

9 . Damni infecti intrā quantum tempus, & vsque ad quem terminum caueri debeat, Fudex, causa cognita, statuere debet. Et potest, si res distent, delegare id iudici inferiori. Et quid si cautio præstita sit nullo ter mino præfixo.

10 . Damnum si timetur ex opere facto in flumine publico, aut in ripa fluminis publica, cautio in decēnium præstari debet: alioquin arbitrio iudicis.

11 . Fluminum publicorum, viarum, ac littorum, cōmunis est usus, ipsa tamen loca publica sunt, & nō priuata. Si tamen ad littora publicorum fluuiorū prædia priuatorum terminentur,

via inter prœdia & ea littora non remanente, ea littora quo ad dominium ad eos pertinent, quorum sunt ea prœdia.

12 . In loco publico auctoritate publica licitum est ædificare priuatum ædificium, aliquidq; destruere, dummodo non cedat in aliorum præiudicium ac damnum. Solum verò publicum manet, nisi concessum sit, ut sit etiam priuatum, gratis, aut pro emolumento aliquo.

13 . Damnum si timeatur ex ædificio priuato facto in loco publico, cauendum est tantum ædificio, nō verò de solo, esto ex solo damnum etiam immineat: cum tamen si solum esset priuatum, de eo etiam esset cauendum. Vnde si solum concessum esset ut esset priuatum gratis, aut pro emolumento aliquo, de illo etiam esset cauendum.

14 . Damni infecti ex ædificio publico, aut ex loco publico, non cauetur. Recurritur tamen ad principem, aut ad potestatem aliam publicam, ut periculo sufficienter subueniat, aut ut id destruat.

15 . Dāni infecti cauet, qui vias publicas priuata auctoritate in suum commodum munit: secus si auctoritate publica.

16 . Damni infecti qui cauet nomine proprio, non dat fideiussores: qui verò nomine alieno, quòd alius, ad quem id spectat, soluet dāna, si euenerint, fideiussores dat, quòd ille soluet.

17 . Damnum ex re aliqua si quis sibi cauere petat ab eo, quem credit illius dominum, si alius dicat, se esse dominum, tunc qui cauere petit, eligere debet, quem eorum maluerit, ut is solus caueat, sed sine fide iussoribus.

[[106]] 18 . Damni infecti si cauere petatur ex re, circa quam duo contendunt, is cauere debet, qui eam possidet, alioquin is, qui sibi cauere petit, in possessione mittitur ex primo & secundo decreto. Quod si, qui in possessione erat, vincatur, & aliquod damnum sequutum ex re illa soluat, qui vicit, id ei resarcit.

19 . Damnum si immineat dominoprædii ex ædificio ab aliquo in eo ratione seruitutis debite facto, qui id ædificium fecit, cauere solum debet, non verò fideiussores præstare.

20 . Damni infecti si cauere petatur ex re pertinente ad vnum quo ad proprietatem, & ad alium quo ad dominium utile, vsum fructum, seruitutem, aut aliud ius in re, satis est si proprietarius caueat sine fidei iussoribus: quo dato, cæteri cauere ei tenentur sine fidei iussoribus pro rata dominii utilis, aut iuris, quod in re habent. Cæteri si sine proprietario caueant, fideiussores præstare tenentur. Nullo cauere volente in possessionem ex primo & secundo decreto is qui mittitur, cauere sibi petit. Nullus verò suum ius, aut dominium partiale amittit, nisi cauere requisitus, ipse non caueat. Et quando is, cuius loco ab alio est cautum, nisi caueat ei, qui integre cauit, aui soluat eipartem dāni, quod pro eo soluit, amittat illi partem dominii, aut ius, quod in ea re habet.

21 . Damni infecti non tenentur præstare fideiussores, sed satis est si promittendo caueat, qui rem possidet, quam bonafide a non domino comparauit.

22 . Damni infecti si usque ad certum diem sit cautum, & ante eum diem corruiat id, unde damnum timebatur, & quassauit aliquid, quod post eum diem decedit, soluendum est id damnum.

23 Damni infecti vicissim cauere debent, qui habēt res, unde vicissim damnum timetur.

24 . Damni infecti cautio locum non habet ex solo suapte natura ruinoso. Si verò timeatur ex ædificio in eo superposito, locum cautio habet.

25 . Damni infecti cauere debet, etiam qui habet aliquid solidum, quando ex remotiori ædificio imminet damnum quod id solidum sustinere & impedire non poterit: domino tamen illius ab alio est cauendum tum de suo damno, tum etiam de cautione, quam ipse præstat.

26 . Si eiusdem ædificii vnus habeat vsumfructum. & alter proprietatem, & id ædificium minetur ruinam, neuter cogere potest alterum cauere de dāno, quod in eodem ædificio sibi imminet ex tali ruina. Et ratio cur in eo euentu neuter alteri cauere teneatur.

27 . Damni infecti ex eodem ædificio cauere tenetur proprietarius usufructuario habenti proximum aliud prædium, quando ex solo imminet periculū ei prædio. Et fructuarius proprietario habenti proximum prædium, quando ex aliquo, quod de nouo ædificet in ædificio, in quo habet vsumfructum, imminet periculum proximo prædio. Aliter vnus alteri cauere non tenetur.

28 . Damni infecti neuter alteri cauet, neque nocet cautio, si sit data, si habeant dominium pro indii. iso eiusdem ædificii qui minatur ruinam, esto alter eorum proximum habeat aliud prædium, quod inde etiam periclitetur. Et cur id ita habeat.

29 . Dāni infecti si de pariete caueat vnus alteri duorum, qui illum habent pro indiuiso, non tenetur ex ea cautione, nisi ipse solus onerauerit eum par etem, idque in causa fuerit damni.

30 . Refectione si indigeat res ad multos attiuēs, quādo idonior expensis omnibus, & quando omnes simul sint admittendi.

31 . Damni infecti si quis alteri cauit circa demolitionem parietis vtrique communis, quando ad dānum sequutum teneatur demoliens, quando non item. Et demolitionis expensæ num ab utroque soluendæ.

32 . Damni infecti non valet cautio, neque soluere tenentur damnum vnus alteri, quando cōuenerūt, vt communis paries destrueretur, & reædificaretur, etiam si habeant proxima prædia, quibus id noceat. Cauere tamen tenentur aliis vicinis. Si non errore iuris sed ex spontaneo pacto, mutuò sibi caueant de damno infecto, tunc de eo tenentur.

33 . Seruitus ne altiùs ædificetur, si habeam, & tu altiùs tollas, ego destrui petam, & tu dicas, ex meo consensu id fecisse, & ego negem, destruitur, nisi intra tempus tibi præscriptum probes intentum.

34 . Damni infecti cautio vni præstita quo ad vnā suam domum ruinosæ vicinam, non se extendit ad aliam. si illam de nouo acquirat prope eandem domum ruinosam. Neque cautio præstita ei circæ vnā partem domus, se extendit ad partem eiusdem domus, si ei adiudicetur.

35 . Damni infecti cauere debet, qui ædificat, si inde damnum imminet, esto qui eam cautionem petit, æliunde agat ad impediendum id ædificium.

36 . Damni infecti cautionem petere potest, quicumque ius aliquod habet in re, cui damnum timetur, quo ad id præcisè damni, quod sibi potest prouenire.

37 . Damni infecti cauendo multis, qui ius habent in re, cui damnum timetur, non plus illis cauere debet, quā vni soli, qui integrum dominium rei illius haberet, quia singulis cauere debet quo ad suum partiale damnum.

38 . Damni infecti duobus habentibus eandem domū pro indiuiso, singulis cauetur de dimidio damni: habentes item duo eandem domum ruinosam pro indiuiso singuli cauent de dimidio damni, quod inde obuenerit.

39 . Damni infecti si seruius, communis duobus, stipuletur quoad domum vtrique communem, censetur pro vnoquoque eorum stipulatus quo ad partem, quam in ea domo habet, esto maiorem aut minorem partem proportionalem dominii in eo seruo habeat.

40 . Damni infecti cauendum non est ei, de quo cōstat à non domino comparasse id, cui damnum imminet, neque cautio bona fide ei antea præstita est valida. Cui verè comparauit bona fide aliquid, vnde damnum timetur, cauere debet, aut relinquere eam rem.

41 . Damni infecti si duobus, habentibus commune id cui damnum timetur, cautum sit, si postea vnus comparet partem alterius, transit in illum cautio eius partis præstita, si cautum fuerat ei & successoribus: secus si successores non fuerant expressi.

42 . Damni infecti cautionem petere ad venditorēne, an ad emptorem rei, cui dānum imminet, interim dum res emptori non est tradita, spectet, & alia circa id.

43 . Damnum si inquilino immineat ex domo cōducta, aut ex alia locatoris, licet cautionem de dāno infecto petere non possit, quo iure, & quando, agere poterit aduersus locatorem. Et quando deserere possit domū. Si alteri domui inquilini inde damnum immineat, cautionem damni infecti petere poterit. Si à re aliena damnum immineat doinui conductæ, locater & inquilinus cautio- [[107]]nem damni infecti petere possunt.

44 . Damni imminentis domui alicui qui cauit, tenetur de damno sequuto rebus mobilibus, aut se mouentibus, in ea repertis, modò ad certos quosdā pertineant.

45 . Damni infecti non cauetur ei qui illicitè ædificauit iuxta aliud ædificium, & qui illicitè est passus ædificari ædificium iuxta suum.

46 . Damni infecti qui ex vna causa cauit, si ex alia dānum proueniat, tunc tenetur ille sarcire damnum.

47 . Damni infecti qui cauit ex opere, quod facere intendebat, si ipse id non fecit, nec mandauit, nec ratum habuit, nec factum sit ab eo, quem ipse prohibere potuerit, non tenetur de dāno inde sequuto.

48 . Dāni infecti qui cauit ob aliquod suum prædium, si aliquid in eo efficiat vtendo iure suo, vnde detrimentum vicino prædio proueniat, non tenetur de eo damno.

49 . Damni infecti qui cauit ob vitium rei suæ, si sequatur damnum, non ex eo vitio, sed casu fortuito, non tenetur de eo damno, nisi ob id vitium ex eo casu fortuito sit sequutum.

50 . Damnum sequutum, de quo fuit cautum, quàm moderatè æstimandum, vt soluat.

51 . Damni infecti si iudex cauere non præcepit, requisitus dum pro tribunali sederet, aut postea requisitus non iussit mitti in possessionem ex primo & secundo decreto, & reliqua necessaria præstari, actio in factum ad interesse competit aduersus illum, quæ ad hæredes & aduersus hæredes transit.

52 . Damni infecti si cauere coram iudice sit petitum, & dum iudex deliberat, damnum sequatur, competit actio in factum aduersus dominum rei, vnde damnum prouenit, vt vel illud resarciat, vel rem relinquat damnum ex ea passo.

53 . *Damnum timens, postulat decretum iudicis, ut de damno caueatur, aut relinquatur res, unde timetur, ei, qui illud timet. Id decretum denunciatur domino rei, unde timetur. Si contumax sit, neutrum præstare, alter mittitur in possessionem rei illius primò ex primo decreto, & deinde, perseuerante contumacia, ex secundo. Atque ex tunc ea res efficitur omnino illius, neque alteri permittitur cauere de damno.*

54 . *Damni infecti denunciatio ut caueat, qualis sufficit, & quot modis fieri possit.*

55 . *Damni infecti denunciatione facta ut caueatur intra certum terminum, nec præstita cautione, qui timet damnum, mittitur a iudice in possessionem rei illius ex primo decreto.*

56 . *Damnum timens, mitti iussus in possessionem ex primo decreto, si negligens non fuit, & corrumpit id, unde damnum timebatur, mittitur in possessionem soli, & remanentium, dum non soluitur damnum acceptum, & expensæ, & non cauetur de damno, si quod sequetur.*

57 . *Damnum timens, quando mittitur ex primo decreto in possessionem domus unde id timet, etiam in soli possessionem mitti debet, esto ea domus superficiaria sit. Et quando mitti debeat etiam in possessionem partium, quæ non minantur ruinam, quando non item.*

58 . *Damnum si ex arboribus & aggeribus timeatur, in quantam partem eius fundi mitti is debeat in possessionem, cui non cauetur.*

59 . *Damni si unus caueat, & alter non, duorum, qui dominium eiusdem rei habet, is, cui non cauetur, mitti in possessionem debet partis eius dumtaxat, qui non cauet.*

60 . *Damni infecti si multi domini diuersorum prædiorum, aut unius prædii, cauere sibi pastulent ratione alterius prædii, siue simul, siue unus post alium, id petant, omnes simul & æqualiter mitti ex primo decreto debent in possessionem eius prædii. Si tamen prius missus, posterius petenti caueat, is in possessionem non mittitur.*

61 . *Damni infecti quia non est cautum, eo ipso quòd quis mittitur in possessionem rei alicuius ex primo decreto, incipit illa habere rationem quasi pignoris prætorii, ut distinguitur à iudiciali, & neque ex lata culpa tenetur, si illam non reficiat, nisi fortè quando dominus est absens.*

62 . *Damni infecti quia non est cautum, missus in possessionem ex primo decreto, non possidet eam rem, sed solum legitime illam tenet, ac possessio perseuerat apud illum alium: unde ille alius potest eam præscribere, & non possidens ex primo decreto.*

63 . *Damni infecti quia non est cautum missus in possessionem, si animo illam non deserendi recedat, eam non amittit: secus si animo illam deserendi: quod non præsumitur.*

64 . *Damni infecti qui cauit, si post cautionem id prædium alienauit, & ex illo sequutum est damnum, qui cauit tenetur ad illud. Nouus verò successor non, nisi ab illo etiam petita & præstita fuerit cautio. Quòd si prædium fuisset alienatum postquam alius fuerat in possessione illius ex primo decreto, retinet possessionem eius, quòd ex eo prædio remanet, nisi exoluantur damnum acceptum & expensæ, & ei caueatur de damno futuro. Si verò ulterius perseueret contumacia, mittitur ex secundo decreto, comparatque possessionem ciuilem & naturalem, ac dominium, nisi dominium ad alium quartum pertineret.*

65 . *Damni infecti cautio si offeratur misso in possessionem ex primo decreto, tenetur eam admittere, modo ei soluantur damnum sequutum, & expensæ utiles factæ, & caueatur de damno futuro.*

66 . Damni infecti ob non præstitam cautionem iusso mitti in possessione ex primo decreto, si resistatur, quæ actiones ad interesse ei competant. Illæ cessant, si illi caueatur, aut admittatur in possessionem ex primo decreto. Competit verò actio perpetua trāsiens ad successores in prædio, cui est cauendum, & aduersus successores in prædio, ex quo est cauendū.

67 . Damni infecti ob non præstitam cautionem inſo mitti in possessionem ex primo decreto, si resistat tertius aliquis, quando aduersus illum & aduersus possessionem prædii competat actio, & quando aduersus solum tertium resistantem. Qui si mancipium sit, quando dominus noxæ teneatur illud tradere.

68 . Damni infecti ob non præstitam cautionem missus in possessionem ex primo decreto, à quo iudice, & quando, mitti debeat ex secundo decreto. Minori, & absenti reipublicæ causa, restitutio in integrum aduersus eam missionem conceditur.

69 . Damni infecti ob non præstitam cautionem missus in possessionem ex secundo decreto, comparat eo ipso possessionem ciuilem & naturalem, præscribereq; cum titulo incipit rem illam si erat alicuius tertii. Si verò erat proximè illam possidentis, cōparat etiam dominium. Neque post secundum decretum locus est cautioni: nisi locus sit beneficio restitutionis in integrum.

70 . Damni infecti ob non præstitam cautionem missus in possessionem ex secundo decreto, si inde expellatur, aut regrediens ad eam rem non admit-[[108]]tatur, quæ actiones aduersus repugnantem competant.

71 . Damni infecti ob non præstitam cautionem si multi simul, aut successiue vnus post alium, petant mitti in possessionem ex secundo decreto, mittendi sunt, non æqualiter, sed iuxta proportionem damni, quod quisque timet ex ea re, ad damnum, quod alii timent. Si vnus eorum fecerat in ea re expensas, alii in eadem proportionem contribuere illi debent, quod expendit.

72 . Damni infecti ob non præstitam cautionem si aliqui missi sunt in possessionem rei alicuius ex secūdo decreto, & alius superueniat, qui petat sibi ex eadem re cauere, ad illos spectat ei cauere. Quòd si contumaces sint, & hic mittatur in possessionem rei illius ex primo & ex secundo decreto, hic solus comparat possessionem & dominium illius, & illi alii illud amittunt.

73 . Damni infecti ob non præstitam cautionem si quis missus sit in possessionem alicuius prædii ex secundo decreto, & qui illud ea ratione amisit, habeat aliud prædium vicinum, ratione cuius petat sibi cauere, non tenetur præstare ei cautionem.

74 . Damni infecti ob non præstitam cautionem à creditore ex re, quam in pignus habebat, si quis missus sit in illius possessionem ex secundo decreto, præfertur ei creditori, qui eo ipso amittit ius, quod in ea re habebat. Quando autem creditor illam habebat hypothecatam, neque ab illo petita fuit cautio, sed a domino rei, præfertur creditor, quoad hypothecariam actionem, modò soluat expensas in ea re factas à misso in possessionem illius ex secundo decreto. Quas tamen creditor ille soluere non teneretur ei, qui titulo emptionis dominium & possessionem eius rei eſset consequutus. Et quæ sit diuersitatis ratio.

QVod propositum est, erit consequenter hoc [sect. 1] loco disputandum. Atq; lex. 2. ff. de damno infecto, ferè modo in titulo proposito exponit damnum infectum, dum sic habet: *Damnum infectum est damnum nondum factum, quod futurū veremur.* Consentit. l. prætor ait. §. hoc edictum. ff. eod. titu. vbi habetur, quòd cum sint aliæ actiones ob damnum, vt Aquilia,

& noxales, solùm dētur pro damno iam dato, actio tamen ex hoc edicto solùm competit pro damno nondum sequuto, sed pendentī. In re autem proposita dānum infectum dicitur, quod imminet domui vnius, ac rebus in ea contentis, vel plantis, aut cuicunque alteri ædificio, puta parieri, aquæducto, aggeri, aut alii simili, & denique cuicunque prædio, ex domo, aut ex pariete, ruinosis alterius, quacunque de causa ruinam minentur, aut ex quocunque opere alterius, vt ex machina, vel ex quocunque alio opificio, siue sint in prædio vrbano, siue in rustico, siue in loco priuato, siue in publico, (modò tamen ædificium non sit publicum, iuxta ea quæ inferiùs dicentur) aut etiam ex arboribus alterius. *Ita habetur. l. eorum. §. siue ædificium. l. fluminum. §. Item apud Viuium. ff. de damno infecto*, aliis iuribus citandis.

Quando damnum, quod timebatur, timerive [sect. 2] poterat, sequitur ex ruina domus alterius, aut ex re alia ex commemoratis, neque is, cui id damnum sequitur, antequam eueniret, sibi petierat cauere de eo damno, tunc dominus rei, vnde id damnum euenit, ad nihil ei tenetur, neque vlla aduersus illum conceditur ei actio, qui tale dānum est passus: quin neque rudera (hoc est, materiam ruinæ, sic dictam à ruina, seu à ruendo) ex domo, quæ ita corruit, ac damnum dedit, cogitur ex ea domo, quæ damnum est passa, is tollere, cuius erat domus, quæ corruit; modò tamen omnia habere velit pro derelicto, relinquereque ei, qui damnum est passus, nullam ex eis partem auferendo. *Ita habetur. l. euenit. ff. de dam. infect. c. l. 11. titu. 32. part. 3. Consentit. l. prætor ait. §. hoc dictum vers. cùm enim ff. de dam. infect.* Vbi Vlpianus hanc reddit rationem. Quòd cùm, quando animalia, etiam mancipium, damnum dant sine culpa domini, non teneatur dominus ad tale damnum, modò ea animalia noxæ dare velit, vt scilicet sint eius, qui damnum est passus: ita multo magis, quando res inanimata, vt domus, aut etiam planta, damnum dedit, quia corruit, satis est, si, quod ita corruit ac damnum dedit, relinquatur ei, qui id damnum est passus, nihil illius inde auferendo, vt non teneatur ad damnum inde subsequutū: maximè cùm domus, quæ corruit, quoad id, quod corruit ac damnum dedit, non extet: animalia verò, quæ damnum dederunt, extent. Subiungit verò ex Iuliano Vlpianus eadem. l. prætor ait. §. vnde quæritur. Si dominus domus, quæ corruit, vellet aliquid de rudibus tollere, non aliter esse permittendum, quā si omnia omnino tolleret, etiam inutilia, & insuper per caueret, tum de dāno futuro, si quod sequeretur ex extractione omnium rudum, & insuper de præterito dato ex ruina suæ domus: iudicis tamen officio esse cogendum in eo euentu ad damnum præteritum, & non ex edicto damni infecti, vt notat ibi glossa *Accursij, verb. debere. iuxta. §. hoc edictum citatum*. Addit Vlpianus in fine eius §.

Quando dominus domus, quæ corruit, neque [sect. 3] rudera tollit, neque cauet de damno præterito ac futuro, tunc domino domus, quæ damnum est passa, conceditur interdictum de tollendis rudibus nuncupatum, cuius verba non extant, quo cogitur, vel rudera tollere, vel totas domus, quæ corruerunt, habere pro derelicto. Hoc autem, vt statim. l. quod fortè, & l. hoc amplius, in prin. subiungitur, ac corrigitur, & constat ex doctrina toto hoc. §, tradita, ex l. euenit, & ex l. prætor ait, à vers. cùm enim, sic intelligas. Quòd quando is, cuius domus passa est detrimentum ex ruina alterius, fuit negligens in petenda corā iudice cautione de damno infecto, quia neque à iudice illam petiit antequam domus corrueret, neque fuit absens toto illo tempore rei publicæ causa, tunc, qui damnum est passus, potest cogere dominum ædium, quæ corruerunt, vt vel rudera omnia relinquat, vel (si maluerit) omnino ea tollat, ac resarciat totum damnum datum, & insuper si quod aliud dederit rudera omnia tollendo. Si verò non fuit negligens, quia vel ex iusto impedimento rei publicæ causa eam non petiuit, vel eam petiit à iudice, sed interim dum iudex deliberabat, vel interim dum iudicis decretum deferebatur intimandum domino ruinosæ domus, domus corruit, ac damnum dedit, tunc

cogitur dominus domus ruinosæ vel resarcire totum damnum ex ea ruina & ex rudum extractione sequutum, perinde ac si de dāno infecto cauisset, vel rudera omnia, & ædes, quæ corruerunt, quoad solum, & quoad partes, quæ non corruerunt, habere pro derelicto, ea [[109]] relinquendo ei, qui damnum est passus: vt enim videbimus, dominus rei, vnde damnum timetur, ad alterum duorum sub disiunctione tenetur, nempe, vel ad cauendum de toto damno, quod fuerit ex illa sequutum, vel, si cauere noluerit, ad eam relinquendum ei, qui inde damnū timet, Atque hoc totum est, quod disponitur ac habetur. *l. quod fortè. l. hoc amplius in prin. l. si finita. §. eleganter, & l. cū postulassem in prin. vers. at si. ff. de damn. infect.*

Obserua tamen, si periculum esset opprimen [sect. 4] di aliquem, eumque interficiendi, aut notabile damnum ei inferendi, tunc iudex præcipere tenetur, vt diruatur statim id vnde id dānū imminet, aut ita fulciatur, aut reficiatur, vt cesset tale periculum. *Ita habetur. l. 10. & 12. titu. 32. part. 3. & consentit. l. præses prouinciæ inspectis. ff. de offi. præsid.*

Quod ad ea attinet, quæ vi fluminis, aut etiā [sect. 5] maris, in fundum alienum deferuntur. In primis domino earum rerum, volenti illa inde extrahere ac vendicare, conceditur interdictum, ne vlla vis ei fiat, à domino fundi, neque à quocunque alio. Excipitur, nisi crustum terræ ex fundo aliquo delatum sit in fundum alienum, aut planta adhuc viuens. Quando enim hæc delata sunt, est distinguendum. Quoniam, si coaluerunt, ita vt planta radices egerit in terra aliena, atque adeò transierit ea de causa in dominium eius, cuius est is fundus, aut si crustum terræ alienæ coaluerit, hoc est, vnitum, continuatum, vnumque adhæsione effectum sit cum fundo, in quem fuit delatum, tunc vendicari, extrahi que, non possunt: quoniam eorum dominium adhæsione illa transiit in dominum fundi, in quo ita coaluerunt. Fortasse tamen valor plantæ, quem habebat antequam radices ageret, erit soluendus domino fundi, vnde fuit delata. Dummodo tamen ille soluat, si quod fortè damnum ea planta suo ingressu intulit domino fundi, in quo coaluit. Si verò non coaluerunt, extrahi hæc possunt, perinde ac nauis vi fluminis in fundum alienum delata, & perinde atque alia similiter delata possunt extrahi, competit que eorum dominis interdictum, ne vis eis fiat, neque impedimentum eis apponatur, in ea extractione. Cæterum vel habere tenentur ea pro derelicto, relinquere que illa domino fundi pro damno, quod suo ingressu ei dederunt, quasi noxæ pro eo damno data; vel tenentur soluere damnum totum, quod dederunt, & in super si quod sequutum etiam fuerit ex extractione, & tenentur ea integra extrahere, si ita velit dominus fundi. *Ita habetur. l. hoc amplius. §. de his. §. Alfenus, & §. Neratius. ff. de dam. infect. idque efflagitat natura ipsa rei.*

Iuxta hactenus dicta, & iuxta ea, quæ subji [sect. 6] ciemus, qui damnum infectum modo suprà explicato rationabiliter timet, vt dominus rei, vnde illud timet, ipsi de eo, si sequatur, teneatur, petere debet, antequam sequatur, vt sibi de illo caueat: alioquin de illo regulariter, vt dictum est, non tenebitur. Et quidem, non satis est petere extra iudicium ab eo, ex cuius re damnum timet, vt sibi caueat, vt ille teneatur, nisi coram iudice pro tribunali sedenti sit etiam petatum, vt expressè habetur. *l. cū postulassem. ff. de dam. inf.* Quando enim iudicis officio alicui est subueniendum, vt in re proposita, tunc interpellatio extra iudicium non constituit aliquem in mora, vt ex Bal. & ex aliis, notat ibidem glossa marginalis. Si tamen priuatus ille extra iudicium cū stipulatione promitteret de damno infecto, (& in hoc Regno, etiam sine stipulatione) ita vt in exteriori foro probari id posset, tunc, vi talis stipulationis, aut promissionis, cogeretur in exteriori foro resarcire id damnum, si sequeretur. Et in conscientia foro teneretur illud tunc resarcire, etiamsi stipulatio, aut promissio, verè interposita, probari in exteriori foro non posset.

Qui coram iudice petit, sibi caueri de damno [sect. 7] infecto, iurare tenetur de calumnia, hoc est, sincere eam cautionem petere, quia verè damnum iustè inde timet, neque intendit iniuste vexare eum, à quo eam cautionem petit. *Ita habetur. l. prætor ait, in prin. l. qui bona fide. §. qui damni. ff. de damn. infect.* Qui autem caueri sibi de damno infecto postulauit, & iurauit de calumnia, si tunc ei non fuit cautum, iterumque sibi ab eodem caueri postulet, iterum iurare tenetur de calumnia: quia fieri potest, quòd nunc. calumniam de nouo intentet. l. qui bona fide citata. §. si quis stipulaturus. Quando aliquis, tanquam procurator, petit caueri de damno infecto ei, cui procurator existit, & cuius nomine eam cautionē petit, iurare debet, non calumniæ causa eum, cuius nomine cautionem petit, eam cautionem postulaturum fuisse, si esset præsens: quando autem is, cuius nomine cautionem petit, non posset cogi iurare de calumnia, si præsens esset, vt quia esset parens, vel patronus, tunc neque procurator iurare, modo explicato, teneretur. *Ita habetur. l. bona fide citata. §. si alieno.* Glossa tamen ibi subiungit, fortè hodie correctum esse per. l. 2. §. sin autē. C. de iur. prop. calum. vt procurator iurare de calumnia prædicto modo non possit.

Quando aliquis tãquam procurator alicuius [sect. 8] petit, vt caueatur de damno infecto ei, cuius se dicit procuratorem, caueri debet ab eo, cuius est res, vnde damnum iustè timetur: atque tunc procurator cauere debet de rato, hoc est, quòd is, cuius nomine cautionem petit, ratum habebit esse ei sic eam cautionem præstitam: is verò, qui ita cauet, in cautione addere debebit, se nolle teneri ea cautione, si vel appareat, eum non fuisse procuratorem vel eum, cuius nomine caueri petit, id ratum non habere. Quando autem in euentu explicato, is, cuius est res vnde damnum timetur, & quem cauere requiritur, cauere non vult, procurator mitti debet in possessionem rei vnde damnum timetur, non secus atque is, cuius nomine caueri postulat, mitteretur, iuxta ea quæ dicenda sunt, si ipse esset, qui sibi cauere postuleret, isque, cuius est res, vnde damnum timetur, cauere non vellet. Neque, procuratorem mitti in eo euentu in possessionem eius rei, impediretur ex eo, quòd is, cuius est ea res, opponeret, seu objiceret, eum non esse procuratorem illius, cuius dicit se esse procuratorem. *Ita habetur. l. inter quos. §. alieno. ff. de dam. inf. concinit etiam. l. prætor ait, in prin. ff. eod. titu.*

Iudex, coram quo petitur, vt caueri iubeat de [sect. 9] damno infecto, præscribere debet ei, cuius est res vnde damnum timetur, intra quantum tempus cautionem debeat conficere, & vsque ad quem diē seu terminum cauere debeat: neque enim in infinitū manere debet obligatus, sed vsque ad certū terminū, seu diem, iudicis arbitrio cōstituendū, cognita causa, & inspecta re, vnde damnum time-[[110]]tur, attentisque aliis circumstantiis concurrentibus. *Ita habetur. l. qui bona fide. §. ult. & l. in causæ, iuncta. l. 4. in prin. & §. si intra diem. ff. de dam. inf.* Quòd si res vnde damnum timetur, & res, cui damnum timetur, distent, opusque sit illas videri, vt iudicetur, an verè damnum immineat, & intra quantum tempus caueri oporteat, poterit iudex superior id delegare iudici inferiori eius loci, vt iudicet, an periculum immineat, & intra quantum tempus debeat caueri. l. 4. citata in prin. Quando cautio de damno infecto fuit præstita, atque ex certa scientia, partiumque conuentione, nullus fuit dies, seu terminus, appositus, vsque ad quem solūm teneretur dominus rei, vnde damnum timetur, tunc, quocunque tempore damnum inde sequatur, tenetur illud soluere, qui eam cautionem præstitit. Si verò per errorem nullus terminus fuit præfixus, tunc, qui cauit, solūm tenetur vsque ad terminum, intra quem in simili euentu consuevit in ea regione caueri. *Ita habetur. l. si finita in prin. vers. si verò. ff. de dam. inf.* Quando aduenit dies, vsque ad quem cautio est præstita, vel proximè accedit, si adhuc damnum timeatur, potest peti, vt iudex terminū cautionis proroget, aut de nouo caueri efficiat, teneturque iudex id ita præcipere

causa similitet cognita & examinata. *Ita habetur. l. 4. in prin. §. l. si finita in prin. ff. de dam. infect.*

Quando opus est factum in flumine publico, [sect. 10] aut in ripa fluminis publica, indeque damnum iustè timetur, tunc cautio præstari debet in decem integros annos. *Ita habetur. l. prætor ait. §. de eo opere, §. l. si finita. §. deinde ait prætor. ff. de dam. infect.* Quando autem opus est factum, vel in loco priuato, vel etiam in quocunque alio loco publico, qui non sit flumen, aut ripa fluminis, cautio est facienda in tempus arbitrio iudicis statuendum: quoniam prætor de nullo alio opere facto in loco publico, quàm de facto in flumine, aut in ripa fluminis, statuit vt cautio fieri in decem annos, sed id reliquit iudicis arbitrio. *Ita habetur. l. si finita. §. deinde ait prætor, §. §. si quid in via. ff. de dam. infect.*

Fluminum publicorum, viarum, ac littorum, [sect. 11] communis est vsus, ipsa tamen loca publica sunt, & non priuata. Excipe littora publicorum fluuiorum, quæ, si ad illa terminentur prædia priuatorum, via inter littora & ea prædia non remanente, pertinent quoad dominium ad eos, quorum sunt prædia, quæ ad illa terminantur, *vt habetur. §. riparũ inst. de rer. diuis. §. l. riparũ. ff. de acqui. rer. dom.*

In eis locis autoritate publica licitum est effi [sect. 12] cere ædificium priuatum, aliquidque destruere, dummodo id non fiat cum aliorum incōmodo ac dā. no. *Ita habetur. l. fluminum in prin. ff. de dam. infect.*

Quòd si in loco publico fiat autoritate publica [sect. 13] ædificium priuatum, tunc, cū ædificium duntaxat maneat priuatum, non verò solum, vtique si ex tali ædificio damnum immineat alteri, is, cuius est tale ædificium quoad vtile dominium, cauere debet de ædificio duntaxat, & nullus tenebitur cauere de solo, etiam si ex solo damnum immineat. Cum tamen, quando ædificium factum est in loco priuato, cauendum sit de ædificio & de solo. *Ita habetur. l. si finita. §. notandum, §. l. fluminum in prin. ff. de dam. inf.*

Obserua tamen, quòd quando ita concederetur fieri ædificium in loco publico, vt locus ex publico fieret priuatus: quia condonaretur pars viæ publicæ, aut soli publici, vel in recompensationem pro alia re concederetur, vt desineret esse locus publicus, & fieret priuatus, id quod sæpo fieri solet; tunc, si ex opere in eo solo facto damnum immineret, teneretur dominus operis cauere, tum ex damno imminente ex opere, tum etiam ex damno imminente ex solo, facto iam ipsius, nec retinente rationem soli publici.

Quando in loco publico fit opus aliquod publicum, aut reficitur, non cauetur de damno infecto: sed, si damnum timetur, recurritur ad principem, vel ad superiorem aliquam aliam potestatem, quæ subuenire periculo ac damno vicinorū ea in parte possit, impediendo id ædificium, aut illud etiam destruendo. Quando enim in loco publico aliquid fit, vnde, vel ratione loci, vel ratione operis, possit damnum aliis imminere, ita cōcedendum est fieri, dummodo vicinis non noceat. *l. si finita. §. si publicus, §. §. si quid, §. l. fluminum in prin. ff. de dam. infect.*

Qui vias publicas priuata sua autoritate in suā [sect. 15] vtilitatem munit, cauere debet de damno infecto: secus si publica autoritate id efficiat. *Ita habetur. l. qui vias. ff. de dam. infect.*

Qui cauet de damno infecto, si caueat nomi [sect. 16] ne suo, hoc est, tanquam dominus rei, vnde periculum timetur, solūm cauet promittendo, se soluturū damnum, si quod inde euenerit, neque tenetur fideiuiffores præstare. Qui verò cauet nomine alieno, hoc est, de re vnde damnum timetur, quæ ad alium spectat, & quatenus ad alium spectat, satisdat, hoc est, fideiussores præstat, quòd soluetur damnum, si quod inde euenerit. Quādo autem dubitatur, an id, pro quo aliquis cauet, ad ipsum spectet, satisdat sub exceptione, quòd si

cōperiat ad se pertinere, fideiussores ad nihil teneantur. *Ita habetur. l. prætor ait in prin. c. l. qui vias vers. si controuersia. ff. de dam. infect.*

Si rei vni damnum immineat ex re alia, & do [sect. 17] minus rei, cui damnum imminet, petat caueri sibi sine fideiussoribus de eo damno ab aliquo, quē dicat esse dominum rei, vnde damnum imminet: atque alius dicat, se esse dominum rei illius, isque, qui caueri sibi postulat, id neget, non potest petere, vt simul sibi caueatur ab hoc sub fideiussoribus, & ab illo alio purè, sed eligere debet, quē eorum duorum velit, sibi caueri. *Ita habetur. l. si proprietarius. §. Plautius. ff. de damno infect.*

Quando est controuersia, ad quem è duobus [sect. 18] pertineat res, vnde damnum timetur, & dominus rei, cui inde damnum timetur, petat sibi caueri de eo damno; tunc is, qui est in possessione rei, vnde damnum timetur, cauere debet: si verò non caueat, is, qui petit sibi caueri, mitti debet in possessionē eius rei ex primo, aut ex secundo, decreto, iuxta ea quæ subijciemus. Quòd si caueat, & aliquid soluat ob damnum sequutum, ac postea vincatur, resq; adiudicetur alteri, qui cōtēdebat ad se pertinere, hic soluere debet ei, qui vincitur, quod in recōpensationē dāni, ex ea re subsequuti, soluit. *Ita habetur. l. inter quos. §. si domus. ff. de dam. infect.*

Quando aquæductum quis facit in fundo a [sect. 19] lienio ratione seruitutis ad id sibi debitæ in eo fūdo, aut quando aliquid aliud quis facit in alieno fundo ratione similiter seruitutis in eo ad id sibi debitæ, tunc, si dominus fundi iustè inde damnum timeat plantis, aggeri, aut alteri ædificio suo eiusdem fundi, petatq; sibi caueri, quamuis Labeo dixerit, debere satisfacere, quasi de re in alieno fun-[[111]]do; Vlpianus tamen id correxit, dicens: Quòd quia aquæ ductus, aut quoduis aliud factum in fundo alieno ratione seruitutis ad id debitæ in eo fundo, est quasi ædificium proprium eius, qui illud ibi ratione talis seruitutis facit, solū debet promittere, se soluturum, si quod damnum inde sequetur; non verò satisfacere, fideiussores adhibendo. *Ita habetur. l. damni infecti stipulatio. ff. de dam. infect.*

Quando res, vnde damnum timetur, vt domus [sect. 20] ruinosam verbi gratia, ad vnum pertinet quoad proprietatē, & ad alterum quoad vtile dominium, vt si sit feudatarius, emphyteuta, aut superficiarius, comparatione illius, vel ad eum pertinet quoad vsumfructum, vel in illa habet seruitutē aliam, aut ius aliud, vt si est illi tradita in pignus, (de discrimine iuris in re inter hos omnes, vide quæ dicta sunt Disp. 10. & 371.) & vicinus petit sibi caueri de damno alteri suæ rei, quod ex illa timet, tunc ad concilianda varia iura, remque hanc explicandam, est distinguendum. Quoniam si à proprietario, & ab illo altero, petatur, vt caueant, & vterque caueat, vnusquisque eorum de eo, quod in ea re habet, tunc satis est, si eorum vnusquisque promittat, neuterq; tenetur præstare fideiussores. Ratio autem est, quoniam neuter cauet nomine alieno, neque de eo, quod ad alterum spectat, sed vnusquisque eorum cauet nomine proprio, & de eo præcisè, quod ad ipsum in ea re spectat. Atque iuxta hoc intelligo legem, qui bona fide. §. 1. ff. de dam. infect. quæ id apertè statuit, reddita ratione, quam nos proximè reddidimus, & sic habet: *Siue corporis (hoc est rei) dominus, siue is, qui ius habet, vt puta seruitutem, de damno infecto caueat, puto, eum repromittere debere, non satisfacere: quia suo nomine id facit, non alieno.* Licet enim exemplum apposuerit in habente in ea re seruitutem, vniuersim tamen lex loquitur, de quocunque habente ius in ea re, distinctum à rei dominio, & loquitur, quando præcisè de eo cauet, vnà cum domino rei, quadratq; ratio reddita, cur satisfacere in eo euentu non teneatur. Vnde ad illā quæstionē, quam Vlpianus excitat, indecisamq; relinquit. l. quid de creditore, in prin. ff. de dam. infect. Videlicet, si creditor, qui in pignus accepit rem, vnde damnum timetur, cauere exigatur, *utrū repromittere debeat, quia*

suum ius tuetur, an satisfacere, quia dominus non est? dicendum est. Si caueat vnà cum debitore ac domino eiusdem rei, satis esse, si repromittat: quia solùm cauet quoad ius præcisè, quod ad ipsum spectat: si verò solus caueat, debere satisfacere, iuxta ea, quæ subjiciemus de omnibus, qui domini non sunt, & cauent de re propter ius, quod in ea habent.

Quando verò seorsum petitur à proprietario, & ab habente dominium vtile, aut vsumfructum, vel seruitutem, vel aliud ius, in aliqua re, vt de ea integre caueant, tunc in primis, si neuter caueat, vicinus, qui petit sibi caueri de damno infecto ex tali re, mitti debet aduersus vtrumque in possessionem eius rei ex primo decreto, & postea ex secundo, eo modo quo exponemus. *Ita habetur. l. hoc amplius. §. quæsitum est, & §. Celsus. l. quamuis, & l. si finita. §. si qua sint, & §. si de vectigalibus. ff. de dam. infect.* Deinde verò proprietarius requisitus, vt caueat de toto damno, satis est, si promittat, se soluturum totum damnum, si eueniat, neque tenetur satisfacere præstando fideiussores: eo quòd dominium, quod est præcipuum in ea re, ad ipsum pertineat. Reliqui verò, si requirantur vt caueant de toto damno, satisfacere tenentur, præstando fideiussores: eo quòd, saltem ratione proprietatis, quæ est præcipuum in ea re, & ad alium spectat, satisfacere teneantur. *Ita habetur. l. hoc amplius. §. quæsitum est, & §. Celsus. l. quamuis. l. si finita. §. si qua sint, & §. si de vectigalibus. ff. de dam. infect.*

Quando is, qui damnum timet rei suæ, petiuit ab eo, qui non est proprietarius, sed emphyteuta, feudatarius, superficiarius, aut vsufructuarius, rei, vnde damnum timetur, aut ab eo, qui in ea habet ius aliud, vt seruitutis, aut pignoris, vt sibi caueret de eo damno, nec cauet satisfacendo de integro damno, tunc, si propter eam contumaciam is, qui sibi caueri petiuit, mittatur in possessionem eius rei ex primo & rursus ex secundo decreto, iuxta ea quæ dicenda sunt, quia neque proprietarius se obtulit ad cauendum promittendo solùm de integro damno, amittunt dominium vtile, quod habebant in ea re, aut vsumfructum, vel aliam seruitutem, aut ius pignoris, quod in eadem re habebant, ei, qui ita ex secundo decreto missus est in possessionem. Proprietarius verò non priùs amittit suum dominium, quàm requisitus etiam sit cauere, promittendo solùm resarcire totum damnum, si sequatur, & propterea quòd ipse etiam sit contumax non ita cauendo, is, qui caueri sibi petiuit, mittatur etiam ex secundo decreto aduersus illum in possessionem eiusdem rei. *Ita habetur. l. si finita. §. si qua sint, & §. si de vectigalibus. ff. de dam. infect.* Atque. §. si de vectigalibus, sermo est de emphyteuta, & de proprietario, vbi glossa vlt. in vltimis verbis ait, idem esse in feudo. Concinunt etiam. *l. hoc amplius. §. Celsus, & l. quamuis. ff. eod. titu.* Credo etiam similiter, si proprietarius cauere admoneatur, & non emphyteuta, feudatarius, superficialis, vsufructuarius, aut habens aliam seruitutē, vel ius in ea re, hos, propter contumaciam solius proprietarii, non amittere suum vtile dominium, aut aliud ius, quod in ea re habeant, sed solum proprietarium amittere, propter suam contumaciam, suum dominium.

Quando proprietarius solus caueret de integro damno, petere posset ab emphyteuta, feudatario, superficiali, vsufructuario, quin & ab habente aliam seruitutem in illa eadem re, vnde dānum timetur, vt sibi etiam caueant de ea parte damni, quam soluere ad eos spectat, pro rata valoris iuris, quod in ea re habent: quòd si ei non caueant, aut ei non soluant post damnum sequutum, partem valoris eius damni, quod pro eis soluit, quando cautionem antea ab eis non petierat, amittere vsumfructum, vel dominium vtile, aut aliam seruitutē, quam in ea re habeant. *Ita habetur. l. hoc amplius. §. Celsus, & l. quamuis, & l. si proprietarius. ff. de dam. infect.* Credo autem eam cautionem, præstandam tunc proprietario, non esse fideiussoriam, sed solùm promissoriā: quoniam illi non cauent pro alia re, aut

pro alio iure, quàm pro eo præcisè, quod in ea re ad ipsos spectat. Eadē ratione, si solus emphyteuta, feudatarius, superficiarius, usufructuarius, vel habens aliam seruitutē, aut ius in ea re, satiscent pro toto damno, non cauente proprietario: postea verò, sequuto damno illud integrum soluant, quia videlicet contribuere non vult proprietor pro rata partem eius damni, quæ ad ipsum spectabat cōtribuere ratione dominii, quod in ea re ha-[[112]]bet, amittit proprietatem soli, aut reliqui ædificii, remanentis, ei, qui loco ipsius satisdedit, ac soluit damnum. *Ita habetur. l. quamuis, in fine, & l. si proprietorius. ff. de dam. infect.* Ac fortasse, antequā damnum sequatur, poterit exigere is, qui loco proprietarii ita satisdedit, vt sibi caueat de parte damni, quam ad eum spectaret soluere, si simul cauisset, ac damnum sequeretur; aut petere ab eo, cui fidei iussoria cautio integri damni est præstita, vt sibi actionem cedat, quam aduersus proprietarium habebat, vt ei pro rata caueret de eodem damno, eamque actionem sibi cessam intentare aduersus proprietarium, vt sibi caueat loco alterius, qui eam actionem cessit: quòd si non velit, contumaxque sit, mittetur ex primo, & ex secundo, decreto in possessionem proprietatis, eamque eo ipso amittet ei proprietor, esto postea nullum damnum sequatur, consentitque satis. l. si proprietarius citata.

Qui bona fide rem, vnde damnum iustè time [sect. 21] tur, emit à non domino, si cauere iubeatur vicino, non tenetur satisfacere, esto vicinus contendat, eū esse non dominum rei, pro qua cauet, ac proinde debere satisfacere, sed satis est, si ei simpliciter promittat de dāno, si fuerit sequutum. Ratio autem est, quoniam, dum eam rē possidet vt suam, quia empram, & pro ea cauet, suo nomine cauet, & non alieno nomine, ac proinde satis est, si de dāno promittat. *Ita habetur. l. qui bona fide in prin. ff. de dam. infect.*

Quauis cautio de damno in fecto præstetur [sect. 22] de damno futuro, soleatque præscribi dies, aut terminus, intra quem cauens teneatur, vt dictum vtrunque suprā est; si tamen domus ruinosas, verbi gratia, pro qua præstita est cautio, cadat quidē supra parietē meum intra terminum cautionis, cūq; quassum relinquat, tunc, esto paries decidat post terminū cautionis, agere possum ad dānū sequutū, vel antequam cadat, vel postquam ceciderit: quoniā damnum acceptum fuit intra terminum cautionis, esto vltimus effectus eius damni, nempe ruina parietis ex ictu intra terminum cautionis accepto, sequutum fuerit post eum diem. *Ita habetur. l. dāni infecti. §. Sabini. ff. de dam. infect.*

Si duæ res, vt duæ domus, vna vicissim mine [sect. 23] tur ruinam alteri, domini earum mutuò tenentur vnus cauere alteri de damno infecto, si vterque id ab altero petat, & vtrius eorum existente contumace, nec volente cauere, alter mitti debet in possessionem domus illius. *Ita habetur. l. damni infecti. §. si vicinas. ff. de dam.*

Si vitium soli sit illi naturale, & periculosum, [sect. 24] vt quia palustre, vel arenosum, non est cauendum de damno, quod inde aliis rebus imminet, nec, si caueatur, valida est cautio. *Ita habetur. l. fluminum. §. vitium. ff. de dam. infect.* Si tamen in eo loco superponatur ædificium, & ratione ædificii superpositi, damnum immineat, etiam ex loco propter ædificium superpositum, locum habet cautio de damno infecto, vt ibi subiungit glossa.

Quando inter domos ruinosas, & alias non rui [sect. 25] nosas, sunt aliæ intermediæ non ruinosæ, & quis timet iustè damnum ex domibus ruinosis mediātibus domibus intermediis non ruinosis, quia videlicet sustinere non poterunt ruinam, & ita cadent etiam & nocebunt aliis domibus, quæ proximè post eas sequuntur, tunc dominus harū domorum remotiorum petere poterit cautionē de damno infecto, tum à domino domorum ruinosarum, tum etiam à domino domorum intermediarum: qui etiam à domino domorum ruinosarum petere poterit

cautionem, tum damnius quod suis propriis domibus ex ruinosis imminet, tum etiam damni, de quo cauere ipse debet proximis aliis domibus non ruinosis. *Ita habetur. l. qui bona fide. §. cum inter. ff. de dam. infect.*

Si alicuius domus ruinosæ vnus habeat pro [sect. 26] prietatem, & alius vsumfructum, neuterque habeat domum aliam sibi propriam, aut aliud ædificium vel prædium propè, cui ea ruinosæ domus nocere possit, tunc neque vsufructuarius petere poterit à proprietario, vt sibi caueat de damno eius domus quoad vsumfructum, neque proprietarius petere poterit ab vsufructuario, vt sibi caueat de damno eiusdē domus quoad proprietatem. *Ita habetur. l. damni infecti. §. ei cuius, & l. inter fructuarium. ff. de dam. infect.* Ac ratio primi redditur vtrouque, quoniam ad vsufructuariū spectat facere sumptus necessarios ad conseruationem eius domus, dum ea fruitur: quòd si ad id necessarii sint alii extraordinarii & magni, qui ad ipsum non spectent, sed ad proprietarium, illos potest facere, & petere illos postea à proprietario actione negotiorum gestorum, vt Disp. 7. vtrumque est dictum, & Disp. 8. est additum, qui sumptus pertineant ad patremfamilias vsufructuarium bonorum aduentitiorum filii sui familias. Ratio verò secundi redditur etiam in vtroque textu: quoniam fructuarius reddere tenetur cautionem, quòd tanquam bonus vir fruetur re, cuius habet vsumfructum, & quòd faciet sumptus ad illius conseruationem ordinarios ac necessarios, ad ipsumque pertinet damnum, si quod sequatur, quòd non vt oportet ea re fruatur, & quòd non faciat sumptus ad illius conseruationem ad ipsum attinentes, vt Disp. 7. citata dictum est, *imo. l. hoc amplius. §. Celsus. ff. de dam. infect. habetur*, si eos sumptus non faciat, priuari à proprietario posse vsufructu. Quando autem ordinario hoc remedio subuenire, consuleréve, sibi potest proprietarius, locum non habet remedium extraordinarium, quòd faciat vsufructuarium sibi cauere de damno infecto. Quòd si ad conseruationem talis domus ruinosæ, necessarii essent sumptus extraordinarii, quos facere, non attineret ad vsufructuarium, sed ad proprietarium, tunc glossæ iuribus citatis volunt, ea de causa proprietarium non posse cogere vsufructuarium sibi cauere de damno infecto, quòd vsufructuarius teneatur eos etiam efficere, posteaque eos petet à proprietario actione negotiorum gestorum: quòd si illos non efficiat, ad eum attineat damnum subsequutum, proprietariusque expellere eum possit ab vsufructu, perinde ac quando ad id essent satis alii ordinarii sumptus, quos facere pertineret ad vsufructuarium, nec tamen illos efficeret. Certè mihi hæc illarum glossarum opinio non probatur. Licet enim vsufructuarius facere possit sumptus extraordinarios necessarios ad conseruationem domus vsufructuariæ, si velit, eosque postea petere possit actione negotiorum gestorum à proprietario; non tamen tenetur illos facere, neque, quod illos non faciat, potest expelli ab vsufructu: sed proprietarius est, qui tenetur eos facere, si vult ea ratione domum illam cōseruare, ne corruat. Hac ergo ratione tunc proprietarius non potest cogere fructuarium, vt sibi caueat de damno eius domus: quoniam impedire tale damnum, faciendo eos sumptus, non per-[[113]]tinet ad fructuarium, quasi illos facere teneatur, vt ea domus conseruetur, sed spectat ad proprietarium ipsum; eaque de causa vsufructuarius non tenetur illi cauere de eo damno.

Quando autem vsufructuarius, aut proprie [sect. 27] tarius, habet aliam domum sibi propriam, aut aliud prædium sibi proprium, iuxta eam domum ruinosam, cui damnum imminet ex ea ruinosæ domo, vtrum vnus alteri cauere teneatur de eo damno, quod ex tali domo ruinosæ imminet, est distinguendum. Quòd si immineat alteri prædio vsufructuario proprio, ex solo domus ruinosæ, & non ex ædificio eiusdem domus, tunc proprietarius tenetur illi cauere de eo damno, *vt habetur. l. inter fructuarium citata*: alioquin fructuarius mittetur in possessionem

proprietatis eius domus ex primo & ex secundo decreto, modo infra explicando. Si verò immineat prædio, proprietario ipsi proprio, ex nouo peculiari ædificio, quod vsufructuarius efficiat in ea domo, in qua habet vsumfructum, tunc tenetur similiter vsufructuarius cauere proprietario de eo damno, vt habetur expressè eadem. l. inter fructuarium, citata. Quòd si ex domo ruinosà, in qua vnus habet proprietatem, & alius vsumfructum, immineat, ratione ædificii ipsius domus in se, damnum aliquod vicino alicui prædio, siue proprietarii, siue vsufructuarii, tunc neuter tenetur cauere alteri de eo damno, idque propter eandem rationem, ob quam dictum est, vnum non teneri cauere alteri de damno ipsius ruinosæ domus in se. *Ita habetur expresse. l. damni infecti. §. ei cuius, & l. inter vsufructuarium, citatis.*

Similiter, si duo habeant domum ruinosam [sect. 28] vtrique communem quoad proprietatem & vsumfructum simul, neuter tenetur alteri cauere de damno infecto, tam ipsius domus in se, quoad partem pro indiuiso, quam in ea habet, quàm ratione alterius prædii vicini, proprii alicuius eorum, cui ex eadem domo immineat damnum. Ratio est, quoniam cùm is, qui peteret sibi caueri de damno infecto, posset aliter sufficienter sibi consulere ac subuenire ei damno, reficiendo domus ruinosas vtrique communes, & petendo actione pro socio, aut communi diuidendo, dimidium earum expensarum à condomino secum earum domorum ruinosarum, non conceditur ei remedium extraordinarium cautionis de damno infecto. *Ita habetur expresse. l. si ædibus meis. ff. de dam. infect.*

Hoc loco obserua, quamuis vnus alteri in [sect. 29] prædicto euentu cauisset, ignorans non teneri caueri, & postea sequeretur damnum ex ruina eius domus, non teneri de damno ita subsequuto, *vt constat ex. l. ex damni. §. quoties. 1. ff. de dam. infect.* Vbi habetur, si duo habeant parietem pro indiuiso ruinosum, & ex vitio illius damnum sequatur vni eorum, cùm tamen neuter peculiarem aliam causam dede rit parieti illi eius ruinæ, tunc alterum ei non teneri de eo damno, esto per errorem ei antea cauisset de damno infecto. Ratio autem est, quam reddiderat. l. si ædibus meis citata. Si tamen vnus eorum onerauit eum parietem, idque in causa fuit, vt rueret ac damnum inferret alteri, tunc, si ei cauerat de damno infecto, tenetur ei ad id damnum sequutum, *idemque habetur. l. inter quos. ff. eod. titu.* Cæterum, si ambo eum parietem onerauerunt, fueruntque proinde in causa, vt corrueret, tunc neuter alteri tenebitur de damno infecto, esto plus damni ex ea ruina sequutum suerit vni, quàm alteri: quoniã tunc ambo in culpa fuissent, & militaret illa alia ratio, quòd vterque poterat reficere eum parietem, petereque dimidium expensarum ab altero, & ita vitare poterat proprium damnum ex ruina eius communis parietis sequutum. Quod autem Pomponius addit. l. inter quos, citata, nempe si alter eorum, quibus est paries communis, habeat pretiosiores domus, quibus is paries possit nocere, huic præstandam esse cautionem, corrigere videntur Caius. l. si ex ædibus, & Vlpianus. l. ex damni. §. quoties. 1. ff. de damno infecto.

Quando paries, riuus, iter, aut aliquid aliud, [sect. 30] communia sunt duorum, aut plurium, & quilibet vult ea reficere, si non conueniant in modo, (quando autem conuenirent, & æquè bene id efficere vellent, omnes simul admitti deberent, ac contribuere debent ad eam refectionem) is præferendus est, vt reffectio ei concedatur, contribuētibus aliis ad expēsas, qui magis idoneè id reficere vult. *Ita habetur. l. in reficiendo. ff. de dam. inf.*

Quando paries est communis duabus domi [sect. 31] bus & vnus eorum, quibus ita est communis pro indiuiso, vult illum destruere, & alter petit sibi caueri de damno, quod timet inde sibi obuenturum, cautioque ei præstatur, est distinguendum. Quoniam si paries, qui est destructus, erat idoneus ad onera vtriusque domus sustinenda, etiam quæ ritè ei volebant imponi, atque ex demolitione illius damnum sequutum fuit, vel in demolitione, vel quia

alius, loco demoliti constructus, non fuit idoneus, tunc qui destruxit, & cauit, tenetur de dāno infecto. Si verò paries destructus non erat idoneus oneribus vtriusq; domus sustinendis, neque culpa demolientis, aut de nouo parietē loco illius cōficiētis, damnum fuit sequutū; tunc, qui cauit de eo damno, non tenetur soluere id damnū: secus verò si culpa illius sequutum sit. Ita habetur. l. in parietis, & duabus sequentibus. ff. de dam. infect. Hoc loco obserua, quando paries demolitus non erat idoneus, tunc, expensas factas in eo demoliendo, & in altero construendo, si rationabiles & moderatæ sint, soluendas esse ab vtroque, quorum erat paries demolitus, idq̄ue actione pro socio, aut communi diuidundo, petere poterit, qui eas fecit, ab eo, in cuius commodum factæ sunt, iuxta ea, quæ suprā dicta sunt.

Quando duo habent eundem parietē cōmunē, [sect. 32] & de communi consensu vtriusque illum destruunt, vt cōmunibus sumptibus vtriusque reēdificetur, tunc, si quod damnum inde sequatur eisdem quoad prædia eorum coniuncta, aut vicina, nihil vnus alteri tenetur, sed neque potest vnus cogere alterum, vt sibi caueat de tali damno, vt ex dictis facilē cōstat, & habetur. l. damni infecti. 2. §. cū parietem. ff. de dam. infect. Si verò damnum inde immineat alicui tertio, ille quidem poterit ab illis petere, vt sibi caueant de eo damno, sed ab vnoquoque eorum, vt sibi caueat solū de dimidio eius damni, vt ex sequentibus patebit, & habetur. §. cū parietem citato. Dubium verò est, utrū, si illi duo, non quidem ducti errore iuris, aut facti, sed sua sponte, sibi mutuò caueant vnus alteri de integro damno, quod ei inde euenerit, teneantur id integrum soluere. Itemq̄ue, si timore iusto, ex destructione & reēdificatione eius parietis, inquilini vnus recedant, nec soluant pensionem locationis domus temporis sequentis, teneatur alter ei [[114]] soluere etiam id damnum amissionis ea de causa eius partis pensionis vicinarum domorū. Atque ad vtrumque in eo euentu respondetur affirmanter. §. cū parietem citato. Quoniam tūc inuicem tenentur ad integrum damnum sequutum ex spontaneo illo pacto, vtrique æquali, quo se inuicem spontaneē atque ex certa scientia ad id totum damnum astrinxerunt.

Si, cū haberem seruitutē in domo tua, aut [sect. 33] in pariete tuo, ne tu altiūs tolleres, altiūs sustulisti, si ego petam destrui, quod altiūs est ædificatum, & tu ex meo consensu id fecisse affirmes, atq; ego id negē, mittor ex primo decreto in possessionē eius quod altiūs ædificasti, præscribiturq̄ue tibi tempus, intra quod tuum intentum probes: quòd si intra id tempus non probes, destruitur, quod altiūs est ædificatum. Ita habetur. l. ædificatum (alias. l. à quo) ff. de dam. infect.

Quando aliquis habebat domum iuxta aliam [sect. 34] alterius ruinosam, & petiit à domino ruinosæ domus sibi caueri de dāno infecto talis domus, atque ille cauit, tunc, si hic, cui est cautum, emat domum aliam iuxta eandem ruinosam, non cēsetur prior cautio se extendere ad hanc aliam domum, sed necessaria est noua cautio. Item si, cū domus aliqua censetur communis duorum, vterque à domino ruinosæ domus vicinæ peteret, vt sibi caueret de damno, quod parti, quam in ea domo habebat, eueniret, & ille vtrique eo modo caueret, tunc, si vni illorum ita possidentium eam domum pro indiuiso adiudicaretur altera pars eiusdē domus, cautio prior in vnam partem, nō se extenderet ad reliquam, quæ de nouo illi adiudicata est. Ita habetur. l. damni infecti. §. si is. ff. de dam. infect. Et obserua, quòd in hoc euentu is, cui altera pars esset adiudicata, non succederet illi, qui antea erat in possessione illius, neque haberet titulum ex illo, sed aliunde, ac proinde neque ille poterat cedere huic cautionem sibi factam quoad eam partē: quin potiūs eo ipso, quòd adiudicata esset alteri, & pronūciatū fuisset non pertinuisse ad illum alium, pronūciatū cēsetur cautionē illam

fuisse nullam, vt de cautione facta ēptori alicuius rei dicemus, eo ipso, quòd pronūciaretur, aut certò sciretur, ēptā fuisse ex non domino.

Esto aliquis aliunde impedire conetur ac intentet opus, vnde domui, aut alteri prædio suo, dānū imminet ex ruina, vt actione de noui operis nunciatione, aut ob seruitutem, quam in domo aut in pariete alieno habeat, ne altiùs tollatur, si tamen inde imminet etiam damnum ruinae, petere poterit simul cautionem de damno infecto: quoniam per illa alia auxilia non subuenitur damno ruinae, si fortè ex illo eodem opere eueniat. *Ita habetur. l. qui bona fide. §. si quis opus. ff. de dam, infect.*

Non solùm potest petere cautionem dāni in [sect. 36] fecti dominus rei, cui ex alia damnum timetur, sed etiam quicūq; habet in illa ius in re, quoad quod damnum etiam imminet illi, vt emphyteuta, feudatarius, superficiarius, vsufructuarius, habens in illa seruitutem aliam, aut habens illam in pignus. *l. damni infecti. 1. in prin. ff. de dam. infect.*

Quando simul proprietarius, & vsufructuarius, [sect. 37] rei, cui damnum timetur, petunt à domino rei, vnde damnum timetur, vt vnicuique eorum caueat de damno infecto, vnicuique eorum cauere debet de parte duntaxat damni, quæ ad eum in ea spectat: vnde non plus cauere debet vtrique simul, quàm vni tantùm, qui solus integrum dominium ac ius in ea re haberet; eaque de causa nulla iniuria ex eo fit domino rei, vnde damnum timetur, quòd multis cauere illo modo debeat. *Ita habetur. l. prætoris. §. si ē dominus. ff. de dam. infect.* Quod autem in eo. § dicitur de proprietario & vsufructuario, similiter est intelligendum de quibuscunque aliis, qui ius in ea re habent, vnde damnum ipsis potest prouenire, simulque omnes cauere sibi petunt. Vnde. *l. inter quos. §. damni infecti* dicitur, cauendum esse proprietario & vsufructuario, & *l. qui bona fide. §. superficiario, de finitur, superficiario, & vsufructuario,* esse cauendum de damno infecto, & *l. quid de creditore* statuitur, cauendum esse de damno infecto ei, qui rem, cui damnum imminet, habet in pignus.

Lege plures. ff. de dam. infect. admonetur. Quā [sect. 38] do duo sunt domini pro indiuiso domus, cui dānū ex alia domo imminet, & petunt sibi cauere de eo damno, singulos petere debere, vt sibi alter caueat de toto dāno, quod ad ipsum spectat; hoc autem solùm est dimidium damni, quod in ea domo euenerit: neque debere petere, vt sibi caueat de parte sui damni, putà de dimidio sui damni: quia nomine eius dimidii solùm intelligeretur quarta pars damni in ea domo subsequuti, quæ est dimidium damni, quod ad ipsum spectat, atque sibi noceret petendo ita sibi cauere. Obserua tamen, nihil sibi nocere, si petat sibi cauere de dimidio totius damni, quod in ea domo euenerit. E contra autem eadem lege admonetur, quando domus ruinosas ad duos spectat quoad dominium pro indiuiso, & ab vnoquoque eorum petitur vt caueat de damno, quod ex ea domo euenerit, vnumquemque cauere debere solùm de dimidia parte eius damni, idque debere exprimere, ne videatur se obligare ad totum damnum, cū solùm teneatur ad dimidium.

Lege ex damni. §. quotiens. 2. ff. eod. titu. consentaneè ad hactenus dicta habetur. Quando domui communi duobus dānū sequitur, de quo fuerat cautum, vnūquēq; eorum dominorum non posse agere pro toto damno in ea domo subsequuto, sed pro parte eius dāni, quæ ipsum contingit, hoc est, pro dimidio. E contrario verò, quando domus ruinosa erat duobus communis, cauerantque de damno ex illa imminente, tunc, si damnum sequatur, vnumquemque solùm posse cōueniri de dimidio damno subsequuto, quod solum ad ipsum soluere spectat ratione dimidii domini, quod in domo ruinosa habebat; non verò posse conueniri de integro damno subsequuto.

Lege si seruus. ff. de dam. inf. habetur, si seruus cō [sect. 39] munis duorum, qui domum etiam habent communem, stipuletur de damno infecto, quod imminet ei domui, censeri vtrumque dominum esse stipulatum, vnusquisque eorum pro parte, quam habet in domo, non verò pro parte, quam habet in seruo.

Ei, qui à non domino emit domum, cui dānum [sect. 40] imminet, meritò statuunt iura non esse cauendū de dāno infecto, *vt sancitur. l. quid de creditore, & l. qui bona fide. §. superficiarium. ff. de dam. infect.* Ratio autem est, quoniam, vt constat, eam domum ad eum non attinere, eo ipso, quòd scitur à non domino eam emisse: ita constat, ad eum non attinere æstimationē damni, quod illi imminet: quare, esto dum ignorabatur, à non domino eā emisse, illi fuisset cautum, cautio fuisset nulla, *vt [[115]] habetur. l. quid de creditore citata*: quia eo ipso, quòd postea constaret, eam emisse à non domino, ac proinde ad eum non pertinere, neque dāni æstimatio ei deberetur. Qui autem bona fide domū emit à non domino, si ex illa dānū immineat alteri rei tenetur nomine proprio de eo damno illi cauere, *vt habetur. l. qui bona fide in prin. ff. de dam. inf.* & suprā dictum est, aut domum relinquere. *Lege damni infecti. 1. §. si is. ff. de dam. infect.* ha [sect. 41] betur: si aliqui habeant communem domum pro indiuiso, quibus cautum sit à vicino de damno infecto, tunc, si vnus eorum emat ab altero partem, quā in ea domo habebat, ipsique tradatur, cautionem de damno infecto, sibi factam circa suam partem, non extendi ad partem alteram de nouo acquisitā ab eodem titulo emptionis. Atque id quidem verum est. Cæterum, si alter, qui illam ei vēdidit, stipulatus fuerat à vicino; vicinusque ei promiserat, quòd si domus vicina ei parti damnum inferret, tam ipse, quàm successores ipsius in ea domo vicina, soluerent ei, successoribusque ipsius in ea parte domus, id damnum, tunc, vi eius stipulationis factæ venditori talis partis domus, tenebatur emptori de damno infecto, esto emptor nihil à vicino stipuletur post eam partem emptam, aut post eam sibi traditam, vt glossa ibidem verb. promissionis, *iuxta. l. fluminum. §. adjicitur. ff. sod. titu. recte tradit*, vbi habetur; *in stipulatione de damno infecto adjici nomen hæredum, vel successorum, eorumque, ad quos res pertinet: successores autē non solum, qui in vniuersa bona succedunt, sed & hi, qui in rei tantum dominium successerint, his verbis continentur*; quasi dicat, nomine successorum, nō solū vniuersales, sed etiam particulares, qui solo dominio rei succedunt, intelligūtur: talis autē est emptor. *Et Bart. ibidem. §. vitium autem. n. 4.* hanc formam eius stipulationis tradit. Titius pro se, suisque hæredibus, & successoribus, eīsve, ad quos ea res pertineret, promisit mihi stipulanti pro me, meisque hæredibus, & successoribus, eīsve, ad quos ea res pertineret. Iuxta. §. adjicitur citatum.

Quia res empta, nondumque tradita, si per [sect. 42] eat, aut deterior fiat, damnum regulariter pertinet ad emptorem, vt à Disp. 366. dictum est, & nihilominus, si illo intermedio tempore vēditor non adhibeat diligentiam debitam, ne damnum, aut detrimentū, tali rei sequatur, qualē diligens adhiberet circa res suas, atque adeò, si culpa, saltem leui, illius pereat, tenetur emptori de eo damno actione ex vendito, ac proinde ad venditorem id damnum spectat, vt eadem Disp. 366. ostensum est; hinc, quando domus, verbi gratia, est vēdita, necdumque est tradita emptori, si ei domui ex vicina alia domo immineat ac sequatur dānū, quæritur, ad quem pertineat id damnum, & ad quem spectet, petere à vicino, vt caueat de eo damno, medio illo tempore, in quo est vendita, necdumque emptori est tradita. Et quidem, si venditor, antequā rem venderet, cautionem petierat de damno infecto iuxta formam. §. præcedente ex Bartolo, & ex §. adjicitur, relatam, & iuxta eam vicinus, vt tenebatur, eandem cautionem ei præstitit, sanè ea sufficit, vt teneatur ipsi de damno sequuto à pūcto vēditionis usque ad traditionem, & vt teneatur emptori de damno subsequuto post traditionē rei venditæ ipsi factam, neque

alia est necessaria cautio. Et cū æstimatio dāni subsequuti, à puncto venditionis usque ad punctum traditionis, debeat emptori ratione dāni, quod ad ipsum iā tunc spectat, vtique venditor, vel poterit petere eā æstimationē à vicino, illāq; sibi persolutam, tradere emptori; vel poterit cedere actionem ad illā petendā, & obtinendam cidē emptori. Quando autem venditori ante venditionem non erat illo modo cautum, vel quia nondum imminere cœperat dānum ex vicina domo, vel quia illam non petierat, aut quia ad damnum imminens non attendit, aliquāve alia ratione, *tunc lex damni infecti. 1. §. emptor, & l. emptor in prin.* (aliàs incipit, cum emptor) *ff. de dam. infect.* glossæ ibi, & doctores, satis obscurè hac de re loquuntur, dicereque videntur, ad venditorem solum attinere petere cautionē pro dāno, si sequatur medio illo tempore ante traditionē emptori factam, non verò ad emptorē. Rationem reddunt. Quoniam, cū remedium cautionis de damno infecto non cōpetat, quando adest aliud distinctū ac sufficiens remediū: & venditor, cuius est adhuc illa res, nisi cautionē, saltem ex leui sua culpa, pro eo tempore petat, teneatur emptori actione ex vendito ad totum damnum ei rei tunc sequutū: vtique emptori non competit petere à vicino eius domus cautionē de dāno, quod eo intermedio tempore fuerit sequutum, neque vicinus tenetur eam illi præstare: maximè quia sequeretur, vicinum teneri duobus præstare cautionē de eodem damno in solidum pro vno & eodem tempore sequuto, quod videtur absurdū. Quando autem venditor illo intermedio tempore non posset illā petere, vt si esset absens causa reipublicæ, aut aliqua alia ratione absque sua leui culpa non posset eam petere, tunc est dubium, an emptor posset valide illam petere pro damno, quod eodem medio tempore eueniret, ita quòd vicinus illi de eo dāno teneretur. Et lege emptor citata, habetur, quòd si venditor pro eo tempore precario emptori permiserit in ea domo esse, & curam illius habere, poterit tunc emptor cautionē de dāno pro eo medio tempore sequuto petere vtiliter ac validè à vicino. An verò validè possit eam petere etiam si domus non concedatur illi eo modo precario, ea præcisa ratione, quòd damnum illud in ipsum tunc redundat; eo quòd venditor de illo ei non teneatur, quia nulla sua culpa omittit tunc petere cautionem de eo damno? Satis obscurè ad hanc quæstionē respondet. §. emptor citatus, & quidam existimant, eam relinquere indecisam, atque quibusdam placet, validè posse eam petere, aliis non posse eam validè petere. Et mihi videtur Paulum iurisconsultum in hoc secundum potiùs in eo. §. inclinare. Simul in eo. §. docet, si emptor, & venditor, medio illo tempore cautionem à vicino petant, validè illam petere ac concedi. Cæterùm cautionem præstitā venditori, intelligendam esse, habereque solū vim, si damnum sequatur ante traditionem rei venditæ emptori: cautionem verò præstitam emptori intelligendam esse, habereque solum vim, si damnum sequatur post rem venditam ei traditam. Vnde, quando aliquis habet solū ius ad rem, vt habet emptor post celebratam venditionem, & ante traditionem rei venditæ, statuere videntur iura, eum, qui id ius habet, non posse petere validè cautionē de dāno infecto ei rei imminēte. Si tamen res vendita esset hypothecata emptori in securitatem venditionis, tunc credo, propter id ius in re, posset emptor petere validè pro eo medio tempore cautionē de dāno ei **[[116]]** rei imminenti, sicut petere eam potest creditor, qui rem habet in pignus, vt supra dictum est. Illud etiam videtur addendum, si venditor medio illo tempore petat cautionem de damno infecto pro se, & pro eius successoribus in ea re, iuxta formam, de qua. §. præcedente est habitus fermo, tūc emptorem, vi talis cautionis, absque alia sua peculiari cautione, posse petere æstimationem dāni infecti sequuti post traditionem ei factam dere vendita. Vtinam verò tot subtilitates, de iure humano ab ethnicis hominibus excogitatæ & introductæ, (ni fallor, instigante Satana, in reipublicarum non leue damnum, qui semper superseminare

curauit zizania in medio tritici) absunderentur à iure, statuereturque, ut præstita cautione alicui de damno infecto, ipso iure trāsiret ad quoscunq; possessores eius rei, & aduersus quoscunq; possessores rei, à qua id damnum imminet. Et ut simul res hæc tota de damno infecto, ad paucissimas regulas, ac leges, dilucidas redigeretur: id quod in plerilque aliasiaris ciuilibus titulis esset optandum.

De inquilino, qui damnum iustè timet, vel [sect. 43] ex domo, quam habet conductam, quia minatur ruinam, vel ex alia vicina, utrū petere possit cautionem de damno infecto, est distinguendū. Quoniam, si ex domo, quam habet conductam, vel ex alia vicina eiusdem locatoris, damnum timeat, tunc non potest petere cautionem de damno infecto. *Ita habetur. l. qui bona fide. §. de illo. l. inquilino, & l. vtique. ff. de dam. infect.* Cæterū tunc iterum est distinguendum. Si enim eodem modo damnum imminebat, quando eam domū conduxit, sibi imputare debet, quòd talem domū conduxerit, integramque tenetur soluere pensionem totius temporis, pro quo illam conduxit. *Ita habetur. §. ex illo citato.* Si verò postea damnum imminere cæpit, & locator illud potest impedire, refectione non magna, neque sibi admodum graui, aut præiudiciali, prudentis arbitrio, tunc conductor poterit agere ex locato aduersus illum, ut id reficiat, iuxta ea quæ Disp. 496. dicta sunt. Et credo, si, requisitus, id non præstet, & sequatur damnum rebus inquilini, teneri illud ei resarcire, vtpote culpa locatoris, ex qua conductor tenetur, subsequutum. Poterit etiam conductor, si velit, id reficere suis sumptibus, & postea illos petere à locatore, vel eos deducere de pensione domus soluenda, iuxta ea quæ eadem Disp. 496. comprobata sunt. Quando verò locator nō tenetur impedire id damnum imminens, tunc conductor deserere potest domum conductam, persoluto locatori solo pretio pensionis tēporis præteriti vsque ad punctum desertionis, non verò temporis suturi. Quòd si tunc locator illi impediatur eam desertionem, aut ab eo exigat pensionem temporis futuri, tunc poterit agere aduersus illum ex conducto, (aut etiam interdicto demigrando, præsertim si illum impediatur, impediendo, in pignus pensionis temporis futuri, extractionem aliquorum bonorum de domo conductâ, *vt habetur. l. 1. ff. de migrando*) ut liberum cum ab ea pensione migrare ex ea domo relinquat, quin & ut illi soluat damna ex ea impeditioe subsequuta. *Ita habetur. §. ex illo. l. inquilino, & l. vtique, citatis, ac consentiunt, quæ Disp. 493. dicta sunt.* Quòd si conductor migrare vellet, non soluta pensione conductionis eius domus vsque ad punctum, quo ea ex causa conductor vult eam deserere, tunc, cum inducta à conductore in eam domum, tacitè censeantur hypothecata pro pensione soluenda, ut Disput. 497 explanatum fuit, poterit locator illa, aut partem eorum, retinere in pignus, quousque ea pensionis portio ipsi soluatur, ut habetur. *l. vtique, citata.* Cæterū, si locator ea relinquat in ea domo, ex cuius ruina, aut vicinæ domus, damnum timebatur, detrimentumque ex tali ruina accipiant, cum tamen locator posset ea seruare sine eo, aut æquali, vel maiori, detrimento in alio loco, tunc conductor poterit agere aduersus eum pignoratitia actione, ut id detrimentum, propter indebitam eorum pignorum custodiam subsequutum, ei soluat, ut habetur. *l. vtique, citata.* Quando autem domui conductæ damnum imminet ex vicina domo, quæ non sit locatoris; tunc, & domino locatæ domus est cauendum de damno, quod ipsi inde potest prouenire, Disputationeque 494. dictum est, quousque conductor reneatur eum admonere de eo damno imminente, si conductor illud sciat, locatorque id ignoret; & inquilino etiam est cauendum de dāno, quod inde ipsi potest prouenire quoad res ipsius in domo conductâ existentes, & quoad deteriorationem, aut omnimodam impeditionem, habitationis ipsius in domo conductâ. *Ita habetur. l. qui bona fide. §. qui damni, in fine, & l. si filius. ff. de dam. infect.* Atque in hoc posteriori iure additur, quòd si filius familias conduxit domum, in qua habeat res

communes sibi cum patre, & damnum illis immineat ex domo alia vicina, tam filium, quàm patrem, posse petere cautionem de damno, quod timetur: ac, si non caueatur, vtrumque mittendum esse in possessionem domus vicinæ, pro parte damni, quæ vnumquemque eorum contingit. Quando inquilino ex domo, quam habet conductam, imminet dānum alteri domo vicinæ propriæ eiusdem inquilini, tunc locator cauere debet inquilino de dāno, quod ex domo, quam inquilinus habet conductam, potest euenire illi alteri vicinæ domui propriæ eiusdem inquilini. *Ita habetur. l. damni infecti. 1. §. sed inquilino. ff. de damni infecti.* Quando aliquis in conducto solo posuit superficiem, seu casulam amouibilem, tunc, quia inter dominum soli, & eiusmodi superficiarium, est verus contractus conductionis & locationis, vt Disputat. 10. dictum est, vtique si damnum superficiario imminere incipiat ex solo, vel domino soli ex casula, neuter potest ab altero petere cautionem de damno infecto, sed solum poterunt agere inter se ex locato, aut ex conducto. *Ita habetur eadem. l. damni infecti. §. ei qui.*

Qui cauet de damno, quod ex sua domo im [sect. 44] minet domui alterius, non solum censetur cauere de damno, si quod sequatur ipsi domui, sed etiam de dāno, si quod sequatur ex eadem ruina rebus mobilibus, aut se mouentibus, in eadem domo repertis, etiam si tempore stipulationis, & cautionis, non extiterint in ea domo, imò neque in rerum natura: vnde ex eadem stipulatione & cautione agi potest ad cōpensationē damni in eis sequuti. *Ita habetur. l. damni infecti. 1. §. si is, vers. si autem res. ff. de dam. infect.* Intelligendum est tamen, modò sint eorum, quorum est ea domus, de cuius damno cauetur, aut inquilinorum eiusdem domus, vel vxorum eorum, aut habitantium cum eisdem. Secus autem, si sint alicuius, [[117]] qui ibi deambulet, aut ibi lauet, vel eò diuertat. *Ita habetur. l. qui bona fide. §. qui damni, vers. cæterum. ff. de dam. infect.*

Quando aliquis illicitè ædificauit iuxta aliud [sect. 45] ædificium, aut passus est illicitè ædificari iuxta suū ædificium aliquid aliud, tunc, si ex illo alio ædificio damnum immineat suo, non cogitur dominus alterius ædificii, ei cauere de eo damno. *Ita habetur. l. qui bona fide. §. si quis iuxta. ff. de dam. infect.*

Quando quis cauit ex damno infecto ex quadā [sect. 46] causa, vnde timebatur ex prædio suo, si perseuerāte tempore cautionis, damnum eueniat, sed non ex ea causa, ex qua fuit cautum, sed aliunde, non tenetur; qui cauit, ad damnum. *Ita habetur. l. damni infecti. 1. §. 1. ff. de dam. infect.*

Quando aliquis cauit de damno; quod ex ope [sect. 47] re, quod facere intendebat, timebatur, si ipse id non fecit, neque alius de mandato illius, aut eo id ratum habente, neque item factum est ab eo, quem ipse prohibere potuerit, tunc non tenetur de damno ex eo opere sequuto. *Ita habetur. l. fluminum. §. quanquam. ff. de dam. infect.*

Quando aliquis de damno infecto, quod ex suo [sect. 48] prædio poterat vicino prædio euenire, cauit domino eius prædii, tunc, si is, qui ita cauit, aliquid in suo prædio efficiat, vtendo suo iure, vnde detrimentum alteri sequatur, non tenetur de eo dāno, seu detrimento, quod prædio vicini inde sit sequutum: quia neque de tali damno cauere tenebatur, neque cauere intendisse est censendus. Exempla sunt. Vt si aliquis fodiat puteum in sua domo, aut prædio, idque in causa sit, vt aquæ putei vicini eò deriuentur. Vel si fossam, seu riuum, in suo fundo faciat, quo deriuentur aquæ, quæ vsque ad vicini fundum consueuerant deriuari. Vel, cū domus, ex qua cauit, seruitutem non haberet comparatione domus vicini, vt altiùs non tolleretur, eam tollat, sicque impediatur lumina domus vicinæ. Certè, qui de damno infecto cauerat vicino, in nullo horum cuentuum tenetur illi de his damnis: quoniam cautio, si aliud non

fuit expressum, non intelligebatur de eis damnis. *Ita habetur. l. fluminū. §. ult. l. Trebatius, c. l. Proculus. ff. de dam, infect.*

Esto aliquis cauerit vicino de damno, quod ex [sect. 49] domo, aut ex alio prædio, cauentis, iuste vicini prædio timebatur, si tamen id damnum postea sequutū sit, non ex vitio rei, vnde timebatur, sed casu fortuito terræmotus, vi fluminis aut venti, vel aliqua alia vi extrinseca, ita quòd similiter euenisset, esto prædium, vnde timebatur, non haberet vitium, ob quod timebatur tunc, qui eam cautionem præstitit, non tenetur de eo damno sequuto, esto in cautione dictum esset, se obligare resarcire damnum, si quod ex eo accideret, quòd aliquid ex suo prædio decideret in prædium vicini. Si tamen vitium prædii, pro quo est cautum, ita adiuuauit, quòd, nisi eo vitio laboraret, accedente ea vi extrinseca, quæ re ipsa accessit, non esset sequuta ea ruina in prædium vicini, ac damnum; tunc, qui cauit, teneretur de damno sic sequuto. *Hæc habentur. l. fluminum. §. hæc stipulatio. §. seruus. §. idem seruus. §. item apud Viuium. §. idem ait. §. sed c. quod. c. l. damni infecti. 2. in prin. ff. de dam. infect.*

Quando præcesserat cautio damni, quod ti [sect. 50] mebatur quibus vicinis, idque damnum subsequutū est, in eo æstimando, vt ab eo soluatur, qui illud soluere promisit, moderatè est faciendæ æstimatione, ita scilicet, vt necessariæ quidam, seu vtilis, expensæ in ea domo factæ, æstimentur iuxta statum, quem res factæ eis expensis habuerint, quādo damnum datum fuit: voluptuariæ verò expensæ picturarum, & similium rerum, non æstimentur. *Ita habetur. l. inter. §. ult. c. l. ex damni, in prin. ff. de dam. infect.* Quando verò aliquis ex causa necessaria destruxit parietem veterem, sibi communem cum alio, eumque iterum ædificauit, socius contribuere tenetur ad expensas factas in nouo pariete ædificato; modò tamen expensæ modum probabilem non excedant, hoc est, non sint factæ omnino non necessariæ, vt in cultu immoderato, minimeque necessario, aut in eo pariete efficiendo plus iusto crasso: nam ad eiusmodi expensas minimè necessarias contribuere non tenetur socius. Atque ita intelligo. *§. ult. citatum. in lege emptor. §. ult. ff. eod. titu.* nescio quid sibi; voluerit Paulus iurisconsultus, nisi forte, quòd quādo aliquis reædificat parietē veterē destructum, ob damnum in eo sequutum, de quo cauerat, qui illud reædificat, cum non teneretur eum reædificare, sed solum soluere æstimationem damni vtique, si eum reædificet ex pacto cum illo, cuius erat veter, & cuius futurus est nouus, quòd soluet, quod plus valuerit nouus, quàm veter, æstimandus erit vterque paries, & de valore noui deducendus erit totus valor veteris, & solum incrementum soluet dominus eius parietis, à quo incremento deducendum erit, si quid materiæ veteris appositum fuit in pariete nouo.

Si iudex requisitus dum pro tribunali sederet, [sect. 51] vt iubeat alium de damno infecto cauere, id non iubeat, aut, si, postquam id iussit, & aduersarius fuit contumax, non cauendo, vt ei fuit denunciatum, iudex, similiter requisitus, non mittat eum, qui cauere sibi postulauit, in possessionem, ex primo decreto rei, vnde damnum timetur, & postea suo tempore ex secundo decreto, reliquaque, quæ subjicienda sunt, requisitus, non præstet, actio competit aduersus eiusmodi iudicem in factum ad interesse, quantum scilicet intererat hæc postulanti, illa esse facta: non verò iuratur aduersus eum iudicem in litem, neque damnatur ad aliquid aliud, vltra id interesse, soluendum in pænam. *Ita habetur. l. dies. §. in eum, c. §. hoc autem. ff. de dam. infect.* Cum verò hæc actio eatetenus sit rei prosequutiua, quatenus iudex tantundem damni censetur dedisse prædicta poscenti, eo quòd ex officio tenebatur ea præstare, nec præstitit illa ab eo petenti, competit hæredi ea postulantis, & aduersus hæredem talis iudicis. Ita subiungitur ibidem. *§. hæc autem.*

Iam verò suprà est dictum, si, dum cautio pe [sect. 52] tita est coram iudice, iudexque deliberat, res, ratione cuius cautionem præstari petitur, damnum det, concedi actionem in factum aduersus dominum rei, quæ damnum dedit, vt vel damnum totum resarciat, vel rem, quæ illud dedit, habeat pro derelicto, fiatque damnum passi, idque *habetur. l. si finita. §. eleganter. ff. de dam. inf.*

Quoniam, vt dictum est, & ex dicendis pate [sect. 53] bit, dominus rei, vnde damnum timetur, iussus cauere à iudice de damno, quod ex ea re timetur, non tenetur præcisè cauere, sed tenetur, vel cauere de eo damno, vel rem, vnde id damnum timetur, relinquere vicino, qui damnum inde [[118]] timet: in primis denunciari illi oportet iudicis decretum, quo illi præcipitur, vt caucat, vt vel id opere præstet, vel dicat, se relinquere rem vicino, vel, si neutrum faciat, contumaxque sit, iudex procedat vsque ad plenam traditionem, & applicationem eius rei illi, qui ex illa damnum timet: id quod iudex paulatim facit, primò mittendo vicinum in possessionem illius, solùm ex primo decreto; vt, si is, qui cauere præcipitur, contumax vltèriùs sit, nec caueat, vicinus tandem mittatur in possessionem illius ex secundo decreto, sitque illi plenè applicata, ita vt quamuis is, cuius erat, velit postea cauere, & soluere damna illucusque sequuta, & expensas illucusque factas, non audiat, sed res maneat eius, cui ita ex secundo decreto iudicis autoritate fuit applicata.

Quod ergo ad denunciationem decreti iudi [sect. 54] cis, vt caueat, attinet. Ea denunciatio fieri debet domino rei, vnde damnum timetur, ubicunque ille fuerit repertus, siue in eo prædio, aut domo ruinosà, siue in quacunque alia domo aut loco. Quòd si absens sit, aut fugiat, sui que copiam non faciat, vt ei decretum denunciatur, satis est, si denunciatio fiat procuratori illius, aut in domo vbi habet domicilium, vxori, aut domesticis illius, vel inquilinis domus ruinosæ, ex qua damnum timetur, vel, si nullus in ea habitet, domui ipsi. *Ita habetur. l. dies. §. prætor ait. ff. de dam. infect.* Si autem res, vnde damnum timetur, neque habitetur, neque sit tunc vllius, eo quòd adita non sit hæreditas, ad quam illa pertinet, cessat obligatio faciendi denunciationem, antequam, qui damnum timet, in possessionem eius rei mittatur: tametsi tutius sit, mittere libellum ad eam domum, seu ad eam rem, vnde damnum timetur, facereque illi denunciationem, si fortè ea ratione aliquis, cuius id intersit, se offerat, qui caueat de eo damno. *Ita subiungitur. l. citata totiens.*

Facta denunciatione, modo proximè explica [sect. 55] to, domino rei, vnde damnum timetur, si non caueat de eo damno intra terminum à iudice ei præscriptum, tunc iudex mittit eum, cui erat cauendum, in possessionem rei, vnde damnum timetur, ex primo decreto. *Ita habetur. l. dies. §. si intra. l. prætor ait. §. de co opere, vers. eum cui. ff. de dam. infect.* & aliis iuribus citandis. Atque mitti eo modo in possessionem debet, etiam si res sit pupilli, idque siue tutorem habeat, siue non, *vt habetur. l. si finita. §. si pupillus. ff. eod. titu.*

Quando, qui damnum timebat, iussus à iudice [sect. 56] estamitti in possessionem rei, vnde damnum timebat, ex primo decreto, eo quòd dominus eius rei, intra terminum ei à iudice præscriptum, nō cauisset; tunc, si negligens non fuit, & dum iret, vt in possessionem eius rei mitteretur, aut dum non erat in mora eundi, res illa, putà domus, corrui, ac damnum dedit, perinde habendum est, ac si, antequam corruisset in possessionem illius esset missus. *Ita habetur. l. cum postulassem, & l. si finita. §. eum tamen. ff. de dam. infect. & l. ult. ff. ne vis fiat ei qui in poss. mis. est.* In eo enim euentu, vt habetur eadem. l. si finita. §. si iam ruerunt. ff. eod. titu. mitti debet in possessionem soli, eiusque, quod remansit, nec tenetur eam possessionem deserere, nisi priùs ei soluatur damnum datum post iudicis decretum de cauendo, ei que caueatur de quocunque alio, quod deinceps euenire inde potest, & nisi ei

soluantur expensæ, quas per se, vel per alium, rationabiliter fecit, aut quas condemnatus est soluere, factas ab alio. Potest verò has omnes expensas petere in eo euentu, actione etiam in factum, vt ibi habetur: non verò actione negotiorum gestorum, vt glossa ibidem affirmat: quoniam eas fecit, respiciendo etiam suum commodum, si fortè dominus eius rei contumax vltèriùs esset in cauendo, ipseque mitteretur etiam ex secundo decreto in possessionem eiusdem rei, plenumque dominium illius compararet.

Quando ex eo, quòd dominus domus, vnde [sect. 57] damnum timetur, intra tempus ei præscriptum non cauit, is, cui erat cauendum, in possessionem eius domus mittitur; tunc, esto ea domus superficiaria sit, hoc est, cuius solum, ac dominium directum, ad alterum spectat, mitti debet in possessionem soli. Vtrùm autem, quando pars sola eius domus ruinam minatur, mitti debeat in possessionem totius domus, etiam quoad partes, quæ ruinam non minantur, distinguendum est. Quoniam, si contignatione eadem sit aliquid vnitum cum parte, quæ ruinam minatur, aut sit ita illi adhærens, vt periculum sit, ne secum trahat id, quod est illi vnitum, tunc mitti debet in possessionem, etiam earum pattium, quæ eo modo vnitæ sunt illi, quæ ruinam minatur, aut quasi periculum est, vt secum trahat. Quando autem vel domus sunt distinctæ ac diuisæ inter se, vel est vna magna domus, cuius vna pars ita ruinam minatur, vt non sit periculum, vt secum trahat aliam, quæ coniuncta cum illa non est eadem contignatione, tunc mitti non debet in possessionem domus omnino distinctæ, neque in possessionem partis, à qua nullum imminet periculū. *Ita habetur. l. si finita. §. ex hoc edicto. ff. de dam. infect.*

Hinc iam intelliges, quo pacto sit intelligenda. l. in stipulatione. ff. de damn. infecto, dum statuit, quando domus minatur ruinam, & dominus illius cauere iubetur de damno, quod ex ea imminet, non satis esse, si caueat de parte eius domus, sed necesse esse, vt caueat de tota domo, alioquin is, cui caueri iubetur, mittitur in possessionem totius eius domus: intelligenda enim est, quando non cauet de tota domo, quoad id, quod, modo proximè explicato, minatur ruinam: tunc enim is, cui caueri iubetur, mitti debet in possessionem eius totius: non verò in possessionem earum partium eiusdem domus, ex quibus nullum imminet periculum.

Licèt ex agris, quoad aggeres & arbores eorum, [sect. 58] quando inde pendet ruina & damnum prædio vicino, caueri etiam debeat de eo damno; tunc tamen, quia vna pars non solet secum trahere aliam, vt in domibus, cauendum solùm est de parte, quæ ruinam minatur, non verò de reliquis: iudex tamen, causa cognita, statuere debet, ex quanta parte caueri debeat, in quantamque vicinus mitti in possessionem debeat, si ei non caueatur. *Ita habetur. l. emptor. §. si agri. ff. de dam. infect.*

Quando multi sunt domini eiusdem rei, vnde [sect. 59] damnum timetur, si omnes cauere iubeantur, & vnus caueat, & alius non; tunc is, cui est cauendum, mitti debet, tum ex primo decreto, tum etiam, si vltèriùs contumax sit, ex secundo decreto, in possessionem solùm partis eius, qui non cauit, non verò in possessionem partis eius, qui cauit. *Ita habetur. l. prætoris. §. 1. ff. de dam. infect.*

Quando multi, siue diuer sorum prædiorum [sect. 60] domini, siue eiusdem pro indiuiso, petierunt sibi caueri de dāno, quod ex vicino prædio imminet ipsorum prædiis, eisque non est cautum, omnes simul, ac æqualiter, mittendi sunt ex primo decreto in possessionem prædii vicini, siue simul petierint cautionem, & obtinuerint possessionē, siue vnus post alium. Si tamen posteriùs petenti cautionem, aut possessionem ex primo decreto, illi caueat, qui priùs missus est, tunc posterior non mittitur in possessionem. *Ita habetur. l. prætor ait.*

§. in eum vers. eius rei. l. si finita. §. si plures, & §. equaliter, & l. emptor. §. ult. ff. de damn. infect.

Quando aliquis ex primo decreto missus est [sect. 61] in possessionem rei, unde damnum timebatur, eo quòd dominus rei illius ei non cauerit, eo ipso res illa sortitur rationem quasi pignoris prætorii (vt distinguitur contra pignus iudiciale pressè sumptum) comparatione eius, qui ita in possessionem illius est missus, vt in calce Disputationis 536. dictum est: solùm quippe per missionem in possessionem creditoris ex secundo decreto incipit habere rationem pignoris iudicialis pressè sumpti, vt distinguitur contra pignus prætorium, vt ibidem est traditū. Est tamen hoc discrimen inter pignus conuentionale & prætorium, vt Disp. 535. ostendimus, quòd, qui pignus conuentionale tenet, si pereat id pignus, aut deterius reddatur, culpa ipsius leui, tenetur ad dānum subsequutū: qui verò pignus prætorium tenet, solùm tenetur de dolo, & subinde de lata culpa, quæ dolo in re proposita comparatur. Hinc prouenit, quòd si is, qui pignus conueutionale tenet, illud non reficiat, quando refectione indiget, in eoq̃ue non efficiat expensas necessarias ad illius conseruationem, ita quòd culpa, saltem leui ipsius, propter defectum expensarum ac refectionis, pereat, aut deterius reddatur, teneatur domino pignoris de eo damno sequuto: qui autem missus est in possessionem rei alicuius ex primo decreto, eo quòd ipsi non caueatur de dāno, quod ex ea re imminet, non teneatur ad refectionem & expensas, neque ad damnum ex tali omissione domino eius rei sequuto, vt vtrum que habetur. *l. si finita. §. si quis damni. ff. de dam. infect.* Vtrum autem teneatur de damno lata culpa sequuto ob eam omissionem? Dicerem non teneri: quoniam textus hic eum ad id non obligat. Et quoniam, in re proposita, res, in cuius possessionem est facta missio ob omissionem cautionis de damno infecto, non habet rationem pignoris prætorii pro damno, vt tādē vendatur, & resarciatur damnum, incrementumq̃ue recdatur domino illius rei: vt fit, quando creditori non soluitur suum debitum, bonaq̃ue debitoris absentis occupantur iudicis autoritate, ob id debitum, creditorq̃ue, eadem iudicis autoritate, mittitur primò in possessionem eam ex primo decreto, & postea ex secundo, vt Disp. 536. explanatum est. Sed in re proposita, etiamsi dominus eius rei sit præsens, si non caueat, is, cui est cauēdum, mittitur in possessionem illius, vt tandem fiat omnino illius, quasi pro derelicto habita à domino illius: semperq̃ue integrum manet domino illius, interim dum missio non est facta ex secundo decreto, offerre cautionem, & subuenire rei suæ, eam reficiendo, & administrando: atque hac ratione suprā non diximus, eam rem, dum possidebatur ex primo decreto, habere rationem pignoris prætorii, sed diximus sortiri rationem quasi pignoris prætorii. Quando autem missio in possessionem fieret ex primo decreto, eo quòd omnino absens non caueret, tunc æquitas postulat, vt vsurpans eam rē ex primo decreto, teneatur eam reficere, maximè quando ea ratione esset impedimento alteri, qui alioquin eam refecisset, ne eam reficeret: atque tunc verisimile est, quòd teneretur de damno lata culpa sequuto ex omissione talis refectionis.

Qui in possessionem rei, unde damnum immi [sect. 62] net, missus est ex primo decreto, eo quòd dominus illius de damno non cauerit, non possidet simpliciter, sed solùm obtinet legitimam tentionem eius rei, possessioq̃ue manet apud eum, cuius antea ea res erat, quique cauere omisit: is enim per seipsum possidet adhuc ciuilit̃er, & per legitimum eius rei tentorem possidet naturaliter. Vnde, si res illa verè non erat eius, qui illam possidebat, & credebatur dominus, cauereq̃ue omisit, vtique missus in possessionem ex primo decreto, præscribere illam non incipit per eam tentionem aduersus verum dominum illius, sed is, qui cauere omisit, perseueratq̃ue in sua possessione eius rei, continuat aduersus dominum

præscriptionem, si nondum eam absoluerat, bonaque fides perseveret. *Ita habetur. l. si finita. §. Iulianus, & §. si quis autem ff. de dam. infect.*

Si missus ex primo decreto in possessionem [sect. 63] rei, unde damnum timetur, recedat ex ea re, non animo possessionem deserendi, sed timore ruinæ, aut aliqua alia ratione, non idcirco amittit possessionem illā: secus autem, si animo possessionem deserendi recedat, quod in dubio nunquam præsumitur. *Ita habetur. l. si finita. §. si quis metu, iuncta glossa ultim. ibi. ff. de damno infect.*

Quando aliquis postquam cauit de damno, [sect. 64] quod ex suo prædio timebatur, illud alienavit, si postea damnum sequatur, qui cauit, tenetur id damnum soluere: quoniam obligatio erat personalis, licet ratione prædii. *Ita habetur. l. si quis missum. §. ult. ff. de dam. infect.* Unde, ut sequentem successorem in eo prædio habeat etiam obligatum, ab eo etiam petere debet novam cautionem. Si verò prædium alienavit, postquam alius missus est ex primo decreto in illius possessionem, tunc, nisi ipsi solvantur damnum acceptum, & expensæ illuc factæ, eique caueatur de dāno futuro, retinet possessionem eius prædii quoad id, quod ex eo remanet, modo supra explicato: quod si ulterius perseveret contumacia, quia neque prior dominus, neque novus successor in illo, ei cauet, mittitur in possessionem illius ex secundo decreto, comparatque non solum verā possessionem illius civilem & naturalem, sed etiam dominium, nisi dominium re vera pertineret ad aliquem alium quartum, iuxta ea quæ subiungemus. Atque iuxta hanc nostram doctrinam iudicandum est de veritate, aut falsitate, glossarum. §. ult. citato.

Quandocunque misso ex primo decreto in [sect. 65] possessionem rei, unde damnum timetur, offertur cautio damni, admittere illam tenetur, & [[120]] relinquere prædium domino illius: modò tamē ei solva tur damnum, si quod iam evenit à puncto, quo cautio primò petita fuit, non interveniente mora culpabili in eo, qui illam petiit, occupandi possessionem ex primo decreto, postquam idcirco iussus est in eam mitti, quod dominus non caueret, ut supra dictum est: & modò ei solvantur expensæ utiles in ea re factæ ad illud usque tempus: atque modò ei caueatur sufficienter de damno, si quod ex eadem re in futurum evenierit. *Ita habetur. l. si finita. §. item videamus, & §. illud. ff. de dam. infect.* Is autem, qui missus iam est in possessionem ex secundo decreto, non tenetur admittere cautionem, esto ei offeratur, ut subijciemus.

Quando aliquis à iudice mitti iussus in possessionem ex primo decreto rei, unde damnum imminet, non admittitur ad eam possessionem à domino rei, sed resistitur, tunc datur huic non admissio actio in factum adversus dominum rei, nempe ad interesse, modo statim explicando, ut habetur. *l. dies. §. intra. ff. de dam. infect.* Eidem etiam competit actio in factum ad idem interesse ex interdicto, ne vis fiat ei qui in possessionem est missus, ut habetur. *l. ult. ff. ne vis fiat ei, qui in pos. mis. est.* Atque quidam existimant, iudicem eius causæ, non quidem delegatum, sed ordinarium, posse cogere dominum rei, pignoribus ex illo ad id extractis, admittere ad illam possessionem eum, qui ad eam mitti est iussus, ut §. si intra citato glossa refert, & innuit textus. *Ut verò habetur. l. prætor ait. §. in eum, & dilucidius. l. si finita. §. ult. iuncta. l. sequenti. ff. eod. titu.* Hoc interesse extenditur etiam ad tempus ante damnum subsequutum, ita scilicet, ut si damnum sequatur, perseverante contumacia, non cauendi, & non admittendi ad possessionem, teneatur, quantum teneretur si à principio cauisset, si id melius sit ei, qui in possessionem iussus est mitti. Si tamen is, qui ad possessionem non admisit, caueat illi, antequam damnum sequatur, de damno, si fuerit sequutum, vel eum admittat ad possessionem, ex primo decreto, tunc cessat omnino actio in

factum aduersus ipsum, perindeque res habet, ac si à principio cauisset, vel admisisset illum ad eam possessionem statim, atque à iudice admitti fuit iussus. Ita habetur iure postremo loco citato.

Licet autem actio, quæ competit aduersus prohibentem, nec admittentem ad aliquid, esse soleat annalis, vt notat glossa. 1. §. citando; hæc tamen est perpetua, & competit hæredi eius, qui in possessionem non est admissus, cæterisque eiusdem successoribus vniuersalibus, & particularibus, in prædio, cui damnum imminet, & aduersus hæredes & successores vniuersales & particulares eius in eo prædio, qui in possessionem non admisit. *Ita habetur. l. si quis missum. §. actio. ff. de damn. infect.* Ratio autem, cur hæc actio successoribus, & aduersus successores, concedatur, est: quoniam succedit loco cautionis nõ præstitæ, quæ tam late peti poterat, & præstari debebat, vt suprâ dictum est.

Etiam si is, qui in possessionem non admittit, pu [sect. 67] pillus sit, doli tamen capax, in eum competit actio in factum explanata. *Ita habetur. l. damni infecti. 1. §. si pupillus. ff. de dam. infect.*

Quando, qui resistit, nec ad possessionem admittit eum, qui ex primo decreto in possessionem est iussus mitti, non est dominus, seu possessor prædii illius, sed est aliquis alius, distinguendum est. Quoniam, vel id facit de mandato domini seu possessoris prædii, eoque ratum id habente postquam nouit nomine ipsius esse factum; vel sua propria autoritate. In primo euentu actio in factum competit aduersus vtrunque: sed vno satisfaciente, cessat aduersus alterum. In secundo verò non competit aduersus prædii possessorem, sed aduersus eum solum, qui prohibuit in possessionem intrare. Quòd si hic mancipium sit domini prædii, cuius possessionem intrare prohibuit, aut alicuius alterius, tunc vel dominus talis mancipii tenetur soluere integrum interesse, vel mancipium noxæ tradere pro eo interesse. *Hæc habentur. §. si pupillus citato, iuncto. §. non solum sequenti, & l. si quis missum in prin. ff. de dam. infect.*

Quando aliquis, ob cautionem non præstitam, [sect. 68] missus est in possessionem ex primo decreto eius prædii, vnde damnum imminet, restat vt, si contumacia in non cauendo perseueret, missio fiat in possessionem ex secundo decreto. Ea autem fieri debet causa cognita, non autoritate iudicis delegati, sed ordinarii eius causæ, vt habetur. *l. dies. §. si fortè. ff. de dam. infect.* Nec fieri debet statim, ac missio fuit facta in possessionem ex primo decreto, sed ex interuallo, ita vt dominus rem censeatur habere pro derelicto, saltem quia multo tempore non accedit ad cauendum. Quantum autem debeat esse hoc interuallum, iudicis arbitrio est relinquendum, attentis circumstantiis concurrentibus, vt glossa verb. misso. §. statim citando, rectè ait. Neque enim in re proposita expectandum est biennium, vt quando creditores mittantur ex primo decreto in possessionem bonorum debitoris non comparentis, expectatur biennium antequam missio fiat in possessionem ex secundo decreto, iuxta ea quæ Disp. 536. dicta sunt, ex dispositione iuris. C. de bon. iud. autorit. poss. Et præcipuè festinare non debet iudex ad concedendam possessionem ex secundo decreto, quando, qui non cauet, est absens reipublicæ causa, aut ex alia legitima, aut quando est minor. Atque, si tunc ex secundo decreto aliquem mittat in possessionem rei, vnde damnum timetur, conceditur postea absentibus ac minoribus restitutio in integrum, vt dicemus. *Hæc habentur. l. si finita. §. non autem, & §. si fortè. ff. de dam. infect.*

Quando, ob non præstitam cautionem, mitti [sect. 69] tur aliquis ex secundo decreto in possessionem rei, vnde damnum imminet, comparat eo ipso ciuilem & naturalem possessionem eius rei, eaque amittit, qui cauere omisit, atque adeò, esto res non fuisset quoad dominium eius, qui ita à possessione illius fuit deiectus, is tamen qui possidere illam incipit ex

secundo decreto præscribere incipit illam aduersus tertium illius dominum; idque cum titulo vi talis missionis ex secundo decreto in possessionem illius, per quam dominium comparasset, si res fuisset illius, qui proximè illam possidebat. *Ita habetur. l. dies. §. si fortè. l. prætoris in prin. iuncta glossa ibi verb. capere, & iunctis iuribus, quæ citat. l. prætor ait. §. de opere vers. eum cui. l. si finita. §. Iulianus*, illis verbis; *non priùs incipere per longum tempus dominium capere*, (per præscriptionem scilicet aduersus tertium dominū) *quā secundo decreto à prætore dominus cōstituatur*, cō paratione scilicet immediati possessoris, si verè sit dominus: id enim intendit prætor [[121]] per secundum decretum, & id verè fit, si immediatus possessor dominus erat, vt dominus esse credebatur. §. vbi autem, &. §. postquam. ff. de dā. infect. vbi ita habetur: *Post quam quis possidere iure dominii* (quod fit per secundum decretum) *à prætore iussus est, nequaquam locus erit cautionis oblationi*. Vbi vides, iure dominii, hoc est, tãquā dominū verè eo ipso effectum, possidere eum, qui in possessionē rei, vnde damnum imminebat, missus est ex secundo decreto, atque adeò possidere cū titulo ad præscribendum aduersus tertium dominum, si, qui ita à possessione deiectus est, non erat dominus eius rei. Item vides, postquam aliquis missus est in possessionem ex secundo decreto, locum iam non esse oblationi cautionis, vt relinquere teneatur eam rem, possessionemque illius, priori possessori ac domino: quare, si prior possessor erat dominus, statim, qui ex secundo decreto missus est in possessionē, est effectus dominus, neque indiget tempore ad præscribendum requisito, vt dominium comparatione illius acquirat. Quorsum enim id tempus expectaretur ad dominium acquirendum comparatione illius, si à possessione expelli non potest, etiam si ille alius offerat ei cautionem & reparationem omnium damnorum imminentium ac sequutorum.

Quando tamen alicui competit restitutio in integrum, quoniam ideo non cauit, quia absens fuit reipublicæ causa, aut ex alia legitima causa ex iis, quæ Disp. 80. & Disp. 574. explanatæ sunt, vel quia erat minor, tunc, esto aliquis ex secundo missus sit in possessionem rei illius, eo quòd cautio non fuerit præstita, comparaueritque possessionem ac dominium illius, per beneficium tamen restitutionis in integrum admittitur ad cauendum intra tempus disputationibus citatis explicatum, recuperatque dominium ac possessionem eiusdem rei. *Ita habetur. l. dies. §. si fortè. l. si finita. §. si fortè, &. §. postquam, &. l. eorum. ff. de dam. infect.* Sicut quando, iussus admitti ex primo decreto, [sect. 70] non admittitur, aut, postquam est admissus, expellitur, conceditur ei actio in factum ad interesse aduersus non admittentem, aut expellentem, vt suprà dictum est: ita quando, missus in possessionē ex secundo decreto, inde expellitur, aut, regrediens ad eam rem, in eam non admittitur, quia intrare non permittitur, conceditur ei eadem actio in factum, & insuper interdictum vnde vi. Si tamen vtatur actione in factum, vti ei non permittitur interdicto vnde vi: quoniam in concessione vtriusque actionis solum intenditur, ne missus in possessionem ex secundo decreto dānum patiat, non verò vt lucrum reportet. *Ita habetur. l. damni infecti. 1. §. non solum. ff. de dam. infect. & l. ult. ff. ne vis fiat ei, qui in pos. est missus*: quæ lex habet competere etiam interdictum, ne vis fiat ei, qui in possessionem est missus.

Quando multi in possessionem erant missi ex [sect. 71] primo decreto, eiusdem rei, quia diuersis eorū prædiis, aut vni omnibus communi, damnum inde imminebat; tunc, si omnes petant, vel simul, vel vnus post alium, mitti ex secundo decreto in possessionem eiusdem rei, eo quòd non caueatur, mittendi sunt, non omnino æqualiter, sed solū proportionem quadam, ita scilicet vt iuxta proportionem quoad valorem damni, quod vnusquisq; timet, ad damnum, quod cæteri timent, mittantur in possessionem, & consequantur pro indiuiso

partem dominiū eius rei. Si tamen aliquis eorū secerat in ea re aliquas expensas vtilēs, cæteri iudicio communi diuidūdo contribuere ei debēt in eadem proportionē expēsas factas. *Ita habetur. l. si finita. §. si ante, & §. cum aute. ff. de dam: infect.*

Quando iam aliquis, aut aliqui, missi sunt ex [sect. 72] secundo decreto in possessionem rei, vnde damnum imminebat, factique sunt illius domini, si alius accedat, qui sibi cauere de eadem re petat, ad illos, vtpote iam illius rei dominos, caue re de illa spectat; quòd si, iussi, non caueant, atque is ea de causa mittatur primò in possessionem illius ex primo decreto, & deinde, crescente contumacia, ex secundo, tunc iste solus incipit eam rem poffidere, & comparat dominium illius, cæteri que vtrumque eo ipso amittunt. *Ita habetur eadē. l. si finita. §. si plures vers. quòd si, & §. si ante. ff. de dam infect.*

Quando dominus rei, vnde dānum immine [sect. 73] bat: cauere de ea re noluit, ea que de causa, qui cautionem petiit, missus est in possessionē eius rei ex primo & ex secundo decreto, dominium que proinde ac possessionem illius acquisiuit, si eueniat, vt is, qui cauere noluit, aliud præ dium iuxta illud habeat, cui damnum ex illo etiam immineat, tunc, esto cauere sibi de eo petat, non tenetur alius ei cauere, quasi in pānam, quòd ipse cauere de damno ex eadem re noluerit. *Ita habetur. l. qui bona fide. §. si quis quia. ff. de dam. infect.*

Quando res, vnde damnum imminet, pigno [sect. 74] ri erat tradita, si is, cui ex illa damnum imminebat, sibi cauere petat, neque creditor de illa caueat, ea que de causa, qui sibi cauere petiuit, mittatur in possessionem illius ex primo & ex secundo decreto, tunc hic præfertur creditori illi pignoratitio, qui iuxta proportionem eius, pro quo sibi erat obligata, non cauit. *Ita habetur. l. bis (alias eis). ff. de dam infect.* Lex verò, *cum postulassem. §. damni. ff. eod. titu.* habet: Si ex domo aliqua damnum imminebat prædio meo, & ego petii mihi cauere de eo damno, atque, quòd non fuerit cautum, missus sim in possessionem illius ex primo & ex secundo decreto, consequutusque proinde sim dominium & possessionem illius, si superueniat creditor, cui pignori erat obligata, (videtur sumere pignus latè pro hypotheca, quod non infrequenter fit in iure, vt in materia de pignoribus est dictum) non esse admittendam pignoratitiam, seu hypothecariam, prosecutionem, qua ea domus de mea potestate extrahatur oc vendatur, vt illi solutio fiat, nisi paratus ille sit mihi soluere impensas, quas in ea fecerim. Hanc legem ego intelligo, quādo creditor ille requisitus non fuerat, vt ipse etiam caueret de eo damno: nam, si, requisitus, non caueret, amitteret totum ius, quod in ea re habebat, iuxta dicta superiùs in hac disputatione: atque in hoc euentu loquitur lex his citata, quę huic alteri legi non repugnat. Additur verò in eodem. §. non idem competere emptori domus, qui expensas in ea domo empta, sua que iam effecta, fecerit: nam creditor hypothecarius agere poterit, vt sibi ex ea domo soluatur suum debitum, quo ad id, quod ea domus valet, secluis expensis in ea domo factis: melioramenta quippe, & expensas necessarias; sine quibus deterior esset domus, nullus negare potest, integras debero [[122]] remanere emptori. Reddit verò §. ille rationem diuersitatis, cur meritò statuatur, vt in eo euentu, qui missus est in possessionem ex secundo decreto, factusque est dominus eius rei, eo quòd sibi non fuerit cautum de damno infecto, soluēdæ sint omnes expensæ, admittendumque alioquin non sit, fieri exequutionem in ea re ob debitum, pro quo fuerat hypothecata; non verò idem statuendum sit in emptore similis domus.

Quoniam emptor petere fidei iussoriam cautionem potuit à venditore circa illam domum, quòd domus illa alteri non erat obligata, & quòd, si aliquod damnum ipsi eueniret ex eo, quòd ea domus non esset omnino libera, ei solueretur: qui verò idcirco missus est in possessionem

domus ex secundo decreto, quòd sibi non caueretur, nullam talem cautionem petere potuit, vt euitaret damnum amittendi expensas, quas in ea re bona fide faceret.

Atque hæc dicta sint de tota hac materia, satis obscurè, ac sine methodo, tradita in iure. Coactus autem sum vnica disputatione eam totam comprehendere: quoniam non occurrit mihi modus, quo eam commodè secare possem in multas.

De damno proueniente ex aqua ratione operis facti in viouino prædio: cuius operis ac damni comparatione competit ciuili iure actio aquæ pluuiæ arcendæ. Disput. 704.

SVMMARIVM.

- 1 . D Amnum, ob quod actio aquæ pluuiæ arcendæ competit, in futurum pendet, & quod sit, & ad quæ competit ea actio. Et quæ actiones competant ob damnum datum ante actionem de aqua pluuiæ arcenda contest atam.*
- 2 . Actio aquæ pluuiæ arcendæ non competit, si quis sciens fieri opus, ex quo videbat aquam pluuiam nocere prædio suo, tacuit: secus si ignorans id damnum inde prouenturum.*
- 3 . Aquæ pluuiæ nomine, quoad actionem aquæ pluuiæ arcendæ attinet, etiam fontium & fluuiorum aqua intelligitur.*
- 4 . Actio aquæ pluuiæ arcendæ præstè, quoad quæ cõpetat. Et quo ad seruitutes, aut quasi seruitutes, confessoria actio, & negatoria vniuersalis actio, quid.*
- 5 . Actio aquæ pluuiæ arcendæ non competit, neque aliqua alia, vt ex prædio superiori non fluat aqua, quæ naturaliter in inferius fluit, esto inde detrimentum inferiori sequatur, quando non est seruitus in superiori, vt non ita fluat.*
- 6 . Seruitus si sit in vno prædio, non naturalis, sed pacto acquisita, vt aqua alterius prædii in ipsum deriuetur, intelligitur de consueta deriuari, non verò de incremento, simul excrescat.*
- 7 . Actio aquæ pluuiæ arcendæ competit vt destruat opus, & compensetur damnum à lite contestata sequutum, si in agro inferiori, in quem aquæ naturaliter fluunt, fiat aliquid, unde in superiorem restagnent.*
- 8 . Actione aquæ pluuiæ arcendæ vtili cogitur dominus agri inferioris permittere dominum agri superioris purgare suis sumptibus vias, quibus aqua naturaliter descendebat in agrum inferiorem, quando restagnat in superiorem ob vias in inferiori oppletas sine opere aliquo in eo facto.*
- 9 . Actione aquæ pluuiæ arcendæ cogere potest dominus agri inferioris, in quem natur aliter fluunt aquæ ex superiori, dominum agri superioris, vt reducat rem in pristinum statum, quando ob aliquid factum, aut destructum in superiori, aliter fluunt, aut qualitate diuersa affectæ, ita vt plus noceant, quàm antea.*
- 10 . Actione eadem potest dominus agri inferioris cogere dominum agrisuperioris, vt patiat seruitutis inferioris refici aggerem, aut aliud agri superioris, si sine notabili illius præiudicio id*

fieri potest, quando inde sequitur, ut aqua ex superiori fluat, aut aliter fluat, quàm consuevit, cum dāno inferioris.

11 . Aqua agri superioris si pacto, præscriptione, aut consuetudine loci, diuertatur aggeribus, aut fossis, vel alia ratione, ne descendat in inferiorem, non potest dominus agri superioris impedire eam seruitutem. Vicini tamen reficere tenentur eos aggeres, aut fossas, vel instrumenta.

12 . Seruitutis iure fossam existentem in agro superiori, ne aqua ex illo deriuetur in inferiorem, si restagnet in agrum, in quo est, quòd sit repleta, dominus agri inferioris tenetur eam purgare ac reficere.

13 . Actio aquæ pluuiæ arcendæ non competit domino agri inferioris, si ob seruitutem, quam fundus superior ad id habet, aqua decurrat ex illo ac noceat. Et quanto tempore easeruitus præscribatur.

14 . Actione aquæ pluuiæ arcendæ agi aduersus eum potest, ut patiat purgari, aut ut ipse purget fossā, quam seruitute habet in agro suo, si restagnet in vicinos agros, & ut soluat damna sequuta à lite contestata. Eadem actio competit aduersus vicinum, inter cuius & meum prædium interiecta est fossa, quam valente me purgare quoad medietatem, quòd restagnet in meum prædium, non vult ipse purgare quoad suam medietatem, aut contribuere ut purgetur. Idem de refectione aquæductus communis. Et de refectione septi fluminis, quo deducitur aqua ad diuersa molendina: contribuere enim tenentur domini molendinorum.

15 . Actio aquæ pluuiæ arcendæ non competit, si aquæ noceat alicui prædio ob opus in alio factum a tempore, de cuius initio non extat memoria, aut sufficiēte ad præscribendum. Et quo modo tempus, de cuius initio non extat memoria, probetur.

16 . Actio aquæ pluuiæ arcendæ mihi competit, quatenus mea id interest, si ex opere facto aqua noceat viæ prædio meo in alio debitæ.

17 . Ripæ quando priuatæ quo ad dominium, eorum videlicet dominorum, quorum sunt prædia, quæ ad illas terminantur, & quando publicæ, communes omnibus quoad vsum.

18 . Actio aquæ pluuiæ arcendæ competit dominis agrorum, etiam eorum, qui in vltiori parte ripæ fluminis sunt, quando ex aggeribus, factis in ripa alicuius priuati, vnda nocet aliis agris, nisi tales aggeres facti sint à tempore, de cuius initio non extat memoria, aut alia ratione ritè. Quòd si ex eo, quòd non fierent, longè maius detrimentum sequeretur agris, in quorum defensionē facti sunt, soluenda est dominis aliorum agrorum æstimatio damni, quod ex illis eis prouenit. Lege longam ea de re disputationem.

19 . Flumen præssè, riuus, & torrens, quid.

20 . Flumen publicum quid.

21 . Ripa fluminis quid. Est locus publicus, saltena quoad vsum, sicut & flumen.

[[123]] 22 . Alueus fluminis quid. Qualiter varietur. Est locus publicus, sicut & flumen, dum aluei fluminis rationem retinet.

23 . Fossa flumini publico si fiat, per quam tanta pars fluat, quæ fluminis, & non riui, rationem subeat, locus publicus efficitur.

24 . In flumine quid factum dicatur, & quid in ripa.

- 25 . Fluminum, quæ nauigabilia dicantur, quæ efficere flumen nauigabile, quæ non item.
- 26 . Flumine in nauigabili, aut quod nauigabile efficit, neque in eius ripa fieri potest aliquid, quo nauigatio, aut statio nauigiorum, deterior reddatur. Si factum sit, in pristinum redigitur statum. Et quæ pænæ in hoc regno statutæ.
- 27 . Flumine in publico, aut in eius ripa, nihil fieri potest, ob quod flumen cursum mutet, quem in æstate solet tenere, noceatque ea ratione alienis agris. Si autem factum sit, in pristinum redigitur statum. Licitum verò est cuique, se tueri aduersus inundationes, etiam cum aliorum præiudicio, quibus fas similiter est se tueri, modò tamen id in causa non sit, quòd flumen cursum statis mutet. Et quid æstatis tempus sit.
- 28 . Flumine in publico, aut in eius ripa, fieri possunt aggeres, aut quoduis aliud, ad tuendos proprios agros, modò aliis caueatur de dāuo infecto. Quòd si longè maius damnum vitetur eis aggeribus, quā sit, quod aliis sequitur, destruendi non sunt, sed compensandum est damnum dominis aliorum agrorum.
- 29 . Torrentis aquam fas est auertere opere facto in proprio prædio, esto per accidens inde sequatur detrimentum aliorum. Modò tamen id non fiat sine proprio emolumento, animo aliis nocendi.
- 30 . Seruitus, aut quasi seruitus, vt præscribatur aduersus rem aliquam publicam, etiam si continua sit, non minus tempus sufficit, quàm de cuius initio non extet memoria.
- 31 . Fluminis publici ob cursum mutatum ex aggeribus factis, aut ex alia re facta, damnum aliis proueniens, non præscribitur ea quasi seruitus minori spatio, quam de cuius initio non extet memoria.
- 32 . Actio aquæ pluuiæ arcendæ non competit aduersus opus factum in flumine, aut in ripa, vel alibi, esto inde aliis detrimentum proueniat, quando principis, senatus, vel autoritate ab eis deriuata, factum est. Fieri tamen tunc non debet, nisi in magnum commodum publicum, & compensatione iis facta, quibus damnum prouenit.
- 33 . Actio eadem non competit aduersus opus factum in loco publico quo ad directum & utile dominium simul. Si aqua noceat ex opere facto in loco priuato, quæ tamen transit per publicum, cōpetit. Et quæ actiones competant aduersus priuatum, qui in loco publico priuata autoritate aliquid fecit.
- 34 . Actio eadem competit aduersus facientem opus in loco distante, vnde aqua nocet prædio meo. Aduersus vicinum verò, per cuius prædium pertrāsit, competit etiam, si ille potest id impedire, nec impediat.
- 35 . Actio eadem non competit, si aliquid ad cultum vtiliorem agrorum pertinens fiat in vno prædio, vnde aqua alteri noceat.
- 36 . Aquam, quæ in suo fundo oritur, aut in illum deriuatur, seruitute in contrarium non existente, retinere sibi quis potest, etiam facto ad id opere, in suo fundo, & non aliene. Actions tamen de dolo prohiberi id potest, si animo nocendi vicino, & nō vtendi iure suo, id efficiat.
- 37 . Aquam publicam, ad prædia certo modo irriganda deputatam, non potest sibi quis plus usurpare, quàm lege, pacto, aut consuetudine sit introductū. Si autem aliquid efficiat, quo eam sibi plus usurpet, actio competit aquæ pluuiæ arcendæ.

38 . Aquæ venas si quis præscindat in suo fundo, quæ deriuabantur in alienum, aut puetum fodiat, quo confluât aquæ ex fundo alieno, nullo actio aduersus eum competit. Si tamen non animo vtendi iure suo, sed nocendi id efficiat, quod præsumitur, quando absque vllo suo emolumento id efficit, actione de dolo cogitur rem deducere ad priorem statum.

39 . Actione aquæ pluuiæ arcendæ si quis destruere aliquid iubeatur, solùm tenetur id efficere, quatenus nocet & non plus.

40 . Actionis aquæ pluuiæ arcendæ post litem contestatam, si factum sit aliud opus, vnde nouum timeatur damnum, noua actio erit intentâda. Quâdo verò factum est aliud, quod impedimentum sit, ne opus destruat, circa quod lis erat contestata, eatenus destrui debet, quatenus ad id sit necesse.

41 . Actione aquæ pluuiæ arcendæ si opus sit destruendum, & dominus fundi illud fecit, aut tacitè, vel expresse, illud fieri mandauit, aut ratum habuit, sumptibus illius est destruendum, & solui debene damna, post litem contestatam sequuta, neque satis est, si cedat prædio: hæredesque illius post eius mortem ad eadem tenentur. Quando ipso nec tacitè consentiente, necratum habente, fuit factum, solùm tenetur pati vt destruat. Ac si damnum timeat, petere poterit, vt sibi de eo caueatur. Expensis verò eius, qui illud fecit, est demoliendum, & soluenda sunt damna. Si sit mancipium, dominus ea soluit, aut mancipium noxæ dat.

42 . Actio aquæ pluuiæ arcendæ utilis competit usufructuario aduersus proprietarium, & aduersus dominum vicini prædii: & competit aliis aduersus usufructarium: qui, omisso usufructuario, agere possunt aduersus proprietarium.

43 . Actio eadem directa competit emphyteutæ ac feudatario: & competit etiam aduersus emphyteutâ & feudatarium.

44 . Actio eadem competit aduersus fabricantem sepulchrum, si inde aqua noceat, etiam si mortuum iam in illud intulerit. Neque destruendo postea sepulchrum actione aquæ pluuiæ, tenetur de sepulchro violato.

45 . Actio aquæ pluuiæ arcendæ quatenus competat aduersus habentes commune prædium, vnde dñum prouenit: & quatenus competat habentibus commune prædium, cui damnum sequitur.

46 . Actio aquæ pluuiæ quatenus competat aduersus eum, qui opus fecit, vnde damnum prouenit, & postea prædium alienauit, & quatenus aduersus sccessorem.

47 . Actio eadem, quando dominus prædii, qui patitur damnum, illud alienauit, quousque ad successorem, vel ad alienantem, pertineat.

DIsputatio hæc affinis est præcedenti. Sicut [sect. 1] enim damnum, de quo præcedente disputatione est dictum, nondum est datum, sed imminet ac pendet in futurum: ita damnum, pro quo competit actio aquæ pluuiæ arcendæ, nondum est datum, sed imminet in futurum. Ita habetur, l. ante ius. §. in hoc iudicium. ff. de aqua plu. arc. cu-[[124]]ius verba sunt: In hoc iudicium, sicut in damni infecti, suturum damnum venit: cùm reliquis ferè omnibus iudiciis præteritum præstetur. Idem habetur. l. 1. §. 1. ff. eod. titu. Actio quippe aquæ pluuiæ arcendæ, solùm competit, quando aliquid fit in prædio aliquo, siue id ager sit, siue aliud prædium, ratione cuius aqua nocet agro vicino, siue sit interiectum aliud medium prædium inter vtrumque, siue non. Atque tûc domino agri, cui aqua ita nocet, nocerêve potest, competit actio aquæ pluuiæ arcendæ, aduersus dominum prædii, vbi id factum est, ad duo.

Primum est, vt destruat, quod in eo prædio est factum, vnde imminet periculum, quod aqua suo agro noceat, resq; ad pristinum redigatur statum, saltem ita vt periculum id cesset. Secundum verò est, vt, si quod damnum, post actionem aquæ pluuiæ arcendæ aduersus eum contestatam, aqua in eo agro dederit ratione eius, quod in illo altero prædio est factum, illud soluat. Et quia hoc damnum, vi huius actionis soluendum, nondum est datum tempore litis contestatæ, sed pendet ac timetur in futurum, dicitur actionem hanc, sicut & actionem damni infecti, respicere damnum, non præteritum ac iam datum, sed futurum. Damnum enim, quod ante litem contestatam inde euenit, petitur inter dicto quod vi aut clàm tãquam subsequutum ex re facta indebitè vi, si is, cuius agro nocet, extra iudicium fieri vetuit, dum fieri intentabatur, aut fiebat; aut clàm, si non vetuit, quia vel id fieri, vel damnum inde suo agro imminere, ignorabat, *vt habetur. l. Anteiis citata. §. de eo, & no tat glossa vlt. l. si tertius. §. officium. ff. eod. tit u. consentiuntq. l. 1. & sequentes. ff. quod vi aut clam*, atque ex dicendis Disputat, 706. circa interdictum quod vi aut clàm, liquidò constabit. Prædicta verò omnia patent *ex. l. 1. §. 1. ex. §. officium citato, ex. l. Anteiis. §. hoc iudicium, & duob. sequentib. ff. de aqua plu. arcen. vbi. §. de eo, habetur, quòd si periculum timeatur ex eo opere, sed non multum ac vrgenter, tunc iudex præcipere debet ei, in cuius prædio factū est, vt vel caueat de damno infecto, hoc est, quòd soluet damnum, si quod inde fuerit sequutum, vel opus destruat, remque in pristinum statum redigat. Quando verò experientia postea deprehenderetur, damnum inde sequi, tunc, & iubendus esset damnum subsequutum soluere, vt antea cauerat, & destruere opus, ne damnum vlteriùs ex illo sequeretur. Quo loco obserua, ad damnum præteritum, culpa eius, qui tale opus fecit, sequutum, etiam competere actionem legis Aquiliæ, seu in factum illi subsidiariam, argumento legis vnica in fine. ff. de ripa tuenda.*

Quando aliquis, sciens & prudens fieri opus [sect. 2] in prædio vicino, vnde agro suo damnum aquæ pluuiæ imminebat, tacuit, fierique illud est passus, tunc non competit ei actio aquæ pluuiæ arcendæ; quoniam consensisse videtur in eo opere cum eo damno ac detrimento suo agro. Secus res habet, si tacuit, quia ignorauit posse inde id damnum sibi euenire: quoniam tunc non censetur consensisse, vt id opus cum eo suo detrimento fieret. Primum habetur. *l. Labeo, & secundum. l. sed hoc, proximè sequenti ff. de aqua plu. arcen.*

Nomine aquæ pluuiæ in re propofita non so [sect. 3] lùm intelligitur aqua imbrium, quæ de cælo decedit, siue hyberna, siue æstiu sit, sed etiam, quæ cum illa mixta fluit, *vt habetur. l. 1. in prin. ff. de aqua pluuiæ arcenda: qualis est, quæ excaturit ex fontibus, & quæ in fluminibus fluit. Aqua enim fontium incrementum magnum accipit ex aqua pluuiæ, quæ terræ imbibita, simul scaturit cum aqua ex aëre in cauernis terræ generata, multumque aqua fontium ex pluuiæ pendet: si enim anno aliquo modicum pluatur, fontes exsiccantur. Flumina verò ex aqua pluuiæ ac fontium constant. Vnde, vt videbimus, si ex opere aliquo aqua fontium, aut fluminum, vicino agro noceat, competit actio aquæ pluuiæ arcendæ, vt id opus destruat, & vt soluatur damnum, post litem contestatam, ea aqua datam.*

Merito suprà diximus, actionem aquæ pluuiæ [sect. 4] solùm competere, si aqua noceat agro obaliquid factum in vicino prædio, siue id prædium ager sit, siue quoduis aliud. Quoniam, *vt Vlpianus. l. 1. §. item sciendum. 2. ff. de aqua plu. arcen. cum Labeone, Cascellio, & Cassio, ait, hæc actio solùm competit, quando aqua eo modo nocet agro, ex quocunque prædio illa proueniat: si verò noceat ædificio, aut oppido, non competit ea actio, sed negatoria generalis. Quod vt intelligas, obserua. Actionem ad vendicandam seruitutem, quæ debetur ab vno prædio alteri, (idem intellige de seruitute vsusfructus, qui personæ debetur) si, cùm*

debeatur, denegetur, appellari cōfessoriā. Contrarium verò, qua quis, prætēdēs vsumfructū sibi deberi, aut seruitutem aliam suo prædio, repellitur, contendendo non deberi, & vt soluat valorem vsus talis seruitutis iniustè vsurpatæ, appellari negatoriam vniuersalem: co quòd comparatione cuiuscunque seruitutis, aut quasi seruitutis, locum habeat: vt hæc omnia habentur. *l. 2. in prin. ff. si seruitus vendicetur*. Hac igitur actione ait ibi Vlpianus, & affirmant Accursius & Bart. ibidem, esse agendum ad damnum, quod ex stillicidiis, aut ex fluminibus, hoc est, ex maiori vi aquæ, quàm sit stillicidium, sequitur edificio cuicunque, aut oppido, ob opus in alio prædio factum, vt destruat id opus, ac refarciatur damnum: qua eadem actione, vt ibidem Accursius notat, agi etiam potest ad damnum aquæ pluuiæ, quod agro similiter imminet: eo quòd negatoria illa actio communis sit seruitutibus omnibus. Neque obstat, quòd Pileus, ab Accursio ibidem relatus, voluerit, actionem negatoriam non competere, nisi præcesserit seruitus, quæ fuerit amissa aut remissa. Non, inquam, id obstat: quoniam æquè ea actio locum habet in seruitute, quam quis de nouo occupare velit, contendatve sibi deberi, cū nunquam antea fuerit ei debita: qui autem aquam indebitè ex suo prædio immittit in quo dcunque aliud prædium vicinum, siue id ager sit, siue non, nisi ei obsistatur intra tempus necessarium ad eam seruitutem in prædio sui vicini comparatione sui præscribendam, sanè eam seruitutem in eo, vt videbimus, sibi acquirit: quare agi optimè potest ea negatoria vniuersali actione ad illum repellendum, ne talem seruitutem præscribat, vt opus, vnde id damnum imminet, destruat, & resarciat damnum, si quod inde fuerit subsequutum. Etiam competit actio in factum subsidiaria legi Aquiliæ, pro dāno ita dato culpa facientis id, vnde subsequutum est, vt ea aqua noceret, *argumento. l. unica in fine. ff. de ripæ [[125]] tuenda*. Vtinam tot subtilitates, diuersitates, ac distinctiones, abscinderentur à iure. Certè lex. 13. titu. 32. part. 3. permixtim concedit actionem, vt destruat opus, quantum satis sit vt non noceat, & vt resarciatur damnum, siue agro vicino immineat, siue edificio, nihil exprimendo, qua actione sit id petendum.

Illud deinde obserua, quando aqua ex vno [sect. 5] prædio naturaliter fluit in aliud, hoc est, minimè adiuta opere, aut facto aliquo, tunc, quando non est seruitus in prædio, vnde fluit, comparatione eius, in quod fluit, vel pacto, vel præscriptione acquisita, vt non ita fluat, vtique quantūcunque noceat, & in quacunque quantitate fluat, nulla competit actio domino prædii, in quod fluit, vt impediatur, euiteturque id damnum ipsius: quo niam inferiora prædia eam habent quasi seruitutem naturalem comparatione superiorum, vt recipiant aquam ex illis naturaliter fluentem. Sicut etiam suscipiunt pinguedinem terræ, quæ ex superioribus agris descendit, & quam secum aqua fluens defert. *Ita habetur. l. 1. §. iidem aiunt. 1. §. item sciendum. 1. §. in summa, & apertius. §. vlt. l. 2. in prin. ff. de aqua plu. arced. & l. 14. titu. 32. part. 3.* Quæ exprimit, etiam si aqua, quæ ita naturaliter descendit, secum deferat lapides, & alia, qui bus noceat agro inferiori, ad nihil teneri dominum fundi superioris. Paulus autem Castrensis, & Oldrandus, ibidem à Greg. Lopez relati, voluerunt, si aqua naturaliter descendat in magna quantitate, & multum noceat agro inferiori, posse agi aduersus dominum agri superioris actione aquæ pluuiæ arcendæ, ad damnum, atque vt illud impediat. Ipse verò Greg. Lopez (tametsi non admodum firmus) meritò contrarium affirmat.

Licèt enim, quando esset seruitus in vno agro, [sect. 6] non quidem naturalis, sed pacto, aut præscriptione, acquisita, vt susciperet aquam alterius prædii, quam, seclusa ea seruitute, pacto, aut præscriptione, acquisita, recipere non teneretur, sed agere posset actione aquæ pluuiæ arcendæ, intelligenda non esset ea seruitus, de aqua excessiua, quæ temporis progressu flueret, quæque lōgè in maiori esset quantitate, quàm quæ a principio fluebat, & de longe maiori

damno, quod temporis progressu ex illa redundaret, quàm quod à principio redundabat; quoniam per epicheiam non est censendum, pactum, & concessionem illam seruitutis, ad id incrementum postea sequutum extendi, *argumento. l. si cui. ff. de sernit.* imò verò id habetur expressè. *l. 2. §. ult. ff. de aqua plu. arcend.* neque maior seruitus præscriptione censetur acquisita, quàm quæ illucsq; tempore ad præscribendum requisito, fuerit permissa; nihilominus longè aliter res habet in seruitute naturali, quam inferiores agri habent ad suscipiendam aquam naturaliter fluentem ex superioribus: eam quippe totam, siue magna sit, siue parua, & siue multum, siue parum, aut nihil, noceat, sed potius prosit, tenentur suscipere: quoniam id postulat natura ipsa rei, ac disponunt iura consentaneè ad eandem rei naturam.

Ex hac quasi naturali seruitute, quam agri in [sect. 7] feriores habent comparatione superiorum, vt suscipiãtaquã ex superioribus naturaliter effluẽtem, prouenit, quòd si dominus agri inferioris aliquid efficiat in suo agro, vnde impediatur fluxũ ac cursum illum naturalem aquarum ex agro superiori, illasque restagnare retrocederẽ faciat in agrum superiorem, cursũmve mutare, competat domino agri superioris actio aquæ pluuiæ arcendæ comparatione domini agri inferioris, vt id opus destruat, soluatque damnum, quod ex ea aqua ipsi prouenerit à puncto litis contestate. *Ita habetur. l. 1. §. sciendum. 1. ff. de aqua plu. arcend.*

Quando dominus agri inferioris nihil fecit, [sect. 8] quo impediretur naturalis cursus aquæ descendantis ex superiori, sed ipsamet aqua oppleuit naturalem viam, qua fluebat, eaque ratione restagnare retrocederẽque cæpit in superiorem agrum, illique detrimentum afferre; tunc, quamuis de rigore iuris ad nihil teneatur dominus agri inferioris, ex equitate tamen cogitur actione vtili aquæ pluuiæ arcendæ, permittere dominũ agri superioris purgare in eo inferiori agro viam, qua fluebat aqua, vt eo modo naturaliter fluat, quo antea fluebat: id tamen fieri debet sine vllo alio detrimento domini agri inferioris. Ita aduersus Labeonem, *Paulus iurisconsultus cum Namusa. l. 2. §. apud Namusam. ff. de aqua plu. arcend.*

Rursus quamuis (non existente seruitute in [sect. 9] agro superiori comparatione inferioris pacto, aut præscriptione, locive consuetudine, comparata) domino inferioris agri non cõpetat actio aquæ pluuiæ arcendæ comparatione domini prædii superioris, quando aqua ex eo prædio nõ aliter fluit, quàm flueret naturaliter, siue in eo superiori prædio aliquid effecerit, aut opus aliquod destruxerit, siue non: si tamen ex destructione operis, aut ex opere aliquo facto, in eo superiori prædio, aliter aqua fluat, quàm flueret naturaliter, quia vel in maiori quantitate fluit, vel fluit vnita, vel sordida, aut calida, & quauis harum rationum, aut aliqua alia, plus nocet agro inferiori, quàm alioquin foret nocitura, tunc domino agri inferioris competit actio aquæ pluuiæ arcendæ aduersus dominum prædii superioris, vt rem eatenus ad pristinum statum redigat, quatenus non plus noceat, quàm nocuisset, si nihil factum, aut destructum, fuisset in prædio superiori. Hoc verò sequens exemplum adhibetur. *l. 3. in prin. ff. de aqua plu. arc.* Si in prædio superiori nascatur multum aquæ, fiantq; in eo fullonica, hoc est, stagna, & alia necessaria, vt ea aqua res abluantur, neque inde sequatur, aquam aliter fluere, quàm naturaliter flueret, si factæ non fuissent tales fullonica, neque plus aliqua alia ratione nocere, quàm si eadem fullonica non fuissent factæ, tunc domino agri inferioris nullam competere actionem aduersus dominum prædii superioris. Ceterum si inde sequitur, aquam, quæ sparsim fluebat, fluere vnitam, & concitatiorem, caque de causa plus nocere, aut sequitur flucre conspurcam, vel fluere ex eisdem fullonicis, aut ex balneo calidam, ac nocere, tunc posse agere actione aquæ pluuiæ arcendæ, aut etiam actione iniuriarum, vel interdicto

vti possidetis, quando conspurca aut calida fluit. Hęc omnia, pręter ius citatum, habentur. *l. 1. §. item sciendum. 1. c. §. sed c. si vicinus. ff. de aqua plu. arc.*

Si in prędio superiori erat agger, vel natura [sect. 10] lis, vel manufactus, qui impediēbat aquam descēdere ac nocere agro inferiori, tunc siue initii talis aggeris extaret memoria, siue non, si vis aquę illum destrueret, indeque sequeretur, aquā [[126]] descendere, ac nocere agro inferiori, saltem plus, quā antea noceret, vtique, quamuis ex iuris rigore nulla actio competeret domino agri inferioris; ex æquitate tamen ei conceditur vtilis actio aquę pluuię arcendę aduersus dominum prędii superioris, vt permittat eum aggerem refici, si sine notabili suo incommodo ea refectio fieri possit. *Ita habetur l. 2. §. item Varus, c. §. quanquam. ff. de aqua plu. arc.* Concinit *lex Anteiū. §. cū igitur. ff. eod. titu.* quę habet, quando aliquid superioris agri decedit ob loci naturam, absque vllo facto domini, idque in causa est, vt aqua noceat agro vicini, non teneri dominum superioris agri, nisi permittere, vt sumptibus vicini, sine suo damno, reficiatur. Itemque, si ædificium subsederit, idque in causa sit, vt aqua vicino noceat, ad nihil aliud teneri, quā ad permittendum similiter, vt sumptibus vicini, sine suo damno, reficiatur.

Quando aqua agri superioris, vel pacto, vel [sect. 11] pręscriptione, vel loci consuetudine, diuertitur aggeribus, aut fossis, vel aliqua alia ratione, ne descendat in agrum inferiorem, non potest dominus agri superioris eam seruitutem fui prędii impedire. Eiusmodi tamen aggeres, ac fossas, neque facere, neque reficere, tenetur do minus agri, in quo sunt, sed vicini tenentur eas facere ac reficere, in quorum commodum sunt factę, *Ita habetur. l. 1. §. vlt. ff. de aqua plu. arc. c. l. 15. titu. 32. part. 3.*

Quando in agro superiori est fossa iure ser [sect. 12] uitutis, ne aqua ex eo agro deriuetur in inferiorem, si terra repleatur, aut aliis rebus, ita vt restagnet in agrum, in quo est, eique noceat, vicinus, qui in suum commodum illam fecisse videtur, est cogendus eam purgare, ne agro, in quo est, noceat, *Ita habetur. l. 2. §. apud Anteiū. ff. de aqua plu. arc.*

Quando ex fundo superiori aqua decurrit nō [sect. 13] naturaliter in agrum inferiorem, ob seruitutem, quam ad id fundus superior habet in inferiori, siue pacto acquisitam, siue pręscriptione, tunc, esto damnum inde recipiat ager inferior, non competit domino illius, actio aquę pluuię arcendę aduersus dominum prędii superioris. *Ita habetur. l. 2. in prin. ff. de aqua plu. arc. c. l. 14. titu. 32. part. 3.* Porrò, cū eiusmodi seruitus continua sit, aut quasi continua, iuxta ea quę Disput. 11. dicta sunt, ad eam pręscribendam, satis est sine titulo spatium decem annorum inter pręsentes, & viginti inter absentes, id est, si is, aduersus quem est pręscribenda, absens sit, vt Disput. 70. ostendimus, &, in re proposita, affirmat glossa. *l. 1. §. vlt. ff. de aqua plu. arc. habeturque expresse. l. 14. titu. 32. part. 3.*

Si in agro vicino erat fossa, quę à tempore, de [sect. 14] cuius initio non extat memoria, (idem intellige, si sit pacto, aut consuetudine pręscripta) recipere solebat aquas decurrentes ex agris vicinis, &, quòd terra, lapidibus, aut aliis similibus rebus, esset oppleta, aqua restagnaret in agros vicinos, nec pateretur eam à vicinis purgari, agi aduersus eum posset actione de aqua pluuię arcenda, vt vel purgari pateretur, vel ipse eam purgaret, & agi insuper posset ad damna subsequuta à lite contestata. Si autem in confinio duorum agrorum esset fossa vtrique agro communis, in quam aquę confluerent, &, cū vnus eorum purgare vellet partem, quę ad ipsum attineret, ne aqua in suum restagnaret agrum, alter id impediret, competeret aduersus eum actio aquę pluuię arcendę. Vtrumque habetur. *l. 2. §. apud Labeonem. ff. de aqua plu. arc. c. l. 15. titu. 32. part. 3.* vbi additur, si fossa sit communis multorum agrorum, in omnium vtilitatem facta, vt quia eò confluunt aquę diuersorum agrorum, atque elabuntur,

tunc vnumquenque vicinum teneri purgare partem, quæ per suum agrum pertransit, aut contribuere cum vicino, qui agrum habet ex altera parte, quando fossa pertransit inter duos agros diuersorum vicinorum in vtriusque vtilitatem, atque ad hæc cogendi sunt vicini: quia, quod in cōmunem vtilitatem aliquorum est factum, aut inseruit communi eorum vtilitati, sumptibus communibus eorundem est pro rata reficiendum ac conseruandum. Idem dic de aquæducto ad irrigandum. Ita habetur. l. 15. citata, idque confirmat ibi *Greg. Lopez argumento. l. sed & Ioct. §. sed & si. ff. finium rigund. & l. ex parte in prin. ff. famil. hercis.* Atque inde cum Bart. infert, si reficiatur fluminis obstaculum, quo aqua ducitur ad diuersa molendina, (septum appellatur. l. 1. in prin. ff. de riuis, ab Accursio ibi vers. excogitata, & ab aliis esclusa nuncupatum, Hispanè verò *pressa* dicitur) dominos eorum molendinorum cogendos esse contribuere ad eos sumptus pro rata.

Quando damnum prouenit agro alicui ex a [sect. 15] qua ob opus factum in alio prædio à tempore, de cuius initio non extat memoria, vel à tanto tempore, quantum satis sit ad præscribendum, vt aqua eo modo in eum agrum fluat, tunc non competit domino eius agri actio aquæ pluuiæ arcendæ. *Ita habetur. l. 2. §. Cassius. l. quod principis. ff. de aqua plu. arc. & l. 14. titu. 32. part. 3.* Quomodo autem sit probandum, aliquid esse à tempore, de cuius initio non extat memoria, *habetur eadem. l. 2. §. idem Labeo. 2.*

Si ex opere facto in agro, in quo seruitus iti [sect. 16] neris debetur prædio meo, aut ex opere facto in vicino alio prædio, sequatur aquam reddere deteriore eam viam, possum tunc nomine mei prædii, cui ea seruitus debetur, agere actione aquæ pluuiæ arcendæ, quatenus id redundat in detrimentum mei prædii. *Ita habetur. l. is cuius. ff. de aqua plu. arc.*

Quando aggeres flunt iuxta flumina in [sect. 17] priuato, id est in ripa, quæ iure proprietatis est eius, qui illos facit, vt glossa. §. aggeres citando exponit, ripæ enim fluuiorum, licet quoad vsum publicæ sint, quoad proprietatem tamen eorum sunt, quorum sunt prædia, quæ ad illas terminantur, *vt habetur inst. de rerum diuis. §. riparum, l. riparum. ff. eod. titu. & l. riparum. ff. de acquir. rerum domin.* Intellige, nisi via publica sit relicta inter prædia & ripam: nam tunc ante ripam terminantur prædia: viaque & ripa, etiam quoad dominium & proprietatem, communia manent.

Quando, inquam, aggeres siunt iuxta flumina [sect. 18] in priuato, in sensu proximè explicato, tunc, si inde proueniat detrimentum aliis agris, etiam qui sunt in vltiori parte fluminis, quia scilicet aqua fluminis, obstaculo eorum aggerum, maiori vi repellitur, inundatque agros aliorum, aut vi sua ripam, quæ ad aliorum agros terminatur, partemque eorum agrorum consumit, eam partem conuertendo in alueum ac ripam, tunc [[127]] dominis eorum agrorum competit actio aquæ pluuiæ arcendæ aduersus cum, qui eos aggeres fecit, vt eousque illos destruat, quantum satis sit, vt non noceant, & vt soluat damna inde à puncto litis contestatæ subsequuta. Obiter obserua, pro damnis datis ante litem contestatam, competere actionem legis Aquiliæ, subsidiariam, seu in factum, *vt habetur. l. 1. ff. de ripa munienda.* Quod similiter intellige in aliis euentibus, in quibus dictum est, & dicetur, locum non esse actioni aquæ pluuiæ arcendæ quoad damna data ante litem contestatam. Additur. §. aggeres citando, id intelligendum esse, modò non sint facti à tempore, de cuius initio non extat memoria, & modò fieri non deberent. Glossa vltima ibi exponit, iure pacti, vel nature, vel etiam nimie vetustatis. *Hæc habentur. l. quod principis. §. aggeres, & consentit. l. 1. §. Neratius. ff. de aqua plu. arcend.* Et quidem si interuenisset pactum cum vicinis prædiorum, quibus nocent, vt tales aggeres ita fierent, aut si legitima interueniret præscriptio, vt flumen ob illos eo modo flueret, nullum potest esse dubium, locum non habere actionem aquæ

pluuiæ arcēdæ. Textus autem in. §. aggeres citato, illis verbis; *Ita, si memoria eorum extet, & si fieri non debuerūt*; tanquam distinctum titulum excipit, si iure sint facti, à titulo legitimæ præscriptionis. Vt verò meliùs intelligas, quando iure censendi sint facti, vt iuxta eum textum locum non habeat aquæ pluuiæ arcendæ, obserua.

Vt habetur. l. 1. c. 3. ff. de fluminib. c. l. 1. ff. nequid [sect. 19] in flumine publico. Flumina, licèt aliquando latiùs sumantur, pressè tamen sumpta, distingui à riuus, & à torrentibus. A riuus quidem distinguuntur magnitudine: decursus quippe aquarum, si paruus sit, riuus nuncupatur, non verò flumen. Vt verò aliquis decursus aquarum riuus sit censendus, & non slumen, multum facit incolarum existimatio, qui eum riuum reputent, ac appellent; *vt habetur. l. 1. ff. de fluminibus.* Flumen verò à torrente distinguitur, quòd flumen perenne sit, sempërue fluat, esto rarò aliquando in æstate aliqua exarescat. Torrens verò est, qui regulariter exsiccat in æstatibus.

Flumina publica illa dicuntur, (*vt Vlpianus. l. 1. [sect. 20] citata cum Cassio & Celso* probabile existimat) quæ riui non sunt, suntque perennia, ac proinde à torrentibus pressè sumptis distincta. Dixit, id esse probabile: quoniam arbitrio prudentis est relinquendum, num tantus sit aliquis decursus aquarum, tametsi æstatibus regulariter ob ariditatem terrarum, quas percurrit, exsiccat; vt flumen publicum nihilominus sit censendus ac nuncupandus. Sola autem flumina publica inter loca publica computantur, vt additur. l. 1. citata, de quibus proinde solis intelliguntur interdicta, quæ aliquid in eis fieri prohibent autoritate priuata, etiam ab habentibus prædia vtrinque.

Ripa autem fluminis, *vt habetur eadem. l. 1. c. [sect. 21] 3. ff. de fluminibus*, est, quod continet vtrinque flumen quoad suum cutsum naturalem, alueumq; proinde illius vtrinque terminat. Atque ad ripā spectat, quod, prudentis arbitrio, à plano terræ, in quo prædia censenda sunt finiri, vergere incipit usque ad aquam, vt habetur. l. 3. citata. Et cùm ripæ fluuiorum publicorum, loca publica sint, quoad vsum necessarium, licèt non quoad proprietatem, vt dictum est, quèadmodum & fluuii ipsi publici, id totum cēsendum est locus publicus, saltem quoad vsum; non verò terra, seu prædia, quæ sunt iuxta eiufmodi ripas, vt eadem. l. 3. habetur. Dictum autem est; quod continet vtrinque flumen quoad cursum suum naturalem, esse ripam illius: quoniam, si aliquando exundet, & longè plus occupet, vtique tunc sicut, quod de nouo occupat, non dicitur alueus illius, neque proinde efficitur locus publicus, sed manet priuatus quoad dominium & possessionem, vt antea erat; ita neque, quod tunc aquas vtrinque terminat, est ripa eius fluminis, efficiturque locus publicus, sed manet priuatus, vt antea erat, vt eadem. l. 1. citata subiungitur.

Quando autem flumen publicum dilatat suū [sect. 22] alueum, ita quod plus incipit occupare, non ad breue tempus, sed simpliciter ac permanenter, vt quia alueus antiquus repletus est multa arena, aut quia vis aquæ consumpsit partes prædiorū ripæ vicinorum, easque in alueum cōuertit, vel aliqua alia de causa, tunc id, quod ita ex prædiis vicinis conuertit in alueum, aut in ripam, locus etiā publicus efficitur. Si autem eisdē, aut aliis de causis, flumen mutet alueum, quia permanēter aliò fluit, tunc is alueus & ripæ, quibus de nouo cōtinetur, incipiunt esse loca publica: antiquus verò alueus, si cum omnino deserat, & ripæ, quibus continetur, desinunt esse loca publica. Ita subiūgitur eadem. l. 1. citata. Lege quæ Disput. 57. dicta copiosè his de rebus sunt, ex quibus ea melius intelligas, atque illis hæc adiunge.

Si fossa flumini publico fiat, per quam vel to [sect. 23] tum, vel pars magna, fluat, quæ publici fluminis, & non rlui, rationem, iuxta ea, quæ dicta sunt, retineat, ea etiam fossa locus est publicus, sicut & flumen ipsum, vt eadem lege subiungitur.

Quod in aqua fit, dicitur fieri in flumine: [sect. 24] quod verò fit extra aquam, non dicitur fieri in flumine, sed in ripa, si in illa sit factum, vt etiam eadem lege subiungitur.

Deinde fluuiorum quædam sunt nauigabilia, [sect. 25] quia naues, aut alia nauigia, in eis recipiuntur, aut quia ratibus saltem nauigantur. Et quædam non sunt nauigabilia. Atque horum quædam cum alio efficiunt flumen nauigabile, neque valde distant, vt in illud influant: quædam verò talla non sunt. *Ita distinguitur. l. 1. citata, iuncta. l. 2.*

His ita constitutis, *lege. 1. citata. iuncta. l. 2. & iū* [sect. 26] *cta. l. cum autem. §. si fluminū. ff. de aqu. plu. arce.* circa flumina nauigabilia, aut quæ cum alio, in quo influūt, efficiunt flumen nauigabile, sequens interdictum statuitur, cōtinēs duas partes, prohibitoriā vnam, & restitutoriam alterā. Prior pars est. Ne quid in nauigabili fluuio, neque in eius ripa, fiat, quo statio nauigiorum, id est, locus, in quo stare solent anchoris defixis tāquā in parte tutiori, aut aptiori, deterior fiat; neque fiat aliquid, quo iter nauigiorum per fluuium fiat deterius. Id autē fieret, si vel aqua eius fluminis, aut alterius, quod in illud influit, efficitque illud nauigabile, extraheretur, aut diucrteretur, eaque ratione minor aquæ copia maneret in statione, aut in flumine, ita vt nauigia solum alieūve contingerent, difficiliorq; aut periculosior, esset statio in eo flumine, vel nauigatio per illud, vel si aqua ita occuparet maiorem alueum, vt in singulis illius partibus minor esset, minusq; apta vt per illam nauigaretur, vel si aqua constringeretur in minori alueo, rapidiorq; redderetur, eaque ratione, aut alia, minus apta ad nauigam dum redderetur. Denique id omne fieri, [[128]] prohibetur in ripa, aut in flumine, vnde statio, aut nauigatio per illud deterior reddatur. Posterior verò pars interdicti est. Vt si quid tale factū sit, restituatur res in pristinum statum, cessetque id damnum stationis aut nauigationis per id flumen.

Lege. 2. titu. 10. lib. 7. nouæ collect. sic habetur: Mandamos, que qualquier consejo, o persona particular, que cerrare, o embargare, las canales, y los rios, que entran por los terminos de las ciudades y villas, por donde suelen andar los nauios y pescadores, y aprouecharse dellos de otros oficios, de que comunmente acostumbra aprouecharse dellos los vecinos del tal lugar y tierra, quando los han menester, peche seiscientos marauedis parala nuestra camara, y deshaga el embargo que fuere hecho del dia que le fuere denunciado dentro de treinta dias a su propria costa, en tal manera que quede desenibargado segun que antes solia estar, y esto sera cumplido so pena de la nuestrn merced: saluando ende aquel, o aquellos, quemostraren priuilegios de los Reyes, donde nos venimos, para lo poder fazer, y como lis fue otorgado por ellos, o faziendo en ellos mencion, como se los da por iuro de heredad.

Lege autem. 1. ff. nequid in flumine publico, [sect. 27] quoad omnia vniuersim flumina publica, siue nauigabilia sint, siue non, sequens interdictum statuitur. Nequid in flumine publico, vel in eius ripa, priuata autoritate fiat, quo aqua cum detrimento vicinorum incolarum, habentium ad ripas illius prædia, aliter fluat sequenti æstate, quā præterita, vel rapidior, ita vt prædiis aliorum detrimentum inferat, vel aliqua alia ratione aliter cum eorundem detrimento. Fit autem comparatio cursus fluminis in æstate, quæ sequitur post opus factum in eo, aut in eius ripa, cum cursu anterioris æstatis eiusdem fluminis, vt videatur, an ex opere illo cursus fluminis sit mutatus cum vicinorum detrimento; & non fit comparatio cursus fluminis in hyeme: quoniam, vt in eadem lege subiungitur, naturalis cursus fluminis non is est, quem habet tempore hyemis, quando exundat: fas quippe est vnicuique prædium suum tueri præcisè aduersus inundationes, etiam si inde detrimentum aliis sequatur, qui similiter curent se etiam aduersus eas inundationes tueri; modò tamen, qui se ita tuetur, non mutet cursum naturalem fluminis, quem in æstate tenere solet, quando inundationes illius

non sunt. Nomine autem æstatis, in re proposita, vel intelliguntur tres menses anteriores, qui terminantur ac finiuntur in æquinotio hyemali mensis Septembris; vel intelliguntur sex menses ab æquinotio vernali mensis Martii vsque ad æquinotium hyemale mensis Septembris, vt notat glossa ibi verb. refertur, & approbant Bart. & alii, quo tempore cursus naturalis fluuiorum spectari debet. In eadem lege subiungitur altera pars eiusdem edicti restitutoria, vt scilicet, si aliquid factum sit in flumine publico, aut in eius ripa, quod cursum illius naturalem, modo explicato, cum aliorum detrimento mutet, id destruat, ac restituatur in pristinum statum, damnaque data soluantur.

In eadem lege deciditur quæstio, ad rem no [sect. 28] stram attinens, occasione cuius tam multa dicta sunt. Quærit Vlpianus, si quis faciat opus ad tuendam ripam, suumque proprium prædium, quod prædium damnum magnum ex flumine patitur, vt si aggeres in flumine ipso & in ripa faciat, quibus suum prædium, ripamque, quæ ad illud terminatur, defendat: indeque sequatur, cursum fluminis mutari cum præiudicio aliquo prædiorum vicinorum, num tueri se possit aduersus vicinos, prohibentes eos fieri, aut contententes postquam sunt facti, vt destruantur, exceptione, quòd id factum sit, ad tuendam ac muniendam ripam prædio suo coniunctam, defendendumque; proprium prædium, (vt enim habetur. l. vnica. ff. de ripa muni. vnicuique fas est, ripam suam, prædiumque suum munire, quod necessarium ad id fuerit, in fluuiò & in ripa efficiendo, modò inde deterior non fiat nauigatio, & modò caueat vicinis de dāno infecto, si quod damnum timent suis prædiis inde euenturum) an verò admittenda non sit talis exceptio, sed eo ipso, quòd aggeres illi cursum fluminis naturalem cum præiudicio aliorum mutant, impediendi omnino sint, ac destruendi, si fuerint facti. Relata verò ab Vlpiano sententia quorundam asserentium, nihil impediens ea exceptione, impediendos destruendosque esse, Vlpianus ipse desinit, attendendum esse præiudicium ac damnum, quod is, qui eos aggeres facit, ab eo flumine patitur, conferendumque esse cum aliorum præiudicio ex iis aggeribus, & ex ea cursus fluminis mutatione, atque, si inueniatur, longè maius esse damnum, quod ex eo flumine patitur, qui eos aggeres facit, quàm sit damnum, quod ex eisdem aggeribus aliis obuenit, impediendos destruendosque non esse, sed consulendum esse potiùs vtilitati illius, cæterum sine iniuria aliorum: quoniam præcipiendum ei est, qui eas aggeres facit, vt aliis compenset damnum, quod inde eis provenit. In hoc itaque euentu, & in quocunque alio, in quo sunt publica interueniente autoritate ob maius bonum commune, aut quando facti sunt ex consensu eorum, quorum prædiis fluuius propter illos nocet, intelligo verba illa Pauli iurisconsulti. *l. quod principis. §. aggeres*, ad quæ explicanda, hæc omnia dicta sunt.

Ex dictis quoque intelligetur, non repugna [sect. 29] re. §. *aggeres citato. legem. 2. §. penul. ff. de aqua plu. arc.* Vbi habetur, si aliquis, opere in suo prædio facto, aquam torrentis auertat, ne suo prædio noceat, esto inde sequatur, eam aquam nocere prædio vicini, non teneri illi actione aquæ pluuiæ arcendæ, si id fecit, ne sibi noceret, non verò animo nocendi prædio vicini. Ibi enim non est sermo de flumine publico, in quo non licet facere aliquid, neque in eius ripa, quo cursus illius naturalis, qualis est, quem habet tempore æstatis, mutetur cum damno vicinorum; sed est sermo de torrente, cuius inundationes licet cuique auertere à prædio suo, ne ei noceant, illis obstaculum apponendo, etiam si per accidens sequatur, quòd vicinis noceant; modò, sine vllo proprio commodo, non fiant animo nocendi vicinis. Atque iuxta hæc sunt accipienda, quæ hac de re *Greg. Lopez. docet. l. 14. titu. 32. part. 3. glos. penult.* Illud admonuerim, Cæpollam de seruituti [sect. 30] bus rusticis. c. 4. sæpe admonere, ad præscribendam seruitutem, aut quasi seruitutem, aduersus rem aliquam publicam, vt circa

[[129]] aquam publicam, aut locum publicum, etiam si id seruitus, aut quasi seruitus, sit continua, vel quasi continua, non satis esse spatium decem annorum inter præsentes, & viginti inter absentes, sed necessarium esse tempus, de cuius initio non extat memoria.

Hinc est dubium, num, vt præscribatur muta [sect. 31] tio cursus naturalis fluminis ex aggeribus in eo, & in ripa illius, factis cum vicinorum detrimento, *iuxta legem quod principis. §. aggeres. ff. de aqua plu. arc.* necessarium sit tempus, de cuius initio non extat memoria, vt apertè exigere videtur. §. aggeres citatus: an verò sufficiat spatium decem annorum inter præsentes, & viginti inter absentes. Et quamuis seruitus illa, vt vicini patiantur eum fluminis cursum ex talibus aggeribus, sit continua, aut quasi continua, atque si de solo damno vicinorum ageretur, neque aqua illa fluuiusque ille esset publicus, sufficeret tempus decem, aut viginti, annorum, vt ea seruitus aduersus illos præscriberetur: quia tamen sua illorum interest, cursum fluminis publici non esse mutatum, credo, quatenus id damnum provenit ex cursu fluminis publici mutati, non præscribi eam mutationem cum illorum damno, minori tempore, quàm de cuius initio non extet memoria: præsertim cùm id apertè innuat ac significet. §. aggeres citatus, & cùm ad præscribendam publicam rem, non minus tempus sufficiat, vt Disput. 707. dicitur.

Quando iussu principis aut senatus (intelli [sect. 32] ge siue immediate id præcipiant, siue per alium ab eis auctoritatem ad id habentem) opus aliquod est factum; tunc, esto ex illo sequatur aquam vicinis agris nocere, non competit actio aquæ pluuiæ arcendæ eis, quibus ita aqua nocet. *Ita habetur. l. 2. §. Cassius, & l. quod principis in prin. ff. de aqua plu. arc.* Principes tamen, & potestates alię ab eis deriuatæ id præcipere non debent nisi in magnum commune bonum, factaque compensatione iis, quibus detrimentum inde sequitur, contribuereque ad id debent alii, in quorum commodum id fit.

Si in loco omnino publico, quoad directum [sect. 33] scilicet & vtile dominium, sit factum opus, ratione cuius aqua noceat, tunc non competit actio aquæ pluuiæ arcendæ, quoniam ea datur aduersus dominum loci, in quo id opus est factum; quod locum non habet comparatione loci publici. Si tamen ex opere facto in loco aliquo priuato aqua noceat alteri agro, mediante aliquo publico loco interiecto, per quem transeat, tunc actio aquæ pluuiæ arcendæ competit aduersus dominum loci priuati, in quo id opus factum est. *Ita habetur. l. apud. §. aquæ pluuiæ, & l. si in publico. ff. de aqua plu. arc.* Obserua tamen, agi posse interdicto quod vi aut clam, aduersus eum, qui priuata auctoritate id in loco publico fecit, *vt iuxta. l. vim facit vers. ult. ff. quod vi aut clam, affirmat glossa. l. si in publico citata, verb. non potest.* Neque video cur hic non sit cogendus soluere domna, & destruere suis sumptibus opus illud in loco publico factum, sicut dicemus de eo, qui in alieno loco priuato idem facit, domino loci neque id iubente, neque ratum id habente, vt infra dicitur. Competit præterea aduersus eum actio legis Aquiliæ subsidiaria in factum, ad damna ex eo opere culpa illius sequuta.

Quando aliquis opus secit in suo prædio priuato, vnde agro meo aqua nocet, quæ per agrum priuatum alterius intermedium in meum deriuatur, tunc agere possum actione aquæ pluuiæ arcendæ, vel contra eum, qui id opus fecit in suo prædio, vnde aqua mihi nocet, vel contra dominum agri vicini, vt maluero. *Ita habetur. l. si tertius in prin. ff. de aqua plu. arc.* Merito tamen glossa ult. ibi & Bart. id intelligunt, quando dominus agri vicini vult eam aquam suscipere. Quando autem in potestate sua non est eam non suscipere, quia necessariò, ipsove non valente eam impedire, fluit in agrum suum, & per suum in meum, nulla actio competit mihi aduersus eum, eo quòd absque vlla sit culpa, sed solùm competit aduersus

tertium, qui opus fecit, ob quod fluit ac nocet, vt satis perspicuè docet. *l. 2. §. idem Labeo. ff. nequid in loco publi.*

Quando aliquis, fructuum percipiendorum [sect. 35] causa, aliquid facit in suo agro, quod ad id necessarium vtilè sit, etiam ad herbam ac pastum, modò tamen non faciat aliquid ad id minimè vtile ac conducens, aut animo nocendi vicino; tunc, esto inde sequatur aqua, quæ inde elabatur, nocere agro vicino, non competit vicino actio aquæ pluuiæ arcendæ, idque in agriculturæ fauorem. Vt si quis suum agrum conuertat in pratum, quod ad herbam sit necesse rigare sæpius, quàm antea solebat, eaque ratione aqua sæpius descendat in vicini agrum, illique noceat. Vel, si arando suum pratum, aut alium suum agrum, causa fructuum percipiendorum, sulcos faciat, aut etiam portas (alii textus porcas habent) hoc est, sulcos latiores & profundiores, qui in locis, vbi aqua pluuiæ multum sæpe nocet, vt in Lusitania, fieri solent intercalariter inter sulcos aliquos ex consuetis, quò aqua confluat à sulcis minoribus, & per eos maiores labatur, exeatque agrum, ne humiditas nimia suffocet sementem, ac opprimat sata; tunc, esto id in causa sit, vt aqua ita dilabens noceat agro vicino, in quo recipitur, non competit vicino actio aquæ pluuiæ arcendæ. Et fortè eiusmodi portæ sunt, quas lex. 1. §. Labeo etiam, in fine, appellat sulcos aquarios. Atque in locis, vbi eiusmodi portæ fiunt, sulci consueti esse solent profundiores, quàm sint in locis pinguioribus, & vbi aqua non nocet, sed potius prodest, vt nocere non solet in hoc Castellæ regno. Vnde in Lusitania, vbi portæ illæ aliquando fiunt, sulci consueti profundiores sunt, quàm in Castella, vt eis labatur aqua, semenque non manet in profundo sulci consueti, ne suffocetur & opprimatur nimia humiditate. Quòd si sulci, ac portæ, fiant, non decliues versus locum inferiorem, sed fiant transversales, vt aqua ad latus, & quasi æqualis, fluat in agrum, qui est ad latus, tunc impediri possunt actione aquæ pluuiæ arcendæ à domino agri, qui est ad latus, nisi necesse sit ita fieri ad meliùs fructus in eo agro percipiendos, in quo eo modo fiunt. *Hæc habentur. l. 1. §. de eo opere, & quatuor sequentibus. l. 3. §. si vi cinus. & dilucidius ac meliùs. l. vicinus. ff. de aqua plu. arc.*

Seruitute non existente, quæ aliud habeat, [sect. 36] vnicuique fas est, aquam, quæ in suo fundo oritur, aut quæ ex alieno fundo in suum deriuatur, si-[[130]]bi retinere, nec sinere deriuari in fundum alicui, idque efficiendo in suo fundo opus, quod ad id vo luerit: dummodo nihil ad id efficiat in alieno fundo. Quoniam id est iure suo vti, sibiq; prodesse, non nocendo alteri, cui ea aqua minimè est debita. Si tamen animo nocendi vicino id fieret, & non iure suo vtendi, tunc actione de dolo ex iuris equitate in commune bonum prohiberetur, iuxta ea, quæ mox subiungemus. *Ita habetur. l. 1. §. iidem aiunt. 2. & §. sicut. ff. de aquæ plu. arc.*

Si tamen aqua esset publica, quæ ad irrigandū [sect. 37] prædia inseruiret, vt omnes eo beneficio participarent, aut certa lege statuta ac præscripta qualiter inter prædia esset diuidenda, aut sine tali lege præscripta, tunc nefas esset, vnum totam eam aquam sibi vsurpare, aut plus ex illa in detrimentum aliorum, ad quos inde dilabatur, quàm par sit, aut efficere aliquid in suo prædio, vnde cursus & deriuatio illius, in aliud, aut in alia prædia, impediretur, agique aduersus illum ea de causa posset actione aquæ pluuiæ arcendæ, vt ex se est notissimum, & *habetur. l. 14. titu. 32. part. 3.*

Quando aliquis in agro suo præscindit venas, [sect. 38] vnde aqua deriuatur in fontem, aut in puteum vicini, aut fodit puteum in prædio suo, eaque ratione in causa est, vt aqua putei vicini in suum puteum confluat, iure suo vtitur, nisi esset seruitus constituta vnde id sibi non liceret, eaque de causa non competit aduersus eum actio aquæ pluuiæ arcendæ. Si tamen

solo animo nocēdi vicino id efficeret, (quod præsimitur, quādo sine vllo suo cmolumento id faceret, vt cum Paulo Castrensi notat Greg. Lopez. l. 19. titu. 32. part. 3.) tunc ex iuris æquitate actione de dolo prohiberetur, cogereturque rem ad statum pristinum reducere. *Ita habetur. l. 1. §. iidem aiunt. 2. §. l. si in meo. ff. de aqu. plu. arc. l. Fluminum. §. vlt. §. l. Proculus. ff. de dam. infecto, §. l. 19. citata.*

Quando aliquis actione aquæ pluuiæ arcen [sect. 39] dæ cogitur destruere opus, vnde aqua nocet, solūm tenetur id destruere, redigere rem in pristinum statum, quantum præcisè sit satis, vt aqua deinceps non noceat. *Ita habetur. l. si usufructuarius. §. non aliter. ff. de aqua plu. arc.*

Quando post litem contestatam de aqua plu [sect. 40] uia arcenda, factum est aliud opus, si ex illo nouum nocumentum timeatur, noua actio erit intentanda. *Ita habetur. l. Antei. §. vlt. ff. de aqu. plu. arc.* Quando verò post litem contestatam factum est aliquid aliud, quod destrui sit necesse ad illud aliud opus destruendum, ob quod lis est contestata, tunc simul eatenus destrui id debet, quod post litem contestatam est factum, quatenus necesse sit ad illud aliud destruendum *Ita habetur. l. sed interdum. ff. eod. titu.*

Quando dominus ipse fundi, in quo opus est [sect. 41] factum, pro quo competit actio aquæ pluuiæ arcendæ, illud fecit, aut fieri mandauit, vel ratum habuit nomine suo esse factum, tunc sumptibus illius destrui debet, resarciriq̃ue debent damna, post litem contestatam, inde subsequuta. Idem dic de hærede illius post mortem eius: reputatur enim ac si ipse id opus fecerit, ad effectum, vt de bonis defuncti teneatur illud destruere, & soluere damna subsequuta. *Ita habetur. l. quanquam. §. idem Iulianus. l. si colonus, & l. tertius. §. Celsus. ff. de aqu. plu. arc.* Neque liberatur ab opere destruendo, & à soluendis damnis post litem contestatam sequutus, si dicat, se cedere prædio, in quo id opus fecit. *Ita habetur. l. is cum. ff. de aqu. plu. arc.*

Quando verò alius, domino prædii nec tacitè nec expressè iubente, nec ratum habente, id opus fecit, tunc dominus prædii solūm tenetur pati, vt id opus destruat, quantum satis sit, vt damnum cesset; non tamen tenetur soluere expensas necessarias, sed vicinus ad eas, & ad damna sequuta, agere potest aduersus eum, qui id opus fecit, actione quod vi aut clām, imò & actione in factum legi Aquiliæ subsidiaria. Quòd si dominus prædii ex demolitione eius operis damnum aliis rebus suis timeat, petere poterit, vt, antequam destruat, sibi caueatur de damno infecto, neque aliter pati tenetur, vt demoliat. Quo loco obserua. Quæ dicta sunt disputatione præcedente, de missione in possessionem ex primo & ex secundo decreto, quando aliquis non vult cauere de damno, quod ex re illius timetur, intelligenda esse de damno, quod ex eo timetur, quòd periculum sit, ne res iam facta corruat ac noceat: non verò de damno, quod timetur ex re, quam facere, augere, aut demoliri, aggreditur: in his enim euentibus cogendus omnino est, ea non aggredi, aut ab eis inceptis omnino desistere, vel cauere statim de damno infecto, quod inde timetur, vt in eo exemplo, & in aliis, quæ subijciemus, iuxta iura citata: idque perspicuè ipsamet natura rei efflagitat. Quòd si mancipium domini prædii id opus fecit inscio, nec ratum habente, domino, tunc dominus prædii tenetur suis expensis id opus demoliri, & soluere damna subsequuta, vel mancipium pro eis expensis, ac damnis, noxæ dare. Si autem, qui id opus fecit, erat colonus domini prædii, aduersus illum est agendum vt soluat expensas & damna. Si autem dominus prædii loco illius ea soluerit, tunc agere poterit aduersus illum actione locati, aut etiam negotiorum gestorum, vt ea ipsi persoluat; & eodem modo à quocunque alio extraneo, qui idem opus similiter fecisset, posset repetere eas expensas pro eo factas actione negotiorum gestorum.

Hæc habentur. §. idem Iulianus. l. si colonus, & §. Celsus. citatis. Quando procurator vniuersalis domini prædii id opus fecit, sine domini mandato ac voluntate, & scientia. l. quanquam citata. §. vlt. videtur statui, dominum ob procuracionem vniuersalem illi datam, teneri ad expensas & damna, sed posse illa repetere à suo procuratore interdicto quod vi aut clàm; vicinusque eodem interdicto agere poterit aduersus eundem procuratorem, vt illa sibi soluat, si maluerit agere aduersus illum, quàm aduersus dominum prædii.

Quamuis actio aquæ pluuiæ arcendæ di [sect. 42] recta, & quæ de summo iuris rigore conceditur, solùm competat proprietario, & aduersus proprietarium, non verò vsufructuario, & aduersus vsufructuarium, quando ad vnum pertinet pro-[[131]]prietas, & ad alium solus vsusfructus, si vel tali agro aqua ex opere facto in vicino prædio noceat, vel ex opere facto in eo agro aqua noceat vicino agro; vtilis tamen actio competit vsufructuario, tum aduersus proprietarium, si in eo ipso agro opus efficiat, vnde aqua vsufructui eiusdem agri noceat, tum etiam aduersus vicinum, si in vicino prædio opus faciat, vnde aqua similiter eidem vsufructui noceat. Cōpetit item vtilis actio aduersus vsufructuarium aquæ pluuiæ arcendæ, si in prædio, in quo vsumfructum habet, opus efficiat, vnde aqua vicino agro noceat: in quo euentu dominus agri vicini agere poterit actione directa aduersus proprietarium, si potius eligat aduersus illum, quàm aduersus vsufructuarium, agere. *Ita habetur. l. 3. §. vlt. & copiosius. l. si vsufructuarius. ff. de aqu. plu. arc.*

Obserua tamen, quando aliquis emphyteuta [sect. 43] esset, aut feudatarius, prædii alicuius, tunc, quia ad ipsum integre ac plenè spectaret dominium vtile eius prædii, vtique eidem competeret directa actio aquæ pluuiæ arcendæ, si agro, cuius haberet emphyteusim, aut feudum, aqua noceret ex opere facto in prædio vicino: similiterque competeret aduersus ipsum eadem directa actio, si ex opere ab eo facto in prædio emphyteutico, aut seudali, aqua noceret vicino agro. *Ita habetur. l. quod principis. §. hæc actio. ff. de aqu. plu. arc.*

Quamuis directa actio aquæ pluuiæ arcendæ [sect. 44] solùm competat aduersus dominum facientem opus in prædio, vnde aqua vicino agro noceat, si tamen quis ædificet sepulchrum, illationeque defuncti in illud, dominium amittat, eo quòd locus sacer fiat; atque ex eo opere facto aqua noceat vicino agro, domino agri vicini competit actio aquæ pluuiæ arcendæ vt id opus destruat: quoniam satis est, quòd illud effecerit, quando erat dominus loci ac ædificii illius antequam sacer fieret. Quòd si, iussus à iudice, illud destruat, non tenetur de sepulchro violato. *Hæc habentur l. quanquam in prin. ff. de aqu. plu. arc.*

Quando prædium, in quo factum est opus, [sect. 45] vnde aqua agro vicino nocet, commune est multis quoad dominium, aut ager, cui nocet, est cōmunis multis, competitque actio aquæ pluuiæ arcendæ, est distinguendum. Quoniam, vel agitur ad opus destruendum, atque vt res redigatur ad statum, in quo antea erat, ita vt agro vicino aqua non noceat: vel agitur ad damna ex eo opere subsequuta. Si agatur ad opus destruendum, tūc vnusquisque eorum, cuius est ager, cui aqua nocet, potest agere in solidum aduersus vnumquēque eorum, qui id opus fecerunt, vt integrum opus destruat, & poterit agere aduersus multos eorum, & aduersus omnes simul, vt illud destruant, vt ipse voluerit; & omnes, qui domini sunt agri, cui aqua nocet, possunt etiam agere simul aduersus singulos, aut aduersus omnes simul dominos prædii, qui id opus in eo fecerunt, prout maluerint. Si tamen vnus eorum, qui id opus fecerunt, illud destruat, aut quidam eorum illud destruant, cessat actio aduersus cæteros: cæteri tamen, qui illud fecerunt, mandauerunt, aut ratum habuerunt, esse factum, contribuere huic actione cōmuni diuidendo ac negotiorum gestorum tenentur partes proportionales eorum sumptuum, illi, aut illis, qui loco omnium illos fecerunt. Dixi, posse agi in solidum aduersus singulos,

aut aduersus omnes, qui id opus fecerunt: quoniam, si aliqui eorum, nec tacitè, nec expressè, consenserunt, vt id opus fieret, aduersus eos agi non potest, vt illud destruant, aut vt ad expensas contribuant, sed solùm vt patiantur destrui: poteruntque petere, vt sibi caueatur de damno infecto, si ex demolitione damnum timent. Si verò agatur ad damna ex eo opere subsequuta, singuli domini agri, cui damnum est illatum, agere possunt ad partem solùm damni, quæ ipsum contingit, & omnes simul ad totum damnum. Itemque aduersus singulos dominos, qui id opus fecerunt, agi solùm potest, vt vnusquisque solùm contribuat partem damni, quæ ad ipsum soluere spectat. Quod si vnus eorum sua l'ponte soluat totū damnum, (neque enim cogi ad id potest) tunc actione negotiorum gestorum potest à reliquis petere, quod loco illorum soluit. Hinc sequitur, quòd si duo habeant agrum communem, & ex opere facto in prædio vicino, proprio vnus eorum, aqua ei agro noceat, alter petere ab illo possit, vt totum quidem opus destruat, cæterū non potest petere, vt soluat, nisi partem damni, quæ ipsum contingit. Hæc omnia, præterquā quòd perspicua sint, & consentanea rectæ rationi ac æquitati naturali, *constant. ex. l. si tertius. §. si ex plurium, &c. §. inde sequitur. l. supra iter. §. Cassius. §. apud Ferocem. §. officium. §. penult. & ult. ff. de aqua plu. arc. & ex. l. 17. titu. 32. part. 3.*

Quando aliquis in prædio suo opus fecit, vn [sect. 46] de aqua nocet agro vicino, ita quòd actio competat aquæ pluuiæ arcendæ, tunc si, qui opus illud in prædio suo fecit, prædium illud alienet, si alienatio ficta fuit, perinde aduersus eum cōpetit actio, vt illud destruat, & soluat damna, ac si id prædium non alienasset, vt est notissimum, *& habetur. l. emptor. ff. de aqu. plu. arc.* Quando, verò alienatio vera fuit, Hinc particularis in eo successor solùm tenetur pati, vt destruat; ad expensas verò non tenetur, neque ad damna: vnde, si cedat ei prædio, facit plus, quàm tenetur. *l. is cum. ff. eod. titu.* Quòd si, vel actor, qui damnum inde in suo agro patitur, eas faciat, vel qui successit in eo prædio, recuperare eas possunt ex eo, qui id opus fecit. Ille quippe tenetur ad illas personali actione, & ad damna sequuta post litem contestatam: quin, si id prædium ante litem contestatam alienauit, agitur contra eum intra annum actione aquæ pluuiæ arcendæ, vt expensas soluat, ac damna, & post annum actione de dolo. *Hæc omnia habentur. l. quanquam. §. Iulianus. l. emptor. l. venditor. l. post venditionem. ff. eod. titu. & l. 16. titu. 32. part. 3. iuncto Greg. Lopez ibi.*

Quòd si dominus agri, cui id damnum sequi [sect. 47] tur, cuique proinde actio aquæ pluuiæ arcendæ cōpetebat, eum agrum alienet ante litem contra dominum prædii contestatam, tunc ad nouum successorem, & non ad priorem dominum, spectat cam actionem intentare aduersus eum, qui id opus in eo prædio fecit: quoniam ad ipsum attinet iam damnum ratione agri ad ipsum attinentis: neque tunc ea actio, personalis quidem, sed in rem scripta, hoc est, competens ratione rei, cui damnum imminet, dicitur propriè transire ab alienante agrum in eum, cui est alienatum, sed competere nouo in eo agro successorì ratione eiusdem agri. Si verò alienator eius agri, antequam eum alienasset, litem **[[132]]** contestatus fuerat cum domino prædii, in quo id opus erat factum, tunc transiret ea actio in nouum successorem in statu, in quo erat tempore alienationis factæ, & quoad dāna post contestatam litem sequuta, vel alienator agit ad dāna, &, recuperata, tradit illa ei, cui agrum alienauit. *Hæc habentur. l. si tertius. §. si quis prius. l. post venditionem. ff. de aqu. plu. arc. & l. 16. citata, iuncto Greg. Lopez. ibi.*

De aquæductis, & aqua quotidiana. & æstiuæ. Disp. 705.

SVMMARIVM.

1. *A Quædtsctus latè quid. Et riuus latè, pro viis, quibus aqua ducitur.*
2. *Aquæ priuatæ quæ. Eorum sunt, in quorum prædiis nascuntur, & quousque eis uti easque deriuare liceat. Receptæ in aliis prædiis priuatis, dominorum eorum prædiorum efficiuntur. Dum verò ad publicum locum deueniunt, publicæ efficiuntur.*
3. *Aquæ pluuiæ quæ. Multiplices sunt. Quatenus earum vsus prohibitus aut permissus.*
4. *Aqua æstiuæ, & aqua quotidiana, quæ.*
5. *Aqua hyberna quæ. Et quod interdictum quoad eam competat.*
6. *Aquæductus seruitus in quibus aliis locum habeat: & in quibus seruitus haustus æquæ.*
7. *Aquæ quotidianæ, & æstiuæ, interdicta. Et aquæductus seruitus, in quibus aquis habeant locum.*
8. *Molendina quousque construere in eodem flumine liceat, etiam cum damno molendinorum antæ structorum, & quousque ad illa extrahere liceat aquam de flumine publico.*
9. *Aquam extrahere de flumine publico cuique licitum. Et quousque sit prohibitum.*
10. *Alueus, per quem aqua ad molendinum extrahitur ex flumine publico, publicus locus efficitur, & ripæ vtrinque quo ad vsum.*
11. *Molendinum in torrente quousque construere liceat. Et quando torrens publicus reputetur.*
12. *Flumine in publico quousque instrumenta, quæ aquis mouentur, consicere liceat, etiam cum detrimento prius instructorum, ut molendina papiri, olei, serram aquæ, batuaria, &c.*
13. *Molendinum super aquas catenis alligatum ad ripas, quiuis efficere potest priuatæ autoritate in quacunque parte fluminis publici, nisi nauigationem impediat.*
14. *Molendinum qui prius ædificauit, an comprimere in suum commodum possit aquam cum detrimento alterius, qui posterius ædificauit.*
15. *Scripturæ in eodem portacollo, aut libro, eodem die confectæ, illa censetur prius consecrata, quæ in superiori parte reperitur scripta.*
16. *Aquam si quis ducebat ex flumine publico, per fundum interiectum, qui ad id seruitutem aquæductus habebat, & fluuiis subito recedat, relicto alueo antiquo interse & eum fundum, qui alueus ei fundo cedit, non potest eam educere per eum alueum, quia non habet seruitutem, quam habebat fundus, cui accessit: si verò paulatim recedat & insensibiliter, tunc educere illam potest per partes aluei, quæ accreuerunt; quoniam reputantur partes eiusdem fundi, habereque eandem seruitutem aquæductus.*
17. *Aquæductus illa seruitus manet in prædio illo intermedio, tametsi impedita quoad vsum. Vnde si flumen ad cursum antiquum redeat, regreditur vsus eius seruitutis, aut si facultas adueniat ducendi aquam per loca intermedia.*

18 . Seruitus esse potest in prædio distante, non existente in intermediis, etiam non impedita quo ad usum, quando usus ab intermediis non pendet, aut obtinetur facultas utendi ad eum affectum intermediis.

19 . Aquam quotidianam si quis eduxit non vi, clam, aut precario, banaque fide, in iureque non errans, semel de die, aut de nocte, intrà annum computatum usque ad punctum, in quo prohibetur, idque de loco non indigente facultate principis, aut communitalis, ut inde educeretur, quod interdictum ei competat aduersus prohibentem, esto corruialis is sit, & competit etiam cuicunque successor in prædio, ad quod fuiteducta.

20 . Aquam æstiuam qui similiter eduxit saltem semel de die, aut de nocte, priori æstate, competit ei simile aliud interdictum aduersus ipsum prohibentem. Et quo pacto sumenda quo ad id sit æstas.

21 . Aquam astiuam qui non eduxerat præcedente æstate, sed hac, quo interdicto gaudeat aduersus prohibentem.

22 . Aquam ob hyemalem simile inter dictum competit, ac circa aquam æstiuam.

23 . Aquam educendi ex eo loco publico, ex quo sine facultate principis, senatus, aut cõmunitalis, autoritate eorum, non potesteduci, si quis sit in possessione, ac prohibeatur, ostendatque legitimam ad id facultatem, quo interdicto illi subueniatur. Quãdo autem facultatem non ostendit, alia possessio ad eam aquam educendam, quàm de cuius initio nõ extet memoria, illi non sufficit.

24 . Aquæ eiusmodi faculias educendi, si prædio sit concessa, cum domino prædii non expirat. Si verò concessa sit personæ, cum ea persona expirat. Et quando facile successor concedetur, adeò ut iniuria illi facta videatur, si ei non concedatur.

25 . Aquam si rite prædictis omnibus modis explicatis in possessione sim educendi ac deducendi per rinos, & quis me impediat per eosriuos eam deducere, aut illos aliaque ad id necessaria reficere, ac purgare, quo interdicto subueniat.

26 . Riuis annexa, circa quæ reficienda ac purganda competit prædictum interdictum, sunt species, septa, incile, cuniculi vaporum.

27 . Riuous, & illis annexa, per quæ quis est in possessione ducendi aquam quotidianam aut æstiuam, si aliquis reficere impediatur, ei statim subuenitur, esto ius non ostendat, quod ad id habet: ad reficiendum verò iter, quod illi seruit, ius simul ostēdat neceße est.

28 . Riuous reficere quid, & ad quæ se extendat. Purgare quid, & ad quæ se extendat.

29 . Riuous quoad modum & qualitates quousque fas sit, aut non sit, mutare.

30 . Riuous reficienti, aut purganti, dum aduersus impedientem subuenitur interdicto de riuis, locum aduersus eum non habet noui operis nunciatio. Compelli tamen potest cauere de damno infecto, & quæ alia actio aduersus illum possit intentari.

31 . Aquam cui intrè annum computatum usque ad punctum, in quo prohibetur, similiter bona fide, nec vi, nec clam, nec precario, ausit de alieno fonte, puteo, lacu, piscina, cisterna, vel alia simili re, si prohibeatur, competit ei aduersus prohibentem directum, aut utile, interdictum de fonte nuncu-[[133]]patum, neque est neceße ut probet habere ad id ius. Idem interdictum competit ei, si prohibeatur illi iter, aut via, quibus transibat ad eum aquæ haustum, aut ad

appulsum pecorum. Et competit successor in prædio, si tanquam ius prædii eum vsum habebat. Idem interdictum competit, si impediatur purgare aut reficere id, unde baustum cum habet.

32 Cloaca quid, & quotuplex fas est illam, esto priuata sit, reficere ac mundare, etiam si ad id necesse sit aperire prædium alienum. Et quo interdicto subueniatur, si id non permittatur. Fas item est illam efficere de nouo, & mittere in cloacam publicam.

33 Cloaca in publica si aliquid sit factum, aut immissum, quo usus illius deterior reddatur, res in pristinum redigitur statum, & fieri impeditur, si fieri attentetur.

34 Aquæ ducendæ ex aliquo prædio, aut per aliquod prædium multis commune, ut seruitus sit concessa, omnium consensus requiritur. Quando quidam eorum consenserunt, satis est si accedat aliorum consensus, persistentibus illis aliis in suo consensu, ut concessa censeatur.

35 Seruitutem in prædio validè sine proprietario non concedunt usufructuarius, emphyteuta, aut proprietarius. Hi tamen duo valide illam concedunt in tempus, quo durauerit emphyteusis, aut feudum, modò ea seruitus non sit usufructus.

36 Seruitus si concederetur in prædio vendito cum pacto adiectionis in diem, aut cum alio suspendente alienationem, tunc consensus simul emptoris & venditoris esset necessarius, ut firma omnino eßet. Et constituta manet, si res cedat, ut prædium maneat eius, qui illam concessit. A cedente item consensus alterius, priore non reuocante consensum, firma similiter maneret.

37 Aquæ ducendæ si seruitus pluribus concedatur, quando necessarius sit consensus aliorum, quando non item. Aqua posteriori semper censetur concessa sine præiudicio priorum. Aqua si de publico concedatur à principe, intelligitur, quæ superfluat necessitatibus publicis, nisi aliud exprimatur.

38 Aquam deducendi ex aliquo prædio qui seruitutem habet, quando concedere illam, aut partem illius, alteri non possit, & quando possit, & alia quoad eam aquam.

39 Aquæductus seruitus, aut quæuis alia, si ab vno prædio alteri prædio debeatur, ius ad eam seruitutem quo pacto sit in toto prædio dominante, & in singulis eius partibus: atque, si seruitus quoad commoditatem diuidi possit, ut potest diuidi seruitus aquæductus, & prædium dominans inter multos quo ad partes diuidatur, quo pacto commoditas illa inter eas partes sit diuidenda. Si seruitus quo ad commoditatem sit indiuidua, ut itineris, tota debetur singulis partibus prædii dominantisdiuisi. Et num vnâ pars prædii dominantis debeat tunc transitum ad eam partem remotiorem.

40 Aquæductus seruitus, aut alia, concessa in aliquo prædio, quando in pactum non fuit deductum, qua parte concederetur, & qualis esse deberet, qua parte sit concedenda, & qualis, & num liceat postea variare.

41 Aquæ certæ ducendæ per alienum fundum qui habebat seruitutem, si aquæ illi admisceat aliam, quæ cum priori mixta fluat, amittit iusducendi, etiam priorem, a parte aquæductus, à qua incipit fluere mixta: secus si naturaliter accrescat & admisceatur: aut si, quæ admixta fuit, possit diuertere, ut sola prior fluat.

42 Aquæ ducendæ de nocte seruitus si vna concessione sit concessa, & aliæ aquæ ducendæ de die, duæ sunt distinctæ seruitutes: vnaque amitti potest per non vsum illius, non amissa alia, qua interuenerit usus.

HÆc Disputatio affinis etiam est duabus [sect. 1] præcedentibus. Atque de aquæducto latius

sumpto, quàm vt seruitutem solam contineat, de qua Disp. 11. est dictum, futurus est nobis hoc loco sermo. Dicen dum verò est de aqua ipsa ducenda, atque de viis, ac instrumentis, quibus ducitur: quæ riuorum nomine, latè sumpto vocabulo, comprehendi possunt. Porro riuus hoc loco, non pro decursu aquarum, vt à flumine pressè sumpto distinguitur, sumitur: in qua tamen significatione sumptus à nobis fuit disputatione præcedente, sumiturque. ff. *de fluminib. l. 1. in prin.* dum flumen à riuo distinguitur, quòd riuus sit exiguus decursus aquarum, flumè verò magnus. Sed in re proposita riuus sumitur pro via ipsa, qua aquæductus decurrit ac deriuatur: in qua significatione sumitur. ff. *de riuis. l. 1. & sequentibus.*

Vt verò ab aquis vniuersim ordiamur. Earū [sect. 2] quædam sunt priuatæ, vt illæ, quæ in prædiis priuatis aliquorum nascuntur, neque à republica, lociue communitate, sunt usurpatæ ad aliquos vsus publicos. Atque eiusmodi aquæ, interim dum non ingrediuntur eorum prædia, quorum est origo, vbi nascuntur, eorum sunt propriæ, quorum sunt ea prædia, possuntque proinde de illis disponere, eisque vti, vt voluerint, atque eas deriuare, quò voluerint intra sua prædia; modò tamen, si inde deriuentur ac fluant in vicina aliorum prædia, id non sit cum eorum iniuria ac detrimento, ita vt eis ea de causa competat actio aquæ pluuiæ arcendæ, iuxta ea quæ Disputatione præcedente explanata sunt. Quādo verò deriuatæ iam sunt ac fluxerunt in alia prædia, eorum similiter efficiuntur, quorum prædia ingrediuntur. Eo verò ipso, quòd ad cōmunem aliquem alucum, vel ad communem alium locum, deuenerunt, communes efficiuntur tanta communitate, quantam habet is alueus, aut locus, in quem fluxerunt.

Reliquæ aquæ communes sunt. Cæterum in [sect. 3] multiplici gradu. Quædam enim sunt, quæ ad nullum vsum sunt cuiquam interdictæ. Vt regulariter esse solent aquæ fluuiorum, quæ nauigabilia non sunt, neque influunt proximè in nauigabile flumen. Tametsi, quando ex aliquo vsu detrimentum sequeretur communi bono populi, interdici is vsus posset, ac deberet, à cōmunitate, à potestatibusve publicis eius commun itatis, circa quam id flumen fluit. Vt si ex ablutione pannorum, aut aliarum rerum sordidarum, vel ex influxu cloacæ, aut alterius rei immundæ, in parte superiori fluminis, aut ex aliqua alia re, sequeretur aquam, dum ad locum deuenit, in quo ab ea communitate colligi ad bibendum solet, immundam, aut minus salubrem, fluere, interdici is vsus posset, ac deberet. Aliæ verò sunt aquæ publicæ ac communes, sed interdictæ quoad aliqua. Vt sunt nauigabilia flumina, aut quæ in ea proximè influunt, vel quæ flumen, in quod influunt, efficiunt nauigabile. [[134]] Eiusmodi quippe aquæ extrahi & deriuari aliò non permittuntur, neque in eis aliquid effici, aut in earum ripis, vnde detrimentum aliquod nauigationi obuenire possit, vt disputatione præcedente explicatum est. Interdum etiam aquæ fluuii alicuius, torrentis, aut fontis, à communitatibus, aut à principe, ad irrigandum assumuntur, ac distribuuntur, vel assumuntur ad aliquem alium vsum; neque interdicuntur quoad vsus, qui detrimentum non afferunt vsui, ad quem assumptæ sunt; vt interdictum non est ablui in eis pannos, & alia, quæ irrigationi non nocent, aut alteri vsui, ad quem assumptæ sunt. Quando autem assumuntur, vt deriuentur ad fontes publicos in ea ciuitate, aut oppido, tunc interim, dum in fontibus publicis non fluxerunt, interdici in eis consuevit vsus, qui illis ad hominum potum noceat, aut qui illas minuat, nisi in tanta sint abundantia, vt pars illarum concedi soleat ad alios vsus, aut gratis, aut persoluto pretio, ad eum aquæductum, quò deriuantur, reficiendum ac conseruandum, aut ad aliquid aliud, quod in bonum publicum conuertatur.

Rursusaqua, quæ ad irrigandum vel ad ali [sect. 4] qua alia ministeria ac vsus ducitur, diuiditur. *l. 1. ff. de aqua quotid. & æst.* in aquam quotidianam, & in aquam æstiuam. Æstiuæ aqua, *vt habetur eadem. l. 1. & l. de interdicto. ff. eod. titu.* ea dicitur, quæ sola æstate, hoc est, à verno æquinociali mensis Martii, vsque ad autumnale æquinociale mensis Septembris (sic enim in re proposita sumitur æstas, vt videbimus) ducitur, saltem in parte aliqua eius semestris, siue quia illo tantum semestri potest duci, siue quia, licet alio etiam tempore posset optimè duci, intra illud tantum semestre consuevit duci, vel quia eo solo tempore prædia, ad quæ ducitur, illa indigent, vel quia dominus prædiorum illo tantum tempore consuevit illam ducere. Quotidiana verò aqua dicitur, quæ æstiuo & hyberno tempore duci consuevit, siue quotidie ducatur, siue certis statutis diebus, aut hebdomadis, siue quouis alio modo: id enim non impedit quominus quotidiana aqua dicatur. Itaque æstiuæ aqua non differt à quotidiana, quod æstiuæ quotidie non possit duci, sed quia siue duci quotidie possit, siue non, sola tamen æstate ducitur. Neque ad rationem aquæ quotidianæ requiritur, quod quotidie ducatur, sed quod duci consueuerit æstiuo & hyberno tempore, esto fas non sit quotidie eam utroque tempore duci. *Ulpianus. l. 1. citata*, ad rationem aquæ quotidianæ exigere videtur, quod peremniter fluat, siue semper ducatur, siue non, & siue semper fas sit eam ducere, siue non. Non tamen video, si torrens hyberno tempore fluat, & æstate vsque ad initium Iunii, quales sunt multi, atque in parte vtriusque semestris anni aqua inde ad ministeria aliqua ducatur, cur aqua illa dicenda non sit quotidiana, quod attinet ad interdicta, de quibus infra erit sermo.

Quando aqua solum ducitur hyberno tem [sect. 5] pore, nempe ab æquinoclio autumnali mensis Septembris vsque ad æquinoclium vernum mensis Martii, saltem in aliqua eius semestris parte, tunc dicitur aqua hyberna: & quia non consuevit esse vsus ducendi aquam solo illo tempore, non est constitutum peculiare interdictum circa hanc aquam; sicut constituta sunt diuersa interdicta circa quotidianam & æstiuam aquas, de quibus infra erit sermo; sed solum circa hybernæ aquam conceditur vtile interdictum aquæ æstiuæ, hoc est, instar interdicti aquæ æstiuæ, *vt habetur. l. 1. citata. §. si quis hyeme, iuncta glossa ibi verb. vtile. Ulpianus. l. 1. citata. §. quanquam*, ait, aquæ [sect. 6] ductus seruitutem, solum habere locum in aquis, quæ fluunt super terram: secus autem in putealibus, quæ super terram non fluunt, esto venæ earum peremnes sint: sed in putealibus aquis locum habere seruitutem haustus, de qua Disp. 11. est dictum.

Addit *Ulpianus*, interdicta aquæ quotidia [sect. 7] næ & æstiuæ, atque aquæductus seruitutem, solum habere locum in aqua, quæ ducitur à capite, hoc est, à fonte vnde primò emanare incipit super terram, aut quæ immediatè educitur à flumine, vel à palude, aut quando aqua sudoribus emanat super terram, & congregantur sudores illi in vnum locum, ex quo coniuncti incipiunt emanare in aqua, quæ inde incipit educi, quasi illa quatuor tantum sint capita, vnde deduci aqua immediatè debeat, vt rationem seruitutis aquæductus habere possit, competantque circa illam interdicta aquæ quotidianæ & æstiuæ. Cæterum quamuis de iure illo antiquo id ita fuisset sancitum; vt tamen *Paulus iuris consultus. l. seruitus aquæ ducendæ. ff. de seruit. rust. præd.* expressè ait, & notat glossa. *l. 1. citata verb.* non aliunde, postea fuit introductum, vt aquæductus seruitus habere posset locum, etiam in quacunque alia aqua aliunde ducta, esto concessa esset ex quocunque alio priori aquæducto. Nec dubito, sicut illa extensio facta fuit ad aquas ductas non immediatè ex quatuor capitibus explicatis: ita interdicta, de quibus erit sermo, ad eas etiam aquas eo ipso esse etiam extensa.

Quod ad aquas publicorum fluuiorum atti [sect. 8] net, est obseruandum. Esto quis habeat molendinum in flumine publico, siue collocatum in ipsomet alueo fluuii, siue extra alueum in loco, ad quem ducitur aqua ex fluuio vsque ad molendinum, indeque deriuatur iterum ad alueum fluuii, fas esse cuicunque alteri facere aliud molendinum, vel suprà in eodem fluuio, vel infrà, esto inde sequatur detrimentum domino molendini priùs constructi, quia minus lucrabitur, eo quòd pauciores ea de causa accedant ad molendum in ipsius molendino: est enim per accidens id damnum ac detrimentum, vtentibus aliis iure suo, molendina efficiendo in eodem fluuio, vel in aliis fluuiis, vnde per accidens id detrimentum sequitur. Intellige tamen, dummodo, qui eiusmodi noua molendina efficiunt, in suo proprio solo ea ædificent, vel in communi de facultate principis, aut communitatis, ad quam pertineat id concedere, vel in solo alicuius alterius priuati de legitimo illius consensu. Et dummodo non impediant cursum aquæ in illud aliud molendinum eo modo, quo antea in illud fluebat. *Ita habetur. l. 18. titu. 32. part. 3. & consentiunt Gregor. Lopez ibi. Barth. l. quominus. ff. de fluminib. & Cæpola de seruit. rust. c. 4. n. 41.* resque ex se est satis perspicua.

Quo loco obserua, vt habetur eadem. l. quomi [sect. 9] nus, & notant doctores citati, vnicuique fas [[135]] esse educere sua propria autoritate aquam de flumine publico, nisi ex peculiari aliqua causa id à principe sit vetitum, aut à communitate, permittente id principe; vel nisi ea aqua ad aliquem alium vsum publicum sit deputata, cum quo ea extractio pugnet, vt si deputata sit ad irrigandos aliquos agros: tunc enim non, nisi ad id, ad quod est deputata, extrahi potest, neque aliter ad id, ad quod est deputata, potest esse vsus illius, quàm iuxta leges, & ordinem, ad id præscriptum. Ratio verò vtriusque asserti hæc est. Quoniam cùm flumina publica gentium iure sint omnibus communia quoad vsum, vtique, interim dum ex rationabili causa de iure humano non superuenit prohibitio aliqua vsus aquæ illorum, vnicuique est fas illam autoritate propria extrahere, eaque vti, ad quod voluerit: secus autem superueniente ex rationabili causa prohibitione de iure humano. Quo pacto. l. quominus citata cùm dictum fuisset, vnicuique esse licitum extrahere aquam de flumine publico, prohibetur nihilominus illam extrahere de flumine nauigabili, aut quod proximè influit in nauigabile flumen, vel cum eo nauigabile flumen efficit, ne nauigationis vsus impediatur, aut deterior reddatur. Vbi notat glossa, si nihilominus facultas à principe ad eam extrahendam concedatur, opus esse apponi derogationem eius iuris in tali concessione, vt sit valida. Satis tamen ad id, meo iudicio, erit dicere, non obstante, quòd tale flumen nauigabile sit, aut quod influat in nauigabile flumen. Eadem etiam lege habetur, quando aliqua aqua alicuius fluminis ad aliquem vsum publicum est deputata, cum quo scilicet repugnet extractio illius ad alia, tunc etiam nefas esse, extrahere eam ad alia. Quamuis autem hæc ita fint; quia tamen aqua publicorum fluuiorum minui propter molendina non solet, neque propter illa impediri solent alii eiusdem aquæ publici vsus; eo quòd, esto ad molendina aliqua extra alueum extrahatur, continuò ad eum refluere soleat, continuareque per illum cursum suum in eadem quantitate, in qua flueret, si ad molendinum non accessisset; quia item molendina vtilia valde reipublicæ sunt, in communeque bonum cedunt; vtique prohibitiones prædictæ extractionis aquæ, etiam à fluminibus nauigabilibus, aut quæ influunt in nauigabile flumen, non intelliguntur de extractione ad molendina, vt bene notat Cæpola vbi suprà, iunctis duobus numeris præcedentibus, quando ad extrahendam ita aquam nihil fieret, vnde nauigatio aliqua ex parte impediretur, aut alius vsus aquæ, ob quem extrahi sit prohibita: quoniam ex fine, ad quem lex est condita, accipere debemus sensum, intentum, ac interpretationem illius. Quando item aliquid fieret ad extrahendam aquam ex flumine quocunque publico, vnde

vicinis damnum sequeretur, vt si ob septum in flumine factum (*presa nostri vocant*) aqua fluminis damnum aliis inferret, tunc nefas est cum illorum detrimento id efficere, *vt habetur. l. hoc iure in prin. ff. de aqu. quot. & est.* nisi fortè ea extractio in maiorem vtilitatem cederet, & id damnum vicinis resarciretur, vt Disputatione præcedente dictum est.

Nonnulla insuper obserua. Primum est, [sect. 10] quando aqua fluminis publici extra alueum ad molendinum aliquod extrahitur, tunc, esto extrahatur per prædium proprium domini molendini, aut per aliud alterius, qui eam seruitutem in eo suo prædio patiat, nouum tamen eum alueum, manu atque arte factum, quo pars ea fluminis in molendinum fluat, atque inde rursus in reliquum fluminis relabatur, ripasque vtrinque eiusdem noui aluei, ac talis fluminis, effici loca publica ac communia, sicut & pars ipsa fluminis, quæ per eum fluit, publica ac communis est, *vt expressè habetur. l. 1. ff. de fluminib.* Quod tamen ad ripas attinet, intellige effici solùm publicas & communes, solùm quoad vsum comparatione tantùm aquæ eius partis fluminis: nam quoad proprietatem, eius remanent, cuius est prædium, vt præcedentibus Disputationibus dictum est.

Secundum est, quæ dicta sunt de molendinis [sect. 11] in fluminibus publicis constructis, intelligenda similiter esse de molendinis constructis in torrentibus, qui in æstate siccantur, qualia aliqua vidi in Lusitania. Riuus quippe ac torrens, licet proprius sit domini prædii, in quo oritur, & per quem fluit, quando à republica non vsurpatur ad aliquem publicum vsum, atque ad solùm dominum talis prædii spectet construere tunc molendinum in eo suo prædio, si aqua tanta sit, quæ ad molendinum sufficiat; quando tamen egreditur id prædium, efficitur eius, cuius prædium ingreditur, & interdum communis efficitur duorum, inter quorum prædia dilabatur; atque aliquando efficitur communis reipublicæ, si alueus publicus reputetur, communisque sit vsus talis riui, aut torrentis, toti reipublicæ, oppidive communitati: atque tunc ad dominos prædiorum, per quæ dilabatur, spectabit efficere in eis molendina, ad communitatemque oppidi attinebit vel efficere molendinum in solo publico, per quod dilabatur, vel concedere facultatem alicui priuato, vt in eo molendinum ædificet.

Tertium est, quæ de molendinis tritici dicta [sect. 12] sunt, similiter esse intelligenda de aliis instrumentis, quæ fluuiorum aqua mouentur, vt de molendinis olei, & papyri, de serris, quæ aqua mouentur, de instrumentis, quibus batuuntur ac abluuntur panni, (nostri *batanes* vocant) & de iis, quibus ferrum conficitur, quæ *herrerias* appellamus: fas quippe est cuicunque alteri aliud simile, vel diuersum, instrumentum conficere similiter in superiori aut inferiori parte eiusdem fluminis, aut diuersi, vt lex 18 citata affirmat, resque est perspicua, cùm eadem ratio de his omnibus sit instrumentis.

Quartum est, postquam hanc & quasdam [sect. 13] alias sequentes Disputationes composui, me legisse longam *Antonii Gom. disputationem de molendinis. l. 36. tauri. à n. 10.* multis doctoribus & iuribus citatis, quam legas, atque ad hactenus à nobis hac de re dicta illa admetiaris: neque onim cum illo consentio in iis, in quibus à nobis discrepat. Illud probo, quod ex Paulo Castrensi refert. Quando in flumine publico molendinum fieret supra aquam, catenis alligatum ad ripas, vt fiunt Romæ in Tiberi, & in aliis fluminibus aliis in locis, tunc necessarium non [[136]] esse facultatem priuatis ad illud conficiendum: quoniam vsus aquæ fluminis omnibus est communis, itemque vsus riparum ad alligandum ibi nauigia, retia tendendum, & ad similia alia, quæ coniuncta sunt cum vsu aquæ fluuiorum: vnde communes etiam sunt quoad hunc vsum reipublicæ valde vtile ratione molendinorum. Intellige tamen non esse necessarium eius facultatem ad eiusmodi molendina conficienda, quando ex illis non impediretur nauigatio aliqua ex parte, saltem lintris, vt tiberis Romæ nauigatur.

Circa id autem, quod suprà dictum est, ne [sect. 14] fas scilicet esse, eum, qui posteriùs ædificauit molendinum in aliquo flumine, aliquid facere, quo vsus aquæ impediatur aliqua ex parte molendino priùs ædificato, obserua. Id verum esse, quando primus licitè illud ædificasset: quando enim illicitè illud ædificasset, esto impediretur ab ædificante posteriùs, siue licitè, siue illicitè, posteriùs ædificasset, non competeret actio domino prioris molendini, *vt patet. ex. l. 2. §. idem ait. ff. nequid in loco publico, & affirmat communis sententia, quam Ant. Gom. vbi suprà. n. 12. refert ac sequitur.* Qui autem priùs molendinum ædificasset, posset continere ac reprimere aquam, prout sibi vtile ac commodum esset, esto inde sequeretur detrimentum molendino posteriùs ædificato obuenire: quoniam priùs habuit ius ad vtendum in suum commodum ea aqua, neque alius posteriùs ædificans potuit præiudicare tali iuri iam antea acquisito. *Ita cum Bart. Ant. Gom. n. 12. citato.* Quando autem non constaret, quis priùs molendinum ædificasset, tunc quicumque eorum posset vti eo modo in suum commodum ea aqua, non curando præiudicium, quod per accidens alteri sequeretur, vt ibidem Ant. Gom. cum Bart. subiungit. Ex eo autem, quòd molendinum vnum sit ædificatum in superiori parte fluminis, non est coniectura priùs esse ædificatum, quàm aliud, quod sit in posteriori parte fluminis ædificatum: cùm non is ordo in ædificandis molendinis soleat seruari: sed casu omnino eueniat in superiori, aut in inferiori, parte priùs ædificari: neque est eadem ratio de scrip [sect. 15] turis, quæ in eodem portacollo notarii comperiuntur, eadem die conscriptæ, vt illa censeatur priùs scripta, quæ scripta in eodem libro reperitur ante aliam in superiori parte, aut in priori quaternione eiusdem libri aut portacolli: in libro enim is ordo seruatur in scribendo: secus verò in ædificando in fluminibus. Vnde non probo sententiam, in quam propendet ibidem Ant. Gom. cum Bal. & Iasone, quòd argumento ex scripturis id molendinum censeatur priùs ædificatum, quod in superiori parte fluminis ædificatum deprehenditur.

Vt ex dictis, tam hac, quàm Disputatione [sect. 16] præcedente, liquet, vnicuique fas est aquam educere de flumine publico, quando id prohibitum modis explicatis non est. Atque quando prædium meum coniunctum est cum flumine publico, ita vt nullum aliud alienum prædium mediet, sanè tunc seruitus non est meo illi prædio debita, quòd ex eo flumine educi possit aqua in id prædium meum; idque siue illam educam, quia iure gentium id mihi licèt, neque vlla sit prohibitio iuris humani ad eam ita educendum; in quo euentu nulli potest esse dubium, locum non esse seruituti; siue eam educam ex principis, aut ex communitatis, facultate mihi, aut illi meo prædio, concessæ, eo quòd à principe, aut à communitate, ex rationabili causa, educi esset interdicta, nisi ex ipsius præscripto & concessione. In hoc enim secundo euentu, licèt per eam facultatem ius sit comparatum ad eam aquam, nihil ea prohibitione impediante, inde educendam, vel personale meum, quod cum mea persona expiret, si mihi sit concessum, vt ego possim eam educere; vel reale prædio meo affixum, & ratione illius competens quibuscunque possessoribus illius, si illi prædio sit concessa, vt alibi dictum est, & inferiùs repetetur; id tamen propriè non habet rationem seruitutis: quoniam res communis ac publica, quale est id flumen, nulli seruit: sed est reductio eius rei per eam facultatem ad terminos iuris gentium comparatione talis personæ, aut talis prædii, ex rationabili ac iusta causa, qua ea facultas illi conceditur. Quando autem inter id flumen, & tale prædium, mediet prædium aliud alienum, per quod deduci deberet ea aqua, tunc obligatio eius intermedii prædii ad id patiendum, iusque in extremo meo prædio, vt per id intermedium duceretur, esset vera seruitus aquæductus prædii intermedii comparatione extremi prædii mei.

His ita explicatis, *Pomponius iuris consultus. l. hoc iure. §. si aquam. ff. de aqu. quot. & æstiva*, quod ad rem præsentem attinet, sic ait: *Si aquam ex flumine publico duxeris, & flumen recesserit, non potes subsequi flumen: quia ei loco seruitus imposita non sit, quamvis is locus meus sit. Sed si alluvione paulatim accesserit fundo tuo, subsequi poteris: quia locus totus fluminis seruiat deductioni. Sed si circumfluere cæperit mutato alueo, non potes: quia medius locus non seruiat, interruptaque sit seruitus.* Hæc ille. Azo, vt ibi Accursius refert, & plerique alii, exponunt hunc textum de eo, qui prædium habet coniunctum flumini publico, ita vt nullum aliud prædium alienum mediet, quique facultatem à principe habet educendi in id suum prædium aquam ex eo flumine, ita vt Pomponius dicat: *Si flumen recesserit*, non paulatim, sed simul, à prædio tuo, relicto antiquo alueo inter se & prædium meum, *non poteris subsequi flumen*, quasi possis adhuc, vi eiusdem antiquæ facultatis, educere aquam ex illo in tuum prædium, vt antea eam educere poteras: reddatque rationem: *quia ei loco* (hoc est, nouo alueo occupato à flumine, ratione cuius flumen censetur diuersum ab eo, quod antea erat, quando fluebat per relictum alueum) *seruitus imposita non sit*, (vt scilicet ex eo educi posset aqua in prædium tuum, sed solùm imposita fuerit flumini, vt antea fluebat per antiquum alueum relictum) *quamvis is locus* (id est, alueus antiquus, relictus inter flumen & tuum prædium) *meus sit* (id est, sit tuus, iure vicinitatis tibi tuoque prædio cedens, iuxta ea, quæ disputatione præcedente, & copiosius disput. 57. dicta sunt) Ego non dubito hanc adeò violentam, textumque destruentem, expositionem, alienam omnino esse à mente illius iurisconsulti, falsumque & omnino alienum à vera philosophia naturali ac morali esse sensum, qui ea intenditur. Nempe, flumen eo ipso, quòd alueum ac cursum mutat, esse aliud [[137]] numero flumen ab eo, quod erat antea, quando per alium fluebat alueum, eamque proinde solam causam sufficere, vt facultas concessa, iusque, quod erat antea ad extrahendam ex illo aquam, expiret omnino, vt intendunt & affirmant autores huius sententiæ, &, inter alios, Cœpolla. c. 4. citato à n. 35. Quare cùm pleraque ex iis, quæ Cœpolla ab eo numero tradit, huic falsæ expositioni falsoque fundamento innitantur, corruunt profectò, neque vlla illorum est habenda ratio. In primis ridiculum, & contra communem sentiendi ac loquendi vsum, veramque philosophiam naturalem, est affirmare, flumen eo ipso, quòd alueum in parte aliqua mutat, & aliò fluit, esse distinctum flumen ab eo, quod antea erat. Etenim flumen, non alueum significat, quo fluit, sed decursum ipsum aquarum, qui per alueum fluit: is verò aquarum decursus continuatione sui fluxus sine interruptione, quibusdam suis aquis, quibus tanquam partibus constat ac integratur, succedentibus aliis, dicitur vnum numero flumen interim dum fluere non desistit: ex eo autem quòd Tagus, verbi gratia, in parte aliqua mutet alueum, & aliò fluat, non desinit esse idem numero fluxus aquarum continuatione, ac proinde idem numero flumen, quod antea erat, sed alueus in ea parte est diuersus: flumen verò est idem alia alvei parte fluens: porrò facultas educendi aquam in aliquod prædium ex flumine (Tago verbi gratia) flumen ipsum, aquarumque decursum, significat, non autem alueum. Deinde quis non videat, violentissimam, textumque destruentem, esse expositionem, dum dicitur *eo loco*, intelligere alueum de nouo occupatum; & dum statim subiungitur, *quamvis is locus* (vbi apertè est sermo de eodem loco) intelligere, alueum antiquum, inter flumen & prædium relictum? Quis item non videat, violentissimam, textumque destruentem, esse expositionem, dum protinus subiungitur, *meus sit*, exponere, sit tuus, prædio scilicet tuo cedens? Præterea, quis non videat, violentum falsumque esse exponere, *quia ei loco* (id est, alueo de nouo occupato, ac proinde flumini iam diuerso ratione talis alvei diuersi) *seruitus imposita non sit* (aquam videlicet educendi, sed scilicet flumini antiquo, qui alvei mutatione

iam non existit, ac proinde ea de causa servitutem illam, ac facultatem educendi aquam, expirasse) Sanè id non quadrat cum illis aliis verbis proximè subiunctis, *quamvis is locus meus sit*. Neque ex facultate educendi aquam ex flumine publico, censetur imposita servitus ei flumini publico, vt ex illo aqua possit educi, vt idemmet Cœpolla. n. 46. sequenti, cum Bart. confitetur ac asseuerat.

Hac ergo expositione explosa, legitima sanè expositio est, quam Accursius ibidem ex negotio subiungit. Nempe, si aquam educebas ex flumine publico, siue gentium iure absque facultate principis, siue ex principis facultate, si erat interdicta, (vbi enim textus non distinguit, neque nos distinguere debemus) cæterum per prædium alienum inter medium (meum videlicet, qui tecum loquor) quod prædium servitutem aquæductus habebat impositam comparatione tui prædii, vt per illam educere eam ex eo flumine in tuum prædium posses; flumenque recesserit, relicto, non paulatim ac insensibiliter, sed simul alueo antiquo inter se, & inter prædium illud intermedium, qui alueus proinde cessit prædio intermedio, effectusque est meus, cuius est id prædium, iuxta ea, quæ Disp. 57 dicta sunt, tunc non potes subsequi flumen, & educere ex illo aquam per idem prædium, & alueum antiquum effectum meum ratione prædii coniuncti, cui cessit: *quia servitus ei loco*, hoc est, ei alueo relicto, *imposita non fuit*, sed soli prædio ab eo alueo diuerso: *quamvis is locus*, id est, is idem alueus, *meus sit*, ratione prædii coniuncti, cui cessit. Subiungit deinde Pomponius: *Sed si alluuione* (alueus scilicet idem) *paulatim acceperit fundo tuo*, (fortasse superfluit, mendoseque additum fuit verbum, *tuo*. Si verò non est mendum, expone, *tuo*, quoad servitutem in eo tibi deditam, sed meo simpliciter, vt paulo antea idem Pomponius dixerat) *subsequi potes*, flumen scilicet, educendo ex illo aquam per prædium, & partem aluei, quæ alluuione ei accessit: *quia locus totus*, id est, prædium vna cum parte, quæ alluuione ei accessit, *flumini seruiat deductioni*, id est, seruit deductioni aquæ ex eo flumine: eo quòd id totum reputetur idem numero prædium cum eo, quod antea erat, quia incrementum illud paulatim alluuione accedens non censetur res diuersa, sed vnum numero cum priori prædio, vt ex dictis Disp. 57 constat, eaque de causa servitus aquæductus existens in priori prædio, sese extendat ad id etiam, quod alluuione paulatim ac insensibiliter ei accreuit. Addit Pomponius: *Sed si flumen circumfluere ceperit mutato alueo*, (ita quòd non solum alueum antiquum, sed & aliud prædium, interiecta reliquerit inter se & inter meum prædium, quod tuo antea seruiebat aquæ per illud ex eo fluuio ducendæ in prædium tuum) *non potes*, subsequi videlicet flumen, & ducere ex eo aquam in prædium tuum, vt antea faciebas: *quia medius locus* (aluei videlicet antiqui, & alterius prædii, quæ iam nunc mediant inter flumen & prædium meum) *non seruiat*, (id est, non habeat servitutem aquæ per ea ducendæ in prædium tuum, sicut servitutem habet prædium meum) *interrupta sit servitus*, mei videlicet prædii comparatione tui, ob defectum aluei antiqui & illius alterius prædii, quæ mediant, & quæ servitutem non habent, vt ducere per ea possis aquam ex eo flumine.

Occasione horum vltimorum verborum [sect. 17] Pomponii, quibus docet, in hoc vltimo euentu interruptam esse servitutem aquæductus prædii mei comparatione tui, quærit Accursius in glossa verb. interrupta, num si flumen redeat ad antiquum alueum, dicendum sit, servitutem redire, seu esse, in prædio meo comparatione tui, ita vt ex eo flumine ducere possis aquam per prædium meum in prædium tuum, vt eam antea ducebas. Cæpolla vbi suprà neganter respondet, inhærendo semper primæ violentæ ac falsæ expositioni huius textus, quam impugnauius. Rationem verò reddit: quoniam eo ipso, quòd flumen deseruit primum alueum, non mansit idem numero flumen, quod antea erat, ac proinde extincta omnino

[[138]] est omnis seruitus, ut ex eo aqua in aliquod prædium deriuetur: & quoniam, quando flumen ad alueum regreditur primò relictum, est etiam aliud numero flumen.

Dicendum tamen est cum Accursio glossa citata, non solum restaurari, sed etiam nunquam fuisse amissam eam seruitutem, sed fuisse solum interruptam, hoc est, impeditam quoad vsum illius ex defectu, quòd duci aqua ex eo fluuio vsque ad id prædium non potuit propter alueum antiquum intermedium, aut etiam propter aliud prædium inter flumen & eum alueum interiectum, quæ seruitutem eius aquæductus non habeant: quare eo ipso, quòd flumen ad antiquum alueum regreditur, vel quòd obtinetur seruitus aut facultas ducendi aquam per alueum, aut etiam per prædium, interiecta inter flumen & prædium, quod seruebat, vel quòd dominus prædii, ad quod ducenda est aqua, comparat eorum dominium, manet vsus eiusdem seruitutis interruptæ, ut antea erat: id quod Pomponius satis apertè hoc loco docet, dum ait, interruptam in euentu, de quo loquitur, esse seruitutem. Confirmatur aper [sect. 18] tè ex. l. in tradendis. §. interpositis. ff. commun. præd. ubi habetur. Non solum posse acquiri seruitutem in domo distante à mea comparatione domus meæ, ne illa distans altiùs tollatur, aut ut altiùs tollatur, esto in alia intermedia, aut in aliis intermediis, nulla sit talis seruitus: idque propterea quòd vsus, aut quasi vsus, talis seruitutis, nempe quòd illa distans in meæ domus commodum non extollatur, aut quòd extollatur, esse possit independeter à seruitute in domibus intermediis: sed etiam posse comparari seruitutem in prædio distante, sine seruitute in prædio intermedio, à quo tamen intermedio pendeat vsus seruitutis prædii distantis, ut si sit seruitus itineris, aut aquæductus, vel alterius similis: atque tunc, si prædium intermedium sit quoad dominium illius, cuius est prædium, cui ea seruitus à distante debetur, uti poterit ea seruitute per id suum prædium intermedium: si autem sit alicuius alterius, qui non permittat per id prædium uti seruitute prædii extremi, erit interpolata ea seruitus prædii extremi, quousque in eo etiam constituatur similis seruitus, adde tu, aut aliunde sit facultas vtendi ea seruitute per prædium intermedium. Vnde quando. l. qui sella. §. ult. ff. de seruit. rust. præd. sic scriptum legimus: *In rusticis autem prædiis impedit seruitutem medium prædium, quod non seruit*; intelligitur illam impedire quoad vsum illius: non verò ut in eo esse non possit interpolata, seu interrupta, quoad vsum illius, ut duo iura citata apertè docent. Præterea intelligitur eam impedire, quando nec seruit, neque alia ratione est facultas ea vtendi per id medium prædium, ut explicatum est. Idcirco autem dictum in eo textu est, *in rusticis prædiis*; quoniam, ut ex §. interpositis est dictum, in vrbaniis, ut in vna domo, comparatione alterius, esse potest vsus seruitutis domus distantis, sine seruitute, ac vsu seruitutis, intermedia, aut intermediis. Lege glossam. §. ult. citato.

Quando aliquis est in possessione, aut quasi [sect. 19] possessione, ducendi aquam, adiuuenta sunt à iure interdicta quædam prætoria ad eum tuendum in sua possessione, aduersus prohibentem ac impediendem eam ducere, de quibus est consequenter à nobis hoc loco dicendum. Et quidem quando aqua est quotidiana, iuxta ea quæ suprà dicta sunt, neque educitur de loco communi, quam proinde concedere educi ad principem, aut ad communitatem, attineat; si is, qui eam educere prohibetur, aut impeditur, nec vi, nec clam, nec precario, bonaque fide, existimans se iure id efficere, neque in iure errans, illam semel saltem de die, aut de nocte, eduxerat intra annum computatum vsque ad punctum, in quo eam educere prohibetur, aut impeditur, competit ei interdictum de aqua quotidiana nuncupatum, quo prohibetur obstaculum ei apponi, cumve impediri, quominus illam educat ea præcisè forma ac modo, quo illam intra eum annum eduxerat, defenditurque ac conseruatur in ea possessione, aut quasi possessione, illam eo modo ducendi, interim dum

aliunde non probatur, nullum ius eum habere ad eam ita ducendum, neque præscriptionis titulo, neque quocunque alio. *Ita habetur. l. 1. ff. de aqua. quotid. & æstiu.* consentitque communis doctorum sententia. Competit verò id interdictum, non solum si aqua educatur ad irrigandum, sed etiam si educatur ad quodvis aliud ministerium, etiam ad vrbani prædium, atque etiam si aqua educatur calida. *Ita habetur ibidem. §. illud quæritur.*

Quando autem aquam educere vellet alia forma & modo, quam eo anno esseteducta, ut quia in maiori quantitate educeretur, vel alia via ac modo, tunc impunè prohiberetur ita educi, ut ibidem habetur. §. illud tamen. Postquam tamen ingressa aqua esset prædium, ad quod educitur, tunc de illa efficere posset dominus prædii, quod vellet, modò id non cederet in præiudicium eius, unde educitur, aut loci, per quem educitur & deriuatur vsque ad id prædium, ut ibidem subiungitur, & habetur. *l. ex meo. ff. de seruit. rust. præd.* Quamvis autem hoc interdictum ei non competat, qui intra annum vsque ad punctum, in quo impeditur, eam non duxit, esto ante eum annum inceptum illam duxerit, quia tunc non censetur esse in quasi possessione eam aquam ducendi; si tamen, cum illam ante eum annum coeptum duxisset, ipsa non destiterit per se ipsam intra eum annum fluere in prædium, quo ducta ante annum fuit, tunc competeret hoc interdictum, esto in rigore verè non posset dici, ipsum intra eum annum illam duxisse. *Ita subiungitur. l. 1. citata. §. quæsitum est, iuncta glossa ibi verb. videatur, & verb. penitus, & iunctis iuribus, quæ ea glossa citat.*

Competit verò hoc interdictum aduersus quemcunque prohibentem educere aquam, ut eo annoeducta est, siue qui prohibet, dominus sit prædii, unde est educenda, aut per quod educitur, siue non. *Ita habetur ibidem. §. competit.* Item si duo riuales, aut corriuales, id est, qui aquam aliquam per eundem riuum educant, inter se contendant de eius aquæ vsu, vnoquoque contendente ad se, & non ad alterum, pertinere, eumque prohibeat, vnicuique competit hoc interdictum aduersus alterum, ac proinde vtrique simul competit duplex. Item agere possunt interdicto vti possidetis. *Ita subiungitur ibidem. §. si inter, iuncta glossa ibi verb. duplex.* Hoc idem interdictum aduersus eum etiam competit, qui aliquid facere aggreditur, fodiendo, serendo, succidendo, putando, ædificando, aut quid aliud simile faciendo, unde sequitur, ut aquam, quam hoc anno eduxisti, educere non possis, aut non possis eam educere, qualem eduxisti, sed vitiatam quoad qualitatem, aut non in tanta quantitate, in quanta es in possessione ut eam educaas, & competit, ut id efficere prohibeatur. *Ita habetur ibidem. §. Labeo putat.* Quod si id iam effecit, competit idem interdictum, ut illud destruat, & reducat in pristinum statum, ita ut aqua educi possit, ut antea fuiteducta. Atque, quoad hoc, interdictum hoc non est prohibitorium, ut est quoad alia, quæ dicta sunt, sed est restitutorium, *ut habetur eadem. l. 1. in prin.* Hoc verò interdictum, actioe ex illo, quia est in rem scripta, eo quod competat ratione prædii, in quod aqua ducitur, competit etiam successoribus in eodem prædio, etiam si titulo particulari, ut emptionis, aut alio simili, in id prædium succedant, si prohibeantur ducere in illud aquam eo modo, quo intra annum ducta est. *Ita habetur eadem. l. 1. §. ait prætor inter hæredes. Cæpolla de seruitut. rust. præd. c. 4. a. numer. 99. tradit ex Roff.* Venauentano praxim conficiendi libellum iuxta hoc edictum, itemque conficiendi articulos, seu positiones, ac capitula, quæ tum ab actore, tum etiam a reo, præsentari hac de re debeant, ut ab eis probentur, & circa quæ aduersarii interrogari debent. Eum legito.

Quando aqua est æstiuæ, iuxta ea quæ in [sect. 20] principio huius Disputationis dicta sunt, neque educitur de loco communi, quam proinde concedere educi ad principem aut ad communitatem spectat; tunc si is, qui hac æstate eam educere prohibetur, aut impeditur,

nec vi, nec clàm, nec precario, bonaque fide existimans se iure id efficere, neque in iure errans, illam semel saltem de die, aut de nocte, eduxit priore æstate, competit ei interdictum de aqua æstiva ad ea omnia, quæ suprà in priori edicto de aqua quotidiana dicta sunt, eoque modo, quo ibi dicta sunt. Solùm enim differt hoc edictum à præcedente, quòd præcedens competit, quando aqua, cum prædictis conditionibus bona fide fuerat educta intra annum vsque ad punctum, in quo educi prohibetur; non verò si intra eum annum non suerat cducta, esto antea educta fuerit, quia non censetur esse in possessione eam educendi: hoc verò edictum competit, in quocunque tempore præcedentis æstatis fuerit bona fide cum eisdem conditionibus educta, sumptaque æstate, non pressè, pro mensibus tribus, qui sunt à solstitio æstivo vsque ad æquinodium autumnale, sed latè pro sex mensibus, qui sunt ab æquinodio verno, hoc est, quod incipit in fine hyberni, vsque ad æquinodium autumnale, atque ita interdictum hoc ad longè maius tempus potest sese extendere, quàm interdictum aquæ quotidianæ, vt, si statim post æquinodium verni, in initio æstatis, quæ tunc incipit, aquam æstivam eduxit, neque iterum illam eduxit vsque ad finem æstatis sequentis prope æquinodium autumnni, quo tempore prohibeatur eam educere, competit ei adhuc hoc interdictum, cùm tamen elapsi sint ferè decem & sex menses. Hæc habentur. l. 1. citata à §. deinde ait prætor vti, iunctis verbis præcedentibus in fine prioris edicti.

Ei verò, qui, cùm in priori æstate eam a [sect. 21] quam non eduxisset, in ea tamen ipsa æstate, in qua prohibetur, illam ante eam prohibitionem eduxerat bona fide & cum cæteris conditionibus explicatis, non competit aduersus prohibentem directum interdictum aquæ æstivæ, sed vtile, vt habetur ibidem vers. qui hac æstate. Vbi glossa ait, vt hoc vtile edictum in eo euentu ei competat, necessarium esse, vt triginta diebus illam eduxerit, hoc est, à triginta diebus à puncto, ex quo illam educere cœpit, aliquoties illam eduxerit vsque ad punctum, in quo prohibetur, argumento. l. 1. ff. de itinere actuque priuato, vbi, vt interdictum aduersus prohibentem vsum itineris per aliquod fundum ei competat, qui prohibetur cransire per eum fundum, necesse est, quòd eo anno, computato vsque ad punctum, in quo prohibetur, triginta diebus eo itinere, modo explicato, fuerit vsus. Multum tamen dubito de veritate eius glossæ. Nam aliud longè diuersum sancitum est, vt quis censeatur esse in possessione ducendi aquam quotidianam, aut æstivam, & vt censeatur esse in possessione itineris. Ad aquæ quippe possessionem sancitum est, vt sufficiat vnicus actus intra tempus, pro quo edictum competit, cum conditionibus requisitis: ad itineris verò possessionem fuit statutum, vt interueniret vsus itineris cum eisdem conditionibus triginta diebus intra annum modo explicato.

In eadem. l. 1. §. citato: ff. de aqua quotid. & æst. [sect. 22] habetur: Si quis solitus sit educere aquam solùm hyeme, & non æstate, atque prohibeatur, competere illi vtile interdictum aquæ æstivæ, hoc est, instar aquæ æstivæ, vt scilicet si priori hyeme illam cum conditionibus requisitis aliqua die, aut nocte, vel semel eduxit, & in hyeme hac prohibetur illam educere, competat ei hoc interdictum aduersus prohibentem: vnde tantam latitudinem temporis habet hoc interdictum vtile aquæ hyemalis, quantam habet directum aquæ æstivæ. *Cæpolla. cap. 4. citato à numer. 103.* tradit praxim conficiendi libellum, & positiones, iuxta interdictum aquæ æstivæ. Eum legas.

Tertium additur interdictum, quod nuncu [sect. 23] patur de aqua ex castello. Quando enim aqua est ita publica, quòd nefas est cuiquam illam [[140]] inde educere absque principis facultate, vel senatus, aut communitatis, cui vsus & distributio illius à principe sit relicta ac permissa, iuxta ea quæ suprà dicta sunt; tunc, si aliquis legitimam habeat facultatem illam ducendi, vel ex castello, hoc est, loco vbi congregatur ea aqua, vt inde

deriuetur, ac distribuatur, (*arca* Hispanè nuncupatur, atque ea est vna ex significationibus vocabuli, castellum) vel ex quocunque alio loco publico, vt ex riuo, aut flumine, interdicto quoad extractionem aquæ ex illo absque speciali facultate; atque prohibeatur eam educere iuxta facultatem sibi concessam, competit sic prohibitio eiusmodi interdictum aduersus prohibentem, vt eam educere sinat iuxta eandem facultatem. Modò tamen, si ex tali extractione ac ductione eius aquæ, periculum immineat alicui vicino, illi caueat de damno infecto. Nam princeps, aut communitas, nihil concedere potest cum damno & præiudicio aliorum, nisi illis resarciatur ac compensetur, quando expediret vti ea facultate, nihil impediendo eo minori damno, ac proinde, quando vicino damnum aliquod imminet ex vsu talis facultatis, isque sibi de eo cauere postulat, non permittitur vsus educationis aquæ iuxta eam facultatem, nisi prius vicino caueatur de damno infecto. Vt verò hoc interdictum alicui competat, non satis est, eum antea bona fide eduxisse aquam ex tali loco publico, vt in duobus prioribus interdictis satis est vsus aquæ priuatæ bona fide intra tempus eis præscriptum; sed necesse est, vt constet de legitima facultate sibi ad id concessa, eamque sufficienter probet, si dubia sit, alioquin locum non habet hoc interdictum. Ratio autem est, quoniam, cum educere eam aquam nulli liceat absque legitima facultate, sanè, interim dum facultatem legitimam sufficienter non ostendit, censetur esse in possessione mala fide educendi eam aquam, à quocunque tempore, de cuius initio extat memoria; neque, si bona fide illam eduxisset, sufficeret minus tempus, quàm de cuius initio non extaret memoria ad sibi præscribendum ius absque facultate eam educendi aduersus rempublicam; eaque de causa non competit ei hoc interdictum aduersus prohibentem illam educere. Quando autem à tanto tempore, de cuius initio non extaret memoria, eam ita eduxisset, tunc ea immemorabilis possessio non solum præsumeretur fuisse cum bona fide, sed etiam cum legitimo titulo à principio ad id comparato. *Hæc omnia habentur. l. 1. §. ait. prætor quo. ff. de aqua quot. & æst. Cæpolla vbi supra à n. 108.* tradit praxim conficiendi libellum ac positiones iuxta hoc edictum. Vlpianus vbi supra. §. & datur, de eiusmodi [sect. 24] facultate & iure, quod conceditur ad educendam aquam ex loco publico, sic ait: *Datur interdum prædiis, interdum personis. Quod prædiis datur, extincta persona*, (quæ scilicet id ius prædio obtinuit) *non extinguitur* (quia videlicet est ius ipsiusmet prædii, illudque proinde comitatur, ad quemcunque hæredem, aut successorem in eo, tale prædium transeat) *Quod datur personis, cum personis* (quibus scilicet conceditur) *amittitur: ideoque, neque ad alium dominum prædiorum, neque ad hæredem, vel qualemcunque successorem, transit. Planè ei, ad quem dominum transit, impetrabile est* (id est facile is impetrabit eandem facultatem ac ius.) *Nam, si docuerit, prædiis suis aquam debitam, & si nomine eius fluxit, a quo dominium ad se transiit, indubitato impetrat ius aquæ ducendæ. Neque est hoc beneficium, sed iniuria, si quis fortè non impetrauerit.* Hæc Vlpianus ibi. Quia verò hæc tota Vlpiani doctrina copiosè Disp. 484 à nobis est explanata, non est cur in ea iterum explicanda hoc loco immoremur.

Quantum interdictum, tribus prioribus qua [sect. 25] si connexum ac adminiculum, traditur. ff. de riuis. Nempe in euentibus, in quibus dictum est competere tria priora interdicta, pro diuersitate aquæ ducendæ, atque pro temporibus, pro quibus dictum est vnumquodque eorum competere, iuxta diuersitatem aquæ, quæ ducitur, quotidianæ scilicet, æstiuæ, aut ex loco communi de facultate principis, aut communitatis, si eam duxeram, non vi, clam, aut precario, per aliquem riuum, aut riuos (hoc est, per loca quoad longitudinem depressa, seu decliua, quibus defluit aqua: sic enim in re proposita sumitur riuus, vt habetur. l. 1. in prin. ff. de riuis) intra tempus prædictis interdictis præscriptum, & quis me impediat

illam per eosdem riuos ducere, aut tam eos riuos, quàm alia, ad id annexa & necessaria, reficere, & purgare, vt aqua fluat, eamque educam, non aliter, sed eo modo, quo illam antea ducebam, tunc competit mihi interdictum de riuis nuncupatum, vt prohibeatur, ne me ea facere impediat. *Ita habetur. l. 1. ff. de riuis.*

Loca autem riuis annexa, quæ reficere ac [sect. 26] purgare possum, & circa quæ competit hoc interdictum aduersus eum, qui id impedit, sunt. In primis specus, hoc est, loca ad inspiciendum aquam, quando per riuos subterraneos, aut coopertos, fluit, fabricata, quæ profundiora esse solent, quàm sint riui ipsi, vt in fundo sordes residere possint, indeque extrahi, ne riuos obturent: inseruiunt etiam ad inspiciendam aquam, an illucusque perueniat, & in quanta quantitate, vt intelligatur, an riuus sit fractus, aut obturatus, & qua in parte, vt facilius, minori que cum sumptu ac labore, ei damno subueniri possit; sic dicta, ab inspiciendo. Hispanè *arcas* nuncupantur. Sunt deinde septa, quæ in fluminibus, aut torrentibus, fiunt ad continendam ac eleuandam aquam, vt inde per riuos extrahatur, siue ex lignis, siue ex lapidibus, aut ex aliqua alia materia sint confecta. Nostri *pressas* vocant, Accursius. l. 1. citata verb. excogitata, & alii, Sclusas appellant. Est deinde incile, hoc est, locus incisus in latere fluuii, quo aqua ex illo extrahitur ac fluit, ab incidendo dictus, quòd petram, aut terram, incidendo fiat, vt inde aqua ex flumine deriuetur, fluereque, quo volumus, incipiat. Hæc habentur. l. 1. citata in prin. Quando aqua in vnum locum adducitur, vt inde per multos ductus fluat ac ducatur, competit etiam hoc interdictum vtile aduersus eum, qui impediret eum locum refici aut purgari. Idem quoque interdictum competit comparatione omnium riuorum, & locorum eis annexorum, ad ductumque aquæ conducentium, siue riui in publico [[141]] loco, siue in priuato, sint constituti, etiamsi inseruiant ad aquam calidam eis deferendam: quin & competit hoc vtile interdictum ad reficiendos cuniculos, seu vias, per quas solus vapor aquæ calidæ trahitur ad locum aliquem, vbi eis vaporibus sudatur, vt morbi ea ratione expellantur. Competit etiam hoc interdictum eis personis, & aduersus eas personas, quibus, & aduersus quas, dictum est tria priora interdicta competere. *Hæc subjiciuntur. l. 3. §. si aqua. ff. de riuis.*

Quando aqua est quotidiana, aut æstiuæ, vt [sect. 27] interdictum competat aduersus impediendum reficere, aut purgare, riuos, quibus ducitur, & res alias ad illam ducendam inseruientes, satis est si, qui ita prohibetur, probet, se illam duxisse per eos riuos bona fide, non vi, clàm, aut precario, eo anno, aut superiori æstate, prout fuerit aqua, quæ ducitur; neque est necesse, vt simul etiam probet, se habere verum ius ad illam ita ducendam. *Ita habetur. l. 1. §. hoc interdictum competit, & l. 4. ff. de riuis.* Cùm tamen circa iter per fundum alienum, quamuis vt ei, qui transire prohibetur, competat interdictum de itinere aduersus prohibentem, satis sit probare eo anno triginta diebus fuisse vsum eo itinere nec vi, nec clàm, nec precario, & necesse non sit probare habere verum ius eius itineris; nihilominus, vt eidem competat interdictum de eo itinere reficiendo aduersus reficere illud prohibentem, necesse sit probare, vltra vsum eius itineris triginta diebus, se habere verum ius eius itineris, *vt habetur. l. 3. §. ait prætor, vers. hoc autem. ff. de itin. actuque priu. & l. 4. ff. de riuis.* Ratio autem huius discriminis, inter vtrumque interdictum de reficiendo, hæc redditur. l. 4. citata, iuncta. l. 3. etiam citata. Quoniam longè magis necessaria est reformatio riuorum ad vsum aquæ ducendæ, quàm sit reformatio itineris ad illo transeundum, plusque nocimenti euenire potest sitis, & detrimenti plantarum, ex eo quòd riui, quibus aqua est ducenda, non reficiantur, quàm ex eo, quòd iter non reficiatur; siquidem non propterea vsus itineris impeditur, licet

difficilior ac molestior reddatur; eaque de causa non tantam moram patitur refectio riuorum, quantam patitur itineris refectio.

Riuos, & cætera ad aquam ducendam necesse [sect. 28] saria, reficere, comprehendit, quod corruptum est, in pristinum statum reducere, seu instaurare, regendo, substernendo, sarciendo, & ædificando, quæ scilicet collapsa omnino sunt, non tamen aliquid de nouo ædificando ultra antiquum ædificium: id quippe non esset reficere, sed quid à reficiendo distinctum, *ut habetur. l. 3. in fine. ff. de itinere actuque priuato*, ubi, sumpto eo modo ædificare, dicitur esse distinctum à reficere. Item reficere comprehendit aduehere & asportare humeris, iumento, aut vehiculo, quæ ad prædicta efficienda sunt necessaria. Verbum autem purgare, quid importet, satis perspicuum est. Addit verò Vlpianus, purgare, non solum habere locum circa riuum, qui integer perseuerat, (ut quidam existimarunt) sed etiam circa eum, qui refectione indiget: cum fieri optimè possit, ut refectione & purgatione simul indigeat. Limites refectionis transgrederetur, neque aquam duceret, ut antea solebat, qui riuum per aliam fundi partem vellet ducere, aut illum latiore, depresso, aut altiore, vellet facere, quam antea erat, vel aliquid aliud facere vellet cum incommoditate aliqua domini fundi quoad ipsum fundum, eaque ratione non competere ei interdictum de riuis reficiendis aduersus eum, qui id illi prohiberet. *Hæc habentur l. 1. §. ult. & l. 2. & 3. in prin. & §. ult. ff. de riuis.*

Vtrum autem, qui antea aquam ducebat per [sect. 29] riuum opertum, prohiberi impunè possit, si illum aperiat, ducereque illam velit per apertum, aut è contra, qui aquam per riuum apertum ducebat, possit prohiberi, si illum operiat, vel, qui aquam per riuum terrenum ducebat, possit impediri, si cæmeticiam velit illum facere, vel sternendo solum, vel etiam latera aquæducti lapidibus & calce muniendo, ne aqua imbibatur per fundum, per quem ducitur, sed copiosior ad suum fundum deueniat, vel ad eundem effectum canales, aut fistulas (nostri *arcaduzes* vocant) in eo opere, aut è contra, qui aquam per riuum cæmeticiam, aut canales, vel fistulas, ducebat, possit prohiberi eam ducere per terrenum, ita quòd in his omnibus euentibus non competat aduersus iis de causis prohibentem, interdictum de riuis reficiendis, aquamque per illos ducendi. Concertatio est inter Vlpianum, Ofilium, Labeonem, Pomponium, & Seruium, quæ refertur tribus iuribus proximè citatis, & vix, aut ne vix quidem, scias quid tandem sit tenendum ex eorum iurium dispositione. Iurisconsultos verò illos ad concordiam, quoad fieri possit, adducendo, consentaneè ad rectam rationem, ad ipsamque rei naturam, arbitror esse dicendum. Si à principio, quando concessa fuit seruitus aquæductus per fundum alienum, aliquid constitutum, expressumque fuit circa qualitatem & modum riuorum, per quos aqua esset ducenda, tunc ei pactioni & expressioni est standum, neque fas est quicquam immutare contra voluntatem domini fundi, per quem aqua ducitur. Quando verò nihil fuit expressum, tunc ex circumstantiis concurrentibus, prudentis arbitrio est iudicandum, an aliquod damni augmentum ex ea riuorum mutatione domino fundi sequatur, quoad fundum in se, & res, quæ illi solo adhærent, quia videlicet plus terræ occupat riuus tunc, quam antea, vel aliqua alia ratione, vel certe sequitur aliquod damnum extrinsecum, aut priuatio commodi, cum quo damno, aut cum cuius commodi priuatione, nunquam à principio fuisset admissa talis seruitus, ut si admisit riuum terrenum, quia ex humore, qui inde in suum fundum redundaret, intelligebat fecundiores futurum suum fundum, plantis de ea humiditate participantibus, nulla ratione admissurus riuum cæmeticiam; vel si admisit riuum discoopertum, quia poterat appellere suos greges ad bibendum in eo, nulla ratione admissurus à principio riuum coopertum. Et quidem in his

euentibus, qui aquam per talem riuum ducit, mutare non potest modum riuui quoad qualitates illius contrarias. Si verò ex circumstantiis concurrentibus, prudentis arbitrio nullum damni augmentum sequatur fundo in se, ex ea mutatione riuui quoad qualitatem, neque item aliter sequatur tale damnum extrinsecum, aut priuatio [[142]] talis commodi, cum quibus nullo modo à principio admisisset riuum eo modo confectum, tunc licetè potest illum mutare quoad talem qualitatem, neque prohiberi à domino fundi potest, nihil impediante, quòd ex ea mutatione per accidens ei sequatur, non posse, verbi gratia, adquare in eo cooperto greges suos, quos, dum apertus erat, in eo adquarebat, *vt recte Pomponius lege. 2. citata ait.*

In euentibus, in quibus dictum est, compe [sect. 30] tere interdictum de riuui reficiendis aduersus eum, qui illos reficere, aut purgare, impedit, aut prohibet, tunc si noui operis nunciatio obijciatur, vt ea refectio impediatur, non auditur, qui id obijcit, sed contemnitur, neque refectio impeditur: *quia* (vt rectè Vlpianus ait) *cùm prætore ei vim fieri vetet, absurdum est per operis noui nunciationem eum impediri.* Poterit tamen aduersus illum agi negatoria reali actione, quòd scilicet ei non competat ius ducendi per eum riuum, aut fundum, eam aquam. Cæterum interim, dum plenè actor non probauerit tale ius ei non competere, refectio non impeditur ei, qui eo anno, aut priori æstate, eam aquam per eum fundum ac riuum duxerat, vt suprà dictum est. Item, si ex ea refectione damnum aliquod immineat, peti poterit, vt caueat de damno infecto, alioquin reficere non permittetur. *Hæc habentur. l. 3. §. si quis riuum. ff. de riuui, consentiuntq. l. de pupillo. §. si quis riuos. ff. de nou. oper. nunciat. & l. 1. §. si quis purificationi. ff. de cloacis.*

Præxim libelli, ac positionum, iuxta hoc interdictum, *tradit Cæpolla. c. 4. citato. à n. 112.* Quintum interdictum præcedentibus est af [sect. 31] fine; eo quòd ad seruitutes, iurave, haustus aquæ, & appulsus pecorum ad bibendum, attineat. Dicitur verò interdictum de fonte, denominatione sumpta à præcipua parte, vnde aqua hauritur. Et continet duas partes. Prior est. Quando quis intra annum, computatum vsque ad punctum, in quo prohibetur, bona fide, credens se vti iure, quod ad id haberet, nec vi, nec clàm, nec percario, hausit aquam de alieno fonte, puteo, lacu, aut piscina, in quibus aqua viua, seu emanans, continebatur, aut eò sua pecora appellebat vt biberent, si prohibeatur, competit ei interdictum de fonte nuncupatum, aduersus ita prohibentem, vt omnino eum prohibere desistat. Satis verò est probare vsum ita fuisse ea aqua intra eum annum, vt ei competat hoc interdictum, neque est necesse probare habere verum ius ad id, vt eo mediante in tali possessione, aut quasi possessione, defendatur. Quando autem vsus est eo haustu, aut appulsu, tanquam ius suo prædio vicino debitum, competit idem interdictum, seu actio, cuicunque successori titulo quocunque in eo prædio, si prohibeatur similiter vti, vt de interdictis aquæ quotidianæ & æstiuæ dictum est. *Hæc omnia habentur. l. vnica. ff. de fonte, consentitque communis doctorum sententia. Consentit etiam. l. 6. titu. 13. part. 3.* tametsi de seruitute concessa loquatur. Dictum est, dum modò aquam viuam contineant: quoniam, vt Vlpianus ibi ait, vt hoc interdictum competat, necesse est piscinam, aut lacum, viuam aquam, seu perpetuò manantem, continere. Vnde negat interdictum hoc competere circa aquam cisternæ, quæ ex imbribus congregatur. *Cæpolla tamen de seruit. rust. præd. c. 7. n. 9.* cum Bart. ad eundem locum, & cum Roff. rectè affirmat, competere tunc vtile idem interdictum. Addit Vlpianus lege vnica citata, idem interdictum competere ei, cui denegatur iter per idem prædium ad hauriendam inde aquam, aut ad appellendum pecora. Quoniam, cui competit aquam haurire, aut appellere sua pecora, tanquam annexum, omninoque ad id necessarium, competit etiam iter ac via ad eundem

fontem, puteum, lacum, aut piscinam. *Consentiunt. l. 6. titu. 13. part. 3. & iura*, quæ Greg. Lopez ibi citat.

Posterior pars interdicti est. Si is prohibeatur purgare, aut reficere fontem, quantum satis sit vt contineat aquam, atque vt aqua eo præcisè modo vtatur, quo ea vti est solitus, competit ei interdictum aduersus ita prohibentem, vt omnino prohibere ac impedire desistat. Idem est, si prohibeatur similiter purgare, aut reficere, puteum, & alia, vnde haustus aquæ aut ad quæ appulsus competit: estque idem dicendum de hac parte interdicti, quod de interdicto circa riuos purgandos ac reficiendos dictum est.

Præxim conficiendi libellum, & positiones, iuxta hoc interdictum, *tradit Cæpolla. c. 7. citato à numer. 12. iuncto. c. 8. sequenti in fine.*

Sextum interdictum, quod de cloacis pur [sect. 32] gandis & reficiendis nuncupatur, præcedentibus est etiam affine. Vnde & de illo agitur immediatè post interdicta præcedentia. ff. de cloacis, estque nobis hoc loco de eo dicendum. *Vt autem habetur. l. 1. §. 1. ff. de cloacis, cloaca est locus cauius, per quem colluies quædam fluat.* Atque vt ibidem habetur, cloaca est duplex. Quædam publica, quæ proinde, vt reficiatur ac purgetur, publicam curam meretur, neque spectat ad aliquem priuatum. Alia verò est priuata, quam reficere, ac purgare, ad eum, cuius est, spectat. In fauorem autem publicum, ne scilicet immunditiæ aërem inficiant, & ne colluies residens causa simul sit ruinarum, fas est cuicunque suam priuatam cloacam reficere ac purgare, esto per domum, aut per aliud prædium, alterius vicini, tam immediati quàm mediati, pertranseat, aperiendo in domo, aut in prædio alio alterius, quod necessarium fuerit ad eam cloacam reficiendam ac mundandam, dummodo, quod ita aperuerit, restauret, caueatque de damno infecto, si quod ex apertione, refectione, emundatione, ac restauratione immineat. Atque aduersus prohibentem, aut impediensem, talis cloacæ refectionem & emundationem, conceditur interdictum de cloacis reficiendis & purgandis, quo omnino cohibetur, ne id prohibeat ac impediat. Neque in hoc interdicto, vt in præcedentibus, est necesse, quòd præcesserit vsus nec vi, nec clàm, nec precario: quoniam id non impedit, quominus hoc interdictum competat aduersus impediensem, aut prohibentem, cloacæ refectionem ac purgationem. Nomine autem cloacæ in re proposita, comprehenditur tubus & fistula, *vt habetur. l. 1. citata. §. cloacæ appellatione.* Vbi glossa ait, tubus est foramen cloacæ, vnde purgatur collu-[[143]]uies aquæ. Fistula est aliud instrumentum ad idem. Fortasse tubus est locus latus in cloaca, vt ibi, dum aperitur, faciliùs mundetur, atque vt inde interstitia aliqua cloacæ, quæ sunt inter tubum & cubum, mudentur. Fistulæ verò sunt viæ strictiores, quibus aqua in cloacam effunditur ac confluit. Vt autem hæc etiam reficere ac mundare non impediuntur, competit etiam hoc interdictum. Idem etiam interdictum competit, vt, qui suam priuatam cloacam immittere velit in cloacam publicam, non prohibeatur. Quin & idem interdictum competit, vt si quis efficere de nouo velit cloacam priuatam, non impediatur, neque impediatur illam etiam immittere vt in cloacam influat publicam. Tametsi, quando cloaca priuata, quæ de nouo fieret, transire deberet per locum publicum, facultas esset petenda ab eo, cui est cura viarum publicarum, vt ille videat, an nocumentum bono publico afferat, & an expediat, vt deriuetur potiùs per alium locum. Credo etiam quando aliquis tentaret cloacam priuatam de nouo efficere, illamque immittere per prædium vicini, audiendum esse vicinum, si aliò commodiùs duci possit, vt potiùs per illum alium locum ducatur. *Hæc omnia habentur. l. 1. & 2. ff. de cloacis.*

Alterum interdictum subiungitur circa cloa [sect. 33] cas publicas, vt scilicet, si aliquid in eis sit factum, aut immissum, quo vsus earum deterior reddatur, reddive in futurum possit, res

in pristinum restituatur statum. Quare interdictum hoc restitutorium est. *Ita habetur. l. 1. citata. §. ult.* Per epicheiam autem intelligendum est, prohibendum, impediendumque esse fieri, dum attentatur. Atque quoad hoc erit prohibitorium.

Praxim libelli, & positionum, circa primum horum duorum interdictorum, *tradit Cæpolla ubi suprâ. c. 6.*

Nunc ad aquæductum reuertamur. *Quan* [sect. 34] *do* prædium, ex quo aqua est ducenda, aut per quod aqua est ducenda, est multorum quo ad dominium, non satis est, si vnus eorum concedat seruitutem eius aquæ inde aut per eum locum ducendæ, vt seruitus teneat, validaque sit concessio, sed necesse est accedat consensus omnium: tametsi, quando aliquis aut aliqui eorum non consenserunt, satis est si sequatur horum consensus, vt à puncto consensus vltimi, persistentibus aliis in suo consensu, hoc est, ab eo non recedentibus, integre concessa ac constituta ea seruitus censeatur. *Ita habetur lege si autem, & consentiunt duæ præcedentes. ff. de aqua pluua arcenda. Idemque est in cæteris seruitutibus in prædio multis communi concessis.*

Quando autem aliquis habet integrum vsum [sect. 35] fructum in prædio aliquo, aut etiam ius emphyteuticum in perpetuum, aut feudale, solus non potest validè concedere in eo seruitutem, nisi simul accedat consensus proprietarii: quippe id cedere possit in proprietarii præiudiciū: quamuis enim non ad ipsum, sed ad emphyteutam, aut vassallum, in perpetuum attineat vsus eius prædii, aut aquæ, quia tamen euenire potest, vt id vtile dominium cum proprietate consolidetur, ad proprietariumque pertineat, sanè id cedere poterit in illius detrimentum, eaque de causa, vt valida sit talis concessio, necessarius est consensus etiam illius. *Ita habetur. l. in diem. §. ult. ff. de aqu. plu. arc.* Hoc tamen intelligendum est de seruitute, quæ duret vltra tempus, in quo emphyteuta ipse, aut feudatarius, qui illam concedit, habuerit emphyteusim aut feudūnam in solūm tempus, quo concedens habuerit emphyteusim aut feudum, concedere illam possunt sine consensu proprietarii, modò ea seruitus non sit vsusfructus, vt hæc omnia copiosè Disp. 461. & 470. explanata à nobis sunt: id quippe in nullum detrimentum proprietarii redundat, neque prohibitum, sed permissum expressè reperitur in iure, vt ibidem ostendimus.

Quando prædium aliquod venditum esset [sect. 36] cum pacto adiectionis in diem, tunc, interim dum ea venditio pendet, vt seruitus aquæ ducendæ, aut quæcunque alia, validè in eo prædio concederetur, necessarius esset consensus, tam emptoris quàm venditoris, vt in quemcunque euentum res cederet, validè esset concessa. *Ita habetur. l. in diem citata.* Idemque est dicendum de quacunque alia venditione similiter pendente in futurum. Si tamen vnus illorum tantūm eam concessisset, & venditio cederet, ita vt prædium maneret omnino illius, tunc valida omnino efficeretur ea concessio eo ipso, efficereturque omnino atque irreuocabiliter illius, vt satis in eodem textu innuitur. Item in hoc, & in præcedente euentu, atque in quocun que alio simili, semper quando accederet consensus eius, qui deest, vt concessio esset omnium, firma redderetur concessio ac constitutio seruitutis, nisi aliquis aliorum à suo consensu antea destitisset, illumque reuocasset, iuxta ea quæ ex. l. si autem suprâ dicta sunt.

Vtrū autem pluribus concedi possit serui [sect. 37] tus aquæ ducendæ, ita vt sit satis consensus domini prædii, quo eam seruitutem vnicuique eorum concedat, sine aliorum consensu, quibus vel tunc simul conceditur, vel antea concessa sit? Distinguendum est. Quoniam si aqua sufficit vtrique eorum, quibus conceditur, tunc, siue vtrique concedatur simul, siue vni post alium, valida est concessio vnicuique illorum absque alterius consensu. Idem est, si aqua tota

concedatur simul aut successiuè duobus, sed vt vtantur ea alternis diebus, aut hebdomadibus, vel alio simili modo, ita vt vsus, qui vni conceditur, non impediat vsum eiusdem aquæ, qui conceditur alteri, vel si concedatur dimidium aquæ vni, & dimidium alteri, siue aqua magnæ sit quantitatis diuersis temporibus, siue parua. Atque in his omnibus euentibus, si iurgium ac quæstio inter eos oriatur circa vsum eius aquæ, ipsi inter se debent contendere, communiq̃ue diuidi iudicio res debet inter eos componi ac definiri. *Ita habetur. l. Lucio. ff. de aqua quotid. & æst. & consentiunt. l. 2. & l. cum constet. ff. eodem titu.* in hisq̃ue omnibus euentibus est intelligenda lex Lucio citata. *Idem habetur. l. 2. §. 1. & 2. ff. de seruit. rust. præd. iuncta. l. arbor. §. vlt. ff. commu. diuid.* quæ docet, communi diuidendo iudicio rem esse inter eos dirimendam, si quæstio circa illam inter eos oriatur. Quando autem seruitus aquæ priùs vni fuit concessa, si postea seruitus eiusdem aquæ conce-^{[[144]]}datur alteri cum præiudicio aliquo alterius, cui priùs fuit concessa, quia scilicet impeditur aliqua ex parte vsus eiusdem aquæ priùs illi alteri concessus, tunc inualida est talis concessio, nisi de consensu eius, qui priùs habebat id ius seruitutis, aut nisi post concessionem accedat consensus huius. *Ita habetur expresse. l. in concedendo. ff. de aqua plu. arcend.* quæ in hoc euentu, non verò in illis aliis prioribus, perspicuè loquitur. *Concinit. l. per quem. ff. de seruit. rust. præd.* Eorum enim omnium consensus est requirendus ad id, in quo iuri eorum præiudicatur. Atque in his consentiunt. *l. 5. titu. 31. part. 3. & glossæ iuribus citatis, atque Cæpolla de seruit. rust. præd. c. 4. n. 30.* Ex proximè autem dictis rectè infert atque affirmat Cæpolla ibidem. n. 23. semper concessionem aquæ posteriori, siue à priuato, siue à principe, aut à communitate concedatur, intelligi, saluo iure & priuilegiis eius, aut eorum, quibus priùs est concessa: quia non est intelligendum cum iniuria, aut detrimento, priorum, concedi posterioribus: quandoquidem illicitum nefasque id esset. *Consentiunt. l. imperatores. ff. de seruit. rust. præd. l. 2. §. si quis a principe. ff. ne quid in loco publico, & l. nec auus. C. de emancipationib. liber. Greg. Lopez. l. 5. citata cum Ioanne de Platea ait,* quando princeps aquam alicui priuato concedit ex publico aquæducto, intelligendum id esse, de ea quæ superfluit, non verò de ea, quæ necessaria est ad necessitates publicas, atque ad vsum publicum.

Vtrùm quando aliquis habet seruitutem du [sect. 38] cendi aquam ex aliquo prædio in suum prædium, possit de illa aqua alicui alteri dare, vel concedere, saltem haustum. Dicendum est, antequam ea aqua sit suum prædium ingressa, nefas illi esse sine noua facultate domini prædii, vnde eam aquam ducit, aut sine pacto à principio cum illo inito, vt id possit efficere, eam alicui alteri, etiā quoad haustum, concedere, esto is sit dominus prædii interiecti inter prædium vnde ducitur, & ad quod ducitur, qui seruitutem in eo suo prædio habeat, vt per illud ea ducatur. Ratio autem est, quoniam ea seruitus solùm censetur concessa, quoad prædium quo duci est permissa, & in quantitate & modo, quo duci est permissa, & quando quantitas aut modus non fuit expressus, præcisè quantum indiguerit prædium, cui fuit concessa, neque ad aliud habet ius dominus prædii, quò duci est permissa: quare, si idem dominus aliud emat prædium, non potest ad illud eam ducere, nisi postquam fuerit ingressa illud aliud suum prædium, comparatione cuius ea seruitus est concessa, atque tunc, modò id sit sine præiudicio vllo domini prædii, vnde aqua ducitur, *vt expresse habetur. l. 1. §. illud habeo. ff. de aqua quot. & æst. iuncta. l. non modus. C. de seruit.* Quòd autem nulli alteri possit illam concedere, etiam quoad haustum, esto is, cui concederetur, esset dominus prædii interiecti, per quod transiret, *habetur expresse. l. ex meo, iuncta. l. ergo, in fine, & l. cum essent. §. vlt. ff. de seruit. rust. præd. & l. modus. C. de seruit.* Atque lege cùm essent. §. vlt. citato habetur, ex pacto inito cum domino, vnde aqua ducitur, vel à principio, vel postea, posse

concedi de ea aqua, etiam domino fundi, per quod pertransit: & tunc censerī concessam eam quasi seruitutem ex prædio, vnde primò aqua ducitur, vt ex aqua illius id etiam accipiat, censeturque concessa à domino eius prædii, mediante illo alio, cui ius eam ita concedendi ex præuio illo pacto concessisset, vt bene ibi glossa notat. Quando autem aqua ingressa esset fundum, quò ducitur, & cui ea seruitus debetur, tunc, quia eo ipso est illius quoad dominium intetum dum sua prædia non egreditur, potest illam deriuare in aliud suum prædium, cui seruitus non debetur, aut concedere illam, cui voluerit, deriuando eam versus quodcunque prædium vicini voluerit, dummodo inde nullum præiudicium sequatur domino fundi, vnde primò esteducta, & qui eam habet seruitutem, vt si ea de causa educatur in maiori quantitate, quàm esset debita, aut quàm indigeret prædium, pro quo fuit concessa, inuito domino prædii, vnde educitur. *Ita habetur. l. 1. §. idem habeo. ff. de aqua. quot. & aest.* Consentit in his omnibus Cæpolla. c. 4. citato. n. 31. iunctis iis, quæ. n. 11. docet. Rectè verò. n. 31. subiungit, posse tunc imponere quasi seruitutē prædio vicini, quò eam deriuat, vt teneatur partem illius deriuare in aliud prædium alterius vicini, aut totam, postquam illa rigauerit id suum prædium: quam seruitutem comparatione alterius prædii si vicinus non consentiat, poterit aliò eam deriuare, quò ipse valuerit, pro locorum dispositione ac commoditate. Obserua autem, quando aqua nasceretur in aliquo prædio, atque inde deriuaretur in aliud vicinum, cui esset commoda, nulla in superiori prædio existēte ad id seruitute, neque alia obligatione, aut si ex flumine publicoeducta, aut aliunde illuc vsque naturaliter deriuata, vel adducta ex alieno prædio in tanta quantitate, quia seruitus erat constituta expressè, vt in tanta quantitate posset educi, indeque similiter deriuaretur in vicinum prædium, tunc posse similiter constitui in vicino prædio eam quasi seruitutem, & obligationem, vt partem, vel totam, postquam ea suum prædium rigasset, deriuaret in prædium aliud certum vicinum, aut vt pro illa aliquod pretium, aut pensionem, solueret: atque, si id admittere non vellet is vicinus, posset, qui id peteret, eamque aquam in illius prædium deriuaret, eandem aliò deriuare, quò vellet, & commodè posset, vicinumque illum ea commoditate priuare. Obserua etiam, quando seruitus esset constituta in prædio, vnde aqua deriuaretur, vt in quantitate certa perpetuò, aut statutis diebus, vel horis, deriuaretur in prædium, cui ea seruitus esset concessa, tunc dominus prædii, cui est concessa, dare posset partem illius, quam vellet, aut etiam totam, cui vellet, etiam antequam ingrederetur suum prædium. Quoniam ea tota quantitas aquæ sua est quoad vsum ac dispositionem, ac proinde, modò ipse ea priuetur, poterit eam cōcedere alteri fruendam loco sui, aut loco sui prædii.

Quando seruitus aquæductus, aut quæcunq; [sect. 39] alia, ab vno prædio debetur alteri, tunc ius in re in prædio dominante, quo mediante est ei formaliter debita ea seruitus, est totum in toto prædio, & totum in qualibet ipsius parte; quodammodo sicut anima rationalis est tota in toto corpore, quod informat, & tota in qualibet illius parte: eo quòd seruitus, quæ debetur, indiuidua sit, & ius ad illam sit etiam in prædio, cui ea seruitus debetur, indiuiduum, ita quòd tota debetur toti prædio, & tota cuilibet illius [[145]] parti. Est tamen hoc discrimen, quòd ita seruitus debetur toti prædio dominanti totaliter, tam ex parte rei, quæ debetur, quàm ex parte eius, cui debetur: partibus verò eiusdem prædii, licèt totaliter debeatur ex parte seruitutis debitæ, debetur tamen partialiter, sed pro indiuiso, partialitate eius, cui debetur, quoniam similiter pro indiuiso debetur simul cæteris partibus eiusdem prædii. Atque hinc euenit, quòd si seruitus, quæ debetur, diuidi quoad commoditatem & vsum possit, vt in re proposita diuidi potest aqua; & prædium, cui ea seruitus debetur, inter multos dominos diuidatur, vel titulo emptionis & venditionis, vel quouis alio; commoditas

quoque eius seruitutis eo ipso diuisa censeatur inter eos dominos prædii iuxta proportionem quoad quantitatem partis eius prædii, quæ vni contingit, ad partem, quæ contingit alteri, nihil impediante, quòd vna pars eius prædii sit longè melior, maiorisque prætium, quàm alia, & quòd ante diuisionem vna pars consueuerit participare ac frui maiori parte eius aquæ, quàm alia. Quo fit, vt si prædium diuidatur in duas medietates, æquales quoad quantitatem, licèt non quoad valorem, vnicuique earum debeat dimidium integrum commoditatis esus seruitutis, atque adeò dimidium eius aquæ, esto vna medietas prædii non tanta aqua indigeat quàm alia, & esto, quando vtraque medietas erat eiusdem domini, maiori copia eius aquæ consueuerit participare vna pars, quàm alia, eo quòd plus illa indigeret, maiusque lucrum inde domino resultaret. Quòd ius seruitutis sit totum in toto prædio dominante, & totum in qualibet parte, modo explicato, *habetur. l. via. §. quæcunque. ff. de seruit. rust. præd. c. l. 2. in fine, ac. l. 3. ff. si seruit. vend. c. quoad aquæductum habetur etiam. l. 1. §. idem Labeo. ff. de aqua quot. c. æst.* Quòd autem, quando prædium diuiditur venditionis titulo, aut alio, seruitus aquæductus prædicto modo quoad commoditatem diuidatur, *habetur. l. si partem fundi. ff. de seruit. rust. præd. & consentiunt alia iura citata.* Atque in his omnibus consentit *Cæpolla. c. 4. citato. a. n. 13.* Excipit cum Bart. & aliis, quando pars aliqua prædii, cui aquæductus seruitus debetur, non potest participare aqua illa, quia ad eam non potest ascendere, vel aliqua alia ratione, aut quia illa omnino non indiget: quoniam cùm seruitus illa præcisè debeat, & sit concessa, quantum prædium dominans ea indigerit, vtique ea pars, quæ illa omnino non indiget, est excipienda, & inter reliquas est diuidenda commoditas aquæ modo suprà explicato, *Argumento, l. ergo. in fine. ff. de seruit. rust. præd.* Quando seruitus, quæ debetur quoad commoditatem, non potest diuidi, vt seruitus viæ quoad commoditatem diuidi nequit, tunc tota, indiuisa quoad commoditatem, debetur singulis partibus prædii dominantis, quando prædium diuisum est inter multos dominos, ita quòd singulis dominis debetur via à prædio seruiente in partem prædii dominantis, quæ vnumquemque contingit: qua de causa quodammodo ea seruitus multiplicatur comparatione partium prædii dominantis, quando diuisæ sunt, pertinentque tanquam diuersa prædia ad diuersos dominos, *vs affirmat glossa. l. via. §. quæcunque, verb. diuisus est. ff. de seruit. rust. præd. iuxta. l. nam satis. §. 1. ff. quemad. seruit. amitt.* Quo loco obserua, si prædium dominans inter duos dominos diuidatur, ita quòd pars vnus maneat interiecta inter alteram, & inter prædium seruientem, tunc illa interiecta non debet seruitutem viæ, aut transitus aquæ, à prædio seruiente ad alteram partem distantem, nisi id deductum fuisset in pactum tempore diuisionis, atque adeò vsus seruitutis prædii seruientis manebit impeditum comparatione eius partis distantis, nisi per intermediam vsus illius fuerit in pactum deductus, aut nisi de nouo concedatur, vel nisi pars vtraque deueniat iterum ad dominum vnus & eiusdem. Ita *habetur. §. quæcunque citato, & affirmat glossa vlt. ibi, c. habetur apertiùs. l. si quis ex fundo, c. l. si partem. ff. quemad. seruit. amitt.*

Quando alicui seruitus aquæductus aut iti [sect. 40] neris per aliquod prædium est concessa, si expressum fuit, per quam partem prædii, & quantè latitudinis esse deberet, aut cuius qualitatis deberet esse iter aut aquæductus, vtrum per fistulas, (*arcaduces* nostri vocant) siue fictiles, siue ligneas, siue alterius materiæ, an verò lapidibus constructus, vel sine vllo lapide aut fistula, solo riuo in terra facto, quo aqua ducatur, tunc pactioni est standum, vt ex se est notissimum, *c. habetur. l. si prius. §. Recto placuit. ff. de aqu. plu. arc. l. loci. §. si quis mihi, ibi; nisi nominatim id conuenit; c. l. etsi fortè. §. modus. ff. si seruit. vend.* Quando verò nihil fuit expressum, aut constitutum, sed talis seruitus simpliciter, & sine vlla expressione, fuit concessa, tunc à principio is, cui fuit concessa, dirigere potest iter, aut aquæductum, per

quam partem fundi voluerit: si tamen aliò possit commodè dirigi ac duci, & cum minori detrimento domini fundi, tunc eò, & non ea parte, quam is eligit, cui seruitus est concessa, dirigi debet iter, & duci aqua, *vt expresse habetur. l. si cui. ff. de seruit. Lex si via. ff. de seruit. rust. præd. habet*, quando via alicui fuit legata per fundum testatoris sine alia expressione, ad hæredem pertinere eligere per quam partem eius fundi velit legatario viam concedere. Atque dicendum est, vel hoc ius præcedenti ea de causa non repugnare: quoniam, cùm legatarius eligere debeat viam, quæ ita sibi non sit incommoda, vt cum quàm minimo detrimento fundi sit possibile, eam sibi commodam eligat, vt in priori iure habetur; neque hæres eligere possit, nisi, quæ comoda sit legatario, vt posteriori iure satis exprimitur illis verbis; *si modò nulla captio legatario in seruitute sit*; parum vtique refert, siue dicatur, electionem esse legatarii, siue hæredis: vel certè dicendum est, posterius ius intelligendum esse solùm, quando exequutio legati directa est hæredi, vt quia dictum est, præcipio vt detur Petro via per talem fundum meum in tale prædium suum: nam tunc electio ad hæredem pertinet, iuxta ea quæ Disp. 198 dicta sunt, & consentit *Cæpolla. de seruit. vrba. præd. c. 22. n. 4.* cum plerisque aliis, quos citat. Postquam autem seruitus itineris aut aquæductus, simpliciter & sine alia expressione **[[146]]** concessa, semel per partem aliquam fundi est electa, nefas postea est illi, cui fuit concessa, variare inuito domino fundi, & eligere, vt potiùs ducatur per aliam partem fundi: quin potiùs cæteræ partes fundi, facta semel ea electione, liberè manent ab ea seruitute, solaquæ ea pars fundi illi subiecta manet. *Ita habetur l. si cui. ff. de seruit. l. vlt. iuncta glossa ibi. ff. de aqua quot. & æst. & l. certo. §. si totus. ff. de seruit. rust. præd.* quæ exprimit eo ipso reliquas fundi partes manere liberas ab ea seruitute. Habet tamen. §. ille in principio, quòd quando ita seruitus expressè fuisset concessa, vt semper is, cui conceditur, posset, qua vellet parte, iter aut aquam ducere, id facere posset tunc ex eo, quòd iter, aut aqua, per vnam fundi partem ducatur, reliquas partes fundi non manere liberas ab ea seruitute: quia, vi talis pacti expressi, potest mutare iter, aut aquæductum, per quancunque aliam eiusdem fundi partem voluerit, vt est notissimum, & *idem habetur. l. nam satis. §. cæterum. ff. quemad. seruit. amit.* Quod verò ad latitudinem, & qualitatem, itineris, aut aquæductus, attinet, quando simpliciter, & sine expressione aliqua, seruitus fuit concessa, non potest cum domini prædii maiore incommodo aliter à principio construi, quàm habeat loci consuetudo, & postulent circumstantiæ aquæ concessæ, & finis ad quem sit concessa, vt si fistulis duci consuevit, duci non potest aquæductu ex lapidi bus constructo, quando ex circumstantiis concurrentibus non intelligitur, vt & aquæductu ex lapidibus constructo duci posset, fuisse cōcessum; aut, si consuevit duci solo riuo facto in terra, non potest duci aquæductu lapidibus & calce confecto: quoniam talis aquæductus plus fundi occuparet, ac infecūdum & ineptum redderet ad plantas, quod ita occuparet. Similiter ex eo, quòd iter esset concessum, sterni non posset lapidibus, nisi id expressè fuisset concessum. *Ita quoad iter habetur. l. loci. §. si quis. ff. si seruit. vend. & quoad aquæductum. l. si priùs §. Recto placuit. ff. de aqu. plu. arcend. & l. 4. titu. 31. part. 3.* Postquam autem seruitus aquæductus constituta est ritè, esto fistulæ appositæ non essent, apponi de nouo possent, & fieri quæcunque alia mutatio posset, quæ in detrimentum nullum cederet domini fundi: secus autem, quæ in illius cederet detrimentum, vt suprà dictum est, & *habetur. l. quintus. ff. de seruit. rust. præd. l. hoc iure. §. is qui, & l. vlt. ff. de aqua quot. & æst.* consentiunt, quæ ex. l. 1. §. vlt. & ex. l. 2. & 3. *ff. de riuus supra dicta sunt.* Quando controuersia oriretur inter eum, qui seruitutem concesserat, & eum, cui esset concessa, nec conuenirent, per quam fundi partem duci iter deberet, aut aquæductus, iuxta formam concessionis, & num plus loci occuparet, quàm par esset, vel non, atque circa

aquæductus qualitatem, tunc arbitri deputari debent, qui id definiant. *Ita habetur. l. certo. a. §. si totus. ff. de seruit. rust. præd.*

Qui ius habebat certam aquam ducendi per [sect. 41] fundum alienum, si aliam propria industria illi admisceat, tunc prohiberi potest, etiam priorem aquam ducere ab ea parte aquæductus, qua illam miscuit: quia postquam aqua est admixta, discerni vna ab alia non potest: atque in indiuiduis, seu in indiuisibilibus, vtile per inutile vitiatur. *Ita habetur. l. 1. §. item quæritur. ff. de aqu. quot. & æst.* Si tamen naturaliter ac sine industria accrescat in ipso riuo, tunc ipsi accrescit, prohiberi que non potest totam ducere. *Ita habetur. l. hoc iure. §. aqua quæ. ff. eod. titu. & vtrumque asserit Cæpolla. c. 4. citato. n. 68.* Ego verò primum intelligerem, dum ea aqua mixta flueret: secus autem si diuerteretur omnino ea, quæ admixta fuit, & sola antiqua, ad quam ducendam habebat ius, flueret per aquæductum: neque enim per eam admixtionem amisit penitus ius antiquum, neque est cur dicendum sit illud amisisse, neque textus ille id sonat.

Quando vna concessione est concessa serui [sect. 42] tus aquæ ducendæ de nocte, & postea alia concessione est concessa seruitus ducendæ aquæ de die, distinctæ sunt seruitutes: eaque de causa, si illarum possessor vna quidem vtatur, sed non vtatur altera decennio inter præsentis, aut vicennio inter absentes, per eum non vsum amittitur ea, qua non vtitur. *Ita habetur. l. si prius in prin. de aqua plu. arcend.*

De noui operis nunciatione, & simul de interdicto quod vi aut clàm. Disp. 706.

SVMMARIVM.

1. *N*unciationis noui operis interdictum quas tres partes contineat. Et quot modis censeatur facta remissio nunciationis noui operis.
2. *N*unciationis noui operis edictum, etiam quoad secundam partem, vt scilicet nunciatus destruat, quod post nunciationem, & ante illius remissionē, adisicauerit, locum habet, etiam si nunciatus ius habuerit ad ædificandum: modò apertè non constaret, per nequitiam & sine ullo iure nunciari.
3. *I*nterdictum hoc locum habet quo ad id, quod nondum est ædificatum tempore nunciationis factæ: secus quoad partem ædificatam. Quoad ædificatum verò locum habet interdictum quod vi aut clàm, etiam si sola possessio ad alterum pertineret, & quam latè, vis, & clàm, quo ad id sumatur.
4. *V*is, quo ad interdictum quod vi aut clàm, quàm latè sumatur. Et quàm latè sumatur in eo clam aliquid efficere.
5. *A*edificatum ante factam nunciationem, vt interdicto quod vi aut clam destruat, necesse est vt factum sit, ignorante eo, qui nunciare poterat, id fieri.
6. *A*nte nuntiationem noui operis si aliquid factum sit in re, in qua alius erat in possessione, ignorante eo fieri, tunc inter dictum etiam vt possidetis cōpetit ei in continenti quando id scit: antequam possessionem amittat, vt regrediatur ad pristinum statum.

7. *Noui operis nunciatio locum habet, non solùm si quis paret ædificare fodiendo ad id terram, sed etiam si diruat ac destruat aliquid in alterius præiudicium: non verò habet locum in plantis, siue seminet, aut plantet, siue metat, aut aliter plantac destruat.*

8. *Nunciatio noui operis in quibus locum non habeat: locum tamen habeat interdictum quod vi aut clā: & in quibus neque interdictum quod vi aut clā locum habeat.*

[[147]] 9. *Noui operis nunciatio locum non habet, quando ædificatur aliquid in præiudicium seruitutis rusticæ: secus si ædificetur in præiudicium urbanæ. Et quod remedium locum in priori euentu habeat.*

10. *Nunciatio noui operis locum non habet aduersus fulcientem aut reficientem ædificium, si nihil addat, aut detrahat, quominus in eodem statu maneat.*

11. *Nunciatio noui operis locum non habet aduersus purgare aut reficere volentem riuum, vel cloacam, aut eam facientem, aut factam mittentem in publicam, etiam per alienaprædia: neque quando ex retardatione operis periculum magnum immineret, etiam priuatum.*

12. *Nunciatio noui operis locum habet, siue opus fiat in oppido, sine in villa, aut in agro, siue in loco priuato, siue in publico.*

13. *Nunciatio noui operis quibus ex causis iustè fiat. Variæ etiam sanctiones circa ædificia.*

14. *Nunciatio noui operis, intendendo ius proprium nostrum, quibus ex causis fiat. Et ad quem pertineat, vt vnum monasterium, aut vna parochia non ædificetur intra certum terminum alterius comparatione.*

15. *Nunciatio noui operis quot modis & qualiter fiat.*

16. *Nuncians nouum opus primo modo, possessionem amittit nunciato, eius circa quod nunciat, si illam habeat: non verò nuncians duobus aliis modis.*

17. *Nunciare qui vult coram iudice, si iudex sit absens, & protestetur se coram illo velle nunciare, ac adueniente iudice, vel accedendo ad illum cùm primùm potuerit, coram illo nunciet, censetur à puncto protestationis coram illo nunciasse.*

18. *Nunciatio in quocunque die, etiam feriato, fieri potest.*

19. *Nunciatio in rem, & non in solam personam, dirigi debet, vt efficacior sit, etiam quo ad ignorantes, & transeat in possessorem, & qui & quousque tunc teneantur.*

20. *Nunciatio cur potius fieri debeat in loco, in quo ædificatur, aut ædificari paratur, quàm extra eum locum. Et opifices, qui ibi operantur, si non cessent, quousque ipsi teneantur, & quousque dominus.*

21. *Nuncians quousque de loco publico, aut priuato, in quo ædificatur, aut ædificari paratur, facere debeat mentionem, aut de parte operis, aut de toto opere. Quando de diuersis operibus nunciatur, quæ in distinctis locis fiant, distinctæ nūciationes fieri debent. Et remissiones quando diuersæ esse debeant.*

22. *Nuncietur si de opere iam incæpto, ne continuetur, expediens est, vt testes adhibeantur, quantum ante nunciationem esset ædificatum, quin vt iudicis autoritate id mensuretur, vt postea sciatur reliquum, quod est demoliendum.*

- 23 . Nunciare circa res priuatas qui possint. Et nuncians, non habens ius ad id, ad quam restitutionem damnorum teneatur.
- 24 . Nunciat dominus rei, circa quam est nunciandum, aut prætendens se dominum esse, etiam habens utile tantum dominium, ut emphyteuta, aut feudatarius. Et nunciant superficiarius, aut habens ibi seruitutem urbanam realem.
- 25 . Nunciare non competit usufructuario comparatione proprietarii. Et quæ actiones aduersus eum illi competant. Aduersus vicinum nunciat nomine proprietarii, tanquam procurator eo ipso illius. Et proprio nomine quæ actiones aduersus illum ei competant.
- 26 . Nunciat possidens rem. Item cui subiecta est pignori aut hypothecæ.
- 27 . Non nunciat conductor, nisi eandem rem habeat hypothecatam, saltem in vniuersali: neque quicumque alius, qui solum habet ius personale. Et quæ actio conductori competat. Tenetur verò admonere ea de re locatorem. Atque, si absens sit, nunciare potest nomine illius, cauendo de rato.
- 28 . Nunciant validè quousque pupillus & vxor.
- 29 . Nuncient qui nomine alieno, & qui eorum cauere de rato debeant. Et pro eo, quod, post eam nunciationem, esto de rato non cauerint, fuerit ædificatum, competit interdictum quod vi.
- 30 . Nunciat quiuis dominorum loci communis multorum, ratione cuius nunciatur. Nunciatio tamē facta ab vno non prodest aliis, nisi nomine eorum sit facta cauendo de rato, aut ex mandato eorum.
- 31 . Nunciare non potest vnus condominorum, quādo alter in re vtrique communi ædificare aggreditur. Et quibus aliis remediis ei subueniatur, etiā ut cessare efficiat, quando non est expediens, quod alter aggreditur facere.
- 32 . Nuncians nouum opus, iurare tenetur de calumnia.
- 33 . Nunciare opus nouum, ob locum publicum omnibus quo ad vsum communem, cuicumque de eo populo competit. Qui excipiantur. Et num forenses admittantur. Concurrentibus multis ad nunciandum, idonior eligitur.
- 34 . Nunciatio noui operis cui fieri possit. Si, ob prædium multis commune, vni eorum fiat, quousque eorum domini teneantur, aut non teneantur.
- 35 . Vt nunciet de nouo opere, qui in particulari est constitutus procurator, aut tutor, vel curator minoris, si remittant nunciatio nem factam, quod postea fuerit ædificatum, non destruitur. Et quatenus minor in integrum quoad id restituatur. Procuratoris verò generalis remissio non valet, ut quod post nunciationem sit ædificatum, non destruat. Qui curam habet locorum publicorum cum facultate ad nunciandum opus nouum, non valet eius remissio: nisi in particulari sit aliud ei concessum, aut consuetudo aliud habeat.
- 36 . Nunciatum si per iudicem sit alicui opus nouum ad petitionem alicuius, concessio iudicis, ut ædificet, est sufficiens ad id remissio.
- 37 . Nunciatum si sit in commodum priuati, etiam no aliquid in loco publico fiat, ut remissio legis autoritate censeatur facta, satis est si nunciatus adhibeat fideiussores; quod si compertum fuerit non iure esse factum, id destruet, & soluet damna; aut si eos offerat, & per nunciantem stet, quod illos non recipiat. Quando autem nunciatum est in commodum publicum, satis

quidem est, si promittat se demoliturum; sed necesse est, ut coram indice ostendat ius, quo ædificare id potest.

38 . Nunciato & nuncianti qua ratione sufficienter sit cautum, aut consultum ea remissione nunciationis legis autoritate introducta.

39 . Nunciatio si remittatur præstita cautione, aut promissione, quæ forma in eis præstandie idonea.

40 . Duo iura exponuntur & conciliantur inter se. [[148]] Et quatenus actio ad hæredes nunciati transeat, aut non. Et quanto tempore duret actio ex posteriori edicti parte.

41 . Nunciatus si solum post nunciationem apposuerit fundamentum, ita ut id nuncianti non noceat, ad nihil tenetur, esto post ea comperiatur non iure ædificasse.

42 . Nuncietur si multis ædificantibus opus nouum, singuli cauere debent: ac si multi nuncient, singulis est cauendum, aut vni omnium loco, si omnes in eo conueniant.

43 . Nunciet si procurator opus nouum, & nunciatus satisdet, ac procurator progrediatur impedire continuationem ædificii, quæ actio aduersus eum competat, cogiturque cauere iudicatum soluere, alioquin repellitur a iudicio: quod non similiter locum habet in tutore, aut curatore, minoris nomine agentibus.

44 . Nunciatus si satisdedit, aut obtulit satisfactionem, & per nunciantem stetit, vel si ratione loci publici fuit ei nunciatum, & promisit, ac simul ostendit ius, quo id facere poterat, & impediatur, quo remedio ei subueniatur, & intra quantum tempus. Si per nunciantem stetit, quo minus satisfactionem admitteret, eamque postea petat, tenetur nunciatus eam dare, alioquin impune potest impediri.

45 . Nunciatus hodie de iure Codicis, esto cautionem offerat, si nuncians non velit illam acceptare, & ostendat se paratum ad probandum, nunciatum non iure ædificare, non potest nunciatus intratres menses continuare ædificium, & cætera quæ quo ad id sunt statuta. Et num si nuncians succumbat, competat aduersus illum actio de dolo ad damna.

46 . Nunciatus si ante remissionem ædificet, competit aduersus eum, non solum pars secunda interdicti de noui operis nunciatione, sed etiam interdictum quod vi aut clam. Et quanto tempore vnum, & alterum, competat.

Quoniam ex ædificiis, quæ alii aggredi, aut prosequi, volunt, sæpe priuatis, aut etiam communitati, ac reipublicæ, damnum, præiudiciūmve, sequitur, eo quòd contra ius ipsorum fiant; atque ad obuiandum ei damno ac præiudicio, prætorium interdictum, de noui operis nunciatione nuncupatum, est introductum; prosequendo materiam de damno dato, de eo interdicto est consequenter dicendum.

Interdictum de noui operis nunciatione [sect. 1] tres continet partes. Prima est prohibitoria, qua videlicet prohibetur eum, cui nunciatur, ne ædificium fiat in aliquo loco, aut in re aliqua, vel ne ceptum continetur, illud facere, aut continuare, nisi prius sit ei remissa nunciatio, quia scilicet facta est ei facultas, ut, nihil nunciatione impediante, possit ædificare, vel ab eo, qui nunciauit, qui contentus iam est, ut nihilominus ædificet, vel à iudice, qui pronunciauit, nunciatum habere ius ad ita ædificandum, ac proinde nunciationem fuisse nullam; vel quia nunciatus ipse satisdat, hoc est, fideiussorem idoneum præbet, quòd si compertum fuerit, se non iure ædificare, destruet suis sumptibus opus, & satisfaciet

dāna, si quę inde fuerint sequuta, aut certè quia, ablata ab eo cōpetente satisfactione, per aduersarium, nunciantēmve, stat quominus eam acceptet: in his enim duobus posterioribus euētibz lex ipsa nunciationem remittit, liberum relinquens ædificare, nihil impediēte priori nunciatione: quo fit, vt in quatuor euentibus explicatis, remissa censeatur nunciatio, liberumque proinde nunciato sit relictum, nihil impediēte præcedente nunciatione, aggredi opus prohibitum, aut illud continuare, absque vllius pænæ timore. Secunda pars interdicti est restitutoria, atque est effectus nunciationis. Ea enim nunciatus, si, ante nunciationis remissionem, aliquo ex modis explicatis, edificet cogitur demolite suis sumptibus, quod post nunciationem fuerit ædificatum, remque ad statum reducere, in quo erat ante nunciationem, siue verè haberet ius ad ita ædificandum, siue non: satis enim est, non paruissè interdicto prætoris, iurisque dispositioni, qua prohibetur, facta nūciatione, ædificare, aut continuare ædificium, nisi priùs ei nunciatio sit remissa, vt ea pēna iustè sit puniendus. Tertia autem interdicti pars est prohibitoria, qua prohibetur, nunciatum impediri ædificare, aut prosequi ædificium in priuato loco post cautionem datam, aut ablatam, nunciante illam non acceptante, quòd si compertum fuerit, ipsum non iure ædificare, demoliet suis sumptibus, quod post nunciationem fuerit ædificatum. Hæc omnia ita summatim proposita habentur. l. prætor ait, & aliis iuribus citandis. ff. de noui operis nunciat. & l. vnica. ff. de remissionibz. Sunt verò per partes copiosius explicanda.

Hoc interdictum quoad primam sui partem, [sect. 2] & consequenter etiam quoad secundam, vt scilicet sumptibus ædificantis destruat, quod post nunciationem fuerit ædificatum, si ante nunciationem remissam ædificatum id sit, locum habet, non solùm si iure sit facta nunciatio, quia scilicet ius non habebat nunciatus ad ita ædificandum, sed etiam si nullum ius nunciatus habuerit ad eam faciendam, quia videlicet ius verum habebat nunciatus ad eo modo ædificandum, quo ædificare volebat, aut continuabat. Cùm enim hoc interdictum in bonum commune sit latum ad rixas vitandas, & ad impedienda mala, quæ oriri poterant, si, dum contentio oriretur inter aliquos, num vnus in præiudicium alterius, aut reipublicæ, ædificaret, an non, non statueretur aliquid, quo pax conseruaretur, sancitumque eo sit, vt, orta contentione, & facta nunciatione, supersedeatur ab ædificando quousque remissio nunciationis aliquo ex modis prædictis sit facta, iure optimo fuit statutum, vt quamuis nunciatus verum ius ad ædificandum haberet, si tamen edictum transgrederetur ob eam inobedientiam, transgressionemque vtilis eiusmodi iuris dispositionis, pœnam illam incurreret. *Ita habetur. l. 1. in prin. c. §. sed etsi. l. prætor. §. 1. c. §. ait prætor. ff. de noui oper. nunc. l. 8. titu. 32. part. 3. c. 1. ac. 2. de noui oper nunc. Atque capite. 2. citato, iuxta. l. 1. §. sed etsi, additur, eum, qui post nunciationem factam, & ante eam remissam, ædificauit, admittendum non esse ad probandum ius sibi fuisse, aut esse, ad ita ædificandum, nisi priùs destruat, quod post nunciationem sibi factam ædificauit. Panor. tamen. c. 1. citato. n. 10. c. 11. c. Greg. Lopez. l. 8. citata, Ant. Gom. l. 46. tauri à. n. 36. cum Bart. & aliis, quos citant, rectè affirmant, hæc intelli-[[149]]genda esse, quando potuit aliquo modo esse dubium, num nunciatio iusta & valida esse posset: si enim notorium erat, nullum ius eum habere ad ita nunciandum, posse nunciationem contemni, neque ædificantem illa contempta incidere in eam aut in aliquam aliam pœnam: leges quippe censendæ per epicheiam non sunt fauere notoriis iniuriis ac versutiis hominum iniquorum.*

Interdictum hoc denunciatione noui operis, [sect. 3] tam quatenus inhibitorium est, quàm quatenus est restitutorium, competit solùm quoad opera futura, hoc est, quæ nondum sunt facta tempore nunciationis; non verò quoad id, quod est iam factum tempore nunciationis:

id enim destrui non potest ex hoc interdicto. Si ergo aliquis parat incipere aliquod opus, nondumque quicquam illius fecit, aut dubitetur ex indiciis, an velit ædificare, locum habet nuntiatio, hocque interdictum, quoad totum opus: si verò partem fecit, continuareque opus volebat, habet locum quoad id, quod nondum est factum, ut scilicet ædificium cesset, non verò quoad partem iam factam. *Ita habetur. l. 1. §. 1. & §. sed etsi. ff. de noui oper. nunc.* & affirmat communis doctorum sententia, quam *Ant. Gom. l. 46. tauri. num. 20. refert ac sequitur.*

Quoad id verò operis, quod ante nunciationem fuerit factum, quamuis non competat hoc interdictum, ut destruat, si tamen iniuste fuit factum, competit interdictum quod vi aut clam, ut habetur eadem. *l. 1. §. 1. ff. de noui oper. nunc.* cuius verba sunt: *Nam si quid operis fuerit factum, quod fieri non debuit, cessat edictum de operis noui nunciatione, & erit transeundum ad interdictum quod vi aut clam,* (introductum scilicet) *quod olim factum erit, ut restituatur;* hoc est, destruat, ad pristinumque redigatur statum, & affirmat ibi glossa verb. transeundum, & communis doctorum sententia: *Idem constat ex. l. 1. & sequentibus. ff. quod vi aut clam.* Sic enim lex. 1. habet. *Prætor ait, quod vi aut clam factum est, qua de re agitur; id, cum experiendi potestas est, restituas.* Subiungit verò Vlpianus, *Hoc interdictum restitutorium est: & per hoc occursum est calliditati eorum, qui vi aut clam quedam moliuntur,* (hoc est ædificant) *iubentur enim ea restituere* (id est, destruere, reduceré ad pristinum statum.) *Et parum refert, utrum ius habuerit faciendi* (qui id scilicet fecit, quando scilicet alius erat in possessione rei, in cuius possessionis præiudicium factum est) *an non. Siue enim ius habuerit* (quia scilicet ad ipsum, & non ad possidentem, id prædium verè attinebat) *siue non,* (quia scilicet ad eum non pertinebat id prædium) *tamen tenetur interdicto, propter quod* (id est, propterea quòd) *vi aut clam fecit. Tueri enim ius suum debuit,* (prædium exigendo) *non iniuriam comminisci* (efficiendo contra possessionem alterius interim dum iuridicè non erat ab illa deiectus.) Vnde subiungit Vlpianus, non admitti exceptionem, quòd in solo facientis id opus sit factum, ad effectum, ut non destruat, sed destruitur, posteaque auditur, si probare velit id prædium ad se attinere, & non ad possidentem, ac proinde ius sibi esse, id ibi ædificandi.

Vt interdictum, quod vi aut clam, intelliga [sect. 4] tur, atque in lucem eorum, quæ dicenda sunt, est obseruandum. Vim, in hoc interdicto, latius multo patère, quàm vim, de qua Disp. 682 in principio dictum est, quæ ad vim publicam ac priuatam requiritur ac sufficit. Quod enim ad hoc interdictum attinet, non solum dicitur aliquid vi factum, si fiat interueniente tanta ea vi ex parte facientis id cum præiudicio alterius, sed etiam, si id efficiat per se, vel per alium, prohibitus, seu nunciatus, ne id efficiat aliquo ex modis, quibus dicemus nunciari opus nouum, modò remissa ei nondum ritè sit nuntiatio. Quare, si nunciatus ne id efficiat, siue iudicis ministerio, siue ab ipsomet, qui prætendit sua interesse, ne id efficiat, idque siue lapilli iactu, siue solo verbo adhibitis testibus, vel sine testibus, siue ab aliquo, loco & nomine ipsius, iuxta ea quæ dicenda sunt, id efficiat, antequam nuntiatio ritè sit ei remissa, dicitur vi id fecisse, esto, quando nunciatus fuit, se continuerit ac destiterit: efficiendo enim id postea, antequam remissio nunciationis sit ei facta, dicitur vi id fecisse. Imò, qui, sciens se prohibendum, sibiue nunciandum, ne id efficeret, per vim fuit in causa per se, vel per interpositam personam, ne prohiberetur, néve sibi nuntiatio fieret, idque effecit, dicitur vi fecisse. Vt si nunciando aduersario aliquod triste, fecit illum recedere, impediuitque quominus nunciaret, vel si clausit ei ianuam, ne accedere possit ad nunciandum, vel aliqua alia ratione illum impediuit, ne ad nunciandum ac impediendum accederet, idque efficiat, quod sciebat sibi impediendum, nisi eo modo aduersarium ipse impediuisset, dicitur vi id

effecisse. *Hæc habentur. l. 1. citata à. §. quid sit. l. 3. §. l. vi facit. ff. quod vi aut clàm.* Quando tamen aduersarius morbo fuit impeditus ne accederet ad nunciandum & prohibendum opus, aut ductus, ne offenderet eum, quem alioquin prohibuisset, aut ne offenderet amicum illius, vel si, territus armis ab alio, accedere non est ausus ad prohibendum, cùm tamen nullus dolus interuenerit ex parte eius, qui opus facere aggrediebatur, quia nullo modo cooperatus est, vt terror ille ei incuteretur, tunc, qui id opus facit, non dicitur vi illud efficere. *Ita habetur. l. 1. §. penul. §. vlt. §. l. 2. ff. quod vi aut clam.* Atque. l. 2. citata redditur ratio, cur metus ab alio incussus, sine culpa eius, qui opus facere aggrediebatur, non sit sufficiens, vt id opus vi factum esse dicatur; *Ne scilicet in aliena potestate sit, conditionem nihil delinquentis, deteriore facere.*

Clàm facere, quod ad idem interdictum attinet, is dicitur, qui, cùm timeat, aut timere meritò debeat, (esto ob suam vecordiam & inertiā ad id non attendat; *ne melioris conditionis sint stulti, quàm periti; vt habetur l. 4. ff. quod vi aut clàm*) sibi mouendam esse controuersiam ac prohibendum ab aliquo, si id tempestiuè sciat, vel non aggreditur id facere coram illo ita vt illud sciat, occurrereque ac impedire id optimè ac sufficienter possit, vel illum ea de re certiore non facit, ita vt commodè accurrere possit ad tempestiuè id impediendum, mouendamq; ei controuersiam. Quare, si vel decipiat eum, quem impediturum timet, aut timere debuit, **[[150]]** aliter opus faciendo, quàm ei denūciauerit, aut aliqua alia arte ac ratione, vel ita obscure ac persunctoriè (hoc est, segniter, leuiter, & quasi id non agens) id ei denunciauit, vt ea de causa non haberet eam rationem eius denunciationis, quam par esset eum habere, vel ita ei denūciauit, vt tēpus oportunum, cōmoditatemque oportunam, non haberet ad id impediendū, propter absentiam, aut propter aliquam aliam rationem, vtique, si opus id efficiat, dicitur clàm illud fecisse. *Ita habetur. l. 3. §. vlt. & duabus legibus sequentibus, iuncta. l. vlt. §. vlt. ff. quod vi aut clam:* suntque dicta, tam hoc paragrapho, quàm paragrapho præcedente, ante mentis oculos habenda ad intelligendū, quādo quis vi, aut clam, iuxta dispositionē iuris, sit dicendus possidere, & quando non item, quod attinet ad interdicta disputatione præcedente explicata, & quando quis vi, aut clam, dicendus sit aliquid fecisse, quod ad hoc interdictum attinet.

Iuxta hæc notat bene *Ant. Gom. l. 46. Tauri. n. 20. cum Bart.* & cum communi doctorum sententia, quam refert, quando ante nunciationem noui operis aliquid ædificatum est in præiudicium alicuius modo explicato, vt cōpetat illi interdictum quod vi & clàm ad illud destruendum ac reducendum ad pristinum statum, necesse esse, vt factum non sit illo id sciente, ita vt commodè posset illud impedire, iuxta ea quæ dicta sunt, adde, neque sit factum vi, impediēte illo per vim, modo explicato, ne ei fieret nunciatio, néve impeditur: tunc enim, quodante nunciationem esset factum, neque clam, neque vi, posset dici esse factum, ac proinde, ad illud destruendum ac reducendum ad pristinum statum, non haberet locum interdictum quod vi aut clàm.

Ibidem idem *Ant. Gom. cum Bart.* & cum com [sect. 6] muni doctorum sententia addit, quando aliquid ante nunciationem factum est vi aut clàm in re, in cuius possessione is erat, qui in præiudicium ipsius prætendit id esse factum, tunc, si in continenti statim, ac nouit esse factum, agat ad illius destructionem, cùm nondum suam possessionē ciuilem amiserit in te, in qua id est factum, per hoc, quòd clàm, aut vi, sit ibi id factum, iuxta ea quæ *Disp. 12. 15. & 16.* dicta sunt, vtique agere poterit, vt destruat, resque in pristinum statum redigatur, non solùm interdicto quod vi aut clam, sed etiam interdicto vti possidetis: in consequētiā quippe, vt conseruetur in sua possessione, in qua adhuc perseuerat, petere

potetit, vt aduersarius desinat ab illa molestia circa suam possessionem, & in consequentiam, vt destruat, ac res in pristinum redigatur statū. Ita probat. l. si duo. §. si vicinus. ff. vti possid. qui sic habet: *Si vicinus meus in pariete meo tectoria habeat, & in pariete suo, vti possidetis interdictum mihi efficax est, vt ea tollere compellatur.* Idem probant, quæ Ant. Gom. citat. Quando autem is, qui præten dit, in suum præiudiciū esse, quod est ædificatum, nō esset in possessione rei, in qua id esset ædificatum, tunc non competet ei interdictum vti possidetis, vt destrui id efficeret, sed solū interdictum, quod vi aut clām, quod non indiget possessione, vt ex illo agi ad id possit, vt dicemus, & affirmat ibidem Ant. Gom. Nunc regrediamur ad noui operis nunciationem.

Interdictum de noui operis nunciatione non [sect. 7] solū habet locum, quando aliquis aliquid ædificat, aut parat ædificare, in præiudiciū alterius, vt si fodiat ad id terram, sed etiam si aliquid ædificii alicuius in alterius præiudiciū diruat ac destruat. *Ita habetur. l. 1. §. inde quæritur vers. opus nouum, & §. hoc autem. ff. de noui oper. nunc.* Habet verò solū locum in ædificiis conficiendis, aut destruendis, in alterius præiudiciū: non autem in plantis: siue enim serat, aut seminet, in alterius præiudiciū, siue segetes metat, vites putet, aut præscindat alias arbores, non habet locum hoc interdictum de noui operis nunciatione. *Ita habetur. §. hoc autem proximè citato, & concinit. l. 1. in prin. titu. 32. part. 3.*

Atque in hoc differt etiam hoc interdictum [sect. 8] ab interdicto quod vi aut clām, quod latiùs multo patet: extendit enim se, in primis ad ædificia facta aut destructa, vi, aut clām, in præiudiciū alterius, etiam ad partes illius, vt ad tegulas dum tecto sunt superpositæ, etiamsi calce, aut re alia, tecto non sint affixæ, quia censentur pars domus, ipsam integrantes ac complentes; secus verò, si essent non integrantes & complentes domum, sed separatæ ac seorsim positæ: quod idem intellige de aliis, quæ ædificio non sunt affixæ; ad ea quippe non se extendit id interdictum: extendit tamen se etiam ad solum cuiuscunque prædii, si fossa in eo fiat, vel aretur, in præiudiciū alterius, vel aliquid in eo projiciatur, vnde deterius reddatur: quin & se extendit ad aquam putei, si aliquid in eo projiciatur, vnde aqua deterior reddatur: nam aqua prædii viua, pars prædii reputatur. Deinde etiam se extendit ad plātas, quæ prædio adherent, si in alterius præiudiciū, rami saltem earum, præscindantur, aut demetantur segetes, vel aliud in plantis fiat, quo eis noceatur. Quin si ridicæ, hoc est, padimenta, quibus vites sustentantur, euellantur, competit idem interdictum. Si autem soli fructus vi aut clām ex plantis colligantur, non competit hoc interdictum, sed competit actio furti, aut rapinæ, eorum. Hæc habentur. l. si alius. §. notauimus, & quatuor legibus sequentibus. ff. quod vi aut clām, in quarum vltima subiungitur, etiam competere hoc interdictum pro statu is sepulchrorum, & pro aliis rebus sepulchris in ornamentum affixis, si vi, aut clām, auellantur, aut eis nocumentum inferatur. Pro eo autem, quod vi, aut clām, fit in naui, aut in quacunque alia re mobili, minimeque solo affixa, non competit interdictum quod vi aut clām, *vt habetur. l. vi facit. §. vlt. ff. quod vi aut clām.*

Vtrū autem, quando alicui debetur serui [sect. 9] tus rustica in aliquo prædio, vt via per illud in suum prædium, aut aquæductus per illud in suum prædium, si ædificium fiat in eo prædio, quo impediatur ea seruitus viæ aut aquæductus, nunciare possit de nouo opere. Lex, qui viam. ff. de nouo oper. nunc. quæ est Iuliani iurisconsulti, satis apertè neganter respondet. Sic enim ea lex habet: *Qui viam habet, (debitam scilicet suo rustico prædio) si opus nouum nunciauerit aduersus eum, qui in vta ædificat, nihil agit: sed seruitutem vindicare* (confessoria nimirum actione) *non prohibetur.* Idem apertè disponit. l. 5. titu. 32. part. 3. quæ habet, si confessoria agatur ad vendicandam seruitutem, & probetur seruitutem deberi, iudicem

debere præcipere destrui ædificium, & persolui actori damna, si quæ ex eo ædificio, ob eam seruitutem impeditam, **[[151]]** sint sequuta. Et consentit communis doctorum sententia. Accursius ibi rationem reddit, cur potius circa ædificium factum in præiudicium seruitutis rusticæ, denegetur remedium nunciationis noui operis, quàm circa factum in præiudicium seruitutis vrbanae, dicens, id factum esse in fauorem culturæ agrorum. Merito tamen *Greg. Lopez. l. 5. citata, & Ant. Gom. l. 46. tauri n. 24.* & alii, cam rationem improbant. Quoniam fieri ædificium in agro, quo via, aut aquæductus, impediatur, potius cedit in damnum culturæ eius agri, in quo fit tale ædificium, quàm in culturæ agrorum fauorem: nisi ædificium fieret ad fructus colligendos: quod tamen parum ad culturæ agrorum fauorem attinet; cùm alibi fieri possit, aut in alia parte agri, vbi via non impediatur. *Greg. Lopez* ait, fortè in fauorem ædificiorum statutum fuisse, vt quando seruitus deberetur prædio vrbano, locum haberet nunciatio noui operis circa ædificium, quo illa impediretur: secus verò quando deberetur prædio rustico. *Bart. & alii*, censent, etiam quando seruitus rustica debetur, locum esse nunciationi noui operis circa ædificium, quo impediuntur. Exponunt verò legem, qui viam, vt solùm intelligatur, quando ædificium reficitur, in quo euentu, vt statim dicemus, locum non habet noui operis nunciatio. Hæc tamen interpretatio eius legis, manifestè est nulla: nam tunc locum non haberet agere confessoria ad seruitutem vendicandam, vt ædificium destruat, ac persoluantur dāna. Qua etiam ratione reprobatur alia expositio *Ant. Gom. n. 24.* citato, cum Romano, quòd scilicet lex, qui viam, intelligatur, quando debetur via per agrum alienum, nondumque est constitutum, per quam partem agri esse debeat; in quo euēru, vt disputatione præcedente dictum est, via debetur à toto agro, & à singulis illius partibus, atque tunc, si ædificium fiat in eo agro, ita vt cōmodus locus relinquatur, vnde via possit concedi, non potest nunciari nouum opus aduersus id ædificium: secus autem si post viam constitutam per certam partem (in quo euentu reliquæ agri partes manent liberæ ab ea seruitute, & sola ea pars manet illi subiecta, vt disputatione præcedente est etiam ostensum) ædificium fieret, quo ea via impediretur: nam tunc, inquiunt, locum haberet noui operis nunciatio circa id ædificiū. Hęc, inquam, expositio similiter reprobatur: nam in priori euentu locum non haberet, posse nihilominus agi confessoria ad seruitutem vendicandam, & in consequentiam, vt ædificium destruat, & soluantur damna, vt agi posse disponunt. *l. qui viam, & l. 5. citatæ.* standum ergo est apertæ definitioni earum duarum legum, quòd scilicet in eo euentu locum non habeat operis noui nunciatio, interim dum illæ duæ leges non reuocantur, & contrarium non statuitur. Vtinam verò tot subtilitates, minimeque necessariæ exceptiones à dispositionibus vniuer salibus, absunderentur à iure, quæ illud longum, difficile, tricus plenum, litiumque seminarium ingens efficiunt.

Aduersus fulcientem, aut reficientem, opus [sect. 10] antiquum, si nihil amplius faciat, quia neque addendo ædificio antiquo, neque detrahendo de illo, quicquam facit, ita vt tandem id ædificium non reducat ad pristinum statum, non comperit noui operis nunciatio: vnde si ei, qui ita reficit, nuncietur nouum opus, potest, contempta ea nunciatione, impunè facere, aut prosequi, quod fulcire aut reficere intendebat. *Ita habetur. l. 1. §. si quis ædisicium. ff. de noui oper. nunc.*

Hac eadem ratione, & quoniam id postulat [sect. 11] commune bonum, locum non habet noui operis nunciatio aduersus eum, qui purgare, aut reficere, vult riuum, quo aquam ducit, vel cloacam, imò neque aduersus volentem facere priuatam cloacam de nouo, aut, factam, mittere in cloacam publicam, etiam si vel in loco publico, vel in prædiis aliorum, aperiat, & efficiat, quæ ad hæc omnia necessaria sunt, modò, si quid aperiat, illud reficiat, ac reducat

ad pristinum statum: & modò, si damnum inde timeatur, & ab eo exigatur, vt de damno caueat infecto, id efficiat: quòd si aduersus eum nouum opus nuncitur, potest contemnere nunciationem, idque facere aut prosequi, quod intendebat; vt hæc omnia disputatione præcedente dicta explanataque sunt, dum sermo nobis erat de interdictis circa riuos & cloacas, & habetur. l. de pupillo. §. si quis riuos. ff. de noui oper. nunc. l. 3. §. si quis riuum. ff. de riuis. l. 1. §. si quis purgationi. ff. de cloa. & l. 7. titu. 32. part. 3. Lege autem de pupillo. §. si quis riuos citato, additur. Vniuersim locum non habere noui operis nunciationem, sed contemni impunè posse, si fiat, quando ex eo, quòd opus retardaretur, periculum notabile immineret. Cōueniunt verò omnes, cum glossa ibidem, id verum esse, quando ex retardatione immineret periculum boni communis, aut viciniæ, vel multorum. Quando verò immineret periculum eius tantum, qui id opus retardaret, glossa citata affirmat, contemni non posse nūciationem, sed eam tunc locum habere. Dicendum tamen est cum additione ad eandem glossam, cum Greg. Lopez. l. 7. citata. Ant. Gom. l. 46. tauri in calce. n. 37. & cum aliis, quos citant, intelligendum id etiam esse de priuato magno eius periculo ex tali retardatione, cui nunciatio fieret. Adhibent exēplum, in ædificante in æstate molendinum in flumine aliquo, aut septum (pressa nostri dicunt) si ex retardatione immineret periculum, quòd, adueniente hyeme ac pluua, detrimentum magnum sequeretur, nisi opus continuaretur ac perficeretur. Tunc enim ob adeò ingens detrimentum, quod ex ea retardatione iustè timeri posset, sperni nunciatio, & continuari ac perfici impunè opus posset, iuxta. §. si quis riuos citatum, consentiunt etiam, quæ ex. l. 1. ff. nequid in flu. publi. Disput. 704. §. in eadem lege, relata à nobis fuere. Nempe impediri non posse aggeres in ripa & flumine publico, esto ex illis sequatur detrimentum aliquod vicinis, quando fiunt ad vitandum longè inaius detrimentum proprium, vicinisque resarcitur detrimentum, quod ex eis aggeribus ipsis prouenit: quare longè maiori cum ratione, quando, cessando ob nunciationem ab opere, immineret longè maius periculum eius, cui fieret nunciatio, quàm sit dānū eius, qui nūciat, ex eo quòd opus cōtinuetur, cōtēni poterit impunè nūciatio, & cōtinuari ac perfici opus poterit: præsertim cū integrum maneat nuncianti prosequi suum ius, si fortè illud ea in parte habeat, atque, si probauerit, iniustè id opus fuisse factum ac prosequutum, obtinere alia via possit, vt opus destrua-[[152]]tur, sibi que resarciantur damna, ex eo opere, facto contra suum ius, ipsi subsequuta. Ant. Gom. vbi suprā ait, si in hoc euentu nunciatio post habeatur, eum, qui opus continuat, cauere debere, quòd destruet opus, si comperiat postea fuisse factum contra ius. Puto tamen id esse falsum. Quoniam quando, iuxta. §. si quis riuos citatum, & iuxta alia iura citata, fas est spernere nunciationem, & continuare opus, non tenetur, qui ita opus continuat, talem præstare cautionem; eo quòd in eo euentu locum non habeat interdictum de noui operis nunciatione: neque contrarium statuit. l. vnica. C. de noui operis nunc. quæ postea fuit lata. Noui operis nunciatio locum habet, siue o [sect. 12] pus fiat in oppido, siue in villa, aut in agro, & siue fiat in loco priuato, siue in publico. Ita habetur. l. 1. §. siue autem. ff. de noui oper. nunc. Iusta noui operis nunciatio fieri potest vno [sect. 13] ex tribus capitibus, seu vna è tribus causis in genere, vt habetur. l. 1. §. nunciatio. 2. ff. de noui oper. nunc. In primis, vt tueamur ius nostrum, cui alieno ædificio contrahenitur. Deinde, si ex alieno edificio, in publico aut in priuato loco facto, esto factum non sit contra ius nostrum aut publicum, damnum rebus nostris immineat, quia ruinam minatur: possumus enim tunc nunciare opus nouum, vt impediatur ne fiat, aut ne vltius progressio in eo fiat, nisi prius de damno infecto nobis caueatur: præstita verò cautione sufficiente de damno infecto, cessat in hoc euentu nunciationis vis ac impedimentum, vt ibidem, iuncto fine illius. §. & l. 3. §. penul. ff. quod

vi aut clā, habetur. Et tertio ad ius publicum tuendum, ut si aliquid factum sit contra leges, edictave principum, quæ quoad modum in edificiis servandum latae sunt. Exempla sunt. *vt. l. ult. ff. fin. regun.* san citum fuit, ut si quis parietem erigeret in fundo suo iuxta alterius fundum, relinqueret spatium pedis unius inter eum parietem & alienum fundum. Si verò erigeret domum, relinqueret duos pedes inter eam domum, & vicinum fundum. Item. *l. meniana. C. de edificiis priuatis*, fuit statutum, ut, si quis domum ædificaret iuxta domum priuatam alterius, relinqueret inter vtramque decem pedes. Si verò eam ædificaret iuxta domum publicam, ut iuxta horrea publica, relinqueret quindecim pedes. Et quia illis temporibus domus esse debebant ita vndique separatæ à domibus vicinorum, insulæ quàm sæpissime in iure cæsareo vocantur. Glossa. *l. meniana* ait, eam legem intelligendam esse, quando in absentia vicini, aut eo renuente, domus ædificaretur non relicto eo spatio: secus verò, si ipso sciente, nec resistente, ædificaretur non relicto eo spatio. Tu dic, similes leges vim non habere in vnoquoque loco, nisi quatenus vsu sint receptæ, ut etiam cum *Cæpolla* notat *Greg. Lopez. l. 22. titu. ult. part. 3. Glossa. 1.* In Hispaniis autem vsu quoad domos non sunt receptæ. Exemplum præterea est, si ab una domo in aliam eiusdem domini pons fiat (*Castellani pontido, y pasadizo*, Lusitani *pasadizo* appellant) super publicum flumen, quod prohibetur. *l. ult. ff. de fluminib.* aut super viam publicam, quod. *l. 2. §. scio tractatum. ff. nequid in loco publi.* similiter prohibetur, affirmatque communis doctorum sententia, quam *Ant. Gom. l. 46. Tauri. n. 13.* refert ac sequitur, & vtrumque consentaneè ad ipsam rei naturam. Cum enim flumen publicum, & via publica, non ad eos spectent, quorum sunt domus sitæ vtriusque, sed publica loca sint, solaque eorum distincta sint à solis domorum; vtriusque, sicut ad dominos earum domorum, ratione soli earum, pertinet spatium quoad altitudinem ei correspondens vsque ad cælum, ita ad solum publicum viarum, ac fluminum publicorum, spectat spatium totum in altum, quod eis vsque ad cælum respondet, *vt habetur. l. ult. in prin. ff. de seruit. c. l. penult. in sine, ac. l. ult. §. penult. ff.* quod vi aut clām, ac proinde in eo fieri non potest pons ab una domo in aliam, nisi id ritè ab eo sit concessum, ad quem pertinet concedere ædificium facere in loco publico. Eadem ratione illicitum ex ipsa rei natura est, aliquid in domibus ædificare supra parietem, quod solum, parietemque infimum domus, in publicam viam egreditur. Atque ea de causa in hoc regno à *Carolo 5 lege. 8. titu. 7. lib. 7. nouæ collect.* inhibuit ædificare in viis publicis, *pasadizos, ni saledizes, corredores, ni balcones, ni otros edificios algunos, que salgan à las calles fuera de la pared en que se hiziere el tul edificio*, & ut, quæ ex his antea fuerant facta, non reficiantur, & ut postquam corruerint, aut destructa fuerint, non ædificentur iterum, sub pæna, quoad eorum singula, ut, si ædificentur, diruantur statim publica autoritate, & decem mille maravedinorum. Vnicuique autem in hoc regno permissum est, pontem in flumine publico suis sumptibus ædificare, quo transeant iter facientes, modò nullum tributum ea de causa imponant, & sub grauibus pænis inhibetur, quenquam alium prohibere facere tales pontes. *Ita habetur. l. 9. titu. 11. lib. 6. nouæ collect.* Multa alia exempla adduci poterant ex ordinationibus Lusitanis lib. 1. titu. 49. à §. 24. quæ ibi legi poterunt: inter quæ §. 31. habetur, si quis habeat domum ex una parte viæ publicæ, & alter velit ædificare aliam è regione, aut illam habeat ædificatam, non posse fabricare aut aperire ostium, vel fenestram, è regione ostii aut fenestræ domus alterius, ita ut videri possint, quæ in altera domo fiunt, obserua autem circa ea, quæ dicta sunt de ponte ab una domo in aliam, super viam publicam, aut de fabricatione supra parietem extra solum domus super viam publicam, non censenda esse prohibita fieri vbi sine vlla contradictione permittuntur, ut ante eam legem Caroli 5 permittebatur in hoc regno, & permittuntur hodie in Lusitania.

Et quamuis ius maneat iis, quorum sunt viæ publicæ, aut quibus cura earum incumbit, vt, postquam fuerint ædificata, sine expressa facultate, & quasi condonatione principis, aut reipublicæ, diruantur, (si ita iudicauerint expedire) vtpote facta in solo, seu loco, alieno ac publico, id quod satis apertè habetur in ordinationibus Lusitanis titu. 49. §. 34. Nefas tamen est, postquam palàm fuerit ædificatum, nullo contradicente, quin potiùs tacitè id permittente republica, absque vrgente causa, illa dirui facere; id quod satis perspicuè innuitur. §. 34. citato: Vnde Carolus 5 lege citata, non iussit dirui antea ædificata, **[[153]]** sed solùm, vt non reficerentur, neque restaurarentur, si corruerent, aut alia ratione destruerentur, & vt nihil tale de nouo fieret. Præterea. §. nunciatio citato, inter exempla computantur, si quid ædificetur in loco sacro, vel religioso, aut publico, ripave fluminis, vel in ipso publico flumine. Licèt enim circa hæc lata sint peculiaria alia interdicta, vt ex parte disputationibus præcedentibus est dictum; quando tamen illa locum habent, etiam noui operis nunciatio locum habet, vt impediatur, & vt diruatur, si quid post nunciationem sit factum. Eodem. §. additur, si quis in mari, aut in littore illius, ædificet, quamuis non ædificet in suo solo, attamen eo ipso, quòd ibi ædificat, occupatque id solum, suum illud efficere interim dum in eo manet tale ædificium: eo quippe destructo redit locus in pristinum statum, quo gentium iure est omnibus communis, *vt habetur. l. in tantum in prin. iuncto. §. ult. legis præcedentis. ff. de rerum diuis.* consentiuntque dicta Disp. 53. & 55. Hinc in eodem. §. subiungitur; *si quis igitur velit ibi ædificantem prohibere, nullo iure prohibet,* (intellige, priuato; si enim id opus impedimento esset nauigationi, iure publico prohibere id posset, vt Disp. 704. dictum est) *neque opus nouum nunciare, nisi ex vna causa, potest, si fortè scilicet damni infecti velit sibi caneri,* vt si coniunctum habeat aliud suum ædificium, priùs à se factum, cui damnum ex eo, quod de nouo ædificatur, immineat: tunc enim nunciare illi poterit opus nouum, vt non progrediatur in eo, nisi sibi priùs de damno infecto caueat.

Vlpianus, cuius est. §. nunciatio, hactenus ex [sect. 14] plicatus, *lege de pupillo. §. & belle. ff. de noui oper. nunc. ex Sexto Pedio*, triplicem causam distinguit, vnde iuste possumus nunciare opus nouum intendendo ea nunciatione ius nostrum proprium (vt Bart. ibi, & addito ad glossam verb. leges, exponunt) Primam appellat naturalem, quando scilicet nunciamus ob tuendum ius, quod naturaliter nobis competit, seclusa cōcessionem alterius, & seclusa humana ac positua lege, quæ illud nobis concedant. Vt quando nūciamus, quia alius vult ædificare in solo nostro, aut quia vult mittere tignum in domum nostram, quando ad id nullum ius habet, & in aliis similibus euentibus. Atque hæc exempla adhibentur in eo. §. iūcto. §. sed & si, proxime antecedente. Secundam appellat publicam, hoc est, quando nunciamus ad tuendum ius, quod nobis competit ex lege humana id nobis concedēte, vt quod domum non ædificet, nisi relinquendo duos pedes inter ipsam, & fundum nostrum, aut decem inter ipsam & domum nostram, aut Lusitano iure, quòd fenestram non aperiat è regione fenestræ aut ostii nostri. Ad secundam causam explicatam attinere videtur nunciatio, qua monasterium vnum nunciat, ne aliud ædificetur intra spatium, intra quod religiones habent priuilegium canarum, quod vocant, ne intra illud aliud monasterium ædificetur, & quo Ecclesia vna impedit aliam ædificari contra ius suum intra limites parochianorum sibi subditorum, de qua nunciatione sermo est. c. 1. & 2. de noui oper. nunc. Tertiam appellat imposititiā, aut impositiuā, quia scilicet fit nunciatio ad defendendum ius, quod nobis competit ex seruitute imposita, concessa, aut acquisita, in rebus illius, cui nunciamus. Vt si nūciamus aduersus volentē altiùs tollere, quando in re, quam altiùs vult tollere, est nobis debita seruitus, non altiùs tollendi.

Noui operis nuntiatio vno è tribus modis fit. [sect. [15]] Primò, verbis eius, cuius intersit, aut alterius, qui loco illius possit nunciare (iuxta ea quæ subjicienda sunt) denunciando ac protestando, vt id opus non fiat in suum, aut in publicum, præiudicium, aut vt non continuetur, rationemque reddendo, cur in suum, aut in publicum, præiudicium id fiat, vt multi affirmant, & habetur. l. 1. titu. 32. part. 3. Neque est necesse, vt scripto fiat, sed satis est si fiat verbis. Turum autem erit, vt fiat coram testibus, vt postea probari possit fuisse factam, destruique præcipiatur, quod post eam, & ante illius remissionem, fuerit factum. Secundò fit iactu lapilli, aut lapillorum, in eum locum, vbi opus fit, aut fieri paratur. Atque, vt cum Ioan. affirmat glossa. l. de pupillo. §. meminisse verb. manum. ff. de noui oper. nunc. & habetur. l. 1. citata, simul fieri debet verbis nuntiatio ne id opus fiat, aut ne ulterius prog ediat, reddendo causam. Estque efficacior hic secundus nuntiationis modus quàm præcedens, vt dicemus. Constitutum verò fuit, vt lapilli iactu potius, quàm acriori alia re, fieret, ad rixas ac cædes vitandas. Tertiò, per iudicem, illum adeundo, & ab eo petendo, vt nouum id opus nunciet. Qui per seipsum, aut per tabellionem, aut aliam personam, præcipiet, vt id opus non fiat, ab eoque cesset, donec, cognita causa, quid facto opus sit, statuatur. In Lusitania ad ædiles, quos *almozar* vocant, pertinet nunciare opus nouum, apponendo pœnam, quam ædificantes aduersus nuntiationem ita factam soluere coguntur, & insuper destruitur opus, quod post eam nuntiationem, & ante illam remissam, fecerint, vt habetur lib. 1. ordi. titu. 49. §. 25. Tres hi modi nuntiandi opus nouum habentur. §. meminisse, & l. 1. citatis, & consentit communis doctorum sententia, quam referunt ac sequuntur Anton. Gom. l. 46. Tauri. n. 31. & Greg. Lopez. l. 1. citata.

Est verò hoc discrimen inter primum modum [sect. 16] & duos posteriores. Quòd, qui nunciat primo modo, si in possessione sit eius, circa quod nunciatur, illam amittit nunciato: secus autem si nunciet aliquo ex posterioribus modis. Ita habetur. l. 1. §. in operis. l. de pupillo. §. meminisse. ff. de noui oper. nunc. & l. si alius. §. ait Iulianus vers. licere. ff. quod vi aut clam, & affirmat communis doctorum sententia, quam Ant. Gom. vbi suprà. n. 32. refert ac sequitur. Rationem huius discriminis reddit glossa. §. si operis citato, quam sequuntur Bart. & alii: quia, qui solo verbo nouum opus nunciat, videtur meticulosus, ac proinde relinquere videtur possessionem illi alteri: possessio autem, solo animo eam deserendi, amittitur. Sed certè plus metus habere videtur, qui iudicis ministerio nouum opus nunciat: ne enim sibi aliquid mali eueniat, per seipsum nunciando, ad iudicem accedit. Item non maior animus requiritur ad simul iactandum lapillum in locum, in quo ædificatur, aut ædificari paratur, quàm ad solo verbo nouum opus nunciandum. Vnde non video meliorem rationem reddi posse, quàm quòd ita sancitum est. Vtinam verò similia discrimina, minimè naturis rerum consentanea, à iure rescinderentur. Ob discrimen [[154]] constitutum inter primum nuntiandi modum, & duos posteriores, ait Vlpianus. §. meminisse citato, quando aliquid fit in re nostra, in cuius possessione nos sumus, vt si aliquid ædificetur in prædio, in cuius possessione nos sumus, aut si lignum mittatur in parietem domus, in cuius possessione nos sumus, vtilius nunciari opus nouum aliquo ex duobus posterioribus modis, quàm primo, ne, nunciando primo modo, amittamus possessionem, eamque aduersario cōcedamus. Quando autem alius tollit altiùs domum suam, in cuius possessione ipse est, aduersus seruitutem nobis in ea debitam, ne altiùs tollatur, tunc posse nos etiam primo modo nunciare: quia non tantum præiudicium eo nuntiandi modo nobis prouenit.

Si iudex sit absens, isque, qui coram eo vult [sect. 17] nouum opus nunciare, protestetur se velle coram eo opus nunciare, posteaque vel adueniente iudice, vel accedente ad illum cum

primùm nactus fuerit opportunitatē, coram eo id opus nunciet, perinde reputatur, ac si à puncto protestationis coram iudice illud nunciasset, ad effectum, vt nunciatus destruere teneatur, quod à protestatione vsque ad nunciationem coram iudice factam ædificauit. *Ita habetur. l. de pupillo. §. si quis ipsi. ff. de noui oper. nunc.* Tametsi alii eum textum exponant, (licet non ita accommodatè ad verba illius) quando iudex ipse ædificat: tunc enim satis est ipsi factam esse protestationem, quòd nunciare vult coram iudice, vt adueniente postea alio iudice, factaque nunciatione coram illo, destrui debeat, quod à puncto protestationis fuerit à priori iudice ædificatum.

Nunciatio noui operis fieri potest in quocū [sect. 18] que die, etiam Deo feriato. *Ita habetur. l. 1. §. nunciatio. 1. vers. item nunciatio. ff. de noui oper. nunc.* & affirmat communis doctorum sententia, quam Ant. Gom. vbi suprà in calce. n. 31. refert ac sequitur.

Nunciatio noui operis, vt rem ipsam efficiat, [sect. 19] in qua opus fieri paratur, aut continuatur, & vt effectus illius transeat ad quemcunque alium illius possessorem, saltem vt interdum patiatur demoliri, quod post eam nunciationem sit factum, ipso eam nunciationem ignorante, dirigi debet, non in personam, cui fit talis nunciatio, sed in rem ipsam, dicendo, nuncio, aut tibi nuncio, ne fiat opus in tali re, aut ne continuetur, & non vt facias, aut vt non continues opus in tali re, vt ex forma interdicti in principio nuius disputationis relata, & ex. l. prætor. ff. de noui oper. nunc. constat. *Consentit. l. operis, iuncta. l. cuilibet, sequenti. ff. eod. titu.* vbi habetur, quòd quia nunciatio noui operis fit in rem, & non in personam, si fiat furioso, aut infanti, rationis vsum non habentibus, eam scilicet dirigendo in rem, & non in personas eorum, quibus fit, esto non adsit tutor, aut curator eorum, vim contra eos habet: modò tamen facta sit in præsencia fabri, aut alterius intelligentis, qui operi insistant, rem carentium ita vsu rationis agentes; alioquin vim non habebit ea nunciatio aduersus carentes ita vsu rationis. In priori autem euentu, quando scilicet eis fit coram illo rationis vsum habente, vim habet, vt, si quid post talem nunciationem sit fabricatum, demoliat. Opifices tamen, qui, scientes nunciationem, id fecerint, tenentur soluere impensam, tam eius, quod ita fabricatum fuerit, quàm demolitionis postea illius, iuxta ea, quæ statim dicenda sunt, quando in ab sentia domini coram fabris nunciatio est facta, & ipsi, domino ignorante, prosequuti sunt opus post eam nunciationem. Aut tenebitur tutor, vel curator, furiosi aut infantis, si postquam nunciatio illa ad ipsorum notitiam deuenerit, opus prosequi fecerint, aut ab eo desistere non iusserint: & non tenebuntur furiosus aut infans, qui absque omni prorsus culpa sunt. Atque hoc sanè est, quod Vlpianus intendit ac docet. l. operis citata, & non, quod glossa, vim textui inferendo, illumque peruertendo, Vlpianum velle exponit. Eandem doctrinam confirmat. l. vlt. ff. eod. titu. Vbi Iauolenus iurisconsultus ait: Si domino prædii alicuius nunciatum fuit opus nouum, atque is, propter eam nunciationem, ab illo opere destitit, & postea prædium vendidit, emptorque opus illud fecit contra id, quod nunciatum fuerat, emptorem teneri id opus suis sumptibus demoliri; non verò venditorem, cui nunciatio fuit facta. Reddit verò is iurisconsultus hanc rationem: *quia nunciatio operis non personæ fit; & is demum obligatus est, qui eum locum possidet, in quem opus nouum nunciatum est.* Vnde, argumēto à contrario sensu, si nunciatio esset facta solùm personæ venditoris, ne ibi ipse ædificaret, & non rei, non sequeretur prohibitio illa rem ipsam, ac proinde, si emptor, sciens & prudens inhibitionem factam venditori, iure opus in ea re efficeret, non incideret in pœnam, vt illud demoliretur, & multo minùs, vt ipsius sumptibus demoliretur. Ac sanè hunc textum intelligo, quando emptor, sciens nunciationem esse factam, ne in eo prædio ædificaretur, ipse ædificauit, ac iurisconsultum affirmare, teneri non solùm ad patientiam,

sed etiam ad impensam in eo opere demoliendo, contrà atque glossa, parum accommodatè ad textum, exponit teneri solùm ad patientiam. Quòd si ignoraret, nunciationem factam fuisse in rem venditori, tunc utique emptor solùm teneretur ad patientiam, non verò ad impensam, excusante eum ignoràtia, vt à culpa, sic etiam ab ea pæna: quare in eo euentu venditor, qui ipsum non admonuisset de nunciatione facta, atque de eo quasi vitio eius rei, teneretur ipsi de impensa ab eo facta in eo opere, quod ita demoliretur: neque aliter credo, posse tunc licitè demoliri in pænam, quā soluente ei venditore impensam operis: neque enim æquitas patitur, vt ipse, absque vlla sua culpa, iacturam patiatur eius impensæ, seu operis, iustè ex natura ipsa rei facti: quare, si venditor soluendo non esset eam impensam, aut si mortuus esset antequam id in pænam exigeretur, in quo euentu expirat pæna aduersus eum, neque ad hæredem transit, vt habetur. l. penult. ff. de noui oper. nunc. tunc demoliri non posset id opus ea præcisa ratione, quòd factum esset contra nunciationem, quam emptor inuincibiliter ignorauit, nisi simul ostenderetur, factum etiam esse contra verum ius eius, qui de nouo opere nunciauit. Atque tunc venditor, aut hæres illius, teneretur ei emptori de eo iure ex ipso euicto. Iuxta hunc autem nostrum planum intellectum legis vltimæ citatæ non refragatur, *sed potius consentit. l. vi facit. §. item si. ff. quod vi aut clam*, in quarum duarum legum concilia-^{[[155]]}tionem anxie laborat glossa vtrobique, varias expositiones vtriusque legis tradendo. Cùm enim ad demoliendum, quod post nunciationem noui operis est factum, & interdictum noui operis, & interdictum quod vi aut clam, competat, vt ex multis iuribus constat, & inferiùs ostendetur; eo quòd eo ipso censeatur vi factum; Paulus iurisconsultus. §. item si, citato, sic ait: *Item, si prohibiti hæres, vel is, qui ab eo emerit, ignorans causam præcedentem* (hoc est prohibitionem) *fecerit*, (id est, ædificauerit) *dicendum esse Pomponius ait, non incidere eum in interdictum*, vt scilicet teneatur demolire, quod ædificauit. Quo loco obserua, si ab emptore esset ædificatum, viuente adhuc venditore, etiam si ex ipsa rei natura iustè sit ædificatum, sumptibus venditoris esset demoliendum, qui operis & demolitionis impensam soluere teneretur, vt dictum est. Si verò ædificatum esset post mortem venditoris, idque iustè ex natura rei, tunc, cùm vtrumque esset in pænam, eo quòd obeditum non fuerit nunciationi, & pæna expirasset aduersus venditorem, morte illius, nec transiret ad hæredes, qui loco illius tenerentur eam soluere, demoliendum non esset id ædificium iustè ex natura ipsa rei factum, & idem dic de hærede ædificante cum ignorantia denunciationis, vt vtrumque satis apertè significat. §. item si, citatus. Neq; refragatur. l. penul. ff. de noui oper. nunc. quæ solùm loquitur, quando defunctus ipse post nunciationem ei factam ædificauerit: si enim dum viueret non est actum aduersus eum, vt illud demoliret, hæres solùm tenetur ad patientiam, vt scilicet patiatur demolitionem eius, quod inobedienter defunctus ædificauerat, esto, si iustè ex natura rei id fecerat, sit etiam id in pænam: id quippe ex maxima quadam æquitate sancitum est: non verò tenetur ad pænam alicuius expensæ, quam de nouo facere aut soluere teneatur, etiam de bonis defuncti: quoniam quoad id totum expirauit pæna morte illius, quæ litis contestatione exacta ex illo non fuit dum viueret. Atque quoad hanc pænam præcisè loquitur lex penul. citata, vt illam legenti perspicuè liquet: sicque iura omnia citata consonant.

Lex. 1. titu. 32. part. 3. tradendo primum modum ex tribus suprà explicatis, quibus nunciatio fieri potest, formam tradit, dirigendo nunciationem, ne in aliqua re opus fiat, in personam, cui fit nunciatio, & non in rem ipsam, vbi Greg. Lopez verb. *e que la non fagades*, ait, eam formam esse iuxta. l. non solùm. §. si cùm possem, & iuxta glossam. l. de pupillo. §. meminisse, verb. possesorem. ff. de noui oper. nunc. atque iuxta Azonis sententiam. Addit verò,

Bartolum reprehendere eam glossam, quatenus ea forma nunciationem refert in personam, cui fit. Ac sanè, quando nunciatio referretur ad personam, ne in tali re ædificaret, aut ne in ea continuaret ædificium, saltem aduersus eam personam competeret tum interdictum noui operis nunciationis, vt demoliretur, quod post eam nunciationem, & ante illius remissionem, ibi ædificasset, tum etiam interdictum quod vi aut clàm. Vnde non probo, *quod additio glossæ. l. si procurator. ff. de noui oper. nunc.* cum Bart. exponendo eam legem, ait. Paulus enim iurisconsultus in ea lege docet, si procurator alicuius nomine eius, cuius est procurator, prohibéat aliquem opus aliquod facere, & ille nihilominus illud efficiat, competere domino, cuius nomine id prohibitum est, interdictum quod vi aut clàm, vt illud demoliat. Circa doctrinam verò huius legis, eamque exponendo, additio ad glossam ibi, cum Bart. ait. Idcirco non competere interdictum nunciationis noui operis in casu eius legis, sed solùm interdictum quod vi aut clàm: quoniam prohibitio illa, seu nunciatio noui operis, fuerat facta personæ, ne ibi ædificaret, nō verò fuerat facta dirigendo illam in rem, ne scilicet in illa ædificaretur: vt autem competat interdictum nunciationis noui operis, necesse est, vt nunciatio in rem, modo explicato, dirigatur. Hoc, inquam, illius additionis, cum Bart. dictum, nobis non probatur. Quoniam præterquam, quòd ex illo textu non constet, nunciationem directam fuisse in personam, & non in rem; & quòd glossa ibi asseueret, in euentu eius legis simul cōpetere interdictum nūciationis noui operis, id quod confirmat ex. l. prætor. §. nulli. ff. eod. titu. vtique, esto nunciatio fiat personæ, ne scilicet ipse in ea re ædificet, neque aliter nunciatio in rem dirigatur, competit aduersus personam, contra eam nunciationem in re illa ædificantem, interdictum nunciationis noui operis. Quod autem in dubium potest reuocari, solùm est, vtrùm in eo euentu, si res transeat in alium possessorē, illeque ædificet, competat aduersus eum interdictum noui operis nuntiationis, an nō; eo quòd nūciatio personalis sit, neque afficiat rem: Bartolusque affirmat, non transire, idque satis consentaneè ad iura citata. *Neq; lex. 1. titu. 32. part. 3. neque item. l. non solum. §. si cum possem, aut glossa citata, contrarium affirmant: sed solùm innuunt, aut docent, eam formam, quæ inseruire potest, vt interdictum nunciationis noui operis cōpetat aduersus personam, cui fit: eo quòd regulariter id solet sufficere: facileque, si res alienetur, circa quam facta est talis nunciatio, fieri possit similis nūciatio aduersus nouum possessorē, si ipse paret idem opus aggredi efficere, aut cōtinuare.*

Nūciatio fieri debet in ipso loco, in quo ædi [sect. 20] ficari paratur, aut in quo ædificatur. Quoniam, si nunciatio domino fiat extra eum locum, tunc, si quid ædificatum fuerit à puncto talis nunciationis, quousque ille commodè accedere possit ad locum, in quo ædificatur, vt cessare ab ædificando præcipiat, non competit interdictum nunciationis noui operis, vt id destruat, sed solùm vt destruat, quod fuerit ædificatum, postquam commodè, post eam nunciationem, potuit impedire. Quando autem fit in loco, in quo ædificatur, aut ædificari paratur, tunc satis est, si nūciatio fiat, vel domino operis ibi existēti, vel magistro operis, vel opificibus, qui ibi ædificant, vel alicui ad dominum operis aliquo modo attinenti, qui ea de re possit certiorē dominum facere, siue is sit mancipium, siue liber, & siue sit masculus, siue femina, & siue sit puer, siue maior ætate. *Ita habetur. l. de pupillo. §. nunciationem, iuncto versiculo seruo, antecedente. ff. de noui oper. nunc. c. l. 1. titu. 32. part. 3. & affirmat communis doctorum sententia, quam referunt ac sequuntur Greg. Lopez ibi, & Ant. Gom. l. 46. Tauri. n. 28.* Atque, si nūciatio facta sit sciente domino, aut aliquo, qui vicē illius gerat, cessareque possit præcipere, tunc, si aliquid post eam nūciationē sit ædificatum, [[156]] tenetur dominus id demoliri suis sumptibus: poterit verò agere ad sumptus demolitionis, atque etiam

ad sumptus factos in eo ædificando, ad dānūmve ipsi ex eo subsequutum, quòd cessatum non sit, aduersus eum, quem præfecit loco sui ei operi, quique cessare præcipere tenebatur. Quòd si opifices nūciationē agnouerunt, ignorante domino, ac quocūq; alio, qui ei operi à domino esset præfectus, opusque continuerunt post nūciationem, quamuis Otho, relatus à glossa. §. nūciationem citato, verb. nunciationē factam, asseruerit demoliendum esse opus sumptibus domini, qui tales operarios adhibuit, multiq; meritò subiungant, domino cōpetere actionem aduersus eos operarios, tum ad sumptus in demoliendo opere factos, tum etiam ad sumptus in eo opere faciendo, damnave subsequuta; crediderim tamen, quando id præcisè in pænam esset demoliendum, quia iure esset factum, sed contra nūciationem, fabrorum sumptibus esse demoliēdum, soluēdo simul domino operis sūptus in eo opere factos, damnave ex continuatione operis subsequuta, atque eatenus solūm teneri dominum tunc ad patientiā vt demoliatur. Quòd si opifices soluendo non essent, credo demoliendum non esse, quod persolui domino operis non posset. Ducor, quoniam tunc constaret, dominum operis in nulla esse culpa continuationis eius operis post eam nunciationem: nulla autem æquitas patitur, vt, absque vlla sua culpa, pænam ipse sustineat. Atque iuxta hanc nostram limitationē intelligo glossam citatam, quæ ab ea non discrepat, si attentè legatur, quin omnino consentiunt, tam illa, quam doctores, quos Ant. Gom. vbi suprā. n. 29. citat: atq; cum ea limitatione accipienda sunt, quæ Ant. Gom. ibidem affirmat, alioquin à veritate discrepant, & cum naturali iure pugnant. Hinc dico, si autoritate tutoris, aut curatoris, fiat opus in prædio carentis vsu rationis, nunciatioque sit facta, ipsis sciētibus, & continuatum sit opus, sumptibus ipsorum esse demoliendum, ac soluendos esse sumptus in eo opere factos: quòd si soluendo nō sint, non posse demoliri, præcisè in pænam, cū detrimento dominorum prædii, qui in nulla fuerunt culpa in eo, quòd id opus continuaretur post nunciationem factam. Imò idem dicendum est, si fine culpa vlla minoris, habentis vsum rationis, id opus similiter continuatum est. Quando nullus, ad dominum operis attinens, præsens est in loco ædificii, validè quidem potest ibi fieri nūciatio, ad effectum, vt, si postquam ad notitiam domini deuenerit, opus sit continuatum, demoliendum sit sumptibus illius, argumento. l. dies. §. totiens. ff. de damno infecto, & Disp. 703. dictum est, & aliorum iurium, quæ citant glossa citata, & Ant. Gom. n. 5429. citato; interim tamen, quòd ad notitiam domini ea nunciatio non venit, demoliri non tenetur, quòd à puncto eius nunciationis vsque ad eam notitiam, cum cōmoditate præcipiendi, vt ab opere cessetur, est ædificatum, vt rectè eadem glossa affirmat, & communis doctorum sententia, quam Ant. Gom. n. 29. citato refert ac sequitur. Atque iuxta doctrinam traditam verum est, nunciationē validè fieri posse aduersus absentes, & inuitos, ac ignorantes, quorum nomine ædificium fiat, aut fieri paretur, *vt habetur. l. 1. §. nunciatio. 1. ff. de noui. oper. nunc.* Qui de nouo opere nunciat, debet dicere in [sect. 21] quo loco, siue publico, siue priuato, id opus fiat, aut fieri paretur. Hoc autem intelligerem, quā do iudicem addit, vt ille per se, aut per ministrum, de opere nouo nunciet. Si enim nunciario fieri debet ei, qui opus parat, aut continuat, in loco in quo illud parat, aut continuat, mentione facta de opere in particulari, illud designando, non videtur necessarium mentionem aliam facere de loco, nisi quando id esset necessarium ad exprimendam causam, ob quam opus nunciat. Quando autem nunciatio fieret domino operis extra locum operis, tunc oporteret exprimere locum operis, vt intelligeretur, de quo opere nunciaret. Item, si de parte tantūm operis nunciatio fiat, & non de toto opere, necesse est exprimere, de qua parte in singulari nunciet. Quando verò de toto opere nunciatur, satis est de illo facere mentionem, sine alia partium expressione. Quādo duo opera fiunt, aut fieri parantur, in locis distinctis, tunc, si de vtroque fieri debet

nunciatio in ipsis locis, necesse est ut fiant duæ distinctæ nunciationes, & per consequens, necessariæ etiam sunt distinctæ earum remissiones, hoc est, non sufficit remissam esse vnam, ut censeatur remissa alia. *Ita habetur. l. de pupillo. §. qui nunciat, & §. si in pluribus. ff. de noui oper. nunc. & l. 1. in fine titu. 32. part. 3. Ant. Gom. vbi supra in calce. n. 32. ait, quando loca adeò sunt propinqua, ut ex vno audiri nunciatio possit in alio, satis esse facere vnam nunciationem exprimendo vtrumque opus. Sicut etiam satis est, quando factæ sunt nunciationes duorum operum, vtranque remittere vnico actu, quo sufficienter exprimatur, vtramque remitti.*

Quia, ut dictum est, & habetur. l. prætor. §. sius [sect. 22] autem. ff. de noui oper. nunc. nunciatio noui operis habet locum, tum ut impediatur ne inchoetur opus, quod fieri parabatur, tum etiam ut si coeptum iam erat, impediatur vltius continuari; quando coeptum est, & nunciatione prohibetur, ne continuetur, lege non solum. §. 1. ff. de noui oper. nunc. admonetur nuncians, ut tunc testes adhibeat, qui videant, & notent, quantum tempore nunciationis fit ædificatum, ut, si post eam aliquid addatur ante remissionem, necesse non sit quærere, qui dicant, quantum id sit, ut destrui præcipiatur, sed illi iidem testificentur, quantum, & quod, illud sit. *Quin ibidem. §. sciendum, ad maiorem cautelam, & planiorem probationem admonetur, ut petat à iudice, ut mensura sumatur, quantum ædificatum sit, cordula, aut baculo, & seruetur, ut postea melius constet, quod sit ædificatum, ut destruatur.* Deinde explicandum est, qui nunciare possint [sect. 23] opus nouum, & primò, qui nunciare possint circa priuatas res: deinde verò, qui circa publicas. Atque, ut primo in genere dicamus, quis circa res priuatas nunciare possit, posteaque id in particulari magis explicemus ac limitemus. Is in primio nunciare potest, ad quem res, ob quam nunciatur, pertinet. *Sic enim. l. 1. §. penult. ff. de noui oper. nunc. habetur: Iuris nostri conseruandi, aus damni depellendi, causa, opus nouum nunciare potest is, ad quem ea res pertinet.* Adde, vel qui prætendit ad se pertinere, esto verè ad ipsum non pertineat, ut habetur eadem. l. 1. in prin. Nunciatio enim per eum facta non minùs impedit, ne opus fiat, interim dum non pronunciat, nunciantò nullum ius ad id habere, interim dum non aliter remissio fit eius nunciationis, quàm si verè res [[157]] illa ad se pertineret, ut suprà est dictum. Si tamen, qui nunciat, scit se verè non habere ius ad id, nunciatio est iniusta materialiter ac formaliter, teneturque proinde nuncians ad omnia damna, etiam lucri cessantis, ex ea nunciatione sequuta: si verò id probabiliter ignorat, erit iniusta solum materialiter, non verò formaliter, ac proinde non tenebitur ad damna. Si tamen nunciàs diligentiam non adhibeat competentem ad ignorantiam depellendam, tenebitur in conscientiæ foro ad damna ex ea iniusta nunciatione sequuta.

Is in primis, qui dominus est rei, ob quam [sect. 24] nunciatur, quive prætendit dominum esse, potest nunciare nouum opus. Habet autem id verum, etiamsi dominium tantum vtile eius rei habeat, ut habent feudatarius & emphyteuta, & consentit. l. 3. in prin. ff. de noui operis nunc. *Quin & superficiario competit nunciare posse, ut habetur. l. 3. §. si ego. ff. de noui oper. nunc.* Competit etiam habenti seruitutem realem, *ut habetur eodem. §. si ego. l. de pupillo. §. sed et si, & §. & belle Sextus. ff. de noui oper. nunc. l. vnica. §. ius habet iuncto vers. penul. ff. de remissionib. cuius verba sunt: Ius habet opus nouum nunciandi, qui aut dominium aut seruitutem habet. l. inter seruitutes. §. vlt. ff. de seruit. vrb. præd. l. sed etsi fortè. §. sciendum, & §. vlt. ff. de seruit. vend. & l. in iudicio. ff. fam. herc.* Vtrum autem id intelligendum sit de solo habente seruitutem vrbanam, an verò etiam de habente rusticam seruitutem, suprà examinatum est.

Dixi, eum, cui debetur seruitus realis, posse [sect. 25] nunciare opus nouum: quoniam mero vsufructuario, qui solùm habet seruitutem personālē, tametsi cum iure in re, comparatione prædii, in quo ei is vsusfructus debetur, non competit nūciatio noui operis, aduersus quidem dominum eiusdem prædii, si aliquid ædificare attentet, in quo præiudicet vsufructui, neque nomine proprio, neque procuratorio, (nomine videlicet alicuius alterius) ei competit nunciare nouum opus; sed solùm potest agere aduersus illum confessoria, vendicando suum vsumfructum, atque agēdo simul ad interesse, si quod ei nocumentum sequutum est in suo vsufructu ex tali ædificio, *vt habetur expressè. l. 2. iuncto. §. ult. legis antecedentis. ff. de noui oper. nunc. c. l. unica vers. ipsi autem domino. ff. de remissionib.* Itaque aduersus dominum prædii Cæsareum ius omnino denegat mero vsufructuario in eodem prædio beneficium nunciationis noui operis; solumque ei concedit agere confessoria actione aduersus eum ad vendicandum suum vsumfructum, & in consequentiam ad impediendum, ne ædificet, & vt destruat, quod ædificatum est, quatenus vsufructui præiudicat, atque vt soluat damna ex eo ædificio subsequuta. *Ita habetur. l. 2. iuncto. §. ult. legis antecedentis, c. iunctis glossis ibi. ff. de noui oper. nunc. l. unica vers. ipsi autem domino. ff. de remissionib. l. si eo loco, iuncto. §. 1. c. l. loci corpus. §. in confessoria. ff. de seruit. vend. l. vti frui. §. in iis, c. l. fructuario. §. sicut fructuario. ff. si vsusfructus pet.* Atque lege si eo loco, & cæteris post illam citatis, habetur, quemcunque, cui seruitus debetur, posse agere aduersus ædificantem in præiudicium eius seruitutis, confessoria, vt seruitus vendicetur, & in consequentiam, vt impediatur ædificium, & destruat, quod ædificatum est contra ius talis seruitutis, & vt soluatur damnum ex eo ædificio subsequutum, quantum æstimabitur prohibitū ipsum esse ab usu talis seruitutis. Et similiter dominum prædii, qui prætendit, non competere seruitutem, aut ius ædificandi in suo prædio, posse agere negatoria actione, vt impediatur ædificium, quod in eo prædio fieri attentatur, & vt destruat, quod ædificatum est, atque vt soluatur damnum subsequutum, quantum id damnum æstimabitur. Est tamen obseruandum, quando proprietarius ita ædificauit in præiudicium vsusfructus in eodem prædio, quod extinctus est vsusfructus, vt quia eo ædificio mutata est substātia ac forma rei, in qua erat vsusfructus, vt si vsusfructus competebat alteri in area, & proprietarius in ea ædificauit domum, tunc, cū vsusfructus eo ipso, quod in ea area ædificata est domus, sit extinctus, non competere actionem, vt ædificium destruat, sed competere actionem de dolo ad æstimationem damni, hoc est, valoris totius vsusfructus, quantum æstimabitur vsufructuario non fuisse ita illo iniuste priuatum. *Ita habetur. l. repeti. §. ult. ff. quib. mod. vsufruct. amit. c. l. si eo loco. ff. si seruit. vend.* Eidem quoque vsufructuario competit aduersus proprietarium, qui in præiudicium vsusfructus ædificauit, interdictum quod vi aut clām, vt destruat, quod compertum fuerit esse ædificatum in præiudiciū vsusfructus, & ad interesse ob dāna ex eo ædificio vsufructuario subsequuta. *Ita habetur. l. sed c. ff. quib. mod. vsufruct. amit. c. l. denique in prin. ff. quod vi aut clam.* Vbi glossa ait, cōpetere in hoc euentu vtile interdictum quod vi aut clām, non verò directum. Intellige tamen, competere hoc interdictum, modò vi, aut clām, fuerit ædificatum, in sensu suprā circa hoc interdictum explicato. Et competere idem interdictum vt ædificium destruat, modò eo ædificio non sit extinctus vsusfructus, quia scilicet mutata eo sit substantia ac forma rei, in qua fuerat concessus: tūc enim solùm competit actio ad totum interesse eius vsusfructus, vt dictum est. Præter prædicta omnia competit vsufructuario aduersus proprietarium actio legis Aquiliæ ad damnum subsequutum, *vt habetur. l. denique in prin. ff. quod vi aut clām. l. item Mala. §. ult. ad legem Aquiliam.* Quādo vicinus ædificat in prædio alio vicino in præiudicium vsusfructus, aut etiam in ipsomet prædio vsufructuario, tunc non conceditur

usufructuario nunciatio noui operis aduersus illum nomine proprio; quia id solū competit proprietario: conceditur tamen usufructuario nunciare aduersus illum procuratorio nomine, nempe nomine proprietarii tanquam procuratori illius. *Ita habetur. l. 1. §. ult. ff. de noui oper. nunc. & l. unica. ff. de remissionib.* Eo enim ipso, quod alicui competit vsusfructus in re aliqua, cēsetur factus procurator quoad eam rem proprietarii, nec solū potest, sed etiam tenetur curam eius rei habere, nomine ac loco proprietarii, aduersus quēcunque præiudicium circa illam molientem, *vt habetur. l. ult. in fine, iuncta. l. 2. sequenti. ff. usufruct.* quemad. caue. affirmatque *Ant. Gom. l. 46. tauri. n. 25.* Nominē verò suo proprio potest talis usufructuarius agere aduersus eum vicinū confessoria ad vendicandum suū vsumfructum, & in consequentiam ad impediendum id opus, atque vt destruat, si sit factum, quatenus utrūque fuerit in præiudicium vsusfructus, atque **[[158]]** etiam poterit agere ad interesse, eo modo quo hęc tria aduersus proprietarium explicata sunt. *Ita habetur. l. 1. §. ult. ff. de noui oper. nūc. & l. unica. ff. de remissionib.* Poterit quoque agere interdicto quod vi aut clam, & actione. 1. Aquilię eo modo, quo aduersus proprietarium utrūq; est etiam explicatum, *vt hab. l. denique in pri. ff. quod vi aut clam, & l. item Mela. §. ult. ff. ad legem Aquiliā. lex. 4. tit. 32. part. 3.* disponit, usufructuariū nūciare posse nouum opus extraneo ædificāti in præiudicium vsusfructus. *Et Ant. Gom. n. 25. cita.* intelligit eam legem, etiam nomine proprio, aitq; exponi non posse nomine tātū proprietarii, sed suo etiam proprio, sicque ait affirmandum esse in hoc regno propter eam legem id ita disponentē. Cōfirmare verò id possumus: quoniam eadem lex idem dicit de vassallo & ēphyteuta cōparatione prædii, in quo habent vtile dominiū: hos autem constat, etiā nomine proprio, nūciare posse opus nouum aduersus ædificātē in præiudicium dominiū vt ilis ipsorum, vt suprā ostensum est. Greg tamen Lop. eadē. l. 4. eam, quoad usufructuarium, exponit, quod iuxta ius commune id intelligatur, non nomine proprio, sed nomine proprietarii: eam verò legem ita fuisse loquutā, quoniam eo ipso quod aliquis est usufructuarius prædii alicuius, constituitur procurator circa eam rē proprietarii, vt id efficere possit proprietarii loco ac nomine. Anxiē autem laborāt doctores ad reddendam rationem, cur usufructuarius nūciare non possit nomine pro prio: cum tamen, qui habet seruitutē realē, nūciare possit aduersus ædificātē contra ius eius seruitutis, & cum creditor, cui res tradita sit in pignus, aut subiecta sit hypothecā, possit nūciare aduersus ædificātē in illa, vel in illius præiudicium, vt videbimus. Prætermissa verò ratione Ant Gō. n. 25. citato, cum Bart. & aliis, quos citat, ratio humanæ, positiuæve, eius sanctionis videtur esse, quoniam usufructuarius in re, ratione cuius nūciat, solum habet vsūfructū, existēte in alio proprietate & dominio simpliciter illius, ac proinde equitas postulabat, vt nūciatio solum ei cōcederetur nomine a loco proprietarii; reliqui verò, qui nūciare possunt nomine proprio, habēt in re, ratione cuius nūciāt, vel dominium, saltem vtile simpliciter, (vt cōprehēdamus vassallum & emphyteutā quēcunq; etiam eum, qui est solum ad decennium, aut vltra) vel habent ius in tota re in particulari, vt distrahi & alienari possit in ipsorum commodum, vt habent creditores, qui illam in pignus habent, aut subiectam particulari hypothecā. Antonius Gō. vbi suprā. n. 23. ait, interdictū [sect. 26] nunciationis noui operis cōpetere ei, qui habet quasi dominium rei, in qua ædificatur, aut in cuius præiudiciū ædificatur, hoc est, ei qui possidet eā rē cum bona fide & titulo, licet verè non sit sua, cui Publiciana actio competit circa eam rē: *idq; probat argumento. l. eum qui. §. 1. vers. publiciana, & l. quæcūque. ff. de publiciana.* Itēq; affirmat idem interdictum cōpetere ei, qui habet solam nudam possessionē eius rei, *argumēto. l. vim facit. ff. de vi & vi armat.* Est autem id indubitatum

ex supradictis: quoniam cōpetit ei, qui prætendit rē ad se attinere, eiūq; ædificiū pręiudiciū afferre, siue utrūq; ita in re sit, siue nō.

Creditori, cui pignori, aut hypothecę, est subiectū prędium, si aliquid in eo ædificare intētetur, aut in vicino contra seruitutē illi debitam, aut aliter in pręiudiciū eius prędii, competit, sicut domino prędii, eo modo pignori, aut hypothecę, subiecti, nunciare nouum opus, & confessoria ad vendicādā seruitutē tali prędio debitam, ita ad utrūq; cōpetit vtilis actio, nempe vt nūciet nouum opus, & vt agat confessoria ad seruitutē ei prędio debitam vendicandam. *Ita habetur. l. creditori. ff. de noui oper. nūc. l. unica in fine. ff. de remis. & l. ei qui. ff. de seruit. ac consentit communis doctorum sententia, quam Ant. Gom. in fine. nu. 23. citati sequitur.*

Inquilinus, & colonus, qui prędium habent cō [sect. 27] ductū, nunciare non possunt nouum opus, neque intentāti ædificare in eo, neque vicino, qui in pręiudiciū illius, aut seruitutis illi debitę, ædificat. Ratio autem est, quoniam non habet ius in re eius prędii, ratione cuius esset nunciādū: *Ita habetur. l. 3. §. si ego. ff. de noui oper. nunc.* Vnde glossa ibi verb. inquilinus, colligit, nullum, cui solum competit personalis actio, quique non habet ius in re comparatione prędii, ratione cuius velit nūciare, posse nūciare nouum opus, & consentit glossa. *l. 1. §. penul. ff. eod. titu.* Atque inde Ant. Gom. vbi suprā in calce. n. 27. colligit, neque emptorem, neque donatarium, neque quencunque alium similem, qui solū habeant ius ad rem ipsis venditam, donatam, aut alio titulo debitam, necdumq; ipsis traditam, competere nunciare nouum opus ratione illius. Meritò verò eodem. n. 27. cum Bart. & aliis, quos citat, ait Ant. Gom. si inquilino, aut colono, locator subiecisset hypothecā, vel id prędiū ipsis conductum, vel omnia sua bona, in securitatē eius contractus, tunc posse talem inquilinum, aut colonum, nunciare nouum opus ratione talis prędii, iuxta ea, quę ex. l. creditori. §. pręcedente dicta sunt. Et idem est de emptore, donatario, aut alio simili, cui vel ea ipsa res esset subiecta hypothecā in securitatē eius contractus, vel cui subiecta essent hypothecā omnia bona eius, cuius ea res adhuc esset, idq; propter eandem rationem. Eodem. n. 27. Ant. Gom. rectē affirmat, quamuis colono & inquilino non competat nūciare opus nouum ratione prędii, quod habent conductum, si tamen videant aliquid ædificari in illius pręiudiciū, teneri admonere locatorē eius prędii ea de re, alioquin ipsos teneri ei ad interesse, ad damnūmve sequutum, *iuxta. l. videamus. §. item prospicere. ff. locati, qui ita habet. Item prospicere debet conductor, ne in aliquo, vel ius rei, vel corpus, deterius fiat, vel fieri patiatur. Cosentit. l. item queritur. §. exercitu. ff. eod. titu.* dictūq; Disp. 494. à nobis est cum eodem Ant. Gom. 2. tom. var. res. c. 3. n. 20. & cum aliis, quos citat. Numero item 27. citato addit idē Ant. Gom. cum Paulo Castręsi, Romano & Cumano, in absentia locatoris posse cōductorē & inquilinum nunciare nouum opus nomine locatoris, in quo nullum potest esse dubium, pręsertim si de rato caueat, hoc est, quòd locator ratam habebit eam nunciationem nomine ipsius factam, iuxta ea quę statim dicenda sunt. Locatori autem & inquilino competit interdictum quod vi aut clām, *vt constat. l. si is qui in puteum. §. si post quam. vers. si tamen precario. ff. quod vi aut clam.*

Pupillus ad suum priuatum commodum nun [sect. 28] ciare validē potest, etiam sine autoritate tutoris, quando non est in possessione rei, ob quam nunciat: quia id in suum commodum cedere potest, & in nullum suum detrimentum: si autem sit in possessione rei, ob quam nunciat, validē etiam nūciat per iudicem, aut iactu lapilli: quia id similiter cedere potest in suum cōmodum, & in nullum ipsius detrimentū: valent autem, quę agit minor in suum commodum sine tutoris autoritate, [[159]] vt Disp. 224. copiosē comprobatum est: solis

autem verbis nunciare non potest tunc validè sine tutoris autoritate: quia eo ipso amitteret possessionem, ac proinde talis nunciatio cederet in ipsius detrimentū. Ita habetur. l. de pupillo in prin. iuncta glossa ibi, eoque modo est intelligendus textus ille. ff. de noui oper. nunc. & cum communi doctorum sententia tradit *Ant. Gom. vbi supra, n. 26.* Qui inde colligit, vxorem sine mariti autoritate & consensu validè nunciare ob res suas, in euentibus, in quibus dictum est, pupillū validè ob suas nunciare sine tutoris autoritate: secūs autem in euentu, in quo pupillus validè non nunciat sine tutoris autoritate: quia similiter valida sunt, quæ vxor in suum commodum administrat ac facit sine mariti autoritate: secūs autem, quæ in suum præiudiciū cederent.

Nunciare possunt nouum opus filius, mancipium, mercenarius, negotiorum gestor, qui negotiis eius, cuius nomine nunciatur, sit expositus, & *maior-domo* appellatur, procurator, & amicus; non tamen possunt hi nūciare nomine proprio, sed alieno eius, qui autoritate sua propria posset nunciare; validaque est horum nunciatio, modò tamen caueant de rato, hoc est, eum, cuius nomine nunciant, ratam eam nunciationem habiturum, *Ita habetur. l. 1. §. nunciatio. 1. vers. item nunciationem. l. de pupillo. §. qui procuratorio. ff. de noui oper. nunc. c. l. 1. titu. 32. part. 3. affirmatque vniuersim Ant. Gom. vbi supra. n. 27.* & quidem quod ad procuratorem attinet, si is ad id particulare habeat mandatum ab eo, cuius nomine nūciat, necesse non est illum de rato cauere: quoniam eo ipso constat, ratum id habere illum, cuius nomine nunciat. Quando verò solūm est procurator vniuersalis, sine mandato ad id in particulari, tunc necessarium est, eum cauere de rato, modò tamen exigatur, vt ait glossa. §. qui procuratoriocitato, verb. satisdabit. Quòd si non cauerit de rato, nunciatio est nulla, ipsoque iure cēsetur eo ipso remissa, vt habetur. §. qui procuratorio citato. Quod ad reliquos attinet, lex. 1. citata satis apertè affirmat, validam esse eorum nūciationē, modò satisdent de rato, esto nullum ad id habeant mandatum ab eo, cuius nomine nunciant, & idem affirmat *Ant. Gom. vbi supra.* Possumus etiam id confirmare, quia eo ipso, quòd haberēt mandatum, essent procuratores ad id eius, cuius nomine nunciant, & præterea satisdare non tenerentur de rato, quia superflua esset ea satisfactio, cū ex eo mandato constaret, eum, cuius nomine nunciant, id velle, ratumque id habere. *Greg. Lopez. l. 1. citata. verb. deuen dar recaudo,* ait glossam, & *Bart. §. nuntiatio citato affirmare,* hos nō posse validè nunciare sine mandato, etiam si de rato cauant, eamque esset communem opinionem stando in iure communi. Glossa tamen illa non id tanquam indubitatum affirmat, sed solum, cū præmisisset, procuratorem, etiam sine mandato, posse nunciare, modò de rato caueat, addit. *Vel dic, cum mandato* (quasi scilicet procurator, etiam si de rato caueat, non possit validè nunciare, nisi habeat mandatum ad id in particulari) *vnde negotiorum gestor non nunciat, cū hoc edictū habeat instar actionis.* Hęc glossa illa. Quæ sanè nō præfert posteriorem expositionē priori: existimoque posteriorem esse falsam. Duo obserua. Primum est. Vt quis censeatur vi ædificasse, teneaturque; proinde interdicto quod vi aut clām, satis esse, si prohibeatur per procuratorem eius, in cuius præiudiciū ædificat, vel per alium ad eum attinentem, vt per filium, seruum, aut, mercenarium illius, esto neque de rato caueant, neque ad id habeant mandatum. Atque hoc est, quod habetur. l. prohibere in prin. ff. quod vi aut clām. Reddit verò rationem ibi *Vlpianus,* quoniam, si clām ædificasset, competeret actio ex eo interdicto: multo verò magis cōpetere debet, si prohibitus ab aliquo illorum, etiam à mancipio, ædificet: cū non ex prohibitione illius actio resultet, sed ex actu ædificantis contra illam prohibitionem, præcedentē ea prohibitionem. Secūdum verò est, quando. l. de pupillo in prin. vers. seruo autem, dicitur. *Ipse* (scilicet seruus) *nunciare non potest, neque nunciatio*

ullum effectum habet, intelligendum id esse, si nūciet nomine proprio: secūs verò si alieno, nomine scilicet domini sui, nunciet, vt glossa ibi exponit.

Hoc loco obiter est exponenda subobscura lex cū procurator. ff. de noui oper nunc. Vbi, absque vlla violentia illius contextus, hoc docere videtur Iulianus, cuius est ea lex. Si procurator (de quo non constabat habere ad id mandatum) nunciauit opus nouum, pręstita satisdatione de rato, (quòd scilicet solueret ei, cui nuntiatio esset facta, quantum sua intererat, non esse impeditum opus ea nunciatione, si dominus, cuius nomine esset facta, eam ratam non haberet) & cum pacto, quòd intra certum tempus non ædificaretur, & quòd consuleretur dominus, num remittere vellet nūciationē, tunc, si dominus intra id tempus nūciet, committitur stipulatio, vt teneatur procurator ad interesse, quasi dominus ratam non habuerit nunciationem: cauerat enim procurator, se soluturum interesse sub conditione, si dominus ratam non haberet nunciationem, purificata verò seu impleta conditione, sub qua promiserat adhibita stipulatione, quia videlicet dominus ratā non habuit nūciationē, dicitur cōmitti stipulatio, quia obligat impleta conditione, sub qua fuit facta. Si verò elapso eo tempore dominus nūciet, tunc non committitur stipulatio, quia cēsetur dominus ratam habuisse nūciationē nomine ipsius à suo procuratore factam, solamque interpositam pro tempore illo pręterito, dependenterq; à domini voluntate, num remittere vellet eam nūciationem, an non, sed vlteriùs in ea progredi, nunciando in tempus etiam futurum opus nouum.

Quando locus, ratione cuius nūciatur, est cō [sect. 30] munis duorum, si vicinus aliquid in eo ædificet, aut in vicino prædio, in præiudicium loci illius communis, tunc vnusquisque eorum, quibus cō munis est locus ille, nunciare potest nouum opus vicino illi seu extraneo. *Ita habetur. l. 3. in prin. vers. si in loco. ff. de noui oper. nūc.* Obserua tamen, non satis esse, si vnus eorum tunc nunciet opus nouum, vt cōparatione etiam non nunciantis, vim habeat ea nūciatio, *vt habetur. l. de pupillo. §. si plurium, vers. si plurium dominorū. ff. eod. titu.* Intellige, nisi nomine omnium sit facta nunciatio, atque tunc necessarium erit nuncianti cauere de rato comparatione cæterorum, si id postulet is, cui fit, nisi speciale mandatum dedissent cæteri, vt ipsorum etiam nomine nunciatio fieret.

Quando vnus eorum, quibus communis est lo [sect. 31] cus, seu prædium, aliquid in eo ædificat, aut destruit, non competit alteri aduersus eum nunciare opus nouum, sed agere potest aduersus eum cō-[[160]]muni diuidendo, aut iudicis officio; quod est in eo euentu remedium ordinarium, ad id ex professo institutū; vbi verò ordinarium remedium, ad id ex professo institutum, habet locum, cessat, neque habet locum extracrlinarium, quale est nunciationis noui operis. *Ita habetur. l. 3. in prin. vers. planè. ff. de noui oper. nunc.* Porrò iudicio communi diuidūdo, aut officio iudicis, quando vnus dominorum prædii multis communis, aliquid in eo ædificat, aut destruit, sine alterius consensu, impediri in primis potest, ne id ædificet, potiorque est cōditio impediētis, quam ædificare aggrediētis, atque adeò præualet, quousq; alius ostendat, se ad id ius habere. *Ita habetur. l. Sabinus. ff. communi diuid. l. parietē, & l. in re, ff. de seruit. vrb. præd.* Quòd si quid ædificet sine expresso consensu alterius, siquidē in præsentia illius id ædificauit, aut ita vt impedire id potuerit, nec impediuit, cogitur, iudicio communi diuidūdo, soluere dānū, non verò destruere, qædificauit; si verò in absentia illius id ædificauit, ita vt impedire illud non potuerit, (& lōgè maiori cum ratione, si illo cōtradictēte id ædificauit) cogitur non solum soluere dānū, sed & destruere, quod ædificauit. Quando verò de consensu socii id ædificauit, neque destruere id cogitur, neque soluere dānū. *Ita habetur. l. Sabinus, & l. in re, citatis.* In nullo verò horum euentuum, locum habet nūciatio noui operis.

Idem cum Labeone affirmat Vlpianus. l. 3. citata in prin. vers. quòd si socius, quando duo habent domū cōmunē, & vnus eorum habet aliam vicinam sibi propriam, atque alter in domo communi ædificat, quod simul cedit in præiudicium domus illius vicinæ: quia enim dominus vicinæ domus impedire potest iudicio communi diuidūdo, aut iudicis officio, ædificare id in domo vtrique communi, non cōceditur ei nūciatio noui operis, etiam quatenus id cedit in præiudicium alterius domus, quæ non ædificanti est propria: idque propter illam rationē; quia cum locum habeat remedium aliud ordinarium, cessat extraordinarium nūciationis noui operis, cum pæna, vt, etiam quod in re iure est ædificatum post nūciationē, destruat. In euētibz autem toto hoc §. explicatis, licet non cōpetat nūciatio noui operis, competit tamen interdictum quod vi aut clam, vt patet. l. deniqz. §. si ex sociis. ff. quod vi aut olā. Quando, quod in communi prædio vnus sociorum aggreditur ædificare, vtrique est omnino expediēs ac necessariū, vel aliqua alia ratione, qui id efficere aggreditur, ius peculiare ad id habet, tunc, si alter resistat, ædificareque id impediatur, iudicio cōmuni diuidundo, aut interdicto vti possidetis, cogitur desistere ab eo opere impediendo. Ita habetur. l. si ædes. ff. comm. diuid. & concinit. l. in re, citata.

Qui nouum opus nunciat, iurare tenetur coram [sect. 32] iudice de calūnia, hoc est, quòd iure, quantum ipse arbitratur, & non maliciosè, animo iniustè impediēdi opus, nunciet: tenetur verò id ita iurare, si nūciatus id petat: quòd si iurare non velit, remittitur nūciatio, & pro non facta habetur. Ita habetur. l. de pupillo. §. qui opus. ff. de noui oper. nūc. & l. 9. tit. 32 part. 3. Atque hoc idē similiter intellige de eo, qui opus nouum nūciat circa rem aliquam publicam. Quando in loco publico ædificatur, (idem intel [sect. 33] lige, si in præiudicium illius ædificetur) omnes ciues, siue qui de eo populo sunt, nunciare possunt opus nouum, in bonum publicū. Ita habetur. l. 3. §. vlt. & l. 4 ff. de noui oper. nunc. ac. l. 3. titu. 32. part. 3. Verba. §. vlt. & l. 4. hæc sunt: Si in publico aliquid fiat, omnes ciues opus nouum nunciare possunt. Nam reipublicæ interest quàm plurimos ad defendēdā suā causam admittere. Quòd si multi nūcient idem tale opus nouum, cum hæc causa publica popularisve sit, vt ex se, & ex. l. 2. §. hoc interdictum perpetuū. ff. nequid in loco publico, constat, iudex colligit ex eis idoneiorem, qui illam prosequatur, vt notat glossa. §. vlt. citato, & habetur. l. 1. ff. de popularib. act. Pupillus tamen non admittitur ad nunciandum in eo euentu, nisi simul sua interesset, ibi non ædificari, vt habetur. l. de pupillo in prin. ff. de noui oper. nunc. l. mulieri. ff. de popul. act. & l. 3. tit. 32. part. 3 Atque idem est de muliere, vt eade. l. mulieri. & l. 3. tit 32. citato habetur, affirmatque glossa citata. Infamis præterea non admittitur ad nūciandū in eo euentu: quia vniuersim nōadmittitur ad popularē actionē. Ita habetur. l. popularis. ff. de popul. act. & affirmat Ant. Gom. l. 46. tauri. n. 30. Vtrū autem forenses nūciare possint de opere nouo facto in loco publico, Bart. & alii, quos referunt ac sequuntur Ant. Gom. n. 30. citato, & annotatio in margine. l. 3. §. vlt. ff. de noui oper. nunc. negant, nisi opus fieret in via publica, quæ omnibus, etiam forensibus, est communis, nullusque per illam transire prohiberi potest, argumeto. l. per agrum. C. de seruit. & l. 1. ff. de via publica. Concinunt. l. 3. §. vlt. citato, & l. 3. titu. 32. citato, quæ de ciuibz, seu oppidanis, loquuntur sunt, neque externos comprehenderunt. Non tamen refragatur, quòd circa viam publicam exteri possint nunciare opus nouum, vt Bart. & alii affirmant, esto Greg. Lopez. l. 3. citata glossa. 2. refragari eam legem. 3. autemet. Quod dictum est, quēlibet de populo nunciare posse nouum opus factū in loco publico, intelligendum est de loco publico, qui inseruit ad vsum publicum, non verò de loco fisci, aut proprio oppidi, nec deputato vsui publico, oppidanorū: tunc enim solus is potest nunciare, qui à principe, aut ab ea cōmunitate, ad id est deputatus, mādātūve habet,

ut probat. l. 2. §. hoc interdictum ad ealoca. ff. nequid in loco publico, iuncta. l. nulli. ff. quod cuiusq; vniuer. & cum Bart. & cōmuni doctorum sententia, affirmat. Ant. Gom. n. 30. citato. Suprà explicando, nunciationem debere fieri [sect. 34] in loco, in quo opus fit, potius quam extra cum locum, personæ, qui opus fieri præcipit, explicauimus magna ex parte, quibus fieri possit nunciatio: nūc verò addenda sunt sequētia. Primum est, non solū posse fieri nunciationē vicino proximo, quem cōtendimus ædificare contra ius nostri prædii, sed. etiam remoto: quoniam potest esse seruitus cōparatione nostri prædii in remoto prædio, ne, verbi gratia, altius tollatur, non existente tali seruitute intermediis prædiis. *Ita habetur. l. non solū in prin. ff. de noui oper. nunc.* & disputatione præcedente est dictum. Secundum est, quando opus fit in loco multis communi, satis esse vni eorum nunciari in loco vbi fit, vt si quid deinceps, ante remissionem nunciationis, sit factum, destruat. Cæterum, si id ab vno eorum sit factum, aliis ignorantibus nunciationē, minimeque cōsentientibus, vt post nunciationem id fiat, tunc sumptibus solū illius est demoliendū. Adde, teneri etiam ad sumptus factos in eo opere cōtinuādo, esto socii ante nūciationē consensissent, vt nomine & sumptibus omnium id fieret, vt suprà dictum est de opificibus, qui continuarunt opus post nunciationē ipsis in loco operis factam, ignorante eam nunciationē domino operis. *Ita habetur. l. de pupillo. §. si plurium. ff. de noui oper. nunc. Consentit, quod definitur. l. ædilus. ff. eod. titu.* Ibi enim decernitur. [[161]] si opus fiat in loco communi duorum, saltem quia illum possident tanquam communem vtriusq;, esto postea comperiatur fuisse vnus illorum tātū, vniūque eorum opus nouum nuncietur, & post nunciationem factam ædificetur, tunc, si vtroque consentiente, id post nunciationem sit factum, aut vno id post nunciationem faciente, & altero ratum id habente, postquam sciuit nūciationem esse factam, vtique expensis vtriusq; est demoliendum. Quòd si vno eorum ignorante nunciationem, nec ratum postea id habente, ab altero sit factum, tunc si solus, qui id fecit, tenetur soluere expensas demolitionis, quin & expensas factas in tali opere conficiendo: alter verò solū tenetur præstare patientiam, vt demoliatur.

Nunc dicenda sunt aliqua de remissione nunciationis noui operis. Et quidem, qua cunque ratione sit facta nunciatio, etiam si iudicis ministerio facta sit, si inter partes postea conueniat, vt nihilominus opus fiat, atque adeò, si pars, in cuius commodum facta est nunciatio, illam remittat, esto ad id nulla iudicis autoritas interueniat, locum non habet, opus, post eam remissionē factum, destruat: quoniam, cū in nunciantis commodum introductum sit prætorium interdictum, vt si quid post nunciationem, & ante remissionem illius, sit ædificatum, id destruat, eo ipso, quòd de consensu partis, quæ nunciauit, ædificatum est, cessat id, quod in pænam eo edicto meritò fuit sancitum: eaque ratione, si pars, quæ ita remisit nunciationem, agere postea ex interdicto prætoris velit, vt destruat, quod post nūciationem ædificatum est, competit aduersus ipsum exceptio, quòd de ipsius consensu ac beneplacito ædificatum id sit. *Ita habetur. l. 1. §. inde quæritur. ff. de noui oper. nunc. & l. 3. §. sed si. ff. quod vi aut clām, vnde & interdictum, quod vi, cessat, quando post nunciationem, seu prohibitionem, ne ædificetur, pars, quæ in suum commodum prohibuit, concessit vt ædificaretur. [sect. 35]*

Eo autem ipso, quòd aliquis constitutus est procurator alicuius cum particulari mandato, vt opus nouum nunciare possit, vtve in priuati alicuius commodum prohibere possit ædificare, si is remittat nunciationem, quòdve erat ædificari prohibitum, ædificari permittat, locum non habet, vt destruat interdicto noui operis nunciationis, aut interdicto quod vi aut clām, quin potius si destrui postea intentetur, quia contra nūciationem aut prohibitionem factam

sit ædificatum, competit exceptio, quòd ex talis procuratoris permissione sit ædificatum, *vt habetur l. 3. §. sed si, vers. non tantùm. ff. quod vi aut clàm* idemque ibidem subiungitur esse de tutore, & curatore, qui eo ipso censentur procuratores ad nunciandum & prohibendum ædificare in commodum minorum, ipsorum curæ commissorum: tametsi glossa ibidem subiungat, minori competere postea restitutionem in integrum, si se læsum ex tali permissione ac edificio inueniat: quod tamen solùm reputo verum ad effectum, vt destruat, quod non iustè ex natura rei fuerit ædificatum in minoris damnū: non verò vt, quod iustè ex natura rei fuerit ædificatum, destruat in pœnam, tanquam factum contra nunciationē, aut prohibitionem: neque enim in eo vlla cernitur læsio talis minoris. Eadem. l. 3. §. planè, iūcto. §. sed etsi à principe, subiungitur ex eo, quòd aliquis curator sit constitutus publicarum rerum, aut quòd præses sit reipublicæ, possitque proinde prohibere, ne aliquid in loco publico ædificetur, non censi illi concessum, vt permittere possit in eisdem publicis rebus ædificari, nisi consuetudine, aut à principe, vel alia legitima ratione, comperiatur ei concessum, ac proinde ex tali eorum permissione non oriri exceptionem, quòd permissu eorum ædificatum sit, vt non destruat, quod contra nunciationem, prohibitionemve, compertum fuerit ædificatum, demoliri que ea de causa intentatur. Illud verò est obseruandum, quando priuatus aliquis in suū proprium commodum nunciauit alteri, ne aliquid ædificaret in priuato aliquo loco, tunc, si procurator ita nunciantis, qui ad nunciandum & remittendum nunciationem non habebat ab eo particulare mandatum, remittat talem nunciationem, ædificareque, quod erat inhibitum, permittat, inuolidam esse talem remissionem in dānum nunciantis sine ipsius mandato factam, nisi nuncians ratam illam postea habeat, ac proinde tunc demoliendum esse, quod post eam nunciationem ex tali permissione fuerit ædificatum, *Ita habetur l. cùm procurator. §. vlt. ff. de noui oper. nunc.*

Quando per iudicem, ad petitionem alicuius, [sect. 36] facta est alicui noui operis nunciatio, tunc, si iudex postea permittat, pronuncietve, posse ædificari, sanè, quod iudicis permissu ædificatum postea fuerit, destrui non potest, quasi contra interdictum prætoris sit post nunciationem ædificatum: eo enim ipso, quòd iudex ædificari permisit, censetur remissa prior nunciatio. *Ita habetur l. si opus. ff. de noui oper. nunc.*

Quod attinet ad remissionem nunciatio [sect. 37] nis noui operis, non quidem ex consensu partium, sed legis autoritate ac dispositione, nempe, quando is, cui nunciatum est, satisdat, quòd destruet suis expensis, quod ædificuerit, si cōpertum fuerit non esse iure ædificatum, aut offert eā satisdationem, & per aduersarium stat, qui non vult illam recipere, dicemus primò, quid de iure digestorum hac de re fuerit sancitum, deinde verò secundò dicemus, quid de iure Codicis fuerit postea innouatum ac mutatum.

Ante omnia verò est obseruandum, hoc esse discrimen inter eum, qui nunciat nouum opus, suum interesse priuatum intendendo, quia scilicet, siue opus fiat in loco priuato, siue in publico, contendit cedere in suum particulare detrimentum, nec iure fieri posse; & inter eum, qui nunciat nouum opus, publicum præcisè communitatis, reipublicæve, bonum intendendo. Quòd in priori euentu, vt remissa legis autoritate censeatur nunciatio, necessarium est, nūciatum satisdare, hoc est, fideiussores idoneos adhibere, quòd si compertum fuerit ædificium nō iure esse factum, illud destruet, & damna soluet, aut certè eam satisdationem offerre, atque per aduersarium stare, qui eam non admittat. In posteriori verò euentu satis est promittere se destructurum opus, & soluturum damna, si cōpertum fuerit non iure esse factum, neque necesse est fideiussores adhibere. *Ita habetur l. non solùm §. si cùm, & §. quòd si. ff. de noui oper. nunc. & l. 1. §. penul. ff. de prætor. stipul.* Is tamen, qui in publico solo

ædificare vult, non priùs id ei permit-[[162]]titur, quàm ius, quod ad id habet ex principis priuilegio, aut aliunde, coram iudice ostendat, vt habetur. l. prætor. §. adjicitur. vers. neque enim. ff. de noui oper. nūc. Atque ad iudicem spectat, eū prohibere donec ius, quo id facit, ostēdat, *vt habetur. l. 2. §. si quis nemine. ff. nequid in loco pub.* Cōparatione ergo priuati, qui nunciat nouum opus, satis est, si promittat se demoliturum, si cōpertum fuerit, non iure esse factum: & idem est, si, ostenso iure coram iudice, quo ædificare potest, aliquis contra illud aliquid contendat ac apponat.

Is, cui nouum opus est nunciatum, si satisdet, [sect. 38] aut promittat, (iuxta discrimē proximè traditum) si compertum postea fuerit, se indebitè ædificare, destructurū opus, ac soluturum dāna, aut offerat cautionem, vel promissionē, quam nuncians recipere non velit, ita quòd per nunciatum non stet, quominus cum effectu eam præstet, sed per nūciantem, qui non vult eam recipere, tunc censetur remissa nunciatio præterita, perindeque nūciatus continuare potest opus, ac si talis nunciatio facta non fuisset. Hoc verò remedium eam vtilitatem nunciato affert, quòd necesse non habet adire iudicem, & expectare, vt de causa agnoscat, & pronunciet, nunciatum debitè ædificare, eaquē sententia remittere nunciationē, integrum illi relinquendo, nihil illa impediēte, ædificare. *Hæc omnia habentur. l. de pupillo. §. si is cui. l. prætor. §. si quis paratus, & l. stipulatio in prin. & §. 1. ff. de noui oper. nunc.* Atque in hoc postremo iure additur, hoc remedio consultum esse, tam nuncianti, quàm nunciato; nuncianti quidem, quoniam cautum sufficienter habet, quòd, si compertum fuerit non iure esse ædificatū, destruetur opus, indemnisque omnino seruabitur: nūciato verò, quoniam non impeditur prosequi suum opus; cū tamen contraria impeditio, præter molestiam, esse posset coniuncta cum damno.

Formam cautionis, siue fideijussoriæ, siue so [sect. 39] lius promissionis, prout fuerit res, circa quam nouum opus fuerit nunciatum, *ponit glossa. l. st ipulatio in prin. verb. nunciatione, ff. de noui oper. nunc.* collectam ex variis iuribus, continentemque, quid stipulari debeat nuncians à nunciato, & quid nunciatus debeat ei promittere, ad quidve se debeat illi obligare. Ea verò talis est. Promittis te, hæredemque tuum post tuam mortem, demoliturum, restitutorum ve tuis sumptibus in pristinum statum, quod post nunciationem tibi factam ædificaueris, damnumque totum, quod inde fuerit sub sequutum soluturum, si iudicatum fuerit, non iure esse ædificatum, aut si per te steterit quominus iudicetur, quia vel ad defendendas partes tuas non accedes per te, aut per alium, vel quia dolo feceris, ne pronuncietur sententia, eam pronunciarī impediendo. Aut si prædicta non feceris, vel ego id potiùs maluerim, promittis te soluturum, quantum ea æstimabuntur? Respondetque nunciatus, promitto.

Quòd autem nuncians in hoc euentu stipu [sect. 40] lari debeat à nunciato, vt pro se, & pro suis heredibus, post mortem suam, ad id se astringat, idque promittere debeat nunciatus, *habetur expressè. l. non solum. §. ult. ff. de noui oper. nunc.* vt glossa citata rectè ait. Verba enim vltima illius. §. hæc sunt: *Idq̃ ex eo apparet, quòd in stipulatione, quæ ex hac causa interponitur, etiam hæredis mentio fit*, eius scilicet, qui cauet, se demoliturum opus, si compertum postea fuerit, non iure esse ædificatum. Operæpretium autem erit exponamus eum. §. *atque cum. l. prætor. §. hoc interdictum perpetuo. ff. eod. titu.* eum conciliemus. Paulus iurisconsultus in eo. §. vltimo sic ait: *Morte eius qui nunciauit, extingitur nunciatio: sicut alienatione*, (intellige prædii, ob quod nunciatur, quia scilicet in præiudicium eius prædii contenditur cedere ædificium, quod nunciatur, ne fiat) *quia his modis finitur ius prohibēdi.* (ne scilicet fiat tale ædificium) *Quòd si is, cui opus nouum nunciatum erat, decesserit, vel ædes alienauerit*, (in quibus scilicet nunciatum erat, ne ædificaret, quia videlicet id erat in præiudicium tertii nunciantis) *non*

extinguitur operis noui nunciatio. Et continuò Paulus subiungit illa verba, quorum occasione referimus atque exponimus totum. §. *Idque ex eo apparet, &c.* eisque verbis absoluit totum eum §. eamque legē. Cū verò interdictum nunciationis noui operis tres partes contineat, vt in principio huius disputationis dictum comprobatumque est, primam videlicet prohibitoriam, qua nunciatur, ne fiat opus aliquod, néve continuetur, si erat cæptum, antequam nunciatio remittatur, saltem cautione præstita, aut oblata, modis hactenus explicatis, de sola ea prima parte eius interdicti sermo est Paulo iurisconsulto in eo. §. vlt. aitque: Si quis nunciauit opus nouum alteri, isque se continuit, neque vltèrius est facta progressio, tunc, si is, qui nunciauit, è vita discessit, aut alienauit prædium, ob quod nūciauit, extingui nūciationē, nec trāsire in hæredem, aut in nouum alium quouis alio titulo eius prædii possessorē: quoniam nunciatio est personalis ex parte eius, qui nunciat, iusque nunciandi, licèt ratione alicuius prædii competat, transeatque proinde ius ac facultas nūciandi ad quēcunque possessorem eius prædii, expirat tamen in eo, cuius antea erat id prædium, ac proinde nūciatio ab eo facta vnà cum eo iure expirat in illo, vtpote personalis illius, interim dum illius erat id prædium, ratione cuius facta ab eo est ea nunciatio. Itaque Paulus iurisconsultus non negat, nouum successorem, siue titulo hæredis, siue quouis alio, in prædio, ratione cuius facta est nunciatio, ius habere nunciandi, sicut habebat antecessor in illo, qui nunciauit, posseque nunciare, si alius aggrediatur facere aut prosequi opus, quod antecessor nunciauerat, ne fieret: hoc quippe ius perpetuò competit domino, possessorive eius prædii, interim dum opus, quod in præiudicium talis prædii cedit, non est perfectum ac consummatum, nulloque vnquam tempore aduersus eum præscribitur, quoad id, quod nondum est factum, ceditque adhuc in præiudicium talis prædii, eaque ratione semper est integrum tali possessori id prohibere, nunciare ne fiat, vt rectè affirmat probatque *Ant. Gom. l. 46. tauri. n. 39.* Tametsi sermo hac de re non sit. l. prætor. §. hoc interdictum perpetuò. ff. de noui. oper. nunc. vt videbimus. Neque Ant. Gom. in huius rei confirmationem debuisset eum textum eo loco citare. Quod verò Paulus intendit ac affirmat, est, nunciationem factam ab antiquo possessore eius prædii, morte illius, aut alienatione prædii, ratione cuius eam fecit, expirasse, quia personalis ipsius erat; atque adeò eum, cui illa facta fuerat, si postquam illa ita expirauit, continuet **[[163]]** opus, quod fuerat ei nunciatum, ne efficeret, nō incidere in pœnam, vt teneatur illud demolire, etiamsi ex natura rei iustè illud effecerit: sed, vt in eam pœnam incidat, necessarium esse, vt antequā illud continuaret, nouus possessor eius prædii, ratione cuius nūciatio antiqua facta est, nouam aliam ei efficeret. E contrario verò subiungit ibi Paulus iurisconsultus, esto is, cui nunciatio facta est, ne ædificet in aliquo suo prædio, è vita discedat, vel id prædium alienet, non extinguitur nunciatio, sed trāsit ad hæredem, nouūve aliū eius prædii alio titulo possessorem, ita quòd, si contra nunciationē antecessori factam ædificet, incidat in pœnam interdicti, nempe, quòd id suis sumptibus teneatur demolire, etiam si ex natura ipsa rei sit iure ædificatum. Ratio autem est, quoniam nunciatio facta est rei, ne scilicet in ea id ædificetur: eaque ratione trāsit in quēcunq; illius possessorē. Intellige tamen, possessorē ita ædificantē incidere in eam pœnam, nisi excusetur ignorantia inuincibili talis nunciationis factæ, vt suprā dictum ostēsumq; est: si enim inuincibiliter nūciationē ignorabat, in pœnam non potest incidere, quæ locum habere non potest, nisi vbi est culpa. Cōfirmat verò idem Paulus in fine eius. §. nunciationē non extingui morte eius, cui est facta, aut alienatione prædii, in quo prohibitum est ædificari: quoniam instipulatione, quę interponitur, quòd nunciatus destruet, quod ædificat, si cōpertū fuerit, se iure non ædificasse, vt, nihil nunciatione impediēte, continuare ædificium possit, mentio fit hæredis, astringente scilicet

ad id nunciantē se, suumque hæredem post mortem ipsius. Hoc loco obserua, quòd cum ea stipulatio nihil omnino pænæ contineat, quia nūciatus non se astringit ad demolitionē suis sumptibus eius ædificii, & ad dāna ex eo ædificio nuncianti subsequuta, etiamsi iure sit ædificatum, sed solūm si cōperiat non iure esse ædificatum; vtique, esto in stipulatione nō esset facta mentio hæredis, non minus hæres teneretur ad ea omnia, quàm teneatur facta de eo expressa mentione in stipulatione. Etenim nunciat, vi contractus iusti, tenetur ad ea omnia; quoniam non aliter ei permittitur post nūciationē cōtinuare ædificium, neque æquitas patitur, vt cōtinuare ædificium aliter ei permittatur, quam se ad ea omnia astringendo, ne, si aliter permetteretur, nuncians maneret ex eo ædificio in vero dāno ex natura rei ipsi illato, à quo soluendo meritò se excusaret nūciatus, dicens, bona fide, ex ignorantiaq; inuincibili, quòd iniustè illud daret, se ædificasse, ac proinde ad illud, secluso eo pacto, nō teneri, quia neque ex parte rei acceptę neque, ex parte iniustæ acceptionis, ad illud teneretur: quādo autem aliquis ex pacto iusto, omninoque rationabiliter facto, ad aliquid tenetur, vtique obligatio illa ad hæredes trāsīt, vt ex bonis defuncti illud, defūcti loco, soluāt: neque, quando in stipulatione nūciatus se, suūq; hæredem post mortem suam, expressè ad illa obligauit, aliter hères tenetur ea soluere, quam ex defuncti bonis, ac iuxta vires hæreditatis: quo fit, vt hæres eodem modo teneatur ea soluere, siue nunciat expressè de hærede mentionē fecerit in stipulatione, suāve promissione, qua se ad ea omnia dāna resarcienda, si cōperiretur non iure ædificasse, obligauit, siue nullam de illo in ea stipulatione ac promissione mētionē fecerit.

Nūc exponenda est. l. prætor. § hoc interdictū perpetuò, ostendēdumq; est, doctrinam, quam ibi Vlpianus tradit, nihil pugnare cum doctrina Pauli. §. vlt. citato tradita, à nobisque hucusq; explicata. Id quod vel ex eo est satis perspicuum, quòd Paulus loquutus est de prima parte interdicti, quæ prohibitoria est, sermoque illi est de nūciatione facta, ne ædificetur, & obiter in cōfirmationē secūdæ partis doctrinæ, quam ibi tradiderat, mentionem fecit de stipulatione ac promissione, quæ interuenire solet, vt, nihil impediēte nūciatione, fas sit ædificare: Vlpianus verò loquitur de secunda parte eiusdē interdicti, quæ est restitutoria, vt ex principio, totoque decursu eius legis, usque ad eū. §. cōstat. Nempe de eo interdicto quatenus præcipit, vt, quod ædificatum fuerit post nūciationē factam, & ante eam remissam, sumptibus ædificantis destruat, de actionēve, tam actiua, quàm passiuā, quæ ex eo interdicto competit. Ait verò, *hoc interdictum actiōve*, quæ ex eo interdicto competit, vt ædificantis sumptibus demoliat; quod post nūciationē, & ante illius remissionē, est ædificatū, *perpetuò datur*, id est, triginta annis à tēpore, quo ita ædificatum est, vt ibi glossa exponit iuxta id, quod habetur inst. de perpetuis actionib. *Et heredi ceterisque successoribus cōpetit*. Id est, competit, non solum ei nūciāti, qui erat tempore, quo ædificatū est (si enim mortuus fuisset tempore, quo ædificatū est, aut iam tunc alienasset prædium, ratione cuius nūciauerat, expirasset vtique nūciatio ab eo facta, vt Paulus. §. vlt. paulo antea à nobis exposito docuit, neq; illi, hæredibus, successorib;ve aliis in eo prædio, actio ex secunda parte interdicti cōpeteret, nisi illi, antequam esset ædificatum, nouam feeissent nūciationē) sed etiam competit postea hæredibus, aliisve successoribus in eo prædio, qui fuerint intra eos triginta annos. *Aduersus ipsum quoque, qui id opus fecit, vel factū* (nomine ipsius) *ratū habuit, interdicto* (hoc est, actioni ex illo) *locus erit. Planè si quæretur, an in hæredem eius, qui opus fecit, interdictū hoc* (hoc est, actio ex hoc interdicto, vt demoliat, quod à defūcto fuit contra nūciationē ædificatū) *cōpetat; sciēdū est Labeonē existimasse in id, quod ad eum peruenit, dumtaxat dari oportere: vel si quid dolo malo ipsius factum sit quominus perueniret. Quæ omnia meritò exponit glossa, dari quoad hanc actionē aduersus hæredem, solum vt patiat, id demoliri, non verò vt sumptibus, etiam*

bonorum defūcti, demoliatur. Quo loco obserua, sermonē non esle de aliis successoribus in eo prædio ante mortem defūcti, qui id opus fecit. Cum enim ibi sit sermo de demolitione in pœnam eius, quod ita ædificatum est, quando ex natura rei ritè fuit ædificatum, pœnaque expirauerit morte defuncti, quando bis circa eam cōtestata non fuerat cum eo dum viueret, solum ex quadā æquitate fuit sancitum, vt succedēs per vltimam voluntatem defuncto in eo prædio, pati teneretur id demoliri, non camen sumptibus suis, aut defūcti: quando autem lis circa eam pœnam contestata fuisset cum defūcto dum adhuc viueret, tunc sumptibus bonorū defuncti cogeretur hēres illud demolire, vt hęc ōnia suprā. §. nūciatio noui operis vt rē, &c. copiosè explanata sūt. His ita explicatis circapriora verba formæ stipulationis ptopositæ regrediamur ad reliqua eiusdem formæ explananda.

Quòd nunciatus astringere se debeat, demoliturū se, restitutorūmve in pristinum statum suis sumptibus, quod post nunciationē ædificauerit, si compertum fuerit, non iure esse ædificatum, ex dictis hactenus in antecedentibus constat, & habetur. l. vnica in sine. C. de noui oper. nūc. & l. stipula-[[164]]tio. §. habet. ff. de noui oper. nunc. Quia verò hęc stipulatio, qua nunciatus ad hęc, & ad sequentia, astringitur, eam habet conditionem, si compertum fuerit, non esse iure ædificatum, tunc sanè demum committitur ea stipulatio, compellīve potest nunciatus ea implere, ad quæ tali stipulatione se astrinxit, quando impleta fuerit conditio, quòd scilicet compertum sit non iure se ædificasse: comperitur verò non iure ædificasse, quando, agente altero eorum confessoria, aut negatoria contraria, vel rei vendicatione, iudex vltima sententia definitiua pronunciat, non iure esse ædificatū: quare præcedere debet hoc prius iudicium antequam ex stipulatione illa agi possit, vt nunciatus ea adimpleat, ad quæ tali stipulatione se astrinxit. Atque hoc est, quod habetur §. habet citato.

Quòd verò nunciatus astringere se etiam debeat, soluturum se totum damnum, quod inde fuerit sequutum, confirmat glossa citata ex. l. qui bona. §. si quis opus. ff. de damn. infect. vbi habetur, eum, qui nouum opus nunciauit, posse etiam simul petere, caueri sibi de damno infecto: vnde damnum etiam, si quod id ædificium intulerit, tenetur soluere. Ibi tamen solūm est sermo de damno infecto, quod resarciendum non esset, nisi cautio de illo esset petita, vt ex dictis Disp. 703 liquet. In re autem proposita, non solūm argumento eius textus, sed etiam ex ipsamet rei natura constat, æquum non esse, vt nunciatio de opere aliquo, tanquam quod iniustè, & cū præiudicio, iniuriaque alterius fiat, permittatur illud ante nunciationē remissam efficere, quin potiùs caueat, non solūm de illo suis sumptibus reducendo ad pristinum statum, si comperiatur iniustè factum, sed etiam, vt resarciat quæcunque damna, quæ ex continuatione eius operis nuncianti fuerint sequuta, etiam si non sint ex ruina eius ædificii; quod tamen solūm damnum est, de quo in titulo de damno infecto est sermo.

Quòd verò continere etiam debeat stipulatio, quòd si per nunciatum steterit, quominus pronunciatur sententia, vel quia ad partes suas defendendas in priori illo iudicio explicato non accesserit, vel quia, si dolo impedierit, ne sententia pronunciatur, teneatur ad ea omnia, habetur §. habet, citato, & §. siue autem, iuncta. l. si priùs. ff. eod. titu.

Denique, quòd stipulatio continere etiam debeat, vt soluat æstimationem, si nuncians ita maluerit, habetur eadem l. stipulatio. §. siue autem, & §. idem dicit, iuncta. l. ex operis, & glos. vlt. ibi. ff. de noui oper. nunc.

Eadem. l. stipulatio. §. opus, habetur, ad effectum, [sect. 41] vt nunciatus cogi possit destruere ædificatum, si postea comperiatur non iure fuisse ædificatum, non satis esse, si nunciatus apposuerit cæmentum aliquod, intellige, quando id cæmentum nullum detrimentum affert nuncianti: secus autem, si prudentis arbitrio detrimentum aliquod ei afferret.

Si pluribus ædificantibus nuncietur opus nouum [sect. 42] uum, omnes cauere debent prædicto modo, interposita uidelicet stipulatione explicata. Si uero plures opus nouum nuncient, debet omnibus prædicto etiam modo cauere, aut vni loco omnium, si in eo cæteri conueniant, alioquin singulis cauere eo modo debet. Atque stipulatio tunc concepta simpliciter ad interesse de interesse omnium intelligitur. *Ita habetur. l. stipulatio citata. §. ult.*

Quando alicui nunciatum est opus nouum, (siue in præsentia nunciati, intelligas, siue in absentia opificibus, aut alicui alteri partes domini ædificii agentis) si quis nomine illius remissionem nunciationis petat, offerendo cautionem, quod si non iure compertum fuerit esse ædificatum, destruat ædificium, & damna soluentur, modo supra explicato, tunc non debet cauere, quod ratum hoc habebit is, cuius est opus, & cuius nomine remissionem nunciationis petit, sed quod ipse ea omnia præstabit, quando dominus ædificii, cuius nomine ipse remissionem nunciationis petit, eam non præstiterit. *Ita habetur. l. de pupillo. §. qui remissionem ff. de noui oper. nunc.*

Quando aliquis nomine alterius, tanquam il [sect. 43] lius procurator, nouum opus alicui nunciauit, si ita nunciatus satisdedit, & procurator ille ulterius progrediatur impedire continuationem ædificii, competit tunc nunciato aduersus eum tertia pars interdicti, de qua statim erit nobis sermo, qua agit aduersus eum, ut post satisfactionem datam, aut oblatam, neque acceptatam ab aduersario, non impediat continuationem operis: in qua parte iudicii, procurator ille impediens, sustinet partes rei, & nunciatus habere incipit partes actoris: tunc autem, si procurator desistere omnino non velit, sed velit iudicio contendere, non iure ædificare, cogitur satisfacere, non quidem, quod ille, cuius partes agit, ratum id habebit, sed quod ipse procurator iudicatum soluet: alioquin non solum à prohibitione continuationis ædificii semouetur, sed etiam semouetur à iudicio cõtendendi ac probandi, absque iure nunciatum ædificare. Tutor tamen, aut curator, qui minorum nomine rectè opus nouum nunciant, non ita semouebuntur, aut cogentur ipsosmet cauere, se ex suo proprio marsupio, de bonisve propriis, iudicatum soluturos. Hæc sunt, quæ haberi videntur. *l. de pupillo citata. §. ult. & duabus legibus sequentibus.*

Tertia pars interdicti de noui operis nuncia [sect. 44] tione prohibitoria est, atque in hunc modum habet. Si, post nunciationem noui operis alicui factam, is sufficienter, modo hactenus explicato, satisdedit, se demoliturum suis sumptibus ædificium, restitutumque damna, aut soluturum quantum hæc omnia æstimabuntur, si cõperiatur non iure esse ædificatum, aut post eiusmodi satisfactionem oblatam, stante pernunciatæ quod accipiat, nuncians prohibeat adhuc id opus fieri, aut continuari, tunc ei à prætore interdicitur ac cohibetur, ne fieri, aut continuari, prohibeat, vel impediat. Atque hoc ita sancitū prouisumque est in fauorem ædificiorum, splendoremque urbium: habetque locum, siue qui ita cauet, cautionemve offert, iure re ipsa prosequatur tale ædificium, siue non: id enim in præiudicium nunciantis non cedit, cum sit ei sufficienter cautum, aut per ipsum stet, quominus sit ei sufficienter cautum, si cautionem accipere nō velit. Hæc tamen tertia pars interdicti, locum non habet in eo, cui nunciatum sit, ne in loco publico ædificet: esto enim re promittat, se illud suis sumptibus demoliturum, ac soluturum damna, aut interesse, prohiberi nihilominus adhuc impunè potest, ne efficiat, aut continuet, tale ædificium, nisi prius ostendat, quo iure ibi ædificet. Item, si [[165]] is, cui nunciatum fuit, ne ædificaret in loco priuato, satisdedit sufficienter, attamen vsque ad certum tempus, tunc quamuis intra id tempus impediri non possit, prosequi id ædificium, sed locum habeat tertia interdicti pars, de qua agimus, elapso tamen eo tempore, locum non habet, sed impediri impunè potest continuare

edificiū. Hocverò intelligo de eo, qui satisdedit, se demoliturum, quod intra certum tempus ædificaret, si postea comperiretur, non iure esse ædificatum, ita quòd limitatio temporis satisfactionis fuit quoad id, quod intra id tempus ædificaret, non verò, quòd si id ultra id tempus comperiretur non iure ædificatū, non esset elapso eo tempore demoliendū. Item, esto eadem tertia pars interdicti competat nunciato aduersus nunciantem, ne nunciatum impediatur continuare ædificium eo ipso, quòd nunciatum obtulit competentem satisfactionem, & per nunciantē stetit, qui noluit eam recipere; nihilominus, quocunque tempore nuncians velit eam recipere interim, dum continuatur ædificium, & nondum est absolutum, si per nunciatum stet, qui illam tunc non det, potest nuncians eam deinceps impunè prohibere, ne ædificium ulterius continuet, nisi prius satisfaciat, aut aliter remissio nunciationis ei fiat, alioquin incidit in pœnam, vt quicquid deinceps ædificauerit, id sumptibus nunciati demolitur, esto iure sit re ipsa ædificatū. Hæc tertia interdicti pars non competit perpetuò, sed intra annum à puncto inquietationis post satisfactionē præstitam, aut oblatam, nec receptam à nunciante, competitque intra eum annum vt agi ex ea parte aduersus nunciatum possit, tam nunciato, quàm hæredibus illius. *Hæc omnia habentur. l. prætor. § deinde, & reliquis sequentibus usque ad finem eius legis. ff. de noui oper. nunc.* Atque hæc quod attinet ad iura digestorum. Postea verò de iure Codicis, *l. unica de noui [sect. 45] oper. nunc. (aliàs. l. ult. C. de edificiis priuatis) c. penul. & apertiùs. c. ult. de noui oper. nunc. ac. l. 9. titu. 32. part. 3.* quamuis nihil innouatum est, quādo remissio nunciationis facta est per nunciantem, aut per iudicem, itemque quando cautio oblata est à nunciato, & recepta est à nunciante; quando tamen cautio offertur à nunciato, nec recipitur à nunciante, sancitum est, vt, si nunciās dicat, se velle probare id ædificium non iure fieri, esto nunciatum cautionem offerat, quam nuncians recipere non velit, nunciatum non possit progredi in ædificio, aliquin incurrat pœnam, vt, si quid post oblatam eam cautionem ædificauerit, teneatur illud suis sumptibus demolire, esto iure re ipsa sit ædificatum, ac proinde non statim censetur iam hodie per eam cautionem oblatam remissa nunciatio, sed conceduntur tres menses nuncianti, computati, non quidem à puncto nunciationis, quantumcunque longè antea præcesserit, sed à puncto oblatæ cautionis per nunciatum, intra quos probare possit ædificium non iure fieri, finireque debeat lis. Quòd si lis intra eos tres menses non sit finita, vel quia lata nondum est sententia, esto nunciatum exceptiones aliquas opposuerit contra nunciantem, quibus retardata sit, vel quia est lata contra nunciantem, sed nuncians ab ea appellauit, tunc oblata cautione per nunciatum, censetur ei remissa nunciatio ad effectum, vt continuare ædificium possit sub ea sua cautione ac obligatione, quòd si tandem fuerit per vltimam sententiam pronunciatum, non iure esse ædificatum, illud suis sumptibus destruet, & soluet damna, &c. vt circa stipulationem eiusmodi cautionis paulo antea explanatum est. Neque in re proposita locum habet dispositio illa iuris, quòd appellatione pendente nihil innouetur, ad effectum, vt nunciatum, elapsis tribus mensibus à puncto, quo obtulit primam cautionem, nec nuncians voluit eam recipere, possit continuare suum opus, præstita iterum eadem cautione, quando sententia in prima instantia lata fuit pro nunciato, & ab ea nuncians appellauit; quoniam tunc nunciatum ædificat legis autoritate, quæ statuit, vt quacunque ratione finita non sit lis intra eos tres menses, possit nunciatum ædificare præstita ea cautione, quare sicut si in prima instantia lata non esset sententia, intra eos tres menses posset, lite pendente, legis autoritate continuare ædificium illud præstita ea cautione, nihil impediante, quòd nuncians ab ea appellauerit sententia, ita longè maiori cum ratione, si lata in fauorem ipsius sit sententia, potest eadem legis autoritate continuare ædificium præstita cautione, nihil impediante, quòd nuncians

ab ea appellauerit sententia. Quando autem in prima instantia lata intra prædictos tres menses esset sententia aduersus nunciatum, tunc nefas esset illi continuare ædificium, esto cautionem offerret, sed expectare deberet vltimam definitiuam sententiam. Ait verò Ant. Gom. cum aliis, quos citat, ea ratione de iure Codicis concessos fuisse illos tres menses, intra quos, esto nunciatum offerret cautionem, non posset ædificare, si nuncians non vellet eam recipere, vt vtrique consuleretur. Nunciato quidem, ne, si nullo tempore priùs dato ad causæ discussionem, statim oblata cautione posset ædificare, damnum sustineret demolitionis ædificii, ac solutionis damnorum insuper subsequutorum, si postea comperiretur non iure fuisse ædificatum: nuncianti verò, quoniam non nihil iniuriæ illi videbatur fieri permittendo nunciato continuare ædificium in ipsius præiudicium, statim ac offerret cautionem, non dato sibi aliquo competenti tempore, in quo ius suum posset probare, & ostendere, quale ac quantum esset, vt vel intra id tempus ferretur sententia, vel certè cognito intra id tempus iure ipsius aliqua ex parte ex probationibus, nunciatum se contineret à cautione præstanda, & à continuando sub illa ædificio. Communis doctorum sententia, quam Ant. Gom. refert ac sequitur, affirmat, si nuncians, qui recipere non vult primam cautionem, quam ei nunciatum offert, non dicat se velle probare suum ius, ad idque se paratum ostendat, audiendum non esse, sed statim censendam esse remissam nunciationem ad effectum, vt sub ea cautione nunciatum possit statim, non expectatis tribus illis mensibus, continuare suum ædificium: quia tunc credendum est, nunciantem ex sola sua malitia velle impedire ædificium, atque id satis innuitur. c. vlt. de noui oper. nunc. estque ea opinio rationi ac æquitati valde consentanea. Quando tamen nuncians se ostenderet paratum ad probandum suum ius, saltem quia affirmat se velle illud probare, arbitror expectandos [[166]] esse eos tres menses, esto nihil intra eos probet. Hæc iuxta iura citata, eaque iura ex parte exponendo, affirmant doctores, quos referunt ac sequuntur *Ant. Go. l. 46. tauri. n. 34. & Greg. Lopez. l. 9. citata*, tametsi neuter eorum ea omnia affirmet. Vtrum autem, si sententia aduersus nunciantem feratur, possit nunciatum agere aduersus nunciantem, vt sibi ea soluat damna, quæ verè sit passus ex eo, quòd ea nunciatione ædificium sit retardatum, sitque nuncians ad ea soluenda condemnandus. *Ant. Gom. vbi supra. n. 35. refert. Bart.* communemque doctorum sententiam affirmatè respondere, agendumque esse ad ea damna actione de dolo, argumento. l. rem quandam. ff. de dolo. Placet tamen cum eodem Ant. Gom. & Rainero, quem citat, dicamus, id verum esse, quòd cōiecturæ apertæ fuerint, id dolo secisse, causa impediendi ædificium, atque id solum probat lex citata: secus verò rem habere, quando nulla est doli præsumptio, sed id fecisse apparet causa experiendi ius suum, de quo probabilitatem haberet. Quando apertè constaret, nunciantem nullum habere ius impediendi ædificium, vel quia causam apertè nullam afferret, vel quia aliunde apertè constaret, eum nullum habere ius, tunc, etiam post iura Codicis, contemnenda est nunciatio, atque permittendum est continuari ædificium, etiam nulla præstita cautione, vt suprà cum Bart. Panor. Greg. Lopez, Ant. Gom. & communi doctorum sententia est dictum. Lege apud Ant. Gom. vbi suprà à. n. 36. longam hac de re disputationem, vbi multa refert, vnde intelligi apertè possit, nunciatum nullum habere ius ad impediendum ædificium, & vbi rectè ait, nunciatum petere coram iudice posse, vt causam proferat, cur nunciet, aut nunciauerit, & ob quam prætendat non iure ædificari: quòd si vel nullam proferre velit, vel proferat causam apertè nullam, tunc contemnendam esse nunciationem, permittendumque esse continuari ædificium, etiam nulla præstita cautione. Addo, & condemnandum tunc esse ad expensas litis, & ad damna omnia ex nunciatione, & ex impeditioe operis, illucque sequuta.

Postremò circa secundam partem interdicti de [sect. 46] noui operis nunciatione est obseruandum. Quotiescunque id interdictum competit, vt sumptibus ædificantis demoliatur, quod ædificatum est, eo quòd post nunciationē noui operts, & ante illius remissionē aliquo ex modis hactenus explicatis sit ædificatum, competere etiam interdictum quod vi aut clàm, vt similiter demoliatur sumptibus ædificantis, & vt soluat damna subsequu:a: quoniam eo ipso, quòd contra eam nunciationem, seu prohibitionem, nondum remissam, est factum, censetur factum vi, vt in principio huius disputationis, dum de interdicto quod vi aut clàm erat nobis sermo, explanatum comprobatumque à nobis est, ac proinde competit id interdictum quoad illam partem, quod vi. Quòd autem semper, quando competit secunda pars interdicti noui operis nunciationis, competat etiam interdictum quod vi aut clàm, *habetur expressè. l. prætor. §. nulli. ff. de noui oper. nunc. & constat ex. l. 1. §. quid sit vi, & ex. l. si alius. §. ait Iulianus. ff. quod vi aut clam. verba. §. ait Iulianus*, hæc sunt: *Qui ante remissionem nunciationis contra, quam prohibitus fuerit, opus fecerit, duobus interdictis tenebitur. Vno, quod ex operis noui nunciatione: altero, quod vi aut clam.* Idem constat ex aliis iuribus citandis. Multo verò latius competit interdictum quod vi aut clàm, vt sumptibus ædificantis destruat, quod ædificatum est, & vt soluat damna subsequuta, quàm competat secunda pars interdicti de noui operis nūciatione. In primis enim, si quis impedimento sit, ne ipsi nouum opus nuncietur, modis, quibus suprà, dum de interdicto quod vi aut clàm erat nobis sermo, explicatum est, censi vi ædificasse, competit interdictum quod vi aut clàm: non verò secunda pars interdicti de noui operis nunciatione, eo quòd nulla talis præcesserit nūciatio. *Deinde supra. §. atque in hoc, §. vtrum autē. §. dixi, eum eisi. §. inquilinus. §. quando vnus*, traditi sunt multi alii euētus, in quibus non habet locum interdictum de noui operis nunciatione, cū tamen in eisdem euentibus locum habeat interdictum quod vi aut clàm, vt ibidem comprobatum est, & cum aliis affirmat *Ant. Gom. l. 36. tauri. n. 22.* Obserua autem interdictum quod vi aut clàm, non cōpetere triginta annos à puncto operis facti post prohibitionem, sicut competit interdictum de noui operis nunciatione, sed solū per annum à puncto operis effecti, *vt habetur. l. semper. §. hoc interdictum in hæredem. ff. quod vi aut clam, & affirmat Ant. Gom. ubi supra. n. 20. & 21.* Si quis autem alia actione consequatur, quod interest opus non esse factum, agere non potest interdicto quod vi aut clàm, *vt habetur eadem. l. semper. §. ult.* Atque hæc dicta sint de tota hac molesta materia.

De ædificiis, operibúsve, ac immissionibus, in loco sacro, aut publico, & peculiariter in viis publicis, & quæ illæ sint. Disp. 707.

SVMMARIVM.

1. *L*oca sacraquæ. Muros etiam publicos comprehendunt. Quæ prohibita sint fieri aut ædificari in locis sacris, aut in illis coniunctis. Et quo remedio subueniatur. Et quousque hodie vsie hæc seruentur.
2. *L*ocus publicus variè usurpatur, & inter alia, pro loco vsui communi, aut saltem singulorum de populo, deputato.
3. *I*ter, vt est seruitus, & via, vt etiam est seruitus, in quo differant, dicunturque priuata. Via publica & iter publicum non differunt. Si autem via publica lapidibus strata sit, strata

peculiari nomine nuncupatur. Lusitanè verò, corrupto vocabulo, quæcunque via publica strada dicitur.

4 . Via, alia publica, alia priuata, & alia vicinalis. Publica via interdum sumitur pressè, pro ea quã græci basilicam, hoc est regiam, vocant, & Hispanè dicimus camino real, latini prætoriam, consularem, ac militarem eam appellant. Interdum verò sumitur latè pro omni ea, cuius solum publicum est. Via priuata, quæ & agraria nuncupatur, interdum sumitur latè pro omni ea, quæ non est publica primo modo. Quo pacto comprehendit nō solū iter & viam, quæ sunt seruitutes, sed etiam vias alias, quarum solum non est publicum, sed priuatum, & vias quarum solum est publicum, & non sunt viæ regiæ seu prætoriæ. Et quæ viæ dicantur vicinales.

[[167]] 5 . Viæ publicæ quo ad vsum sunt omnibus communes, etiam exteris: quo ad dominium verò sunt supremi principis eius regionis, non recognoscentis superiorem. Idem de plateis, fluminibus publicis, & de aliis similibus rebus.

6 . Loca publica particularium oppidorum, deputata vsibus eorum, qui sunt de eo oppido, aut aliquorum, vel ad sumptus communitatis, propria sunt quoad dominium eius oppidi: licet supremi principis administrationi subjaceant, quatenus id postulat commune reipublicæ bonum.

7 . Loca ea publica, quæ quoad dominium ad supremum principem spectant, vt vias publicas, plateas, &c. esto ab oppidis factæ sint publicæ ex rebus priuatis, alienare aut conuertere in aliud non possunt validè oppida, aut rectores eorum, absque principis facultate.

8 . Loca publica, quæ quoad dominium ad supremum principem spectant, præscribi vllō tempore non possunt. Tempore tamen de cuius initio non extaret memoria, censerentur eius, qui illa obtinuisset: quoniam præsumeretur titulus, legitimæque possessio.

9 . Loco in publico deputato vsui omnium, aut eorum, qui sunt de aliquo populo, si aliquid fiat, aut immittatur, quo interdicto subueniatur.

10 . Ædificia, aut immissa, seu pendentia, in vias publicas, & in alia loca publica, quousque prohibita, & diruenda, aut non reparanda.

11 . Aedificare in mari, aut in littore maris, quousq; liceat.

12 . Loco in publico, vt in mari, qui piscari, aut nauigare prohibet, aut ludere in campo publico, lauari in publico balneo, spectare in publico teatro, competit aduersus eum iniuriarum actio.

13 . Loco in publico, quoad vsum, si aliquid fiat, aut immittatur, quo alius commo ditate ex eo loco sibi proueniente priuetur, competit ei interdictum. Secus si ex eo quòd aliquid fiat in loco priuato, vnde per accidens priuetur commoditate proueniente ex loco publico. Et secus si commoditas per accidens eueniret aliunde per locum publicum.

14 . Loco in publico si quis prius ita illicitè ædificauit, vt aduersus eum interdictum competeret, si alter similiter ædificet in loco publico cum præiudicio prioris, denegatur priori interdictum ob similem suam culpam præteritam.

15 . Loco in publico quod ædificatum est, nemine cōtradicante, quando non sit destruendum, sed imponendum sit salarium ob publicum solum: quādo verò sit destruendum. Et quando iubendum vt non reparetur, si corruat. Item quando vendicari possit, quod ædificatum est, etiam in bono communitatis, aliis quo ad vsum non deputato.

16 . Via in publica, hoc est, cuius solum est publicum, & quæ est extra oppidum, ne aliquid fiat, aut mittatur, quo deterior ad usum fiat, & ut si factū fuerit, redigatur ad pristinum statum, atque ut usus earum viarum aliis non impediatur, quo interdicto sit subuentum.

17 . Via in publica quousque prohibitum sit facere scalas domibus adhærentes, quibus ad domus ascendatur.

18 . Via in publica oppidi quousque fieri possit, aut non possit, canalis, aut aquarelus.

19 . Via vicinalis inter aliquas domus, quando publica quo ad solum, ita ut claudi non possit, nec impedi aliis transitus: & quando priuata, ut claudi ac impedi transitus possit. Et quando ad vtrunque vicinum, & quando ad vnum tantum pertineat.

20 . Vias circa publicas quid ædilibus esset iniunctum ut curarent. Et quatenus seruari ac cuari debeat.

21 . Reficere viam publicam nullus prohiberi impunè potest.

22 . Viam immittens per agrum alienum, ad damnum datum tenetur, & vendicatur ea agri pars.

Consequenter, quod est propositum, erit examinandum, quatenus inde damnum, præiudiciūve, obuenerit potest, communi bono.

Quod ad rem præsentem attinet, loca sacra hodie dicuntur, quæ autoritate summi Pontificis, aut Episcopi, Deo dicata sunt, ut sunt Ecclesiæ, capellæ Episcopi autoritate Deo dicatæ, & cæmeteria. *Id constat inst. de rer. diu. §. nullius, & §. sacræ. l. in tantum. §. sacræ, & l. sacræ, ff. eod. titu. iunctis gloss. in eisdem locis.* Quondam autem, ante legem gratiæ, cū Reges ac Imperatores sacerdotes essent, res Deo ipsi etiam dicabant, sacrasque efficiebant. Quod ad rem etiam præsentem attinet, muri & portæ, nō solū Romanæ ciuitatis, sed etiam aliarum ciuitatum ac oppidorum, loca sancta dicuntur, ad interdictumque, de quo nobis hoc loco est sermo, spectant, *ut constat inst. de rer. diuis. §. sancta quoque, & §. ideo autem, & sacræ. §. muros, & l. vlt. ff. eod. titu. & l. 2. & 3. ff. nequid in loco sacro, consentit. l. 6. titu. 29. part. 3. iuncta glossa. 1. Greg. Lopez. ibi.* In his itaque locis omnibus interdictum est aliquid facere aut immittere. Non tamen est prohibitum in eis efficere, quod ad ornatum & pulchritudinem eorum spectet, sed quod spectet ad detrimentum aliqua ex parte, seu ad deformitatem vel indecentiam eorum, Ita habetur l. 1. 2. & 3. ff. nequid in loco sacro. Quod si aliquid tale in loco sacro factum sit, etiam competit interdictum restitutorium, ut destruat, resque ad pristinum statum redigatur. *Ita habetur. l. 2. §. si quis nemine. vers. locorum sacrorum. ff. nequid in loco pub. Nicolaus papa. c. nulla. 12. q. 1.* sic ait: *Nulla ædificia in atrio Ecclesiæ ponantur, nisi tantum clericorū.* Glossa ibi exponit, in cæmeterio, Dicerē in toto ambitu, quod Ecclesiæ, illius ministerio, ac cæmeterio, est dicatū: hæc enim omnia ad Ecclesiæ atriū attinent. *Lex. 24. iuncta. l. 22. antecedente, tit. 32. part. 3.* sic ait: *Alas iglesias non deuen arrimar casas, ni tiendas, ni fazer otro edificio ninguno. Otro si, porque la iglesia es casa santa de Dios, alrededor della no se deuen fazer tiendas de mercaudurias, nin de otras cosas, si non de aquellas que pertenecen a obras de piedad, è de merced. E si por auentura fuere hi alguna cosa fecha, deue ser ende tollida.* Et l. 22. citata prohibetur, *arrimar casa, o otro edificio, a los muros.* Imò præcipitur, ut inter tale ædificium ac muros, relinquatur spacium quindecim pedum: & idem spacium videtur lex 24. citata intendere, ut relinquatur inter quodcunque aliud ædificium & Ecclesiam. Et vtrumque desumptum est ex. l. si cui, & l. mæniana. l. de ædif. priu. quæ

iura statuunt, id spacium relinquere debere inter quodcunque ædificium priuatum & ædes, ædificiæ publicæ: nomine autem publicorum ædificiorum comprehenduntur Ecclesiæ. *Greg. autem Lopez. l. 22. citata cum Cæpolla ait*, hac in re standum esse consuetudini cuiusque loci; in Hispaniis verò non ea viget hodie [[168]] consuetudo, vt id spacium relinquatur inter priuata ædificia, & Ecclesias, aut muros, vel vt idem paries communis esse non possit Ecclesiæ & domus priuatæ, aut vt multæ domus pro pariete nō habeant murum oppidi, quin potiùs multæ supra murum sunt ædificatæ. *Et. l. Lusitana lib. 1. ord. titu. 49. §. penul. sic habet: E toda pessoa, que teuer campo, ou perdiero, à pardomuro da villa, pode se acostar à elle, è fazer casa sobre elle: por em fica sempre obrigado, se vier guerra, ou cerco, de ha derribar, è dar por ella corredoria, è seruentia. E se omuro, sobre que à si ouuer casa, ou a que se acostare, cabir, aquelle, que à si teuer ha dita casa, sera obrigado à tornar à fazero dito muro à sua custa.* Hæc de loco sacro.

Quod verò ad publicum locum attinet, licet [sect. 2] aliquando latiùs vsurpetur, nempe vt comprehendit etiam loca ad fiscum regis, coronæque regni, attinentia tãquã eius propria, quo pacto sumitur. l. 1. ff. de loco publico fruendo; & aliquando vt comprehendit etiam ædes sacras, loca sacra, vt patet. l. acceptam. C. de usuris, & l. si cui, & l. mæniana. C. de ædif. priu. quin vt cōprehendit etiam res proprias communitatis, quæ non sunt communia singulis de populo quoad vsum, vt horrea publica, carcerem publicum, & similes publicas domus, ac prædia oppidi, ad redditus communitatis oppidi deputata, quæ proinde communitas tanquam propria bona ipsius ea possidet, neque deputata sunt vsui singulorum de populo, atque de cōmemoratis ædificiis publicis sermo sit. l. fi cui, & l. mæniana citatis; & interdum etiam loca publica vsurpentur, vt distinguuntur ab illis, quæ ita gentium iure sunt omnibus communia, vt ad nullius, etiam cōmunitatis, dominium spectent, vt sunt aer communis, aqua profluens, mare, & littus maris, atque vt distinguuntur à locis propriis communitatis, quo pacto flumina, & portus, publica loca dicuntur *inst. dererum diuis. à. §. 1. usque ad. §. vniuersitatis, & l. 2. 4. 5. & 6. ff. eod. titu.* licet, inquam, locus publicus variis his modis explicatis interdum vsurpetur; quod ad rem tamen præsentem attinet, illa loca publica dicuntur, quæ ad publicum vsum singulorum spectant, vt sunt plateæ, viæ publicæ, prædium vsibus singulorum de populo deputatum, & similia alia. *Ita habetur. l. 2. §. publici loci, & §. hoc interdictum. ff. nequid in loco pub.* Vnde quædam loca publica sunt vsui omnium vniuersim deputatæ, vt plateæ, & viæ publicæ, & quædam vsui tantum eorum, qui sunt de populo aliquo, vt sunt prædia deputata pastui animalium singulorum, qui sunt de populo, cuius sunt ea prædia, & similia alia.

Inter loca publica, viæ publicæ, itineraque [sect. 3] publica, quod ad rem præsentem attinet, ac simpliciter loquendo, computantur. Iter verò, si loquamur de priuato, vt est seruitus, minus cōtinet, quàm via, si de priuata etiam, atque vt est seruitus, loquamur, vt patet. *inst. de seruit. rust. præd. in prin.* Idem proportionem quadam vult esse de itinere & via publica *glossa. l. 2. §. ait prætor, verb. in via publica itineréve. ff. nequid in loco pub.* Existimo tamen pro eodem vsurpari viam & iter publicum, solumque discrimen illud intelligendum esse, quando ea nomina seruitutes significant; non verò quando significant viam ipsam ac iter, quo pergitur: tunc enim synonyma sunt. Via autem, si lapidibus sit strata, peculiari nomine nuncupatur strata, *iuxta. l. 1. ff. de via pub. reficiend. & affirmat Cæpolla de seruit. rust. præd. c. 3. n. 3.* Hodie tamen Lusitani, corrupto vocabulo latino, quancunque viam publicam, seu regiam, *stræda* vocant.

Sumpta autem via, vt est idem, quod iter, quo [sect. 4] gradimur, diuiditur, seu potius distinguitur. *l. 2. citata. §. ait prætor, etiam citato, & §. viarum, iuncta. l. ult. ff. de locis & itineribus publicis, in publicam, & priuatam, ac vicinalem.* Publica via duobus modis sumitur. Vno, pressè, pro ea via publica, quam græci basilicam, hoc est regiam, vocant, & eodem modo hispanè eam *camino real* appellant; latini verò eam prætoriam, consularem, ac militarem viam appellant, vt à græcis, & à latinis, prædictis nominibus appellari, *habetur. l. 2. §. viarum. ff. nequid in loco pub. iuncta. l. ult. ff. de locis & itiner. pub.* Priuata via, quæ & agraria nuncupatur, eo quòd in prædiis rusticis agrisve concedi soleat, aut per similia prædia & agros, in quibus sita est, ducere soleat ad villas, & alias colonias, seu agriculturas, duobus etiam modis vsurpatur. Vno, latè, vt distinguitur à via publica pressè sumpta, pauloque antea explanata. Quo pacto sumpta, in primis comprehendit vias, quarum solum non est publicum, sed alicuius, aut aliquorum priuatorum. Tales sunt viæ per agrum alienum, quibus solum habent ius vtendi, qui habent seruitutem itineris, actus, aut viæ, per eum agrum ad aliquem locum, aut prædium, quarum proinde viarum solum pertinet, quoad dominium, ad dominum duntaxat agri, in quo est aliqua ex eiusmodi seruitutibus, & tantum quoad vsum spectant ad eum, aut ad eos, qui in eo agro aliquam ex prædictis habent seruitutem. Atque de eiusmodi via, seu itinere, sermo est. *ff. de itinere actuque priuato: de qua re inferius peculiarem texemus disputationem.* Tales etiam sunt viæ, quæ ex prædiis priuatorum factæ sunt, nullique earum vsus denegatur: si autem de illarum initio extet memoria, (adde, neque titulo donationis, aut venditionis, vel alio gratuito, aut oneroso, vt legati, aut permutationis, solum earum sit concessum vt sit publicum, neque à republica sit vsurpatum, vt sit commune; quod tamen facere non posset communitas, nisi facta priuatis debita compensatione) vtique solum earum publicum non est, sed pertinet quoad dominium ad priuatos, quorum sunt ea prædia, poteruntque proinde destruere talem viam, impedireque; cæteris vsum illius, quandocunque eis placuerit: eo quòd de suo, interim dum alii non habent seruitutem comparatam, neque transitus per eum locum est cuiquam concessus tanquam ei debitus, sed permissus quasi precario, dum ipse etiam eo vult vti, nec ad aliud vult conuertere suum prædium, vtique facere potest, quod voluerit. *Concinit. l. 1. §. summa cum vtilitate. ff. de his quæ diuer.* Vnde constat, fieri posse, vt locus aliquis sit priuatus, & nihilominus sit per eum via frequens, transitusque per eum multorum. Deinde via priuata eodem modo sumpta, comprehendit vias, quæ non sunt regiæ, seu consulares, prætoriæ, ac militares, & tamen earum solum est publicum: quia licet constet, solum desumptum fuisse ex prædiis, quæ tales viæ intersecant, aut secus quæ prædiatales viæ sunt, de **[[169]]** initio tamen non extat memoria, eoque ipso solum aërem publicum esse censetur, & non dominorum, quorum sunt ea prædia. Adde tu, publicum etiam esse, esto de initio earum viarum extet memoria, si constet vsurpatum esse à republica, vt in viam inseruiret, facta compensatione, aut si à priuatis ad id solum illud fuisset condonatum, aut traditum titulo venditionis, aut alio oneroso, vt ex se satis est perspicuum. Eiusmodi autem viæ, quæ regiæ, consulares, prætoriæ, ac militares non sunt, ac proinde nec viæ sunt publicæ pressè sumpto vocabulo in priori illa acceptione, de qua suprà loquuti sumus; sunt tamen viæ publicæ sumpto latius ac propriè vocabulo, prout via publica ea dicitur, cuius solum est publicum, & cuius vsus ad omnes spectat, qui ea vti voluerint. *Atque id affirmat Vlpianus. l. ult. ff. de locis & itinerib. pub. & l. 2. §. viarum. vers. priuatæ viæ dupliciter. ff. nequid in loco pub.* Quo fit, vt via priuata duplex sit, vt Vlpianus versiculo citato rectè ait. Vna, cuius solum ad dominum prædii attinet, in quo sita est, aut ad dominos prædiorum, secus quæ est confecta, quæ proinde non solum à via publica pressè sumpta, sed etià à

via publica latè sumpta distinguitur. Altera, cuius solum publicum est, & est via priuata, vt distinguitur à via publica pressè sumpta, sed verè est via publica, comprehenditurque proinde sub via publica latè sumpta. Atque de via publica latè sumpta, vt comprehendit non tantùm regales, prætoria, consulares, seu militares, sed omnes vniuersim, quarum solum est publicum, vsusque communis omnibus, distinguiturque à priuata pressè sumpta, *sic dixerat Vlpianus. l. 2. §. ait prætor. ff. nequid in loco pub. Viam publicam eam dicimus, cuius etiam solum publicum est. Non enim sicuti in priuata via, ita & in publica accipimus. Viæ priuatae solum alienum est; ius tantùm eundi & agendi nobis competit. Viæ autem publicæ solum publicum est, relictum ad directum, certis finibus latitudinis, &c.* Vicinales viæ, vt constat ex. §. viarū. vers. vicinales, & ex. l. vlt. citatis, sunt illæ, quæ neque publicæ sunt in prima acceptione viæ publicæ, prout solæ viæ regiæ, consulares, prætoriæ, seu militares, publicæ dicuntur, neque item sunt ita priuatæ, vt transitus per illas solùm cōpetat habentibus seruitutem per tales vias: vnde vicinales viæ solùm sunt reliquæ priuatæ viæ, in acceptione viæ priuatæ latè sumptæ. Quia ergo neque sunt viæ publicæ, in prima ac pressa acceptione viæ publicæ, neque itē sunt ōnes viæ priuatæ, in acceptione viæ priuatæ latè sumptæ, imò neque sunt ōnes, aut solæ, viæ priuatæ, in acceptione viæ priuatæ pressè sūptæ, sed cōprehēdūt solas ōnes priuatas, pressè sumptas, quæ seruitutes non sunt, & insuper vias publicas, quæ non sunt regiæ, seu consulares, prætoriæ, ac militares, idcirco Vlpianus vicinales vias distinxit à publicis, hoc est, regiis, & à priuatis. Dicuntur verò vicinales, quia regulariter in vicis sunt, aut ad vicos (rusticos intellige) ducunt, vt Vlpianus. §. vicinales citato ait. In villas etiam, aliasque colonias, seu agriculturas, ducere, inferiūs etiam in eodem. §. affirmat. Lege autem vltima. ff. de locis & itinerib. pub, sic Vlpianus ait: *Inter vicinales & vias militares hoc interest, quòd viæ militares exitum ad mare, aut in vrbes, aut in flumina publica, aut ad aliam viam militarem habent: harum autem vicinalium viarum dissimilis conditio est: nam pars earum in militares vias exitum habent, pars sine vllò exitu interimuntur.* terminatæ videlicet ad var ia prædia, aut vicos, viculósve, aut villas. &. l. 2. §. viarum, vers. vel quæ. ff. nequid in loco pub. de eisdem viis, sic ait: *Ad agros ducunt, per quas omnibus permeare liceat: in quas exitur de via consulari, & sic post illam excipit via vel iter vel actus ad villam ducens. Has ergo, quæ post consilarem excipiunt in villas vel in alias colonias ducentes, putem etiam ipsas publicas esse.* Intellige, quando solum non est priuatorum, quia de initio earum non constat, vt. l. vlt. ff. de locis & itinerib. pub. dixerat. Ad hæc sunt admetiendæ, quæ Cæpolla de seruit. rust. c. 3. a. 16. tradit, in quibus, & inuolutè loquitur, & nonnihil ab hac doctrina, & à iuribus citatis, discrepat. Dubium est, cuiusnam sint viæ publicæ. Ad hoc [sect. 5] dicendum est. Quoad vsum, esse singulorum priuatorum: quoad dominium verò, esse supremi principis eius loci, non recognoscentis superiorem: quod similiter intelligēdum est de plateis, fluminibus publicis, & de aliis similibus rebus, quæ omnibus vniuersim sunt communes quoad vsum. Quod autem quoad vsum sint omnibus priuatis communes, constat ex. l. 2. in prin. ff. nequid in loco pub. Vbi de omnibus locis publicis, quæ ad id interdictum pertinent, vt sunt, non solùm quæ ad vsum omnium vniuersim pertinent, sed etiam, quæ propria sunt alicuius oppidi, deputata vsibus omnium, qui sunt de eo oppido, vt est prædium communitatis alicuius oppidi, deputatum ad pastum pecorum eorum omnium, qui sunt de eodem oppido, vt est silua cædua propria alicuius oppidi, deputata vsibus cædendi ligna necessaria omnibus, qui sunt de eodem oppido: vbi, inquam, de omnibus his locis sic dicitur: *Loca enim publica utique priuatorum vsibus deseruiunt: iure scilicet ciuitatis, non quasi propria cuiusq.* Quo in loco verba illa, *iure ciuitatis*; exponit glossa, cuiuscunque, vel Romanæ, vel aliarum, quia scilicet multa

sunt loca publica ex his, de quibus ibi est sermo, quæ propria sunt ciuitatum, seu oppidorum particularium, atque ab eis sunt facta publica, deputata videlicet vsibus singulorum, qui sunt de eo oppido, qui proinde non vtuntur eis bonis tanquam propriis cuiusque eorum, sed tãquam propria sui oppidi, atque adeò iure & concessione sui oppidi aut ciuitatis. Aliter exponit etiam eadem glossa verba illa, vt intelligantur, *iure ciuitatis Romæ*, hoc est, iure Romanorum, quod commune est ciuitatibus omnibus, imperio subiectis, idque disponit, tam de locis publicis propriis eius vrbs, quàm de locis publicis propriis aliarum ciuitatum aut oppidorum. Cæterum tunc ius Romanum non solū ciuile comprehendit, sed etiam gentium, quod simul est insertum in corpore iuris ciuilis Romanorum. Viæ etenim publicæ iure gentium communes quoad vsum sunt omnibus gentibus, etiã exteris, vt sine iusta causa denegari eis transitus per illas in alia loca non possit, vt disputatione præcedente dictum est. Et quia Numerorum 21 Seom Rex Amorreorum, trāsitum per vias publicas sui regni absque iusta causa denegauit filiis Israel, licitum ac iustum ob eam causam fuit bellum filiorum Israel aduersus illum, vt Disput. 104 cum doctoribus, quos ibi citauimus, est dictum. Non ergo sensus illorum verborum est, quasi ibi voluerit Vlpianus affirmare, vsum publicarum rerum esse communem priuatis sin-[[170]]gulis iure ciuitatis Romæ, hoc est, tanquam rerum attinentium quoad dominium ad ciuitatem Romæ, quæ tunc dominabatur toti Romano imperio, & non recognoscebat superiorem, & quasi inde colligatur, publicas omnes res, de quibus ibi Vlpiano erat sermo, & ad quas id interdictum sese extendit, pertinere quoad dominium ad supremum principem regionis, in qua sunt, non recognoscentem superiorem, sicut tunc pertinebant quoad dominium ad orbem Romæ, quæ domina supremaque erat prouinciarum, non recognoscentem superiorem; & quasi eo iure, & concessione, vsus illarum sit communis singulis, & non quia ea loca sunt cuiusque propria. Quamuis enim ita eum textum & glossam intelligant *Cæpolla de seruit. rest. præd. c. 3. a. 21. & alii*, quos citat, sanè non est is sensus eius textus & glossæ, sed qui à nobis est traditus, vt perspicuè constat, eum textum & eam glossam expendenti: præsertim cùm inter publicas res, de quibus ibi est sermo, comprehendantur, quæ quoad dominium spectant ad oppida particularia, à quibus facta sunt communia quoad vsum suis solis oppidanis tantum. Licet autem ex eo textu non colligatur, vias publicas, plateas, flumina publica, & similia alia, attinere quoad dominium ad principem eius loci non recognoscentem superiorem, sed solū esse communia quoad vsum priuatis, & nulli in particulari esse propria quoad vsum; id tamen ex aliis iuribus colligitur, vt ex. c. 1. quæ sunt regaliæ, in vsib. feud. Vbi inter iura regalia, quæ propria sunt supremi principis non cognoscentis superiorem, computantur *viæ publicæ flumina nauigabilia, & ex quibus fiunt nauigabilia, portus, ripa*: quæ tamen constat esse loca publica, omnibusque quoad vsum communia, *inst. de rer. diuis. §. flumina. §. riparum, & §. littorum. l. 2. 4. & 5. ff. eod. titu. & l. fluminum in prin. ff. de dam. infect.* Atque, iuxta hæc, ordinatio Lusitana lib. 2. titu. 15. computando iura regalia, sic habet: *Item stradas pubricas, è ruas pubricas antiguamente usadas, eos rios naueguauais, eaquelles, de que se fazem os naueguauais, se sam caue daes que corram continuadamente en todo tempo. E pero o que o uso asi das stradas è ruas pubricas, como dos rios, seja yualmente comun a toda gente, à qualquier otra cousa animada, sempre a propriedade dellas fica no patrimonio real. Item os portos do mar, onde os nauios constumam de ancorar.* Idē colligitur ex multis aliis iuribus, quæ idcirco statuunt, ad ædificandum in eiusmodi locis publicis, eāve vsurpandum, necessariam esse principis facultatem, aut supremi ipsius senatus, neque sufficere facultatem ciuitatum, aut rectorū earum, nisi expressè, aut tacito consensu, sit id eis à principe concessum, *vt patet. l. 1. §. ait prætor quo. l. 2. §.*

Casius, &c. l. quod principis; in prin. ff. de aqua pub. arc. Sunt verò eiusmodi loca publica, quoad dominium, principum supremorum non recognoscentium superiorem, non quidem ex natura ipsa rei, seclusoque iure humano: nam stando in natura ipsa rei, iureque gentium, potius pertinent quoad dominium ad communitates, res publicasve ipsas regionum, quarum sunt partes, quam ad principes; cæterum eo ipso, quòd principibus supremis concessum est dominium iurisdictionis in eas regiones, concessum etiam cēsetur dominium rerum, quæ alioquin ad totā rempublicam quoad dominium & vsum pertinebant, iureque ciuili Romanorum est applicatum, relicto omnibus de republica vsu earundē rerum perinde, ac si apud ipsam rem publicam dominium remaneret, quin & exteris competit, relictusque est idem vsus earundem publicarum rerum, quatenus conuictus humanus iusq; gentium id postulat, sine præiudicio rerum publicarum earum regionum, quarum eiusmodi publicæ res partes sunt.

Quamuis autem dominium locorum, quæ cō [sect. 6] munia sunt quoad vsum omnibus, qui sunt de eadem republica, seu regione, ad supremum principem, superiorem non recognoscentem, attineat: secus tamen est de rebus, quæ propria sunt ciuitatum aliquarum, aut oppidorum, siue omnibus, qui de eadem ciuitate sunt, aut oppido, communia sint quoad vsum, siue non, sed sint deputata redditibus ac sumptibus communitatis, aut ad potestates publicas, rectoresque communitatis, conuentus, aut aliqua alia ibi exercēdum. Eiusmodi quippe res propriè manent quoad dominium ipsarummet communitatum, & quoad vsum eatenus communes manent omnium, aut aliquorum, de ea communitate, quatenus præscriptum constitutumque est ab ipsa communitate, postulatque id, ad quod instituta destinataque sunt. *Ita habetur. l. in. tantum. §. vniuersitatis. ff. derer. diuis. &c. inst. eod. titu. §. vniuersitatis*, cuiusverba sunt: *Vniuersitatis sunt.* (quoad dominium, vt ex eodem textu & ex antecedentibus liquet) *non singulorum, veluti quæ in ciuitatibus sunt*, (tanquam propria videlicet ipsarum) *vt teatra, stadia, &c. similia, &c. si quæ alia sunt communia ciuitatum*, quoad dominium nempe. Cōparatione verò harum rerum cura vniuersalis ad supremum principem spectat, quatenus precisè postulat commane bonum totius reipublicæ, ipsarumque ciuitatum, aut oppidorum, quorum sunt: eaque de causa arctare potest, aut liberum relinquere, vt sine ipsius auctoritate non alienentur, aut non fiat circa eas aliquid, prout ipsi expediens fuerit visum.

Cùm dominium viarum publicarum, platea [sect. 7] rum, & similium rerum, quæ publicæ omnibus de republica sunt quoad vsum, ad supremum principem spectet, facilè liquet, neque alienari in totum, aut in parte, neque destrui, aut conuerti in alios vsus posse absque eiusdē supremi principis facultate & auctoritate expressa aut tacita, & siquid aliter fiat, irritum id esse ac nullum. Atque inde vlteriùs liquet, quamuis ciuitas aliqua conuertere aliquem locum priuatum possit in plateam publicam, aut in viam publicam, quando id iudicauerit expedire, si ipsi is locus ad id condonetur, aut illum emat, vel alio titulo acquirat, id quod innuere viderur glossa. l. 2. §. ait prætor, verb. habuit, in fine. ff. nequid in loco pub. postquam tamen conuersum est in viam aut plateam publicam, non posse illum alienare aut conuertere in alium vsum priuatum aut publicum, absque supremi principis expressa aut tacita facultate; eo quòd factus sit iam ipsius quoad dominium. *Consentit. l. continuus. §. cum quis, iuncta glossa ibi. ff. de verb. oblig. quæ habet*, basilicas, hoc est, vias publicas, & similia alia, absque principis autoritate, non posse validè vendi, aut alienari, &c. *l. apud Iulianum (aliàs incipit, idem Iulianus) §. vlt. ff. de leg. 1. Cæpolla. c. 3. citato. n. 21. 22. &c. 23. cum Bart. arbitrantur*, ciuitates pos-[[171]]se vendere & alienate vias publicas, &

alia eiusmodi loca publica, sine Regis facultate, faciendo tamen legem, quòd curator ab ea circa respublicas institutus, aut quòd rector ciuitatis possit eas alienare. *Ducuntur. l. 3. §. planè, iuncto. §. sed etsi à principe. ff. quod vi aut clam.* Vbi habetur, ex eo, quòd aliquis curator sit constitutus publicarum rerum, aut quòd præsides sit reipublicæ, possitque proinde prohibere, ne aliquid in loco publico ædificetur, non censi illi concessum, vt permittere possit in eisdem publicis rebus ædificari. Additur: *Hoc ita verum est, nisi lex municipalis curator reipublicæ amplius concedat:* nam tunc, si id ille permittat, facultatem ad id concedendo, tunc, quod ex ea facultate in loco publico fuerit ædificatum, non potest eo titulo destrui, quòd in loco publico sit ædificatum. Subiungitur: *Sed etsi a principe, vel ab eo, cui princeps hoc ius concedendi dederit,* (facta scilicet sit ea facultas ædificandi in loco publico) *idem erit probandum,* non posse scilicet, quod ex ea facultate fuerit ibi ædificatum, destrui, sed competet ædificanti exceptio, quòd ex legitima facultate sit ædificatum. Equidem improbabilem omnino existimo eam Cæpollæ & Bartoli opinionem, neque vlllo modo ex illo textu collegi. Ridiculum quippe est arbitrari; denegari ciuitati, principem superiorem recognoscenti, facultatem ad directe alienandum loca publica, eaque conuertendum in loca priuata; & concedi nihilominus ei facultatem, ad condendam legem municipalem, qua eam facultatem possit ipsa concedere curator ab ipsa ad publicas res constituto, aut præsidi prouinciæ, ipsamque, post eam suam legem ac statutum, posse id efficere, quod antea non posset efficere, quin potius, si id attentasset, irritum esset & inane. Vt autem intelligas, nihil tale colligi ex §. plane citato, obserua. Ibi non esse sermonem de solis publicis rebus, quarum dominium pertinet ad supremum principem, & vsus communis est singulis de republica, sed etiam de publicis rebus, quæ quoad dominium pertinent ad ciuitatem aut oppidum, cuius sunt, siue quoad vsum communes sint omnibus de eo populo, siue non, sed ad redditus & sumptus eius populi spectant. In eo verò paragrapho docetur, ex eo, quòd aliquis sit constitutus curator communis alicuius oppidi, ciuitatis, aut reipublicæ, vel quòd præsides in ea ciuitate, aut republica, sit constitutus, ad eumque spectet prohibere, nequid ædificetur in quouis loco publico ex explicatis, non proinde censeri concessam facultatem, vt permittere ac concedere possit in eis ædificare, additur: *Nisi lex municipalis curator reipublicæ amplius cõcesserit,* quoad loca scilicet, quæ ad ipsam quoad dominium spectant, de quibus vt ipsa potest disponere, (nisi ex aliqua iusta causa sit ei prohibitum de illis disponere absque consensu & autoritate principis) ita potest idem concedere curator rebus suis ab ipsa creato, idque vel per legem seu statutum ab ipsa ea de re conditum, siue concessione alia priuata. Quoad ea autem, quorum dominium non ad ipsam, sed ad supremum principem spectat, quæque proinde extra ipsius sunt iurisdictionem, sanè, vt illa directò non potest alienare, ita multo magis non potest condere legem, qua integrum vel curator suo vel sibi, mediante ea lege, faciat illa alienare; ridiculumque est, quenquam sibi persuadere, id ius ciuile statuere intendisse. Vnde corrui cautela, quam inde elicit Cæpolla, vt aliqui indirectè facere possint contra statuta ab ipsis iuramento confirmata. Solidioribusque multo fundamentis inniti deberent iuris periti aliqui, ad similes res introducendas, quas omnino intellectus, rectaque ratio, respuit, quæque in præiudicium sunt animarum, cum periurii euidenti periculo. de eiusmodi rebus publicis, quæ ad vsum cõ [sect. 8] munem omnium sunt deputatæ, & quarum dominium, earumque proinde alienatio, ad solū supremum principem spectat, diximus Disput. 79. §. respublicæ, præscribi non posse: id quod probat, *l. vsucapionem. ff. vsucapionib. l. præscriptæ. C. de operib. publ. l. 2. ff. de via pub. & nisi. pub. refic. edo. & l. 7. titu. 29. part. 3. Greg. Lopez ibi glossa. 1. latè disputat,* vtrum id etiam intelligendum

sit de immemoriabili præscriptione. Adductis verò doctoribus pro vtraque parte (tametsi multi eorū loquantur de centennaria, non verò de sola immemoriabili) ipse propendet, neque præscribi posse tempore, de cuius initio non extet memoria. Dicendum arbitror, quamvis neque centennaria præscriptione possit præscribi, vt glossa. l. 2. citata, & multi ex doctoribus, quos Greg. Lopez citat, rectè affirmant; eo quòd eiusmodi res possideri à priuatis non possint, ac proinde, nisi verus titulus legitimè probetur, quo à supremo principe sint concessæ, neque centennaria præscriptio, quæ sine possessione esse non potest, vim in eis habere possit; nihilominus possessio earum à tempore, de cuius initio non extat memoria, sufficit, vt censeatur præcessisse verum titulum, ac proinde vt censeatur, fuisse à principio legitimam earum concessionē à supremo principe, etiam si post tam longum tempus probari iam non possit. Cùm enim eiusmodi res ex concessione principis supremi acquiri ac possideri ritè possint; & in præscriptione immemoriabili præsumat legitima possessio, legitimusque titulus à principio fuisse, eo quòd tanto tempore pacificè sint possessæ, quod non cernitur in aliis præscriptionibus, nisi probetur; vtique, quamvis in eiusmodi rebus non sufficiat alia præscriptio, etiam centennaria, sufficiet tamen immemoriabilis, non quidem in ratione præscriptionis, quæ rem, quæ non erat possidētis, efficiat titulo legitimæ præscriptionis præscribentis; sed quia eo ipso, præsumptione iuris & de iure, censetur fuisse à principio legitimum titulum, atque adeò fuisse legitimam principis supremi concessionem, esto de ea iam nūc aliter non constet, quàm ex eiusmodi immemoriabili similium rerum possessione. In aliis verò rebus, quarum dominium spectant ad priuatas ciuitates, aut oppida, licèt deputata sint communi vsui eorum tantum, qui de eo sunt populo, imò & in confiniis regnorum, qui eorum oppidorum sunt, quorum terræ ad eam lineam terminantur, existimo sufficere præscriptionem, quæ aduersus ciuitatem sufficit, iuxta ea quæ in materia de præscriptione copiosè explanata sunt: id quod Greg. Lopez vbi suprà, & alii, quos citat, non satis in re proposita attendunt.

His ita explanatis ac constitutis, sumpto loco [sect. 9] publico vt comprehendit tam eum, qui vsui omnium est deputatus, quàm eum, qui deputatus est vsui eorum, qui sunt de communitate, ad [[172]] quam pertinet quoad dominium, (non verò pro eo, qui vel ad fiscum, aut patrimonium principis pertinet, vel ad dominium alicuius oppidi ad reditus ac sumptus illius, sine deputatione illius ad vsum publicum, quo pacto sumitur locus publicus. ff. de loco publico fruendo) interdictum est prohibitorium, quo quicquam facere in illo, aut in eo immittere, est inhibitu, quo detrimentum aliquod, vel ipsi loco publico in se, vel alicui priuato, sequatur, nisi quod lege municipali, senatus consulto, edicto, decretòve principis, fieri sit concessum. Intellige, saltem tacito, permissione videlicet ac communi vsu. *Ita habetur. l. 2. in. prin. c. §. publici, c. §. hoc interdictum ad ea. ff. nequid in loco pub.* Potest verò hoc interdictum intentari per procuratorem, *vt habetur. l. penul. ff. eod. titu. Ait verò Vlpianus. l. 2. citata in prin. tam publicis vtilitatibus, quàm priuatorum, per hoc prospicitur. Et tantum iuris habemus ad obtinendum,* (vsum scilicet publicum hoc interdicto, & vt nullum præiudicium nobis sequatur ex eo, quòd in loco publico aliquid fiat) *quantum quilibet ex populo ad prohibendum habet,* proponendo scilicet hoc interdictum, eoque vtendo. *Vt enim habetur. l. 1. ff. de locis c. itin. pub. Cuilibet in publicum petere permittendum est id, quod ad vsum omnium pertineat, veluti vias publicas, itinera publica; c. ideo quolibet postulante de his interdicitur,* id est, interdictum conceditur. Et neque monumentū in via publica permittitur extruere; vt ibidem l. 2. subjicitur. *Subiungit verò Vlpianus. l. 2. in prin. ff. nequid in loco pub.* post verba ex illo relata. *Propter quod, si quod fortè opus fiat, quod ad priuati damnum*

redundet, prohibitorio interdicto potest conueniri: propter quam rem (id est, ad quam rem) hoc interdictum propositum est.

Hinc, quando aliquis in mæniano, seu solario suo, immissum habet velum in locum publicum, quo impeditur lumen fenestræ vicini, aut qui ex hasta oblonga est appensum, ita vt contingat partem viæ publicæ, quæ respondet fenestræ vicini, vel aliqua alia ratione lumē fenestræ vicini impediat, competit tali vicino interdictum hoc vtile, quo impedit id velum eo modo appendi & immitti in locum publicum cum ipsius præiudicio. Ita habetur. l. 2. §. hoc interdictum ad ea, vers. cū quidam. ff. nequid in loco pub. Cæpolla de seruit. verb. præd. c. 61. n. 5. ait, si quis habeat mænianum, seu protectū in domo sua, quod supra parietem inferiorem egrediatur in viam publicam, partemque occupet, quia in eo oppido permissum sit habere eiusmodi protecta, tunc fas illi esse, supra protectum extendere velum in altum, etiam si officiat luminibus domus eminentioris, quæ sit à tergo: quia fas etiam illi est, eleuare suum protectum in directum vsque ad cælum: sicut fas illi esset cum eodem detrimento vicini, qui est à tergo, eleuare vsque ad cælum suam domum, in qua non esset protectum in viam publicam. Si infra protectum esset fenestra vicini, non posset extendere velum in suo protecto, quod versus partem inferiorem egrederetur parietem talis protecti, cum præiudicio vicini inferioris, aut transeuntium: quia tunc occuparet cum præiudicio aliorum partem viæ publicæ, quæ est infra protectum, quod non licet.

Quando aliquis illicitè ædificauerat in loco publico, nemine prohibente, atque in euentu, in quo non est destruendum postquam est ædificatum, quia non est in tantum præiudicium publicum, vt non expediat potius non destrui, ne ruinis vrbs deformatur cum detrimento eius, qui id ædificatum iam habet, vt statim subijciemus, tunc, si id corruat, aut alia ratione destruat, & dominus reficere illud velit, reducereque ad pristinum statum, competit aduersus eum hoc interdictum, quo id efficere prohibeatur. Ita habetur ibidem. §. si quis quod.

Cū mare & littus communia omnibus sint, [sect. 11] *vt constat inst. de rer. diuis. §. & quidem, & §. littorum. l. 3. ff. nequid in loco pub. & aliis iuribus (tametsi eadem lex. 5. dicat littora, quæ terminant terras, quibus supremus aliquis princeps dominatur, ad ipsum pertinere, idque exponit ibi glossa quoad iurisdictionem & quoad vsum, qui exteris denegari non debet, modò hostes no sint) si quis in mare molē projiciat ad edificandum, cum detrimento alterius, qui ibi ante edificauerat, aut cum eodem præiudicio alterius, in littore ædificare tentet, competit aduersus eum hoc interdictum, quo prohibeatur. Quando autem inde nullum præiudicium sequeretur, tunc, quia solum id commune est omnium, fitque primò occupantis ædificio aliquo, interim dum in eo perseuerat tale ædificium, prohiberi non potest id ædificium efficere. Ita subiungitur. §. si quis citato, & consentit. l. 3. citata, & 4. tametsi meritò subiūgat, prohiberi posse eas ibi immitti, si vsus maris, aut littoris, ex illis deterior reddatur, & consentiunt, quæ præcedentibus disputationibus dicta sunt.*

Ei, qui piscari in mari, aut nauigare, prohibe [sect. 12] retur, aut qui prohiberetur ludere in campo publico, vel lauari in publico balneo, aut spectare in publico teatro, non cōpeteret aduersus prohibentem hoc interdictum, sed in his euentibus actione iniuriarum est aduersus eum vtendum, quatenus iniuriam facit, iniustitiamque committit, frui prohibendo loco communi ad id omnibus concesso. *Ita subiungitur eodem. §. si quis quod, & consentit. l. iniuriarum. l. 1. §. ult. ff. de iniur. quæ actionem iniuriarum aduersus piscari in loco publico prohibentem tribuit, & eadem est ratio in reliquis euentibus commemoratis.*

Quia loca publica, circa quæ versatur inter [sect. 13] dictum, de quo loquimur, communia sunt cæteris quoad vsum, vsusque proinde ac cōmoditas ex illis suo quodammodo iure vnicuique eorum, quibus eo modo sunt communia, competit eo ipso, quòd ita communia sunt effecta, inde efficitur, quòd si aliquid in locis publicis fiat, aut immittatur, quo aliquis priuatur cōmoditate, quā ex eo loco habebat, vt si luce priuatur, prospectu, aut si aditus in suam domum fiat ei deterior, aut angustior, vel alia simili commoditate inde priuatur, cēseatur id factum in dānū ac in præiudiciū ipsius, cōpetatque proinde ei hoc interdictū ad prohibendum ac impediendum, ne id fiat aut immittatur. Secūs autem res haberet, si ex eo, quòd aliquis edificaret in loco sibi proprio, per accidēs priuaret simili commoditate: quia tunc ille vteretur iure suo, cōmoditasque mihi proueniens ex eo, quòd non edificetur in loco alteri proprio, non est mihi debita, neque ius ad illam habeo, sicut ius habeo ad commoditatem ex loco, [[173]] esset cum aliis communi quoad vsum, prouenientem. Hinc efficitur, quòd quia princeps, sine iusta causa, priuare nec debet, nec potest, alios commoditatibus ex locis publicis ipsis prouenientibus, sanè ex eo, quòd concedat alicui edificare, aut immittere aliquid, in loco publico, non censetur, neque intelligitur, illud concedere cum detrimento aliorum, aut alicuius eorum, nisi id exprimatur in concessione. Quando autem bonum commune postularet, vt id concederet cum detrimento aliorum, indeque longè maius bonum sequeretur, quàm esset paruum aliorum detrimentum, posset illud concedere cum eo illorum detrimento. Atque tunc ex circumstantiis concurrentibus attendere deberet, num facienda esset compensatio aliqua eis, qui inde id detrimentum subirent. Ex dictis præterea facilè intelligitur id, quod ex Labeone Vlpianus ait. Nempe si ex edificio in loco publico sequeretur aliquem priuari commoditate, nulla ratione ipsi debita, vt aqua, quæ per locum publicum ex prædio edificantis in prædium illius deriuabatur, cum tamen nulla ratione esset illi debita, tunc non competere illi ob eam commoditatem, qua priuatur, hoc interdictum ad impediendum id edificium fieri in loco publico. Si tamen, addit Vlpianus, ex eo edificio priuaretur lumine, quod à cælo per locum publicum recipiebat, vtique competit ei hoc interdictum; quia ius habebat ad eam commoditatem per locum publicum percipiendam. *Hæc omnia habentur. l. 2. §. meritò ait, & §. si quis a principe. ff. nequid in loco pub.*

Quando aliquis illicitè, cum præiudicioue a [sect. 14] liorum, edificauerat in loco publico, ita quòd aduersus eum competeat interdictum, de quo agimus, vt prohiberetur ac impediretur, tunc, si alius similiter edificaret postea in loco publico cum præiudicio illius prioris ad id edificium, quod illicitè antea edificauerat, non competit ei, qui priùs illicitè edificauerat, interdictum, de quo agimus, ad impediendum tale edificium: quia sunt in culpa æquali. *Ita habetur l. 2. citata. §. idem ait, & consentiunt iura alia, quæ ibi citat glossa.*

Quando aliquid in loco publico edificatum [sect. 15] est, nemine, neque potestate scilicet publica, neque priuato aliquo, prohibente ac contradicente, (si enim contradicente aliquo edificatum esset, destrui deberet, tanquam vi factum, idque interdicto quod vi aut clàm, quod restitutoriū est, vt *constat. l. 1. in prin. ff. quod vi aut clàm, & aliis iuribus*) tunc, si id non multum obstet vsui publico, nec sit in notabile præiudicium illius, destrui non debet. Tum ne ruinis vrbs, oppidūmve, deformetur, cum magno præiudicio eius, qui id edificauit. Tum etiam quia interdictum, de quo agimus, non est restitutorium, sed prohibitoriū. Imponi tamen ei edificio, ratione loci publici, in quo sine facultate fuit edificatum, debet solarium, seu salarium ac vectigal, quod quotannis ratione publici soli soluatur: atque à solo id vectigal solarium nuncupatum est. Quando autem id edificiū in præiudicium magnum esset

vsus publici, bonique publici, tunc officio iudicis destrui debet: non verò interdicto, de quo agimus. *Ita habetur. l. 2. citata. §. si quis nemine, & l. ult. eod. titu.* Obserua tamen, attendendum esse ad damnum publicum, & ad detrimentum priuatum, vnius, aut multorum, quod sequeretur, si id edificium, aut ea ædificia, postquam nemine contradicente sunt facta, destruerentur, conferendumque esse vnum cum alio, vt iudicetur, num destrui expediat: neque enim pro quo emolumento publico posset aliquando licite destrui vnum ædificium priuatum, quod non magni esset valoris, destrui licite posset ædificium magni valoris, aut destrui possent multorum ædificia cum eorum non leui detrimento, sed hæc iudicis prudentis arbitrio pensanda iudicandaque sunt. *Vnde Carolus. 5. l. 8. titu. 7. lib. 7. nouæ collect.* de qua disputatione præcedente loquuti sumus, non iussit destrui, quæ cum viarum publicarum præiudicio ædificata erant supra fundamenta extra parietes occupando & arctando à parte superiori vias publicas: sed solum iussit, similia de nouo non ædificari, nec, diruta, refici, sub pæna, vt iudicis officio diruerentur: Quin dico, si post eam legem, multa in aliquo oppido essent contra eam legem ædificata, nemine contradicente, nefas esset, cum quàm maximo multorum præiudicio, ea destrui: sed iterum oppidani essent præmonendi, ne deinceps id efficerent, & tunc, quæ de nouo contra eam legem ædificarentur, dirui possent, simulque exigi posset pæna alia pecuniaria eadem lege statuta. Illud etiam obserua, legē. 23. titu. 32. parte. 3. in euentu, quo ædificium non esset destruendum, statuere, rempublicam posse illud sibi vindicare. *Lex si legatum. §. ult. ff. de operib. publ.* statuit, quando priuatus aliquis occupat locum, aut ædificium publicum, (& videtur loqui, etiam de iis, quæ ad coronam regni aut ad oppidum aliquod ad sumptus spectant) integrum esse, vel illa vindicare, vel imponere vectigal & solarium, prout melius expedire fuerit iudicatum principi, aut reipublicæ, cuius sit is locus, aut ædificium publicum. *Greg. Lopez. l. 23. citata,* tandem ait, triplex remedium competere aduersus priuatum, qui in loco publico ædificauerit, nempe vel vt destruat, si ita expedire fuerit iudicatum, vel vt vsurpetur, illudque omnino amittat, qui illud edificauit, vel vt ei relinquatur sub vectigali ac solario, quod quotannis soluat ei, cuius fuerit dominium talis loci publici. Dicerē, si aliquis priuatus vsurpauerit locum, aut edificium publicum, quod iam antea erat edificatū, eratque bonum publicum, tunc locum habere, vel vindicari, vel ei relinquere sub vectigali ac solario, quod quotannis soluat, prout iudicatum fuerit magis expedire ei, cuius erat is locus, aut edificium publicum. Si verò aliquid à priuato ædificatum sit de nouo in loco publico, tunc vel diruendum esse ædificium, vel ei relinquendum sub vectigali, vt disponit §. si quis nemine citatus. Neque discordat. l. 23. citata dum dicit: *E si acordare el comun de aquel logar, do acaeciese, de lo retener para si,* (quoad dominium directum eius ædificii, quod eo ipso, quod ibi ædificatum est, cedit solo) *si lo no quiera derribar, puedelo fazer, e la renta, que sacaren dende,* (ex solario scilicet, seu vectigali, sub quo relinquatur) *deuen vsar della assi como de las otras rentas comunales, que ouieren.* Vbi vides, hanc legem nihil repugnare. §. si quis nemine citato: *Ant. tamen Gom. l. 46. tauri, n. 13. arbitratur,* in hoc Castellæ regno, iuxta eam legem, quod ita ædificatum fuerit, posse vindicari, ita vt ædificans illud omnino amittat. Refert præterea *legem 9. titu. 7. lib. 7. nouæ Collect.* quæ sic habet: *Porque nos a sido [[174]] hecha relacion, que muchas personas vecinos y moradores de las ciudades y villas y lugares de nuestros reynos, tienen entrado y tomado alguna parte de los terminos realengos y concegiles de las dichas ciudades, y villas, y lugares, en que tienen plantadas viñas y huertas y arboles, y hechos otros muchos edificios cō licentia de los tales consejos, y de las tales ciudades villas y lugares, y por luengo tiempo: los quales terminos en que assi tienē labrado y edificado, agora diz q̃ se los piden y demandan: y si losouiesen de dejar aquellos, que tenian hechos*

los dichos edificios y plantas, recibirian mucho agrauio y daño en lo que en los dichos terminos est a plantado y edificado: y porque à nos, como à Rey y reyna y señores, en lo talperteneoe proueer y remediar: mandamos, que à los que uiuierẽ plantado en terminos realengos y concegiles, viñas y huertas y otros arboles, y hecho otros edificios con licencia del concejo de latal ciudad y villa o lugar de veynte años à est a parte, se les pōga cēso de cinco marauedis por cada alañada de viña, y a este respeto en lo otro que est uiuere plantado y edificado, attenta la qualidad de la tierra, y con esto se queden a los q̄ tuuieren los dichos edificios y plantas; (vbi à contrario sensu innuitur, quòd si sine facultate id fuerit factum, amittatur domino loci) y que aquello q̄ assi fuere cargado de ceso sobre los tales heredamientos, sea para los propios del concejo de la tal ciudad, o villa, o lugar: para que con ello se escusen otras imposiciones y necesidades del pueblo. Et. l. 10. sequēti statuitur, quando termini aliqui adiudicantur aliquibus oppidis tanquam bona propria communitatis ipsorum, vt neque à Rege donētur priuatis aliquibus, neque à communitatibus ipsis eorum oppidorum aliquibus priuatis concedantur. Et. l. 11. præcipitur, absque Regis facultate communitatibus oppidorum non posse cōcedi alicui de los terminos y propios y valdios eorūdem oppidorum, & vt, quę donata sunt à Rege, examinentur, num valide sint donata, & à Regio senatu, quod iustum fuerit, decernatur.

Inter loca publica viæ publicę cōputātur, vt di [sect. 16] ctū est. Explicatūq; est, quæ sint viæ publicæ latè sumpto vocabulo, dictumq; est, esse eas, quarum solum est publicum. De eiusmodi ergo viis, non omnibus, sed de rusticis, hoc est, quę sunt extra oppida, (de vrbicis enim, hoc est, de iis, quæ sunt intra oppida, satis est præcedens interdictum, vnà cum officio iudicis, seu magistratuum, vt habetur. l. 2. §. viarum, vers. hoc interdictū ff. nequid in locopub.) peculiare constituitur interdictū eade. l. 2. à. §. ait prætor in via, quod tres continet partes. Prima est prohibitoria, qua in eiusmodi via publica, itinerēve publico, prohibetur aliquid facere, aut immittere, quo deterius in præsentī aut in posterum fiat. Dicitur autem fieri via deterior, si corrumpatur ad vsum commeandi, hoc est, ad eundum, vel agendum iumēta, aut ad ducendum plaustra, vel similia alia per illam, vt si ex plana fiat cliuosa, aut ex molli aspera, vel ex latiori angustior, vel ex sicca palustris, aut aliter ad vsum deterior. Vnde, si quis in viam publicam cloacam immittat, qua via ad vsum deterior fiat, saltem ob nimium sætorem; aut si fossam in suo fundo faciat, vnde aqua vndique collecta in viam publicam cōiūcta fluat, aut aliquid aliud edificet, vnde similiter in viam publicam aqua fluat; eaque ratione deterior ad vsum talis via reddatur, competit aduersus eum hoc interdictum, tanquam aduersus eum, qui in viam publicam mittit id, quo deterior fiat. Quādo autem ex prædio remoto fluit aqua eo modo in viam publicam per aliud prædium viæ coniūctum, tunc, si dominus prædii coniuncti necessariò, & non voluntate sua, eam aquam recipiat in suo prædio, interdictum compedit aduersus eum, ex cuius prædio ita fluit in prædium viæ cōiūctum, in ipsamq; viam: si verò sua voluntate illam recipiat, competit aduersus eum interdictum, de quo est sermo. Si quis pascatur animalia in via publica, quæ illam deteriorē reddant, vt sues, competit etiam aduersus eum hoc interdictū. Item si specum quis faciat in via publica, qua deterior ad vsum reddatur, competit similiter aduersus eum hoc idem interdictum. Est verò hoc interdictum perpetuum, id est, cōpetens triginta annis à puncto, quo aliquid factum est contra prohibitionem alicuius, condēnariq; debet, qui contra eam prohibitionem tale quid fecerit, quantum sua actoris intererit, id non esse factum. *Hæc omnia habentur. l. 2. citata. §. ait prætor in via. §. viarum. vers. si viæ publicæ exemptus. §. idem Labeo, & §. deinde ait prætor.* Secunda pars eiusdē interdicti est restitutoria, qua præcipitur, vt si quid factum, immissumve, sit in viam rusticam, quo deterior reddatur, id restituatur, hoc est, in pristinum redigatur

statum, auferendo, quod fuerit appositum, aut addēdo, quod fuerit ablatum. Quòd si is sit in possessione eius, quod est appositum, vt ædificii facti in huiusmodi via, quo illa deterior sit reddita, qui illud fecit, fieri præcepit, aut ratum habuit suo nomine esse factum, tunc suis sumptibus tenetur illud auferre; quòd si de communi consensu duorum sit factum, sumptibus vtriusque est auferēdum: si verò alius in possessionem illius iam deuenit, siue gratuito siue oneroso titulo, tunc sumptibus illius, qui illud fecit, aut hæredum de bonis illius, auferri debet: præsens autem possessor solùm tenetur præstare pacientiam, vt destruat. Quòd si vel ipse, vel qui illud fecit, doio fecerunt, quominus tempore, quo destrui præcipitur, id possiderent, tunc perinde tenentur, ac si ipsi adhuc essent in possessione. Quando ex prædio vnus arbor decedit in viam, vnde via deterior reddita sit, si dominus arboris eam habeat pro derelicto, tollique eam, ac ligna ex illa, permittet cuicunque voluerit ea auferre, non tenetur eo interdicto, ac proinde non tenetur suis sumptibus eam tollere: secus autem si non permittat ea ab aliis sibi ipsis tolli. Pars autem hæc secunda huius interdicti perpetua est, sicut & præcedens. *Hæc omnia habentur, l. 2. citata. §. prætor ait quòd. & §§. sequentibus.* In fine eiusdem legis additur tertia pars interdicti, quæ prohibitoria est. Ea enim prohibetur, quenquam impediri vti via publica, iter per illam agendo, aut agendo iumenta, vel plaustrum, aut alia vehendo, quæ ibi fieri consueuerint, aliisque permittantur. Atque, qui ita fuerit prohibitus, agere etiam poterit iniuriarum.

Iuxta hactenus dicta quoad interdicta expli [sect. 17] cata *Cæpolla de seruit. vrb. præd. c. 54. n. 6.* rectè affirmat, nefas esse in loco publico, vt in via publica, facere scalam absque facultate eius, qui id, iuxta hactenus dicta, possit concedere, qua ascendatur ad domum aliquam, etiam si eadem domus stillicidium habeat, quod extra eam scalā in loco publico, aut in via publica, sese exten-[[175]]dat. Neque enim id satis est, vt id viæ publicæ, ad quod se extendit stillicidium, senseatur esse domini eius domus, *vt rectè idem autor. c. 60. n. 2. & alii affirmant.* Excipit, nisi contrarium habeat loci consuetudo, argumento. l. an in totum. C. de ædif. priuat. Eiusmodi autem scalas vidi multas in Lusitania domorum priuatarum in via publica, quibus ad eas domus ascendebatur. *Neque refragari videtur ordinatio Lusitana lib. 1. titu. 49. §. 32. & 33. quæ sic habet: E bem assi non poder. d pesoa algũa poer escada em à rua dereito do portal de seu vezinho, por quelle embargue à entrada do seu portal. Ebem assi non se poderafazer narua escada, nem ramada, nem alpendere, nem outra cousa algũa, que faeza embargo aa seruentia da dita rua, ese ofezerem, nam lhes sera consentido, eos almotaceos lho mandaram derrubar.*

De canali, aut aquarelo, si decidat aqua in viā [sect. 18] publicam, ita vt nocere possit transeuntibus, aut ita vt viam notabiliter reddat deteriorem, quàm permitti consueuerit in eo oppido reddi ex aqua, & ex similibus rebus, quæ in viam publicam in eodem oppido de fenestris dejici cōsueuerunt, tunc impediri talis canalis potest ac debet, vei interdicto ne quid in loco publico, si fieri attentetur, vel officio iudicis, si facta sit, & via sit vrbica, iuxta ea, quæ dicta sunt: secùs autem, si non plus noceat, quàm projici consueta. *Ita Cæpolla vbi supra. C. 67. n. 5. & 68. n. 2. Consentit ordinatio Lusitana vbi suprà. §. 42. quæ sic habet: E se algum quiser verter todas as aguas da sua casa ahum luguar da rua, podeo fazer por cal, (canal nostri vocant) por onde as aguas vabam por sua parede: porem non poderaa fazer à caltam longa, que saca fora em à rua, porque faza nojo, nem mal a seu vezino, ou à os que passarem po la rua. E se alguem teuer ja feita cal longa, noma poderaa mudar para poer hi outra maior, nem doutra feitura, da que era dante em aquelle mesmo lugar: por em à tal cal assi longa nom poderaa prescreuer por tempo algum, se nojo fazerao vezinho, ou aos que pasarem po la rua, como dito he.*

Iuxta dicta suprà de viis vicinalibus, est dicen [sect. 19] dum. Si inter aliquas domos est via, quæ inseruit vsui earundem domorum, siue exitum habeat vtrimque ad viam publicam, siue non, dicendum est. Si non constat de initio, quo ex contributione soli dominorum earum domorum facta sit, aut si non semper ab vno illorum, aut ab vtroque, possessa sit tanquam sua propria, tunc cēsetur via publica, neuterque eorum neque vterque simul potest cam claudere, aut occupare, vel aditum aliis per illam denegare. Secus autem si deinitio constet, quod ab vtroque contributa sit, aut quod vt suam propriam semper illam possederunt, vel quod eorum alter eam vt suam possederit: nam tunc is, cuius est, aut illi, quorum est, possunt illam claudere, & denegare aditum reliquis per eam. *Ita Cæpolla vbi suprà. c. 75. & de seruit. rust. præd. c. 3. n. 27. & 28. Qui. c. 75. citato ait*, quando constat publicam viam non esse, tunc; si sit inter duas domos, in dubio cuiusnam duorum illorum vicinorum sit, censendum esse dimidium illius quoad latitudinem pertinere ad vnum, & alterum dimidium pertinere ad alterum. Tradit etiam varias cōiecturas, quibus iudicari possit, ad vnum eorum, vel totam, vel maiorem partem, attinere. Eum legito.

Lege vnica. ff. de via publ. & si quid in ea factum [sect. 20] dicatur; præcipiebatur ædilibus curulibus, vt etiā vię, quæ essent iuxta vrbes, in burgis, aut suburbanis, æquarentur, neque essent in eis foueę, & in equales partes, quoad fieri posset; & vt ita essent dispositę, vt effluxiones pluuiarum, aliarūq; aquarum, non nocerent domibus, & vt pontes in eis essent ad fluxus aquarum, vbicunque illis opus in eis esset, atque vt parietes & ædificia, quę iuxta vias essent, non essent ruinosę, ita vt nocere possent transeuntibus: quod si domini ea reficere & reparare nollent, pænis eos id efficere cogerent. Et vt curarent, ne aliquis in viis publicis aliquid foderet, aut subrueret, vel construeret, dissolueretque, si tale quid in eis ab illo esset factum. Item vt curarent, vt vnusquisque construeret partem vię, quæ est iuxta suam domū: & vt, si aliquis domum conductam haberet, & dominus eius domus eam vię partem non construeret, inquilinus id efficere cogeretur, qui sumptus postea detrahat de pensione pro ea domo illius domino debita. In hac autem ciuitate Conchensi, & in plerisque aliis locis huius regni, ex propriis oppidorum hæc fieri solent, & aquæductus publici refici. Item eisdem ædilibus præcipiebatur, vt curarent, vt nihil expositum esset in viis publicis, vnde transitus curruum aut liber vsus viarum impediretur, & vt stercora, morticina, & alia immunda, in eis non projicerentur. Hęc in vnoquoque loco obseruari deberent, atque eatenus obseruanda sunt, quatenus fuerit vsu receptum ea seruari. Ac fortasse multis in locis statuendum in hoc regno esset, vt exactiūs hæc seruentur, quàm vsu seruari soleant: videndumq; est in vnoquoque loco, cui hæc cura demādata sit, aut demandari debeat: atque ad iudices spectat hæc omnia, vnā cum rectoribus oppidi, curare, interim dum aliquibus aliis in particulari non est hæc cura demandata.

Lege. 1. ff. de via pub. & itin. pub. reficiendo, in [sect. 21] terdictum proponitur, quo prohibetur quēquā impedire alium, quominus aperiat vel reficiat quancunque viam publicam, siue vrbicam, siue rusticam, quam aperire aut reficere voluerit aggredi, dummodo ea apertione, aut refectione, illam deteriore non reddat: nam tunc impunè posset impediri, atque hoc interdictum perpetuum est, & competit omnibus, qui aggredi voluerint aperite, aut munire, viam publicam, & aduersus omnes, qui impedierint, & condēnabitur impediens ad interesse actoris, damnaque ex ea impeditio sequuta, vt eadem lege hæc omnia habentur. Vt autem eadem lege ait Vlpianus, id interdictum exponendo, reficere viam est, eam reducere ad pristinum statum: eaq; de causa, qui illam aperit, cum inre proposita nō sit, facere eam de nouo, sed eam reducere ad veterem altitudinem & latitudinem, hoc est, profunditatem, sanè

reficere illam censetur: sicut & qui illam purgat, sublato quod super eam est, reficere illam dicitur: quo fit, vt apertio viæ, viæque purgatio, partes quædam sint refectionis viæ.

Lege si in agrum. ff. eod. titu. habetur: Si quis in [sect. 22] vicini agtum rejiciat viam publicam, partem eius agri ea occupando, competit domino agri actio in factum aduersus ita rejicientē, ad interesse, vt scilicet ei soluat, quantum sua intererat non esse id damnum ab eo illi datum. Quod intelligo, vltra vendicationē partis sui agri ea via [[176]] publica occupati. Si enim semina tali parti agri mandata, destructa ea de causa sunt, aut impedimento fuit via immissa per eam partem agri, ne eo anno semina illi mandarentur, aut vallum, quo ea pars agri munita erat, destructum fuit, vel quod aliud damnum ei dedit ea viæ publicæ reiectione in talem partem agri, ad ea omnia dāna illi tenetur, vt ea lege habetur. Atque ita cessant multa ex iis, quæ *Cæpolla de seruit. rust. præd. c. 3. a. n. 40.* hac de re tradit. Illud verò cum Bart. & cum illo, probo, lege si agrum citata, non tradi peculiarem actionem, quæ de via reiecta nūcupetur, & ex lege illa competat: sed in ea lege doceri, competere actionem ad damnum ea ratione datum, quod ex natura ipsa rei atque in foro conscientiæ debetur, & pro eo competit utilis subsidiaria actio in factum legis Aquiliæ, iuxta ea quæ, dum de damno dato, legeque Aquilia, suprà à nobis habitus est sermo, dictum est. Eadem. l. si in agrum, subiungitur, si quis exarauit, aut dānum aliud simile intulit viæ publicæ; compelli ad illius munionem ac restaurationem in statum, in quo antea erat.

De itinere, actu, viaque, priuatis. Disp. 708.

SVMMARIVM.

1. *Via, iter, & actus, vt seruitutes sunt, in quo differant.*
2. *Itineris seruitus ad quæ se extendat.*
3. *Actus seruitus ad quæ se extendat, & comprehendit seruitutem itineris tanquam partem integram, etiam quo ad ius.*
4. *Viæ seruitus ad quæ se extendat.*
5. *Viæ seruitus quantæ latitudinis esse debeat, quando aliud non fuit conuentum. Itineris, aut actus latitudo, arbitris est definienda, quando pacto nō fuit definita, nec partes conueniunt.*
6. *Via, itinere, aut actu per alienum prædium, non vi, clam, nec precario, qui intra annum computatum vsque ad litem contestatam triginta diebus, saltem interpolatis, est usus, quo interdicto aduersus impediētem vltiū eadem seruitute vti subueniatur.*
7. *Via, itinere, aut actu, qui ita triginta diebus est usus, vt ei concedatur prædictum interdictum, necesse est vt fuerit usus cum credulitate, quòd seruitutem, quam intendit, haberet. Atque si interrogatus, verisimilem rationem reddat, quòd id crediderit, tuendus sine alia probatione est in eo interdicto, ad hibito ei iuramento, quòd cum ea credulitate fuerit usus, si pars aduersa id petat. Si verò verisimile sit non cum ea credulitate fuisse vsum, denegandum ei est id interdictum.*
8. *Via publica quando impedita est, qui prædium iuxta eam viæ partem habet, transitum concedere debet per suum prædium, donec id impedimentum cēset.*

9 . Via, itinere, aut actu, satis est aliquem vsum esse triginta diebus modo explicato, per suum familiarem, aut quencunque alium nomine ipsius transeuntem, ut id interdictum ei competat. Emphyteuta autem, feudatarius, & usufructuarius transeundo, sibi ipsis competit id interdictum.

10 . Via, iter, actus, si impedita fuerunt, aut is, qui eis erat usurus, legitime fuit impeditus ne eis vteretur, atque intra annum retro usque ad punctum, quo impedimētum cæpit, usus est eis triginta diebus, per restitutionem in integrum conceditur ei hoc interdictum.

11 . Via, itinere, aut actu, quod precario vtantur familiares domini prædii dominantis, aut is, cui precario ipse suum prædium dominans concesserat, non impedit quominus domino prædii dominantis competat idem interdictum, etiam pereum illorum vsum, quando ipse tanquam re sibi debite intendebat se illosque vti.

12 . Via, itinere, aut actu, si quis, vel antecessor ipsius in prædio dominante, usus est triginta diebus intra eum annum, tanquam seruitute debita, quod postea in eodem anno vtatur precario, non impedit, quominus ei competat id interdictum. Idem est, si intra eundem annum succedat alius in eo prædio, & vtatur comparatione illius precario, vi, aut clam.

13 . Via, itinere, aut actu, si quis sit prohibitus vti per se, aut per suum domesticum, & postea continuetur vsum, censetur vsum vi aut clam. Si tamen dominus ignorauit prohibitionem factam suo, & ipse vsum continuat, non censetur vti vi aut clam.

14 . Via, itinere, aut acta, si quis aliquem vti prohibuit, & postea successor similiter prohibeat, comparatione neutrius competit hoc interdictum.

15 . Via, itinere, aut actu, si partim dominus prædii dominantis, & postea successor illius vtantur triginta diebus, successor illi competit hoc interdictum aduersus prohibentem.

16 . In hoc interdicto etiam agitur ad interesse.

17 . Eodem interdicto subuenitur ut impediatur via, iter, aut actus eiusdem quantitatis, & non maioris, qua usus est eo anno.

18 . Viam, iter, aut actum, reficere volens, si impediatur efficere, quantum iure sibi competit, quo interdicto ei subueniatur; modò si dubium sit, probet se vsum illis fuisse eo anno triginta diebus; & ius verum habere ad eam seruitutem: & modo caueat de damno infecto, si ex tali refectioe timeatur.

19 . Viæ, aut itineris, qui probat ius habere, agere potest confessoria, ut sibi permittatur ea reficere, esto eo anno illis non fuerit usus: ut verò ex hoc interdicto ei subueniatur, necesse est probet etiam vsum triginta diebus eo anno.

20 . Viæ itinerisque refectio qualis & quanta permittenda.

21 . Viæ & itineris interdictum quibus, & aduersus quos, competat.

VT, quæ ad vias spectant, coniungamus, ac [sect. 1] absoluamus, hæc disputatio præcedenti erit adiungenda. Iter & via hoc loco, ut & in titulo. ff. de itinere actuque priuato, non sumuntur pro itinere ac via materialibus, quibus gradimur, sed significant seruitutes rusticas, quas prædium vnum rusticum habet in aliud. Ut verò ex parte diximus suprâ Disp. 11. & nunc copiosius est explicandum. Hoc est discrimen inter iter, actum, & viam, ut modò sumuntur.

Quòd iter est ius hominem eundi & ambu [sect. 2] landi per prædium, quod eam seruitutem rusticam impositam habet, non verò agendi iumentum, aut vehiculum, *vt habetur inst. de seruit. rust. præd. in prin. & l. 1. ff. eod. titu.* Vbi glossæ exponunt, eundi, hominem scilicet solum: am-[[177]]bulandi verò, cum socio, aut sociis. Lex. 3. titu. 31. part. 3. exponit, quòd quamuis ire possit cum socio, aut sociis, non tamen possint ire simul, sed vnus post alium: quod videtur nimia restrictio, & contrarium ait ibidem Greg. Lopez communiter affirmare doctores stando in iure communi. Quamuis autem, qui seruitutem solùm itineris habet in aliquo prædio, non possit per id prædiũ agere iumentum, aut vehiculum, hoc est, ducere illa ante se, vel post se, potest tamen ipse ire eques, vel in sella gestatoria, aut in lectica, vel in reda, etiam si illam ferant vnus, aut plures equi, vel iumenta, vt expressè habetur. l. qui sella in prin. & l. inter. ff. de seruit. rust. præd. quoniam id non est agere iumenta, lecticam, redam, vel currum, sed eis vehi, iterque illis agere, vt. l. qui sella, rectè dicitur, sed solum illa agere seu ducere. Vnde rectè *Cæpolla de seruit. rust. præd. c. 1. n. 4. & 5.* ait, attendendum esse, num, qui supra iumentum onustum, aut supra plastrum onustum, sedet, ac ducitur, sedeat gratia agendi iumentum, aut iumenta, onusque vehendi, an verò gratia iter agendi in illis, esto tanquam necessaria ad iter aliqua in eis asportet; vt culcitram, aut victum, vel aliud simile. Si enim gratia iter agendi sedeat, ac vehatur, illud ad seruitutem dumtaxat itineris attinet, & non ad seruitutem actus, ac proinde, tanquam minimè excedens seruitutem itineris, est licitum, etiam si in ea reda, aut curru, aliquis super equos, aut iumenta, sedeat, qui illa moderetur. Si verò, qui ita supra onus vehitur, ibi sedeat gratia moderandi iumenta, vehendiq; onus, tunc illud est agere plastrum, & iumenta, vehereq; id onus, licet simul ipse ibi iter faciat, egrediturque proinde limites seruitutis itineris, pertinetque ad actum, atque adeò non licet.

Seruitus autem actus, est ius hominis eundi & [sect. 3] ambulandi, agendi que iumenta, vehiculum, aut aliud simile. Vnde, qui habet iter, non continuò actum habet: sed qui habet actum, iter habet, eo que vti potest etiam sine iumento. *Hæc emnia habentur inst. de seruit. rust. præd. in prin. & l. 1. ff. eod. titu.* Vtrobique autem exponunt glossæ, quòd, qui habet actum, habet etiam iter, quoad commoditatem, non verò quoad seruitutem: quia sunt seruitutes diuersæ, *vt constat ex. l. loci. §. 1. ff. si seruit. ved. ex. l. 1. ff. de adimẽd. leg. & ex. l. si mater. §. siquis iter. ff. de excep. rei. iud.* Cæterum non video quomodo ius actus non includat ius eundi & ambulandi, & ius tantum agendi iumenta aut vehiculum, atque ex vtroque tanquam ex partibus integralibus coalescat, quæ partes ad inuicem sunt separabiles, vt si vni concedatur ius tantum agendi iumenta & vehicula, denegato ei iure eundi & ambulandi, & alteri ius tantum eundi & ambulandi, ac proinde nuda seruitus itineris. Atque. l. loci citata, de actu hoc posteriori modo accepto, pro nudo iure ad agendum, exponi posset. Lex verò si mater, ob id aduersus eum, qui petit seruitutem actus, docet, non obstare exceptionem rei iudicatę, eo quòd succubuerit antea petendo seruitutem itineris in eodem prædio: quoniam ex diuersa causa & titulo obuenire debuit seruitus actus, à præcisa seruitute itineris, circa quam damnatus antea fuit. Lex verò. l. ff. de adim. leg. eandem difficultatem continet, siue dicas de intrinseca ratione seruitutis actus (integre sumendo eam seruitutem) esse seruitutem itineris, tanquam partem illius, siue commoditatem eius seruitutis: intelligendaque proinde videtur illa lex, quando de mente testatoris non constet, semouere intendisse seruitutem itineris, aut commoditatis seruitutis itineris, à seruitute actus, sumpti præcisè proiure nudo ad agendum, sine iure ad eundem & ambulandum; quæ duo iura constat potuisse diuidere testatorem, & concedere vnum præcisè, denegando alterum: atque, si constaret, eam fuisse suam voluntatem, idque

sufficienter expressisset, illi esset standum: quando autem legauerat seruitutem actus, sine alia expressione, legasset vtique seruitutem, quæ vtrumque includit, & distincta est à seruitute itineris, tanquam includēs ab incluso, ac proinde adimēdo iter per id prædium, non censeretur ademisse seruitutem actus, quæ absolutè sumpta vtrumque includit.

Seruitus autem viæ, est ius hominis eundi, [sect. 4] ambulandi, & agendi: nam via, iter, & actum, in se continet, *vt habetur inst. de seruit. rust. præd. in prin. §. l. 1. ff. eod. titu.* & insuper addit, ius trahēdi lapides, & trabes, & similia alia, atque deferendi hastam eleuatam per id iter sine fructuum præiudicio, quæ denegata sunt habenti ius tantum itineris aut actus, *vt hæc omnia habentur l. qui sella. ff. de seruit. rust. præd. §. l. 3. titu. 31. part. 3.*

Via, quando aliud pacto non fuit defini [sect. 5] tum, lege est constitutum, vt habeat latitudinem octo pedum, vbi inflexiones seu anfractus non habuerit: in parte autem inflexionis esse debet sedecim pedum, vt flecti vehiculum commodè per eam ibi possit. *Ita habetur. l. viæ latitudo, §. l. via constitui. ff. de seruit. rust. præd. ac. l. 3. titu. 31. part. 3.* Atque in hoc differt seruitus viæ à seruitute itineris & actus, quæ lege non habēt definitum, quantæ latitudinis esse debeant. Ac in eis seruitutibus, & etiam in seruitute viæ, quando à principio, quando concessæ sunt, expressum fuit, cuius latitudinis esse deberent, ei tunc expressioni ac conuentioni est standum. Quando verò non fuit expressum, & partes inter se postea conuenerint, conuentioni postea de communi consensu factæ est standum: si verò inter se non conueniant, arbiter est assumendus, qui latitudinem definiat, quantum, attentis circumstantiis concurrentibus, sufficiēs iudicatum fuerit, vel ad nudum iter, vel ad agendum iumenta, aut vehiculum, pro qualitate loci ac consuetudine regionis. *Ita habetur l. certo. §. latitudo. ff. eod. titu.*

His ita constitutis, duo interdicta prohi [sect. 6] bitoria, aut duæ partes vnus interdicti, traduntur circa iter, actum, aut viam, quæ explicata sunt. Primo interdicto, primæ parte interdicti, prohibetur eum, qui nec vi, nec clām, nec precario, itinere, actu, vel via, triginta saltem diebus intra annum vsus est per prædium alienum in suum prædium rusticum, impediri eo vti, quin potiùs defenditur in ea quasi possessione, & tentione eius seruitutis, vt illa vtatur, interim dum non probatur sufficienter, eum talem seruitutē non habere: annus verò computandus est, retro à pūcto, quo, impeditus vti eo itinere, actu, aut via, litem est contestatus, id interdictum aduersus impediētem intendendo. *Ita habetur. l. 1. in prin. ff. de itiu. act. q̄ priuat.* Neque, vt hoc interdicto [[178]] gaudeat, satis est, vsum fuisse semel eo itinere, actu, aut via, intra eum annum, vt in interdicto de aqua quotidiana, vel æstiuā, est satis, dictumque est Disput. 704. sed necesse est, vt triginta saltem diebus, siue continuis, siue interpolatis, sit vsus, alioquin eo non gaudet. Quia enim non consuevit permitti aquam duci ex fundo alieno, vel per fundum alienum, familiaritatis gratia, sed solū habenti ius ad illam ducendum, faciliusq; multo non impediri consuevit tāsitus per fundum alienum, idcirco ius statuit, vt in illo alio interdicto sufficeret vnus actus, non verò in hoc, *vt Bart. ait, & Cæpolla de seruit. rust. præd. c. 3. n. 25.*

Quamuis autem, vt hoc interdictum conce [sect. 7] datur, necesse non sit, eum, cui conceditur, verè habere eam seruitutem, iūsve vtendi eo itinere, actu, aut via, sed eo interdicto gaudeat, modò triginta illis diebus tali itinere, actu, aut via, sit vsus, esto verè in re ius ad id non haberet, quia eo ipso cēsetur esse in quasi possessione iuris illius, tuendusque proinde in ea est interdicto illo; nihilominus, vt eo gaudeat, necesse est, vt fuerit vsus eo itinere, actu, aut via, credens se eam seruitutem habere, alioquin eo non gaudet, *vt habetur. l. ult. ff. de itiu. act. q̄ priuat. §. l. ult. ff. quem admod. seruit. amitt.* Vnde oritur dubium, an ipse probare debeat,

vsum fuisse eo itinere, actu, aut via, credendo se vti iure suo, an ad aduersarium spectet probare contrarium, & qualis probatio sufficiat, atque vtrum sit satis vtentem iuramento affirmare, se vsum fuisse credendo, se vti iure suo. *Hoc dubium tangunt gloss. l. 1, in prin. verb. vsus sit. ff. de iti. act. 'q̄ priuat. & Cæpolla vbi supra. n. 27.* vbi refert multorum opiniones. Arbitror autem, vtentem, quique sibi subueniri hoc interdicto petit, interrogandum esse, qua ratione ductus, fuerit arbitratus, se iure suo fuisse vsum. Quòd si verisimilem rationem reddat, quæ, attētis circumstantiis concurrentibus, verisimile iudici efficiat, eum, id credendo, vsum fuisse itinere illo, actu, aut via, neque contrarium omnino persuadeant, quæ aduersarius proposuerit ac obiecerit, defendendum esse in sua quasi possessione: quia toties eum eo anno fuisse vsum eo itinere, actu, aut via, præsumptionem ea de re facit ex ipsamet iuris dispositione, quæ in eo euentu concedit id interdictum. Si tamen aduersarius postulet, vt ab eo exi gatur iuramentum, num, credendo se vti iure suo, eo itinere, actu, aut via, sit vsus, cogendus est id iurare, atque si renuat, denegandum ei est interdictum. Si verò coniecturæ sint, quæ suadeant, eum, non credendo se vti iure suo, vsum fuisse eo itinere, actu, aut via, tunc denegari ei debet id interdictum, nisi sufficienter ipse probet eam suam credulitatem. Atque id sanè est, *quod habetur. l. 1. §. Iulianus ait. vers. Viuianus. ff. de iti. act. 'q̄ pri. dum dicitur.* Eum, qui, quòd riuus occupauerit viam publicam, aut quòd interrupta sit, ruina, hiaru, aut alio impedimento, per proximum vicini agrum iter fecit, esto frequēter iter fecerit, putà triginta aut pluribus diebus, non competere ei hoc interdictū: quia talis vsus in eo euentu reputatur non vsus, non tam quia precatio censetur eo itinere vsus, quàm quia propter necessitatem in publicum bonum censetur concessus, quin & præceptus tunc non impediri, *vt habetur. l. si locus. §. ult. ff. quemad. seruit. amitt.* cuius verba sunt: *Cū via publica, vel fluminis impetu, vel ruina, amissa est, vicinus proximus viam præstare debet.* Quare nulla ratione in eo euentu censendus est, quòd cum crudelitate, quòd iure suo vteretur, eo itinere fuerit vsus. Idem est dicendum, si propter simile impedimentum desiit vti via priuata in suum prædium per fundum vicini, eaque necessitate cōpulsus, iter sepius facit per alium agrum alterius vicini in suum prædium, dum id impedimentum perseuerabat: nam tunc propter eandem rationem non concedetur ei hoc interdictum, si à domino agri, per quam ea de causa iter facit, prohibeatur iter facere, vt eodem. §. Iulianus ait, subiungitur.

Vt ei, qui triginta diebus, modo explicato, iter [sect. 9] facit per agrum alicuius in rusticum suum prædium, competat hoc interdictum aduersus prohibentem continuare iter per eum agrum, satis est, si triginta illis diebus vsus sit eo itinere, vel per se, vel per suum colonum, aut hospitē, vel domesticum, vel quencunque alium, qui nomine, intuitū ipsius, eo itinere vterentur in idē prædium, esto ignorarent, cuius esset ager, per quem ita iter conficerent; qui commemorātur l. vsu retinetur, & quatuor sequentibus. ff. quēadmodum seruit. amit. Si tamen amicus meus, cū arbitraretur ad se pertinere fundum meum, iter faceret suo nomine per agrum vicini, credens deberi eam seruitutem fundo, quem suum arbitrabatur, tunc sibi, & non mihi, acquirit interdictum, vt prohiberi ipse non possit. *Hæc subiunguntur. l. 1. citata. vers. is cuius colonus, & l. 3. §. vti videmur.* Excipitur vsufructuarius, & multo maiori cum ratione emphyteuta, aut vassallus: nam si ad vnum pertineat vsufructus, & ad alium proprietas, si vsufructuarius triginta diebus iter faciat per agrum vicinum, sibi acquirit interdictum, vt prohiberi non possit, non verò illud acquirit proprietariæ, quin etiam si à proprietario ipso iure tunc prohibeatur transire per agrum illum vicini, competit etiam ei aduersus eundem proprietarium idem interdictum. Quòd si proprietarius etiam triginta diebus iuit per idem agrum vicinum, & prohibeatur, proprietario quoque competit

idem interdictum aduersus iter sibi prohibentem. Ita habetur l. 3. citata. §. sed enim per fructuarium.

Quando aliquis vti non potuit itinere, pri [sect. 10] uato hoc anno propter inundationem, aut quia per violentiam fuit impeditus, vel ob aliquod aliud impedimentum, ex parte itineris, aut ex parte ipsius, qui eo vti debebat, tunc, si anno, antecedente id impedimentum, vsus fuit eo itinere triginta diebus, per beneficium restitutionis in integrum, ex clausula illa generali, *si qua alia iusta causa mihi videbitur*, de qua Disput. 80. explicatum est concedi maioribus restitutionem in integrum repitita die, id est, sumpta iterum die, à qua cæpit legitimum impedimentum, indeque computando integrum annum retro, in quo triginta diebus vsus fuerit eo itinere, competit ei interdictum hoc, vt defendatur in possessione talis itineris, *Ita habetur. l. 1. §. si quis propter inundationem. ff. de itin. act. q̃ priu.*

Si dominus fundi dominantis, qui in proxi [sect. 11] mo fundo seruitutem itineris suo fundo deberi [[179]] arbitrabatur, suum dominantem fundum ita alicui precario concedat, vt in illum possessionē tranferat, tunc, esto hic, aut colonus eiusdem domini prædii dominantis, à domino prædii seruiantis, petant præcario iter per id prædium, (cùm tamen id non esset eis necesse) nihil domino prædii dominantis id nocet quominus, si intra annum triginta diebus vsus sit eo itinere, etiam per talem vsum coloni, aut eius, cui concesserat suum prædium precario, si postea prohibetur vti eo itinere, competat ei aduersus prohibentem hoc interdictum: quoniam ad intentionem domini, qua vtebatur per se, aut per illos nomine ipsius, eo itinere, est attendendum, non verò ad intentionem eorum, qui nomine ipsius illo vtebantur, vt censeatur esse in possessione, aut quasi possessione, vsus illius itineris tanquam sibi omnino debiti, etiam per actus, quibus illi alii alia intentione eodem itinere vtebantur, quo fit, vt non precario censeatur is vsus eo itinere, esto duo illi alii precario intendissent eo vti. *Ita habetur. l. 1. §. si tibi fundum. ff. de itin. act. q̃ priuat.*

Si quis vsus fuisset triginta diebus itinere in [sect. 12] fundo proximo, tanquam sibi debito, posteaque in eodem anno precario à domino eiusdem fundi petiisset vsum eiusdem itineris, tunc cùm iam ex vsu illo alio triginta diebus, non precario, sed tanquam sibi omnino debito, comparasset quasi possessionem eius itineris, atque adeò ratione illius sibi competeret interdictum hoc, si ei iter denegaretur, sanè non desinit ei competere ex eo, quòd postea precario vsum eiusdem itineris petiisset. *Ita habetur. l. 1. §. vlt. c̃. l. 2. c̃. l. penul. ff. de itin. act. q̃ priuat.* Idem est si antecessor in eo prædio vsus esset legitimè triginta diebus itinere per fundum vicinum intra cum annum, & postea successor quocunque titulo in eodem prædio dominante, precario postularet à vicino iter per eundem fundum: nam tunc id illi non impediret, quominus sibi competeret idem interdictum aduersus vicinum id iter sibi prohibentem. *Ita habetur. l. penul. citata.*

Si cùm vsus essem triginta diebus itinere per fundum tuum, non vi, clàm, aut precario, tu vèdidisti eum tuum fundum, atque emptor postea me prohibuit, vsusque sum proinde deinceps eodem itinere vi aut clàm, modò tunc non sit elapsus integer annus à puncto, quo triginta illis diebus eo itinere sum vsus non vi nec clàm, competit mihi aduersus emptorem idem interdictum: quia adhuc est verum dicere, me vsum esse intra eum annum eo itinere triginta diebus nec vi, nec clàm, nec precario; quod est satis, vt mihi competat id interdictum aduersus quencunque possessorem eius fundi, qui me impedierit eo itinere vti. *Ita habetur. l. 3. in prin. ff. de itin. act. q̃ priu.*

Siue ego prohibear à te ire per fundum tuum, [sect. 13] siue colonus meus prohibeatur, aut alius, qui nomine meo eat, posteaque nihilominus eamus, dicimur vi aut clàm ire. Cæterum,

si ego ignorem, meum colonum, aut alium, qui it nomine meo, esse prohibitum, & ego, minimè à te prohibitus, eam, non censeor vi aut clàm ire: quare, si intra annum eam ita triginta diebus, ignorando colonum meum, aut alium, qui ibat nomine meo, esse prohibitum, competit mihi hoc interdictum aduersum te, si me post eos triginta dies ire prohibeas. *Ita habetur eadem l. 3. §. item sciendum.*

Ei, qui comparatione domini fundi vi, clàm, [sect. 14] aut precario, vsus est itinere per eum fundum, sicut si à domino fundi prohibeatur, non competit illi hoc interdictum aduersus talem dominum, ita neque, si is fundus transeat ad aliū titulo hæreditario, emptionis, aut aliquo alio, nouusque successor eum prohibeat vti eodem fundo, competit aduersus eum hoc idem interdictum, vt est satis perspicuum: quippe cùm in toto iure prædecessoris hic succedat. *Ita habetur ibidem. §. siquis ab autore.*

Quandocunque fundus aliquis in alium titulo [sect. 15] aliquo transit, siue gratuito, siue oneroso, aut eodem titulo vsumfructum, aut vsum illius, is adeptus est, tunc, si triginta diebus eo anno ipse, vel antecessor illius, vsus est, modo suprà explicato, itinere, aut via, per fundum vicinum, vel in parte eorum dierum vsus est ipse, & in reliqua parte antecessor, vtique, si prohibeatur vti eodem itinere aut via, competit ei hoc interdictum aduersus prohibentem. Idem est, si vnus mandato alterius emit prædium dominantem, & qui emit, & is, cui emptus est, vsi similiter sint itinere, aut via, per agrum vicinum in id prædiū triginta diebus, aut etiam in parte eorum dierum venditor eo vsus fuerat, tunc, si ei, cui venditus fuit, prohibeatur vsus eiusdem itineris, aut via, competit ei hoc interdictum aduersus prohibentem. *Ita habetur. l. 3. citate. §. hoc interdictum & ei.*

In hoc interdicto agitur simul ad interesse, [sect. 16] nempe, vt si is, qui prohibet, admonitus à prohibito vt desistat, quoniam est in legitima possessione eius itineris aut viæ, triginta diebus, nō desistat, soluat prohibito interesse, hoc est, quātum sua prohibiti intererat, non esse prohibitum: vt si ea ratione colligere non potuit fructus sui prædii, aut maiori cum sumptu eos collegit, vel aliqua alia ratione ex ea prohibitione damnum aliquod ei emersit, aut lucrum cessauit. *Ita habetur eadem. l. 3. citata §. in hoc interdicto.*

Hoc interdictum solū competit, vt eousque [sect. 17] quis non impediatur transire per fundum alienum in suum, quousque transiisse triginta diebus in eo anno constiterit per talem alienum fundum: si enim aliam, aut maiorem, viam conficere voluerit per eum fundum, vltiùs progrediendo, illāmve extendendo in longitudine, prohiberi tunc impunè potest. *Ita habetur. l. 1. §. Iulianus ait. ff. de itin. act. q̃ priu. Hæc de. 1. interdicto, primāve interdicti parte.* Secundo interdicto, secundāve interdicti [sect. 18] prohibitoria parte, quia is, qui seruitutem itineris, actus, aut viæ, per alium fundum habet, nisi illa reficiat, quando opus id fuerit, non potest commodè illis vti, inhihetur eum, qui nec vi, nec clàm, nec precario, vsus est per fundum alienum itinere, aut via aliqua, triginta diebus in eo anno, modo præcedente interdicti parte explicato, si reficere illa velit, prout ius ad id ei competit, non impediri id facere. Si tamen dominus fundi alieni petat, sibi cauere de damno infecto, si quod timet sibi ex ea refectione ac opere posse euenire, cauendum ei est, [[180]] alioquin permittere non tenetur eam refectionem. Præterea is, cui hoc interdictum concedēdum est aduersus reficere prohibentem, duo simul probare priùs debet, alioquin ei non conceditur hoc interdictum. Primum est, se vsum esse eo itinere, aut via, triginta diebus eo antecedente anno. Secundum verò est, sibi verè eam seruitutem competere. Alioquin ei denegatur hoc interdictum. Quia enim longè maius præiudicium est, quenquam reficere, opūsve facere, in fundo alieno, quàm permitti continuari viam per eum, qua triginta diebus eo anno est vsus, idcirco, vt prima pars

interdicti cōpetat, satis est præcessisse vsum eius itineris, aut vię, eo anno triginta diebus: vt verò secundum cōpetat, necesse est, duo illa simul probare. Ideo autem dictum est, inhiberi eo interdicto prohiberi illa reficere, prout ius ad ea reficiendum illi competet: quia si à principio, quando seruitus fuit constituta, aut postea deductum fuit in pactum, vt non posset illa reficere, aut vt reficere illa posset certo modo, aut vsque ad certum terminum, & non alio modo; tunc ei conuentioni est standum, prohiberi que licitè ac impunè poterit, id refectione transgredi, esto duo illa simul probet. *Hęc habētur. l. 3. §. ait prætor. ff. de itin. act. q̄ priuat.* Dubium est, vtrūm quanuis, si, qui prohibe [sect. 19] tur reficere, incipiat à primo e duobus, quę dicta sunt necesse esse ei probare, vt illi competat hoc interdictum, teneatur etiam probare secundum, atque adeò vtrunque simul, si tamen incipiat à secundo, satis sit illud probare, sine primo, vt illi competat hoc interdictum. Etenim, si quis dūtaxat probet, sibi competere eam seruitutem, statim potest confessoria agere aduersus impediētem, ne id iter, aut eam viam, reficiat, vt illū reficere permittat, esto non vsus sit eo anno ea via, aut eo itinere, triginta diebus, *vt habetur. l. loci. §. siquis mihi. ff. si seruit. vend.* Dicendum tamē est cum glossa vtroque, & cum Cēpolla de seruit. rust. præd. c. 1. n. 41. quamuis, fi agatur confessoria, vt quis reficere iter aut viam permittatur, satis sit probare seruitutē eius itineris, aut vię, sibi competere; vt tamen ex hoc interdicto aduersarius compellatur, non impedire refectionem, non esse id satis, sed necesse insuper esse probare simul vsum eius vię, aut itineris, triginta diebus eo anno. Quare, quando non præcessit is vsus, aut probari non potest, non est agendum hoc interdicto, sed potiùs confessoria, vt refectio permittatur.

Refectionis modus talis esse debet, vt iuxta [sect. 20] pristinam formam refectio fiat, neque illam excedat. Vnde nefas est reficiendo facere iter, aut viam, latiore, aut longiorē, quàm à principio esset, aut depressiorem, vel eleuatiore, quin neq; si strata non erat, eam lapidibus sternere, *vt habetur. l. loci corpus. §. si quis mihi. ff. si seruit. vend.* Si tamen riuus destruat eiusmodi viam, aut iter, fas est efficere pontem, si necessarius est ad cōmodum vsum; quem tamen non licet facere in loco publico sine principis facultate, vt disputationibus præcedentibus dictum est. *Hęc omnia habentur. l. 3. §. ult. ff. de itin. act. q̄ priuat.* Veteres secundę parti interdicti, de qua agimus, expressè addebant, inhiberi vetare eum, qui ad eiusmodi refectionem necessaria afferet, ea asportare. Id tamen sublatum est, quia minimè necessarium erat exprimi interdicto: eo quòd id necessarium sit ad refectionem: & cui refectio conceditur, concessum eo ipso censetur id, sine quo refectio esse non potest: atque adeò, quando prohibetur impedire aliquem reficere aliquid, cēsetur eo ipso prohiberi impedire illum asportare necessaria ad eam refectionem. Et quamuis fas sit egredi id iter, aut viam, per eundem fundum, quātū necesse sit ad asportandum necessaria ad refectionem, vt habetur. l. refectionis. ff. communia præd. id tamen intelligendum est, dūmodo id fiat cum quanto maiori compendio id commodè fieri possit, & cum minori detrimento domini talis fundi. *Hęc habentur. l. 4. & 5. in prin. ff. de itin. act. q̄ priu.* Hoc loco obserua, quando à principio cōceditur seruitus itineris, aut vię, per aliquem fundum, censeri concessam viam ac commodatam, ac proinde censeri concessum, vt fiant, quę ad talem viam necessaria sunt, etiam conficiendo gradus, quibus commodè ascendatur, si ita necessarium sit, & rumpendo, aut æquando in eo fundo, atque ædificando, quę necessaria fuerint ad commodam viam, prout concessa est intelligenda. *Ita habetur. l. si iter. ff. de seruit. & affirmat Cēpolla de seruit. urb. præd. c. 22. n. 6.* idemque est de aliis seruitutibus similibus; id tamen fieri debet expensis eius, cui seruitus est concessa.

Hoc interdictum de itinere aut via reficien [sect. 21] dis competit cuicumque successor in prædio dominante, & aduersus quemcunque successorem in prædio seruiente, modò similiter successor probet, sibi cōpetere eam seruitutem, & per se, aut per suum antecessorem, vsum fuisse eo itinere, aut via, triginta diebus eo anno. Et quamuis possessor dominantis prædii non ostendit titulum, quem ea seruitus tali prædio debeat; si tamen ostendat, possessores eius prædii dominantis, à tempore de cuius initio non extat memoria, fuisse in possessione eius seruitutis, id satis est loco tituli. Cùm enim eiusmodi seruitus discontinua sit, non minori tempore præscribitur, quàm de cuius initio non extet memoria: in ea verò præscriptione titulum antecessisse præsumitur, vt Disp. 70. ostensum est, atque eo ipso, quòd seruitus aliqua legitimè est præscripta, ea legitima præscriptio incipit habere rationem tituli dominii, aut quasi dominii, rei legitimè præscriptæ. *Hæc habentur. l. apparet. §. hoc interdictum. ff. de itin. act. priu.*

Quousque cuique liceat ædificare in suo solo proprio, aut non liceat, quia id cedit in alterius, aut in boni communis, damnum, seu præiudicium. Disp. 709.

SVMMARIVM.

- 1 . *Ædificare licet unicuique in suo solo. suæve area, & in ea in altum se tollere vsque ad cælum, eã non aggrediendo, esto inde detrimentum vicino sequatur, nisi seruitus sit in contrarium, aut statutum, vel consuetudo præscripta loci alicuius aliud habeat.*
- 2 . *Seruitus altiùs non tollendi, intelligitur ædificando: vnde plantæ apponi ibi possint, esto fini aduersentur, ob quem constituta est ea seruitus. Seruitus verò ne luminibus officiatur, intelligitur quacunque re, etiam plantis.*
- [[181]] 3 . *Aedificia in hoc regno attolli non possunt cum detrimento, vt multum secreta domorum vicinarum pateant.*
- 4 . *Aedificia siue de nouo fiant, siue longè antea sint facta, fas est de iure comuni aperire in illis quascumq; fenestras, etiam si inde pateant secreta vicinorum, nisi seruitus sit in contrarium. Si tamen quis, prohibitus facere, aut aperire aliquam, desisteret decem annis inter præsentis, & viginti inter absentes, præscripta aduersus eum esset seruitus, vt illam aperire non posset.*
- 5 . *Circa ædificia quæ Lusitano iure liceant, aut nō liceant.*
- 6 . *Seruitutem ne se attollat, aut ne fenestram faciat aut aperiat, potest quis cogi vendere monasterio, aut alteri loco publico, quando inde notabile damnum sequeretur monasterio, aut loco publico. Et num aliquando cogi etiam possit comparatione priuati.*
- 7 . *Aedificium attollere, & fenestram aperire, quamuis liceat cuiuis, si tamen ad amulationem id efficiat, hoc est, non animo vtendi iure suo, sed ex odio, vt noceat, impeditur, cogiturque factum destruere. Et quando censendum sit. factum ad æmulationem.*
- 8 . *Aedificare, aut tenere fortalitium in confiniis imperii, aut regni, sub quibus penis prohibitum. Hodie de iure huius regni omnino est prohibitum facere in quocūq; alio loco*

fortalitium, etiam si intuitu faciendi domum ad habitationem propriam id fiat. De iure verò communi licebat, nisi ad æmulatione, aut cum graui scandalo alicuius oppidi fieret.

9. *Fortalitium reficere quousque liceat.*

STatuenda est hæc regula. Vnicuique fas est æ [sect. 1] edificare in suo proprio loco, in suauē area propria, vt libuerit, atque in altum in ea se attollere vsque ad cælum in directum illam non egrediendo: quoniam totum spatium vsque ad cælum in directum, quod ei areæ respondet, ad eum pertinet cuius est ea area ac solum. Excipitur ab hac regula, nisi alteri seruitus in contrarium debeatur, aut nisi statuto sit aliud in commune bonum sancitum, vel consuetudine præscripta introductum. Regulam hanc affirmat communis doctorum sententia, quam *Ant. Cō l. 46. tauri. n. 6. refert ac sequitur. Consentit Cæpolla de seruit. verb. præd. c. 27. n. 4. & c. 40. a. n. 1.* eam autem probant. l. altiùs. C. de seruit. cuius verba sunt: *Altiùs quidem ædificia tollere, si domus seruitutem non debeat, dominus eius minimè prohibetur. Et idem habetur. l. si in ædibus, statim ibi sequenti. l. si opus. §. si iussero. vers. in opere. l. si vitem. §. penul. ff. quod vi aut clam. l. vlt. in prin. vers. quia cælum ff. de seruit. l. cum eo. l. imperatores, & l. cuius. ff. de seruit. vrb. præd. & aliis iuribus.* Neque refert, quòd inde detrimentum, etiam magnum, sequatur vicino: quoniam neque iniuriam illi facere, neque damnum illi dare, censetur, si per accidens id illi sequitur, dum ita iure suo vtendo ædificat, vt ex se constat, & ex l. fluminum. §. vlt. atque ex l. Proculus ff. de dam. infect. Neque est eadem ratio de loco publico & de loco priuato. Nam commoditas ex loco publico, omnibus debet esse communis, ac proinde, cum præiudicio aliorum, qui inde priuantur commoditate luminis, aut aliqua alia, nulli fas est in eo ædificare: neque princeps potest ad id facultatem concedere, nisi pro maiori alio bono: neque si concedat facultatem alicui ædificandi in loco publico, intelligenda est cum præiudicio alicuius alterius, nisi id exprimat, vt habetur. l. 2. §. meritò, & §. si quis à principe. ff. nequid in loco pub. & Disp. 707. copiose dictum est, affirmatque communis doctorum sententia, quam *Ant. Gom. n. 6.* citato refert ac sequitur. Si quis verò in suo loco proprio ædificet, iure suo vitur, neque curare tenetur de damno priuationis commoditatis, quæ vicino proueniebat ex eo, quòd solum suum, areæ suæ, non occuparetur ædificio usque ad cælum: neque ordinata caritate tenetur postponere commodum suum proprium, ad quod ius habet, proximi commodo.

Quando seruitus debetur, tunc nihil fieri potest [sect. 2] in ea area, aut solo, quod sit contra seruitutē debitam. Vt si domus tua seruitutē habeat, vt altiùs non tollas, aut paries tuus, vel area tua, seruitutē habeat, vt vel ibi nihil ædifices, vel non tollas altiùs, quàm vsque ad certam distantiam, tunc tollere amplius non potes. Obserua verò, seruitutem altiùs non tollendi, intelligi ædificando, vnde ea seruitus non impedit, quominus arbores ibi plantentur, etiamsi supra eam altitudinem se tollant, & luminibus domus, comparatione cuius est ea seruitus, officiant, vel prospectum eius domus impedian, & causa, seu finis, imponendi eam seruitutem fuerit, ne luminibus ea ratione officeretur, vel ne prospectus eo ædificio impediretur: quin esto, quando seruitus altiùs non tollendi constitueretur, expressè diceretur, imponi ne luminibus officiat, aut ne prospectus impediatur, fas esset arbores cum eo detrimento plātare: quoniam nomine eius seruitutis solū intelligitur, ne tollatur ædificando. Si autem seruitus esset constituta in aliquo loco, ne luminibus alicuius domus officeretur, aut ne prospectus impediretur, tunc, ne plantis etiam id fieret, intelligeretur, ac proinde plātæ, quæ prospectum impedirent, aut quæ luminibus officerent, essent tollendæ. *Vtrumq;*

habetur expresse. l. adificia, iuncta. l. quod autem. ff. de seruit. verb. præd. & affirmat. Cæpolla de seruit. vrb. præd. c. 27.

Vt verò simul misceamus, quæ statutis non li [sect. 3] cent, obserua. Quamuis, stando in iure communi, fas sit vniciue se attollere usque ad cælum ædificando in suo proprio solo ac area, de iure tamen huius regni. l. 25. titu. 32. part. 3. in bonum commune ac vicinorum adhibitam esse eiusmodi limitationem. *E puede la alçar quanto se quisiere, guardandose toda via, que non descu bra mucho las casas de sus vezinos.* Vbi vides, impediri posse attolli domum in hoc regno, quando esset cum præiudicio vicinorum, quia scilicet inde multum paterent secreta domorum ipsorum: quando verò id non esset in causa, quòd multum paterent habitantibus in domo, quæ attollitur, secreta domorum aliorum, impediri non posset attolli. Quando autem cēsendum esset, multum patère, quæ in domibus vicinorum fierent, vt impediri posset attolli, iudicis prudētis arbitrio id iudicandum relinquitur. Item si is, qui attolleret domum, ita disponderet fenestras domus suæ, vt id incommodum vicinis non sequeretur, attollere se posset, quantum vellet. Ius Lusitanum hac de re, simul cum iure eiusdem regni circa fenestras, subjicietur.

Ex eadem regula proposita facilè patet, quòd quando seruitus in contrarium non est imposita, aut obligatio alia ad id peculiaris non interuenit, fas est cuicunque ædificanti in proprio [[182]] solo ac area aperire fenestram, aut fenestras, in eo edificio, idemque efficere posse progressu temporis quocunque tempore voluerit in eo edificio longè antea confecto, esto nunquam ibi apertæ fuerint fenestræ, & esto inde conspiciantur interiora domorum, aut hortorum, vicinorum, vel aliud detrimentum per accidens inde eis sequatur, idque quando non est statutum aut lex in contrarium, vt nulla talis reperitur de iure communi. Ita affirmat Cæpolla de seruit. vrb. præd. c. 62. n. 1. & communis doctorum sententia, quam Ant. Gom. vbi suprà. n. 7. refert ac sequitur. Excipe, quando quis ædificare in suo solo aggrediretur, & relinquere aliquem fenestram in aliqua parte eius ædificii, prohibitusque à vicino, desisteret, atque elaberentur decem anni inter præsentis, aut viginti inter absentes, in quo tempore, prohibitus, eam non aperiret: nam tunc vicinus ea quasi possessione, quòd eam, prohibitus, non aperiret toto eo tempore, præscripsisse, comparasseque censeretur eam seruitutem, vt ibi non aperiretur. Idem esset, si, post confectum iam antea ædificium, tentaret in aliqua parte illius aperire fenestram, ac prohibitus, desisteret, clabereturque idem tempus: nam tunc similiter præscripsisse, comparasseque censeretur eam seruitutem, vt Cæpolla & Ant. Gom. vbi suprà cum communi doctorum sententia affirmant. *Consentitq̃ glosa. 1. l. qui luminibus. ff. de seruit. vrb. præd.*

Iure Lusitano lib. 1. titu. 49. §. 26. circa hoc, & [sect. 5] circa dicta. §. præcedente, sic sancitum legimus: Item qualquer que teuer casas, ou casa, pode nellas fazer cirado (terrado nostri vocant) compeitoril, è janelas, efrestas, e portaes, quantos elle quiser, è alçarse quanto quiser, è telher e lume à qualquer outro seu vecinbo dante si, se quiser. Por em nin huranẽ poderæa fazer fresta, nem janela, nem cirado com peitoril sobre casa, nem sobre quintal doutro, porque e descubra, que este coniuente a parede onde asi quer fazer à janela, oufresta, ou cirado, sem cousa algũa se meter em meio. E bem poderæa fazer cirado com parede tam alta, que se nom possẽ geytar sobre ella, para ver à casa, ou quintal doutrem. E assi quen quiser poderæa fazer na sua parede, sobre o tel hado, ou quintal, doutrem see teira por onde somentẽ possa auer claridade. E quando o outro sobre que se faz se quiser aleuantar, poder lba à fazer tapar, posto que seja passado anno e dia, ou outre qualquer mais tempo que esteueße feita. & §. 27. additur: E tende algum feita janela, aut fresta, ou cirado, coen peitoril, en caso, que o nom podia fazer, depois de ser passado anne edia, ea

parte era presente no luguar onde se fez, ja lhanem podera fazer desfazer, poste que se aleuantar queiræ. §. 28. additur: Item em beco nom pederas fazer algum janela, nem portal: saluo por licença des almotações, è officiaes de camara, à quellhe daram se virem que tem neceſidade, è nom trazmuito perjuicio. §. 29. subiungitur: Item quando algũa pessoa teuer algũa janela aberta em sua parede, sobre algũa azinhaga, que for tam streita, que nom pase de quatro palmos, è que non aja nella portas, somente corremas aguas, dos tel hados por ella, nom se pode o outre vezinho alçar tãto, quelle tolha o lume da janela, mas perderse a alçar à tee direita da janela, em modo quel he non tolha o lume, è mais nom. §. 30. additur: Item se algũa pessoa teuer janela, ou beyras de telhado em algũa parede, que seja sobre casa de eutrem, è desfazer esa parede, ou lhe cabir, ea quiser renouar, ou refazer de nouo, nom podera hi fazer maior janela, nem beiras, nẽ em outra lugar, se nom como adante auia, nem podera hifazer mais janelas. §. 31. subiungitur: Item se algũa peſoa teuer hũa casa de hũa parte da rua, eo outro seu vezinho quer fazer casa da outra parte da rua, ou se ja dantes a casa era feita, è quer nella abrir portal de nouo, ou quer hi fazer janela, ou fresta, nõ opoderaa abrir, nem fazer, dereito do portal, ou da janela, ou da fresta, do outro seu vezinho, que moura da outra parte darua: saluo se dãte, hi ouue ja o dito portal, ou janela, ou fresta, onde hoora quer abrir: porque entonce à pode raa fazer, no proprio modo è maneira que dante staba. E por em desuiado do outro, e poderaa fazer. Et. §. 35. habetur: Item se algũ teuer janela sobre algum quintal, ou campo, doutrẽ; è aquelle, cujo for o quintal, ou campo, quiser hi fazer casa, nom poderaa fazer parede tam alta, que tape à janela, que ante hi era feita, se paſsar de anno è dia, que era feita. Par em se o que quiser fazer à dila casa, quiser leixara zinhagua de vna vara è quarta de medir panno en larguo, bem podera fazer à dita casa, è alçarse quanto quiser. Et. §. 36. additur: Item se huña casa for de dues senhorios, de guisa que de hũ delles seja o sotam, è doutro o sobrado, nom poderae aquelle, cuio for o sobrado, fazer janela sobre o portal de aquelle, cuio foro sotam, nem outro edificio algum. Et §. 40. habetur: Item se alguem teuer casa, que verta agoa do seu telhado, sobre à casa do seu vezinho, o qual vezinho quiser fazer parede no seu, podese alçar, è podelhe britar as beiras è cimalthas, è encaamentos, è alçarse quanto quiser, se ho seu vezinho hi non teuer fresta, ou janela: è quando se aſſi alçar tomar lhe à as agoas, è dara seruentia para ellas em tal maneira, que o dito seu vezinho nom receba dano. Et. §. 41. additur: E se alguem teuer parede de per meo com outro seu vezinho, è ha casa de hum he mais alta, que à do outro, è tem à cal porque verte a agoa do seu telhadona dita parede, eo que tem à casæ mais baixa quer se à leuantar po la parede, mais alto que o outro poder sea alçar por toda a parede, em tal guisa que leixe tamãho lugar de parede, porque colba agoa de telhado, da quelle que ante hi tinha à cal. porque recebia à agoa, em modo quelle non venha por elle dano.

Quamuis, vt dictum est, fas sit vniciue se at [sect. 6] tollere in suo solo ac area usque ad cælum, & aperire in suo edificio fenestram, aut senestras: quas voluerit, quando neque est seruitus in contrarium, neque loci statutum, quod in commune bonum id ptohibeat, dubium tamen est, vtrũ, si aliquẽ se attollere in suo edificio, aut aperire fenestram, cedat in præiudicium monasterii religiosorum, aut religiosarum, quia inde secreta monasterii conspiciuntur, aut aliud præiudicium in dñum communis boni sequitur, possit is cogi, vendere seruitutem tali monasterio, ne se tollat cum eius monasterii præiudicio, aut ne fenestram aperiat cũ eiusdẽ monasterii præiudicio. Ad quod affirmãter est respondẽdũ cum Couar. 3. var. res. c. 14. n. 7. & 8. Ant. Gom. l. 36. citata. n. 9. & cum aliis, quos Disp. 341 citauimus, consentiuntque, quẽ ibi dicta sunt, num cogi aliquis possit vendere suum prædiũ ad edificandum monasterium, Ecclesiam, aut aliud pium aut publicum opus. Id tamen intelligẽdum est, modò iustum pretium talis seruitutis domino eius ædificii soluat:ur:

neque enim priuandus est gratis suo illo iure: sed sicut, si ab illo auferretur id ædificium, aut solum, ad monasterium, ecclesiam, **[[183]]** aut aliud publicum ædificium ibi construendum, soluendum ei esset pretium talis ædificii, aut soli, vt disputatione citata dictum est: ita soluendum ei esset iustum pretium talis seruitutis. Intelligendum præterea est, dummodo non maior seruitus ei imponatur, ipso inuito, quàm sit necesse ad euitandum præiudicium talis monasterii, aut alterius reipublicæ. Et dummodo ex ea seruitute non sequatur longè maius damnum illi priuato, quàm sit propè nullum præiudicium, quod fortè inde tali monasterio sequatur: neque enim alii subire tenentur iacturam maximam, pro modico præiudicio talis monasterii aut loci publici. Hæc sententia, ita explicata ac limitata, *probat ex. l. si quis sepulchrum. ff. de relig. & sump. funer.* Vbi habetur, si quis habeat sepulchrum edificatum in aliquo loco, neque pateat ei via ad id sepulchrum, nisi per prædium vicini, quia fortè via antiqua vi fluminis, aut alia ratione, impedita est, officio iudicis cogatur dominus prædii vicini concedere illi viam per id suum prædium, quātum satis ad id sit, & quanto cum minimo ipsius detrimento id sit possibile, persolutoque ei pretio iusto illius viæ: ergo simili modo ad vitandum notabile præiudicium religiosorum, aut religiosarum, potest quis cogi vendere seruitutem, ne se tollat, vel ne fenestram aperiat, quantum præcisè ad id sit satis, & persoluto ei iusto pretio pro ea seruitute. *Probat etiam ex. l. si locus. §. ult. ff. quemad. seruit. amitt.* Vt habetur. Quòd si via publica vi fluminis, ruina, aut alia ratione, destruat, cogitur vicinus proximus viā præstare, vt Disp. 707 visum est, persoluto tamen ei pretio ex natura ipsa rei, & de iuris rigore, iuxta glossam ibi, Bart. & communem doctorum sententiam, quam *Aluar. Valas. consult. 22. n. 4.* refert ac sequitur: neque enim quisquam gratis tenetur concedere, quod suum est, etiam in bonum publicum, nisi facta ei competēti compensatione: ergo simili modo, ad vitandum notabile præiudicium monasterii, atque adeò in cōmune bonum, potest quis cogi subire seruitutē, ne se attollat, aut ne fenestram aperiat, quantum satis sit ad id præiudicium vitandum, persoluto ei competenti pretio talis seruitutis. Quin addo, si alicui priuatę præiudicium magnum sequeretur ex eo, quòd alius se attolleret, aut aperiret fenestram in suo ædificio, parumque admodum esset præiudicium huius, quòd prohiberetur id nō efficere, credo posset licitè impediri, persoluto ei competenti pretio eius seruitutis, *iuxta. l. 1. §. sunt autem qui putant. ff. nequid in slum. pub.* Vbi pro magna commoditate vnus, quoad suū fundum, cogitur alius subire aliquam incōmoditatem longè minorem in aliquo suo fundo, persoluto ei competenti pretio eius damni, de qua re Disp. 704 copiosè est dictum. Denique ea omnia, quæ probant, posse aliquem cogi vèdere suum prædium ad ædificandum monasterium, Ecclesiam, aut publicum aliud ædificium, de qua re Disp. 341 est dictum, probant argumento à maiori ad minus, quod hoc loco de seruitute asserimus. Quamuis, stando in solo iure naturali, quando [sect. 7] debita non est seruitus in contrarium, cuius integrum sit se attollere in altum in suo solo quantum voluerit, & aperire in suo ædificio quas fenestras voluerit, etiamsi præiudicium inde vicinis sequatur, vt dictum est; quod sanè verum est stādo in solo iure naturali, etiamsi in vicini odiū id efficiat, ad effectum, vt contra iustitiam non peccet, qui id in odium fecerit, sed solū contra caritatem, quia iure suo vitur, ac proinde ad effectum, vt, stando in solo iure naturali, prohiberi non possit; iure tamen ciuili in commune bonum est statutum, vt, si id, & similia alia, efficiat, non in suum commodum & vtilitatem, sed ad æmulationem, atque vt præiudicium vicino afferat, tunc antequam fiant impediatur ea efficere, & vt suis sumptibus cogatur ea destruere postquam fuerint facta. Ita communis doctorum sententia, quam, inter alios, referunt ac sequuntur *Cepolla de seruit. vrb. præd. c. 62. n. 2. & Ant. Gom. l. 46. citata. n. 8. eamque probant. l. 1. §.*

iidem aiunt. 2. l. si in meo. ff. de aqua. plu. arc. l. fluminum. §. ult. l. Proculus. ff. de dam. inf. l. 3. ff. de operib. pub. c. l. 19. titu. 32. part. 3. dictumque est Disp. 704 ac alibi, vbi diximus, quando præsumentum sit, aliquid horum ad emulationem atque in odium esse factum.

De iure communi, quemadmodum nulli erat [sect. 8] licitum possideri castrum in limine imperii, nisi ex præsripto principis, alioquin capite plectebatur, & confiscabantur omnia illius bona, *vt habetur. l. 2. C. de fundis limitrophis lib. 11.* ita longè magis, sub eisdem pænis, nefas erat propria autoritate illud construere de nouo, etiam in proprio solo, in limine imperii, illudque possidere: quoniam si possidere castrum in limine imperii ea pæna plectebatur, multo magis eandem pænā incurrerat, qui illud propria autoritate cōstruebat ac possidebat: eademque ratione hodie pænam illam incurrat, qui in confinio regni non recognoscētis superiorem, atque vbi ius ciuile Romanorum locum habet, castrum possidet, aut construit in confinio eius regni, sine Regis autoritate. Ita communis doctorum sententia, quam Ant. Gom. l. 46. tauri. n. 14. refert ac sequitur, consentit glossa. l. 3. verb. tenuerit. ff. ad leg. Iul. maiest. De iure tamen communi prohibitum non erat facere castrum in proprio loco non iuxta limen imperii; modò tamen non fieret ad æmulationē alicuius oppidi, aut cum illius scandalo. *Ita habetur. l. 3. ff. de oper. pub. cuius verba sunt: Opus nouū priuato, etiam sine principis autoritate, facere licet, præterquam si ad æmulationē alterius ciuitatis pertineat, vel materiam seditionis præbeat.* Concinit. l. per prouincias. C. de ædif. priuat. cuius verba sunt: *Cunctis volentibus permittatur murali ambitu fundos proprios, seu loca sui dominii constituta, vallare, & affirmant Bart. Panor. & communis doctorum sententia, quam Ant. Gom. n. 14. citato refert ac sequitur, In hoc tamen regno nefas est cuicūque absque Regis facultate facere castrum, etiam in suo proprio solo, neque domum propriæ habitationis fortem, vt consentaneè ad iura mox referenda ait Ant. Gom. in calce. n. 14. citati. Lege enim. 8. titu. 5. lib. 6. nouæ collect. inter alia ad hanc rem attinentia, sic habetur: Y defendemos, que ningunas, ni algunas personas, de qualquier condicion y estado que sean, no sean osados hazer casas fuertes en nuestros reynos y señorios sin nuestra especial licencia y mandado, con acuerdo de los del nuestro consejo, y parecer de las ciudades, o villas, o lugares comarcanos, do la tal fortaleza se ouiere de hazer, &c. Idem habetur. l. 18. titu. 6. lib. 3. eiusdē nouæ collect. Et lex 46. tauri in fine sic habet: Pero por esto no es nuestra intencion, de dar licencia ni facultad para que sin nuestra licencia, o de los Reyes que de nos vinieren, se puedan hazer, o reparar, las dichas cercas, fortale- [[184]] zas: mas que sobre esto se guarden las leyes de nuestros reynos, como en ellas se contiene.*

Occasione verborum huius legis quærit Ant. [sect. 9] Gom. Vbi suprā n. 15. num, quamuis nullus in hoc regno possit absque Regis facultate efficere castrum, aut fortalitium, possit tamen antiquum reficere ac reparare. Partem negantem suadere videtur, præter legem tauri proximè relatam, quæ id apertè statuere videtur, *lex sacra. §. muros. ff. de rer. diuis. cuius verba sunt: Muros autem municipales, nec reficere licet sine principis, vel præsidis, autoritate, nec aliquid eis coniungere, vel supponere. Item. l. 1. §. penul. ff. de mortuo inferendo, cuius verba sunt: Aedificare non solùm, qui nouum opus molitur, intelligendus est, verùm is quoque, qui vult reficere.* Dicendum tamen est, quòd si fortalitium sit solo equatum, tunc nefas est illud reficere, seu reædificare, absque Regis licentia, non solùm si ob delictum esset iussum solo in pænam equari, (in quo euentu nulla potest esse difficultas) sed etiam si per se vetustate corruisset, aut infortunio solo esset æquatum: nam tunc reffectio illius esset ædificare illud de nouo, quod non licet. Interim tamen dum fortalitium, licitè possessum, permanet ac extat, prohibitum non esse domino illius illud reficere, siue ruinam minetur, siue non: neque id intendisse legem 46 tauri, quæ nihil de nouo ea in parte statuit, sed se remittit ad antiquiores

leges huius regni ea in parte statutas, vt perspicuè constat eam legēti: antiquiores autem leges huius regni non prohibent reparationem, quæ esset refectio propriè sumpta, sed solūm reparationem, quæ esset constructio noua castrī, aut fortalitii, siue iam antea in eodem loco fortalitium fuisset, & extarent ruinæ, siue non. Ac, præterquam, quòd rationi non esset consonum, refectionem pressè sumptam prohibere, id sanè cedere posset in præiudiciū vicinorum ac trāseuntium, quibus ruina illius nocere posset. Ad. l. sacra. §. muros, dicendum est, ibi sermonem esse de muris publicis oppidi, circa quos, etiam refectio, prohibita est priuatis auctoritate propria, sed incumbit præsidi, sumptibus priuatorū. Ad, l. 1. §. penul. ff. de mort. inf. dicendum est, vel nomine refectionis intelligi erectionem sepulchri de nouo in solo alieno, etiamsi ibi præcessisset, sine domini facultate: vel ibi, peculiariter refectio sepulchri, in solo alieno, absque domini soli facultate, est inhibita. Quorum autem sumptibus fortalitia ac muri refici debeant, & alia, quæ ad fortalitia in hoc regno spectant, præter. l. 20. titu. 32. par. 3. legas titulum. 5. lib. 6. nouæ collect. Atque dictis à Disp. 703. vsque ad hanc, explicata habes ea, ad quæ Disp. 11 lectorem remisimus.

De quæsi delictis circa res externas, iudicis videlicet, qui, sine dolo, culpabiliter sententiam iniussam tulit; patris familias, qui tenetur ad damna ex iis, quæ ejiciuntur de sua domo, absque sua culpa sequuta; nautarum, cau ponum, & stabulariorum, qui similiter tenentur de damnis à suis datis. Disp. 710.

SVMMARIVM.

1. *Q*Vasi delicta quæ.

2. *I*udex si absque dolo culpabiliter sententiam iniustam ferat, ex quasi delicto tenetur. Et an id sit delictum censendum.

3. *D*amnum datum in bonis externis ob rem effusam aut eiectam ex domo, aut naui, caput demus, aut nauis, soluit duplum, ex quasi delicto.

4. *C*aput domus in re proposita quis censeatur. Atque quando constat, quis damnum id dederit, is soluit tale duplum, vel damnum passo, vel capiti domus, qui illud soluerat loco illius.

5. *D*amnum si ex re eiecta, aut effusa, datum est in corpore hominis liberi, morsque est sequuta illius, quantum caput domus, aut qui deiecit, soluere teneatur ratione eius mortis, & cui sit soluendum. Si autem non sequatur mors, quid sit soluendum.

6. *D*amnum ex re eiecta, aut effusa, si datum sit, quanto tempore competat actio aduersus caput domus, aut aduersus eum, qui illud dedit, tum quādo damnum datum est in corpore, tum etiam quando datum est in aliis rebus, & num actio ad hæredes & aduersus hæredes transeat.

7. *D*amnum si sequatur ex re appensa, aut apposita, ita vt effundi aut decidere possit, ad illud tenentur caput domus, aut qui in culpa eius damni fuerunt, ac si ex re eiecta aut effusa esset

sequutum. Et ad quam pœnam teneantur, esto damnum non sit sequutum ob appensionem, aut appositionem periculosam, & qui ad eam teneantur. Et ad quem ea pœna pertineat.

8. Defurto & damno dato per ministros suos in nauigio, caupona, aut stabulo, tenentur nauta, caupo, & stabularius. Et ea actio transit ad hœredes eius, qui damnum est passus, non verò aduersus hœredes nautæ, cauponis, vel stabularii.

SVperest concludamus rem hanc totam de [sect. 1] delictis & quasi delictis circa bona

externa, eorum discussione quatuor disputationibus sequentibus, quæ idcirco quasi delicta nuncupantur, quòd quis absque sua culpa, atque adeò absque vero suo delicto, ad resartionem alicuius damni circa res externas dati, iuris dispositione teneatur.

Instituta de obligationib. quæ ex quasi deli [sect. 2] cto in prin. habetur. Quando iudex, non quidem dolo, aut muneribus corruptus, sed per imperitiam, aut negligentiam culpabilem, indebitè iudicando, litem suam facit, quia videlicet lis eo ipso aduersus cum competit, vt soluat damnum, quod ita culpabiliter indebitè iudicando dedit, teneri, non quidem ex delicto, sed ex quasi delicto satisfacere, quantum legitimus iudex ipsius, apud quem fuerit conuentus, iudicauerit. Nescio tamen cur hoc appellandum non sit delictū damni culpa sua lata, aut leui, dati, perinde atque quod ex simili culpa dant medicus, chirurgus, aduocatus, & similes alii, de quibus Disp. 697 est dictum, verum censetur delictum damni culpa ipsorum dati.

Quando aliquis dejicit aliquid ex domo, aut [sect. 3] ex alia simili re, vnde damnum est sequutum, quousq; dejiciens ipse teneatur lege Aquilia ad damnum, aut etiam in pœnam, tanquam ex vero delicto ipsius, Disp. 697 præsertim. §. quando aliquis cædit, & §. peculiariter, est dictum. Instituta de obligat. quæ ex delicto à §. 1. & l. 1. & sequentibus. ff. de iis qui deiecer. vel effud. habetur. Quando de domo alicuius aliquid est eiectū **[[185]]** vel effusum, siue in via publica, siue in priuata, siue in aliquo alio loco, per quem solent homines transire, aut in quo solent commorari, *vt habetur. l. 1. in prin. & §. 1. ff. de iis, qui deiecit. vel effud.* atq; adeò vt summatim dicam, ita vt meritò existimari deberet, nocere alicui posse, (intellige, nisi proclamatum priùs fuit, ita vt transeuntes, aut ibi existentes, cuitare optimè potuerint id damnum, & ipsorum culpa euitatum non sit, vt Disp. 697 citata explanatum est) atque ex ea deiectione, aut effusione, sequutum est damnum, tunc, si non sit in corpore hominis liberi, tenetur, qui in ea domo habitat tanquam caput illius, soluere illud duplum, esto ipse in nulla fuerit culpa, sed aliquis suorum domesticorum, aut hospitem, vel in ea domo quauis ratione existentium: & quia tenetur, esto ipse in nulla fuerit culpa, sed alius, qui id deiecit, aut effudit, idque ex rationabili ac optima iuris dispositione in commune bonum, ad cæterorum securitatem, & vt habitantes domos, tanquam eorum capita, cautiores sint, ne ex eis similia damna eueniant, iniuncto eis eo onere, vt resarciri similia damna faciliùs, puniriq; faciliùs eiusmodi delicta possint, inquirentibus ipsis postea maiori cum facilitate domesticos suos malefactores, ab eisq; recuperantibus, quod loco eorum soluerint, dicitur teneri, non quidem ex delicto, sed ex quasi delicto, *vt habetur. §. 1. inst. de oblig. quæ ex quasi delict. Hæc habentur. l. 1. in prin. & §. tuæ in factum, & l. penult. ff. de iis qui deiecit. vel effud. & l. 25. titu. 15. part. 11.*

Quando de naui aliquid est effusum, aut eiectum, & nocuit, vtilis etiam actio datur aduersus caput eius naui, vt soluat duplum eius damni, sicut datur aduersus caput domus, vnde aliquid est eiectum aut effusum, *vt habetur. l. penult. §. ult. ff. de iis qui deiecit. vel effud.*

Qui domum habitat tanquam caput illius, [sect. 4] tenetur ad id duplum soluendum, siue ita inhabitet suam propriam domum, siue alienam, quā habeat conductam, aut in qua gratis

concessa illi sit habitatio. *Ita habetur. §. 1. inst. de oblig. quæ ex quasi delict. l. 1. §. hæc in factum, & §. habitare. ff. de iis qui deiecit. vel. effud. & l. 25. titu. 15. part. 7.* Qui verò domum locauit, aut gratis concessit alteri ad habitandum, si ipse in ea simul non habitet, non tenetur ad id damnum, vt ex se liquet, & constat ex iuribus citatis: quoniam tenetur, qui tanquam conductor aut qui gratis eam domum habitat, & expressè habetur. §. hæc in factum. Si verò ipse habitet simul in eadem domo, tunc est distinguendum. Quoniam, si tanquam præcipuus eam totam domum habitet, esto alicui, quem tanquam domesticum, aut hospitem, habeat, cellam locatam habeat, tunc ipse solus cogitur soluere duplum damni: poteritque postea illud recuperare ab eo, qui damnum dedit, siue sit ille velut domesticus, aut velut hospes ipsius, siue quicumque alius. Hospes autem non tenetur tanquam caput domus, sed tanquam domesticus reputatur interim dum hospes est, vt habetur. l. 1. §. hospes. ff. de his qui deiecit. & l. 25. citata. Si verò dominus domus solùm habitet tanquam præcipuus partem eius domus, & partem aliam locatam, aut gratis concessam, habeat alius, qui tanquam præcipuus illam etiam habitat, tunc singuli tenentur in totum, & æqualiter, vt dicetur, nisi constet, ex qua parte eius domus sit eiectum: nam tunc is solus tenetur, qui tanquam caput eam partem domus inhabitat. Atque hæc omnia sunt, quæ intèduntur ac docentur. l. si verò. §. 1. & sequentib. ff. de iis qui deiecit. vel. effud. & consentit. l. 25. citata.

Si filius familias seorsum à patre habitet in alia domo tanquam caput eius domus ac habitationis, (id quod de iure communi frequentius erat, quàm de iure huius regni, aut Lusitano: eo quòd cōiugati, viuentē patre aut auo, filii familias erant) tunc damnum datum ex domo silii non tenetur soluere pater, sed aduersus filium, tanquam aduersus eius domus caput, competit ea actio. Idēq; est, si filius familias ex imperitia, aut negligentia culpabili, indebite iudicet: actio quippe ex eo quasi delicto, aut delicto, non aduersus patrem, sed aduersus silium familias competit. *Vtrūq; habetur §. si filius familias. inst. de obl. quæ ex quasi delict. & l. 1. §. si filius familias. ff. de iis qui deiecit. vel. effud.*

Quando multi habitant eandem domum tanquam capita, aut quia duæ familiæ permixtæ eādē habitant domum, aut quia habitant diuersas partes eiusdem domus, tunc, si non constat ex qua parte diuersæ habitationis elus domus id deiectum aut effusum sit, omnes, qui tanquam capita eam domum habitant, tenentur simul id duplum damni soluere, singuli in totum, ita vt quiuīs illorum indifferenter cogi possit id totum soluere. Vno verò integre illud soluente, cessat actio ex parte eius, cui id duplum est soluēdum, aduersus reliquos. Qui tamen soluit loco omnium, repetit ab aliis, quod loco eorum soluit. Quòd si constet, quis in particulari, id effundendo, aut ejiciendo, damnum illud dederit, ille solus cogitur illud soluere, idque actione legis Aquiliæ, vel immediatè ab eo, qui id damnum est passus, vel à capite domus, qui loco illius id soluit: qui si locatam illi habebat tanquam hospiti eam cellam, vnde id eiectum est, agere etiam ex locato poterit, vt id sibi soluat. Quando autem constaret, quis in particulari id damnum dedit, tunc, si ille non esset soluendo, solus, qui in ea habitatione esset velut caput illius, teneretur id duplum loco illius soluere: reliqui verò, qui tãquam capita habitarent etiam eandem domum, non tenerentur contribuere ad id duplū. Quando autem constaret ex qua parte domus id esset eiectum aut effusum, tunc, qui eam partem habitaret, teneretur duplum totum eius dāni soluere: non verò qui partes alias eiusdem domus habitarent, esto non constaret, quis in particulari id deiecerit aut effuderit. *Hæc habentur. l. 1. §. vlt. & tribus legibus sequentibus, ac. l. 5. in prin. & §. interdum, ac duobus sequentibus. ff. de iis qui deiecer. vel. effud. & l. 25. citatæ.*

Quando aliquid eiectum aut effusum est, ex [sect. 5] aliqua domo, & id nocuit corpori hominis liberi, tunc, si ille mortuus sit, cogitur similiter, qui tanquam caput eam domum habitat, soluere quinquaginta aureos, seu solidos: quos similiter repetit ab eo, qui id deiecit aut fudit. *Ita habetur. §. ob hominem inst. de obli. quæ ex quasi delict. l. 1. in prin. & §. sed cum liber. ff. de iis qui deijcer. vel effud. & l. 25. titu. 15. part. 7.* Lex verò 25. citata addit, dimidium horum quinquaginta solidorū soluendum esse hæredibus defuncti, & alterum dimidium soluendum esse fisco Regis. *Atque idē affirmant glossa. l. si verò. §. hæc autem actio verb. pænalis. ff. de iis, qui deiecit. & Bart. à Greg. Lopez. l. 25. [[186]] eitata relatus.* Quia enim æstimari non potest vita hominis liberi, ea pæna in illo euentu statuitur, quando sine animo occidendi illo modo fuit occisus. Si verò, quod ita fuit deiectum, aut effusum, nocuit quidem corpori hominis liberi, non tamen eum interficit, soluit similiter, qui domum tanquam caput inhabitat, simplam dāni æstimationem, computando iudicis arbitrio sumptus omnes curationis, & valorem mercedum omnium, quibus propter eam læsionem caruit, & quibus in futurum carebit, eaque similiter recuperabit postea ab eo, qui id damnum dedit. *Ita habetur. §. ob hominem inst. de oblig. quæ ex quasi delict. l. 1. in prin. & §. hæc autem verba, ac. l. ult. ff. de iis qui deijcer. vel effud.*

Actio, quæ aduersus caput familiæ compe [sect. 6] tit ratione damni ex eo sequuti, quòd ex ea domo aliquid eiectum aut effusum est, si damnum non sit in corpore hominis liberi, sed in vestibus, aut in aliqua alia re, est perpetua, & transit in hæredes eius, qui damnum accepit, & cui ea actio competit: non verò aduersus hæredes capitis domus. Si verò damnum sit in corpore hominis liberi, atque is interfectus sit, tunc actio solū competit per annum, neque transit aduersus hæredes capitis domus, neque transit ad hæredes interfecti, ea ratione qua hæredes sunt: eo quòd sicut in bonis corporis succedere non debebant hæredes, ita neque in æstimatione eius dāni succedunt: sed hæredes ex testamēto, aut ab intestato, quales sunt consanguinei, agere possunt intra annum ad eam pēnam, à morte interfecti, aduersus caput domus, si toto eo tēpore superstes sit, ipsique in ea actione (quæ popularis est, id est, competit cuius de populo) præferuntur cæteris, quatenus dimidium saltem eius pænæ ipsis est applicandum tanquam hæredibus interfecti, ac proinde plus ipsorum interest intentari eam actionem, quam cæterorum. Quòd si damnum sit in corpore hominis liberi, neque inde sit interfectus, comparatione ipsius, interim dum viuit, ea actio est perpetua: comparatione verò hæredum, ipso iam defuncto, solū competit per annum. *Hæc habentur. l. si verò. §. hæc autem actio. ff. de iis qui deijcerer. Consentit. §. ult. inst. de oblig. quæ ex quasi delict.* Quo loco obserua, si ita percussus non statim est mortuus, sed sumptus fecit in vulnere, aut ictu, curando, & tandem ex illo mortuus est, hæredes non solū posse agere ad pēnam quinquaginta aureorum, ratione mortis ex eo ictu sequutæ, sed etiam ad sumptus factos dum vixit, & ad mercedes suorū operum, quibus toto eo tempore fuit priuatus.

Quando aliquid est appensum, aut appositum, [sect. 7] supra viam, aut locum, per quem solent homines transire, aut in quo solent commorari, ita vt decidere, aut effundi, nocereque possit; tunc, si decidat, aut effundatur, ac noceat, ad idem tenetur caput domus, in qua est appensum, aut appositum, ad quod diximus teneri, si id ex eadem domo eiectum aut effusum esset: tenetur enim ad duplum damni, quod dederit, non in corpore hominis liberi, & ad soluendos quinquaginta solidos, si interficiat hominem liberum, atque ad sumptus, si illum non interficiat: reputatur quippe ac si ex eadem domo esset eiectum aut effusum: ac proinde ea omnia, quæ dicta sunt, quando aliquid eiectum aut effusum est de domo aliqua, sunt similiter dicenda in hoc euentu. *Ita habetur. l. 1. §. quod cū suspenderetur. ff. de iis qui*

delect. vel effud. §. cui similis, iuncto. §. ob hominem, inst. de oblig. quæ ex quasi delict. Et. l. 26. titu. 15. part. 7. Quando verò aliquid est appensum, aut appositum, ita ut nocere possit transeuntibus, aut subitus existentibus; tunc is ipse, qui id apposuit, aut appendit, incidit in pœnam soluendi decem solidos, propter periculum, quod est, ut decidat, vel effundatur, ac noceat transeuntibus, aut subitus existentibus. Is verò, qui domum habitat, tanquam caput illius, si id patiatur esse appensum, aut appositum, quia videt aut scit ita esse appositum, aut appensum, & illud non remouet, aut ita facit apponi, ut cesset id periculum, incidit in eandem pœnam. Quare hæc pars eiusdem interdicti omnes & singulos id apponentes, aut appendentes, & habitantem domum tanquam caput, qui id patitur esse appositum aut appensum, comprehendit, singulique in integram pœnam incidunt, integramque illam singuli tenentur soluere. Quòd si mancipium alicuius id apponat aut appendat, domino ad id non attendente, mancipium incidit in eam pœnam; eaque de causa mancipii dominus tenetur vel eam soluere loco mancipii, vel tradere mancipium noxæ, loco illius pœnæ. Si verò dominus mancipii patiatur id ita esse appositum, aut appensum, in domo suæ habitationis, iam tunc proprio nomine tenetur eam pœnam soluere: quia ipse iam est in culpa. Neque hæc pars interdicti loquitur, quando iam id decidit & nocuit, sed quando non decidit, decidereque poterat. *Hæc omnia habentur. l. si verò. §. prætor ait, & sequentibus. ff. de iis qui delect. vel effud. §. cui similis inst. de oblig. quæ ex quasi delict. & l. 26. titu. 15. part. 7.* quæ ait, dimidium huius pœnæ pertinere ad accusantem, & alterum dimidium ad fiscum Regis. Vtrum autem, quando appositum fuit, & decidit, dominus domus, in qua fuit appositum aut appensum, teneatur ad utramque pœnam, tam scilicet huius partis interdicti, quam prioris; *Glossa. l. si verò citata. §. si id quod verb. competit actio*, in fine, affirmanter respondet, cui subscribit *Greg. Lopez. l. 26. citata verb. el daño doblado*. Contrarium tamen existimo verum. Quoniam pœna huius partis interdicti solum est imposita pro appësis, aut apposis, quæ nondum ceciderunt, nec nocuerunt, sed cadere & nocere possunt: quando autem iam ceciderunt ac nocuerunt, non habet locum ea pœna, sed solum habet locum pœna prioris partis interdicti.

Qui nauigii præcipuam curam habent, cau [sect. 8] po, & stabularius, tenentur de furto & damno commissio in naui, caupona, aut stabulo, per eos, quorum ministerio inibi vtuntur: & quia in hoc euentu tenentur, non ex culpa sua, delictoque suo, sed ex culpa & delicto suorum, dicuntur ipsi teneri, non quidem ex suo delicto, sed ex quasi delicto: ipsi autem perspiciant, quorum opera ac ministerio vtantur, quia cum eo onere id munus censentur ex iuris dispositione suscipere. Hæc etiam actio non solum competit ei, qui id damnum est passus, aduersus habentem curam nauis, cauponem, & stabularium, sed etiã transit ad hæredes eius, qui id damnum est passus: non tamen competit aduersus hæredes habentis curam nauis, cauponis, aut stabularii. *Hæc habentur. §. item exercitor, & §. vlt. inst. de oblig. ex quasi delicto. Eo autem. §. vlt. habetur.* nullam actio-[[187]]nem, de quibus tota hac disputatione habitus est sermo, transire aduersus hæredes eorum, contra quos conceduntur. Atque hæc adiunge dictis Disp. 227.

Vtrum autem commemorati tota hac Disputatione, aduersus quos competit solum actio ex quasi delicto, (excipe iudicem, qui sua culpa indebitè sententiam tulit, quem ex proprio delicto teneri arbitror, atque in foro conscientie, nulla expectata sententia) teneantur id soluere in foro conscientie, ad quod actio aduersus illos datur, non expectata litis intentione aduersus eos, & quòd aduersus eos sententia feratur, Disput. 713 examinabitur.

Ad damnum à mancipio absque domini culpa datum quousque dominus teneatur. Disput. 711.

SVMMARIVM.

1. *Actio civilis in seruum, etiam ad pœnam pecuniariam, cum domino, & non cum seruo, intentatur. Tenetur verò dominus vel iudicatum soluere, vel seruum noxæ dare. Criminalis verò actio in seruum intentatur.*
2. *Damnum datum à mancipio non tenetur restituere dominus, nisi culpa m̃cipii sit datum, aut inde m̃cipium vel dominus facti sint locupletiores.*
3. *Seruus si delinquat, potest dominus illum defendere. Sequuta verò condemnatione, tenetur vel iudicatum soluere, vel seruum noxæ dare. Poterit etiam illum non defendere, sed noxæ statim dare ad vitandos litis sumptus.*
4. *Lite contestata ob delictum serui, si seruus moriatur, & constabat id delictum commississe, cogitur dominus soluere damnum ac pœnam.*
5. *Mancipium si delictum commisit domino sciente, ac prohibere potente, non liberatur tradendo illud noxæ, sed tenetur soluere damnum & pœnam, esto mancipium alienauerit, manumiserit, aut mortuum fuerit.*
6. *Mancipium statim atque à domino noxæ datur, dominus amittit dominium illius, & illud is cōparat, cui noxæ datur. Si tamen mancipium, cōparata aliunde pecunia, damnum & pœnam soluat, consequitur libertatem. In foro tamen conscientie tenetur soluere priori domino damnum culpa talis mancipii ei sequutum.*
7. *Mancipium, quod deliquit, si dominus alienauit, aut manumisit, non competit aduersus ipsum noxialis actio, sed aduersus nouum dominum, aut aduersus mancipium sui iuris effectū. Quòd si prior dominus titulo oneroso illud alienauerat, tenetur nouo domino de re ita vitiosa sibi alienata. Si autem dolo, sciens mancipii delictum, illud alienauit, ipse tenetur ad damnum & ad pœnam.*
8. *Mancipium, qui ob delictum quæreretur ad pœnam mortis, aut ad aliam grauem corporalem, occultare, & adiuuare ad fugam, posset dominus, quando contrarium in bonum publicum non esset iussum. Tradere verò illud absens posset noxæ ob damnum ab eo datum, & pœnam ciuilē.*
9. *Mancipii defensionem si suscipiat dominus, defendere illud tenetur in loco, in quo deliquit. Si moriatur mancipium ante sententiam, ad nihil tenetur dominus. Siue ciuilitè, siue criminaliter, agatur aduersus mancipium, si ex delicto aliquid actoris deuenit ad dominum, aut dominus inde factus est locupletior in aliquo, id quoque potest actor petere à domino.*
10. *Serui ex culpa non transit noxialis actio ad hēres domini, nisi ad ipsos seruus deueniat. Atque tunc transit, non quia hēres sunt, sed quia domini sunt talis serui.*
11. *Seruus multis communis si delinquat, quousque noxalis actio aduersus singulos aut omnes cōpetat.*

12. Damna culpa mancipii, sed absque domini culpa data, an dominus soluere teneatur ante latam sententiam, aut tradere mancipium noxæ.

MAteria huius, & sequentis disputationis, [sect. 1] affinis est quasi delictis, materiæ præcedētis disputationis. Iure ciuili. ff. C. inst. de noxalibus actionibus est sancitum, quando mācipiū alienū delictum aliquod absque domini culpa cōmisit, ratione cuius agendum est ciuilitèr, saltem ad pēnā pecuniariam, vt si furtum cōmisit, rapuit, dānum dedit, vel aliam iniuriam intulit, ita quòd locum habeat condictio aliqua, vel pæna pecuniaria, iudiciū illud non cum seruo esse intentādū, qui bonis externis caret, vnde soluat, ineptusque est, vt aduersus illum eo modo agatur, *vt habetur. l. ult. C. de noxalib. act.* sed intentandum esse aduersus eius dominum, qui ad alterum duorum, quod ipse potiùs elegerit, in eo euentu tenetur, nempe vel ad tradendū seruum pro noxia, trāsferendo dominiū illius in actorē, loco dāni dati ac pænæ, qua erat puniēdus, vel ad soluēdū dāna & pænam, qua fuerit condemnatus. Data verò est ea optio dominis mancipiorum, vt eligant potiùs dare noxæ mācipia, quando absque dominorum culpa mancipia delictū patrarūt: quoniam, *vt habetur inst. de noxalib. act. in prin. & consentit. l. 2. in prin. ff. eod. titu.* iniquum erat, nequitiam eorum contra ipsorum corpora dominis dānosam esse. Quando verò criminaliter est agendum ad mortis aut ad aliam corporalē pænam mancipii, tunc locum habet, iudicium cū mancipio ipso, intentarique proinde aduersus ipsum, & non aduersus illius dominum, debet, *vt habetur. l. penul. iuncto. l. 3. C. de noxal. act. Inst. de noxalib. act. in prin.* sic scriptum legimus: *Noxa autē est ipsum corpus quod nocuit, id est seruus; noxia ipsum maleficium, veluti furtum, damnum, rapina, iniuria.* Et quoniam in eiusmodi iudicio, quando nulla interuenit culpa domini, integrum ipsi est tradere noxā ipsam pro noxia, seu pro delicto patrato, actio ipsa, quæ aduersus dominum pro delicto serui intētatur, noxialis est nūcupata. Glos. ibidem verb. noxia sic ait: *Vnde versus, Noxia delictum, delinquēs noxa vocatur. sed quandoque vno pro alio utimur.*

Obseruādū verò est. Vt dominus mancipii dā [sect. 2] nū, quod mancipium dedit, soluere teneatur, aut tradere mācipiū loco dāni, necesse esse, vt dānū culpa mancipii datum sit. Si enim mancipium absque vlla sua culpa dānū aliquod dedit, quia aliud in potestate mancipii non suit; atque ex eo dāno neque ipsum, neque dominus eius, facti sunt locupletiores; tunc, quemadmodum mancipium, si esset sui iuris, ad nihil teneretur, quia neque ex parte rei acceptę, neque ex parte iniustę acceptionis, ita domin⁹ illius ad nihil ōnino tenetur. Quòd si ex eo mācipii dāno factus esset locupletior, tunc id solū restituere teneretur, in quo factus esset locupletior

Obseruandū est deinde. Dominum defendere [sect. 3] posse suum mancipium: quando autem succumberet, quia probatum esset, mancipium cōmisisse id delictum, tunc dominus per sententiam in eo iudicio ad alterum duorum ipsius optione est condemnandus, nempe, vt vel mancipium [[188]] tradat, vel soluat damnum totum ac pænam loco illius. Ita colligitur ex illis verbis inst. de noxalib. act. in prin. *Ex maleficiis seruorum, veluti si furtum fecerint, aut bona rapuerint, aut damnū dederint, aut iniuriam commiserint, noxiales actiones prodite sunt, quibus domino damnato permittitur, aut litis æstimationem sufferre, aut hunc hominem noxæ dedere.* Ecce domino iam damnato, ea optio conceditur. *Idem habetur apertiùs. l. 1. ff. eod. titu.* illis verbis: *Quarum (noxalium videlicet actionum) vis & potestas hæc est, vt si damnati fuerimus, liceat nobis, deditione ipsius corporis, quod deliquerit, euitare litis æstimationem. Consentit. l. 2. C. eod. titu.* Quod si sine defensione velit dominus mancipii illud noxæ dedere, vt liberet se à sumptibus, & à molestiis litis, poterit id efficere.

Illud tamen est obseruandum, si lis sit conte [sect. 4] stata aduersus dominum Mancipii, & de delicto illius constet, ita quòd in mora sit tradendi Mancipium, vt se liberet à resarciendo damno & à soluēda pæna, tunc, si Mancipium moriatur antequam lis absoluator, tenetur resarcire dānum, & soluere pænam, *argumento. l. 1. §. planè si ante litem. ff. si quad. paup. fecis. dica. iuncta Glossa* ibi, quo in textu idem satis innuitur, quando intentata fuit actio de pauperie, de qua disputatione sequenti erit sermo, nec traditum fuit animal, quod damnum dedit absque culpa domini: si enim id animal periit ante litem contestatam, cessat ea actio aduersus dominum animalis: secùs verò si post litem aduersus eum contestatam periit: nam tūc renetur ad damnum, vt ibi satis innuitur, & affirmat Glossa, quæ idem ait esse in noxiali actione, de qua loquimur, si post litem contestatam moriatur Mancipium, quod absque culpa domini dānum dedit, *citātq. l. si plurium. §. ult. ff. de noctialib. act. quæ tamen meo iudicio id non probat.*

Si domino iubente, consulente, aut sciente, [sect. 5] nec prohibente, quando prohibere potuit, mācipium commisit delictum, tunc non liberatur dominus, noxę mācipium dedendo, sed tenetur ad damna omnia, & ad pænas omnes pro eo delicto, esto Mancipium alienauerit, aut manumiserit post tale delictum commissum, vel Mancipiū moriatur: secùs autem si vel dominus ignorauit Mancipii delictum, quando mācipium illud commisit, vel esto illud sciuerit, prohiberetamē delictū non potuit: tunc enim liberatur, mācipium noxę dedendo. *Ita habetur, l. 2. 3. 4. 5. & sequentibus. ff. de noxialib. act. & l. 2. & l. penult. C. eod. titu.*

Si dominus Mancipium noxę det in euentu, [sect. 6] in quo id potest efficere, continuò amittit dominium illius, illudque comparat is, cui Mancipium noxę datur. Si tamen Mancipium quæsita pecunia, soluat damna omnia, & pænas cōdemnationis pro eo delicto, consequitur libertatem, prætorisq; auxilio manumittitur, etiam inuito co domino. Ita habetur. §. dominus inst. de noxal. act. Quo fit, vt id dominium reuocabile sit ex iuris dispositione, si Mancipium ipsum dāna & pænas soluat, quæsita aliunde pecunia. Cū enim loco damnorum ac pænarum nouus hic dominus consequutus sit dominium talis Mancipii, voluit ius, in fauorem libertatis, vt si Mancipium aliunde compensaret illi omnia damna, & solueret omnes pænas, libertatem consequeretur. Ex ea. §. citati dispositione intelliges, eiusmodi Mancipium ex iuris dispositione non teneri priori domino ad damnum amissionis ipsius, quod culpa talis Mancipii ei domino subsequutum est. Quandoquidem non redigitur in pristinam seruitutem, postquam se liberauit ab eo, in quem noxiam commisit. Id quod confirmatur ex. §. si seruus eod. titu. Vbi nulla actio competit domino in seruum, postquam est egressus ipsius potestatem, propter damnum, aut delictum, quod in eum dominum commisit quando in illius erat potestate: sicut nec seruo pro eodem tempore competit actio in dominum. Nescio tamen, an in foro conscientię mutuò teneantur seruus & dominus, ac teneri propendeo: quoniam denegatio actionis in foro exteriori non tollit obligationem, quæ ex natura ipsa rei oritur in foro conscientię, *consentiréq. videtur syluest. verb. restitutio 2. §. 1. in prin. & clariùs. §. 14.* Non tamen cogerem seruum, qui via paulo antè explanata libertatem consequitur, se iterum redigere seruitutē prioris domini, sed solū pecunia resarcire illi æstimationem dāni, quod culpa ipsius subsequutum illi fuit.

Si dominus, post commissum delictum per [sect. 7] suum Mancipium, illud bona fide alienet, aut manumittat, cessat actio noxialis aduersus talem dominum, & transit in nouum eius Mancipii dominum, aut in Mancipium ipsum, quod deliquit, sui iuris iam effectum. *Ita habetur inst. de noxial. act. §. omnis.* Si tamen titulo oneroso prior dominus id Mancipium alienauit, tenebitur posteriori domino, perinde ac si rem vitiosam illi vendidisset, iuxta ea

quæ Disp. 352 & 353 dicta sunt. Quod si in dolo fuit, quominus in potestate ipsius esset id mancipium, sciens delictū illius, tenetur noxiali actione ad totum damnum, & ad integram pœnam. *l. quoties, & l. de ille. ff. de noxial. act.*

Illud est obseruandum. Si mancipium deli [sect. 8] ctum commisisset, ob quod mortis, abscissionis membri, aut flagellorum pœna esset plectendum, licitè tunc dominus posset illud adiuuare ad fugam, transferreque illud in locum tutum: solumq; teneretur noxiæ illud dare, vbicunque esset repertum, pro damnis in bonis temporalibus, quæ offenso dedisset, & pro pœnis ciuilibus, quæ pro eo delicto ei essent impositæ, vel ea omnia soluere. Primum probatur, quoniam sicut quiuus alius posset adiuuare ad fugam, & occultare delinquentem, qui ad mortem, mutilationem, aut ad flagellorum, vel triremium pœnam quæritur, (quando tamen contrarium in bonum publicum non est iussum aut statutum) quia illud esset adiuuare delinquentem ad id, quod ipsi mancipio licet post delictum cōmissum; ita dominus potest adiuuare ad fugam atque occultare suū mācipiū, quod ad eandem pœnam quæritur.

Quando dominus actionem sur mancipii sus [sect. 9] cipit, tenetur illud defendere in loco, vbi delictum cōmisit. *l. vlt. ff. de noxial. act.* Si quis, ignorans mancipium suum, quod delictum commisit, mortuum esse, iudicium pro illo suscipiat, absolui debet. Quoniam, desinente mancipio, loco cuius intendebat soluere, desinit quoque obligatio soluendi pro illo: præsertim cū, facta condemnatione, integrum esset domino, vel eā soluere, vel mancipium noxæ dare, vt suprā dictum est. *Ita habetur. l. penul. ff. de noxial. act.* Eadē ratione credo, conce dendam ei esse repetitionem, si pro mancipio, quod mortuum iam erat, soluit: quandoquidem soluit indebitum. Si contra. **[[189]]** mancipium criminaliter agatur, & aliquid actoris ex delicto mancipii ad dominum illius peruenit, simul potest actor illud vendicare, vt est notissimum, & similiter petere potest ex domino mancipii, si in aliquo idem dominus factus sit locupletior ex tali delicto. Simili modo, esto agatur ciuilitè, & dominus mancipium noxæ dedat, repetere potest actor ex domino mancipii, si quid ex delicto talis mancipii ad dominum peruenit, aut si in aliquo ex eodem delicto factus sit locupletior. *Ita habetur. l. penul. & vlt. C. de noxial. act.* Aduersus hæredes domini mancipii non com [sect. 10] petit hæc actio noxialis, quando lis cum domino mancipii non fuit contestata: si tamen ad hæredes tansiisset mancipium, tunc aduersus illos competeret actio, non tanquam ad hæredes domini mancipii, sed tanquam ad possessores ac dominos eius mancipii. *Ita habetur. l. si plurium. §. vlt. & l. penul. si. de noxial. act.*

Quando mancipium aliquo modo est multis [sect. 11] commune, traduntur multa. ff. de noxialib. act. circa rem, de qua disputamus. Quia tamen molestum esset ea hoc loco explanare, raroque in praxi eueniunt, si aliquando mancipium, multis commune, delictum commiserit, actioque noxialis tunc intentetur, recurre ad illa iura, vt intelligas, quousq; singuli aut omnes teneantur vel non teneantur.

Vtrū autem dominus mancipii, ante inten [sect. 12] tatam noxialē actionem, latāmque sententiam, qua condēnetur resarcire damna, & soluere pœnas, vel mancipium noxæ dare, teneatur in foro conscientiæ, si de damnis, culpa quidem mancipii, sed absque vlla sua culpa, datis ei constet, vel soluere ea damna loco mancipii, vel mancipium noxæ dare, transferendo pro eis damnis mancipii dominum in eum, qui illa est passus, examinabitur Disp. 713.

Ad damna, quæ animalia bruta absque domini culpa dant, quousque eorum dominus teneatur. Disp. 712.

SVMMARIVM.

- 1 . *D*Amna ab animalibus, custodis aut domini culpa data, quousque soluenda.
- 2 . *D*amnum si animal alienum absque cuiusquam culpa det, cogitur dominus animalis vel illud tradere pro damno, vel id damnum soluere, & quando de subtilitate iuris ea actio sit directa, & quando utilis.
- 3 . *D*amnum in persona hominis liberi si animal alienum det, non competit actio pro eo damno. Pro damno tamen inde ulterius sequuto sumptuum, aut aliarum rerum externarum, actio prædicta competit.
- 4 . *D*amnum si det animal per aliquid aliud, vt per plastrum, tenetur dominus talis animalis. Si vnum animal aliud concitauit, & concitatum ea de causa damnum det, dommus concitantis tenetur, & non dominus concitati. Si animal aggrediens damnum alteri animali det, dominus illius tenetur. Si verò animal inuasum damnum inuadenti det, dominus animalis inuasi ad damnum non tenetur.
- 5 . *D*amnum si det fera fugiens, se recipiens in suã naturalem libertatem, ad nihil tenetur, qui erat dominus illius, esto illam postea capiat, dominiũmque illius ea captura comparet.
- 6 . *A*nimal, quod damnum dedit, si bona fide transeat in dominium alterius, nouus dominus tenetur de eo damno. Et ad quid teneatur prior dominus, etiam quando, sciens damnum, illud alienauit.
- 7 . *M*ortuo animali, quod damnum dedit, ante litem contestatam, dominus illius ad nihil tenetur, nec etiam ad carnes noxæ dandum. Si moriatur post litem contestatam, tenetur soluere integrum damnum. Si autem alius culpabiliter illud occidit, satis est, si dominus animalis cedat actionem legis Aquiliæ damnum passo aduersus occisorem, vel si soluat damnum.
- 8 . *A*ctio ob damnum ab animali alterius datũ & transit ad hæredes eius, qui damnum est passus, & aduersus hæredes domini animalis, si lis cum eo domino fuerat contestata; alioquin aduersus eos non transit, nisi animal ad ipsos pertranseat.
- 9 . *A*ctionem hanc intentare potest etiam is, cuius intererat non esse datum, vt commodatarius, & similes.
- 10 . *O*b damnum datum ab animali, quando dominus non teneatur.
- 11 . *D*amnum quando dedit animal, & dominus interrogatus in iudicio, an suum esset id animal, neganter respondisset, tenetur soluere integrum damnum.
- 12 . *D*amnum quando datum est ab animali communi multis, quousque aduersus singulos & omnes actio competat.
- 13 . *D*amnum ex animali datum, an in conscientie foro sit soluendum nulla expectata sententia, nec intentata actione, aut tradendum sit animal noxæ.

Disputatione 697, §. si aliena animalia, & se [sect. 1] quentibus, explanatum est, quousque

dominus brutorum animalium, aut custos eorum, teneantur ad damna, quæ ea animalia dant interueniente culpa domini, aut custodis, multaq; dicta sunt, quæ hoc loco dici etiam poterant: illo autem in loco ea legantur. Solùm hoc loco erit nobis sermo de damno, quod talia animalia dant absque vlla culpa domini aut custodis.

Quando brutum animal alicuius absque cul [sect. 2] pa, tam domini, quàm etiam cuiusuis alterius, damnum aliquod intulit cuicumque alteri animali, etiam homini libero, aut cuiuis alteri rei, datur alia actio noxialis aduersus dominum animalis, quod damnum dedit, vt vel damnum soluat, vel tradat animal ei, qui damnum est passus, pro eo damno. Porrò damnum, quod brutum animal ita dat, appellatur in iure pauperies, ad differentiam damni, quod culpa hominis datur, & actio, quæ aduersus dominum talis animalis pro eo damno competit, actio de pauperie nuncupatur, vt hæc omnia constant *insti. si quadrupes pauperiem fecisse dicatur in prin. & versiculis sequentibus, & l. 1. ff. eod. titu.* Pro eo autem damno, quod animal brutum culpa hominis alicuius dat, quatenus ita culpa hominis illud dat, competit actio legis Aquiliæ aduersus hominem, cuius culpa est datum, vt Disp. 697 explanatum est, atque hoc est quod docetur & intenditur. *l. 1. a. §. quod si propter loci feritatem. ff. si quad. paup. fecis. dicatur.* [[190]] De iuris ciuilis subtilitate, vt constat *inst. loco citato in prin. & vershæc autem actio, & l. 1. citata in prin. & §. generaliter*, actio de pauperie directa solùm competit, quando quadrupes, sine cōsuetudine innata toti suæ speciei, damnum dat, vt si equus recalcitrando damnum det, aut si bos cornu damnum der: neque enim consuetum innatumque est toti equorū speciei recalcitrare, neque omni boui esse cornupetam. Cæterùm vtilis actio de pauperie datur, & si brutum animal non sit quadrupes, sed bipes, & damnum det, vt *habetur. l. penul. ff. si quad. paup. fecis. dicat.* & similiter competit vtilis actio etiam si brutum, vt pātera, vel aliud animal, iuxta suam feritatem, damnum det, vt patet. §. vlt. *inst. si quad. paup. fecis. dicat.* & vniuersim actio de pauperie, non curādo vtrūm directa aut vtilis concedatur, datur pro quocūq; damno à quocunque animali sine culpa hominis dato, dum id animal in dominio alicuius est.

Si animal alienum, sine culpa alicuius homi [sect. 3] nis, noceat homini libero, tunc, si interficiat, aut deformitatem relinquat in homine libero, pro damno vitæ aut corporis, quatenus præcisè est damnum corporis, quia tale damnum æstimationem non recipit, non competit actio de pauperie, neque aliqua alia: pro damno tamen, quod ex nocumēto corporis hominis liberi vltèrius in rebus illius externis resultat, quoad sumptus in curando vulnere aut ictu, & quoad æstimationē operarum, quibus ea de causa priuatus est, & in futurum priuabitur, si mācus, aut claudus, vel alia ratione minùs aptus, aut omnino ineptus, ad laborandum maneat, competit hæc actio de pauperie, vt *vtrumque habetur. l. ex hac lege. ff. si quad. paup. fecis. dicat.*

Vt actio de pauperie locum habeat, satis est, [sect. 4] si alienum animal, vel per suum corpus immediatè, vel per aliquam aliam rem, vt per plastrum, aut euertendo aliquid, quod vltèrius sit causa damni, aut aliqua alia ratione, damnum det. *Ita habetur. l. 1. §. siue autem. ff. si quad. paup. fecis. dicat.* Quando vnum brutum animal concitauit aliud, atque in causa suit, quòd animal id concitatum damnum aliquod daret, tunc, quia animal, quod concitauit, principalis causa fuit eius damni, dominus illius tenetur actione de pauperie, non verò dominus animalis, quod fuit causa immediata damni. *Ita habetur. l. 1. citata §. & si alia.* Si duo animalia rixentur, & vnum interficiat alterum, aut illi noceat, si animal, quod priùs est aggressum, noceat

alteri, dominus illius, quod est aggressum, tenetur de pauperie. Quòd si alterum animal aggressori noceat, tunc dominus illius ad nihil tenetur. *Ita habetur ibidem. §. cum arietes.*

Quando fera alicuius fugit absque domini [sect. 5] culpa, & se recipiens in suam naturalem libertatem, damnum aliquod dedit, locum non habet actio de pauperie: quoniam illa eo ipso, quòd fugit, desiuit esse domini sui, vt ex dictis Disp. 41 constat. Vnde etiamsi postea ab eodem domino capiatur, ad nihil tenebitur, eo quòd de nouo comparet dominium illius, eo modo, quo quiuus alius illud compararet, si eam similiter caperet. *Ita habetur. l. 1. citata. §. in bestiis, & inst. eod. tit. §. cæterum.*

Si animal, quod damnum dedit, bona fide, [sect. 6] post damnum datum, trāseat in dominium alterius, tunc actio de pauperie trāsit aduersus nouū dominum, desinitque competere aduersus antiquum: quoniam actio illa ratione rei, quæ damnum dedit, trāsit in dominum illius, vt de noxali actione ob damnum à mancipio datum disputatione præcedente est dictum: reliquaque quæ ibi circa mancipium dicta sunt, similiter circa brutum animal, quod damnum dedit, & alienatur, vel perit, similiter intelligenda sunt. *Ita habetur l. 1. citata. §. & cum etiam.*

Si animal, quod damnum dedit, moriatur an [sect. 7] te litem contestatam, qua damnum à domino illius petatur, vel vt pro damno tradat animal, tūc cessat actio: atque innuitur loco citato, non competere actionem, vt tradat carnes, ea fortasse ratione, quòd carnes mortuæ non sint partes animalis, quod damnum dedit; eo quòd non sint eiusdem rationis & speciei cum illis, quæ erant in animali viuo; quippe tunc esse haberent carniū à forma animalis, nunc verò à forma cadaueris, quæ distinctæ sunt speciei. Quòd si animal post litem contestatam moriatur, cū notum tunc domino esset, suum illud animal id dānum dedisse, tenetur soluere integrum damnum, nec liberatur carnes tradēdo aut aliud simile animal. Si tamen illud animal culpabiliter ab aliquo alio sit interfectum, ita quòd aduersus illum alium competat domino animalis actio legis Aquiliæ, tunc satis est, si dominus eius animalis cedat eam actionem ei, qui damnum ex eo animali accepit, vt liberali actione intētata aduersus ipsum maneat. Obserua tamen, si maluerit soluere damnum, quod illud suum animal dedit, & intentare actionem legis Aquiliæ aduersus interfectorem illius, vt si videlicet plus valeat suum animal, quàm damnum, quod alteri dedit, posse optimè id efficere: quoniam domino, qui damnum ex eo animali est passus, sufficienter satisfacit, vel soluendo illi suum integrum damnum, vel cedendo illi actionem aduersus culpabiliter interfectorem animalis, quod damnum dedit, loco animalis, vt maluerit dominus talis animalis. *Hæc habentur. l. 1. citata. §. planè. §. noxæ, & §. si post litem.*

Actio de pauperie transit ad hæredes eius, qui [sect. 8] damnum est passus, & contra hæredes eius, cuius erat animal, quod damnum dedit; modo tamen ad illos perueniat illud animal, quoniam actio sequitur possessorem animalis: secūs autem si ad illos non perueniat animal, quia tunc aduersus illos ea actio non transit, quare simpliciter aduersus hæredes non transit. *Ita habetur. l. 1. citata. §. ult.* Obserua tamen, si dominus animalis fuisset in mora illud tradendi post litem aduersus eum contestatam, tunc, esto animal non transiret ad hæredes, sed mortuum esset viuento domino illius, trāsiret actio, cæpta cum defuncto, aduersus hæredes illius: quoniam & cum illo lis fuisset cōtestata, & quoniam factus esset debitor damni totius eo ipso, quòd post litem cum eo contestatam animal mortuum esset, vt dictum est: ad hæredes autem transit obligatio soluendi debita contracta omnino à defuncto.

Actionem de pauperie non solūm potest in [sect. 9] tētare aduersus dominum animalis, quod damnum dedit, is, qui dominus est rei, cui damnum à tali animali est datum, sed etiam quicumque alius, cuius interest, id damnum in ea re non esse datū, vt sunt cōmodatarius eius

rei, fullo, qui ad eam abluendam apud se illam habebat, & alii [[191]] similes. *Ita habetur. l. hæc actio. ff. si quad. paup. fecis. dic.*

Quando animal, vt canis ferox, constructus e [sect. 10] rat in aliqua domo, & aliquis, fugiēs ministrum publicum, intrauit domum, vbi erat constrictus, atq; in canem ligatum incidit, à quo damnum accepit, non datur ei actio de pauperie aduersus dominum eius animalis: quoniam ipse potius sibi fuit causa, eò ita accedendo, quòd acciperet à cane debite custodito id damnum. *Ita habetur l. hac actione citata. §. ult. & multo magis non competeret actio de pauperie aduersus dominum eius animalis, si, qui damnum accepit, eò accessisset dando operam rei illicitæ, vt ad furādum, vel ad aliud flagitium in ea domo committendum. Atque ex ea dispositione eius iuris conijcere ac iudicare facile poteris in similibus euentibus, quando ex eo capite non competat actio de pauperie, quòd, qui damnum ex animali accepit, ipse sibi illud quæsiuit, neque euitauit, cū euitare aut non quærere illud debuisset: præsertim quando dominus animalis cum debita cautela illud habebat, suoque iure utebatur, illud ita habendo. Quando aliquis, interrogatus in iudicio, an [sect. 11] suum esset animal, quod damnum dedit, neganter respondisset, tunc, si probaretur suum esse, teneretur integrum damnum soluere, nec satis esset, si pro damno animal offerret. Ita habetur. l. 5. §. interdum. ff si quad. paup. fecis. dic.*

Quando animal, quod damnum dedit, com [sect. 12] mune est multorum, locum habent, quæ circa noxalem actionem, quando mancipium, quod damnum dedit, est commune multorum, sunt disposita. *Ita habetur. l. 1. citata. §. si commune.*

Vtrū dominus animalis in foro conscientie [sect. 13] tiæ, si ipsi constet de damno, quod suum animal dedit, teneatur, nulla expectata actione & sententia, tradere animal pro damno, aut illud integrum soluere, sequenti disputatione examinabitur.

Vtrū in foro conscientie, nulla expectata actione, teneatur caput domus soluere dāna absque vlla sua culpa, à suis domesticis data projiciendo, effundendo, vel appendendo aliquid indebite de domo. Idem de nautis, cauponibus, & stabulariis, comparatione damnorum suorum famulorum. Et de domino mancipii, aut animalis, comparatione damnorum, quæ mancipium, aut animal, similiter dederint. Disp. 713.

SVMMARIVM.

1. Qui asserant damnum, absque lata culpa iuridica datum, non esse restituendum in foro conscientie ante latam sententiam.

2. Qui asserant damnum, absque culpa theologica datum, non esse restituendum in foro conscientie ante latam sententiam. Damnum verò culpa theologica lethali datum integre esse restituendum. Datum autem culpa solum veniali, pro parte solum esse restituendum. Excipiunt, quando ex damno, etiam nulla culpa dato, qui id dedit, est factus locupletior: nam tunc ad

id tenetur nulla expectata sententia. Et quando mancipium culpa sua theologica damnum dedit: nam tunc dominus vel tenetur mancipium noxæ dare, vel id damnum restituere.

3 . Damnum datum ab alio, siue sine culpa, siue interueniente illius culpa, etiam theologica, alter restituere in foro conscientie non tenetur ex natura ipsa rei seclusa dispositione iuris humani.

4 . Damnum datum absque culpa eius, qui iure humano præcipitur illud soluere, vt præcipiuntur capita domorum, nauis, cauponæ, stabuli, dominus mancipii, aut alterius animalis, neque in conscientie neque in exteriori foro tenentur illud soluere in aliis euentibus, quàm in expressis à iure, & quatenus à iure comperitur expressum.

5 . Damni dati non in recompensationem, quod inre humano eiusmodi omnes soluere interdum præcipiuntur, non tenentur illud soluere ante latam sententiam.

6 . Damni dati in compensationem, quod prædicti omnes iure humano soluere præcipiuntur, soluere non tenentur ante latam sententiam.

QVod propositum est, erit hoc loco exa [sect. 1] minandum circa dicta tribus præcedentibus

disputationibus: quod tamen pauci admodum in controuersiam vocant, Syluest. verb. rect. 2. in fine, in ea est sententia vt dicat, nullum horum in conscientie foro teneri restituere id damnum: quoniam arbitratur nullum eorum teneri restituere damnum, antequam actio aduersus eum intentetur ac damnetur, nisi culpa lata ipsius sit sequutum. Quæ autem tribus præcedentibus disputationibus dicta sunt, ait solum habere locum in foro exteriori, debetque in conscientia, si intentata sit actio: secus verò, si non intentetur. Idem dicerent Innocentius, & alii, pro ea sententia Disp. 698 citati, quod nullus lege Aquilia teneatur in foro conscientie restituere damnum culpa ipsius leui, aut leuissima, datum, antequam aduersus eum actio intentetur ac cõdemnetur. Quoniam arbitrantur, legem illam esse pænalem quoad recompensationem damni dati, quando solum interuenit culpa leuis, aut leuissima, eaque ratione nullum ad eam pœnam teneri ante condemnationem. Longè autem maiori cum ratione videntur idem dicturi de legibus tribus disputationibus præcedentibus relatis ac explicatis, quæ absque vlla dominorum culpa statuunt recompensationem damni à domesticis suis, ab ipsorum mancipiis, ac animalibus, dati: imò, quæ aliquando insuper statuunt solutionem alicuius quantitatis vltra valorem damni dati, pro delictis domesticorum, vt visum est.

Quidam alii in ea sunt sententia, vt dicant, Quando damnum culpa theologica dominorum est datum, teneri dominos in foro conscientie illud restituere. In hoc tamen sensu, quod, quando damnum culpa ipsorum lethali est datum, tenentur id totum restituere; quando verò est datum culpa ipsorum tantum veniali, tenentur solum restituere partem prudētis arbitrio, pro culpe quantitate. Quando verò, addunt, datum est, nulla interueniente ipsorum theologica culpa, [[192]] ad nullam restitutionem tenentur in conscientie foro, siue interuenerit aliqua eorum culpa iuridica, siue nulla: nisi tamen intentata aduersus eos in foro exteriori fuerit actio: nam in eo euentu locum habent iura tribus prioribus Disputationibus citata, quæ in foro exteriori concedunt actionem, atque adeò, tanquam iustæ ac rationabiles leges, in foro conscientie inducunt obligationem restituendi id damnum, si intentata ad id fuerit actio. Ab hac tamen regula excipiunt primò, quando ex damno dato factus est dominus locupletior: tunc enim in foro conscientie, nulla expectata intentione actionis, tenetur dominus restituere id damnum, quantum ex illo fuerit factus locupletior. Vt si absque vlla theologica sua culpa iumentum ipsius depastum fuit in segetibus alienis, eaque ratione

excusauit sumptum aliquem, quem facturus erat in eo iumento alendo, restituere in foro cōscientiæ tenetur, non quantum æstimabitur dānum, quod id iumentum in illis segetibus dedit, sed quantum ea via factus sit locupletior. Secundo ab eadem regula excipiunt. Quando mācipium alicuius sua culpa Theologica & absque Theologica culpa domini, damnum dedit: tunc enim, quia mancipium obligatum manet ad resarciendum damnum, quod ita sua culpa dedit, & ad soluendam pœnam, quæ propter illud iustè fuerit ei imposita, tenetur, inquiunt, mancipii dominus in conscientiæ foro vel tradere illud loco damni, & loco pœnæ pecuniariæ iustè vltèrius ob id crimen illi impositæ, vel, retento mācipio, compensare integre id damnum, & soluere insuper pœnam, si quæ fuerit pro eo crimine imposita. Quando autem mancipium puniendum esset pœna corporali, posset dominus transmittere mancipium in alium locum, persoluendo personæ, quæ damnum esset passa, folam dāni æstimationem, aut illi condonando ius mancipii illius, quod habet in illo alio loco, in recompensam talis damni, vel in illo alio loco vē dendo mancipium, & tradendo pretium personæ, quæ damnum esset passa, aut ex pretio, quātum præcisè esset satis ad id damnum compensandum, reliquumque sibi retinendo. Differunt verò hi autores ab autoribus prioris sententiæ. Primò, quia illi nihil loquuntur de hac posteriori exceptione. Secundò, quia cū dari possit damnum culpa lata, ita vt lethalis culpa non interueniat; & fieri etiam aliquando possit, vt, damnum dando ex sola culpa iuridica leui, culpa interueniat lethalis, vt vtrumque Disp. 698 est dictum, iunctis iis, quæ Disp. 293 sunt explanata; vtique, iuxta sententiam horum doctorum, aliquando non consurget obligatio restituendi in foro conicientiæ, esto damnum datū sit culpa iuridica lata, & aliquando consurgat, esto datum sit culpa leui: contrarium verò vtriusque partis affirmant doctores prioris sententiæ.

Quid de hac re sentiam, conclusiones sequē [sect. 3] tes aperient. Prima est. Stando in solo iure natu⁴⁹rali, seclusoque toto iure humano legum hac de re latorum, quando nulla interuenit culpa Theologica capitis domus, aut cæterorum, de quibus est hæc controuersia, ad nullam satisfactionem tenentur damnorum per suos domesticos, per suum mācipium, aut per sua animalia illatorum, esto domestici, aut mācipium, ea damna intulerint culpa ipsorum lata, aut culpa ipsorum Theologica, neque tradere tenentur mācipium, quod illa ita dedit, neque sua animalia, quæ illa dederunt, in recompensationem eorum damnorum. Probatur hæc conclusio. Quoniam, stando in solo iure naturali, seclusoque humano iure, quo aliquid ea de re disponat, obligatio restituendi solūm consurgit, vel ex parte rei acceptæ, vel ex parte iniustæ acceptionis, vel ex contractu & cōuentione partium, quæ ad aliquid se astrinxerunt, vt si depositarius, aut commodatarius, se astringant ad soluendam rem, quam suscipiunt, esto casu fortuito pereat, aut depositarius se astringat ad illam soluendam, esto ex minori sua culpa, quam lata, pereat: sed capita domorum, & reliqui, de quibus disputamus, non tenentur ex parte rei acceptæ; quandoquidem, quod deterius est redditum, aut omnino periit tali damno, ea ex parte, qua periit, aut qua deterius est redditum, non extat, neque inde facti sunt locupletiores, vt suppono: si enim in aliquo facti inde essent locupletiores, id vtique restituere tenerentur, tanquam fructum ex re alterius apud ipsos existens: neque item tenentur ex parte iniustæ acceptionis; quippe cū non peccauerint, vt supponimus, in eo, quod sui aut sua animalia id damnum dederint: neque denique tenentur ex pacto, quod inter ipsos & eum, qui damnum est passus, interuenerit: ergo nulla ratione tenentur compensare id damnum, aut partem aliquā illius. Quod si dicas, saltem, quando mancipium sua culpa Theologica damnum dedit, tenetur dominus vel id damnum resarcire, vel tradere pro illo mancipium, esto ipse in nulla fuerit culpa: eo quod, vt dicebant autores sententiæ posterioris

loco suprà relatæ, mancipium ipsum ex natura rei manet obligatum ad id damnum. Si, inquam, id dicas, in hunc modum probo contrarium. Quoniam mancipium ante delictum commissum erat domini sui, ac proinde dominus habebat verum ius in re in eo mancipio ad omnes operas illius, & ad omnem fructum, qui ex illo percipi poterat: ergo, stando in solo iure naturali, seclucisque noxalibus actionibus Disp. 711. relatis, posterior obligatio, quæ per suum delictū in eo mancipio oborta est ac resultauit ad resarciendum damnum sua culpa datum, præiudicare non potuit domino suo, qui anterior creditor cum iure in re reputatur comparatione illius ad omnia commoda, quæ ex illo poterant percipi; cū tamen obligatio, quæ in mancipio ex suo delicto resultauit ad resarciendum damnum, solū sit personalis comparatione eius, qui damnum accepit, ac proinde posterior hic creditor solū habeat ius ad rem, vt scilicet, si id mancipium aliquando consequutum sit libertatem, aut si, dum manet mancipium, aliqua bona habeat, quæ sint ipsius, & non domini, ex illis eis satisfaciatur damnum iniuste illatum. Hoc ipsum confirmant, quæ copiosè Disp. 536 sunt dicta, vbi ostendimus, creditorem habentem ius in re, & multo magis habentem dominium rei, præferendum esse cæteris creditoribus personalibus, & inter creditores habentes ius in re, antiquiorem præferendum esse posteriori: ergo si secludas leges noxales, quæ de iure humano introduxerunt, dominum mancipii teneri resarcire dānum à suo mancipio datum, vel illud pro eo tradere, vtique stando in solo iure naturali, domi-~~[[193]]~~nus ad neutrum tenebatur. Ex hac conclusione sic confirmata in foro, cū [sect. 4] caput domus, & dominus mancipii, aut alterius animalis, stando in solo iure naturali, non teneātur restituere damna per suos domesticos, per suum mancipium, aut per sua bruta animalia, absque sua theologica culpa, data, sed tota ea obligatio iure humano sit iniuncta, non plus eam esse extendendam, quàm iure humano, legibus tribus disputationibus præcedentibus relatis, comperiatur iniuncta. Quare domus cuiusque caput, neque in conscientiæ, neque in exteriori foro, tenetur soluere alia damna, quæ ipsius filii, vel famuli ipsius mercenarii, extra domū, absque culpa ipsius, dederint: nisi fortè, si eos liberare voluerit à vinculis, aut ab aliqua pæna, soluendo aliquid loco eorū. Quin neque tenetur soluere alia dāna, quæ dederint in domo sua, aut de sua domo, præterquam projiciendo, aut effundendo aliquid, vel appendendo, quod sine præuia sufficiente admonitione noceat transeūtibz, aut cōmorantibus in loco, in quo esse, aut per quē transire, homines soleant; vel nisi sint famuli, aut domestici, nautarum, cauponum, aut stabulariorum, & damnum inferant rebus ibi se recipientium, saltem eas furando, vt Disp. 710. est dictum. Similiter dominus mancipii non tenetur soluere damna, nisi quæ mancipium sua culpa dederit. Si enim aliqua absque sua culpa dederit, ita quòd mancipium ipsum, si sui iuris esset, non teneretur ea soluere, vtique neque dominus tenetur eadem soluere, tam in conscientiæ quàm in exteriori foro: quoniam iura de noxalibus actionibus non loquuntur de eiusmodi damnis, vt constat illa legenti ac expendenti: id quod aliqui non satis attendunt. Eadem ratione, quamuis dominus irrationalis animalis teneatur modo præcedente disputatione explicato ad damna, quæ suum irrationale animal dederit; non tamen tenetur ad damna, quæ res aliæ ipsius sensu carentes, absque vlla ipsius culpa, dederint: eo quòd iure humano sancitum non sit, vt id damnum solvatur. Item ad damna explicata tenentur illi, de quibus disputamus, eousque duntaxat, quo cis humano iure præscribitur, & non amplius. Vnde, si irrationale animal alicuius damnum aliquod det, & dominus toto tempore, quo postea possedit id animal, damnum ignorauit, esto post mortem animalis illius, id damnum sciat, ad nihil ei tenetur, qui damnum est passus: quoniam in eo euentu

non conceditur huic actio ad id damnum vt disputatione præcedente est dictum. Idemque est intelligendum de mancipio.

Secunda conclusio. Quicquid iuribus Disp.⁵⁰ 710. & 711. citatis, capitibus domorum, aut dominis mancipiorum, soluere præcipitur, quod nō sit in compensationem damni illati per domesti [sect. 5] cos, aut per mancipium, non tenentur illud soluere ante intentatam actionem & latam sententiā in exteriori foro. Verbi gratia, capita domorum soluere præcipiuntur duplum damni, quod domestici dederunt projiciendo, aut effundendo, aliquid de domo, sanè ante actionem intentatam & latam sententiam non tenentur soluere incrementum illud vltra damnum datum. Item, qui appendit, aut passus est in domo, in qua habitat, esse appensum aliquid, quod nocere possit transeuntibus, aut inferiùs existentibus, esto id nullum damnum dederit, cogitur soluere in pœnam decem solidos, sanè, cùm illud non solvatur in cōpensationē damni, nullus eorum tenetur id soluere ante actionem intētatam, & ante latam sentētiā. Similiter dominus mācipii soluere non tenetur ante latam sententiam, pœnam, qua mancipium est dignum propter dānum, quod intulit, & delictum, quod commisit. Ratio huius conclusionis est, quoniam ea omnia, quæ solui iubentur, & non in damni compensationem, iubentur solui in pœnam pro delicto domesticorum aut mancipii: pœna autem, sicut ab ipso domestico, aut mancipio, non debetur ante latam sententiam, ita neque à capite familiæ, aut à domino mancipii, debetur loco eorum, ante latam sententiam.

Tota ergo controuersia est circa id, quod sol [sect. 6] ui iubetur in recompensationem damni dati, siue per domesticos, siue per mancipium, aut per irrationale animal, num caput domus, nauta, caupo, stabularius, dominus mancipii, aut irrationalis animalis, teneantur in foro conscientie illa soluere, ante latam sententiam, intentatamque ea de re actionem, eo ipso, quod ipsis constat de damno, absque vlla ipsorum culpa, dato. Arbitror autem nullum diffiteri posse, in principe esse potestatem ad condendam in commune bonum legem, vt caput domus teneatur ad cōpensationem damni, quod domestici dederint, aliquid ejiciēdo, aut effundendo de domo, vt capita domorum vigilātiora sint in suos ea in parte, ne aliquod detrimentum in curia & negligētia eorum sequatur, & quoniam id postulat æquitas, cōmuneq; bonum, remanente in capite domus iure ad id repetendum ab eo, cuius culpa sequutū sit, si ille sit famulus mercede conductus, aut alius, qui possit illud soluere, à quōve repeti possit. Nullū item arbitror diffiteri posse, esse in principe potestatem ad similem legem cōdendā circa nautas, caupones, & stabularios, quando sui auferūt aliquid ab eis, quos in nauim, cauponam, aut hospitium recipiunt, vt vigilantiores sint in suos, videantque, quos tanquam famulos ac administros in domum suam recipiant, vel in domo sua habeant: & quoniam id similiter postulat æquitas ac bonum commune, cùm quasi in suam fidem recipiant eos, illorumque bona, quæ secum deferunt, quos in hospitium recipiunt, aut ad trāsportandum in sua nauī, & ne fortè ipsorum consilio & industria datum illis sit damnum, posteaque causentur, vt illud non restituant, absque vlla sua culpa esse datum, hospitesque ipsos cogant, sumptibus & molestia dum in transitu extra domos suas sunt, inquirere malefactores, suaque recuperare. Nullum præterea arbitror defiteri posse, in principe esse potestatem ad legem condendam, vt dominus mancipii tencatur vel resarcire dāna culpa mācipii aliis data, vel tradere mancipium in illorum compensationem, vt ea ratione domini mancipiorum vigilantiores sint circa ea, ne damnum aliis dent, & vt cum eo onere illa possideant, ne grauamen maximum alii de republica ex mancipiis recipiant, dum damna, quæ ab illis culpa eorum acciperent, nulla omnino ex parte compensare possent. Denique nullum arbitror defiteri posse, in principe esse potestatem ad similem legem condendam circa animalia rationis expertia, vt & domini

ipsorum vigilantiores sint in illis custodiendis, cauendoque ne aliis damnum inferrent, & [[194]] vt, qui damnum ab eis essent passi, vel ea via solamen aliquod acciperent, minusque grauarentur damnis ex aliorum eiusmodi an imalibus acceptis.

Status autem punctumque huius controuersiæ in eo est positum, vt videamus an mens legumlatorum iuribus, tribus disputationibus præcedentibus relatis, fuerit, vsque adeò arctare eos omnes, quod attinet ad præcisam compensationem damnorum aliis inde sequutorum, vt statim in foro conscientię tenerentur ea integre compensare, nulla expectata intentione actionis, qua ea compensatio ab eis exigeretur, relicta potestate dominis mancipiorum, atque animalium rationis expertium, vt potius traderent in compensationem damnorum mancipia ipsa, aut animalia alia, quæ illa dederunt: an verò mens legumlatorum fuerit, non adeò illos arctare, sed solùm condere leges his de rebus instar pænaliū, quibus tenerentur modis explicatis resarcire ea damna, dependenter ex eo, quòd ab illis exigerentur in exteriori foro, lisque cum illis contestaretur, & non aliter. Dixi paulo antea, quod attinet ad præcisam compensationem damnorum aliis inde subsequutorum: quoniam, quod attinet ad incrementum vltoriùs in pœnam aliquando statutum soluendum, facilè constat, non priùs eos teneri illud soluere, quàm lata sit ea de re sententia, vt conclusione secunda dictum comprobatumque est.

Mihi secundum, & non primum, videtur fuisse mentem legumlatorum, atque adeò nullum prædictorum teneri in foro conscientię compensare ea damna absque sua theologia culpa data, nisi dependenter ex eo, quòd exigantur, lisque aduersus ipsos in exteriori foro contestetur: atque quoad hoc, eas omnes leges esse, non quidem pœnales aduersus eos, qui coguntur ea compensare absque sua culpa: quoniam vbi nulla est culpa, non potest habere locum pœna, sed esse instar legum pænaliū, vt de lege Aquilia quoad damna, quæ compensare iubet ex culpa iuridica, absque vlla theologia culpa, Disp. 698 dictum etiam est. Ducor. Primò, quoniam præterquam quòd huiusmodi leges iubent id soluere, quod stando in solo iure naturali non debetur, vt in conclusione prima est ostẽsum, sanè, si primum, & non secundum, intenderent, rigidæ ad modum essent & irrationabiles, & quæ, attenta fragilitate humana, sine emolumento boni communis (cui sufficienter est consultum intendendo solùm secundum) laqueos conscientiis hominum injicerent, occasioque essent multorum peccatorum, atque adeò fortasse essent leges iniustæ: lex quippe, vt iusta sit, continere non debet onus graue & importabile, attenta fragilitate humana, maximè sine emolumento boni communis: credendum verò non est, legissatorem intendisse, quod irrationabile ac intolerabile esset, & fortè iniustum. Secundò, quoniam ex ipsismet legibus constat, secundum fuisse intentum earum legum, & non primum: nulla quippe earum concedit actionem aduersus hæredem cuiusquam horum, quando lis aduersus defunctum non fuit contestata antequam moreretur, idque instar legum pænaliū: si autem intentum harum legum fuisset, obligare hos in foro conscientię independẽter ex eo, quòd aduersus illos actio ea de re intentaretur, illique re ipsa in foro cōscientię statim ac damnum esset datum, tenerentur illud compensare independentẽter à quacunque actione, vtique actio concederetur ac transiret ad hæredes eorum, vt soluerent verum æs alienum perfectè à defuncto ante mortem contractum ac debitum, atque vt exonerarent conscientiam defuncti, iniquæque essent leges, quæ cam actionem denegarent aduersus hæredes, si primum, & non secundum, eisdem legibus intenderent. Quòd autem nulla earum legum concedat actionem aduersus hæredes horum omnium, quando lis cum defuncto ante ipsius mortem non fuit contestata, constat ex dictis tribus disputationibus præcedentibus. Tertiò, quoniam huiusmodi leges vsu videntur

solùm receptæ, vt soluantur hæc damna, si in foro exteriori exigantur, lisque contestetur aduersus horum aliquem antea quàm ex hac vita decedat: leges autem humanæ non plus obligant, quàm vsu sint receptæ: quare, esto primum, & non secundum, fuisset intentum legumlatorum, (quod tamen est falsum) iam hodie solùm obligarent ad secundum. Quartò, quoniam in dubio melior est conditio horum omnium, qui retinent sua bona, suntque in eorum possessione, quàm sit conditio eorum, quibus esset facienda illorum restitutio: quare, esto res, de qua agimus, non esset adeò certa, quàm certam esse ostendimus, sed esset dubia, amplectenda esset sententia, quæ ait, iubendos eos non esse restituere, antequam compensatio horum damnorum ab eis in foro exteriori exigatur.

DE RESTITVTIONE IN GENERE, ET CIRCA RES externas.

Quid sit restitutio. Et cuius virtutis sit actus. Disp. 714.

SVMMARIVM.

- 1 . *REstitutio tribus modis usurpatur. In duobus prioribus esse potest actus iustitiæ etiam distributiue. In tertio solum est actus iustitiæ commutatiue, esto debitum restituendi, ortum habuerit ex antecedente læsione iustitiæ distributiue.*
- 2 . *Restitutio latissimè, & præse, quid.*
- 3 . *Restitutio vnde dicta.*

SVperest concludamus secundum hunc de iustitia tractatum disputationibus de restitutione in genere, & circa bona externa. Iacimus enim nunc fundamenta ad omnem vniuersim restitutionem, etiam circa bona corporis, honoris, famæ, ac spiritualia, de quibus sermo nobis [[195]] erit duobus sequentibus tractatibus, descendemusque peculiariter ad restitutionem circa bona externa, quæ propria est huius secundi tractatus, longiorique indiget Disputatione. Vt verò intelligatur, quid sit restitutio in ge [sect. 1] nere, & cuius virtutis sit actus, obseruandum est. Restitutionem, quod ad rem præsentem attinet, tribus modis usurpari posse. Primò, latissimè, pro exhibitione eius, quod quis ex iustitia præstare tenetur: Quo pacto gratuita quidem exhibitio alicuius rei, restitutio non erit, attamen non solùm dicitur restitutio redditio, aut compensatio eius, in quo quis est defraudatus, sed etiam solutio pretii pro re empta eo tempore, quo constitutum erat vt solueretur, solutio mercedis pro re locata, tempore ad id statuto; redditio depositi, commodati, mutui pignoris, ac similiũ rerum, tempore congruo, & absque vlla mora, atque adeò antequam iniustitia fiat, tam formalis quàm materialis, in earum rerum detentione. Restitutio hoc modo accepta esse vtique potest, tam actus iustitiæ commutatiue, si id, quod redditur, ex iustitia commutatiua debeat, quàm actus iustitiæ distributiue, si, quod redditur, ex iustitia distributiua debeat. Distributio quippe bonorum communium iuxta cuiusque merita, facta tempore, pro quo iustitia distributiua obligat, actus sanè est iustitiæ distributiue. Atque restitutio hoc modo sumpta non aliud est, quàm exequutio actus iustitiæ, siue commutatiue, siue distributiue, tempore quo, qui eum exequitur, ad id tenetur.

Secundo modo sumi potest restitutio pressius, pro exhibitione eius, quod quis ex iustitia præstare tenetur, præcedente iam iniusta illius retentione, saltem materialiter. Hoc modo redditio depositi, commodati, mutui, aut pignoris, pretii pro merce, tempore constituto, ita quòd nondum interuenerit iniusta aliqua mora, non dicitur restitutio, esto, quod soluitur, de iustitia debeatur: horum tamen solutio, si iam præcessit iniusta mora, dicitur restitutio in hac secunda restitutione nis acceptione.

Restitutio hoc modo sumpta, esse etiam potest actus, tum iustitiæ commutatiuæ, tum etiã iustitiæ distributiuæ. Quamuis enim aliquis in mora fuerit distribuendi bona communia tẽpore, quo tenebatur, atque adeò peccauerit omissionis peccato exercendi actum iustitiæ distributiuæ, si tamen eadem bona adhuc perseuerent communitatis, & per eum illis distribuuntur, quibus erant distribuenda, talis distributio erit iustitiæ distributiuæ actus, vt liquet.

Tertio modo sumi potest restitutio adhuc pressius & proprius, pro exhibitione eius, quod idcirco aliquis ex iustitia reddere tenetur, quòd alius iniuste formaliter, aut materialiter, fuerit in aliquo defraudatus aut læsus. Nomine defraudationis ac læsionis in re proposita intelligo, carere illum aliquo, quod habere debeat, siue illud sit membrum, siue honor, fama, bonum spirituale aut externum, & siue illo careat per furtum, rapinam, aut contractum iniustum, siue quia illi est damnum datum, vel impediendo illum ab assequutione alicuius boni, siue quauis alia ratione iniusta, saltem materialiter. Dixi idcirco, quòd alius iniuste formaliter, aut materialiter, fuerit in aliquo defraudatus aut læsus; vt comprehenderem, tum eam restitutionem, cuius obligatio oritur ex parte iniustæ acceptionis, hoc est, defraudationis aut læsionis, in qua defraudatione, aut læsione, formaliter interuenit iniustitia: tum etiam eam restitutionem, cuius obligatio oritur ex parte solius rei acceptæ, in qua defraudatione solùm interuenit iniustitia materialiter, & non formaliter. Sub restitutione hoc modo sumpta non comprehenditur id, quod contractu, aut alio titulo iusto, debetur, siue interuenerit mora iniusta in solutione illius, siue non: id enim non debetur propter iniustam moram, neque quòd alius iniuste materialiter, vel formaliter, sit defraudatus aut læsus, sed debetur ex iusto titulo præcedente. Quòd si mora illa iniusta damnum aliquod illi dedit, saltem lucri cessantis, tunc compensatio illius, quæ est insuper facienda, pertinet ad restitutionem hoc modo acceptam: eo quòd sit pro damno iniuste dato, atque adeò pro defraudatione ac læsione iniusta. De restitutione hoc tertio modo sumpta intelligendus est *D. Thom. 2. 2. q. 62. art. 1. iuncta responsione ad tertium*. dum ait, restitutionem esse actum iustitiæ commutatiuæ, etiam quando obligatio restituendi ex eo habuit ortum, quòd aliquis contra iustitiam peccauerit distributiua, defraudando aliquos rebus, quos ex iustitia distributiua eis tribuere debebat iuxta meritorum ac dignitatis cuiusque proportionẽ. Licet enim peccatum, quo, usurpando ea sibi, aut aliis illa tribuendo, ea distribuere omisit, quibus ex iustitia distributiua tenebatur, fuerit peccatũ contra iustitiam distributiua; inde tamen oritur illi obligatio compensandi vnique illorũ ad æqualitatem arithmeticam damnum totum, quod ea omissionem dedit, ita vt tantum vnique persoluat, quantum habiturus erat, ex iustitiæque distributiua erat ei antea debitum. Atque debitum hoc personæ illius, quæ ita antea contra iustitiam distributiua peccauit, non est iam illius quatenus persona publica, cui distributio bonorum communium ac publicorum per iustitiam distributiua incumbit, sed est illius quatenus persona priuata, quæ in se ipsa per omissionem illam id debitum contraxit, vt in defectum bonorum, quibus illos defraudauit, teneatur illud soluere ad æqualitatem arithmeticã atque ex iustitia iam commutatiua de suis propriis bonis, ortum habente hoc debito de iustitia commutatiua, ex

delicto contra iustitiam distributivam, quod antea contra illos commisit: quare id debitum eam personam comitatur, etiam quando esse desiuit persona publica. *Observant verò optime Cai. 2. 2. q. 62. art. 1. & Sot. 4 de iust. q. 6. art. 1. ad. tertium.* quando aliquis contra iustitiam omisit distributionem aliquorum bonorum, quæ inter aliquos iuxta proportionem meritorum ad merita erant distribuenda, restitutionem, siue sit eorundem bonorum, quæ adhuc extant, siue aliorum, faciendam esse illis ipsis, inter quos erant distribuenda, aut illorum hæredibus, non verò aliis de communitate, qui, quando facienda est ea restitutio, præsentis sint, & qui soli ius habeant, vt bona communia præsentia inter ipsos solos distribuuntur.

Iuxta hactenus dicta, restitutionem latissi [sect. 2] mē sumptam sic possumus definire: Est actus, quo redditur, quod ex iustitia debetur. Is verò a-[[196]]ctus interdum ac frequentius est iustitiæ commutativæ, interdum verò, licet rariùs, est iustitiæ distributivæ, vt explanatum est. Restitutionem autem pressè sumptam possumus sic definire: Est actus, quo ex iustitia commutativa redditur seu exhibetur aliquid in recompensationem eius, in quo aliquis formaliter aut materialiter defraudatus aut læsus est. Intellige, siue quod ita redditur, sit illud idem numero, in quo quis defraudatus aut læsus est, siue aliud loco illius, quando idem numero reddi non potest, aut non est necesse vt reddatur, vel quia is, cui facienda est restitutio, contentus est æquivalenti, vel quia res sunt æqualis bonitatis, & eiusdem rationis, consistuntque in pondere, numero, aut mensura.

Quod verò ad nominis significationem, ety [sect. 3] mologiamque, attinet, restituere est iterato statuere aliquid in pristinum statum: vnde restitutus aliquis dicitur in pristinam dignitatem, rei publicæ, filiis, &c. habetque id locum, siue ex gratia, siue ex debito, sit in statum pristinum reductus. A theologis verò sumitur restitutio pressè & propriè, pro reductione ex debito iustitiæ defraudati ac læsi ad statum, in quo antea erat, quoad id fieri potest, ac debet, vt explanatum est, siue reddendo illi idem numero, in quo defraudatus ac læsus est, siue æquivalens modo explicato.

Discrimen inter restitutionem, & satisfæctionem, & num pro iniuria & offensa, sumptis præcisè, à damno dato, restitutio debeatur? Disput. 715.

SVMMARIVM.

1. *REstitutio pressissimè, quid.*
2. *Satisfactio quot modis usurpetur, & in quæ acceptione à restitutione pressissimè sumpta distinguatur, & comprehendatur sub restitutione pressè.*
3. *Satisfactio, qua Deo pro peccatis satisfacimus, quid. Actus est suo modo iustitiæ commutativæ ex parte nostra, Dei comparisonem.*
4. *Satisfactio, quæ pars est sacramenti pœnitentiæ, quæ.*
5. *In peccatis contra iustitiam iniuria & offensa distincta est à damno dato: atque cum æqualitate dāni esse potest maior iniuria & offensa in vno peccato, quàm in alio.*

6 . Restituendi ac compensandi ad aequalitatem damna iniuste data, obligatio est in foro conscientiae nulla expectata sententia. Iniuria verò ac offensa sumptis praecise à damno dato, non restitutio, sed pœna respondet, quam subire obligatio non est in conscientiae foro ante latam sententiam.

7 . Satisfactio pœnis, quæ in hoc seculo à ministris publicis aut à Deo pro peccatis infliguntur, multum minuit de pœnis, quæ infligendæ erant igne ex purgatorio, aut quæ aliter satisfaciendæ erant in hoc seculo.

8 . Priuati iniuriam passi, quamvis licite exigere de malefactoribus panam coram potestatibus publicis possint; & potestates publicæ teneantur de iustitia commutatiua illam infligere; non tamen priuati possunt sua autoritate illam decernere ac sumere. Seclusa tamen dispositione in contrarium iuris humani, transigere possunt & accipere aliquid pro iure, quod habent ad pœnam exigendam.

9 . Restituendi obligationem consurgere ex solo damno, & non ex iniuria & offensa, sed pro his petendum esse veniam, si offensus inde sit commotus, & deberi pœnam solum post latam sententiam, & quousq; offendens licite se possit defendere in iudicio, ne sibi imponatur, variis exemplis explanatur ac comprobatur.

10 . Pœna licet statuatur ipso iure, aut ipso factu, cur subeunda ac soluenda in foro conscientiae non sit ante latam sententiam.

11 . Compensatio occulta licet interdum licita in foro conscientiae sit pro damno iniuste accepto, cur similiter licite non sit compensatio aliqua occulta pro iniuria præcisa à damno dato.

12 . Discrimen quoddam inter restitutionem, & eam satisfactionem, quæ pars est sacramenti pœnitentiae.

SI ad vim nominis, restitutio, in calce præce [sect. 1] dentis disputationis explanatam,

attendas, restitutio pressius adhuc & proprius sumpta est reductio defraudati ac læsi ad id omnino, in quo ante defraudationem ac læsionem erat, quod sit reddendo illi idem numero, in quo fuit defraudatus ac læsus.

Satisfactio verò multis modis sumitur: Pri [sect. 2] mò, latissimè ac propriè, pro impletione eius, quod quis modo aliquo debet. Quo pacto sumpta comprehendit restitutionem in tribus acceptionibus disputatione præcedente explanatis, ac proinde comprehendit etiam quartam acceptionem pressissimam restitutionis proximè explicatam, sub tribus illis aliis acceptionibus cōprehensam. Secundò sumitur, vt distinguitur à restitutione pressissimè ac proprissimè sumpta, nempe pro impletione, seu exhibitione, in æquialèti eius, quod quis debet. Hoc modo, quia dānorum illatorum, non vsurpando aliena, sed læsionem, iacturamve, in rebus aliorum efficiendo, itemque iniuriarum & offensarum, non potest esse compensatio nisi in æquialenti, consequēs profectò est, vt compensatio damnorum, iniuriarum, ac offensarum, non sit restitutio pressissimè ac proprissimè sumpta, sed sit satisfactio à tali restitutione distincta. Hinc Greg. c. ult. de iniuriis & damno dato, pro iniuria & damno culpa, saltem iuridica, dato, satisfactionem fieri præcipit.

Si ergo satisfactionem sumamus pro compensatione ad aequalitatem damni, de quo loquimur, iniuste illati, sumptique præcise ab iniuria ac culpa in eo dando commissa, vtique satisfactio hoc modo sumpta distinguitur à restitutione pressissimè sumpta, & vnà cum ea, tanquam pars subiecta, comprehenditur sub restitutione in tertia acceptione præcedente disputatione

explicata, & per consequens comprehenditur etiam sub duabus aliis prioribus acceptionibus eadem disputatione explicatis.

Vt verò simul explicemus secundum, quod in titulo disputationis est propositum, ostendamusque restitutionem non deberi pro iniuria & offensa, sumptis præcisè à damno dato, sed solùm pro damno iniuste dato sumpto damno latiùs quàm hactenus in hac disputatione à nobis sit sumptum, nempe, vt comprehendit etiam iniustam vsurpationem, aut retentionem, rei alienæ, alterive debitæ, & simul explicemus, in quo differat restitutio sumpta ita latè (si enim rectè attendas, comprehendit latitudinem totam re-[[197]])stitutionis in tertia acceptione disputatione præcedente explanata, modò adiungas restitutionem, cuius obligatio oritur ex parte solius rei acceptæ, & non ex parte iniustæ acceptionis) à satisfactione, qua Deo pro peccatis nostris satis [sect. 3] facimus, & à satisfactione, quæ tertia pars est sacramenti pænitiæ, obseruandum est. Nos peccatis omnibus nostris Deum offendere, nullum tamen dānum illi inferre, sed neque inferre illi posse. Quatenus autem peccata nostra offensæ sunt Dei, digni pro illis sumus pæna, dimissaq; per contritionem, aut attritionem & sacramentum, culpa, manet sæpe pæna pro illis soluenda, vt suo loco est copiosè ostendēdū. Hæc autem pæna si à Deo in alia vita ex purgatorio igne infligatur, sane ea inflictio ex parte Dei effectus est iustitiæ vindicatiuæ, qua de nobis iustam vindictam, supplicium ve iustum, sumit. Ex parte verò nostri non tam est satisfactio, quàm satis passio: eo quòd extra statum iam simus merendi ac satisfaciendi, neque ibi attendat Deus voluntatem, qua id patimur, vt iuxta patientiam ac caritatē, qua id patimur, cōpensemus tunc partem aliam pænæ, qua eramus digni, Deusque proinde, iuxta eandē patientiā ac caritatem, sit contentus minori vel maiori pæna, sed ibi solùm attendat ad latitudinē ac quantitatem pænæ, vt proportionata sit ei, quod adhuc pro delictis & offensis, iuxta leges ab eo ea de re constitutas, soluendum restat. Dū autem in hac vita in gratia amicitiaque ipsius sumus, quemadmodum operibus nostris vim merendi, Christi meritis innitendo, tribuit; & quēadmodum voluit, vt per sacramenta Christi merita ex opere operato nobis applicarentur, ita quòd nobis infunderetur aut augeretur gratia, qua vita æterna, aut maiori vita æterna, essemus digni: sic voluit, vt eadem nostra iusta opera, ac pænalitates, quas nostra sponte pro eo susciperemus, aut pateremur, essent (Christi meritis ac satisfactioni similiter innitendo) satisfactoria pro pæna igne ex purgatorio luenda; & insuper voluit, vt virtute sacramentorum ac indulgentiarum, ex opere operato nobis applicaretur satisfactio Christi & Sanctorum, in Ecclesiæ thesauro reseruata. Quod itaque in hac vita Deo reddimus, ex ipsius dispositione, in recompensationem pro pæna, qua nostris peccatis sumus digni, itemque, quod similiter ei reddimus in hac vita in recompensationem pro pæna, qua digni adhuc sunt, qui ex purgatorio igne puniantur, appellatur, vereque est, satisfactio nostra, qua Deo pro peccatis nostris satisfacimus, estque actus, qui ad iustitiam commutatiuam reducitur, eo modo, quo inter nos & Deum iustitia esse potest. Quoniam iuxta leges ipsius, ac Christi vt hominis, reddimus illi æquiualens pro pæna ob nostra delicta, aut fratrum nostrorum, qui ex purgatorio igne cruciantur, debita. Pars au [sect. 4] tem huius nostræ satisfactionis, illa scilicet, quæ in sacramento pænitiæ à confessario ex Christi institutione in pænæ satisfactionem, quæ remanet dimissa culpa, atque in medicinam salutarem, virtute clauium nobis iniungitur, & quam, iuxta præceptum ac onus ab eo ibi nobis impositum, postea adimplemus, est satisfactio, quæ tertia pars est sacramenti pænitiæ, cum duobus prioribus, nempe cum confessione, præuia aut comitante, contritione, vel attritione, & cum absolutione, tanquam vltima pars illius integralis, vt vocant, illud omnino complens ac perficiens.

Illud deinde est observandum. In iis nostris [sect. 5] peccatis, quæ sunt contra iustitiam, duo esse considerata. Vnum est damnum, quod proximis inferunt. Alterum verò est offensa, qua illos offendimus, seu iniuria ac culpa, quam in illos committimus. Verbi gratia, cæteris paribus, si quis furetur æquale à paupere & à diuite, sanè æquale damnum vtrique infert, plus tamen offendit pauperem, maioremque iniuriam ac culpam in eum committit, quam offendat diuitem, & quàm iniuriam ac offensam in eum committat, vsque adeò vt ex hac circum stantia interdum iniuria & offensa facta vni perueniat ad culpam lethalem, quando iniuria & offensa facta alteri ad læthalem culpam non peruenit, vt Disp. 685. & sequentibus, cum communi doctorum sententia, est ostensum. Item, si cætera sint paria, & vnus plus diligat rem aliquam, quàm alius, vehementerque doleat, illa priuari, sanè grauius peccat, qui illam ab eo furatur, quàm qui eandem, aut aliam illi prorsus similem, ab alio furatur, adeò vt Nauar. & alii dixerint, ex hac sola circumstantia aliquando offensam proximi pertingere ad lethalem culpam, quando, seclusa illa circumstantia, id non esset culpa lethalis, vt ibidem retulimus; cum tamen damnum vtrique illatum æquale sit. Præterea culpæ & offensæ, quibus proximos contra iustitiam offendimus, non solùm eos offendunt, sed etiam rempublicam, communeque bonum, quatenus proximi offensi partes sunt reipublicæ & communitatis, & quatenus reipublicæ pacem ac securitatem perturbant ac impediunt, rempublicamque fædant ac denigrant. Nec solùm id habent culpæ, quæ sunt contra iustitiam, sed etiã pleræque aliæ, vt deserere suum locum in bello, & transgredi præcepta alia ad militarem disciplinam attinentia, committere sodomiam, se ipsum interficere, & alia eiusmodi, quorum proinde punitio ad publicam spectat potestatem.

His ita explicatis, dicendum est. Ex illatione [sect. 6] damnorum proximis iis nostris peccatis, quæ sunt contra iustitiam, consurgere obligationem ex commutatiua iustitia illa ad æqualitatem resarciendi ac compensandi nulla expectata iudicis sententia, vt ea inæqualitas, in quibuscunque illorum bonis iniustè data, ad æqualitatem reducatur in aliquo æquiualentem. Atque ciusmodi satisfactionem esse, quæ, cum restitutione pressissimè ac proprissimè sumpta, comprehenditur sub restitutione disputatione præcedente definita ac explanata. At verò ex iniuria & offensa proximi contra iustitiam in eum commissa, considerata præcisè à damno dato in quibuscunque illius bonis, nullam consurgere obligationem illam compensandi ante latam sententiam. Ratio autem est, quoniam, vt sic spectatur, nullum proximi bonum minuit, neque corporis, neque honoris, aut famæ, neque externum, sed solùm cum offendit, sicut nostris quibuscunque peccatis Deum offendimus; eaque de causa, qui illa proximum contra iustitiam offendit, dignus quidem est pæna pro quantitate talis delicti ac offensæ, non tamen consurgit obligatio quicquam ob illam satisfaciendi. Hinc dico, iniuriam & offensam proximi contra [[198]] iustitiam, consideratam præcisè à quocunque damno proximo illato, itemque tam ipsam, quàm quodcunque aliud debitum, spectata vt cedunt in iniuriam reipublicæ, atque vt sunt contra bonum commune, esse quidem materiam & obiectum iustitiæ vindicatiuæ, vt pæna debita pro illis infligatur, competensque vindicta de illorum patratoribus sumatur; non verò esse materiam & obiectum iustitiæ commutatiuæ, quasi inde obligatio consurgat de iustitia ex parte delinquentis aliquid ob eam iniuriam ac delicta compensandi, nullo expectato præcepto ac sententia iudicis. Iustitia autem vindicatiua, vt tractatu 1 in calce disputationis 12 dictum est, non est pars subiecta iustitiæ, sed potentialis, & ideo neque est iustitia distributiua, neque commutatiua propriè, sed reducitur ad commutatiuam iustitiam, quatenus pænam infligit iuxta proportionem arithmetica, vt tanta sit, quanta est iniuria ac culpa: ab ea autem differt, quatenus nihil resarcit

& compensat iniuriam ac offensam passo, sed malefactor punitur, quantum est iustum ac æquum, vt pro ea iniuria & offensa patiatur: & quatenus ex parte malefactoris non consurgit obligatio imponendi sibi ac assumendi pœnam, iniuriæ ac culpæ commensuratam, ante iudicis sententiam, imò sæpe nec pœnam exequendi post latam sententiam, non solùm si sit flagellorum, mutilationis, mortis, aut alia corporalis grauis, sed etiam si sit amissionis bonorum, aut partis eorum, quando delinquens non præcipitur vt sit exequutor eius pœnæ, vt regulariter præcipi non solet, sed expectare debet, vt talis pœna corporalis ab alio infligatur, & potest expectare, vt pœna amissionis bonorum post latam sententiam exigatur, quin & illam præscribere potest, cum sciētia, quòd ad eam sit condemnatus, si tanto tēpore post latam sententiam non exigatur, quantum ad eam præscribendam est necessarium, vt Disp. 66, Disp. 95. ad 2 ostendimus.

Illud est obseruandum. Cùm proximi iniuria [sect. 7] & offensa, eo ipso, quòd proximum iniustè offendit, estque contra caritatem illius ac bonum commune, sit etiam Dei offensa, contra ipsius caritatem, ac proinde digna pœna à Deo in seculo venturo infligenda, Deusque non puniat bis in id ipsum; consequens est, vt pœna, quam Deus in hoc seculo malefactoribus pro suis delictis infligit per ministros suos, qui vicem ipsius in iustitia administranda, puniendisque delictis, tenent, inseruiat, vt remittatur de pœna, quæ luenda erat in alio seculo. Atque hinc sequitur, quòd delicta, quę in hoc seculo non puniuntur per ministros publicos, vel à Deo flagellis immissis, reseruentur acriùs in futuro seculo punienda, nisi bonis operibus, ac indulgentiis, dum in hoc seculo viuimus, compensentur. Quòd si pœna per ministros publicos inflicta, aut à Deo aliis flagellis immissa, patienter atque ex caritate sustineatur, cum opus, quo ita suscipitur ac toleratur, meritorium sit, virtuteque passionis ac meritorum Christi satisfactorium, proculdubio longè maior pœna ea patientia ac tolerantia remittitur ac compensatur de illa, quæ in futuro seculo erat infligenda, quàm sit, quæ ita in hoc seculo toleratur.

Illud deinde est obseruandum. Quamuis, vt in hac. 2. 2. q. 25. art. 8. ostendimus, fas priuatæ personæ sit, pœnas pro delictis in ipsos, atque in suos, commissis exigere coram publica potestate ad id deputata, ad quam potestatem loco Dei spectat pœnam decernere, ad eamque obligare, iustamque vindictam de malefactoribus sumere: nulli tamen priuatæ personæ, etiam in defectu publicæ potestatis, esse licitum per se ipsam talem pœnam decernere ac sumere de malefactoribus, vt Disp. 100 dictum est: scriptum est enim: *Mibi vindictam, & ego retribuam, dicit Dominus*: neq; malefactor eam debet integre ac perfectè, antequam à publica potestate ei decernatur, ad eamque condemnetur: sed solùm priuata persona, accepta iniuria ac offensa, ius habet ad pœnā competentem exigendam coram publica potestate, & tunc demum habet ius plenum, vt sibi pœna debeatur, si adiudicata ipsi sit, & pœna sit talis, quam reus exequi & soluere teneatur, saltē si ab eo post latam sententiam exigatur. Quòd si non adiudicetur, vel nequitia iudicis, vel alia ratione, poterit quidem iudex iniustitiam committere, cum restituendi onere; eo quòd ad petitionem partis pœnam non imponat ac exequatur, vt de iustitia tenetur, eaque commutatiua ex parte iudicis ipsius, vt tract. 1, Disp. 12 ostensum est; delinquens tamen, qui non iniustè vindictiue iustitiæ exequutionē impedierit, non tenebitur ad solutionem eius pœnæ interim dum ad eam nō fuerit condemnatus, sed pœna pro delicto debita reseruabitur diuino iudicio in futuro seculo infligenda, nisi operibus bonis, ac indulgentiis, fuerit in hoc seculo compensata. Quia verò, antequā reus condemnetur, is, qui offensus est, aut ad quem loco offensi pœnam petere spectat, ius habet ad illam exigendum, iusque illud pretio est æstimabile; consequens sanè est, vt, stando in solo iure naturali, valeat

pactum, seu transactio, qua is, cui tale ius competit, iusto pretio illud remittit; & subinde ulterius est consequens, vt, post tale pactum, id in conscientia atque ex iustitia commutativa debeat, quòd eo pacto fuerit cōstitutum; quandoquidem in cōpensationē pro vero iure ad pānam sit promissum, in pactūque deductum. Id autem quod delinquens dat, aut facit, vt offensus, aut vt is, ad quem, loco offensi, spectat exigere pānam, iniuriam pānāque remittat, iurique illi suo cedat, appellari potest satisfactio delinquentis facta proximo suo pro delicto & pāna tali delicto commerita: solutio tamen, seu perpessio pānæ, iam iudicatæ, dum exequutioni mandatur, potius est satisfactio ex parte delinquentis, quàm satisfactio. Quando autem pāna iam est imposita, per ipsumque delinquētem est iam exequutioni mandanda, quia vel sententia continet, vt eam ipse exequutioni mandet, vel ab eo iam exigitur, tenetur, vi sententiæ, iustiq; præcepti iudicis, de iustitia commutativa eam soluere ob suum delictum: sicut, quando præcepto iusto impositum est aliquod tributum, de iustitia commutativa, vi illius præcepti, & causæ, ob quam iustè imponitur, tenentur ii illud soluere, quibus est impositum, & à quibus exigitur.

Ex dictis colligere licet nonnulla. Primum [sect. 9] est regula quædam, qua discernendum est, quādo ex delictis contra iustitiam obligatio restituēdi consurgat nulla expectata sententia, & quousque ea obligatio se extendat. Quando enim in [[199]] delicto contra iustitiam cernitur sola iniuria & offensa proximi, absque iactura aliqua ac læsione in bonis illius, tam externis, quàm corporis, honorisq; ac famæ, (de iactura in bonis spiritualibus, vtrum ex ea consurgat obligatio restituendi, in fine tractatus 4 dicitur) tunc nulla consurgit obligatio restituendi: quoniam nulla iniusta inæqualitas facta, sequutave, inde est in bonis proximi, quæ ex iustitia cōmutativa resarciri cōpensarique debeat. Tametsi ex caritate, debitoque suo modo ex iustitia, ex ipsamet rei natura, iniuriaq; iniustè illata, consurgente, si frater iustè sit commotus, seque ipsum sentiat offensum, obligatio sit petendi ab illo veniam, ostendendo coram illo pēnitentiam, doloremque, quòd in ipsum sit commissa, *iuxta illud Christi Matihæi 5: Si offers munus tuum ad altare, & ibi recordatus fueris, quia frater tuus habet aliquid aduersum te, relinque ibi munus tuum ante altare, & vade prius reconciliari fratri tuo, & tunc, veniens, offeres munus tuum.* Si tamen ea iusta ac debita humiliatione ac satisfactione, quæ verè restitutio non est, neque integra iniuriæ compensatio, frater rencorem quidem ac odium deponat, vt tenetur, attamen compensationem integram, quam ex iustitia vindicativa licitè potest exigere, remittere ac condonare non velit, tunc eam integram compensationem, seu satisfactionem, pro iniuria & offensa commissa, non tenetur delinquens subire, antequam per publicam potestatem ad eam condemnetur, eamque exequutioni mandari præcipiatur: quin potius potest se in iudicio defendere, congruis ac competentibus mediis, negareque delictum, interim dum semi plenè non est aduersus eum probatum, nec iuridicè interrogatur, vt tractatibus sequētib; ostendetur: potest item, etiam postquam lata fuerit sententia condemnatoria, interim dum pāna non exigitur, neque præcipitur eam soluere, illam, si pecuniaria sit, retinere, congruoque tempore præscribere, cum scientia, quòd condemnatus ad eam sit, illamque iam eo modo debeat, vt locis suprā in hac disputatione citatis ostendimus: quæ omnia longè aliena sunt ab obligatione veræ restitutionis in conscientiæ foro, ad quam quis ex commutativa iustitia teneatur. Quando verò in delicto cōtra iustitiam, vltra iniuriam ac offensam, cernitur iactura ac læsio ex eo delicto iniustè in bonis proximi data, consurgit quidem obligatio restituendi, non tamen tantum, quantum est iniuria & offensa commissa, sed quantum est damnum, læsiōve ac iactura data. Verbi gratia, ex temerario iudicio, quo immeritò quis sinistre concipit ac iudicat de

proximo, nulla consurgit restituendi obligatio: quoniam, licet id peccatū contra iustitiam sit, proximoque sit iniuriosum, eumque offendat, nullam tamen iacturam, nullumque damnum, relinquit in bonis illius eo ipso, quod à tali temerario iudicio cessatur: caque de causa, solum consurgit obligatio cessandi ab eo iudicio, illudque deponendi: non verò quicquam restituendi propter præteritam iniustitiam aduersus proximum commissam, postquam à tali iudicio est cessatum. Item, quamuis, qui furatur à paupere, grauius, cæteris paribus, peccet, maioremque illi faciat iniuriam ac offensam, quam peccet, iniuriamque ac offensam diuiti efficiat, qui tantundem ab eo furatur, inde tamen non consurgit obligatio, plus vni, quam alteri, restituendi: quoniam restituendi obligatio metienda non est quantitate iniuriæ ac offensæ, sed quantitate damni, proximo iniuste illati. Offensæ autem atque iniuriæ quantitas efficit, vt imponi iuste possit, ac debeat, maior pæna pro vno eorum delictorum, quam pro alio. Simile exemplum est de duobus furantibus æquale, sed vno eorum furante occultè, altero verò grassando mortisque metum incutiendo, nulla tamen facta læsione in corpore ei, à quo ita sit furatus, neque vlla relictæ illi læsione in honore & fama ex tali rapina. Quamuis enim eiusmodi grassator grauius peccet, maioriq; pæna sit dignus; eo quod pæna iuste per vindictuam iustitiam infligenda respondere debeat culpæ, quantitatique ac qualitati iniuriæ; non plus tamen tenetur restituere grassator, quam ille alius fur occultus: quoniam non maiorem latitudinem damni dedit vnus eorum in bonis proximi, quam alius; latitudo verò restitutionis respondere debet latitudini solæ damni iniuste dati. Ex regula proposita, atque ex hactenus dictis, simul patet ratio, cur is, qui furatus est centum, longoque tempore illa contra domini voluntatem detinuit, quamuis eo modo furando, ac detinendo rem alienam, iniuriam faciat proximo, non tamen tenetur plus illi restituere, quā si nullam iniuriam illi fecisset, sed solum iusto errore illa centum accepisset, ac proinde, quam si solum teneretur ea restituere ex parte rei acceptæ, & non ex parte iniustæ acceptionis, vt affirmat communis doctorum sententia, habetque praxis confessionum in Ecclesia. Ratio quippe est, quoniam pro culpa & iniuria, præcisè sumpta à damno ea culpa & iniuria dato, delinquens manet solum obnoxius pænæ, qua pro ea culpa & iniuria est dignus: nulla verò est obligatio subeundi aut soluendi pænam ante latam sententiam, vt communis doctorum sententia affirmat. Vnde, si ex iniuriosa acceptione & retentione rei alienæ nullum damnum, etiam lucri cessantis, est vterius sequutum domino talis rei, sanè, qui iniuriosè illam accepit ac retinuit, ad nullam maiorem restitutionem tenetur, quam si, permanente integra eadem re iniuriosè accepta ac retenta, solum teneretur eam restituere ex parte rei acceptæ, & non simul ex parte iniustæ acceptionis: idque propterea quod restitutionis obligatio, quæ consurgit ex parte iniustæ acceptionis, metienda est latitudine damni tali iniusta acceptione dati, non verò quantitate culpæ & iniuriæ commissæ in eo auferendo. Regulæ à nobis traditæ, & tam multis tota hac disputatione stabilitæ, *consentit apertissimè D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 3.* Vbi cū quæsiuisset, *utrū sufficiat restituere simplum, quod iniuste ablatum est*, partem affirmantem in hunc modum probat in argumento sed contra. *Restitutio reducit ad æqualitatem, quod inæqualiter ablatum est: sed aliquis reddendo, quod accepit simplum, reducit ad æqualitatem: ergo solum tenetur restituere tantum, quantum accepit.* Et in corpore articuli sic dicit: *Respondeo dicendum, quod cū aliquis iniuste accipit rem aliquam, duo sunt ibi consideranda: quorum vnum est inæqualitas ex parte rei, quæ quandoque est sine iniustitia, vt patet in mutuis. Aliud autem est iniustitiæ culpa, quæ potest, esse etiam cum æqualitate rei, putæ [[200]] cū aliquis intendit inferre violentiam, sed non præualeat. Quantum ergo ad primum adhibetur remedium per restitutionem, in quantum per eam æqualitas reparatur: ad quod sufficit, quod restituatur*

tantum, quantum habuerit de alieno. Sed quantum ad culpam, adhibetur remedium per pœnam, cuius inflictio pertinet ad iudicem. Et ideo, antequam sit condemnatus per iudicem, non tenetur plus restituere, quàm accepit. Et cùm primo loco sic esset argumentatus: Dicitur Exod. 22. Si quis furatus fuerit bouem, aut ouem, & occiderit, vel vendiderit, quinque boues pro vno boue restituet, & quatuor oues pro vna oue: sed quilibet tenetur mandatum diuinæ legis observare: ergo ille, qui furatur, tenetur restituere quadruplum aut quintuplum. Sic respondet: Patet responsio ad primum, quia lex illa determinatiua est pœnæ, per iudicem infligendæ. Et cùm ad observantiam iudicialis præcepti, nullus teneatur post Christi aduentum; potest tamen idem, vel simile, statui in lege humana, de qua erit eadem ratio. Et art. 4. docet, damni solùm restitutionem esse faciendam. Et art. 6. docet, rem alienam acceptam, quod attinet ad rem ipsam, esse restituendam. Ex parte verò iniustæ acceptionis, esse etiam restituendam, etiam si non maneat, quia qui percutiendo damnum iniustè dat, tenetur illud cõpèsare, etiamsi nihil inde apud ipsum remaneat. Addit autem: Ita etiam, qui furatur, vel rapit, tenetur ad recompensationem damni illati, etiamsi nihilinde habeat. Et ulterius pro iniuria illata debet puniri. Et in responsione ad tertium sic ait: Quia restitutio principaliter ordinatur ad remouendum damnum eius, à quo est aliquid iniustè ablatum, ideo postquam ei restitutio sufficiens facta est per unum, (multorum scilicet, qui damnum dederunt) alii non tenentur ei ulterius restituere, sed magis refusionem facere ei, qui restituit, partes videlicet ipsorum. Et in opusculo de usuris, c. 20. ex eodem fundamento docet, quando interuenit iniuria vltra damnum, solùm fieri debere restitutionem pro damno, non verò pro iniuria: pro qua aliter fieri debet compensatio. Ex hoc principio, quod non frustra tam multis hoc loco explanamus & stabilimus, ex dictisque tota hac disputatione decidenda sunt multa hoc tractatu, & sequentibus, grauissima ac quotidiana.

Secundum, quod ex dictis licet colligere, est [sect. 10] causa, ob quam regulariter homines non teneanturante latam sententiam soluere pœnam delictis ipsorum condignam, ac commeritam, esto legibus statuta sit, & esto lex contineat, quòd statim ipso iure, aut ipso facto, incurratur. Quia enim ex delicto & iniuria, ea ex parte qua delictū & iniuria est præcisa à damno proximo in suis bonis illato, non consurgit obligatio restituendi in conscientia foro, sed consurgit solùm condignitas ad pœnam, quæ per iustitiam vindicatiuam à potestate publica infligitur, vt explanatū est: duræ autem admodum atque intolerabiles essent leges, ac proinde minimè iustæ, quæ delinquentem exequutorem pœnæ efficerent aduersus se ipsum statim commisso delicto; præsertim cum ex variis circumstantiis cõcurrentibus necesse sæpe sit iudicis arbitrio moderari aut augere pœnam, eaque de causa oporteat deliquentē audire antequam vltimo obligetur ad pœnam; consequens profectò est, vt non solum ante conditas leges pœnales, quibus decernatur pœna, sed etiam post illas conditas, pœna in conscientia foro non debeatur ante latam sententiam, esto lex ipso iure, aut ipso facto, eam statuatur: quoniam sensus eiusmodi legum est, non vt delinquens statim commisso delicto teneatur ad exequutionē pœnæ antè quàm sententia feratur, sed vt, lata sententia, retrahatur pœna ad tempus cõmissi delicti, vt Disp. 95. & 96. dictum est.

Tertium est. Quamuis, quando iactura & dā [sect. 11] num in bonis proximi iniustè est datum, licitum ei sit, qui id damnum accepit, compensationem autoritate propria facere, tantundem occultè accipiendo de bonis illius, qui illud iniustè dedit, quando iudicis autoritate, concurrentibusque aliis circumstantiis Disp. 691 explicatis, nō potest commodè id obtinere, nihilominus illicitum esse propria autoritate, minimeque interueni ente iudicis sententia, cõpensationē vllam facere pro offensa & iniuria sumpta præcisè à dāno dato, tenerique,

qui illam fecerit, ad restitutionem illius, damnorūque, si quæ fortè vltèrius subsequuta ei sint, cuius bona ita in compensationem vsurpata sunt. Ratio autem est, quoniam ante latam sententiam, qua aliquid ei adiudicatur in pēnam delicti aduersus ipsum commissi, nihil delinquens ei debet, esto dignus delinquens sit, qui puniatur, & esto offensus ius habeat ad pēnam competentem coram publica potestate exigendam per iustitiam vindicatiuam, quæ delinquēti infligatur, & accusanti applicetur.

Postremò est obseruandum, hoc esse discri [sect. 12] men, præter alia, inter restitutionem & satisfactionem, quæ vltima pars est sacramenti pēnitētiæ. Quòd restitutio necessaria est, vt non continuetur peccatum retentionis rei alienæ, alterive debitæ, inuito domino: qui enim contra voluntatem alicuius retinet, quod ex iustitia illi debet, in mora que iam est id ei tradendi, vtique peccatum suum iniustitiæ aduersus eum continuat, nisi sit legitima aliqua causa, quæ eum excuset. Atque hac ratione restitutio, quando non adest legitima causa, quæ ab ea facienda excuset, antecedere debet pēnitentiā, tanquam conditio ac dispositio ad cōtritionem, artritionemque, veram necessaria. At verò satisfactio est pars vltima sacramenti pēnitentiæ ad cōpensandam pēnam pro peccatis debitam, dimissa culpa per sacramentum, aut antecedentem contritionem: vnde ea satisfactio nō antecedit veram contritionem, aut attritionem, absolutionemque à peccatis, sed post illa sequitur, estque illis posterior.

Vtrū restitutio necessaria sit ad salutem. Disp. 716.

SVMMARIVM.

1. *Error existimantium restitutionem necessariā non esse ad salutem.*
2. *Restitutio necessaria est ad salutē eo modo, quo præceptorū decalogi observatio est ad salutē necessaria.*
3. *Restituendi præceptum in septimo decalogi præcepto includitur.*
4. *Restituendi præceptum in quo sensu ad semper obliget.*
5. *Eleemosyna sine restitutione ac pēnitentia, quādo alienum detinetur, ad salutem non sufficit.*
6. *Eleemosyna in quo sensu sit præsidium maximum contra peccata, & ad vitam æternam consequendā.*

[[201]] **P**Osito, quòd quis damnum la tē iniustē dederit proximo, aut rem illius retineat, quæritur, num, si quantitas notabilis sit, neque adsit legitima causa, quæ ab onere restituendi deobliget, restitutio necessaria sit ad salutem. Pars, quæ negat, suaderi potest.

Primò, quoniam ad salutem satis est seruare⁵¹ mandata, iuxta illud *Matih. 19. Si vis ad vitam ingredi, serua mandata*: sed in præceptis decalogi, de quibus Christus ibi loquebatur, non continetur præceptum restituendi, vt constat: quoniam si in aliquo contineretur, maximè id esset in septimo, nempe *non furtum facies*: in eo autem non contineri, ex eo liquet, quòd in eo nō præcipitur actus positivus, qualis est restitutio, sed prohibetur actus furandi.

Confirmatur, quoniam, cū præcepta nega⁵²tiva in hoc ab affirmatiuis differant, quòd negatiua obligent ad semper, & affirmatiua non, sanè, si restituendi præceptum in negatiuo

præcepto non furandi contineretur, obligaret ad semper restituendum: quòd tamen nulla ratione videtur asserendum.

Secundò, nullus peccat detinendo alienum ex⁵³ domini illius consensu, saltem debito: sed, cùm vnusquisq; pro salute spirituali proximi teneatur exponere bona omnia sua temporalia, tenetur dominus rei furto ablatae consentire, vt fur, qui ad id non est paratus, non restituat, vt ea furti remissione peccatum illius euitet, & per pænitentiam solius delicti præteriti reponatur in gratia: ergo fur, non restituendo, non peccat.

Tertiò, sæpe restitutio fieri non potest, aut nõ⁵⁴ sine notabili detrimẽto famæ, aut vitæ, eius, qui restituere debebat: ergo restitutio non est de necessitate salutis.

Quartò, *Cùm Christus Lucæ 11. dixisset, quod⁵⁵ intus est Pharis eorum plenum esse rapina & iniquitate, addidit; Veruntamen, quod superest, date eleemosynam, & ecce omnia munda sunt vobis.* Vbi nullam restitutionem iniunxit Christus, vt mundarentur ac reponerentur in gratia, sed eleemosynam ad hoc sufficere docuit.

Vt Guido de erroribus Græcorum, & Alfonsus Ca [sect. 1] stro de hæresibus verb. restitutio, referunt, inter errores Græcorum computatur, quòd sacerdotes ipsorũ non iubeant restituere ablata per furtum & rapinam, sed raptores ac fures absoluant, illis in pænitentiam iniungendo, vt partem ita per iniustitiam acquisitorum, sibi & ecclesiæ in eleëmosynā tribuant, quasi ad salutem necessaria non sit restitutio. Eundem errorem sequutus est Erasmus in annotationibus in illud Lucæ citatum, in quatuor prioribus editionibus, sic dicens: Illud adnotandum, cùm priùs fecerit mentionem rapinæ, in remedio non fieri mentionem restitutionis, sed tantum pollicetur, eleemosyna data, omnia fieri munda. Postea verò in quinta editione, vel vt notam effugeret, quòd errorem illum amplecteretur, vel à veritate ipsa cõpulsus, verbis ipsius proximè relatis addidit: *sed, qui iubetur dare, quibus nihil debetur, multo magis iubetur reddere, si quid cui debet.*

Hic error manifesta est hæresis cum lumine naturæ perspicuè pugnans, estq; tanquam veritas orthodoxa affirmadũ, restitutionem iniustè ablatorũ, aut iniustè detentorum, necessariam esse ad salutem eo modo, quo mandatorum decalogi observatio ad salutem est necessaria. Atque, vt à rationibus ordiamur, sanè non minus ex natura rei est illicitum ac iniustum retinere alienum, alteriue debitum, contra illius voluntatem, cum priuando usu rei suæ, aut sibi iam debitæ, quam sit illud ab eo accipere contra ipsius voluntatẽ: sed hoc secundum priuat gratia ac vita æterna, quia est contra proximi ac Dei caritatẽ, vt patet, quoniã prohibetur seprimo præcepto decalogi: ergo & primum, quod etiam eodem septimo præcepto decalogi continetur ac prohibetur, vt Disp. 680 explanatum est, & quo non cessatur à peccato commisso per secundum, nisi per rei iniustè acceptæ restitutionem. Ac sanè, qui restitutionem nõ esse necessariam ad salutẽ affirmaret, assereretq; sine continuatione peccati furti contra septimum decalogi præceptum, posse restitutionẽ omitti, continuò teneretur concedere, non esse necessarium ad salutẽ, quenquam ex sua parte implere contractus, ad quos implendos ex iustitia teneretur, vt non esse cuiquam necessarium ad salutem, accepto pretio pro merce, mercem tradere, aut accepta merce, tradere pro ea pretium, & ita de impletione aliorum contractuum, ad quam ex iustitia teneatur: quoniam perspicuè non est maior iniquitas in retinendo pretio, accepta merce, aut in merce retinenda, accepto pretio, quàm in retinendo alienum per furtum ablatum, inuito eius rei domino: quandoquidem non minus ius est ei, à quo aliquid per furtum est ablatum, vt ipsi reddatur, quàm sit ei, qui tradidit mercem, vt ipsi soluatur pretium, aut ei, qui pretium tradidit, vt ipsi res empta reddatur, imò maius: quippe cùm is, cui res furto ablata est restituenda,

dominium illius retineat, alii verò solùm habeant ius ad pretium, aut ad mercem, vi contractus emptionis aut venditionis, quem ex sua parte impleuerunt. Adde, obligationē implendi contractum non magis contineri septimo præcepto decalogi, (cum tamen perspicuè in nullo alio præcepto contineatur) quàm contineatur obligatio restituendi furtū. Neque plus esse obligationē remittendi restitutionis obligationē furi, vt fur in gratia reponatur ac saluetur, quam sit obligatio remittendi pretium, aut mercem, vt saluetur, qui nollet ea tradere, vt ex contractu emptionis aut venditionis tenetur. Ex scripturis verò sacris probatur, restitutionem necessariam esse ad salutem, & per consequens contrariam assertionem errorem esse in fide. *Reddite omnibus debita. Cui tributum, tributum. Nemini quicquam debeatis. Matth. 22. Reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari. Tobie 2.* Cum sanctus ille senex hædum balantem audisset: *Videte, inquit, ne fortè furtiuus sit. Reddite eum dominis suis: quia non licet nobis, aut edere ex furto aliquid, aut cōtingere. Ezech. 33.* inter requisita ad impii iustificationē, restitutio malè ablatorum, iniusteque retentorum, computatur. Sic enim ibi scriptum legimus: *Si dixero impio, morte morieris. Et ille ogerit pœnitentiam à peccato suo, feceritque iudicium & iustitiam, & pignus restituerit, rapinamque reddiderit, in mandatis vitæ ambulauerit, nec fecerit quicquam iniustum, vita viuet, & non morietur.* Denique hæc semper fuit concors doctrina Ecclesiæ ac Patrum. *Vnde Augus. Epist. 54. ad Macedonium, & refertur. 14. q. 6. c. 1. Si res, inquit, aliena, propter quam peccatum est, reddi possit, & non redditur, pœnitentia non agitur, sed simulatur. Si autē veraciter agitur, non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum, si, vt dictum est, restitui potest. Hactenus Augus.*

[[202]] Ad primum autem argumentum in contra⁵⁶rium, concessa maiori, negāda est minor. Ad probationem similiter concessa maiori, neganda est [sect. 3] etiam minor, nempe præceptum restituendi non contineri in septimo præcepto. Vt enim Disp. 680 fuit explanatum, atque in hac disputatione retulimus, non furtum facere sumitur latè in eo præcepto, vt cōprehendit, non accipere quocunque modo alienum iniustè, & non inferre damnum rebus alienis iniustè, atque non retinere iniustè alienum, idve, quod ei debetur. Porrò eiusdem speciei est in genere moris, non accipere alienum iniustè, & non retinere alienum iniustè: in consequentiam verò huius, quod est, non detinere iniustè alienum, (cui dictamini rectæ rationis ac legis Dei tenemur nos cōformare) censetur illo eodem negatiuo præcepto, non furtum facies, præceptus actus positivus restituendi pro tempore, quo res aliena iniustè detinetur, tanquam medium, quo cessandum est, & sine quo non cessatur, ab iniusta rei alienæ detentione: quandoquidem, qui finem præcipit, eo ipso censetur præcipere medium, sine quo finis mandari non potest executioni; neque alia malitia est in omissione medii, ea præcisa ratione, qua necessarium est ad finem, ab ea, qua non impletur præceptum de fine: quin in re proposita, cū idem prorsus sit, retinere iniustè alienum, quod transgressio est septimi illius præcepti, non furtum facere, & omittere restitutionem eius, quod ita retinetur, sanè eadem numero culpa est, retinere alienum iniustè, hoc est, illud ei non tradere, cui debetur, & omittere restitutionē illius. Quo fit, vt in illo septimo præcepto decalogi, quatenus continet prohibitionem retentionis iniustæ rei alienæ, alterive debite, contineatur præceptū restitutionis, cuius ommissio est formaliter retentio iniusta rei alienæ: quoniam retinere iniustè, & iniustè illud non exhibere ac restituere, idem prorsus sunt. *Adrianus. q. 1. de rest. & Ioan. Med. q. 2.* adhibent in exēplū, quòd in præcepto negatiuo non furandi includatur affirmatiuum restituendi, modo explicato: sicut, inquit, in præcepto negatiuo, non occides, includitur præceptum affirmatiuū, subuenies proximo extremè indigēti: quoniam, qui proximum non defendit ac liberat à morte, quæ illi iniustè

paratur, cū tamen possit, & qui eum non pascit, fame morientem, aut in alia occasione ipsum non liberat à morte illi imminēti, (quæ tamen iustè à potestate publica ei non infligatur) cū tamen liberare eum possit, peccat contra præceptum negatiuum, non occides. Hoc tamen exemplum non est satis idoneum ac firmum. Transgressio quippe præcepti negatiui, nō occides, est peccatum contra iustitiam: transgressio verò præcepti affirmatiui, subuenies proximo extremè indigenti, solū est peccatum cōtra caritatem ac misericordiam proximi, quod proinde obligationem restituendi non inducit damna, seu detrimenta proximo ex ea omissione subsequuta: quo fit, vt præcepta illa, non occides, & subuenies extremè indigenti, diuersa sint, ad virtutes diuersas attinentia. Quando autem sancti aliqui dicunt; si non pauisti, occidisti; non intelligunt peccato veri homicidii contra quintum præceptum decalogi: sed peccato contra caritatem ac misericordiam proximi, quo mors proximi, quam ex his virtutibus vitare tenebatis, ad culpam lethalem tibi imputatur.

Ad confirmationem minoris eiusdem primi⁵⁷ argumenti, dicendum est. Quando præceptum affirmatiuum deriuatur à negatiuo, & in eo con [sect. 4] tinetur eo modo, quo in præcepto non retinēdi alienum iniustè, continetur præceptum restituēdi, vt explanatum est, tunc præceptum affirmatiuum obligare ad semper eo modo, quo negatiuum, à quo deriuatur, & in quo includitur: eaque ratione, quamdiu, & quoties, peccat quis retinēdo iniustè alienum, peccat etiam non restituendo, non quidem distinctis peccatis, sed vno & eo dē prorsus, vt explicatum est. Cæterū, quia retentio alieni, alt erīve iam debiti, vt ei sine mora soluatur, supponit primam illius occupationē, aut esse iam ita debitum, vt sine mora sit necessariò soluendū, sicut rei conseruatio præsupponit esse præteritum eiusdem rei, quod in futurum manu teneatur ac conseruetur, sanè præceptum restituendi solū obligat post primam occupationem rei alienæ, aut postquam res restituenda est iam ita debita, vt sine mora sit soluenda, atque ab eo puncto obligat, quousque integre restitutio perficiatur. Item, quia multa sunt, quæ excusare possunt à peccato retentionem rei alienæ, alteri verò iam perfectè debitæ, multa consequenter etiam sunt, quæ excusant omissionem restituendi. Est etiam præceptum non retinendi alienum, seu illud restituendi, intelligendum moraliter, nempe vt res, spectato congruo tempore ac loco, restituatur. Quæ omnia inferiùs patebunt, dum explicabimus quando facienda sit restitutio. Vnde ad confirmationem in forma concedenda est consequutio, si consequens intelligatur, interim dum obligatio est non retinendi alienum, modo explicato.

Ad secundum dicendum est, in primis maio⁵⁸ rem non esse vniuersum veram. Quoniam ad quā plurima satis non est consensus debitus alterius. Vt ad hoc vt is, cui baptismus applicatur, eo maneat baptizatus, non sufficit consensus illius debitus, sed requiritur verus illius consensus ad id præstitus. Item, vt pauper, qui non extremè indiget, occupare possit ac retinere rem diuitis, nō satis est, quòd æquitas, misericordia, & caritas id postulent, imò & quòd sub præcepto obligent diuitem, vt consentiat: quoniam licèt diues peccet non consentiendo; pauper tamen iniustitiam cōmittit, eum inuitum spoliando bonis suis, atque idem esset in euētu argumēti propositi esto gratis daremus, minorem esse verā. Minor tamen est etiā falsa. Quoniam quando proximus non indiget ad salutē spiritualē, aut corporalē, bonis alterius temporalibus, nisi ex sua malitia & nequitia, quia sine illis potest ipse sibi subuenire, si velit, vt cernitur in euentu argumenti propositi, tunc non consurgit obligatio concedendi illi talia bona, vt suprā in hac 2. 2. in materia de caritate variis in locis à nobis explanatum est. Imò verò, ad conseruandum, non solum propriam vitam, sed etiam bona temporalia externa, quæ alius iniustè eripere vult, non solū fas est illorum domino

interficere iniustum aggressorem, sed etiam permittere, vt, decedendo in peccato lethali, quod tūc committit, simul cum temporali vita, quæ in defensionem iustam ab eo eripitur, amittat æternam, addigaturque sempiternis cruciatibus, *vt Sotus 4. de iust. q. 6. art. 2. ad. 1. rectè ait, & tractatu 3. sequenti ostendemus.* Adde, in euentu argumenti popositi, cū fur in animo sit non **[[203]]** restituendi, esto debitum illi non remittatur, per remissionem (occultam præsertim, quam iguorat) non liberari à culpa lethali, in qua est non restituendi alienum, cū possit.

Tertium argumentum petit, quæ excusent à⁵⁹ culpa retinendo alienum, illudve non restituendo statim, saltem per interpositam personam: de qua re inferiùs dicitur.

Quod ad quartum argumentum attinet.⁶⁰ Cū Phariseus quidam Christum rogasset, vt apud se pranderet, Christusque discubisset; non seruatis de industria ablutionibus externis, quas ante cibi sumptionem studiosè ac supersticiosè Pharisei, cæteri que iudæi, seruabant, quasi in illis religio ac sanctitas esset posita; Phariseusque admirari cæpisset, quod non esset lotus, quam internam pharisei admirationem editio vulgata expressit, dicens: *Phariseus autem cepit intra se reputans dicere, quare non baptizatus esset ante prandium*, (id enim continet esse ea de re admiratum) *dixit illi Christus: Nunc vos Pharisei*, (quasi diceret, vestra est hæc institutio, non legis) *quod de foris est calicis & catini mundatis.* Vt autem constat ex eadem obiurgatione, quæ Matthæi 23 habetur, metaphora sumpta à vasis cibi & potus, quæ erant in mensa, nomine, *calicis & catini*, intellexit ac significauit Christus homines ipsos, qui constant anima tanquam parte interiori, & corpore tanquam parte exteriori, sicut vasa illa constant parte interiori, in qua cibi ac potus apponuntur, ac proinde in qua maior necessaria est munditia, & constant etiam parte exteriori. *Sic enim habent verba Christi Matthæi 23. Væ vobis, scribe & Pharisei hypocrite, qui mundatis, quod de foris est calicis & paropsidis, intus autem pleni est is rapina & immunditia. Pharisei cæce, munda priùs quod intus est calicis & paropsidis, vt fiat id, quod de foris est, mundum.* De munditia spirituali, ad religionem ac virtutem attinente, loquebatur, nomine, *calicis & paropsidis*, hominem ipsum perspicuè ibi intelligens, à cuius munditia interiori, quoad virtutum actus, pendet munditia actuum earundem virtutum externorum, quæ sola est munditia spiritualis virtutis ac religionis, de qua Christo erat sermo: Vnde rectè dicit; *munda priùs, quod intus est calicis & paropsidis*; hoc est, interiorem partem tui, in qua, tanquam in interiori parte vasis, apponuntur & offeruntur Deo virtutum ac iustitiæ opera, vt (eo videlicet ipso) *fiat id, quod de foris est, mundum*: neque enim in materiali calice, aut paropside, ex eo quod pars interior mundatur, fit mundum, quod de foris est illius. Nunc ad verba Lucæ regrediamur. Post illa verba, *Nunc vos Pharisei, quod de foris est calicis & catini mundatis*, subiungit Christus; *quod autem intus est, vestrum, plenum est rapina & iniquitate. Stulti, nōne, qui fecit, quod de foris est, (vestrū scilicet) etiam id, quod intus est, fecit.* Idque, quasi dicat, tanquam longè magis præcipuum, atque tanquam in quo longè magis munditiam exigat. *Veruntamen quod superest, date eleemosynam: & ecce omnia munda sunt vobis.* Occasione autem horum verborum, quæ ad rem præsentem faciunt, cætera retulimus ac exposuimus. Porro hæc verba vno è tribus modis exponuntur.

Primò, in sensu eorum proprio absque vllo [sect. 5] tropo. *Quo pacto ab August. in Enchiridion à. c. 72. ita exponuntur*, vt nomine eleemosynæ, omnia opera misericordiæ, tam spiritualia quàm corporalia, intelligat, etiam illud, quo quis animæ suæ miseretur, pænitentiam agendo de peccatis, ac Deo placendo, *iuxta illud Ecclesiastici 30. Miserere animæ tuæ placens Deo.* Vnde mūditiā internā ita à Christo tribui eleēmosynē hoc loco affirmat, vt non solūm præsupponat veram pænitentiam de peccatis, (quæ esse non potest sine alieni

vera restitutione, si facultas sit restituendi) fidem, & cætera ad lutum necessaria, sed etiam illa includat, si is mundandus sit, cuius interiora rapina & nequitia sunt plena. Sic de Zachæo, qui, verè pænitens, cum eleëmosyna, restitutionem coniunxit, dicens: *Ecce domine, dimidium bonorum meorum do pauperibus, & si quid aliquem defraudaui, reddo quadruplum*, dixit Christus Lucae 19. *Quia hodie salus huic domui facta est*. Quòd autem sola eleëmosyna, sine fide, & pænitentia, cæterisque, quæ ad veram pænitentiam necessaria sunt, non satis sit ad mundandum, vel infidelem, vel fidelem, qui in lethali peccato est, perspicuum est ex quàm plurimis aliis testimoniis scripturæ sacræ, etiamsi nomine eleëmosynæ intelligamus omnia misericordiæ opera, tam corporalia quàm spiritualia, quæ circa proximos nostros exhibemus, vt Aug. capitibus citatis perspicuè ostendit. De numero verò eorum locorum sunt, illud ad Hebræos 10. *Sine fide impossibile est placere Deo*. Lucae 13. *Nisi pænitentiam egeritis, omnes peribitis*. 1. Cor. 13. *Si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, & si tradidero corpus meum ita vt ardeam, caritatem autem non habuero, nihil mihi prodest*. Vnde quando eleëmosynæ remedium ad munditiam internam, ad extinguenda peccata, & vt ciues cæli, facti per eam nostri amici, nos in æterna recipiant tabernacula, in scripturis sanctis asseritus, sanè non excluditur, sed supponitur pænitentia, cum cæteris, quæ ad veram pænitentiam necessaria sunt, si à lethalibus culpis, in quibus facti Dei inimici iacemus, mundati interiùs sumus. *Sicut quando Dominus Matth. 6. dicit; Si dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittet vobis pater vester cælestis delicta vestra*; non excluduntur cætera ad salutem & veram pænitentiam necessaria, sed supponuntur. Vnde Aug. in Enchi. c. 75. aduersus quosdam, qui, freti testimonio scripturæ, de vi eleëmosynæ, non curabant abstinere à lethalibus culpis, & de eis pænitere, quasi eleëmosyna sola ad mūditiā internam, sempiternāque felicitatē obtinendā, sufficeret, sic ait: *Sanè qui sceleratissimè viuunt, neque curant, talem vitam moresque eorrigere, & inter ipsa facinora & flagitia sua eleëmosynas frequentare non cessant: frustra sibi ideo blandiuntur; quoniā Dominus ait; Date eleëmosynam, & ecce omnia munda sunt vobis. Hoc enim quàm latè pateat, non intelligunt. Sed, vt in telligant, attendant quibus dixerit. Nempe in Euangelio sic scriptum est: Cū loqueretur, rogauit illum quidam Pharisaus, vt pranderet apud se, &c.* Et relato toto testimonio ex Luca subiungit Augustinus: *Itāne hoc intellecturi sumus, vt, Phariseis non habentibus fidem Christi, etiamsi in eum crediderint, nec renati fuerint ex aquæ & spiritu sancto, mūda sint omnia, tantū si eleëmosynas dederint, sicuti isti eas dandas putant: cū sint immundi omnes, quos non mundat fides Christi, de qua scriptum est: Mundans fide corda eorum, & dicat Apostolus, Immundis autem, & infidelibus; nihil est mundum, sed polluta sunt [[204]] eorum mens & conscientia. Quomodo ergo Phariseis omnia munda essent, si eleemosynas darent, & fideles non essent? aut quomodo fideles essent, si in Christum credere, atque in eius renasci gratia noluisent? Et tamen verum est, quod audierant, date eleemosynam, & ecce omnia munda sunt vobis.* Et. c. 76. ostendit, non solū à Christo supponi, debere simul habere fidem, & reliqua, quæ ad salutem sunt necessaria, sed etiam in eleëmosyna, de qua ibi loquebatur, hæc omnia includi: quod etiam antecedentibus capitibus docuerat. *Quin eodem. c. 76. ex iis, quæ immediatè Christus apud Lucam eodem c. 11. subiunxit, præcipuè ostendit Augustinus, solam externam eleemosynam non satis fuisse illis eisdem Phariseis ad internam munditiam, salutemque spiritualem. Continuò enim Christus addidit: Sed vè vobis Phariseis, qui decimatis mentam & nutam & omne olus, (id est, has decimas in eleemosynas soluitis) & præteritis iudicium & caritatem Dei. Hæc (iudicium scilicet & caritatem Dei, tanquam præcipua & necessaria ad internam munditiam ac ad salutem) oportuit facere, & illa non omittere.* Capite autem 77 sic subiungit Augus. *Non ergo se fallant, qui per eleemosynas*

quaslibet largissimas fructuum suorum, vel cuiuscunque pecuniæ, impunitatem se emere existimant in facinorum suorum immanitate ac flagitiorum nequitia permanendi. Et c. 70 sic dixerat: Sanè cauendum est, ne quisquam existimet, infanda illa erimina, qualia qui agunt, regnum Dei non possi debunt, quotidie patranda, & eleemosynis quotidie redimenda. In melius quippe est vita mutanda, & per eleemosynas de peccatis præteritis est propiciandus Deus, non ad hoc emendus quodàmodo, ut ea semper liceat impunè committere. Nemini enim dedit laxamentum peccandi, quamnis miserando deleat iam facta peccata, si non satisfactio congrua negligatur. Hactenus Augustinus in Enchiridion.

Vt verò intelligatur, in quo sensu eleemo [sect. 6] synæ tribuatur in scripturis sacris extinguere, purgare, ac remittere peccata, munditiam internam, ac salutem, vitamque æternam in nobis efficere, ut præter testimonium Lucæ 11. in sensu, in quo illud hactenus exposuimus, constat ex sequentibus. Daniel. 4. *Consilium meum placeat tibi, Rex, & peccata tua eleemosynis redime: forsitan ignoscet tibi Deus delictis tuis.* Psal. 40. *Beatus vir, qui intelligit super egenum & pauperem, in die mala liberabit eum Dominus.* Prouer. 15. *Per misericordiam & fidem purgantur peccata.* Et c. 16. *Misericordia & veritate redimitur iniquitas.* Tobix 4. *Eleemosyna ab omni peccato & à morte liberat, & non patietur animam ire in tenebras.* Et c. 12. *Eleemosyna purgat peccata, & facit inuenire misericordiam, & vitam æternam.* Lucæ 16. *Ego vobis dico, facite vobis amicos de mammona iniquitatis, ut cum defeceritis, recipiant vos in æterna tabernacula.* Vt, inquam, intelligatur, in quo sensu in his testimoniis eleemosynæ hæc tribuantur, obseruandum est. Peccatorem spectari posse, & antè quàm per pænitentiam reponatur in gratia, & postquam in gratia est repositus. Et quidem utroque tempore multum ad hæc conducunt eleemosyna ac misericordia proximis exhibita, siue operibus misericordiæ corporalibus, siue spiritualibus, remittendo iniurias ac condonando delicta, sanum consilium præbendo, proximosque adiuuando, ut eruantur ac præseruentur à peccatis, aut quacunque alia ratione misericordiam in illos exercendo: atque ea omnia nomine eleemosynæ spiritualis ac corporalis intelligere in his testimoniis possumus. Si peccator spectetur antè quàm per pænitentiam in gratia reponatur, valet multum eleemosyna & misericordia in proximos, non quidem ut ipsa peccata remittat, sed ut homo peccator à Deo excitetur ac moueatur ad pænitentiam, eo maiorem ac generosiores, qua non solùm culpa deleatur, sed & pæna, quæ, remissa culpa, solet manere, vel soluenda in alia vita, vel compensanda in hac operibus bonis ac indulgentiis, magna ex parte, vel omnino, deleatur, quo elargitio eleemosynarum fuerit maior, & misericordiæ opera fuerint abundantrora ac vtiliora proximis. Inde enim Deus optimus & maximus, ex sua infinita misericordia ac bonitate, copiosius ac potentiùs solet adiuuare eiusmodi misericordes in alios, eos ad pænitentiam copiosius ac potentiùs excitando, excitatosque, copiosius ac potentiùs adiuuando, tum per se ipsum immediatè, tum etiam per suam prouidentiam illis præbendo media externa ac occasiones, quibus magis adiuuentur, hostesque inuisibiles comprimendo, atque impedimenta illis arcendo, quibus retardari ac impediri poterant. Solet etiam eos ad pænitentiam expectare, media eis præbendo, quibus eorum vita prorogetur, arcendoque ab eis pericula, ne, dum in culpa sunt læthali, ex hoc seculo migrent. Atque ad hæc omnia, & ad alios similes diuinæ misericordiæ in illos effectus, conducunt maximè merita & orationes pauperum, ac proximorum, in quos ita misericordes fuerint, tum dum eiusmodi pauperes ac proximi in hoc seculo viuunt, tum præcipuè dum in alio seculo diuino conspectu perfruuntur, qui effectus eiusmodi à Deo illis impetrant. Qua ratione Christus Lucæ 16 nos admonuit, ut eleemosynis conciliaremus, pararemusque nobis eiusmodi amicos, qui ea ratione, & aliis, dum deficeremus, ac migraremus ex hac

vita, nos reciperent in æterna tabernacula. Si verò peccator spectetur dum per pænitentiam repositus est iam in gratia, eleemosynasque, & alia misericordiæ opera, in proximos suos exercet, qualia Tobias ea exercebat, tunc eiusmodi opera misericordiæ verè iam meritoria, ac satisfactoria pro pæna, quæ remanet remissa culpa, non solùm redimunt, purgant, & extinguunt, peccata, tum lethalia præterita, quoad eiusmodi pænam, tum etiam venialia, sine quibus iusti non transigunt hanc miseram & corruptibilem vitam, sed etiam valde præservant homines iam iustos effectos à lethalibus culpis, nec patiuntur eos ad tenebras ire, à variisque aliis eos præservant ac eruunt malis, dum Deus optimus maximus ex sua infinita misericordia ac bonitate eiusmodi operibus permotus, quæ & sibi gratissima sunt, & sunt ex se nimis apta ad permouendam ac inclinandam diuinam misericordiam, maxima confert auxilia, atque [[205]] atque ita res per suam prouidentiam disponit, vt misericordes in alios ea omnia bona, si per ipsos non steterit, consequantur. Ad id etiam multum adiuuant merita & orationes pauperū ac proximorum, in quos ea opera misericordiæ sunt exhibita, qui suis orationibus prædicta à Deo impetrant, tum dum sunt in hac vita, tum præcipue dum Deo in alia perfruuntur. Atque hac etiam ratione Christus nos admonuit, vt eleemosynis nobis illos conciliaremus, ac efficeremus amicos, vt, dum deficeremus, nos in æterna reciperent tabernacula. Porro cùm Nabucodonosor in lethali esset culpa, atque in pænam temporalem luendam in hoc seculo, illi fuisset pronunciatum, eum, ob suam superbiam ac flagitia, in bestię figuram commutatum, ejiciendum, vt interbestias pasceret ac commoraretur, atque Daniel ignoraret, an sententia illa esset comminatoria ac conditionalis, nisi pænitentiam ageret, aut fortè sciret sub ea conditione esse latam, sanum profectò consilium illi dedit, vt, aggrediendo pænitentiam facere, eleemosynis simul, quas largissimas poterat effundere, sua peccata redimeret: eo enim potentissimo remedio, sibi que faciliore, quàm alio, adiuuari poterat, tum vt ad veram perueniret penitentiam, tū etiam vt illi condonaretur ea temporalis pæna: Rex tamen ille, neque eleemosynas illas elargiri voluit, neque curauit de peccatis dolere, sicque pænam illam postea sustinuit. Hæc de primo sensu illorum verborum Lucæ 11.

Secundum sensum tradunt Caiet. Iansenius, & alii, ad cum locum, acceptis quidem eisdē verbis in sensu proprio, cæterum dicunt, verbum, *date*, ancipitem esse in textu græco, vt sit imperatiuum, vt habet editio vulgata, & vt sit indicatiuum, ac transferatur, datis. Putat verò Caiet. transferendum esse verbum, non in imperatiuo, sed in indicatiuo, atque ita verba illa non continere doctrinam & consilium Christi traditum ibi Phariseis, quo munditiam consequerentur internam, sed continere narrationem Christi, qua retulit, quid ipsi facerent, quo arbitrabantur se consequi munditiam internam, cū tamen longè abessent à consequendo ea via mūditiā internam. Vnde sensus est: *Veruntamen, quod superest*, id est, quod habetis, & vobis remanet de acquisitis per fas & nefas, *dati eleemosynā, & ecce omnia munda sunt vobis*, id est, arbitramini omnia vobis esse munda, cū tamen ridiculi in ea existimatione sitis. Tertium sensum tradunt breuiter iidem autores, qui mihi sanè vehemēter placet; eo quòd cum natura ipsa rei, cum editione vulgata, cum forma ipsa loquendi Christi, & cum antecedentibus & sequentibus quadret, neque vllam vim literæ inferat. Nempe, vt ea verba dicta à Christo sint per ironiæ tropum, Phariseorumque commeritam irrisionem; sicut & illa Dei ad Adamū Gen. 3. *Ecce Adam quasi vnus ex nobis factus est, sciens bonum & malum*, quasi ei diceret, longè aliter sibi euenit. Sensus ergo est, *veruntamē quod superest*, id est habetis ac vobis remanet, (vt enim Iansenius rectè notat, non quadrat cum textu græco sensus ille, quem Beda innuit, id est, quod superfluū habetis victui ac vestitui, statuique vestro) *date eleemosynam*, (tuba

videlicet canētes ante vos, vt Matth. 6. notati fuerant à Christo) & ecce ònia munda sunt vobis, id est existimationi vestræ: cùm ridiculi sitis in tali puerili ac stulta cogitatione.

Ex his constat, nullam vim habere quartum argumentum propositum. Tum quia illa verba prolata sunt à Christo, non in sensu proprio, sed in ironico ac irrisoriè. Tum etiam quoniam, esto in sensu proprio intelligerentur, Christi que concilium ad comparandam internam munditiam continerent, pręsupponunt tamen & includunt omnia ad veram pænitiā necessaria, de quorum numero est restitutio, si furtum dānūmve iniustè datum, præcessit, & facultas restituendi adsit, vt suprà explantum fuit.

De radicibus vnde restituendi obligatio oritur. Disp. 717.

SVMMARIVM.

1. *Radices duæ vnde restituendi obligatio oritur sumpta restitutione præssè.*

2. *Restitutionis latè & pressius sumptæ variæ radices ac tituli.*

DIsp. 714. tres distinximus acceptiones resti [sect. 1] tutionis. Et quidem restitutionis

in tertia acceptione ibi explicata, nempe pro actu, quo ex iustitia redditur aliquid in recompensationem eius, in quo quis iniustè materialiter, aut formaliter, est defraudatus, seu læsus, duæ tantum sunt radices, maximè ante mentis oculos habēdæ, in materia de restitutione. Prima est, res ipsa accepta seu habita. Secunda verò iniusta acceptio latissimè sumpta, vt suo ambitu comprehendit iniustam vsurpationem rei, iniustam damni illationem, & retentionem iniustam rei alteri debitæ, vt Disp. 680 est dictum. Qui enim iniustè res alienas demolitur, aut iniuste nocumentum illis infert, vel detinet iniustè, quod alteri debetur, imputatur ei ad effectum, vt teneatur illud restituere ac compensare, ac si illud iniustè accepisset, sibi que iniustè vsurpasset. Hinc dici meritò consuevit, duas esse radices restitutionis, nempe ex parte rei acceptæ, & ex parte iniustæ acceptionis.

Restitutionis verò in prima acceptione eadē [sect. 2] Disp. 714 explicata, nempe pro exhibitione eius, quod quis ex iustitia præstare tenetur, siue præcesserit iniusta acceptio, vel iniusta detentio, siue non, multo plures sunt radices, videlicet duæ proximè explicatæ, res scilicet accepta, iniusta acceptio, & insuper omnis titulus, ex quo obligatio insurgit dandi, aut faciendi, aliquid ex iustitia. Interdum quippe obligatio consurgit ex contractu, vt ex venditione, emptione, locatione, conductione, promissione, & ex cæteris cōtractibus, tam consuetis, quàm inconsuetis, vt quando commodatarius obligat se ad restituēdam rem commodatam, etiam si casu fortuito pereat. Interdum verò consurgit talis obligatio ex vltima voluntate, vt si res, quæ apud vnū est, alteri sit relicta tanquam pars hæreditatis, vel tanquam legatum. Interdum consurgit ex dispositione iuris, vt quòd commodatarius teneatur de culpa leuissima, quando res commodata perit, etiam sine vlla sua theologica culpa; quòd conductor teneatur de leui, & depositarius de lata; quòd lege Aquilia teneatur quis de culpa leui, aut leuissima, ex damno alteri [[206]] dato; quòd nauta, stabularius, aut caupo teneatur de damnis suorum, etiam si nulla ipsius interuenerit culpa; quòd caput domus teneatur de damnis ex eo aliis subsequutis, quòd ex ipsorum domibus aliquid proiectum vel effusum sit, esto nulla ipsius culpa interuenerit; quòd dominus mancipii, aut bruti animalis, teneatur

ad damna à suo mancipio, vel à bruto animali, absque vlla sua culpa data; quousque in superioribus explicatum est, hos omnes ad hæc teneri. Hæ autem omnes obligationes, & aliæ similes, vt quòd hæreditas aliqua ab intestato alicui obuuiat & debeatur, ex sola humani iuris dispositione proueniunt, eas in commune bonum statuentis. Cum his titulis coniungi debet obligatio aliquid de iustitia faciendi accedente præcepto aut statuto principis per se, aut per suos ministros publicos, legitimè id iubentis, vt quòd tantum, vel tantum, soluatur in tributum. Affinis etiam prædictæ obligationi est, quæ prouenit ex iusta sententia, in pænam iustam aliquid soluere præcipientis. Ex his omnibus, & ex aliis similibus titulis, qui ex parte suis locis explicati sunt, & restant in sequentibus explanandi, consurgunt variæ obligationes ex iustitia aliquid dādi, aut saciendi, qui omnes radices sunt restituendi in prima ac latissima restitutionis acceptione.

Quod verò ad mediam, secundamve, restitutionis acceptionem attinet, pro exhibitione videlicet eius, quod quis ex iustitia præstate tenetur, præcedente iam iniusta illius acceptione, saltem materialiter; sanè, cùm tituli, seu radices, ex quibus obligatio huiusce restitutionis oritur, non alii sint, quàm tituli ac radices restitutionis latissimè sumptæ, nec obligatio hæc in alio ab obligatione restitutionis latissimè sumptæ differat, nisi quòd hæc adiunctam habeat morā iniustam restituendi, quod ex illa prima restitutionis obligatione debetur; si verò obligatio aliqua vltiùs restituendi aliquid ex tali iniusta mora oriatur, propter damnum, saltem lucri cessantis, iniustè ea mora datum, ea restituendi obligatio ad obligationem restitutionis tertio modo attineat; necessarium profectò non erit explanare ampliùs radicem huiusmodi restitutionis. Nihilominus de restitutione in hac tertia acceptione redibit sermo à Disp. 724, quousq; ea fieri debeat, quando præcessit iniustitia percurrando varias partes, quæ sub ea continentur, in quibus diuersitas cernitur circa id, quod est restituendum.

Quou sive obligatio consurgat restituendi ex parte rei acceptæ, ad alterumve attinentis. Disp. 718.

SVMMARIVM.

1. *Restitutio ex parte solius rei ad alterum attinentis, quo vsque, & quoad quæ, facienda, aut non faciēda. Et quousq; præscriptio eam facere excuset, maximè quoad fructus inde perceptos.*
2. *Restituere quis tenetur ex parte rei ad alterum attinentis, quantum inde factus est Iocupletior, quando res, aut aliquid illius, iam non existit, modò non excedat valorem eius, quod non existit.*
3. *Restituere tenetur legitimo hæredi, qui credens se legitimum hæredem, lucratus est aliquid ultra rei valorem ex re ad hæreditatem attinente.*

Consequenter est explicandum, quousq; ex [sect. 1] radicibus disputatione præcedente explicatis restituendi obligatio oriatur, præsertim ex duabus præcipuis, ex quibus solis dictum est, oriri obligationem restituendi in tertia pressa ac magis propria restituendi acceptione: ordiendumque est ab obligatione ex parte solius rei acceptæ, hoc est, ex eo, quòd aliquis rem alterius, ad alterumve pertinentem, possideat, aut possederit, bona fide. Eo enim ipso, quòd quis possidet mala fide, incipit oriri obligatio restituēdi ex secunda radice, nempe ex parte

iniustæ acceptionis, seu retentionis iniustæ, rei alienæ. Quis autem dicetur bona fide, aut mala fide, possidere, Disp. 63 fuit explicatum. Præterea disputatione. 36, iunctis quæ in antecedente disputatione fuerant dicta, eam doctrinam applicauimus ad praxim mancipiorum, explicando eo in loco, propter rumores & vrgentia indicia, quæ erant, multa ex mancipiis, quæ in Lusitaniam variis ex locis asportantur, iniustè esse in seruitutem redacta, quousque fas esset illa emere, & quis dicendus esset malæ cut bonæ fidei possessor eorum, & quam diligentiam tenerentur facere emptores, aut alio titulo possessores eorum, tam ante emptionem, quàm post dubio insurgente, an legitimè in seruitutem essent redacta, & quousq;, ac quando, facienda illis esset restitutio libertatis ac obsequiorum, damnorumque illis subsequutorum, quæ omnia non modicam lucem afferent dicendis hac & sequenti disputatione.

Quod attinet ad radicem restitutionis ex parte solius rei acceptæ, hanc regulam generalem possumus statuere. Qui solùm restituere tenetur ex parte rei acceptæ, hoc est, quia bona fide possidet, aut possedit, vel consumpsit, aut alienauit, rem ad alterum pertinentem, antequam eam ipse præscriberet, solùm tenetur restituere, quod ex ea re permanet, & quantum ex illa est factus locupletior, in ea re, aut cum ea re, computando fructus omnes permanentes ex ea perceptos, & quantum ex consumptis factus est locupletior: deducendę tamen sunt expensæ. Quo fit, vt, si nihil ex ea re, aut ex fructibus illius, permaneat, in nulloque inde sit factus locupletior, ad nullā omnio restitutionem teneatur. Regula hæc cōmunis est doctorum. *D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 6. Caiet. ibidem, & in summa verb. restitutio, Soti. 4. de iust. q. 7. art. 2. Ioan. Med. de rest. q. 10. Couar. reg. peccatum part. 3. in initio. Nauar. in manu. c. 17. n. 7. & aliorum.*

Dictum est in regula, antequam eam ipse præscriberet: quoniam si bona fide eam possedit toto tempore ad eam præscribendam requisito, concurrentibusq; aliis conditionibus ad illam præscribendam, iuxta ea quæ in materia de præscriptione explanata sunt, necessariis, tunc eo ipso comparauit dominium illius, isque ad quem dominium, aut eius ad illam, attinebat, illud amisit, eaque de causa is bonæ fidei illius possessor non tenetur deinceps eam restituere. Hoc loco obserua, fieri optimè posse, vt quis præscriptos habeat fructus ex re immobili, quam bona fide possedit, perceptos, quando nondum rem ipsam immobilem præscripserit: eo quòd longè minus tempus sufficiat ad fructus aliquos præ-[[207]]scribendos, qui res mobiles sunt, quàm ad præscribendam rem immobilem: atque tunc, si cesset bona fides, restituere tenebitur talem rē immobilem, non verò eos fructus, eamve fructuū partem, quos, vel quam, vsque ad punctum amissæ bonæ fidei præscripserit, quia scilicet integro triēnio bona fide eos possederit. *Ita Panor. c. grauis de rest. spol. n. 11. Syluest. verb. fructus, & alii.* Idem dic de fructibus beneficii bona fide possessi.

Quòd autem bonæ fidei possessor rei, quæ ad alterum pertinet, statim ac scit ad alterum pertinere, restituere illi teneatur, quod ex ea permanet, satis est manifestum. Quoniam si illud, altero inuito, retineat, vtique iniustitiam aduersus eum committit, id ita retinendo: quare tenetur id illi restituere. Atque idem est de fructibus ex ea re permanentibus, quos nondum præscripserit. Quoniam fructus tanquam partes rei, cuius sunt fructus, reputantur, ad eumque pertinent, ad quem ea res pertinet, vt sæpe toto hoc tractatu 2 dictum comprobaturque est.

Tota autem regula proposita colligitur aper [sect. 2] tè ex. *l. item veniunt. §. eos autē. ff. de pet. hæred.* vbi glossa ait, nullam veriore regulam esse in iure, quàm quòd possessor bonæ fidei ad nihil ampliùs teneatur, quàm quantum ex re bona fide possessa factus sit locupletior. *Idem colligitur ex. l. sed etsi. §. consuluit. ff. eod. titu. & ex aliis iuribus.* Ratio autem est, quoniam

id, in quo factus est quis locupletior ex re alterius, eam, vel fructus ex illa, consumendo, aut alienando, est quasi effectus rei illius, aut fructuum ex illa, succeditq; proinde loco rei, aut fructuum ita consumptorum, vt inde compensetur vsque ad iustum rei ac fructuum valorem, ita scilicet quòd, si factus sit ditior plus, quàm res ac fructus valeant, non tenetur restituere totum, in quo inde factus est ditior, sed solùm vsque ad integrum valorem eius, vnde factus est ditior. Verbi gratia, si ex eo, quòd inuitatus sim ab aliquo, qui, me ignorante, cænam mihi dedit de re aliena, factus sim ditior vltra valorem eius partis rei alienæ, quàm consumpsi, quia re vera plus ego insumpsissem in cænam, si ab illo non fuisset inuitatus, non teneor restituere totum, in quo factus sum ditior, sed solùm valorem partis rei alienæ, quam ego consumpsi. Ratio est perspicua, quoniam quādo id, quod resultat ex re aliena, non est fructus illius, qui proinde fructus ad dominum rei illius pertineat, sed est augmētū mearum diuitiarum, tunc, quamuis id obligatum maneat ad inde cōpensandū, quod ex re aliena consumptum est, quatenus equitas postulat, neminē cum alterius iactura, seu detrimento, locupletari, *vt habetur. l. nam hoc natura. ff. de condict. indeb.* non tamen manet obligatum ad compensandum vltra id, quod est consumptum, & ob quod locupletior sum factus: eo quòd sufficienter proximo compensem, quod de bonis illius in meum cessit commodum, si illud ad æqualitatem compensem. Vnde regula proposita non habet, po sessorē bonæ fidei restituere teneri totum, in quo ex re ita possessa, aut ab eo consumpta, factus sit locupletior, sed teneri solùm, quantum inde sit factus locupletior; hoc est, non vltra, quàm inde factus fuerit locupletior. Quia verò is, ad quem pertinet res, ex qua alius est factus locupletior, non plus iuris comparat ad id, in quo hic alius factus est locupletior, quàm haberet ad rem ipsam, quando erat apud hunc alium; neque plus manet ei obligatum id, in quo alius est factus locupletior ex re ipsius, quàm obligata ei esset res ipsa, quamdiu salua manebat apud hunc alium; consequens profectò est, vt si is, qui ex tali re aliena factus fuit locupletior, bona fide illud consumat, ita vt, perseuerante bona fide, non plus habeat postea temporis decursu in bonis suis, quàm esset habiturus, si nunquam res illa aliena ad suam potestatem deuenisset, ad nullam omnino restitutionem teneatur. Hac ergo regula est vtendum ad iudicandum, quousque possessor bonæ fidei restituere ex eo teneatur, quòd ex re alterius, aut ex fructibus ex illa factus sit locupletior. Respiciendum est ad instans, in quo bonam fidem amittit, scitque rem ad alterum pertinere, attendendumq; est, num tunc aliquid plus habeat in bonis suis propter rem alterius, & fructus ex illa, quod non esset habiturus, si ea res, & ii fructus, non deuenissent in ipsius potestatem; & quidem, si aliquid plus habeat, in eo solo, constitutus in eo instanti, censendus est factus locupletior, idq; solùm tenetur restituere: si verò nihil plus in eo instanti habeat, quàm habiturus esset, si res illa, & fructus ex illa, in suam non deuenissent potestatem, nihil restituere tenetur, esto antea ex illa fuerit locupletior effectus. Imò verò addo, si postquam cognouit eam rē, aut fructus ex illa, ad alterum pertinere, probabiliter ignorauit, se teneri restituere id, in quo fuerat locupletior effectus, illudque bona fide consumpsit, ita vt in instanti, in quo depellitur ac cessat ignorantia inuincibilis, nihil plus habeat in bonis, quam habiturus esset, si ea res, aut fructus ex illa, ad suam non deuenissent potestatem, nihil omnino restituere tenetur: quia neque tenetur ex parte rerum consumptarum, quæ non extant, neque ex parte consumptionis, eo quòd, vt supponimus, nulla in ea consumptione interuenerit culpa.

Illud est obseruandum, quando, quod aliquis [sect. 3] bona fide possideret, esset hæreditas ad alium, & non ad se, re ipsa pertinens; tunc, si ex illa sit factus locupletior, vt quia rem aliquam hæreditatis vendidit maiori pretio, quam postea minori pretio redemit, vtique

incrementum illud non ad se pertinet, sed ad legitimum hæredem: sicut, si eadem bona fide rem aliquam priùs vendidisset minori pretio, quam postea eadem bona fide maiori pretio redemisset, decrementum illud, non ad se, sed ad legitimum hæredem pertineret: quoniam in his vniuersalibus, de quorū número est hæreditas, pretium succedit loco rei, atque ad hæreditatem attinet: vniuersimque bonæ fidei possessor hæreditatis restituere tenetur legitimo hæredi id omne, in quo ex tali hæreditate est factus locupletior: sicut etiam, si quid ex hæreditate luxuriosè ac malè, bona tamen fide, consumpsit, id totum detrimentum ad legitimū hæredem spectat, vt Disput. 246 hæc omnia copiosè ostensa à nobis sunt.

Quousque bonæ fidei possessor rei aliene, ad alterúmve attinentis, fructus illius restituere teneatur. Et num tali bonæ fidei possessori solui debeant impensæ, & melioramenta in tali re facta? Disp. 719.

SVMMARIVM.

1 . Fructus industriæ qui. Et fructus rei qui.

[[208]] 2 . Fructus rei, qui naturales, qui industriales, & qui ciuiles, à iurisperitis dicantur.

3 . Fructus rei licèt iurisconsulti non reputent partus ancillarum, à theologis tamen ad restitutionis negotium inter fructus rei computantur.

4 . Restituenda est ab eo, qui possessor illius fuerat bona fide, res cum omnibus illius fructibus, qui sint fructus rei, si existant, & quantum ex non existentibus factus fuerit locupletior, deducendæque inde sunt expensæ. Non verò tenetur restituere fructus suæ industriæ.

5 . Restitui debet ab eodem bonæ fidei possessore pretium vsus torquis ad ornatum ab eo locati.

ANtequam regulam, præcedente disputatione propositam, aliquibus adhibitis exemplis,

disputatione sequenti ampliùs elucidemus, quod primo loco est propositum, erit circa eandem regulam examinandum: eo quòd in ea dictum sit, fructus perceptos ac permanētes ex re aliena bona fide possessa, & quantum ex ea re, & ex fructibus consumptis, possessor illius bonæ fidei fuerit factus locupletior, deductis expensis, esse restituendum.

Est autem obseruandum, quosdam esse fru [sect. 1] ctus rei, & quosdam industriæ mediante aliqua re, interuentúve illius. Fructus industriæ sunt, quorum res ipsa non est ferax, sed solùm vt subest industriæ, tanquam in strumētum, quo mediante industria humana illos acquirit. Eiusmodi sunt fructus, qui comparantur negotiando pecunia, tritico, & quibuscunque aliis rebus, tam mouilibus, quàm immobilibus, cas emendo & vendēdo: lucrum quippe, quod inde reportatur, non est fructus proprius ipsarum rerum, sed industriæ, vt eis rebus humana industria negotiando vtitur. Similiter arte factum, quod quis alieno instrumento conficit, non est fructus instrumenti, sed industriæ atque artis humanæ eo vtentis instrumento. Fructus verò rei sunt, quorum res ipsa mediātè, vel immediātè, est ferax, esto interdum illos non producat, nisi adiuta humana industria. Tales sunt fructus agrorum, vsus etiā cuiusque rei, qui non sit illius consumptio, (nomine, consumptionis, alienationē etiam illius intellige) est quoque fructus illius: mediatus verò fructus eiusdem rei, est etiam valor, qui pro tali vsu comparatur. Vt vsus domus ad habitandum, aut custodiendum aliquid,

est fructus domus, & similiter fructus mediatuſ eiusdē domus est pretiū, quod pro tali vsu illius datur. Vsus item equiad equitandū, aut ad aliquid aliud, est fructus equi; & similiter pretium, quod pro eo vsu datur. Vnde, si quis instrumentum alienum, inscio domino, locet ad aliquid eo conficiēdū, pretium illud, tanquam fructus rei, & non industriæ, pertinet ad dominum instrumenti, & non ad locantem, esto nūquam dominus instrumenti eum fructum ex suo instrumento fuisset percepturus, nisi interuenisset industria illud locantis. Fructus autem seminum, vt tritici, aut alterius similis, potiūſ est fructus agri, cui semina sunt mādata, & cui plantę sunt affixę, quām seminis, eaque de causa pertinet ad dominum agri, vel ad eum, cui ad id vsus talis agri conuenit, & non ad eum, cuius erat triticum, aut semen aliud simile terrę mandatū. Quare, si quis furetur triticum, quod seminet in agro suo, tenebitur quidem domino tritici restituere valorem illius, & totum lucrum ea de causa illi cessans, ac damnum emergēs; fructus tamen ad dominum agri attinebūt. Eadē ratione, si quis instrumento alieno vtatur, domino illius inscio, ad arte factum conficiēdum, quia talis vsus, tanquam verus fructus eius instrumēti, aut ex eo instrumento perceptus, ad dominum instrumēti spectat; arte factum verò non item, sed est fructus industriæ illud conficiētis eo tali instrumento; vtique, qui tali instrumento, inuito domino illius, est vsus, tenetur illi restituere, præter instrumentum, valorem eius vsus, & si quod lucrum illi cessauit, aut damnum emersit, ex usurpatione talis instrumēti: arte factum verò ad ipsum spectat, tanquam fructus suę industriæ mediante eo instrumento. Circa hanc distinctionem, fructus rei & industrię, multa diximus in materia de vsura, & aliās sæpe.

Iurisperiti fructus rei diuidunt, in naturales, [sect. 2] industriales, & ciuiles. Naturales appellant, quos ipsa natura producit, nulla, aut modica, apposita industria. Vt sunt herbę sua sponte à terra productę, aut arborum poma, & his similia, quę vel nulla, vel modica, indigent industria. Industrielles fructus appellant, in quibus multum requiritur industriæ, tametsi rei natura, cuius sunt fructus, ad illos producendos cooperetur. Tales sunt, segetes, vinum, lana, caseus, & similia. In dubio autem, num tantum industriæ interueniat, vt potiūſ industriales dicendi sint, quām naturales, res expendenda ac definienda iudicis arbitrio relinquitur. Ciuiles dicuntur, quos res, quorum sunt fructus, non fert in ipsi smet, sed solūm per æquiualeſtiā. Huiusmodi sunt pēsio locationis, aut equi, & alii similes. Lege circa hanc subdiuisionem *Bart. l. ex diuerso, c. l. in fūdo. ff. de rei vend. Panor. c. grauis de rest. spol. syluest. verb. fructus, c. Couar. 1. var. res. c. 3.* Hi tamen omnes fructus à theologis fructus rei appellantur, & distinguuntur à fructibus industriæ: neque quicquam subdiuisio hæc iurisperorum repugnat.

Illud etiam hoc loco obserua, quamuis à iuris [sect. 3] consultis partus ancillarum inter fructus non cōputentur, vt Disp. 7. & Disp. 188. ac alibi dictum est; à Theologis tamen, atque quoad rem præsentem de restitutione attinet, inter fructus cōputari, pertinereque ad fructus rei, vt à fructibus industriæ distinguuntur.

His ita constitutis, quando in regula disputa [sect. 4] tione proposita asseritur; restituendam esse rem, vnā cum fructibus ex illa permanētib; & quātum ex illa, & ex fructibus consumptis, possessor illius est factus locupletior: intelligēdū est id de fructibus, qui sunt fructus rei, esto ad illos cooperata sit industria possessoris: hi nāq; soli sunt, qui ad eum pertinent, ad quem ea res attinet. Nō verò est id intelligendum de fructibus industrię: quoniam hi proprii sunt possessoris eius rei, qui industriā apposuit, vt sæpe in materia de vsura est dictum, & consentit communis doctorum sententia. A fructibus autem rei (vt in eadem regula est dictum) deducēdę sunt expensę factę à possessore bonę fidei: quoniam

regula alia est generalis, quam Disput. 455. §. vlt. stabiliuimus ac probauimus, & de qua sæpius in hoc tractatu secūdo est dictum, id præcisè censi ac esse fructus rei, quod ex eis remanet deductis expensis, computando in expensis iustum etiam stipendium laboris & industriæ appositæ: valor quippe fructuum, expensis, laborique, ac industriæ respondens, potiùs est fructus expensarum, laboris, & industriæ, quàm ipsius rei; eaque ratione potiùs sunt cēsen-[[209]]di fructus in dustriæ, quam rei. Quòd autem valor expensarum extrahi de fructibus debeat, Disp. 455 est ostensum, & dicitur Disp. 725, conclu. 1. Item, qui laborem, industriam, & expensas necessarias, aut vtilis, apponit ad rei cōseruationē, atque ad fructus ex ea percipiendos, ac custodiendos, qui domino eius rei cedunt, vtique agit vtiliter negotium illius, ac proinde actione negotiorum gestorum potest hæc ab eo repetere, & deducere de fructibus ex ea re perceptis. Obserua autem, fi possessor bonæ fidei sit in aliquo factus locupletior ex re, aut ex fructibus, in illo ante omnia compensari debere expensas, laborē, ac industriam, quæ fuerint appositæ. Quòd si, vel in nullo sit factus locupletior, vel non in tāto valore, quātus est valor expēsarū, laboris, & industriæ, quæ sint appositæ, tunc, si partem fructuū cōsumpsit bona fide, & pars extat, pro rata partis fructuum, qui extant, restituendique ei sunt, ad quem res, cuius sunt fructus, spectat, deduci ex eis debet pars expensarum, valorisque laboris & industriæ, quæ sint appositæ. Cū enim reliquam fructuum partem perceperit ac cōsumpserit tanquam suam, sanè, quod in ea expendit, non tenetur ei soluere dominus rei ac fructuum, isve, ad quem ex natura ipsa rei expectabant.

Ex dictis colligo, falsum esse, quod Nauar. in [sect. 5] manu. c. 17. n. 25. affirmat. Eum videlicet, qui torquem aureum, à non domino emptum, sæpius locauit, non teneri restituere pretium locationis domino torquis; eo quòd id pretium fructus sit industriæ, & non rei. Ex dictis enim constat, fructum esse rei, non minus, quàm pretium vsus equi, aut instrumēti artis: quare, cū fructus rei ad dominum rei pertineant, nihil impediēte, quòd ea res illi non fructificaret, nisi accedente industria alterius, & nihil impediēte, quòd in potestate domini, fructum non esset habitura; cōsequēs profectò est, pretium illud dominotorquis, vnà cum torque, esse restituēdū, nisi bona side sit cōsumptū, neque, qui illud consumpsit, factus ex illo sit locupletior. Confirmare autem hoc possumus ex doctrina eiusdē Nauarri, qui in materia de vsura affirmat, monetas aureas locari ad ornatum, & ad similia alia, posse, feracesque, vt sic, esse illius fructus, exigique ea ratione posse competentē mercedē: quod non esset, si ad negotiandum traderentur: quoniam, vt sic, feraces ex se non sunt lucri, sed solum vt subsunt industriæ eis negotiātis.

Quod. 2. loco in hac disputatione fuit propositū, Disp. 463, à §. vt autem explicemus, fuit explanatum.

Ex regula Disp. 718. tradita, nonnulla deducuntur, quibus magis elucidatur. Disp. 720.

SVMMARIVM.

1. *EX*emplis explicatur, quousque quis restituere teneatur, aut non teneatur, ex re, quam bona fide consumpsit, aut qua est vsus, & quousque cēseat factus inde locupletior, aut non censeatur, vt id restituere teneatur, in quo, in puncto scientiæ, se inuenit locupletiozem.

2. *Lucrum cum re aliena, quando est fructus industriæ, neque fur neque alii tenentur restituere.*

3. *Bello, quod quis probabiliter ignorabat iniustum, aut in quo dubius, de mandato superioris pugnavit, damna data quousque non restituenda.*

4. *Restituere tenentur integrum incrementum iniustum, aut integrum damnum datum, ex parte iniustè acceptionis, qui ex crassa ignorantia, quæ ad culpam theologicam spectatis circūstantiis cōcurrentibus sufficiat, contractu aut alia ratione, aliquid iniustum acceperunt, aut damnum aliquod dederunt.*

5. *Restituere non tenetur rem alienam, qui sine crassa ignorantia existimans esse suam, illam prodigè destruit, aut ex ignavia amittit.*

EX regula Disp. 718 tradita, & præcedente dis [sect. 1] putatione ex parte magis explanata,

nōnulla in hac sunt deducenda, quibus veluti exemplis magis adhuc elucidabitur. Ex ea facilè liquet, si quis inuitatus sit ad prædiū rei alicuius furtiuæ, quam, ita inuitatus, furtiuam esse ignoret, ad nullam restitutionē teneri, quando postea nouerit furtiuam fuisse, si inde factus non sit locupletior, vel quia, esto inuitatus non fuisset, nihil erat insūpturus in prædio, vel quia, propter tale prædiū, nihil minus in ipsius domo fuit insūptū ea die, vel denique quia, licet aliquid tunc non fuerit insumptum, factusque fuerit in eo locupletior; tempore tamen, quo furtiuā fuisse agnouit, nihil plus habebat in bonis, quā si in eo non fuisset antea factus locupletior; quia videlicet illud lusit, aut in aliis rebus consumpsit, ita quòd re vera tempore sciētix non plus habet, quā esset habiturus, si antea in eo non fuisset factus ditior. Quòd si tempore scientiæ in aliquo se inueniat factum locupletiorē, quia re vera aliquid propter id prædiū habet plus in bonis, quam tempore talis sciētix habuisset, si ad id prædiū non fuisset inuitatus, id solum incremētū, quod tunc inuenit in suis bonis, tenetur restituere, & non plus. Idem dic si dono accepisset perdices, aut aliquid aliud ad potum, vel ad cibum, spectans, quod bona fide domi suæ cōsumpsit. Si enim tempore sciētix in nullo se inueniat locupletiorē, ad nullam tenetur restitutionem: si verò in aliquo se locupletiozem inueniat, id solum tenetur restituere. Intellige in hoc, in præcedenti, & in sequentibus euentibus, teneri id restituere, in defectum furis, si furto à principio id fuit ablatum: nam fur tenetur illud restituere, si habeat vnde restituere possit, possitque ex illo commodè recuperari: alioquin is restituere tenetur, qui se inueniat ex re illa factum locupletiozem. Eadem ratione, si dono quis accipiat vestem sericam pretiosam, qua bona fide vtatur, ignorans esse alienam, vtique, quando sciuerit alienam esse, non tenebitur soluere, quantum valet vsus ille, aut quantum detrimēti ea vestis ob talem vsum, aut aliqua alia ratione, sit passa, sed quantum in puncto talis scientiæ se inuenit locupletiozem ex eo vsu, quia fortè excusauit ea de causa vsum ac detrimentum aliarum suarum viliorum. Quòd si in nullo se inueniat locupletiozem, nihil sanè restituere teneretur.

Ex eadem regula liquet. Si quis bona fide dono à fure accipiat rem furtiuam, aut bona fide possideat quancunque aliam rem alienam, eamque vendat, teneri, quando alienam fuisse sciuerit, restituere totum pretium domino rei illius, si tempore scientiæ se inueniat in eo toto locupletiozem: alioquin solū tenebitur restituere id valoris illius, in quo se inuenit locupletiozem; & nihil, si in nihilo se inueniat locupletiozem, quia videlicet id totum consumpsit, nec plus habet in bonis, quàm tunc fuisset habiturus, si id pretium ad suas manus ac potestatem non deuenisset.

Ceterum, si rē trāstulit in alium locum, in quo scie [sect. 2] bat plus valere, eaque de causa illam vēdidit maiori a-[[210]]liquo pretio, quam valebat vbi eam antea possidebat, non tenetur restituere id incrementum pretii, esto in illo se inueniat locupletiolem: quoniam incrementum illud pretii, quod accepit, est fructus suæ industriæ, acquisitus mediante ea re, & non est fructus rei in se, ac proinde ad se spectat, iuxta ea quę disputatione præcedente dicta sunt, & non ad dominum rei. Sicut etiam, quod lucratur fur, aut vsurarius, negotiādo cum re furto ablata, aut per vsuram acquisita, & quod lucratur depositarius negotiando cum tritico, aut pecunia, depositis, ad ipsos spectat, vt Disp. 327 & 524 ostendimus. Quæ autem circa rem emptam ex fure dici hoc loco poterant, commodiùs dicētur disputatione sequenti. Id verò, quod de restitutione pretii domino rei, aut partis, in qua vendens ita bona fide se locupletiolem inueniat, intelligenda sunt, quando dominus non recuperat rem ipsam ad se attinentem, illam vendicando, ac extrahēdo de potestate possessoris, neque illi restituitur. Ex eadem regula facilè etiam liquet, quod in [sect. 3] calce disputationis 113 definiuimus. Nempe cum, qui in bello, quod, adhibita debita diligentia, credidit esse iustum, aut dubius de iustitia belli, iussus à suo superiore, pugnavit, multaue inimicorum destruxit, & multa etiam vsurpauit, quæ partim consumpsit, & partim alienauit, si postea ei constet de belli iniustitia, nihil teneri restituere, nisi tempore talis scientiæ se inueniat in aliquo ex illis rebus locupletiolem. Atque tunc teneri solùm restituere id solum, in quo se inuenit inde locupletiolem. Restitutio verò erit illis facienda, ex quorum rebus in particulari se inuenit locupletiolem: tantum cuique, quantum ex rebus illius apud se reperit, aut quantum ex illis se inuenit locupletiolem. Aliis autem, etiam si illis damnum intulerit, aut illorum res occupauerit, si ex illis nihil apud se inuenit, in nulloque locupletiolem se reperit, nihil restituere tenetur.

Dubium est, num illi, qui bona fide contra [sect. 4] ctus aliquos celebrarunt, nescientes esse iniustos, si postea comperiant eos fuisse vsurarios, aut aliter in iustos, solùm teneantur restituere, quantum se inuenerint locupletiores ex incremēto, quod ita iniustè acceperunt, ita quòd, si in nullo se inueniant locupletiores, quia re vera tempore, quo scire incipiunt iniustos eos fuisse, nihil plus habent in bonis, quam si id in cremenū non accepissent, ad nullam restitutionē teneantur. Dicendum autem est, si in celebrādis huiusmodi contractibus interuenit ignorantia affectata aut crassa, ita quòd peccauerint eos celebrando, ea ignorantia minimè eos excusante à culpa theologica, tunc non dici bonæ fidei, sed malæ fidei possessores eius incrementi, vt Disp. 63 fuit comprobatum; eaque de causa eos teneri ad restitutionem totius illius iniusti incremēti, esto ex illo non se inueniant locupletiores. Ratio autem est, quia, eo dato, non solùm tenētur ex parte rei acceptæ, sed etiam ex parte iniustæ acceptionis: eo quòd contra iustitiam peccauerint celebrando eos contractus, idque accipiendo, in quo suos proximos defraudarunt. Arque hoc magnopere est attēdū in re hac de possessore bona fide, & de restitutione ex parte solius rei acceptæ, ne quis fallatur, arbitrando, semper eum, qui absque peccati scrupulo aliquid accipit, quod re ipsa, rei natura spectata, non poterat iustè accipere, aut dānum aliquod ita dat, accepisse id, aut dedisse id damnum, bona fide, solumque teneri ad restitutionē ex parte rei acceptę, & non ex parte iniustæ acceptionis. Est enim semper conjiciendus oculus, an ignorantia fuerit tam crassa, vt, attenta qualitate personæ, ac circumstātiarum concurrentium, non excuset à culpa theologica. Et quidem, quando iudicatū fuerit esse talem, quæ à theologica culpa non excuset, iudicandum consequēter est, illum non habuisse bonam fidem in defraudādo ita proximo suo, ac proinde teneri ad restitutionem, non solū ex parte rei acceptæ, sed etiam ex parte iniustæ acceptionis. Quòd si in eiusmodi

contractibus nō interuenit crassa ignorantia, tunc, cū acceptores ac detētores eiusmodi iniusti in se incremēti censendi sint bonæ fidei possessores illius, ac proinde obligatos non fuisse ad restituēdum ex parte iniustæ acceptionis, sed solū ex parte rei acceptæ, vtique non plus iudicandi sunt teneri restituere, quā se ex tali incremento locupletiores tempore depulsæ ignorantiæ repererint.

Sotus. 4. de iust. q. 7. art. 2. ait. Eum, qui bona fide [sect. 5] de rem alienam accepit, si absque magna sua culpa eam amittat, nulli restitutioni manere obnoxium. Quibus verbis innuere videtur, si sua culpa eam amiserit, teneri ad restitutionem illius. *Nauar. item in Manu. c. 17. n. 7. ait,* si res illa sine culpa illius pereat, nihil aliud teneri restituere, quā quod ex illa fuerit factus locupletior. Quibus verbis similiter innuit, si culpa illius pereat, teneri restituere valorem illius. Ceterum, si de possessore illius bona fide tanquam suæ, qui in culpa theologica non sit, ignorando esse alienam, id intelligant, falsa profectō est ipsorum opinio. Esto enim ex professo eam destrueret, arbitrando se destruere, quod suum erat, & esto in eo peccatum prodigalitatis incurreret, nihilominus, quando postea sciret fuisse alienam, ad nullam restitutionem teneretur, nisi quantum ex illa fortē se inueniret locupletiores. Ratio autem est, quoniā neque teneretur ex parte rei, quæ non extaret, neq; ex parte iniustæ destructionis; eo quod in ea destructione nullum iniustitiæ peccatum cōmiserit, excusante eum ignorantia inuincibili, quod talis res esset aliena. *Ledesmius. 2. 4. q. 18. ad finem art. 6. tribuit Adriano de rest. q. vtrū in foro animæ, quod esserit, quando aliquis ex iusta ignorantia, credens eam rem esse suam, quæ verē sua non est, eam destruit, aut donat alteri, ex quo recuperari non possit, non minū teneri eum illam restituere, quā si, sciens esse alienam, id fecisset. Quamuis autem Adrianus. q. citata ad finem. §. 3. id asserere videatur, postea tamen § penult. id videtur limitare, atque ita explicare, vt à sententia nostra nihil discordet. Quicquid autem ille senserit, nostræ profectō est standum sententiæ.*

Nonnulla alia circa eum, qui rem alienam cæpit bona fide possidere. Et num, si titulo emptionis, aut alio oneroso, cæpit illam possidere, & postea bona fide illam vendat, aut permutet, teneatur restituere domino illius, quod in commutationem pro illa accepit, comperto alienam fuisse. Disp. 721.

SVMMARIVM.

1. Dominus rei vindicare eam potest ex quocūq; apud quem illam repererit, nullo ei persoluto

[[211]] pretio, esto ille pretio illam comparauerit; neque tentor potest eam illi denegare, si sciat dominum illius esse, sed agere de euictione poterit aduersus venditorem.

2. Excipitur, quando agendo vtiliter negotium domini rei, illam emit modico pretio, ne dominus illum amitteret. Nam tunc ei solui debet pretium à se pro illa datum.

3. Quibus variis modis potest esse affectus possessor rei alienæ quo ad bonam vel malam fidem, quod sit aliena, explicatur.

4. *Bona fide qui cæpit possidere rem, & dubitare incipit an aliena sit, tenetur facere moralem diligentiam, ut id sciat; si id scire non possit, neque occurrat unde id postea sciri possit, licet eam retinet ac consumit.*

5. *Si in eo dubio is omittat facere eam diligentiam existente occasione id sciendi, & quòd elapsa sit ea occasio, spes pereat id sciedi, restituere tenetur partem valoris rei, pro quantitate verisimilitudinis, quæ erat, ut tunc id sciretur, & pro quantitate verisimilitudinis, quòd eares aliena esset.*

6. *Restituere non tenetur quicquam, qui rem alienam bona fide emit ac vendidit, si non plus pro ea accepit, quàm pro illa dedit, aut si plus accepit, illud fuit fructus sui laboris aut industriæ.*

7. *Rei alienæ emptor medius, quando postea scit rem fuisse alienam, ad quid teneatur ex iustotia, vel ex caritate, aut non teneatur, tam comparatione domini, quàm comparatione prioris, aut priorum venditorum, aut posterioris, vel posteriorum emptorum, tam quando res adhuc existit, quàm quando iam non existit.*

8. *Emptio rei alienæ valida est, & emptor transfert dominium pretii in venditorem, licet non comparet dominium rei emptæ. Tenetur verò ei venditor de euictione. Quòd si emptor eam rem cõsumpsit, aut alienavit, vel in potestate illius perit, ad nihil tenetur ei venditor.*

9. *Emptio vnius rei existimatæ alia, autrei vitiosæ, quando vitium causam dedit contractui, cur nihilominus sit nulla, venditorque non comparet dominium pretii.*

10. *Emptor rei alienæ, si illam vendat maiori pretio, quam illam emerit, non tenetur restituere incrementum illud domino rei; eo quòd non sit fructus rei, sed suæ industriæ.*

IN lucem eorum, quæ hac & duabus sequen [sect. 1] tibus disputationibus dicenda sunt,

statuendum est. Dominum rei, vbicunque eam repererit, posse illam vindicare, eamque tanquam suam accipere, nullo persoluto pretio, esto is, qui illam possidet, bona fide eam emerit, tignorans alienam esse. Talis enim possessor exigere non potest pretium à domino rei, quippe qui nullam iniuriam ei possessori fecerit, nihilque iuris ex eo circa rem suam amiscrit, quòd malitia furis, aut absque cuiusquam malitia, in eum deuenerit statum. Is tamen possessor agere cum venditore poterit de euictione ad pretium, & ad interesse, ut hæc omnia copiosè explanata ac comprobata sunt præsertim Disp. 327. 330. & 380. Conueniunt itaq; doctores, possessorē rei, quam emit à fure, non posse denegare eam domino petēti, si constet eum verè esse illius dominum, reique illius dominū non teneri soluere tali possessori pretium, quod pro ea dedit, nihil impediēte, quòd fur non cõpareat, & quòd is possessor amissurus sit pretium, atq; ita habetur expresse. l. in ciuilem. C. de furtis. l. mater, & l. si mancipium. C. de rei vend. & aliis iuribus.

Ab hac tamen regula excipitur, quando ali [sect. 2] quis modico pretio emit rem furto ablatam eo animo, ut eam redderet domino illius; quia videbat, nisi ipse ita illam emeret, dominum nunquam eam recuperaturum, aut meritò id valde esse timendum; intendendoque agere vtiliter negotium domini eius rei, illam ita emit. Quod licitum esse affirmat Aug. c. rapinam. 14. q. 5. his verbis: *Rapinam emere non licet, nisi ea intentione, ut, cui est ablata, restituatur.* Tunc autem dominus, non solum in conscientia, sed etiam in exteriori foro, tenetur soluere pretium emptori actione negotiorum gestorum, ut rectè affirmant Caiet. 2. tom. opuscul. tract. 31. (qui est 17. responsum, resp. ult. casu. 3. Gabr. in 4. dist. 15. q. 3. art. 3. dub. 5. propos. 1. Couar. reg. peccatum, part. 3. in initio. n. ult. & plerique alii, quos Couar. citat. Tametsi

optimè cum aliis obseruet, in foro exteriori id locum non habere, nisi quando sufficienter probatur, aut coniecturis sufficienter præsumitur, intendisse agere vtiliter proximi negotium. Illud deinde est obseruandum. Eum qui à fu [sect. 3] re, aut ab aliquo alio, cuius res non erat, eam emit, aut alio oneroso titulo illam acquirit, vel etiā gratuito, variis modis posse se habere. Quoniam à principio, quando eam emit, aut alio titulo illam comparauit, vel fuit bonæ fidei emptor, atque adeò possessor bonæ fidei, quia scilicet probabiliter meritoque ignorauit rem esse alienam, vel fuit emptor aut aliter possessor malæ fidei. Si à principio fuit possessor malæ fidei, id euenire potuit multis modis. Quia, vel quando emebat, possideré inceptit eam rem, vel nouit esse alienam, vel, essétne aliena, dubitauit, vel ignorantia crassa eam emit, aut possidere inceptit, attendere debens esse alienam, ex qualitate rei, venditoris, aut alio titulo eam tradentis, & ex aliis circumstantiis concurrentibus, aut certè debens de ea re dubitare. Rursus, post comparatam bonæ fidei possessionem, multis etiam modis potest se habere. Quoniam vel potest amittere bonam fidem, sciendo rem esse alienam, idque vel postquam eam distraxit, aut consumpsit, vel perseuerans adhuc in illius possessione; vel potest incipere ea de re dubitare. Iuxta hæc verò omnia membra, variæ statuendæ sunt conclusiones hac disputatione & Disp. 723.

His ita constitutis, prima conclusio est. Qui⁶¹ bona fide emit, aut alio iusto titulo cæpit rē bo [sect. 4] na fide possidere, si antequam eam distrahat, aut consumat, dubitare in cipiāt, an sit aliena, tenetur adhibere competentem diligentiam, vt sciat, an ad alium pertineat. Quòd si competētem diligentiam ad liibuit, nec comperire potuit esse alienam, nec ei occurrat diligentia alia, quam efficere possit, & vnde speret id scire posse, tunc tuta conscientia potest illam retinere, & consumere, neque ad vllam restitutionē tenetur, esto dubius maneat, an sua sit. Ratio autem est, quoniam in dubio melior est conditio ipsius, qui bona fide possidere cæpit. Item quoniam, cum dubio illo speculatiuo, an sua sit, stat vera ac firma opinio practica ac moralis, quòd licitè cum eo speculatiuo dubio possit eam rem totam perinde sibi retinere, eamque consumere, ac si certò esset sua, vt Disput. 16. 35. 36. 63. 103. & [[212]] alibi, dictum comprobaturque est.

Secunda conclusio. Si dubius idem, an res esset [sect. 5] sua, de quo præcedente conclusione est habitus sermo, neglexisset adhibere diligentiam competentem ad sciendum, an esset aliena, quam adhibere potuit, ita quòd, elapsa ea oportunitate, sciri iam non potest, an res sit aliena, restituere tenetur partem valoris eius rei, maiorem, vel minorem, pro quantitate probabilitatis, quæ erat, vt sciretur, rem esse alienam, & pro quantitate maioris, vel minoris, verisimilitudinis, quæ erat, eam rem esse alienam, iuxta ea, quæ Disp. 36 in calce 2 conclusionis, & Disp. 63, conclu. 2. dicta sunt. Ratio autem est, quoniam per tale dubium, accedente ea negligentia culpabili, cōstituitur possessor malæ fidei, vt ad restitutionē teneatur, nō quidem integræ rei; siquidem non constat alienā esse, sed adhuc dubium perseuerat, an sit ipsiusmet ipsam possidētis; sed quantum æstimabitur dānū, quod ex ea culpabili negligentia est sequutū: & quoniam res erat anceps, an, adhibita ea diligētia, cōperiēdū fuisset, rem esse alienam, non tenetur restituere rē totam, sed quantum quis æstimare iure optimo posset illam spē, quòd scilicet cōperiretur ad se pertinere: porrò ea spes eo plus valet, quo maior esset verisimilitudo, eam rem alienam esse, & quo maior esset probabilitas, quòd cōperiēdū fuisset, alienam esse, si adhibita fuisset ea diligētia.

Tertia conclusio. Qui emit rem bona fide, &⁶² postquam illam alteri vendidit, cōperit fuisse alienā, si non accepit maius pretium pro ea, quam fuit [sect. 6] rit illud, quod pro ea dedit, nullūq; alium fructū ex illa percepit, ad nullam restitutionem tenetur domino rei. Idem dic,

quando, si aliquid amplius accepit, illud fuit iustum pretium sui laboris, aut fuit fructus suę industrię. Vt, si emit triticum bona fide, quod re vera erat alienum, & illud transportauit in alium locum, vbi plus valebat; aut si ex illo, redacto in farinam, & panes, quos vendidit, accepit incrementũ, tãquã pretium sui laboris ac industrię, aut tanquam fructum suę proprię industrię, ad nullam restitutionem tenetur domino tritici. In hac conclusione omnes cõueniũt. Quoniam hic in nullo est factus locupletior ex re alterius, quã bona fide emit, ac bona fide vendidit: id quippe incrementũ, quod accepit, non est ex re illa tãquã fructus eius, sed est fructus suę industrię, aut simul etiam cõdignũ pretium sui laboris ac operarum, quod proinde sibi acquirit, & non domino rei, qua negotiando illud acquisiuit. Quare, si res iã sit omnino consumpta, aut emptor vltimus disparuit, ita quòd res iam recuperari non possit, ad nullam restitutionẽ tenetur. Atque in primis ad nullã restitutionem tenetur emptori: eo quòd res ex illo non sit euicta, teneaturque ei de euictione, si ex illo euincatur, vt Disp. 380 ac alibi est dictum, & contractus fuerit validus, vt ibidem, & Disp. 327. & 330 ostendimus. Deinde verò, neque ad vllam restitutionem tenetur domino rei. Quoniam hic medius emptor & venditor in nullo est factus locupletior ex illa, solumque teneretur domino rei illius, quantum ex illa esset factus locupletior: quippe cùm solũ teneretur ei ratione rei, & non ratione iniustę acceptionis, cùm illam possederit semper ac distraxerit bona fide.

Hoc loco obserua, quando res iam non existit, aut [sect. 7] recuperari iam non potest, medium hunc bonę fidei emptorem, ac venditorem, qui scire incipit rem esse alienam, neque ex illa est factus locupletior, in foro exteriori ad nihil teneri dominorei, cui in eo euentu solum competit actio aduersus malę fidei vsurpatorem, aut retentorem, eius rei, non verò aduersus bonę fidei possessores, nisi in defectũ malę fidei possessoris, aut malę fidei detentoris, atq;, in horum defectum, solũ competit ei actio aduersus illos bonę fidei antiquos possessores eius rei, quantum ex illa sunt facti locupletiores: qui postea, si titulo oneroso illam cõparauerãt, possunt id repetere ab eis, à quibus immediatẽ titulo oneroso illam acceperant, qui ipsis tenentur de euictione ad totum ipsorum interesse, & per consequẽs ad id emolumẽtũ, quod ex ea re perceperãt. In foro autẽ conscientię, vltra id, in quo facti sunt locupletiores ex re illa, (ad quod, vt dictum est, solum tenẽtur in defectum malę fidei anteriorum possessorũ) solũ ex caritate tenentur admonere primũ malę fidei possessorẽ, & in defectum primi, seq uẽtes malę fidei possessores, vt restituant integre domino rei, & curare, vt id opere pręstẽt; media ad id omnia necessaria adhibẽdo, qualia adhibere teneretur ex caritate quicũq; alius, qui id sciret, iuxta ea quę in materia de correctione fraterna, & tractatu quinto, dicẽtur. Quando autem res existit, atque dominus illius ignorat ad se pertinere, qua de causa illam non vendicat cum fructibus, neque agit aduersus vsurpatorẽ, aut alium malę fidei possessorẽ, ad interesse totum & dãna, tunc illa locum habent, quę Disp. 380, §. quando venditor sciens, dicta sunt, neque est necesse hoc loco ea repetere.

Illud etiam est obseruãdũ, quosdam iuniores theo [sect. 8] logos, vim cõtractuũ onerosorum non penetrãtes, ignorantesq; apertissimas iuris ciuilis sanctiones in contrarium statutas, naturis eorundẽ cõtractuũ innitẽtes, asseuerare. Quando res aliena venditur, emptorque alienam esse ignorabat, contractũ emptionis & vẽditionis esse nullum, ac vẽditorem rei non comparasse dominium pretii, sicut neque emptor cõparauit dominium talis rei alienę emptę. Ducuntur, quoniam sicut venditor trãsferre per eũ cõtractũ non potuit dominium rei vẽditę in emptorẽ, vtpote alienę, cuius proinde dominium perpetuò apud antiquum dominum perseuerat: ita neq; venditor per eundem contractum comparare potuit dominium pretii, sed ad quencunque id pretiũ deueniat, perseuerat quoad dominium apud antiquum emptorẽ,

qui illud dedit in cōm utationem pro tali re aliena sibi vēdita: quare, inquiūt, contractus ex vtraque parte fuit nullus. Ex hac autem eorum sententia sequitur, medium illum bonæ fidei emptorē ac vēditorē, de quo in tertia conclusione sumus loquuti, teneri restituere pretium, quod pro ea re accepit, idque ēptori illius rei, cuius id pretium perseuerat quoad dominiū: si autē res illa casu fortuito periisset apud vltimum emptorē, vel illam prodigē consumpsisset bona fide, credēs esse suam, ad nullam restitutionē ipsius, in pretii recōpensationē, teneri: quia periisset, non sibi, cuius non erat, & ad quam neque ex parte rei accepte, neq; ex parte iniustæ acceptionis, aut cōsūptionis, teneretur, sed periisset domino rei, aut ātquo malē fidei illius possessori, qui eam alienare incēpit, atque aduersus hunc solum maneret tali vēditori recursus. Nos verò Disp. 327. 330. 380, atque aliis in locis, perspicuē ostēdimus, quamuis eo cōtractu vēditionis, dominium rei vēditē non transeat in emptorē, sed perseueret apud antiquum dominum, qui, ipso non consentiente, spoliari non potuit dominio rei suæ: nihilominus contra-[[213]]ctum emptionis & venditionis fuisse validum, & furem, qui rem alienam vendidit, vsurarium, qui illam per vsuram comparauerat, ac vēdidit, & similiter depositarium, aut commodatarium, qui rem alienam depositam, aut sibi commodatam, vendidit, & similiter bonæ fidei possessorem, qui rem alienam bona fide etiam vendidit, cōparasse dominium pretii; teneri tamen emptori, ex tali contractu venditionis valido cum eo celebrato, de euictione ad interesse totum, & ad omnia dāna ei ex eo interesse subsequuta, quòd verè per eam venditionem non sit in eum translatus dominium, sed ad alterum pertineat. Vnde eo ipso, quòd res empti fuit ab eo consumpta, aut apud ipsum, vel apud alium, in quem ipse eā transtulit, periit, aut fuit ab hoc alio consumpta, ad nihil ei tenetur venditor; quoniam ex ea emptione nullum damnum ei resultauit.

Neque est eadem ratio, quòd sicut contractus, [sect. 9] in quo, siue bona siue mala fide, vēditur res aliena, est validus modo explicato: ita contractus, in quo mala aut bona fide venditur vitrum pro lapide pretioso, aut res vitiosa, sit validus. Quoniam illo priori contractu venditur res, quæ id pretium valet, neque est deceptio in re, quæ venditur: in his verò aliis contractibus non venditur res, quæ id valet, decipiturque emptor circa rem venditam: & ideo, si deceptio causam dedit contractui, est nullus, aut rescinditur: si verò nō dedit causam contractui, sed interuenit in contractu, reduci debet ad aequalitatem, habetque locum, non quidem redhibitoria actio, sed actio quanto minoris, vt hæc ōnia Disp. 352. & 353 explanata sūt.

Dubium graue remanet circa eundem mediū [sect. 10] bonæ fidei emptorem ac vēditorem rei alienæ, vtrū, si, nulla facta mutatione in re, illam emit minori pretio iusto, & postea in eodem loco eam vendidit maiori pretio etiam iusto, vel quia accreuit pretium eius rei, vel quia mediat ea tota latitudo inter infimum & supremum pretium iustum, teneatur restituere domino rei id, in quo ita est factus locupletior ex re illa. Doctores cōmuniter respondent affirmanter. Ducti ea regula, quòd possessor bonæ fidei tenetur domino rei quatenus ex illa est factus locupletior. Contrarium tamen existimo esse verum. Primò, quoniam illud non est fructus rei, sed industriæ, illam ementis iustè vno pretio minori, & vendētis etiam iustè alio maiori pretio: fructus autem industriæ, ad possessorem bonæ fidei, & non ad dominum rei spectat. Quòd autem id non sit fructus rei, sed industriæ, probatur. Tum quia, si fur ipse emeret iterum eandem rem ab vltimo possessore, eamque domino restitueret sine vlla proximi læsione, seruandoque illum omnino indemnem, neque res illa vllos fructus habuisset, sanè, qui ita id esset lucratus, emendo illam à fure, aut ab alio intermedio venditore, & vendendo illam maiori pretio iusto alicui alteri, nō teneretur illud restituere: eo quòd esset

fructus suę in dustrię, & non rei. Tum etiam quoniam, quod fur, aut vsurarius, ita lucratur re aliena, ad ipsos spectat tanquam fructus suę industrię, & non rei; eaque de causa, neque fur, neque vsurarius, tenetur illud restituere, vt Disp. 327 cum communi doctorum sententia ostendimus. Secundò, quoniā, si is, qui emit à fure maiori pretio iusto, venderet eandem rem minori pretio iusto, non tenetur fur restituere ei decrementum illud pretii, neque dominus rei, neque quisquam alius: de domino rei, & de aliis, satis perspicuè patet: de fure autem probatur. Quoniam solū tenetur ei de euictione, quantum sua eius, qui ita emit à fure, intererat, rem non esse alienam, siue autem res ea aliena esset, siue non, eodem pretio fuisset tūc eam vēditurus: quare fur non tenetur illi de eo pretii decremento. Valde autem durū est, quod is, qui bona fide emit à fure, aut à tertio rei alienę bona fide possessore, possit, negotiādo bona fide cum ea re aliena, amittere, ita quòd nullus teneatur ei restituere id prætii decrementum, & quòd, si lucretur, restituere teneatur id incrementum ac lucrū, quod ita prouenit ex sua industria ac negotiatione, vt euenire similiter potuerit decrementum ac iactura. Tertiò, quoniam, qui ita emit à fure, aut ab alio bonę fidei possessore rei illius alienę, ac vēdidit eam alteri, tenetur emptori de euictione ad totum interesse: cur ergo non reportabit etiam lucrum, si ex tali negotiatione proueniat. Certè res esset omnino irrationabilis, minimèque iusta. Neque vlla ratione satisfacit responsio Nauarri in manu. c. 17. n. 8. dicens, quòd liberabitur ab eo onere, si secūdo emptori cedat actionem de euictione, quam ipse habet aduersus furē, aut alium bonę vel malę fidei venditorem, qui sibi eam rē vendidit, iuxta. l. in creditore. ff. de euictionib. Non, inquam, satisfacit hęc Nauarri respōsio. Quoniā falsum est, liberandum ea cessione actionis. Si enim vel fur, vel quicūq; alius anterior venditor, non cōpareat, vel non sit soluēdo, ipse profectò cogetur soluere secūdo ēptori, quantum sua secūdi ēptoris intererat, eam rē non esse alienā. Imò sola sua libera voluntate poterit secūd⁹ ēptor nō esse cōtētus cessione actionis in furē, aut in aliū āteriorē vēditorē, cogereque immediatum vēditorē, vt sibi soluat totum suum interesse; & vt ipse, si velit, recursum habeat aduersus anteriorē vēditorē. Neq; ius, quod Nauarrus citat, id probat, quod ipse ex illo probare intēdit. Quoniam ius illud solū loquitur, quando creditor, seruatis ōnibus de iure in eo euētu requisitis, pignus sibi traditum in securitatē sui debiti vēdidit, vt ex pretio recuperaret suum debitum, significādo emptoribus, se vt pignus sibi traditum, & non vt rē suam, illud vendere: in quo euētu, vt Disp. 538. §. superest, & §. obserua tamen, ostēdimus, si postea id pignus euincatur, quia alius probat, rē illam ad se pertinere, & non ad debitorem, qui illam in pignus creditori tradidit, creditor, qui illam vt pignus vēdidit, non tenetur de euictione, tenetur tamen cedere ēptori actionē pignoratitiā, quam aduersus debitorem habet, qua mediante competit ēptori aduersus eum debitorem actio de euictione rei sibi ita vēditæ. In aliisautē euētibus, imò si creditor ille vendi disset eam rē, nō significādo sufficiēter emptori, se vēdere illam vt pignus, venditor tenetur de euictione immediato ēptori, nec liberatur cedēdo illi actionem, quam ipse habet in suum debitorem, aut in alium anteriorē eius rei vēditorē, vt eadem disputatione liquet, & affirmāt iura, cōsētītq; communis doctorum sententia. Quartò, quoniam iura, quibus autores cōtrarię sētētię nituntur, vt. l. sed etsi. l. item veniūt. §. eos. ff. de pet. hæred. loquuntur in hærede, qui rem hæreditatis vendidit, arbitratus hæreditatem ad se attinere: in eiusmodi enim vniuersalibus bona fide distractis, atque iterum emptis, pretia ex eiusmodi rebus comparata, cedunt hæreditati loco rerum, & res pecunia hæreditatis comparatæ, [[214]] cedunt similiter hæreditati loco pecuniæ, eaq; ratione incrementum pretii ex re hæreditatis primò venditæ maiori pretio, & postea redemptę pretio minori,

hæreditati cedit: longè autem aliter res habet in aliis cuentibus, de quibus nos hoc loco disputamus.

Vtrùm, qui bona fide rem emit, aut, per mutatione compar auit ex latrone, si, dum eam possidet, sciat ad alium pertinere, possit, vt se indemnem seruet, reddere eam latroni, & recuperare, quod pro ea dedit; an teneatur illam reddere domino. Disp. 722.

SVMMARIVM.

1. *EMens à latrone bona fide rem, quam postea scit esse alienam, reddere potest latroni, vt recuperet suum pretium, aut vt consulat honori ac famæ latronis, quando id fieri potest sine periculo detrimenti alicuius talis domini.*
2. *Idem emptor de iustitia, & cum restituendi onere, tenetur illam reddere domino, nihil impediante, quòd pretium amittat, quando, si illam reddat furi, amittet illam dominus, aut periculum est ne illam amittat.*
3. *Quando emptor idem rem restitueret furi, vt recuperaret suum pretium, credens absque dubio id sibi licere, ad nullam restitutionem tenetur, esto dominus rem suam amittat.*

Conuēiunt doctores, quando verisimile ad [sect. 1] modum esset, reddendo rem furi, nullum damnum esse incursum rei dominum, quia vel fur sua sponte illam domino restituet, vel facilè dominus, & absque vlla molestia & incommodo, eam ex illo recuperabit, posse tunc bonæ fidei emptorem reddere eam furi, quando, nisi eam illi redderet, pretium, quod pro ea dedit, ipsi periclitaretur. Ratio autem est, quoniam in eo euentu dominus rei irrationabiliter esset inuitus, quòd id ita fieret, ac proinde nihil de eo esset tunc curandum. Idem dicerem, si eo modo consuleretur honori latronis, nihilque dominus periclitaretur ex eo, quòd res latroni redderetur, vt per illum fieret restitutio proprio domino. Tota autem difficultas est, quando, si res latroni non reddatur, pretium emptori periclitatur; si verò illi reddatur, res illa domino, aut omnino, aut ex parte, periclitatur, num emptor tunc, nihil impediante eo periculo domino rei, possit tuta conscientia, & sine restituendi obligatione domino rei, eam reddere latroni, vt recuperet suum pretium, quod bona fide illi pro ea dedit; an verò teneatur, nihil impediante periculo sui pretii, reddere illam domino; alioquin teneatur ei restituere totum damnum, quod illi fuerit ex eo subsequutum, quòd ei non restituerit rem suam, sed illam latroni reddiderit.

*Alexander Alen. 4. p. q. 86. memb. 3. art. 5. Gab. in 4. dist. 15. art. 3. lib. 5. sylu est. verb. rest. 3. q. 7. Nauar. in manu. c. 17. n. 9. & quidam alii, affirmanter respondent. Probari autem hæc sententia potest.*⁶³ Primò, quoniam emens rem aliquam bona fide, nullo iure tenetur cum grauissimo suo damno ac incommodo reducere eam in meliorem statum, quàm sit is, in quo erat, quando sibi est tradita: sed, quando sibi fuit tradita, erat in manibus latronis: ergo, quando periculum sibi imminet, nisi eam reddat latroni, pretium amittendi, non tenetur eam tradere domino cum tanto illo suo damno ac incommodo, sed poterit eam reducere in manus latronis.

Secundò, qui timet graue aliud damnum, si rē,⁶⁴ quā à latrone accepit, ei non restituat, vt, si timet vulneratum ab eo iri, non tenetur restituere eā rem proprio domino, sed potest eam reducere in manus latronis, vt *Sotus. 4. de iust. q. 7. art. 1.* ante solutionem argumentorum affirmat: ergo pari ratione, si timeat amittere pretium, atque id pretiū sit magnum, poterit illam reducere in manus latronis: quo fit, vt male Sotus admittat primum illo articulo. 1. citato, & neget secundum art. 2. sequēti.

Contrariam sententiam, nempe emptorem tunc contra iustitiam peccare, non tradendo rem illam proprio domino, sed reddendo eam furi, nihil impediēte, quòd pretium latroni datum amittat, tenerique proinde ad restitutionem illius domino, in defectum furis, affirmant Ioan. Med. de rest. q. 10. *Sot. 4. de iust. q. 7. art. 2. Couar. reg. peccatum part. 3. in initio. n. 3. Ledesmi. 2. 4. q. 18, art. 6. & alii*, quæ mihi sanè probabilior multo videtur.

Sunt verò non nulla obseruāda antequam eam [sect. 2] probemus. Primum est: Autores prioris sententiæ non in omnibus cōuenire. Quidam enim eorum affirmant, quando emptor mala fide rem emit à fure, sciens rē esse alienam, pēnitentiæque ductus, vult postea eam restituere, non posse reddere illā fuii, vt suum pretium recuperet, sed teneri tradere illam domino, nihil impediēte, quòd pretiū amittat: quoniam, cum fuerit malæ fidei possessor, iniustitiæque contra eius rei dominum cōmiserit illam retinendo, dominus rationabiliter est inuitus, quòd eam furi restituat cum qualicunque suo periculo, nihil impediēte, quòd pretiū sit alioquin amissurus. Alii verò admittūt, etiam in hoc euentu posse licitè reducere rem in manus furis, vt suum pretium recuperet, quando, nisi id efficeret, periculum esset, ne pretium amitteret. Huius sententiæ fuit Alex. Alensis.

Secundum est. Vt bene Sotus & Ledesmius locis [sect. 3] citatis notant, quando bonæ fidei emptor, arbitrat⁹ se licitè id efficere, nihilque ea de re dubitās, rē tradidit furi, vt suum pretium recuperaret, ad nullam restitutionē teneri domino eius rei. Quoniā post illam ita furi redditam, neque tenetur restituere eam domino ex parte ipsius rei, quam iam non habet, sed solūm habet suum pretium: neque item ex parte iniustæ acceptionis; eo quòd non peccauerit, ita illam bona fide reddēdo furi: præsertim cū res in se sit adeò abstrusa, vt multi viri docti, examinatis aliorum rationibus, hodie existiment, id esse licitū. Quo fit, vt etiam quicunque vir doctus, qui sibi persuaderet veram esse Alexandri sententiā, eāq; sequutus, id efficeret, ad nullam restitutionem teneretur, idque propter eandem rationem. Confirmatur hoc totum, quoniam, qui ita bona fide contractum rescinderet cum fure, reddēdo illi rem, & accipiēdo ab eo pretium, perinde haberet, ac si antequam sciret esse alienam eundem contractum cum fure rescidisset: in hoc autem euentu nullus affirmaret, hunc ad restitutionem aliquam teneri: quia neque tenetur ex parte rei, neque ex parte iniustæ acceptionis.

His ita explicatis, nostra sententia probari potest. Primò, quoniam sicut fructus omnes, quos producit res aliena bona fide possessa, ad dominum illius pertinent, nihil impediēte, quòd producti sint cooperante industria eam possidentis, & quòd res in potestate domini non esset illos productura, vt Disp. 719 dictum est: [[215]] sic, quòd casu eadem res aliena deueniat ad meliorem statum, cū deuenire potuerit ad potestatem eius, qui statim bona fide illam consumeret, pertinet etiam ad prosperum successum domini eius rei, iniuriamque illi faceret, qui, sciens ad illum pertinere, eam ad peiorem statum reduceret: quo fit, vt quamuis, qui illam bona fide antea possidebat, non teneatur, cum graui suo incommodo, reducere illam ad meliorem statum, quā sit is, ad quem re ipsa deuenit; nihilominus, vt euitet incommodum, quod malitia alterius ipsi imminet, extrahere eam non potest de statu, in quem casu indomini commodum deuenit, eamque in peiorem statum eiusdem domini

comparatione reducere; eo quòd id in illius cedat iniuriam, sitque rationabiliter inuitus, quòd eo modo res sua contractetur cum ipsius incommodo, vt qui illam possidet euitet incommodum, quod sola alterius malitia ei imminet. Atque hæc ratio aperit, vnde debile ac nullum sit fundamentum, cui ratio potissima contrariæ opinionis nititur. Aliud quippe est, possessorem bonæ fidei perducere rem ad meliorem statum, quàm esset antequam illam emeret, & aliud longè diuersum, extrahere illam de statu, ad quem iam casu, réve ipsa, deuenit. Et quidem ad primum non tenetur cum graui suo damno seu incommodo, vt si, postquam ad ipsius deuenit potestatem, necessarium esset facere de nouo sumptus aliquos, vt eam restitueret domino, quos dominus rei non esset soluturus, non teneretur eam restituere domino cum suo incommodo. Ad secundum verò tenetur, nihil impediante, quòd inde per accidens sequatur suum aliquod damnum malitia alterius. Neque enim præiudicare potest iuri ac commodo domini rei, vt se protegat à damno, quod ipsi malitia alterius imminet.

Secundò, quoniam, vt autores contrariæ sententiæ confitentur, si rei dominus sciat illam esse apud eum, qui bona fide illam emit, potest eum prohibere, ne illam tradat furi, eumque cogere, vt sibi illam restituat; peccabitque, atque ad restitutionem tenebitur, si in eo euentu illam deneget proprio domino, furique eam tradat, vt suum pretium non amittat: imò verò, si dominus coram iudice cum eo emptore quoad hæc omnia contendat, sic à iudice hæc omnia in fauorem domini eius rei iudicabuntur: ergo dominus ex ipsa met rei natura ius habet prohibēdi, vt, nihil impediante, quòd is emptor pretium amittat, non tradat eam rem furi, sed sibi eam restituat: & cùm præsumere debeat is emptor, eā esse domini voluntatem, quando dominus statū rei suæ ignorat; consequens profectò est, vt contra voluntatem ac ius domini faciat, ac proinde iniustè, si illam furi reddat, vt pretium ab illo recuperet, atque adeò est consequens, vt teneatur restituere illam, damnaque omnia subsequuta, rei illius domino. Quòd si emptor rei illius, dū res est apud ipsum, ius haberet ad reddendam eam furi, vt ex fure pretium suum recuperaret, sanè, neque rei dominus, neque iudex, possent eum probibere, ne id efficeret, eumque iure illo suo ad id faciendum spoliare. Secum ergo pugnare apertè videntur autores contrariæ sententiæ, dū simul affirmant, emptorem posse rem illam tradere furi, vt se indemnem à iactura sui pretii seruet, & peccare contra iustitiam, si id efficiat, prohibente id, ac rem suam petente domino illius.

Tertiò, res illa in eo statu constituta debetur illius domino, & non furi: ergo emptor illius, qui eam possidet, vt recuperet suum pretium, quod fur tradere sine ea re illi tenetur, non potest illi eā tradere: sicut enim non potest illam alteri vendere, vt recuperet valorem, quod pro illa dedit, ita nec potest illam tradere furi, vt recuperet suū pretiū: eo quòd traderet illi ea de causa alienum, alterique, quia suum, iam omnino debitum, cooperareturque ad iniquam illius à fure detentionem. Quòd si in exteriori foro probari posset, eum, sciētem iam alienam esse, trodidisse illam furi ad pretium suum recuperandum, furque non compareret, ex quo posset recuperari, vtique cogeretur restituere domino illius valorem ob eam traditionem rei alienæ furi, & non domino, cum ea scientia: cuius rei non alia est causa, nisi quia traditio illa ex natura rei est iniusta ac iniuriosa domino rei.

Ad primum autem argumentum in contrarium dicē⁶⁵ dum est. Quanuis emens rem bona fide, & sciens dum in potestate ipsius est, esse alienam, non teneatur per se ac faciendo aliquid de nouo, vnde damnum ac incommodum incurrat, reducere illā ad meliorem statum, quam esset is, in quo erat, quādo sibi fuit tradita; teneri tamen non deducere eam ad peiorē statum, quàm sit is, ad quem re ipsa deuenit, & in quo iam est: deduceret autem illā ad peiorem statum, quàm sit is, in quo est in potestate ipsius constituta, si, vt euitaret damnum amissionis

sui pretii, quod sola malitia alterius ipsi imminet, eam traderet furi, in potestatēq; illius eam reduceret: in consequentiā verò, quòd neque reducere eam possit in latronis potestatem, neque eam sibi retinere, tenetur illam tradere proprio domino, cuius est. Ad argumentum ergo in forma, licet maior per se sit vera; secus autem per accidēs, quatenus non potest illam sibi retinere; cum eaque perseuerare in statu, in quo re ipsa est, eo quòd dominium illius ad alterum pertineat, cui omnino est debita: & minor simpliciter sit vera: negāda est tamen consequentia. In primis quoad secundā consequentis partem: quoniam reducere eā in manus latronis, licet non sit reducere illam in peiorem statum, quā sit is, in quo erat quando sibi fuit tradita; est tamen reducere illam in peiorē statum comparatione domini illius, quā sit is, in quo iam re ipsa est; quod tali emptori non licet, etiam ad recuperandum suum pretium: eo quòd deducere illam ad eum peiorē statū; quam sit status illius præsens, sit cum iniuria, ac contra ius, domini illius, vt ostensum est. Quoad primam etiam cōsequentis partem est etiam nulla ea consequētia quoniam in consequentiam, quòd neque possit illam tradere latroni, neque eam sibi retinere, tenetur eam reddere proprio illius domino.

Ad secundum dicendum est, si emptor, qui pos⁶⁶idet rem, quam iam scit alienam esse, nihil cooperetur ad extrahendam rem illam à meliore statu, in quo iam est, sed solūm permetteret furi, vt illam acciperet de loco, in quo est, aut de manibus talis emptoris illam possidentis, licita tunc sibi esset ea permissio: tum vt euitaret damnum propriæ personæ, quod ex prohibitione sibi immineret: tum etiam, vt recuperaret suum pretium: quoniam id non esset extrahere ipsum rem illam de statu, in quo est, cum iniuria proximi; sed esset permittere eam iniuriam aduersus proximum ab altero fieri, vt se indemnem seruaret; [[216]] quod est licitum, quando damnum proprium alicuius momenti, quod non facile resarciatur ac recuperabitur: eo quòd solūm ex caritate tenetur id impedire, si commodē, & sine suo notabili detrimento, posset id efficere: secus cum suo notabili detrimento; ordo quippe caritatis non habet, vt nobis ipsis proximum nostrum in eodem genere boni præponamus. Si verò loquamur de actu, quo is emptor extrahat rem de statu, in quo est, & illam reducat in potestatem furis, de quo actu loquitur argumentum, dicēdum est. Neque ad vitandum damnum corporale, neque ad recuperandum pretium, fas esse aliter eam rem reducere ad potestatem furis, qui illam non sit restitutus, quā fas esset eā consumere, aut tradere alicui extraneo, ad simile æqualeque damnum vitandum. Sicut autem nefas esset illam consumere, aut tradere illam alicui alteri, ad vitandum damnum corporale, aut iacturam in rebus propriis externis, nisi animo illam integre restituendi proprio domino in euentu, quòd ille alius eam non restitueret: ita in re proposita nefas est illam tradere furi, nisi animo eam integre restituendi, si fur illam non restituat, aut si ex fure non recuperetur ac tradatur proprio domino: &, esto sine eo animo id fiat, obligatio similiter est eam domino restituendi. Quidam inde contendunt, fas esse reducere rem alienam in manum furis, quòd fur ius habeat ad illam repetendum, vt eam tradat proprio domino. Et quòd, vt habetur. c. in literis de rest. spoliat. *Prædo etiam est, secundum rigorem iuris restituendus. Consentit. l. 1. § qui à me. ff. de vi & vi armat.* quę interdictum de restituendo in possessionem vi eiectum ait competere ei, qui vi alterum deiecerat, aduersus eum, qui ipsum postea è possessione deiecerat. Ad primum enim horum dicendum est, furem habere quidem ius ad eam petendum, & obtinendum, ad eum finem, vt in principio huius disputationis ex parte est dictum: secus verò quando non constat, ad eum finem eam petere, & multo magis, si constet, aut rationabiliter timeatur, ad eum finem illam nō velle, sed ad eam sibi retinendum & vsurpandum, vt in euentu, de quo nunc loquimur, cernitur. Sicut autem quando res aliqua est in manu depositarii, si

dominus accedat, dicatque furto ex ipso fuisse ablatam, detinetur, nec traditur deponenti, quousque res examinetur, vt Disp. 526 fuit ostensum: ita, quando est in manu cuiuscunque possessoris, est idem faciendum: possessorq; ipse, sciens à fure peti, detinere illam potest ac debet, esto dominus illius ignoret penes ipsum esse, ne tradendo eam furi, in peiorem statum illam reducat. Ad secundum dicendum est, illud esse intelligendum, aduersus postremum vi ejicientem à possessione, qui in foro exteriori non excusatur à restituenda possessione vi occupata, etiam si dicat, alium vi antea eiecisse, aut iniuste eam possidere: secus autem de possidente sine vi, de quo nunc loquimur. Præterea, quandocunque diceretur, rem mobilem furto, aut per rapinam, fuisse occupatam ab eo, qui vi deiectus est à possessione, iuberetur poni in sequestro, donec res examinaretur, nisi, qui fuit deiectus à possessione, sufficientem cautionem daret, quòd, si alienam esse, furtoque ablatam, comperiretur, dominus illius indemnus omnino redderetur.

De malæ fidei possessore rei alienæ titulo emptionis, aut quouis alio, quousque ad restitutionem teneatur. Disp. 723.

SVMMARIVM.

- 1 . *Possessor malæ fidei rei, quam ad alium pertinere scit, ad quam restitutionem teneatur, quando res perseuerat, & ad quam quando res perit.*
- 2 . *Emens aut accipiens rem alienam ex ignorantia craffa, quod esset aliena, ad eandem restitutionem tenetur.*
- 3 . *Emens aut aliter possidere incipiens cum dubio, an res sit aliena, si postea cõperiat rem alienam fuisse, ad totam restitutionem proximè dictam tenetur. Nisi animo id examinandi, ac restituendi, illam acciperet. Nam tunc minus restituere teneretur. Si comperiat non fuisse alienam, ad nullam restitutionem tenetur. Si facta diligentia, maneat res dubia, pro quantitate dubii est pars restituenda. Quando dubitatur, ad quos ex multis pertineat, qualiter restitutio sit facienda.*
- 4 . *Restituere nihilominus tenetur integram rem, qui dubius, an ad se pertineat, alterum spoliat illa, qui bona fide cæperat illam possidere.*
- 5 . *Occupans rem morte alicuius, aut alia ratione domino vacantem, cum dubio, an ad se vel ad aliũ pertineat, quam diligentiam facere debeat, vt intelligatur, ad quem pertineat, & qualiter cum illo se gerere debeat; & manente postea dubio, diuidere cum illo eam debet pro dubii quantitate.*
- 6 . *Qui alteri succedit in re, quam ille alius bona fide capit possidere, esto tempore, quo ita succedit, dubium habeat, an ad alium pertineat, ad nullam restitutionem tenetur, sed solum ad faciendam moralem diligentiam, an verè ac certò ad illum alium pertineat.*
- 7 . *Qui ignorantia craffa, quòd res ad eum non pertineret, a quo illam accipiebat, illam accepit absq; ullo dubio, cùm tamen meritò dubitare debuisset, tenetur postea inquirere, an verè ad alium pertineat, vt integre eam illi restituat: & remanente dubio, an alienasit, tenetur partem illius restituere pro dubii quantitate.*

8 . Emens, aut accipiens à mancipiis, à famulis, à filiis familias, & ab aliis suspectis, an res sit ipsorum, vel de mandato aut permissu dominorum illam alienent, quousque iudicandi sint, aut non sint, teneri restituere.

DEueniendo ad malę fidei possessorem titulo emptionis, aut quouis alio, iuxta modos malę fidei possessoris in principio disputationis 721 explicatos, sequentes conclusiones in hac disputatione sunt statuendę.

Prima conclusio. Qui mala fide emit, aut alio⁶⁷ titulo mala fide cępit possidere rem, quam scie [sect. 1] bat esse alienam, restituere illam tenetur cum omnibus fructibus ex ea perceptis à puncto, quo illam possidere cepit, & quos insuper percepisset ex illa dominus illius, si illam habuisset, pręterea tenetur illi restituere, si quod aliud lucrum ex ea illi cessauit, aut damnum emersit, quod priuatus fuerit ea re frui, illamque possidere. Ad hęc autem tenetur primus malę fidei illius possessor, siue res illa apud ipsum perseueret, siue apud alium. Corrupta autem, vel destructa, ea re, ad [[217]] nihil aliud tenetur, quàm ad valorem illius, & ad fructus omnes vsque ad instans desitionis illius ex illa perceptos, & quos insuper vsque ad id instans percepisset dominus illius, si quos fortę plures percepisset, si priuatus non fuisset possessione rei illius, & insuper tenetur domino rei ad omne aliud lucrum cessans, & damnum emergens, si quod fortę insuper illi cessauit, aut emersit, ex ea iniusta detentione illius rei.

Conclusio hęc quoad priorem illius partem probatur. Quoniam eo ipso, quod emptor malę fidei, aut quicunque alius malę fidei possessor rei alienę, eam incipit mala fide possidere, iniustę illam detinet: ergo tenetur domino illius, non solùm ratione rei, sed etiam ratione iniustę acceptionis, seu iniustę detentionis, eaque de causa non solùm restituere ei tenetur rem cum omnibus fructibus illius, sed etiam cum omni alio commodo, quod dominus rei fuisset insuper ex illa percepturus, & cum toto lucro cessante, aut damno emergente, si quod tale inde illi fuit subsequutum: co quod horum omnium damnorum causa iniusta illi fuerit per talem iniustam rei illius detentionem: & quoniā res aliena detenta, domino fructificat, vbicunque illa sit. Dixi in eadem priori conclusionis parte, ad ea omnia teneri, etiamsi res non perseueret apud talę malę fidei possidere incipiētę, sed perseueret apud alium: quoniam eo ipso, quod ipse illā alienauit, fuit causa iniusta, quod dominus rei illius his omnibus emolumentis priuaretur. Quod si sua sponte eam non alienauit, sed ab alio clām aut vi ablata fuit, tunc causa nihilominus iniusta fuit eorum omnium damnorum, quatenus illam non restituit, quando potuit ac debuit. Quemad modum fur etiam, si fortę illam ipsi vendidit, tenetur domino rei ad ea omnia vniuersim damna, quatenus illorum omuium fuit causa iniusta, illam furando, eamque ipsi vendendo. Quis autem pręcipuę teneatur, aut quatenus aut quousque vnusquisque eorum tenetur, patebit inferiūs, quando de concurrentibus cum iniustę accipiente, aut cum iniustę damnum dante, disputabimus.

Posterior verò pars conclusionis, quod scilicet corrupta re, &c. probatur. Quoniam res solùm quamdiu existit, fructificat domino suo: fructus verò, quamdiu sunt in potentia rei, non augent valorem illius, quin potiūs valor cuiusque rei fructiferę æstimatur attenda potentia, quam habet ad fructificandum: ergo ab instanti, quo res est corrupta, qui eam mala fide possidere cęperat, solùm tenetur ad valorem illius, & ad valorem fructuum ex ea re vsque ad id instans perceptorum, atque ad lucrum cessans, & ad damnum emergens, domino rei ex eo, quod fuerit ita iniustę detenta, (cum quo lucro ei cessante, ac damno emergente, computa fructus, si quos plures ipse ex ea re vsque ad id instans fuisset percepturus) non verò

tenetur ad valorem fructuum, qui, si ea res incorrupta perseueraret, ex illa perciperentur. Quousque autem fur teneatur emptori eius rei de euictione, quando emptor mala fide illam emit, Disp. 380 fuit explicatum. *Ioan. Medi. de rest. q. 10. & de usur. q. 4. ad. 3. prin.* vt Disp. 330 relatum est, excipit ab hac & à sequentibus conclusionibus, quando id, quod accipitur, est vsu consumptibile, recipitque proinde functionem in genere suo, hoc est, soluitur sufficienter re alia, eiusdem speciei, iuxta ea quæ Disp. 327 explanata sunt. Arbitratur enim, quando fur, dando aliis huiusmodi res, quas furto acceperat, non manet impotens ad illas soluendum vero illarum domino, accipientem tunc eas ex fure comparare illarum dominium, nec teneri restituere illas priori domino, à quo fur illas acceperat furto. Contrarium tamen satis perspicuè ostendimus Disp. 330 citata: neque est necesse, quæ eo in loco dicta sunt, hoc loco repetere. *Atque Medina ipse videtur se ipsum corrigere q. 10. citata. §. ult. primæ partis illius quæstionis.*

Secunda conclusio. Qui rem alienam emit,⁶⁸ aut alio titulo accepit, ignorantia crassa, quòd [sect. 2] esset aliena, ita quòd prudentis arbitrio non excusetur à culpa theologica eam ita accipiendo, ad ea omnia tenetur, ad quæ conclusione præcedente est explicatum teneri incipientem possidere rem alienam mala fide. Probatur, quoniam, vt ex dictis disputationibus præcedentibus, & Disput. 63 liquet, iste talis possessor est malæ fidei, ad restitutionemque tenetur, etiam ex parte iniustæ acceptionis, ac retentionis iniustæ.

Tertia conclusio. Si à principio, quando ali⁶⁹quis emit, aut alio titulo possidere cæpit, dubi [sect. 3] taut, an ea res esset aliena, & postea constet alienam esse, tenetur ad restitutionem omnium, ad quæ conclusione prima dicta sunt, teneri eum, qui, sciens esse alienam, eam emit, aut alio titulo possidere eam cæpit. Si verò è contrario postea constet, non fuisse alienam, ad nullam restitutionem tenetur. Quòd si adhuc perseueret dubium, tenetur apponere possibilem moralem diligentiam, vt sciat, an aliena sit, si autem ea adhibita, aut nulla occurrente possibili, qua id sciri possit, adhuc dubium perseueret, tenetur restituere, non quidem totum, quòd conclusione prima est dictum, sed partem, maiorem vel minorem, pro quantitate dubii, ita quòd, si dubium sit æquale pro vtraque parte, restituatur dimidium: si verò probabilius sit rem esse alienam, restituatur plus quàm dimidium, eo plus, quo probabilius fuerit esse alienam: si autem sit minus probabile alienam esse, restituatur minus, quàm dimidium, pro dubii quantitate. Quòd si solùm dubitetur de aliquo in particulari, an res sit illius, tunc ei soli est facienda restitutio. Si autem de multis in particulari dubitetur, ad quem illorum, vel num ad aliquem eorum pertineat; tunc, si certum sit ad illos pertinere, & ignoretur ad quem eorum, inter eos solos integre est res cum fructibus diuidenda, iuxta dubii quantitatem, ita quòd maior pars proportionalis, pro dubii quantitate, ei restituatur, ad quem probabilius est eam pertinere, & minor ei, ad quem minus probabile est eam attinere. Si verò dubium sit, an ad possidentem vel ad illos pertineat, inter possidentem, & illos, erit similiter pro dubii quantitate diuidenda. Quòd si dubitetur, an sit aliena, atque omnino ignoretur ad quem attineat in euentu, quòd sit aliena, pars proportionalis, pro quantitate dubii, erit distribuenda pauperibus, aut insumenda in operibus piis pro anima illius, cuius fortè fuerit. In quo euentu, si non erat aliena, ea satisfactio ad restituentem attinebat, tanquam sua propria.

Prima pars, quòd scilicet, quando à principi [sect. 4] pio dubitauit, an esset aliena, si postea comperiatur alienam esse, teneatur ad eam totam restitutionem, probatur. Quoniam, vt Disp. 63 ostensum est, ille cæpit mala fide possidere; eo quòd dubium in principio possessionis, malæ fidei possessorem efficiat: ergo, quando postea comperitur rem esse alienam, tenetur

ratione iniustæ acceptionis ad omnia damna subsequuta, si rem accepit animo eam sibi vsurpandi. Quod addo, quoniam si eam accepit animo adhibendi competentem diligentiam ad sciendum, cuius esset, dominoque illam restituendi, si comperiretur, cuius esset, tunc solùm teneretur ad restitutionem rei, & fructuum, quos, adhibita competenti diligentia, ex illa percepisset: atque, si aliquid horum sine sua culpa periisset, non teneretur illud restituere, nisi quantum inde fortè factus esset locupletior. Ad lucra verò cessantia, & ad damna rei domino emergentia, non tenetur: quippe cùm nullam iniustitiam aduersus eum commisisset, rem eo animo accipiendo. Quin potiùs rei dominus tenetur ei ad expensas, si quas cum ea re fecisset.

Secunda verò pars, quòd scilicet, si comperiat postea alienam non fuisse, ad nullam restitutionem teneatur, probatur. Quoniam, licèt peccauerit, eam cum illo dubio accipiendo animo sibi illam retinendi; quia tamen re vera aliena non erat, sed propria eius, qui iusto titulo ipsam in eum transtulit, vtique dominium illius comparauit, ac proinde ad nullam restitutionem tenetur. Quòd si, dubitans an esset eiusdem tertii, illam accepisset; attamen, dato, quòd illius tertii non esset, credens esse eam sibi tradentis, illam accepisset, ac proinde se in eo euentu comparare illius dominium, tunc, si postea comperiretur, non fuisse quidem illius tertii, cæterùm esse cuiusdam alterius, sanè, cùm aduersus dominum illius non peccauerit contra iustitiam, neque iniustè illam retinuerit, credo illi solùm teneri ex parte rei acceptæ, & non ex parte iniustæ acceptionis, ac proinde illi non teneri, nisi quoad id, quod ex re illa, & ex fructibus illius, remanet, & quantum ex non existentibus locupletior fuerit effectus.

Tertia autem pars, quòd scilicet, quando perseuerat dubium, & non occurrit alia diligentia, quæ fieri possit, restituenda sit pars dumtaxat rei pro quantitate dubii eo modo, quo in ea explicatur, vt probetur, & simul explicetur, in quo euentu in ea loquamur, obseruandum est. Multis modis posse aliquem incipere possidere rem aliquam cum dubio, an ad aliquem alium pertineat.

Primò, spoliando alium possessione, in qua ille erat. Vt si quis, dubius an res, quam alius possidet, ad ipsum pertineat, credensque probabiliter ad se pertinere, alium occultè, aut palàm, spoliet possessione, in qua erat, eamque rem sibi vsurpet. Atque in hoc euentu non loquitur tertia pars nostræ conclusionis. Quoniam hic restituere tenetur rem totam antiquo possessori illius, quando non constat illum à principio mala fide incepisse rem illam possidere: eo quòd, in dubio, melior sit conditio possidentis, integramque rem possit licitè retinere, neque partem teneatur alteri tradere.

Secundò potest quis in dubio, an ad se, vel ad [sect. 5] alium, res pertineat, incipere illam possidere, non quidem spoliando aliquem possessione illius, sed, cùm vacet morte alicuius, & dubitet, an ad se vel ad aliquem alium pertineat, eam occupando. Atque in hoc euentu, cùm æqua sit conditio ipsius, & aliorum, de quibus est dubium, ad quem ipsorum pertineat, Disput. 103 cum Victoria est dictum, vnumquemque horum teneri inquirere, ad quem ea res pertineat, vt, comperto ad illum attinere, illi relinquatur, & teneri audire rationes aliorum. Quòd si iudicem communem habeant, cui sint subiecti, aut ad quem cognoscere ea de re attineat, saltem ratione loci, in quo ea res est sita, vtique coram illo ea de re est contendendum, standumque est supremæ sententiæ. Quòd si principes, qui superiorem non recognoscunt, illi sint, inter quos est ea controuersia ac dubium, ibidem explicatum fuit, quomodo negotium esset peragendum. Dictum præterea fuit, si, re diligenter ac vltimò, vel inter principes, vel coram supremo iudice, examinata, ita vt nihil amplius occurrat,

quod fiat ad examen, atque ad inquirendam ac deprehendendā veritatem, res maneat dubia, tunc diuidendam esse inter eos omnes, de quibus dubitatur, ad quem pertineat, pro dubii remanentis quantitate, aut aliter circa illam erit ipsis transactio pro dubii quantitate facienda, seu potius amicabile compositio: eo quòd æqua sit conditio eorum omnium pro eiusdem dubii quantitate, Atque neque de hoc euentu loquitur tertia pars nostræ conclusionis, sto, quod in ea dicitur, faciendum similiter sit in hoc euentu.

Tertiò potest quis incipere possidere dubi [sect. 6] tando, an res ad alium pertineat, cæterum succedendo in ea illi, qui bona fide illam possidebat, vt si illam ab eo emit, aut dono accepit, qui bona fide illam possidebat, vel si titulo hæreditario ei in illa successit, qui similiter bona fide eam possidebat. Et nec in hoc euentu loquitur pars tertia nostræ conclusionis. Quoniam, licet hic, qui ita dubius rem possidere incipit, teneatur facere competentem moralem diligentiam, vt sciat, an ad alterum pertineat, interim tamen dum illam facere non prætermittit, neque sibi omnino constat, ad alterum eam pertinere, tuta conscientia potest illam integram sibi retinere: quia successit in iure illius, qui bona fide illam possidebat: & quemadmodum ille, si in ipso oriri inciperet hoc idem dubium, quod habet nouus in ea successor, ad nullam restitutionem teneretur, eo quòd in dubio melior esset conditio ipsius, qui bona fide cæpit illam possidere: ita neque ipse, qui cum suo dubio successit in iure pleno anterioris rei illius possessoris, tenetur ad ullam restitutionem: neque hic dicendus est incepisse eam rem possidere mala fide, sed bona: eo quòd tale dubium, sicut, si adueniret postea post inceptam possessionem, non efficeret illum malæ fidei possessorem, ita neque modò eum malæ fidei possessorem efficit, idque propter bonam fidem pos-[[219]]essoris antecessoris, cui hic successit, & cuius possessionem continuauit.

Quartò denique potest quis incipere possidere cum dubio, an res sit alterius, quia dubitat, an bona fide illam possideret, qui eam sibi tradidit, vt si erat persona suspecta, attenta qualitate rei & personæ, atque in hoc euentu loquitur tertia pars nostræ conclusionis. Pro quantitate enim dubii, quod tunc habuit, aut debuit habere, & quantitate dubii, quod postea, facta morali diligentia, manet, quòd ille non fuerit possessor bonæ fidei, resque aliena sit, tenetur restituere partem maiorem, vel minorem, eo modo, quo in ea tertia parte conclusionis dictum est. Probatur autem ea pars ita explicata. Quoniam, licet in hoc euentu restituere proculdubio teneatur; eo quòd mala fide cæperit possidere, perseueretque ad huc dubium, an res sit aliena; quia tamen simul est dubium, an verè fuerit eius, qui illam sibi tradidit, ac proinde an tota ad ipsum pertineat, qui in iure toto eam sibi tradentis successit; vtique non tenetur plus restituere, quàm pro quantitate dubii, quod in ipso remanet, an ad se eo iure tota pertineat, vel pertineat ad alterum; cum pares ea in parte sint ipse & ille alter.

Reliqua, quæ in ea conclusione adduntur, probatione alia non indigent. Ex eo autem satis sunt perspicua, quoniam ea ratione seruatur, quàm maximè fieri potest, æqualitas attenta existimatione & conscientia rem illam tunc ita possidentis, in eoque conuenire deberent omnes, de quorum interesse agitur, attento dubio, & statu rei, nisi irrationabiles esse viderique vellent.

Quarta conclusio. Qui ignorantia crassa e⁷⁰mit, aut alio titulo possidere cæpit rem, de qua meritò dubitare debebat, an esset aliena, ad [sect. 7] eadem tenetur, ad quæ præcedente conclusione diximus teneri eum, qui, dubitans, an res esset aliena, eam possidere cæpit. Probatur hæc conclusio, quoniam ignorantia illa crassa eum non excusat à culpa, incepitque proinde mala fide possidere, perindeque reputatur, atque si cum dubio, an ea aliena esset,

(à quo dubio tunc habendo ea culpabilis ignorantia ipsum non excusat) eam rem possidere incepisset.

Iuxta has quatuor conclusiones expenden [sect. 8] dum est in confessionibus, quousque restituere teneantur, qui emunt, aut alia ratione accipiunt, à mancipiis, à filiis familias, & ab aliis suspectis personis, quando non sunt verisimiles coniecturæ, quòd id, quod vendunt, aut aliter traditur, sit ipsorum, aut quòd id fiat de voluntate eorum, quorum sunt tales res. Porrò iudicandum est, vtrùm ignorantia eo modo id accipientis crassa sit, ita vt ipsum à theologica culpa non excuset, attenta qualitate personæ quoad simplicitatem & quoad perspicacitatem ingenii. Multum etiam iuuat, an, qui emit, aut aliter accipit, sit timorata persona, quæ, si suspicaretur in ea emptione, aut acceptione, culpam interuenire, nulla ratione id emeret, aut acciperet. In eiusmodi quippe persona nulla ratione præsumenda est ignorantia crassa, sed potiùs in ea est præsumenda probabilis ignorantia, quæ excusat omnino ab iniusta acceptione, vel propter inaduertentiam, quæ sæpe non est in hominum potestate, vel quia non penetrabat has iuris subtilitates, quodque ea via iniuriam proximo inferret. Quando autem persona non est timorata, si nimia ruditas eam, arbitrio prudentis, non excusat à culpa, præsumenda esset ignorantia crassa, eo faciliùs, aut difficiliùs, quo circumstantiæ concurrentes plus, aut minus, indicarent, rem non esse eam tradentis, spectataque ruditate ac simplicitate, vel ingenii perspicacitate, eam accipientis.

Obligationis restituendi, quando formalis iniustitia antecessit, tres partes distinguuntur. Et quousque sit restituendum in prima. Nempe, quando neque obligatio restituendi oritur ex eo, quòd res aliena iniustè sit læsa, aut destructa, neque ex re, cuius dominium ad alium attinet. Disput. 724.

SVMMARIVM.

1. *R* Estituendi obligatio ex tribus generibus iniustitiæ antecedentis.
2. *Restituere qui tenetur ob moram tradendi debitum, quòd ad creditorem nondum quoad dominium spectat, restituere tenetur integrum debitum, & lucrum cæssans ob eam moram.*
3. *Emptor tamen & venditor ob moram iniustam tradendi mercem, aut pretium, non tenetur ad lucrum cæssans, aut damnum emergens, extrinseca, sed solùm ad intrinseca: tenentur tamen ad fructus ex re emptæ, aut venditæ, perceptis, & qui percipi potuerunt tempore moræ.*

INIustitiam circa res externas posse euenire [sect. 1] variis modis, Disp. 680 est à nobis explicatum. Atque secunda restitutionis acceptio ac obligatio Disp. 714. & in calce Disputationis 717. explanata, quando ob iniustitiam circa res externas antecedentem fieri debet, iniustitiæ illi, eos omnes modos comprehendenti, respondet. Quod verò ad rem præsentem attinet, obligationem restituendi, quando iniustitia circa res externas antecessit, in tres partes possumus distribuere. Prima est, quando iniustitia antecessit, iniustè retinendo, quod ita alteri debetur, vt neque retentum sit, quod ad alterum quoad dominium spectat, neque quod debetur ratione damni dati. Exempla sunt, quando quis restituit pecuniam, aut

rem aliam, quam mutuo accepit, postquam iniusta mora interuenit id soluendi, aut restituit pretium rei emptæ, postquam in mora iniusta fuit illud soluendi, & ita de aliis similibus euentibus. Secunda est, quando iniuste fuit vsurpatum, aut retentum, quod ad alterum attinebat quoad dominium, rationeque eius vsupartionis iniustæ, aut iniustæ retentionis, fit restitutio. Tertia est, quando restitutio fit pro damno iniuste proximo dato, quoad res illius externas. Circa singulas has tres partes obligationis restituendi aliquid hac, & sequentibus disputationibus, est addendum, ad pleniorē rei huius de restitutione notitiam.

Quod ad primam partem attinet, de qua [sect. 2] sola est nobis sermo in hac disputatione, hanc [[220]] possumus statuere regulam. Qui iniuste detinet, quod alteri ita debet, vt dominium illius nondum pertineat ad creditorem, tenetur ei restituere totum debitum, & insuper totum lucrum ex eo creditori cessans, aut damnum ei emergens, quod iniuste sit detentum. In hac regula omnes conueniunt. Et quidem quoad debitum, nulli potest esse dubium: quoniam loquimur de debito, quod non solum ex iniustitia debetur, sed etiam coniunctam iam habet iniustitiam ob moram illud soluendi, iniustamve illius detentionem. Quoad lucrum verò totum inde cessans, aut damnum inde emergens, facile etiam liquet: quoniam per eam iniustam talis debiti detentionem causa est iniusta creditori totius eius lucri cessantis, aut damni emergentis: qui autem causam iniustam damni iacturæve dat, restituere id damnum ac iacturam tenetur, vt ex se est perspicuum, & habetur. c. vlt. de iniur. & damn. dat.

Ab hac tamen regula excipitur, quando em [sect. 3] ptor est in mora iniusta tradendi pretium venditori, aut venditor est in mora iniusta tradendi mercem emptori. Vtrumque autem ad restitutionem, de qua in hac disputatione nobis est sermo, spectat: eo quod neque venditor dominium pretii sibi debiti comparet antequam ei tradatur, neque emptor comparet dominium mercis emptæ, sibi que iam debitæ tradi, antequam ei tradatur. Quamuis autem, stando in solo iure naturali, locum in vtroque hoc euentu habere debeat regula generalis proposita, vt ex se est satis notum, nullusque doctorum refragatur; iure tamen humano ciuili est dispositum, vt venditor solum teneatur emptori ad fructus, quos tempore moræ erat ex re emptæ percepturus, & ad interesse intrinsecum, tam mercis, quam eorum fructuum; vt si res emptæ plus valebat tempore, quo erat tradenda, & postea tempore, quo fuit tradita, minus valuit, aut deterior in se est reddita, vel fructus tempore, quo fuissent percipiendi ex re vendita congruo tempore tradita, plus valebant, tenetur venditor emptori ad totum hoc interesse, ultra mercem ex eo emptam; & quoad hæc omnia locum etiam habet in merce, ex contractu emptionis debita, regula generalis proposita: non tamen tenetur venditor emptori ad interesse extrinsecum lucri cessantis, aut damni emergentis, ex mora iniusta tradendi illi mercem: vt, si emptor negotiaturus erat re emptæ, & fructibus ex illa percipiendis, aliquidque erat lucraturus, quod ea mora iniusta fuit impeditum, non tenetur venditor restituere illi id lucrum cessans: aut si, quia res vendita non fuit emptori congruo tempore tradita, vel quia fructus ex ea non percepit, quos percepturus fuisset, si congruo tempore fuisset illi tradita, mancipium, aut iumentum, illius periit, non tenetur venditor illi restituere hoc damnum ex tali mora iniusta ei emergens. Similiter ex dispositione eiusdem humani iuris ciuilis, si emptor accepta merce fuit in mora iniusta soluendi pretium, solum tenetur venditori ad fructus, quos ex re emptæ percepit, aut percipere potuit, & sua negligentia non percepit, toto eo tempore, quo in mora fuit soluendi pretium. Quod si partem pretii soluit, in moraque iniuste fuit soluendi partem aliam, solum tenetur restituere venditori partem proportionalem eorundem fructuum, quæ respondet ei parti proportionali pretii non soluti. Non verò tenetur

illi restituere interesse lucri cessantis, aut damni emergentis ex eo pretio non soluto congruo tempore, vt hæc omnia copiosè ostensa ac explanata à nobis sunt Disp. 368, quo in loco etiam explicauimus, qui fructus rei venditæ ad emptorem pertineant, & qui ad venditorem: qua de causa non plus hoc loco immotor in his omnibus explicandis ac comprobandis. Porro exceptio hæc de iure humano ciuili facta in contractu emptionis & venditionis à regula illa generali vniuersim vera, stando intra solos limites iuris naturalis, non plus est extendenda, quàm iure humano comperiat extensa, vt sæpe toto hoc secundo tractatu admonuimus. Peculiatiter quippe ius humanum id constituit in eo contractu propter maiorem frequentiam ac necessitatem illius, quàm cæterorum contractuum, ad tollendas lites, quæ facilè circa lucrum cessans ac damnum emergens, num verè interueniret, an non, & in quanto valore ac quantitate id interueniret, ex eo frequentissimo ac necessarissimo contractu passim orirentur.

Quousque sit restituendum, quando restituendi obligatio consurgit ex re iniustè vsurpata, aut iniustè retenta, quæ ad alterum quoad dominium spectat. Et num deducendæ sint expensæ cum ea factæ. Ac num aliquando pereat domino illius, & non iniustè detentori. Disput. 725.

SVMMARIVM.

- 1 . *Restituendi obligatio quando resultet ex iniusta retentione rei, quæ ad alterum quoad dominium iam spectat, variis exemplis explicatur.*
- 2 . *Restituere quæ teneatur iniustus occupator, aut detentor rei, quæ quoad dominium ad alterum attinebat.*
- 3 . *Ex fructibus restituendis eius rei, quales expensas deducere debeat is malæ fidei rei illius possessor.*
- 4 . *Restituere tenetur fructus ex ea re perceptos, etiã si dominus non fuisset illos percepturus, & iam non existant.*
- 5 . *Idem iniustus rei alienæ detentor, si res consumatur, aut pereat, non tenetur restituere maiorem valorem, quem postea fuisset habitura; tenetur tamen illi restituere quodcunque lucrum ei cessaret, aut damnum emergeret, ea de causæ in futurum.*
- 6 . *Idem iniustus detentor restituere tenetur rem in valore, quem habebat, quando periit, aut consumpta fuit, esto dominus venditurus eam antea fuisset in minori valore.*
- 7 . *Idem iniustus rei alienæ detentor, si res erat usu consumptibilis, quæ sufficienter restituitur alia eiusdem speciei & bonitatis, eamque vendidit quando plus valebat, experientiaque compertum est, dominum illam fuisse seruaturum in tempus, [[221]] quo minus valet, sufficienter restituitur tempore, quo minus valet, alia eiusdem bonitatis, lucrumq; illud incrementi illius valoris pertinet ad iniustum detentorem, tanquam fructus suæ industriæ.*
- 8 . *Quando res non er at usu consumptibilis, vt equus, quid in præcedente euentu sit restituendum.*

9 . Si res iniuste detenta accreuit in valore postquam cepit iniuste detineri, & postea decreuit, si dominus illam vendidisset in illo maiori valore, aut illa excusasset æqualem sumptum, si tempore, quo plus valuit, fuisset sibi restituta, in eo maiori valore est ei restituenda, esto, si detenta iniuste non fuisset, illam vendidisset antea minori pretio. Quòd si seruaturus eam fuisset in tempus, quo decreuit in valore, satis est eam tunc illi restituere. Si res sit dubia, quid factururus fuisset, tunc pro quantitate dubii est aliquid de illo incremento illi restituendum.

10 . Res iniuste detenta, si periit, aut deterior est reddita, dum ita iniuste retinetur, neque constat, idem omnino rei illi similiter euenturum in potestate domini, restituenda illi est integra. Quando autem esset reddita deterior, in optione domini esset, vel petere integrum rei valorem, & nolle illam, vel petere illam, & æstimationem deterioramenti. Quando detentor purgasset moram, offerendo illam antequam periret aut deterior esset reddita, & per dominum staret illam accipere, ad nihil illi teneretur iniustus antea detentor.

11 . Res eadem si similiter erat peritura in potestate domini, ad nihil illi in conscientie foro ratione illius tenetur iniustus detentor. Et quid in foro exteriori. Tenebitur tamen ad fructus, & qui illi, & ad lucrum cessans, ac damnum emergens.

12 . Possessori rei mala fide, quæ expense in ea factæ sunt soluendæ, quæ non item, & quas extrahere, & quousque possit.

13 . Expensas quousque detrahare possit possessor malæ fidei in conscientie foro ante latam sententiam de valore rei restituendæ.

SECUNDÆ huius partis obligationis restituendi [sect. 1] e tribus, quas disputatione præcedente

distinximus, exempla sunt. Obligatio restituendi ob rem furto, aut rapina, ablatam, vel per vsuram immediatè acquisitam, quarum dominium ad antiquum dominum pertinet. Obligatio restituendi rem depositam, commodatam, aut in pignus traditam, à puncto quo iniusta mora interuenit reddendi eiusmodi res propriis earum dominis. Obligatio restituendi id, quod emptionis titulo, aut quocunque alio, cepit mala fide possideri cum scientia, quòd ad alium attineret. Vel, licèt possideri cæperit bona fide, depulsa fuit bona illa fides, ac sciri cæpit, esse alienum: obligatio quippe restituendi, quæ oriri incipit à puncto, quo agnoscitur rem esse alienam, & iniuste iam retinetur, ad hanc etiam secundam obligationis partem spectat. Quando autem cum dubio, an res esset aliena, cæpisset possideri, aut, orto post inceptam bona fide possessionem tali dubio, culpabiliter esset omissum inquirere, an aliena esset, quanta obligatio tunc sit restituendi, sat sunt, quæ Disput. 723 sunt dicta. Ad hanc etiam partem obligationis restituendi attinet obligatio, qua hæres iniuste retinet rem in singulari alicui legatam: eo quòd dominium illius ad legatarium spectet, attinentque similes aliæ retentiones iniustæ rerum, quæ ad alios quoad dominium spectant.

Hac autem de re prima conclusio est. Qui⁷¹unque iniustus vsurpator, aut detentor, rei ad [sect. 2] alterum quoad dominium attinentis, tenetur à puncto iniustæ usurpationis, aut iniustæ detentionis, restituere domino rei ea omnia, quæ Disput. 723, conclusione prima, explanata sunt, idque propterea, quæ ibi dicta sunt. Neque hæc conclusio alia explanatione aut probatione eget, consentiunt. c. graui de rest. spol. & alia iura. Quoad fructus autem ex ea re perceptos, & qui percepti non sunt, dominus tamen illius percepturus fuisset ex illa, nisi iniuste fuisset priuatus toto eo tempore possessione illius, quos omnes conclusione citata ostendimus restituendos esse, duo sunt obseruanda.

Primum est circa fructus ex ea re perceptos. [sect. 3] Nempe nomine eorum intelligi, qui remanent deductis expensis in eis percipiendis rationabiliter factis, siue enim à possessore bonæ fidei, siue à possessore rei mala fide, sint percepti, semper nomine fructuum intelliguntur illi soli, qui remanent deductis iustis expensis; eo quòd semper deducendæ sint ex illis iustæ expensæ, vt Disp. 455. §. vlt. ostendimus, & constat ex. l. si à domino. §. fructus. ff. de pet. hered. ex. l. fundus qui, in prin. ff. de famil. hereis. quo in iure habetur, nullum euentum euenire posse, in quo expensæ non sint è fructibus deducendæ, ex. l. 42. titu. 28. part. 3. ex. l. fructus. ff. solut. matr. ex. l. 1. C. de fructibus & litium expens. & ex. l. in fructibus. ff. de usufruct. consentiuntque Bart. l. in fundo ff. de rei vend. Panor. c. grauis citato, & communis doctorum sententia, quam referunt ac sequuntur Nauar. in Manu. c. 17. n. 25. Conar. 1. var. res. c. 3. n. 3. & Aluar. Val. de iur. emphy. q. 25. Obserua tamen, in possessore malæ fidei solas iustas expensas, in eis colligendis factas, esse deducendas; maiores autem deducendas non esse. Quin, si dominus rei minoribus suis sumptibus fuisset illos percepturus, suaque industria ac labore & suorum, quæ aliunde non compensauit, non plures sumptus erunt deducendi, quàm rei dominus fuisset factururus in illis colligendis: quandoquidem incrementum supra illos, ad lucrum cessans, aut damnum emergens, domino talis rei spectaret, si ex cis fructibus deduceretur.

Secundum verò est circa fructus ex ea etiam [sect. 4] re perceptos, quos tamen percepturus non fuisset dominus rei illius. Circa quos nobis non probatur opinio Couar. reg. peccat. part. 2. §. 6. n. vlt. qui, cùm nobiscum conueniat, hos etiam fructus restituendos esse domino rei, si existant; eo quòd, si rei fructus sint, & non solius industriæ, dominium illorum ad rei dominum pertineat, & non ad possessorem siue bona siue mala fide rei illius, esto industria talis possessoris cooperata sit, vt illos produceret, iuxta ea quæ Disput. 719 dicta sunt; affirmat tamen, quando iam non existunt, neque ex illis malæ fidei possessor factus est locupletior, non teneri ad illorum restitutionem: si verò factuo [[222]] ex illis sit locupletior in aliquo, teneri solùm restituere, quantum ex illis est factus locupletior; eo quòd in eo adhuc existant. Ducitur verò, quoniam talis malæ fidei possessor nec tenetur restituere fructus, quos ita ex tali re aliena percepit, & iam omnino non existunt, ex parte rei acceptæ, hoc est, ipsorummet fructuum, qui iam non existunt; neque item ratione damni illati; quandoquidem dominus habiturus non fuisset eos fructus, esto rem illam suam, vnde percepti sunt, semper possediffet, neque ab alio fuisset usurpata, aut iniustè detenta. Dicendum verò proculdubio est, non minùs teneri eos restituere, quàm si pars essent fructuum, quos percepturus fuisset dominus rei, & similiter non existerent. Ratio autem est, quoniam eo ipso, quòd semel in rerum natura extiterunt tanquam fructus veri rei illius, dominium illorum pertinuit ad dominum rei, & qui illos ab eo puncto detinuit, neque eos ipsi restituit, iniuriam illi intulit, damnumque proinde iniustum illi dedit, qui eos consumpsit: vnde ex parte iniustæ detentionis ac acceptionis tenetur illi ad illorum restitutionem. Quod itaque fefellisse videtur Couarruiam est, non attendisse, eo ipso, quòd tales fructus in rerum natura extiterunt, dominum rei, cuius fuerunt fructus, comparasse dominium illorum, furemque, aut alium malæ fidei possessorem eorum, & subinde non attendisse, quòd quamuis talis malæ fidei possessor damnum non intulerit domino rei, cuius fuerunt illi fructus, si præcisè attendamns ad statum, in quo dominus ille futurus fuisset, si res ex illo non fuisset iniustè ablata, aut contra ipsius voluntatem non fuisset iniustè detenta, damnum tamen illi intulisse attento statu, in quo re ipsa dominus fuit eorum fructuum, esto futurus non fuisset, si penes ipsum semper permansisset.

Dubium autem est, vtrùm fur, aut quicumque alius malæ fidei possessor, vel malæ fidei detentor, rei alienæ, si illa consumatur, pereat, aut deterior reddatur, teneatur illam restituere in maiori pretio, quo valuit intra tempus totum, in quo iniuste illam detinuit, neque illam restituit.

De qua re est secunda conclusio in ordine.⁷² Eo ipso, quòd res illa consumpta est, aut aliter [sect. 5] periit, non tenetur talis malæ fidei possessor restituere maiorem valorem, quem ea res in futurum habitura fuisset, esto culpa talis detentoris pereat aut consumatur. Si tamen inde domino rei aliquod lucrum cesset, quatenus, si in ipsius fuisset potestate, seruaturus illam fuisset in id tempus, distracturusque tunc fuisset illam maiori pretio, id lucrum cessans, aut quodcunque aliud, quod ea de causa cessauerit, vel si quod damnum inde ei emergerit, est illi restituendum. Prior pars huius conclusionis Disput. 723 in posteriori parte conclusionis primæ asserta ac comprobata fuit. Res enim non valet domino suo, nisi quamdiu existit: unde, si ex eo, quòd pereat, non cesset aliquod lucrum domino illius, quod ex illa, existente in ipsius potestate, foret percepturus, iniustus illius detentor non tenetur eam illi soluere in maiori pretio, quod postea foret habitura, esto culpa illius pereat. Posterior verò in eadem Disput. 723, atque in eadem posteriori parte primæ conclusionis, asserta comprobataque fuit. Semper enim iniustus rei alienæ detentor tenetur domino illius ad omne lucrum cessans, ad omneque damnum emergens, ex tali iniusta detentione proveniens, tanquam eo ipso iniusta illius causa. Atque inde proficiscitur, quòd si iniustus vsurpator, aut detentor, aliquarum mensurarum tritici, illas consumat, aut vendat, tempore, quo minus valebant, si dominus seruaturus illas erat, vendendas tempore, quo plus essent valiturae, teneatur illi restituere id totum lucrum, quod re ipsa ea de causa illi cessauit. Atque idem est de quocunque alio simili euentu.

Tertia conclusio. Esto dominus rei consum⁷³pturus, aut distracturus, illam fuisset tempore, [sect. 6] quo minus valebat, utique, si in manu furis, aut alterius iniusti illius detentoris, accrescat in valore, restituere eam tenetur in maiori valore, in quo fuerit reperta, aut quod habuit tempore, quo ab illo fuit consumpta. Probatur, quoniam quamdiu res illa existit, dominium illius ad eum pertinet, cuius erat quando vsurpari aut detineri iniuste cæpit: ergo quicquid in valore illa accrescit, domino illius accrescit. Quo fit, ut si aliquis furetur ab aliquo measuras aliquot tritici tempore, quo parum valebant, & postea accrescat valor earum in manu furis plusquam in duplo, teneatur eas integras domino illius restituere, nihil impediens, quòd dominus venditurus illas fuisset longè minori pretio, & quòd ex furto lucrum illarum domino per accidens accrescat. Si tamen fur consumeret illas tempore, quo parum valebant, satisfaceret, si eas domino restitueret pretio, quod valebant, quando illas erat venditurus aut consumpturus, ut ex præcedente conclusione liquet. Quoniam, dum extiterunt, non habuerunt maiorem valorem, & ex consumptione illarum nullum lucrum cessauit, nullumque damnum emerit, ipsarum domino. Secus autem res haberet, si fur illas vendidisset, & perseueraret apud aliquem earum possessorem tempore, quo plus valerent: quoniam, cum dominium illarum semper perseueret apud antiquum dominum, maior ille valor ad ipsum pertinet, eique est restituendus, vel suum triticum adhuc existens.

Quarta conclusio. Si fur, aut alius iniustus⁷⁴ detentor, accepit rem tempore, quo multum valebat, eamque consumpsit, aut vendidit, do [sect. 7] minusque distracturus illam non erat, sed reseruaturus in tempus, in quo longè minus erat valitura, si res erat de numero earum, quæ usu consumuntur, quæve functionem in genere suo recipiunt, hoc est, quæ sufficienter soluuntur reddita alia eiusdem speciei & bonitatis, ut sunt triticum, oleum, mel, & similia,

sufficienter illam restituit tempore, quo minus valet, reddendo aliam eiusdem speciei & bonitatis, nihil impediens, quòd fur inde per accidens commodum ac lucrum reportet: tale quippe lucrum fructus est suæ industriæ, non verò rei, iuxta ea quæ Disput. 327, 524, 719, 720, & sequentibus, dicta sunt, quod proinde ad ipsum spectat. Verbi gratia, si furatus est quis aliquot tritici mensuras tempore, quo multum **[[223]]** valebant, expetentiaque postea compertum fuit, dominum non fuisse illas venditurum, neque consumpturum, deuentumque sit ad tempus, in quo longè minùs triticum valet, sufficienter satisfaciet, si reddat totidem mensuras tritici, eiusdem bonitatis, quot accepit. Probatur, quoniam reddit æquale in iis, quæ functionem in suo genere accipiunt, nullumque inde lucrum cessauit domino rei, nullum que inde damnum est passus.

Dixi, si res erat de numero earum, quæ usu [sect. 8] consumuntur, quæve functionem in genere suo accipiunt: quoniam, si non sit talis, sed sit equus verbi gratia, poterit dominus non velle esse contentus solutione alterius similis in bonitate, sed velle potius pretium, esto non esset equum venditurus. Præterea, si aliquis fuit vsus eius equi, poterit velle iustum pretium illius vsus, tanquam ex fructu ex sua re percepto, ei que omnino debetur. At certè, quando equus iam non esset in rerum natura, constaretque dominum venditurum non fuisse illum tempore, quo plus valebat, neque damnum aliud ei emersisse, improbable non videtur, sufficienter fieri ei restitutionem, si, decrescente postea pretio equorum, eo quòd necessarii iam non essent ad bellum, quod antea imminabat, aut parabatur, vel alia ratione, illi restitueretur equus alius æqualis in bonitate: quandoquidem æquale ei redditur, neque ex furto lucrum ei cessauit, aut damnum emersit. Et licèt, quando res, quæ in genere suo functionem non suscipit, perseuerat eadem numero, possit dominus rationabiliter non esse alia contentus, quàm sua; quando tamen illa restitui non potest, quia iam non existit, certè non minus compensatur alia æquali in bonitate, quàm valore illius. Imò verò faciliùs tunc attingitur æqualitas reddendo aliam eiusdem speciei & bonitatis, quàm arbitrando pretium, quod, intra limites iusti, magnam habet latitudinem. In dubio tamen, an dominus equum fuisset venditurus, restituendus esset valor, quem res habebat tempore, quo plus minùs credebatur fuisse verisimiliter ab eo vendendus. Obserua tamen, vsum equi perceptum restituendum etiam esse, quantum ob illum equus non est redditus deterior.

Quinta conclusio. Si res accreuit in valore in⁷⁵ potestate furis, aut alterius, ad quem deriuata [sect. 9] tandem sit ex iniusto illius detentore, & postea in valore decreuit, verisimileque erat, si restituta fuisset tempore, quo plurimum valuit, dominum illam venditurum, aut illa excusaturum fuisse emptionem alterius æqualis valoris illi magno, tunc fur, aut quicumque alius iniustus illius detentor, teneretur illam restituere iuxta maximum illum valorem, nihil impediens, quòd dominus, si ex ipso non fuisset ablata, fuisset illam venditurus, aut consumpturus tempore, quo longè minùs valuit. Verbi gratia, si quando aliquis furatus est triticum, (quod dominus distracturus erat statim) valebat quinque, & postea accreuit in valore vsque ad decem, iterūque decreuit in valore, si verisimile sit, dominum, si ei restitueretur quando valebat decem, illud fuisse venditurum decem, vel eo tritico excusaturum emptionem æqualis quantitatis tritici eo pretio, vtique tunc fur teneretur illud restituere iuxta maiorem illum valorem. Probatur, quoniam quando ad illum maximum valorem peruenit, totus ille valor erat domini tritici illius adhuc in rerum natura existentis, furque iniustè distulit illud restituere: ergo ex parte iniustæ illius retentionis tenetur ad restitutionē domino illius totius lucti ex eo ei cessantis, aut dāni emergentis, quòd tunc non restituerit: id autē fuit totum, quod decst, valoris in eo tritico usque ad illum maximū. Idem

dicendum est de quacunque alia re iniuste retenta, quæ similiter acciescat & decrescat in valore. Quòd si moraliter non sit verisimile ac certum, dominum rei illius venditum fuisse rem illam maiori illo pretio, aut illa excusaturum emptionem alterius eodem maiori pretio, si res sua restituta ei fuisset, quando ad eum magnum valorem peruenit, tunc, iuxta dubii quantitatem, restituendum illi est plus, vel minus, prout prudentis arbitrio plus vel minus æstimabitur lucrum ei cessans, aut damnum eidẽ emergens, ex tali iniusta rei suæ detentione, vt id lucrum, aut damnum, est sub eo dubio.

Sexta conclusio. Quando res deterior est red⁷⁶ dita, aut periit, dum fuit extra potestatem domi [sect. 10] ni, ex quo fuit iniuste ablata, aut detenta, nec cõstat, simili modo fuisse perituram, aut deteriorẽ reddendam, in potestate domini, quia fortasse dominus illam distraxisset, antequam ad eum statum deuenisset, vel impediisset ne id eueniret, vel casus, qui circa illam extra domini potestatẽ constitutam euenit, non similiter euenisset, si in potestate domini perseuerasset, tunc iniustus illius occupator, aut detentor, restituere illam tenetur domino in integro illius valore, ac si nõ periisset, aut non fuisset reddita deterior. In hac omnes conuenire videntur, cõsentiũtq; Ioa. Medi. de rest. q. 6. & Couar. reg. peccatum part. 2. §. 6. n. 1. & alii, quos citat. Ratio autem est. Quoniam eiusmodi iniustus illius occupator, aut detentor, restituere illam tenetur ratione talis iniustæ detẽtionis, in eoq; euentu ipsi imputari debet, quòd res perierit, aut deterior fuerit reddita; quandoquidem fuit in mora iniusta illam restituendi, euenireque verisimiliter potuit, vt dominus iacturam illam nõ sustinisset, si iniuste non fuisset ex ipso ablata aut detenta. Quòd si iniustus rei illius detentor moram purgasset, offerendo rem proprio domino, quando ille accipere eam potuit antequam periret, aut deterior redderetur, tunc non imputaretur iniuste rẽ illam illuc vsque detinenti, quicquid absque sua culpa deinceps circa eam rẽ eueniret. Porrò, quando iniustus detentor rei redditæ deterioris, restituere eam teneretur quoad integrum valorem, perinde ac si deterior non fuisset reddita, ad alterum duorum sub disiunctione optione eius, cui restitutio est facienda, tenetur, nempe vel ad reddendam rem, & ad restituendũ insuper, quod æstimabitur detrimentum, quod est passa, vel ad restituendum valorem integrum, quem haberet, si deterior non esset reddita, accipiendo sibi eam rem. Ita Med. q. 6. citata. Ratio autem est, quoniam rei illius dominus rationabiliter potest esse inuitus, vel quòd rem cogatur accipere postquam est deterior reddita, esto ei offeratur, quod minus ea de causa valet; vel quòd re sua priuetur eo obtentu, quòd deterior sit reddita; eaque de causa vtrumuis respicere poterit, quod maluerit, & eligere potiùs alterum: quandoquidem iniustitia iniqui rei illius detentoris est ad eum statum deuentum.

[[224]] Septima conclusio. Quando constat, rem⁷⁷ simili modo fuisse perituram, aut deteriorem [sect. 11] reddendam, apud illius dominum, non tenetur fur, aut alius iniustus illius detentor, eam in conscientia foro restituere, si absque noua sua culpa pereat, aut deterior reddatur. Fructus tamen restituere tenebitur, si quos ex illa percepit, aut percepisset dominus rei. Inter eos autem computa valorem vsus rei illius, si vsus fuit aliquis re illa, aut si dominus rei illius priuatus fuit vsu eiusdem rei. Tenebitur quippe restituere domino rei, quantum æstimabitur vsus, quo illum re ipsa priuauit: imò quantum æstimabitur illum habere eam rem domi ad honorem ac splendorem familiae, esto non aliter vsurus fuisset ea re: & insuper restituere ei tenebitur, si quid amplius valeret vsus ex ea re perceptus, & denique totum lucrum cessans, ac damnum emergens.

Non video posse esse dubium in posteriori huius conclusionis parte: quandoquidem ea omnia, vel sunt fructus rei, qui ad dominum illius eo ipso pertinent, vel in eis rei illius

dominus iniuste damnum est passus. Quo fit, ut in casu, quem Med. q. 6. citata proponit de seruo, qui à nobili furatus est equum, quo dominus vsurus non erat, eo quòd ægrotauerit, & quo nec famulus ipse est vsus, quia ea de causa fuit coniectus in vincula, neque ei licuit eo uti, attendendum sit, num præterquam quòd moraliter esset certum, equum eodem modo fuisse perituum in potestate domini, quo in serui potestate fuit mortuus, vsus fuerit aliquis alius eo equo de licentia famuli, vel priuatus fuerit dominus equi emolumento aliquo splendoris familiæ, aut vsus, quo per famulos suos eo equo fuisset vsurus, vel alio simili. Hæc enim omnia, ut minimum resarcienda in foro conscientiæ atque in exteriori sunt, nisi sufficienter compensentur necessariis expensis factis cum eo equo.

Quod verò ad priorem partem attinet, communis sententia est, iniustum rei alienæ occupatorem aut detentorem cogendum esse in exteriori foro, integrum illius valorem restituere, nihil impediens, quòd res simili modo in potestate domini foret peritura, ut *Couar. reg. peccatum part. 2. §. 6. n. 1. refert*. Ipse verò, cum Martino, & aliis, quos citat, contrarium, etiam exteriori foro, in eo euentu affirmat. Tum quia natura ipsa rei, debitumque ex iustitia, non aliud habent. *Tum etiam argumento. l. si cum exceptione. §. quòd si homo. vers. sed etsi non culpa. ff. quod metus caus. c. l. si plures. ff. deposit.* Quod verò ad conscientiæ forum attinet, *Med. q. 6. citata latè Disputat.* hanc quæstionem, neutramque partem improbabilem reputat, satisque æquitati consonam arbitratur priorem nostræ conclusionis partem: eo quòd iniustus rei alienæ detentor solùm teneatur restituere compensando ad æqualitatem damnum, quod ex ipsius iniusta occupatione aut detentione fuerit subsequutum: at verò, inquit, quando res simili modo erat peritura, aut deterior reddenda, in potestate domini, nullum damnum illi est subsequutum ex tali iniusta occupatione aut detentione, quippe cum nihil minus habeat, quàm fuisset habiturus, si ea iniusta occupatio aut detentio non præcessisset. Maximè autem ait hoc videri verum, quando res statim periit, aut deterior est reddita, eo modo, quo in potestate domini peritura fuisset, aut deterior reddenda; ut si per superuentum hostium, qui omnia diripuerunt, res eo modo fuit ablata, quo ablata fuisset, si in potestate domini esset, aut si aliquis de nauis, quæ naufragium patiebatur, aliquid est furatus animo sibi illud detinendi; & statim, ac illud accepit, eadem tempestate in mari periit eo modo, quo fuisset in nauis perituum. Ait eandem partem probabilem etiam esse, quando res ex interuallo eodem modo periit, quo in potestate domini fuisset peritura. Contrariam etiam partem non improbabilem reputat de iustitiæ rigore. Atque idcirco optionem aliis relinquit, ut unusquisque eam partem eligat, quam probabiliorem iudicauerit. *Couar. verò. n. 1.* citato absolute atque omnino amplectitur, non consurgere obligationem restituendi in foro conscientiæ, esto res post longum tempus eodem modo pereat penes iniustum illius detentorem, quo peritura erat apud suum dominum. Quoniam de iustitiæ rigore nullus tenetur ex parte iniustæ acceptionis, nisi ad compensandum damnum, etiam lucris cessantis, quod ex iniusta acceptione, aut ex iniusta detentione, fuerit sequutum; & res domino pereat, quando sine culpa alterius periit, neque deductum fuit in pactum, aut dispositum, ut alteri periret: in re autem proposita constat, non teneri ex parte ipsius rei, quæ iam non extat, quoad id, quod ex illa periit, aut deterior est reddita. Quòd si talis iniustus rei occupator, aut detentor, in foro exteriori condemnaretur, soluere integrum rei valorem, neque ea sententia fundaretur in præsumptione, quòd res in potestate domini non fuisset similiter peritura, tunc ea condemnatio esset in pœnam iniustæ acceptionis, aut retentionis, quæ pœna locum in conscientiæ foro non haberet, nisi postquam per sententiam iniuriam passo fuisset adiudicata. Hæc sententia mihi probatur, quam idcirco in nostra conclusione asserui. Hoc loco obserua,

doctores, qui contrarium affirmant prioris partis nostræ conclusionis, non ea ratione ad id duci, quasi pro iniuria iniustæ acceptionis, aut retentionis, sumpta præcisè à damno dato, id sit restituendum nulla expectata sententia: sed duci ea ratione. Quòd eo ipso, quòd res fuit iniustè accepta, datum sit domino damnum valoris illius, neque vnquam fuerit illis redditum ac satisfactum. Nos autem dicimus, quòd, cùm dominus rei illius nunquam dominio illius fuerit spoliatus, sed semper apud ipsum manserit; & res domino pereat, quando culpa alterius non periit, neque aliud fuit in pactum, aut iusta lege sancitum; illam periisse domino, neque id damnum fuisse illi subsequutum ex iniusta detentione; eo quòd similiter domino periisset, esto nunquam antecessisset ea iniusta detentio: quare negamus aliud damnum esse datum iniusta rei alienæ occupatione aut detentione, quàm quod compertum fuerit illi adesse re ipsa, vel iacturæ rei illius, vel fructuum, vel alterius [[225]] lucri cessantis, aut damni emergentis, ex ea iniusta rei illius occupatione aut detentione.

Quod attinet ad expensas cum re mala fide [sect. 12] occupata aut retenta, *vt constat ex l. impensæ. ff. de verb. sign. & sæpe in hoc tractatu cum Bart. l. in fundo. ff. de rei vend. & cum communi doctorum sententia est dictum, quædam sunt necessariae, quædam vtilis, & quædam voluntariæ, seu voluptuariæ. Necessariæ sunt, quæ nisi fierent, periret, aut reddita esset deterior, res cum qua, aut circa quam, sunt factæ, vt sunt curare mancipia, quando in morbum incidunt, reficere domum, quæ minatur ruinam, & aliæ similes. Vtilis sunt, quæ vtiliorem melioremque rem efficiunt, vt sunt plantare vtile oliuetum, aut vineam vtilem. Voluntariæ, seu voluptuariæ, sunt, quæ pulchriorem seu aptiorem efficiunt rem ad capiendam ex illa voluptatem, vt sunt viridaria, picturæ, structuræ fontium, ad solam recreationem, & his similia. Hæc omnia constant ex. l. impensæ citata, consentitque communis doctorum sententia.*

Hoc ita constituto, possessor malæ fidei extrahat repetitque in exteriori foro impensas necessarias factas in re aliena, vt Disp. 445 & 463 ostensum est. Excipitur, nisi sit fur, & fecerit expensas in alendo puero infante mancipio, quem surripuit: licet enim expensæ in illo alendo necessariae sint, illas tamen non extrahit, sed omnino amittit, *vt habetur. l. ex argento. ff. de condit. furt. & l. 1. C. de infant. exposit.* Quoad expensas vtilis est distinguendum, quoniam si cedunt in dominium eius, cuius est res, cui adhærent, neque existere possunt separatæ ab ea re, vt est figura atte facti ex auro aut ex argento alieno, tunc omnino amittitur domino rei, *vt constat. l. ex argento. ff. de condit. furt.* Si verò existere possunt separatæ quoad materiam, vt est ædificium, aut sunt plantæ solo affixæ, tunc, si res, in qua factæ sunt, à principio cæpit bona fide possideri, postea verò desinit esse bona fides, factæque sunt tales expensæ postquam fuit cognitum rem esse alienam, tunc permittuntur tolli ab eo, qui illas fecit, & auferri, *vt habetur. l. Iulianus. 38. ff. de rei vend.* nisi dominus rei, in qua sunt factæ, velit soluere illarum æstimationem, quantum valeret, quod extraheretur, postquam esset extractum. Si verò res, in qua factæ sunt, cæpit à principio mala fide possideri, tunc expensæ omnino amittuntur domino rei. §. ex aduerso inst. de rerum diuisione. Quando autem expensæ factæ sunt in aliquo, quod ita sit affixum rei alienæ, vt non cedat in dominum eius, cuius est ea res, vt essent ianuæ, & fenestræ, factæ & appositæ in aliena domo, lapis pretiosus affixus in alieno annulo, & alia eis similia, tunc permittuntur tolli sine læsione rei alienæ quoad antiquum illius statum, quem habebat antequam tales sumptus in ea re aliena essent facti: & in hoc euentu intelligenda est. l. domum. C. de rei vindicatione. Voluptuariæ autem expensæ factæ in re mala fide possessa, omnino amittuntur, vt Disputationibus citandis dictum est,

& constat ex iuribus citatis. Atque hæc quod ad forum exterius attiner, addendaque sunt dictis Disp. 455 & 463.

Vt verò optimè obseruat *Ioan. Medi. de* [sect. 13] *rest. q. 6. & cum eo Couar. reg. peccatum. part. 2. §. 6. n. 3.* hæc, quæ in exteriori foro de amissione expensatum in re aliena mala fide possessa dicta sunt, in pænam sunt statuta, neque habent locum, nisi post latam sententiam, aut quando obtinente domino rem suam cum melioramentis in ea ita effectis, exigenteque, qui ea effecit, expensas, aut valorem melioramentorum, repelleretur à domino eius rei exceptione, quòd ea amiserit, tanquam in re mala fide possessa, effecta. Quare, in foro conscientia, si ageretur de restituenda re, ante latam sententiam, & ante occupationem illius à proprio domino cum melioramentis, seu expensis, detrahare posset malæ fidei possessor, quantum res illa plus valet ob expensas, etiam voluptuarias, in ea factas. Vnde, qui furatus esset mancipium infans, & in eo alendo aliquid expendisset, posset extrahere ex illo, & ex emolumentis, aut ex vsu illius, si aliquid tale pretio æstimabile ex eo mancipio percepit, aut percepturus fuisset dominus illius, nisi furto fuisset ablatum, quantum proprius dominus cum eodem mancipio erat expensurus. Et si quis furatus sit aurum, & ex illo annulum, aut aliud arte factum, confecit, satis est si restituat tantundem massæ auri æquè boni, retinendo sibi id arte factum, quod plus valet propter formam in ea materia inductam.

Quousque sit restituendum, quando obligatio consurgit ex damno iniustè rebus aliorum externis dato. Disput. 726.

SVMMARIVM.

1 . *Damnum in rebus externis qui iniustè dat, æstimationem illius, & lucrum vltierius cessans, ac damnum emergens, restituere tenetur.*

2 . *Damnum datum in re, quæ ab alio erat destruenda iniustè, aut diripienda, integre est restituendum: itemque quod datum est in re, quæ erat peritura, quando de eo euentu erat ignorantia. Quando verò sciebatur periculum, non plus est restituendum, quàm valeat constituta in eo periculo. Si tamen ab aliquo eripiat, & postea destruat, aut consumatur, integre est restituenda.*

3 . *Damnum, qui iniustè dat, ultra æstimationem damni, & lucri aliunde cessantis, aut dāni emergentis, non tenetur restituere fructus, qui ex ea re fuissent alioquin percipiendi.*

4 . *Damnum in satis, & in aliis similibus rebus, æstimatur, quantum tunc valent, nec plus est restituendum, Sotusque refellitur.*

5 . *Damnum eueniens ex dilatione solutionis in tempore præfixo tenetur debitor creditori soluere, etiam si absque sua culpa solutionem distulerit. Excipitur damnum extrinsecum ex eo, quòd pretium rei emptæ solutum non sit in termino præfixo, esto potuerit. Et quando lethalis culpa interueniat ex culpabili dilatione solutionis.*

Q Vando aliquis damnum iniustè dat, rem [sect. 1] externam alterius destruendo, aut deteriorem reddendo, vel aliqua alia ratione, restituere illi tenetur valorem totius damni ita iniustè dati. Quòd si illi vltierius inde sequatur iactura [[226]] aliqua lucri cessantis, aut

damni emergentis, id etiam totum restituere illi tenetur, quantum prudentis arbitrio hæc æstimabuntur. In his nulla est difficultas, facileque ex eo liquet, quod, qui damnum ita dat, est causa iniusta horum omnium: unde, cum is, qui causa est iniusta damni, seu iacturæ proximi, teneatur ea omnia restituere, quorum ita est causa iniusta; consequens profectò est, ut, qui causa est iniusta damni in bonis externis proximi, ad restitutionem eorum, quæ dicta sunt, teneatur.

Sunt verò nonnulla circa hoc observanda. [sect. 2] Primum est. Esto res, in qua damnum proximo datur, alia via domino ipsius esset peritura; qui tamen damnum in illa ei dat, tenetur integrum valorem illius ei restituere, ac si peritura non esset; saltem quando tempore damni dati non erat notitia de interitu illius futuro. Item, quando vnus præuenit damnum dando, quod alius iniustè erat in eadem re daturus, tenetur ad integram damni restitutionem, ac si alius non esset illud daturus. Ratio huius posterioris asserti est. Quoniam sicut ille alius, si id damnum iniustè dedisset, teneretur integre illud restituere: ita, qui illum præuenit, idemque damnum dedit, tenetur integre illud restituere, tanquam integra, ac sola, iniusta causa totius eiusce damni. Ratio verò prioris asserti est. Quoniam, quando non constat de interitu rei futuro, res illa in communi hominum æstimatione valet, quantum valeret, si is interitus illi non immineret: sicut triticum, interim dum de fertilitate anni superuentura, aut de ingenti illius copia, quæ mari asportatur, non constat, tantum valet, quantum valeret, si talis fertilitas, aut copia, quæ mari asportatur, non esset superuentura, ut Disp. 354 fuit ostensum: quare, qui damnum in re aliqua iniustè dat, interim dum non est notitia de interitu illius futuro, sanè iniustè destruit integrum illius valorem, quem haberet, esto res non esset breui interitura; eo quòd valor cuiusque rei in hominum commerciis is est, quem res in communi hominum æstimatione tunc habet; ac proinde id totum tenetur restituere, tanquam qui in eo toto iniustè læsit dominum rei illius iuxta statum, quem ea res tunc habebat. Quo loco observa discrimen inter furem, qui accepit rem, quæ in ipsius potestate eo modo periuit, quo in potestatem domini fuisset peritura, & inter eum, qui damnum dat in re, quæ paulo post erat peritura, id tamen ignorabatur. Quòd fur rem non destruit, sed manet domini, vbicunque & apud quemcunque ea sit, eaque de causa, quando iniusta acceptio neque fuit causa, neque occasio, interitus eius rei, sed res, eo modo periuit, quo apud dominum erat peritura, sanè domino perit, nullumque damnum re ipsa sequutum est domino ex tali iniusta acceptione, aut detentione, ut Disputatione præcedente explicatum fuit. At verò is, qui iniustè damnum dat, destruit rem, illamque perire domino facit, ac proinde damnum infert domino in toto eo valore, quem tunc res habet, illum iniustè priuando, non solum possessione, sed etiam dominio eius rei; eaque de causa, ratione rei iniustè destructæ, tenetur illi de iustitia ad integrum valorem, quem tempore, quo destructa fuit, habebat. Dixi in priori asserto, saltem quando tempore damni dati non erat notitia de interitu illius futuro: quoniam, si constabat, aut rationabilis timor erat, rem breui domino perituram, sanè ea notitia multum minuit valorem eius rei apud id scientes, ac proinde dandum iniustè in illa dans non tenebitur restituere maiorem valorem, quam res, existente ea notitia, sub eoque statu constituta, habebat. Quo fit, ut si aliquis destruat, quod vi tempestatis, aut incendio, vel alio euentu fortuito, breui credebatur periturum, imò & quod ab hostibus credebatur breui diripiendum, non plus teneatur restituere, quam res sub ea scientia, atque in eo statu constituta, valeret: eo quòd non minus damnum re ipsa in valore dederit. Secus autem res haberet, si quis animo sibi eam vsurpandi liberaret ab interitu rem, quæ breui peritura credebatur, eamque consumeret, quando, post ita ab interitu liberatam, multum valebat.

Quia enim dominus illius, neque ex eo, quòd res illa in eo discrimine fuerit constituta, neque ex eo, quòd fuerit ita ab eodem discrimine liberata, amisit dominium illius, sanè maior ille valor, qui in ea eo ipso resultat, quòd est à periculo illo liberata, ad ipsum spectat, eaque de causa, qui tunc illam in iustè consumit, aut aliter destruit, damnum illi iniustè dat in toto eo valore, in quo toto est proinde illi restituenda; deducto, si quid ereptori debetur pro opere, industria, aut periculo, cui se exposuit in ea ab interitu liberanda. Illud etiam obserua, aliud esse anteuertere in damno iniustè dando, eum, à quo creditur rem tandem fore restituendam, aut qui de eadem republica est, & ob id exigi ab illo poterat, aut, si non restitueret, sua culpa, & cum suo onere, id omitteret; & aliud anteuertere hostes, qui de aliena republica sunt, & bellum, licèt iniustum, ferunt, de quibus credendum sit, nunquam restitutos, quæ deripuissent, aut damna iniusta, quæ dedissent: eaque de causa, quod deripiendum, aut destruendum erat per hos secundos, comprehendimus in priori asserto: de eo verò, quod breui erat destruendum per illos alios primos, loquuti sumus in posteriori asserto.

Secundum est. Is, qui damnum dat, non te [sect. 3] netur restituere fructus, qui ex re, quam destruxit, percipiendi essent in futurum, sed satisfāciet restituendo rem quoad valorem, quem habebat quando illam destruxit. Hoc idem assertum à nobis fuit Disp. 723, in posteriori parte primæ cōclusionis. Ratio autem illius hæc est: quoniam valor rei tempore, quo destruitur, æstimatur attentis fructibus, qui ex illa percipi possunt, & attento vsu illius, commoditateque omni, quæ ex illa in futurum possunt percipi, ac proinde hæc omnia, vt sunt in potentia eius rei, proximiora, aut remotiora, ab actu, soluuntur, dum iustus valor illius rei soluitur. Quo fit, vt, qui alienam domum iniustè combussit, aut qui alienum equū iniustè interfecit, quam dominus erat solitus locare, non teneatur restituere valorem domus, & insuper valorem pensionum, quæ ex illa erant percipiendæ, aut valorem equi, & stipendia quæ ex locatione illius erant percipienda, sed satis esse, si restituat eum domus, aut equi, valorem, quem tempore damni in eis dati habebant: [[227]] quoniam compensando ad æqualitatem eum valorem, soluuntur eiusmodi pensiones ac stipendia, prout in potentia erant talis domus aut equi. Quòd si dominus domus, aut equi, potiùs velet rem suam, quam iustum illius valorem, fanè, quòd inuitus re sua priuetur, spectat ad iniuriam, quam accepit, eritque ea iniuria punienda condigna pæna pro quantitate culpæ id damnum iniustè inferentis: quia tamen damnum ea iniuria iniustè datum, ad æqualitatem pretio iusto rei, quæ iniustè fuit destructa, compensatur; consequens profectò est, vt, ante latam sententiam, qua is delinquens ad pænam condemnetur pro culpæ quantitate, non consurgat maior obligatio restituendi, quàm id iustum rei pretium. Illud tamen est obseruandum, si rei domino non restituatur statim valor rei destructæ, aut, esto ei statim restituatur, si non inueniat emptionem rei, vnde æquales fructus, & emolumenta, possit percipere; tunc, qui damnum ei dedit, tenetur illi vlteriùs ad id interesse lucri cessantis, quantum prudentis arbitrio id lucrum cessans æstimabitur, attentis circumstantiis omnibus concurrentibus.

Tertium est. *Optimè diuum Thom. 2. 2. q. 62. art. [sect. 4] 4.* ad primum affirmasse, eum, qui semina, satàve, destruit, non teneri restituere, quantum dominus sperabat inde percipere, sed quantum æstimabantur in statu, in quo destructa fuerunt. Quo enim remotiora erant à fructu inde percipiendo, & quo pluribus subiacebant periculis, maioribusque adhuc sumptibus ac laboribus indigebant, eo minus valebant, minorique pretio venderentur, si dominus velet ea tradere: neque plus, qui illa destruxit, restituere tenetur, quàm æstimarentur ac valerent, quando destructa fuerunt. Idem dicendum est de pullo equino, qui nunc valet triginta, &

speratur post duos annos valiturus centum: si enim quis illum iniustè interficiat, quando solùm valet triginta, non tenetur restituere nisi solùm triginta.

Objicit Sotus. 4. de iust. q. 6. art. 5. quòd mi⁷⁸ser agricola rationabiliter vellet potiùs expectare euentum fortunæ circa sua sata, aut circa suum pullum, ac lucri, quod se lucraturum sperabat, quàm vendere illa pretio, quod secundùm statum præsentem valebant: ergo plus illi est restituendum, quàm ea valeant, quando destruuntur: præsertim cùm aliquis, propter maximam affectionem, quam circa aliquam rem suam habeat, possit carius illam vendere, augendo in pretio, quantum æstimabitur, se ipsum priuare re, quam adeò diligit, vt Disput. 351 est dictum.

Adde, si destruantur sata totius alicuius po⁷⁹puli, vnde sequatur, illos postea premi egestate, multo plus esse illis restituendum propter graue id detrimentum, quod inde eis sequitur, quàm esset valor eorundem satorum quoad statum, in quo destructa sunt.

Propter hæc argumenta ait Sotus, quamuis doctrina diui Thom. vera sit, quando casu damnum infertur: secùs tamen rem habere, quando de industria per iniuriam, renuente domino, destruuntur. Secum autem videtur Sotus pugnare in hac doctrina. Vel enim, quando cum diuo Thoma consentit, si damnum casu detur, intelligit interueniente culpa theologica, quæ ad culpam sufficeret lethalem, si quantitas damni esset magna, atque tunc sanè ad totam damni æstimationem tenebitur, ac si de industria illud dedisset. Vel intelligit, non interueniente culpa theologica, quæ sufficiat in materia graui ad culpam lethalem, sed vel nulla interueniente culpa theologica, sed solùm iuridica, vel interueniente culpa theologica veniali. *Atque tunc ex sententia Soti. 4. de iust. q. 7. art. 2.* ad nullam, vel ad modicam, restitutionem tenetur damni dati, etiam spectati quoad valorem rei in statu, in quo fuit destructa. Dicendum verò est, doctrinam diui Thomæ absolutè atque vniuersim esse veram. Quòd autem dominus rei destructæ, meritò ægre ferat commutationem illam pretii iusti pro re sua destructa, attinere solùm ad iniuriam illi illatam, quæ, iuxta ea quæ Disput. 715 explanata comprobataque sunt, non est restituenda per iustitiam commutatiuam, sed punienda est per iustitiam vindicatiuam, eo plus, quo maior fuerit culpa in damnum dante: quo fit, vt, ante latam sententiam, nulla restituendi obligatio consurgat ex illo capite. Eademque ratione neque obligatio restituendi ex eo capite consurgit, quòd rei destructæ dominus esset multum affectus ad eam rem suam, nolletque illam vendere, aut aliter alienare. Quamuis etiam vendere posset rem suam, ad quam ita multum esset affectus, maiori pretio, si esset, qui, simul cum re, emere ab eo vellet, quantum æstimaretur, ipsum à se alienare rem, quam tantopere diligit; nihilominus, quando non est, qui id emere velit, pretiùmve pro eo dare, sanè, quòd priuatur ea re iniustè, solùm facit ad iniuriæ incrementum, non verò vt per iustitiam commutatiuam debeat ea res maiori pretio compensari, quàm si ad illam non esset tanta affectio. Confirmari autem id potest, quoniam quando cogeretur pretio iusto eam vendere, quia bonum publicum postulare, vt de potestate illius eriperetur, sanè necesse non esset, solui ei incrementum aliquod pro molestia, quam pateretur ex eo, quòd ea re priuaretur: quoniam id pretio non est dignum, nisi comparatione eius, qui id ab eo emere vellet. Illud tamen est concedendum, ac affirmandum, quando ex damno dato sequeretur populo, aut priuato alicui, cui id damnum esset datum, aliud alterius damnum, vt si ex magna satorum destructione cogeretur postea emere triticum maiori pretio, quàm alioquin fuisset emendum; tunc, qui primum damnum iniustè dedisset, teneretur restituere hoc aliud damnum ex illo vlteriùs sequutum, tanquam causa iniusta huius etiam alterius damni, vt suprà dictum est.

Ad primum ergo argumentum Soti, con⁸⁰cesso antecedente, neganda est consequentia: quoniam ea omnia faciunt quidem ad iniuriæ incrementū, & vt delinquens maiori pæna sit dignus: non verò ad damni augmentum, & vt in conscientia foro consurgat restituendi obligatio per iustitiam commutatiuam ante latam sententiam.

Ad secundum dicendum est, illa quoque facere ad⁸¹ iniuriæ incrementum, & vt delinquens maiori [[228]] pæna sit dignus: non verò, vt consurgat restituendi obligatio, nisi quando ex damno ita dato sequeretur, eos maiori pretio asportaturos, aut empturos, triticum ob illius penuriam, quàm alioquin fuisset valiturum: tunc enim, quia id etiam esset damnum iniuste datum, atque ex priori damno sequutum, id quoque esset restituendum, vt dictum est.

Quartum est, *quod diuus Thom. 2. 2. q. 62. art. [sect. 5] 4.* ad secundum docet. Nempe debitorem, qui in mora est soluendi creditori, quod ei debet, teneriei restituere lucrum illi cessans, aut damnum illi emergens, ob eam dilationem solutionis, quatenus detinendo iniuste solutionem debiti vltra terminum solutioni præfixum, causa illi est iniusta talis lucri cessantis, aut damni emergentis. Obseruat verò diuus Thom. lucrum cessans non esse æstimandum, vt mercatori soluatur, quantum ipse lucrari ea pecunia sperabat, sed quantum prudentis arbitrio valebat illa spes. Sicut enim sata non valent, quantum ex eis colligi sperabatur, ita neque lucri spes valet, quantum lucri speratur, vt Disp. 316 copiosè est explicatum, vbi simul est dictum, quonam modo æstimari debeat. *Hinc Ledesmius. 2. 4. q. 18. art. 4. infert*, nobiles, qui mercatorum pecunias longo tempore iniuste detinent, restituere eis teneri lucrum ea de causa illis cessans, neque aliter esse absoluendos. Obseruat tamen, quando pecunia debetur mercatoribus ex mercibus emptis, vt regulariter deberi eis à nobilibus, & ab aliis, solet ex mercibus, quæ nullos pariunt fructus, ipsis credito venditis, tunc illos neque in exteriori neque in conscientia foro debere eiusmodi mercatoribus lucrum extrinsecum eis cessans ex ea pecunia iniuste detēta, quale est, quod negociando illa pecunia lucrari poterant, idque ex peculiari dispositione iuris ciuilis circa contractum emptionis & venditionis, contrà atque res haberet stando in solo iure naturali, vt Disp. 724 & 368 comprobatur. Quare hunc euentum excipias ex doctrina diui Thom. Esto autem non esset sufficientissimum hoc caput, vnde nobiles excusarentur à restitutione ratione lucri mercatoribus cessantis ex pecunia ob merces credito emptas, non solutam in termino constituto, aut tempore congruo, quando nullus præfixus fuit terminus; ex multis tamen aliis capitibus frequenter potest excusari. In primis, quoniam sæpe præsumendum esset, nullum lucrum illis cessasse: quia alia sua pecunia, aut pecunia mutuo aliunde accepta, negotiati sunt. Deinde, quoniam mercatores credito vendentes nobilibus solent eis vendere multo carius, quàm pecunia statim numerata, intelliguntque non in termino præfixo esse statim soluturos pretium. Multoque plus lucentur vendendo illis in magna quantitate, quàm si eis non venderent. Quare in confessionibus, qui credito ex mercatoribus emerunt, cogendi non sunt restituere lucrum mercatoribus ex eo cessans, quòd pretium eis non soluerint, vel in termino constituto, vel tempore congruo. Licet autem vrgendi in confessionibus sint, vt non differant solutiones huiusmodi pecuniæ cum mercatorum damno; non tamen sunt facile damnandi culpæ lethalis, quando dilatio non esset multum notabilis ac exorbitans, propter ea, quæ proximè dicta sunt. Idem Ledesmius subiungit: Si debitor omnino non potuit soluere debitum in termino præfixo, restituere non teneri lucrum cessans, quoniam non peccauit, non soluendo, excusante illum impotentia: quando autem damnum absque vlla culpa est datum, non consurgit obligatio illud restituendi: quia neque ex parte rei acceptæ, neque ex parte iniustæ acceptionis. Addit tamen, si potuit aliquo modo soluere, vendendo domum, aut alia

sua bona, etiam cum maiori iactura sua propria, quā sit lucrum creditori cessans, teneri ad restitutionem talis lucri cessantis, si debitum tempore, quo tenebatur, non soluat: quoniam non potest iustè velle, se seruare indemnem cum iactura alterius: eaque de causa, si in eo euentu se vult seruare indemnem, id esse debet cum onere ac proposito restituendi alteri lucrum, quod ex tali dilatione solutionis illi cessauit. Hæc verò lima indigent. In primis paulo antea dictū est, si debitum erat pretium rei emptæ minimè fructifera, nullam consurgere obligationem restituendi, etiamsi iniustitiæ peccatum interuenerit in dilatione solutionis pretii, nedum quando nullum interuenit peccatum, excusante impotentia à culpa omnino. Deinde verò, quando debitum est ex mutuo, aut ex quocunque alio contractu, vel titulo, qui emptio non sit ac venditio, vtique, qui in termino præfixo non soluit, tenetur in conscientia & in exteriori foro, creditori ad totum lucrum cessans, aut damnum illi emergens, esto is debitor absque vlla sua culpa nō soluerit: non quidem ex parte rei acceptæ, neque ex parte iniustæ acceptionis, sed ex contractu, pactōve tacito, quo eo ipso, quod quis se astringit, soluere aliquid in aliquo termino, si id non impleat, quacunque ratione eueniat, quod id non impleuerit, tenetur creditori ad totum lucrum ea de causa illi cessans, & ad damnum ei emergens, vt cum D. Thom. & cum communi doctorum sententia, Disp. 299 & 315 ostensum à nobis est.

Num, qui impedit aliquem ab assequutione boni alicuius, teneatur id illi restituere. Disp. 727.

SVMMARIVM.

1. *IVs quot modis dicatur quis habere ad aliquid.*
2. *Restituere non tenetur, qui absque vi ac fraude impedit alium ab assequutione eius boni, quod ei non debebatur, suadendo ei, à cuius voluntate conferre illud pendebat, vt illud ei non conferret, & aliquando meritoriè potest id ita impediri.*
3. *Religiosis quousque prohibitum suadere, ne legata fiant ecclesiis matricibus, suadendo vt ipsis potiùs aut suis fiant.*
4. *Restituere in eodem euentu non tenetur, etiam si ex odio & praua intentione contra solam caritatem id efficeret. Si tamen iniustè id impediret, non solùm id, sed simul etiam totum aliud damnum datum tenetur restituere.*
5. *Si quis vtendo iure suo noceat alteri, quamuis stando in solo iure naturali ad nihil ei teneatur, esto sinistra intentione, animo illi nocendi, [[229]] id efficiat, quousque tamen iure humano actio de dolo aduersus eum competat, vt desistat, & vt rem ad pristinum reducat statum.*
6. *Restituere tenetur, qui impediuit ne aliquis consequeretur, quod sibi erat debitum ex iustitia, quantum id damnum æstimabitur, attento iure, quod solus impeditus aut simul cum aliis habebat, & atteta certitudine, aut probabilitate, quod id alioquin consequuturus fuisset.*

7 Restituere tenetur, qui contraueniendo iuri, quod alius habet, vt recipiat, quod alii liberaliter dare ei voluerint, vel vt aliquid ipse faciat, illum impedit ab aliquo bono assequendo; solum tamen quantum id bonum, prout adhuc erat in illo statu, æstimabitur.

Circa damnum iniuste datum est consequenter examinandum, num, qui aliquem impedit à boni alicuius assequutione, quod licetè consequi poterat, teneatur id illi restituere, tanquam qui damnum ea in parte illi dedit. Exempla sunt: Decreuerat aliquis donare Petro aliquid, vel eum hæredem instituerat, aut legatum illi relinquebat in suo testamento, quæ tamen licetè reuocare poterat, vt in materia de donationibus, & de vltimis voluntatibus, est dictum: Ioannes dissuadendo illi, qui id Petro relinquebat, aut donare volebat, vel ab eo precibus petendo, vt potius id sibi, aut alteri, donaret, vel relinqueret, in causa fuit, vt mutaret propositum, & vt Petro id non daret, aut non relinqueret: quæritur, num Ioannes restituere Petro id damnum teneatur.

Pars affirmans suaderi potest ex illo *Aristote*⁸² *lis. 2. physi. c. 5. tex. 56. Quod parum distat, nihil distare videtur.* Quo Aristot. confirmat, eum dici posse infortunatum, cui parum defuit, vt magnum aliquod bonum consequeretur, quod non est consequutus; quoniam intellectus concipit id bonum, ac si iam adfuisset, illudque amisisset is, cui tam parum defuit, vt id consequeretur: ergo perinde est, impedire aliquem à consequutione boni, quod distabat parum, vt illud consequeretur, atque illud ab eo eripere, postquam esset iam illud consequutus: sed, qui eriperet bonum ab aliquo, qui illud esset iam consequutus, teneretur illud ei restituere: ergo tenetur etiam, qui impedit, ne illud assequatur.

Vt res hæc melius intelligatur, obseruandum [sect. 1] est, vt Disputatione 1 huius secundi tractatus explanatum est, duobus modis dici aliquem habere ius ad aliquid. Vno, quia est ei aliquo modo debitum, aut suum. Ius, hoc modo sumptum, Disp. 2. diuisimus in ius in re, & in ius ad rē. Altero modo dicitur aliquis habere ius ad aliquid, non quòd sit ei aliquid debitum, sed quòd facultatem habeat ad aliquid, cui si contraueniatur, fit ei iniuria. Hoc modo dicimus, vnumquenque habere ius vtendi suis rebus propriis, vt cōdendi suum proprium cibum, ita vt, si impediatur, iniuria ac iniustitia ei fiat. Dicimus etiam, pauperem habere ius petendi eleemosynam, mercenarium habere ius locandi operas suas, vnumquemque habere ius venandi & piscandi in locis non prohibitis, ita vt, si horum aliquis in istorum aliquo impediatur, iniuria ac iniustitia ei fiat, cum restituendi onere, quantum æstimabitur impediri ea via aliquid consequi, esto nullus ei debeat, quod eo modo est impeditus consequi. Eodem modo dicimus, vnumquēque habere ius accipiendi, quod quiuis voluerit ei donare, legare, aut quouis alio titulo tribuere, ita vt, si quis obstaculum ponat facultati passiuæ, quam is habet, per vim, aut fraudem, eum impediendo, ne id assequatur, vel per vim, aut fraudem, eum impediendo, qui id illi tribuere vult, ne illud ei tribuat, iniuriam iniustitiamque illi faciat, cum restituendi onere, quatenus iuri contrauenit iniuste, quod ille habebat accipiendi, quod gratuito titulo quiuis alius ei tribuere vellet.

Hoc ita constituto, sequentibus conclusioni [sect. 2] bus est dirimendum, quod in titulo fuit propositum. Prima conclusio est: Quando bonum, à⁸³ cuius assecutione aliquis impeditur, non erat ei debitum ex iustitia, ita quòd, salua iustitia, integrum erat ei, qui illud conferre volebat, id nō conferre, vt cernitur in legatis, in institutione hæredis, in donatione antequam acceptetur, imò interdum in collatione beneficii, & in aliis similibus, restituere non tenetur, qui absque vi & fraude persuadendo, in contrariumque mouendo collatorem, impedit aliquem ab assequutione alicuius boni. Imò verò sæpe licetè ac meritorie id fit. In hac

conclusionem conueniunt doctores communiter, Adri. de rest. q. consequenter quæro utrū impediens, &c. *Sotus 4. de iust. q. 6. art. 3. ad 4. Couar. reg. peccatum part. 2. §. 7. n. 8. Syluest. verb. rest. 3. n. 12. Palud. in 4. dist. 15. q. 2. art. 2. conclu. 4. Scot. eadem dist. & q. in resp. ad vlt. Richard. ibidem art. 5. q. 4. ad 7. Caiet. 2. 2. q. 62. art. 2. ad 4. Nauar. in Manu. c. 17. à. n. 69. & alii.* Probari verò quoad priorē partem potest. Quoniam, qui ita mouet ac persuadet collatorem, non peccat contra iustitiam, sicut neque collator ipse mutando suam voluntatem contra iustitiam peccat: ergo ad nullam restitutionem ei tenetur, cui ea via collatum non fuit bonum, quod alioquin foret illi conferendum. Neque enim, qui ita collatorem mouet ac persuadet, aliud facit, quam, absque vlla vi & fraude, collatorem ad id coadiuuare, quod collator ipse absque vlla iniustitia potest efficere: in quo planè nulla cernitur iniuria, aut iniustitia, ex parte eius, qui ita ad id coadiuuat. Posterior verò pars, quòd scilicet sæpe id licite ac meritoriè fiat, probatur. Quoniam sæpe esse poterit melius, quod ita suadetur; vt quod aliquid detur potius pauperibus, aut insumatur in aliud opus melius ac Deo gratius, quā sit illud, quod collator facere intendebat: ergo ea persuasio, qua aliquis ab assequutione boni alicuius impeditur, esse poterit sæpe licita ac meritoria: cū non aliud sit, quā cooperatio ac incitatio ad maius bonum, sine cuiusquam iniuria. Præterea, cū caritatis ordo efflagitet, vt sibi potius velit aliquis bonum aliquod, quā aliis, & vt, cæteris paribus, illud potius velit sibi coniunctis, quā extraneis, sanè, quòd aliquis persuadeat alicui, vt sibi potius relinquat hæreditatem, aut legatum, vel donet aliquid, quā extraneis, quibus id conferre constituerat, aut vt potius id relinquat sibi coniunctis, vel coniunctis collatori, quā aliis, quando cætera sunt paria, nihil mali facit, quin potius exercet actum caritatis ordinatum. Illud hoc loco est obseruandum. In clemen [sect. 3] tina. 1. de priuil. inter alia, sub interminatione maledictionis æternæ, atque in virtute sanctæ obediētæ, prohiberi religiosis, ne, dum intersunt testamentis confi ciendis, retrahant testatores à [[230]] legatis faciendis matricibus Ecclesiis, illis suadendo, vt ipsis potius, aut aliquibus de suo ordine, vel suis monasteriis illa relinquunt. Si tamen absque fraude, nihilque contra iustitiam cōmittendo (iuxta ea quæ duabus conclusionibus sequentibus subjicienda sunt) illos ita retraherent, peccarent quidem lethaliter, non tamen tenerentur illa restituere, antequam eiusmodi bona ab eis peterentur, quibus ea in parte præiudicium intulerunt: quoniam, quoad eiusmodi restitutionē, lex est pænalis, quæ non obligat, antequam ea bona petantur, ac feratur sententia. Quando autem aliquis ex odio eius, cui collator aliquid conferre volebat, animoque ei nocendi, persuasit collatori, ne illud ei conferret, *affirmāt Scotus, Richar. & Palud. locis citatis, quin & D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 2. ad. 4.* eiusmodi persuasorē restituere teneri id damnum alteri datum. Peculiariter tamē loquuntur, quando eo modo quis impedimento alteri fuit, ne beneficium assequeretur.

Potest verò id confirmari ex. l. 1. §. iidē aiunt. 2.⁸⁴ ff. de. aqua pluuiæ. arcēd. vbi habetur, si quis fodiat puteum in suo proprio agro, præcidatque venas aquæ, quibus in puteum, aut in fontē, alterius fundi aqua deriuabatur, idque in causa sit, ne deriuetur, non dari actionem aduersus ita præscindentē venas in prædio suo, quando id non fecit, vt noceret alteri. Ratio autem est, quoniam vsus est iure suo, occupando ita aquam, quam in suo fundo inuenit, quæque sua erat, dum ita intra venas sui fundi erat, nihil impediens, quòd inde deriuaretur in fundū vicini, & quòd ex ea venarum præcisione sequatur fundum vicini priuari ea aqua. Dum autem textus ille dicit, quando id non fecit, vt noceret alteri, apertè argumento à contrario sensu, docet, dari actionem aduersus illum, si id ex odio, peruersæ intentione, fecit animo alteri nocendi: idq; affirmat communis doctorum sententia, & in eo, atq; in

aliis similibus euentibus, probant multa alia iura, quæ Disp. 704 & 709. §. quamuis stando, citauimus: pari ergo ratione, qui ex odio, animoq; nocendi, persuadet collatori, ne aliquid alicui tribuat, quod ex iustitia tribuere illi non tenebatur, eaq; ratione impedimento illi est, ne id assequatur, tenebitur in conscientia & in exteriori foro illud ei restituere.

Contraria verò sententia est communis, Adria [sect. 4] ni ac cæterorum doctorum, quos suprà citauimus, consentitq; cum eis Caiet. in resp. ad. 4. citata, in fine totius cõmenti, quando aliquis ex odio impedit legata, donationes, & similia alia, quæ collator ex mera sua liberalitate confert, non verò quando impedit assequutionē beneficii. Adrianus verò, & reliqui, hanc generalem regulam statuunt. Quando aliquis, neque contra iustitiam peccaret, neque ad restitutionē teneretur, impediendo collationē cuiuscunq; boni, nullo interueniente odio, animoque nocendi, neque etiam peccare contra iustitiam, neque teneri ad restitutionē, esto illud similiter impediat, cæterum ex odio, animoque nocendi. Atque mihi hæc regula probatur. Quoniam odium, animusque nocendi, in iis rebus, in quibus potest quis alioquin nocere absque iniustitia, non est peccatum contra iustitiam, sed contra caritatē: vt si iudex malefactorē, qui morte est dignus, simul ex odio illius, iubeat interfici ob delictum, quod commisit, non peccat contra iustitiam, sed solū contra caritatē: quare, cū peccatum contra solam caritatē commissum non inducat restituendi obligationē; consequēs profectō est, vt, qui ex odio impedit collationem beneficii, aut cuiusuis alterius rei, in euentu, in quo, secluso odio, nec peccaret cōtra iustitiam, nec ad restitutionē teneretur, etiamsi odium, nocendique animus, in illo eodem euentu interueniat, neque contra iustitiam peccet, neque ad restitutionē teneatur. Hoc tamen loco obserua, quando aliquis peccato contra iustitiam aduersus aliquem esset vlteriùs causa, quòd collator illi non conferret, quod alioquin illi erat collaturus, sanè teneretur ei restituere æstimationē damni vlteriùs illi subsequuti ex impeditone ea via illius boni. Vt, si crimen alicuius erat occultum, quod eum indignum non efficiebat aliqua re, quodq; nefas esset detegere ad impediendum eū ab assequutione eius rei, tunc, qui iniustè crimen illud detegeret, eaque ratione in causa esset, vt collator, notitia eius criminis permotus, eam rem illi non conferret, quam alioquin fuisset illi collaturus, sanè, qui id crimen detexisset, non solū restituere teneretur ei, quem ita iniustè infamauit, famam contra iustitiam ab eo ablatam, sed etiā illud aliud damnum inde vlteriùs ei subsequutū.

Ad legem primam citatam respondet Caiet, vbi⁸⁵ suprà, eam habere locum, quando id, quod odio aufertur, erat iam eius, ex quo aufertur, vt aqua emanans in puteo, aut fonte, prædii vicini, erat vicini, quamuis transiret per venas prædii eius, qui eam aufert. Vt enim iniuriam non faciat ei, ex quo aufertur, necesse est, vt auferens in suam propriā vtilitatem eam auferat, non solo animo alteri nocendi: nam tunc iniuriam illi inferret, tenereturq; ei ad restitutionē eius damni dati. Quando verò, inquit Caiet. quod impeditur, non erat alterius, neque illi ex iustitia aliquo modo debitum, nulla fit ei iniuria, esto ex odio illud consequi impediatur.

Dicendum tamen est, vt duabus disputationibus citatis dicebamus, stando in solo iure naturali, eū, qui, præscindendo venam aquæ in suo fundo, impedit, ne emanet in fundo alterius, nullam iniuriā illi efficere, nec teneri illi ad restitutionē, esto ex odio, animoque illi nocendi, id efficiat. Ratio autem est, quoniam non accipit, quod est alterius; eo quòd non accipiat partem aquæ quæ iam ad fundū alterius deuenerat; sed accipit, quod est suum, dū intra venas sui prædii est, nec dumque effectū est alterius, sed futurum erat alterius, si ad prædiū ipsius deueniret, nec deuenire iustè impediretur, præoccupante illam domino alterius prioris prædii, cuius erat iam effecta. Quia ergo is, qui venā in suo fundo præscindit, vtitur iure suo, accipitq;, quod pro tunc est suum, consequens est, vt, stando in solo iure

naturali, non faciat alteri iniuriam, esto ex odio, animoque illi nocendi, priuandive illum eo commodo, id efficiat.

Nauar. in Manu. c. 17. n. 71. aperte innuit, neque in foro exteriori, cogendum esse eum, qui ex odio, animoque; nocendi, id efficit, ab eo efficiendo desistere, aut damnum vicino resarcire. Ad. l. verò 1. citatam respōdet. Quamuis argumentum à cōtrario sensu validum sit, quando non constat contrarium esse dispositum in iure; quando tamen constat contrarium esse in iure dispositum, non esse efficax, nullamve habere vim: at verò, inquit, ex iure naturali constat, vt ex se liquet, communisque doctorum sententia affirmat, eum, qui ex odio id facit, quod, secluso eo odio, iniustum non est, **[[231]]** nullam committere iniustitiam, nullamque facere iniuriam, ac proinde neque ad restitutionē teneri.

Dicendum verò arbitror, cum communi do [sect. 5] ctorum sententia, quam duabus disputationibus citatis iuxta varia iura retulimus, iure ciuili meritò fuisse dispositum, vt quando quis absque vllo suo emolumento, animo solū alteri nocendi, (qui tamen animus non præsūmitur, nisi probetur) venas eo modo præscinderet, vel altius tolleret domum suam, aut aliud simile efficeret, concedi aduersus illum actionem de dolo ad id impediendum, antequam sit opere impletum, & ad demoliendū, ac reducendum ad pristinum statum, quod eo animo fuerit effectū. Cæterū ad id nulla in foro conscientiae est obligatio, nisi postquam in foro exteriori fuerit petitu, & quasi in pænam peruersæ intentionis iudicatū: neque id esse plus extendendū, quàm iure humano comperiatur dispositum: eo quòd contrarium habeat rei natura, stando in solo iure naturali. Vnde in legato, quod alteri esset relictum, voluntate eius, qui de suo disponere potuit, vt voluit, etiamsi cuiusdā tertii suasionibus esset relictum vni, & detractum alteri, procedentibus huiusmodi suasionibus ex odio eius, cui est detractum, sine vlla tamen vi aut fraude, credo in exteriori foro non concederetur actio aduersus id ita impediētem.

Secunda conclusio. Qui voluntarie fuit alicui⁸⁶ impedimento, ne consequeretur, quod sibi ex iustitia erat debitum, restituere ei tenetur id dam [sect. 6] nū, quantum æstimabitur, attento iure, quod, qui impeditus fuit, ad id habeat, & attenta certitudine, aut probabilitate, maiori vel minori, quæ erat, quòd id consequeretur, si non fuisset illo modo impeditus. Conclusio hæc communis est. Probari autem potest, quoniam, qui eo modo impediuit, mouendo collatorē, ne id conferret, aut quauis alia ratione, sanè contra iustitiam peccauit, causaq; iniusta fuit dāni subsequuti: ergo restituere illud tenetur. Dixi, damnum esse æstimandū. attento iure, quod, qui impeditus fuit, ad id habebat, quod assequi fuit impeditus: quoniam, si tres erant oppositi ad cathedram, aut præbendam, finitumq; erat tempus edicti, ita quòd non posset alius opponi, illique proinde soli habebant ius ad eam cathedram, aut præbendam, collataque sit cuidā quarto suasionibus alicuius, tenetur vnicuique illorum trium, non ad integram æstimationē cathedrę, aut præbendę, sed pro quantitate iuris, quod simul cum aliis habebat. Addidi, & attenta certitudine aut probabilitate, maiori vel minori, quæ erat, quod id consequeretur, si illo iniusto modo nō fuisset impeditus: quoniam si certum non erat omnino, quod id fuisset consequuturus, tunc, qui iniustè impediuit, non est cogendus restituere totā rei illius æstimationē, sed partem dumtaxat, quantum scilicet æstimabitur, vt est præcisè sub illa sola probabilitate. Si autem postea debitor principalis, qui eam iniustitiam cōmisit, damnum restituat, liberabitur à restituendi onere, qui suis suasionibus, ac prauo consilio, concausa fuit eius damni: aut, si iam, in illius alterius defectum, restituerat, restituere ipsi tenetur principalis causa eius iniustitiæ, quod loco illius restituit.

Tertia conclusio. Qui aliquem impedit ab asse⁸⁷quutione boni alicuius, quod ex sola liberalitate erat ei cōferendū, si eum per iniuriam impediat, hoc [sect. 7] est, contraueniendo iuri, præiudicādoq; facultati illius passiuæ, quam habet ad recipiendū à quocūq;, quod sibi titulo gratuito conferre voluerit, restituere illi tenetur, quantum æstimabitur id bonum dū in eo statu erat, in quo fuit impeditum, dum scilicet depēdēs erat adhuc à mutabili collatoris volūtate, & ab euētib; qui superuenire poterāt: res quippe in spe minus vt plurimum valet, quam si iam ad effectum esset omnino perducta. Cōclusionē hanc affirmant Sotus & Nauar. vbi suprā, tametsi non adeò explicatā. Probari autem potest, quoniam, vt constat ex iis, quę ante primam conclusionē sunt dicta, qui eo modo præiudicat iuri, ac facultati passiuæ, quam vnusquisque habet ad recipiendum à quocūq;, quod gratuito titulo voluerit ei cōferre, vtique iniuriam ei facit, & contra iustitiam aduersus eū peccat, vt in eo liquet, qui pauperē eleemosynā petere prohibet, aut qui prohibet aliquem piscari aut venari, loco & tempore omnibus cōcesso: ergo restituere ei tenetur, quantum æstimabitur damnum ita iniustè datū. Qui autem mēdacis, fraudibus, vel metu, aut vi, collatorē auertit, ne bonū aliquod alicui conferat, sanè contrauenit iuri, ac facultati passiuę, quam is habet, cui tale bonum gratuito erat conferendū. Simili modo, si metu, vi, aut fraudibus, impediat eum, cui bonum erat conferendū, ne accedat ad illud petendum, vel ad se opponēdū, vel ne aliquid aliud efficiat ipse, aut alius tertius, quod adiuuare debebat, vt illud cōsequeretur, eaque de causa illud non obtineat, sanè contrauenit iuri huius, iniuriāq; ei facit, ipsum ita impediendo ab assequutione eius boni, ac proinde restituere ei tenetur æstimationē dāni ita iniustè ei dati. Ex hac conclusione facilè constat, falsam esse regulā illam Gerardi Oldonis, quem Adrianus vbi supra refert. Nempe, quādocunq; aliquis impeditur ab assequutione eius, quod illi ex iustitia non erat aliquo modo debitum, impediētē ad nullam teneri restitutionē. Hoc loco texenda fuisset lōga disputatio de eo, qui alium impedit, ab assequutione beneficii Ecclesiastici, cathedræ, aut alterius muneris publici, tam quando erat oppositus, quàm quando oppositus non erat, nisi commodiūs res hæc tractatu 6 esset disputanda.

Ad argumentum autem initio huius disputationis⁸⁸ positū ex propositione illa Aristotelis, dicendū in primis est, eam propositionē esse topicam, neque quoad effectum omnem esse vniuersim verā: neque enim is, cui parum defuit, vt in iustitiam cōmitteret, aut vt peccaret, perinde est reputādus, ac si iniustitiā cōmisisset, aut ac si peccasset. Neque in re, in qua illa est vsus Aristoteles, æquē est is infortunatus, qui non est consequutus bonum, quod parū defuit vt consequeretur, ac infortunatus esset, si postquam illud esset assequutus, illud amitteret, nihil impediēte, quò intellectus apprehendat id bonum, quod parum defuit, vt adesset, quasi iam aliquo modo adesset. Neque in re, in qua D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 2. ad. 4. eadem propositione est vsus, (nēpe, quòd quando aliquid ex iustitia erat debitū, & parum defuit, vt conferretur, perinde est ac si iam fuisset collatum, ad effectum, vt impediēs teneatur ad integram illius restitutionē) propositio illa est vera omnino, si periculum aliquod erat, eam assequutionē impediri: ea quippe res, pro quātitate periculi, quod erat, vt impediretur, minus valet vt est sub eo periculo, ac proinde minor impediēti iniungenda est restituendi obligatio. Quicquid autem sit, quando res debita erat ex iustitia; quando tamen nullo modo erat debita, sed solum cōferēda erat ex liberalitate, negādū est perinde esse, [[232]] quod ad restituendi onus attinet, impedire aliquem, collatorem persuadendo, ne conferat, atque illud idem ab eo auferre postquam est collatum: res enim per collationem facta est iam illius, ac proinde auferēdo illam tunc ab eo, committitur furtum, fitq; ei iniuria: ante collationem verò, inclinando collatorem absque vi, ac fraude, in contrarium, nulla fit ei iniuria, ac proinde

nulla consurgit obligatio quicquam ei restituendi. Ad argumentum ergo in forma, neganda est prima consequentia, si consequens intelligatur, quoad restituendi obligationem.

De restitutione damnorum in bonis externis, quæ ex adulterio sequuntur, vbi disputandum. Et num dans operam rei illicitæ restituere teneatur damna, quæ absque alia sua culpa sequuntur. Disp. 728.

SVMMARIVM.

1. *D*amnum quando est periculum ne ex vno crimine vltteriùs alteri sequatur, tunc qui committit id crimen, peccat simul exponendo se ea via periculo dandi id aliud damnum; & quousque ea circumstantia exprimenda sit in cōfessionibus. Si autem id damnum sequatur, obligatio est illud restituendi. Et vbi disputandum de damno ex eo sequuto, quòd adultera concipiat.
2. *D*amnum sequutum dando operam rei illicitæ, ex qua natum non erat sequi, neque in conscientiæ neq; in exteriori foro obligatio est illud restituere.
3. *Q*uando res illicita est apta, vt inde id damnum sequatur, facile cùm minimum interuenit lata culpa, vt ob eam, saltem in pœnam, in exteriori foro obligatio iniungi possit illud restituendi.

Quædam sunt damna in bonis aliorum exter [sect. 1] nis, quæ nata sunt sequi ex culpa præcedēte, tanquam effectus illius: atque tunc, committere priorem culpam, attēdendo, aut attendere debendo, nata esse inde sequi talia damna, est committere nouam culpam illo eodem actu contra iustitiam commutatiuam, se ita exponendo periculo inferendi ea damna proximis, siue illa re ipsa sequantur, siue non sequantur, vt prima 2. suo in loco explicauimus. Vt, qui se inebriat, si experientia didicit, se, dum ebrietate est captus, solere inferre damna proximis, vel in rebus externis, vel in corpore, interficiendo, aut percutiendo, vtique, quando se inebriat, non solùm committit peccatum lethale intemperantiæ, se illo modo priuando vsu rationis, sed etiam iniustitiæ aduersus proximos, vel contra quintum vel contra septimum decalogi præceptum, prout fuerint damna, quæ experientia didicit ex sua ebrietate esse nata sequi, & ad quæ inferenda se exponit ita se inebriando: neque minorem culpā committit, se tunc inebriando, quando illa non sequuntur, quàm quando sequuntur, vt 1. 2. ostendimus. Tenetur verò ad integram restitutionem eorum damnorum, quando sequuntur, ex parte iniustæ acceptionis, damniue iniustè illati; eo quòd iniustè illa dederit, se contra iustitiam exponendo periculo illa dandi, quando se inebriauit. Eodem modo, quia ex adulterio nata est sequi conceptio prolis illegitimæ; atque inde vltteriùs natum est sequi damnum in bonis externis aliorum, dum proles ita concepta expensis mariti adulteræ educatur, & in bonis tam mariti, quàm adulteræ, succedit, priuatque legitimam prolem eorum coniugatorum, aut alios legitimos illorum hæredes, bonis, quæ obtinere debebant, sanè quæ coniugata adulterium committit, & qui cum illa id crimen committit, non solùm contra iustitiam peccat aduersus maritum, contra sextum decalogi præceptum, sed etiam

simul peccat contra septimum, dum illo eodem actu se exponit periculo damnorum contra iustitiam in bonis externis aduersus maritum, legitimam prolem, aut alios hæredes mariti. Non tamen necesse est, eam circumstantiam, speciem mutantem, ac valde aggrauantem, exprimere in particulari in confessionibus, dum expressio fit sufficienter peccati adulterii: quoniam cùm per se sit cõiuncta cum peccato adulterii, dum adulterii peccatum exprimitur, illa concomitanter censetur sufficienter expressa. Quando quis operam dat rei illicitæ, ex qua, attentis circumstantiis concurrentibus, natum est sequi proximo damnum in rebus externis, in corpore, vel in honore, aut fama, tunc, si dando ita operam rei illicitæ sequatur re ipsa vltèrius id damnum, dubitandum non est, qui eo modo operam rei illicitæ alteri dedit, teneri in conscientiæ & in exteriori foro, ex parte iniustæ acceptionis, damniue eo ipso iniustè dati, restituere id totum damnum vltèrius subsequutum. Quin si interuenit culpa iuridica, & non theologica, comparatione talis damni, Disput. 697 & 698 explicauimus, quousque in foro exteriori, qui illud ita dedit, cogatur id resarcire, & num in conscientiæ foro ante latam sententiã resarcire illud teneatur: neque de hac re hoc loco disputamus. Quia tamen peculiaris est difficultas, neque infrequens in confessionibus, quando proles ex adulterio est iam nata, quousque adultera & adulter teneantur impedire damna in bonis temporalibus, quæ inde marito, legitimæ proli, aut aliis, sequuntur, & quousque illa restituere teneantur, quando fuerint sequuta, & quomodo, id sanè hoc loco foret explicandum, in quo nobis est sermo de damno in rebus externis proximis iniustè dato, nisi id potiùs reseruandum censeremus in sequentem tertium de iustitia tractatũ: in quo nobis futurus est sermo de adulterio, quatenus peccatum est contra iustitiã aduersus coniunctam alterius cõiugis personã, atque ibi disputabimus simul de eo altero effectui iniustitiæ ex eodem adulterii crimine sequuto. Solùm autem hoc loco disputamus, num, quan [sect. 2] do, dante aliquo operam rei illicitæ, sequutum est damnum absque alia sua culpa theologica ac iuridica, teneatur id damnum restituere ea ratione, quia, dando operam rei illicitæ, fuit sequutum: Exẽpla sunt, si quis cẽdendo ligna in sylua aliena contra domini voluntatem, adhibitaque debita diligẽtia, ne cui noceret, mancipium alienum aut ouẽ alienã interficit; vel si illa ita cedebat in loco deserto, in quo neque homines, neque similia animalia, esse solent. Item, si quis domum alienam intrans furãdi gratia, illam incendit, aut damnum aliud ita ibi det, quòd, si ex legitima ingrederetur causa, id damnum nulla ratione imputaretur ei ad culpam, num restituere illud teneatur. Dicendum verò est, neq; in conscientiæ neque in exteriori foro teneri illud restituere. Probatur, quoniam iure naturali id restituere non tenetur: eo quòd neque ex parte rei acceptæ, neque ex parte iniustæ acceptionis, ad id teneatur; quippe cùm nullum in eo commiserit peccatum, vt supponimus: [[233]] neque tenetur ex aliquo contractu, quo ad id se astrinxerit: neque item tenetur lege aliqua positiua, qua respublica voluerit ad id homines in commune bonum obligare: eo quòd nulla talis reperiatur: si autem aliqua esset, quæ in pœnam antecedentis culpæ ad id obligaret, illa esset pœnalis, ac proinde ante latam sententiam ad id non obligaret: ergo in euẽtu, de quo disputamus, neque in conscientiæ, neque in exteriori foro, tenetur ad vllam restitutionẽ eius damni. *Confirmare id possumus ex Augustino. c. inebriauerunt. 15. q. 1.* quo in loco, quoniam ex ebrietate Loth præter omnem ipsius existimationem sequutus fuit incestus, & absque omni prorsus culpa cõparatione eius effectus, eo quòd in potestate ipsius non fuerit præuidere eum incestum, solam ebrietatem illi ad culpam imputat, non verò incestũ. Quando autem effectus malus ad culpam non est imputandus, eo quòd nullo modo fuerit voluntarius, sanè neque ad pœnam est imputandus, & multo minùs est iniungendum restuendi onus propter illum, esto nocius sit proximo.

Illud tamen obserua, quando res illicita, cui [sect. 3] aliquis operam dat, est apta, vt damnum sequatur, vt si quis de nocte domum alienam ad furandū ingrediatur, pedibusque offendat, atque aliquid infringat, aut damnum aliud det, tunc in eo effectū proximo nociuo facilè interuenire latam culpam, coniunctam cum theologica culpa cōparatione talis effectus, & multo facilius in exteriori foro præsumitur, atque, saltem in pœnam antecedentis culpæ aptæ, vt inde id sequeretur, iniungi in eo foro potest onus restituendi id totum damnum. Secūs autem res habet, quando manifestè constat, effectum sequutum nullo modo fuisse culpabilem in antecedente culpa, actūve illicito, cui quis operam dabat.

Qui ad restituendum teneantur. Et de iubente, seu mandante, ratūmve habente damnum nomine ipsius iniustè esse datum. Disp. 729.

SVMMARIVM.

- 1 . *REstitutionis pressæ ex parte iniustæ acceptionis, tanquam concausas, quos obligatio constringat.*
- 2 . *Iubens tacito aut expresso mandato quis censeatur, vt, damno inde sequuto, restituere illud teneatur.*
- 3 . *Restituere non tenetur damnum iniustè datum, qui ratum postea habet nomine ipsius esse datum: tametsi decens sit, vt illud restituat.*
- 4 . *Ratum habens delictum nomine ipsius factum, pœnam spiritualem, vt excommunicationis, aut irregularitatis, pro eo impositam, incurrit; non tamen retrahitur, vt incurratur à puncto commissi delicti.*
- 5 . *Ratum habens delictum nomine ipsius antea patratum, vt pœnas pro eo delicto statutas incurrat, necesse est, vt quando fuit patratum, fuerit in statu vt potuerit illud percipere.*
- 6 . *Sciens aliquod damnum fore nomine ac intuitu ipsius dandum, nec cobibens, cūm possit, restituere tenetur id damnum ipsius intuitu datum.*

EXplicatis hactenus radicibus, ex quibus re [sect. 1] stituendi obligatio oritur, explanandum consequenter est, qui ad restitutionem teneantur. Atque potissimū erit nobis sermo de restitutione pressè sumpta, & de obligatione restituendi ex parte iniustæ acceptionis. Qui enim restituere teneantur ex contractu, & ex aliis radicibus restitutionis latiūs sumptæ, disputatione non indiget: cūm id facilè constet ex titulis, ex quibus aliquis de iustitia efficere aliquid tenetur. Quis item, & quousque, restituere teneatur ex parte rei acceptæ, à Disp. 718 fuit explanatū. Quod autem ad obligationē restituendi ex parte iniustæ acceptionis attinet, præter eum, qui acceptionē iniustam exequitur, ad restitutionem etiam tenentur, quicunque ad eandem iniustam acceptionē cooperantur. Nouem autem modis euenit, aliquem ad iniustam acceptionem cooperari, vt tradunt D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 7. & doctores communiter, qui his duobus carminibus continentur:

Iussio, consilium, consensus, palpo, recursus, participans, mutus, non obstans, non manifestans. Sex prioribus ex his nouem modis dicitur aliquis causa iniustæ acceptionis directè, influendo scilicet cum exequutore in effectum. Tribus verò posterioribus dicitur causa indirectè, quatenus videlicet non impedit iniustam rei acceptionem, aut retentionem, quando id efficere potest ac tenetur.

Quod ad iussionem attinet, iussionis nomine [sect. 2] intelligitur quicumque suo imperio, seu mandato, expresso vel tacito, causa est iniustæ acceptionis, damniue iniustè dati. Expresso quidem imperio, seu mandato, vt si expressè præcipiat rapere, interficere, non soluere, quod debetur, aut damnum aliud iniustè inferre. Tacitè verò, vt si famulo, filio, aut alteri, qui ipsius imperio moueatur, dicat, vindictam ex tali opto, vel quod tale aut tale damnum ei inferatur. Vel si dicat, non placebis mihi, nisi aliquid noui feceris, aut non appareas coram me, donec aliquid noui de te audiam, vel aliud simile, quo illi occultè significet, velle, vt damnum alteri inferat. Lege quæ Disp. 550 dicta sunt. Atque obserua, vt iubens, seu mādans, dari damnum iniustè, restituere illud teneatur, necesse esse, non solùm vt sequatur, sed etiam vt sequatur cooperante ad id tali mandato, ita quòd exequutor verè ex illo fuerit motus, seu adiutus, ad damnum inferendum. Si enim non sequatur, quia mandatarius id non est exequutus, constat nullam esse obligationem id restituendi. Si item sequatur, ceterùm non ex tali imperio, quoniam aliunde ille decreuerat id efficere, neque quicquam cooperatum est id imperium, tunc iubens ad nullam restitutionem eius damni tenetur, vtpote ex tali imperio non sequuti. Quod idem intellige in consulente, & in aliis concausis, de quibus erit sermo.

Dubium est. Quid si filius, famulus, aut aliquis⁸⁹ alius, neque præcedente expresso neque tacito consensu patris, heri, aut alterius, cui se placiturum ea in re credidit, nomine illius est aggressus damnum alteri inferre, illudque re ipsa intulit, tenebiturne ille, cuius nomine est illatum, illud restituere, saltem si, postquam illatum fuerit, ratum id habeat? *Syluest. verb. rest. 3. q. 6. pronuntiato. 2. Nauar. in Manu. c. 17. n. 133. Ang. ver. furtum. n. 20. Palud. in. 4. dist. 15. q. 2. art. 3. & alii*, affirmanter respondent, quando duo illa simul concurrunt, datum scilicet damnum esse nomine illius, arbitrando gratum illi id esse, & sequuta postea ratihabitione eiusdem.

[[234]] Ducuntur, quoniam in iure, tam ciuili, quàm⁹⁰ canonico, quando aliquid nomine alicuius est factum, si illud postea ratum habeat, eiusmodi ratihabitione retrotrahitur, mandatoque æquiparatur, hoc est, perinde, quod nomine ipsius est factum, subsequuta ratihabitione, reputatur, eique imputatur, ac si de mandato ipsius fuisset à principio factum, vt constat regula ratihabitionem, iuncta regula antecedente, *de reg. iur. lib. 6. c. cum quis de sent. excom. lib. 6. & aliis iuribus*, quibus rem ita habere, quod ad contractus attinet, ostendimus Disp. 337. & aliàs sæpe.

Contrariam sententiam affirmant *Ioannes* [sect. 3] *Med. de rest. q. 7. ad. 4.* & quidam alii, quos *Syluest.* & *Ang.* locis citatis referunt, quæ nobis proculdubio est amplectenda. Nempe, quando per suam ratihabitionem in causa non fuit, vt, qui damnum dedit, illud non restitueret, ad nullam teneri restitutionem in conscientiae foro. Tametsi humanitas postulet, vt, quia damnum intuitu ipsius est datum, datumque esse ratum habuit, illud restituat. Quòd in conscientiae foro ad nullam restitutionem teneatur, probat satis efficaciter *Medina*. Quoniam per ratihabitionem sequentem non fuit causa damni antea dati; eo quòd id, quod posteriùs est tempore, esse non potuit efficiens causa præcedentis effectus: ergo hic, de quo loquimur, non tenetur restituere id damnum ex parte iniustæ acceptionis; eo quòd nullo modo fuerit illius causa efficiens: cùm ergo nec teneatur ex parte rei acceptæ,

vt supponimus, solumque nobis sit controuersia cum autoribus contrariæ opinionis, num ex parte iniustæ acceptionis restituere teneatur; consequens profectò est, vt in conscientia foro ad restitutionem non teneatur.

Ad iura autem, quibus doctores contrariæ⁹¹ opinionis nituntur, dicendum est. Intelligenda esse, in primis in contractibus cum alio celebratis nomine ipsius: eo enim ipso, quòd nomine ipsius celebrati sunt, & id ipse ratum postea habet, ipsius nomine gestum celebratumve esse, meritò statuerunt iura, vt perinde id haberetur, ac si ipse à principio mandatum ad id dedisset. Intelligenda deinde esse, quoad incurrendum [sect. 4] pœnas ob delictum nomine ipsius gestum, etiam spirituales excommunicationis, ac irregularitatis, iure statutas, vt tractatu sequenti videbimus. Obserua tamen, quamuis ad incurrendum pœnas spirituales pro delicto impositas censeatur atque imputetur delictum, ac si à principio mādato ipsius esset commissum, quando nomine ipsius fuit commissum, sequutaque est postea ratihabitio, intelligendum tamen est id, non vt retrotrahatur pœna excommunicationis, aut irregularitatis, quasi incursa sit à puncto, quo commissum fuit delictum; id quippe est impossibile: quoniam eiusmodi pœnæ non incurruntur, nisi ob culpam propriam eius, qui illas incurrit; & ante ratihabitionem nulla fuit culpa in eo, cuius nomine, ipso id ignorante, tale delictum commissum est; neque vllus vnquam affirmavit, retrotrahi excommunicationem, aut irregularitatem, vt incurraturante ratihabitionem delicti, ob quod hæ pœnæ sunt impositæ, quando id delictum nomine ipsius fuit antea commissum, sed solùm intelligendum est id, ad effectum, vt à puncto ratihabitionis pœnam eam [sect. 5] spiritualement incurrat, & non antea. *Nauar. item in Manu. c. 27. n. 233. cum Ioanne And. & Panor.* obseruat, vt ratihabitio prædictum effectum habeat, necesse esse eum, cuius nomine delictum est commissum, in eo statu fuisse tempore, quo delictum nomine ipsius fuit commissum, vt potuerit illud præcipere. Quare, si nomine alicuius, quando ille erat infans, aut furiosus, commissum sit crimen, ob quod excommunicationis, aut irregularitatis, pœna sit imposita, esto is postea ratum habeat, nomine ipsius commissum esse tale delictum, non incurrit excommunicationem, aut irregularitatem: idemque est dicendum de aliis pœnis, siue spiritualibus, siue corporalibus, pro eo crimine statutis: fictio enim illa iuris, quod ratihabitio retrotrahat, vt delictum de mandato illud ratum habentis cēseatur commissum, vt pœna pro eo statuta incurratur, intelligitur, quando præcipere illud potuit tempore, quo erat commissum. Ad effectum autem, vt verè fuerit causa effectus sequuti, ac damni dati, vt tanquam vera illius causa, aut concausa, teneatur ex natura ipsa rei illud restituere, ratihabitio neque retrotrahit, neque retrotrahere potest, ratum habentem, nomine ipsius id damnum iniustè esse datum, vt ex se est satis perspicuum.

Illud tamen obserua, quando aliquis crede [sect. 6] ret, aliquos nomine ipsius damnum aliquod iniustè alteri daturus, ac posset illud impedire, eos cohibendo, illisque significando, nulla ratione velle, vt id efficiant, teneretur id efficere, atque, si id prætermitteret, teneretur restituere damnum sequutum, esto postea ratum non haberet id damnum esse datum. Ratio autem est, quoniam, cū videat, aut timeat, nomine ipsius id damnum esse dandum, tenetur, non solùm ex caritate, sed etiam quasi ex officio, ex proprioq; iustitiæ onere, impedire, ne nomine ipsius, & tanquam aliquid sibi gratum, damnum proximo iniustè inferretur. *Consentit Nauar. in Manu. c. 27. n. 231.* dum id sufficere affirmat, vt excommunicatio & irregularitas incurratur.

De consulente. Disp. 730.

SVMMARIVM.

1. *VT consulens restituere teneatur damnum consilio ipsius datum, quàm ample usurpetur.*

Fieri verò interdum potest, vt consulens restituere teneatur, etiam damnum, quod exequenti latè consilium fuit sequutum, & exequutor non teneatur.

2. *Consulentium varia genera, & ex quanta culpa unusquisque eorum teneatur, si ex ipsius consilio damnum sequatur, etiam accipienti id consilium.*

3. *Consulore licet minus malum, etiam iniustum eidem ipsi, cui paratur maius, sine obligatione restituendi: secùs vt alteri inferatur: nam tunc obligatio esset consulenti id restituere in defectum exequutoris.*

4. *Consulens esto à principio non persuadeat malum, quod consulit, si tamen postea is, cui consilium est datum, inde moueatur ad damnum inferendum, tenetur consulens illud restituere in defectum exequutoris.*

[[235]] **N**omine consulentis, in re proposita, intel [sect. 1] ligitur, non solùm qui consilium

dat, sed etiam qui hortatur, rogat, instruit, vtilitatem ac commoda proponit, vel aliud simile, vnde aliquis ad damnum alteri iniustè inferendum moueatur. Fiet autem potest, vt qui aliquo istorum modorum consilium dat, restituere teneatur proximo damnum tali consilio ei illatum, quādo, qui ex eo consilio id damnum dedit, exequutusve illud est, ad nullam restitutionem teneatur. Si enim, qui consilium est sequutus, inuincibiliter ignoret, damnum, quod dat, iniustum esse, ductus meritò autoritate consulentis: consulensque à culpa non excusetur, id consilium dando: vtique, qui consilium ita fuerit exequutus, damnumque dederit, non tenebitur illud restituere, nisi quatenus fortè fuerit inde factus locupletior; is verò, qui consilium illud culpabiliter dedit, tenebitur restituere, non solùm id damnum, sed etiam quodcunque aliud, quod inde fuerit ei sequutum, qui tale consilium exequutioni mandauit, exequutionivé mandare præcepit. Hoc modo causa damni iniusti esse possunt consiliarii principum, atque ad illius restitutionem tenentur, si consilium dent, vt lex iniusta, statutúmve iniustum, condatur, vel si cōsiliū dent, vt tributum iniustum imponatur, vel vt bellum iniustum inferatur, aut vt aliquid aliud iniustum fiat. Eodem modo esse possunt causa damni iniusti aduocati, medici, doctores, quos alii de rebus dubiis consulunt, confessarii, & alii similes, si consilium dent, vnde alteri damnum iniustum sequatūmidque non solùm, quando scienter consilium iniustum dant, sed etiam quando ex culpabili ignorantia illud dant: de qua re lege quæ Disp. 549 dicta sunt.

Atque hoc loco circa eos, qui consilium dant, [sect. 2] est distinguendum. Quoniam vel, qui consilium dat, est talis, qui, attenta personæ, aut etiam muneris, qualitate, peritiam in re, circa quam consilium dat, profitetur, vt sunt ii omnes quos memorauimus; vel est talis, qui non profitetur circa illam rem talem peritiam, vt sunt illi, qui supra alios communes homines peritiam circa eam rem non profitentur, vtpote qui neque scientiam, neque artem circa eam didicerunt, aut profitentur. Prioris generis homines, si vel quia ob suam imperitiam insufficientes sunt ad præbendum aliis circa talem rem consilium, eos decipiant, vel ob negligentiam in examinanda & expendenda ea re, consilium nociuum dent, vnde, præter

ipsorum intentionem, damnum sequatur, vel iis ipsis, quibus id consilium dant, vel aliquibus aliis, tenentur ad restitutionem eius damni, diuersimodè tamen. Quoniam, si in actu tradendi id consilium intendant solùm cōmodum eius, cui, præter ipsorum intentionem, damnum ex taliconsilio sequitur, solùm tenentur de lata culpa, non verò de leui, aut leuissima. Vt si medicus gratis curet, aduocatus gratis patrocinetur, doctor, aut confessarius, ex catitate absque vllo stipendio, aut mercede, in confessionibus, aut extra confessiones, consilium det. Si verò consilium id dando, simul intendat commodum proprium, & aliorum, quatenus stipēdio accepto, vt eum actum exerceat, consilium dat, saltem quia, vt id munus exerceat circa illum, aut alios, qui de eadem sunt paræscia, fructus beneficii accipit, tenetur de leui culpa, non verò de leuissima. Posterioris verò generis homines, qui non profitentur circa eam rem peculiarem peritiam, si bona fide consilium nocium dent, & præsertim si illud dent gratis, solum tenentur de dolo. Quoniam hi homines non profitentur consilium dare, integrumque est eos, qui illud petunt, aut quibus datur, illud non exequi. Atque in hoc euentu loquuntur reg. nullus ex consilio de reg. iur. *lib. 6. & l. consilii. ff. eodem titu.* quæ id docent. Consentunt regulæ generales, quibus toto hoc secundo tractatu sæpe explicauimus, quando quis teneatur de leui culpa, aut solùm de lata ac dolo. Ex circumstantiis verò concurrentibus, & ex qualitate consilium dantis, ex munere illius, & ex rei qualitate, circa quā consilium datur, prudentis arbitrio est iudicandum, num culpa aliqua in eo consilio dando interueuerit, & quanta ea sit, neque certa regula hac de re præscribi potest.

Vtrùm autem liceat consulere minus malum [sect. 3] ad vitandum maius. Rem discussimus Disp. 335, partemque affirmantem ostendimus esse veram, quando aliter diuertere malefactorem non possumus à patratione maioris mali, & quando minus malum, quod consulimus, non esset in iniuriam alterius tertii: nam tunc non liceret consulere minus malum in præiudicium tertii. Atque si consuleretur, eaqueratione illi inferretur, restituendum id illi tertio esset, in cuius præiudicium tale consilium cederet. Illud autem est obseruandum, quando auertere non possumus malefactorem ab inferendo maiori malo proximo, illudque impedire aliter non possemus, quàm suadendo illi minus malum in rebus eiusdem proximi externis, adiuuandoque malefactorem in eo damno inferendo; tunc, cùm eiusmodi adiutorio minimè tali proximo iniuriam inferremus, quin potius negotium illius vtiliter ageremus absque vllo nostro peccato, nullam nobis ex tali adiutorio ad id præstato manare obligationem restituer di illi id damnum, nisi forte locupletiores in aliquo inde maneremus; sed obligationem totam manere apud solùm malefactorem, cui id adiutorium præstaremus.

Dubium est, num, si quando aliquis prauum [sect. 4] consilium alicui dedit, vt proximo suo damnū iniustum inferret, id illi non potuit persuadere, postea verò ex eo consilio fuit motus ad id damnum proximo inferendum, teneatur, qui id consuluit, restituere tale damnum in defectum eius, qui id damnum exequutus est. Respondendumque est affirmanter. Quoniam re vera id consilium ad id damnum inferendum cooperatum tunc est, quando damnum fuit illatum, licèt à principio non permouerit, aut etiam illi contradixerit, qui postea ex illo fuit permotus ad tale damnum inferendum.

Discrimen inter mandantem & consulentem, quando post reuocatum mandatum, ac consilium, damnum iniuste infertur. Disp. 731.

SVMMARIVM.

1 . MAndans si expressè, aut tacitè, reuocauit [sect. 1] mandatum, & de reuocatione mandatario constabat, si damnum mandatarius dèt exe-[[236]]quando mandatum, solus mandatarius tenetur illud restituere: nisi in mandato eſset admixtum aliquid consilii, unde mandatarius motus fuerit ad id exequendum: nam tunc mādans, tanquam causa minus principalis, tenetur restituere in defectum exequutoris. Consulens verò licèt consilium reuocet, & suadeat, ne exequutioni mandetur, si inde sequutum sit damnum, tenetur illud restituere in exequutoris defectum.

Licèt quidam in ea sint sententia, vt dicant, [sect. 1] si, post prauum mandatum aut consilium, alicui datum, mandans aut consulens, antequam damnum inde sequatur, mandatum, vel consilium, reuocet, non teneri restituere damnum nequitia mandatarii, aut eius, cui consilium tale est datum, post reuocatum tale mandatum, aut consilium, sequutum: alii tamen rectiùs hoc discrimen inter prauè mandantem, & prauè consulentem, constituunt. Quòd si mandans, ante damnum exequutioni mandatum, expressè reuocauit mandatum, verbis, scripto, per internuncium, aut alia ratione, vel tacitè, ineundo amicitiam, aut affinitatem contrahendo, cum eo inimico, cui damnum inferri mandauerat, tunc, si postquam mandatario de tali reuocatione mādati constitit, mandatarius damnum illi inferat, non tribuitur id damnum mandanti, sed mandatario, ac proinde mandans tunc non tenetur illud restituere, sed solus mandata rius. *Ita Innot. c. ad audientiam de homic. quem, post Bartolum sequuntur Angel, & Syluest, vterque verb. mandatū. n. 5. & Nauar. in Manu. c. 27. n. 233.* At verò quando post reuocatum consilium, petitumque ab eo, cui est datum, vt illud exequutioni non mandet, damnum iniuste est datum, damnum illud ei, qui consilium dedit, imputatur tanquam concausa per id consilium, atque adeò ad restitutionem illius tenetur in defectum eius, qui illud exequutioni mandauit, *vt cum Inno. asserit Panor. c. ad audientiam citato. n. vlt. Rationem reddit Nauar. n. 233. citato*, (licèt quoad irregularitatem ex homicidio loquatur) quoniam consilium datur gratia eius, cui datur, vt is illo vtatur tanquam suum negotium agens, eaſque ratione, quandocunqueis, illo permotus, damnum iniuste infert, imputatur opus, quo damnum infert, atque effectus, ei, qui tale consilium dedit, tanquam causæ per id consilium ad id opus ad eumſque effectum cooperanti. Mandatum verò est præcisè ratione mandantis, vt mandatarius, tanquam negotium agens mandantis, operetur interim dum mandans voluerit; eaſque de causa statim, ac mandans illud reuocat, non amplius mandāti imputatur opus atque effectus, sed mandatario, qui sua nequitia ex tali mandato occasionē sumpsit ad id damnum, absque mandantis culpa, inferendum. Quo loco obserua, nullum esse dubium, dānum iniuste à mandatario illatum, post mandatum à mandante reuocatum, non imputari mādanti, quasi ad illud restituendum teneatur tanquam causa principalis, quæ sola, ante omnes alias illius damni concausas, teneatur id integrum damnum restituere, & reliqui solūm in defectum illius, quo pacto procul dubio ad restitutionē eius dāni teneretur, nisi mandatum, ante id damnum datum, reuocasset, vt

infra dicetur, quando cōcausas omnes damni iniustè dati inter se conferemus, ostendemusque, quousque vnaquæque ad illius restitutionem teneatur, aut non teneatur. Est tamen dubium, quando mandatarius, nihil impediens, quod mandatum esset à mādante reuocatum, idque mandatario constaret, ex eo nihilominus mandato fuit motus ad damnum inferendum, num mandans ad restitutionē teneatur eius damni, in defectum tamen mandatarii, qui tanquam causa principalis iam tunc illius, illud integrum ante mandantē restituere teneretur: quemadmodum pravi consilii exequutor tenetur principaliter integrum damnum, à se ex tali consilio iniustè datum, restituere, & consiliarius non, nisi in defectum talis exequutoris, vt infra, quando concausas dāni iniuste illati interse conferemus, explanabitur. Dicendum autem est, quādo mandatum nihil admixtum habet pravi consilii, quia scilicet nihil habet vnde mandatarius ad illius exequutionem moueatur, præter mandantis iussionem atque auctoritatem, sed mandatarius, post mandatum reuocatum, sola sua nequitia, aut cupiditate obtinendi, quod sibi fuerat promissum, vt id mandatum exequeretur, tale mandatum fuit exequutus, tunc mandantem ad nullam teneri restitutionem, propter rationem à Nauarro redditam. Cæterum, si mandatum admixtam habeat rationem aliquam à mandante mandatario propositam, vnde mandatarius, seclusa auctoritate ac imperio mandantis, motus fuit ad id damnum inferendum, tunc mandantē teneri restituere id damnum tanquam causam minùs principalem in mandatarii defectum, eo quòd verè, per id consilii admixti, cooperatus est ad damnum ita iniustè illatum, quando exequutioni fuit mandatum: semper enim consilium, quando ex illo aliquis motus damnum iniustè dat, cooperatur ad id damnum tanquam instrumentum eius, qui illud dedit, illique, tanquam cōcausæ illius imputatur id damnum, nihil impediens, quòd tale consilium reuocauerit, & quòd dissuadere ei sit conatus, cui illud dedit, vt nihil tale efficeret.

De consentiente Et num consentiens aut suffragium ferens ad damnum iniustum, quando sine tali consensu, aut suffragio, similiter id damnum daretur, ad restitutionem illius teneantur. Disp. 732.

SVMMARIVM.

*1 . C*onsulens, vt restituere teneatur damnum ex consilio dato sequutum, quid dicatur.

Comprehendit verò suffragium ferentē ad id damnum.

2 . Suffragia ferentes, aut consentientes, postquam aliquid, indepēdenter à posterioribus suffragiis, irrevocabiliter est decretum iniustè, non tenentur ad damnum plenè iam per anteriores datū. Neq̃ exequutio obligationem restituendi inducit in exequentes, quando suffragia, licet iniusta, ius electo contulerunt. Induceret verò, quando exequutio esset de re mala, nihil impredientibus anterioribus suffragiis ac consensibus.

3 . Qui ante damnum integre datum suffragia dant, non excusantur à restituendo damno, esto sciant, si ipsi non suffragentur, alios postea id damnum plenè suis suffragiis duros. Qui item post damnum integre datum suis suffragiis augent dedecus & infamiam iniustè reiecti, restituere illi tenentur id dedecoris & infamiae augmentum.

[[237]] 4. *Suffragia sua qui in capitulo renuntiant, quibus impediuiſſent damnum ab aliis datum, & qui tacent, quæ ibi dicere aut proponere tenebantur, quibus damnum id impediuiſſent, restituere illud tenentur.*

Nomine consentientis in re proposita, non [sect. 1] intelligitur, qui quouis modo consentit:

si enim aliquis, quia ex iustitia non tenetur prohibere aliquid, eo quòd ex officio id ei non incumbat, aliquid non prohibeat, sanè esto ex caritate id prohibere sub reatu culpæ lethalis teneatur, huius tamen consensus non solùm per hoc, quòd non prohiberet, cùm posset, sed etiam per hoc, quòd diceret, per me facite, quod volueritis, ego non impediam, & insuper tacebo, neque vnquam id detegā, neque est consentiēs, de quo modò loquimur, neque vlla ei inde insurgit obligatio restituēdi damnum ab aliis, ipso, modo explicato, illud non prohibente, illatū: quia non est causa talis damni, cùm nihil ad illud cooperetur, sed solùm illud non impediāt: non impediens autem tunc solùm censetur causa damni iniustè ab aliis dati, quando ex officio, ac proinde ex iustitia, tenetur illud impedire, non verò, quando solùm tenetur ex caritate illud impedire, vt infrā dicitur. Quin obserua, esto aliquis prædicto modo cōsentiret damnum ab aliis iniustè inferri, quando ipse illud ex officio atque ex iustitia impedire teneretur, ac proinde quando inde contraheret obligationē illud restituendi in defectum eorum, qui illud dederunt, iuxta ea quæ infrā dicenda sunt, non tamen esset consentiens, de quo modò loquimur, sed esset non obstans, & non manifestans, de quibus infrā futurus est sermo. In re autem proposita nomine consentientis intelligitur, qui per suum cōsensum est causa damni, in id damnum positiuè influendo. Vt si aliquis exequi vellet iniustum aliquod damnum, quod inferre non possit absque cōsensu, autoritatē, principis, aut alterius potestatis publicæ, tunc, si princeps, aut talis alia potestas publica, ad id præstet suam autoritatē, seu consensum, vt id fiat, consentiens est, de quo in re proposita loquimur: & quia per talē consensum est concausa damni iniusti, quod ex eo consensu fit, tenetur illud restituere. Si item à consensu aliquorum pendeat, quòd bellum in feratur; atque illi consentiant, suffragiāve præstent, quòd iniustum aliquod bellum inferatur; consentiētes sunt, de quibus modò nobis est sermo: & quoniam per eum consensum, quemadmodum concausæ sunt iniustæ talis belli, ita quoque concausæ iniustæ sunt damnorum, quæ ex eo bello sequuntur, ad eorum omnium restitutionē tenentur. Illi verò, qui post tale bellum definitum, illud approbant, ita tamen quòd ex ipsorum approbatione non pendet inferri, aut non inferri, vt sunt homines de plebe, à quorum approbatione, postquam est definitum, nec inferri, nec non inferri, pendet, sanè sicut per eum suum consensum & approbationem causa non sunt talis belli, ita neque causa sunt damnorum, quæ ex illo sequuntur, nec proinde tenentur illa restituere, nisi postea in illorum exequutione sint aliter eorundem concausa, vt bene Caiet. in summa verb. reresitutio, ait. Item, qui suffragiis contra iustitiam aliquem eligunt ad cathedram in vniuersitatibus, vel ad canonicatum in ecclesiis cathedralibus, aut aliquid aliud contra iustitiam suffragiis efficiunt, concausæ sunt iniustæ talis electionis, restituereque proinde tenentur damna, eis suffragiis proximè, vel remotè, iniustè data.

Quando aliquid iniustè suffragiis confertur, [sect. 2] aut decernitur, vnde damnum iniustum sequitur, quod restituere tenentur, qui illius per suffragia, aut consensum, causæ sunt, aut concausæ, vt proximè est dictum, est obseruandum. Si, vt id fiat, pendeat à maiori suffragiorum parte, ita quòd postquam maior pars suffragiorum accessit, suffragia, quæ post illa accedunt, ac sequuntur, nihil mutare iam possunt, aut impedire, tunc, qui iniustè suffragatur post maiorem partem suffragiorum, quæ rem iam decreuerunt, aut alicui contulerunt, non

tenetur ad restitutionem talis damni iniuste dati. Ratio autem est, quia, cùm iam damnum totum esset integre datum per antecedentia suffragia, hic, qui posteriùs iniuste suffragium tulit, non est cooperatus ad id damnum integre ac plenè iam antea per alios datum, ac proinde, cùm causa iam non sit eius damni, restituere illud non tenetur. Hoc potissimùm locum habet, quando secretis suffragiis, nulla pręuia consultatione inter suffragium habentes, antequam suffragia pręstentur, non confertur, aut decernitur, vt fieri solet in collatione cathedralium per scholasticorum suffragia in vniuersitatibus, & in collatione aliquorum canonicatum, quę per oppositionem suffragiis canonicorum, & episcopi, conferuntur in ecclesiis cathedralibus. *Ita Caiet. vbi suprā, Nauar. in Manu. c. 17. n. 21. Ioan. Med. de rest. q. 7. & doctores communiter.* Medina tamen addit, si, qui posteriùs tulerunt suffragia ita iniusta, concurrant ad exequutionem eius, quod suffragiis est definitum, tanquam concausę, pręcipientes vnà cum aliis exequutionem, teneri ad restitutionem tanquam concausas eius iniustę exequutionis. Quę sententia mihi non probatur. Atque in primis, quod ad cathedras vniuersitatum attinet, scholastici suffragantes, suis suffragiis cathedram conferunt, quoad ius, quod ad illam eis conferunt, pro quibus suffragantur. Regulare autem vota (vt vocant) & videre, cui suffragiis sit collata, & facere fidem, ac mittere schedulam, qua exequutio fit, ad rectorem & consiliarios vniuersitatis spectat: qui, quamuis sciant suffragia fuisse iniusta, non possunt aliud facere, neque ipsi iniustitiam committunt, rem exequutioni mandando: quandoquidem electus eis suffragiis, licet iniustus, ad eam cathedram, ius iustitię ad illam comparauit, ac proinde eam illi tribuēdo iuxta suffragia, non peccant contra iustitiam, neque contra aliquam aliam virtutem, sed suum munus debitè exequuntur: scholastici verò, qui iniuste suffragia tulerunt, sunt, qui contra iustitiam peccauerunt, quique ad restitutionē damni iniuste dati tenentur. Deinde, quamuis in capitulis cathedralium ecclesiarum, ipsi, qui suffragia tulerunt, essent, qui rē exequutioni mandarent, sanè, neque damnum ipsi darent, neque contra iustitiam peccarent, aut contra aliam virtutem, iuxta maiorem suffragiorum partem, collationem exequutioni mandantes: quoniam similiter suffragia, etiam si iniusta, iustitię ius contulerunt ad canonicatum electo eis suffragiis, illique post ea suffragia canonicatus est debitus: qui autem primò vsque ad maiorem partem suffragia eo modo iniusta tulerunt, tenentur ad restitutionem damnorum iniuste eis suf- 238 fragiis illatorum: quare exequutio post talia suffragia non est iniusta, neque, qui ad illam post suffragia concurrunt, causę sunt iniustę, ita ad illam concurrento. Quando autem exequutio post suffragia, aut post definitionem aliam factā à maiori parte communitatis, esset mala, aut iniusta, tunc peccaret contra iustitiam, qui ad eam iniustam exequutionem cooperaretur, neque vllę partes communitatis, aut aliqui alii, quibus pręciperetur exequutio illa, tenerentur, aut possent, tali pręcepto, vtpote iniquo, parēre, quin potius ibi haberet locum illud Petri & Ioannis Actorum 4: *Si iustum est in conspectu Dei, vos potiùs audire, quàm Deum, iudicate.*

Sunt verò circa hęc nonnulla obseruanda. [sect. 3] Primum est. Quando collatio pendet à maiori parte suffragiorum, aut consensuum, tunc, qui antequam maior pars suffragiorum esset pro aliquo lata, pro illo iniuste suum suffragium daret, esto sciret, maiorem partem habentium suffragium, pro eodem suffragia laturam, eaque de causa ipse pro illo suffragium tulerit, alioqui minimè pro illo suffragium laturus, tenetur nihilominus, vnà cum cæteris, qui ante alios maiorem suffragiorum partem pro illo dederunt, restituere damna inde iniuste sequuta. Quoniam ipse re vera cooperatus est suo suffragio ad id damnum iniustum: &, quòd alii id damnum essent post ipsum daturi, nisi ipse illos anteuertisset, non tollit, quòd ipse id damnum iniuste re vera dedit.

Secundum est. Qui post maiorem suffragiorum partem pro aliquo latam, suffragium suum pro illo eodem iniuste ita dant, vt impedire non possint damnum plenè ab aliis suis suffragiis iniuste datum, restituere non teneantur, quod illi iniuste fuit collatum, vt dictum est, neque item iacturam honoris, aut famæ, eius, qui ad id eligi debebat; si tamen suis suffragiis auxerunt iacturam dedecoris ac infamiæ, quatenus maius dedecus & maior infamia est, aliquem excludi maiori suffragiorum copia, quàm minori, teneri id damni augmentum illi restituere, quatenus concausæ iniustæ illius fuerunt.

Tertium est. Eos, qui sua vota in capitulo re [sect. 4] nuntiant, attendentes, aut attendere debentes, id in causa esse, quòd aliquid iniuste fiat, dum ea ratione præualent suffragia eorum, qui iniuste aliquid conferunt, aut decernunt, & peccare lethaliter, & restituere teneri damna, quæ inde fuerint sequuta, quòd ipsi suffragia non tulerint: quoniam ex officio tenebantur tunc impedire ea damna, tanquam partes totius communitatis, cui ius suffragii ad id est tributum. Eadem ratione, partes capituli, quæ proponendo aliquid circa id, de quo agitur, aut aliquid manifestando, impedire in capitulo potuerunt, ne aliquid ab eo capitulo, ac communitate, iniuste fieret, cùm ex munere ad id proponendum, iuxta ordinem in eo capitulo ac communitate præscriptum, tenerentur, & let haliter peccant, si id omittant, & ad restitutionem damnorum inde subsequutorum tenentur. *Ita Inno. c. 1. de iis quæ à maiori parte capituli. & Syluest. verb. consensus, q. 3.*

De adulatore & receptatore. Disp. 733.

SVMMARIVM.

1. *Restituere in defectum exequutoris quis vt palpo seu adulator teneatnr.*
2. *Receptator quis dicatur, vt tanquam concausa restituere teneatur ablata, damnave data, etiam concausando ne restitutio fiat. Cum receptatoribus comprehenduntur, qui alios in iudicio aut alibi defendunt, ne aliena reddant. Et quousque ad pœnam liceat nihilominus malefactores in iudicio defendere.*
3. *Receptatores ad ludum, ad comessationes, & ad similia tanquam concausæ, quòd aliena ibi distrabantur, aut consumantur, quousque restituere teneantur.*

PAlpo, seu palpator, licèt is sit, qui adulatur, [sect. 1] eo tamen vocabulo, in re præsentì, intelligitur quicumque, vel laudando, vel etiam exprobrando, irridendo, aut murmurando de aliquo, vel quouis alio simili modo, illum ad damnum iniustum proximo suo inferendum mouet, vel sumendo de alio vindictam, vel quouis alio modo. Talis quippe restituere tenetur damnum totum, cuius, ita alterum mouendo, fuerit causa aut concausa. Tenetur tamen in defectum exequutoris, vt infrà dicetur. Exemplum est, vt si quis alterum ad vindictam moueat, proponendo illi suam nobilitatem, aut gesta suorum maiorum, vel illi exprobrando adulterium vxoris, aut alio quouis simili modo: tenetur enim, tanquam concausa illorum iniusta, ad damna omnia subsequuta, non solùm, si illa intendit, sed etiamsi attendere debuit, id inde sequi posse.

Rekursus nomine in re præsentì intelligitur, [sect. 2] qui vel recipiendo aliquem, vel prædam illi asseruando, vel aliquo alio modo, illi securitatem præbendo, ad eamve eum adiuuando,

in causa est, ut damnum aliquod iniuste inferat, aut ut, postquam illud intulit, id non restituat. Tenetur enim restituere damnum omne, cuius aliquo modo fuerit concausa ob tale adiutorium, vires aliquo modo & animum illi augendo, aut conseruando, securitatēve aliqua ex parte illi præbendo: atque restituere etiam illi tenetur damnum, cuius licet ipse non fuerit causa, fuit tamen ea ratione impedimento ex parte, ne id restitueretur, aut recuperaretur. Atque cum his, & cum palpatoribus, computare, seu comprehendere, possumus eos, qui illum coram iudice defendendo, aut excusando, aut etiam coram damnum iniuste passo, vel coram partes illius agente, in causa sunt, ne restituere cogatur. Quando tamen simul conueniretur ad pœnam illi pro eo delicto imponendam, tunc, quantum ipse se posset licite defendere, tantum liceret eum adiuuare: modò, si adiuuanti constaret, illum damnum iniuste dedisse, quod in conscientiae foro restituere teueretur, nulla expectata sententia, prouideret, ut id illi occulte restitueret, si esset soluendo, aut, si soluendo non esset, præstaret sufficientem cautionem, qualem, attentis circumstantiis concurrentibus, præstare tunc posset. Obserua autem, nos hoc loco solùm loqui de receptatoribus, quatenus concausæ sunt damni iniuste dati. De receptatoribus autem aliter delinquentium, & de pœnis illis statutis, suis in locis est dicendum. Atque dum suprâ de pœnis furium, ac raptorum, dictum est, sermo etiam est habitus de pœnis illos recipientium.

De iis autem, qui in domo sua recipiunt ad [sect. 3] ludendum, aut ad comedendum ac bibendum, filios [[239]] familias, & alios, qui ludunt ac consumunt res, de quibus constat, aut suspicio est, alienas esse, nū illarum rerum dominis restituere teneantur res ita consumptas, tanquam concausæ talis iniustæ cōsumptionis. Dicendum est. Si ita recipientes, aliquid earum rerum accipiant, vel in stipendium receptionis, vel in precium pro rebus, quas illis tradunt, restituere teneri, quod ita accipiunt, ratione rei acceptæ, & ratione iniustæ acceptionis. Nisi, semoto omni dubio, præsumant, earum rerū dominos non velle restitutionem: eo quòd solū sint inuiti, quòd res ipsorum ita alienentur: postquam autem alienatę aut consumptæ sunt, restitutionem contemnunt. Si verò recipientes, nihil earum rerum recipiant, sed solū permittāt in ipsorum domibus eas res ludi aut consumi, tunc si cartas, aut aleas, ad ludendum tradant, imò si mensam ad ludendum illis sternant, & alia ad id necessaria præbeant, ut sedilia, lumen, & similia, restituere tenentur tanquam concausæ eius damni iniusti; in defectum tamen eorum, qui res ita alienant, quin & in defectum eorum, qui eas res lucrati sunt: qui omnes, ante eiusmodi receptatores, restituere tenentur. Quòd verò aliquis, sciens aliquos ingressos esse domum suam ad ludendum, ibique ludere, inde illos non ejiciat, restituere non tenetur aliena, quæ ibi ludunt, modò eos non occultet, & quasi defendat: neque enim ex iustitia, sed solū ex caritate, tenetur impedire ludum in ea sua domo, eos inde ejiciendo, quando ipse nihil ad ludum cooperatur, saltem eos defendendo aut occultando.

De participantibus. Et quousque singuli, in variis euentibus, restituere teneantur. Disp. 734.

SVMMARIVM.

1. Restituere ut teneantur, varii participantium in furto, aut in damno dato, modi, & quousque unusquisque restituere teneatur.

2 . Restituere vnus non tenetur partes aliorum, quando solum fuit occasio vt alii simul furarentur: secùs quando fuit causa, & quibus modis causa esse possit.

3 . Damna iniusta, quæ milites in exercitu dant, quãdo qui illa exequentur, & quando omnes, teneantur ea restituere, hoc est, singuli ea integra, in defectum aliorum. Et cur non tanto rigore singuli præcipiendi sint restituere, sed vnusquisque moderate prudentis arbitrio.

Participantes hoc loco dicuntur, quicunque [sect. 1] ad iniustitiam, præter modos hactenus

explicatos, coadiuuant, siue simul participant re iniustè accepta, seu detenta, siue non. Et quidem, quando aliquis solùm in re accepta participaret, absque vlla iniusta acceptione ex parte ipsius, non esset participans, de quo modò loquimur, iuxta ea, quæ in principio Disp. 729 dicta sunt: solumque restituere teneretur, quod ad se ex ea re peruenisset, si extaret, aut quantum ex eo, quod non extaret, factus esset locupletior, vt ex iis, quæ, dum de radice restitutionis ex parte solius rei acceptæ sunt dicta, facilè liquet.

Inter participantes ergo, de quibus nobis hoc loco est sermo, in primis numerantur, qui cooperantur ad furtum, aut ad quamcunque aliam iniustam acceptionem, vel damnum iniustum, influendo iniustè ad illud immediatè, illudque exequendo, aut postquam res iniustè detinetur, aliquid illius accipiendo, aut retinendo iniustè. Numerantur etiam, qui mediatores sunt ad iniustitiæ exequutionem, vt sunt vsurariorum famuli, qui contractus iniustos, vsurariorum nomine, celebrant, pecuniasque recipiunt, & sunt famulus, aut quicūq; alius, qui, quod filius familias, aut quod quiuus alius furatur, scienter, aut præsumendo, præsumeréve debendo, esse furto ablatum, vendit, aut aliter distrahit, & qui illud similiter emptum, aut quouis alio titulo sibi traditum, accipit, & sunt alii similes.

Numerantur deinde fabri ferrarii, & alii, qui scientes, aut præsumentes, præsumeréve debentes, claues, aut alia instrumenta, peti ad furandum, aut ad aliud damnum eis inferendum, ea conficiunt, aut tradunt: sunt enim concausæ damni sequuti, tanquam cooperantes ad illud ministrando instrumenta, quibus alii ad id sunt vsuri. Numerantur item, qui scalas applicant, aut tenent, quibus alii ascendunt ad damnum iniustè inferendum. Et præterea, qui exploratores seu vigiles sunt eorum, qui damnum iniustè inferunt, vt illos admoneant, quo tutiùs ac faciliùs id iniustum damnum exequantur. Item numerantur, qui illos comitantur, animo eos defendendi, aut quoduis aliud auxilium ad id iniustum damnum inferendum eis præstandi. Ex his exemplis facilè quiuus intelliget ac iudicabit, oblato ei quouis alio euentu, num in illo dicendus sit aliquis participans in damno aliquo iniustè illato, aut non, vt ex hoc capite iudicandus sit teneri ad illius restitutionem an non.

Vt autem intelligatur, quantum quiuus participantium iniustè in damno dato restituere teneatur; respiciendum semper est ad effectum, damnumve iniustè datum, atque in illo est attēdendum, quantum illius sua causalitate attigerit. Et quidem, si totius effectus, damniue, fuit causa, quia videlicet totum id damnum totalitate effectus, & singulas illius partes, attigit sua causalitate, tunc, nihil impediēte, quòd partialitate solùm causæ fuerit illius causa, quia scilicet alius, aut alii, simul fuerunt causæ eiusdem totius effectus, restituere tenetur totum effectum, saltem in defectum aliorum, vt explicauimus. Si verò sua causalitate solùm attigit partem effectus, damniue dati, ita quòd reliquæ partis, aut reliquarum partium, ipse nullo modo fuit causa, quia eas sua causalitate non attigit, sed alii fuerunt soli illarum causæ, tunc ipse solùm tenetur restituere eam partem, quàm sua causalitate attigit, siue illam attigerit totaliter totalitate causæ, quia ipse solus causa fuit eius partis damni, siue partialiter solùm partialitate causæ, quia videlicet alius secum causa etiam fuit eius partis damni.

Hinc quando, verbi gratia, multi vineam in [sect. 2] grediuntur, ut vvas furentur, aut aliquem alium locum, ut damnum iniuste dent, distinguendum est: Quoniam, si nullus alium ad id inuitavit, consiliumve ad id illi dedit, neque animo se inuicem defendendi, ac adiuvandi, si vinitor, [[240]] aut vineæ dominus, compareret, ingressi sunt, sed simul vineam sunt ingressi, nullo eorum cooperante ad parziale furtum alterius, licet forte unus eorum ingrediendo prius aliis, occasionem illis præbuerit ipsum sequendi, ac damnum similiter dandi, tunc nullus eorum restituere tenetur, nisi id, quod ipse accepit: quia nullo modo concurrat ad partes, quas alii iniuste acceperunt, concausave fuit, quod acciperentur: neque enim sola occasio cōparatione effectus alicuius dici potest causa illius. Si autem unus inuitavit aut movit alios ad furtum illud, ita quod alii permoti, aut confirmati suasionem illius, ingressi sunt ad furandum; tunc, qui alios ita movit, restituere tenetur, non solum partem, quam ipse est furatus, sed etiam partes aliorum, quos ita ad furtum movit: quoniam effectus tota talitate earum etiam partium causa suo consilio fuit: eas tamē partes solum restituere tenetur in defectum eorum, qui illas furati sunt, quique magis principales causæ eius damni fuerunt: quare, si loco eorum illas restituat, unusquisque eorum restituere ei tenetur, quod loco ipsius restituit. Hi verò qui, inuitati ita ab alio, furtum commiserunt, si alios ad id furtum non permoverunt, solum tenentur restituere unusquisque quod accepit: quoniam eius tantum damni fuit causa, & non damni, quod alii dederunt. Quando autem multi ita accesserunt ad damnum inferendum, quod mutuus comitatus fuit causa damni ab unoquoque illorum illati, vel quia nullus accederet ad id damnum dandum, nisi fretus communi defensione, vel quia non prævalerent id damnum inferre, nisi comitati accederent, tunc unusquisque restituere tenetur, non solum dānum, quod per se ipsum immediatē dedit, sed etiam, in aliorum defectum, restituere tenetur damna, quæ cæteri dederunt: quoniam singuli, dum ita sibi mutuo fuerunt præsidio ac adiutorio ad id damnum dandum, causa fuerunt totius damni ab omnibus dati, totalis quidem totalitate damni ac effectus, licet partialis causæ partialitate. Hinc in damnis, quæ exercitus iniuste dat, est [sect. 3] distinguendum. Quoniam si sunt talia, quæ dantur à singulis, ut per accidēs sunt coniuncti cum aliis, quia videlicet damnum, quod unusquisque iniuste dat, simili modo ab eo daretur, esto non esset coniunctus cum aliis, ut si aliquid ex aliena vinea accipiat in transitu exercitus, minimē fretus, quod comitatus accedat, & quando nullus esset, qui impediret, esto comitatus non accederet, tunc solum teneretur restituere partem, quam ipse ita iniuste accepit, non verò partes aliorum, quos ipse ad illas accipiendas non permovit: quoniam nullo modo est causa damni, quod ita alii de exercitu in ea vinea dederunt. Si verò damna sunt talia, quæ dantur à singulis ut per se sunt coniuncti cum aliis, ita quod nullus eorum per se ipsum id damnum exequeretur, atque cum effectu illud daret, nisi fretus aliorum auxilio, ut sunt damna, quæ dantur in cōgressu exercitus, in direptione urbium, in depopulatione regionum, in direptione navium, & sunt pleraque alia, quæ in exercitu dantur, tunc unusquisque militum restituere tenetur damnum totum ab exercitu datum, in defectum tamen aliorum, qui non restituerint partes damni, quas singuli per se ipsos immediatē dederunt. Ratio autem est, quoniam singuli milites causa iniusta fuerunt totius illius damni, totalitate quidem effectus, licet partialitate causæ. Ita *Adria. q. 1. de rest. Caiet. 2. 2. q. 62. art. 7. Sotus. 4. de iust. q. 7. art. 3. Couar. reg. peccatum part. 2. §. 12. ad finem. n. 2. & alii.* Neque mihi probatur, quod ait *Nauar. in manu. c. 17. n. 20.* militem scilicet, sine cuius ope dux Borbonius urbem Romanam tempore Caroli 5 & Clementis 7 diripisset, non teneri restituere totum id damnum, sed solum id, quod ipse diripuit. Etenim unusquisque miles in particulari de numero eorum

omnium, qui eam urbem diripuerunt, dicere verè potuit, sine me cæteri, si ad id concurrerent, diripuissent eam urbem, ac proinde, ex sententia Nauarri, nullus teneretur restituere, nisi solam partem, quam diripuit aut destruxit; cùm tamen nihil damni fuisset ab vnoquoque eorum datum, nisi alii simul concurrissent, atque adeò nisi exercitus totus fuisset causa totius damni ac singularum partium. Quare dicendum est, de iustitiæ rigore, vnumquemque militem restituere teneri totum damnum ab exercitu datum, tanquam causam totius illius damni totalitate effectus, licèt partialitate causæ. Vt tamen Caiet. loco citato ait, per impotentiã excusabitur vnusquisque, si restituat, quòd commodè possit. Ego dicerem, ex præsumpta urbis voluntate, aut cæterorum, qui ab exercitu iniustè passi sunt id damnum, satis esse si, præter dānum particulare, quod vnusquisque miles in particulari dedit, insuper restituere iubeatur moderatum aliquid, prudentis arbitrio, attenta qualitate personæ, & attento, quòd plus, aut minus, cooperatus sit ad damna, quæ alii dederunt. Neque enim existimandum est, tam inhumanos esse Christi fideles, vt post damnum ita datum, velint tanta cum seueritate obligare eos, qui eo modo concausæ fuerunt totius illius damni, vt cogant eos restituere secundum vltimum de potentia. Præsertim cùm ea in parte non solùm essent crudeles ac irrationabiles, sed etiam minùs vtiliter suum negotium agerent: eo quòd singulos milites omnino arcerent à restitutione, militesque in desperationis baratrum mitterent, obligarentque ad rem humano more impossibilem, si vellent, vt secundum vltimum de potentia, prout acquirerent bona, ea restituerent, sine vlla spe vnquam integre restituendi, etiam efficiendo totum, quod in totam suam vitam possent.

Qui coadiutores sunt ad exequutionem damni, quòd iniustè datur, & qui conficiunt, aut tradunt, instrumenta ad id damnum exequendum, qui item scalas applicant, aut tenent, quibus ascendatur, vt id damnum detur, itemque, qui exploratores, aut vigiles, sunt ad eos monendos, qui damnum iniustè dant, & qui illos defendunt, aut comitantur, restituere tenentur totum damnum, quod ita fuerit iniustè datum: eo quòd verè sint causæ totales eius totius damni, effectus totalitate, licèt partialitate causæ. Tenentur tamen solùm id restituere in defectum causarum principalium, quas ita coadiuuarunt. Nisi ipsi partes rerum iniustè ablatarum obtinerent, ex pacto inter ipsos ita inito, aut alia ratione: nam tunc singuli eas partes, tanquam causæ principales, restituere tenerentur principaliter, & non in aliorum defectum. Si item aliqui concurrerent ad aliquid iniustè destruendum de communi [[241]] consilio, & tanquam commune negotium ipsorum omnium agendo, attamen distribuerant munera, vt quidam ipsorum vigiles, in aliorum securitatem, essent, alii applicarent aut tenerēt scalas, vel aliquid aliud ad id administrarent, & cæteri damnum immediatè darent, tunc singuli omnes tanquam causæ principales, & non in aliorum defectum, restituere tenerentur partes æquales damni iuxta numerum ipsorum omnium, qui ad id ita principaliter concurrerunt: reliquas verò partes eius integri damni, solùm restituere tenerentur tanquam concausæ partialitate causæ, in aliorum defectum, qui illas tanquam causæ principales restituere tenebantur.

De muto, non obstante, & non manifestante. Et num, qui solùm ex caritate ad hæc tenetur, restituere teneatur, si illa omittat. Ac

vrùm, qui aliquid accipit, vt ea omittat. restituere id teneatur. Disp. 735.

SVMMARIVM.

1. *REstituere vt teneantur damna ab aliis iniustè data, tanquam concause illorum indirectæ, qui nomine muti, non obstantis, & non manifestâtis, intelligantur. Et qui ex officio tenentur ea impedire, cum quanto suo detrimento ad id non teneantur.*
2. *Restituere non tenentur tanquam cause indirectæ eorum damna, ab aliis iniustè data, qui solùm ex caritate ea impedire tenentur, etiam si ex odio ea impedire omittant, sed solum qui ex officio seu ex iustitia ad id tenentur, & qui hi sint.*
3. *Accipiens aliquid à fure, vt taceat, quando teneatur illud restituere, quando non item.*
4. *Restituere non tenetur damnum alteri iniustè datum, qui, cùm solum ex caritate illud teneretur impedire, velletque id impedire, illud ei dissuasit absque vi, metu, & fraude, esto ex odio eius, cui id damnum parabatur, id efficeret. Secùs si vi, dolo, aut fraude, seu mendaciis, id efficeret.*
5. *Restituere quando teneantur famuli, qui impedire possunt furta & damna, quæ heris suis fiunt, nec impediunt. Quando non item.*

NOmine muti, non obstantis, & non mani [sect. 1] festantis, intelliguntur hoc loco, qui verbo, etiam scripto, aut facto, impedire possunt damnum proximo iniustum, antequam fiat, vel postquam factum est, nec impediunt, cùm possint ac teneantur. Hi quippe causæcensentur indirectæ talis damni, eaque de causa ad restitutionem talis damni, in defectum eius, qui illud dedit, tenentur. Damnum verò antequam fiat impeditur, clamando, denūciādo paratum ad delinquēdum, aut opem ac auxilium aduersus illum ferēdo, vt id damnum impediatur. Postquam verò datum est, isque, qui illud iniustè intulit, resarcire id non vult, impeditur, malefactorem denūciando, seu reuelando, sententiam aduersus eū ferendo, vt id damnum restituat, eūque ad solutionem cogendo, & aliis similibus modis. Dictū verò est, mutum, non obstantem, & non manifestantem, esse causam indirectam damni iniusti ab alio dati, si possit, ac teneatur id impedire, nec impediat. Quoniam qui impedire illud non tenetur, non censetur causa eius dāni. Sicut Deus non censetur causa eorum peccatorum, quæ fiunt, & potest impedire: eo quòd non teneatur ea impedire, vt in *Concord. q. 14. art. 13. Disp. 31.* & in secunda editione *Disp. 32* ostendimus. Item quoniam licet ex officio teneatur quis impedire tale damnum, si tamen vel omino impedire illud non possit, vel non sine grauiori reipublicæ dāno, vel non sine periculo propriæ vitæ, ad id nō tenetur. Ita *D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 7. ad 3. Scot. in 4. dist. 15. q. 2. art. 4. §. de secundo*, & doctores communiter. *Obseruant verò optimè Sotus. 4. de iust. q. 7. art. 3. ad 3. & alii.* Expendendum esse iniustum damnum, quod priuatis, aut reipublicæ, timetur, expendendamque esse quantitatem periculi, quod ex eo potestatibus ac ministris publicis imminet, quòd id damnum impedire aggrediātur, vt ex officio alioquin tenentur, simulque expendendam esse probabilitatem, quæ est, ea via impediendum id damnum re ipsa fore, attentisque his omnibus, atque cæteris circumstantiis concurrentibus, iudicandum esse, num aliquando,

etiam cum periculo vitæ, attentare teneantur impedire id damnum. Quemadmodum enim potestas publica obligare aliquando subditos potest, etiam cum periculo propriæ ipsorum vitæ, reipublicæ subuenire: sic aliquando eadē potestas publica, aliique ministri publici, qui ex officio rempublicam defendere malaque arcere tenentur, quique ea de causa iustum accipiunt stipendium, tenebuntur attentare impedire danum iniustum, quod reipublicæ aut partibus eius imminet, etiam cum periculo propriæ vitæ. Quando autem dānū non est tale, ac tantum, vt recta ratio exigat, attentare illud vitare, etiam cum probabili propriæ vitæ periculo, & multo magis quando temeritas esset id attentare, propterea quod mors inde esset moraliter certa, & nulla, aut perexigua, spes id damnum vitandi, non tenerentur se tanto exponere periculo: quia neque ipsi cum tanto suo periculo se intenderunt ad id obligare, neque populi cum eo periculo eos obligare intenderunt, nihil impediēte, quod ad ipsos defendendos, protegendos, ac eruendos à periculis, ac damnis, stipendium condignum eis tribuant. Atque vt summatim res hæc dicatur, prudentis arbitrio considerandum ac iudicandum relinquitur, cum quanto periculo ac onere vnaqueque potestas publica, ministræve publicus, teneatur impedire damnum quodcunque in particulari occurrens, attento gradu talis ministri publici, stipendio, quod accipit, & attentis cæteris circumstantiis concurrentibus: neque certa alia hac de re statui potest regula. Hæc de primo eorum, quæ proposita sunt.

Quod verò ad secundum attinet, dubium est: [sect. 2] Num, qui ex sola caritate impedire proximi dānum tenetur, si id, cum possit, non impediāt, cēseatur causa indirecta eius damni, ac proinde, teneatur illud ei restituere, in defectum eius, qui tanquam causa directa, ac principalis, illud dederit: an verò is solus cēsendus sit causa illius indirecta, qui ex officio, seu speciali obligatione, atque adeo ex iustitia, illud impedire tenetur: quales sunt publicæ potestates, ministræve publici, & vniuersim, qui ad id se astrinxerunt, siue ea ratione stipendium accipiant, siue non, vt sunt custodes, eorum comparatione, quæ ex officio custodienda susceperunt. Cum his computare eos etiam possumus, quibus cura incumbit cu-[[242]]st odiendi aliqua, ne nocumētum aliis inferant. Vt vnusquisque tenetur curare, ne sua pecora, armenta, aut quoduis aliud suum, nocumentum aliis det: si autem sua culpabili negligentia noceant, de iustitia tenetur restituere damnum ita illatum, quatenus de iustitia impedire ea tenebatur, ne id damnum darent. Cum eisdem possumus computare medicos ac chirurgos, qui alios curandos suscipiunt, procurato res, qui aliquorum defensionem suscipiunt, & alios similes.

Richardus in. 4. dist. 15. art. 5. q. 4. & apertiùs Caiet. verb. restitutio, ac maior in. 4. dist. 15. q. 26. ad. 3. affirmant, esto quis ex officio non teneatur impedire proximi damnum, sed solum ex caritate, si tamen commodè illud impedire possit, nec impediāt, censendum esse causam illius indirectam, atq; ad illius restitutionem teneri. In contraria verò sententia sunt D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 7. ad. 3. Alex. Alen. & Altisiodorensis, quos Adrian. q. 1. de rest. refert ac sequitur, ac sunt Scot. in. 4. dist. 15. q. 2. art. 4. Ioan. Med. de rest. q. 9. Sotus. 4. de iust. q. 7. art. 3. Couar. reg. peccatum part. 2. §. 12. Nauar. in Manu. c. 17. n. 18. & doctores communiter. Nempe eum solum censeri causam indirectam damni proximo iniuste illati, ac proinde teneri id ei restituere, qui ex officio, aut ex speciali alia obligatione, quæ non esset ex sola caritate, tenebatur illud impedire, nec impediuit, cum posset; non verò eum, qui ex sola caritate illud impedire tenebatur. Ratio autem est, quoniam peccatum contra solam caritatem obligationem restituendi non inducit, sed illud solum, quod iustitiam violat, vt in eo liquet, qui non pascit fame moriētem, aut qui innocentem, qui iniuste interficitur, non

defendit. Atque hæc sententia omnino nobis probatur. Si circa eam longiorem disputationem desideras, lege Adrian. & Med. locis citatis.

Angelus verb. furtum. n. 26. hanc sententiam limitat, vt intelligatur, præterquam, si is, qui ex sola caritate proximi damnum impedire tenetur, dolo id facere omittat, hoc est, ex odio eius, cui id damnum infertur, intentioneque, vt id ei inferatur. Merito tamen ea limitatio communiter à doctoribus rejicitur. Quoniam praua illa intentio peccatum est solùm contra caritatem: quo sit, vt sialiter non influat ad id damnum, quàm illud non impediendo, quando ex iustitia impedire illud non tenetur, ea intentio ac odiũ obligationem restituendi non inducant. Quin si is, qui ea praua intentione damnum illud non impediuit, interrogatus à dominorei, qui in ea id damnum iniustum est passus, num sciat, quis id damnum intulerit, ex eadem praua intentione ac odio respondeat, se id nescire, ad nullam tenebitur restitutionem: quia solùm peccat cōtra caritatem. Vtrùm autem, si à iudice interrogatus, idem respondeat, ad restitutionem tunc teneatur, tractatu 5. id examinabimus. Hæc de secundo.

Quod verò ad tertium attinet, dubium est. [sect. 3] Vtrùm si aliquis accipiat aliquid à fure, vt taceat, restituere teneatur, quod ita accepit. *Sotus. 4. de iust. q. 7. art. 3. & Nauar. in Manu. c. 17. n. 21.* non teneri affirmant, quando, quod ita accepit, non erat de bonis furto ablati, sed de aliis bonis furis; & quando, qui illud accepit, non tenebatur ex officio id damnum impedire. Arbitror tamen esse distinguendum. Quoniam, vel fur id in mercedem dedit, cum pacto, vt taceret; vel in donum absolutum, vt accipiẽtem alliceret ad tacendum. Eo modo, quo aliquid mulieri donatur, vt alliciatur ad consentiendum in peccatum, absque vllo pacto, ac conuentione, quòd propter illud in peccatum consentiat. Ac tunc dico. In hoc posteriori euentu non teneri restituere. Quoniam illud est donatio absoluta, sed cum modo, modo solùm se habente, vt causa finali seu motiua ad donandum, non verò vt conditione, sub qua esset valida donatio, & sine qua esset inualida, neque item se habente vt grauamine, quo non impleto, amitteretur res donata, nihil impediẽte, quòd donaus, si sciret ea via donatarium non inducendum ad id, quod intendebat, non donaret, vt de donatione simili modo facta mulieri ad alliciendam eam ad peccandum Disp. 208 & 286 est dictum. In priori autem euentu, quando scilicet aliquid datur cū pacto, & sub conditione expressa, vel tacita, vt taceat, vt regulariter solet dari, credo contrà esse dicendum, ac Sotus & Nauar. affirmant. Nempe quando is, qui id, vt taceat, accipit, non tenebatur ex officio impedire id furtum, neque ex sua taciturnitate alicui periculo sua bona externa, suam famam, aut suam personam, exposuit, restituere teneri, quod ita acceperit: Secùs autem, quando ex officio tenebatur impedire id furtum, vel tacendo periculo exposuit propria bona, vel suam famam, aut personam. Quoad priorem partem ducor. Quoniam datio illa non fuit donatio, sed contractus; do tibi tantum, vt taceas; neque id est datum, vt tunc solùm taceat, sed vt in perpetuum taceret, nunquam id crimen detegendo, sed perpetuò illam iniustitiam permittendo: cū verò accipiens, sub reatu lethalis culpæ, teneatur ex caritate curare, vt fur dānum iniustè illatum restituat, & quando id aliter non potuerit ad effectum perducere, teneatur detegere furtum; consequens profectò est, vt acceptio illa sit pro peccato in futurum patrando, atque adeò vt contractus sit nullus: non secùs atque est nullus contractus, quo mulier aliquid accipit, vt in suturum copiam sui corporis saciat; in quo euentu potest is, qui id illi dedit, illud ab ea repetere, nolendo id, pro quo illud dedit; sicut etiam mulier tenetur non velle id, pro quo id accipit, reddereque tenetur, quod pro eo opere in futurum patrando accepit: & quemadmodum contractus, quo aliquis accipit aliquid pro homicidio in futurum patrando, est nullus, teneturque vterque contrahentium desistere ab eo contractu ante

homicidium patratum, vt Disp. 94 cepiosè est ostensum. Quo fit, vt, qui pro furto tacendo, aliquid à fure accepit, teneatur dissoluere contractum, dicendo, se nolle deinceps consentire furtum, pretiumque reddendo, quod pro furto in futurum permittendo, ac tacendo, accepit. Et similiter fur possit dissoluere contractum, dicendo, se velle restituere, neque indigere deinceps ea taciturnitate, ac permissione furti, ac proinde petendo pretium, quod pro ea dedit; ad quod reddendum tenetur ex iustitia is, qui illud accepit, vt disputatione citata cōprobatū fuit. Ducor item. Quoniam, posito cum, qui tacendo furtum permittit, nulli se exponere periculo iacturæ sui honoris ac famæ, suorum bonorum externorum, aut lēsonis propriæ personę, [[243]] non video in eo, quod pro tali pretio præstat, aliquid eo pretio dignum; quare, cū datum nō fuerit liberaliter ac gratuite ex parte furis, sed in recompensationem pro taciturnitate ac permissione furti, non video titulum iustum, quo accipiens possit iustè illud retinere. Quando verò periculo exponeret propriam personam, honorem, famam, aut bona sua externa, vel, qui tacet; ex officio teneretur impedire iniustum dānum, quod permittit, ac proinde, illud permittendo, super se induceret onus restituendi totū damnum ei, qui illud esset passus, in defectum furis, tunc, vt id detrimentum subiret, posset absq; iniustitia accipere competens pretium, iuxta ea quæ disp. 94 citata dicta sunt, nec illud restituere postea teneretur danti.

Dubium vltteriùs est, vtrū si aliquis non te [sect. 4] neretur ex officio impedire damnum proximi iniustum; vellet tamen illud impedire: & quidam tertius, qui similiter ex officio non teneretur impedire idem damnum, in causa esset, vt non impediretur, arcendo eum, qui impedire illud volebat, ab illo impediendo: teneatur restituere id damnum illi, qui illud est passus. Ad hoc, distinguendo, est respondendum. Quoniam, si impedimento illi fuit, qui illud impedire volebat, absque aliqua vi, aut fraude, solū illum rogando, ne illud impediret, aut illi proponendo rationes aliquas, minimè falsas, vt dicendo, eum, cui dānum paratur, esse satis diuitem, vel admonendo, ne ea via incurreret odium aliorum, vel ne se exponeret alicui periculo, aut ne curaret sumere molestiam id impediendo, vel simile aliud, tunc ad nullam restitutionem teneretur, esto ex odio illius id efficeret, cui damnum illud parabatur, sed solū peccaret contra caritatem. Probatur, quoniam, cū ita impediens, nihil prohibeat, quod ex iustitia ei esset debitum, cui id damnum iniustè parabatur, neque vsus sit vi, dolo, aut fraude, ad eum arcendum, ne impediret id damnum, qui ex sola caritate illud impedire volebat: sanè nullam iniustitiam aduersus eum commisit, cui damnum est illatum, sed solū contra caritatem aduersus eum peccauit: perinde atque is, qui ex odio eius, cui alter volebat telinquere bona sua, absque vi, metu, aut fraude, collatori persuasit, vt ea illi non relinqueret, vt Disp. 727 ostensum est: quare, sicut is, qui eiusmodi suasionibus dimouetur, ne impediat damnum, quod impedire volebat, solū peccat contra caritatem id damnum non impediendo, quando suasiones sufficientes non erant, vt meritò ab eo damno impediendo desisteret, ita, qui absque vi, ac fraude, illi persuasit, contra iustitiam in illo eodem euētu non peccat, sed solū contra caritatem. Si verò vtatur vi, metu, aut fraudibus, tunc, quia contrauenit iuri eius, cui damnum iniustè infertur, contra iustitiam peccat aduersus eum, ac proinde tenetur id damnum illi restituere, in defectū eorum, qui illud iniuste ei intulerunt, iuxta ea quæ Disp. 727 citata dicta sunt. Atque in hoc posteriori euentu verum est, quod loan. Med. de rest. q. 9. in fine, & Nauar. in manu. c. 17. n. 140. hac de re affirmant.

Quod ad famulos attinet familiæ, qui vident [sect. 5] furta aliqua fieri dominis suis, aut alia damna eis iniustè inferri, neque ea impediunt, cū possint, est dubium, num dicendi sint concausæ indirectæ eorum damnorum, teneanturque proinde illa restituere in defectum

eorum, qui iniuste illa dederunt, an non. Dicendum autem est. Si illis commissa erat cura, aut custodia earum rerum, circa quas furtum committitur, aut damnum infertur, aut peculiariter accipiebant stipendium, ut earum rerum curam haberent, vigilaréntve circa illas, tunc censendos esse concausas indirectas eorum damnorum, tenerique ea restituere in eorum defectum, qui illa iniuste dederunt. De horum verò numero sunt, qui curam habent penus, neque impediunt furta rerum, quæ ibi custodiuntur. Item sunt ii, quibus traditur clavis ad extrahendum aliquid de aliquo loco, & permittunt inde aliquid furto accipi, aut aliud damnum eis rebus iniuste dari. Quando autem unus famulus videret alterum famulum, aut quævis alium, accipere aliquid de rebus, quarum cura, aut custodia, ac defensio, nullo modo esset ei commissa, ac taceret, non teneretur id restituere: quia non peccaret in eo contra iustitiam, sed contra caritatem ac fidelitatem hero debitam, si commodè, ac sine suo notabili detrimento, posset id impedire.

De custodibus, & aliis ministris publicis, inferius disputatione particulari subjiciemus, quæ hoc loco addenda sunt.

Vtrum, ut aliquis restituere teneatur damnum iniuste datum, sat sit esse concausam iniustam illius; an verò necesse sit esse causam, sine qua id damnum non esset datum. Disp. 736.

SVMMARIVM.

1. *Concausa, aut causa, ut restituere teneatur, neesse est, ut damnum iniuste ex ea verè sit sequutum. Nec plus effectus tenetur restituere, quàm quod sua causalitate ac influxu iniusto attigit. Et multa inde inferuntur.*
2. *Qui ei, qui furari quinquaginta intendebat, consilium dedit, ut furaretur potius centum, si dignosci possit, quæ quinquaginta auxit propter id consilium, tunc consulens solum tenetur restituere, in defectum illius, quinquaginta: Si vero dignosci non possunt, restituere tenetur integra centum.*
3. *Restituere tenetur integrum damnum in defectum illud dantis, qui ei, qui decreuerat post dece dies illud dare, persuasit ut statim illud daret.*
4. *Restituere ne teneantur damnum, qui accedentes ad bellum cum aliquibus animo impediendi dandum, quod illi inferre vellent aduersariis, aduersarii eos videntes, & credentes accedere ad illos alios adiuuandos, terga verterunt cum suo magno detrimento.*
5. *Concausans damnum iniustum, restituere illud tenetur, in defectum causæ magis principalis, esto si ipse non influxisset, sequuturus fuisset effectus, atque adeò esto non sit causa sine qua non.*
6. *Restituere tenetur pro quantitate dubii remanentis, qui cooperatus ex sua parte est ad damnum iniustum, & facta debet a diligentia, an verè sua causalitate attigerit id damnum, dubius manet.*
7. *Sciens rem aliquam alienam esse, & dubitans ad quem trium pertineat, restituere illam tenetur distribuendo illam inter eos, iuxta probabilitatem, quæ est, ad unum verisimilius, quam ad alium, eam pertinere.*

8 . Qui suo consilio fuit concausa alicuius damni, nō [[244]] liberatur ab onere restituendi, esto faciat causam principalem concipere propositum restituendi, nisi illa opere id restituat.

Loquimur de obligatione restituendi ex par [sect. 1] te iniustæ acceptionis, damnive iniustæ

dati: non verò ex parte rei acceptæ. Atque ea regula generalis est ante omnia statuenda, quæ ex hactenus dictis ferè constat. Nullum scilicet teneri ad restitutionē dāni iniustè dati, nisi damnum verè sit sequutum, & nisi sequutum sit ex cooperatione iniusta, influxive iniusto eius, de quo inquiritur ac expenditur, num restituere illud teneatur; neque plus eius damni teneri eum restituere, quàm sit id, quod suo influxu ac causalitate attigit; ita quòd si non totum damnum, effectus totalitate, attigit, sed partem, non tenetur restituere totum damnum, sed eam solam illius partem, quam suo influxu ac causalitate iniusta attigit.

Ex hac regula multa colliguntur. Primum est: Esto aliquis, ex cooperantibus aliquo ex nouem modis explicatis, ex sua parte sufficientē causam iniustā dederit effectus iniusti suo consilio, mādato, consensu, suffragio, aut quauis alia ratione, si effectus iniustus inde non sit sequutus, quia vt sequeretur, pendebat ex aliis causis, quæ ad idcooperatæ non sunt, quamuis contra iustitiam peccauerit, ita iniustè ex sua parte cooperando, ad nullam tamen teneri restitutionem.

Secundum est. Quando duo cooperantur ad eundem effectum iniustum, si vnus eorum iniustè operatur, alter verò non iniustè, tunc eum solūm, qui iniustè est operatus, teneri ad illius restitutionem, non verò eum, qui cooperatus est non iniustè. Vt, si aliquis iniustè volebat inferre maius dānum alicui, & alter, nō aliter valens impedire id malum, quàm illi suadendo, vt potius minus aliud illi eidem inferat, id illi suadeat, quin & ipsum ad id minus malū in bonis externis inferendum adiuuet: negotiū eius, cui infertur, ea in parte agendo, ad nullam restitutionem tenetur, vt Disput. 730 dictum est: quoniam hic, licèt ad effectum iniustum, comparetione alterius concausæ, cooperetur, ipse tamē non cooperatur iniustè. Eodem modo, si duo cooperentur ad eundem effectum in se iniustum, vnus tamen eorum excusetur inuincibili ignorantia, quòd sit iniustus, & alter non item, is solus tenetur id totum damnum restituere, qui ab iniustitia non excusatur: non verò is, qui inuincibili ignorantia à culpa excusatur: vt Disp. 730 dictū de eo est, qui meritò consilium alterius est sequutus, inuincibiliter ignorans, esse iniustum; cum tamen, qui illud dedit, à culpa iniustitiæ in eo consilio dando non sit excusatus: similiaque adhiberi possunt alia exempla.

Tertiū est. Esto effectus iniustus sit sequutus, & tertius quidam, quantum est ex parte sua, id iniustè fecerit, quo influere iniustè ad eum effectum potuit tanquam concausa iniusta illius, si tamen nihil re ipsa cooperatus est, quia ex suo influxu iniusto non est sequutus, ad nullam restitutionē illius tenetur. Exempla sunt, vt si consilium dedit, vt damnum iniustum daretur is verò, cui tale consilium dedit, iam decreuerat omnino idē damnum dare, ita quòd ex consilio non magis permotus, nec magis animatus & confirmatus fuit ad idem damnum dandum, tunc, qui consuluit, ad nullam restitutionem tenetur: quia effectus non fuit sequutus ex suo prauo consilio, esto ipse contra iustitiam peccauerit, id iniustum cōsiliū dando, & esto illo intenderit eundem iniustum effectum. Similiter, si suffragium iniustum tulit ad aliquod damnum iniustum, & iam tot erant lata suffragia, quæ sufficiebant ad idem dānum integre & completè dandum, neque ipse susuffragio in contrarium, poterat id damnum ia impedire, ad nullam restitutionem tenetur eius damni iniusti: eo quòd ex suo suffragio, licèt iniusto, non sit re ipsa sequutum, sed ex antecedētibus aliorum suffragiis. Habet autem id

verum, etiam si, quando tale suffragium iniustum tulit, ignoraret, esse iam lata tot iniusta suffragia, quæ sufficerent ad idem damnum iniustum integre ac completè dandum.

Quartò inferunt doctores, cōmuniter. Quā [sect. 2] do aliquis omnino decreuerat furari quinquaginta, & alius illi suasit, vt furaretur centum, eaque consilio huius est furatus, hunc iniustum suasorem teneri restituere solūm quinquaginta: eo quòd eorum tantūm fuerit cancausa iniusta, non verò aliorum quinquaginta, quæ iam antea fur omnino furari decreuerat, quando non magis animatus confirmatusque est eo consilio ad furandum illa alia quinquaginta, quæ iam antea furari decreuerat. Et quidem quando priora quinquaginta, quæ decreuerat furari, erant certa & determinata, illaque furatus est, & insuper alia quinquaginta, aut quando distinctis acceptionibus furatus est primò quinquaginta, & secundò alia quinquaginta, vel numerando sine interpolatione, postquam deuenit ad quinquaginta, alia insuper quinquaginta numerauit ac accepit, res non continet difficultatem: quia cōsulens, de quo loquimur, solūm fuit concausa, vt furaretur posteriora quinquaginta. Quando autem simul vnica indiuidua acceptione centū accepit, inter quæ distingui non possunt, quæ eorum fuerat accepturus, si non accessisset id iniustū cōsiliū, res continet difficultatē: quoniam id cōsiliū iniustum cooperatum videtur ad integra centum, & ad singulas illius partes, effectus totalitate, & non ad medietatem solam. Primò, quia ibi vnica fuit volitio iniusta furis, qua imperata fuit acceptio vnica externa iniusta: neque dici potest ad vnā partem effectus cooperatum fuisse iniustū consilium, & ad aliam non: ergo consilium ad integrum effectum, totalitate effectus, ac partiū singularum illius, fuit cooperatum. Secundò, quoniam si furtum fuit commissum accipiendo marsupium, in quo erant centum, non est maior ratio cur dicas, consilium cooperatum fuisse ad eam acceptionem, vt terminatur porius ad hæc quinquaginta ex eis centum, quā ad alia: ergo vel dicturus es, consilium cooperatum fuisse ad singula quinquaginta, vel ad nihil. Tertiò, quoniam si fur intendebat furari quinquaginta, quæ erant in vno loco, & consilium fuit, vt potius acciperet centum eiusdem, quæ erant in alio loco, vel si furari intendebat rem, quæ valebat quinquaginta, & consilium fuit, vt potius furaretur rem aliam eiusdem, quæ valebat centum, vtique tale consilium diceretur cooperatum ad totum eum iniustum effectum, & ad singulas illius partes: ergo idem dicendum est, quando vnica volitione ac acceptione iniusta accipiuntur integra centum, inter quæ non possit distingui, quæ in particulari addiderit propter id prauum consilium. Sanè in hanc partem inclino, quam con-[[245]]mant. *l. vulgaris. §. vlt. ff. de furt.* Vbi ex hoc fundamento definitur, si muti furentur trabem, quam singuli portare non poterant, amoueréve ex proprio loco, singulos teneri totam soluere. Redditurque hæc ratio, quoniam eo ipso cooperati sunt ad totum effectum; cū non sit maior ratio, cur influxus cuiusque eorum terminatus sit potius ad vnā partem effectus, quā ad alias: quia tamen partialitare solūm causæ singuli eum totū damnum dederunt, tanquam principales causæ, quæ illum exequutioni mandatunt, singuli inter se contribuere tenentur partes suas eius effectus, & supplere, quod alii non soluerint, vel quia soluendo non sint, vel quia non comparent. *Simile quid definitur. l. ita vulneratus. §. vlt. ff. ad leg. Aquil.* vt disp. 697. §. exemplum verò, retulimus ac explanauimus.

Dubium est. Num si aliquis decreuerat dare [sect. 3] damnum iniustum hinc ad decem dics, & suasu alterius illud dedit statim, teneatur, qui id ita suasit, illud integre restituere, tāmquam concausa iniusta totius illius damni, in defectum eius, qui id damnum iniustè dedit. Dicendum est teneri. Ratio autem est, quoniam ad id totum iniustè influxit, cooperatusque est, vt fieret statim. Adde, nisi is suasisset, vt id damnum statim daretur, potuisse, qui

post decem dies illud dare intendebat, mutare consilium, aliisque modis potuisse id damnum fortè impediri.

Ex hactenus dictis potest facilè intelligi, quid [sect. 4] dicendum sit ad eum euentum, *cuius meminere Adrian. q. 1. de rest. & Ioan. Med. q. 7. ad. 3.* Quidam comitati sunt exercitum, eo tamen animo, vt impedirent bellum, atque iniuriam, quam aduersariis parabant. Id verò ignorātes aduersarii, credentesque illos comitari animo damnum, vnà cum illis, ipsis inferendi, terga verterunt, diffidentes, se posse vtrisque simul resistere, eaque ratione damnum inde iis, qui fugerunt, sequutū fuit. In dubium fuit reuocatum, num, qui aduersarios eo animo sunt comitati, restituere tenerentur aliis damnum inde eis sequutum. Dicendum verò est. Si attenderunt, attēderēve debuerunt, id damnum ex eo suo comitatu posse sequi, neque adhibuerunt competentem rationabilemque diligentiam, ne sequeretur, illos alios de suo animo admonendo, ex eorumque consensu accedendo, restituere id damnum teneri. Quia vere eo accessu causam illius damni præbuerunt, cum iniustitiæ peccato ex parte ipsorum, id efficientes, vnde verisimiliter id damnum sequi poterat, ac proinde causæ indirectè fuerunt eius damni, non desistendo ab eo, à quo desistere tenebantur, nisi prius sufficienter cauerent, ne inde alii terrentur, ac terga verterent. Quòd si ex circumstantiis concurrentibus id timere, ad idque attendere, non debuerunt, aut sufficientem adhibuerunt diligentiam, qua alii id sibi persuadere non debuissent, tunc, sicut sine peccato accessissent, ita ad nullam restitutionem tenerentur damni absque sua culpa subsequuti.

His ita constitutis, dubitant doctores, vtrum, [sect. 5] vt aliquis restituere teneatur damnum iniustè datum, satis sit verè fuisse concausam illius iniustam aliquo ex nouem modis explicatis; an verò sit necessarium fuisse concausam, sine cuius influxu tale damnum non fuisset datum. Duobus autem modis euenire potest, aliquem, attingēdo suo insluxu & causalitate effectum iniustum, non esse causam sine qua non illius. Vno, quia influxus ac dispositio alterius causæ principalis, quam coadiuuat, est talis, quòd esto ipse non eo modo illam coadiuuaret, nihilominus effectus ex solo influxu alterius causæ sequeretur. Verbi gratia. Est aliquis paratus ad faciendum furtum, & accedit consilium alterius, qui illum magis confirmat in voluntate furandi, tunc consulēs, licet re vera in effectum influat, non tamen est causa sine qua effectus non sequeretur: quoniā ex solo furis proposito futurum erat furtum, esto non accederet tale consilium, quo fur magis in eo proposito ac voluntate cōfirmaretur. Quòd si, accedente consilio, fur est furatus, in eaque erat dispositione, quòd, nisi accederet id cōsiliū, non furaretur, tunc consulens causa esset sine qua non talis furti. Altero modo euenire potest, aliquem, attingendo effectum, non esse causam sine qua non illius, quia scilicet, si id ipse non fecisset, alter erat illud idem factururus. Quo pacto, qui anteuertit, ac furatus est aliquid, quod nisi ipse esset furatus, alius idem erat furaturus, non dicitur causa sine qua non eius furti; quia, esto ipse id non esset furatus, alius furatus idem fuisset.

Potissima controuersia hoc loco non est in hoc posteriori sensu, sed in priori. Vt enim Adrian. q. 1. de rest. & alii, rectè dicunt, non est cur in controuersiam vocetur, num, qui causa est iniusta damni, non tamen sine qua non, posteriori modo explicato, teneatur illud restituere. Qui enim damnum aliquod iniustè dat tanquam causa principalis, quod nisi ipse dedisset, aliquis alius erat daturus, sanè illud restituere tenetur, perinde ac si nullus alius id damnum fuisset daturus: sicut enim, si alius illud postea dedisset, tunc qui illud postea dedisset, teneretur id restituere, ita si ipse anteuertat, priusque id damnum iniustè det, tenetur illud restituere, vt Disp. 726 est dictum. Eadē ratione, qui, coadiuuādo iniustè alium, dānū cum eo iniustè dat, ad quod, nisi ipse adiuuasset, alius erat similiter coadiuuaturus,

sanè, quâuis nō sit concausa sine qua non modo explicato, ad restitutionē eius damni, tanquam concausa iniusta illius, tenetur perinde ac si nullus alius fuisset coadiuuaturus, neque sequendus suisset effectus, nisi ipse ad eum coadiuuasset. Simili modo, si duo aliqui simul suo consilio moueant tertium aliquē ad furandum aliquid, quod, secluso prauo cōsilio, furaturus non fuisset, vterque sanè ita prauē cōsultiū tenetur id restituere in defectum eius, qui id est furatus, esto idem effectus foret sequendus, si vnus eorum tantū præbuisset id prauum cōsiliū, aut si, vtroque id non consulente, defuturus nō fuisset quartus alius, qui idem consuleret, atque ex eius consilio idem effectus esset sequēdus. Atque hoc potissimum probant rationes *Caietani. 2. 2. q. 62. art. 7. & Soti. 4. de iust. q. 7. art. 3.* Et quoniam res saris est perspicua, nullamque difficultatem continet in sensu posteriori loco explicato, longiorem ea de re disputationem non facio.

Quod verò ad priorem sensum attinet, multi graues doctores asserunt, vt concausa damni alicuius iniusti restituere illud teneatur, necessariū esse, causam esse sine qua exequutor non daret id damnū. Si enim, inquiunt, exequutor idem prorsus damnum esset daturus, quia ad illud dandum erat iā sufficienter motus, tunc concausa, esto illum adiuuet, eūmve aliquantulum magis confirmet, non tenetur illud restituere, esto contra iusti-[[246]]tiam peccauerit eo modo adiuuando. Huius sententiæ videtur esse *D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 7. & in. 4. dist. 15. q. 1. art. vlt. quæstiuncula vlt. & sunt Adrian. q. 1. de rest. citata. Scot. in. 4. dist. 15. q. 2. art. 4. Palud. ead. q. art. 3. Gabr. ead. q. & art. dub. 2. Syluest. verb. rest. 3. q. 6. Nauar. in Manu. c. 17. n. 20. Couar. reg. peccatum part. 2. §. 12. & alii*, tametsi eorum aliqui solū loquantur de consulente & adulante: & quidam eorum mandantem excipiant; eo quòd mandans causa sit principalis, eaque de causa inquiunt, esto exequutor sine tali mandato esset id exequutioni mandaturus, si tamen mandato firmatus magis fuit ad exequutionem, tenetur mandās ad restitutionem eius damni. In participante etiam, qui vnā cum alio influit immediatē in effectum, dicturi videmur, eum restituere teneri: eiusmodi est, qui furem adiuuat ad furtum accipiendum, & ad portandum pondus, quod solus accipere ac portare non poterat. Maximè quia hic est causa sine qua non; nisi in secundo sensu suprā exphcato defuturus nonfuisset alius, qui furem similiter adiuuaret.

Caiet. & Sotus, locis citatis, & Ioan. Med. de rest. q. 7. & 8. vniuersim affirmant, quando aliquis sua iniusta causalitate ac influxu verè attingit effectum iniustum, teneri illud restituere, esto non sit causa sine qua non, sed solū confirmet magis exequutorem, aut quouis alio modo cum eo cooperetur. Atque in hanc planè inclino sententiam, tanquam in tutiorem, & mihi lōgè probabiliorē. Ducor. Primò, quoniam is verè est causa iniusta eius damni: ergo quantum illius sua causalitate ac influxu attingit, tantum tenetur restituere ex parte iniustę acceptionis: qui enim causam damni dat, illud satisfacere tenetur, vt habetur. c. 1. de iniur. & dam. dat. Secundò, quoniā si aliqui aggrediantur furtum cōmittere, & constituent aliquem vigilem, qui ipsos admoneat, si aliquis adueniat, quo tutiūs furentur, tunc, esto hic vigil constitutus causa sit, sine qua alii nihilominus aggredierentur furtum, illudque ad effectum perducerent, & esto nihil eos admonuerit, quia non fuit necesse, tenetur tamen ad restitutionem totius damni tanquam concausa iniusta illius totius, firmans magis ac securiores red dēs socios ad illud patrandum: ergo satis est esse cōcausam iniustam damni firmans magis exequutores, vt restituere teneatur damnum iniustè datum. Tertiò, quoniam non videtur, cur potiūs quædam ex concausis, sine quibus damnum fuisset nihilominus datum, teneantur illud restituere, quàm alie: autores autem cōtrarię sententiæ quasdam teneri affirmant, & quasdam alias non. Obseruandum tamen est, eum, qui scalam, post illam

ab aliis appositam ad furandum, teneret, quando inde, qui ad furandum per illam ascendit, non magis mouetur, nec magis firmatur in animo furandi, neque est verisimile, quòd furtū impediretur, si hic alius scalam non teneret, nō videri teneri restituere id furtum, si nullo alio modo ad illud concurrat, vt probè Sotus vbi suprā affirmat: quoniam hic nihil re vera in furtū influit, aut parum admodum: hæc verò omnia moraliter sunt intelligēda. Quod attinet ad forum externum, lege quæ diximus Disp. 549 à §. quando item, & quæ diximus in calce Disp. 695, §. iust. §. interdum, vbi eum paragraphum, & similia alia iura, quoad forum exterius exposuimus.

Dubium est. Quid, si aliquis id exhibuit, quod [sect. 6] ex se mouere aut confirmare magis potuit exequutorem, dubitat verò, an re vera illum mouerit, aut confirmauerit ad effectum iniustum, tenebiturne ad restitutionē eius damni? *Sylvester verb. restitutio. 3. q. 6. Foan. Med. de rest. q. 7. & alii*, respondent. Eum, qui ita dubitat, teneri adhibere competentem diligentiam, vt sciat, an verè causa fuerit eius damni. Si verò, inquiunt, facta competenti diligentia, dubium adhuc maneat, ad nullam teneri restitutionem: eo quòd in dubio melior sit conditio possidentis. Mihi verò est satis dubia hæc opinio. Quoniam, qui per iniustitiæ peccatum sufficiēter ex se dedit causam damni iniusti, quod re ipsa est sequutum, & dubitat, num ex ipsius causalitate iniusta sit sequutum, ei vtique comparatur, qui à principio possidere cæpit aliquid dubius, an esset vendentis, de quo dicendum non est, esse bonæ fidei possessorem, sed peracta competenti diligentia, teneri ad restitutionem partis valoris eius rei pro quātitate dubii remanentis, vt Disp. 723, cōclusionē 3, dictum est: eaque de causa, qui peracta competenti diligentia manet adhuc dubius, an fuerit causa iniusta dāni alicuius re ipsa subsequuti, certè pro quantitate dubii remanentis videtur teneri restituere partem eius damni. Confirmatur, quoniam, si constet aliquem trium, quorum quilibet causam sufficientem dedit iniustè alicuius damni, id damnum dedisse, & vnusquisque eorū dubitet, an ipse id damnum dederit, sanè omnes tres videntur teneri contribuere, vt resarciatur id damnum; tenebitur verò vnusquisque plus vel minus contribuere, pro quantitate maioris vel minoris probabilitatis, quæ erit, ipsum id damnum dedisse: ergo quòd, qui iniustè, quantū est ex se, sufficientem causam damni dedit, dubitet, an sua causalitate damnum id dederit, sanè per id dubium non deobligatur omnino ab onere illud restituendi. Confirmare possumus an [sect. 7] tecedentem præcedentis confirmationis, quoniam, vt bene dicunt *Caiet. 2. 2. q. 62. art. 5. ad. 3. & Sotus. 4. de iust. q. 7. art. 1. ad. 3.* qui aliquid habet, quod scit esse alienum, & dubitat, cuius aliquorum trium sit, tenetur illud distribuere inter illos tres; ergo pari ratione, quando constat aliquē trium dedisse iniustè aliquod damnum, & vnusquisq; dubitat, an ipse fuerit, qui illud dedit, tenetur contribuere ad restitutionem illius.

Dubium præterea est. Quid, si consulens, aut [sect. 8] aliquo alio modo concausa iniusta alicuius dāni, quemadmodum iniustè mouit, aut cooperatus est, ad damnum iniustè dandum, sic postea consulat restitutionem, ita vt concipere eum fecerit propositum restituendi, qui damnum tanquā causa principalis dedit; si eueniat, vt totalis causa principalis mutet propositum, aut aliqua alia ratione non restituat, tenebiturne ille alius, qui cōsultuit, aut aliquo alio modo cooperatus est cum tali causa principali id damnum iniustum, illud restituere? Respondendum est affirmanter: Quoniam eo ipso, quòd sua iniusta causalitate id dānum iniustum attingit, illiusque fuit concausa, contraxit onus, illud restituendi in euētū, quòd causa principalis illud opere non restituat, à quo onere non liberatur ex eo, quòd fecerit causam principalem concipere restituendi propositum.

[[247]] *Quousque, & quo ordine, nouem concausæ explicatæ, executorque ipse, restituere teneantur. Disp. 737.*

SVMMARIVM.

- 1 . *REstituere ex concausis damni iniusti qui ante quos teneatur, & qualiter quidam contribuere teneantur, & restitui debeat ei, qui loco aliorum restituit.*
- 2 . *Habens aut consumens rem iniustè detentam, restituere ante alios illam tenetur.*
- 3 . *Mandans quousque ante alios restituere teneatur.*
- 4 . *Exequutor quousque ante alios restituere teneatur.*
- 5 . *Vniuersim quando aliquis restituit, quod alius restituere tenebatur, qui ita tenebatur, restituere eitenetur, quod loco ipsius restituit.*
- 6 . *Restituere si tenerentur tres contribuendo partes suas, & vnus restituat loco aliorum, secundus, qui restituere accesserit, tenetur primo restituere, nō solū partem suam, sed etiam dimidium partis eius, qui nondū restituit.*

VNusquisque horum omnium, qui concau [sect. 1] sæ damni iniustè fuerunt, in euentu, quòd cæteri non restituant, restituere tenetur totum damnum, quod ipse sua causalitate, modo præcedētibus disputationibus explicato, attingit: id verò damni, quod ipse sua causalitate ac influxu non attingit, restituere non tenetur.

Quòd verò attinet ad ordinem, quo restitue [sect. 2] re tenentur, dicendum est: Si apud aliquem eorum permanet aliquid, in quo alius iniustè fuit læsus, tunc is ante omnes alios tenetur id restituere: quòd si, post vsurpationem, ipse illud iniustè consumat, aut alienet, tenetur etiam ipse ante omnes alios id restituere, nisi de mandato alterius, damnum ipse dederit, atque in præmiū id ab illo acceperit: nam tunc mandans, etiam ante hunc, tenetur id restituere, tanquam principalior causa. Multo magis, si alicui relictum, velut in depositum aut custodiam, esset aliquid in iustè ablatorum, ipseque id consumeret, aut alienaret, teneretur ante omnes alios id restituere. Restituente verò eo, qui ita aliquid iniustè acceptorum retinet, aut iniustè postea consumpsit, vel alienauit, tunc cæteri deobligati manent à restituendi onere. Quòd si, hoc disparente, aut restituere non volente, vel non potente, aliquis aliorum loco huius restituat, tunc postea restituere id illi tenetur, qui loco ipsius restituit.

Secluso euentu, in quo aliquis ratione ipsius [sect. 3] rei, quam tenet, aut iniustè consumpsit, vel alienauit, restituere ante omnes alios tenetur, si, inter damnum iniustè dantes, reperiatur aliquis, qui id damnum dari iussit, ita quòd ex imperio & mandato illius datum est, cæteris id exequentibus, aut ad illud dandum cooperantibus, vt iussionem implerent, negotiumque illius agerent, tunc is solus mandans tenetur id totum damnum restituere tanquam causa magis principalis illius: eoque ita restituente, exequutor, & cæteri, qui eiusdem damni fuerunt concausæ, deobligati omnino manent à restituendi onere, ita vt, neque ipsi mandanti, qui totum damnum restituit, quicquam restituere teneantur. Si autem, in defectum iubentis, qui vel non comparet, vel nō vult, vel non potest restituere, aliquis aliorum id damnum restituat, tunc iubens tenetur ei id totum restituere: eo quòd loco illius, atque in illius defectum, id restituerit. *Hæc D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 7. ad. 2. & doctores communiter. Obserua*

tamen, si exequutor damnum iniustè dedit, iussus quidem ab alio, attamen mandatum non fuit sola principalis causa, quasi exequutor solùm negotium mandantis agere intenderit, sed simul ipse, aliunde motus, voluit idem damnum dare, quasi agens simul suum negotium, aut alterius cuiusdam tertii, tunc, quia iubens ille non fuit solus causa principalis, sed simul fuit principalis causa exequutor ipse, suum, aut cuiusdam tertii, negotium agens, vtique exequutor contribuere tenetur cum mandante ad restitutionem eius damni pro rata, attenta quantitate influxus & causalitatis cuiusque eorum in ratione causæ principalis eius damni, ita videlicet, quòd si æqualiter fuerunt causæ illo modo totius illius dāni, vnusquisque eorum solùm teneatur contribuere dimidium: si verò vnus eorum plus illo modo fuit causa eius damni, quia magis eius intuitu fuit datum, plus pro rata contribuere prudentis arbitrio teneatur.

Quando nullus ad damnum iniustum con [sect. 4] currit, cuius autoritate, imperio, seu mandato, sit datum, tunc exequutor tenetur ante omnes alios restituere id totum damnum: eoq̃ue restituente, manent cæteri omnes deobligati ab illius restitutione, ita vt neque ipsi exequutori, qui damnum totum restituit, quicquam restituere teneantur. Ratio autem est, quia, inter cæteros omnes, solus exequutor censetur causa principalis, cui perinde restituendi onus incumbit. Quo fit, vt si cæterorum aliquis, vt consulens, adulat, non obstans, aut aliquis alius, in defectum exequutoris restituat, teneatur postea ei exequutor restituere id totum, quod in ipsius defectum restituerit. Nomine autem exequutoris intelligo eos omnes, qui immediatè influunt ad damnū. Vnde, qui instrumenta conficiunt, ac tradunt, & qui scalas applicant, vt alii ascendant, ac damnum dent, restituere non tenentur damnum, nisi in illorum defectum, qui illud exequuti sunt. Obserua tamen, quando aliqui concurunt ad damnum dandum, illoq̃ue æqualiter perticipādum; aut de communi consensu concurrerent ad delictum aliquod omnium nomine patrādū, tunc, esto illud per vnum, aut duos, mandarent exequutioni immediatè, omnes tamen contribuere tenerentur æqualiter ad id damnum restituendum: quia omnes æqualiter essent causæ principales talis delicti. Quòd si aliqui inter eos sint principaliores, & alii minus principales, tūc iuxta proportionem concursus cuiusq; eorum tanquam causæ, cuius nomine & autoritate delictum exequutioni mandaretur, tenerentur contribuere ad restitutionem. Si esset societas latronum, vt prędam inęqualiter inter se diuiderent, quia quidam eorum essent magis præcipui, fortiores, aut in dustriores, tunc iuxta proportionē diuisionis prædæ, inter ipsos communi consensu constitutæ, contribuere etiam tenerentur ad dāna, tanquam causæ eorum dānorum principales.

Quando inter exequutores damni vnusquisq; sibi accipit, quod surripit, aut concurrunt cōmuni consensu ad furtum, aut ad aliud damnum dandum, vnoquoque suum negotium agente, & [[248]] non aliorum, tunc vnusquisque tenetur restituere, quod ipse accipit, aut damnum, quod ipse dat. Quòd si aliquis aliorum, in defectum huius, restituat, quòd hic vsurpauit, aut damnum, quod hic dedit, quia fuit aliquo modo concausa eius partis damni, tunc, qui id damnum, tanquam exequutor illius, dedit, tenetur illi alteri restituere, quod loco ipsius restituit. Lege, quæ de participantibus in eodem delicto Disp. 734 dicta sunt. Et quando vnus, in defectum aliorum, restituere teneatur, quando non item: neque enim est opus illa hoc loco repetere.

Consulēs, & consentiens, (quando non sunt causæ principales dāni, iuxta ea quę Disp. 730 & 732 dicta sunt) palpo, receptator, seu defēsor, mutus, non obstās, & non manifestās, quando ad restitutionem non tenentur ex parte rei acceptę, quia nihil eorum, quæ furto

ablata sunt, ad ipsos peruenit, sed solum restituere tenentur tanquam concausæ iniustę dāni ab aliis dati, tunc solum restituere tenentur in defectum exequutorum, aliarumve causarum principalium eorundē dānorum: quod si aliquid in defectū eorum restituant, tunc illi, in quorum defectum restituerunt, restituere ipsis tenentur, quæ loco eorum restituerūt. Atque si multæ cōcausę eiusmodi minūs principales concurrerunt simul cum causa principali ad damnum iniustę dandum, neque causa principalis illud restituere possit, aut velit, ita quod, in defectum illius, aliæ minus principales restituere teneantur, tunc omnes minūs principales, nulla ante aliam, tenentur contribuere ad restitutionē eius damni pro rata, arbitrio prudētis, iuxta maiorem vel minorem influxum ac causalitatem cuiusq; ad id damnū. Quod si aliquæ earum non contribuāt, vel quia nolunt, vel quia non possunt, reliquæ contribuere tenentur totum dānum: quoniā semper vnusquisque eorum tenetur restituere damnum in solidum, seu integrum, cōparatione eius, cui dānum iniustę est datum in euentu, quod aliūde non fiat ei integra restitutio. Principalis tamen causa tenetur ei restituere totum, quod loco ipsius restituit, vt dictum est, & in defectum causę principalis tenentur minūs principales ei restituere, vnaquæq;, quod loco illius restituit, quin & contribuere ei tenentur pro rata eorum vnusquisque, quod loco aliarum concausarum minūs principalium restituit, quando illę nolunt, aut non possunt, illud restituere, vt in vltimo dubio huius disputationis dicemus. Ratio autem cur inter eiusmodi causas minūs principales, nulla teneatur restituere loco aliarum, nisi quando sua nequitia non vult, aut quando restituere non potest, hæc est: Quoniam nulla earum est principalis cōparatione alterius, sed singulæ causæ sunt iniustę damni per exequutorem, illum mouendo, aut defendendo, vel dānū ei non impediendo, quod ex iustitia impedire tenetur.

Dubium est. Num vniuersim, quando aliqua concausa, in defectum aliarum, restituit, quod aliæ tenebantur ac debebant restituere, teneantur illæ aliæ ei restituerere quod in ipsarum defectum restituit. *Caiet. 2. 2. q. 62. art. 6. ad. 3.* cui ex parte consentire videtur *Sotus. 4. de iust. q. 7. art. 3. ad. 2.* quibusdam vtitur distinctionibus. Quod scilicet, quando aliquis restituere tenebatur ratione rei acceptæ, quam apud se haberet, vel quam habuit, acconsumpsit, aut alienauit, si alius in defectum illius restituat, tanquā concausa, quæ in illius defectum tenebatur, tūc teneatur ille alius huic restituere, quod in illius defectum restituit. Quando verò solūm tenebatur restituere ratione iniustę acceptionis, seu damni dati, destruendo, aut deteriore reddendo, rem alterius, tunc interdum restituere teneatur, interdum non item, iuxta distinctiones quasdā, quas adhibet. Alii, quos *Ioan. Med. q. 8. de rest.* refert, ex alio fundamento affirmant, eum, cuius loco concausa alia damni restituit, non teneri illud ei restituere. Quia videlicet, cū talis concausa fuerit etiam in culpa eius damni, indigna est, cui restituatur, quod in recōpēsationē eius damni ipsa dedit: qua de causa in exteriori foro non conceditur ei repetitio eius, quod ita soluit.

Est tamen statuenda hæc vniuersalis, contraria⁹² vtriq; sententiæ, conclusio. Quandocunque con [sect. 5] causa aliqua restituit aliquid in defectum alterius, qui id restituere tenebatur, is, in cuius defectū id restituit, tenetur ei restituere, quod loco illius restituit. Hæc conclusio videtur esse apertē *D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 6. ad. 3. & est communis, vt ibi Caiet. confitetur. eam etiam affirmant Ioan. Med. q. 8. citata, Couar. reg. peccatum, part. 2. §. 12. & alii.* Probatur verò, quoniam, qui ita restituit, subit onus, quod alius de iustitia subire tenebatur: neque intendit liberare illum alium ab onere, sed liberare se ipsum,tribuendo, quod alius tribuere tenebatur, interim dum ille alius id non soluit: quare, cū ex eo, quod fecerit, quod tenebatur, non sit deterioris conditionis, neque ex eo, quod alius non fecerit, quod

tenebatur, sit futurus melioris conditionis; præsertim cùm, qui in illius defectum restituit, non intenderit exonerare illum, eumque melioris conditionis efficere, sed solum facere, quod pro tunc ipse loco illius facere tenebatur; consequens profectò est, ut is, in cuius defectum restitutio est facta, reddere illi teneatur, qui eam fecit, quod loco illius soluit. Confirmatur, quoniam, dato contrario, resultaret maxima inæqualitas, isque, qui ex sua nequisitia restituere non vellet, quod de iustitia tenebatur, ex sua iniquitate ac iniustitia reportaret cōmodū, ac liberationem à iustitiæ onere, cū grauamine ac dāno alterius, quod nullum ius, nullaque æquitas, patitur. Falsum autem est, huic in foro exteriori denegandam fore repetitionē eius, quod loco alterius restituit, ab eo, cuius loco illud restituit. Quamuis, si ea occasione detegeretur delictū vtriusque; præteritum, id delictum aduersus vtrunque, iuxta legum dispositionē, puniretur.

Dubium deinde est. Quid si, verbi gratia, tres [sect. 6] contribuere æqualiter teneantur ad restitutionem duodecim, (aut etiam inæqualiter) in quibus aliquis ab eis iniuste fuit læsus: & vnus eorum illa integra restituat, in defectum aliorum, qui portiones suas restituere non potuerunt, aut noluerunt: atque postea vnus aliorum duorum, penitentia ductus, aut factus soluendo, velit restituere: satisne tunc erit, si restituat sua quatuor, in euentu, quod æquales portiones tenerentur restituere, an verò teneatur restituere sex, quatuor loco sui, & duo loco alterius, qui nondum vult restituere, aut nondum potest restituere, ita ut illa quatuor diuidantur inter ipsum, & inter alium, qui iam antea restituit? ut facere tenebantur, si à principio de communi consensu cum illo alio restituerent, quod ipsi tenebantur, & quod tenebatur restituere tertius ille, qui sua nequitia, aut sua impotentia, nondum [[249]] restituit. Atque respondendum est, teneri restituere sex, quoniam æqualiter tenetur subire onus cum eo, qui primo loco restituit: quippe cū non minùs teneretur ad integrum debitum, in defectum aliorum, quàm primus, neque minùs teneretur subire onus eius, qui non restituit, quàm teneretur, qui loco vtriusque à principio, in vtriusque defectum, restituit. Postea verò tertius, qui nondum restituit, tenebitur restituere unicuique eorum duo, quæ loco ipsius restituerunt.

Si is, cui facienda est restitutio, remittat vni concausarum damni iniuste dati obligationem restituendi, num reliquæ concausæ eiusdem damni maneant nihilominus obligatæ in solidum. Disp. 738.

SVMMARIVM.

- 1 . QVando multi in foro conscientie restituere aliquid tenentur, quando remissio, facta vni à creditore, alios deobliget, quando non item.
- 2 . Remissio pænæ, qua multi in foro exteriori tenentur pro eodem delicto, si fiat vni, non deobligat alios a pænæ debito. Nisi contrarium circa aliquod delictum sit lege sancitum.
- 3 . Remissio si facta sit ei, in cuius defectum alii tenebantur id soluere, si idem debitum a concausis in foro exteriori petatur, committitur contra eos peccatum contra iustitiam, cum restituendi onere, quod ita soluerint, & damna ea via illis data.

PArs affirmās suaderi potest. Primò, quoniam,⁹³ quando sunt diuersæ obligationes ad

eandem rem, ex eo, quòd vna tollatur, non cōtinuò tollitur alia: vt si aliquis teneatur non fornicari, non solùm præcepto iuris naturalis, decalogi, sed etiam ex voto, aut ex iuramento, quo ad idem se astringerit, sanè ex eo, quòd dispensetur in eo voto, aut iuramento, & quòd tollatur obligatio, quæ inde emanabat, ad virtutem religionis spectans, non tollitur altera obligatio iuris naturalis: in re autem proposita, multæ cōcausæ iniustæ eiusdem damni habent vnaquæque suam obligationem in solidum, vt illud restituant: ergo ex eo quòd is, cui facienda est restitutio, remittat vni earum obligationem, qua ei tenebatur, non proinde reliquæ manent deobligatæ, sed perinde tenentur in solidum, ac si illi alteri non esset facta remissio suæ obligationis.

Secundò, si vna earum concausarum impotēs⁹⁴ efficiatur ad restituendum, tollitur illius obligatio, neque ea de causa reliquæ concausæ desinūt esse obligatæ in solidum, vt antea erant: ergo à simili, esto creditor remittat vni earum obligationem, qua ipsi tenebatur, non desinent aliæ manere obligatæ in solidum, vt antea erant.

Obseruandum est. Nos posse loqui, vel de remissione obligationis eius restitutionis, quæ in foro conscientiæ debetur, damni iniustè à multis concausis dati: vel de remissione eius, quod iniustè lēsus poterat in iudicio petere ratione delicti. Hac distinctione præhabita, sequentibus conclusionibus satisfaciendum est quæstioni propositæ.

Prima est. Si loquamur de obligatione restitu⁹⁵endi in foro conscientiæ, tunc, si remissio fiat ei, qui solùm in alterius defectum restituere tene [sect. 1] batur, reliqui, ex ea remissione, non manent deobligati, sed perinde tenentur, ac si facta non esset talis remissio. Excipe, nisi, inter remanentes essent aliqua concausæ, quæ solùm tenerentur in defectum causarum principalium: nam tunc, licèt eiusmodi concausæ non manerent omnino deobligatæ, manerent tamen deobligatæ à portione, quam concausa, cui remissa est obligatio, contribuere teneretur, in defectum, quòd causæ principales non restituerent, aut quòd aliqua cōcausarū minùs principalium non contribueret, quod, in defectum causarum principalium, contribuere tenebatur; iuxta ea quæ disputatione præcedente explanata sunt. Adhibeamus exemplum. Si vnus fuit concausa damni iniusti, quia confecit clauēs, quibus daretur, alius; quia consilium dedit, vt id damnum daretur; & alius, quia tanquam causa principalis in suum solùm commodum, suumque solùm negotium agens, damnum exequutus est, reque ipsa illud dedit; tunc ex eo, quòd is, cui id damnum iniustè fuit datum, remittat obligationem sibi restituendi ei, qui clauēs confecit, deobligati non manent exequutor, qui tanquam causa principalis id damnum dedit, & qui consilium dedit, qui solùm tenetur ad restitutionem in defectum exequutoris; sicut & is, qui clauēs confecit, solùm tenebatur ad restitutionem in defectum eiusdem exequutoris. Cæterum si exequutor non restituat, in defectumque illius restituere debeat, qui consiliū dedit, tunc, quia is, qui clauēs confecit, contribuere debebat cum eo, qui consilium dedit, ad eam restitutionem: vtique tunc, qui consilium dedit, non tenetur restituere totum damnum ab exequutore datum, sed solùm portionem illius, quam cum eo, qui clauēs confecit, contribuere tenebatur: neque enim remissio facta à creditore illi, qui clauēs confecit, debet cedere in præiudicium consiliarii, eumque grauare: quin potius eo ipso, quòd creditor eam remissionem fecit, remississe censetur, ac pro impleto habere, grauamen totum, quod is, qui clauēs confecit, super se induxerat. Conclusio ita limitata, ac declarata, probatur. Quoniam obligatio cæterorū in nullo pendebat ab obligatione eius, cui remissio est facta: neque talis remissio in vllum præiudicium cæterorum cedit, vt explanatum est, quin

potiùs in exemplo proposito cedit in consilarii commodum, qui eo ipso, quòd talis remissio facta est, non tenetur ad restitutionem in defectum eius, cui illa est facta: ergo potest optimè creditor eam remissionem facere, manentibus cæteris obligatis, vt antea erant.

Secunda conclusio. Quando concausa aliqua⁹⁶ restituere aliquid tenebatur, & non in defectū alterius, si creditor illi obligationem remittat, manent cæteræ eo ipso deobligati à restitutione eius, quod illa restituere tenebatur, vt si causæ principali remittat obligationem restituendi, manent reliquæ concausæ deobligatæ à restitutione eius, quod in defectum illius restituere tenebatur. Cōclusiohec satis est perspicua, quoniam obligationes cæterarum causarum, de quibus loquimur, dependētes erant ab obligatione principalis: quia solum tenebantur in defectum illius, si [[250]] non posset, aut non vellet, suam obligationem impellere: sublata autem obligatione principali, cui cæteræ nituntur, sublata eo ipso manent cæteræ.

Tertia conclusio. Si sermo sit de remissione⁹⁷ delicti in foro exteriori, atque de remissione actionis, quæ læso aduersus delinquentes com [sect. 2] petit ad pænam, qua vnusquisque eorum pro eo delicto est dignus, tunc indifferenter potest læsus remittere pænam & actionem, quibuscunque illorum voluerit, & intentare actionem aduersus reliquos, exigendo pænam. Excipe, nisi in euentu aliquo id iure posituo sit prohibitū. Probatur conclusio, quoniam vnusquisque eorum, qui concausæ iniustæ fuerunt eius delicti, fuit in culpa sua propria ac peculiari, factusque est debitor suæ propriæ ac peculiaris pænæ ratione eius culpæ; idque non in defectum, quòd alius puniatur: ex eo enim, quòd alii puniantur, vnusquisque eorum pro quantitate suæ propriæ ac peculiaris culpæ, non desinit alius esse dignus ac debitor suæ peculiaris pænæ pro suæ propriæ culpæ quantitate: ergo poterit læsus remittere quibus voluerit suam actionem ad pænam, illis pænam condonando, non remittendo actionem ac pænam aliis.

Quarta conclusio. Si læsus debitum, damnivē⁹⁸ iniustè dati compensationem, remittat ei, qui principaliter tenebatur ipsi illud restituere, peccat, si in exteriori foro petat, vt, qui in defectū [sect. 3] illius tenebantur illud soluere, illud ipsi soluant. Atque, si quid ita ab eis extorserit, tenetur id illis reddere. Quin, si iis, à quibus ita peteretur, constaret de tali remissione, possent in eodem exteriori foro excipere, illivē objicere, iam id debitum remissum esse illi, qui principaliter illud soluere tenebatur, & in cuius defectum ipsi id soluere tenebantur. Verbi gratia, si quis aliquem iniustè percussit adiutus ab aliis duobus, quos ad id inuitauerat. Tunc, si percussus cōdonet principali percussori expensas, non poterit illas in iudicio, aut extra iudicium, petere ab illis aliis duobus, qui percussorem ad iuuaruntisi autem eas ab illis petat & accipiat, tenetur illas ei restituere. Ratio huius conclusionis est, quoniā debitum pro damno iniustè dato, præcise sumpro à pæna pro eodem delicto, quando ab eis debetur, qui solūm in defectum alterius tenentur illud soluere ac restituere, est depēdens ab obligatione eius, qui principaliter restituere illud tenetur, atque in defectum eius, dum id non soluit, vt soluere illud tenetur: quare, desinente ea obligatione ex eo, quòd formaliter aut virtute satisfecit, remittente illi læso eam obligationē, desiuit quoque obligatio cæterorum, qui in illius defectum eidem læso tenebantur: eaque de causa, si quid tunc ex eis in recompensationem damni illius accipiat, accipitur, quod non debebant, ac proinde tenetur accipiens illud ei restituere. Consentiant cum dictis hac & præcedentibus conclusionibus, quæ Disp. 562 sunt dicta.

Ad duo argumenta proposita, quatenus cum his conclusionibus pugnare alicui videri poterunt, dicendum est.

Ad primum, maiorem esse veram, quando vna⁹⁹ obligatio non pendet ab alia, vt obligatio ad nō fornicandum, quæ est ex iure naturali, non pendet ab obligatione superaddita ex iuramento, aut ex voto, ac proinde hac secunda sublata, manet prima: falsum verò esse de obligatione, quæ omnino pendet ab alia, qualis est concausæ minùs principalis damni iniustè dati, ab obligatione causæ principalis eiusdem damni: vnde, sublata obligatione causæ principalis, tollitur omnino obligatio causæ minùs principalis.

Ad secundum negandum est antecedens, nē¹⁰⁰ pe per impotentiam ad restituendum alicuius ex concausis, tolli obligationem, quam habebat ad restituendum: impotens quippe adhuc manet cum obligatione restituendi, quando potuerit; sed solùm impotentia ad restituendum excusat à peccato non restituendi, interim dum illa perseuerat, & reddit talem impotentem inhabilem pro tunc ad restituendum; ratione cuius inhabilitatis tenentur aliæ concausæ eiusdem damni iniusti restituere loco illius, & ille obligatus manet ad reddendum, quod loco ipsius fuerit restitutum, quando ipse reddere illud potuerit, si ipse sit causa principalis, aut alia quæ exonerata nondum sit ab onere restituendi, iuxta ea quæ conclusionibus propositis, & disputationibus præcedentibus, dicta sunt.

Custodes diuersarum rerum, & alii ministri publici, qui ex officio ad aliqua tenentur, quousq; periuri sint, contraiustitiam peccent, atque ad restitutionem teneantur. Disp. 739.

SVMMARIVM.

1. Custodes, qui inuigilant circa aliquid iniustum, aut iniquum, peccant id, cuius curam habent, exequendo, & tenentur restituere damna ea sua vigilia aliis subsequuta, (regulariter in defectū principalium, qui id munus ipsis iniunxerunt) nisi excusantur inuincibili ignorantia, aut parendo in dubio, quod expellere non possint, supertoribus: neque eos obligat iuramentum de ea re exequenda.

2. Custodes, & alii ministri publici, si id, cuius curam habent demandatam, illicitum non sit, sēq; astrinxerunt iuramento certam formam circa id seruare, quoties illam non seruant, peccatum periurii lethale incurrunt, nisi absque dubito intelligant, qui eos iuramento illo astrinxerunt, no intendisse in eo euentu eos obligare: neque sunt absoluendi, nisi serio proponant, id deinceps non facere, nisi obtenta prius relaxatione quoad id iuramenti.

3. Custodes, & ministri publici, si dissimulatione, aut negligentia ipsorum, dāna dentur circa ea, quorū curam habent, vt quia non soluuntur tributa debita, aut alia ratione, restituere illa tenentur illis, quibus subsequuta sunt, in defectum solū eorum, qui illa dederunt.

4. Custodes, & alii ministri publici, si solū ea permittāt, ex quibus nullum dānū sequitur, nec debetur aliquod tributum, sed solum ea facietes subiacēt pænæ, tunc, qui hæc efficiunt, ad nullam restitutionem tenentur, neque tenentur soluere pœnam, quam incurrerunt, nisi post latam sententiam. Peccant verò transgredientes legem iustam.

5. Custodes, & alii ministri publici, qui eos, qui in pœnas iustè impositas inciderunt, condemnari, vt eas soluant, non curant, aut qui negligentes sunt in illis inquirendis &

cōprehendendis, vt eas soluant, de iustitiæ rigore restituere emolumētum earum tenentur illis, quibus erant applicandæ, si cum tan-[[251]]to onere munus sit ipsis iniunctum, eaque sit voluntas eorum, quibus pænæ sunt applicatæ, & qua moderatione id sit condiendum. Et quid quando pæna est corporalis. Et quid quando minister publicus facultatem dedit, vt id fieret, pro quo pæna pecuniaria est statuta.

6 . Custodes, & alii ministri publici, quando restituere non teneantur, quod acceperunt, vt aliquid sieri permetterent contra munus suum, illo iam opere impleto, & quando restituere teneantur.

7 . Custodes, qui in consinibus regnorum donationes à transeuntibus extorquent, ne eos vexent restituere illas eis tenentur.

8 . Custodes sylvarum, & alii similes, licitè possunt se abscondere, vt transgressores capiant leges transgredientes, neque regulariter tenentur restituere dominis sylvarum damna, quæ transgressores interim dant.

HÆc & sequens disputatio texēdæ sunt circa mutum, non obstantem, & non manifestantem:

examinandumque est, quousq; custodes, & alii ministri publici, quibus ex officio cura ac vigilia incumbit, circa sylvas cæduas, venationem, vineas, transportationem mercium, extractionem earum de nauibus, de domo Indica in Lusitania, & de alia simili Hispali, de Alfandegis, ac aduenis, & vniuersim de ceteris ministris, quibus ex officio incumbit cura, vigilia, ac impedire damna circa quæcunque alia, quousq; inquam, periuri sint, contra iustitiam peccent, restituereque teneantur, si munus suum indebitè exequantur.

Atque loquimur, quando id, circa quod curā [sect. 1] habent, nihil iniustitiæ, nihilque iniquitatis cōtinet. Si enim iniustu id esset, aut aliter iniquum, vt si custodirent syluam, aut vigilarent circa venationē, quæ iniustè, aut aliter cum peccato, prohiberentur, vel si vigilarent circa exactionem tributi iniusti, aut circa aliam rē iniustam vel inquam, tunc, esto iureiurando se astrinxissent ad custodiam ac vigiliam, non peccarent dissimulando cum cædentibus ligna, cum venantibus, cum transeuntibus, aut vendentibus aliqua, sine solutione eius tributi. Ratio autem est, quoniā iuramentum in eo euentu eos non obligat, eo quod non sit vinculum iniquitatis. Imò verò, si contrarium facerent, peccarent, restituereque tenerentur, quantum sua volentium ligna cædere, aut venari, interesset, non prohiberi ac impediri, aut quantum esset tributum, quod iniustè acciperent, & insuper restituere tenerentur alia damna, si quæ vltèrius ex ea iniqua impeditio sequerentur. Sicut enim principes, aut alii potētes, iniustè prohibentes eiusmodi res, aut iniusta imponentes tributa, contra iustitiam peccarent, restituereque tenentur damna omnia inde subsequuta: ita eiusmodi ministri eorum, ac cooperatores ad eadem damna, nisi ignorantia inuincibili iniustitiæ excusentur, obedientiaque id sibi præcipiētium, dum ipsis non constat præceptum esse iniustum, neque ipsis occurrit quid efficiant, vt eam ignorantiam expellant, lethaliter contra iustitiam peccant, restituereque eadem damna tenentur. Quia tamen causæ sunt minùs principales comparatione eorum, qui id eis præcipiunt, solùm tenentur restituere ea damna in defectū causarum principalium, nisi fortè portio aliqua iniustè acceptorum ipsis sit deputata: tunc enim illam acceptam, restituere ipsi tenentur, iuxta ea, quæ præcedentibus disputationibus dicta sunt.

Quando custodes, aut alii ministri publici, li [sect. 2] citè exequi possunt, quod ex officio eis incumbit, quia videlicet id nullam continet iniquitatem, atque ipsis ab eo est id iniunctum,

qui potestatem ad id iniungendum habet, tunc, si sub iureiurando se astrinxerunt, id exequi iuxta formā ipsis traditam, legesque, aut statuta, circa id præscripta, lethaliter peccant periurii peccato, si in aliquo eam formam, ac statuta circa id ipsis præscripta, transgrediantur, nisi in aliquo euentu intelligant, voluntatem eius, qui id onus eis iniunxit, non esse, vt in eo euentu eis statutis, ac modo ipsis ab eo præscripto, se accōmodent, aut quòd non cum tanto rigore ea intelligant, atque exequutioni mandent. Cùm enim iuramentum, ita ab ipsis præstitum, promissorium fuerit, sanè nō plus obligat, quàm fuerit aut sit intentio eius, cui per illud talis minister publicus se intēdit obligare. Atque, post illud præstitum, potest is, cui fuit præstitum, obligationem illius remittere, vel omnino, vel in aliquo, aut in aliquibus euētibz: eaque de causa, si constat, saltem per præsumptionem, quæ nullum relinquat dubium, voluntatem illius non esse, vt in aliquo aut in aliquibus euentibus obliget, tunc, qui illud præstitit, non tenebitur in eo, aut in eis euentibus, illud seruare.

Ex his facile liquet, quid dicendum sit ad illud quotidianum dubium de iis ministris publicis, quos in hoc regno *Alguæziles*, & in Lusitania *Merinhos* vocant, *alcaydes*, & de aliis similibus, qui iureiurando se astruxerunt, debite, iuxta formam ipsis traditam, suum munus exequi, nū lethaliter peccent periurii peccato, si cum aliquibus suis amicis, & cum quibusdam aliis, dissimulent, quos reperiunt, post signum datum cāpanæ, vt omnes de nocte se recipiant, neque iuxta ordinem ipsis præscriptum eos comprehendunt: aut si cum aliquibus dissimulent, qui sericum aliquid, vel rem aliam vetitam, deferunt, atque, iuxta formam ipsis præscriptam, tenētur in eos pānam exequi, quam ea de causa incurrerent. Idem est de quā plurimis aliis rebus, quibus, tam hi ministri publici, quā plerique alii, non se accommodant, cū tamen in forma ipsis tradita contineantur, quam sub iureiurando se astrinxerunt seruare. Respondendum quippe est, nisi ipsis constet, aut absque dubio præsument, mentem eius, cui se eo iuramento astrinxerunt, non esse, vt obligati in eis euentibus eo iuramento sint, in quibus formæ ipsis traditæ nō se accommodant, peccare eos lethaliter periurii peccato: neque esse à confessariis absoluendos, nisi firmiter ac seriò proponant, se in posterum omnino accommodaturos in eis euentibus formæ ipsis traditæ, aut nisi in futurum, relaxationem eius iuramenti in eis euentibus, ac expositionem, ab eo obtineant, cui tali iuramento se astrinxerunt, quòd non intendat in eis euentibus ac cum tanto rigore ipsos obligare. Atque consulendum eiusmodi ministris publicis esset, vt quando munus suscipiunt, eiusmodique iuramētū præstant, significēt, antequam illud præstent, non intendere cum tanto rigore se obligare, quin, nihil ea forma impediēte, possint eos euentus prætermittere, quos omittere intendunt, & quos vt-[[252]]banitas ac lenitas postulat sæpe, vt omittantur, alioquin, vel munus cum tanto rigore non suscipiant, vel formam ipsis præscriptam omnino seruent. Quā maximè autem possum, obnoxie in Christi visceribus, à præsidentibus, regiis senatoribus, & à quibuscunque aliis, quibus id incumbit, peto, vt formas omnes munerum publicorum percurrant, quas sub iureiurando seruare præcipiunt, illasque (quod ad iuramentum attinet) moderentur, vt non sint obseruatu difficiles, aut potiùs, fragilitate humana attenta, & modico timore Dei, qui esse in hominibus solet, impossibiles, & tales eas reddant, vt ministri ipsi publici facile intelligant, quæ sub reatu periurii seruare teneantur, quæ non item: id enim præses senatus, & senatores, quibus id incumbit, facere tenentur, vt euitent innumeras peccati lethalis occasiones; Christianaque caritas id efflagitat: meminertique, se rempublicam secularem teneri moderari accommodatè ad sinem spirituales sempiternæ felicitatis, præscindendo, quā maximè potuerint, peccatorum lethalium occasiones, exactissimeque seruari efficiendo, quæ sub lethali peccato præcipiunt.

Siue autem custodes, & alii ministri publici, de quibus in hac disputatione nobis est sermo, munus iuramento præstito susceperint, siue iuramento minimè præstito, sequentes conclusiones sunt hoc loco statuendæ.

Prima est. Si ex eo, quòd cum aliquo, vel cum¹⁰¹ aliquibus, dissimulent, aut aliquo alio modo suū munus transgrediantur, damnum aliquod iis se [sect. 3] quatur, in quorum bonum munus susceperunt, quia, vel non soluitur eis tributum debitum, vel damnum eorum rebus, aut ad quas ius habent, infertur, vt si vinearum custodes permittant, aut, cū possint, non impedian earum direptionē, vel sylvarum custodes permittant, aut similiter non impedian, scindere, & auferre ex eis ligna, vel custodes locorum ad venandum prohibitorum (nostri *bosques*, lusitani *cautadas* vocant) per mittant, aut non impedian, in eis venari, & alii similes, restituere eis tenentur damnaomnia, quæ ita permiserint, aut, cū possent, non impedierint. Quia tamen non sunt causæ principales horum damnorum, sed minùs principales, non tenentur ea restituere, nisi in defectum eorum, qui illa dederunt, aut debita tributa non soluerunt: vnde, si illi alii restituant, custodes restituere non tenentur: si verò custodes, in illorum defectum, ea restituant, causæ principales restituere custodibus tenentur, quæ loco eorum restituerint, vt hæc omnia ex dictis disputationibus præcedentibus sunt perspicua. Quando autem venantes in loco prohibito cēseantur damnum dare, & quando non, & quousque illud dare censeantur, ac proinde quousque teneantur, aut nō teneantur, ad restitutionem, Disput. 51, iunctis antecedentibus, fuit explanatum. Quousq; item cæsiō lignorum prohiberi possit, aut non possit, & quousque scindentes ligna aliena, aut vtentes alienis pascuis, ad restitutionem teneantur, disp. 46, 58, & 59 est dictum: inde autem pēdet, quātum ex eo capite custodes horum omnium locorum restituere teneantur, in illorum defectū. Conclusio proposita non alia indiget probatione. Cū enim eiusmodi ministri publici causæ iniustæ sint indirectè horum omnium damnorum, satis ex præcedentibus disputationibus liquet, eos ad restitutionem eorum teneri solū in eorum defectum, qui illa dederunt. *Consentiunt inter alios Ioan. Medi. de rest. q. 12. §. antepenul. & vlt. & Nauar. in Manu. c. 17. m. 123.*

Secunda conclusio. Quando custodes, & alii¹⁰² ministri publici, solū ea permittut, ex quibus nullum sequitur damnum, & quæ nullum habēt [sect. 4] tributum annexum, sed solū est pæna imposita iis, qui illa efficiunt, tunc, qui leges tranigrediuntur illa efficiendo, ad nullam tenentur restitutionem, peccant tamen lethaliter, aut venialiter, transgrediendo illo modo leges, pro materiæ qualitate ac quantitate, & pro necessitate, vt rales leges obseruentur, habita simul ratione pænæ eas transgredientibus statutæ, maximè si seuerè ac integre talis pæna exigatur, exequutionivé mandetur. Exempla sunt, vt si quisvenetur, aut piscetur, custode dissimulante, in mensibus ad id faciendum prohibitis. Aut si contra prohibitionem pecora transportet ex vno regno in aliud, quando ex trāsportatione nullum tributum debetur, sed solū transportans incidit in pænam amissionis eorum, aut insuper in aliam, vt in Lusitania ex transportatione boum in hoc Castellæ regnum. Aut si contra prohibitionem transportet triticum, pecuniam, aut aliquid aliud ab vno regno in aliud. Aut si vestes sericas, vel aliquid aliud, gestet contra præscriptum legum. Si ex India transportet merces prohibitas, pro quibus nullum impositum sit tributum, eo quòd prohibitæ sint transportari, sed solū incidat in pænam amissionis earum, & in pænas alias. Prior pars huius conclusionis probatur, quoniam, qui eo modo leges transgrediuntur, non tenentur ad pænam ante latam sententiam, legemque transgrediendo, nullum damnum inferunt, vt suppono, licèt id in reipublice incommodum aliqua ex parte cedat: ergo ad nullam restitutionem tenentur ante latam

sententiam. Quando autem, ita legem transgrediēdo, solūm desraudarent principem, aut aliquem alium, tributo iusto, solūm tenerentur restituere id tributum, non verò pœnam, nisi ad eam soluendam essent condemnati, ab eisq; exigeretur, vt satis liquet. Atque in his omnibus consentit *Ioan. Med. q. 12. citata. §. penult. & vlt. & q. 15. §. penult.* Posterior verò conclusionis pars, quòd scilicet peccent lethaliter, aut venialiter, pro materię qualitate, &c. satis etiam est perspicuà, neque ad hunc locum spectat ea tradere, ac disputare, vnde veritas illius pendet.

Tertia conclusio. In euentu prioris partis cō¹⁰³clusionis præcedentis, quando custos, aut alius minister publicus, qui ex officio ad id tenetur, [sect. 5] apprehendit transgressorem legis in delicto, pro quo pœnam incurrit, atque ad quod delictum illi facultatem non concessit, illumque relinquit, non curans pœnam exequutioni mandari, aut apprehendere ac comprehendere potest talem transgressorem, eumq; non comprehendit, vt pœna exequutioni mandetur, restituere tenetur iis, de iustitię rigore, quibus ea pœna legibus erat applicata, quantum sua illorum intererat, eum comprehendi, pœnamq; exequutioni mandari: nisi sibi constet, aut absque dubio præsumatur, munus non cum tanto onere esse sibi iniunctum, vt teneatur eas pœnas cum eo onere exequi, aut nisi verisimiliter præsumat, illum, qui id munus sibi iniunxit, contentum fore, vt in euentibus, in [[253]] quibus dissimulat, eas non exequatur: in dubio tamen, an cum tanto onere id munus sit sibi iniunctum, & an ea sit voluntas eius, qui sibi id munus iniunxit, tenetur inquirere, qualis sit eius voluntas, illiq; debet se accommodare, alioquin cogendus est restituere, aut remissionem ab iis obtinere, quibus pœnæ illæ erant adiudicandæ ac applicandæ: neque est absolendus, nisi firmiter ac seriò restituere, aut remissionē obtinere, proponat: & nisi seriò similiter ac firmiter proponat, vel exequi in futurum cas pœnas, vel facultatem ad eas non exequendas obtinere in euentibus, in quibus, vel ex misericordia, vel ex amicitia, vel quia alioquin videretur nimius rigor, eas consuevit non exequi, vel nisi munus dimittat, vt de eo, qui sub iureiurando se astrinxit exequi munus suum iuxta formam sibi præscriptam, neque illam integre seruat, suprà est dictum. Hæc conclusio probatur, quoniam custodes, aliiq; ministri publici, de quibus loquimur, ex officio, atque adeò ex iustitia, tenentur comprehendere eos, qui ita delinquant, ac incidunt in prædictas pœnas, curareq; tenentur, vt eæ pœnæ exequutioni mandentur: quippe cū ad id suscipiant tale munus, ad idq; se astringant, quando illud suscipiunt, eaq; de causa concedatur eis stipendium, & concedantur illis emolumenta alia, quæ ex eo munere ipsis proueniunt: ergo iniuriam faciunt illis, iniustitiãq; aduersus eos committunt, quibus pœnæ illæ legibus sunt applicatæ, dum sua dissimulatione, aut negligentia, in comprehendendis delinquentibus, atque in mandandis eiusmodi pœnis exequutioni, eos priuant commodo ac emolumento, quod ex eis pœnis erat ipsis obuenturum. Ita *Ioan. Med. de rest. q. 12. §. antepenult. ac penult. q. 15. §. penult. Angelus & Syluest. verb. pœna. §. vlt. consentaneè ad. D. Tho. 2. 2. q. 67. art. 4. Quicquid in contrarium, cum sancto Bernardino, dicant Nauar. in Manu. c. 25. n. 34. Syluest. (sibi contrarius) verb. rest. 3. q. 5. pronunci. 7.* Licet enim hi tres autores fateantur, eiusmodi ministros periuros esse, lethaliterq; proinde peccare, si iuramento se astrinxerant suum munus exequi; absque vllo tamen solido fundamento asseuerant, eos non teneri restituere pœnam, quam sua culpa omiserunt mandare exequutioni. Tametsi Syluest. ibi solūm loquatur de custodibus ac vigilibus ciuitatum, qui non accusant, quos post campanæ sonum de nocte inueniunt, vt pœna illis statuta, exequutioni mandetur. De quibus sermo erit infrà, dum moderationem quandam eiusmodi conclusionibus subijciemus. Dixi, absque vllo solido fundamento hos

tres autores id affirmare: quoniam hoc vnico fundamento ducuntur. Delinquens ipse, patrato iam delicto, nō debbat pēnam legibus statutam ante latam sententiam: ergo custos, aut quicunque alius minister publicus, qui ex officio tenebatur illum comprehendere, pānamque exequutioni mandare, suaque negligentia ac culpa id omisit, non tenetur restituere emolumentum eius pēnæ, antequam ipse ad id condemnetur. Non videntur autem attendisse, hanc consequentiam esse nullam, hocque proinde eorum fundamentum solidum non esse. Etenim obligatio horum ministrorum publicorum restituendi id emolumētum pānæ, quam sua culpa omiserunt exequutioni mandare, non oritur ex eo, quòd illi, qui in eas pānas inciderunt, illas completè deberent ante latam sententiam: neque item ex eo, quòd ipsi ministri publici eas debeant in pēnam sui delicti, quo cum delinquentibus dissimulauerunt, vel quo negligentes fuerunt in comprehēdēdis illis, vt pānæ exequutioni mādarentur: sed ex eo oritur, quòd sua culpa omittendo pānas illas exequutioni mandare, vt ex officio tenebantur, causa iniusta fuerunt indirecta, quòd illi emolumento earum pānarum priuarentur, quibus legibus erant applicatæ, quibusque erant adiudicandæ, & qui per delictum eorum, qui in eas pānas inciderunt, ius comparauerunt, vt ipsorum efficerentur, si per ministros publicos, vt ex officio tenebantur, mandarentur exequutioni. Quare non valet consequentia illa, delinquentes, qui in eas pānas inciderunt, non tenentur illas soluere, ante latam sententiam aduersus eos: ergo neque custodes & ministri publici, qui in culpa fuerunt, vt pānæ illæ non mandarentur exequutioni, non tenentur restituere emolumentum ex illis, quo iniustè priuauerunt eos, quibus fuissent applicandæ, ante latam sententiam. Delinquentes enim illi solūm tenebantur ad id in pānam, quæ non debetur ante latam sententiam: ministri verò, de quibus loquimur, non tenentur ad restitutionem emolumenti ex tali pāna, in pānam sui proprii delicti, sed tanquam causæ iniustæ indirectæ, quæ eo emolumento priuarunt iniuste eos, qui illo erant potituri, ac proinde, nulla expectata sententia, tenentur illud restituere, tanquam causæ indirectæ iniustæ amissionis illius. Quia verò in eiusmodi ministris publicis solūm consurgit restituendi obligatio, quatenus fuerunt causæ indirectæ eiusmodi damni illis, quibus tales pānæ essent adiudicandæ, consequens est, vt non teneantur illis restituere, quantum æstimarentur pānæ, si integre iam essent solutæ, sed quantum æstimarentur dum erant ita in spe, attento quòd poterat emolumentum illud impediri, & quòd sēpe remitti solet pars earum pānarum, & attentis aliis circumstantils concurrentibus. Consequens præterea est, vt, quando pānæ ipsismet ministris publicis essent legibus applicatæ, ad nullam restitutionem teneantur: & vt, quādo ex parte ipsis essent applicatæ, non teneantur ad restitutionē eius partis, quæ ipsis esset applicata.

Est tamen hæc doctrina prudenter accipienda, excipiendo ab illa, vniuersim sumpta, quæ epicheia, rectæ ratio, excipienda esse docet. Neque enim est credēdū, eis quibus vigilandi, custodiendique de nocte ciuitatem, cura est commissa, cum tanto rigore eam curam esse datam, vt si desides negligētēsve sint in ciuitate post campanæ sonum percurrēda, teneantur restituere pānas, in quas illi inciderunt, quos verisimiliter comprehendissent, si debitam adhibuissent diligentiam. Neque item est credendum, illis, quibus cura est data pānas aduersus eos exequendi, qui vestes sericas, aut aliud, contra præscriptum legis gestant, cum tanto onere id munus esse iniunctum, vt restituere teneantur pānas, in quas illi inciderunt, quos comprehendissent, si desides, aut negligentes, non essent, in illis inuestigandis, ac comprehendendis: & idem est de pānis ludi, & de similibus aliis: neque id habet praxis confessionum aut reipublicæ. Quin, etiam si [[254]] dissimulent cum iis, quos norunt, has pānas incurrisse, dicendum est, non teneri restituere emolumenta harum pānarum,

vt praxis habet, atque epicheia similium legum interpret cuique cordato viro præscribit. Quare dicendum est, attenta qualitate rei, circa quam cura est demandata, cæterisque expensis circumstantiis concurrētibus, iudicandum esse num ii, qui munus iniunxerunt, intenderint minus, aut plus, oneris ea in parte iniungere. Perspicuum quippe est, plus oneris intēdisse principem iis iniungere, maiorēq; restituendi obligationem, quibus curam tradidit vigilandi, ne quid extraheretur de nauibus, aut de domo Indica, vel Alfaudega, aut aduana, quā iis, quibus curam commisit vigilandi, ne quis de nocte post campanæ signum diuagetur per ciuitatem, aut quibus curam commisit vigilandi, ne luderetur certis ludorum generibus, vel ne gestarentur serica, & alia legibus prohibita. Atque hac de causa in conclusione proposita diximus; nisi ministro publico constet, non cum tanto onere munus esse sibi iniunctum, &c. Neque potest certa alia regula statui circa varios euentus in diuersis materiis occurrentibus. Illud est admonendum. Quando pæna imposita non esset pecuniaria, aut rei æquiualentis, vt amissionis mercium, domus, aut partis bonorum externorum; sed esset pæna corporalis, vt flagellorum, inclusionis in carcerem, exilii, & vt sunt aliæ similes, tunc, qui cum incurrentibus has pænas dissimularet, non teneretur restituere earum æstimationem: sed solū teneretur restituere damnum, si quod fortè ex ipsius dissimulatione sequeretur, vel reipublicæ, vel alicui particulari, in cuius commodum id munus susciperet: rarò autem tale damnum deprehendetur.

Dubium est, num, quando custos ipse alicui concessiffet efficere aliquid contra præscriptum legis, pro quo pæna est imposita; quod tamen facturus is non esset, nisi permissu acsacultate custodis, quia nolebat se exponere periculo eius pænæ, num, inquam, tunc teneatur custos pænam restituere, in quam ille alius incidit. Verbi gratia, est pæna imposita, vt qui transportat aliquid ab vno regno in aliud, illud amittat, aut vt soluat tantum, vel tantum; custos autem, pecunia corruptus, aut aliqua alia de causa alicui, qui alioquin rimore pænæ transportaturus non erat eas merces, illas transportare permisit, quæritur, num custos eam pænam restituere teneatur, quam ille incurrit. Atque dubitandi ratio hæc est. Quoniam, vt dictum est, custos solū tenetur pænam restituere, quatenus est causa indirecta damni, priuans eum, cui pæna lege est applicata emolumēto eius pænæ: in euentu autem proposito custos nullius damni est causa; eo quòd is, cui eam facultatem concessit, incursum non erat eam pænam, seclusa tali facultate, vt supponimus: ergo ad nullam restitutionem tenetur ratione talis pænæ, quando illi, in cuius commodum custos est constitutus, nullum aliud damnum inde prouenit. Partem tamen contrariam persuadere videtur. Quòd eo ipso, quòd ille alius transgressus est legem, incurrit pænam ea lege statutam, nihil impediēte, quòd custos iniquè eam facultatem illi concesserit: vnde ex eo, quòd custos, post pænam incursum, non curat, vt ea pæna exequutioni mandetur, vt ex officio tenetur, curare illam exequutioni mandari, priuat iniustè cum, cui pæna illa lege est applicata, emolumento talis pænæ. Res aliquantulum est mihi dubia. Atque propenderem, custodem, de iustitiæ rigore, teneri ad aliquam restitutionem eius pænæ: non tamen dicerem, teneri ad tantam restitutionem, ad quantam teneretur, si de ipsius consensu, ac præuia facultate, non esset commissum tale delictum: sed teneri solū ad restitutionem partis eius pænæ arbitrio prudentis. Quoniam licèt, si facultatem non dedisset, nec incurreretur nec deberetur pæna, ac proinde id in causa sit, vt non obligemus eum ad integrum emolumentum ex ea pæna: esse tamen illum indirectam causam priuationis emolumenti eius pænæ, postquam pæna, præcedente ipsius facultate, est incursum, efficit, vt non deobligemus illum à restitutione partis eiusdem emolumenti, prudentis arbitrio.

Quarta conclusio. Quando custos, aut a¹⁰⁴lius minister publicus, aliquid accepit, vt in a [sect. 6] liquo delicto consentiret, de quibus præcedentes conclusiones loquuntur, delictumque est iam exequutioni mandatum; tunc, si obligatio, quam ea de causa in se susceperat, restituendi, quæ præcedentibus conclusionibus dicta sunt, periculumque, cui se exposuit, vt ea de causa puniretur, famamque amitteret, dignum sit tanto pretio, vtique, quamuis peccauerit similia accipiendi, nec sit absoluendus, nisi seriò ac firmiter statuatur, se deinceps nihil tale facturum, non tamen tenetur id restituere. Quòd si id, quod ita accepit, excedens sit pretium pro oneribus ac periculis, quæ in se suscepit, restituere tenetur incrementum. Vtraque pars conclusionis satis liquet ex dictis Disput. 94, iunctis antecedentibus disputationibus. Sicut enim, qui pretium accipit, vt aliquem interficiat, non tenetur, post delictum patratum, restituere, quod accepit, modò non acceperit excedens pretium, habita ratione onerum ac periculorum, quæ in se pro eo pretio suscipit, vt Disp. 94 ostensum est: ita res habet in proposito.

Quinta conclusio. Custodes, qui in regno¹⁰⁵rum confiniis donationes extorquent, ne transeuntes indebitè vexent, restituere tenentur, [sect. 7] quæ ita à transeuntibus accipiunt. Idem est dicendum de quibuscunque aliis custodibus, qui simili modo aliquid extorquent. Probatur conclusio, quoniam nullus alius iustus est titulus, quo similia possint accipere, quàm donationis titulus; quòd autem donatione nec dominium, nec ius, acquirant ad ea, quæ ita accipiunt, ex eo satis liquet, quòd dantes inuoluntariè mixtè id dant ad redimendam suam vexationem: id quod non sufficit ad transferendum dominium, aut ius, titulo donationis, vt sæpe in hoc tractatu dictum comprobaturque est, satisque est perspicuum in usurario, qui ea sola do causa nec dominium, nec ius, comparat eorum, quæ per vsuram acquirit.

Ioan. Med. de rest. q. 12. §. vlt. quem nonnulli ex recentioribus theologis sequuntur, affirmat, custodes, qui se abscondunt, vt capiant legum transgressores, pænasque legibus statutas ab eis exigant, quando, si custodes vidissent, transgressi non fuissent leges, neque in eas pænas incidissent, duplici ex capite peccare. Nempe, quia non impediunt peccata [[255]] eo modo leges transgredientium, quæ tamen possent impedire: & quia permittunt inferri damna dominis, à quibus constituti sunt custodes, dum priùs sinunt scindere ligna in syluis, quas custodiunt, aut venari in saltibus prohibitis. Asseuerat etiam, eiusmodi custodes restituere teneri dominis damna, quæ ita permittunt, nisi ex pænis tantundem commodi eisdem dominis proueniat.

Nostra verò sexta conclusio est. Neque custo¹⁰⁶des tenentur se manifestare iis, quos leges transgressuros esse suspicantur, nisi se illis manifestent; [sect. 8] imò verò possunt se abscondere, vt eos cõprehendant: neque regulariter tenentur dominis, quorum res custodiunt, ad vllam restitutionem damnorum quæ legum transgressores in rebus illorum dant. *Ita Nauar. in Manu. c. 17. n. 124.* atque id habet communis custodum, quin & confessionum, forique externi, praxis. Prior verò pars probatur, quoniam, vt in hac 2. 2. in materia de correctione fraterna ostendimus, fas est, permittere vnum peccatum, vt multa euitentur: nisi autem custodes se occultarent, multo plura peccata fierent, quàm sint illa, quæ se occultando permittunt, eo quòd homines rarò à custodibus comprehenderentur in delicto, eaque de causa audaciores fierent ad leges transgrediendas, pluresque ad eas transgrediendum accederent: ergo fas est custodibus se abscondere, permittereque aliquas transgressiones inchoari, vt tam in eis comprehensi, quàm alii, similia in posterum non audeant. Præterea quoniam, licet quibus teneatur vitare peccata & damna proximorum, si id possit sine suo temporali incommodo; aliquando tamen potest illa permittere, vtendo

peccatis aliorum in suum commodum, vt patet de eo, qui, quando indiget, sub vsuris petit; sed, nisi custodes, se occultādo, permetterent aliqua peccata, vt delinquentes punirentur, non bene custodirentur syluæ cæduæ, loca venationum, trāsitus de regno in regnum, & similia alia: ergo, ne in his domini tantum detrimentum temporale patiantur, fas est custodibus, se occultando, permittere aliqua peccata, quæ puniantur. Posterior verò conclusionis pars ex eo est perspicua, quòd regulariter tam citò possunt custodes accurrere, vt vel nullum detur damnum rebus, quas custodiunt, vel adeò paruum, vt longè plus præponderet custodiri eo modo res illas, cæterosque timore pænæ similia non euadere. Præterea domini pænis compensant parua damna ita accepta. Adde, vltra pænas, exigere etiam posse damna data.

Vtrùm custodibus, similibusque aliis ministris publicis, fas sit conuentionem facere circa pænas. Et vtrùm restituere teneantur, si quid ita accipiant, antequam ipsis, lata sententia, adiudicetur. Disp. 740.

SVMMARIVM.

1. *Cvstos, & alius minister publicus, si prohibitus sit facere conuentionem circa pænam incursum ante latam sententiam, peccat illam faciendo, & periurus est, si dum id munus accepit, iuramentum præstitit, quòd ad id se extendat. Quòd si simul alios priuet emolumento, quod inde habere debebant, quousque restituere teneatur.*
2. *Conuentio pro pæna incursum non est illicita ex natura rei ante latam sententiam. Et, esto sit prohibita fieri, nulla oritur obligatio restituendi ei, qui illam incurrit. Et quando nulla est obligatio restituendi etiam aliis.*
3. *Custodes sylvarum cæduarum, & aliarum similiũ rerum, qui conductas habent pænas, ob delicta circa ea commissa, restituere tenentur pretium, quod acceperunt, vt impunè possent cedere ligna, aut aliud prohibitum facere, pro quo pæna est statuta.*
4. *In eiusmodi euentu, quando ita damnum esset datum communitati, aut priuato, qui illud dedit, teneretur restituere, & in defectum illius tenetur custos, possetque id restituere de pretio pro ea facultate accepto, & si quid superesset, restituere illud teneretur danti.*

DE duplici conuentionis genere circa pænas possumus agere. Primum est, circa pænas iam incursas, ob delictum commissum, pro quo pæna est imposita, & in quo delinquens fuit deprehensus. Secundum verò est, circa pænas nondum incursas, ita vt, soluta certa quantitate, esto postea delinquens deprehendatur in delicto, vt cædendo ligna, aut pascendo in loco prohibito, nihil soluere teneatur.

Quod attinet ad primum conuentionis genus, solent delinquentes, quando in delicto sunt deprehensi, pro quo pæna est statuta, offerre custodi, aut alicui alteri ministro publico, qui eos deprehendit, & cui exequutio eius pænæ incūbit, vel integram pænam, vt se liberent à molestia comparendi in iudicio, & faciendi fortè alios sumptus in expediendo coram iudice suo negotio, aut etiam vt se liberent ab ingressu in carcerē, vel offerre illi partem pænæ, petēdo ab illo vt illa sit contentus, eosque relinquat liberos: id quod custodes, & alii ministri publici,

solent sæpe accipere, vel ex misericordia, vel quia ipsi plus ea ratione lucrantur. Quæritur ergo, vtrùm hæc omnia non solùm illicita sint, sed etiam ministri id accipientes teneantur illud in conscientia foro restituere, & cui facienda sit restitutio.

Et quòd illicitè id accipiant, teneanturque in conscientia foro illud restituere, suaderi potest. Primò, quoniam pæna non debetur ante latam¹⁰⁷ sententiam: neque, qui id ad redimendam suam vexationem dat, habet animum illud donandi, quin potius inuoluntariè mixtè id dat: ergo, qui id accipit, inuito domino accipit, quod sibi non debetur, ac proinde tenetur illud restituere.

Secundò, *quoniam lib. 1. Lusit. ord. titu. 56. §. 19.*¹⁰⁸ iis ministris, quos *alcaydes* vocant, prohibetur facere conuentionem cum iis, quos de nocte post campanæ sonum comprehendunt, circa pænas, quas incurrunt, antequam illis per sententiam adiudicentur, idque sub certa pæna ibidem eis statuta: atque eodem modo videtur in eo regno, & in cæteris, prohibitum aliis ministris publicis similes conuentiones facere circa pænas ante latam sententiam, qua ipsis adiudicentur: ergo nō solùm est illis nefas eas conuentiones facere, sed etiam tenentur restituere, si quid ita acceperint. Patet consequentia, *quoniam. l. non dubium. C. de legib. habetur*, quicquid contra legum prohibitionem fit, esse ipso iure nullum, neque esse opus [[256]] legemaddere, quòd si contra legem aliquid fiat, fit nullum, sed eo ipso, quòd lege est prohibitum, esse nullum.

Res hæc sequentibus conclusionibus est definienda¹⁰⁹. Prima est. Quando ministro publico est prohibitum conuentionem facere circa pænam [sect. 1] ante latam sententiam, peccat talem conuentionem ante sententiam latam faciendo. Atque si iuramentum præstitit, suum munus fideliter exequendi iuxta formam ac leges circa illud præscriptas, periurus est eas conuentiones faciendo. Præterea, si prohibitus sit eas conuentiones facere ante latam sententiam, ne publicos alios ministros priuet emolumento aliquo, vt carceris custodem stipendio, quod illi ex eo erat soluendum, quòd comprehensus, in vincula erat conjiciendus, & ministros alios emolumento alio, tenetur illis ad aliqualem restitutionem, ita contra iustitiam eos priuando eo emolumento, quantum æstimabitur damnum, inde illis subsequutum, prout ita erat in spe: nisi non tanto cum rigore sit eis munus iniunctum, vt Disputatione præcedente dictum est. Conclusio hæc perspicua est quoad priorem partem, quoniam is minister publicus legem iustam transgreditur sibi impositam, atque iuramentum de re licita. Quoad posteriorem verò partem ex eo etiam liquet, quòd causa, saltem indirecta, sit eius damni, non seruando, quod ex officio seruare tenebatur.

Secunda conclusio. Quando ea pæna lege¹¹⁰ statuta, non erat deputata ei soli ministro publico, sed vel tota, vel pars illius, ad alios attinebat, restituere illis tenetur, si in aliquo eos defraudauit, eam conuentionem faciendo: nisi nō cum tanto rigore sit ei munus iniunctum, vt dictum est. Hæc ex probatione posterioris partis conclusionis præcedentis est manifesta: quoniam fuit causa, saltem indirecta, damni ita illi subsequuti.

Tertia conclusio. Ex natura rei licita est conuentio¹¹¹ pro pæna iam incursa, facta ante latam sententiam. Probatur, quoniam eo ipso, quòd [sect. 2] aliquis delictum commisit, pro quo pæna est statuta, oritur ius aduersus delinquentem ad eam pænam ab eo exigendam; quod ius pecunia est æstimabile; & regulariter tantum valet, quantum valet ipsa pæna, si tota sit adiudicanda ac soluenda: ergo, si is, ad quem pæna spectat, delinquentem comprehendat, & cum eo circa eā pænam conueniat, licitè, quantum est ex natura ipsa rei, accipit competens pro ea pretium. Et eadem ratione, si ex facultate eius, cui ea pæna lege est applicata, faciat conuentionem, licitè etiam pro ea accipit competens pretium. Quo fit, vt

quando eiusmodi conuentiones lege non sunt prohibitæ, sed iudex est deputatus in solùm commodum eius, cui pænæ sunt deputatæ, vt illas exequutioni mandet, delinquensque audiatur, ac cogatur eas soluere, licitæ sint eiusmodi conuentiones nulla expectata sententia. Quare, cùm legis prohibitio incapacem non faciat ministrum publicum eius, quod ita per conuentionem accipit, vt ex solutione argumentorum patebit; consequens profectò est, vt, quando ipsimet ministro legibus est decreta, quamuis peccet, ita contra legis prohibitionem tales conuentiones faciendo, non tamen teneatur restituere, quod eo modo per illas acceperit. Ad primam ergo partem antecedentis primi¹¹² argumenti propositi dicendum est, quamuis pænâ in hoc sensu ante latam sententiam non debeatur, quòd delinquens non teneatur eam exequi aduersus semetipsum, atque illam offerre ei, cui à lege est applicata; statim tamen patrato delicto, maximè deprehenso in illo delinquente, consurgere ex tali delicto ius pecunia æstimabile ad eam pœnam ex delinquente exigendam, idque ius ex natura ipsa rei posse licitè vendi. Vnde ad argumentum in forma, concessa prima antecedentis parte in eo priori sensu explicato, & concesso reliquo eiusdem antecedentis, neganda est consequentia, si consequens intelligatur, ita accipi inuito domino, seu inuoluntariè mixtè, quod non debetur, quasi accipiens non habeat iam ius pecunia æstimabile ad eam pœnam, quod, quantum est ex natura rei, possit licitè vendere pro eo, quod ita ei datur in recompensationem pro eo iure: quando autem aliquid alicui datur, non via donationis, sed oneroso contractu in recompensationem pro aliquo, tunc inuoluntarium mixtè, quo dans nollet id dare, nisi ita esset sibi vtile, aut necessarium, in recompensationem pro alio, quod illud valet, neque impedit transsationem dominii, neque efficit acceptionem iniustam, aut illicitam, vt sæpe in hoc secundo tractatu dictum est.

Ad secundum, concesso toto antecedente, ne¹¹³ ganda est consequentia. Ad probationem verò dicendum est, in calce Disp. 88, & in materia de ludo, esse dictum cum Panor. & plerisque aliis, eam legem intelligendam esse, quando lex aliqua solùm prohibet aliquid, neque vltèrius progreditur ad pœnam imponendū: lex autem Lusitana relata pœnam apponit, & idem facere videntur aliæ similes leges. Præterea dictum est, eam legem, quando solùm prohibet, neque vltèrius progreditur ad pœnam apponendam, intelligendam esse in foro exteriori, & post latam ea de re sententiam: neque vsu esse aliter receptam. Adde, esto, quando lex aliquid prohibet, contractus esset ipso iure nullus, nihilominus, quando contractus esset onerosus, quo daretur vnum in recompensationem pro alio, non teneretur vnus contrahentium reddere, quod accepit, nisi sibi redderetur, seu recōpensaretur, quod pro eo dedit, vt in calce Disp. 405 ac alibi in hoc tractatu dictum est: in re autem proposita, minister publicus non accipit gratis, quod sibi datur conuentione facta circa pœnam incursum, sed id accipit in recompensationem pro iure, quod remittit, atque vt desistat à pœnæ prosecutione: quo fit, vt in conscientia foro non teneatur reddere, quod accepit, nisi sibi recompensetur ius, quod pro eo remisit. Quod attinet ad secundum conuentionis genus circa pœnas nondum incursum. Abusus est multis in locis in Lusitania, & aliquibus in locis in hoc Castellæ regno, vt prohibeatur cædere ligna in aliquibus syluis cæduis, sub certis pœnis, & locentur pœnæ alicui pro aliqua nummorum summa, quam ille soluat communitati loci ad sumptus publicos, ipseque conductor earum pœnarum eam syluam custodiat ac perfruatur pœnis, quas exegerit ab illis, quos deprehenderit in eo delicto cæsionis lignorum in ea sylua. Et quidem, si hæc sincerè fierent, neque id damnares, neque appellares abusum. Cæterum communi-[[257]]tati ipsi, seu capitibus communitatis, qui has pœnas locant, (*Camara* in Lusitania nuncupantur, quæ constat iudice & *dos vercadores*, quos vocant, & in hoc Castellæ regno *aiuntamiento* dicitur,

cōstatque iudice *y de los regidores*) compertum est, hos conductores harum pænarum cum multis cōventionem facere, vt ipsis quotannis, aut aliis statutis temporibus, certum quid soluant in pecunia, tritico, aut in alia re, atque impunè scindant, quæ voluerint, quod nullum ius nullaque æquitas patitur. Multæ aliæ pænæ locantur in Lusitania simili modo, vnde non modici abusus conscientiarumque pericula oriuntur.

Hac autem de re, quarta nostra conclusio in¹¹⁴ ordine est, tam hi, quàm quicumque alii custodes, aut ministri publici, qui pro pretio permittunt aliquibus leges transgredi, tenentur restituere illis pretium, quod eo modo ab illis accipiunt. Probatur, quoniam ante transgressionem legis nullum ius habent acquisitum ad pænā: neque in eorum potestate est permittere transgressionem legis, & multo minùs accipere ea de causa pretium: imò neque respublica ipsa, quæ eis eas pænas locauit, potest pretium accipere pro permissione transgressionis legum: ergo tenentur id pretium restituere. Dices. Sæpe tempore restitutionis ii, qui pretium dederunt, transgressi sunt legem, in longeque maiores pænas inciderunt, quam sit id pretium, quod dederunt: ergo cōductores pænarum retinere possunt pretium acceptū pro eis pænis iam tunc incursis. Neganda tamen est consequentia. Tum quia transgressores legis nō tenentur soluere pænas præteritas, nisi aduersus ipsos delictum sufficienter probetur, ac condēnentur eas soluere: qui autem eas pænas conduxerunt, ad id non habent probationem sufficientem: neque, qui legem sunt transgressi, darent tunc id pretium pro iure, quod conductores pænarum tunc habent ad eas pænas iam præteritas. Tum etiam quoniam, si in iudicio constaret de illa cōuentione facta pro permissione transgressionis legis, non adiudicarentur pænæ illi conductori pænarum, sed potiùs noua aliqua pænā pro illa conuentione facta puniretur.

Quinta conclusio. Quando ex eiusmodi trās¹¹⁵gressionibus legis, ita conuentione permissis, damnum aliquod sequeretur communitati, aut [sect. 4] priuato, ad quem ea res spectat, circa quam facta est transgressio, tenerentur, tam qui illud dedit, quàm conductor pænarum, qui ea conuentione illud permisit, restituere illud ei, cui est datum. Qui tamen illud dedit, teneretur principaliter; conductor verò pænarum, qui ea conuentione illud permisit, solūm teneretur in defectum principalis, qui illud dedit. Vnde conductor pænarum, de pretio conuentione accepto, posset id damnum restituere. Quòd si aliquid pretii superesset, restituere teneretur tale incrementum ei, à quo id pretium accepit. Quādo autem transgressor legis solūm teneretur ad pænā, iuxta ea, quæ Disp. 58, 59, dicta sunt, tūc conductor pænarum teneretur restituere ei integrum pretium, quod pro permissione trāsgressionis legis accepisset. Tota hæc conclusio satis est perspicua, neque probatione alia indiget. Qui autem huiusmodi pænas statuunt, ac locant, cauere tenentur, ne pænæ, quas statuunt, solūm sint, vt inde habeant annuos redditus, extractos cum tanta inæqualitate eorum, qui sunt de populo, conductoribusque harum pænarum longè plus extrahentibus à populis, vnde ipsi viuant, & soluant pretium conductionis talium pænarum: simul etiam cauere tenentur, ne locationes eiusmodi pænarum pariant adeò perniciosum abusum, vt permissiones transgressionum legum vendantur. Confessarii autem examinare hac de re seriò debent, maximè in Lusitania, eos, qui eiusmodi pænas locant, eorumque conscientias grauare debent, vt par est, quoad hos, & alios similes abusus, qui etiam sequuntur, *de varias posturas das camaras*, quæ solūm respiciūt commoditatem propriam eiusmodi ministrorum, aut paucorum de republica, cum damno artificum, ac cæterorum de populo: aut quæ, cum modico emolumento reipublicæ, multum innodant conscientias hominum. Audiui, dum Euoræ commorarer, taxari calcem tam modico pretio, vt si, qui illam conficiunt, eo pretio vendituri illam essent, inde non

extraherent sumptus, quos in ea conficienda efficiunt: & tunc ministros cameræ, ac iustitiæ, accipere illam eo pretio, cōfectoresque calcis tam magno pretio, vltra iniustè ita taxatum, reliquum calcis aliis impunè vendere, vt ab aliis id etiam recuperent, quod cum prædictis ministris publicis amiserunt. Similia alia audiui, quæ num vera sint, qui mihi ea retulerunt, ministrique ipsi publici, viderint.

Cui facienda sit restitutio. Et num fieri debeat domino, prætermisso non solùm iniusto illius rei detentore, sed etiam iusto. Disput. 741.

SVMMARIVM.

1. *Restitutio ei regulariter est facienda, ex quo res est ablata, aut in cuius potestate damnum est datum.*
2. *Restitutio ei est facienda, qui non iniustè illam tenebat, esto ad alium quoad dominium attineret, restituendæque ei sunt omnia damna ex ablatione eius rei, aut destructione, illi sequuta, etiamsi restituta sit proprio domino, admonendusque est proprius dominus esse restitutam.*
3. *Eidem tenenti est restituenda in dubio, an iniustè illam detinebat. Quando constabat, ad eum non attinere, restituenda est proprio domino, certiorè faciendo detentorem, restitutam esse, quoad commodè fieri posset. Non tamen licet ex illo eam accipere, vt restituatur domino, nisi quando dominus posset illam occultè compensare, aut in flagranti delicto.*
4. *In quo euentu prædo restituendus est in possessionem rei alienæ, qua fuit spoliatus.*
5. *Quando, qui non iniustè rem antea tenebat, incipiat iniustè illam detinere, quando tertius aliquis, si ad potestatem ipsius deueniret, posset illam tradere domino, & quando occultè eam posset accipere & tradere domino.*
6. *Restitutio eorum, quæ ex eis accepta sunt, qui administrationem eorum non habent, non ipsis, sed legitimis earum rerum administratoribus est facienda: cum quanta tamen minori iactura eorum, ex quibus accepta sunt, fuerit possibile. Neque administratoribus detegenda sunt furta aliorum, nisi id sit necessarium omnino, vt impediatur [[258]] damna iniusta in futurum, & consulatur saluti spiritali ita furantium.*
7. *Restitui etiam in foro conscientie fisco, & non delinquenti, aut hæredibus illius, ea debent, quæ tempore latæ sententie confiscationis delinquenti debebantur, sub onere id iterum fisco restituendi. Nisi deberetur res determinata in indiuiduo, & per ignorantiam inuincibilem restitueretur alteri, & tunc curandum sine proprio detrimento est, vt fisco reddatur.*
8. *Restitutio accepti illicitè, tam quando dans illicitè dedit, quam quando dedit licitè, cui facienda.*

Explicato præcedentibus disputationibus, [sect. 1] qui restituere teneantur: consequenter est dicendum, cui restitutio fieri debeat. Atque cum dino Tho. 2. 2. q. 62. art. 5. & cum communi doctorum sententia est dicendum: Regulariter ei esse faciendam restitutionem, à quo id, quod est restituendum, fuit ablatum, vel cui damnum iniustè fuit illatum, quando

ratione damni iniuste illati restitutio est facienda. Probatur, quoniam restitutio ordinatur ad reducendam ad æqualitatem inæqualitatem effectam per acceptionem, aut damnum illatum: ergo ei regulariter facienda erit restitutio, à quo fuit acceptum, quod est restituendum, cuius damnum fuit illatum. Atque videtur D. Tho. loqui de restitutione pressè sumpta. Dictum autem est, regulariter: quoniam regula tradita suas habet exceptiones: quarum quædam hac & sequētibz disputationibus subjicientur; aliæ verò suis locis explanantur.

Obserua autem, restitutionem ei esse facien [sect. 2] dam, ex quo res restituenda fuit ablata; modò ille iusto titulo illam teneret, siue esset dominus illius, siue non. Quo fit, vt, quod iniuste fuit ex eo acceptum, qui illud tenebat in pignus, depositum, commodatum, conductum, aut alio simili non iniusto titulo, ita quòd non esset in mora iniusta reddendi illud proprio domino, illi sit restituendum, non verò domino rei illius. Tum ne priuatur commoditate, quam ex ea re poterat licitè absque iniustitiæ vitio percipere, aut ne priuatur iure, quod in ea re habebat. Tum etiam, quoniam ipsi incumbit onus reddendi eam rem proprio domino. Tum denique, quoniam iniuria est illi facta spoliatione, ipso inuito, rei, quā ita tenebat, quin & furtum est aduersus eum commissum, vt Disp. 681, 690, & 696 fuit comprobatum: eaque de causa ipsi est restituenda. Quin & restituenda sunt ei omnia damna, etiam lucri cessantis, ei ex tali iniusta rei ablatione ac detentione subsequuta: inter quæ computa, si quid insumpsit in ea re quærenda, aut si quid lucri ea de causa omisit. Quando autem, eo prætermisso, res illa proprio domino restitueretur, tunc tali legitimè eam tenenti, à quo iniuste fuisset ablata, restitutum esset emolumentum ex ea re, si quo ita fuisset iniuste priuatus auferendo illam ab eo, nec eam illi reddendo, & insuper essent ei restituenda quæcunque alia damna vltèriùs ei inde essent sequuta, atque certior esset faciendus, rem esse iam in potestate proprii domini, ne anxietur, & ne eam iterum illi restitueret.

Quando autem aliquis rem alterius iniuste [sect. 3] detineret, tunc, si ex illo acciperetur, restituenda esset, non ei, ex quo fuisset accepta, sed proprio domino: modò tamen apertè constaret, rem ad illum, ex quo fuit accepta, non attinere, sed ad illum alium. Vt si aliquis ex fure, aut ex alio, cui fur eam tradidisset, accepisset rem ad alium attinentem, restitutio tunc facienda esset proprio domino, non verò ei, ex quo fuisset accepta: nisi securè constaret, eum, ex quo fuisset accepta, restitutum illam esse proprio domino. Si enim, vt Disp. 722 fuit ostensum, neque is, qui bona fide rē furto ablatam emit à fure, potest illam ei reddere, vt suum recuperet pretium, sed tenetur restituere illam proprio illius domino; quanto magis, qui nihil amittit restituendo proprio domino rem, quam ex fure accepit, tenetur eidem proprio domino, & non furi, eam restituere? Dixi, rem esse restituendam proprio domino, modò apertè constaret, eam non attinere ad illum, ex quo fuit accepta, sed ad illum alium: quoniam in dubio reddenda ei esset, ex quo proximè fuit accepta: eo quòd in dubio sit melior conditio eius, qui proximè illam possidebat, vt fiat ei restitutio illius. In his conueniunt doctores communiter, *Caiet. 2. 2. q. 62. art. 5. in summa verb. restitutio. c. 4. Ioan. Med. de rest. q. 2. à. §. de eo quod secundo loco, Sotus 4. de iust. q. 7. art. 1. Syluest. verb. rest. 4. q. 3. & alii.* Quando res proprio domino restituitur, prætermisso eo, ex quo proximè fuit accepta, qui illam tradere eidem proprio domino tenebatur; tunc, qui id efficit, curare tenetur, tum ne prior illius iniuste derentor, pænitentia ductus, eam iterum eidem proprio domino restituat, ignorans restitutam illi iam esse: tum etiam, ne idem proximus iniustus rei illius detentor in peccato perseueret, credens se adhuc teneri eam rem restituere, nec illam restituens: eaque de causa, si fieri commodè possit, significandum illi est, redditam iam esse proprio domino, vt Disp. 690 & 691 dictum est. Hoc autem loco obserua, sicut proprio domino licitum non

est auctoritate propria, vi accipere, quod suum est, de manu furis, nisi in flagranti delicto, etiam absq; vi, quando via iudicis potest commodè id recuperare, vt Disp. 691 est dictum: ita longè maiori cum ratione neque alius potest id in eisdem euentibus accipere, vt illud reddat proprio domino. In foro tamen conscientiæ, quando credit dominum fore contentum vt id accipiat, concurruntque conditiones, cum quibus Disp. 691 citata fuit explicatum, licitam esse occultam compensationē, poterit id accipere, vt illud tradat proprio domino. Ratio autem est, quoniam id non est aliud, quàm cooperari ad acceptionem, quam dominus rei illius per se, vel per alium, licitè poterat mandare exequutioni. Quod autem in hac Disputatione querimus, non est, vtrùm liceat accipere rem ex fure, aut ex alio, cuius non est, & tradere eam domino illius; sed num, quando aliquis restituere tenetur rem, quam ex eo accepit, ad quem non pertinebat, teneatur eam restituere illi, ex quo illam accepit, an verò ei, ad quem verè pertinet. Respondemusque, restituendam illi esse, ad quem verè ac indubitatè pertinet.

Quòd si quis objiciat. c. in literis de rest. spol. [sect. 4] cui consentit. l. 1. §. eunuchi, vers. qui à me. ff. de vi & viarmata, vbi habetur, de rigore iuris prædonem restituendum esse in possessionem rei, ex qua vi fuit deiectus. Præterea, quæ in calce Disp. 722 ea de re sunt dicta: Dicendum est cum [[259]] Panor. in idem caput, & cum doctoribus, quos suprà citauimus, caput illud intelligendum esse, in foro exteriori, quando apertè non constat, aut in continenti apertè non probatur, eum, ex quo res accepta est, fuisse iniustum eius rei occupatorē. Ordo quippe fori exterioris summa cum ratione postulat, vt, quando à principio iudicii apertè nō constat, vi spoliatum re, quam antea possidebat, non fuisse iniustum illius occupatorem, restituitur in possessionem eius rei, à qua ita fuerat eiectus, posteaque aduersus illum audiatur, qui cōtendit, rem non esse illius. Forum autem conscientiæ, quando apertè constat, rem ad illum non attinere, id non habet.

Dubium est, vtrùm si aliquis à principio cæ [sect. 5] pit rem aliquam titulo iusto tenere, vt commodatam, aut in depositum, postea verò eam iniustè detineat, quia transactum est iam tempus, pro quo erat ei data, nec vult eam restituere, fas sit cuidam tertio illam accipere ex illo, ac tradere proprio domino. Aut, si casu aliqua ratione ad manus ipsius deuenit, an restituere illam debeat domino rei illius, vel iniusto illi detentori? Atque respondendum est: Quando dominus commodè potest illam obtinere via iudicis, tunc, sicut nefas est proprio domino auctoritate propria illam eripere de potestate iniusti illius detentoris, vt Disp. 691 est dictū: sic longè maiori cum ratione, nefas est cuidam tertio, eam similiter eripere de potestate talis iniusti possessoris, vt reddat eam proprio illius domino. Quando autem dominus non posset commodè via iudicis illam obtinere, tunc, sicut cessante scandalo, & concurrentibus cōditionibus, de quibus Disp. 691 est dictum, posset dominus clàm eam eripere de potestate iniusti detentoris, vt ibidem explanatum est: Sic etiam quicumque alius, de præsumpta domini illius rei voluntate, concurrentibus eisdem conditionibus, posset ac deberet in conscientiæ foro eam accipere, ac tradere eiusdem rei domino. Et longè maiori cum ratione, si casu in manus ipsius deuenisset, posset in conscientiæ foro, ac deberet, eā reddere proprio illius domino. *Ita Nauar. in Manu. c. 17. n. 28.* Ne tamen fortè in exteriori foro id in aliquo ei præiudicaret, posset admonere dominum eius rei, vt iudicis auctoritate eam sibi traderet tanquam suam.

Quando aliquid acceptum esset ex filio fami [sect. 6] lias, pupillo, aut ex quocunque alio minore, amente, vel prodigo, cui datus esset curator, si administratio rerum ita acceptarum ad eos non attineret, ex quibus essent acceptæ, tunc restitutio facienda non esset iis ipsis, ex quibus essent acceptæ, sed illis, quibus administratio earum rerum incumbit, putà patri,

tutori, aut curatori, quando hi contenti non essent, quòd illis aliis fieret. Hac eadem ratione, si aliquid ex religioso esset acceptum, cui administratio eius rei concessa non esset, sed prælato, non esset id restituendum tali religioso, sed prælato. Idem est dicendum, quando aliquid ex vxore, in his præsertim regnis, esset acceptum, contra viri voluntatem, quod constaret virum rationabiliter non velle, vt vxori redderetur: restituendum enim tunc esset viro, sine detrimento vxoris, & non vxori. Idem quoque est dicendum de accepto ex mancipio, quod ad dominum attineret, & cuius alienatio m̃cipio nō esset concessa: restituendum quippe esset domino, & non mancipio, quando præsumendum esset, eam esse domini voluntatem. Atque idem dicendum est de similiter accepto ex famulo, quod ad dominum attineret, etiam si emptionis aut alio oneroso titulo ex illo esset acceptum: restituendum enim esset domino, & non famulo, aut famulæ, quando præsumendum esset, eam esse domini voluntatem, vt regulariter in hoc, & in antecedētibz euentibus, est præsumendum. *Consentiunt Caiet. art. 5. citato, Syluest. verb. rest. 4. q. 2.* & doctores communiter. Semper tamen in his omnibus euentibus facienda est restitutio seruata fama eorum, ex quibus res est accepta, & cum quanta minori iactura eorum fuerit possibile. Nisi aliquid esset opus detegere, quia aliter ii, ex quibus eiusmodi res sunt acceptæ, non desisterent à furando, ac proinde perseuerarent in peccato, cum iactura aliorum temporali: tunc enim, si aliter non possit consuli saluti spirituali ita peccantium, nec damno eorum temporali pendenti in futurum, quorum sunt ea bona, detegi posset, quantum ad ea mala vitanda esset sufficiens, præponendo salutem spirituales peccantium, iacturæ illi famæ eorundem, simulque obuiando damno eorum temporali, quorum sunt ea bona, quatenus ex nequitia ita peccantium, à qua sua culpa desistere nolunt, id damnum proueniret.

Quando, post bona alicuius iudicis sententia [sect. 7] confiscata, aliquid est restituendum, quod delinquenti tempore latæ sententiæ confiscationis debebatur, etiamsi id ei deberetur soluendum in futurum, tunc restituendum est fisco, aut ei, cui per eam confiscationis sententiam bona talis delinquentis fuerunt applicata, non verò delinquenti, cui id debebatur, aut hæredibus illius. Ratio autem est, quoniam delinquens, per confiscationis bonorum ipsius sententiam, priuatus est toto iure, quod re ipsa quoquo modo ad quæcunque bona habebat, fiscusq; aut quicumque alius, cui ea bona per eam sententiā fuerunt adiudicata, transiuit in id ius totum. Quare, si debitor id restituat delinquenti, aut hæredibus illius, tenetur id iterum fisco restituere, aut alteri, cui ea bona fuerant adiudicata: eo quòd per eam solutionem non satisfecerit ei, cui iam tunc id debebatur. Excipe, si debitum esset aliquid certum ac determinatum in indiuiduo; atque id soluens delinquenti, aut hæredibus illius, per inuincibilem ignorantiam excusetur à culpa id ita soluendo. Tunc enim, quia obligatio soluendi solùm erat ad dandum illud in singulari; illoque dato ei, cui non erat dandum, non tenetur fisco, aut alteri, cui dandum foret, ex parte rei acceptæ, quæ non manet apud ipsum, neque ex parte iniustæ acceptionis; eo quòd non peccauerit illud soluendo delinquenti, aut hæredibus illius, excusante ipsum ignorantia inuincibili; consequens profectò est, vt ad nullam restitutionem teneatur fisco, aut alteri, cui bona talis delinquentis fuerunt adiudicata. Curare tamen tenebitur, vt, qui id accepit, restituat illud fisco, aut alteri, cui debebatur: quantum sine suo periculo, & cum spe, quòd restitutio fiet, commodè potuerit.

Quando, qui aliquid illicitè accepit, teneatur [sect. 8] illud restituere, tam quando dans illicitè etiam illud dedit, quàm quando dedit illud licitè, & cui tunc facienda sit restitutio, à Disp. 82 [[260]] est copiosè explanatum, suisque propriis in locis, quæ dicenda restabant, sunt dicta, restantq; adhuc dicenda.

Restitutio quousque hæredibus illius, cui res erat debita, sit facienda. Disp. 742.

SVMMARIVM.

1. *Restitutio quando hæredibus sit facienda, nec satisfiat, si in operibus piis insumatur. Et quando insumi possit.*
2. *Restitutio qualiter inter hæredes, aut simul etiam inter alios, distribui debeat.*
3. *Restitutio, aut distributio aliquorum bonorum, quando à testatore iussa est fieri per aliquos, per illos est executioni mandanda. Et quando culpa non esset lethalis, hæredem per seipsum id fideliter exequi, & quando nullum esset peccatum.*

Quando is, cui restitutio erat facienda, est [sect. 1] iam defunctus, neque aliter quoad id debitum disposuit, restitutio est facienda hæredibus illius, si quos habeat, siue ex testamento, siue ab intestato. Ita D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 5. ad. 3. Caiet. ibi, & doctores communiter. Hæredes quippe vicem illius subeunt, eumque repræsentant, atque in totum ius illius succedunt: eo quòd tale ius pars sit hæreditatis, inter bonaque defuncti computetur, vt dum sermo nobis erat de vltimis voluntatibus, copiosè hæc omnia ostensa sunt. Quare nefas est tunc distribuere id pauperibus, aut illud insumere in operibus piis, pro anima defuncti, sed restituendum est hæredibus: quoniam ex iuris dispositione hæredes in totum ius defuncti succedunt: eaque de causa, qui illud distribueret pauperibus, aut insumeret in aliis operibus piis, pro anima defuncti, non solueret debitum ei, cui iam tunc debebatur, ac proinde teneretur illud iterum soluere vero creditori; sicque in exteriori foro cogeretur. Nisi illud suisset res determinata in indiuiduo, quam, excusante eum ignorantia probabili seu inuincibili, dedisset pauperibus, aut insumpsisset in aliis operibus piis, eo modo, quo vtrumque in calce Disputationis præcedentis est dictum, quando, quod fisco erat soluendum, datum fuit delinquenti, aut hæredibus illius. Quando autem, quod est restituendum, esset modicum: neque defuncto, ob paupertatem, fuissent facta cōpetentia suffragia, qualia fierent, si id comparuisset tempore mortis illius, idque totum fuisset tunc insumendum in sunere & suffragiis, vtique defunctus ille censendus esset, nihil hæredibus reliquisse, ac proinde id tunc insumi posset, ac deberet, pro anima illius, aut tanta illius pars insumi eo modo deberet, quanta fuisset consumpta, si tempore sepulturæ id debitum comparuisset. Quando item res esset modica, neque de hæredibus facilè constaret, aut difficilè, pro rei qualitate, ac quantitate, & pro distantia loci, ad eos posset deferri, distribui posset pauperibus, aut insumi in aliis operibus piis, pro defuncti, ac hæredum, animabus, prout Deo esset notum, id potiùs fieri debere.

Quando defunctus haberet descendētes, aut [sect. 2] ascendentes, quibus necessariò obuenire deberet pars bonorum ipsius, tanquam legitima illis debita, tunc, si tertium suorum bonorum reliquisset vni eorum, vel alicui extraneo, aut in aliquod opus pium, vel in hoc regno tertium & quintum reliquisset alicui, aut aliquibus, ex suis descendētibz, vel quintum alicui extraneo, aut in aliquod opus pium, tunc, quod ita post defuncti mortem esset restituendum, diuidendum esset pro rata portionum bonorum defuncti, in quibus singuli succederent, atque in eadem proportionē esset singulis diuidendum, ita vt tertia pars, aut quinta, diuidenda

esset inter eos, qui in tertio, aut quinto, succederent, siue, qui ita in eis succederent, essent opus aliquod pium, siue homo aliquis, aut homines aliqui, in particulari. Si autem defunctus solùm reliquisset legata certæ quantitatis ex suo tertio, aut quinto, quantum arbitrabatur se posse extēdere suum tertium, aut quintum, non verò disposuisset, vt tertium, aut quintum, suorum bonorum, tanquam quota suorum bonorum, hoc vel illo modo insumeretur, aut vt obueneret alicui, vel aliquibus; tunc, quod post mortem defuncti appareret, aut esset restituendum, accresceret solis hæredibus, & nihil legatariis, inter quos tertium, aut quintum, suorum bonorum, arbitraretur se eo modo per partes certæ quantitatis distribuisset, idque nihil impediens, quòd si defuncto tempore sui testamenti, aut codicilli, constaret de ea parte suorū bonorum, partem quoque tertiam, aut quintam, illius, sicut & ceterorum suorum bonorum, distribuisset in eisdem, aut in aliis, legatis. Ratio autem est, quoniam, vt, dum de vltimis voluntatibus est habitus sermo, sæpe est dictum, id totum, quod de suis bonis defunctus non distribuit in legata, ad hæreditatem pertinet, estque inter solos hæredes vniuersales diuidendum.

Quando aliquis reliquisset bona sua, aut quo [sect. 3] tam eorum, distribuenda per aliquem, aut per aliquos, inter pauperes, aut insumenda in aliquo, vel in aliquibus operibus piis, tunc, quod, tanquam ad ea bona, aut ad eam quotam bonorum, attinens, esset restituendum, tradendum est ei, vel eis, cui vel quibus defunctus commisit, vt ea bona distribuerent, aut insumerent in talibus operibus piis. Si tamen, qui restituere id tenetur, illud fideliter distribueret, aut insumeret, in eisdem operibus piis, non condemnarem eū peccati lethalis: quoniam, quòd exequutio voluntatis defuncti fideliter per alium fiat, non est notabile damnum, aut iniuria, quæ ad lethalem culpam sufficiat. Imò verò, si id tradi non posset distributoribus, à defuncto ad id cōstitutis, sine probabili periculo honoris, aut famæ, eius, qui id restituere teneretur, nullum esset peccatum fideliter per se ipsum exequutioni mandare, quoad id, voluntatem defuncti: quoniam præsumendum esset, eam esse voluntatem defuncti, essetque irrationabiliter inuitus, nisi contentus esset, vt id ita fieret. Quin, si difficilè transmitti posset ad exequutores, à defuncto designatos, atque, quod est restituendum, non esset magna quantas, in eo præcisè, quod exequutio fieret per eum, qui id restituere tenetur, non arbiträrer interuenire in eo euentu peccatum.

[[261]] *Vtrùm soluens creditori sui creditoris, liberetur ab onere restituendi suo creditori. Disput. 743.*

SVMMARIVM.

1. *Solutio facta à debitore creditori sui creditoris, tunc in foro exteriori liberat debitorem comparatione sui creditoris, quando pro eodem debito ipse etiam debitor obligatus erat creditori sui creditoris.*
2. *Solutio in solo foro conscientie tunc à debitore fieri licet potest creditori sui creditoris occultè, quando is secundus creditor licet poterat facere occultam compensationem ex illo creditore debitoris.*

DVbium non est, quando debitor, de con [sect. 1] sensu sui creditoris, solueret quantitatem

aliquam creditori sui creditoris, eo ipso, tam in conscienti quam in exteriori foro, liberari ab obligatione eius quantitatis comparatione sui creditoris. Difficultas autem est, quando sine consensu sui creditoris id soluit, num in exteriori & in conscientię foro liber maneat. Et quidem quod ad externum forum attinet, *Bart. l. solutum. §. solutam. n. 2. ff. de pign. act. c. l. non solum. §. sed si pecunia. ff. soluto mat. quem sequuntur Ioan. Med. de rest. q. 3. causa. 5. c. Sylvest. verb. solutio. q. 4. sic distinguunt.* Quòd aut debitum est ex eadem causa, vt si Petrus conduxit domum ex Ioanne, quam ego ex Petro conduxì, & tunc, si ego soluam Ioanni id pensionis ex conductione eius domus, quod Petru; Ioanni debebat, esto Petrus non consenserit in co, quòd ego id ita Ioanni soluerem, liberor eo ipso ab obligatione soluendi Petro eandem pensionis quantitatem. Si verò Petrus iam Ioanni soluerat pensionem domus, tunc, esto Petrus ex alio titulo debitor esset Ioāni alicuius quantitatis, non liberor ego ab obligatione soluendi Petro pensionē domus, ex eo, quòd illam soluerim Ioanni in recompensam talis debiti Petri: quoniam debita non sunt ex eadem causa, sed ex longē diuersa. Aliud exemplum est, si Petrus, vt ageret vtiliter negotium meum, mutuò sumpsit ex Ioanne decem, quæ in meum insumpsit commodum, tunc soluendo ea Ioanni, cui Petrus adhuc illa debebat, liberor ab obligatione ad illa decem, qua Petro tenebar, *vt colligitur ex. l. si liber homo. ff. de neg. gest.* Ego autem aliter dicendum puto. Nempe, tunc solum me in foro exteriori liberari ab obligatione soluendi meo creditori, quod illi debebam, si illud solui creditori illius, quando ego quoad id, quod ita solui, obligatus eram aliquo modo illi alteri creditori: secus autem si nullo modo eram illi obligatus, quia nullo modo ille agere poterat contra me, vt illud ei soluerem. Vnde, quia in primo exemplo, conductor secundus domus, debitor est primo locatori totius pensionis, pro qua primus locator domum locauit primo conductori, idque in defectum primi conductoris, primoque locatori hypothecata sunt ex iuris dispositione omnia inuecta in eam domum à secundo conductore, pro solutione illius pensionis, vt Disput. 489 & 497 est ostensum, ea ratione est illi cōcessum in iure, vt soluens primo locatori id pensionis, quod nondum primus conductor illi soluerat, liberetur ipso iure à soluendo secundo locatori id pensionis pro eadem domo. Similiter in secundo exemplo, quia debitor ille tenebatur Ioanni actione negotiorum gestorum, aut de in rem verfo, ad illa decem, quæ mutuauerat Petro, vt ita vtiliter id ageret, & nondum Petrus Ioanni soluerat, inde efficitur, vt soluendo ea Ioanni, liberetur ab onere ea soluendi Petro actione negotiorum gestorum, simulque liberet Petrum ab onere ea soluendi Ioanni. *Vt item habetur. l. nomen. C. quæ res pig.* quando creditor aliquis, quod sibi suus debitor debebat, obligauit alicui alteri suo creditori, tunc quia eo ipso talis debitor obligatus manet ad id debitum soluendum creditori illi sui creditoris, in euentu, quòd suus creditor illi non soluat, inde efficitur, quòd quamuis debita non sint ex eadem causa, si talis debitor soluat creditori sui creditoris, liberetur à soluendo suo proximo creditori, quòd loco illius soluerit; quin tenetur illud soluere creditori sui creditoris, & non suo creditori, si à creditore sui creditoris sit admonitus, vt sibi illud soluat, etiamsi renuat suus immediatus creditor, vt in eodem textu habetur.

Quod ad forum verò conscientię attinet, di [sect. 2] cendum est: Quando debitum, quod deberetur Petro, verbi gratia, aut hæredibus illius, esset occultum, tunc in euentu, in quo Ioannes, verus Petri creditor, posset facere compensationem occultam in bonis Petri, iuxta ea quæ Disp. 691 dicta sunt, fas esset tali debitori soluere Ioanni tantum de debito, quod Petro debebat, quantum est id, quod Ioānes cōpensare occultè potest in bonis Petri: quoniam non aliud est, quàm eū debitorem cooperari cum Ioanne ad eam iustā compensationem, vt

Disp. 741 est dictum: manetque tunc is debitor liber in conscientiae foro ab onere restituendi Petro, aut hæredibus illius, quantitatem, quam in talem iustam compensationem Ioanni soluerit. Atque hoc idem est dicendum, esto, quod Petro debebatur, esset res determinata in indiuiduo, quando in ea, iuxta ea quæ Disp. 661 citata dicta sunt, posset Ioannes facere occultam compensationem. Et quoniam, quæ de hac re addi hoc loco potuerant, intelligentur facile ex Disputationibus citatis, non plura hac de re hoc loco dicam.

Bona incerta, quæ. Et quæ diligentia adhibenda, ut iis, ad quos spectant, restituantur. Disp. 744.

SVMMARIVM.

1. *Incerta bona quæ.*

2. *Incerta bona antequam alteri, quàm proprio domino, restituantur, aut circa illa summi Pontificis autoritate compositio fiat, quæ inquisitio as diligentia adhibenda, & cuius sumptibus.*

3. *Incertorum bonorum ne quis se fingat dominum, ut ei tradantur, qua cautela vtendum.*

4. *Incerta bona, qui non facta prius competenti diligentia, insumpsit in opere pio, aut illa lata suæ culpa tradidit ei, qui se finxit verum dominum, comparente postea vero domino, tenetur integre ea illi restituere. Et in hoc posteriori euentu tenetur integre ea insumere in opere pio, si constet illum non fuisse verum dominum, nec verus dominus compareat: in dubio autem, tenetur partem, pro dubii quantitate, insumere in opere pio, & ius illi manet ad ea recuperandæ ex illo, qui se finxit dominum.*

Vt in calce Disputationis 53 dicebamus, [sect. 1] bona incerta sunt, quæ habent quidem dominum, eumve ad quem pertineant, seu cui debeantur, & ignoratur quis is sit; qualia vt plurimum sunt inuenta, quando ignoratur, quis illorum sit dominus, & sunt quædam alia. Inter bona autem incerta non computantur, quæ carent domino, eoque, ad quem spectent, & sunt primò occupantis, vt lapilli pretiosi in littore maris aut intra terram inuenti, & similia alia, quæ Disp. 53 citata explicauimus, neque thesauri, neque missilia, & vniuersim, quæ pro derelicto habentur, neque bona vacantia, quæ ad fiscum regis eo ipso spectant, vt hæc omnia Disputatione citata explanata sunt, vbi quædam alia adiecimus, quæ hoc loco dici poterant: ea legas, & quæ sequentibus Disputationibus connexa cum illis sunt.

Vt autem sequentibus Disputationibus explicemus, cui facienda sit bonorum incertorum restitutio, ante omnia est obseruandum cum *D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 5. ad. 3. Caiet. ibidem*, & cum aliis doctoribus communiter. Antequam restitutio bonorum incertorum fiat alicui, qui non sit eorum dominus, isve, ad quem pertineant, quin & antea quàm circa illa autoritate summi Pontificis compositio fiat, præcedere debere diligentem inquisitionem veri domini, eiusve ad quem pertinent, si spes aliqua sit inueniendi quisnam is sit, vt illi tradantur. Porro ea inquisitio fieri debet in locis, ac temporibus, & à personis, in quibus, & ex quibus, recta ratio præscribit vt fiat, eo quòd spes sit ea via deprehendendum, ad quem ea bona pertineant. Quantitas verò sufficientis inquisitionis, prudentis arbitrio est iudicanda, attento valore rei restituendæ, & attentis viis, quæ occurrunt, vt fiat cum spe deprehendendi, ad quem ea

res pertineat, atque attentis sumptibus, qui in ea inquisitione fieri debent: præsertim si ex re ipsa restituenda sint faciendi, eo quòd neque in illa accipienda, neque in ea retinenda, interuenerit iniustitia ex parte eius, qui illam restituere debet, ratione cuius sumptus, aut maiores sumptus, fieri debeant ex parte eius, qui illam restituere debet, ad inueniendum, ad quem ea res pertineat; sed solùm in ea inquisitione agatur negotium eius, ad quem ea res pertinet, cuius proinde sumptibus fieri debet. His itaque & aliis circumstantiis concurrentibus attentis, prudentis arbitrio est iudicandum, quousque & quanta inquisitio sit facienda. Interim verò dum spes fuerit, quòd deprehenderetur persona, ad quam ea res pertineat, restituenda non est alteri, nisi ex rei qualitate intelligeretur, personam illam cõtentam fore, vt in eleemosynam erogetur, aut in alio opere pio, pro anima illius insumatur, sed seruanda erit, aut collocanda in depositum, vt, quando ea persona comparucrit, ei tradatur; & vt, quando amissa fuerit spes omnis eam personã deprehendendi, insumatur in opere aliquo pio. Quando eram in Lusitania, vbi domus, seu cõfraternitates, sunt misericordiæ, nunquam satis laudatæ, ad eleemosynas, & ad alia misericordiæ opera exercenda, eratque spes modica deprehēdēdi, ad quem bonum aliquod incertum attineret, aut, esto esset certum, ad quem id bonum attineret, ille erat absens, modicaque erat spes, illum inueniendi, consulebam, vt traderetur alicui domui misericordiæ ad opera pia, quæ ea domus exercet, pro anima illius, cuius id bonum esset, cum onere, vt si quando dominus rei illius apparet, ea domus illud ei solueret: libenterque ea domus cum eo onere id accipiebat, chirographumque dabat, quo se astringebat, id soluere ei, ad quem attineret, si ille compareret, aut aliquando sciretur, qui is esset: quin & ea domus onus assumebat faciendi diligentiam ad inuestigandum dominum illius rei, quando via aliqua occurrebat, qua id sciri posset.

Qui rem tenet, cuius dominum ignorat, cau [sect. 3] tus esse debet, ne quis se fingat dominum eius rei. Ea verò de causa, quando periculum eiusmodi fictionis timeri iuste potest, sanum consilium est, rem non ostendere, sed manifestare rem in specie, nec quantitatem, nec qualitatem illius, nec cæteras circumstantias detegendo, vt, qui se dixerit dominum illius, id comprobet rei quantitatem, qualitatem, ac cæteras circumstantias, exprimendo. Neque enim cuicunque asserenti, se esse dominum illius, est facilè credendum, nisi id probet, aut verisimiles sint coniecturæ, quæ id persuadeant. Quam autem diligentiam is facere teneatur, qui rem aliquam inuenit, ad comperiendum, quis sit dominus illius, vt eam illi tradat, & ipse de furto suspectus non habeatur, & vt non puniatur tanquam fur, Disp. 681 est dictum. Quando aliquis, non ductus verisimilibus cõ [sect. 4] iecturis, quibus meritò sibi persuaserit, eum, qui se finxit dominum rei, quam tanquam incertam ad quem attineret ipse tenebat, verè dominum illius esse, illi eam tradidit; aut quando, non facta priùs debita diligentia ad inquirendum dominum rei alicuius, illam tribuit pauperibus, aut in aliud opus pium illam insumpsit, tunc, comparente postea domino, tenetur illi eam restituere, vt Caiet. in responsione ad tertium citata, & doctores alii affirmant: quoniam non potuit eã illo modo in præiudicium veri domini alienare. Si tamen, attenta qualitate personæ, ac circumstantiarum concurrentium, excusaretur à culpa lata in tali alienatione, tunc, quia id in nullum suum commodum proprium fecit, neque item tenetur ad restitutionem ex parte rei acceptæ, quæ apud ipsum non manet, vtique ad nullam restitutionem teneretur. Quo loco obserua, quando sua culpa lata, coniuncta cum theologica culpa, rem illam tradidisset ei, qui se finxisset dominum illius, tunc, si certum postea compareret, eum non fuisse dominum illius, teneretur inquirere verum dominum, eamque illi restituere, recuperando illam ab eo, cui illam dedit, aut eam soluendo de suis propriis bonis. Non inuento autem domino illius, teneretur simili

modo eam restituere, tribuendo illam pauperibus, aut insumendo illam in alio opere pio pro vero domino rei illius. Quòd si dubium esset, an is, cui ita culpabiliter eam tradidit, verè esset dominus rei illius, & facta debita diligentia, idem dubium remaneret, tunc, pro quantitate dubii, teneretur restituere solùm partem valoris illius, modo paulo antea explicato, maiorem vel minorem, prout maior vel minor esset probabilitas, illum, [[263]] cui eam tradidit, non esse dominum illius. Quādo autem aliquis, ommissa debita diligentia ad inquirendum dominum rei, illam tradidisset pauperibus, aut insumpsisset in alio opere pio, tunc solùm teneretur facere debitam diligentia ad inquirendum verum illius dominum. Si autem inueniret quis is esset, teneretur eam illi restituere, vt dictum est, nihil impediēte, quòd in opere pio pro salute animæ illius eam distraxisset, nisi ille ratum id haberet. Quòd si facta debita diligentia, deprehendere non posset quisnam ille esset, ad nullam aliam teneretur restitutionem: quoniam, si tunc alicui esset faciēda, esset insumendo illam in opere pio pro anima domini illius: id verò iam opere præstitit.

De restitutione itæ incertorum, vt licèt incertum sit, cui, aut quibus, in particulari debeantur, certum tamen est, alicui, aut aliquibus, ex certis quibusdam, id deberi. Disput. 745.

SVMMARIVM.

1. *Incetorum, cuius sint, duo genera.*

2. *Incetum, ad quem ex quibus paucis aliquid pertineat, & certum quòd ad illorum aliquem pertineat, quomodo omnibus restituendum. Si autē transactio aut compositio fiat inter eos circa eam rem, tunc, esto postea comperiatur, ad quem ipsorum attinuerit, non est illi reddenda.*

3. *Restitutio direpti ex aliqua ciuitate bello iniusto, quando ignoratur, cuius id fuerit, quo modo faciēda.*

QVod aliquis tenet, restituerēve tenetur, [sect. 1] duobus modis potest esse incertum ad quē pertineat. Vno, quia constat, alicui, aut aliquibus, ex certis quibusdam, id deberi; facta autem debira diligentia, dubium manet, cui, aut quibus, in particulari ex illis quibusdam debeatur. Altero verò, quia prorsus est incertum, cui, aut quibus, debeatur, ita quòd non dantur pauci aliqui prudentis arbitrio, comparatione eius, aut eorum, quibus in particulari id debetur, quibus certum sit deberi, & ignoratur, cui, aut quibus, ex illis debeatur in particulari. Quod dico, quoniam licèt certum sit alicui, aut aliquibus duobus, ex aliquo oppido aliquid deberi, si ignoretur cui, aut quibus, ex illo oppido debeatur, nō efficit id incertum primo, sed secundo modo, vt varius modus, qui hac & sequenti disputatione explicabitur, in restituendo sit seruandus. Hac itaque disputatione sermo erit de incertis primo modo, & sequenti de incertis modo secundo.

Quando certum est, aliquid ad aliquem duorum, trium, aut quatuor, verbi gratia, pertinere, & facta competentī diligentia, dubium incertumque maneat, ad quem eorum attineat, tunc restitutio rei illius non est faciēda pauperibus, aut insumendo illam in alio opere pio, sed ea res illis omnibus est tradenda, vt pro quātitate dubii, ad quem, aut ad quos, potiùs illa

pertineat, inter ipsos compositionem seu transactionem faciant, vel circa illam sortes mittēdo, vel eam inter se diuidendo, vel vno eam accipiēte, & compensante aliis ius dubium, quod circa illam habebant, partēsve illius, quas ratione eius iuris dubii prætendere poterant: eo modo, quo in materia de bello suprā Disp. 103 dictum est fieri debere, quando res esset dubia, ad quē duorum attineret, antequam quisquam eorum illam bona fide cæpisset possidere. *Ita Caiet. 2. 2. q. 62. art. 5. ad. 3. Sotus. 4. de iust. q. 7. art. 1. ad. 3. & doctores communiter.* Quo loco obserua, facta inter illos de communi consensu transactione circa eam rem, modo explicato, esto postea comperiat, ad quem eorum in particulari ea res attinuerit, reliquos non teneri reddere illi, quod in compensationem pro iure tunc dubio de communi consensu acceperunt, etiamsi aliquis eorum, ad quem verè non attinebat, eam totam obtinuerit, quia sorte ei contingit, vt ex iis, quæ in materia de transactione Disp. 556 patet. Ratio autem est, quoniam fuit quasi venditio iuris dubii, quod in illa re prætendebat, pro eo, quod in recompensationem ita accepit, quicquid rei veritas tunc haberet, aut temporis progressu deprehenderetur.

Sotus vbi suprā ait. Quando in direptione a [sect. 3] licuius ciuitatis aliqua bello iniusto essent capta ex aliquo, atque ignoraretur, quis is esset in particulari, restitutionem esse mittendam ad administratores eius ciuitatis, vt illa distribuerent inter ciues. Id verò solū probarem, quando à variis militibus diuersa essent ita iniustè direpta ex eadem ciuitate, & verisimilitudo esset, quòd multi restituerent: quando enim multa diuersorum restituerentur, & ignoraretur ad quos ciues illa attinerent, ille esset bonus restituendi modus in eo euentu: atque etiam quando restitueretur res aliqua eadem numero, quæ fuit iniustè direpta, & ignoraretur, ad quem pertineret: mitti enim tunc posset ad potestates publicas, vt inuestigarent, ad quem attineret, illique eam restituerent, alioquin eam distribuerent pauperibus, aut insumerent in alio opere pio. Quādo autem restituendum esset vni tantū de populo, & omnino sciri non posset, quisnam is esset, res non est diuidenda inter ciues diuites, sed restitui debet pauperibus, aut debet insumi in alio opere pio pro anima eius, ad quem ea res attinebat.

Quando aliquid esset incertum, ad quem, aut [sect. 4] ad quos, in singulari attineret, quia aliquis vendendo in aliqua ciuitate, aut oppido, multos defraudauit in pondere, aut mensura, aut admiscendo aquam vino, quod est in vini mensura defraudare, aut alio simili modo, ignoratque ementes in particulari, & quantum vnumquemque ita per minima defraudauerit, tunc, si coniectura sit, plus minus, perseuerare eosdem ementes, aut ementium hæredes, optimus restituendi modus erit, vt tantundem, qui ita defraudauit, in pondere, aut mēsurā, accrescat, vel decrescat in pretio, ita vt ad æqualitatem eidem reipublicæ restituat quoad eosdem emptores, quā maximè fieri possit. Tenebitur verò reseruare suas portiones iis, quos emisse recordabitur, nec viderit accedere ad emendum. Item sanum consilium erit, si aliquid reseruet de summa tota, quam restituere tenetur, quod distribuat pauperibus, aut in aliis piis operibus insumat pro animabus eorum, quos defraudauit, & ignorat, qui sint, nec accedent ad emendum.

[[264]] *De restitutione omnino incertorum. Et num inuenta, quando, facta diligentia, nescitur, cuius sint, restitutioni sint obnoxia. Dis. 746.*

SVMMARIVM.

1. *Incetorum omnino post factam diligentiam competentem, ad quem pertineant, restitutio est facienda pauperibus, aut ea insumendo in aliis operibus piis.*

2. *Inuenta similiter sunt restituenda.*

3. *Incerta quando, post competentem diligentiam ad inveniendum dominum, restituta sunt pauperibus, aut ea insumendo in alio opere pio, si postea compareat dominus, tunc, qui illa ita restituit, non teneretur ea iterum ei restituere, & quid de pauperibus, & de aliis, ad quos deriuata sunt.*

QUod attinet ad omnino incerta, ad quem [sect. 1] pertineant, communis sententia doctorū

affirmat, quando facta debita diligentia non cōperitur dominus eorum, neque est spes, quòd comperietur, restitutionem eorum faciendam esse pauperibus, aut insumenda esse in opere, aut in operibus piis, pro anima illius, cuius ea bona sunt, vt in redemptionem captiuorum, in resarcienda aut erigenda Ecclesia, in emendis ornamentis ad diuinum cultum, in luminaribus sanctissimæ Eucharistiæ, & in similibus aliis. *Ita diuus Thom. 2. 2. q. 62. artic. 5. ad. 2. Caiet. ibidem, & in summa verb. restit. c. 4. Ioan. Med. de restit. q. 3. causa. 10. Nauar. in Manu. c. 17. n. 29. & 171. Couar reg. peccatum part. 3. §. 1. n. 2. Syluest. verb. rest. 3. q. 2. & 3. & plerique alii.*

Sotus. 5. de iust. q. 3. art. 3. ad. 2. quamuis fateatur sententiam hanc veram esse in aliis bonis incertis, communemque eam esse, tam theologorum, quàm iuris canonici interpretum, circa bona etiam inuenta, neque omnino contradicere audeat, propendit tamen, eum, qui inuenit aliqua bona, factaque morali diligentia, non inuenit, cuius sint, non teneri restituere ea pauperibus, aut insumere illa in aliis piis operibus pro anima illius, cuius sunt, sed posse ea sibi ipsi vsurpare, nihil impediante, quòd diues sit. Fandem sententiam multi hodie amplectuntur.

Ducitur Sotus. Primò, quoniam illa in re natura¹¹⁶ ac gentium sunt inuentoris, non secus ac thesauri: nullumque est ius positium, euangelicum, aut ecclesiasticum, quod illa pauperibus tribuat: ergo potest inuentor illa, tanquam sua, sibi retinere. Maiorem probat, quoniam, stando in folo iure naturali, omnia sunt communia, de iure autem gentium id, cuius non extat dominus, est primò occupantis: cū ergo eo ipso, quòd facta est debita diligentia, & non inuenitur rerum inuentarum dominus, perinde res inuenta se habeat, ac si dominum non haberet; consequens est, vt sit inuentoris, qui primò illam occupauit. Minorem verò probat, quoniam ad probandum inuenta restituenda esse pauperibus, non aliud ius citatur, quàm. c. cū tu, de vsuris, & similia alia iura, in quibus pecunia vsurariè aut simoniacè acquisita adiudicatur pauperibus: quæ tamen iura solū loquuntur de malè partis, de quorum numero non sunt inuenta.

Secundo, quoniam ante legem euangelicam¹¹⁷ verisimillimum est, naturæ ac gentium iure res inuentas, facta debita diligentia ad inquirendum dominum, nec eo inuento, fieri inuentorum:

ergo non est, cur in lege euangelica dicamus, inuentores de iustitiæ rigore teneri illas restituere.

Cum communi tamen doctorum sententia [sect. 2] est affirmandum, quæcunque bona omnino incerta, etiam inuenta, restituenda esse pauperibus, aut insumenda esse in operibus piis pro anima illius, cuius ea bona sunt. Ratio autem hæc est. Quoniam re vera habent dominum, tametsi ignoretur, quis is sit, neque id potest Sotus negare circa bona inuenta: etenim, si, post factam competentem diligentiam ad inueniendum verum eorum dominum, dominus casu compareat, non negabit Sotus, inuentorem teneri illi ea restituere: neque enim ex eo, quòd dominus illa amiserit, & alius ea inuenerit, adhibueritque diligentiam debitam ad dominum inueniendum, verus dominus amisit dominium eorum, illudque comparauit, qui illa inuenit; alioquin etiam comparente vero domino post eam diligentiam adhibitam, non teneretur inuentor ea illi restituere: quia ergo bona illa dominum habent eum, qui illa amisit, restituenda illi sunt meliori modo, quo id fieri possit, atque iuxta præsumptam illius voluntatem in eo euentu: voluntas autem præsumpta fidelis populi in eo euentu est, vt pauperibus distribuuntur, aut insumantur in alio opere pio in bonum spirituale eius, cuius sunt, atque in satisfactionem pro peccatis illius: ergo restituenda sunt pauperibus, aut insumenda sunt in alio opere pio, pro anima illius, cuius ea bona sunt.

Dices: Saltem quando bona illa essent alicuius infidelis, restituenda non essent pauperibus, neque insumenda in alio opere pio. Respondendum est: Etiam tunc obligationem esse restituendi eo modo bona illa. Tum quia nulla est gens tam barbara, quæ non arbitretur, Eleemosynas esse bona opera, & quæ non eligat, vt, quando bona sua sibi non possunt restitui, distribuuntur potius pauperibus, quàm retineantur ab inuentore. Tum etiam, quoniam bona illa insumi à Christianis in operibus piis pro salute eorum, quorum funt, adiumento illis est, vt Deus propitius illis sit ad eis miserendum: quod si ipsi scirent, gratum vtique ac ratum id haberent. Adde, si ratio hæc vim haberet, etiam concluderet, neque Christianos teneri restituere pauperibus, quæ ex infidelibus iniustè acciperent per vsuram, aut furtum, in euentu, quòd postea nescirent, quinam essent illi, quibus ea deberent, sed posse illa sibi retinere, eo quòd similiter non esset voluntas præfumpta eorum, quibus debentur, quòd tribuerentur pauperibus, aut insumerentur in aliis operibus piis: id autem Sotus, & autores alii erus sententiæ non concedunt.

Ex ratione explicata emanauit c. cùm tu de vsuris citatum, quo, sub pæna denegationis sacramentorum ac ecclesiasticæ sepulturæ, vsurari restituere coguntur vsuras accepras, vel iis ipsis, ex quibus eas acceperunt, vel eorum hæredibus, vel his omnibus deficientibus, pauperibus, ac ratio ibi redditur, quia non dimittitur peccatum, [[265]] nisi restituatur ablatum. Quo in loco erogatio pauperibus in eorum defectum, à quibus vsuras acceperunt, & in defectum hæredum ipsorum, non statuitur in pænam vsurariis, sed tanquam obligatio, quam ex natura rei habent, vt è peccato egrediantur. Consentit. c. sicut dignum. §. eos de homic. vbi à contrario sensu apertè innuitur, in eorum defectum, quibus aliquid debetur, restituendum esse id pauperibus. Quæ iura, & similia alia, confirmant communem doctorū sententiam. Atque in hunc modum possumus contra Sotum argumentari. Si bona, quorum, post debitam factam diligentiam, ignoratur dominus, re vera carerent domino, aut perinde haberent, ac si domino carerent, vt essent primò occupantis, sequeretur, acquisita per furtum, aut vsuram, quorum postea similiter ignoraretur dominus, esse primò occupantis, ac proinde vel posse licitè retineri ab vsurario aut fure, vel certè posse licitè accipià quocunque alio: quod Sotus nulla ratione admittet. Sequi probatur, quoniā ex eo solo fundamento affirmat

Sotus, bona inuenta fieri inuentoris tanquam primò occupātis. Neque satisfacit, quod Sotus videtur innuere, nempe hæc, quæ iniquè fuerunt occupata, iura citata adiudicare pauperibus, eaque de causa illis deberi. Non, inquam, hoc fatiscit. Tum quia, seclusa saltem ea iuris dispositione, possent vsurarius ac fur licitè illa sibi retinere. Tum etiam quoniam capita citata non condunt nouum ius, sed solùm explicant, quid natura ipsa rei habeat, vt intuenti ea iura est manifestum. Tum denique quoniam, esto in pœnam delicti ea adiudicarent pauperibus, possessores tamen non tenerentur eā pœnam ante latam sententiam exequutioni mādare. Illud hoc loco obserua, quamuis iura illa solùm pauperum meminerint, rationem tamen eius dispositionis redditam probare, posse etiam ea bona insumi in alia pia opera pro anima eius, cuius ea bona sunt. *Id quod confirmant Syluest. vbi supra. q. 7. & Nauar. in Manu. c. 17. n. 93. cum Ioanne Andrea communiter recepto*, quoniam ecclesiastici redditus restitutioni obnoxii applicari possunt non solùm pauperibus, sed etiam operibus aliis piis, vt alio in loco est ostendendū.

Ad primum ergo Soti argumentum neganda¹¹⁸ est maior. Ad probationem verò negāda est minor illa propositio, nempe inuenta, post factā diligentiam ad dominum inueniendū, per inde habere, ac si dominum non haberēt. Cū enim dominum habeant, vt est ostensum, (in quo à thesauris differunt) iuxta præsumptam talis domini voluntatem in ipsius spirituale commodum, atque in Dei laudem, sunt restituenda, neque potest inuentor ea sibi, contra præsumptam domini voluntatem, usurpare.

Ad secundum negandum est antecedēs. Cū¹¹⁹ enim dominum habeant, vt est ostensum, non est cur tunc fierent inuentoris. Quòd si tunc abusus aliquis inter aliquos ea de re fuit, illud sanè esset, quia homines tunc non essent adeò solliciti de vita æterna, & salute animæ suæ, atque de inquirendo, quid de similibus rebus fieri deberet, quando post competentem diligentiam non reperiretur dominus. Iura autem ciuilia vt fures puniebant eos, qui non manifestabant res inuentas, aut eis utebantur, nec competentem diligentiam adhibebant ad dominum earum inueniendum, vt Disp. 681 explanatum fuit.

Dubium est, si bona inuenta aut alia ratione [sect. 3] incerta, post diligentem domini illorum inquisitionem, amissamque spem illum inueniendi, tribuantur pauperibus in eleemosynam, aut in aliis operibus piis insumantur, & postea compareat is, ad quem attinebant, num, qui ita illa distribuit, teneatur ea illi restituere. Ad quod neganter est respondendum *cum Syluest. verb. rest. 8. q. 4. & cum Soto. 4. de iust. q. 7. art. 1. ad. 3.* qui enim ita illa distribuit, rationabiliter id agit, negotiū illius, iuxta existimationem, quæ tunc erat, vtiliter agendo: quare, cū neque ratione rei acceptæ, neque ratione iniustæ acceptionis, teneatur illi restituere bona, quæ ita distribuit; consequens est, vt nulla ratione teneatur ea illi restituere.

Maius dubium est de pauperibus, si adhuc in potestate ipsorum extent, quæ ita in eleemosynam acceperunt. Ac dicendum arbitror, quod ita apud ipsos extaret, restituendum esse vero domino, si is id ita vellet. Quoniam distributio videtur facta sub tacita conditione, si non compareat dominus antequam ea bona consumantur, aut alienentur, ab ipsis pauperibus, qui illa in eleemosynam proximè acceperunt pro anima illius, cuius erant. Neque aliter vtiliter ac rationabiliter gereretur negotium eius, ad quem ea bona attinebant, ac proinde nec validè. Si autem alienata, aut consumpta, iam essent, etiam si existerent in manu illius, cui à pauperibus alienata sunt, sanè restituenda non essent, neque vëdicari in foro exteriori possent, non solùm si autoritate publica distributa ita fuerant pauperibus, sed etiā si autoritate priuata vtiliter, modo explicato, agendo negotium illius, cuius ea bona erant: osset enim irrationabilis & iniqua conditio, si ita traderetur in eleemosynam, vt etiam postquam ritè alienata essent à

pauperibus, aut ad aliud opus pium, restituere illa teneantur domino comparenti, qui illa acceperunt bona fide, maximè oneroso titulo.

Quibus pauperibus restitutio bonorum incertorum fieri debeat. Et num ad illa distribuenda necesse sit interueniat Episcopi autoritas. Disp. 747.

SVMMARIVM.

- 1 . *Incertorum restitutio quibus pauperibus fieri debeat. Et num si is, qui facere eam debet, pauper sit, possit sibi etiam partem aut totum applicare.*
- 2 . *Eleemosyna quando ab vno fit per alium, quòd instrumentum, per quod fit, in peccato sit lethali, nō impedit, quòd satisfactoria ei sit, qui illam fieri præcepit.*
- 3 . *Incertorum restitutio fieri potest pauperibus sine autoritate Episcopi. Et in quibus euentibus possit Episcopus se in ea intromittere, aut eam facere.*
- 4 . *Reseruare nihilominus sibi Episcopi possunt lethale peccatum commissum ob usurpationem bonorū incertorum, aut ob dilationem restitutionis illorum. Et quæ ea de re sint in archiepiscopo patu Euorensi sancita, & quo modo intelligenda.*

QVod ad primum eorum, quæ proposita sunt, [sect. 1] attinet, dicendum est. Satis esse, si verè pau-[[266]]peribus distribuuntur. Quorum nomine non intelligo quo scunq;, qui sufficientia ad suum statum non habent: neque item solùm illos, qui adeò pauperes sunt, vt cogantur mendicare ab aliis: sed etiam illos, qui, attenta ipsorum qualitate, notabiliter egestate premuntur: quales sunt multi artifices pauperes, & personæ quædam notæ altioris, quæ præ egestate quasi à suo statu deciderunt, egreque admodum sustentantur. Atque iuxta hæc intelligo, quæ Nauar. in Manu. c. 17. n. 93. docet.

Vtrùm autem, si pauper aliquis bona aliqua incerta apud se habeat, quemadmodum restituere ea posset aliis pauperibus, sic etiam posset accipere ea sibi in eleemosynam tanquam pauper. Affirmanter est respondendum cum Caiet. 2. 2. q. 62. art. 5. ad. 3. Nauar. vbi suprà, & aliis. Præsertim, si non iniustè deuenit in possessionem eorum bonorum, per furtum, vsuram, aut alia via iniusta, sed casu illa inuenit, aut licitè aliter in ipsius potestatem deuerunt. Neque enim idcirco est deterioris conditionis, quàm reliqui pauperes, quòd in ipsius potestatem deuerint, ipseque ea distribuere teneatur, vt non possit omnia, aut partem eorum, perinde accipere in eleemosynam, atque alius posset ei illa in eleemosynā dare, si alius eadem bona incerta similiter haberet, distribuereque ea teneretur. Eodem modo, quando alicui à testatore, aut ab aliquo alio, cōmissa esset distributio aliquorum bonorum inter pauperes, si ipse pauper esset, eique competerent qualitates pauperum, inter quos est iniunctum vt fiat ea distributio, vt si dictum fuit, vt distribuerentur inter pauperes talis oppidi, & ipse pauper esset de eodem oppido, posset ipse sibi tantam partem licitè in eleemosynam vsurpare, quantam licitè tribuere posset alteri pauperi eiusdem conditionis secum. Quando autem, qui bona incerta distribuenda inter pauperes haberet, non tanta premeretur egestate, vt cogeretur mendicare ab aliis, consilium esset, vt peteret sibi ea in eleemosynam applicari à prælato, parocho,

vel confessario. Et quamvis aliqui dubitent, num, vt eleemosyna prosit, satisfactio ei sit, cuius sunt ea bona incerta, necesse sit talem eleemosynam applicari ab aliquo alio, eaq; de causa suadeant, vt semper, quando tenēti bona incerta sunt in eleemosynam applicāda, applicatio ei fiat per parochum, aut per confessarium; ego tamen non dubito applicationem in persona eius, cuius sunt ea bona, factam in eleemosynam ab eo, qui illa tenet, esse satisfactoriam ei, cuius sunt, etiam si sibimet ea tenenti fiat applicatio.

Deus quippe tunc non tam respicit, ad eum [sect. 2] effectum, personam, quæ ea bona in eleemosynam applicat; quàm eum, cuius nomine eo loco applicantur. Atque hac de causa mihi omnino persuadeo, eleemosynam à defuncto relictam, vt post ipsius mortem tribuatur pauperibus, satisfactoriā esse defuncto, esto exequutor in culpa sit lethali, quando illam pauperibus tribuit: quoniam non est eleemosyna instrumenti, per quod distribuitur, sed eius, qui per id instrumentum illam tribuit. Idem quoque est dicendum de eleemosyna, quam viuis per alium de suis bonis fieri præcipit: prodest enim ei, cuius nomine ac de cuius bonis datur, esto instrumentum, per quod datur, in culpa sit lethali.

Dixi suprà, præsertim si non iniustè deue nit in possessionem eorum bonorum: quoniam si iniustè deuenit, arctiùs est cogendus restituere, post factam diligentiam & inquisitionem eius, ad quem pertinent, eoq; non inuento, amissaq; spe illum inueniendi: idq; ne, spe lucri, assuescat similibus facinoribus. Quando autem notoriè esset pauper, cui admodum graue esset restituere, applicari illi possent à prælato, parcho, aut confessario, in eleemosynam, vt & cuius alteri pauperi.

Vtrùm autem necesse sit eleemosynam de bonis incertis fieri pauperioribus, & inter eos fieri melioribus. Dicendum est, quamvis consilium sit, vt id ita fiat: tum quia id melius est in se: tum etiā quia fidelior erit dispensator, qui id ita fecerit: satis tamen esse, si fiat pauperibus. *Ita Nauar. vbi suprà, & alii.* Necesse item non est, iniungere pauperibus onus orandi pro domino eorum bonorum, esto illa tenens, sibimet ea applicet. Neque item est necesse, restitutionem eorum bonorum fieri pauperibus eius loci, cuius ille erat, ad quē ea bona pertinebant: tamersi, ceteris paribus, consilium sit, eis pauperibus distribui, tanquam consentaneum magis præsumptæ voluntati illius, ad quem ea bona attinebant. Hæc de primo eorum, quæ proposita sunt.

Quod verò attinet ad secundum, quamvis ali [sect. 3] qui asseruerint, necessariam esse Episcopi auctoritatem, vt bona incerta pauperibus distribuantur, aut insumantur in aliis operibus piis. Communis tamen doctorum sententia affirmat, necessariam non esse. Quin addit, Episcopum impedire non posse, quominus, qui ea bona tenet, illa distribuat. *Ita Ioan. Med. de rest. q. 3. causa. 10. Nauar. in Manu. c. 17. n. 92. Syluest. verb. rest. 8. q. 5. & plerique alii.* Posset tamen episcopus in aliquibus euentibus vsurpare assumptum distribuendi prædicta bona. Primus est, quando, qui illa distribuere debebat, mortuus esset, neque hæredem, aut exequutorem, reliquisset, qui ea distribueret. Secundus, quando, qui ea bona teneret, esset suspectus, de quo verisimiliter esset timendum, non esse restitutorū. Hac ratione. c. cū sit de Iudæ is præcipitur, vt malè parta per Iudæum, quæ inter pauperes erant distribuenda, diœcesani arbitrio distribuantur. Atque idem est in eo vsurario, de quo non esset fidendum, quòd restitueret malè parta, quorum dominus ignoraretur. Huic enim, & cuicunque alteri, qui non restitueret similia bona, quę restituere teneretur, præcipere episcopus posset, vt ea sibi ad restituendū traderet, vel vt ea debitor ipse distribueret, sciēte episcopo, vel persona alia ab episcopo deputata, quibus & quantum cuique restitueretur. Itē, si episcopus

intelligeret, aliqua indebitè distribui, cogere posset, vt debitè distribuerentur, ea per se ipsum distribuendo, si ita esset opus. Ita Nauar. & Syluest. Vbi suprà, ac alii.

Quamuis, qui bona tenent incerta, possint per se [sect. 4] ipsos ea distribuere, neque aliter se possit episcopus intromittere in eorum distributione, quàm modo explicato; nihilominus reseruare sibi possunt episcopi absolutionē peccati lethalis, quod tētores eorum bonorum cōmiserint, sibi vsurpādo prēdicta bona, vel differēdo illorum restitutionē. Possunt itē prācipere confessariis, ab ipsis non exemptis, vt de eiusmodi bonis nihil disponant, sed dispositionem episcopis ipsis remittant, vt melius ea dispositio fiat, & vitentur abusus ac scandala, quæ [[267]] euenire solent, dum confessarii aliqui per imperitiam malè aliqua circa ea bona consulunt, aut cupiditate iubent ea ipsis tradi. Sic in Euorensi archiepiscopatu, dum in Lusitania commorabar, in constitutionibus tituli. 3. c. 6. Archiepiscopus sibi omnino reseruabat absolutionem peccati eorum, qui tantam quantitatem bonorum incertorum retinerent, quæ attingeret valorem *de tres mil reais*. Quòd si minoris essent valoris, concedit absolui a confessariis posse; modò tamen valor ille, aut pignus, quod id valeat, loco illius, priùs tradatur vicario, quem vocant *da vara por ante o escriuam de seu cargo*. Quo loco obserua, quando neque in occupatione, neque in retentione talium bonorum lethale peccatum interuenisset, tunc nullam esse reseruatiōem, vt est perspicuum. Item, esto lethale peccatum interuenisset, si tamen pēnitens distribuisset iam ea bona pauperibus, aut illa insumpsisset in aliis operibus piis, ad idve ea iam tradidisset, ita quòd iam ad nullam eorum restitutionem teneretur, nulla quoque esset iam reseruatio peccati prāteriti commissi. Quoniam reseruatio solūm erat, vt pēnitens adduceretur ad tradendum ea bona Archiepiscopo immediatè, si pertingerent ad valorem trium milium *reais*, vel ad tradenda ea, aut pignus loco eorum, vicario, si ad eum valorem non pertingerent, cōsuetudoque in eo archiepiscopatu est interpretata, peccatum prāteritum non esse in eo euentu reseruatum. Confessarius autem, qui, interueniente lethali peccato in occupatione, aut retentione, talium bonorum, absolueret antequam illa modis explicatis traderentur, vel antequam pēnitens illa distribueret pauperibus, aut ea traderet insumenda in aliis operibus piis, cōmitteret lethale peccatum sacrilegii, absolutioque esset nulla. Postea in additionibus eisdem constitutionibus factis fuit sancitum, vt in singulis Ecclesiis, vbi sunt vicarii *da vara*, essent arcæ quædam, in quibus mitterentur ea bona incerta, quæ essent restituenda, & vt eo ipso, quòd in eam arcam essent missa, peccatum non esset reseruatum. Obserua tamen, pēnitentes, non reperto illorum domino post adhibitam competentem diligentiam, non teneri mittere ea bona in arcam illam, sed posse illa distribuere pauperibus, aut insumere in aliis operibus piis. Ante factam autem debitam diligentiam, amissamque spem reperiendi proprium eorum bonorū dominum, nefas esset mittere ea bona in illam arcam: eo quòd id cederet in prāiudicium domini illorum, nondumque sunt debita, vt pauperibus distribuantur, aut vt insumantur in aliis operibus piis, neque item sunt interim bona simpliciter incerta: quare, esto prācessisset peccatum lethale in illis occupandis, aut retinendis, non esset tale peccatum reseruatum, sed posset absolui pēnitens, statuendo firmiter, se adhibiturum debitam diligentiam ad sciendum dominū eorum bonorum, restitutumque ea tempore congruo. Quòd si ante adhibitam diligentiam debitam ad inquirendum proprium illorum dominum, amissamque spem illum inueniendi, mitterentur ea bona in arcam illam, tentor eorum, qui illa ita mitteret cum iniuria proprii illorum domini, teneretur postea facere competentem diligentiam ad eum inquirendum, eoque inuento, teneretur de suo ea illi restituere, quando ex arca non posset illa recuperare, vt proprio illorum domino traderentur. Excipe, nisi inuincibilis ignorantia

illum excusasset à peccato, mittendo ea bona in arcam illam. In eisdem quoque additionibus ad constitutiones illas sancitum etiam fuit, vt, quando, qui ea bona sibi occupauit, aut iniuste detinuit, soluendo illa non est, pro prima vice constituatur ei certū tempus prudentis arbitrio ad illa restituendum, ac absoluatur, esto valor excedat quantitātē triū mille *reis*. Et vt, transacto eo tempore, si ad cōfessionem accedat, eis bonis minimè restitutis, casus sit omnino reseruatus. Quo loco obserua, si toto eo tempore ad restituendum illi præscripto, ob impotentiam, aut aliqua alia iusta causa, non restituit, ita quòd non accedat cum nouo lethali peccato, eo quòd eo tempore non restituerit, tunc absolui à reliquis peccatis posset, esto non restituerit. Cū enim tunc nullum cōmisisset peccatum non restituendo, non haberet peccatum reseruatum, ratione cuius non posset absolui. In eisdem additionibus sub pæna excommunicationis ipso facto incurrendæ præcipitur confessariis, vt neque per se neque per alios applicent in suum commodum restitutionem bonorum incertorum. Vicariis item, & quibuscunque aliis, ad quos deuenerit restitutio aliqua bonorum incertorum, præcipitur (tametsi non sub pæna excommunicationis) vt illam in eam arcam mittant.

Vtrūm, qui circa bona incerta summi Pontificis autoritate compositionem faciunt, tuti sint in conscientia. Disp. 748.

SVMMARIVM.

1. *Compositio locum non habet circa certa, quæ alicui debentur, illique, aut hæredibus illius, restitui possunt, sed solū circa ea, quæ pauperibus sunt restituenda, aut insumendo illa in aliis operibus piis.*
2. *Compositio locum non habet autoritate summi Pontificis circa bona Ecclesiastica, quorum, restitutio facienda est Ecclesiis, pauperibus, aut insumendo illa in aliis operibus piis, & qualiter hodie bulla cruciatæ in hoc regno fiat. Locum verò non habet circa ea ecclesiastica bona, quæ restituendæ sunt consociis, ob non intereßentiam eius, qui illæ restituere consociis tenetur, aut alia ratione.*
3. *Quando suspecta eiusmodi compositio censenda sit, vt non liberet in foro conscientie, quando non item.*
4. *Quando aliqua in pænam restituenda essent pauperibus, aut insumenda essent in aliis operibus piis, fieri circa illa potest compositio, non solū autoritate summi Pontificis, sed etiam alterius, qui eam condidisset legem.*
5. *Circa bona, quæ debentur priuatis, & quæ idcirco restituenda sunt pauperibus, aut insumendo illa in aliis operibus piis, quia ignoti illi sunt, quibus fieri debet restitutio, aut quia valde sunt remoti sine spe reuertendi, aut aliis de causis, compositio fieri potest autoritate summi Pontificis, & quā accommodatè fieri debeat ad creditorum præsumptam voluntatem, & qualiter bulla cruciatæ fiat.*
6. *Compositio fieri potest, etiam circa bona iniuste acquisita, quæ quamuis iusta de causa restitui non possunt iis, quibus debentur, ipsorumve hæredi-[[268]]bus, restituenda tamen sunt pauperibus, aut insumendo illa in aliis operibus piis.*

7. *Compositionem non possunt concedere Episcopi, & multo minus princeps secularis, circa bona, quæ debentur priuatis, & iusta de causa restituenda sunt pauperibus, aut insumenda sunt in aliis operibus piis.*

8. *Compositionem sperando, quousque peccent, qui differunt restituere aliqua insumendo illa in opere pio. Qui autem esset in proposito non restituendi, si compositio non concedatur, in statu esset damnationis æternæ.*

9. *Compositione facta, si compareat creditor, ad quæ attinebant, illi sunt integre restituenda in exteriori & in conscentiæ foro.*

DOctores communiter conueniunt, neque [sect. 1] summi Pontificis autoritate posse validè

feri compositionem circa bona, quæ alicui certæ perlonę debentur, ita vt illi, aut hæredibus illius, restitui possint. Cum his cōputa illa ita incerta, cui in particulari debeantur, vt nihilominus inter aliquos certos, propter id dubium, diuidi debeant, de quibus Disp. 745 loquuti sumus. Neque enim summus Pontifex priuare quenquā potest re sua, illive debita, nisi propter culpam aliquā, cuius punitio ad fummum Pontificē attinet, & ob quam, qui in illam incideret, dignus esset ea pæna: vel quando illum ita priuare re sua postulare omnino spirituale bonum, quod rarò aut nunquam euenit. Quo fit, vt circa bona, quæ ita debentur alicui certæ personæ, vt illi, aut hæredibus illius, restitui possint, compositio locum nō habeat. Solū ergo locum habet proposita quæstio circa bona incerta, de quibus duabus disputationibus præcedentibus sumus loquuti; itēq; circa bona, de quibus, licet certum sit cui debeatur, quia tamen fieri illi non potest restitutio propter absentiam, aut alia de causa, restituenda sunt pauperibus, vel insumenda sunt in aliis operibus piis, pro anima illius, atque etiam circa bona, quæ, cū nulli in particulari debeantur, restituenda sunt pauperibus, aut insumenda sunt in aliis operibus piis, vt sunt fructus, quos beneficiarius suos non fecit, quique alteri particulari non sint debiti, & si quæ sunt similia alia bona. Circa hæc, inquam, omnia bona locum habet proposita quæstio, nū scilicet circa ea autoritate summi Pontificis ita fieri possit compositio, vt, qui illa tenent, soluēdo aliquid longè minus ad subueniendum alicui publicę necessitati, vel ad aliud opus pium, liberi re vera maneant ab obligatione restituendi reliquum, condonante id illis sūmo Pontifice pro potestate, quam ad id habeat. Et quamuis non defuerint, qui id negauerint, & multi, præsertim recentiores, ex illo falso fundamento, sufficienter, ni fallimur, duabus præcedentibus disputationibus à nobis euerso, eam locum habere asseruerint, quòd scilicet ipso, quòd adhibita cōpetenti diligentia ad sciendum illorum dominum, bona aliqua manent omnino incerta, ad quem pertineant, transeat dominium, aut ius ad illa, in rempublicam, aut in tenētē ea bona, solaque lege humana canonica distribuenda sint pauperibus, aut sint insumenda in aliis operibus piis, eaque de causa ad summum Pontificē spectare concedere circa illa cōpositionem, quatenus subpositiua illius lege iam cadunt: sequentibus tamen cōclusionibus, quid hac de re sentiamus, paucis aperiemus.

Prima conclusio. Circa bona ecclesiastica,¹²⁰ quorum restitutio facienda est ecclesiis, pauperibus, aut insumendo illa in aliis operibus piis, [sect. 2] potest sūmus Potifex concedere ex causa rationabili compositionē. Rationabilis verò causa erit, si vt & consulat simul fragilitati hominum, qui circa similia bona oneratas habent consciētias, neque facilè damnationis statum egredientur, & vt illi contribuant ad subueniendum alicui causæ publicæ, vel ad aliud opus pium, illam cōcedat pro lōgè minori quantitate, quam sit, quod de eisdem bonis ita

debeatur. Probatur hæc cōclusio, quoniam licet summus Pontifex dominus nō sit horum bonorum, est tamen supremus illorū dispensator: ergo ex rationabili causa cōcedere potest eiusmodi cōpositionē circa illa. Id quod vehementer confirmat vsus, quo frequenter illam concedit. Illud obserua, summos Pōtisices non solere taxare summam, pro qua fieri debeat cōpositio, sed id remittere cōmissariis ad id deputatis. Obserua deinde, summum Pontificem concedere facultatem componendi circa fructus beneficiorum restitutioni obnoxios ob non recitatas horas canonicas, aut aliis de causis, dummodo dimidium summæ, pro qua fit cōpositio, tribuatur ecclesiæ, cuius est tale beneficium, ad sumptus fabricæ eiusdem ecclesiæ, & alterum dimidium ad sumptus belli in defensionem ecclesiæ. Commissarius verò cruciatæ decreuit, vt usque ad summam centum mille marauedinarum cōpositio fieret, contribuendo pro quibuscunque quinq; mille marauedinis quatuor regales argenteos, duos eorum in fabricam ecclesiæ, cuius esset tale beneficium: & duos alios Regi ad sumptus belli. Illud insuper obserua, quando restitutio fructuum beneficiorum facienda non esset ecclesiæ, aut distribuendo illos inter pauperes, vel illos insumendo in aliis operibus piis, sed restituendi essent alicui particulari personæ, vel restituendi essent aliis consociis in eadem ecclesia, qui interessendo illos suos fecissent, tunc locum non haberet compositio, sed restituendi omnino essent iis, quibus in particulari debentur, quiq; illos fecissent suos. Sic in ecclesiis cathedralibus, aut collegiatis, quoad summam manualium distributionem attinet, quæ solūm distribuitur inter interessentes, ita quòd, quo plures intersunt, eo minor quantitas eius summæ vnunquēque contingit, & quo pauciores intersunt, eo maior quantitas eiusdem summæ vniciuique obuēnit, si eueniat aliquem canonicorum, portionariorum, aut aliorum ministrorum, inter quos ea summa distribuitur, non facere suam partem aliquā eius summæ, quam accipiat, tenerique illam restituere, locum circa illam non habet compositio: quia debetur consociis, qui interfuerunt eisdem cononicis horis, inter illos distribuenda. Idem est dicendum de quibuscunq; aliis redditibus, qui solūm distribuuntur inter eos, qui intersunt, pro rata dierum, quibus vnusquisque interest diuinis officiis, vt in ecclesia Euorensi ferè totum triticum, & magna pars reliqua mensę capitularis, illo modo inter canonicos, & reliquos præbendatos, distribuitur.

Caiet. 2. 2. q. 100. art. 1. ad. 7. ait, quando, spectatis; [sect. 3] circumstantiis concurrentibus, verisimile esset, summū Pontificem non intendere condonare per compositionem, sed solūm extrahere ea via, quod potest, ex iis, quæ ecclesiis debentur, quod [[269]] aliter obtinere non potest, tunc, quia remissio & condonatio incrementi libera non esset, sed inuoluntaria mixtè, non redderet tutum in conscientia eum, qui ita componeret, sed teneretur restituere incrementum. Addit, quando cōpositio esset irrationabilis ac exorbitās, vt si pro modica re multum irrationabiliter remitteret, non esse validam talem compositionem: quoniā summus Pontifex non est dominus, sed dispensator bonorum ecclesiasticorum, neque ad id se extendit ipsius potestas. Atque consentaneè ad Caietanum loquuntur alii, quos 3 conclusione citabimus. Obserua tamen, quæ à summo Pōtifice hac in parte fierent, aut ab ipsius ministris de illius autoritate, non essent temere damnanda, aut iudicanda, sed humiliter suscipienda, illisq; esset standum, quando luce clarius non cōstaret contrarium, vt regulariter non constabit. Præsertim cū in huiusmodi cōpositionibus saluti animarum, hominumque fragilitati, consulatur, multaue ea via recuperentur in commune bonum, aut in alia opera pia, quæ alioquin nunquā restituerentur: & cū eiusmodi compositiones solūm concedantur in conscientię foro, quando in exteriori non constat deberi, neque cogi in exteriori foro detentores eorum bonorum possunt, vt illa integre restituant. Quando autem cogi aliquis in

exteriori foro optime posset integre restituere. & absque rationabili causa magna summa pro modico illi remitteretur, aut solùm remitteretur illi magna summa pro modico, quia difficilis admodum est, ac magnæ potentiæ, tunc locum habere possent, quæ eo loco Caiet. tradit.

Secunda conclusio. Quando aliqua ideo præ¹²¹ cisè restituenda essent pauperibus, aut insumēda essent in aliis operibus piis, quòd accipiens [sect. 4] in pænam factus esset incapax illorum per legem, aut ex eo, quòd dans similiter in pænam eo ipso priuaretur illis nulla expectata sententia, tunc licita ac valida esset compositio circa huiusmodi res pro longè minori valore: fierique posset, nō solùm autoritate summi Pontificis, sed etiam principis, aut alterius, cuius autoritate ea lex suisset condita. *Hanc affirmat Couar. reg. peccatum. p. 3. §. 1. n. 3.* probarique potest. Quoniam dispositio illa, & obligatio ita restituendi, oritur ex potestate eius, qui eam legem condidit: ergo, vt potest remittere obligationem illam, applicareque valorem illum ad quod voluerit, ita concedere licet ac validè poterit compositionem circa illum pro interesse aliquo ad aliquod bonū publicum, vel ad aliud opus pium.

Tertia conclusio. Quando aliqua idcirco resti¹²²tuenda essent pauperibus, aut insumenda essent in aliis operibus piis, quòd dominum haberent, [sect. 5] sed ignotum, aut notum, cui ob distātiā, aut alia ratione, fieri non posset restitutio, sed applicandū esset pauperibus, aut insumendum esset in operibus piis, in euentibus, qui inferiūs à Disp. 751 sunt explicandi, tunc, cū restitutio illo modo esset facienda in spirituale commodum eius, ad quem ea bona attinent, sanè quanuis summus Pontifex tanquam supremus pastor, supremusq; dispensator eorum, quæ ad salutem conducunt animarum, concedere circa illa possit compositionem, applicareque, quod in compositione fuerit datum, in bonum aliquod commune ac publicum, vel in aliud nium opus, pro anima illius, ad quem spectant bona, circa quæ fit ea cōpositio; id tamen fieri debet, seruata æquali vtilitate eorum, quorum sunt eiusmodi bona, quoad id fieri possit, ac iuxta præsumptam eorundē etiam voluntatem, quantum commodè fieri possit. *Consentit Couar. n. 3. citato*, qui melius, magisque perspicuè, hac de re videtur loquutus, quàm alii: atque iuxta hæc accipienda sunt, *quæ docent Ioan. Med. de rest. q. 3. causa. 11. Sotus. 4. de iust. q. 7. art. 1. ad. 3. Nauar. in Manu. c. 17. n. 93. & alii.* Ratio autem huius conclusionis est, quoniam sicut summus Pontifex priuare non potest homines rebus ipsis debitis, quando ii, ad quos pertinent, nori sunt, vt in principio huius disputationis est dictum: sic, quando sunt ignoti, cū non amiserint dominium rerum suarum, iūsve rerum sibi debitarum, priuare illos non potest, ipsis præsumptè inuitis, iure, quod habent, vt in ipsorum spirituale bonum expendantur, atque quàm maximè sieri possit iuxta præsumptam eorum voluntatem, quando non est rationabilis causa, quæ aliud efflagitet: tunc enim, tanquam supremus eorum dispensator, quæ in pias causas pro animarum salute sunt insumenda, quæque non habent proprium illorum dominum administratorem, occurrente rationali causa, reque pia, maximè ad commune bonum spectant, potest ad illam similia bona applicare, vt de legatis piis à testatoribus relictis Disput. 249 est dictum. Quo loco obserua, quando verisimile esset, nisi eiusmodi compositiones concederentur, multo pauciora esse restituenda ac connertenda in bonum spirituale eorum, ad quos ea bona spectant, idque nequitia & fragilitate eorum, qui illa tenent, vt regulariter euenire solet, tunc summum Pontificem vtiliter agere negotium spirituale eorum, ad quos ea bona spectant, concedendo eiusmodi compositiones, simulque id efficere valde consentaneè ad præsumptas eorundem voluntates, qui, attentis circumstantiis concurrentibus, id verisimiliter eligerent. Obserua item, condonationem, qua summus Pontifex, tanquam Christi vicarius, vniuersalisque pastor, debiti partem condonat, vt facilius ac citius Christi fideles periculum suarum animarum

euadant, esse opus satis pium ac satisfactorium, quod proinde cedit in satisfactionem ac bonum eorum, ad quos pertinent bona, quæ summus Pontifex eorum loco ac veluti eorum nomine condonat. Vt autem conclusione prima dicebamus, summi Pontifices non solent exprimere quantitatem, pro qua summa aliqua condonari via compositionis debeat, sed id committunt commissariis cruciatę. In hoc autem regno commissarii exprimunt, vt bullis cruciatę compositio fieri possit vsque ad centum mille marauedinos, tot bullas sumendo, quot fuerint quinque mille marauedini inclusi in tota summa, quam componere volunt, atque soluendo duos regales argenteos pro singulis quinque mille marauedinis, qui ipsis ita condonantur. Quòd si summa componenda centum mille marauedinos excedat, tunc pro incremento compositio fiat cum commissariis ipsis cruciatę.

Quod ad bona attinet, circa quæ, iuxta tertiã [sect. 6] propositam conclusionem, fieri potest modo explicatio compositio, vt summam comprehendam, quæ à multis pluribus explicantur, dicendum est. Fieri posse, non solum circa bona, [[270]] quæ licite tenentur, comparatæ sunt, vt sunt bona inuenta, quæ tenentur animo illa restituēdi, & plura alia sine peccato cōparata, sed etiam circa bona illicitè per vsuram, furtum, aut aliam viam iniustam, acquisita, quando, quòd restitui non possunt vero domino, eive, ad quem spectant, restituenda essent pauperibus, aut insumenda essent in alia opera pia: quæ autem hæc sint, suis in locis est explicatum, explicandumque adhuc restat. Atque ad hanc regulam à nobis proximè traditam, admetienda sunt omnia, quæ à doctoribus hac de re traduntur, aut in exemplum adducuntur. Dubium est, vtrum sicut summus Pontifex [sect. 7] concedere potest compositionem modo explicato circa bona, de quibus tertia conclusione loquimur: ita episcopi in suis diæcesibus possint circa eadem bona illam concedere. Ad quod, licet aliqui contrarium censeant, neganter arbitror esse respondendum. Quoniam sicut episcopi commutare non possunt legata, quando impleri possunt, vt Disp. 249 est dictum: ita neque cōcedere possunt eiusmodi compositiones: neque id habet consuetudo. De principibus autem secularibus multo minus credo posse illas concedere circa eadem bona insumenda in operibus piis, de quibus conclusione proposita est sermo.

Quarta conclusio. Qui restituere tenentur bona aliqua, distribuendo illa pauperibus, aut insu [sect. 8] mendo illa in aliis operibus piis, peccant ea non restituendo spe compositionis concedendæ in futurum: nisi fortè tantisper expectent, illam statim ex rationabili aliqua causa, per se, vel per interpositam personam, petēdo, parati, si negetur, restituere statim ac denegata fuerit compositio. Primum affirmant Nauar. & Sotus locis citatis. Et in euentu solo limitationis adhibitæ non repugnarem contrariæ quorundam aliorum sententiæ. Quòd si culpabiliter non restituant, posteaque compositio concedatur, tunc facta compositione, deobligantur ab onere restituendi. Si tamen in actuali proposito essent, esto per compositionem ab onere restituendi non liberarētur, nunquam restituere, in statu essent damnationis æternæ, nisi id prauum mutarent propositum.

Quinta conclusio. Si facta legitimè compositione¹²⁴, præter spem, comperiatur, ad quem ea bona [sect. 9] na, circa quæ est facta compositio, attinerent, tunc in foro exteriori esset cogendus ea soluere illi, ad quem pertinebant, ac si compositionem non fecisset. Idem etiam est dicendum in foro conscientię. Quoniam vt conclusione tertia dictum est, summus Pontifex compositione præiudicare non potest, neque intendit, iuri priuatorum, quo minus consequantur bona, quæ ipsis debentur, neque potest concedere compositionem circa ea bona, nisi accommodatè ad rationabilem mentem talium creditorum: mens verò

rationabilissima eorum est, vt compositione non impediuntur consequi sua bona, quando, seclusa compositione, illa obtinuissent, si in culpa non sint imusti detentores.

Lusitanæ leges circa animalia inuenta expenduntur, num iustæ sint.
Disp. 749.

HÆc etiam disputatio & sequens ad res incertas spectant, in eisq̃ue solùm est sermo de rebus inuentis. *Ordiendo verò a Lusitanis legibus, lib. 3. ordi. titu. 76.* (corrupto latino vocabulo de inuento, vt videtur, Lusitanè res quædam inuentæ, *de vento* nuncupantur in eo titulo, & cōmuni hominum sermone) neque in eo titulo sermo est de quibuscunque inuentis, sed solùm de animalibus quibuscunque aliorum inuentis, siue pecudes sint, siue iumenta, aut alia armenta. Atque ibi præcipitur, vt quicumque inuenerit quodcunque animal alienum, teneatur intra quinq; dies à pūcto, quo illud inuenerit ac acceperit, manifestare illud publicano, qui conductum habuerit emolumentum, quod inde poterit euenire, vel præfecto, qui ad id fuerit deputatus in loco, vbi publicanus non fuerit, idq̃ue sub pæna soluendi duplum, quod ita fuerit inuentum. Publicanus verò, aut præfectus ad id deputatus, tenetur continuò facere scribere per scribam reddituum Regis, aut per tabellionem ad id deputatum, animal illud in libro publico ad id deputato, exprimendo per quem, ac vbi, fuerit inuentum, signaq̃ue talis animalis. Item tenetur publicanus, aut præfectus ad id deputatus, adducere id animal, aut animalia reperta, singulis hebdomadibus ad locum in vnaquaque ciuitate *ou vila* ad id deputatum, esseq̃ue debet is locus ciuitatis, *ou da vila*, districti, in quo id animal fuit repertum, & tenetur ita adducere prædictum animal per integros quatuor menses cōputatos à die, in quo in suprà dicto libro fuit scriptum. Dies autem, in quo singulis hebdomadibus ad eum locum debet adduci, esse debet feria tertia in locis, in quibus est consuetudo vt fiant *feiras*; (*mercados publicos* nostri dicunt, quæ vt inter nos diebus Iouis fieri consueuerunt, ita in Lusitania consueuerunt fieri die Martis feriæ tertia, vt illi loquuntur) in aliis verò locis, in quibus non consueuerunt fieri *feinas*, adduci id animal debet in quocunque die hebdomadæ, qui in eo loco ad idsuerit deputatus. Item in eo loco singulis hebdomadibus publicanda sunt ea animalia ad eum locum adducta præconis voce, scribendaq̃ue sunt singula ea præconia in eodem libro per eundem scribam aut tabellionem. Quòd si intra prædictos quatuor menses comparuerit dominus animalis, probaueritq̃ue suum esse, illi est tradendum, soluetq̃ue publicano, aut ad id præfecto, expēsas factas in eo custodiendo ac alendo. Si autem dominus intra prædictos quatuor menses non comparuerit, seruataq̃ue sint omnia, quæ dicta sunt, ex parte publicani, aut præfecti, esse seruanda, tunc publicanus petit à iudice eius loci, vt sibi adiudicet id animal; iudexq̃ue, cognito priùs adhibitas fuisse prædictas omnes diligentias, tenetur illud ei adiudicare, lataq̃ue ea sententia, comparat publicanus dominium illius; illudq̃ue amittit eo ipso prior dominus illius, ita vt, esto postea compareat, probetque suum fuisse id animal, non teneatur publicanus illud ei reddere. Publicanis verò præcipitur, vt tempore toto illorum quatuor mensium, neque vendere, neque interficere, neque abscondere, neque transferre possint prædicta animalia in alium locum, sed teneantur ea habere *no termo da vila ou cidade*, vbi fuerint reperta, & in loco vbi conspici possint, ac sciri vbi sint; atque [[271]] hæc omnia illis præcipiuntur sub pæna, vt puniantur, ac si illa essent furati.

Quid de hac re sentiam, sequentibus con¹²⁵clusionibus explanabo. Prima est. Lex hæc, si publicani seruent omnia, quæ in ea continentur, & Rex, potestatisve Regi subordinatæ, sufficienter vigilant, vt ea omnia seruentur, inquirendo sufficienter transgressores, eosq̃ue

puniēdo, atque, vt summatim dicam, opere efficiendo, vt regulariter ea omnia præstentur, non est cur condemnetur, comparantque publicani dominium eorum animalium, quæ, seruatis omnibus, quæ in ea lege continentur, ipsis adiudicantur. Imò verò, qui aliena animalia reperiunt, eaque publicanis, aut aliis præfectis ad id deputatis, non manifestant, eaque de causa publicanos emolumento aliquo priuant, contra iustitiam peccant, restituereque eis tenentur, quantum æstimabitur emolumentum, quo eos priuant: nisi bona fides, inuincibilisque ignorantia, quòd teneantur illis manifestare ac tradere ea animalia, eos à restituendi onere excuset: Eodem modo, si, quia ea non manifestant, ac tradunt publicanis, domini eorum animalium suis priuantur animalibus, quia publicani adhibuissent diligentias omnes lege relata præscriptas, domini que comperissent sua animalia apud publicanos, eaque accepissent; sanè tenentur restituere dominis eiusmodi animalium dāna inde eis sequuta, nisi similiter inuincibili ignorantia excusentur.

Prima pars huius conclusionis ex eo probatur, quòd ea lex cedit in vtilitatem publicam, in commodumque dominorum talium animalium, qui, si omnia seruentur, quæ ea lege continentur, faciliè inuenient sua animalia deperdita, quæ alioquin non faciliè, sed multo cum labore, inuenissent, multi que illa omnino amitterent; lexque illa sufficiens tempus sufficientissim asque diligentias fieri præscribit, quæ si seruentur, domini que talium animalium negligentes omnino non sint, faciliè ac regulariter sua inuenient ac recuperabunt animalia: ergo pro communi bono, atque in præmium eorum, quibus ex officio incumberet exequutioni mandare prædictas omnes diligentias, ac simul quasi in pœnam eorum, qui tanto tempore negligentes essent ad inquirenda sua animalia, quæ tam faciliè accedendo ad ea loca, aut inquirendo ab aliis, qui ad ea loca accessissent, poterant inuenire, potuit princeps illos priuare dominio talium animalium, illudque eis applicare, quibus incumberet eas facere diligentias: quemadmodum lege præscriptionis priuare homines potuit dominio suarum rerum, illudque bonæ fidei talium rerum possessoribus applicare. Quin arbitror, populo id postulante, ac præcipuè dominis pecorum, eam legem in eorum bonum fuisse sancitam. Vnde non probo sententiam *Couar. reg. peccatum. p. 3. §. 1. n. 5.* asserentis similem aliam legem huius regni (de qua sequenti disputatione erit sermo) iustam non esse, nisi in cuentu, quòd post factas diligentias omnes ea lege præscriptas ad inueniendum dominū, cōparente domino, res ipsi restituantur.

Secundam verò partem, quòd scilicet, si seruarentur, quæ in ea lege præscripta sunt, contra iustitiam peccaret aduersus publicanum, qui illi non manifestaret ac traderet animal inuentum, tenereturque restituere illi æstimationem emolumenti, quo ea ratione illum priuaret, nisi, qui animal illi non manifestaret, à culpa excusaretur inuincibili ignorantia, probatur. Quoniā publicanus per eam legem iustum comparasset ius ad emolumentum illud, quod vi talis legis illi poterat obuenire: ergo qui ea animalia eis, iuxta præscriptum eius legis, non manifestarent, eosque priuarent commodo illius spei, contra iustitiam peccarent, illisque restituere tenerentur, quantum ea spes ad id commodum æstimaretur. Si autem non manifestantem id animal excusasset ignorantia inuincibilis, neque ex illo esset factus locupletior, quia iam integrum distribuisset pauperibus, aut insumpsisset in aliis operibus piis pro anima domini illius, tunc ad nullam restitutionem teneretur: quia neque ex parte rei acceptæ, neque ex parte iniustæ acceptionis.

Tertia verò pars, quòd scilicet in eodem euentu peccaret contra iustitiam aduersus dominum animalis, & teneretur ei restituere, quantum æstimaretur detrimentum inde ei sequutum, nisi similiter eum excuset ignorantia inuincibilis, satis perspicua est. Quoniam, supposita

lege, obseruationeque integra illius, iniuriam illi faceret, quæ cederet in damnum iniustum illius, priuando illum iniuste via illa valde accommodata ad inueniendum ac recuperandum suum illud animal.

Secunda conclusio. Si publicani aliquid eo¹²⁶rum, quæ lege relata præscripta sunt, prætermittant, occultando, interficiendo, transferendo in alium locum, animalia inuenta, prætermittendo aliquid eorum, quæ ea lege facere præcipiuntur, antequam animalia illa ipsis adiudicentur, vel in illis exequendis fraude aliqua, aut dolo, vtendo, vt eligendo ad præconia tempora, in quibus homines solent minùs conuenire ac accedere ad locum ad ea præconia destinatum, vt dum homines communiter prandent, aut simili alia fraude vtendo, peccant contra iustitiam, restituereque tenentur illorum dominis animalia ipsis adiudicata, si qua via cõperire illos possint: sin minùs, restituere illa tenentur pauperibus, aut insumere illa in aliis operibus piis, tanquam bona incerta, pro animabus eorum, quorum ea animalia erant. Probatur, quoniam lex non concedit illis dominium eorũ animalium, neque priuat illorum dominos iure suo ac dominio, nisi sub conditione, si publicani priùs seruent omnia, quæ ea lege præscripta sunt; essetque lex iniqua, si aliud statueret: ergo publicani quandocunque non seruant ea omnia, quæ lege illa præscripta sunt, restituere tenentur animalia virtute eius legis ipsis adiudicata: quin, vt eadem lex statuit, puniendi insuper sunt tanquam fures, non secùs ac si ex propriis illorum dominis furati illa fuissent.

Tertia conclusio. Si (vt fama erat in Transtaga¹²⁷na regione, dum in Lusitania commorabar) publicani sæpe non seruant, quæ lege relata seruari præcipiuntur; tunc, qui eiusmodi aliena animalia inueniunt ac retinent, non tenentur ea illis tradere, sed per se ipsos possunt, ac debent, facere competentem diligentiam ad inquirendum ac inueniendum proprium illorum dominum, vt illa ei tradant: præsertim si æquè [[272]] sit verisimile, eiusmodi animalia ea via deuencura esse ad illorum dominum, ac via publicanorum; vel si præsumptio sit, dominum contentum fore, vt publicano non tradantur. Facta autem tunc competenti diligentia per eiusmodi priuatum detentorem talium animalium, si spes non sit dominum inueniendi, tunc pauperibus, tanquam bona incerta, sunt distribuenda, vel ipsa, vel eorum æstimatio, aut insumenda sunt in aliis operibus piis, pro eius anima, cuius erant, Probatur, quoniam, cùm publicanus lege abutatur in reipublicæ dominorumq; eorum animalium præiudicium, ius sanè vi eius legis non habet, vt ei tradantur: quin potiùs, si aliunde ea traditio non excusaretur, modo conclusione sequenti explicando, iniuriosa illa esset domino eorum animalium, cum onere ipsis illa restituendi. Neque lex esset iusta, si in eo euentu præciperet, vt publicano, ea lege abutenti, traderentur: id quippe esset, quasi cooperari ad peccatum ac iniustitiam publicani.

Quarta conclusio. Quia lege relata pæna du¹²⁸pli statuta est retinentibus eiusmodi animalia, nisi illa publicano manifestent intra quinque dies à puncto, quo illa inuenerint ac acceperint: eaque pæna seuerè solet exequutioni mandari, publicanis variis modis inquirentibus, quinam illa retineant; manifestatio verò & traditio eiusmodi animalium publicano ex se non est mala, sed publicanus est, qui sua nequitia solet ea abuti: sæpeque euenire solet, vt domini ea via inueniant, acquirantque sua animalia: & quia legis autoritate fit: sanè nec peccant, nec restituere tenentur, qui, vt pænam euadant, publicanis manifestant ac tradunt ea animalia, nihil impediende, quòd iustè timeant, eos cum iniuria dominorum, quorum sunt ea animalia, seruatuos non esse, quæ lege eis præscripta sunt. Hæc conclusio probatur, quoniam nullus cum tanto suo onere tenetur id omittere, quod ex se non est malum, legisque autoritate fit.

Potestates verò ipsæ publicæ videant, qua ratione talia ea lege præcipiant, non curando seriò ac seuerè, vt, quæ eadem lege præcipiuntur, exactè ac integre exequutioni mandentur.

Quinta conclusio. Lusitana lex relata tolli¹²⁹ deberet, aut mutari. Quoniam re vera occasio est, vt quàm multæ committantur iniustitiæ: multiq̃ue conqueruntur, fraudes ac iniustitias frequentes à publicanis committi, minimè, quæ lege sunt præscripta, seruantibus, eaq̃ue ratione iniustè aliorum bona vsurpantibus. Fraudem autem dicuntur quàm sæpissime committi, transferendo animalia reperta in districto vnus ciuitatis, aut villæ, quam vocant, in aliam ciuitatem, aut villam, ibiq̃ue exequutioni mandando præconia. Item non toties præconia continuando, quoties lex præcipit, neque tempore, quo homines eò conuenire solent. Item interficiendo eiusmodi animalia, eorumq̃ue carnes vendendo. Item illa occultando, nec publicè in confinio, in quo sunt reperta, illa pascendo, aliisq̃ue similibus modis. Atque cùm eiusmodi emolumenta in vnaquaq; ciuitate, aut *vila*, locentur aliquod millibus marauedinarum, seu *reais*, puta quindecim, viginti, vel alia minori aut maiori summa, prout fuerit spes lucri: & qui id emolumentum conducunt, ad lucrandum illud conducant, operamq̃ue ac laborem apponant, neque esse soleant viri timorati, neque inquire soleat de eorum excessibus ac iniustitiis, ne arceantur ab eo ineundo contractu; sanè lex relata non potest non esse occasio multarum iniquitatum ac iniustitiarum. Quapropter, qui regni regimen in manu tenent, illiq̃ue, quibus in eo regno est commissum examinare, quæ ad Regis conscientiam pertinent, videant, num tuta conscientia tolerari lex relata possit: præsertim non curando, vt abusus, qui circa illam committuntur, efficaciter de medio tollantur. In hoc Castellæ regno mestæ, quas vocant, variis in locis, staturis anni temporibus, celebrantur, quò consluere solent pecorum domini, quique negotia circa lanas, & alia, ad pecora attinentia, habent, ibiq̃ue manesant pecorum custodes, quas pecudes aliorum deperditas in suo grege habeant, sicq̃ue multa pecora deperdita inueniuntur, præter illa, quæ muenuintur, facta diligentia à dominis, & ab illorum custodibus, in territoriis, in quibus fuerunt deperditæ, atque, vt experientia docet, rarò pecora non inueniuntur. Fortasse expediret, vt simile quid in Lusitania fieret, lexq̃ue illa abrogaretur.

Leges huius Castellæ regni circa inuenta. Disput. 750.

Couar. reg. peccatum. part. 3. §. 1. n. 5. leges refert, tum huius Castellæ regni, tum etiam quorundam aliorum regnorum, quibus sancitum est, vt quæcunque inuenta, esto animalia non sint, (quæ *lo mostrenco* apud nos dicuntur) tradantur iudici, aut aliq̃ personæ ad id deputaræ, fiantq̃ue certæ diligentia eis legibus præscriptæ, vt inueniatur dominus, eiq̃ue tradantur; alioquin, transacto certo tempore, factisq̃ue ritè eis omnibus diligentibus, fisco adiudicentur, aut aliis, quibus lege, consuetudine, aut priuilegio sunt concessæ. Leges huius regni retulimus suprà Disp. 681. §. lege. 6. & 7. vbi etiam adiecimus, leges illas, quamuis in noua collectione sint insertæ, nullibi esse in vsu, vt quæ illis sancita sunt, seruentur, ac proinde vim non habere in hoc regno, sed de rebus inuentis esse id faciendum, quod, seclis eis legibus, disputationibus præcedentibus est explanatum, faciendum esse circa inuenta, & circa alia bona incerta. *Couar.* loco citato, vt iniustas eas leges damnat, etiam si fiant diligentia omnes illis præscriptæ, neque tutum esse in conscientia illum, cui res inuentæ post factas eas omnes diligentias essent adiudicatæ, nisi eis statuatur, vt comparente domino rei post eas diligentias factas, & post eam adiudicationem, sua illi tradantur. Ego verò tutum illum in conscientia redderem, neque tales leges damnam, si omnia, quæ illis fieri præscripta sunt, ad vnguem essent seruata.

Fertur, Castellæ regnum fratribus Mercenariis ac Trinitariis applicasse *lo mostrenco* in redēptionem captiuorum, locumque esse pręuentioni, qui eorum fratrum priores illud petant ac accipiāt. Fertur item, Philippum secundum idem illis confirmasse, Gregoriumque decimum-tertiū idem illis cōprobasse, atque à nūciis apostolicis eos obtinere paulinas, vt per cēsuras melius ea bona [[273]] in tam sanctum finem ac opus obtineantur. Dicendum est, si eiusmodi fratres, per ministros, quos ad id in variis oppidis habent deputatos, fideliter exequantur circa res inuentas pręscripta omnia legibus huius regni ad inquirendum verū illorum dominum, vt, si comparuerit, ea illi tradant, tunc eas res ipsis ad eum finem deberi, quantum priuilegiis suis fuerit compertum eas ipsis ad eum finem esse applicatas, & non amplius. Quæ autem seruare debent, vt ex dictis Disp. 681 citata liquet, hæc sunt: Vt per quatuordecim menses à puncto, in quo talis res fuerit reperta, *la tengan de manisiestosy la bagan pregonar en publico cada mes vna vez en el dicho lugar por pregonero conocido del tal lugar, y que los tales pregonos se bagan en dia de mercado*. Siverò prædicta omnia non seruant, eis non debentur: quoniam non alia ratione sunt eis concessa, neque concedi potuerunt, nisi seruatis eis conditionibus. Nunquam autem audiuntur eiusmodi præconia ab eiusmodi ministris fieri. Atque ipsi viderint num cum iniuria dominorum, & cum onere restituēdi eis dāna inde eis subsequuta, per ministros suos hæc vsurpent, non faciendo competentem diligentiam vt domini reperiantur, eisque restituantur.

Quid sit restituendum. Quòd si pereat, aut dum mittitur, non perueniat ad eum, cut facienda est restitutio, cui pereat. Disp. 751.

SVMMARIVM.

1. *REstitui debet eadem numero res, quæ debetur, si res determinata in singulari debeatur, restituiq̃ possit, & is, cui debetur, contentus non sit æquiualentī; alioquin culpa incurritur, & restituendum est damnum, si, quia non restituitur eadem res culpa debitoris, damnum aliquod sequatur. Quando debetur res indeterminata in indiuiduo, æquiuolenter restitui debet.*
2. *Restitutionis obligatio cęsat, quando res debebatur determinata in indiuiduo, & periit, aut ad creditore non peruenit absque culpa debitoris, & nec contractu nec iuris dispositione tenebatur ad id detrimentum. Secus si nihil horum interuenit.*
3. *Si debebatur res determinata in indiuiduo, interuenitq̃ iniusta illius detentio, quæ occasio fuit, quòd res periret, aut non deueniret ad creditorem, restituenda illi est.*
4. *Si debeatur res indeterminata in indiuiduo, non prius censetur ei debito satisfactum, quæ tradatur creditori, aut alteri, qui vices ad id a creditore habeat.*

DISputatio hæc facilis expeditaque est, ex di [sect. 1] ctis Disp. 296, 561, & 563, ac alibi in præcedētibz. Quando id, quod debetur, est res determinata in singulari, tunc, siue ex delicto debeatur, siue ex contractu, siue quacūq; alia ratione, tenetur debitor eādē numero restituere, seu soluere, si id fieri possit & is, cui debetur, contentus nō fit solutione æquiuolētis: aliter peccat restituēdo solū æquiuolens: poteritque peccatum ad culpam peruenire lethalem, pro rei restituēdæ qualitate, & circumstantiis concurrentibus. Dixi, si id fieri possit: quoniam, si

fieri nequeat, vel quia res non existit, vel quia illam distraxit, nec potest illam recuperare, vel quia sine notabili iactura, in suis bonis externis, aut in suo honore, aut fama, non potest illam recuperare, aut restituere eandem numero, tunc satis est, si æquivalens restituat. Si tamen ipse in culpa fuit, ne restitueret eandem rem, eaque de causa lucrum ei cessavit, aut damnum emersit, cui facienda erat restitutio, tunc restituere ei tenetur id etiam lucrum cessans, aut damnum emergens. Addidi, & is, cui debetur, contentus non sit solutione æquivalentis: quoniam, si contentus sit, tunc volenti ac cōsentienti nulla fit iniuria. Quando verò id, quod debetur, non est res determinata in indiuiduo, sed aliquid in specie, putà tantum tritici, pecuniæ, vini, aut olei, tunc indifferenter restitui potest hoc vel illud in singulari, modò eius sit speciei, cuius debetur, competentemque habeat bonitatem iuxta id, quod in obligatione continetur. Hæc per spicua sunt, & præter alios, *consentiunt Caiet. in summa verb. rest. c. 2. & Nauar. in Manu. c. 17. n. 10. & 24.*

Quod ad secundum verò eorum, quæ proposita sunt, attinet, distinguendum est. Quoniam vel id, quod restituendum est, est res certa ac determinata in indiuiduo, vt si restituenda sit res commodata, conducta, pignori data, deposita, vt reddatur eadem singularis, vel vendita determinata in singulari, aut legata similiter, vel res ipsa furto ablata, aut aliqua alia simili ratione debita determinata in singulari: vel, quod restituendum est, est res debita solùm in specie, non verò determinata in indiuiduo, vt est mutuum, res vendita, aut legata, in specie, pretium rei emptæ aut conductæ, & similia alia, quæ sunt debita, determinata quidem in specie, sed indeterminata in indiuiduo. Quando id, quod debetur, est determinatum in indiuiduo, est rursus distinguendum. Quoniam, vel præcessit iniusta acceptio, aut retentio, ex parte debitoris, aut eius, cuius nomine ac loco fit restitutio, aut ex parte defuncti, cuius loco hæres restituit: vel non præcessit talis iniusta acceptio aut retentio. His ita constitutis, sequētibz conclusionibus est satisfaciendū secundæ parti disputationis propositæ.

Prima est. Si, quod est restituendum ac debetur, est res determinata in indiuiduo, neque in¹³⁰teruenit iniusta illius acceptio aut retentio, tunc, si pereat, deteriórve sit reddita, aut culpa [sect. 2] internūcii non perueniat ad creditorem, nulla interueniente culpa ex parte debitoris, ex qua, iuxta tituli naturam, aut contractus, ex quo illud debebat, perit, deteriórve redditur, creditori, & non debitori, eaque de causa debitor deobligatus omnino manet à restitutione, ita vt nihil loco illius, deteriorationisve, restituere teneatur. Si autem pereat, aut ad creditorem non perueniat, culpa debitoris, ex qua, iuxta tituli, aut cōtractus, naturam ac dispositionem iuris, vel ex pacto peculiari superaddito, teneatur, tunc perit debitori, eaque de causa tenetur valorem illius restituere. Hæc patet ex dictis disputationibus citatis. Ratio autem prioris partis est, quoniam res perit, deteriórve redditur, domino, aut ei, qui solùm ad illam in singulari habebat ius, quando non interuenit culpa aliqua eius, qui illam tenebat, quique soluere illam tenebatur; & quando aliud non fuit deductum in pactum: si enim deductum in pacto fuisset, vt debitori periret, etiam ex casu fortuito, tunc pacto esset standum, [[274]] modò pactum nihil contineret iniustum, aut contra bonos mores, vt disputationibus citatis dictum est. Posterior verò conclusionis pars probatione non indiget. Quoniam, si res debita culpa debitoris periit, qua, iuxta titulum, aut contractum, iurísve dispositionem, tenebatur, ipsi perit: & idem est, si pacto iusto in se suscepit quodcunque aliud illius periculum. Quia verò in his euentibus, eo ipso, quòd res periit, solùm tenetur illam cōpensare; nihilque iam debet in singulari determinatum, sed fas illi est hac vel illa pecunia illam compensare, vel re alia indeterminata in indiuiduo, consequēs est, vt iam tunc perinde iudicandum sit de hoc

debitore, ac de illo, qui solùm debet rem determinatam in specie, sed indeterminatam in individuo, de quo conclusione tertia est sermo.

Secunda conclusio. Si, quod restituendum est,¹³¹ ac debetur, res sit determinata in individuo, sed interuenit iniusta illius acceptio, aut detentio, tunc, si ea iniusta acceptio, aut detentio, occasio fuit, quòd res periret, aut non perueniret ad creditorem, tunc debitori perit, & non creditori, ac proinde creditori est compensanda. Hinc, si res furto ablata pereat in potestate furis, aut alterius, in quem ex fure fuit deriuata, quæ tamen peritura non fuisset simili modo domino, si ex illo non fuisset furto ablata, constat teneri furem eā illi restituere. Si item conductor, cōmodatarius, qui pignus accepit, & alii similes, in mora iniusta sint restituendi res illis, ad quos spectant, eaq; occasione pereant, cū perituræ simili modo non fuissent in manu eorum, ad quos pertinent, tenentur eas restituere. Ratio autem est, quoniā ex iniusta acceptione, aut retentione talium rerum, subsequutum fuit id damnum illi, ad quem ea res attinebat, vt locis citatis est dictum. Quòd si res simili modo peritura erat in manu eius, ad quem attinebat, tunc non perit debitori, sed illi, cui debebatur: vt locis citatis, & Disput. 725, cōclu. 7, est ostēsū, quo in loco, & cōclusionē. 6. ibi antecedēte legas, quę circa has duas cōclusiones dici hoc loco poterant. Atque obserua, postquam res fuerit ex eo compensanda, quòd occasione iniustæ acceptionis, aut detentionis, perierit, aut non peruenerit ad potestatem eius, ad quē attinebat, tunc quia id, quod loco illius debetur, non est aliquid determinatum in individuo, perinde est iudicandum de tali debitore, atque de eo, qui debet aliquid in specie, vt in fine conclusionis præcedentis dicebamus.

Tertia conclusio. Quando id, quod debetur,¹³² non est determinatum in individuo, non priùs censetur ei debito satisfactum, quàm tradatur cre [sect. 4] ditori, aut alteri, qui vices à creditore habeat ad nomine creditoris illud accipiendum. Quis autem à creditore eiusmodi vices habere censeatur, disputationibus citatis est dictum, præsertim Disp. 563. lege etiam, quæ Disp. 569 sunt dicta. Vnde, si debitum mittatur per aliquem, quem ad id debitor elegerit, ad creditoremque non perueniat, quia nuncius cum ea re aufugit, aut quia absque vlla sua culpa spoliatus illa in itinere fuit, vel aliqua alia ratione, perit debitori, & non creditori. Ratio autem est, quoniam debitor in eo euentu non habet obligationem ad hoc smgulare individuum, quod mittebat, sed ad soluendum, tradendūmve creditori, tantum, vel tantum, talis speciei, siue sit hoc singulare, siue illud: eaque de causa non extinguitur obligatio ex eo, quòd pereat illud numero, quod mittebatur, vt sæpius in præcedentibus dictum comprobatūque est. Reliqua quæ de hac re dici hoc loco poterant, Disp. 296, 563, & aliàs sæpe sunt dicta, quibus in locis iura & doctores adiecimus, qui in his consentiunt.

Vbi, & cuius expensis, restitutio sit faciendæ. Disp. 752.

SVMMARIVM.

1. Restituendum, aut soluendum, præcisè quia fuit inuentum, casūve deuenit ad manus alicuius, aut comperitur ad alium pertinere, præcedēte bona fide, ibi est soluendum, vbi reperitur. Si autē sit ad eum mittendum, ad quem attinet, expensis illius est id faciendum.

2 . Restituendum, aut soluendum, si sit aliquid ex cōtractu, aut alio simili titulo, & locus fuit designatus, ibi facienda est solutio: alioquin in loco, vbi credebatur debitorem tempore solutionis habiturum domicilium. Et quid quando res debetur ex contractu merè lucratiuo.

3 . Soluenda si sit res in vno loco, & per debitorem stet, quòd ibi non soluatur, quæ actio aduersus illum creditori competat: si verò stet per creditorem, quæ actio aduersus eum debitori competat.

4 . Soluere mutuarius, aut commodatarius, non tenentur mutuum, aut commodatum, ante tempus contractu præfixum, neque in alio loco, ex eo quòd mutuans, aut commodans, in alium migret locū.

5 . Soluere si quis ex delicto tenetur aliquid, seruare omnino indemnem tenetur creditorem, ita vt suis expensis illud creditori tradat, demendo, si quid creditor erat insumpturus in ea re transportanda. Et quid si expensæ, quas debitor in restituenda ea re esset factururus, nimie admodum essent futuræ.

Circa rem hanc est distinguendum. Quoniam, quod est restituendum ac debetur, vel est res inuēta, aut quam debitor bona fide possidebat, deprehenditque alteri deberi; vel debetur ex contractu, aut ex quocunque alio titulo absque delicto, vt debentur mutuum, pretium rei emptæ, tributum, & similia alia; vel debetur ex delicto, vt ex furto, rapina, damno dato, quia acceptum vsurariè, aut quauis alia ratione iniustè; vel quia iniustè est detentum, interueniente scilicet mora iniusta illud restituendi.

His ita constitutis, prima conclusio hac de re¹³³ est. Quando aliquid est restituendum quia debetur, non ex contractu, neque ex alio simili ti [sect. 1] tulo, neque ex delicto, neque præcedente mora iniusta illud restituendi, seu soluendi, sed quia vel fuit inuentum, casuue deuenit ad manus alicuius, vel quia quacunque ratione comperitur ad alium pertinere, cum præcessisset possessio illius bona fide, tunc restituendum est in loco, vbi illud est. Quòd si is, cui restitutio est facienda, absens sit, significandum ei est, vt veniat ad illud accipiendum, aut significet cui loco ipsius sit tradēdum, quidve ea de re sit faciendum; vel seruari illi id debet quousque veniat, occasiove se offerat, vt illi tradatur, aut vt intelligatur ex illo, quid de ea re sit faciendum; vel tradi iudicis autoritate debet in depositum, quousq; veniat, aut signifi- [[275]]cet, quid ea de re fieri velit, vel illius expensis mitti ad eum debet, vt iudicabitur horum aliquid magis ei expedire, cui restitutio est facienda. Deniq; si qui sumptus in horum aliquo sint faciendi, creditor, cuius negotium ea in re agitur, tenetur illos soluere. Quando autem maiores sumptus essent ad id necessarii, quam esset rei valor, neque spes esset, quòd, seruata re sine sumptibus in loco, in quo est, tādē ad domini manus deueniret, aut dominus significaret, quid de illa fieri vellet, tūe tradi posset, ac deberet, pauperibus, aut insumi deberet in aliis operibus piis pro anima illius, ad quem spectat, fierique circa illam posset compositio, vt Disp. 748 conclus. 3 vtrumque est dictum. Si tamen spes aliqua esset, sed modica, dominum rediturum ad locum vbi restitutio ei fieri posset, aut significaturum, quid ea de re fieri vellet, neque talis esset persona, de qua verisimiliter crederetur, contentam fore, vt id traderetur in eleemosynam pauperibus, aut insumeretur in aliis operibus piis pro ipsius anima, tunc sanum esset cōsilium, si traderetur congregationi alicui, quæ operibus piis intendat, vt in Lusitania domui alicui misericordiæ, cum onere, vt si dominus adueniret, illi traderetur valor ille, si contentus nō esset, insumptum esse in iis operibus piis pro ipsius anima, vt fieri aliquando consului dum in Lusitania commorabar. *In hac tota doctrina*

consentiunt. D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 5. ad. 3. & doctores communiter, de quorum numero sunt infra citandi. Circa euentus huius conclusionis obserua. Si postquam possidens, aut tenens aliquam huiusmodi rem, sciuit cui esset restituenda, eam secum detulit in alium locum, attendens, aut attendere debens, ea via fieri domino præiudicium, qui sumptibus ad rem suam recuperandam indigeret; tunc, quia per eam delationem causa esset iniusta eius damni, restituere eam teneretur suis propriis sumptibus, & non sumptibus eius, cui debetur; præcisè tamen quoad id, quod ea asportatione dedit damni. Quòd si bona fide, ignorantiaque probabili, ab ea culpa excusaretur, vel à culpa excusaretur, quòd eo modo vtiliter ageret negotium illius, ad quem ea res attinebat; eo quòd tutum non esset relinquere eam rē in loco illo: necesseq; erat illam tenēti inde migrare, aut alia simili ratione, tunc restituenda non esset sumptibus debitoris, sed sumptibus eius, cui deberetur.

Secunda conclusio. Quando aliquis ex contra¹³⁴ctu, aut ex alio simili titulo, tenetur restituere, seu soluere aliquid, neque iniusta mora interuenit illud soluendi, si locus aliquis designatus erat cō [sect. 2] tractu, vbi solutio fieret, ibi solutio est facienda. Si verò non erat locus solutioni designatus, facienda est, vbi, quando celebratus fuit contractus, intelligebatur, debitorem tempore solutionis habiturum domiciliū. Quare, si creditor ante tempus solutionis aliò migret, mittere debet ad locum domicili debitoris, qui ibi solutionē accipiat: si quæ autem faciendæ sint expensæ, vt solutio ad creditorem trāsmittatur, creditor tenetur eas facere. Si verò debitor mutet domicilium, expensis ipsius transmitti solutio ad creditore debet; præcisè solūm quatenus suo discessu causa fuit earum expensarum. Ratio autem horum omnium est, quoniam tacitè, aut expressè, ita cēsentur homines intelligere, ac obligare ad solutionē, dum contractus celebrant. Nisi tamen cōtractus esset promissio merè gratuita: nam tunc, cū promissio non plus obliget, quàm fuerit animus actualis, aut quasi habitualis promittentis, vtique, si promittens, quando promisit, in ea erat dispositione, quòd si ei tunc proponeretur, num intēderet se ita obligare, vt in euētu, quòd in alium discederet locum, teneretur suis expensis mittere solutionem, responderet neganter, non teneretur mittere solutionem suis expensis.

Legē. 1. ff. de eo quod certo loco, & l. unica. C. eod. [sect. 3] titu. habetur, quando aliquis soluere tenebatur certo loco, in eoque non soluit, agi posse aduersus eum in alio, vbi commorabitur: simulque posse ab eo peti, quantum creditori plus intererat, ei solui in illo alio loco, tam ratione lucri cessantis, quā dāni emergētis. Iē. l. 2. ff. eod. titu. habetur, quando aliquid erat soluēdū in certo loco, & per debitore stetit, quominus ibi solueret, cōpetere creditori aduersus illum actionem proximè explicatam; quando verò stetit per creditorem, quominus ibi eā reciperet, cōpetere debitori actionem aduersus illum, vt tantum detrahatur de debito, quantum debitori intererat in eo loco esse factam.

Ioan. Medi. de rest. q. 2. §. similis dubitatio, asse [sect. 4] rere videtur, quando aliquis mutuo dedit in vno loco, & præter spē in alium migrat, teneri mutuatarium seruare illum indemnem, tam à lucro cessante, quam à damno emergente, eaque de causa affirmare videtur, teneri propriis expensis mittere ad illum debitum, detrahendo solūm, si quas fortè expensas facturis fuisset creditor in asportando eo debito, si solutum ei fuisset tempore discessus. Idem affirmat de commodatario comparatione commodantis. Similē autem opinionem Maioribus impugnavimus suprā Disp. 314. Quare dicendū est, de iustitiæ rigore, mutuatarium non teneri soluere mutuum ante terminum solutioni præfixum, neque teneri solvere mutuanti lucrum ea de causa illi cessans, aut damnum emergēs, quod in pactum nondeduxit, vt ipsi soluererur, ac proinde nec teneri illi soluere expēsas, quas fecerit in recuperanda sua pecunia

ac trāsportāda in locum, in quem migrat. Forte enim mutuatarius non acciperet id mutuum cum eo onere: mutuansque sibi debet imputare, quod id non præcauerit, nec deduxerit in pactū. Lege alia, quę disputatione citata dicta sūt.

Tertia conclusio. Quando aliquis ex delicto¹³⁵ soluere, restitueréve aliquid tenetur, quia rē iniustè accepit, destruxit, aut detinuit, tenetur re [sect. 5] stituere illam in loco, vbi illam accepit, aut destruxit, vel in quo ante iniustam detētionē tenebatur illam soluere. Quòd si ipse ex eo loco discedat, vel eam trāsferat in alium locum, tenetur suis expensis restituere illam in illo alio loco. *Atq; hoc est; quod definitur. c. episcopi, & c. non infereda. 3. q. 1.* Si autem creditor ex eo loco discedat, tenetur debitor eā restituere suis expēsis in loco, in quo fuerit creditor. Ita tamen, quòd si creditor aliquid erat insūpturus in trāsferēda ea re in illum alium locum, aut in transferēdo pretio illius, (si illam vēditurus erat in loco, in quo eam habebat) id detrahat debitor, vt expēsis fiat creditoris. Ratio autem huius est, quoniam solūm tenetur seruare creditorem indēnē, ita vt nullum lucrum illi cesset, aut damnum emergat, ex debitoris delicto: quod præstat etiam id detrahēdo. In his cōsentiūt *Caiet. 2. 2. q. 62. art. 5. & in summa verb. rest. c. 5. Sotus: 4. de iust. q. 7. art. 1. ad. 3. Ioan. Med. q. 2. citata, Couar. reg. peccatum part. 1. n. 7. Nauar. in Manu. c. 17. n. 42. & alii.* Horum verò omnium ratio est, quoniam, qui ex parte [[276]] iniustæ acceptionis restituere tenetur, seruare debet omnino indemnem illum, cui ex eo capite restituere tenetur, ita vt nullum omnino detrimentum illi ex tali delicto maneat. Aliqui non immeritò addunt, quando longè maiores expēsæ essent faciendæ in restituenda ea re, quā esset valor illius, non teneri debiterem cum tanto suo onere eam rem illi, cui debetur, soluere, sed posse spectare tempus, in quo sine tanto suo onere eam illi restituat: aut, si nunquam speraret posse restituere sine tanto suo onere, restituere eam deberet pauperibus, aut insumendo illam in aliis operibus piis pro anima illius, ad quem spectat: quoniam dominus irrationabiliter vellet, vt cum tanto onere ac sumptu illam ipsimet restitueret, vt tractatu sequenti dicemus, dum examinabimus, ad quam restitutionem teneatur adultera ob damna sequuta ex filio nato ex adulterio. Quæ in hac disputatione sunt dicta, adiunge iis, quæ de solutionibus suprā in materia de contractibus dicta sunt.

Quando restitutio sit facienda. Et num continuè peccet, qui non restituit: & quando peccata non restituendo numero multiplicentur. Disp. 753.

SVMMARIVM.

1. *Solutio debiti ex contractu, aut ex alio simili titulo, quando facienda. Ex dilatione verò solutionis quando debitor condemnandus non sit culpæ lethalis.*
2. *Restituendi obligatio quando oritur ex iniusta acceptione, iniustave retentione, fierirestitutio statim debet sub reatu culpæ lethalis, continuationisve eiusdem peccati iniustæ acceptionis. Et quid sufficiat, vt cēset continuatio eius peccati.*
3. *Restitutio dum lōgo tempore non fit, quando imerueniat vnum numero peccatum, & quando ob interruptionem interueniant multa numero. Et, quod ad confessionum praxim attinet, qualiter examinandus ea de re sit penitens.*

4. Restitutio si fiat post tempus aliquod eam omiſſam, restitui etiam debet lucrum cessans ac damnum emergens ex ea iniusta dilatione restitutionis. Pro iniuria verò toto eo tempore ea dilatione facta, sumpta præcisè à damno dato, restitutio non debetur.

REstitutio latè sumpta, hoc est, quæ or [sect. 1] tum non habet ex iniusta acceptione, neque

ex parte rei acceptæ, sed ex contractu, aut ex alio simili titulo, facienda est tempore, quo debitor, iuxta eum contractum, aut titulum, tenetur, prout contractu ipso, aut titulo, fuerit expressum, aut habuerit loci consuetudo. Quæ autem hoc loco addi ex iuris dispositione poterant, etiam quando pæna apposita fuit non soluenti intra certum terminum, copiosè dicta sunt in materia de contractibus, præsertim Disput. 284 & 564. Illud admonuerim, quando debitor est iam in mora culpabili soluendi, quod prædicto modo debet, si animum soluendi habeat, certoque sit futura solutio, neque ex dilatione solutionis detrimentum vllum sequatur creditori, non facilè debitorem esse condemnandum culpæ lethalis ob eam iniustam moram; præsertim si non esset admodum magna, quam creditor grauatiè admodum ferret. Ratio autem est, quoniam nuda dilatio solutionis, quando creditori neque lucrum inde cessat, neque damnum emergit, estque certa solutio, non est tanta iniuria, vt propter eam debitor lethalis culpæ sit facilè damnandus, esto creditor sæpius suum exegisset debitum, præsertim si tunc debitor ægrè difficileque soluere possit. Hoc admonui, quoniam licèt confessarii, dum in confessionibus inueniunt eiusmodi debita non soluta, vrgere pēnitentes debeant, vt soluant; non tamen facilè condemnare eos debent culpæ lethalis, aut cis denegare obligationem debent, quando creditores pressi non sunt necessitate sui debiti, nullumque illis lucrum cessat, aut damnum emergit, ex dilatione solutionis.

Quando obligatio restituendi oritur ex iniu [sect. 2] sta rei acceptione, aut ex iniusta illius detētionē. *conclusio D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 8.* & communis doctorū est, Restitutionē esse faciendam statim, idque sub reatu lethalis culpæ, nisi iusta aliqua causa ex iis, quæ à disputatione sequēti explicabuntur, excuset ab obligatione statim restituēdi: aut nisi leuitas materiæ, vel modica iniuria, quæ in eo interuenit, quòd restitutio ad breue tempus differatur, quando & adest firmus animus transacto eo tēpore restituendi, & inde notabile aliquod detrimentum creditori non sequitur, à culpa lethali excuset. Ratio huius conclusionis est, quoniam, vt Disput. 716 explanatum ostensumque fuit, in detentione & dilatione solutionis eius, quod debetur, iniuria fit proximo eiusdē rationis ac speciei cum ea, qua aliquid illius iniustè accipitur, quatenus per eam detentionem priuatur usu ac possessione rei ad ipsum attinentis: quo fit, vt sicut prima iniusta acceptio ex suo genere est peccatum lethale: ita detentio ac dilatio solutionis eius, quod debetur, culpa ex suo genere sit lethalis, nisi ex aliqua rationabili causa excusetur à culpa, vel nisi ex leuitate materiæ, aut ex modica iniuria, eo quòd ad breue tempus, & sine iactura alicuius momenti creditoris, differatur solutio, venialis reddatur.

Idcirco autem est statim restitutio facienda, quoniam, vt Disput. 716 citata in responsione ad primum, atque in responsione ad confirmationem illi subiunctam, explicauimus, quanuis, restituendi præceptum sit affirmatiuum, supponit tamen, adiunctumque habet, negatiuum non detinendi alienum inuito eo, ad quem id pertinet, atque ex illo deriuatur, tanquam medium necessarium, sine quo negotium impleri non potest: neque sunt distincta præcepta, quasi sint obligationes duæ, aut quasi sint obligationes sub distinctis culpis, aut sub distinctis partibus culpæ; sed eadem omnino culpa est omissio restitutionis contra præceptum affirmatiuum restituendi, & retentio alieni, alteriue debiti, contra præceptum negatiuum,

non detinebis alteri debitum, quod pars est septimi præcepti negatiui decalogi, non furtum facies, vt hæc omnia loco citato copiosè sunt ostensa. Quia ergo præceptum illud negatiuum, non detinebis iniustè alienum, obligat ad semper sub reatu nouæ culpæ, aut sub reatu continuationis ac augmenti extensionis culpæ [[277]] iam inchoatæ; id quod commune est cæteris negatiuis præceptis; quanto enim tempore quis perseuerat in continuatione fornicationis contra præceptum negatiuum non fornicaberis, à fornicatione non desistendo, tanto tempore continuat & extendit culpam fornicationis, addendo nouas partes extensionis eius culpæ ac peccati correspondentes partibus temporis, in quo fornicatio continuatur, eodemque modo res habet in cæteris transgressionibus præceptorum negatiuorum; inde efficitur, quòd interim dum obligatio est restituendi, & restitutio omittitur, neque adest aliquid, quod à culpa excuset, continuetur & extendatur additione nouæ culpæ, aut nouæ partis culpæ, peccatum omissionis restitutionis contra illud præceptum affirmatiuum, quod modo explicato à negatiuo deriuatur, coniunctamque habet transgressionem præcepti illius negatiui, non detinebis iniustè alteri debitum. Atque in hoc differt præceptum hoc affirmatiuum restituendi à præcepto pænitendi, audiendi sacrum, & ab aliis affirmatiuis, quæ non habent adiuncta præcepta negatiua, à quibus deriuentur, quæque præsupponant, atque ad quorum obseruationem sint media omnino necessaria: eaque de causa non obligant ad semper, atque ad statim, vt obligat præceptum restituendi affirmatiuum.

Vt tamen probè notant doctores, quos in progressu citauimus, quamuis ad egrediendum, aut etiam ad cessandum à peccato, (quando non excusabat à continuatione illius inaduertentia, impossibilitas restituendi, aut alia legitima causa) necessaria statim mathematicè sit restitutio quoad actum internum, hoc est, quoad conceptionem propositi restituendi; quoad actum tamen externum, necessarium non esse, vt fiat statim mathematicè, sed solùm moraliter. Si enim debitor in mensa, in lecto, dum sacrum audit, aut dum creditor est absens & expectatur, restituere cum effectu statuatur, sanè, vt à continuatione peccati non restituendi cesset, quin vt ab illo illucusque commissio per contritionem resurgat, in gratiaque reponatur, necesse non habet, surgere, statimque restitutionem exequutioni mandare, sed satis est, si congruo tempore, expectataque commoda opportunitate, illam exequutioni mandet. Quin illud addiderim, dum quis non attendit, se retinere alienum, satis esse, vt à peccato præterito talis iniustè retentionis egrediatur, si in genere doleat de suis omnibus peccatis, in genereque statuatur, se deinceps nullum lethale peccatum commissurum: in tali enim proposito continetur in confuso, & tanquam pars subiecta in suo genere, propositum restituendi, quando discutiendo postea suam conscientiam, recordatus fuerit, se retinere alienum.

Dubium est, num, qui iniustè accepit alie [sect. 3] num, illudque longo tempore non restituit, committat multa lethalia peccata, quæ necessariò confiteri debeat. Atque in partem affirmantem est hoc argumentum. Quòd, cùm non solùm peccauerit commissionis peccato accipiendo alienum, sed etiam toto tempore, quo non restituit, peccauerit omissionis peccato contra præceptum affirmatiuum restituendi, quod, vt dictum est, ad semper obligat, consequens est, vt in quolibet instanti illius temporis peccarit, atque adeò vt commiserit, non solùm multa, sed etiam infinita peccata. *Calet. 1. Tom. opuscul. tract. 17. qui est de contritione, c. 2. 2. q. 66. art. 3. ad. 2.* quem nonnulli sequuntur, in ea est sententia, vt dicat. Toto eo tempore, quo, qui ad id tenetur, non restituit, ex eo, quòd restituere omittat, non peccare, sed solùm esse in statu peccati præteriti, quo iniustè alienum accepit. Ait tamen, toties de nouo peccare lethaliter, quoties elicit nouum actum vel internum non restituendi,

vtendi re aliena in præiudicium eius, ad quem spectat, illam alienandi, aut consumendi, vel externum, quo illa vtitur, eam alienat aut consumit. Quia tamen ad numericam distinctionem peccatorum necessaria est discontinuatio illorum moralis: consequens, inquit, est, vt quoties, vel continuando actus internos per externum, vel externos per internum, actus multiplicentur, illi omnes sint vnum numero peccatum contra præceptum restituendi: non secus ac, qui accipit pallium & ensem, vt aliquem iniuste interficiat, itque ad quærendum illum, eumque interficit, non committit multa numero peccata contra quintum decalogi præceptum, sed vnum numero conflatum ex illis omnibus partibus, modo tamen hi omnes actus moraliter continuè fiant ac sine interruptione.

Hac verò & aliis opinionibus prætermissis. Imprimis aduersus Caiet. dico. Nudam omissionem restituendi tempore, quo quis restituere tenetur, esse peccatum, modo voluntaria sit, vel quia aduertit, se restituere teneri ac posse, nec restituit, negatiuè se habendo, hoc est, neque eliciendo actum voluntatis, quo velit, neque actum, quo nolit; vel, quia debuit ac potuit aduertere se teneri restituere, suaque negligentia non aduertit nec restituit. Cum enim eiusmodi omissio sit contra restituendi præceptum, quod ad semper obligat interim dum restitutio non est facta, sitque voluntaria, quatenus in potestate voluntatis fuit restituere; consequens profectò est, vt, esto non sit volita, habeat tamen requisita omnia, vt sit peccatum: atque adeò consequens est, vt incuratur peccatum contra præceptum restituendi, non solum quando elicitur actus internus, quo volita est omissio restituendi, & quando elicitur actus internus aut externus, quo quis alienat aut consumit rem ad alterum attinentem, vel illa vtitur cum iniuria seu præiudicio eius, ad quem pertinet, sed etiam quando voluntariè omittit restitutionem illius absque actu aliquo interno & externo. Dicendum itaque est, iniustum rei alienæ detentorem toto tempore re ipsa peccare, suumque peccatum extensiuè augere, quo voluntariè restitutionem omittit, siue simul eliciat actum aliquem ex commemoratis, siue non. Cæterum quia omissio ipsa voluntaria, & actus omnes commemorati, eiusdem sunt speciei in genere moris, tam inter se, quam cum prima iniusta acceptione, aut destructione rei, vt Disp. 716 ostensum est, & ad distinctionem numericam peccatorum necessaria est discontinuatio moralis peccati; consequens profectò est, vt quamdiu peccatum continuatur per voluntariam omissionem resti-[[278]]tutionis, esto actus interni aut externi multiplicentur, non sint multa peccata, sed vnum numero, ex illis omnibus & ex voluntaria ipsa omissione conflatum, atque adeò consequens est, vt prima iniusta destructio aut acceptio rei, & continuatio retentionis eius, quod ea de causa debetur, interim dum talis continuatio detentionis voluntaria perseuerat, quia accipiens restituere optimè potuit, nec restituit, non sint multa peccata, sed vnum numero peccatum. Vnde constat, omnes actus elicitos, tam internos quam externos, interim dum omissio restitutionis est voluntaria, non esse multa numero peccata, sed vnum numero peccatum, conflatum tanquam ex partibus integrantibus ex illis omnibus actibus, & ex omissione ipsa restituendi voluntaria. Quia verò omissio restitutionis sæpe desinit esse peccatum, vt si pro tunc desinit esse voluntaria, vel quia is, qui restituere tenetur, factus est impotens ad tunc restituendum, vel quia in ipsius potestate tunc non est attendere, se restituere teneri, vt dum dormit, & quam sæpissime dum rebus aliis est intentus; neque enim in potestate ipsius situm tunc est, ad id attendere; consequens sanè est, vt sæpe discontinuetur peccatum, & vt, per eiusmodi moralem discontinuationē, multiplicentur peccata numero distincta. Quod autem ad praxim attinet confessionis eiusmodi peccatorum, satis profectò erit, si confessarius examinet pœnitentem, quanto tempore, plus minus, fuit in mora restituendi, & num semper, aut

sæpe, eo tempore restituere potuerit: atque, si placuerit, poterit etiam inquirere, quot vicibus distraxit, aut consumpsit, res iniuste acceptas, aut illis vsus est in damnum earum: attenta verò qualitate personæ, facile (quantum rei natura patitur, verisimileque est, Deum voluisse obligare, vt hæc in confessionibus exprimerentur) intelliget quantitatem culpæ, peccatorumque numerum. Neque in his sit nimius, aut mathematicè velit hæc inquirere, molestiam sibi ac pænitentibus ingerendo, tempusque absque fructu insumendo: satis quippe erit, si, adhibitis breuibus quibusdam interrogationibus, non multum præmendo, neque molestiam pænitentibus ingerendo, aliquantulum per se ipsum conjiciat numerum eum incertum peccatorum, quantum natura rei patitur. In opinione hac pluralitatis numericæ peccatorum, quæ tempore, quo non restituitur, incurruntur, *consentit nobiscum Maior in. 4. dist. 15. q. 26. in responsione ad. 1. ab eaque non multum discrepat Nauar. in Manu. c. 17. n. 54. Plus verò aliquantulum discrepat Sotus. 4. de iust. q. 7. art. 4.*

Illud verò est obseruandum, quamuis ex eo, [sect. 4] quòd omittatur aut differatur restitutio, nullum damnum proximo sequatur, quando tamen eo inuito omittitur; peccata, quæ interim, dum restitutio non fit, committuntur, esse peccata contra iustitiam, illique iniuriam inferre. Quia tamen pro iniuria, præcisa à damno dato, restitutio non debetur, sed tantum pæna, satis est, eum, qui post longum tempus restituit, restituere id, quod accepit, & si quod aliud damnum inde sequutum est proximo, etiam lucri cessantis: pro iniuria verò omissionis restitutionis tam longo tempore, nihil restituere tenetur, neque vsus Ecclesiæ vnquam habuit, vt pro ea iniuria ac iniustitia restitutio iniungeretur. Id quod non parum confirmat doctrinam Disp. 715 à nobis traditam, nempe pro iniuria, præcisa à damno dato, restitutionem non deberi.

De causis excusantibus à restitutione statim facienda. Et præsertim de impotentia. Disp. 754.

SVMMARIVM.

1. *Restitutionis dilatio culpabilis non est, si de voluntate creditoris, præsumpta saltem absque illo dubio, siat. In dubio, autem, vel statim est facienda, vel obtinenda est à creditore facultas. Ignorantia etiam inuincibilis, quòd obligatio sit restituendi, à culpa excusat.*
2. *Restitutio quousque licitè differri possit, aut non possit, propter impotentiam, nomine impotentiae detrimentum graue comprehendendo in rebus externis, aut in rebus altioris ordinis, vt famæ, & honoris, aut corporis, latè examinatur.*
3. *Restitutio etiam si licitè differatur ob graue detrimentum, tenetur debitor restituere creditori, si quod lucrum ei cessauit, aut damnum emersit, ex tali restitutionis dilatione.*

Nunc dicendum est de causis, quæ à resti [sect. 1] tutione statim facienda excusant. Atque

in primis, si creditor consentiat, vt restitutio differatur, cum volenti ac consentienti iniuria non fiat, potest restitutio absque peccato differri interim dum ea fuerit creditoris voluntas formalis, aut præsumpta absque illo dubio. In dubio quippe, an ea sit creditoris voluntas, vel facienda est statim restitutio, vel obtinenda ex creditore est libera facultas eam differendi.

Item, si ignorantia inuincibili restitutio omissa esset tempore aliquo, ea ignorantia à culpa excusaret, quòd restitutio illa illucusque facta non fuisset.

Deinde impotentia ad statim restituendum, à [sect. 2] culpa excusat omissionis restituendi interim dum ea impotentia perseuerat. Et quidem, quando debitor omnino non potest, quia non habet unde restituat, neque quid faciat, ut restituere possit, dubitandum non est, eiusmodi impotentiam excusare illum à culpa: eo quòd nullus ad impossibile obligetur: & peccatum, autore Augustino, præscribenteque id communi omnium animi conceptione, ut in Concordia sæpe diximus, adeò ad sui rationem exigat, ut sit voluntarium, ut, si voluntarium non sit, continuò nec sit peccatū. Quando verò debitor restituere non potest sine notabili suo detrimento, examinandum est, utrū ea impotentia excuset ab obligatione restituendi statim. Quòd autem id appellari impotentia possit, *testatur Arist. qui. 1. de celo. c. 11. docet*, posse aliquid dici duobus modis impossibile. Vno, quia nullo modo fieri potest. Altero verò, quia ægre ac difficilè potest fieri. Consentit etiam scriptura sacra, quæ sæpe, quod difficilè fieri potest, impossibile appellat.

In primis autem, quando aliquis, si statim restituat, incurrat detrimentum vitæ, membri, aut notabile valetudinis, quia interficietur, vulnerabitur, fame peribit, aut grauiter infirmabitur, dubitandum non est, eiusmodi impoten-^{[[279]]}tiam à culpa excusare non restituendi statim. Creditor quippe in eo euentu irrationabiliter esset inuitus, subuenireque eidem debitori teneretur, tribuendo illi etiam alia, si ad euadendam eam necessitatē ita esset opus, ne dum permittendo, ut restitutio differretur, ut in hac. 2. 2. dum de ordine caritatis. q. 26. art. 8. nobis erat sermo, & in materia de eleemosyna à nobis est dictū: quibus in locis disseruimus de multis tēpore extremæ necessitatis, quæ doctores aliqui hoc loco, extra suam propriam sedem, disputant.

Quando verò solū sequitur notabile detrimentum in bonis externis eius, qui restituere tenetur, *distinguunt bene Caiet. 2. 2. q. 62. art. 8. & in summa verb. rest. c. 6. Sotus. 4. de iust. q. 7. art. 4. & alii*. Si detrimentum in eo solo sit positum, quòd res restituenda sit magna, eique opportuna, qui restitutionem est factururus, tunc nihil eo detrimento impediēte, teneri restituere integre statim: eo quòd, restituendo ita integre statim, nullum patiatur detrimentum in rebus suis, sed solū absteineat ab iniusta rei detentione. Si autem quis ex eo deobligandus esset à restitutione integre faciēda statim, quòd res restituenda magnæ esset quantitatis ac valoris, tunc melioris conditionis esset, qui multum furaretur, aut multum iniuste quacunque ratione detineret, quā qui parum furaretur, parūve iniuste detineret; sicque ex maiori suo delicto commodū reportaret: quod nulla ratione est concedendū. Ac sanè, quando restituendi obligatio ex eo oriretur, quòd is, qui restituere tenetur, possideret aliena, quæ furto, vsuris, aut simili alio delicto acquisiuisset, non dubito teneri statim restituere totum, nihil impediēte, quòd ipsi id esset necesarium ad conseruandum suum statum, creditori verò non item, nihilque impediēte, quòd necessarium ipsi esset mendicare, *ut rectè probat Ioan. Med. de rest. q. 5. quem sequuntur Sotus art. 4. citato, & alii*: neque enim fas est retinere alienum, male partum, inuito eo, ad quem id pertinet, ut quis conseruet suum statum. Exciperem, si bona, quæ ita cum delicto acquisiuisset, iam omnino, aut magna ex parte, dissipasset, haberetque patrimonialia alia bona, unde viueret. Si enim tunc spes esset probabilis, futurum, ut restituendo paulatim ac per partes, resarciret intra non admodum longum tempus integrum debitum, & damna, etiam lucri cessantis, creditori ex dilatione solutionis subsequuta, tolerari posset, ut paulatim eo modo restitueret, iuxta ea quæ dicemus: alioquin cogendus esset integre restituere id debitum statim.

Quando autem aliquis damnum magnum iniuste dedisset, quod, ob sui magnitudinē, restituere integre non posset statim, nisi ad summam redigeretur paupertatem, sui status conditione spectata, adeò, vt neque parcissimè se posset sustentare, si integre, aut magna ex parte, statim restitueret, sed necesse illi esset, decidere omnino ab statu; vel quando, reflante fortuna, tot haberet debita, & adeò pauca ad illa restituenda, vt, si integre, aut magna ex parte, cogeretur ea restituere statim, neque ægre & parcissimè in eo statu se posset sustentare, sed necesse illi esset ab eo omnino decidere; volunt aliqui, etiam hunc teneri statim restituere integre, esto necesse illi sit mēdicare deinceps, atque esto creditor sine ea restitutione posset decēter in suo statu viuere. *De borum numero videtur esse Ioan. Med. q. 5. citata.* Quo fit, vt hi autores, ex parte indigentia debitoris, solam extremam, aut quasi extremam, arbitrentur sufficientē causam restitutionē differendi. Consentire autem videtur Sotus art. 4. citato, quando restituendi obligatio consurgit ex delicto, & quando, esto ex delicto non consurgat, sua tamen culpa debitor ad eum statum deuenit. Certè, quando debitor sua culpa eam obligationem super se induxisset, in easque angustias se redegisset, difficilè ab hac sententia recederē, (tametsi videam multos ex recencioribus non tanta cum seueritate hac de re loqui) solumque exciperem, quando debitor ex aliis bonis suis propriis restituere deberet, atque spes esset probabilis, si paulatim restitueret per partes, tandem intra moderatum tempus omnia restitutum, etiam lucrū creditori ex ea restitutiois dilatione cessans. Ducor, vt, hoc solo euentu excepto, in illam sententiam inclinē, quoniam non facilè contra creditoris voluntatem est permittendum, debitorem restitutionem differre, esto necesse sit eum à suo statu cadere, præsertim quando ipse fuit in culpa, quòd per iniustitiam ad eas deueniret angustias.

Quando verò absque sua culpa, reflante fortuna, ad eum statum deuenisset, est dubium, num sententia, quam *Syluest. verb. rest. 5. q. 3. Nauar. in Manu. c. 17. n. 62. & alii*, ad alios etiam extēdunt, & Sotus art. 4. citato admittere solūm videtur in hoc euentu, sit admittenda, fas scilicet esse eiusmodi debitori differre solutionem, retinēdo solūm, quod sibi sit necessarium parcè viuendo iuxta suum statum, constringendo se in illo, quantum sua conditio patitur, & reseruando simul vnde paulatim lucrari ac restituere possit. Et quidem quando creditor simile aut paulo minus detrimentū habiturus ex eo esset, quòd eo modo illi restitutio differretur, conueniunt omnes, nefas esse illam ita differre: quoniam semper est melior conditio creditoris, vt ipse debitori præferatur, etiam si necesse sit, debitorem à suo decidere statu. Item, quando ex dilatione solutionis spes non esset, debitorem aliquando restitutum, quia eius est ingenii, talesque sunt circumstantiæ, vt potiùs sit præsumentum, eum in dies minus habiturum, quàm bona comparaturum, vnde paulatim restituat, arbitror illum teneri restituere statim, esto necessariū illi sit à statu decidere. Quando autem spes verisimilis cōiecturæq; essent, eum paulatim acquisiturum vnde restitueret, & simul conseruaturū suum statum, ab eo non prorsus decidendo, probabilitate non caret opinio *Syluest. Nauar. Soti, & aliorum.* Quoniam is debitor impotens est suo modo ad soluendum integre statim, irrationabiliterq; tunc erit creditor inuitus, quòd restitutio eo modo differatur. Non tamen caret etiā sua probabilitate contraria opinio. Quoniam creditor non videtur teneri consentire, quòd detineantur bona ipsius, vt debitor à suo statu non decidat. Et quoniam sicut homines, diuitias acquirēdo, per fortunam ab inferiori statu conscendunt ad superiorē: sic reflante fortuna, pati debent descēsum ad inferiorem statum: quandoquidem ex natura rei, spectataque conditione humana, nō magis vni, quàm alii, sit debitus superior status. Confirmari autem hoc potest, quoniam in exteriori foro, quando locum habet cessio

bonorum, debitor spoliatur omnibus suis bonis, relictis solùm illi tenuibus vestibus, quibus se [[280]] tegat, aut certè solis quotidianis, minimeque pretiosis, attenta qualitate sui status, vt Disput. 572 fuit comprobatum. *Meritò ergo Couar. reg. peccatum in prin. n. 2. ait*, non facilè ea de causa, sed summo cum iudicio esse admittendam restitutionis dilationem, Sotusque trepidus in euentu, de quo disputamus, ad Syluestri sententiam accedit, atque ego sanè ægre illam admitterem. Vnusquisque autem eligat, quod maturo cum iudicio sibi sua conscientia præscripserit.

Illud admonuerim, perperam aliquos ex iuribus, quæ aliquibus concedunt priuilegium, ne vltra soluere cogantur, quàm commodè facere possint, quales sunt, debitor ex contractu gratuito, vt donationis, socius, clericus, miles, ascendentes comparatione descendentium, & è contra, ascendens masculus, qui dotem promisit, is qui bonis cessit, postquam spoliatus fuit omnibus suis bonis, de quibus Disp. 413, 425, 571, & 572 est dictum, atque ex priuilegio eorum nobilium in hoc regno, quos *Hidalgos* vocant, quòd scilicet pro debito, quod ex delicto non oritur, detrudi regulariter non possint in carcerem, neque exequutio fieri possit in aliquibus eorum bonis, vt Disp. 572 fuit explanatum, perperam, inquam, aliquos ex his iuribus ac priuilegiis colligere, fas esse vniuersim propter debita differre solutionem, quando, si debitor integre statim solueret, necesse illi esset decidere à suo statu ac mendicare. Contrarium quippe ex eisdem iuribus ac priuilegiis colligitur. Neque enim illud esset priuilegium illorum in illis solis euentibus, si id debitoribus omnibus esset commune. Quare, quòd in illis solis euentibus, eisque solis personis, sit concessum id priuilegium, præsupponit apertè, in aliis debitoribus, in aliisque euentibus, id locum non habere, sed integre illos cogendos esse soluere, & non solùm quantum commodè facere possint, relinquendòve illis ita vt non egeant.

Quando detrimentum debitoris in eo, quòd statim restituat, solùm est lucri cessantis, quia scilicet, si debitor non statim restituat alienum, sed differat restitutionem in aliud tempus, multum re aliena lucrabitur, affirmant bene Caiet. & cum eo Sotus, Nauar. & alii, id detrimentum non excusare à culpa non restituendi statim. Quoniam id non est detrimentum in rebus propriis, sed in eo, quòd non lucretur rebus alienis, inuito eo, ad quem spectant.

Quando detrimentum in eo, quòd debitor statim restituat, est in rebus suis propriis, atque est notabile, quia videlicet, vt restituat statim centum, quæ debet, necesse illi est vendere vili pretio res suas; eo quòd non sit tunc copia emptorum, & quia merces oblata vilescent; vel quia non est tunc opportunum tempus ad eas vendendum; vel quia multum sua intersit non vendere eam rem; vel quòd restitutio non possit fieri tunc sine magnis sumptibus; eo quòd distet creditor, spereturque non post multum tempus venturus, aut alia simili de causa; tunc fas est debitori differre restitutionem ad tempus, in quo speratur posse fieri sine tanto suo dispendio. Ita Caiet. Sotus, & Nauar. locis citatis, Scotus, & Richardus ab eisdem citati, & doctores communiter. Tametsi quoad rationem, vnde id proueniat, non consentiant *Scotus in. 4. dist. 15. q. 2. art. 4. & alii*, rationem esse affirmant, quoniam tunc creditor irrationabiliter esset inuitus, nisi consentiret differri restitutionem in id tempus. Caiet. verò & Sotus, vbi suprà, non approbant hanc rationem. Quoniam, inquiunt, non tenetur creditor consentire, vt debitor in id tempus detineat, quæ ei debet, ne debitor in suis bonis id patiatur detrimentum, sed potest vti iure suo, petendo, quod iam sibi debetur, nihil impediens, quòd inde per accidens id detrimentum debitori sequatur. Atque arbitror veram esse hanc Caietani & Soti sententiam. Si enim creditor consentire teneretur in ea dilatione solutionis, sanè peccaret vrgendo de bitorem ad solutionem: quod nequaquam vniuersim

admitterem. Eo enim dato, dicendum consequenter esset, peccare creditores, qui via iudicis exequutionem pro suis debitis petunt vsque ad venditionem bonorum debitoris in publica subhastatione, vt inde ipse satisfaciat: eo quòd, quæ ita venduntur, regulariter vendi soleant vili admodum pretio, cum debitorum non leui detrimento. Ratio ergo legitima sententiæ illius est impotentia tunc debitoris ad soluendum propter tantum detrimento, quod necesse est eum subire, si statim soluat. Eiusmodi autem impotentia licet debitorem excuset à culpa differendo solutionem, non tamen impedimento est creditori, quominus absque culpa suum ius prosequatur, exequutionemque sui debiti aduersus debitorem petat: nisi fortè parum, aut nihil, sua tunc referret, restitutionem non fieri sibi statim, & debitor maximum detrimento pateretur restituendo statim: tunc enim caritatis lege teneretur creditor dare inducias debitori ad solutionem, quæ damnum eidem creditori non afferrent.

Dubium autem est, vtrum etiam quando restituendi obligatio ortum habet ex delicto debitoris, vt ex furto, aut ex damno iniuste dato, vel ex alio simili, possit debitor licite differre solutionem, quando non potest facere eam statim absque graui alio detrimento in rebus suis propriis. *Atque affirmanter est respondendum cum D. Anto. & Nauar. in Manu. c. 17. n. 58. quicquid in contrarium dixerit Caiet. in summa verb. rest. c. 6. & innuat Sotus art. 4. citato.* Cum enim æquè impotens sit debitor, quando æquale pateretur detrimento restituendo statim, siue debitum contractum esset iusto titulo, siue iniusto, sanè in conscientia foro æquè propter impotentiam excusandus esset in vtroque euentu.

Sicut autem notabile detrimento proprium in bonis externis excuset ab obligatione restituendi statim: ita longè maiori cum ratione notabile detrimento in bonis altioris ordinis, vt in fama, vita, ac corporis salute, excusabit. Hac de causa, si non potest quis restituere statim sine detrimento famæ, quia sciatur crimen ipsius occultum, aut de eo non leuis suspicio orietur, vel sine detrimento in corpore, **[[281]]** quia interficietur aut percutietur, differri potest restitutio, quousque inueniatur aliquis, per quem fieri restitutio sine eo detrimento possit, aut quousque tempus & opportunitas adueniat, in quibus sine tali detrimento restitutio fieri possit.

Quando per confessarium, cui crimen suum in confessione detexisset, aut per aliam personam, posset statim restituere sine detrimento famæ & corporis, tenetur statim restitutionem efficere. Videat tamen, vt fidelis is sit, per quem restituit: ne, si ille restituere omittat, teneatur ipse iterum restituere, iuxta ea quæ Disput. 75 ac aliàs dicta sunt. Neque de quocunque est id facile fidendum, esto concionator aut confessarius sit. Quando autem non se offert persona satis tuta, differri restitutio potest, quousque persona tuta, tempusve aptum, se offerat. Atque semper erit tutum, vt persona intermedia, per quam restitutio fiet, sumat à creditore chirographum, quo confiteatur, se accepisse à persona, per quam restitutio est facta, tantum, vel tantum, quod sibi in satisfactionem est traditum, non exprimendo, cuius nomine satisfactio sit facta. Inrermedia autem persona, esto fidelissima sit, præsertim si confessarius sit, se offerre debet ad chirographum à creditore asportandum. Atque quamuis, qui restituit, renuat, confessarius tamen petere à creditore debet chirographum, quòd id in satisfactionem acceperit, illudque tradere illi, cuius nomine restitutio sit facta, in maiorem illius securitatem, atque ad maiorem ostensionem sinceritatis, qua sacramentum confessionis administratur.

Quando autem aliquis iuste idcirco restitu [sect. 3] tionem differt, quòd non possit eam statim efficere sine magno suo alio detrimento, est dubium, num, si ex tali dilatione restitutionis creditori sequatur detrimento aliquod, vel lucri cessantis, vel damni emergentis, teneatur

debitor, qui eam restitutionem differt, id etiam detrimentum illi compensare. Pars autem, quæ negat, suaderi potest. Quoniam ad id com¹³⁶ pensandum, nec tenetur debitor ex parte iniustæ acceptionis; eo quòd non peccat differendo in eo euentu restitutionem; nec item ex parte rei acceptæ; eo quòd ad ipsum non peruenerit detrimentum, quod creditor ex tali dilatione restitutionis est passus: ergo nulla ratione tenetur debitor compensare id detrimentum creditori. *Caiet. 2. q. 62. art. 8. ait*, debitorem teneri compensare creditori id detrimentum, quando debitor restitutionem distulit, vt euitaret damnum proprium in rebus suis externis: secùs verò quando restitutionem distulit, vt euitaret proprium damnum in bonis suis altioris ordinis, vt in fama, honore, aut corpore. Dicendum tamen est, in vtroque euentu teneri compensare creditori detrimentum illi sequutum ex dilatione restitutionis. Ratio autem est, quoniam æquitas non patitur, vt velit, alienum detinendo, quod iam ex iustitia debet, euitare damnum proprium cū creditoris iactura ac detrimento: eaque de causa, vt licitè possit velle dilationem restitutionis eius, quod ex iustitia iam tunc soluere tenebatur, necesse est, vt id velit, suscipiendo in se onus resarciendi alteri minus damnum, quod inde illi prouenit. Ad argumentum ergo in contra¹³⁷ rium, concesso antecedente, neganda est consequentia: quoniam tenetur ex tacito pacto ac cōditione, sub qua licitè velle potuit eam dilationem restitutionis, nempe resarciendi creditori damnum, quod inde ei proueniret, & sine qua licitè eam velle non potuit: quare, si à principio voluit eam dilationem restitutionis sine tali pacto ac conditione, fuit iniustus ita eam volendo cum creditoris præiudicio, ac proinde iam tunc illi tenetur ex parte iniustæ acceptionis, iniustæve illationis talis damni.

Vtrum ad vitandum damnum cuiusdam tertii, vel commune, aut etiam eius, cui restitutio est facienda, fas aliquando sit restitutionem differre. Disp. 755.

SVMMARIVM.

1. *Restitutio quando cederet in peccatum iniustitiæ eius, cui fieri deberet, non solùm posset licitè differri, sed etiam obligatio esset sub culpa lethali eam differendi, nisi ex tali dilatione sequeretur graue damnum proprium, aut tertii. Culpa tamen illa non differentis in eo euentu restitutionem non esset contra iustitiam, sed solùm contra caritatem, eaque de causa restituens non teneretur ad damna iniusta ea re ita restituta illata.*
2. *Restitutio quando esset in damnum notabile corporis eius, cui est facienda, culpa esset lethalis eam non differre, nisi ex tali dilatione notabile damnum eam differenti aut aliis immineret. Nō tamen esset obligatio restituendi damna, quæ is, cui esset facta, sibi intulisset.*
3. *Restitutio differri debet sub culpa lethali, quando restitutio cedit in peccatum lethale eius contra solam caritatem, cui est facienda, si ea ratione peccata impediuntur, & id fieri possit sine notabili detrimento differentis solutionem, & aliorum. Et quando tertia aliqua persona eo velut instrumento adducetur ad peccatum, & ex dilatione impediatur, obligatio similiter est illam differendi.*
4. *Differre restitutionem quando ita ad vitanda peccata licet, si ex ea dilatione damnum creditori sequatur, obligatio non est illud ei restituendi.*

5. *Restitutio quando licitè differtur, necesse non est petere ad id facultatem à creditore.*

Non solùm ad vitandum notabile damnum eius, qui restituere tenetur, fas est restitutionem differri in euentibus disputatione præcedente explanatis, sed etiam ad vitandum damnum cuiusdam tertii, aut reipublicæ, seu commune, quin & ad vitandum damnum illius, cui facienda est restitutio: imò verò interdum obligatio erit illam in his euentibus differre sub reatu culpæ lethalis. Vt verò id melius intelligatur, sequentes conclusiones erunt subjici endæ. Prima est. Quando creditor exigit, quod¹³⁸ sibi debetur; ad iniustitiam aduersus alterum committendam, vt ensem depositum [sect. 1] ad proximum iniustè interficiendum, aut [[282]] ad bellum iniustum inferendum, pecuniam sibi debitam ad litem iniustam intentandam, aut prosequendam, aut ad bellum iniustum inferendum, lethaliter peccat, qui soluit eiusmodi res, & non differt solutionem earum. Excipitur, nisi ex eo, quòd solutionem differat, ipsi sequatur notabile detrimentum, quod arbitrio prudentis, spectatis circumstantiis omnibus concurrentibus, ipsum excuset à culpa, vel nisi sequatur notabile detrimentum reipublicæ, aut aliis ex eo, quòd ipse omittat eam solutionem. Prior pars huius conclusionis communis est doctorum, *D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 5. ad. 1. Caiet. ibidem. Nauar. in. Manu. c. 17. n. 63. & complurium aliorum.* Probari autem potest, quoniam vnusquisq; lege caritatis impedire tenetur damnum notabile proximi, si id possit efficere: is autem, de quo conclusio loquitur, differendo restitutionem sine suo notabili damno, id efficiet: ergo lethaliter contra proximi caritatem peccabit, nisi restitutionem tunc differat. *Sotus. 4. de iust. q. 7. art. 1. ad. 1. & Ledesmi. 2. 4. q. 18. art. 5.* affirmant, nisi tunc restitutionem differat, peccare etiam contra iustitiam, tenerique ad restitutionem damnorum proximo inde subsequutorum, in defectum tamen causæ principalis eius damni. Ducuntur, quoniam, soluendo tunc, quod dare non debebat, nec licitè dare poterat, cooperatur ad iniustitiam, ad quam is, cui alioquin id debetur, illud petit, eaque de causa peccat contra iustitiam, restituereque tenetur damna inde subsequuta. Contrarium mihi videtur verum. Quoniam, qui id soluit, non id intendit, neque eo fine soluit, vt sequatur iniustitia: sed solùm vt ipse adimpleat, quod ex iustitia tenetur: quòd autem sciat, qui illud iustè petit, vt sibi verè debitum, illud velle ad abutendum illo in iniuriam ac iniustitiā proximi, non est soluentem cooperari ad iniustitiam illam, sed eam non impedire differendo solutionem, si sine suo notabili damno id possit efficere: ad quod solum tenetur lege caritatis, non verò lege iustitiæ. Posterior verò pars conclusionis communis est doctorum. Probari autem potest, quoniam actus restitutionis tunc non est intrinsicè malus, sed de se indifferens, imò verò bonus: mala autem intentio accipientis, abutendi re, quam ita petit ac accipit, ad iniustitiam aduersus proximum, est, quæ reddit restitutionem pro tunc malam contra caritatem proximi: quando autem actus, vt procedit ab vno, non est malus, sed vt alius intendit eo malè vti, sanè quamuis illicitus sit contra proximi caritatem, quando non adest circumstantia, qua cohonestetur & excusetur à culpa ex parte eius, à quo ita procedit, vt ex parte ipsius non sit malus, sed solùm quatenus ex caritate impedire tenetur damnum proximi; cohonestari tamen ac excusari ab ea culpa potest ex circumstātia grauis detrimenti sibi, aut alteri, ex eo imminētis, quòd illum non eliciat: eo quòd nullus damnum alterius euitare teneatur cum graui suo, aut cuiusdam tertii, detrimento: quo fit, vt elicere illum possit, permittendo alterius abusum, vt in se, aut in aliis, magnum detrimentum euitet. Hac eadem ratione Disp. 115 in materia de bello excusauimus à peccato captiuos Christianos, qui ad imperium Turcarum remigant, dum Turcæ Christianos insequuntur, & similia alia ministeria in Turcarum exercitu administrant aduersus Christianos. Quando

ergo, qui gladium alterius haberet in depositum, mortem sibi inferri timeret, si gladium non redderet domino illum petenti ad alterum iniuste interficiendum; aut timeret notabile reipublicæ damnum, aut aliorū suorum proximorum, qui ea de causa iniuste interficerentur, licite posset illum reddere. Quando item timeret odium & inimicitias cum creditore, nisi illi redderet pecuniam ei debitam, quam petit ad intentandam aut prosequendam litem iniustam, (præsertim si simul sibi persuaderet, esto eam illi non traderet, non cessaturum illum à lite, quia aliunde pecuniam ad id haberet) licite posset eam illi soluere: quoniam cum tanto suo onere non tenetur in eo euentu differre solutionem: præsertim cū ea via non impediretur iniustitia, quæ proximo paratur.

Secunda conclusio. Quando creditor exigit,¹³⁹ quod sibi debetur, ad se ipsum interficiendum, aut ad aliud corporale damnum sibi inferendum, [sect. 2] vt gladium depositum ad se interficiendum, aut cibum ad comedendum, quando creditur valde ei nociturus, sub reatu lethalis culpæ tenetur debitor differre restitutionem talis rei: nisi sibi, aut aliis, notabile damnum ex ea dilatione immineret. Conclusio hæc communis est doctorum, estque perspicua ex præcedenti. Sicut enim lege caritatis tenemur vitare damnum cæterorum proximorum, quando inde nobis non imminet notabile detrimentum: sic etiam vitare tenemur damnum ipsius creditoris, cū non minus sit proximus noster, quam alii. Esto autem vera esset opinio Soti & Ledesmi, quam præcedente conclusione refutauimus; in euentu tamen huius conclusionis cessaret obligatio restituendi creditori damnum ex non dilata solutione subsequutum: quoniam licet creditor dominus non sit propriæ vitæ ac corporis, vt tractatu sequenti videbimus; ei tamen volenti & consentienti nō esset facta iniuria damni propriæ vitæ & corporis, quatenus ei quoad vsum sunt à Deo concessa. Adde, quod cū ipse sibi ipsi fuisset principalis causa sui damni, nullus teneretur illud ei restituere: cū causæ minùs principales damni solū teneantur in defectum causæ principalis, quando cuidam tertio damnum iniuste esset datum.

Tertia conclusio. Quando creditor exigit,¹⁴⁰ quod sibi debetur, ad peccata, quæ non sunt cōtra iustitiam, licitum est debitori differre solu[sect. 3] tionem: quin ad id tenetur lege caritatis, quando ea via impedirentur peccata creditoris, debitorique ex ea dilatione solutionis non immineret notabile detrimentum aut molestia. Quādo tamen ex dilatione solutionis non impedirentur peccata; quia, si nunc debitor ei deneget, quod illi debet, cras petet eodem animo ac intentione, atque ita pluries petet ad peccandum, denegatioque illa debiti erit potius creditori occasio multiplicandi ac committendi plura peccata, quàm commisisset, si prima vice traditum illi fuisset suum debitum, tunc tradi illi statim posset ac deberet. Nisi fortè ex eo, quod statim traderetur, sequeretur ruina spiritualis tertiæ personæ, quam ad peccandum esset inuitaturus & attracturus ea pecunia, neque eam inuitaret, si statim id debitum non esset ei traditū: tunc enim propter detrimentum illud spirituale tertiæ illius personæ, obligatio esset ex cari-[[283]]tate differre solutionem, si commodè sine notabili debitoris detrimento differri posset. Conclusio hæc ex eo est manifesta, quod *Deus unicuique mandauit de proximo suo*: & quod præferenda sitsalus spiritualis proximi famę eiusdem, quando id necessarium est ad eruendum eum, aut ad illum præseruandum à peccato, iuxta ea quæ in materia de correctione fraterna copiosè explanata comprobataque sunt: longè ergo maiori cum ratione differenda erit restitutio, solutiōve debiti bonorum externorum, quæ lōgè inferioris sunt rationis, quando, eam differendo, creditor sine notabili detrimento debitoris à peccatis præseruabitur: eritque tunc creditor irrationabiliter inuitus, si non consentiat, vt differatur solutio, ac proinde curandum non erit de irrationabili ac iniqua illius voluntate. *Consentire*

videtur Sotus in hac conclusione art. 1. citato, & consentiunt D. Antonius. 2. part. titu. 1. c. 14. §. 2. & Nauar. in Manu. c. 17. n. 5. & 63. Qui addunt, fas esse surripere occultè mulieri fucos & pigmenta, quibus alios allicit ad peccandum, & instrumenta lusoria ab habentibus illa ad iniquè ludendum. Quod intellige, quando ea ratione impedirentur peccata. Si enim statim emēda essent instrumenta alia, quibus peccata similiter fierent, fas non esset occultè surripere eiusmodi instrumenta. Nunquam etiam cum peccantium scandalo aut vi arcendi sunt homines à peccatis, nisi à publica potestate, ab eóve, cui id ex officio incumbit.

Dubium est, si in euentibus, in quibus in hac [sect. 4] disputatione est explanatum, fas esse differre solutionem debiti, sequatur creditori ex ea dilatione detrimentum aliquod in bonis ipsius tēporalibus, num debitor teneatur illud ei resarcire: sicut disputatione præcedente ostendimus, debitorem resarcire teneri detrimentum creditori ex eo sequutum, quòd debitor in suum proprium commodum licitè distulerit debiti solutionem. Respondendum verò est neganter. Ratio autem est, quoniam cū debitor in euentibus hac disputatione explicatis non differat licitè solutionē in suum proprium commodum, non tenetur velle dilationē solutionis eius debiti sub tacito pacto ac conditione, quòd creditori resarciet, si quod damnum ea de causa fuerit ei sequutum.

Dubium item est, num in euentibus, in qui [sect. 5] bus hac & præcedente disputatione est ostensum, licitum esse debitori differre solutionem debiti, siue propter debitoris impotentiam, siue ob causas alias explanatas, teneatur debitor facultatem à creditore petere, ad ita solutionem differendum. *D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 8. ad. 2. affirmare videtur.* Dicendum verò est, id necessarium non esse; quoniam iusta causa in his euentibus est, vt, velit, nolit, creditor, restitutio differatur. Fortè tamen D. Tho. intellexit, quando esset dubium, an esset sufficiens causa ad differendam restitutionem: tunc enim consilium esset, debitorem per se aut per alium petere à creditore facultatem differendi solutionem. Atque ita Sotus. 4. de iust. q. 7. art. 4. diuum Tho. exponit.

Num, quando restitutio fieri debet statim, confessarius concedere pœnitenti inducias possit ad restitutionem differendam. Et quousque negare absolutionem debeat non restituenti statim. Disp. 756.

SVMMARIVM.

1. Restituere statim quando debitor tenetur, non potest confessarius inducias illi concedere ad restitutionem differendam, cūmq̃ue absolvere.

2. Restituere qui cū possint, restitutionem in tempus mortis reseruant, item qui dubitant, an aliqua iustè possideant, eam differunt in tempus mortis, vt examē iniungant suis hœredibus, quĩq̃ cū mortis tempore possint restituere, exequutionem committunt in testamento hœredibus, in quanto periculo versentur.

3. Restituere iussus in vna confessione, si in alia accedat, id sua culpa opere non impleto, quomodo cum illo se gerere debeat confessarius.

4. Absolui, qui decimam non soluit, nihil impediēte præcepto Concilii Tridentini, & Archiepiscopatus Euorensis dispositione, quando possit, & quando non possit.

Dvbiū est, in euentibus, in quibus, iuxta [sect. 1] hactenus dicta, nefas est debitori restitutionem differre, sed statim tenetur eam integre facere, num fas confessario sit concedere petenti, vt paulatim illam efficiat, absolutionemque illi impendere, quando ita vtiliter ageret negotium creditoris, quia fortè ita melius recuperabit suum debitum, & quando subueniet simul pæniti, quem adducere non potest, vt simul totum restituat. Quidam, quos Syluest. verb. rost. 5. q. 5. refert, affirmanter respondent. Contrariū tamen est proculdubio affirmandum cum *Ioan. Med. de rest. q. 5. Soto. 4. de iust. q. 7. art. 4.* & cum aliis doctoribus communiter. Debitor quippe, nisi ex creditoris voluntate restitutionem differat, in statu est lethalis culpæ, incapaxque est absolutionis. Neque confessarius in eo foro est sequester inter creditorem & debitorem, aut creditoris procurator, qui creditoris nomine dilationem restitutionis possit concedere; sed est iudex pænitis loco Del, ministerque Dei ad illum absoluendum constitutus, si ad id eum aptum inueniat. Sotus citat Syluestrum, quasi sit in sententia, quam impugnamus: immeritò tamen, vt constat Syluestrum legenti. Ex dictis hac, & præcedentibus disputationi [sect. 2] bus, satis est manifestum, in quanto versentur periculo, quin & in quàm aperto sint peccato, qui restitutionem ad mortis articulum differūt. Si enim restituere statim possunt debitum totum, aut partem, incapaces sunt absolutionis, nisi totum, quod possunt, restituant. Quòd si repentina morte in eo statu ex hac vita discedant, dānationem incurrent æternam, cruciatibusque sempiternis adigentur. In eodem damnationis statu sunt, qui dubitant, an aliqua ex iis, quæ possident, iusto titulo retineant, neque, dum viuunt, id examinare curant; sed solū statuunt id onus suis hæredibus in suo testamento iniungere. Itē in eodem dānationis statu sunt illi, qui in mortis articulo commodè possunt per se ipsos restituere, idque efficere renuunt ac nolunt, dicentes, se præcipere hæredibus suis in suo testamēto, vt id restituant: qui sanè nulla ratione sunt absoluendi. Tum quòd id indicium sit, eos non habere restituendi animum, nisi sub conditione, si ex eo morbo ex hac vita discedant, atque in [[284]] tempus, quo mortui iam sint. Tum etiam quia quàm sæpissime non implentur restamenta, magnatum præsertim. Tum denique quoniam, cū restituere statim possint, nefas illis sit, restitutionem differre, præsertim quæ pendeat ex aliorum voluntate & exequutione post mortem ipsorum.

Caiet. verb. rest. c. 6. & alii, rectè admonent, [sect. 3] quando aliquis iussus antea in confessione aliqua restituere, accedit in alia confessione, restitutione illa minimè impleta, regulariter non esse absoluendum antequam opere restituat, aut restitutionis dilationem à creditore obtineat. Quamuis enim credendum sit, eiusmodi pænitentem accedere cum restituendi proposito, quando dicit, Pater hac vice, cū hinc discessero, restituum; nihilominus timendum est, sicut antea, obtenta absolutione, fuit negligens, propositumque mutauit: ita idem illi modò obuenturum, ob restituendi difficultatem, humanamque fragilitatem: eaque de causa dicendum illi est, interim dum es in hoc firmo proposito, illud adimple, & postea accede, impendeturque tibi absolutio. Obserua tamen, quando pænitens in secunda aut in tertia confessione accedit cum impotentia ad tunc restituendum iuxta ea, quæ præcedentibus disputationibus sunt dicta, denegādā ei non esse absolutionem ex eo, quòd non restituat statim, esto non semel antea fuerit iussus restituere, suaque negligentia non restituerit. Semper tamen est curandum, vt faciat, quod potuerit, si tunc commodè aliquid potuerit facere. Item si confessarius non leuiter credat, pænitentem re ipsa restitutum statim sine mora, quia non ea acrimonia iussa illi fuit restitutio in præcedentibus confessionibus, & quia adsunt circumstantiæ, quibus confessarius sibi meritò persuadet, pænitentem id opere impleturum, poterit aliquando illi impendere

absolutionem: præsertim illi præcipiendo, vt non priùs ad sacram Eucharistiam accedat, quàm opere restitutionem impleat, aut quàm creditorem ea de re alloquatur.

Concilium Tridentinum sessione. 25. c. 12. præcipit, [sect. 4] vt, qui decimas non soluit, aut qui ne soluerentur impediuit, excommunicetur, neque à crimine absoluator, nisi sequuta plena satisfactione. Quo loco obserua, non excommunicare incidentes in hæc crimina, sed præcipere vt excommunicentur. Neque reseruare absolutionē eius criminis, tolleréve iurisdictionem ad absoluendum, sed præcipere confessariis, ne absoluant quousque opere sit facta solutio talium decimarum. *In constitutionibus Euorensis Archiepiscopatus, titu. 3. c. 6.* reseruabatur absolutio à crimine non soluendi decimas, modò quantitas non soluta pertingeret ad valorem ducentorum cruciatorum, quos nos ducatos vocamus. Quando verò quantitas ad eum valorem non pertingebat, permittebatur confessariis absoluere ab eo crimine, sub ea tamen conditione, vt pænitentes priùs opere satisfacerent. Confessariis verò, qui aliter absoluere attentarent, imponebatur pæna excommunicationis ipso facto incurrenda. Postea verò in additionibus ad constitutiones fuit permissum, vt quando aliqui reperirentur impotentes ad decimas restituendas, non priùs casus ille censeretur reseruatus, esto summa excederet valorem ducentorum cruciatorum, quàm à confessario tali pænitenti fuisset præscriptum certum tempus, intra quod illas restitueret: transacto verò eo tempore, si intra illud pænitens non restituisset, maneret deinceps casus Episcopo reseruatus. In omni autem euentu, in quo pænitens opere iam restituisset, cōceditur ibi posse absolui à præterito crimine: quoniam reseruatō solūm intelligitur, quousque restitutio opere fiat.

His ita relatis, dubium est, utrū, nihil prohibitionē Concilii Tridentini impediēte, si aliquis accedat ad confessionem, qui sua culpa non soluit decimas, attamen, quando ad confessionē accedit, impotens est ad restituendum, iuxta ea quæ præcedentibus disputationibus dicta sunt, possit absolui. Affirmanterque est respondendū cum *Nauar. in Manu. c. 17. n. 59.* Ratio autem est, quoniam Concilium non prohibet absoluere, nisi eum, qui pro tunc tenetur restituere, quique peccat non restituendo. Quod verò attinet ad reseruationem Archiepiscopatus Euorensis, sanè is, qui post terminum à confessario illi datum, idcirco non restituit, quia non potuit, absolui potest à quocunque, si adhuc perseueret in impotentia. Ratio autem est, quoniam cū non peccauerit non restituendo, excusante illum impotentia, nullum crimen habet reseruatum, ratione cuius non possit absolui. Qui verò à die, in quo datus illi fuit terminus, restituere potuit, nec restituit, tunc, esto post finitum terminum accedat cum impotentia, absolui non potest, nisi priùs opere restituat: eo quòd in eo euentu crimen præteritum non restituendi est reseruatum. Posset tamen absolui, vel priuilegio bullæ cruciatæ, vel à confessario, comparatione cuius casus ordinarii non essent reseruati.

Num condonatio creditoris liberet debitorem à restituendione. Disp. 757.

SVMMARIVM.

1. *Restituendi ab onere liberat creditoris condonatio ac remissio, modo condonare id possit, & condonatio sit libera, & quot modis libera non censeatur.*

2. Restituendi ab onere ut debitor remissione creditoris liberetur, non est necesse offerri pecuniam debitam creditori: interdumque consilium est, nec illi ostendi nec offerri.

EXaminandum ulterius est, num causæ non [sect. 1] nullæ debitorem à restituendi onere liberent. Quod verò attinet ad condonationem, seu remissionem debiti per creditorem factam, dicendum est. Eam debitorem liberare à restituēdi onere: modò tamen sit libera: & modò is, qui remittit, possit donare. Cùm enim debiti gratuita remissio donatio quædam sit, sanè, qui donare non potest, iuxta ea quæ in materia de donationibus Disp. 274 dicta sunt, neque etiam potest debitum remittere. Similiter quanta libertas requiritur ac sufficit, ut donatio sit valida, iuxta ea quæ Disp. 267 explanata sunt, tanta requiritur ac sufficit, ut debiti remissio debitorem à restituendi onere liberet. Si quis ergo per metum, aut minas, debiti remissionem extorqueat, vel quamvis nihil minetur, is tamen qui debi-[[285]]tum remittit, illud remittit, quia timet, nisi ita remittat, aspere ac iniuste à creditore potente esse tractandum, tunc eiusmodi remissio, vtpote inuoluntaria mixtè, debitorem non liberat ab onere restituendi. Item si quis per fraudes ac mendacia debiti remissionē extorqueat, fingendo se pauperiorem, quàm sit, aut fingendo alia, quorum contraria si creditor sciret, non solùm non remitteret debitum, sed etiam vellet, ut invalida ac nulla esset talis remissio, tunc eiusmodi remissio, vtpote inuoluntaria mixtè, ignorantia ac deceptione causante inuoluntarium, non exoneraret debitorem à restituendi onere: idque non solùm quando creditor eo modo esset deceptus per debitorem ipsum, sed etiam quando per tertiam personam eodem modo esset deceptus. Denique in quibus euentibus in materia de donationibus explanatum est, donationem validam aut invalidam esse, in eisdem valida aut invalida est debiti remissio, ut à restituendi onere liberet.

Diuus Antonius, & pauci alii, in ea fuerunt [sect. 2] sententia, ut dicerent, ut remissio debiti à restituendi onere debitorem liberet, necessarium esse, debitorem offerre creditori, quod illi debet, eo tempore, quo remissio talis debiti illi fit: alioquin remissionem esse invalidam: eo quòd non sit sufficienter libera: quippe cùm multi in pecuniæ absentia debitum remittant, qui, si pecuniam præsentem haberent, eisquæ offerretur, debitum non remitterent. Contrariam tamen sententiam meritò doctores communiter affirmant. *Caiet. 2. 2. q. 62. art. 6. ad. 3. & in summa verb. rest. c. 7. Ioan. Med. de rest. q. 3. causa. 2. Sotus. 4. de iust. q. 7. art. 4. Nauar. in Manu. c. 17. n. 44. Couar. reg. peccatum. par. 2. in initio. n. 5. & plerique alii.* Ut enim debiti remissio valida sit, satis est, eam esse absolutè liberam absque inuoluntario mixtè, esto creditor precibus debitoris, aut alicuius alterius, ad id inducatur ac attrahatur, & esto pecunia sit absens. Atque, quando non constat creditoris consensum esse inuoluntarium mixtè, quia non sunt vehementes coniecturæ, quæ id vehementer persuadeant, præsumendum est, esse liberum sufficienter, ut remissio sit valida, ut probè Caiet. affirmat. Qui rectè etiam admonet, quando debitor est pauper, sanum consilium esse, rem debitam non offerri creditori, quo facilius debitum condonet: sæpe enim creditores in præsentia obiecti, ab eo attracti & illecti, non remittent debitum, quando, si obiectum eis non ostenderetur, debitum remitterent. Ioan. Med. addit, validam esse debiti remissionem, ac debitorem à restituendi onere liberare, quando ex parte creditoris sufficienter, modo explicato, est libera, esto debitor in ea sit dispositione, aut proposito, quòd si creditor illud non remitteret, ipse id debitum non solueret. Id quippe peruersum propositum culpa est lethalis in eiusmodi debitore, eaque de causa contritionem impedit, reponique talem debitorem in gratia interim

dum id propositum perseuerat, ac proinde incapacem eum absolutionis efficit: non tamen impedit eam remissionem validam esse, debitoremque à restituendi onere liberare.

Vtrum debitor per ingressum religionis liber à restituendi onere maneat. Disp. 758.

SVMMARIVM.

- 1 . *DEbitor, qui lucrando in seculo saltem suo labore & industria satisfacere debitis potest, ingredi non potest religionem; neque in ea potest recipi, prætermiſsa restitutione.*
- 2 . *Debitor si religionem prositeatur debitis non solutis, tenetur, si qua via possit aliquid intra monasterium lucrari, illud restituere, neque impediri à prælato quoad id potest. Si quid verò ad monasterium deuoluatur ratione talis religiosi, ante omnia de illo satisfaciendum est debitis. Et quatenus, si in monasterio spos non sit satisfaciendi, sit verò quòd regressus ad seculum satisfaciet, quatenus regredi teneatur, aut non teneatur.*
- 3 . *Religionis ingressus si plus adiuuet, quam impediat, vt debita soluantur, debitor licitè ingredi religionem potest.*
- 4 . *Religionem ingredi non posset, nisi impleto priùs iuramento, aut obtenta remissione ab eo, cui se obligasset, qui ad aliquid licitum se alicui sub iureiurando obligasset.*

D*Iuus Tho. 2. 2. q. 189. art. 6. ad. 3. ait, debitorem, cedendo bonis creditoribus, posse ingredi religionem: neque teneri expectare in seculo donec debita soluat, esto spes sit, quòd negotiando, aut laborando in seculo, possit ea soluere. Ducitur. Quoniam propter debita*¹⁴¹ *persona hominis liberi non obligatur secundùm iura, sed solùm bona illius: quare, cedendo bonis, libera manet persona debitoris. In eadem sententia sunt Palud. in. 4. dist. 38. q. 3. art. 1. conclus. 7. Syluest. verb. religio. 2. q. 4. art. 5. Angelus eodem verb. n. 6. & quidam alii. Quidam eorum addunt, esto iureiurando se astrinxisset aliquid in seculo efficere, posse id infectum relinquere, religionemque intrare: eo quòd iuramentum impeditium non sit maioris boni. D. Tho. ab illa sua opinione excipit, nisi obligatus esset ad aliquid certum, vt si obligatus esset ad rationes reddendas, vel ad aliquod debitum certum in singulari: tunc enim ait, teneri illud priùs expedire, quàm religionem ingrediatur. Quidam alii solùm excipiunt, quando obligatus esset ad ratiocinia cōmunitatis: quoniam antequam illa redderet, recipiendus non esset in religione, vt D. Greg. in Registro affirmat, & habetur. c. legem dist. 35. Post ingressum verò religionis multi ex autoribus citatis affirmant, teneri monasterium restituere de iis, quæ occasione talis monachi acquisierit, si quæ fortè illius occasione comparauerit, successione ex testamento, aut ab intestato, donatione, vel quauis alia ratione: id quod censeo nō esse in dubium reuocandum. Monasterium enim, loco sui religiosi, solùm succedit in iis, in quæ succederet talis religiosus, si sui iuris esset, deducto ære alieno talis religiosi. Addunt verò iidem autores, monasterium de aliis monasterii eiusdem bonis non teneri ad debita sui religiosi. Subiungunt præterea, monachum ipsum, post ingressum, posse scribendo, aut aliter honestè laborando, lucrari, vt suis debitis inde satisfiat, modò in nullo ab officio diuino, & à*

regulari obseruantia, impediatur. Affirmant tamen, non teneri eo modo laborare ac lucrari, vt suis debitis satisfaciatur: sed satis esse, quòd, profitendo religionem, suis bonis cesserit.

[[286]] Suaderi autem potest opinio horum omnium¹⁴² doctorum, quonia, nihil impediante obligatione, qua sponsus tenetur sponse post sponsalia celebrata, & nihil impediante obligatione, qua vnus coniux tenetur alteri post matrimonium per verba de præsenti celebratum antequam consummatum sit per copulam, potest vnus sponsorum, aut talium coniugum, religionem ingredi: ergo longè maiori cum ratione, nihil impediēte debito pecuniario, poterit debitor religionē ingredi: præsertim cum creditor consentire teneatur in eo ingressu, ne debitor, propter creditoris pecuniam, consequi impediatur tantum bonum. In contraria quadam ex parte sententia, quæ sequentibus conclusionibus continetur, *sunt Maior in 4. dist. 38. q. 17. Nauar. c. non dicatis. 12. q. 1. n. 3. & 74. Ioan. Mea. de rest. q. 3. causa. 8.* Ierson in Abecedario, cui multi Parisienses doctores lubscripserunt, eamque vt veram amplector.

Prima conclusio est. Debitor, qui in seculo¹⁴³ acquirere potest suo labore, arte, aut industria, vnde restituat, quæ debet, si peringressum reli [sect. 1] gionis à restituendo impediatur, peccat religionem ingrediendo, neque in ea debet recipi. Probatur primò, quoniam obligatio soluendi debitum, est de iure diuino naturali, modò debitor possit licite acquirere vnde soluat: neque cessio bonorum eum liberat ab eo onere in conscientia foro, sed in exteriori foro eum liberat, ne detrudatur propter id debitum in carcerem interim dum, facta iam prius cessione, non habuerit vnde commodè soluat, relinquēdo illi, ne egeat; quin in hoc Castellæ regno, statim facta cessione, traditur ad seruiendum ordine quodam creditoribus, quousque, ita illis seruiendo, integre persoluat eis sua debita, vt hæc omnia Disp. 572 explanata comprobataque sunt: ergo, qui propria sponte se inhabilem ac impotentem reddit ad soluendum sua debita, peccat contra diuinū ius naturale, quo ea soluere tenetur, nihil impediante, quòd ad id se inhabilem ac impotentem reddat religionem profitendo: quandoquidem professio religionis solūm est de consilio, & propter illa, quæ solūm sunt de consilio, omitti non possint, quæ sunt de præcepto, eoque diuino ac naturali. Quare sicut, qui solo suo brachio comparare posset vnde debita sua solueret, si illud sibi sine iusta causa abscinderet, peccaret non solūm contra caritatem propriam, quintumque decalogi præceptum, sed etiam contra iustitiam aduersus septimum decalogi præceptum, inhabilem se ea via reddēdo ad debita soluenda, quæ septimo decalogi præcepto tenetur soluere: ita qui, profitendo religionem, se inhabilem redderet ad eadem debita soluenda, peccaret contra iustitiam. Secundò vt D. Tho. art. illo. 6. citato affirmat, filius, quando sub reatu lethalis culpæ tenetur subuenire patri indigenti, illi acquirendo vnde sustentetur, non potest ingredi religionem: si verò illam ingrediatur, peccat; eo quòd prætermittat id, ad quod diuino naturali iure tenetur, vt id efficiat, quod solūm est de consilio: ergo eadem ratione, qui solutio nem debitorum prætermittit, ad quæ diuino naturali iure sub culpa lethali tenetur, vt religionem profiteatur, quod solūm illi est de consilio, peccat contra septimum de calogi præceptum. Tertiò, nefas est quærere lucrum suum proprium spirituale aut temporale, cum præiudicio ac detrimento alterius; cū, autore Paulo ad Romanos 3, non sint facienda mala, vt inde eueniant bona; neque sit iustum quenquam cum aliena iactura locupletari, vt. c. suam de pænis, & alibi, habetur: ergo nefas est religionem ingredi, quando ea de causa prætermittitur solutio debitorum, ad quæ ita ingrediens de iustitia tenetur septimo decalogi præcepto. Quartò, qui publicis rationibus sunt astricti, non prius recipi in religionem possunt, quàm ab illis se expediant, vt doctores contrariæ sententiæ concedunt, & habetur. c. legem dist. 53. Imò D. Tho. concedit, eum,

qui debitor est rei alicuius determinatæ, non priùs in religionem posse recipi, quàm illam soluant: mancipia item recipi in religionem non possunt, sine consensu dominorum: si autem recipiantur, extrahi à dominis poslunt intra triennium: hæc autem non aliunde proueniunt, neque aliunde vim habent, nisi quia per eiusmodi ingressum iniuria illis fit, quibus sunt obligati: cùm ergo similis iniuria fiat creditoribus, quando debitores per ingressum religionis impotentes ad soluendum debita redduntur; consequens profectò est, vt nefas tunc illis sit religionem ingredi.

Secunda conclusio. Debitor per ingressum¹⁴⁴ religionis non deobligatur ab onere restituendi; sed tenetur, si qua via honesta possit, laborã [sect. 2] do, aut alia ratione, acquirere, vt satisfaciat. Neque prælatus ea in re potest eum impedire. Quin potiùs, si eiusmodi debitor alia via non posset, spesque esset verisimilis, quòd, egrediendo absque scandalo monasterium, licite in aliquo loco lucraretur, teneretur egredi monasterium ad tempus, quousque satisfaceret. Semper tamen tentandæ essent aliæ viæ possibiles, videndumque esset, an creditores condonare vellent, vel alia via vellent esse contenti. Probatur primò, quoniam nullus per votum potest se obligare ad id, quod est contra ius diuinum naturale; eo quòd votum solùm sit de re placita Deo: sed omissio solutionis debiti, quando aliqua se offert via ad id licita, est contra ius naturale: ergo religiosus per professionem non potuit se obligare prælato aut religioni ad id, quod suorum debitorum solutionem impediret. Secundò, si pater, aut quiuus alius, in extrema esset necessitate, atque ad id indigeret, religiosum laborare, aut egredi monasterium, teneretur talis religiosus sub reatu culpæ lethalis id efficere, nihil impediante, quòd aliud tunc præciperent regulæ aut prælatus: ergo, cùm religiosus debitor, iure naturali teneatur soluere debita, quæ ante ingressum religionis contraxit, tenetur, si ad id opus fuerit, laborare, aut egredi monasterium, etiam contradicente prælato.

Tertia conclusio. Quando, ingrediente ali¹⁴⁵quo religionem, citiùs ac meliùs soluerentur sua debita, tunc licitè posset ingredi religio [sect. 3] nem ante debitorum solutionem. Verbi gratia, est aliquis nobilis, qui bona habet vinculata, quæ illi redditus pariunt, quibus indiget ad sui sustentationem, si in seculo maneat: eiusmodi autem redditibus, si monasterium ingrediatur, soluere debita poterit; tunc licitè poterit ingredi religionem: quoniam ea ratione citiùs & meliùs soluentur ipsius debita. Est item aliquis, [[287]] cui pater tribuit aliqua quotannis ad illius sustentationem; nec pater vult insuper soluere debita illius; si tamen ingredi velit religionem, pater se astringit soluere debita illius intra aliquot annos; tunc licitè is religionem ingreditur. In his itaque, & in aliis similibus euētibus, in quibus ingressus religionis non impedit, sed adiuuat, vt debita soluantur, debita non impediunt religionis ingressum.

Quarta conclusio. Quando aliquis iureiu¹⁴⁶rando se astrinxisset ad aliquid licitum, quod præstare non posset religionem ingrediendo, [sect. 4] teneretur retardare ingressum, donec illud impleteret. Nisi volūtas quasi habitualis ipsius, dum id iurauit, fuerit, non intelligere in euentu, quo ingredi vellet religionem. Si tamen contractus fuisset onerosus, atque simpliciter se astrinxisset in euentu, in quo alter contrahens omnino intelligere debebat se obligare, quia id natura ipsa contractus postulabat, stare teneretur contractui, neque ingredi posset religionem non stando contractui, nisi alter, cum quo contraxit, eā obligationem ei remitteret. Hęc conclusio, quoad primam illius partem, probatur. Quoniam iuramentum promissorium de re licita, vtilique ei, cui præstatur, obligat promittentem iure diuino naturali, nihil impediante, quòd inde iurans impediatur exequi maius bonum, vt Disp. 149, & duabus sequētibus, copiosè est ostensum. Hoc enim est discrimen inter iuramentum promissorium de re non mala Deo præstitum, quod rationem voti iuramento confirmati

sortitur, & præstitum alicui homini in fauorem & vtilitatem illius. Quòd iuramentum Deo præstitum, si impediatur maius bonum, potest non impleri, vt maius bonum exequutioni mandetur: eo quòd Deus semper velit, quod melius est, eaquæ de causa non velit, vt in eo euentu obliget iuramētum sibi præstitum. Iuramentum verò homini præstitum, sit sit de re non mala, esto impediatur maius bonum, obligat, nisi is, cui est præstitum, remittat obligationē cōparatione ipsius ex tali iuramento resultantē, vt vtrumque disputatione citata fuit comprobātū. Secunda verò cōclusionis pars ex eo liquet, quòd talis euentus non cēsetur iuramento ac promissione comprehensus.

Superest respondeamus ad ea, quibus contra¹⁴⁷ ria sententia innititur. Atque ad illud diui Tho. quòd propter debita persona hominis liberi nō obligatur secundum iura, sed solū bona illius, ac proinde debitorem, cedendo bonis, posse ingredi religionem, esto debita maneant insoluta; ad hoc, inquam, iam suprā Disp. 387, dum sermo nobis erat de censu personali, explanauimus, iura hoc solū statuere, quòd in persona hominis liberi non possit constitui ius in re, quasi in pignus dari possit, aut subijci hypothecæ, ac vendi ad debiti solutionem: non verò quasi ex debito, & contractibus, non resultet in persona obligatio personalis, qua ad debita teneatur, etiamsi non habeat bona vnde soluat. Quoad id verò, quod de bonorum cessione addit, Disput. 572 ostēdimus, illam non deobligare in foro cōscientiæ, quin neque in exteriori, ab obligatione personali soluendi debita, si qua via commodè possit, recteque Nauar. n. 3. citato innuit, cōpelli debitorem in foro exteriori posse ad laborādū & acquirendum vnde soluat, quantum conditio, statūsve, illius patitur. Reliqua, quæ alii addunt, satis confutata sunt conclusionibus propositis.

Ad id verò, quo eandem contrariam senten¹⁴⁸ tiam suadebamus, dicendum est. In sponso & sponsa, & in iis, qui matrimonium per verba de præsentī celebrarunt, esse æqualem vtriusque ea in parte conditionem; cū vterque, altero inuito, possit æquè religionem profiteri; eaquæ de causa libertatem illam cū vtrique sit æqualis, neutri esse iniuriosam: quod non ita se habet in debitore cōparatione creditoris. Adde, in matrimonio rato non consummato, & longè maiori cū ratione in sponsalibus, esse libertatem illam utrique coniugum æqualem, explicatum fuisse à Christo, vocante Ioannem de nuptiis ad Apostolatū, eamque libertatem habere vtrumque coniugum, traditione esse notum in Ecclesia, atque in iure ab eadem Ecclesia esse explicatum, vt alio in loco est dicendum: quare, cum ea libertate ac conditione censentur celebrati illi contractus, nullique proinde coniugum fit iniuria, dum alter religionem profitetur. Vnde ad argumentū, concessio antecedente, neganda est consequentia: quoniam est longè diuersa ratio, vt explanatum est. Ad id verò, quod subiungitur, creditorem scilicet teneri consentire in eo ingressu, ne debitor, propter creditoris pecuniam, consequi impediatur tantum bonum, Negandum est, eam esse sufficientem causam, vt creditor consentire in eo ingressu teneatur. Cū enim religionis ingressus non sit medium ad salutem necessarium, sanè sicut creditor non tenetur illi dare alia sua bona, vt religionem ingrediatur, ita neque tenetur remittere illi debitum.

Num creditorem esse excommunicatum, sufficiens causa sit differendi restitutionem eius, quod illi debetur. Disp. 759.

SVMMARIVM.

1. *RE*stitutio ut fiat, impedimentum non est, creditorem esse excommunicatum, maximè si denunciatus non sit, nec sit notorius percussor clerici.

*G*lossa. c. vlt. de hæret. & additio cuiusdam alterius glossæ. c. nos sanctorum. 15. q. 6. Panor.

& Felin. c. inter alia de sent. excommun. idem Panor. c. veritatis de dolo & contum. à. n. 39. Adrian. in. 4. q. 3. de clauib. & alii, quos Couar. reg. peccat. part. 1. n. vlt. refert, quamuis concedant, contractus ab excommunicato celebratos, validos esse qua ratione testamentum ab illo confectum, est validum, vt cum eodem Panor. Ant. Gom. & aliis, Disp. 137 ostendimus; negant tamen debitorem soluere teneri suo creditori interim dum creditor excommunicatus perseuerat, esto iam aduenerit terminus ad soluendum præfixus, & esto sub iureiurando promiserit, se in eo termino soluturum. Id quippe iuramentum intelligi debet, modò creditor in eo termino sit habilis, vt cum illo in eo termino cõmunicetur. Item iuramentũ non est vinculum iniquitatis, vt obligare possit ad illicitum: peccatum autem est cõmunicare cum excommunicato illi soluendo, quod ei debetur.

Hanc suam sententiam confirmant. Primò, ex. c. nos¹⁴⁹ sanctorũ. & ex. c. iuratos. 15. q. 6. quibus in iuribus vassalli ac milites absoluuntur à iuramento fidelitatis seruando dominis, quamdiu excommunicati extiterint: imò verò prohibentur eam fidelitatem & obsequium illis præstare.

Secundò, quia. c. in dubiis, & c. inter alia de [[288]] sent. excommu. solũ iis permittitur commu¹⁵⁰nicare cum excommunicatis, quibus Greg. Septimus. c. quoniam. 11. q. 3. id permisit: inter illos autem non computantur, qui soluunt pecuniaria debita.

Tertiò, quoniam, c. iniungimus de iudiciis,¹⁵¹ excommunicati excluduntur apertè ab agendo in iudicio, tametsi contra illos possit lis optimè intentari: ergo debitores soluere eis non tenentur, quæ illis debent, interim dum excommunicati existunt.

Contrariam sententiam affirmant Glossa. c. nos sanctorum 15. q. 6. Ioan. Med. de rest. q. 3. causa. 9. Couar. n. vlt. citato, Maior in. 4. dist. 18. q. 4. Syluest. verb. excommunicatio. 5. n. 21. Inno. & pleriq; alii, quos hi doctores citant. Nempe excommunicationem creditoris non impedire, quo minùs illi solvatur, quod ei debetur. Ducuntur,¹⁵² quoniam debitor iure diuino naturali tenetur eam restitutionem efficere, cui obligationi cõtrauenire non potuit ius humanum, prohibens communicationem cum excommunicato. Item quoniam communicatio illa cum excommunicato, soluendo illi suum debitum, est modica ac debita, non minùs quàm obsequium famulorum, & solutio colonorum, & aliorum, qui non solũ communicare permittuntur cum excommunicatis. c. quoniam. 11. q. 3. sed etiam. c. inter alia de sent. excom. decernitur, eos teneri cum illis communicare: ergo debitores etiam tenentur communicare cum suis creditoribus excommunicatis, soluendo illis, quod naturali iure eis soluere tenentur.

Vt in hac re, certa ab incertis separemus, in [sect. 1] primis dico, Post Concilium constantiense sub Martino 5, & Lateranense sub Leone 10, dubium non esse, debitores teneri soluere suis

creditoribus excommunicatis, quæ eis debent, quando creditores illi non sunt denunciati, nec sunt notorii percussores clerici. Quoniam duo hæc concilia permiserunt communicationem cum excommunicatis, quando denunciati non essent, neque essent notorii percussores clerici. Deinde dico. Loquendo de denunciatis, aut notoriis percussoribus clerici, neutram sententiam relatam esse improbabilem. Non quidem primam. Quoniam. c. quoniam. 11. q. 3. non excipit communicationem cum excommunicato soluendo illi, quod ei debetur: aperteque ibi innuitur, exceptiones ibidem concessas, prohibitas fuisse ante illum canonem: quare hæc etiam videtur fuisse prohibita: unde, cum neque ibi, neque alibi, reperiatur concessa, probabilitate non caret, eam adhuc esse prohibitam. Neque¹⁵³ cogit id, quod Medina ait, cum videlicet obligatio soluendi debitum sit de iure naturali, ius humanum, prohibens communicationem cum excommunicato, non potuisse impedire eam solutionem. Id, inquam, non cogit. Quoniam ius humanum licet in pœnam iustam potest prohibere ac retardare solutionem eius, quod iure naturali ei debetur, qui sua culpa in excommunicationem incidit, quousque à contumacia desistat, obtineatque absolutionem. Non est etiam secunda sententia improbabilis. Quoniam argumento à longè maiori ratione concludiæ intelligi per epicheiam videtur, eam fuisse mentē Gregorii. 7. c. quoniam citato, iuncto, c. inter alia, etiam citato, coadiuuantque rationes pro eadem secunda sententia confectæ: interimque in eam, vt in humaniorē & communiorē, inclino.

Ad primum ergo argumentum contrariæ¹⁵⁴ sententiæ ex. c. nos sanctorum, & ex. c. iuratos, dicendum est, ibi solū esse sermonem de fidelitate & obsequio, à quibus Ecclesia absoluit subditos in pœnam dominorum, interim dum domini excommunicati existunt.

Ad secundum dicendum est, ibi per epicheiam,¹⁵⁵ argumento à longè maiori ratione, censi permissam communicationem cum excommunicato soluendo illi, quod naturali iure ei debetur, vt dictum est.

Ad tertium dicendum est, eo in capite excō¹⁵⁶municatos, in pœnam atque in odium ipsorum, excludi solū ab agendo in foro exteriori: non verò prohiberi debitores soluere eis debita, vt in conscientiæ foro tenentur. Couer. vbi suprā, & 1. var. res. c. 18. n. 5. ait, excommunicatos apud Hispanos passim admitti ad agendum in seculari foro, nihil impediēte, quòd illi, contra quos agunt, excipiant, seu opponant, eos esse excommunicatos.

Restitutio quo ordine sit faciēda, quive creditores præponendi sint aliis in solutione eorum, quæ illis debentur. Disp. 760.

SVMMARIVM.

1. *IN*restituendo quis ordo seruandus sit, quando sufficientia bona non sunt ad creditoribus omnibus satisfaciendum, vbi copiosè explicatum.
2. *Restitutio bonorum certorum præponenda non est restitutioni bonorum incertorum, hoc est, quæ debentur operibus piis pro animabus eorum, quibus scitur deberi, & ignoratur, qui illi sint.*
3. *Compositio licet fiat à debitore, qui exequutor est testamenti, vel ab hærede, circa bona incerta, inde etiam soluenda sunt debita certa, quando non sunt sufficientia alia bona unde soluantur.*

4 . Restitutio hoc ordine fieri debet. Si aliquod bonum reperiatur inter bona debitoris, quod quoad dominium ad alterum spectet, illi omnino est restituendum. Si inter alios creditores nullus sit, qui ius habeat in re, neque qui privilegium habeat praelationis, bona omnia debitoris inter omnes creditores sunt diuidenda iuxta proportionem quantitatis debiti ad debitum, ex quocunque titulo debeantur. Excipitur debitum titulo gratuito, quod postponi debet omnibus debitis, quæ ortum ex liberalitate non habent. Excipitur etiam dos promissa filię comparatione debitorum aliorum titulo oneroso.

QVæ hoc loco dicenda erant, copiosè Disp. [sect. 1] 536 sunt à nobis explanata: quo in

loco à §. quod verò attinet ad vltimum, ordinem in restituendo seruandum tradidimus: vnde illa magno onere nos hoc loco leuabunt. Et quidem quando is, qui restituere tenetur, sufficientia habet bona, quibus omnibus suis creditoribus satisfaciat, nullum ordinem seruare tenetur. Quando verò sufficientia bona non habet, quibus creditoribus omnibus satisfaciat, tunc ordinem illum seruare tenetur, siue ipse debitor sit, qui satisfaciat, siue hæredes post mortem illius, siue tertius aliquis loco illius.

[[289]] Caiet. in summa verb. rest. c. 8. Ioan. Med. de rest. q. 2. art. 5. Nauar. in Manu. c. 17. n. 47. Syluest. verb. rest. 6. q. 5. & alii doctores communiter, hanc, inter alias, regulam statuunt: Quando debitor habet debita quædam incerta, hoc est, talia, quòd quamuis sciat, se illa debere, ignorat tamen, qui sint illi, quibus debeantur, ac proinde quæ restituenda sint pauperibus, aut insumēda sint in aliis operibus piis, pro animabus creditorum, ad quos spectant; & habet quædam alia debita certa, hoc est, quorum creditores optimè nouit, tunc restituenda prius esse debita certa, prætermittendaque esse debita incerta, si non sit vnde soluantur. Rationem reddūt: Quoniam pauperes, & opera alia pia, non habent tantam actionem, quantam habent creditores certi: neque fit illis tanta iniuria in eo, quòd prætermittantur, quanta fieret creditoribus certis. Præsertim cū, esto adessent sufficientia bona, ad restituenda etiam bona incerta, nulla fieret iniuria pauperibus, si, illis prætermisiss, ea bona insumerentur in aliis operibus piis: neque aliis operibus plis vlla fieret iniuria, si, eis prætermisiss, ea bona pauperibus distribuerentur: quin, esto ea bona distribuenda essent pauperibus, nullis singularibus pauperibus fieret iniuria, si, eis ptætermisiss, distribuerentur aliis.

Quamuis autem fatear, opinionem hanc cō [sect. 2] munem esse, grauateque ab ea discedam, quòd communis sit; inclino tamen in partem contrariam. Nempe, postponendam non esse restitutionem bonorum incertorum, sed æqualem locum esse illi tribuendum cum restitutione bonorum certorum. Ducor. Quoniam neque iure humano est contrarium constitutum, neque fundamentum, cui doctores contrariæ opinionis nituntur, id persuadet. Neque enim est attendendum ad ius, quod habent pauperes, aut causæ aliæ piæ, quibus per accidens, loco verorum creditorum, fit restitutio; sed ad ius, quod habent creditores illi, ad quos ea bona spectant, quibusque restitutio fit in pauperibus, aut in aliis operibus piis, pro ipsorum animabus, iuxta præsumptam illorum voluntatem, & ne eiusmodi creditores defraudentur commodo illo suo spirituali, quod ea restitutione consequuntur. Quare, cū eiusmodi veri creditores, quando cætera sunt paria, æquale ius habeant cum aliis creditoribus, aut, si potior illorum sit causa, excellentius ius habeant, non video, cur postponi cæteris creditoribus debeant: præsertim cū causæ pauperum, & cæteris piis, sit fauendum. Confirmari hoc potest, quoniam durum est, eum, qui grassatus esset, multosque in itineribus spoliasset, quos nunc omnino ignoraret, quinam illi essent, debere postponere restitutionem,

quam ita spoliatis facere teneretur in pauperibus, & in aliis operibus piis, restitutioni aliorum, cum quibus postea contraxisset: præsertim quando magna pars bonorum, quæ possideret, ortum habuisset ex bonis, quibus illos alios spoliasset, quæque aliis vendidisset, aut cum aliis permutasset.

Dubium est. Quid si aliquis habeat debita [sect. 3] aliqua certa, & alia incerta, neque habeat sufficientia bona vnde vtrisque debitis satisfacere possit; autoritateque summi Pontificis compositionem sariat circa bona incerta; poteritne tunc retinere sibi quantitatem illam, circa quam compositionem fecit, non soluendo de illa debita certa, sed eam sibi reseruando? Dicendum est, quando debitor ipse est, qui compositionem facit, siue is sit vsurarius, qui circa vsuras componat, quas ignoret, quibus eas debeat, siue sit quicumque alius debitor, dubitandum non esse, teneri de ea summa restituere debita certa: quoniam tenetur restituere omnia sua bona, vndecunque illi aduenerint, aut vndecunque ea comparauerit, quousque planè soluat omnia sua debita. Quando autem hæres, aut alius à defuncto constitutus exequutor sui testamenti, compositionem circa debita defuncti incerta faceret, esset maius dubium. Nam tunc sibi ipsi videtur acquirere summam, circa quam compositionem facit: ipse verò de suis bonis, quæ sibi ipsi comparat, non tenetur soluere debita defuncti. Dicendum tamen est, hunc etiam soluere teneri de ea summa, debita certa defuncti. Ratio autem est, quoniam cōpositionem eo modo efficiendo, agit negotium ac partes hæreditatis ac bonorum defuncti, eaque de causa summa illa, circa quam est facta compositio, manet pars bonorum defuncti, quæ proinde restitutioni est obnoxia, quousque integre defuncti debita soluantur. Vnde, vt probè doctores citati observant, in statu damnationis sunt, qui virtute eiusmodi compositionum circa bona incerta, retinent summam, circa quam compositio est facta, ac prætermittunt restitutionem debitorum certorum, causantes, non esse vnde illa soluantur.

Caiet. in summa verb. rest. & Nauar. in Manu. c. 17. n. 52. affirmant, debita ex contractibus onerosis, vt ex mutuo, venditione, &c. restituenda esse ante debita, quæ ortum ex eo habent, quòd aliquid vsuarie sit comparatum. Contrà verò Ioan. Med. de rest. q. 2. art. 4. ait, ante omnia esse restituenda, quæ accepta sunt per iniuriam: atque, interea, priùs restituenda esse, quæ accepta sunt per maiorem iniuriam, eaque de causa primo loco esse restituendum, si quid per rapinam sit acceptum, secundo verò loco restituendum esse, si quid acceptum sit per furtum, tertio, si quid acceptum sit per vsuram, & quarto, si quid debetur ex contractu iusto. Neutra autem harum opinionum est proban [sect. 4] da: sed standum est ordini in restitutione facienda, Disp. 536 ex dispositione iuris à nobis copiosè explicato, cui non est cur conscientiae forum non consentiat. Quare, si quid permanet apud debitorem, cuius dominium ad creditorem pertineat, in solutione illius præferendus est talis creditor, quocunque titulo creditor sit, idve illi debeatur. Si verò, quoad cætera debitoris bona, nullus sit creditor, qui vel ratione hypothecæ, vel ratione priuilegii prælationis, iuxta ea quæ disputatione citata explanata sunt, præferri aliis creditoribus debeat, tūc bona debitoris inter omnes creditores, quocunque titulo creditores sint, siue ex delicto, siue ex contractu, sunt æqualiter diuidenda pro rata, hoc est, in eadem proportionem, quam debita inter se collata habuerint, vt ibidem comprobatum est.

Illud tamen est obseruandum, si quid gratioso titulo alicui debeatur, hoc est, liberali promissione, hoc in conscientiae & in exteriori foro [[290]] postponendum esset cæteris debitis, quæ ex mera liberalitate debitoris ortum non habuerint. Ratio autem est, quoniam si tale debitum esset contractum postquam iam debitor impotens esset factus ad soluendum

debita ex aliis titulis, esset in fraudem creditorum, essetque reuocandum, esto inscio donatario, quòd esset in fraudem creditorum, promissum aut traditum esset, si existeret in se, aut in aliquo, vnde, qui illud accepit, esset factus locupletior, & multo magis posset non solui, obligatioque esset illud non soluendi, si nondum esset traditum, vt disputatione 328 comprobatum est. Si verò id debitum fuisset contractum, quando promittens erat soluendo, tunc, cùm ad eiusmodi debitum solùm teneatur promittens, quantum commodè facere possit, ita vt non egeat, satisfactisque prius omnibus aliis debitis ex aliis titulis, vt Disp. 413 est ostensum, consequens profectò est, vt eiusmodi debitum postponi debitis aliis omnibus debeat.

Quando item debitum esset dotis filiæ promissæ, postponendum esset omnibus aliis debitis, quæ non essent titulo gratuito debita. Tum quoniam ascendens masculus promittens dotem, solùm tenetur genero quantum commodè facere possit; eodemque priuilegio gaudet mater comparatione filiæ dissoluto iam matrimonio, vt Disp. 425 est dictum. Tum vel maximè, quoniam filiæ post legem Caroli 5. dari in dotem non potest, nisi portio legitima illius, & in Lusitania insuper tertium bonorum parentum eam dotem promittentium: quando autem non est vnde soluatur creditoribus, nulla superest portio legitima filiæ, nullūque superest tertiū parentum. Quare promissio dotis sub ea tacita conditione intelligitur, si eo vsque pertingat portio legitima filiæ, aut in Lusitania tertium bonorum parentum eam dotem promittentium. Et quamuis gener & filia priuilegium habeant, vt possint stare quantitati bonorum, quæ parentes habebant, quando dotem promiserunt, vel quantitati bonorum, quæ reperta fuerunt tempore mortis talium parentum, vt Disp. 236 & Disp. 238, de iure huius regni & Lusitaniæ, est dictum; illud tamen solùm habet locum, vt non teneatur adducere ad collationem cum reliquis hæredibus dotem acceptam: non verò vt, quod nondum est eis solutum de dote promissa, possint accipere de bonis parentum, antequam ex eis soluantur debita onerosa, ad quæ parentes de iustitia sunt adstricti. Idem est dicendum de donatione ad nuptias promissa filio.

Obseruant insuper doctores circa rem hanc de ordine restitutionis, si in aliquo loco sint peculiaris aliqua statuta ea de re lata, illis esse standum, modò iniqua non sint, iurique naturali contraria. Atque hæc dicta sint ad laudem & gloriam omnipotentis Dei, beatissimæque ac gloriosissimæ semper virginis Mariæ, circa rem hanc de restitutione, totumque hunc oblongum de iustitia tractatum secundum.

FINIS TOMI TERTII

NOTAE

4

- 1 *Ios Lusitao.*
- 2 *Ios Cadlella.*
- 3 *Ius Lusitan.*
- 4 *Ius Castella.*
- 5 *Prima cōclus.*
- 6 *Secunda conclusio.*
- 7 *Prima conclu sio.*
- 8 *Secunda conclusio.*
- 9 *Tertia cōclus.*
- 10 *Prima cōclus.*
- 11 *Secunda conclusio.*
- 12 *Tertia cōclus.*
- 13 *Quarta conclusio.*
- 14 *Dubiū*
- 15 *Decisio*
- 16 *Argumentū.*
- 17 *Argumentū*
- 18 *Castellæ.*
- 19 *Quæstio.*
- 20 *Argumentum*
- 21 *Decisio*
- 22 *Ad argumen tum.*
- 23 *Extẽ difurbæc pæna. l 9. sequet.*
- 24 *a Hæc æ tiā pæna extenditur eæ de. l. 9. b Ad hæc, & adaliæ delicta, extenditur pæna triremiñ. l. 8 sequēti. c Satiæ est hodie si sint 17 annorum. l. 9. sequenti.*
- 25 *Ius Lusitan.*
- 26 *Ius Ca stella.*
- 27 *Ius Castellæ.*
- 28 *Ius Lusitan.*

- 29 *Ius Castellæ.*
- 30 *Ius Lusi tanum.*
- 31 *Ad argu mentũ Alensis.*
- 32 *Ius Ca stellæ. Ius Lu stanũ.*
- 33 *Prior sen tentia.*
- 34 *Argum.*
- 35 *Posterior sentētia.*
- 36 *Argumentũ*
- 37 *Confir. prima.*
- 38 *Confir. secunda.*
- 39 *Confir. tertia.*
- 40 *Ad arg. prioris sentētiæ.*
- 41 *Ad arg. posterioris sentētiæ.*
- 42 *Ad prima cōsir.*
- 43 *Ad secum dam.*
- 44 *Ad tertiam.*
- 45 *Quæstio.*
- 46 *Argumētum.*
- 47 *Decisio.*
- 48 *Ad argu mētum.*
- 49 *Prima cōclus.*
- 50 *Secunda con clus.*
- 51 *Argumentũ primũ.*
- 52 *Cōfir.*
- 53 *Secundum.*
- 54 *Tertium.*
- 55 *Quartum.*
- 56 *Ad primum arg.*
- 57 *Ad confirm.*
- 58 *Ad socundũ.*
- 59 *Ad tertium.*
- 60 *Ad Quartum.*
- 61 *Prima conclus.*

- 62 *Tertia cōclus.*
- 63 *Argumentū primum.*
- 64 *Secundū*
- 65 *Ad primum Arg.*
- 66 *Ad secūdū.*
- 67 *Primæ conclus.*
- 68 *Secundæ conclus.*
- 69 *Tertia conclus.*
- 70 *Quarta conclus.*
- 71 *Prima conclus.*
- 72 *Secunda conclus.*
- 73 *Tertiæ conel.*
- 74 *Quar. concl.*
- 75 *Quinta cōcl.*
- 76 *Sexta conclus.*
- 77 *Septima conclus.*
- 78 *Argumentum primū*
- 79 *Secundum.*
- 80 *Ad primum ar gumētū.*
- 81 *Ad secun dum.*
- 82 *Argumētum.*
- 83 *Primæ conclusio*
- 84 *Ad Argumentum.*
- 85 *Ad Argumentum.*
- 86 *Secunda Con clusio.*
- 87 *Tertià Conclu sio.*
- 88 *Ad Argu mentum*
- 89 *Quæstio.*
- 90 *Argumentū.*
- 91 *Ad Argumentū*
- 92 *Cōclusie*
- 93 *Argumẽ tum primum.*
- 94 *Secundum.*

- 95 *Primæ cōclus.*
- 96 *Secūda cōclus.*
- 97 *Tertia cōclus.*
- 98 *Quarta cōclus.*
- 99 *Ad primum Arg.*
- 100 *Ad secūdum.*
- 101 *Prima cōclus.*
- 102 *Secundæ conelus.*
- 103 *Tertiæ conclus.*
- 104 *Quarcoclus.*
- 105 *Quinta cēcl.*
- 106 *Sexta cōclus.*
- 107 *Argume tū primū*
- 108 *Secundū*
- 109 *Primæ conclus.*
- 110 *Secunda conclus.*
- 111 *Tertia conclus.*
- 112 *Ad primum Arg.*
- 113 *Ad secundū.*
- 114 *Quar. cōclus.*
- 115 *Quinta cōcl.*
- 116 *Argument primū.*
- 117 *Secūdū.*
- 118 *Ad primū arg.*
- 119 *Ad secūdū.*
- 120 *Prima coclus.*
- 121 *Secūda coclus.*
- 122 *Tertia cōclus.*
- 123 *Quarta conclus.*
- 124 *Quinta conclus.*
- 125 *Prima cōclus.*
- 126 *Secūda cōclus.*
- 127 *Tertiæ conclus.*

- 128 *Quarta conclus.*
- 129 *Quinta conclus.*
- 130 *Primæ conclus.*
- 131 *Secūda cōclus.*
- 132 *Tertia cōclus.*
- 133 *Primæ conclus.*
- 134 *Secūda cōclus.*
- 135 *Tertia conclus.*
- 136 *Adargumētum.*
- 137 *Ad argū mentum.*
- 138 *Prima conclusi.*
- 139 *Secūda cōclus.*
- 140 *Tertia cēclus.*
- 141 *Argumentū.*
- 142 *Argumentum aliud.*
- 143 *Prima conslu sio*
- 144 *Secunda conclusio*
- 145 *Tertia conclusio*
- 146 *Quarta conclusio.*
- 147 *Ad argumen tum pri toum.*
- 148 *Ad posterius arg.*
- 149 *Argumentā primū.*
- 150 *Secundū*
- 151 *Tertium*
- 152 *Argumentum*
- 153 *Ad argu mentum postero rusententiæ.*
- 154 *Ad primū arg.*
- 155 *Ad secūdum.*
- 156 *Ad tertium.*